10.04.2019

ŞİRKETLER HUKUKU

GENEL ESASLAR

Ankara - 2019

ÖNSÖZ

"Ticari İşletme Hukuku" isimli çalışmayla başlattığımız genel esaslar serisi "Sigorta Hukuku" isimli kitabın ardından "Şirketler Hukuku" isimli bu çalışmayla devam ediyor. Önümüzdeki döneme yetiştirmeyi umut ettiğimiz "Kıymetli Evrak Hukuku" isimli çalışmayla hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin ticaret hukuku alanındaki derslerinde ihtiyaç duydukları kaynak ihtiyacına cevap vermeye çalışacağız.

Bu çalışma esasen geçmişi uzun yıllara dayanan bir düşünce ve projenin gecikerek de olsa ortaya konmuş halidir. Eserin hazırlanma amacı, lisans öğrencilerinin ders kitabı ihtiyacını karşılamak olarak belirlendiğinden, tartışmalı konularda doktrindeki görüş farklılıklarına atıf yapmakla yetinilmiş veya konuya ilişkin çok kısa değerlendirmeler yapılmıştır.

Çalışmada 1 Mart 2019 tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri esas alınmıştır.

Eserle ilgili çalışmalarda zaman zaman görüş ve düşünceleriyle katkıda bulunan kıymetli meslektaşlarımız Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK'e ve Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Çelebi CAN'a çok teşekkür ediyoruz.

Kitabın düzenlenmesi, yazım hatalarının giderilmesi ve diğer eksikliklerinin tamamlanması konusunda destek veren araştırma görevlilerimiz, Dr. Esra KAŞAK, Dr. Bilge AYTUĞAR, Yasemin AŞLAR ÜÇYILDIZ ve Gözde Sena ERGİNBAY'a çok teşekkür ediyoruz.

Kısa sürede dizgi ve mizanpaj işlerini tamamlayarak eseri yayına hazırlayan Yetkin Yayınevi yöneticileri Y. Ziya GÜLKÖK'e, Muharrem BAŞER'e ve çalışanlarına da teşekkürü borç biliyoruz.

Söğütözü, Mart 2019
Prof. Dr. Rıza AYHAN

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V

İÇİNDEKİLER VII

KISALTMALAR XLIX

KAYNAKÇA LIII

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ VE NİTELİĞİ

GİRİŞ 1

I) ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ 1

A) ŞAHSIN HUKUKU VE ŞİRKET 1

B) BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET 3

1) Genel Olarak 3

2) Sözleşme ve Şirketler Hukuku 5

a) Edim İlişkisine Göre Borç Sözleşmeleri 6

aa) Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 6

bb) Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler 6

cc) Çok Taraflı Sözleşmeler 6

b) Zaman Yönünden Sözleşmeler 7

aa) Ani (Yalın) Sözleşmeler 7

bb) Sürekli Sözleşmeler 7

c) Önsözleşme ve Asıl Sözleşme 8

C) EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET 10

1) Ferdi Mülkiyet 10

2) Birlikte Mülkiyet 10

a) Paylı (Müşterek) Mülkiyet 10

b) Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyeti 11

§2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

I) TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ 14

A) ŞİRKET KAVRAMI 15

1) Kişi Birliği Olarak Şirketler 15
a) Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak Şirket 16
b) Tek Ortaklı Şirketler 16
c) Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler 18
2) Sözleşme 18
a) Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti 19
aa) Tek Taraflı Hukuki İşlem Niteliği 19
bb) İki Taraflı Hukuki İşlem (Sözleşme) Niteliği 20
cc) Müşterek Hukuki İşlem Niteliği 21
b) Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği 23
c) Şirket Sözleşmesinin Tarafları 24
aa) Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar 24
aaa) Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ortak Olması 24
bbb) Sadece Gerçek Kişilerin Ortak Olabileceği Şirketler 25
ccc) Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Birliklerinin Şirkete Ortak Olması 25
bb) Tarafların Ehliyeti 27
aaa) Gerçek Kişilerin Ehliyeti 27
bbb) Tüzel Kişilerin Ehliyeti 28
d) Şirket Sözleşmesinin Şekli 28
aa) Çok Ortaklı Şirketlerde Şekil 29
bb) Tek Ortaklı Şirketlerde Şekil 29
e) Şirket Sözleşmesinin Geçerli Olmasının Esasları (Hâkim Olan İlkeler) 30
aa) Bir Şirket Sözleşmesinin Bulunması 30
bb) Güvenin Korunması İlkesi 31
cc) Anonim Şirketlerle İlgili Özel Düzenleme 32
3) Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti 33
a) Ortak Amaç 33
b) Katılım Payı Yükümlülüğü 34
c) Kazanç ve Zarara Katılma İradesi 36
d) Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio Societatis) 37
e) Ortak Amaç Açısından Şirketler ve Özel Hukuktaki Diğer Kişi Birlikleri 38
aa) Ortak Amaç Açısından Şirket ve Dernekler 38

bb) Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Birlikleri ve Şirketler 39
B) ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK 40
1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler 40
a) Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketlerin Tasnifi 42
aa) Şahıs Şirketleri – Sermaye Şirketleri 43
aaa) Şahıs Şirketleri 43
bbb) Sermaye Şirketleri 44
bb) Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler 45
aaa) Ticaret Şirketlerinde Ortakların Sınırsız Sorumluluğu 45
bbb) Ticaret Şirketlerinde Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 46
cc) Sermaye Niteliği Bakımından Şirketler 47
aaa) Değişir Sermayeli – Değişmez Sermayeli Şirketler 47
(1) Değişir Sermayeli Şirketler 47
(2) Değişmez Sermayeli Şirketler 47
(a) Basit Sermayeli Şirketler 48
(b) Esas Sermayeli Şirketler 48
b) Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketlerde Sorumluluk 49
aa) Şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğu 50
bb) Ortakların Şirket Tüzel Kişiliğinin Borçlarından Sorumluluğu 50
2) Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler 50
II) İRADENİN OLUŞTURULMASI 51
A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI 51
1) Organ Kavramı 52
a) Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ 52
aa) Geniş Anlamda Organ 52
bb) Dar Anlamda Organ 52
aaa) Şeklî Organ 52
bbb) Fiilî Organ 53
b) Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde Başvurulacak Esaslar 54
aa) Şekli Kıstas 54

aaa) Organın Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmesi 55
bbb) Organın Kuruluş Belgelerinde Belirlenmesi 55
ccc) Organların Yetkili Makamlarca Tayini 55
bb) Maddi Kıstas 55
2) Organlarda İradenin Oluşumu 56
a) Toplantıya Davet (Çağrı) 57
b) Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı) 57
c) Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı) 58
aa) Karar Yeter Sayısı Çeşitleri 58
aaa) Oy Birliği (İttifak) 58
bbb) Oy Çokluğu (Ekseriyet) 58
(1) Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet) 59
(2) Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet) 59
(3) Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet) 59
bb) Oy Verme 60
cc) Oylarda Eşitlik 60
d) Kararların Etkileri 61
B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN OLUŞTURULMASI 61

İKİNCİ BÖLÜM

§3- ADİ ŞİRKET

GİRİŞ 63

I) ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMESİ 64

II) ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN ÖNEMİ 65

III) ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI 66
A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI 66
B) ÖZELLİKLERİ 68
1) Kişi Unsuru 68
2) Şirket Sözleşmesi 70
a) Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği 72
b) Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti 73
aa) Sözleşmenin Tarafları 73

bb) Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti 73
c) Sözleşmenin Şekli 75
3) Ortak Amaç 77
a) Genel Olarak 77
b) Ortak Amacın Niteliği 78
aa) Amacın İktisadi Olması 78
bb) Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulup Kurulamayacağı 79
4) Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis) 80
5) Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü 81
a) Katılma Payının Mahiyeti 81
b) Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi 84
aa) Katılma Payının İfası 84
bb) Katılma Payının İfa Edilmemesi 85

IV) ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK 86

A) GENEL OLARAK 86
B) ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI 86
1) Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti 86
2) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre Taraf Ehliyeti 86
3) Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği 87
4) Sorumluluk 88
5) Haksız Fiilden Sorumluluk 88
6) Ticaret Unvanı 89
7) Defter Tutma 89
8) Vergi 90
9) Yerleşim Yeri 90
10) Tâbiiyet 91

V) UYGULAMADA ADİ ŞİRKET 91

A) KURULUŞ ORTAKLIĞI 92
B) GİZLİ ŞİRKET 92
C) ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ 93

VI) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 93

A) GENEL OLARAK 93

1- Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti 94
2- Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü 94
a) Özen Yükümünün Kapsamı 94
b) Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi 95
3- Eşitlik İlkesi 96
4- Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri 96
B) ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ 97
1- Mali Nitelikteki İlişkiler 97
a) Katılma Payı 97
b) Kazanç ve Zarara Katılma 97
aa) Kazanç ve Zarar Kavramı 98
bb) Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması 98
cc) Kazanç ve Zararın Paylaştırılması 99
aaa) Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara Göre Paylaştırılması 99
bbb) Kanun Gereğince Paylaşma 101
c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı 101
d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı 102
2- Şahsi Nitelikteki İlişkiler 103
a) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı 103
aa) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti 103
bb) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı 104
aaa) Olağan İşlerde Yönetim Yetkisi 104
bbb) Olağanüstü İşlerde Yönetim Yetkisi 104
cc) Yönetim Hakkının Kazanılması 106
dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması 107
aaa) Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması 107
bbb) Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması 108
ccc) Kanun Hükmü Gereğince Kazanılan Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması 108
ee) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması 109
aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü 109
bbb) İtiraz 109
b) Adi Şirketlerde İnceleme Hakkı 110

c) Adi Şirketlerde Rekabet Yasağı 111
aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti 111
bb) Rekabet Yasağının Kapsamı 111
cc) Rekabet Yasağının Yaptırımı 112
dd) Zamanaşımı 112
C) ADİ ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ 113
1) Adi Şirketlerde Temsil 113
a) Adi Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması 114
b) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 114
c) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı 114
d) Temsilin Sonuçları 115
2) Adi Şirketin ve Ortakların Borç ve Taahhütlerden Sorumluluğu 115
a) Adi Şirketin Sorumluluğu 115
b) Ortakların Sorumluluğu 115
VII) ADİ ŞİRKETLERDE OY HAKKI VE KARAR 116
VIII) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK 116
D) ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE PAYIN DEVRİ 117
1) Şirkete Yeni Ortak Alınması 117
2) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınması 117
a) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınmasının Şartları 118
aa) Ortaklık payını devreden ile devralan arasında, ortaklık payının kısmen veya tamamen devredilmesine ilişkin bir "devir sözleşmesinin" yapılması 118
bb) Ortaklık payının kısmen veya tamamen devri suretiyle şirkete yeni ortak alınmasında oybirliğinin aranması 118
b) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Yeni Ortağın Şirkete Girmesinin Usulü 120
3) Alt Katılım 120
E) ÇIKMA VE ÇIKARILMA 121
1. Genel Olarak 121
2. Çıkma 121
a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkma 121

b) Kanundan doğan çıkma hâlleri 122
aa) Diğer ortakların rızasıyla çıkma 122
bb) Kanun gereğince çıkma 122
aaa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması 122
bbb) Kısıtlanması 122
ccc) İflâsı 123
ddd) Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi 123
eee) Ortağın ölmesi 123
3. Çıkarılma 124
a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılma 124
b) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılma 125
aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması 125
bb) Ortağın kısıtlanması 125
cc) Ortaklardan birinin iflâsı 126
dd) Bir ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi 126
ee) Ortaklardan birinin ölümü 126
4. Çıkma ve Çıkarılma Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Sona Erdiği An 127
a) Çıkmanın hüküm ifade ettiği an 127
aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an 127
bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an 128
b) Çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an 128
aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an 128
bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an 129
5) Çıkan Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu 130
a) Çıkma veya çıkarılmanın sorumluluk üzerine genel etkileri 130
b) Çıkma ve çıkarılmada özel hâller 131
aa) Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketin muaccel olan ve olmayan borçlarından sorumluluğu 131
bb) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması veya güvence verilmesi 131

aaa) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması 131
bbb) Çıkan veya çıkarılan ortağa güvence verilmesi 132
6) Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları 133
a) Çıkma ve çıkarılmanın yönetim ve temsil yetkisi üzerine etkileri 133
b) Çıkma veya çıkarılma hâlinde ortaklık payının tasfiyesi 134
aa) Ayrılan ortağın ortaklık payının diğer ortaklara geçmesi 134
bb) Tasfiye payının tespiti ve ödenmesi 135
c) Malvarlığının yetersizliği 136
d) Tamamlanmamış işler 136
IX) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ 137
A) SONA ERME SEBEPLERİ 137
1) İnfisah (Dağılma) Sebepleri 138
a) Kanunda öngörülen infisah sebepleri 138
aa) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi 138
bb) Ortaklardan birinin ölmesi ve sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması 139
cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi 140
aaa) Ortağın kısıtlanması 140
bbb) Ortağın iflâsı 141
ccc) Ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi 142
dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi 142
b) Sözleşmede öngörülen infisah sebepleri 143
2) Fesih Sebepleri 142
a) Kanunda öngörülen fesih hâlleri 144
aa) Ortakların alacağı kararla fesih 144

bb) Kanunda tanınan feshi ihbar hakkının kullanılmasıyla şirketin sona erdirilmesi 144
aaa) Kanundan doğan feshi ihbar hakları 144
(1) Şirketin belirsiz süreli olması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı 144
(2) Şirketin ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı 145
bbb) Kanundan doğan feshi ihbar hakkının kullanılması 145
b) Şirket sözleşmesinde öngörülen fesih hakkı 146
c) Mahkeme kararıyla (haklı sebeplerle) fesih 147
B) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI 148
1) Sona ermenin şirketin yönetimine etkisi 149
2) Adi Şirketin Tasfiyesi 150
a) Tasfiye kavramı 150
b) Tasfiye hâlinin şirkette meydana getirdiği değişiklikler 150
c) Tasfiye hâline uygulanacak hükümler 151
d) Tasfiye görevlileri 151
aa) Tasfiye görevlilerinin atanması 151
aaa) Tasfiye görevlilerinin şirket sözleşmesi uyarınca atanması 151
bbb) Tasfiye görevlisinin ortakların kararıyla atanması 152
ccc) Tasfiye görevlisinin kanun gereği atanması ... 152
ddd) Tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması. 152
bb) Tasfiye görevlilerine ilişkin şartlar 153
cc) Tasfiye görevlilerinin hukuki durumu 154
dd) Tasfiye görevlilerinin hak ve yetkileri 155
aaa) Tasfiye görevlilerinin hakları 155
bbb) Tasfiye görevlilerinin yetkileri 156
ee) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesi 156
aaa) Tasfiye görevlisi sıfatının sona erme sebepleri 156
(1) Azil 156
(2) İstifa 157
(3) Diğer sona erme sebepleri 157
bbb) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesinin duyurulması 157
e) Tasfiye işlemleri 157

aa) Tasfiyeye başlanmadan evvel alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler 158
bb) Dış tasfiye 159
cc) İç Tasfiye 159
dd) Kapanış hesabının hazırlanması 160
f) Tasfiyenin Kapanışı 160
3) Şirketin Tasfiyesinin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi 161

X) ZAMANAŞIMI 162
A) ADİ ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ZAMANAŞIMI 162
B) ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ZAMANAŞIMI 162
1) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresi 163
2) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresinin Başlaması 163

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
§4- TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

GİRİŞ 165

I) TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI 165

II) TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ 166
A) ŞAHIS ŞİRKETLERİ 167
B) SERMAYE ŞİRKETLERİ 167
C) KOOPERATİF ŞİRKET 168

III) TÜZEL KİŞİLİK 169
A) TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI 170
B) TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI 170
1) Bağımsız Malvarlığı 170
2) Ticaret Unvanı 170
3) Yerleşim Yeri (Merkez) 171
4) Tabiiyet 171
5) Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti 172
6) Hukuka Aykırı Fiillerinden Sorumluluk 174

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER 174

V) TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE 175
A) SERMAYE KOYMA BORCU 175
1) Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilebilecek Değerler 175
2) Katılma Payı Taahhüdünde Uygulanacak Hükümler 176
a) Taşınmazlara İlişkin Hükümler 176
b) Taşınırlara İlişkin Hükümler 177
c) Fikrî Mülkiyet Haklarına İlişkin Hükümler 178
d) Kişisel Emek ve Ticari İtibarla İlgili Hükümler 179
e) Ticari İşletmenin Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilmesiyle İlgili Hükümler 179
f) Para ve Alacaklarla İlgili Hükümler 180
aa) Paranın Sermaye Olarak Konulması 180
bb) Alacak 180
3) Katılma Payı Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı 182
4) Temerrüt Faizi 182
5) Faiz ve Ücret Alma Hakkı 183
B) SERMAYE KOYMA BORCUNDA KABUL GÖREN KARİNELER 183

VI) ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 183
A) ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 184
B) SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI 184

VII) ZAMANAŞIMI 184

§5-TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ

I) TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ 187

II) TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ 188
A) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN AMACI 189
B) DENETİM İLKELERİ 189
C) DENETİME KONU İŞLEMLER 190
D) DENETİM USULÜ 191
E) DENETİM RAPORLARI 191
1) Düzenlenecek Raporlar 191

a) Teftiş Raporu 192
b) Soruşturma Raporu 192
c) İnceleme Raporu 192
2) Fesih Davası 192

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
§6- KOLLEKTİF ŞİRKET

I) KOLLEKTİF ŞİRKET KAVRAMI 195

II) KOLLEKTİF ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ 197
A) Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulması 197
B) Ticari İşletmenin Ticaret Unvanı Altında İşletilmesi 198
C) Ortaklarının Gerçek Kişi Olması 198
D) Ortakların Şirket Borçlarından Dolayı Sınırsız ve Müteselsil Sorumlu Olması 199
E) Tüzel Kişilik 199

III) KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU 200
A) Şirket Sözleşmesi 200
1) Şirket Sözleşmesinin Şekli 200
2) Şirket Sözleşmesinin İçeriği 201
a) Şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu kayıtlar 201
(1) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları 201
(2) Şirketin kollektif olduğu 201
(3) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi 201
(4) Şirketin işletme konusu 202
(5) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği katılma payının belirtilmesi 203
(6) Şirketi temsile yetkili kimselerin belirtilmesi 203
b) Şirket sözleşmesine ihtiyari olarak konulabilecek kayıtlar 203
3) Şirket Sözleşmesinin İmzalanması 204
B) Şirket Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürü yahut Yardımcısı Huzurunda İmzalanması veya Sözleşmedeki İmzaların Noterce Onaylanması 204
C) Ticaret Siciline Tescil ve İlân 205
1) Tescil 205
a) Tescil Başvurusuna Yetkili Kişiler 205

b) Tescili Talep Süresi 206
2) İlân 206
3) Tescilin ve İlânın Hükmü 206

IV) KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA EKSİKLİK VEYA SAKATLIK 207

A) Tescil Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemiş Olması 208
B) Şirket Sözleşmesinin Kanuni Şekilde Yapılmaması veya Sözleşmeye Konması Zorunlu Olan Kayıtlardan Birinin veya Bazılarının Eksik yahut Geçersiz Olması 208

V) KOLLEKTİF ŞİRKETİN EHLİYETİ 208

VI) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ 209

A) Genel Olarak 210
1) Ortaklar Arasındaki İlişkilerin Mahiyeti 210
2) Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü 210
3) Eşitlik İlkesi 211
4) Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri 211
B) Kollektif Şirketlerde İç İlişki 212
1) Mali Nitelikteki İlişkiler 212
a) Sermaye Koyma Borcu 212
b) Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma 213
aa) Finansal Tablolarının Çıkartılması 213
bb) Kâr ve Zararın Paylaştırılması 213
aaa) Kâr ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara Göre Paylaştırılması 214
bbb) Kâr ve Zararın Paylaştırıcı Tarafından Paylaştırılması 214
ccc) Kanun Gereğince Paylaşma 214
cc) Kâr ve Zararın Paylaştırılmasına İtiraz 214
c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı 215
d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı 215
2) Şahsi Nitelikteki İlişkiler 216
a) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkı 216
aa) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti 216
bb) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı 217
cc) Yönetim Hakkının Kazanılması 218

dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması 218
aaa) Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması 219
bbb) Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması 219
ee) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması 220
aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü 220
bbb) İtiraz 220
b) Kollektif Şirketlerde Denetim ve Bilgi Edinme Hakkı 221
c) Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağı 222
aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti 222
bb) Rekabet Yasağının Kapsamı 222
cc) Rekabet Yasağının Yaptırımı 223
dd) Zamanaşımı 224
C) Kollektif Şirketlerde Dış İlişki 224
1) Kollektif Şirketlerin Temsili 224
a) Kollektif Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması 224
b) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kaldırılması 225
c) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Geri Alınması 227
d) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı 227
e) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 228
f) Temsil Yetkisinin Hükümleri 229
2) Kollektif Şirketin ve Ortaklarının Şirketin Borç ve Taahhütlerinden Dolayı Sorumluluğu 229
a) Kollektif Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu 229
b) Ortakların Sorumluluğu 229
aa) Ortakların Sorumluluğunun Esasları 230
bb) Ortakların İkinci ve Birinci Dereceden Sorumluluğu 230
aaa) Şirkete Karşı İcra Takibinin Semeresiz Kalması 231
bbb) Şirketin Sona Ermesi 231
ccc) Şirketin İflâsı 232
VII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KARAR 232
A) Kollektif Şirketlerde Oy Hakkı 233

B) Kollektif Şirketlerde Karar 233
1) Karar Yetersayısı 234
a) Kanunda Öngörülen Karar Yetersayıları 234
b) Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Karar Yetersayıları 234
2) Kararların İptali 234

VIII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK 235

A) Şirkete Yeni Ortak Alınması 235
B) Payın Devri 236

IX) ÇIKMA VE ÇIKARILMA 237

A) Ortağın İrade Beyanına Bağlı Olarak Şirketten Çıkması ve Çıkarılması 237
1) Ortağın Şirketten Çıkması 237
a) Sözleşme Hükümlerine Göre Çıkma 237
aa) Rızaî Çıkma 237
bb) Kendiliğinden Çıkma 238
b) Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Çıkma 238
2) Ortağın Şirketten Çıkarılması 238
a) Sözleşmede Öngörülen Sebeplerle Çıkarılma 238
b) Kanunda Öngörülen Çıkarılma Sebepleri 239
aa) Ortağın İflâsı Hâlinde Çıkarılma 239
bb) Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine Çıkarılma 239
aaa) Alacağını Tahsil Edemeyen Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine Borçlu Ortağın Çıkarılması 239
bbb) Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirket Süresinin Uzatılmasına İtirazı Hâlinde Borçlu Ortağın Çıkarılması 240
cc) Süresiz Şirketlerde Şirketin Feshini Talep Eden Ortağın Çıkarılması 240
dd) Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması 240
c) Çıkarılma Kararına İtiraz 241
B) Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması 241
1) Haklı Sebeple Çıkarılma Kararı Alınamaması Hâlinde Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması 241
2) İki Ortaklı Kollektif Şirkette Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması 241

C) Çıkma ve Çıkarılmanın Hükümleri 242
1) Çıkma ve Çıkarılmanın Ticaret Unvanına Etkisi 242
2) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi 242
a) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklık Sıfatını Sona Erdirmesi 243
b) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Tasfiye Payını Talep Hakkı 243
3) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu 244
a) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğunun Esasları 244
b) Tamamlanmamış İşler 244

X) ORTAĞIN ÖLÜMÜ 245
A) Şirket Sözleşmesinde Şirketin Ölen Ortağın Mirasçılarıyla Devam Edeceğine İlişkin Düzenleme Bulunmaması 245
B) Şirket Sözleşmesinde Şirketin Ölen Ortağın Mirasçılarıyla Devam Edeceğine İlişkin Düzenleme Bulunması 245

XI) KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ ve TASFİYE 246
A) Kollektif Şirketin Sona Ermesi 246
1) Kollektif Şirketlerin İnfisahı (Kendiliğinden Sona Ermesi). 247
a) Kanunda Öngörülen İnfisah Sebepleri 247
aa) Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi 247
bb) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması hâlinde ortaklardan birinin ölmesi 248
cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi 248
dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi 248
ee) Şirketin iflâsı 249
ff) Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybı 249
gg) Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi 249
b) Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebepleri 249
2) Kollektif Şirketlerin Feshi 250

a) Kanunda Öngörülen Fesih Sebepleri 250
aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması 250
bb) Belirsiz süreli kollektif şirketlerde ortakların fesih hakkı 251
cc) Ortakların kararıyla fesih 251
b) Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebepleri 252
3) Kollektif Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi 252
a) Kollektif Şirketlerin Haklı Sebeple Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi 252
aa) Dava süresi 253
bb) Fesih Kararı 253
b) Kollektif Şirketlerin Kuruluşundaki *Tescil ve İlân* Merasimine Aykırılık Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Fesih 254
c) Kollektif Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Fesih 254
B) Kollektif Şirketin Tasfiyesi 254
1) Tasfiyenin Şirket İlişkileri Üzerindeki Etkileri 255
a) Tüzel Kişiliğin Ehliyeti 255
b) Ticaret Unvanı 256
c) Defter Tutma 256
2) Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi 256
a) Ortakların Hak ve Borçları 257
b) Yönetim ve Temsil Yetkisi 257
c) Denetleme Hakkı 257
3) Tasfiye Memurları 257
a) Tasfiye Memurlarının Seçimi/Atanması ve Görevden Alınması 257
aa) Tasfiye Memurlarının Seçimi veya Atanması 258
bb) Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması 258
aaa) Ortak olan tasfiye memurunun görevden alınması 258
bbb) Ortak olmayan tasfiye memurunun görevden alınması 259
ccc) Mahkeme kararıyla atanan tasfiye memurunun görevden alınması 259
b) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi 259
c) Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri 260
aa) Koruma tedbirleri almak 260

bb) Defter Tutmak 260
cc) Son bilançoyu çıkarmak 260
d) Tasfiye Memurlarının Hakları 261
4) Tasfiye İşlemleri ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 261

BEŞİNCİ BÖLÜM

§7- ADİ KOMANDİT ŞİRKET

I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ 263
A) KAVRAM 263
B) ÖZELLİKLER 263
1. Kişi (Şahıs) 264
2. Ticari İşletme 264
3. Ortakların Sorumluluğu 264
4. Ticaret Unvanı 264
5. Tüzel Kişilik 264
II. İŞLEYİŞ 265
A. İÇ İŞLEYİŞ 265
1. Mali İlişkiler 266
a. Sermaye Koyma Borcu 266
b. Kâr ve Zarara Katılma 266
c. Tasfiye Payı 266
2. Şahsi İlişkiler 267
a. Yönetim Yetkisi 267
b. İtiraz Hakkı 267
c. Denetim Yetkisi 267
d. Rekabet Yasağı 267
B. DIŞ İŞLEYİŞ 268
1. Ortaklığın Temsili 268
2. Şirket Borçlarından Sorumluluk 268
C. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER 269
III. SONA ERME VE TASFİYE 270

ALTINCI BÖLÜM

ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR VE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

§8- *ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR*

I) KAVRAM (TANIM) 272

II) ANONİM ŞİRKETİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ 272

III) ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ 273

A. TİCARET UNVANI 273
B. SERMAYE 274
C. TÜZEL KİŞİLİK 274
D. AMAÇ VE KONU 274
E. ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLULUĞU 274

IV) ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ 275

A) ORTAK SAYISI AÇISINDAN 275
B) TÂBİ OLDUKLARI HÜKÜMLER AÇISINDAN 275
C) HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN 275
D) ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN 276
E) BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLUP OLMAMALARI AÇISINDAN 276

V) ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER 277

A) ÇOĞUNLUK İLKESİ 277
B) HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINDA YARARLANMA İLKESİ 277
C) DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ 278
D) EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ 278
E) EŞİT İŞLEM İLKESİ 279
F) BORÇLANMA YASAĞI 281
1. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı 281
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı 282
G) MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ 282

§9- ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

I) KURULUŞ İŞLEMLERİ 283

A) ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI 283
1) Esas Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Unsurlar 284
a) Kurucu/Kurucular 284
b) Ticaret Unvanı 284
c) Şirket Merkezinin Bulunacağı Yer 285
d) Şirketin İşletme Konusu 285
e) Şirketin Sermayesi ile Her Payın İtibarî Değeri, Bunların Ödenmesinin Şekil ve Şartları 285
f) Pay Senetlerinin Türü 286
g) Devir Sınırlamaları 286
h) Paradan Başka Sermaye Olarak Konan Haklar ve Ayınlarla İlgili Bilgiler 286
ı) Kurucularla Yönetim Kurulu Üyelerine ve Diğer Kimselere Şirket Kârından Sağlanacak Menfaatler 287
i) Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bunlardan İmzaya Yetkili Olanlar ve İlk Yönetim Kurulu Üyeleri 287
j) Genel Kurulların Toplantıya Nasıl Çağırılacakları, Oy Hakları 287
k) Şirkete Ait İlânların Nasıl Yapılacağı, ... 287
l) Pay Sahiplerinin Taahhüt Ettiği Sermaye Paylarının Türleri ve Miktarları 287
m) Şirketin Hesap Dönemi 288
2) Esas Sözleşmede Yer Alabilecek İhtiyari Unsurlar 288
a) Varsa Şirketin Süresi 288
b) Şartlı Sermaye Artırma Yöntemi veya Kayıtlı Sermaye Sistemi Kabul Edilmişse Buna İlişkin Hususlar 288
c) Tanınan İmtiyazlar 288
B) ANONİM ŞİRKETİN KURULMASI 289
C) SERMAYENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMESİ 289
D) GEREKİYORSA BAKANLIK İZNİ 291
E) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN 292

II) KURULUŞTAN SONRA PAYLARIN HALKA ARZEDİLMESİ 293

III) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİK VE AYKIRILIKLARIN YAPTIRIMI 293

IV) KURULUŞ SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU 294

V) KANUNA KARŞI HİLE 294

YEDİNCİ BÖLÜM

§10- ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

I) KURUL-ORGAN OLARAK YÖNETİM KURULU 298

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER 299

A. GENEL OLARAK 299

B. ÜYELİĞE SEÇİLME/ATANMA KOŞULLARI 299

1. Vatandaşlık 299
2. Yerleşim Yeri 299
3. Ehliyet 299
4. Seçilme Engellerinin Bulunmaması 300

C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ 301

D. TESCİL VE İLÂN 301

III. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI 302

A. ESAS SÖZLEŞMEYLE ATANMA 302

B. GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLME 302

C. KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ 303

D. YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLME 304

E. SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ATAMA 304

F. BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ 304

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 305

V. YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ 306

A) YÖNETİM YETKİSİ 306

1) Genel Olarak 306

2) Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler 307

a) TTK m.375'te Sayılanlar 308

aa) Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi 308

bb) Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi 309

cc) Muhasebe, Finans Denetimi ve Finansal Planlamaya İlişkin Görevleri 310

dd) Personelin Atanması veya Görevden Alınmasına İlişkin Görev ve Yetkileri 310

ee) Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimine İlişkin Görev ve Yetkileri 311
ff) Defter ve Kayıtların Tutulması ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Görevleri 311
b) Diğer Görev ve Yetkileri 313
B) TEMSİL YETKİSİ 313
1) Temsil Yetkisinin Kapsamı 313
2) Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 314
3) İmza Yetkisinin Verilmesine İlişkin Esaslar 316
4) Çift İmza Kuralı 316
C) YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DELEGASYONU 316
1. Yönetim Yetkisinin Delegasyonu 317
a) Delegasyon İmkânı ve Anlamı 317
b) Delegasyonun Şartları 317
aa) Şekli Şartlar 317
bb) Maddi Şartlar 318
2. Temsil Yetkisinin Delegasyonu 318
VI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI 318
A) MALİ HAKLARI 318
1) Mali Hak Türleri 318
2) Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kazanç Paylarının İadesi 319
B) BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI 320
1) Genel Olarak 320
2) Toplantı Sırasında 320
3) Toplantı Dışında 321
VII. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 321
A. ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ 321
B. EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 322
C. MENFAAT ÇATIŞMASI 322
D. SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE GÖREVLERİ 323
1. Sermaye Kaybı 324
2. Borca Batıklık 324
E. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ 325

1. Genel Olarak 325
2. Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi 326
3. İstisnalar 327
4. İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması 327
5. Kendi paylarını taahhüt yasağı 328
6. Hakların kullanılması 328

VIII. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÂBİ OLDUKLARI YASAKLAR 328
A. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI 328
B. ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI 329
C. ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞI 329

IX. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ALINMASI 330
A. TOPLANTININ ORGANİZASYONU 330
B. KARAR ALINMASI 331
1. Toplantı ve Karar Nisapları 331
2. Sirküler Karar Ve Elektronik Yönetim Kurulu 331
C. KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİ 332
1. Yokluk 332
2. Butlan 332
3. İptal 333

X. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ 334
A. GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ 334
B. İSTİFA 334
C. AZİL 334
D. DİĞER SEBEPLER 334

SEKİZİNCİ BÖLÜM

§11- ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

GİRİŞ 336

I) GENEL KURULUN YETKİLERİ 337
A. GENEL OLARAK 337
B. GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER 337
1. Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi 337
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süreleri, Ücretleri Gibi Konularda Karar Almak 337

3. Denetçinin Seçimi 338
4. Finansal Tablolar, Yıllık Rapor ve Kâr Dağıtımına İlişkin Karar Alınması 338
5. Şirketin Feshi 338
6. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı 338
C. GENEL KURULUN DİĞER YETKİLERİ 339
D. GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI 339
1. Üçüncü Kişilerin Hakları 339
2. Diğer Organların Münhasır Yetkileri 339
3. Bireysel Haklar, Müktesep Haklar ve Azınlık Hakları 340
4. İmtiyazlı Paylar 342
II) GENEL KURUL TOPLANTI TÜRLERİ 342
A. OLAĞAN – OLAĞANÜSTÜ OLMASINA GÖRE 342
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı (Adi Toplantı) 342
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 342
B. ÇAĞRILI –ÇAĞRISIZ OLMASINA GÖRE 343
1. Çağrılı Genel Kurul Toplantısı 343
2. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı 343
C. ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL 343
D. TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL 344
E. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU 345
III) GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 345
A. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ KİŞİ VE ORGANLAR 345
1. Yönetim Kurulu 346
2. Pay Sahipleri 346
3. Tasfiye Memurları 346
B. TOPLANTIYA ÇAĞRI MERASİMİ 346
C. GENEL KURULUN TOPLANMASI 347
1. Toplantı Yeri 347
2. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar 348
3. Genel Kurul Toplantısına Katılması Zorunlu Olanlar 348
4. Toplantı Nisabı 349
a. Kural 349
b. Özel (Ağırlaştırılmış) Toplantı Nisapları 349

a. Denetçilerin Özellikleri 382
b. Denetçinin Seçimi ve Göreve Başlaması 382
c) Denetim Sözleşmesi 384
d) Denetçilik Görevinin İfası 385
5. Denetim Raporu 386
6. Görüş Yazıları 386
7. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi 388
8. Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü 389
C. ÖZEL DENETİM 390
1. Özel Denetimin Amacı ve Kapsamı 390
2. Özel Denetçinin Atanması 391
3. Özel Denetim Raporu 392

ONUNCU BÖLÜM

§ 13- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

I) GENEL DEĞİŞİKLİKLER 394

II. ÖZEL DEĞİŞLİKLİKLER 394

A. SERMAYENİN ARTIRILMASI 395
1. Sermaye Artırımının Nedenleri 395
2. Sermaye Artırımının Başlıca Türleri 396
a. Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı 396
b. Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı 396
c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı 397
3. Artırıma İlişkin Genel Esaslar 397
4. Esas Sözleşmedeki Dayanağın İçeriği 398
5. Pay Sahiplerinin Korunması 399
6. Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması 399
7. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi 399
B. SERMAYENİN AZALTILMASI 400
1. Genel Olarak 400
2. Sermayenin Azaltılması Türleri 401
a) Olağan Sermaye Azaltımı 401
b) Basitleştirilmiş Sermaye Azaltımı 402
C. SERMAYENİN AZALTILMASI VE EŞZAMANLI OLARAK SERMAYENİN ARTIRILMASI 402

D) SINIRLI ESNEK SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYENİN AZALTILMASI 403
E) ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI YÖNTEMLERİ 403
a) Payların İtibarî Değerinin Düşürülmesi 403
b) Pay Sayısının Azaltılması 404
aa) Payların Birleştirilmesi 404
bb) Payların İtfa Edilmesi 406
c) Esas Sermayenin Azaltılması İşlemleri 407

ONBİRİNCİ BÖLÜM

§ 14- ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ

I. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY 409
A. PAY KAVRAMI 409
B. PAYIN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI 411
C. PAY TÜRLERİ 412
1. Nakit Karşılığı Pay-Ayın Karşılığı Pay 412
2. Oy Hakkı Olan Pay-Oy Hakkından Yoksun Pay 413
3. Adi Pay-İmtiyazlı Pay 414
4. Bedelli Pay-Bedelsiz (Gratis) Pay 418
5. İtibari Değeri Olan Pay-İtibari Değeri Olmayan Pay 418
II. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ 419
A. PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI 420
1. Kanundan Doğan Sınırlandırmalar 420
2. İradî Sınırlandırmalar 421
B. PAY SAHİPLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ 422
C. PAY SAHİBİNİN HAKLARI 423
1. Pay Sahipliği Haklarının Korunma Gücü Açısından 423
a. Vazgeçilemez Haklar 424
b. Müktesep Haklar 424
2. Hak Sahiplerinin Çevresi Açısından 425
a. Bireysel Pay Sahipliği Hakkı 425
b. Azınlık Hakkı 425
aa) Olumsuz Azınlık Hakları 425
bb) Olumlu Azınlık Hakları 426
c. Grup Hakkı 427
3. Hakların İçeriği Açısından 428
a. Mali (Malvarlıksal) Hakları 428
aa) Kâr Payı Hakkı 428

bb) Hazırlık Devresi Faizi Hakkı 430
cc) Tasfiye Payı Hakkı 431
dd) Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı) 432
ee) Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı 432
ff) Bedelsiz Payı Edinme Hakkı 433
gg) İdari (Katılma) Hakları 433
aaa) Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı 433
bbb) Oy Hakkı 434
ccc) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 436
ddd) Özel Denetim İsteme Hakkı 437
D. PAY SAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 438
1) Sermaye Koyma Borcu (Tek Borç İlkesi) 438
2) İkincil Yükümlülükler 441
3) Sadakat Yükümlülüğü 441
4) Sır Saklama Yükümlülüğü 442
III) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER 442
A) PAY SENETLERİ 443
1) Pay Senedi Kavramı 443
2) Pay Senedi Türleri 443
a. Hamiline Yazılı Pay Senetleri 444
b. Nama Yazılı Pay Senetleri 444
c. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri 445
aa) Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar 445
bb) Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar 446
B) İLMÜHABERLER 448
C) İNTİFA SENETLERİ 448
D) BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER 448

ONİKİNCİ BÖLÜM
§ 15- ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME, TASFİYE VE HUKUKİ SORUMLULUK

I- ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYE 452
A) ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ 452
1. İnfisah Sebepleri 452

a) Sürenin Sona Ermesi 452
b) İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesiyle 453
c) Esas Sözleşmede Sayılan İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi 454
d) Şirket Sermayesinin 2/3'ünün Karşılıksız Kalması 454
e) Anonim Şirketin İflası 455
2. Fesih Sebepleri 455
3. Genel Kurul Kararıyla Fesih 455
4. Mahkeme Kararıyla Fesih 455
a) Şirketin Zorunlu Organlarının Mevcut Olmaması 456
b) Kamu Düzenine ve İşletme Konusuna Aykırı Faaliyetlerde Bulunmak 456
c) Şirket Esas Sözleşmesinde Öngörülen Fesih Sebeplerinin Gerçekleşmesi 457
d) Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi 457
aa) Kanundaki Düzenleniş Şekli 457
bb) Haklı Sebep Kavramı 458
cc) Haklı Sebeple Fesih Davasında Usul 459
dd) Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Hâkimin Verebileceği Kararlar 459

II) ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ 460

A. TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ 461
1) Şirketin Tüzel Kişiliği Varlığını Sürdürür 461
2) Şirketin Amacı Değişir 461
3) Şirketin Ticaret Unvanı Zorunlu Ek Alır 462
4) Şirketin Organları Varlığını Sürdürür 462
B) TASFİYE MEMURLARI 462
C) ATANMALARI VE GÖREVDEN ALINMALARI 463
D) TASFİYE İŞLEMLERİ 465
1. Envanter ve Bilanço Hazırlanması 466
2. Alacaklılara Davet 466
3. Diğer Tasfiye İşleri 467
E) TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN 468
F) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME 468

§ 16- ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK

I) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI 470

A. ZARAR 470

B. KANUNA VEYA ESAS SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK 472

1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması 473
2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi 474
3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk 474
4. Halktan Para Toplamak 475

C. İLLİYET BAĞI 476

D. KUSUR 476

II) HUKUKİ SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER 478

A. SORUMLULUĞUN AKDİ OLMASI 478

B. SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI 479

1. Mutlak Teselsül 480
2. Farklılaştırılmış Teselsül 480
   a) Özellikleri 480
   b) Zarar Görenin Dava Açma Hakkı 481
   c) Tazminat Miktarının Hesaplanması 480
   d) İç İlişkide Rücû Davası 483
   e) Farklılaştırılmış Teselsül Uygulamasına Örnek 483

III) SORUMLULUK DAVASI 485

A. DAVACILAR 485

1) Anonim Şirket 485
2) Pay Sahipleri 486
3) Şirket Alacaklıları 487

B. DAVALILAR 487

1. Kurucular 488
2. Yönetim Kurulu Üyeleri 488
3. Diğer Yöneticiler 489
4. Denetçiler 490
5. Tasfiye Memurları 490

C. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 491

IV) SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER 491

A. KUSURSUZLUĞUN İSPATI (YETKİ DEVRİ HALİ) 491

B. İBRA 494

1. İbra Kararının Alınması ... 494
a) Açık İbra ... 494
b) Örtülü (Zımni) İbra ... 497
2. İbranın Etkisi ... 498
3. İbranın Kaldırılamaması ... 499
4. Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra ... 499
C. ZAMANAŞIMI ... 500
V) KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK ... 500
VI) CEZAİ SORUMLULUK ... 501

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
§ 17- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

I. KAVRAM VE ÖZELLİKLER ... 503
II. ŞİRKETİN KURULUŞU ... 504
A) ESAS SÖZLEŞME ... 504
B) KURUCULAR ... 504
C) TESCİL VE İLAN ... 505
III. ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ ... 505
A) YÖNETİM KURULU ... 505
1. Yönetim ve Temsil ... 505
2. Rekabet Yasağı ... 506
B) GENEL KURUL ... 506
C) DENETİM ... 506
IV. SONA ERME VE TASFİYE ... 506

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM506
§ 18- LİMİTED ŞİRKETLER

I) LİMİTED ŞİRKETLE İLGİLİ GENEL ESASLAR ... 507
A) KAVRAM VE ÖZELLİKLER ... 507
1) Kavram ... 508
2) Özellikler ... 508
a. Kişi (Şahıs) ... 509
b. Ticaret Unvanı ... 510
c. Esas Sermaye ve Pay ... 510
d. İşletme Konusu ... 512

e. Tüzel Kişilik 512
f. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu 512

II) KURULUŞ 513
A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ 513
1. Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Kayıtlar 514
2. Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Halinde Bağlayıcı Olan Kayıtlar 514
B. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI 515
C. TESCİL VE İLAN 515
D. ŞİRKETİN KURULUŞUNDAN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER VE MASRAFLAR 516
E. ESAS SERMAYENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖDENMESİ 517
F. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE FESİH 518

§ 19- LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ

I) GENEL KURUL 519
A) GENEL KURULUN YETKİLERİ 519
B) GENEL KURUL TOPLANTILARI 520
1. Çağrı Usulü ve Gündem 521
2. Toplantı ve Karar Yetersayıları 522
a) Alelade Kararlar (Basit Nisap) 522
b) Önemli Kararlar (Ağırlaştırılmış Nisap) 523
c) Kanunda Öngörülen Diğer Özel Kararlar 524
3. Oy Hakkı ve Hesaplanması 524
4. Oy Hakkından Yoksunluk 526
5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği 526

II) MÜDÜRLER 526
A. MÜDÜRÜN SEÇİLMESİ 527
B. BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜN BELİRLENMESİ 528
C. MÜDÜRLERİN ÖZELLİKLERİ 528
D. MÜDÜRLERİN GÖREVLERİ 529
E. MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 530
1. Özen ve Sadakat Yükümlülüğü 530
2. Rekabet Yasağı 530
3. Eşit İşlem Yükümlülüğü 531

4. Müdürlerin Şirketin Mali Durumunun Bozulduğunu Bildirim Yükümlülüğü 531
5. Müdürlerin Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 532
F. MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİ 532
1. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları 532
2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması veya Kaldırılması 533
G. TİCARİ MÜMESSİLLER (TEMSİLCİLER) VE TİCARİ VEKİLLER 535
H. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU 536

III) DENETİM 536

§ 20- LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK SIFATI VE BUNA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR

I) ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ 538
A. PAY DEFTERİ 538
B. PAY SENEDİ DÜZENLENMESİ VE ORTAK SIFATININ KAZANILMASINDAKİ ETKİSİ 539
C. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI 540
1. Aslen Kazanma 540
2. Devren Kazanma 540
a. Payın Sözleşmeyle Devri 540
aa) Devir Sözleşmesi 541
bb) Devrin Genel Kurulda Onaylanması 541
cc) Pay Devrinin Yasaklanması 542
dd) Devir İşlemlerinin Tamamlanması 542
b. Payın Kanunen Devri 543
c. Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Kurulması 544
d. Şirketin Kendi Paylarını İktisabı 545
e. Pay Devrinin Tescili 546
D. ORTAK SIFATININ KAYBEDİLMESİ 547
1. Çıkma 547
a. Şirket Sözleşmesi İle Ortaklara Çıkma Hakkı Tanınması 547
b. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Çıkma 548
c. Çıkmaya Katılma 549
2. Çıkarılma 549
3. Ortaklık Sıfatını Kaybeden Ortağa Ayrılma Akçesi Ödenmesi 550

4. Ayrılma İşlemlerinin Tamamlanması 551
II) ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 551
A. ORTAKLARIN HAKLARI 552
1. Mali Haklar 552
a) Kâr Payı Hakkı 552
b) Tasfiye Payı Hakkı 553
c) Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı 553
2. İdari Haklar 554
a. Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Kullanma 554
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı 554
c. Çıkma ve Çıkmaya Katılma Hakkı 555
d. Haklı Nedenlerle Şirketin Feshini İsteme Hakkı 555
B. ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 555
1. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü 555
2. Bağlılık Yükümlülüğü 556
3. Rekabet Yasağı 557
4. Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 557
5. Ek Ödeme Yükümlülüğü 557
a) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Genel Özellikleri 557
b) Ek Ödeme Yükümlülüğünün İstenebilmesi İçin Gerekli Şartlar 558
c) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Sona Ermesi 558
d) Ek Ödemenin İadesi 558
6. Yan Edim Yükümlülüğü 559
7. Haksız Alınan Kâr Paylarının İadesi Yükümlülüğü 559

§ 21- LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

I) ALELADE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 560
II) ÖZEL ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 560
A. ESAS SERMAYE ARTIRIMI 560
B. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI 561

§ 22- LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

I) SONA ERME 562
II) TASFİYE 562

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

I) GENEL OLARAK 563

II) TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİN DÜZENLENMESİ 564

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ÜST NORM VE GENEL NORM NİTELİĞİ 564

IV) KAVRAMLAR 565

§ 23- BİRLEŞME

I) GENEL OLARAK 567

II) BİRLEŞME KAVRAMI 567

III) BİRLEŞMENİN UNSURLARI 568

A) BİRLEŞMEDEN EVVEL EN AZ İKİ TİCARET ŞİRKETİNİN VEYA TİCARET ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINACAK EN AZ BİR TİCARİ İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ 568

1) Ticaret Şirketinin Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri ile Birleşmesi 569

a) Geçerli Birleşmeler 569

aa) Sermaye şirketleri 569

bb) Şahıs şirketleri 569

cc) Kooperatifler 569

b) Ticaret Şirketinin Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri ile Birleşmesinde Özel Hâller 570

aa) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması 570

bb) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma 571

2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesi 572

a) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesinin Esasları 572

b) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesine Uygulanacak Hükümler 572

aa) Tasfiye Hâlindeki Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeyi Devralması 573

bb) Borca Batık Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeyi Devralması 573

cc) Devralınan Ticari İşletmenin Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması 573
dd) Ticari İşletmeyi Devralan Ticaret Şirketinin Sermaye Artırımı Yapması 574
ee) Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınmasına Uygulanacak Diğer Hükümler 574
B) MALVARLIKLARININ BİRLEŞMESİ 574
C) BİRLEŞEN ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATLARININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE DEVAM ETMESİ 575
D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ 576
E) KÜLLİ HALEFİYET 576
F) BİR ŞİRKET ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEK 576
IV) BİRLEŞME TÜRLERİ 576
V) ORTAKLIK PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI 578
A) ORTAKLIK SIFATININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE DEVAMINDA, HAKLARIN DAĞILIMI 578
1) Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Tanınan Haklar 579
a) Devrolunan Şirket Pay Sahiplerine Tanınan İstem Hakkının Kapsamı 579
b) Değişim Oranını Tespit Tarihi 581
2) Devrolunan Şirkette İntifa Hakkı Sahiplerine Tanınan Haklar 581
B) AYRILMA AKÇESİ 582
VI) BİRLEŞME İŞLEMLERİ 583
A) BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ 584
B) BİRLEŞME RAPORU 585
C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI 587
D) BİRLEŞME KARARI 588
E) BİRLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ 590
VII) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE BİRLEŞMESİ 592
A) OY HAKKI VEREN PAYLARIN TAMAMINA SAHİP OLUNMASI HALİNDE 593
B) OY HAKKI VEREN PAYLARIN EN AZ %90'INA SAHİP OLUNMASI HÂLİNDE 594
VIII) BİRLEŞMENİN HÜKÜMLERİ 595

A) GENEL HÜKÜMLERİ 595
B) ALACAKLILAR, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI VE İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMLERİ 595
1) Alacaklılar Açısından Hükümleri 595
2) Ortakların Sorumlulukları Açısından Hükümleri 596
3) İş İlişkileri Açısından Hükümleri 597

§ 24- BÖLÜNME

I) GENEL OLARAK 599

II) BÖLÜNME KAVRAMI 600
A) GENEL OLARAK 600
B) BÖLÜNMENİN TANIMI 601

III) BÖLÜNMENİN AMACI 601

IV) BÖLÜNMENİN UNSURLARI 602
A) BÖLÜNMEDEN EVVEL BÖLÜNECEK BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN MEVCUDİYETİ 602
1) Geçerli Bölünmeler 602
2) Bölünmede Özel Hâller 603
B) MALVARLIĞININ BÖLÜNMESİ 604
C) BÖLÜNEN SERMAYE ŞİRKETİNİN/ KOOPERATİFİN ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATININ MALVARLIĞINI DEVRALAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE VEYA KOOPERATİFLERDE DEVAMI 604
D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ 605
E) HALEFİYET 605
F) BİRDEN FAZLA SERMAYE ŞİRKETİ VEYA KOOPERATİF HÂLİNE GELMEK 607

V) BÖLÜNMENİN TÜRLERİ 607

VI) BÖLÜNME İŞLEMLERİ 610
A) BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ 610
B) BÖLÜNME RAPORU 613
C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI 616
D) BÖLÜNME KARARI 617
E) BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ 619

VII) KOLAYLAŞTIRILMIŞ BÖLÜNME 621

VIII) BÖLÜNMENİN HÜKÜMLERİ 622

A) GENEL OLARAK 622
B) BÖLÜNMENİN DIŞINDA KALAN MALVARLIĞI 623
C) ALACAKLILARIN KORUNMASI, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI VE İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMLERİ 624
1) Alacaklıların Korunması 624
2) Sorumluluk İlişkileri 625
a) Bölünmeye Katılan Şirketlerin/Kooperatiflerin Sorumluluğu 625
b) Ortakların Kişisel Sorumluluğu 626
c) İş İlişkileri Açısından Hükümleri 628

§ 25- TÜR DEĞİŞTİRME

I) TÜR DEĞİŞTİRME KAVRAMI 629

II) TÜR DEĞİŞTİRMENİN UNSURLARI 629
A) TÜRÜ DEĞİŞECEK BİR TİCARET ŞİRKETİ VEYA TİCARİ İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ 629
1) Ticaret Şirketlerinin Türünün Bir Başka Ticaret Şirketi Türüne Dönüşmesi 630
a) Geçerli Tür Değiştirmeler 630
b) Kollektif şirketin komandit şirkete ve komandit şirketin kollektif şirkete dönüşmesine ilişkin özel düzenleme 631
2) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi 631
a) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesinde Kabul Edilen İlke 631
b) Kollektif veya Komandit Şirketin Tek Kişi İşletmesine Dönüşmesine İlişkin Özel Düzenleme 632
3) Ticari İşletmelerin Ticaret Şirketine Dönüşmesi 632
a) Genel Olarak 632
b) Türk Borçlar Kanunundaki "Ticari İşletmelerin Kollektif veya Komandit Şirkete Dönüşmesi" ile İlgili Özel Düzenleme 633
B) YENİ TÜRÜN ESKİSİNİN DEVAMI OLMASI 633
1) Yeni Ticaret Şirketinin Eskisinin Devamı Olması 634
2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüştürülmesinde, Ticari İşletmenin Eski Ticaret Şirketinin Devamı Olması 635
C) TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATLARININ TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKETTE DEVAM ETMESİ 636

D) TASFİYENİN BULUNMAMASI 636
E) ŞİRKET PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI 637

III) TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ 637
A) TÜR DEĞİŞTİRME PLÂNI 638
B) TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU HAZIRLANMASI 638
C) ORTAKLARIN İNCELEME HAKKI 640
D) TÜR DEĞİŞTİRME KARARI 642
E) TÜR DEĞİŞTİRMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI 643

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE TÜR DEĞİŞTİRMESİ 643

V) TÜR DEĞİŞTİRMENİN HÜKÜMLERİ 643
A) GENEL OLARAK 643
B) ALACAKLILARIN VE ÇALIŞANLARI KORUNMASI 644
1) Alacaklıların Korunması 644
2) Ortakların Sorumlulukları 644
3) İş İlişkileri 646

§ 26- YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

I) ORTAKLIK PAYLARININ VE ORTAKLIK HAKLARININ İNCELENMESİ İLE DENKLEŞTİRME AKÇESİNİN TESPİTİ 647

II) BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ 648

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SORUMLULUK 652
A) Sorumluluk Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 653
B) Zamanaşımı 654

IV) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ 654

ONALTINCI BÖLÜM
§ 27- ŞİRKETLER TOPLULUĞU

I) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AMACI VE KAPSAMI 655

II) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 657

A) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI 658
1) Tanımı 658
2) Unsurları 659
a) Bağlı Ticaret Şirketinin Mevcudiyeti 659
b) Hâkim Şirkete (Teşebbüse) Bağlı Olmak 662
aa) Genel Olarak 662
bb) Hâkimiyet Türleri 667
aaa) Fiili Şirketler Topluluğu 667
(1) Kontrol sistemine dayalı fiili şirketler topluluğu 667
(2) Hâkimiyet sistemine dayalı fiili şirketler topluluğu 669
bbb) Sözleşmeye Dayalı Şirketler Topluluğu 671
cc. Hâkimiyetin Tespiti Esasları 673
aaa) Genel Olarak 674
(1) Bildirim yükümlülüğü 674
(2) Bildirimin tescil ve ilânı 676
(3) Bildirim ve tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 676
bbb) Pay ve pay oranlarına göre hâkimiyet esasları 677
(1) Hâkimiyetin pay oranına göre tespiti esasları 677
(2) Hâkimiyetin oy oranına göre tespiti esasları 678
B) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ 679

III) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN KURULMASININ SONUÇLARI 680
A) GENEL OLARAK 681
1) Bağlı Şirketin "Bağlılık Raporu" Hazırlaması 681
2) Hâkim Şirketin Bağlı Şirketten Bilgi Alma Hakkı 684
3) Hâkim Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı 686
4) Hakların Donması 687
5) Özel Denetim 689
6) Payları Satın Alma Hakkı 690
B) TAM HÂKİMİYET HALİNDE 691

IV) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK ESASLARI 694

A) HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI 694
1. Kötüye Kullanma Halleri 694
2. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılabilmesi İmkânı (Denkleştirme) 695
3. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasının Sonuçları 696
a) Kaybın Denkleştirilmemesi ve Zararın Tazmini 696
aa) Tazminat Davası ve Diğer Koruma Vasıtaları 697
bb) Tazminata Hükmedilememesi 697
b) Bağlı Şirketin Kararına Muhalif Olan Pay Sahiplerinin Hakları 697
B) TAM HÂKİMİYET HALİNDE SORUMLULUK 698
C) GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK 699

KISALTMALAR CETVELİ

AATUHK	Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
Abs	Absatz
AET	Avrupa Ekonomik Topluluğu
APOK/ AktG	Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu (Aktiengesetz)
Art	Madde
Aufl	Baskı
AÜHFD	Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
BanK	Bankacılık Kanunu
BATİDER	Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi
BDDK	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BK	Borçlar Kanunu
Bkz	Bakınız
BSK	Basler Kommentar
C	Cilt
CHK	Handkommentar zum Schweizer Privatrecht
eSPK	eski Sermaye Piyasası Kanunu
EPDK	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
EÜHFD	Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
FE	Forum Europaeum
ff	ve devamı (fortfolgende)
GÜHFD	Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
HAAO	Halka Açık Anonim Ortaklık

HD	Hukuk Dairesi
Hrsg	Herausgeber
İBirK	İsviçre Birleşme Kanunu
İkt. Mal.	İktisat ve Maliye
K	Kanun
KGK	Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
KHK	Kanun Hükmünde Kararname
KİT	Kamu İktisadi Teşebbüsleri
KoopK	Kooperatifler Kanunu
Krş	Kuruş
KUKO	Kurz Kommentar
m	Madde
N	numara
OFK	Orell Füssli Kommentar
OR	Obligationen Recht
PSMKBİGŞ	Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketler
RK	Rekabet Kurumu
S	Sayı
s	Sayfa
SerPK	Sermaye Piyasası Kanunu
SPK	Sermaye Piyasası Kurumu
Y	Yargıtay
YBHD	Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi
TBK	Türk Borçlar Kanunu

TBMM	Türkiye Büyük Millet Meclisi
TFM	Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
TCMB	Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TMK	Türk Medeni Kanunu
TMSF	Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu
TSY	Ticaret Sicili Yönetmeliği
TTK	Türk Ticaret Kanunu
TTSG	Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
vd	ve devamı
VegüV	Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften
VUK	Vergi Usul Kanunu
YHGK	Yargıtay Hukuk Genel Kurulu

KAYNAKÇA

Von Ah, J.: Die Kaptialherabsetzung von Publikumsgesellshaften, Zürich 2001.

Akdağ Güney, N.; Anonim Şirkette Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul 2016 (Yönetim Kurulu).

Akdağ Güney, N.: *"6552 Sayılı Torba Kanun ile TTK md. 371'e Eklenen Yedinci Fıkraya İlişkin Değerlendirmeler"*, Halil Arslanlı Bilim Arşivi, http://arslanlibilimarsivi.com, son erişim tarihi: 20/02/2019.

Aker, H.: *"Hâkim İşletme ile Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu"*, BATİDER, 2003, C. XXII, S. 2, s. 153-204.

Akyılmaz, B./Sezginer, M./Kaya, C., Türk İdare Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2016.

Al Kılıç, Ş.; Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara 2017.

Ansay, T.: Adi Şirket Bir Tüzel Kişi midir? Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU'na 65. yaşgünü Armağanı, İstanbul 1999, s. 1 vd.

Arıcı, M. F.: *"Sermaye Şirketleri Hukukunda Vadeli Alacağın Sermaye Olarak Konulması Yasağı"*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2015, C. LXXIII, S. 1, s. 319-337.

Arslanlı, H.; Anonim Şirketler, C. II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul 1960.

Aydoğan, F., Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012.

Aygül, M., Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Temeli, Ankara 2007.

Ayhan, R.: "*Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr ve Kazanç Paylarının İadesi*", Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Editör: Prof. Dr. Erol Ulusoy, İstanbul 2014.

Ayhan, R./Çağlar, H.: Ticari İşletme Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2018.

Aytaç, Z.; Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982.

Aytuğar, B.: Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018.

Aytuğar, B.: *"Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Sahibi Grubunun Yönetim Kurulunca Temsil Edilme Hakkı"*, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. XXIII, S. 1, s. 93-126.

Bahtiyar, M.: Ortaklıkları Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2019 (Ortaklıklar Hukuku).

Bahtiyar, M.: Anonim Ortaklık AnaSözleşmesi, İstanbul 2001 (Anasözleşme).

Barlas, N.: Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Baskı, İstanbul 2016.

Baudenbacher, C.: Basler Kommentar Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH, Helbing Lichtenhahn Verlag, 5. Auflage, Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, Basel 2016

Becker, H. Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch Bj. V. Obligationenrecht, 2. Abteilung, Bern 1934.

Bilge, M. E.; "*Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi*", EÜHFD, 2012, C. XVI, S. 3–4, s. 261- 293.

Bilge, M.E.: "*Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı*", EÜHFD 2005, C. IX, S. 1-2, s. 429-449.

Bilgeç, H., Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2017.

Bilgili, F., Türk Ortaklıklar Hukuklunda Gizli Ortaklık İlişkileri, 2003.

Bilgili, F./Demirkapı, R.: Şirketler Hukuku, 9. Baskı, Bursa 2013.

Bozkurt, T.: Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) – Die Vinkulierung-, İstanbul 2016.

Böckli, P.: Schweizer Aktienrecht, 4. Aufl., Zürich 2009.

Von Bühren, R./Stoffel, W.A./Weber, R.H.: Grundriss des Aktienrechtsi Mit Berücksichtigung der laufende Revision, 3.Aufl., Basel 2011.

Von Büren, R./Stoffel, W.A./Schnyder, A.K./ChristenWestenberg, C.: Aktienrecht, Schulthess, Zürich 2000.

Can, M. Ç.: *"Pay Sahiplerinin veya Alacaklıların Doğrudan Zararlarının Tazmini Amacıyla İkame Edilen Sorumluluk Davalarında TTK m. 1534'ün Etkisi"*, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. XXI, S. 4, s. 3-32.

Can, M. Ç.: *"Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi"*, GÜHFD, C. XX, Y. 2016, Sa. 1, s. 27 vd.

Can, M. Ç.: "Türk Borçlar Kanunu'nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak Hukukunda Uygulanabilirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı Mı?", GÜHFD, C. 21, S. 3, s. 35 vd.

Can, O.: 6102 Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara 2015.

Chapuis, C.: Schweizerisches Obligationenrecht, OR Kommentar, OFK-Orell Füssli Kommentar, Hrsg: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser, 3. Aufl. 2016.

Çağlar, H.; Anonim Şirketlerde Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası, Ankara 2017 (İbra).

Çağlar, H.; Anonim Şirketlerde Esas Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010 (Sermayenin Azaltılması).

Çağlar, H., *"Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın "Cartesio" Kararı"*, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C.I, Ankara 2010, s. 623- 638.

Çağlar, H./Kaşak, E., "*Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshine İlişkin TTK m 531 Hükmünün Zaman Bakımından Uygulanması*", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 65, S.3, s. 659-686.

Çamoğlu, E., *"Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu"*, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, 2003, s. 139-146.

Çamoğlu, E.: Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İstanbul 1972.

Çeker, M.: *"Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması"*, TFM, 2015, C.1, S.1, s. 57-64.

Çonkar, M. H., Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye, İstanbul 2016.

Deilmann, B.; Die Entstehung des qualifizierten faktischen Konzerns, Berlin 1990.

Doğan, V., Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 1999.

Doğan, B. F.: Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, 2. Baskı, İstanbul 2011.

Domaniç, H., Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, 3. Bası, İstanbul 1970.

Emmerich, V./Habersack, M.: Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Auflage, C.H. BECK 2013.

Eren, F,: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018.

Eren, F.; Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.

Erdem, N.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi 6102 Sayılı Yeni TTK. Hükümlerine Göre, İstanbul 2012.

Eriş, G.: Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, 3. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2010.

Fellman, W./Müller, K., Berner Kommentar-Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. VI: Das Obligationenrecht, 2.Abteilung, Die einzelnen Vertragverhaltnisse, 8.Teilband (Art.530-544 OR), Bern 2006.

Forstmoser, P., Schweizerisches Aktienrecht, BandI/Lieferung I, Grundlagen, Gründung und Anderungen des Grundkapitals, Zürich 1981.

Forstmoser, P.: Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1987.

Forstmoser, P./Meier-Hayoz, A./Nobel, P., Schweizerisches Aktienrecht, Bern 1996.

Gautschi, G., Das Depotstimmrecht der Banken, in Probleme der Aktienrechtsrevision, Berner Tage für die juristische Praxis, Bern 1972.

Glanzmann, L.: in Fusionsgesetz, Hrsg. Baker&McKenzie, Bern 2003.

Göktürk, K./Can, M.Ç.: *"Farklılaştırılmış Teselsülün-Özellikle-Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması"*. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 2, s. 247-283.

Gözler, K./Kaplan, G.: İdare Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Bursa 2012.

Gürbüz Usluel, A.E., Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı, Ankara 2016.

Handschin, L. / Vonzun, R., Kommentar zum schweizerichen Zivilrecht, Band V/4a, Art. 530-551 OR, Aufl.4., Basel 2009.

Huguenin, J. C., Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht, Zürich 1994.

İlbasmış Hızlısoy, Ö.: Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi, 5. Baskı, Ankara 2016.

İzmirli, Y.: Türk Ticaret Kanununa Göre Tasfiye Memurlarının Görev Yetki ve Sorumlulukları, Ankara 2001

Kägi, A., Die Prioritätsaktien nach schweizerischem und deutschem Recht, Zürich 1918.

Kalender, E.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.392), Ankara 2017.

Kalpsüz, T.: "Bilanço ve Oy Kullanma Esaslarına Aykırılık Sebebiyle Genel Kurul Kararının İptali", BATİDER, 1979, C. X, S.1, s. 23-65.

Karayalçın, Y.:, Ticaret Hukuku, II: Şirketler Hukuku, 2. Baskı, Ankara 1973.

Kaşak, E., Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018.

Kaşak, F. E.: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, İstanbul 2019.

Kendigelen, A.: Yeni Türk Ticaret Kanunu, Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler, B. 2, İstanbul 2012 (İlk Tespitler).

Kılıçoğlu, A., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2012.

Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. 1, Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu, Ankara 2013.

Kırca, İ./Şehirali Çelik, F. H./Manavgat, Ç.: Anonim Şirketler Hukuku, C. 2/2, Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, Ankara 2016.

Kırca, İ.: *"Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Temsilci Sıfatıyla Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu"*, AÜHFD, 2004, C. 53, S. 1, s. 65-76.

Kocayusufpaşaoğlu, N./Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A., Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 5. Bası, İstanbul 2010.

Koch, J.: Aktiengesetz, Hrsg: Uwe Hüffer/Jens Koch, C.H. Beck Verlag, 12. Auflage 2016.

Köksal, A., *"Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 397 İlâ 406 Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu"*, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Ankara, 2010, s.1387-1409.

Krneta, G.: Praxiskommentar Verwaltungsrat. Art. 707-726, 754 OR und Spezialgesetze. Ein Handbuch für Verwaltungsrate, Bern 2005.

Kunz, P. V., Der Minderheitenschutz im schweizerischen Aktienrecht, Bern 2001.

Meier – Hayoz, A./Fortmoser, P., Schweizerisches Gesellschaftsrecht mit Einbezug des künftigen Rechnungslegungsrechts und der Aktienrechtsreform, Aufl.11, Bern 2012.

Mimaroğlu, S. K.: Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti, Ankara 1967.

Moroğlu, E.: Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü, 8. Baskı, İstanbul 2017 (Hükümsüzlük).

Moroğlu, E.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Değerlendirme ve Öneriler, 8. Baskı, İstanbul 2016 (Değerlendirme).

Müller, T.R.: Der Schutz der Aktiengesellschaft vor unzulassigen Kaitalentnahmen, Bern 1997.

Narbay, Ş.: Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 2003.

Narbay, Ş./ Deliduman, S., *"Alman Federal Mahkemesinin (Dış-) Adi Şirketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduğuna İlişkin 29.01.2001 tarihli Kararı"*, Prof. Dr. Ömer Teoman' a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, s. 577-594.

Natterer, J.: Materielle Kontrolle von Kapitalherabsetzungsbeschlüssen? Die Sachsenmilch-Rechtsprechung, AG 2001.

Nomer, N. F., Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994.

Oğuzman, K. / Seliçi, Ö. / Oktay-Özdemir, S.: Eşya Hukuku, 12.Bası, İstanbul 2009.

Oğuzman, K. / Barlas, N.: Medeni Hukuk, 18.Bası, İstanbul 2012.

Oğuzman, K./ Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 10. Baskı, İstanbul 2012.

Özdamar, M.: "*6552 sayılı Kanun ile TTK'da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketlerin Temsili*", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, C. XVIII, S. 3-4, s. 137-164 (6552 sayılı Kanun).

Özdamar, M.: Banka Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2016 (Mali Haklar).

Özdamar, Ö.: Anonim Ortaklıkların Kendi Paylarını İktisap Etmesi (TTK md. 329), Ankara 2005 (İktisap).

Özdamar, Ö.: "*Anonim Şirketlerde Özel Denetim*", Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları, Editör: Prof. Dr. Erol Ulusoy, İstanbul 2014, s. 45-74 (Özel Denetim).

Özenli, S.: Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988.

Özer, I., Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013.

Özkorkut, K.: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim, Ankara 2013.

Özsunay E.: *"Türk Kartel Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs birliklerinin Kararı"*, Rekabet Kurulu Perşembe Konferansları 5, Ankara 2000, s. 41-69.

Öztan, B.: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970.

Paslı, A.: *"Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan "Oy"un Hukuki Niteliği"*, İÜHFM, 2009, C. LXVII, S. 1-2, s. 167-182.

Pekcanıtez, H./Sungurtekin Özkan, M./Özekes, M./Atalay, O.: *İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı*, İstanbul 2018.

Plüss, A./Facincani-Kunz, D.: Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung, Art. 530-771 OR – VegüV, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Hrsg. Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb Schulthess Juristische Medien AG, 3. Aufl. 2016.

Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 5. Baskı, Ankara 2017 (Genel Esaslar).

Pulaşlı, H.: Şirketler Hukuku Şerhi C.I-II-III, 3. Baskı, Ankara 2018 (Şerh).

Pulaşlı, H.: Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 6. Baskı, Ankara 2018 (Kıymetli Evrak).

Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E., Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, İstanbul 2014 (I).

Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E., Ortaklıklar Hukuku II, 13. Baskı, İstanbul 2017 (II).

Rado, T., Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul 1974.

Von Salis, U.: Die Gestaltung des Stimm- und des Vertretungsrechts im schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1996.

Schluep, W. R.: Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht, Zürich 1955.

Schönenberger. W./Jäggi, P.: Obligationrech, Zürcher Kommentar, Teilbd. V/1a: Allegemeine Einleitung und Kommentar zu OR 1-17, Zürich 1973.

Serozan,R.: Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007.

Soykan, İ. C.: Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, İstanbul 2012.

Sunaric, P.: Kurzkommentar OR, Art. 1-1186 OR, Hrsg: Honsell, Heinrich, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014.

Stieb, S., *Zulassung der Einpersonen*. GmbHR in Portugal, GmbHR 1997

Şahin, A.: Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi; İstanbul 2013.

Şener, O. H., Adi Ortaklık, Ankara 2008.

Tahiroğlu, B.: Roma Borçlar Hukuku, 2009.

Tandoğan, H., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkiler, C. I/II, 4. Baskı, İstanbul 2008.

Tekil, F., Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998.

Tekinalp, Ü., Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2015 (Sermaye Ortaklıkları),

Tekinalp, Ü.: Tek Kişilik Ortaklık 1 Tek Paysahipli Anonim Ortaklık, İstanbul 2011 (Tek Kişi Ortaklık),

Tekinalp, Ü.: Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Pay Defteri Hukuku ile), İstanbul 2012 (Bağlam),

Tekinalp, Ü., "*Katılma İntifa Senetleri (Partizipationsschein)*", BATİDER, C. VI, 1971 (Katılma Senetleri).

Tekinalp, Ü.: Anonim Otaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara 1965.

Teoman, Ö.: Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Oy Hakkından Yoksunluğu, Ankara 1983.

Thalmann, P./Benninger, N., *"Bares ist Wahres Zur Liberierung in Fremdwährungen nach schweizerischem Aktienrecht"*, Reprax, 4/2003.

Tillmann, E., Das Depotstimmrecht der Banken, Zürich 1985.

Türk, H. S., "*Anonim Ortaklık Pay Senetlerinde İtibari Değer Farkları*", Prof. Dr. Mahmut Koloğlu'ya 70'inci Yaş Armağanı, Ankara 1975, s. 567-580.

Ulmer P./Schäfer, C.: Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB Band: 7 Schuldrecht Besonderer Teil IV., 7. Aufl., 2017.

Ulusoy, E.: Ulusoy, E., Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, Ankara 2016.

Urkan, E.: Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk, Ankara 2016.

Uygur, T., Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. 8, 3. Baskı, 2010

Ülgen, H., Hukuki Görünüş Nazariyesi, İstanbul 2005.

Watter, R./Rampini, C.: Basler Kommentar, Fusionsgesetz (FusG), 2. (Hrsg: Watter, Rolf /Vogt, Nedim Peter/Tschäni, Rudolf /Daeniker, Daniel), 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.

Watter, R./Roth Pellanda, K.: Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Verlag.

Weber, R. H.: Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Verlag.

Wolf, Mathias; in Basler Kommentar, Fusionsgesetz, Hrsg. Watter, Rolf, Nedim Peter/Tschäni, Rudolf/Daeniker, Daniel, Basel 2015.

Yalman, M / Taylan, E., Adi Ortaklık, Ankara 1976.

Yıldız, B., *"TTK Tasarısı'nda Şirketlerin Ehliyeti ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki "Ultra Vires" Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi"*, 2006, AÜHFD, C. 55, S. 1-2, s. 321-353.

Yıldız, B.: *"Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği"*, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111-134.

Yıldız, Ş.:, *"Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu"*, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan'a 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001,

Yıldız, Ş.: Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007.

Yılmaz, E.: Hukuk Sözlüğü, Ankara 2017, 7. Baskı.

Yongalık, A.: Adi Şirkette Sermaye Payı, Ankara 1991.

Yördem, Y.: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi, Ankara 2017.

Ziemons, H.: in: Handbuch der Aktiengesellschaft, Hrsg. Hildegard Ziemons/ Burkhard Binneweis, Köln 2011.

BİRİNCİ BÖLÜM

§ 1- ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ VE NİTELİĞİ

GİRİŞ

Pozitif hukukumuzda şirketler, Türk Borçlar Kanununda *"Özel Borç İlişkileri"* kısmının on sekizinci bölümünde *"Adi ortaklık sözleşmesi"* ve Türk Ticaret Kanununun ikinci kitabında *"Ticaret Şirketleri"* başlığı altında; ticaret şirketlerinden olduğu kabul edilen kooperatifler ise, 1163 sayılı *"Kooperatifler Kanunu"*nda düzenlenmiştir[1].

I) ŞİRKETLER HUKUKUNUN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

Hukuk kaidelerinin şirketlere taallûk eden (şirketlerle ilgili olan) kısmına şirketler hukuku adı verilmektedir. Buna göre *iki veya daha ziyade kişinin*[2] *emek ve/veya mallarını müşterek bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmeyi (şirket sözleşmesi) ilgilendiren muamele, fiil ve işlere dair olan hukuk kuralları, şirketler hukukunun uygulama alanına* girmektedir.

Bu haliyle şirketler hukuku, (diğer hukuk dallarıyla ilişkisi bir kenara), bir şahıs (kişi) topluluğu olması sebebiyle "*şahsın hukukunu*", akit olması nedeniyle "*borçlar hukukunu*", mamelek üzerindeki haklar dolayısıyla da "*eşya hukukunu*" ilgilendiren bir hukuk dalıdır.

A) ŞAHSIN HUKUKU VE ŞİRKET

Şahıs (kişi), haklardan yararlanan, hak sahibi varlık demektir. Bu sebeple hukuk, ilk olarak hak süjesinin kim olacağı sorusuna cevap vermektedir. Şahsın (kişiler) hukuku, hukuk sistemimizde isabetli bir

---

1 Ticaret Kanununun 2'nci Kitabında düzenlenen şirketlerden başka, aynı Kanunda düzenlenmiş bulunan donatma iştirakini de Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiş şirketlere dâhil edebiliriz. Ayrıca özel kanunlarda düzenlenen ve hakkında özel kanun çıkartılmış şirketler de mevcuttur. Özel kanunlarda düzenlenmiş şirketlere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununda düzenlenen bankaları; hakkında özel kanun çıkartılmış şirketlere de TCMB'yi örnek olarak gösterebiliriz.

2 Tek Kişilik şirket için bkz., TTK m.338/1; m.573/1.

yaklaşımla Türk Medeni Kanununun birinci kitabında ele alınmış; hukukun varlık nedeni olan hak süjesi belirlendikten sonra haklardan, yükümlülüklerden ve hukuki muamelelerden bahsedilmiştir.

Türk hukuk sisteminde haklara sahip ve borçlara ehil *iki süje* mevcuttur; bu hak süjeleri, *gerçek* ve *tüzel kişilerdir.*

Tam ve sağ doğmak, insan dediğimiz varlık açısından gerçek kişi olabilmek için lâzım ve kâfidir.

Tüzel kişiler, hukuk sisteminde gerçek kişiler yanında bazı kişi veya mal topluluklarına hak süjesi olma yetkisinin verilmesi sonucu kabul edilmiştir. Bu hâliyle *tüzel kişiler*, kişi veya mal topluluklarına hak süjesi olma özelliği bahşedilen, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hukuk düzeni tarafından kabul edilen kişilerdir.

"Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar" (TMK m.47).

Buna göre, kişi topluluklarının tüzel kişilik kazanabilmesi için belirli özellikleri taşıması gerekir. Bu özellikler, *"belli ve sürekli bir amaç"*; *"başlı başına bir varlığa sahip topluluk meydana getirme iradesi"* (*bağımsızlık*), topluluğun belli olan amacını gerçekleştirmek için sahip olması gereken ve kanun koyucu tarafından belirlenen bir *"örgüt"*tür.

Bu özellikler nazara alındığında tüzel kişiler kendi içinde *"kamu hukuku tüzel kişileri"* ve *"özel hukuk tüzel kişileri"* olarak iki grupta incelenmektedir.

"Kamu (hukuku) tüzel kişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur" (Any.m.123/3)[3]. Kamu hizmeti yürütmek maksadıyla kurulan bu tüzel kişiler, özel hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak, kendilerini feshedemezler; mahkeme kararıyla dağıtılamazlar, sona ermeleri yine kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak söz konusu olabilir.

---

[3] Konumuzu ziyadesiyle ilgilendirmeyen ve esas itibariyle devletin denetimi altında faaliyet gösteren kamu hukuku tüzel kişileri, *"kamu idareleri"* (devlet, il özel idareleri, belediyeler, köyler), *"kamu kurumları"* olarak nitelendirilen *"meslek kuruluşları"* (Barolar, Türk Tabipler Birliği), *"sosyal kamu kurumları"* (Sosyal Güvenlik Kurumu), *"kültürel kamu kurumları"*(TRT, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu), *"iktisadi kamu kurumu"* (Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), THY) gibi kurumlardır.

Özel hukuk alanında bir hukuki işlem ile kurulan *"özel hukuk tüzel kişileri"* ise, *"belli olan amaçlarına"* göre, *"kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişileri"* ve *"kazanç paylaşma amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri"* olarak iki ana gruba ayrılırlar.

"Kazanç paylaşma amacı gütmeyen özel hukuk tüzel kişileri", dernekler (TMK m.56-100) ve vakıflardır (TMK.m.101-117). "Kazanç paylaşma amacı güden özel hukuk tüzel kişileri" ise, ticaret şirketleridir (TTK m. 124).

Şirketleri, dernek ve vakıflardan ayıran en önemli unsur; *kazanç paylaşma* amacıdır. Kişi birliği olan dernekler, kendisini oluşturan kişilere kazanç dağıtma amacı güdemezken; kazanç paylaşma maksadıyla (ekonomik amaç) kişi birliği olarak tesis edilen özel hukuk tüzel kişileri (ticaret şirketleri) sadece ortaklarına kazanç dağıtma amacıyla kurulabilir.

Ticaret şirketlerinde kazanç paylaşma (kollektif ve komandit şirketlerde *ticari işletme işletmek*; anonim ve limited şirketlerde *ekonomik*) amacı bulunmalıdır; bu amacın gerçekleşip gerçekleşmemesi, bir diğer ifadeyle ticaret şirketinin kazanç elde edip etmemesi tüzel kişiliğin kazanılmasında önemi haiz değildir.

B) BORÇLAR HUKUKU VE ŞİRKET

1) Genel Olarak

Türk Borçlar Kanununun, Türk Medeni Kanunu ile ilişkisini düzenleyen 646'ncı maddesine göre, *"Bu kanun (Türk Borçlar Kanunu), 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Beşinci Kitabı olup, onun tamamlayıcısıdır".*

Türk Ticaret Kanununun uygulama alanını hükme bağlayan 1'inci maddesinde de, *"Türk Ticaret Kanunu, 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır"* denilmektedir.

Bu iki hüküm birlikte yorumlandığında, Türk Borçlar Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz parçası olduğu ve ihtilâfların yorumlanmasında bahsi geçen kanunların bir bütün olarak ele alınması gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca Türk Medeni Kanununun 5'inci maddesine göre de "*Bu kanun (TMK) ve Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümleri, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanır*". Buna göre, Türk

Borçlar Kanununun genel nitelikteki hükümleri, tüm özel hukuk ilişkilerine ve bu bağlamda Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçası olan Türk Ticaret Kanununa ve dolayısıyla, Türk Borçlar Kanununda düzenlenen "*adi şirkete*" ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen "*ticaret şirketlerine*" uygulanacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, kanunda boşluk olduğunda genel hükümlerin doğrudan doğruya uygulanması değildir; kanunda, ilişkinin niteliğine "*uygun olduğu oranda*" uygulanmasından bahsedilmektedir[4] (TTK m. 126).

Bu değerlendirmeye göre, irade açıklamaları hakkında da, hukukun bütünlüğü esas alınmalıdır[5]. Konumuz açısından önemli olan irade açıklamaları; *hukuki işlemler*, fiili bir sonuca yönelmiş ve açığa vurulması hukuki bir sonuç doğuran *hukuki işlem benzeri fiiller* (temerrüt ihtarında olduğu gibi) ve hukuki işlemlere ilişkin kuralların esas itibariyle uygulanmadığı *maddi fiillerdir*.

Hukuki işlem, hukuk düzeni tarafından irade beyanlarına hukuki sonuç bağlanan işlemlerdir. Buna göre hukuki işlem (kira, satış, kullanma ödüncü, vekâlet, vasiyet, vs.) hukuki sonuca yönelmiş bir veya birden ziyade irade beyanından meydana gelir. Bu anlamda hukuki işlem en az bir irade beyanını içermek zorundadır.

Hukuki işlemler tek taraflı (vakıf kurma, vasiyetname, iptal, rücu, fesih v.s) olabileceği gibi, iki veya çok taraflı da olabilir. İki veya çok taraflı hukuki işlemler, kendi içinde sözleşme (akid) ve karar başlığı altında ayrıma tâbi tutulmaktadır.

---

4 Şirket, sözleşme (akid) olması sebebiyle Borçlar Hukukunun bilhassa uygulama alanı içine girmektedir.

5 Kamu hukukuna ilişkin kurallar bir tarafa, hukuken önemli olguların bazılarında insan iradesi ön plâna çıkarken, bazılarında insan iradesinin bir etkisi bulunmamaktadır. Doğum, ölüm, zamanın geçmesi gibi olgularda insan iradesinin herhangi bir rolü bulunmazken; hukuki işlemlerin de içinde yer aldığı, geniş anlamda *hukuki fiiller* diye adlandırılan olgularda insan iradesi önem kazanmaktadır. Bu anlamda hukuki fiiller, insanların olumlu veya olumsuz biçimde beliren bilinçli iradesi sonucu oluşan, dış âlemde de ifadesini bulan davranışlarıdır.
Geniş anlamda hukuki fiil olarak adlandırılan bu fiillerin bazıları hukuka aykırı fiiller, bazıları ise hukuka uygun fiiller olarak nitelendirilmektedir. Bir hukuki işlemden bahsedebilmek için hukuk düzeni tarafından uygun görülmesi ve irade, tasavvur, his izharları (açığa vurmaları) şeklinde tezahür etmesi gerekmektedir.

2) Sözleşme ve Şirketler Hukuku

Sözleşme, hukuki bir sonuç doğurmak üzere, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının uyuşmasını ifade eder (TBK m.1/1).

Borç kaynağı olarak TBK m.1-40 arasında düzenlenen sözleşme (akid) kavramı (ki buna borç sözleşmesi adı verilmektedir), sadece borç sözleşmesinden ibaret değildir. Aile hukukunda evlenme, evlat edinme, miras hukukunda miras sözleşmesi, eşya hukukunda ayni sözleşme; tartışmalı olmakla birlikte kişiler hukukunda dernek kurma sözleşmesi hep sözleşme kavramı altında anılır.

Buna göre, sözleşme kavramı sadece borç sözleşmesini ifade etmemekte; tasarruf işlemi (ibra sözleşmesi, ayni sözleşme gibi) de sözleşme kavramı altında incelenmektedir. Ancak, diğer sözleşme türlerinden yararlanma imkânı bulsak da, şirketler hukukunda genel olarak borç sözleşmelerinden istifade edilmektedir.

Borçlar hukukunun konusunu oluşturan borç ilişkileri, esas itibariyle Türk Borçlar Kanununda[6] düzenlenmiş; ancak bu düzenlemelerin yanında bazı diğer kanunlarda da sözleşme tipleri ele alınmıştır.

Ancak hemen belirtelim ki, borçlar hukukuna hâkim olan *sözleşme özgürlüğü* prensibi nedeniyle sözleşme tipleri, sadece Türk Borçlar Kanununun özel borç ilişkileri kısmında düzenlenen tiplerle sınırlı değildir. Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmamak kaydıyla; taraflar, diledikleri tipte sözleşme yapma özgürlüğüne sahiptir.

Gerek Türk Borçlar Kanununda gerek başka kanunlarda veya sözleşme özgürlüğüne dayanarak taraflarca serbestçe belirlenen sözleşme tiplerini belli gruplar altında incelemek mümkündür.

Sözleşmelerin tasnifi konusunu borçlar hukuku müelliflerine bırakarak, *şirket sözleşmesinin sözleşmeler arasındaki yerini tespit edebilmek* ve şirket sözleşmesini daha iyi anlayabilmek bakımından, bazı sözleşme gruplarından ve bu sözleşmelerin özelliklerinden bahsetmenin isabetli olacağı kanaatindeyiz.

---

[6] Türk Borçlar Kanunun birinci kısmında, borçlar hukukunun genel hükümleri (m.1-206), ikinci kısmında ise (m.207-649) özel borç ilişkilerini düzenleyen özel hükümleri bir araya getirilmiş; çeşitli sözleşme türleri hükme bağlanmıştır.

a) Edim İlişkisine Göre Borç Sözleşmeleri

Bütün sözleşmeler iki taraflıdır; ancak sözleşmelerden bazıları, sadece taraflardan birini borç altına sokmaktadır (bağışlama vaadi, kefalet gibi). Bunlara "*bir tarafa borç yükleyen sözleşmeler*" denilmektedir.

Sözleşmelerin önemli kısmını ise, her iki tarafa da borç yükleyen sözleşmeler oluşturmaktadır. Her iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin bir kısmı, *tam iki tarafa borç yükleyen* sözleşmeler; bazıları ise *eksik iki tarafa borç yükleyen* sözleşmeler olarak görülmektedir.

aa) Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler

Mübadele sözleşmeleri olarak da nitelendirilen bu sözleşmelerde, karşılıklı edimlerin mübadelesi (değiş-tokuşu) amaçlanmaktadır. Sözleşmenin tarafları hem alacaklı hem de borçlu sıfatını kazanmakta (satış, trampa, istisna gibi); menfaatleri ise birbirine zıt (satıcının menfaati edimi elde edebilmek için malı satmakta, alıcının menfaati ise edim karşılığı malı almakta) ve aynı seviyededir.

bb) Eksik İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmeler

Eksik iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde tarafların ediminde bir mübadele ilişkisi bulunmaz; tarafların borçları karşılıklı değildir. Bu sözleşmelerin bazılarında, ödünç (karz) sözleşmelerinde olduğu gibi, tarafların borçları karşılıklı olarak aynı zamanda değil, sıra ile doğarken; vekâlette olduğu gibi bazılarında da taraflardan biri (vekil) sözleşme kurulduğunda borç altına girerken (üzerine aldığı işi görmek) müvekkil (vekâleti veren) vekilin borcunu yerine getirirken gelişen olaylara göre (vekilin masraflarını ödeme gibi) borç altına girmektedir.

cc) Çok Taraflı Sözleşmeler

Ortaklık sözleşmesi olarak da isimlendirilen bu sözleşmeler, çok taraflı borç doğuran sözleşmelerdir. İki veya daha çok kişinin, maddi veya manevi *müşterek bir menfaati gerçekleştirmek maksadıyla* borç altına girdiği bu sözleşmelerde, *tarafların menfaati birbirine zıt değildir*; taraflar aynı amacı gerçekleştirmek için bir araya gelmektedirler[7].

Bu tür sözleşmelerde tarafların edimlerinin birbiriyle değiştirilmesi, diğer ifadeyle karşılıklılık ilişkisi bulunmaz. Müşterek bir amacı elde

---

[7] 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, anonim ve limited şirketlerin tek ortaklı olabileceği kabul edilmiş; şirket sözleşmesinde esas alınan "iki veya daha fazla kişi" kavramına önemli bir istisna getirilmiştir.

etmek maksadıyla, edimleri değiştirme niyeti olmadan bir araya gelenlerin her birinin borcu, diğerinin taahhüdüne bağlı olmadan tarafları bağlar; taraflardan birinin sözleşmeden doğan borcunu yerine getirmemesi, diğerinin borcunu yerine getirmemesine imkân sağlamaz (ödemezlik def'inden istifade edilemez). Diğer bir ifadeyle, taraflardan biri ortaklık sözleşmesinden doğan borcunu yerine getirmezse, diğer ortaklar sözleşmeden ve kanundan doğan haklarını (ortaklık türüne göre; ortaklığın feshi, ortağın çıkarılması vs.) kullanabilir; ancak sözleşmeden doğan kendi borçlarını yerine getirmekten kaçınamaz.

Ortaklık sözleşmelerinde, iş görme akitlerinde olduğu gibi, işverenin menfaatlerinin ön plâna çıkartılması gibi bir sonuç da yoktur. Ortaklık sözleşmelerinde, tarafların müşterek menfaatlerinin elde edilmesi amacıyla emek ve/veya malların birleştirilmesi söze konu teşkil eder.

b) Zaman Yönünden Sözleşmeler

Şirket sözleşmesinin özelliklerini ifade edebilmek için sözleşmeden doğan ifanın ve ortaya çıkan borç ilişkisinin sürekli olup olmadığına göre yapılan ani (yalın) sözleşmeler ve sürekli sözleşmeler ayrımına da temas edilmelidir

aa) Ani (Yalın) Sözleşmeler

Asli edim yükümünün zaman içerisinde bir defada yerine getirildiği ve edimin yerine getirilmesiyle sözleşmenin sona erdiği (peşin satışta olduğu gibi) sözleşmelere ani sözleşmeler (ani edimli sözleşmeler veya yalın sözleşmeler) adı verilmektedir.

bb) Sürekli Sözleşmeler

Taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğuran ve asli edim yükümünün sözleşmenin devam ettiği süre içinde devam ettiği *veya* muayyen süreler içinde tekerrür eden tek tek edimler şeklinde belirdiği sözleşmelerdir.

Sürekli sözleşmelerde süre, belirli veya belirlenebilen bir süre olabileceği gibi; belirsiz süreler için de sürekli sözleşmeler akdedilebilir. Bu tip sözleşmelerde asıl edim bir defada ifa edilmemekte; taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi doğurmaktadır.

Bu anlamda *şirket sözleşmesi* de kira, hizmet, elektrik tedariki vs. gibi *sürekli sözleşmeler* grubuna girmektedir. Taraflar arasında sürekli

borç ilişkileri doğuran bu tür akitlerde tarafların güven, sadakat ve özen borcu ön plâna çıkar. Sözleşmenin tarafları, şirketin mahiyetine göre farklı şekillerde tezahür etse de sadece sermaye koyma borcunu yerine getirdiğini ifade ederek, sözleşmeden doğan tüm borçlarını yerine getirdiğini iddia edemez.

c) Önsözleşme ve Asıl Sözleşme

"*Bir sözleşmenin ileride kurulmasına ilişkin sözleşme geçerlidir*" (TBK m.29/1). Buna göre, *önsözleşme* öyle bir borç sözleşmesidir ki, onunla taraflardan biri veya birkaçı veya hepsi, ileride asıl sözleşme olarak nitelendirilen bir borç sözleşmesini yapma yükümlülüğü altına girerler.

Borçlandırıcı bir işleme ilişkin olması gereken *önsözleşmeden bahsedebilmek için*; asıl sözleşmenin konusunun yeter derecede belirli veya belirlenebilir olması ve asıl sözleşmenin bağlı tutulduğu şekle uygun olarak yapılması gerekir. Taraflara asıl sözleşmeyi yapma borcu yükleyen bu sözleşmelerde önsözleşme alacaklısı; aynen ifa talep edebileceği gibi, aynen ifa yerine tazminat davası da açabilir.

Bir *şirketin kuruluşu*, şirket kurmak amacıyla -kural olarak- birden fazla kişinin bir araya gelmelerini ve şirket kurma hususunda müzakerelerde bulunmalarını, sözlü veya yazılı yahut resmi bazı işlemleri icra etmelerini ve şirket, *ticaret şirketi ise*; tescil ettirilip tüzel kişilik kazanmasını temin eden uzun bir süreçtir.

Bu bağlamda ticaret şirketinin kurulması için, öncelikle sözleşme hazırlık safhası gerçekleştirilecek, sözleşmenin esaslı unsurlarında mutabakat sağlandığında şirket sözleşmesi yazılı olarak yapılacak, yazılı yapılan şirket sözleşmesindeki imzalar notere (veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanarak) tasdik ettirilecek, Ticaret Bakanlığının izniyle kurulacak şirketlerde izin alınarak, diğer şirketlerde şirket sözleşmesinin noterlikçe (veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanarak) onaylı bir sureti, onay tarihinden itibaren onbeş/otuz gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline verilerek şirketin tescili gerçekleştirilecektir.

Bütün bu süreç nazara alındığında gerek sözleşme hazırlık safhasının gerek şirket sözleşmesinin imzalanmasından sonra tüzel kişilik kazanıncaya kadar geçen süredeki hukuki durumun TBK m.29'da zikredilen bir *önsözleşme* (sözleşme yapma vaadi) *olmadığı* sonucuna varılabilir.

Zira söz konusu adi şirketse, adi şirketin kurulması herhangi bir şekle tâbi olmadığı için, sözleşmenin esaslı noktalarında mutabakat temin edildiğinde zaten şirket kurulmuş olur. Bununla birlikte, adi şirketin kuruluşunda, şirketin hemen kurulmasını istemeyen taraflar, TBK m.29 gereğince, ileride kurulacak bir adi şirket için önsözleşme yapabilirler. Dikkat edilmelidir ki, şirket sözleşmesi hazırlık safhası bir önsözleşme değildir; sözleşme görüşmesidir ve bu görüşmelerden doğan sorumluluk da, sözleşme görüşmelerinden doğan sorumluluktur.

Hazırlık safhasından sonra kurulacak olan şirketin, ticaret şirketi olması halinde de aynı sonuca varılır. Şöyle ki, hazırlık safhasında, bir diğer söyleyişle, tarafların şirket kurmak amacıyla bir araya gelmelerinde, henüz sözleşmenin esaslı noktalarında mutabakat temin edilmemiş; sözleşme kurulmamıştır. İleride kurulacak ticaret şirketinin esaslı noktalarında mutabakat temin edildiğinde ise, şirket sözleşmesi tamam olur. Ancak kurulmak istenen şirket tipine göre ilâve işlemler yapılması gerekir. Bu esastan olmak üzere ticaret şirketleri bakımından, sözleşmenin yazılı hale getirilip, taraflarca imzalanması, imzaların tasdik ettirilmesi şarttır. Bu aşamalar tamamlanıp, şirket ticaret siciline tescil ettirilinceye kadar olan sürede, şirket henüz tüzel kişilik kazanmadığı için, TBK m.620/2 uyarınca bu safha, şirketin mahiyetine uygun düştüğü nispette adi şirket olarak nitelendirilir[8].

Bununla beraber, taraflar TBK m.29 uyarınca, bu safhalarda ayrıca bir önsözleşme yapabilirler; bu önsözleşme ise sözleşmenin kuruluş safhası veya ön şirketle ilgili değildir; ayrı bir sözleşmedir.

Bütün bu değerlendirmeler ışığında *şirket sözleşmesi*, şirketin tüm kuruluş safhaları da dikkate alındığında, bir asıl sözleşmedir; *önsözleşme değildir.*

---

[8] Ancak önemle belirtilmelidir ki, anonim ve limited şirketler, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayesinin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzaların noterce onaylandığı esas sözleşmede anonim veya limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur (TTK m.335/1, 585/1). Sözü edilen şekilde şirket kurma iradelerinin açıklanması, şirketin kurulması için lâzım ve kâfidir. Bununla birlikte şirketin tüzel kişilik kazanması için ticaret siciline tescil şarttır (TTK m.355/1, 588/1). Esas sözleşmenin imzalanması ile tescil arasındaki süreçte taraflar arasındaki ilişki ise, *önsözleşme* (TBK m.29/1) olarak kabul edilemez; bu safhada şirketler ön anonim veya ön limited şirkettir ve kanaatimizce adi şirket hükümlerine tâbidir.

C) EŞYA HUKUKU VE ŞİRKET

Hak, hukuk düzeni tarafından korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi veren bir menfaattir. Haklar çeşitli açılardan tasnife tâbi tutulmaktadır. Bunlardan birisi de iktisadi değeri haiz olup olmamasına göre yapılan sınıflandırmadır.

İktisadi (para ile ölçülebilen) bir değeri olan haklara, *malvarlığı (mamelek) hakları* adı verilir. Alacak hakları, ayni haklar, maddi değeri olan yenilik doğurucu haklar ve mali yönüyle fikri haklar, malvarlığı haklarından kabul edilir.

Bir kimseye (alacaklı) bir başkasından (borçlu) bir şey vermesini, yapmasını veya yapmamasını isteme yetkisi sağlayan haklara "*alacak hakları*"; bir kimseye bir mal üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve herkese karşı ileri sürülebilen haklara da "*ayni haklar*" adı verilir. Ayni haklar, Türk Medeni Kanununun "*Eşya Hukuku*" adını taşıyan dördüncü kitabında düzenlenmiş; "*Mülkiyet*", "*Sınırlı Ayni Haklar*", "*Zilyetlik ve Tapu Sicili*" başlıkları altında ele alınmıştır.

Ayni hakların, hak sahibine eşya üzerinde tanıdığı en geniş yetki mülkiyet hakkıdır. Mülkiyet hakkı, hak sahibinin adedine göre "ferdi mülkiyet" (*tek şahıs mülkiyeti*) ve "*birlikte mülkiyet*" şeklinde ayrıma tâbi tutulur.

1) Ferdi Mülkiyet

Bir kişinin, bir şeye tek başına malik olması haline ferdi mülkiyet (tek şahıs mülkiyeti) adı verilir.

2) Birlikte Mülkiyet

Birden çok kişinin bir şeye birlikte malik olmaları halinde de birlikte mülkiyetten bahsedilir. Birlikte mülkiyet de, kendi içinde iki alt gruba ayrılır.

a) Paylı (Müşterek) Mülkiyet

Paylı (müşterek) mülkiyet, birden çok kişinin aynı eşya üzerinde bilfiil bölünmemiş paylara malik bulunmalarından meydana gelen bir toplu mülkiyet şeklidir.

Paylı mülkiyet, bir hukuki işlemle kurulabileceği gibi resmi makamın tasarrufu, mahkeme kararı veya doğrudan kanun icabı vücut bulabilir. Hangi surette kurulursa kurulsun, paydaşlardan her biri kendi

payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur (TMK m.688/3); payını diğer müşterek maliklerin rızası olmadan devredebilir, rehnedebilir ve bu hak, alacaklılar tarafından haczettirilebilir[9].

Ticaret şirketlerinin ortakları, şirketin malik olduğu eşyanın ortağı değil; şirketin ortağıdır. Bu sebeple ortakların, şirket tüzel kişiliğine ait bir eşya üzerinde, paylı (müşterek) mülkiyetinden bahsedilemez; *eşya üzerinde, şirket tüzel kişiliğinin ferdi mülkiyeti söz konusudur.*

Adi şirketlerin tüzel kişiliği yoktur. Bu sebeple ortaklar eşya üzerinde "*birlikte mülkiyet*" esasına göre hak sahibidir. Adi şirket ortakları, ortaklık sözleşmesine koyacakları bir hükümle, "*paylı mülkiyet*" esasını benimseyebilir[10].

b) Elbirliği (İştirak Hâlinde) Mülkiyeti

Kanun veya sözleşme gereğince, bir ortaklık ilişkisi ile bağlı olan birden fazla kimse, belirli bir eşyanın tamamı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olursa, buna *elbirliği* (iştirak halinde) mülkiyeti adı verilir (TMK m.701). Ancak hemen belirtmek gerekir ki, tanımda sözü edilen ortaklık, tüzel kişiliği bulunmayan, yalın bir ortaklıktır. Şayet *ortaklığın tüzel kişiliği varsa*, elbirliği ile mülkiyet değil; tek şahıs mülkiyeti (tüzel kişinin kendi mülkiyeti) söz konusu olur.

Elbirliği mülkiyetine imkân veren ve tüzel kişiliği bulunmayan ortaklık, ancak kanunda öngörülen bir ortaklık olabilir. Ortakların mal üzerinde ayrı ayrı bir hakkı, payı yoktur; tümü elbirliği (iştirak) ile mala malik oldukları için bu mülkiyet şekline elbirliği (iştirak halinde) mülkiyeti adı verilmektedir.

Paylı (müşterek) mülkiyette, her paydaş kendi payı üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilirken; bir payın söz konusu olmadığı *elbirliği mülkiyetinde* böyle bir imkân söz konusu değildir; mala yönelik tüm hukuki tasarruflar, tüm maliklerin oybirliği ile gerçekleştirilebilir[11]. Diğer bir ifadeyle elbirliği mülkiyetinde her malik, şeyin tamamı üzerinde,

---

9 Pay, maddi kullanmayı gerektiren irtifak haklarına, aksi paydaşlarca kararlaştırılmamışsa, kira sözleşmesine konu teşkil etmez (Bkz., **Oğuzman, K. / Seliçi, Ö. / Oktay-Özdemir, S.**: Eşya Hukuku, İstanbul 2009, 12.Bası, s. 257 vd.).

10 **Handschin, L. / Vonzun, R.**, Kommentar zum schweizerichen Zivilrecht, Band V/4a, Art. 530-551 OR, Aufl.4., Basel 2009, Art. 530, N. 6706 sK. md. 1-3.

11 Bkz., **Oğuzman, K. / Barlas, N.**: Medeni Hukuk, İstanbul 2012, 18.Bası, s.148.

payı oranında bir hakka sahiptir; fakat bu pay sadece nazari olarak mevcuttur. Gaye birliği ortadan kalkmadıkça, elbirliği ile mülkiyet hâline son verilmedikçe, pay üzerinde tasarruf hakkı yoktur.

Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz (TTK m.125/1) olduğu için, *ticaret şirketlerinin şey üzerindeki mülkiyeti, ferdi mülkiyettir*; ortaklar eşyanın maliki değildir. Ortaklar, eşyanın maliki olan şirketin ortağıdır. Buna karşılık, *adi şirketin* tüzel kişiliği olmadığından; sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece, *ortaklar arasında elbirliği mülkiyeti* vardır.

§2- ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

Hukuken korunan ve sahibine bu korumadan yararlanma yetkisi tanınan menfaate hak; menfaati korunan varlıklara (kişilere) hak sahibi denilmektedir. Hakların, hak sahibi gerçek veya tüzel kişiler tarafından iktisabı yahut kaybı; ya bir hukuki olay ya da bir hukuki fiil ya da bir hukuki muamele (işlem) sonucu meydana gelir.

Hukuki işlemler, kendisini oluşturan irade beyanları nazara alınarak, *yöneltilmesi gereken/yöneltilmesi gerekmeyen* irade beyanına dayalı hukuki işlemler veya etki doğurduğu alan bakımından *kişiliği ilgilendiren hukuki işlemler/malvarlığını ilgilendiren hukuki işlemler* yahut malvarlığına yaptıkları etki bakımından *borçlandırıcı işlemler/tasarruf işlemleri/kazandırıcı işlemler*; hüküm ifade edeceği an bakımından da *sağlar arası işlemler/ölüme bağlı tasarruflar* olarak çeşitli şekillerde tasnife tâbi tutulmaktadır.

Hukuki işlemler, gerekli irade beyanı adedi açısından da, *tek taraflı hukuki işlemler*[12]*-iki taraflı hukuki işlemler* (sözleşmeler)[13]*-kararlar*[14] *ve müşterek hukuki işlemler* şeklinde de türlere ayrılmaktadır.

Hukuki işlemlerin bazıları, birden çok kişinin irade beyanlarının birleşmesiyle meydana gelir. *Müşterek hukuki işlem* adı verilen bu işlem, bir tarafın birden çok kişiden oluşması şeklinde ortaya çıkabileceği gibi (birden çok kişinin bir ev kiralamasında olduğu şekilde); çok sayıda kişinin irade beyanının ortak noktada birleşmesi (şirket veya dernek kurma) tarzında da olabilir[15].

---

12 Hukuki sonucun gerçekleşmesi için bir tek şahsın irade beyanının yeterli olduğu hukuki muamelelere tek taraflı hukuki işlemler adı verilmekte; vakıf kurmada olduğu gibi, yenilik doğuran işlemler, tek taraflı hukuki işlemlerle yapılmaktadır.

13 Arzu edilen hukuki sonucun meydana gelmesi için, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının bulunmalarının gerekli olduğu hukuki işlemlere (TBK m.1) iki taraflı hukuki işlemler (sözleşme) denilmektedir.

14 Hukuki işlem türlerinden olan *karardan* bahsedebilmek için, bir şahıs topluluğunun bulunması gerekir. Bir şahıs topluluğunda hukuki bir sonucu gerçekleştirmek üzere, yeter sayıda kişinin iradelerini aynı yönde açıklamalarına ve bu şekilde hukuki sonucun elde edilmesine *karar* denir. Uygun yeter sayının sağlanmasıyla alınan kararlar, (karara katılsın katılmasın) şahıs topluluğunun her üyesini bağlar.

15 Bu konuda geniş bilgi için bkz., **Oğuzman / Barlas**; s. 176-192.

I) TÜRK HUKUKUNDA ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENMESİ

Yukarıda ifade edildiği üzere, Türk Hukukunda şirketler esas itibariyle Türk Borçlar Kanununun Özel Borç İlişkilerini düzenleyen ikinci kısmının 18. bölümünde (m.620-645) "*Adi Ortaklık Sözleşmesi*" başlığı altında ve ticaret şirketleri ise Türk Ticaret Kanununun ikinci kitabında "*Ticaret Şirketleri*" başlığı altında (m.124-644) düzenlenmiş; TTK m.124/1 gereği ticaret şirketi olarak kabul edilen kooperatifler ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda ele alınmıştır.

Kanun koyucu, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerinin, farklı şekilde ifade edilse de [kollektif ve komandit şirketlerde "*sözleşme*" (TTK m.212, 305/2-306), anonim şirketlerde "*esas sözleşme*" (TTK m.332), limited şirketlerde "*şirket sözleşmesi*" (TTK m. 575)] sözleşme temeline bağlı olduğunu hükme bağlamıştır. Aynı durum 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda da *(ana sözleşme)* söz konusudur (m.2).

Bir diğer ifadeyle, bir ticaret şirketinden söz edebilmek için, şirket tipine göre ek işlemlerin yapılması gerekse de; her ticaret şirketi için, "*şirket sözleşmesinin*" varlığı asgari mecburi şart olarak kabul edilmiştir.

Hâl böyle olmasına, her ticaret şirketi ayrı ayrı tanımlanmasına karşın, şirket akdinin tanımı, bahsi geçen kanunlarda yapılmamış; Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinde, "*Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir*" denilmek suretiyle sadece "*adi ortaklık sözleşmesi*" tanımlanmıştır.

818 sayılı Borçlar Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlükte bulunduğu dönemde, *"818 sayılı Borçlar Kanununun 520'nci maddesi, matlabı bakımından adi şirketin tarifini vermekte ise de, bu tarif aslında şirket sözleşmesinin genel bir tarifidir"* denilmekte ve genel şirket sözleşmesi tarifindeki unsurlar, ticaret şirketleri için gerekli olan ek işlemler saklı kalmak kaydıyla, tüm şirketler için geçerli kabul edilmekteydi.

Ancak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 818 sayılı Kanunun adi şirket başlığını taşıyan 520'nci maddesine tekabül eden 620'nci maddesinde bir değişiklik yapılarak, diğer unsurlar aynı kalmak üzere, mad-

de metnine "*şirket bir akittir ki ...*" yerine, "*adi ortaklık sözleşmesi ...*" ifadesi getirilmiştir.

Bu durumda 818 sayılı Kanunun yürürlükte olduğu dönemde olduğu gibi, hâlâ "*adi şirket*" hükümleri "*ticaret şirketleri*"nin genel hükmüdür, denilebilecek midir? Kanaatimizce, bu değişikliğe rağmen, evvelki kanunların (818 sayılı BK ve 6762 sayılı TTK) yürürlükte bulunduğu dönemde yapılan değerlendirmeler geçerliliğini muhafaza etmektedir.

Şöyle ki, TBK'nin 620/2. maddesine göre, "*Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa*" bu şirketler adi şirket kabul edilmektedir. TTK'nin 214'üncü ve 305'inci maddelerine göre de "*Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu kayıtlardan biri veya bazıları eksik veya geçersiz olan*" kollektif ve komandit şirketler; TTK'nin 126. maddesine göre ise, "*... her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri*" adi şirket hükümlerine tâbidirler.

Buna göre, Türk Hukukunda şirket sözleşmesi ile ilgili genel hükümlerin, "*adi ortaklık sözleşmesi*" hakkındaki Türk Borçlar Kanununun 620-645'nci maddeleri arasında yer aldığını söylemek yanlış olmaz kanaatindeyiz.

A) ŞİRKET KAVRAMI

Özel hukuk anlamında *şirket*, sözleşmeyle kurulan ve müşterek bir amacın elde edilmesine hizmet eden bir *kişi birliğidir*[16].

Bu tanıma göre, özel hukuk anlamında bir şirketten bahsedebilmek için üç unsurun bir arada bulunması gerekir: *i)* Bir kişi birliğidir. *ii)* Sözleşme temeline dayanır. *iii)* Müşterek bir amacın bulunması gerekir.

1) Kişi Birliği Olarak Şirketler

Şirketlerin ayırıcı özelliği ister tüzel ister gerçek kişi olsun, kişi birliği olmalarıdır. Bu bakımdan başlı başına bir varlığı olmak üzere, belli amaca özgülenmiş olan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarından (vakıflardan) (TMK m.101) ayrılır. Gerçekten de, şirket (dernekle birlikte) bir

---

16 **Meier – Hayoz, A. / Fortmoser, P.,** Schweizerisches Gesellschaftsrecht mit Einbezug des künftigen Rechnungslegungsrechts und der Aktienrechtsreform, Aufl.11, Bern 2012, s. 2.

amacın gerçekleşmesi için teşkilatlanmış kişi topluluğu; vakıf ise bir amacın gerçekleşmesi için teşkilatlanmış mal topluluğudur.

Şirketler, bir kişi birliğidir. Bunun sonucu olarak, şirketten bahsedebilmek için en az iki kişinin bulunması gerekir. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile hukukumuza giren "*tek ortaklı anonim şirket*" ve "*tek ortaklı limited şirket*" karşısında, en az iki kişi bulunması ve kişi birliği kavramları ayrıca değerlendirilmelidir.

a) Genel Kabul Gören Sisteme Göre Kişi Birliği Olarak Şirket

Türk hukukuna egemen olan düzenlemelere göre (şirket türlerine ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla), bir şirketten bahsedebilmek için en az iki kişinin bulunması gerekir.

b) Tek Ortaklı Şirketler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, bilhassa "*şirketler hukuku*"nda önemli sayılabilecek değişiklikler yapılmış; özellikle de anonim ve limited şirketlerin tek ortakla kurulabileceği hükme bağlanmıştır (TTK m.338, 573)[17].

---

17 TTK'nın 338'inci maddesinin birinci fıkrasının gerekçesinde, "*Birinci fıkra, kurucular için asgari bir sayı öngörmemiş, böylece tek kişilik anonim şirketin kurulmasına ve tek pay sahibi ile devam etmesine izin vermiştir. Şirketin -istisnaen- pay sahibi olduğu durumlarda şirket pay sahibi olarak kabul edilmemiştir. Tek kişilik anonim şirket bütün dünya uygulamasında gereksinimi duyulan bir hukuki organizasyon şeklidir. Bu şekil "şirket" kavramına aykırı olmadığı gibi sanıldığının aksine muvazaaya da pek müsait değildir... Tek pay sahipli bir anonim şirkette bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi, bir tüzel kişi, binlerce pay sahibi bulunan bir pay senetleri borsada işlem gören anonim şirket veya bir sermaye şirketi de olabilir. Batıda tek pay sahipli anonim şirketler sadece bir limited şirket veya işletmeci vakıf tarafından oluşturulmaktadır. İşletmecilik yapan vakfın Türk Medeni Kanununda tanınmamış olması önemli bir eksikliktir. Ancak tek pay sahipli veya ortaklı anonim ve limited şirketlerin, hukukumuzda da gereksinimi duyulan işletmeci vakıfların yolunu açacağı ve Türk hukukunun bu sayede bir düzenlemeye kavuşacağı düşünülmektedir. Tek pay sahibi veya ortağı işletmeci vakıf olan bir anonim veya limited şirket kurumsallaşmanın en uygun aracıdır. Başarılı ve yerleşik kimi aile şirketlerini tek kişilik anonim şirketin sunacağı olanaklarla dağılmaktan ve kaybolmaktan kurtulmaları bu örgütlenme şekliyle mümkün olabilecektir. Tek pay sahipli veya ortaklı anonim ve limited şirketler bağlamında oluşacak öğretinin ve ilkesel yargı kararlarının Türk hukukuna*

Uygulama kolaylığı temin etmek maksadıyla kabul edilen bu düzenleme, şirketler hukukunun bugüne kadar devam eden anlayışına aykırılık teşkil etmekte; tek kişi ortaklığı kavramı kendi içinde çelişki yaratmaktadır[18].

Bütün itirazlara rağmen kabul edilmesi gerekir ki, kanun koyucu hukukumuza tek kişilik ortaklığı ithal etmiştir (*lex iubeat, non disputet/kanun emreder, tartışmaz*). Kanun koyucu, müteşebbislerin işletme faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için bir arayış içine girmiş ve AB yönergeleri ve gelişmiş batı ülkeleri uygulamalarını nazara alarak tek kişi ortaklığını (tek ortaklı anonim ve limited şirket) hukukumuza dâhil etmiştir. Tek kişi ortaklığını hukukumuza alırken de, anonim ve limited şirketlerinin gelişmiş bir yapıya sahip olduklarını, bireysel işletmeler için bu yapının uygun olduğunu, yeni bir yapı arayışları yerine mevcut şirket kurumundan istifade edilmesinin daha da yararlı olacağını kabul etmiştir[19].

---

katkıları bir süre sonra görülecektir. Bugünkü modern öğretide "şirket" kavramını birden ziyade ortak tanımlamamakta, belirleyici unsur ticari işletmeyi merkez alan ticari, sınai veya hizmete dönük organizasyon olmaktadır.
Hükümde 330'ncu madde saklı tutularak özel kanunların asgari bir sayı öngörmelerine geçerlilik kazandırılmıştır. Böylece AET'nin şirketlere ilişkin 89/667 sayılı Onikinci Yönergesinin tanıdığı olanaktan yararlanılmıştır. Bu hüküm açıkça belirli, tanımlanmış bir anonim şirket "tip"inin kanuni tip olarak kabul edilmemiş bulunduğunu, yani esas tipin halka açık veya kapalı anonim şirket olmadığını da belirtmekte, sınırlayıcı bir tür öğretisine bağlı kalınmadığını ortaya koymaktadır. Tek kişilik anonim şirket, interalia, şirketler topluluğunda çatı şirket olarak kullanılabilir, kurumsallaşmaya yardımcı olabilir, vakıf işletmeciliğini kolaylaştırabilir. Tüm bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için uydurma pay sahibi yaratmak şeklindeki hile-i şer'iyeye kapıları kapattığı için hukuki dürüstlüğe ve gerçekçiliğe de uygundur" denilmektedir.

18 Tek kişi ortaklığı yerine, "sınırlı sorumlu işletme modeli" de öngörülmesine ve bazı ülkelerde uygulanmasına ve bu müesseseden henüz vazgeçilmemiş olmasına rağmen ihtiyacı karşılayamadığı görülmüştür (bkz., **Stephan, S.**, Zulassung der Einpersonen. GmbHR in Portugal, GmbHR 1997, H.6, R.95).

19 Gerçekten de anonim şirketlerle ilgili 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 434 ve 435'inci maddeleri ile ilgili tartışmalar bir tarafa, aynı kanunun limited şirketlerle ilgili 504'üncü maddesinin 2'nci fıkrasında, "*ortakların sayısı sonradan bire iner veya şirketin zaruri organlarından biri mevcut olmazsa münasip bir müddet içinde bu eksiklikler tamamlanmadığı takdirde... mahkeme şirketin feshine karar verir*" denilmekte; geçici de olsa tek ortaklı limited şirkete cevaz verilmekteydi. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile anonim ve limited şirketlerde kabul edilen tek ortaklı şirket kavramı, hukukumuza yabancı değildir. Türk hukukuna göre

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun düzenlemesine nazaran ise, anonim ve limited şirketlerin tek kişi ile kurulabileceği öngörülmekte; anonim ve limited şirketlerin bir kişi birliğine sahip olmaları aranmamaktadır. Bu halde, sözleşme unsuru ile ilgili yapacağımız açıklamalar ışığında, bu durumun uygulamadan kaynaklandığının ve tek ortaklı anonim ve limited şirketlerinin yine şirket olduğunun kabulü; tek ortaklı anonim ve limited şirketlerin, kişi birliği bakımından kendine has özellikleri olan şirketler olduğunun kabulü gerekir.

c) Asgari Ortak Sayısı Hakkında Özel Düzenlemeler

Tek ortaklı anonim ve limited şirketler haricinde, bir şirketin kurulabilmesi ve faaliyetini devam ettirebilmesi için en az iki ortağın bulunması gerekir. Bu esas, tüzel kişiliği bulunmayan kişi birliği olan adi şirket için de; tüzel kişiliği bulunan ticaret şirketleri için de geçerlidir.

Bununla birlikte, bazı şirketlerin kurulmasında ve faaliyetlerini devam ettirmesinde ilâve şartlar aranmış; kimi zaman ortakların sıfatı ön plana çıkarken kimi zaman da ortakların sayısı esas alınmıştır. Buna göre, *kollektif şirketin* kurulması ve faaliyetini devam ettirebilmesi için *ortakların gerçek kişi* olması öngörülmüş; *komandit şirketlerde* ise ortaklardan en az birisinin gerçek kişi (komandite ortak) olması şart kılınmıştır. Bir *kooperatif* en az yedi ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur (KoopK. m. 2/1); limited şirketlerde ortak sayısı elliyi geçemez.

2) Sözleşme

Şirketin, bir kişi birliği olmasının yanında, *sözleşme temeline* dayanması gerekir. Bu kural, TBK'de tanımını bulan (m.620) adi şirket hakkında geçerli olduğu gibi, çeşitli şekillerde ifade edilse de, ticaret şirketleri (kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler ile kooperatifler) için de geçerlidir.

(818 sayılı BK ve 6762 sayılı TTK döneminde) tek kişi ile şirketin kurulması kabul edilmemişken; sonradan ortak sayısının bire düşebileceği kabul edilmiş; 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun düzenlemesine nazaran geçici de olsa tek kişi ortaklığının mevcut olabileceği belirtilmişti.

a) Şirket Sözleşmesinin Hukuki Mahiyeti

Yukarıda da izah edildiği gibi, şirket sözleşmesi olarak nitelendirilen ve kişi birliğini oluşturanların irade beyanı ile teşekkül eden hukuki fiil, bir hukuki işlemdir. Hukuki işlemler, çeşitli açılardan tasnife tâbi tutulmuş; gerekli irade beyanlarının adedi bakımından, tek taraflı hukuki işlemler, sözleşmeler, kararlar ve müşterek hukuki işlemler olarak da sınıflandırılmıştır[20].

Şirket sözleşmesine vücut veren hukuki işlemin, hangi tür bir hukuki işlem olduğunun (tek kişilik anonim ve limited şirketlerin ayrıca incelenmesi gereği karşısında) tartışılması gerekir. Şöyle ki; şirket sözleşmesi, bir tek kişinin irade açıklamasıyla meydana gelen, hukuki sonuçlar doğuran bir hukuki işlem, diğer bir ifadeyle tek taraflı bir hukuki işlem[21] midir?

aa) Tek Taraflı Hukuki İşlem Niteliği

Bu noktada belirtilmesi gerekir ki, bir hukuki işlemin tek taraflı olmasıyla, bu hukuki işlemin taraflara yüklediği borçların tek taraflı ya da karşılıklı olması birbirinden farklıdır. Bazı hukuki işlemler iki taraflıdır. Ancak, bu iki taraflı hukuki işlemde, bağışlamada olduğu gibi, sadece birisi borç altına girmekte; diğer taraf sadece alacak hakkı elde etmektedir. Tek taraflı hukuki işlemde ise, hukuki işlemin kurulabilmesi için, tek tarafın bulunması yeterlidir[22].

Belirtilmelidir ki, sözleşmelere ilişkin birçok kural, tek taraflı hukuki işlemlere de kıyas yoluyla uygulanabilirse de; tek taraflı hukuki

---

20 **Oğuzman / Barlas,** s. 180-183

21 Tek taraflı hukuki işlemlere, vasiyetname, fesih, iptal, sözleşmeden dönme, vakıf kurma, mirasın reddi, ilân yoluyla ödül, temsil yetkisi verme, mülkiyet hakkından feragat örnek gösterilmektedir (**Eren**, F., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 23. Baskı, Ankara 2018, s.165).

22 **Kılıçoğlu,** A., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara 2012 s. 47; Tek taraflı hukuki işlemlerin bazıları, sadece bu işlemi yapanın hukuki alanını etkilerken (mülkiyetten feragatte olduğu gibi), bazıları da üçüncü bir kişiyi etkilemekle beraber, bu işlemle ona bir yetki verilir (temsilde olduğu gibi). Bunun gibi, bazı tek taraflı hukuki işlemler (sözleşmeden dönmedeki gibi), üçüncü bir kişinin hukuki alanında onun aleyhine sonuç doğurur; bazı tek taraflı hukuki işlemlerde ise, hukuki sonucun doğabilmesi için üçüncü kişilere yöneltilmesi gerekir (vasiyetnamede olduğu gibi).

işlemlerde *numerus clausus* (sınırlı sayı) ilkesi hâkimdir. Kanunun öngörmediği tek taraflı hukuki işlemi, beyan sahibi kuramaz[23].

Tek ortaklı anonim ve limited şirketlerle ilgili açıklamalarımız saklı kalmak kaydıyla, şirket sözleşmesi olarak isimlendirilen hukuki ilişkiyi, tek taraflı bir hukuki ilişki olarak değerlendiremeyiz.

bb) İki Taraflı Hukuki İşlem (Sözleşme) Niteliği

İki taraflı hukuki işlemler, arzu edilen hukuki sonucun meydana gelmesi için, tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanında bulunmalarının gerekli olduğu hukuki işlemlerdir (TBK m.1)[24].

Türk Borçlar Kanununun kabulüne göre (m.1/1), ikiden fazla taraflı sözleşmeler (şirket sözleşmesi, ikiden fazla mirasçının yapacağı miras taksim sözleşmesi gibi) de olabilmektedir. Ancak, konunun ele alınış şekli nazara alındığında, TBK'de esas itibariyle iki taraflı sözleşmelerin düzenlendiği; açıklamaların da buna göre yapıldığı anlaşılmaktadır. Kanundaki bu yaklaşımı nazara alan müellifler İsviçre Hukukundan mülhem olarak, Türk Borçlar Kanununun sözleşmeye ilişkin genel kurallarının, çok taraflı sözleşmelere ancak kıyas yoluyla uygulanabileceğini belirtmektedirler[25].

Gerçekten de iki taraflı sözleşmeler ile çok taraflı olduğu ifade edilen sözleşmeler birbirinden farklı özellikler gösterebilmektedir.

Türk Borçlar Kanununun sistematiğine göre, sözleşme, çeşitli açılardan tasnife tâbi tutulmakta, çok sayıda sözleşme türünden bahsedilmekte[26]; Borçlar Hukukunun genel hükümleri incelenirken de, daha ziyade borç doğuran sözleşmeden bahsedilmektedir.

Borç doğuran sözleşmeler, bir müzakere sonucu yapılabileceği gibi, esasları bir tarafça tespit edilmiş sözleşme hükümlerini diğer tarafın kabul etmesi tarzında da (iltihakî sözleşmeler, genel işlem şartları ile yapılan sözleşmeler gibi) yapılabilir.

---

23 **Eren**, s. 165 – 166.

24 **Oğuzman/Barlas,** s.180; 818 sayılı Borçlar Kanununun 1'inci maddesinde yer alan "*iki taraf*" ifadesi, 6098 sayılı yürürlükteki Türk Borçlar Kanununda, İsviçre Hukukunda olduğu gibi "*taraflar*" şeklinde değiştirilmiş; ikiden fazla tarafın bulunduğu (çok taraflı sözleşme) kanaati verilmek istenmiştir.

25 **Oğuzman**, K./ **Öz**, T.;, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, İstanbul 2012, 10. Baskı, s. 43.

26 **Eren**, s. 204-225.

Borç doğuran sözleşmelerin bazıları, taraflardan sadece birine borç yükler (tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler); bazıları ise her iki tarafı da borç altına sokar (iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler). İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerin bazılarında da, tarafların her birinin borcu, diğer tarafın borcunun karşılığını (causa credenti) teşkil eder. Bu sözleşmelerde bir edim değişimi söz konusudur; bunlara tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler (sinallagmatik) denir.

Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, taraflardan her birinin borcu diğer tarafın borcunun karşılığını oluşturur ve bu sözleşmeler birtakım kurallara tâbi tutulmuştur. Buna göre, şayet sözleşme, kanun, işin niteliği ve teamül gereğince taraflardan birinin borcunu önce ifa etmesi gerekli değilse; taraflardan hiçbiri diğerinden önce ifaya mecbur değildir; her iki taraf borcunu karşılıklı olarak aynı anda ifa etmelidir (TBK m.207/2).

Çok taraflı hukuki işlem olduğu tartışmasız kabul edilen ve çok taraflı sözleşme olarak nitelendirilen şirket sözleşmesi, ortakların amacı aynı olduğundan eksik iki taraflı sözleşme sayılamayacağı gibi; borçlar karşılıklı olmadığından tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme de sayılmaz. Ancak karşılıklı edimleri içeren sözleşmelere ilişkin bazı hükümler, niteliklerine aykırı olmadıkça, şirket sözleşmelerine de uygulanabilir[27].

cc) Müşterek Hukuki İşlem Niteliği

Müşterek hukuki işlemler, bir irade beyanının, birden çok şahsın beyanlarının birleşmesiyle meydana gelmesini ifade eder[28].

Müşterek hukuki işlemler, çeşitli şekillerde tezahür edebilir. Bunlardan birisi ve belki de en önemlisi "*şirket sözleşmesi*" olarak nitelendirilen ve çok sayıda kişinin irade beyanının ortak noktada birleşmesiyle oluşturulan, çok taraflı hukuki işlemlerdir.

Bu işlemler, birden çok kişiye borç yükleyen sözleşmelerin özel bir türü olarak nitelendirilmekte; değişik menfaatlerde edimleri "*değiştirmeyi*" amaçlayacak yerde, ortak menfaatler izleyerek edimleri "*birleştirmeyi*" amaçlayan sözleşmeler olarak kabul edilmektedir[29]. Bu sözleşme türü içinde nitelendirilebilecek olan şirket sözleşmelerinde, ne

---

27 **Oğuzman/Öz,** s. 338-339.

28 **Oğuzman/Barlas,** s. 182.

29 **Serozan, R.,** Sözleşmeden Dönme, İstanbul 2007, s. 331.

aynı seviyede zıt menfaatler ve edimlerin mübadelesi ne de bir tarafın menfaatini korumak için iş görme söz konusudur. Bu sebeple, bilhassa mübadele sözleşmeleri esas alınarak hazırlanmış bulunan sinallagmatik akitler hakkındaki genel hükümler, ancak kıyasen ve bu sözleşmelerin mahiyetiyle bağdaşabildiği nispette, birleşme sözleşmelerine uygulanabilir[30].

Müşterek hukuki işlem ve sözleşme olarak nitelendirilmesi sebebiyle "*birleşme sözleşmesi*" şeklinde kabul edilen şirket sözleşmesi çok taraflı olması yanında, *kurucu belge* özelliği taşımaktadır[31]. Gerçekten de şirketi oluşturan bu kurucu belge, sadece şirketi kurmakla kalmamakta, bir statü yaratmakta; üyelerini çoğunluk iradesine tâbi kılmakta, sonradan katılacak olan kişiler de dâhil olmak üzere, tüm üyelere (ortaklara) bir dizi hak sağlayıp, bazı mükellefiyetler yüklemektedir.

Bu denli geniş kapsamlı sözleşmeye, mübadele sözleşmelerine ilişkin hükümlerin, meselâ mübadele sözleşmelerine ilişkin sözleşmeden dönme, ödemezlik def'i gibi müesseselerin, şirket sözleşmesine aynen uygulanması, bu kişi birliğinin (şirketin) mahiyetine uygun düşmez. Daha açık bir ifadeyle, şirket sözleşmesine taraf olan ortaklardan birinin edimini yerine getirmemesi sebebiyle, diğer ortaklar, ne edimini yerine getirmekten kaçınabilir ne de sözleşmeden dönebilir[32].

Bütün bu değerlendirmeler ışığında, şirket sözleşmesinin *müşterek bir hukuki işlem* olduğunun, sözleşme olarak nitelendirilmesi de göz ardı edilmeden, müşterek hukuki işlemlerden sayılan bir *birleşme sözleşmesi* mahiyetini taşıdığının, bu birleşme sözleşmesinin sadece sözleşmeye taraf olanlara uygulanmadığının, şirket ilişkisine sonradan dâhil olacakları da bağlayacağının, bu yönüyle bir statü yarattığının, statüye dâhil olanların (kimi hâllerde) oy birliği aranmadan statünün değiştirilebileceğinin; değişikliğin, değişikliği onaylamayanları da bağlayacağının kabulü gerekir.

Bu yönüyle kendine özgü bir sözleşme sayılması mümkün olan şirket sözleşmesi, ortakların amacı aynı olduğundan; eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme sayılamayacağı gibi, borçlar karşılıklı olmadığından tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olarak da

---

30 **Karayalçın, Y.,** Ticaret Hukuku, II: Şirketler Hukuku, Ankara 1973, 2. Baskı, s. 41.

31 **Aydoğan, F.,** Tek Kişi Ortaklığı, İstanbul 2012, s. 102.

32 **Serozan,** s. 332.

nitelendirilemez. Ancak karşılıklı edimleri içeren sözleşmelere ilişkin bazı hükümler, şirket sözleşmesinin niteliğine aykırı düşmedikçe bunlara da kıyasen uygulanabilir[33].

b) Tek Ortaklı Şirketlerin Hukuki Niteliği

Yukarıda da izah edildiği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, anonim ve limited şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabileceği kabul edilmiştir (TTK m.338, 573). Kanun koyucunun bu kabulü karşısında, çok taraflı hukuki işlem, müşterek hukuki işlem ve bu bağlamda birleşme sözleşmesi olarak nitelendirdiğimiz şirket sözleşmesinin, tek ortaklı şirketler bakımından tekrar gözden geçirilmesi ve tek ortaklı şirketler bakımından hukuki nitelendirmenin ayrıca yapılması gerekir.

Kabul etmek gerekir ki, Türk Borçlar Kanununun 1'inci maddesi hükmü nazara alındığında, tek kişilik şirkette "*taraflar*" kavramından bahsedilemeyeceği için, tek kişilik şirkette Türk Borçlar Kanunu anlamında bir sözleşmeden bahsedilemez; bir sözleşmenin kurulabilmesi için "*tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak ...*" açıklamaları gerekir (TBK m.1).

Bununla birlikte Türk Ticaret Kanununda (m.338, 573), anonim ve limited şirketlerin tek kişi ile kurulabileceği, bu şirketlerin kurulabilmesi için de anonim şirketlerde (asgari içeriği TTK m.339'da belirlenen) bir esas sözleşmenin; limited şirketlerde de bir şirket sözleşmesinin bulunması gerekir.

Tek kişi ile sözleşme olmayacağından, bu konuda başlangıçta yaptığımız açıklamalar ışığında, hukuki işlem kavramından hareket etmek gerekecektir. Bilindiği gibi, *hukuki işlemlerin özelliği*, hukukun bunlara, yapanın arzusuna uygun hukuki sonucu tanımış olmasıdır. Bu nedenle de hakların arzuya uygun olarak kazanılması ve kaybedilmesi; bu bağlamda bir şirket kurulması, hukuki işlem yolu ile sağlanır.

Şirket, esas itibariyle bir kişi birliğidir ve şirket şeklinde kurulacak bir kişi birliği için, iki veya daha ziyade kişinin bir araya gelmesi gerekir (iki veya çok taraflı hukuki işlem). Ancak hukuki işlem, sadece iki taraflı veya çok taraflı değildir; tek taraflı hukuki işlemler de vardır ve

---

[33] **Oğuzman / Öz**, s.339; **Meier-Hayoz / Forstmoser**, s. 28-29; **Fellman, W./Müller, K.**, Berner Kommentar-Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. VI: Das Obligationenrecht, 2.Abteilung, Die einzelnen Vertragverhaltnisse, 8.Teilband (Art.530-544 OR), Bern 2006, Art. 531, Nr.122, 428.

tek kişi ortaklığında, şirket sözleşmesi tek taraflı hukuki işlem olarak kabul edilmelidir[34].

Bu halde, şirket, tek taraflı hukuki işlem ile kurulacak ve bu tek taraflı hukuki işlem ile yapılan şirket sözleşmesi, şirketin *kuruluş belgesi* olarak kabul edilecektir[35]. Bu kuruluş belgesi ister şirket sözleşmesi (Gesellschaftsvertrag), ister *tek yanlı kuruluş beyanı* (einseitige Gründungserklärung) olarak yapılsın; diğer bir ifadeyle ister tek ortaklı ister çok ortaklı bir yapıya sahip olsun, şirketin "*esas sözleşmesi*"ni (limited şirketlerde şirket sözleşmesi) oluşturacaktır[36].

c) Şirket Sözleşmesinin Tarafları

Şirketin, sözleşmeyle kurulan ve müşterek bir amacın elde edilmesine hizmet eden kişi birliği olduğu ifade edilmiş; kişi birliğini oluşturan ortakların sıfatından (bazı şirketlerin özel düzenlemesi haricinde) bahsedilmemiştir.

aa) Şirket Sözleşmesine Taraf Olanlar

aaa) Gerçek ve Tüzel Kişilerin Ortak Olması

Hukukumuzda kişi birliği olarak ifade edilen şirketlerin, kişi birliği olmasından başka bir şart öngörülmemiş; kanunlarda kişilerin sıfatlarıyla ilgili özel bir düzenleme olmadıkça, gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de şirkete ortak olabilecekleri öngörülmüştür.

Bu esastan olmak üzere TBK'nin 620'nci maddesinde, *"iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir"* şeklinde tarif edilen adi şirkette, bahsi geçen "kişiler"le ilgili bir sınırlama yapılmamış (TBK m.620-645); dolayısıyla gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de adi şirkete ortak olabileceği kabul edilmiştir.

Bunun gibi anonim ve limited şirketlerde de bir sınırlamaya gidilmemiş; sadece kişiden bahsedilmiştir. Buna göre, anonim ve limited

---

34 **Aydoğan,** s. 104.

35 Alman hukukunda çok ortaklı anonim şirketler için şirket sözleşmesine "*Gesellschaftsvertrag*" (şirket sözleşmesi) denirken tek ortaklı anonim şirketlerde "*einseitige Gründungserklärung*" (tek yanlı kuruluş beyanı); İsviçre Borçlar Kanununda ise esas sözleşme için kuruluş sayısından bağımsız olarak "*statut*" denilmektedir.

36 **Pulaşlı,** H., Şirketler Hukuku Şerhi, C. I, 3. Baskı, Ankara 2018, s. 763.

şirketlerde ortak veya ortaklar gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilmektedir. Hatta ortakların hepsinin gerçek veya tüzel kişi olabilmesi; tek ortaklı anonim veya limited şirketlerde tek ortağın tüzel kişi olması da mümkün kılınmıştır (TTK m.337, 573).

Ticaret şirketleri içinde kabul edilen kooperatiflere, gerçek kişiler veya tüzel kişiler (KoopK m.1, 9) ortak olabilmektedir.

bbb) Sadece Gerçek Kişilerin Ortak Olabileceği Şirketler

Tüzel kişiliği olan veya olmayan şirketlere, gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin de ortak olabileceği kabul edilmişken; yine ticaret şirketi olan kollektif şirketlere (TTK m.211-303), sadece gerçek kişilerin (m.211) ortak olabileceği hükme bağlanmış, tüzel kişinin kollektif şirkete ortak olması halinde Türk Borçlar Kanununun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır denilmiştir (TTK m.214).

Komandit şirketlerde de, gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de ortak olabileceği kabul edilmiş; bunun yanında "*komandite*" ortağın mutlaka gerçek kişi olması gerektiği hükme bağlanmıştır (TTK m.304-328; TTK m.564-572).

ccc) Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Birliklerinin Şirkete Ortak Olması

Hukukumuzda kişi birlikleri, sadece tüzel kişiliği olan dernekler ve ticaret şirketlerinden ibaret değildir; tüzel kişiliği bulunmayan meselâ adi şirket, miras şirketi gibi kişi birlikleri de vardır.

Şirketlerle ilgili düzenlemelerde özel hüküm bulunmadığı sürece, gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de şirkete ortak olabilmektedir. Buna mukabil tüzel kişiliği bulunmayan kişi birliklerinin (adi şirket, miras şirketi gibi) şirkete bu sıfatla ortak olup olamayacaklarının ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Anonim şirketlerde kimin kurucu olabileceği de TTK m. 337/1'de hükme bağlanmış, "*Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucudur*" denilmiştir.

Bu hükme nazaran, anonim şirketlere ancak gerçek ve tüzel kişiler kurucu olabilmekte; tüzel kişiliği bulunmayan kişi birliklerinin kurucu olamayacağının kabulü gerekmektedir. Kurucu sıfatı ile ilgili durum bu

olmasına karşın, pay sahipliği sıfatında farklı bir özellik söz konusudur[37].

Benzer durum limited şirketlerde de "*Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından... kurulur*" şeklinde düzenlenmiş (TTK m. 573/1); limited şirketlerin ancak gerçek veya tüzel kişilerce kurulabileceği kabul edilmiş, tüzel kişiliği bulunmayan kişi birliklerinin şirkette kurucu olamayacağı belirtilmiştir.

Kooperatifler, "*...gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan*" (KoopK m.1) ticaret şirketidir (TTK m. 124/1). Bir kooperatif en az yedi ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur (KoopK. m.2). Kooperatiflerde kurucu ortaklar gerçek kişi olabileceği gibi, kamu ve özel hukuk tüzel kişileri amaçları bakımından ilgilendikleri kooperatiflerin kuruluşuna yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilirler (KoopK. m.9); tüzel kişiliği olmayan kişi birlikleri kurucu olamasa da, bir paya birden ziyade kişi ortak olabilir (KoopK. m.98; TTK m. 477).

Kollektif şirketlerde ortakların gerçek kişi olması gerekir (TTK m. 211); gerek kuruluşta gerek kuruluştan sonra tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan kişi birlikleri, kollektif şirkete ortak olamaz.

Komandit şirketlerde, gerçek kişi ortağa (komandite), kollektif şirket ortağının tâbi olduğu hükümler uygulanır. Komanditer (sınırlı sorumlu ortak) gerçek veya tüzel kişi olabilir. Şirketin kuruluşunda, sadece gerçek kişiler veya komanditer ortak bakımından gerçek veya tüzel kişiler kurucu olabilir; tüzel kişiliği olmayan kişi birliği, anonim şirketlerde bahsedildiği gibi; bir paya birden ziyade ortak olarak (TTK m.477), komanditer ortak olabilirler; bunlar kurucu olamazlar.

Adi şirketlerde de, tüzel kişiliği olmayan kişi birliklerinin bu sıfatla ortak olması mümkün değildir. Zira TBK m.620 gereğince, adi ortaklık sözleşmesi sadece kişiler arasında kurulabilir.

---

37 "Payların bölünememesi" başlığı altında Türk Ticaret Kanununun 477'nci maddesinde, "Pay şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler" denilmek suretiyle tüzel kişiliği bulunmayan kişi topluluklarının anonim şirkette pay sahibi olabilecekleri kabul edilmiştir. Ancak bu hâlde, bir payın birden fazla malikinin varlığı kabul edilmekte, haklar anonim şirkete karşı "bölünmezlik" ilkesi gereği, ancak temsilci aracılığıyla kullanılabilmektedir.

bb) Tarafların Ehliyeti

aaa) Gerçek Kişilerin Ehliyeti

Şirket sözleşmesi (ister tek taraflı ister çok taraflı) bir hukuki işlemdir. Bir hukuki işlemin geçerli olabilmesi için irade beyanında bulunan kişi veya kişilerin, o işlemi yapma konusunda gerekli ehliyete sahip olmaları zorunludur[38].

Hukuki işlem olarak tavsif edilen şirket sözleşmesindeki tarafların ehliyeti hakkında Türk Ticaret Kanununda özel hükümler mevcut değildir; Türk Ticaret Kanununun, Türk Medeni Kanununun ayrılmaz bir parçası olduğu (TTK m.1/1) nazara alınarak, hukuki işlem ehliyeti bakımından, Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olan genel hükümler (TMK m.9-16) uygulanır.

Bilindiği gibi, "*Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan gerçek kişilerin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz*" (TMK m.15). Buna göre, ayırt etme gücü bulunmayan gerçek kişinin taraf olduğu şirket sözleşmesi, o şahıs için hukuki bir sonuç doğurmaz. Ancak hükümsüzlük iddiasının, ayırt etme gücü bulunmayan şahıs menfaatine ve objektif iyi niyet kaidelerine aykırı olmaması lâzımdır[39].

Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremeyeceklerinden (TMK m.16/1), bunların şirket akdine taraf olabilmeleri, kanuni temsilcilerinin sarih veya zımnî rızasına tâbidir. Ancak bunların, kişisel

---

38 Gerçek kişilerde hukuki işlem ehliyetinin temel şartı, işlemi yapanın ayırt etme gücüne sahip olmasıdır (TMK m.13). Bir kimsede ayırt etme gücü yoksa o kişinin yapacağı işlemler (kanundaki istisnalar dışında), kural olarak geçerli olmaz ve hiçbir sonuç doğurmaz (TMK m.15). Ayırt etme gücüne sahip olan gerçek kişinin, ergin olmaması veya kısıtlanmış bulunması halinde, kendisini borç altına sokan hukuki işlemin hüküm ifade etmesi, kanuni temsilcinin (veli yahut vasi) bu işleme önceden muvafakat etmesine (izin vermesine) veya işlemi sonradan uygun görmesine (icazet=onay vermesine) bağlıdır. İzin alınmadan yapılmış bulunan işlemin geçerliliği "*askıda*"dır: Kanuni temsilci işleme onay verirse, işlem yapıldığı andan itibaren geçerli olacak; onay vermezse işlem yapıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. Görüldüğü gibi, kanuni temsilcinin rızası, ayırt etme gücüne sahip olan küçük veya kısıtlının borç altına girdiği işlemler için bir tamamlayıcı unsur teşkil etmektedir.

39 **Karayalçın,** s. 58.

sorumluluğu gerektiren bir ortaklığa (adi şirket, kollektif şirket ve komandit şirketlerde komandite ortak olması) girmesi veya önemli bir sermaye ile bir şirkete ortak olması hâlinde (TMK m.463/b.3), kanuni temsilcinin rızası yeterli olmaz; vesayet makamının (sulh hukuk mahkemesi) izni ve bu izinden sonra denetim makamının da (asliye hukuk mahkemesi) izin vermesi gerekir.

bbb) Tüzel Kişilerin Ehliyeti

Hukukumuzda hak sahibi kişiler sadece gerçek kişiler değildir. TMK'de, kişi olarak nitelendirilen tüzel kişilerin de, hak ehliyetleri çerçevesinde tam olarak fiil ehliyetine sahip olduğu kabul edilmiş; fiil ehliyetini kazanması ise, "*kanuna ve kuruluş belgelerine göre, gerekli organlara*" sahip olması (TMK m.49) şartına bağlanmıştır.

Buna göre tüzel kişiler organlara sahip olması koşuluyla, şirketin mahiyetine uygun düştüğü kadar, şirket sözleşmesine taraf olabileceği gibi, kurulmuş bir şirkete ortak da olabilir.

d) Şirket Sözleşmesinin Şekli

Hukuk sistemimizde, hukuki işlemin geçerli olarak etkisini doğurabilmesi için, hukuki işlemin taraflarının, o işlemi yapabilme ehliyetinin bulunması, irade beyanlarında bozukluk olmaması, hukuki işlemin konusunun hukuka ve ahlâka uygun olması yanında; *hukuki işlemin kanunda veya taraflarca öngörüldüğü hallerde, şekle de uygun yapılması gerekir.*

Şekil, hukuki işleme katılanların iradelerini dışa açıklamak üzere kullandığı araçtır. Her hukuki işlemin ve hatta her irade açıklamasının tâbi olduğu bir şekil vardır. Bu nedenle bir irade beyanının, bir hukuki işlemin veya sözleşmenin şekle bağlı olmadığından söz edildiği vakit, bununla "*şekilsizlik*" değil; o irade beyanı veya hukuki işlem ya da sözleşmenin geçerliliğinin *belirli bir şekle bağlı olmadığı*, sözlü, yazılı veya resmi şekil türlerinden biriyle yapılabileceği; şekil serbestliğinin bulunduğu kastedilmiş olur[40].

Hukukumuzda, genel sözleşme serbestliği bağlamında, *şekil serbestliği esastır.* Bununla birlikte kanun koyucunun önemli kabul ettiği

---

[40] **Eren**, s. 264 vd.

kimi işlemler için kanunda veya bizzat taraflarca, irade beyanlarının belirli bir şekle bağlanması öngörülmüş olabilir. Bu halde hukuki işlemin geçerliliği bu şekle uyulmasına bağlıdır (TBK m.12).

aa) Çok Ortaklı Şirketlerde Şekil

Türk Borçlar Kanununun "*sözleşmelerin şekli*" başlığını taşıyan 12'nci maddesinin 1'inci fıkrasına göre, "*Sözleşmenin geçerliliği, kanunda aksi öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir*".

Bu kurala bağlı olarak, çok ortaklı şirket sözleşmeleri de esas itibariyle bir şekle bağlanmamış; ancak Türk Ticaret Kanunu ile Kooperatifler Kanununa, ticaret şirketlerinin kurulması ve tüzel kişilik kazanması ile ilgili özel hükümler konulmuştur. Her ticaret şirketinin kuruluşunda özellikle incelenecek olan bu şekil şartları, ticaret şirketlerinin kurulabilmesi ve tüzel kişilik kazanabilmesi için *geçerlilik şartı* olarak kabul edilmiştir.

Ticaret şirketlerinin kurulabilmesi ve tüzel kişilik kazanması için geçerlilik şartı olarak kabul edilen bu şekil şartlarının ortak olan özellikleri: Şirket sözleşmesinin *yazılı* olarak yapılması, şirket sözleşmesindeki *imzaların tasdik* (noterce onaylanması veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması) edilmesi ve tüzel kişilik kazanabilmesi için *sicile tescil edilmesi* olarak belirtilebilir. Bu ortak hususlardan başka, her ticaret şirketi tipi için ek şartlar da aranabilmektedir.

Ticaret şirketleri açısından geçerli olan "*şekle bağlılık*" ilkesi karşısında, adi şirketlerde herhangi bir şekil şartı öngörülmemiş (TBK m.620); adi şirket sözleşmesinin "*şekil serbestliği*" ilkesi dâhilinde, yazılı, sözlü ve hatta "örtülü (zımnî)" bir irade beyanı ile yapılabileceği kabul edilmiştir.

bb) Tek Ortaklı Şirketlerde Şekil

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sadece anonim ve limited şirketlerin tek ortakla kurulabileceğini kabul etmiş; bu şirketlerin kurulmasını da *şekle tâbi tutmuştur*.

Buna göre *tek ortaklı anonim veya limited şirket*, tek ortağın kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan sermayesinin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettiği, anonim şirkette imzasının noterce onaylandığı veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzaladığı esas

sözleşmede; limited şirketlerde ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı sözleşmede anonim veya limited şirket kurma iradesini açıklamasıyla kurulur (TTK m. 335/1; m. 585/1). Şirket, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır (TTK m. 355/1; m. 588/1).

e) Şirket Sözleşmesinin Geçerli Olmasının Esasları (Hâkim Olan İlkeler)

aa) Bir Şirket Sözleşmesinin Bulunması

Bir şirketten söz edebilmek için, yukarıda esasları ifade edilen geçerli bir şirket sözleşmesinin bulunması zorunludur. Şirket sözleşmesi yapılırken, taraflar sözleşmenin esaslı unsurları üzerinde uyuşamamışsa veya kanunda öngörülen şekil şartlarını yerine getirmemişse yahut tarafların irade beyanında bir bozukluk varsa veya taraflardan biri şirket kurma ehliyetini haiz değilse ya da şirket sözleşmesinin konusu hukuka yahut ahlâka aykırı ise; geçerli bir şirket sözleşmesinden bahsedilemez.

Ancak, tüm bu eksikliklere rağmen, şirket faaliyete başlamış; üçüncü şahıslarla hukuki muamele yapmışsa, şirketin yokluğundan veya şirket sözleşmesinin geçersizliğinden bahsetmek, ticari hayatta önemli sorunları da beraberinde getirir. Zira bu halde şirket, hukuken geçersiz ve fakat sanki şirket sözleşmesi geçerliymiş gibi bir görünüm ortaya çıkmaktadır.

Bu bağlamda, şirket sözleşmesi geçersiz olmasına rağmen, sanki bir şirket varmış gibi hareket edilerek, gerçek hukuki durum ile görünüş arasında, üçüncü şahısların aleyhine bir sonuç ortaya çıkabilir. Bunun gibi, şirket sözleşmesi, ehliyet yokluğu, nispi veya mutlak butlan sebebi ile geçersiz sayıldığında, sözleşmenin yapıldığı andan geçersiz sayıldığı zamana kadar geçen sürede, şirket sözleşmesinin geçerli olduğu kanaatiyle şirketle hukuki ilişkiye giren kişilerin ve hatta şirket ortaklarının menfaatleri, (şirket sözleşmesinin başlangıçtan itibaren geçersiz sayılması sebebiyle) ihlâl edilebilir. Bir diğer ifadeyle, geçersiz olan bir şirket sözleşmesi olduğu gerekçesiyle, yapılan işlemlerin geçersiz sayılması, hem ticari hayata güveni sarsar hem de ortakların menfaati zedelenebilir.

Türk-İsviçre hukuk sisteminde bu sorunun çözümü için *fiili şirket* müessesesi kabul edilmiş, "*Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm (TBK m.620-645)*

hükümlerine tâbi adi ortaklık sayılır" denilmiştir (TBK m.620/2; İsviçre BK m. 530/2).

Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için, Kanuna uygun olarak yapılmış olmasa da, bir şirket sözleşmesinin bulunması gerekir. Geçersiz de olsa, bir şirket sözleşmesi bulunmadan, hukuken var sayılmayan bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan kimselere TTK m.12/3 hükümleri tatbik edilir; bunlar iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

bb) Güvenin Korunması İlkesi

Hukuki bakımdan önem taşıyan bir hususun dış belirtisini teşkil eden bir olgu, bazı unsurların olmaması nedeniyle gerçek hukuki durumu yansıtmayabilir. Taraf ya da tarafların gerçeğe uygun olmayan bu olguya (hukuki görünüşe) itibar ederek yaptıkları işlemlerin geçerli olup olmayacağı hukukçular arasında tartışılmaktadır[41].

Bu esastan olmak üzere, şirket sözleşmesi, kurucu unsurlarından birinin eksikliği sebebiyle "*yok*" ise veya *batıl* olması sebebiyle geçersiz sayılırsa; yokluğu veya geçersizliği bilmeden, geçersiz olan şirket sözleşmesi ile kurulan, hukuken geçersiz ve fakat fiilen faaliyette bulunan bir şirketle muamelede bulunan üçüncü kişilerin görünüşe güvenerek yaptıkları işlemlerde, işlemi yapanın güveni korunacak mıdır?

Hukuk ve ticari hayatın güvenliği bakımından, bu soruya olumlu cevap vermek gerekir. Bir diğer ifadeyle, hukuki görünüşe itimat ederek; hukuken geçersiz, fiilen faaliyette bulunan bir şirketle muamele yapan kişilerin, hukuki görünüşe bağlı olarak oluşan güvenlerinin korunması lazımdır. Buna göre, geçerli olmayan bir şirket sözleşmesi ile faaliyette bulunan şirketin daha sonra geçersizliği tespit edilse veya geçersizliğine hükmedilse dahi, şirketin faaliyette bulunduğu süre içinde, üçüncü kişilerin şirketin varlığına ilişkin güvenleri korunur; hükümsüzlük veya geçersizlik geçmişe etkili olmaz; geleceğe etkilidir (ex nunc). Diğer bir söyleyişle, geçerli olmayan şirket sözleşmesi ile kurulan şirketin muameleleri, geçerliliğe inanarak onunla muamelede bulunan kişiler bakımından, geçerli bir şirket ile muamele yapılmış gibi hukuki

---

41 Bkz. **Ülgen, H.,** Hukuki Görünüş Nazariyesi, İstanbul 2005, s. 170 vd.

sonuç doğurur[42] ve geçerli olmayan şirket sözleşmesine dayanarak muamelede bulunanlar, geçerliliğe inanarak onunla muamelede bulunan kişilere karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

cc) Anonim Şirketlerle İlgili Özel Düzenleme

Yukarıdaki tespitlerimize paralel bir düzenleme TTK m. 353'de yer almakta; "*Anonim şirketin butlanına veya yokluğuna karar verilemez*" denildikten sonra, "*Ancak şirketin kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlâl edilmiş olursa yönetim kurulunun, Ticaret Bakanlığı'nın, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nce şirketin feshine karar verilir*" denilmektedir (TTK m. 353/1).

TTK m. 353/1'de, "*yokluk*" ve "*butlan*"dan bahsedilmektedir. Butlandan maksat TBK m.27/1'de de ifade edildiği gibi *kesin hükümsüzlüktür*. *Yoklukta*, sözleşme hiç kurulmamıştır; butlanda ise, başlangıçtan itibaren bir geçersizlik söz konusudur.

Yokluk ve butlanın hukuki sonuçlarının, anonim şirketlerin kuruluşuna tatbik edilmesini arzu etmeyen kanun koyucu, *tescil ile tüzel kişilik kazanan anonim şirketin yokluğunun ve butlanının istenemeyeceğini hükme bağlamış*; şartların varlığı hâlinde ancak feshinin talep edilebileceğini kabul etmiştir. Yine malum olduğu üzere, fesih ileriye etkili bozma bildirimidir. Bu halde, sözleşmenin feshinde, feshe kadar olan döneme ilişkin edim yükümlülükleri ortadan kalkmayacak ve bunlar ifa edilmişse, geri istenemeyecektir. Bu durumda, anonim şirketin yokluğu veya butlanı istenemeyeceğinden; sözleşmenin feshine kadarki sürede, geçerli bir şirket sözleşmesi olduğu zannıyla hareket eden ortakların veya üçüncü kişilerin, hukuki görünüşe güvenerek yaptığı hukuki işlemler geçerli olacaktır[43].

---

[42] **Forstmoser,** s. 20; **Schönenberger, W./Jäggi, P.:** Obligationrech, Zürcher Kommentar, Teilbd. V/1a: Allegemeine Einleitung und Kommentar zu OR 1-17, Zürich 1979, z. OR 1 N 565.

[43] Ancak burada belirtmek gerekir ki, kanun koyucu ilgili maddenin sevki esnasında, gerekli özeni göstermemiş; *yokluk* kavramına hakiki anlamını yükleyememiştir. Zira *yokluk*, sözleşmelerde kurucu unsurun eksikliği hâlinde söz konusu olabilir ki, sözleşmelerdeki tek kurucu unsur, irade beyanıdır; kanunî şekil ve

3) Ortak Amaca (Müşterek Gayeye) Erişme Niyeti

Şirket sözleşmesi, karşılıklı borç doğuran sözleşmelerden farklı olarak, kişilerin emek ve/veya mallarını *ortak bir amaca erişmek üzere* birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmelerdir. Buna göre her şirket, farklı şekilde ifade edilse de, ortak bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla kurulur.

a) Ortak Amaç

Şirket sözleşmelerini diğer sözleşmelerden ayıran özelliği, şirket sözleşmesine katılanların, ortak amaca birlikte erişme niyetiyle birleşmeleridir. Evvelce de ifade edildiği gibi, borç doğuran sözleşme olarak nitelendirdiğimiz ve genellikle mübadele (değişim) akitlerini örnek verdiğimiz sözleşmelerde, taraflar sözleşmenin esaslı noktalarında karşılıklı iradelerini beyan ettiklerinde, amaçları ortak (müşterek) değildir; örneğin, satım sözleşmesinde satıcının amacı malı satmak, alıcının amacı ise, satın almaktır.

Şirket sözleşmesinde ise, katılanların amacı aynıdır ve bu amaca ulaşmak maksadıyla emek ve/veya sermayelerini birleştirmeyi üstlenmekte; ortak amacı elde etmek için yapılan faaliyetler sonucu elde edilen menfaati paylaşmayı, zarar söz konusu olursa, bu zarara müştereken katlanmayı taahhüt etmektedirler.

Şirket sözleşmesine katılanların, kendilerini şirkete katılmaya sevk eden şahsi bir amacı (saik) olsa da, her bir ortak, şirketin diğer ortaklarla paylaştığı amacını kendi amacı olarak görmek; şirkete ortak olma saikini, şirketin ortak amacından üstün tutmamak ve ortak amacın elde edilmesi için gayret göstermek mecburiyetindedir.

Türk hukukunda ortak amacın, (çeşitli şekillerde ifade edilse de) iktisadi olması gerekir; ideal amaçlarla şirket kurulamaz. Bu amaç *adi şirketlerde*, ortaklığa ait kazanç ve zarara katılma; *kollektif ve komandit şirketlerde* "ticari bir işletmeyi işletme"; *anonim ve limited şirketlerde* "her türlü ekonomik amaç"; *kooperatiflerde* ise, "ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını" korumaktır.

---

ayırt etme gücü kurucu unsur sayılmaz. Kanunî şekil ve ayırt etme gücü, sözleşmenin kurucu unsuru değil; geçerlilik unsurudur. İrade beyanının şirket kurmaya yönelik olmadığı hâllerde, hangi gerekçeyle şirketin *yokluğuna* karar verilemeyeceği tartışmaya açıktır.

İktisadi olan bu ortak amacın, aynı zamanda, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusunun imkânsız olmaması gerekir (TBK m.27).

b) Katılım Payı Yükümlülüğü

Bir sözleşmenin şirket sözleşmesi olarak nitelendirilebilmesi için, sözleşmeye katılanların *ortak iktisadi gayeyi*, müştereken oluşturdukları sermaye ile gerçekleştirme iradelerinin varlığı; kâr ve zararı paylaşmak niyetiyle hareket etmeleri ve katılanların şirket kurma niyetinin bulunması gerekir.

Şirket sözleşmesine katılanların, ortak amaca erişmek için, katkıda bulunmak, diğer bir söyleyişle sermaye koymak ve şirketin faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak kâr ve zararı paylaşmak niyeti yoksa bir şirket sözleşmesinden bahsedilemez.

Katılma payı, diğer bir ifadeyle *sermaye unsuru*, şirket sözleşmesinin zorunlu bir unsurudur. Şirket sözleşmesine katılanlar, şirketin nev'ine göre, *ortak amacı elde etmeye elverişli bir değeri, şirkete katılma payı olarak getirmeyi taahhüt ederler.* Buna karşılık, katılma paylarının şirkete fiilen ve gerçekten getirilmiş olması; şirketin varlığı için zorunlu değildir. Gerçekten de şirket (tek ortaklı anonim ve limited şirketlerin özel durumu hariç), sözleşme temeline dayalı bir ilişki ve sözleşme de borçlandırıcı bir işlem olduğu için, katılma payı taahhütleri henüz ifa edilmeden de şirket kurulmuş olur.

Bu husus adi şirketlerde "*emeklerini ve/veya mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi üstlendikleri...*" şeklinde yapılan adi şirket tanımında (TBK m.620/1) açıkça belirtilmektedir.

Kollektif ve komandit şirketlerde de, ortakların "*ticari işletmeyi işletmek*" amacıyla birleşmeleri, şirketin kurulması için lâzım ve kâfidir; ortakların şirket sözleşmesi ile sermaye olarak taahhüt ettiklerinin fiilen ve gerçekten getirilmesi, bu şirketlerin kurulması bakımından zorunlu değildir. Ortakların sermaye koyma borcunu yerine getirmemesinden dolayı mesela fesih davası açılabilir (TTK m. 246).

Anonim şirketlerde tescilden önce ayni sermayeye ilişkin taahhütlerin yerine getirilmemesi (TTK m.128/2) veya nakdi sermaye taahhüdünün en az yüzde yirmi beşinin ödenmemiş olması, *şirketin tesciline engel olacağından* şirket tüzel kişilik kazanamayacaktır (TTK m. 344/1).

Ancak belirtmek gerekir ki, anonim şirketlerde tescilden önce ayni sermayeye ilişkin taahhütlerin yerine getirilmemesi veya nakdi sermaye taahhüdünün en az yüzde yirmi beşinin ödenmemiş olması *tescile engel* ise de; şirketin kuruluşuna doğrudan etken değildir. Gerçekten de, anonim şirketlerde taahhütlerin kuruluşta hiç yerine getirilmemesine karşın; getirilmiş gibi gösterilip, şirketin tescili sağlanabilir. Bu hâlde, taahhütler yerine getirilmemesine rağmen şirket yine kurulmuş olur; şirketin yokluğuna veya butlanına karar verilemez (TTK m.353/1), kurucuların sorumluluğuna gidilir (TTK m.553).

Bundan başka, pay sahibi, kuruluştan sonra yönetim kurulu tarafından tayin edilen vadede, geriye kalan sermaye koyma borcunu ifa etmez, temerrüde düşerse; anonim şirket yönetim kurulu, temerrüde düşen pay sahibini kısmi ödemelerden doğan haklarından mahrum etmeye ve ıskata da yetkili kılınmıştır (TTK m. 482/2).

Limited şirketin tescili için, anonim şirketlerde olduğu gibi, ortakların sermayenin tamamını taahhüt etmesi ve nakit kısmının en az yüzde yirmibeşini hemen ödemesi gerekmez; *nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmibeşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz* [TTK m. 585/1(Ek cümle:15/2/2018-7099/25 md.)].

Kooperatifler, tüzel kişiliği haiz olmak üzere, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını sağlayıp korumak amacıyla kurulan ticaret şirketleridir (KoopK m. 1/1; TTK m. 124/1). Bir kooperatif en az yedi ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Anasözleşmenin ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personel huzurunda imzalanması gerekir (KoopK m. 2/1). Ortakların pay tutarı ve kooperatif sermayesinin ödenme şeklinin ana sözleşmede gösterilmesi gerekir (KoopK m. 4). Ortaklardan ana sözleşme ile taahhüt ettiği ortaklık payı ödeme yükümünü yerine getirmeyen borçlu ortağın ortaklığı,; Kooperatifler Kanununda belirtilen merasime uymak şartıylakendiliğinden düşer (KoopK m. 27). Görüldüğü gibi kooperatiflerde de katılma payı taahhüdünde bulunmak lâzım ve kâfidir; bu taahhüdün yerine getirilmesi, kooperatifin kuruluşu için şart değildir.

Şirketlerde katılma payının, şirketin gayesini elde etmeye elverişli olması gerekir; katılma payının miktarı hususunda taraflar serbestçe anlaşabilirler; sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça katılım payları,

ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır (TBK m.621/2).

c) Kazanç ve Zarara Katılma İradesi

Şirket sözleşmesinden bahsedebilmek için, şirket sözleşmesine katılanlarda, şirket kurma iradesinin ve bunun sonucu olarak, kazançları paylaşmak; zarar söz konusu olursa, zarara da müştereken katlanmak iradesinin bulunması gerekir. Bu unsur, şirket sözleşmesini "*kâra katılmalı tüketim ödüncü*" sözleşmesinden ayırır.

Bilindiği gibi, kâra katılmalı tüketim ödüncü sözleşmesinde, ödünç alan aldığı parayı, belirli bir amaçta kâr getiren bir faaliyette, özellikle bir ticari işletmede kullanmak zorundadır. Ödünç alan, aldığı parayla girişeceği faaliyetten elde ettiği kârdan belli bir kısmını ödünç verene ödemekle yükümlüdür; ödünç veren işletmenin zararına katılmaz[44]. Hâlbuki şirket sözleşmesinde, şirket sözleşmesine taraf olanlar, kâra iştirak hakkını haiz olduğu gibi, zarara da katlanmak mecburiyetindedirler.

Bu noktada üzerinde durulması gereken husus, adi şirketlerde emeğini sermaye olarak getiren ortağın durumudur. TBK m.623/3'e göre, "*Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma payı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir*". TBK m.623/3'de bahsedilen "*zarara katlanmama*" hâli, sadece emeğini sermaye olarak getiren ortak için kabul edilen bir "*istisna*"dır; bu istisna haricinde bir ortağın zarara iştirak etmeyeceği veya kârın tamamının bir ortağa verilmesi kaydı geçerli değildir. Kaldı ki, bu hüküm sadece *iç ilişki* bakımından geçerlidir; *dış ilişkide*, yani üçüncü şahıslara karşı sorumlulukta, emeğini sermaye olarak koyan ortak da diğer ortaklar gibi sorumludur.

Şirket sözleşmesinde, ortak amacı gerçekleştirmek niyetiyle bir araya gelen ortakların, kâr ve zararı paylaşmak iradesi yeterlidir; şirketin amacı doğrultusunda belirli bir süre kâr dağıtılmaması veya zararın yedek akçelerden karşılanması, şirketin varlığı için önemli değildir.

---

44 **Tandoğan**, H., Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkiler, C. I/II, İstanbul 2008, 4. Tıpkı Basım, s. 334-335.

d) Müşterek Amaç Uğruna Birlikte Çalışma Niyeti (Affectio Societatis)

Iustinianus hukukunda "*niyet*" (animus) manasında kullanılan "*affectio*", belli bir gayeye yönelen kayıtsız şartsız iradeyi ifade etmektedir. Bu niyet ve iradenin, sadece şirketin kuruluşunda bulunması yeterli değildir; şirketin faaliyeti sırasında da mevcut olması, devam etmesi gerekir. Zira ortakların birinde şirketi devam ettirme niyet ve iradesi sona erdiği anda, şirket diğer ortaklar için de sona ermiş olur[45].

Roma Hukukunda durum böyle olmakla birlikte, bilimsel öğretide "*affectio societatis*", "eşitlik üzere birleşme arzusu"[46], "müşterek amaç doğrultusunda birlikte çaba gösterme"[47], "ortakların şirket gayesinin elde edilmesine faal olarak katılma niyeti"[48] olarak anılmıştır.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Roma Hukukunda kabul edilen bu kavram, Fransız hukukunda kabul görmüş ve modern hukuk sistemine dâhil edilmiştir[49].

Türk hukukunda, şirket sözleşmesinde, ortaklar arasında eşitlik esastır; ancak şirket sözleşmesine katılanlar bu esastan ayrılabilirler. Bunun yanında, şirket sözleşmesine katılanların ortak amacı gerçekleştirmek üzere şu veya bu şekilde katkıda bulunmaları, ortak amacın gerçekleştirilmesi için bir gayret içinde olmaları gerekir.

Bu gayret, şirket sermayesine iştirakten başka, ortak amacın elde edilmesinde az veya çok, aktif bir rol oynamak şeklinde ortaya çıkabilir. Bu bakımdan "*affectio societatis*"i ortak amacın gerçekleştirilmesini sağlama uğruna bir çaba gösterme olarak nitelendirebiliriz.

Ancak bu çabanın, mutlaka şirket işlerine aktif katılma olarak nitelendirilmemesi gerekir. Zira şahıs şirketlerinde katılma payı taahhüdü yanında, aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklara idareci sıfatı öngörülmüşken; sermaye şirketlerinde ortakların müşterek amaca katkıları, sadece

---

45 **Rado,** T., Roma Hukuku Dersleri, Borçlar Hukuku, İstanbul 1974, s. 141.

46 **Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.,** Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, İstanbul 2014, s. 35.

47 **Barlas, N.,** Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, 4. Baskı, İstanbul 2016, s. 38-39..

48 **Domaniç,** H., Adi, Kollektif ve Komandit Şirketler, İstanbul 1970, 3. Bası, s. 6.

49 Alman ve İsviçre hukukunda, bu kavramı ifade etmek için "Förderungspflicht" tercih edilmektedir.

katılma payı taahhüdünden ve sözleşmeden doğan diğer yükümlülükten ibarettir; idareye fiilen katılmaları idareci sıfatını almadıkları sürece söz konusu değildir.

e) Ortak Amaç Açısından Şirketler ve Özel Hukuktaki Diğer Kişi Birlikleri

Hukukumuzda kişiler, gerçek ve tüzel kişiler olarak iki grupta incelenmiş; tüzel kişilerin, "*başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları...*" olduğu ifade edilmiştir (TMK m.47).

Belli bir amaca özgülenmiş mal toplulukları şeklindeki tüzel kişiler vakıflardır (TMK m.101). Başlı başına bir varlığı olmak üzere kişi toplulukları şeklinde örgütlenmiş *özel hukuk tüzel kişilerinin* kimisi kazanç paylaşmak gayesi ile kurulur (ticaret şirketleri); kimisi de dernekler gibi kazanç paylaşma gayesi gütmeyen tüzel kişilerdir.

Ancak hukukumuzda gerçek ve tüzel kişilerin yanında kendilerine tüzel kişilik izafe edilmeyen kişi birlikleri de vardır. Bu kişi birliklerinin başında adi şirket yer alır; adi şirket kişi birliği olmasına karşın, tüzel kişiliği yoktur (TBK m.620-645). Tüzel kişiliği bulunmayan kişi birlikleri sadece adi şirket değildir; aile hukukunda, miras hukukunda ve eşya hukukunda da tüzel kişiliği bulunmayan kişi birlikleri mevcuttur.

aa) Ortak Amaç Açısından Şirket ve Dernekler

Dernekler ve şirketler, ortak amaçlarını gerçekleştirmek maksadıyla kurulan kişi topluluklarıdır.

Dernekler, Türk Medeni Kanununun 56-100'üncü maddeleri arasında düzenlendikten başka, konunun ehemmiyetine binaen ayrıntılı bir tarzda bağımsız bir kanunda (5253 sayılı Dernekler Kanunu) ayrıca ele alınmıştır. Dernekler Kanununa göre, "***Dernek**, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır*" (Dernekler K. m. 2/1-a).

Buna göre, dernekler de kişi topluluklarıdır; kanun koyucu bir derneğin kurulabilmesi için en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesini zorunlu unsur olarak görmüştür (TMK m.56; Dernekler K. m.2/1-a). Her dernek belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulur; derneğin birden fazla amaç izlemesi yasaktır. Derneklerin amacının

kanunlarla yasaklanmamış olması, üyelerin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla birleşmeleri de gerekir (TMK m.56; Dernekler K. m. 2/1-a).

Derneklerle ilgili bu kısa açıklamalarımızdan da anlaşılacağı gibi, dernek ile şirket arasındaki ayırıcı ölçü (diğer unsurlar bir yana), "*kazanç paylaşmadır*". Dernekler ancak "*ideal*" amaçlarla kurulabilir; kazanç paylaşma amacı yoktur. Hâlbuki şirketlerin asıl amacı kazanç paylaşmaktır; hukukumuzda ideal amaçlarla şirket kurulamaz.

bb) Tüzel Kişiliği Bulunmayan Kişi Birlikleri ve Şirketler

Aile hukukunda, eşler yaptıkları mal rejimi sözleşmesi ile aralarında yasal mal rejimi (edinilmiş mallara katılım) dışındaki seçimlik mal rejimlerinden hangisinin geçerli olacağına karar verebilirler ve geçerli mal rejimini kanunun öngördüğü sınırlar içinde değiştirebilirler. Bu mal rejimlerinden birisi de "*mal ortaklığı rejimi*"dir. Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsar (TMK m.256). Hiçbir eş, ortaklık payı üzerinde tek başına tasarruf hakkına sahip değildir (TMK m.257/3).

Aile hukukunda kişi birliği olarak nitelendirilen "*mal ortaklığı rejimi*"nden başka, aile hukukunun ikinci kısmında "*aile malları*" başlığı altında "aile malları ortaklığı" da ayrı bir kişi birliği olarak düzenlenmiştir. Buna göre, "*Hısımlar, kendilerine geçen mirasın tamamı veya bir bölümüyle ya da ortaya başka mallar koymak suretiyle aralarında bir aile malları ortaklığı kurabilirler*" (TMK m.373).

Benzer bir kişi birliği de miras hukukunda "*paylaşımdan önce miras ortaklığı*" başlığında düzenlenmiştir. TMK m.640/1'e göre, "*Birden çok mirasçı bulunması hâlinde, mirasın geçmesiyle birlikte, paylaşmaya kadar, mirasçılar arasında terekedeki bütün hak ve borçları kapsayan bir ortaklık meydana gelir*". Mirasçılar terekeye elbirliğiyle sahip olurlar ve sözleşme veya kanundan doğan temsil ve yönetim yetkisi saklı kalmak üzere, terekeye ait bütün haklar üzerinde birlikte tasarruf ederler (TMK m.640/2).

Eşya hukukunda da "*Birlikte Mülkiyet*" başlığında yine bir kişi birliği oluşturulmuş; eşya üzerinde birden fazla şahsın malik olmaları hâlinde birlikte mülkiyetin söz konusu olacağı hükme bağlanmıştır (TMK m.688-703). Birlikte mülkiyet, paylı (müşterek) mülkiyet (TMK m.688 vd.) ve elbirliği ile mülkiyet (iştirak hâlinde mülkiyet) (TMK m.701-703) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Farklı hukuki düzenlemelere

tâbi tutulmuş olsa dahi, şey üzerinde birden fazla kişinin malik olması hâli esas alındığından, tüzel kişiliği bulunmayan bir kişi birliği oluşturulmuştur.

Böyle bir kişi birliği 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda da kabul edilmiş; Kat Mülkiyeti Kanunu, bağımsız bölümler üzerinde ilke olarak, tek kişi mülkiyetini öngörürken, arsa ve ortak yerler üzerinde paylı mülkiyeti öngörerek (Kat Mülkiyeti K. m.1, 3), tüzel kişiliği bulunmayan bir kişi birliğine vücut vermiştir.

Bütün bu tüzel kişiliği bulunmayan kişi birlikleri, şirkete benzer özellikler gösterse de, şirket değildir; kendilerine has amaçları ve aralarındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kanunları vardır. Şirket sözleşmesinde söze konu edinen ortak amacı birlikte gerçekleştirme gayesi şirketlerden farklı olsa da, hüküm bulunmayan hâllerde, mahiyetine uygun düştüğü nispette, şirketlere ilişkin benzer hükümler bunlara da tatbik edilebilir.

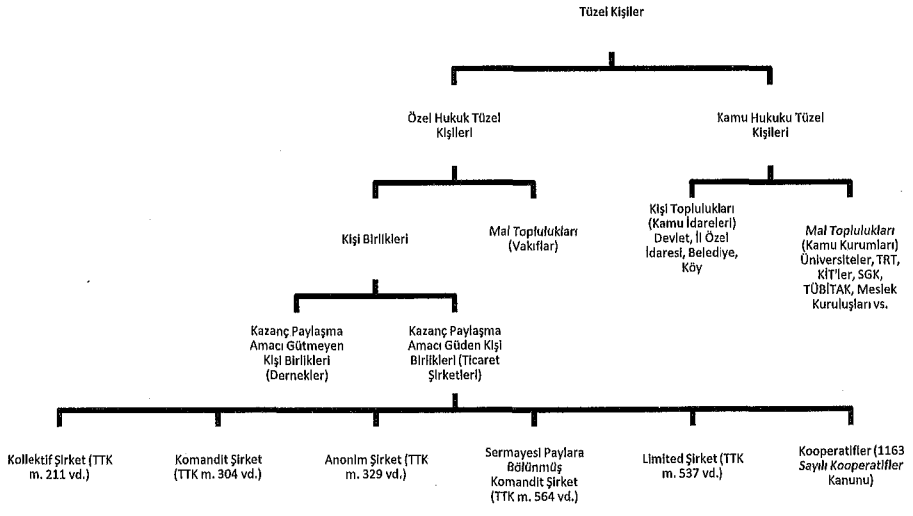
B) ŞİRKETLER HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK

Hukukumuzda şirket tipleri, sınırlı sayı (*numerus clausus*) esasına göre düzenlenmiştir. Buna göre, bir şirket ya Türk Borçlar Kanununda hükme bağlanan *adi şirkettir* (TBK m.620-645) ya da Türk Ticaret Kanununda *ticaret şirketi* olarak kabul edilen (kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif) şirkettir. Amaçları, konuları veya modern finans teknikleri nazara alınarak sıfatları farklı olsa da; Türk Hukukunda, şirket kurmak isteyenler, bu tiplerden ihtiyaçlarına en uygun birini seçmek zorundadır.

Sınırlı sayı esasına göre tipleri kanunla tespit edilmiş bu şirketlerden, adi şirketin tüzel kişiliği yoktur; ticaret şirketleri ise tüzel kişiliği haizdir.

1) Tüzel Kişiliği Olan Şirketler

Esas itibariyle Türk Medeni Kanununun 47 vd. maddelerinde hükme bağlanmış olan tüzel kişiler, *cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün hak ve borçlara ehildirler* (TMK m.48); *kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar* (TMK m.49). *Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır, organlar, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar* (TMK m.50/1-2).



Şirketler hukukunun konusu, kazanç paylaşmak amacı güden kişi birlikleridir. Bu kişi birliklerinden, ticaret şirketleri olarak nitelendirilen şirketler, özel hukuk tüzel kişisidir; şirket tiplerine göre farklı şekilde ifade edilse de amaçları "*iktisadi*"dir.

Hukukumuzda, yine amacı "*iktisadi*" olan; ancak, sermayesinin yarıdan fazlası doğrudan doğruya veya dolaylı olarak devlete ait olan kamu kuruluş ve ortaklıkları da vardır. Bu kamu kurumları, Türk hukukunda "*kamu iktisadi teşebbüsleri* (KİT)" kavramı altında toplanmıştır. KİT olarak anılan iktisadi kamu kurumları, ticaret, sanayi, madencilik, tarım ve bankacılık gibi alanlarda ekonomik faaliyette bulunmak üzere, kamu sermayesi veya kamu sermayesinin katkısıyla kanun veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanarak idari işlemlerle kurulan ve işletilen teşebbüslerdir. KİT'ler, ayrı bir malvarlığı ve personele sahip

kamu tüzel kişisidir; faaliyetlerini de özellikle anonim şirket unvanı altında yapmaktadırlar.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkındaki 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre, "*Kamu İktisadi Teşebbüsü*" (Teşebbüs); iktisadi devlet teşekkülü ile kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır (KHK/233 m.2/1). *Teşebbüsler*, Cumhurbaşkanınca kurulur (KHK/233 m.3/1). Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Anonim şirket şeklinde kurulan iktisadi devlet teşekküllerinde, genel kurul ve denetçiler bulunmaz.

KHK/233 m.2/6'da KİT kavramı altında toplanan "*İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşlarının veya bağlı ortaklıkların, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok yüzde ellisine sahip bulunan anonim şirket*" şeklinde tanımlanmış ve iştirakte "*teşebbüs ve bağlı ortaklık, Türk Ticaret Kanunu gereğince ortaklıkların sahip oldukları bütün haklara sahiptir*" (KHK/233 m.28/4) şeklinde ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere bu teşebbüslerin bazıları anonim şirket şeklinde nitelendirilmiş ve anonim şirketlere ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır. Ekonominin kurallarına uygun yönetilmeleri gereken bu teşebbüsler gerek sundukları hizmetten yararlananlarla gerek *üçüncü kişilerle yaptıkları işlemlerde özel hukuk hükümlerine tâbi olmalarına* ve şirket olarak anılmalarına rağmen, kanunla kuruldukları ve ilgililerin iradeleri kuruluşlarında etkili olmadığı için, Türk Ticaret Kanunu anlamında "*şirket*" olarak nitelendirilmemektedir[50]. Bu teşebbüsler, kamu tüzel kişisidir; kendi kuruluş kanunlarına tâbidir, şirketlerle ilgili hükümlere doğrudan atıf yapılmadıkça veya mahiyetlerine uygun olmadıkça, şirketlere ilişkin hükümlere tâbi değildir; şirkete benzer kuruluşlar olarak nitelendirilebilir[51].

a) Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketlerin Tasnifi

Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir (TTK m. 125/1); *kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir* (TTK m. 124/1).

Tüzel kişiliği haiz olduğu hükme bağlanmış olan ticaret şirketleri çeşitli açılardan tasnife tâbi tutulmaktadır:

---

50 **Poroy (Tekinalp/Çamoğlu),** I, N. 47.

51 **Poroy (Tekinalp/Çamoğlu)**, I, N. 45.

aa) Şahıs Şirketleri – Sermaye Şirketleri

Ortakların şirket içindeki rolü ve önemine göre ticaret şirketleri ikiye ayrılmış; TTK m. 124/2'ye nazaran, "*kollektif ve komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi*" sayılmış; kooperatifler bu tasnife dâhil edilmemiştir.

aaa) Şahıs Şirketleri

Türk Ticaret Kanununda, kollektif ve (adi) komandit şirketler şahıs şirketleri olarak nitelendirilmiştir (TTK m. 124/2). Bu iki şirketin müşterek özellikleri, şahıs şirketlerinin ayırıcı unsurlarını oluşturmaktadır.

Şahıs şirketi olarak nitelendirilen bu şirketlerden kollektif şirketlerde, aksi kararlaştırılmadığı sürece, "*ortakların her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkı ve görevini haizdir*" (TTK m. 218/1). Komandit şirketlere ilişkin özel hükümler saklı kalmak kaydıyla (TTK m. 304-328), kollektif şirkete dair 217 ilâ 231'inci maddeleri, komandit şirketlerde ortaklar arasındaki ilişkilere de tatbik edildiğinden, komandit şirketlerde de her ortağın ayrı ayrı şirketi yönetme hakkı ve görevi olduğu kabul edilir. Ancak bu hak, esas itibariyle komandite (sınırsız sorumlu) ortağa aittir. Aynı şekilde komandit şirketlerde şirketin temsili de kural olarak komandite ortaklara aittir (TTK m. 318/1).

Şahıs şirketlerinde, şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararlar oybirliği ile verilir (TTK m. 226/2; m. 308/1). Bunun gibi, şirkete girme, şirketten çıkma, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi mahiyetinde olduğu için yine oybirliği (veya oybirliği yerine mahkeme kararı) şarttır (TTK m. 253 vd; m. 328).

Bir ortağın ölümü, iflâs etmesi, hacir altına alınması ile şahıs şirketleri esas itibariyle sona erer (TTK m. 243 vd; m. 328). Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin (sınırlı sorumlu ortak) ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi neticesini doğurmaz (TTK m. 328). Şahıs şirketleri, kural olarak gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarının hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir (TTK m. 211). Sadece komandit şirketlerde, tüzel kişiler de *komanditer* ortak olabilir; komanditerler sorumluluğu sınırlandırılmış ortaklardır (TTK m. 304).

Bu izahlarımızdan da anlaşılacağı gibi, şahıs şirketlerinde şirketin en önemli unsuru, kişi unsurudur; şahıs şirketi kurulurken, sözleşmeye

katılanların şahsiyeti, mesleki ve sosyal durumu ön plâna çıkmakta, birbirine güvenen kişiler şahıs şirketine ortak olmaktadır. Bu mahiyeti dikkate alındığında, şahıs şirketlerinin *intiutu personae* (karşı tarafın kişiliği göz önüne alınarak işlem yapılması) karakterini taşıdığını söyleyebiliriz.

bbb) Sermaye Şirketleri

Türk Ticaret Kanununda, *anonim*, *limited* ve *sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket* sermaye şirketi olarak sayılmıştır (TTK m. 124/2).

Sermaye şirketlerinin müşterek özelliklerinin başında, şahıs şirketlerinden farklı olarak, ortakların ferdi idare ve temsil yetkilerinin bulunmaması gelir; bu yetkiler organlar vasıtasıyla kullanılır (TMK m.47; TTK m. 359 vd.). Sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkiler komandit şirketlerdeki hükümlere tâbidir; bununla beraber, anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümleri, yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerlidir (TTK m. 565/1; m. 570).

Şahıs şirketlerinde sözleşme değişikliği için oy birliği aranırken, sermaye şirketlerinde oy birliğinin yerini esas itibariyle, oy çokluğu almıştır (TTK m. 421; 589; 565/2). Ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu yoktur; pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur (TTK m. 329; 573). Sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortak, kollektif şirket ortağı gibi, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumludur (TTK m. 564).

Ortaklarda değişiklik, payın devri ile gerçekleşir (TTK m. 595); anonim şirketlerde hâmiline yazılı hisse senedi çıkarılmışsa, bu senedin devri ile pay devredilmiş olur (TTK m.489); Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlamaya bağlı olmaksızın, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle devredilebilir (TTK m. 490 vd.). Esas sözleşmede, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği öngörülebilir (TTK m. 492).

Limited şirketlerde ise, şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için, ortaklar genel kurulunun onayı şarttır

(TTK m. 595/2); genel kurul kararları, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır (TTK m. 620).

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, ortakların şirketten ayrılmaları, komandit şirket hükümlerine tâbi tutulmuştur (TTK m. 565/1).

Sermaye şirketlerinde ortakların ölümü, iflâsı, kısıtlanması, şirketin kanunî sona erme sebebi sayılmaz.

Bütün bunlar ve ilâve edilebilecek diğer özellikler nazara alındığında, sermaye şirketlerinde ortakların şahsiyeti, meslekî ve sosyal durumunun ikinci plânda kaldığını söyleyebiliriz.

bb) Ortakların Sorumluluğu Açısından Şirketler

Başlı başına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları olan ticaret şirketleri, sicile kayıt edilmekle tüzel kişilik kazanırlar ve bu sıfatlarına bağlı olarak; cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler (TMK m.48; TTK m.125).

Bu mahiyetleriyle ticaret şirketleri, ortakların mamelekinden ayrı, kendine has bir mameleke sahiptir. Bu nedenle ticaret şirketinin alacaklıları birinci derecede, doğrudan doğruya ticaret şirketinin mamelekine müracaat ederler; şirket tüzel kişiliği, şirket borçlarından dolayı birinci dereceden ve bütün malvarlığı ile sorumludur.

Bununla birlikte, bazı ticaret şirketlerinde, ortakların da şirket borçlarından sorumlu olacağı kabul edilmiştir (TTK m.236, m.237, m.304, m.317; AATUHK m.35 gibi).

aaa) Ticaret Şirketlerinde Ortakların Sınırsız Sorumluluğu

Ticaret şirketlerinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır. Organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün filleriyle ticaret şirketini borç altına sokarlar; bu borç ticaret şirketi tüzel kişiliğinin borcudur. Alacaklılar, alacağını, ticaret şirketinin mamelekinden alır; borçlu olan, ortaklar değil, ticaret şirketi tüzel kişiliğidir.

Hâl böyle olmasına karşın, kanun koyucu, şahıs şirketlerinde, ticaret şirketi tüzel kişiliği yanında, şirket borçlarından dolayı, ortakların da sınırsız sorumluluğunun doğduğu hâller öngörmüştür. Bu husus, kollektif şirketin tanımının yapıldığı TTK'nun 211'inci maddesinde "*...ortakların hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket kollektif şirkettir*" şeklinde hükme bağlanmış;

kollektif şirket ortaklarının şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu olduğu kabul edilmiştir.

Buna göre, kollektif şirket tüzel kişiliğinin borçlarından yine tüzel kişilik (birinci dereceden) sorumludur; kollektif şirket tüzel kişiliğinin mamelekinden karşılanamayan borçlarından, kollektif şirketin yanında ortaklar da (ikinci dereceden) sınırsız sorumludur. Kollektif şirket ortaklarının bu ikinci dereceden sınırsız sorumluluğu, şirkete karşı girişilen takibin semeresiz kalması ve şirketin sona ermesi halinde birinci dereceden sınırsız sorumluluk haline dönüşmektedir (TTK m.237/1).

Komandit şirketlerde, komandite ortak, kollektif şirket ortağı gibi, kural olarak, ikinci dereceden sınırsız sorumludur. Komandite ortağın şirket borçlarından (kural olarak) ikinci dereceden sınırsız sorumluluğuna karşın; komanditer ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmıştır (TTK m.304).

Kooperatifler Kanununun 28'inci maddesi uyarınca, ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, kooperatifler (tüzel kişilik) alacaklılarına karşı, sadece malvarlığı ile sorumludur; kooperatiflerin bu sorumluluğu, birinci dereceden ve bütün malvarlığıyla sorumluluktur; kooperatifin borçları sebebiyle ortaklara müracaat edilemez. Ancak ana sözleşmede öngörülmek şatıyla, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hâllerde, ortakların da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacakları hüküm altına alınabilir. Bu takdirde alacaklılar, kooperatifin iflâsı veya diğer sebeplerle dağılması hâlinde alacaklarını tamamen sağlayamazlarsa, kooperatifin borçlarından dolayı kooperatif ortakları, zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olurlar (KoopK m.29).

bbb) Ticaret Şirketlerinde Ortakların Sınırlı Sorumluluğu

Anonim şirketlerde "*pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur*" (TTK m.329/2). Limited şirketlerde "*ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen* ***ek ödeme*** *ve* ***yan edim yükümlülüklerini*** *yerine getirmekle yükümlüdürler*" (TTK m. 573/2).

Kooperatiflerde "*ana sözleşmede aksine hüküm olmadıkça kooperatif, alacaklılarına karşı yalnız mameleki ile sorumludur*" (KoopK m.28). Ortaklar, ana sözleşmede aksine bir düzenleme yapmamışsa

(bkz., KoopK m.29-37); kooperatiften alacaklı olanlar, kooperatifin borçlarından dolayı, kooperatif ortaklarına müracaat edemez.

Komandit şirketlerde de *komanditer* ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmıştır (TTK m.304; m. 564).

Bu düzenlemelerden de anlaşıldığı gibi bazı ticaret şirketlerinde ortakların sorumluluğu sınırlandırılmış; ortaklar sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu tutulmuştur. Şirket alacaklılarının, şirketin borçlarından dolayı, şirket ortağına müracaat hakkı yoktur. Şirket ortağının taahhüt etmiş olduğu sermaye paylarından doğan borcu, *şirket tüzel kişiliğine karşı bir borçtur*. Şirket ortağının, bu taahhüdünden doğan borcunun ödenmesini istemek yetkisi de sadece şirkete aittir; şirketten alacaklı olanlar, taahhüdünü yerine getirmeyen ortağa müracaat ederek, alacağının tahsili yoluna gidemez.

cc) Sermaye Niteliği Bakımından Şirketler

Şirketi diğer kişi birliklerinden ayıran önemli bir özelliği, ortak amaca ulaşmak için ortakların sermaye taahhüdünde bulunmasıdır. Şirket tüzel kişiliğinin ortaklardan ayrı, kendine has bir sermayesi vardır. Ancak sermaye, hukukumuzda değişik anlamlara konu olmaktadır. Ticaret şirketleri, sermayesinin mahiyetine göre çeşitli şekillerde anılmaktadır.

aaa) Değişir Sermayeli – Değişmez Sermayeli Şirketler

(1) Değişir Sermayeli Şirketler

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda, kooperatifler "*değişir ortaklı ve değişir sermayeli*" ortaklıklar olarak tanımlanmaktadır (KoopK m.1). Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamaz (KoopK m.2/3).

Sermaye miktarı sınırlandırılarak kooperatif kurulamayacağı hükmü, Kooperatifler Kanununun amacına da uygundur. Zira kooperatifler aynı zamanda değişir ortaklıdır; ortakların kooperatiften çıkması veya kooperatife (açık kapı ilkesi nedeniyle) yeni ortaklar girmesi, bu ortakların taahhütlerinin toplamından oluşan kooperatifin sermayesinin kendiliğinden değişmesine neden olur.

(2) Değişmez Sermayeli Şirketler

Değişmez sermayeli şirketler kavramı, kooperatifler haricindeki ticaret şirketlerinin sermayesini ifade etmek amacıyla kullanılır. Değiş-

mez sermaye, sermayenin hiçbir zaman değiştirilemeyeceği anlamına gelmez; şahıs ve sermaye şirketlerinde şirket sözleşmesi değiştirilmeden sermayenin değiştirilemeyeceğini ifade eder. Değişmez sermayeli şirketlerde sermaye değiştirilebilir; ancak sermayenin değiştirilebilmesi için şirket sözleşmesinin değiştirilmesi gerekir.

Değişmez sermayeli şirketler de kendi içinde farklı özellikler gösterir. Bunlar:

(a) Basit Sermayeli Şirketler

Basit sermayeli şirketler de değişmez sermayeli şirketlerdendir; şirket sözleşmesini değiştirmeden şirket sermayesi değiştirilemez. Basit sermayeli şirketlerin ortakları, şirket alacaklılarına karşı şirket borçlarından sınırsız sorumlu oldukları için, şirket sermayesi bakımından üçüncü kişileri koruyucu özel hükümlere ihtiyaç yoktur.

Ticaret şirketlerinden kollektif ve komandit şirket (ticaret şirketlerinden sayılmayan adi şirket), basit sermayeli şirketlerdir; bunların sermayesinin; üçüncü kişilerce bilinmesi birinci dereceden önemi haiz değildir. Zira bu şirketlerde ortaklar, şirket borçlarından dolayı alacaklılara karşı sınırsız sorumludur; alacaklıların asıl güvencesi şirketin sermayesinden ziyade sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklardır. Alacaklılar alacağını şirketten alamazsa, sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklara müracaat edebilir.

(b) Esas Sermayeli Şirketler

Esas sermayeli şirketler de şirket sözleşmesi değiştirilmeksizin sermayesi değiştirilemeyen şirketlerdendir. Anonim ve limited şirketlerde sermayenin evvelden belirlenmiş olması gerekir; sermayenin belirli olması, esas sermayenin niteliğidir (TTK m.329/1; m. 573/1). Şirketin sermayesi ile payların itibari değerinin şirket sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur (TTK m.339/2.c; m. 576/1.c); şirket sermayesi, esas sermaye paylarının toplamından müteşekkildir.

Esas sermayeli şirketlerin ortaklarının şirkete karşı sorumluluğu, taahhüt ettikleri esas sermaye payları ile sınırlıdır; şirket alacaklılarının ortaklara doğrudan başvurma hakları yoktur. Şirket borçlarından dolayı sadece şirket, mameleki ile sorumludur.

Esas sermayeli şirketlerde, şirket alacaklılarının menfaatlerinin korunması için, esas sermayenin korunması gerekmektedir. Zira bu

şirketlerde alacaklıların asıl teminatı şirket mameleki ve şirket mamelekinin önemli bir unsurunu teşkil eden esas sermayedir. Bu nedenle kanun koyucu esas sermayenin korunmasıyla ilgili birçok emredici hüküm sevk etmiştir (TTK m.344; m. 347; m. 379 vd.;m. 509; m. 519).

Kanun koyucu, anonim şirketlerin sermayesinin *esas sermaye* olduğunu belirledikten sonra, sadece sermaye artışı için genel kurulun toplantıya çağrılmasını önlemek için "*kayıtlı sermaye*" sistemini kabul etmiş; ayrıca genel kurula, TTK m.463 vd. hükümlerine göre, sermayenin *şarta bağlı olarak artırılmasına* karar verme yetkisi tanımıştır.

b) Tüzel Kişiliği Bulunan Şirketlerde Sorumluluk

Hukuk düzeninin belirli mal ve kişi topluluklarına tüzel kişilik tanımasının sebebi; tüzel kişiyi, onu kuran veya ondan yararlanan kişilerden farklı bir hak süjesi olarak hukuk alanında ortaya çıkarmaktır.

Ticaret şirketleri, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır ve kendisini kuran kişilerden (ortaklardan) farklı bir hak süjesi niteliğini kazanır; cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehil olur (TMK m.48). Ticaret şirketleri, tüzel kişi olarak, kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanır (TMK m.49). İradesini organları aracılığı ile açıklayabilen ticaret şirketleri, organların hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleri ile borç altına girerler (TMK m.50).

Ticaret şirketleri tüzel kişilik kazanmakla, özel bir mameleke sahip olur; şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğu, bu mameleki ile sorumluluktur. Buna göre, şirket alacaklısı, doğrudan doğruya şirketi dava ve takip edecek, alacağını şirket mamelekinden alacaktır; doğrudan doğruya şirket dava ve takip edileceğinden şirketin sorumluluğu "*birinci dereceden sorumluluk*" olarak nitelendirilmektedir. Şirketin bu sorumluluğu; esas sermeye ile değil, malvarlığı ile sorumluluktur.

Şirket alacaklısının, alacağını tahsil etmek için şirkete müracaat etmesi gerekir. Alacağını şirket malvarlığından tahsil edemeyeceği anlaşılan şirket alacaklısı, *kimi şirketlerde* ortaklara da başvurabilir; bu hâlde ortakların şirket borçlarından sorumluluğu (kural olarak) *ikinci dereceden* sorumluluk olarak nitelendirilmektedir.

aa) Şirket tüzel kişiliğinin sorumluluğu

Şirket tüzel kişiliği, şirket borçlarından dolayı, *birinci dereceden*, yalnızca sermayesi ile değil, *tüm malvarlığı ile sorumludur*; bu sorumluluk sınırlandırılamaz.

bb) Ortakların Şirket Tüzel Kişiliğinin Borçlarından Sorumluluğu

Şirket tüzel kişiliğinin borçlarından tüm malvarlığı ile sorumlu olacağı, şirket tüzel kişisinin borçlarından dolayı şirket ortaklarına başvurulamayacağı *kural* olmakla birlikte; kollektif şirket ortakları ile komandit şirkette *komandite ortakların*, şirket borçlarından ikinci dereceden ve bütün malvarlığı ile sınırsız sorumlu olduğu Kanunda kabul edilmiştir (TTK m.211; m. 304).

Buna göre, bu şirketlerin bahsi geçen ortakları, şirkete karşı yapılan takibin semeresiz kalması hâlinde (ortakların birinci dereceden sorumlu olacağı hâller hariç), şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden sorumludurlar. Kollektif ve komandit şirketlerde, şirket borçlarından dolayı (kural olarak) ikinci dereceden sorumlu olan ortakların bu sorumluluğu, şirket alacaklılarına karşı müteselsildir (TTK m. 236); böylece şirket alacaklıları, alacaklarının tamamını, şirket borçlarından dolayı sınırsız sorumlu ortakların birinden, birkaçından veya hepsinden isteyebilir (TBK m.163).

Anonim, limited ve kooperatif şirket ortakları ile komandit şirketlerde komanditer ortak, şirket borçlarından dolayı, şirket alacaklılarına karşı sorumlu değildir; şirket alacaklıları şirketten tahsil edemedikleri alacakları için bu ortaklara müracaat edemez. Hatta bu ortakların taahhüt edip ödemedikleri sermaye borcu dolayısıyla da; şirket alacaklısı, ödenmemiş sermaye borcu için ortaklara başvuramaz. Zira sermaye koyma borcu, şirket tüzel kişiliğine karşı bir borçtur (iç ilişki); ortakların dış ilişkide, ikinci dereceden de olsa, şirket borçlarından sorumluluğu yoktur. Şirketten alacaklı olan kişi, şirket tüzel kişisi tacir olduğu için, şirketin iflâsını isteyebilir; bu hâlde şirketin bütün alacakları ve borçları iflâs masasına geçeceğinden, ödenmeyen sermaye borcunu ancak iflâs masası talep edebilir; ortakların doğrudan talep hakkı yoktur.

2) Tüzel Kişiliği Olmayan Şirketler

Hukukumuzda Türk Borçlar Kanununda "*Adi Ortaklık Sözleşmesi*" başlığı altında düzenlenen (TBK m.620 vd.) "*adi şirketler*" ile Türk Ticaret Kanununun Deniz Ticaretini düzenleyen beşinci kitabında hükme

bağlanan "*donatma iştiraki*"nin (TTK m.1064 vd.) tüzel kişiliği yoktur. Donatma iştirakinin tüzel kişiliği bulunmamasına rağmen "*tacire ilişkin hükümler*" donatma iştirakine de aynen uygulanır (TTK m.17).

Donatma iştirakinin, tacirlere ilişkin hükümlere tâbi olması bir yana; tüzel kişiliği bulunmayan şirketlerin başında adi şirketler gelir. Adi şirket Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiştir (TTK m.620-645); tüzel kişiliği yoktur. Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığından, adi şirket şeklinde oluşan kişi birliğinin, onu oluşturan şahıslardan bağımsız bir hak süjesi olması da söze konu değildir; adi şirketin, şirket sıfatıyla hak ehliyeti yoktur.

Bu nedenle, ortaklık faaliyetleri kapsamındaki bir hukuki işlemde adi şirket taraf olarak yer alamaz; hukuki işlemler ortaklar tarafından, diğer ortakları temsilen yapılır. Ancak bu halde de temsil edilen ortaklardır; adi şirket değildir. Ayrıca, şirkete tahsis edilen katılma payları ve şirket faaliyetlerinden elde edilen gelirler, adi şirkete ait değildir; birlikte mülkiyet (iştirak halinde mülkiyet) esasları doğrultusunda, tüm ortaklara aittir. Şirket işlemlerinden doğan borçlar da adi şirketin değil; ortakların borcudur. Ortakların bu borcu, adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından, birinci derecedendir. Ortaklar birinci dereceden sınırsız ve müteselsilen sorumludurlar. Adi şirket tüzel kişiliğe sahip olmadığından, gerek yargılama hukuku ve gerekse takip hukuku bakımından aktif ve pasif taraf ehliyetine sahip değildir; davaların bütün ortaklar tarafından birlikte açılması (zorunlu dava arkadaşlığı) gerekir.

II) İRADENİN OLUŞTURULMASI

Şirket bir kişi birliğidir; bu kişi birliklerinin bazılarına ortaklardan farklı bir "kişilik" (tüzel kişilik) tanınırken, bazıları bu haklardan yoksun bırakılmıştır. Bu anlamda ticaret şirketleri tüzel kişiliği haiz iken; adi şirketin tüzel kişiliği yoktur.

İster tüzel kişiliği bulunsun ister bulunmasın, kişi birliklerinde, birliğin faaliyetleri için, iradesinin oluşturulması gerekir. Bu konunun, tüzel kişiliği bulunan ticaret şirketlerinde ve tüzel kişiliği bulunmayan kişi birliklerinden adi şirket için ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

A) TİCARET ŞİRKETLERİNDE İRADENİN OLUŞTURULMASI

Ticaret şirketleri iradelerini organları vasıtasıyla açıklar ve organlar, hukuki işlemleri ve diğer bütün faaliyetleriyle ticaret şirketlerini borç

altına sokarsa da; icra ettikleri fonksiyonların farklılığı ve ticaret şirketlerinin farklı yapıda olması, organ kavramına farklı anlamlar yüklenmesine sebebiyet verir. Bu nedenle öncelikle ticaret şirketlerinde organ kavramı üzerinde durulacaktır.

1) Organ Kavramı

a) Genel Olarak Ticaret Şirketlerinde Organ

Ticaret şirketlerinin türleri nazara alındığında, "*ticaret şirketlerinin organı*" kavramına yüklenen anlamlarda da farklılık görülmektedir.

aa) Geniş Anlamda Organ

Ticaret şirketlerini ilgilendiren işlem ve fiilleri tüzel kişiliği bağlayacak (ilzam edecek) şekilde üstlenen kişiler geniş anlamda organ sayılır. Bu esastan olmak üzere, şirketi idare ve temsil etmek üzere kendisine bağımsız karar alma yetkisi verilmiş kişi veya kişiler, organ olarak kabul edilir.

bb) Dar Anlamda Organ

Kanunla veya şirket sözleşmesiyle tüzel kişinin iradesini açıklamak üzere yetki verilen ve hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle ticaret şirketlerini borç altına sokan kişi veya kişilerden oluşan topluluklarına (*kurul*), dar anlamda organ denilmektedir.

Organlar hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle ticaret şirketlerini borç altına soktukları için; bilhassa sorumluluk açısından organların şeklî ve fiilî organ ayrımına tâbi tutulduğunu görmekteyiz[52].

aaa) Şeklî Organ

Kanunda veya şirket sözleşmesinde, kendisine organ vasfı verilen kişiler veya kişilerden oluşan topluluklar (kurullar) şeklî anlamda organdır. Bu vasfıyla kanunun, ticaret şirketlerinin sahip olmasını şart koştuğu organlar kanunî (*mecburî*) organlar; şirket sözleşmesini kuranların kendi iradeleriyle kanunların haricinde oluşturdukları organlar ise *ihtiyarî* organlardır.

---

[52] **Doğan, B. F**, Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, 2. Baskı, İstanbul 2011, s. 5-7 ve s. 7, dn. 7' de zikredilen müellifler.

Gerek kanunî gerek ihtiyarî organlar (kendilerine yetki verilen gerçek kişi veya kişilerden oluşan topluluklar), yetkileri çerçevesinde bağımsız karar alma yetkisine sahip ise, bu kişi veya kişi toplulukları organ vasfını iktisap ederler; bunlar hukukî işlemleri ve diğer bütün faaliyetleri ile şirketi borç altına sokarlar.

Bu niteliği sonucu, anonim şirketlerde yönetim kurulu, genel kurul[53]; limited şirketlerde müdürler (TTK m. 623); kooperatiflerde, yönetim kurulu, genel kurul, denetçiler (KoopK. m.42 vd.); kollektif şirketlerde aksi kararlaştırılmadıkça, ortaklardan her biri (TTK m. 218); komandit şirketlerde idare ve temsil yetkisine sahip komandite ortak organ sıfatını haizdir.

bbb) Fiilî Organ

Ticaret şirketlerinde, kanunda veya sözleşmede organ olarak nitelendirilmeyen veya şirketin faaliyeti içerisinde herhangi bir görevlendirme olmaksızın iradenin oluşumuna yahut idare ve temsil görevine katılan kişi veya kişi gruplarına *fiilî organ* adı verilir. Bunlar kanun veya sözleşmede organ olarak nitelendirilmemelerine karşın, fiilen organ görevi üstlenmekte, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle ticaret şirketlerini borç altına sokmaktadırlar.

Bu bağlamda kişi veya kişi gruplarının şirket idaresine katılması, hukuki işlemleri ile ticaret şirketlerini borç altına sokması, o işlemle ilgili olarak o kişi veya kişi grubuna organ sıfatını izafe etmek için yeterlidir; uzun süreli ve düzenli olarak şirketin idaresine katılmış ve onu etkilemiş olması da aranmaz. Bu şekilde şirketlerde hâkim ortak, şirket

---

53 Sermaye şirketlerinde denetim hak ve görevi doğrudan doğruya denetçilere tanınmıştır (TTK m. 397; 635). Bu itibarla anonim şirketlerde bir veya birden fazla denetçi bulunması zorunludur (TTK m. 400/I). Ancak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan farklı olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre, ***denetçi, anonim şirketin organı değildir***; *eksikliği de şirketin feshi sebebi sayılmaz*. TTK m. 635' de yapılan atıf gereği aynı husus limited şirketler için de geçerlidir. Türk hukuk öğretisinde, bağımsız denetçinin organ vasfının bulunmadığı genellikle kabul edilmektedir: **Köksal, A.**, "*Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın 397 İlâ 406 Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu*", Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, Ankara, 2010, s. 1387 vd.; **Pulaşlı**, C. I, § 28 N 2-3; § 31 N 4; **Tekinalp/(Poroy/Çamoğlu)**, I, N. 636; **Bahtiyar**, M.: Ortaklıkları Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2019, s. 147.

idaresinde görevi olmasa dâhi, bir defa da olsa şirketin iradesinin oluşumuna katılmış, şirketi borç altına sokmuşsa, *bu hukuki işlem dolayısıyla* organ sıfatını kazanacaktır.

Kişi veya kişi grubunun fiilî organ olarak nitelendirilmesinde, bunların imza yetkisinin bulunup bulunmadığının önemi yoktur; anonim şirket yönetim kurulunda temsilci bulunduran tüzel kişiler ve kamu kuruluşları, iradenin oluşumunu temin maksadıyla talimat vermişlerse, fiilî organ olarak sorumlu tutulurlar[54].

b) Ticaret Şirketlerinde Organ Kavramı Tayininde Başvurulacak Esaslar

Türk Ticaret Kanununda organ kavramı tanımlanmamış[55]; ticaret şirketlerinin Türk Medeni Kanununun 48'inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabileceği ve borçları üstelenebileceği hükme bağlanmış (TTK m. 125), bu haliyle de "*organ*" sıfatının tayini Türk Medeni Kanununun 48 vd. hükümlerine bırakılmıştır.

TMK m.48 vd. hükümlerinde "*organ*" kanuni bir ifade olarak yer alsa da tanımı yapılmamış, muhtevası tespit edilmemiş; muhtevasını tayin yetkisi hâkime bırakılmıştır. Bu anlamda TMK m.48 vd. hükümlerinde organ kavramının muhtevası tespit edilmeyerek, istenilerek bir boşluk yaratılmış (intra legem); bu boşluğun hâkim tarafından doldurulması arzu edilmiştir.

Kendi başına bir hak süjesi olmayan, sadece kendisine verilen bir takım yetkileri kullanma hakkını haiz olan "*organ*"ı tespitte iki farklı kıstastan hareket edilmektedir[56].

aa) Şekli Kıstas

Tüzel kişilerde organ, tüzel kişiliği düzenleyen kanunda veya tüzel kişiliği meydana getiren kişilerin iradelerinin oluştuğu kuruluş belgelerinde yahut kanunun öngördüğü bazı hallerde yetkili makam kararıyla belirlenebilir.

---

54 **Akdağ, Güney, N.,** Anonim Şirket Yönetim Kurulu, İstanbul 2016, s. 356-361.

55 Kooperatifler Kanununda, "Kooperatif Organları"nın genel kurul, yönetim kurulu ve denetçiler olduğu belirtilmiş ve fakat burada da bir tanıma yer verilmemiştir (KoopK. m. 42 vd.).

56 **Öztan, B.**, Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970, s. 31 vd.

aaa) Organın Kanun Koyucu Tarafından Belirlenmesi

TMK'nın 49'uncu maddesinde, "*tüzel kişilerin kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organa sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar*" denilmekte; kanunun bir tüzel kişinin, fiil ehliyeti için, sahip olması gereken organlarının bulunması gerektiğine işaret edilmektedir. Fiil ehliyetinin kazanılabilmesi için gerekli olan bu organlara *kanuni (mecburi)* organlar adı verilir.

Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketleri için mecburi organlar belirtilmiş; müşterek zorunlu organ olarak *yönetim organı* kabul edilmiştir (TTK m. 218; m. 309; m. 359; m. 570; m. 623; KoopK.m.42 vd.). Kanunda belirlenen bu organlar, kanunda doğrudan veya dolaylı bir şekilde organ olarak nitelendirildiklerinden, kendilerinde organ kavramı için gerekli özelliklerin var olup olmadığı araştırılmaz.

bbb) Organın Kuruluş Belgelerinde Belirlenmesi

Tüzel kişinin kuruluşuna katılanların iradesinin oluştuğu kuruluş belgelerinde (ticaret şirketlerinde şirket sözleşmesinde) *kanuni organların yanında* başka organlar da öngörülebilir; tüzel kişiliğin kuruluşuna katılanların iradesiyle, kuruluş belgelerinde oluşturulan bu organlara "*ihtiyari organ*" denir.

Bu bağlamda, anonim şirketlerde esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimin kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya bir üçüncü kişiye devredilmesi halinde yetkinin devredildiği kişi/kişiler (*murahhas müdür*), ihtiyarî bir organdır.

ccc) Organların Yetkili Makamlarca Tayini

Anonim şirketlerde, şirketin feshine mahkemenin karar verdiği hallerde tasfiye memuru mahkemece atanır (TTK m. 536/3). Bu şekilde atanan tasfiye memurunun organ sıfatı kabul edilir. Tüzel kişinin gerekli organlardan yoksun kalması ve yönetimin başka yolla sağlanamaması nedeniyle yetkili makamlarca atanan kayyım da (TMK m.427/1.b.4) bu sıfatı ile organ sayılır.

bb) Maddi Kıstas

Kanunda belirtilen veya kuruluş belgelerinde gösterilen organların belirlenmesi herhangi bir güçlük arz etmez. Kanunda belirtilmemekle

veya kuruluş belgesinde yer almamakla birlikte, hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokan kişilerin organ sıfatının tayini önemlidir.

Tüzel kişiyi borç altına sokan bu kişilere organ sıfatını izafe edebilmek için belirli özelliklere sahip olmaları gerektiği düşünülmektedir. Buna göre, iradenin oluşmasına ve iradenin beyanına iştirak ederek tüzel kişinin borç altına girmesine sebebiyet verenler; diğer bir ifadeyle idare ve temsilde görev alanlar, yetkili merciin emirlerini yerine getirmekten ziyade bağımsız hareket etme yetkisini haizse, organ sıfatının varlığı kabul edilmelidir.

Buna göre, bağımsız karar alabilme ve üçüncü kişilerle muamele yapma yetkisini haiz olan kişiler, mesela müdür veya CEO (Chief Executive Officer) bu özelliklere sahipse, kuruluş belgesinde organ olarak tavsif edilmese dahi, organ sıfatı kabul edilmelidir.

II) Organlarda İradenin Oluşumu

Organ, kişi veya kişi grubu (kurul organ) şeklinde olabilir. Organ, şayet bir gerçek kişiden müteşekkilse, şirketin iradesinin oluşumu o gerçek kişinin kararına bağlıdır (*bireysel karar*). Organ kurul organ şeklindeyse, yani birden fazla kişiden teşekkül ediyorsa, şirketin iradesini topluluk belirleyecektir; topluluğun müştereken belirlediği iradeye, *toplu karar* denir.

Toplu karar, ortak bir amacı gerçekleştirmek maksadıyla birleşmiş olan bir kişi topluluğunda, birden çok kişinin kendilerine oy hakkı sağlayan bir düzenleme çerçevesinde, kurulun yetkili olduğu konuda, oy kullanarak gerçekleştirdikleri, kişi topluluğunun tümünü ilgilendiren ortak bir hususta sonuca varılmasını sağlayan, çok taraflı bir hukuki işlemdir[57].

Kararda sözleşmelerin aksine, irade beyanları karşılıklı değildir; toplantıyı yönetene ulaşması gereken irade beyanlarının toplanması ile karar oluşur. İrade beyanlarının birbirine uygun olması da gerekmez; kararın alınması için kural olarak, irade beyan edenlerin çoğunluğu yeterlidir. Karar, ilgili topluluğun iç ilişkilerini ilgilendirir; dış ilişkide hü-

---

[57] **Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı**, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukukî İşlem, Sözleşme, 5. Bası, İstanbul 2010, s. 113-114; **Serozan**, s. 306.

küm doğurması için karara dayanarak şirketi temsil eden kişilerin üçüncü kişilerle işlem yapması gerekir.

Bir topluluğun iradesinin oluşumunu sağlayan toplu kararda, kararın varlığından bahsedilebilmesi için, kararın usulüne uygun bir şekilde alınmış olması; diğer bir ifadeyle, toplantıya, usulüne uygun şekilde çağırılmış kişilerin, kişi birliğinde (kurulda) toplantı yapabilecek bir sayıya ulaşması (*toplantı yeter sayısı*), toplantılarda karara konu hususlarda müzakere edilmesi, kararın oluşumu için *oy verilmesi* ve verilen oyların kararın oluşumuna yeterli olması (*karar yeter sayısı*) gerekir.

a) Toplantıya Davet (Çağrı)

Kişi birliklerinden oluşan organların (kurul organ) karar alabilmesi için, kurulu oluşturan kişilere usulüne uygun bir davetin (çağrı) yapılması gerekir. Usulüne uygun bir davet yapılmadan kurul üyelerinin bir araya gelmesi, toplantı olarak nitelendirilemez[58].

Toplantıya davetin, toplantıya davete yetkili olanlar tarafından, kanuna ve kuruluş belgelerinde belirtilen esaslara uygun yapılması ve bütün üyelere ulaştırılması gerekir.

Toplantıya çağrının (davetin) ne şekilde yapılacağı, kanunda veya kuruluş belgelerinde (sözleşmede) gösterilir; bu hâlde bir toplantıdan bahsedebilmek için, kanun ve sözleşme hükümlerine uygun bir davetin bulunması esastır.

b) Toplantı Yeter Sayısı (Toplantı Nisabı)

Toplantı yeter sayısı, bir topluluğun hukuken geçerli bir şekilde toplanıp, müzakereye başlayabilmesi için o toplantıda bulunması gereken asgari sayıdır.

Toplantı yeter sayısı (toplantı nisabı) kanunda veya kuruluş belgesinde (şirket sözleşmesinde); kurulun ve toplantının mahiyetine göre ayrı ayrı belirlenmiş olabilir. Toplantı yeter sayısının, anonim şirket genel kurul toplantılarında olduğu gibi, ortak sayısına göre değil; şirketin esas/çıkarılmış sermayesine göre belirlenmesi de mümkündür (TTK m. 418).

---

[58] Anonim şirketlerde genel kurulun çağrısız yapılması, genel kurulun hiçbir çağrı yapılmadan kendiliğinden toplanabileceği anlamına gelmez; aksine yine çağrıya yetkili organın daveti (çağrısı) üzerine, ancak bazı ilanların yapılmasına gerek olmadan genel kurulun toplanabileceği anlamına gelir (TTK m. 416).

İster kanunda ister şirket sözleşmesinde belirlenmiş olsun, toplantı yeter sayısı olmadan üyelerin bir araya gelerek aldıkları kararlar; alınan karar oy birliği ile alınmış olsa dâhi "*yok*" hükmündedir.

c) Karar Yeter Sayısı (Karar Nisabı)

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir toplantıda, bir karara varılabilmesi için gerekli bulunan sayıya *karar yeter sayısı* denir. Karar yeter sayısı, kanunda veya şirket sözleşmesinde, kurulun, toplantının ve karar konusunun mahiyetine göre değişir; aksine açık hüküm veya sözleşme hükmü bulunmadıkça, *kural olarak*, oylamaya katılanların sayısına göre hesap edilir[59].

aa) Karar Yeter Sayısı Çeşitleri

Karar yeter sayısı *oy birliği* ve *oy çokluğu* olmak üzere iki çeşittir.

aaa) Oy Birliği (İttifak)

Oy birliği, toplantının ve konunun mahiyetine göre, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde; kurulu oluşturan üyelerin (ortakların) tamamının veya toplantı yeter sayısını oluşturarak toplantıya katılan tüm üyelerin (ortakların) aynı yönde oy kullanmaları, yani hiç karşı oy (muhalif) bulunmamasıdır. Oy birliği gereken kararlarda, *karşı oy* (muhalif) bulunmamasının yanında, *çekimser* oyun da olmaması gerekir; çekimser oy, oybirliğini bozar.

Bu bağlamda, anonim şirket esas sözleşmesinin bazı değişikliklerinde oy birliği aranmış; "*bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirket merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar, sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla (oy birliği) alınır*" (TTK m. 421/2), denilmiştir.

bbb) Oy Çokluğu (Ekseriyet)

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir toplulukta, karar alınabilmesi için oylamaya katılanların çoğunluğunun aynı yönde oy kullanması halinde *oy çokluğu (ekseriyet)* söz konusu olur.

Oy çokluğunun, *adi* (nispi), *mutlak* (salt) ve *vasıflı* (mevsuf/nitelikli) çoğunluk olmak üzere üç türü vardır.

---

[59] **Karayalçın**, s. 120.

(1) Adi Çoğunluk (Nispî Ekseriyet)

Nispî (oransal) ekseriyet (çoğunluk) de denilen *adi çoğunluk* (kullanılan oylar toplamının, tüm oyların yarısından fazlası olması şartı aranmaksızın); alınan oyun, diğer oy topluluklarından fazla olmasını ifade eder. Daha ziyade seçim yapılan hallerde veya oylamada çekimser oyun kullanıldığı durumlarda söz konusudur. Buna göre toplantı yeter sayısının bulunduğu toplantıda, 100 kişi oy kullanmışsa, (A) 40, (B) 35 ve (C) 25 oy alırsa ; (A), (B) ve (C)'ye *nispetle* daha fazla oy aldığı için (A) çoğunluğu elde etmiş olur.

(2) Mutlak Çoğunluk (Salt Ekseriyet)

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir *toplantıda oy verenlerin* yarısından fazlasını ifade eden bir çoğunluktur. Mutlak çoğunluğun arandığı bir kararda, toplantı yeter sayısından az olmamak kaydıyla, toplantıya yüz kişinin katıldığını ve oy kullandığını farz edersek; tekliflerde (A), yarıdan fazla oy alırsa (meselâ 51); karar mutlak çoğunlukla alınmış olur. Diğer teklifin meselâ 40 oy alması, geriye kalan 9 oyun çekimser olması sonucu değiştirmez.

Kanunda veya şirket sözleşmesinde aksi belirtilmediği sürece; *mutlak çoğunluk, oy kullananların yarısından sonra gelen üst tam sayısı olarak anlaşılmalıdır*. Ancak kanunda veya şirket sözleşmesinde "*yarıdan bir fazlası*" ifadesi varsa, hesap buna göre yapılır. Bu hâli bir örnekle açıklarsak, 65 kişinin katıldığı bir toplantıda yarıdan bir fazlası, 65'in yarısı 32,5 bir fazlası 33,5 olur; buçuğun tama iblâğ edilmesi gerektiğinden, mutlak çoğunluk için 34 kişinin aynı yönde oy kullanması gerekir. Aynı toplantıda "*yarıdan bir fazlası*" ibaresi olmasa idi, mutlak çoğunluk yarıdan sonra gelen üst tam sayıyı ifade edeceğinden, 33 oy salt çoğunluğu temin etmek için yeterli olacaktı.

(3) Nitelikli Çoğunluk (Mevsuf Ekseriyet)

Kanunda veya şirket sözleşmesinde, belli kararlar için aranan üçte iki, dörtte üç gibi belirli çoğunluktur. Nitelikli çoğunluk, anonim şirketlerde işletme konusunun tamamen değiştirilmesini öngören esas sözleşme değişikliklerinde olduğu gibi (TTK m. 421), *pay sahiplerinin tamamı* nazara alınarak aranabilir.

bb) Oy Verme

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir toplantıda, kararın alınması, buna bağlı olarak iradenin oluşması, toplantıya katılanların oy vermesine bağlıdır. Oy verme, oylama için öngörülen süre içinde, oylamayı yapana yöneltilmesi ve varması gereken (vusulû muktazî) bir irade beyanıdır. İrade beyanı oylamayı yapana vâsıl olduktan (vardıktan), diğer oylarla karıştıktan sonra geri alınamaz.

cc) Oylarda Eşitlik

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir kurulda hukuken geçerli bir kararın alınmış sayılabilmesi için, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülen karar yeter sayısının elde edilmesi gerekir. Bilhassa, karar alınabilmesi için adi çoğunluğun arandığı toplantılarda, tekliflerden birisinin diğerine nispetle daha fazla oy alamadığı hâller, diğer bir söyleyişle, oylarda eşitlik bulunabilir. Bu hâlde kural olarak, teklif reddedilmiş sayılır.

Ancak, kanunda veya şirket sözleşmesinde bu durum öngörülmüşse, öngörüldüğü şekliyle uygulanması; teklifin red veya kabul edildiğinin buna göre değerlendirilmesi gerekir.

Bu hususa, Türk Ticaret Kanununun 624'üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununu ve anonim şirket yönetim kurulu toplantılarında "*karar*"ı düzenleyen Türk Ticaret Kanununun 390'ıncı maddesini örnek olarak gösterebiliriz.

TTK m.624/3'e göre limited şirketlerde, "*Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır*".

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununda da, oylarda eşitlik hâlinde "*başkanın üstün oyu*" esası kabul edilmiştir. 1211 sayılı Kanunun 21'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, "*Banka Meclisi, üyelerin en az üçte ikisinin katılımıyla toplanır ve mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde (teklif reddedilmiş sayılmaz), Başkanın katıldığı tarafın teklifi kabul edilmiş sayılır*".

TTK m. 390/1'e göre ise "*esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, (anonim şirketler) yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan*

üyelerin çoğunluğu ile alır". "*Oylar eşit olduğu takdirde, o konu (reddedilmiş olmaz) gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa, söz konusu öneri reddedilmiş sayılır*" (TTK m. 390/3).

"*Başkanın üstün oyu*" esasının uygulanabilmesi için, bu hususta, kanunda veya şirket sözleşmesinde açık hüküm bulunması gerekmektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, TTK m. 624/3 haricinde, "*başkanın üstün oyu*" ile ilgili genel bir düzenleme bulunmamakla birlikte kanaatimizce, yönetim kurulu toplantıları için şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle "*başkanın üstün oyu*" kabul edilebilir.

d) Kararların Etkileri

Toplantı yeter sayısının bulunduğu bir toplantıda, kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülen karar yeter sayısı ile alınan kararlar; kararın alındığı kişi birliğinin tüm üyelerini (tüm şirket ortaklarını; toplantıya veya karara katılmış olmaları şartına bağlı olmadan) bağlar.

B) TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN ŞİRKETLERDE İRADENİN OLUŞTURULMASI

Yukarıda bahsedildiği gibi, Türk Borçlar Kanununda "Adi Ortaklık" (TBK m.620-645) sözleşmesi başlığı altında düzenlenen adi şirketler ile Türk Ticaret Kanununda (TTK m. 1064 vd.) ele alınan, donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur. Tüzel kişiliği bulunmayan donatma iştirakine, tacirlere ilişkin hükümler aynen uygulanır (TTK m. 17). Bu haliyle kendine has özellikleri bulunan donatma iştiraki bir yana; tüzel kişiliği bulunmayan şirketlerde iradenin oluşturulmasından bahsederken, adi şirketleri ön plâna çıkartmak istiyoruz.

Hukukumuzda adi şirket kurmak suretiyle ortaya çıkan kişi birliğine, bu kişi birliğini oluşturan şahıslardan bağımsız bir hak süjesi olma vasfı tanınmamış; adi şirkete tüzel kişilik sıfatı verilmemiştir[60].

Türk Hukukunda adi şirket, tüzel kişiliği bulunmadığı için, kişi birliği olarak üçüncü kişilerle hukuki işlem yapamayacağı gibi, malvarlığı

---

60 Alman Federal Mahkemesi 2001 yılında verdiği bir kararda, dış ortaklık olarak kurulmuş bir adi şirketin, tüzel kişiliği olmamasına rağmen, hak ehliyeti olduğunu karara bağlamış; adi şirkete şahsiyet tanıyarak hukuki işlemlere taraf olabileceğini kabul etmiştir (Bu kararın çevirisi için bkz., **Narbay**, Ş./ **Deliduman**, S., Alman Federal Mahkemesinin (Dış-) Adi Şirketin Hak ve Taraf Ehliyetine Sahip Olduğuna İlişkin 29.01.2001 tarihli Kararı, Prof. Dr. Ömer Teoman' a 55. Yaş Günü Armağanı, C.I, İstanbul 2002, s. 577 vd.).

üzerinde de şirket olarak mülkiyet hakkı edinemez. Adi şirketin hak ehliyeti olmadığı için mameleki değerler, elbirliği mülkiyet ilkelerine göre ortaklara aittir; davada da taraf ehliyeti yoktur.

Bütün bunlara rağmen, kişi birliği olan adi şirketlerde, kişi birliğinin iradesinin oluşturulması gerekebilir. Adi şirketlerde, iki veya daha fazla kişi, ortak bir amaca ulaşmak için bir araya geldiklerinden (TBK m.620), bu amaca ulaşmak için bir araya gelerek bir karar almak; kişi birliğinin iradesini oluşturmak zorundadırlar. Adi şirkette karar, iç ilişkiyi ilgilendiren iradenin oluşmasına hizmet eden, ortak sonuca varmayı hedefleyen bir hukuki işlemdir.

Kanun koyucu adi şirketlerde *kararı*, Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesinde hükme bağlamış, "*Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliği ile alınır*" demiş; sözleşmede kararların oy çokluğu ile alınabileceğini, ancak bu halde oy çokluğunun (toplantıya katılanların sayısına göre değil) ortak sayısına göre belirlenmesi gerektiğini (TBK m.624/2) ifade etmiştir.

Bu hükme nazaran kanun koyucu, adi şirketlerde sadece kararların nasıl alınabileceğini düzenlemiş; hangi hallerde karar alınması gerektiğini ve karar alma usulünü belirlememiştir. Ancak, maddenin düzenlemesinde, kararla ilgili olarak yukarıda yaptığımız açıklamaların adi şirketin mahiyetine uygun olduğu müddetçe, geçerli olduğunu söyleyebiliriz.

İKİNCİ BÖLÜM

§3- ADİ ŞİRKET

LİTERATÜR

Barlas, N., Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme İlişkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, 4. Baskı; *Bilgili*, F., Türk Ortaklıklar Hukuklunda Gizli Ortaklık İlişkileri, 2003; *Şener, O.H.*, Adi Ortaklık, Yetkin Yayınları, Ankara 2008; *Kurşat Z.*, "Yeni Borçlar Kanunumuzda Adi Ortaklık Hükümlerinin Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 2012, C.70, s. 301-320; *Bilgili, F.*, Adi Ortaklıkların Fiil Ehliyeti ve Alman Federal Mahkemesinin Verdiği Yeni Karar Karşısında Ortaya Çıkan Durum, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002; s. 197-213; *Kayar, İ.*, Adi Şirketin Ticaret Unvanı ve Ticaret Siciline Tescili, Prof. Dr. Ömer Teoman'a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, s. 479-493; *Eren, F.*, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2018, 6. Baskı; *Yavuz, C. / Acar, F. /Özen, B.*, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul 2018, 15.Bası.

GİRİŞ

Adi şirket, "*Adi Ortaklık Sözleşmesi*" başlığı altında, Türk Borçlar Kanununun "*Özel Borç İlişkileri*"ni düzenleyen ikinci kısmın on sekizinci bölümünde (m.620-645) düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, 1 Temmuz 2012'de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun birinci kısmı (m.1-206), borçlar hukukunun "*Genel Hükümleri*"ni, ikinci kısmı ise (m.207-649), "*Özel Borç İlişkileri*" başlığı altında çeşitli borç ilişkilerini düzenleyen özel hükümleri bir araya getirmektedir.

Genel hükümler, bütün borç ilişkilerine uygulanması mümkün olan genel esaslardır. Özel hükümler ise, çeşitli borç ilişkilerinin her birinin mahiyetine göre konulmuş, sadece ilgili oldukları ilişkiye uygulanması kabil olan, onun özelliklerini göz önünde tutan hükümlerdir. Özel hükümler (lex specialis), kendisi için konuldukları ilişkiye uygulanmak bakımından genel hükümlerden önce gelir.

Çeşitli sözleşme tiplerinin, genel hükümlerin yanında ayrıca düzenlenmesi, çok defa tarihi sebeplerle açıklanabilir; bu sözleşmelere üstünlük sağlamak amacı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu sözleşme tiplerinin daha ziyade uygulandığı ve bu sebeple kanun koyucunun hukuk uygulamasında kolaylık ve açıklık sağlama amacının bulunduğunun da göz ardı edilmemesi gerekir.

Özel borç ilişkilerini düzenleyen kanun hükümleri, esas itibariyle tamamlayıcı ya da yorumlayıcı hukuk kuralıdır; ancak devletin özel hukuk ilişkilerine, kamu düzenini sağlama amacıyla müdahale ettiği, özel borç ilişkilerini düzenleyen emredici hükümlere de yer verildiği görülmektedir.

Özel borç ilişkileri, Türk Borçlar Kanununun ikinci kısmındaki düzenlemelerle sınırlı değildir; kanunda düzenlenmeyen bir sözleşmenin yapılabilmesi mümkündür. Bu bakımdan borçlar hukukumuzda, özel borç ilişkileri bakımından, eşya hukukunda ve Roma hukukunda olduğu gibi "*numerus clausus*" yoktur. Bir diğer ifadeyle, tarafların yapabilecekleri sözleşmeler, kanunen tespit edilmiş tiplere hasredilmiş değildir; taraflar, sözleşme özgürlüğü gereğince, kanuna ve ahlâka aykırı olmamak şartıyla, diledikleri tipte ve içerikte sözleşme yapabilirler.

I) ADİ ŞİRKETLERİN TÜRK BORÇLAR KANUNUNDA DÜZENLENMESİ

Adi şirketlerle ilgili hükümler, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile ilâve edilen dört madde (m.633-636)[61] haricinde, İsviçre Borçlar Kanununun (OR) 530-551'inci maddelerinden iktibas edilmiştir.

Adi şirketler, İsviçre Borçlar Kanununun ikinci kısmında, "*Özel Borç İlişkileri*" içinde, ticaret şirketleri ve kooperatifi düzenleyen üçüncü kısımdan hemen önce, kollektif şirketle ilgili düzenlemeye geçmeden hükme bağlanmıştır. Bu sebeple olsa gerek, İsviçre şirketler hukukunun, Borçlar Kanununun üçüncü kısmında hükme bağlanan kollektif şirketten değil, adi şirket (einfache Gesellschaft) kavramını hükme bağlayan 530'uncu maddeden başladığı ifade edilmiştir[62]. Kanunun sistematiği içinde adi şirketin İsviçre Borçlar Kanununda ele alınmasının sebebi, daha ziyade tarihidir. Roma hukukunda "*societas*"tan kalma

---

61 Bu dört maddenin kaynağı, Alman Medeni Kanununun (BGB) 736-740'ıncı paragraflarıdır.

62 **Handschin / Vonzun,** EinfG Art. 530 N.1.

bir düzenlemeyle, adi şirket "*özel borç ilişkileri*" arasında düzenlenmiştir denilebilir. Adi şirketlerin İsviçre Borçlar Kanunundaki düzenlemesine rağmen, İsviçre hukukunda adi şirketlerin, şirketler hukukunun genel esaslarını oluşturduğu kabul edilmektedir[63].

İsviçre Borçlar Kanununun iktibası esnasında, İsviçre Borçlar Kanununun üçüncü kısmında ele alınan ticaret şirketleri ve kooperatifler, ülkemizde, 865 sayılı 1926 tarihli Ticaret Kanunu içinde hükme bağlanmış; adi şirket ise Borçlar Kanununda "*akdin muhtelif nevileri*" arasında yerini bulmuştur.

Bununla birlikte, adi şirketin Türk Borçlar Kanununda düzenlenmesinin hatalı olduğu ifade edilemez. Kanun koyucu adi şirketin bir sözleşme olduğunu nazara alarak, adi şirketin borçlar hukukunun içinde yer alması gerektiğini arzulamış olabilir. Adi şirketin sözleşme olması, onun *kişi birliği* olduğu gerçeğini de inkâr etmez. Kanun koyucu adi şirketi Borçlar Kanununda düzenlemesine karşın, onun ayrılmaz bir parçası olan (TTK m.1, TBK m.646) Türk Ticaret Kanunu ile arasında bir bağ kurmakla, adi şirketin diğer "*özel borç ilişkileri*"nden farklı, Türk Ticaret Kanununda düzenlenen ticaret şirketlerine yakın bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Bu husus TBK m.620/2'de, "*Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi adi ortaklık sayılır*" denilmek suretiyle doğrulanmıştır.

Kaldı ki, emredici hükümlerin yok denecek kadar az olması, sözleşmeye katılanların iradesinin ön plâna çıkması, adi şirketin "*sözleşme özgürlüğü*" çerçevesinde ele alınması, adi şirketlerin Türk Borçlar Kanununda düzenlenmesinin doğru olduğu sonucunu doğurmaktadır.

II) ADİ ŞİRKETLERİN TİCARET ŞİRKETLERİ BAKIMINDAN ÖNEMİ

Türk/İsviçre hukukunda, şirketler hukukunun ele alınış şeklinde, ticaret şirketlerine ilişkin özel hükümlerine geçmeden evvel, Borçlar Kanununda "*özel borç ilişkileri*" içinde yer alan ve genellikle medeni hukuk-borçlar hukuku şirketi olarak anılan adi şirketin incelemesi yapılmaktadır. Bunun sebebi, adi şirketlerin, ticaret şirketleri bakımından önemidir.

---

[63] **Handschin / Vonzun**, EinfG Art. 530, N.1.

Bu önem, her şeyden evvel Türk Ticaret Kanununun ikinci kitabında yer alan ticaret şirketlerinin birinci kısmında hükme bağlanan genel hükümlerde kendini göstermektedir. Gerçekten de, TTK m.126'ya göre, "*Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medeni Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri hakkında da uygulanır*" denilerek, adi şirketlerin ticaret şirketlerindeki önemi açıkça hükme bağlanmış; adi şirketlere ilişkin hükümlerin ticaret şirketleri hakkında vaz edilmiş özel hükümlere nazaran genel ve tamamlayıcı hükümler olduğu ifade edilmiştir.

TTK'nin 126'ncı maddesinin bu düzenlemesinden başka, TBK m.620/2'de de, "*Bir ortaklık kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici özelliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi adi ortaklık sayılır*" denilmek suretiyle de, adi şirketlerle ilgili düzenlemelerin ticaret şirketleri bakımından önemi bir kez daha açıkça belirtilmiştir.

III) ADİ ŞİRKETİN TANIMI VE UNSURLARI

Adi şirket bir şahıs şirketidir; adi şirket kurulurken katılma payından ziyade, şirket sözleşmesine katılanların şahsiyeti, mesleki ve sosyal durumları önem kazanır. Sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece, katılma payı nazara alınmadan, esas olarak bütün ortaklar eşit hakka sahiptir (TBK m.623/1).

Diğer şahıs şirketlerinde olduğu gibi, adi şirkette de, sözleşmeye katılanların kişiliği ön plânda olduğu için, ortaklık hakkı, diğer ortakların muvafakati olmadan devredilemez; sözleşmede hüküm yoksa ve sağ kalan ortaklar muvafakat etmezse, ortaklık hakkı miras yoluyla intikal etmez; ortaklardan birinin ölümü şirketin sona erme sebebidir (TBK m.639/2).

A) ADİ ŞİRKETİN TANIMI

Adi şirket, Türk Borçlar Kanununda "*adi ortaklık*" olarak nitelendirilmiş; Kanunun ikinci kısmının on sekizinci bölümünde de "*adi ortaklık sözleşmesi*" başlığı altında düzenlenmiştir.

Mehaz İsviçre Borçlar Kanununun Almanca metninde "*einfache Gesellschaft*" terimi tercih edilmiştir. Buradaki "*einfach*" sıfatı, bir şeyin en sade, basit ve yalın halini ifade etmektedir. Belki bu sebepten

olacak ki adi şirket için kimi zaman "*Basit Şirket*"[64], "*Bayağı Şirket*"[65] veya "*Yalın Ortaklık*"[66] terimi kullanılmıştır. Biz açıklamalarımızda, Türk Borçlar Kanununda kullanılan "*adi ortaklık*" terimi yerine, ticaret şirketleriyle bütünlük arz etmesi bakımından, kanundan yaptığımız alıntılar haricinde, esas itibariyle "*adi şirket*" terimini tercih edeceğiz.

Adi şirket, Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinin birinci fıkrasında, "*Adi ortaklık sözleşmesi, iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir*" şeklinde tanımlanmıştır.

"*Adi Ortaklık Sözleşmesi*"nin tanımının yer aldığı TBK m.620/1'in kaynağını oluşturan İsviçre Borçlar Kanununun Almanca metninde "*emek ve mal*" kavramı yerine "*müşterek gayret veya vasıtalarla*" (*mit gemeinsamen Kräften oder Mitteln*) ifadesi tercih edilmiş; Fransızca metninde ise adi şirket (*sociétésimple*), "*Şirket bir akittir ki, onunla iki veya daha ziyade şahıslar, gayret ve vasıtalarını müşterek bir gayeye ulaşmak üzere birleştirmek hususunda anlaşırlar*" tarzında tanımlanmıştır.

İsviçre Borçlar Kanununun her iki metnindeki tanımın, Türk Borçlar Kanunundaki tanımdan başlıca farkı, ortakların şirkete katılma payı olarak "*müşterek gayret veya vasıtaları*"nı; Türk Borçlar Kanununda ise "*emek ve mal*" larını getirmeyi üstlenmeleridir. TBK m.620/1'deki bu tanımda, "*emek ve mal*" kavramının kullanılmasının sebebinin, TBK m.621/1'deki, "*Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılma payı koymakla yükümlüdür*" hükmü olduğu ifade edilmişse de; "*mal*" kavramından, İsviçre Borçlar Kanununda olduğu gibi, "*şirketin gayesinin gerçekleşmesine hizmet eden her şey*"in anlaşılması daha isabetli olur.

Ayrıca, kanun koyucu "*emek ve mal*"dan söz etmiş ve sanki "*emek ve mal*"ın mutlaka beraber getirilmesi gibi bir sonuca yönelmişse de; katılma payı olarak sadece emeğin veya sadece malın getirilebileceği ileriki maddelerde hükme bağlanmıştır. Bu sebeple TBK m.620/1'deki

---

64 **Ansay, T.:** Adi Şirket Bir Tüzel Kişi midir? Prof. Dr. Erdoğan MOROĞLU'na 65. yaşgünü Armağanı, İstanbul 1999, s. 10.

65 **Sungurbay**, İ., Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü, Ankara 1966.

66 Bkz., 13 HD., E. 1981/4014, K. 1981/4757, T. 22.6.1981 (**Özenli**, S., Uygulamada Adi Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara 1988, s.265).

"*ve*" bağlacının "*veya*" yahut "*ve/veya*" şeklinde anlaşılması daha uygun olur.

Bunların dışında İsviçre Borçlar Kanununun Almanca metninin "*adi şirketi*" düzenleyen 530'uncu maddesinin birinci fıkrasında, "*müşterek gayret ve vasıtalarla, müşterek bir gayeye erişmek üzere iki veya daha fazla (zwei oder mehrere Personen) kişinin bir akitle bir araya gelmeleri*"nden söz edilirken; Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinin birinci fıkrasında, ortaklık sözleşmesinin doğumu için "*iki veya daha fazla kişinin emek ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleşmeyi üstlenmelerinden*" bahsedilmektedir. Bu halde TBK m.620/1'e göre, şirketin kurulması için gerekli unsurun, "*emek ve malların birleştirilmesi*"; İsviçre Borçlar Kanununda ise "*sözleşmeye katılanların birleşmesi*" olduğu sonucu çıkmaktadır. Hâlbuki Türk Borçlar Kanunu m. 620-645 hükümlerinin bir bütün halinde incelenmesinden, İsviçre Borçlar Kanununda olduğu gibi, "*sözleşmeye katılanların birleşmesi*"nin arzu edildiği anlaşılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, adi şirketin kurucu unsuru, "*emek ve mal*"ların birleşmesi değil, kişilerin ortak bir amaç üzerine birleşmeleridir.

B) ÖZELLİKLERİ

Türk Borçlar Kanununun 620'nci maddesinin birinci fıkrasında verilen tanımdan hareket ederek, adi şirketin unsurlarını tespit edebiliriz.

1) Kişi Unsuru

Türk Borçlar Kanununun mevcut düzenlemesine nazaran, bir kişi topluluğunun adi şirket olarak kabul edilebilmesi için "*iki ya da daha fazla kişi*"nin bulunması gerekir.

Buna göre bir adi şirketten söz edebilmek için, (tek ortaklı anonim ve limited şirketten farklı olarak) iki ya da daha fazla "*kişi*"nin, şirket sözleşmesine katılması gerekir. Kanun koyucu "*kişi*"den bahsederken, "*adi ortaklık sözleşmesi*"nin en az *iki ya da daha fazla kişi* ile kurulabileceğini hükme bağlamış; üst sınır belirlememiştir. Bu bakımdan adi şirket çok sayıda kişi arasında kurulabilir; ancak çok sayıda ortağın varlığı adi şirketin bünyesine uygun değildir.

Hukukumuzdaki "*kişi*" kavramı, Türk Medeni Kanununun 8-117'nci maddeleri arasında düzenlenmiş; kişiler hukuku düzenlenirken, kaçınılmaz şekilde diğer hukuk dallarına temel olacak prensipler getirilmiştir.

Kişi, hak sahibi varlık anlamına gelir. Türk Medeni Kanununda hak sahibi varlık olarak, "*gerçek kişiler*"(insanlar) ile bir amaç etrafında birleşmiş gerçek kişilerin meydana getirdiği "*kişi birlikleri*" ve bir amaca özgülenmiş *mal toplulukları* (vakıflar), "*tüzel kişi*"ler (hükmi şahıslar) olarak kabul edilmiştir (m.8-117).

Kişinin, hukuk düzeni tarafından korunan, başta hak sahibi olma ehliyeti gibi özellikleri ile kişinin hukuki durumuna ilişkin kişi olmaya bağlı olarak tanınan yetkileri onun kişiliğini ifade eder.

Kişilik gerek gerçek kişiler gerek tüzel kişilere ilişkin ortak bir kavramdır. Ancak kişiliğin kapsamının belirlenmesinde gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasındaki doğal farkları göz önünde tutmak gerekir. Türk Medeni Kanununda gerçek kişileri düzenleyen kısımlardaki hükümler, nitelikleri itibariyle sadece gerçek kişilere özgü olmadıkça, tüzel kişiler hakkında da uygulanır (TMK m.48). Buna karşılık tüzel kişileri düzenleyen hükümlerin gerçek kişiler hakkında uygulanması söz konusu olamaz[67].

Adi şirketin tanımında "*kişi*"den bahsedilmiş; bu kişilerin gerçek veya tüzel kişi olduğu belirtilmemiştir. Bu düzenlemeye nazaran, gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de adi şirkete ortak olabilirler. Tüzel kişiliği olmayan kişi birliklerinin ve bu bağlamda tüzel kişiliği olmadığı için adi şirketin, adi şirkete ortak olması mümkün değildir[68].

---

67 Bu hususlarda bkz. **Oğuzman, K. / Seliçi, Ö. / Oktay-Özdemir, S.**, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 12. Baskı, İstanbul 2012, s.2-3.

68 **Handschin / Vonzun**, EinfG Art.530, N. 233; **Yongalık**, s. 6, dn. 19; aksi görüş için bkz., **Şener**, O. H., Adi Ortaklık, Ankara 2008, s. 5. *Şener* görüşünü Yargıtay 13. HD.nin 26.5.1986 (E. 1986/1596, K. 1986/3120) tarihli kararına dayandırıyorsa da, kararın tetkikinden bu sonuca ulaşılamayacağı kanaatindeyiz. Yargıtay kararında, "*Böylece davalı şirketin tüzel kişilik kazandıktan sonra ortaklık sözleşmesini yaptığı anlaşılmaktadır.*" denildikten sonra "*Kaldı ki, ortaklık sözleşmesinin davalı şirketin kuruluş safhasında yapıldığı kabul edilse bile, şirketin kuruluşu tamamlandığına ve davalı şirket kendi adına yapılan muameleyi benimsediğine göre, bu yön ortaklık sözleşmesinin geçerliliğini etkiler nitelikte değildir*" denilmektedir.

Karardan da anlaşılacağı gibi, Yargıtay'ın ilgili dairesi, anonim şirketlerin tüzel kişilik kazanmadan önceki muamelelerden ve bunun benimsenmesinden bahsetmektedir. Bilindiği gibi, 6762 sayılı TTK'nın 301'inci maddesinin ikinci fıkrasında, "*Tescilden önce şirket namına muamele yapanlar, bu muamelelerden şahsen ve müteselsilen mesuldürler. Ancak, bu gibi taahhütlerin, ileride kurulacak şirket namına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline kaydın-*

2) Şirket Sözleşmesi

Şirket münasebeti, her şeyden önce "*şirket sözleşmesi*"nin mevcudiyetine bağlıdır. "*Şirket sözleşmesi*", Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerine göre, sözleşmeye taraf olanların adi şirket kurmaya yönelik *sarih* veya *zımni* bir şekilde beyan ettikleri, birbirine uygun rızalarının birleşmesi suretiyle kurulur.

Ancak, şirket sözleşmesinin, çok taraflı sözleşmelerden olduğu ve birleşme sözleşmesi niteliğinde bulunduğu unutulmamalı; mübadele sözleşmelerinden farklı olduğu ve şirketin bir kişi birliği olduğu hususları ihmal edilmemelidir[69].

Buna göre, bir hukuki ilişkinin "*adi ortaklık*" olarak nitelendirilebilmesi için, taraflar, ortaklık kurma niyetiyle (*animus contrahende societatis*) iradelerini birbirlerine açık (sarih) veya örtülü (zımni) bir şekilde beyan etmelidirler. Şirket sözleşmesinin kurucu unsuru olan bu karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamaları ile adi şirket kurulmuş olur.

Sözleşmeye katılanların üzerinde anlaştıkları "*şirket kurma niyeti*", adi şirketi, TMK'nın 688-703. maddeleri arasında düzenlenen "*birlikte mülkiyet*"ten, "*miras ortaklığı*"ndan (TMK m.640), "*karışma ve birleşme*" ile oluşan birlikte hak sahipliği ilişkisinden (TMK m.776) ve iflâsta alacaklılar toplantısından (İİK m. 221), bir diğer ifadeyle, kanundan doğan hak sahipliği ilişkilerinden (*schlichte Interessengemeinschaft*) ayırır[70].

Şirket kurma niyeti (*animus contrahendae societatis*) olmadan, taraflar arasında herhangi bir sözleşme bağı bulunmadan; bir diğer söyleyişle, şirket kurulmasına yönelik yazılı veya sözlü, açık ya da örtülü irade beyanları söz konusu değilken, birden fazla kişinin birlikte

---

dan sonra üç aylık müddet içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket mesul olur" denilmektedir. Yargıtay 13. HD.'nin kararı da bu şekildedir.

Şener'in atıf yaptığı Doğanay'ın (**Doğanay**, Y.Ü., Adi Şirket Akdi (Akdin Unsurları-Kurulması-Hükümsüzlüğü), İstanbul 1968) görüşlerine katılmamız da Kanundaki "*kişi*" kavramı sebebiyle, Türk hukukuna göre mümkün değildir.

Arslanlı'da, Siegwart'a atıf yaparak, miras şirketinin adi şirkete ortak olabileceği görüşündedir, (**Arslanlı**, H.; Anonim Şirketler, C. II-III, Anonim Şirketin Organizasyonu ve Tahviller, İstanbul 1960, s. 46).

69 Bkz., Birinci Bölüm, § 1, I, B, 2 başlığı

70 **Meier-Hayoz / Forstmoser,** §1 N. 19 vd.

hareket etmesi, meselâ on kişinin bir yurt dışı seyahati için grup oluşturması halinde (*faktisches Vertragsverhältnis*) (fiili sözleşme ilişkisi) adi şirketten söz edilemez. Keza Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gibi kanuni görevleri ifa etmek maksadıyla kurulan birlikler de, şirket kurma niyeti bulunmadığı için, adi şirket olarak nitelendirilemez[71].

Buna göre, fiili sözleşme ilişkisi kavramının şirketler hukukundaki uzantısı olan "*fiili şirket* (*faktische Gesellschaft*)", kişilerin şirket kurma niyeti olmadığı için, adi şirket ilişkisinin kurulmasına imkân sağlamaz. Buna karşılık, "*eksik şirket* (*die fehlerhafte Gesellschaft*)" olarak nitelendirilen kişi birliğinin durumu farklıdır (TBK m.620/2).

TBK m.620/1'de, "*adi ortaklık sözleşmesi*"nin iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi üstlenmeleriyle kurulacağı belirtildikten sonra; m.620/2'de, "*Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tâbi adi ortaklık sayılır*" denilmiştir.

Buna göre, bir adi şirket, esas itibariyle, geçerli bir şirket sözleşmesine dayalı olarak kurulur. Bununla beraber, kanunla düzenlenmiş bir şirket kurmak niyetiyle hareket eden ortaklar, kurmak istediği ortaklığın ayırt edici niteliklerini sağlayamamışsa; meselâ, bir kollektif şirket kurmak için anlaşan ortaklar, şirkete tüzel kişilik kazandıramamışsa, bu şirkete de adi şirket hükümleri uygulanacaktır (TBK m.620/2; TTK m. 214).

Kanunla düzenlenmiş şirketlerin ayırt edici nitelikleri sağlayamaması, şeklî eksikliklerden, fiil ehliyetinden veya kanuna aykırılık gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Bu halde kanun koyucu taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi "*yok*" saymamakta; bu hukukî ilişkiyi adi şirket olarak kabul etmekte ve kuruluşunda eksiklik olan bu şirketleri de (*eksik şirket*) (*die fehlerhafte Gesellschaft*) adi şirket saymaktadır (TBK m.620/2).

Kanun koyucunun bu yaklaşımı doğrudur. Zira bu halde (TBK m.620/2) bir şirket kurma niyeti vardır; sadece kurmak istedikleri şirketi kuramamışlar, şirkete ayırt edici nitelikleri kazandıramamışlardır[72].

---

71 **Barlas**, s. 56-57; **Poroy (Tekinalp / Çamoğlu)**, I, N. 46.

72 **Barlas**, s. 57-58.

a) Adi Şirket Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

TBK m.620/1'de verilen tanıma göre, "*adi ortaklık sözleşmesi*", iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan bir sözleşmedir. Bu itibarla, diğer sözleşmelerde olduğu gibi, şirket sözleşmesi de tarafların hukuken geçerli irade beyanları ile kurulur. Bu bakımdan Borçlar Kanununun "*sözleşmenin kurulması*" ile ilgili hükümleri, burada da geçerlidir. Ancak, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden farklı olarak şirkette, şirket kurma niyeti hakkındaki irade beyanlarının bütün ortaklara yöneltilmesi gerekir. Şirket sözleşmesi, sözleşmeye iştirak edenlerden sonuncusunun irade beyanı diğerlerine ulaştığında tamamlanmış olur.

Adi şirket sözleşmesi, bir hukuki işlemdir. Bu hukuki işlemin sözleşme olduğu göz ardı edilmeden, müşterek hukuki işlemlerden sayılan bir *birleşme sözleşmesi* mahiyetini taşıdığının; bu birleşme sözleşmesinin sadece sözleşmeye taraf olanlara uygulanmadığının, şirket sözleşmesine sonradan dâhil olacaklara da uygulanacağının, bu haliyle bir statü yarattığının, statüye dâhil olanların rızasıyla (sözleşmede hüküm varsa) oy birliği olmadan değiştirilebileceğinin kabulü gerekir[73].

Bu haliyle, kendine has bir sözleşme sayılan adi şirket sözleşmesi, ortakların amacı aynı olduğundan, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden ayrılır. Bununla birlikte, karşılıklı edimleri içeren sözleşmelere ilişkin bazı hükümler, adi şirketin mahiyetine aykırı düşmedikçe, adi şirkete de kıyasen uygulanabilir.

Bu bağlamda, adi şirkette bir ortağın borcu, diğer ortağın borcunun (onun ediminin) karşılığı olarak anlaşılmamalı; şirketin faaliyeti neticesinde elde edilen kârın paylaşılması da "*ivaz*" olarak nitelendirilmemelidir. Adi şirketin kurulabilmesi için, iki veya daha fazla kişinin ortak bir amaca ulaşmak amacıyla emeklerini ve mallarını birleştirme hususunda bir sözleşme yapmaları lâzım ve kâfidir.

Katılma payı getirme borcu, ortaklığa (kişi birliğine) karşı bir borçtur; katılma payının ifası da adi şirketi oluşturan kişiler tarafından talep ve dava edilebilir[74].

---

[73] Bkz. Birinci Bölüm § 2, I, A, 2, a, cc başlığı

[74] **Barlas**, s. 62-63.

b) Sözleşmenin Tarafları ve Katılma Ehliyeti

aa) Sözleşmenin Tarafları

TBK m.620/1'in açık ifadesi karşısında, sözleşmeye katılanların, Türk Medeni Kanununda (m.8-107) belirtilen "*kişi*" olması gerekir; kişi sıfatını haiz olmayan kişi birlikleri ve bu bağlamda meselâ adi şirket veya miras şirketleri, bu sıfatlarıyla adi şirkete ortak olamazlar. Kişinin gerçek veya tüzel kişi olması; hatta bütün ortakların "*gerçek kişi*" veya "*tüzel kişi*" olması mümkündür.

Kanun koyucu, "*iki veya daha fazla kişi*" diyerek, tek kişi ile adi şirketin kurulamayacağını hükme bağlamış; ortak sayısının üst sınırı için bir düzenleme getirmemiştir. Adi şirket hukuken çok ortaklı olarak kurulabilir; ancak çok ortaklı bir yapı, adi şirketin bünyesine uygun değildir.

bb) Tarafların Sözleşmeye Katılma Ehliyeti

Hukuki işlem olan adi şirket sözleşmesinin geçerli olabilmesi için, tarafların o sözleşmeyi yapmaya ehil olmaları gerekir. Kişilerin hukuki işlem ehliyeti, "*Kişiler Hukuku*"nda incelenmekte; adi şirkete ortak sıfatıyla katılabilme konusunda fiil ehliyeti bakımından genel hükümlere tâbi tutulmaktadır (TMK m.8-107).

Hukuki işlem ehliyetinin *gerçek kişiler* yönünden temel şartı, irade beyanında bulunanın "*ayırt etme gücüne*" (temyiz kudretine) sahip olması; makul surette hareket edebilme iktidarıdır (TMK m.13). Bir kişide, yapılacak sözleşme için irade beyanında bulunabilme konusunda ayırt etme gücü yoksa o kişi, bahsi geçen sözleşmeyi yapma ehliyetinden kesin olarak yoksundur; "*Kanunda gösterilen ayrık durumlar saklı kalmak üzere, ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki sonuç doğurmaz*" (TMK m.15).

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır (TMK m.10). Fiil ehliyetine sahip olan kimse kendi fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir (TMK m.9); adi şirket sözleşmesine taraf olabilir.

Ayırt etme gücüne sahip olan kişinin, *ergin olmaması* (TMK m.12) veya *kısıtlı bulunması* halinde, adi şirket sözleşmesinin hüküm ifade etmesi, kanuni temsilcisinin (veli ya da vasi) bu sözleşmeye önceden izin vermesine veya yapılan sözleşmeyi sonradan onamasına (icazet vermesine) bağlıdır (TMK m.16/1; 463/1, b. 3). Ancak, adi şirket ortaklarının

kişisel sorumluluğu nazara alındığında, kanuni temsilcinin rızası yeterli olmaz; vesayet makamının (sulh hukuk mahkemesi) izni ve bu izinden sonra denetim makamının da (asliye hukuk mahkemesi) izin vermesi gerekir(TMK m.463/3).

Tüzel kişilerin ehliyeti ise, tüzel kişilere özgü kurallara göre belirlenir. TMK m.48'e göre, *"Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler"*.

Türk Medeni Kanununun bu düzenlemesine nazaran, tüzel kişinin ehliyeti bazı özellikler arz eder. Buna göre, tüzel kişilerin sınırlı fiil ehliyeti söz konusu olmaz; eğer organları varsa tam ehliyetli, organları yoksa tam ehliyetsiz sayılır.

Tüzel kişilerin yasal temsilcileri (veli-vasi) yoktur; organları vardır [*Yönetim kayyımı,* bir tüzel kişi gerekli organlarından yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan sağlanmamışsa (TMK m.427/1, b.4) vesayet makamınca atanır (TMK m.427/1)]. Tüzel kişiler, organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar (TMK m.49).

Bu düzenlemeler karşısında tüzel kişilerin ehliyeti iki açıdan sınırlandırılmış sayılır. Bunlardan birincisi *"ehliyetin nitelik gereği sınırlandırılması"*dır; tüzel kişiler, nitelikleri gereği gerçek kişilere özgü haklardan yararlanamazlar. TMK m.48'e göre tüzel kişiler, insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehil olduklarından; borçlar ve yükümlülükler açısından da gerçek kişilerden farklı değildir, sözleşmelerinden ve haksız fiillerinden gerçek kişi gibi sorumludur.

İkinci sınırlama, *"ehliyetin amaçla sınırlandırılması"*dır. Tüzel kişinin ehliyeti, kural olarak izlediği amaçla sınırlıdır. Ticaret şirketleri hakkında ileride yapacağımız açıklamlar saklı kalmak kaydıyla tüzel kişinin amaç dışı işlemi, onun ehliyet dışı (ultra vires) işlemi sayılıp, tüzel kişiyi bağlamayacaktır.

Ticaret şirketlerinde geçerli olan ve fiil ehliyetini sınırlandıran *"ultra vires"* ilkesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa alınmadığı ifade edilmiştir. Buna göre ticaret şirketlerinde, tüzel kişiyi temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemler de şirketi bağlar; meğerki üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya hâlin icabından bilebilecek durumda olduğu ispat edilsin (TTK m. 371/2).

Dernekler tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları dışında faaliyette bulunamaz (DernK. m.30/a). Bu hükme göre, derneklerin fiil ehliyeti "*amaç*"ları ile sınırlandırılmıştır.

Bu açıklamalarımız ışığında, tüzel kişilerin adi şirket sözleşmesine katılma ehliyetinin tüzel kişiler için tam; dernekler bakımından ise "*amaç*" ve "*bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları*"ile sınırlı olduğu ifade edilebilir. Türk Medeni Kanununda özel bir düzenleme olmamasına karşın, vakıflarda da ehliyetin "*amaç*" ve "*bu amacı gerçekleştirmek üzere sürdürebileceği belirtilen çalışma konuları ile sınırlıdır*" denilebilir.

Dernekler ve vakıflar, amaçlarına ulaşmak maksadıyla ticarî işletme işletebilmektedirler (TTK m.16). Bu bağlamda, amaçlarına ulaşmak maksadıyla ticari işletme işletebilen dernek ve vakıfların; amaçlarına ulaşmak maksadıyla bir adi şirkete ortak olabilmeleri de mümkündür.

Kamu tüzel kişileri de ister kamu idaresi (kişi topluluğu) ister kamu kurumu (mal topluluğu) olsun, esas itibariyle kamu hukukuna tâbi olan tüzel kişilerdir; bir kamu tüzel kişisinin bazı yönleriyle kamu hukukuna değil, özel hukuk hükümlerine tâbi tutulması da mümkündür.

Kamu tüzel kişileri, tüzel kişi olmaları sebebiyle, özel hukukta "*tüzel kişilik*" sıfatından kaynaklanan bütün hak ve yetkilere sahiptir. Ancak bunların fiil ehliyetinin adi şirket sözleşmesine taraf olma ehliyetini de kapsayıp kapsamadığı, kendilerini kuran kanunun; kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulanlarda ise idarenin tasarrufunun incelenmesini gerektirir.

c) Sözleşmenin Şekli

Türk Borçlar Kanunu sistemi içinde, bir sözleşmeyi oluşturan irade beyanları için, kural olarak belirli bir şekle uyma zorunluluğu yoktur; şekil serbestliği ilkesi geçerlidir. TBK m.12/1'de açıkça ifade edildiği gibi, "*Sözleşmelerin geçerliliği, aksi kanunda öngörülmedikçe, hiçbir şekle bağlı değildir*".

Bu hükümden de anlaşıldığı gibi, şekil serbestliği ilkesinin istisnaları bulunmaktadır. Kanunda bazı sözleşmeler belirli bir şekle tâbi tutulmuş olabilir. "*Kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil, kural olarak geçerlilik şeklidir. Öngörülen şekle uyulmaksızın kurulan sözleşmeler hüküm doğurmaz*" (TBK m.12/2). Kanun koyucu, "*kural olarak geçerlilik şeklidir*" diye hükme bağladığı için, kanunda öngörülen bu

şekil şartı, kimi sözleşmeler için "*ispat şartı*" kimi sözleşmeler için ise "*geçerlilik şartı*" olarak karşımıza çıkmaktadır. Şeklin "*ispat şartı*" olduğu hallerde, şekle uyulmamış olsa da sözleşme geçerlidir; fakat bu sözleşmenin varlığı her türlü delille özellikle tanıkla ispat edilemez. Buna karşılık şeklin "*geçerlilik şartı*" olduğu hallerde, bu şekle uyulmadıkça sözleşme geçerli olmaz.

Türk Borçlar Kanununun adi şirketi düzenleyen 620-645'inci maddelerinin tetkikinden anlaşılacağı üzere, *adi şirketin kurulması için özel bir şekil şartı öngörülmemiş*; adi şirket bir sözleşme olduğu için, genel esaslara, yani şekil serbestliğine tâbi tutulmuştur. Buna göre adi şirket sözleşmesinin yazılı veya sözlü ve hatta örtülü (zımni) irade açıklamalarıyla, meselâ iki arkadaşın birlikte *loto* oynayıp kazanca iştirak etmek niyetiyle hareket etmesi halinde olduğu gibi, açıkça adi şirket kurmaya yönelik irade açıklaması olmadan dahi adi şirketin kurulabileceğinin kabul edilmesi gerekir[75].

Bununla birlikte, kanunen öngörülmemiş bir *şekil, taraflarca kararlaştırılmış* olabilir (*iradi şekil*). TBK m.17/1'e göre, "*Kanunda şekle bağlanmamış bir sözleşmenin taraflarca belirli bir şekilde yapılması kararlaştırılmışsa, belirlenen şekilde yapılmayan sözleşme tarafları bağlamaz*". Bu halde kararlaştırılan şekil "*geçerlilik şartı*" olarak kabul edilmektedir.

Adi şirket sözleşmesinin yapılmasında "*şekil serbestliği ilkesi*" geçerli olmakla birlikte, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 200'üncü maddesindeki kabule göre, "*...hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar veya değerleri üç bin altı yüz altmış Türk lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir*". Buna göre adi şirket sözleşmesinin yazılı yapılması gerekli değilse de; "*ispat hukuku*" bakımından yazılı yapılması faydalıdır.

Adi şirketlerde katılma payı olarak, devir edilmeleri kanunen şekil şartına bağlanmış mal varlığı unsurlarının bulunması halinde, "*şekil serbestliği ilkesi*" yine geçerli olmakla birlikte; *taahhüdün geçerliliği şekle bağlıdır*. Bir diğer söyleyişle, taahhüdü şekle bağlı bir ifa vaadini ihtiva eden adi şirket sözleşmesi şekil serbestîsine tâbi olmakla birlikte; *taahhüdün geçerli olması için,* taahhüt işleminin işbu şekle uygun olarak yapılması gerekir. Buna göre, bir taşınmaz mülkiyetinin adi şirkete sermaye olarak konulması taahhüdü gerekli resmi şekilde yapılmalıdır.

---

[75] **Meier-Hayoz / Forstmoser,** §12, N.77.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki, bu taahhüdün geçersizliği, adi şirket sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmaz.

Adi şirket sözleşmesi, *rızaî sözleşmelerdendir*; şirket sözleşmesine katılanların, şirket kurma niyetiyle katılma paylarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlenmeleri ile adi şirket kurulmuş olur. *Şekle bağlı bir taahhüdü ihtiva eden adi şirket sözleşmesindeki şekil zorunluluğu, taahhütle ilgilidir; taahhüde ilişkin şekil zorunluluğuna uygun hareket etmemek, şirket sözleşmesinin geçersizliği sonucunu doğurmaz.* Bu halde adi şirket sözleşmesi geçerli, taahhüt geçersiz olacaktır; taahhüt, adi şirket kurulduktan sonra kanuna uygun hale getirilebilir[76].

3) Ortak Amaç

Adi şirket sözleşmesini, diğer borç ilişkilerinden ayıran en önemli unsur; *"iki veya daha fazla kişinin ortak amaca ulaşmak için birleşmeleri"* ve *"ortak amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmeyi kabul etme"* hususunda sözleşmeleridir. Ortak amaç ve ortak amaca ulaşmak için çaba göstermek, şirket sözleşmesinin ayırıcı özelliğidir.

a) Genel Olarak

Ortak amaç, ortakların şirket sözleşmesiyle kabul ettikleri, şirket olarak ulaşmak istedikleri maksattır. Ortaklar bu amaca ulaşmak için ortaklaşa bir gayret göstermek, bu gayretin sonucunda kazanç elde edilirse bu kazancı paylaşmak; başarısızlık söz konusu olduğunda, sonuçlarına birlikte katlanmak hususunda anlaşmışlardır.

Adi şirkette amaç (maksat) müşterektir; bütün katılanlar "*ortak amaç*" konusunda birleşmiş; ortak amacın elde edilmesi için katkıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir. Adi şirketin "ortak (müşterek)" olan bu amacıyla, şirkete ortak olanların şirkete ortak olma amacını (*ortakların saiki*) karıştırmamak gerekir. Şüphesiz her ortağın şirkete ortak olarak girmek istemesinde bir "*saik*" (sebep, güdü) vardır; bu "*saik*" ortaklığın amacı değildir. Ortak amaç, şirket sözleşmesinde kabul edilen, diğer ortaklarla paylaşılan, elde edilmesi için gayret sarf edilen, sonuçlarının ortaklaşa paylaşıldığı bir amaçtır.

---

[76] **Handschin / Vonzun**, §530, N.162-165.

b) Ortak Amacın Niteliği

Ortak amaç geçici (kısa süreli) olabileceği gibi, sürekli de olabilir. Adi şirketin geçici ilişkiler için uygun olduğu tartışmasız olsa da, sadece geçici (kısa süreli) ve küçük sermaye gerektiren işler için geçerli olduğunu söylemek mümkün değildir; sürekli ve büyük sermayelerin birleşmesiyle de adi şirket kurulabilir. Önemli olan "*ortak amaç*"ın kanunun emredici hükümlerine, ahlâk ve adaba aykırı olmaması; konusunun da imkânsız bulunmamasıdır.

TBK m.620/1'de amacın niteliği konusunda herhangi bir sınırlama getirilmemiş; m.620/2'de ise, ticaret şirketlerinin amacının, adi şirkete uygun olduğu kabul edilmiştir.

aa) Amacın İktisadi Olması

TBK m.620/1'de, "*ortak amaç*"tan açıkça söz edilmesine karşın, ortak amaç tanımlanmamış ve kapsamı belirlenmemiş; adi şirketin hangi ortak amacı gerçekleştirmek için kurulabileceği hükme bağlanmamıştır. Buna göre, konusu imkânsız veya kanuna ve ahlaka aykırı olmayan her türlü amaç için (TBK m.27/1) adi şirket kurulabilir.

Bu halde *ideal* amaçla adi şirket kurulabilir mi? sorusu gündeme gelir. Mehaz İsviçre Hukuku'nda "*ideal amaç*"la adi şirket kurulabileceği, meselâ genç bir sanatçıyı yetiştirebilmek için ortak giderlerini karşılamak üzere sanatseverlerin adi şirket kurabilecekleri kabul edilmektedir[77].

Kanaatimizce, şirket kavramının niteliği ve TBK m.622-623'de öngörülen "*Kâr paylaşımı*"na ilişkin kurallar birlikte nazara alındığında, adi şirket "*ideal*" amaçla kurulamaz. "*İdeal*" amaçla kurulabilecek "*kişi birlikleri*" dernekler olmalıdır.

Amacın iktisadi olması, gelir sağlamaya yönelik bir faaliyette bulunulmasıdır; gelir sağlanması önemli değildir, bu amaca yönelmek yeterlidir. Türk Borçlar Kanununda bu husus, "*kazanç ve zarara katılma*" olarak ifade edilmiş; adi şirketin "*kazanç ve zarara katılma*" amacıyla kurulabileceği imâ edilmiştir. Ancak "*kazanç ve zarara katılma*" kavramı dar yorumlanmamalı; bu kavram, *dolayısıyla* elde edilen kazancı da ihtiva edecek şekilde anlaşılmalı; bu bağlamda kendi elektrik enerjilerini üretmek maksadıyla iki veya daha fazla kişinin bir

---

77 **Meier-Hayoz /Forstmoser**, §4, N.20; aynı yönde bkz, **Yongalık**, s.11.

araya gelerek elektrik üretmek ve bu elektriği daha ucuza elde etmek ve kullanmak maksadıyla da adi şirket kurulabileceği kabul edilmelidir.

bb) Adi Şirketin Ticari İşletme İşletmek Amacıyla Kurulup Kurulamayacağı

Adi şirket imkânsız veya kanuna ve ahlaka aykırı olmayan (TBK m.27/1) her türlü "iktisadi" amaç için kurulabilirse de, hukuk düzeni tarafından kendisine kişilik verilmediği, şirket olarak haklara ve borçlara ehil olmadığı için, "*adi şirket sıfatıyla*" bir ticaret siciline tescil edilemez[78]; ticari işletmeyi de adi şirket adına tescil ettiremez. Adi şirket bir ticari işletme işletiyorsa, bu işletmenin bütün ortaklar adına tescil ettirilmesi gerekir. Bu halde, "*bir ticari işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten*" ortaklardan her biri "*tacir*" sıfatını iktisap eder (TTK m.12/1).

Hâl böyle olmasına rağmen, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, "*Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Siciline Tescili Hakkında Tebliğ*"de (2009/2 sayılı tebliğ) farklı bir düzenlemeye yer verilmiştir. 2009/2 sayılı tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında, "*tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmeler talep edilmesi halinde ticaret siciline tescil edilir*" denilmektedir.

Tebliğin bu üçüncü maddesinde bahsedilen, tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek için kurdukları tüzel kişiliği olmayan ortaklıkların adi şirket olduğu açıktır. Tebliğde sözü edilen ticaret şirketleri tarafından kurulan adi şirketlerin "*ticari işletme*" işletebileceği ve talep etmeleri halinde de, şartlarını yerine getirmek kaydıyla, ticaret siciline "*adi şirket*" olarak tescil ettirilebileceği kabul edilmiştir.

Ancak, Tebliğin düzenlemesinden de anlaşılacağı gibi, adi şirketin (adi şirket niteliğindeki ortaklık yapılarının) ticari işletme işletmesi ve ticaret siciline tescili sadece bu özel düzenleme ile sınırlıdır; bütün adi şirketlere teşmil edilemez[79].

---

[78] Yargıtay TD'nin, 17.10.1967 T., E. 65/3828, K. 67/3619 sayılı kararı için bkz., Batider 1968, C.IV, S.4, s.720-722.

[79] Mehaz İsviçre hukukunda, adi şirketin ticari işletme işletmesi konusunda tartışma vardır. **Meier-Hayoz/Forstmoser** gibi bazı müellifler (§12, N.24-30) adi şirketin

Bir ticari işletme işletmek maksadıyla kurulmak istenmesine karşın, kanunla düzenlenmiş ayırt edici niteliklerini taşımadığı için adi şirket sayılan (TBK m.620/2) şirketlerde de aynı sonuca varmak; bu halde işletmeyi şirket sıfatıyla değil, şirketin ortaklarının birlikte işlettiğine hükmetmek ve ticari işletmeyi işleten bu ortakları ticaret siciline tescil ettirmek gerekir.

4) Ortak Amaç Uğruna Birlikte Çaba (Affectio Societatis)

Adi şirketten söz edebilmek için, ortakların müşterek amaç etrafında birleşmeleri yeterli değildir; diğer ortaklarla işbirliği yaparak amaca ulaşmak için, onlarla birlikte çaba sarf etmeyi de üstlenmiş olmaları gerekir. Ortak amaç, ortakların getirmeyi yükümlendiği katılma payı ile desteklenmeli; ortak amacın elde edilmesi için bir gayret gösterilmelidir.

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi, Roma hukukunda "*affectio societatis*" olarak anılan bu kavram, sadece şirket kurma niyetini (*animus contrahendae societatis*) değil, şirketin devamı boyunca ortak olma, ortaklık amacını elde etmek için bir gayreti göstermeyi de ifade etmektedir. Bu niyet ortadan kalkarsa artık adi şirketten bahsetmek mümkün değildir[80].

Roma hukukundan Fransız hukukuna oradan da Kıta Avrupa'sı hukuk sistemine geçen "*birlikte çaba sarf etmek*" hususunda yükümlülük altına girmek, Türk hukukunda da adi şirket sözleşmesinin varlığı için zorunludur; bu unsur adi şirketi, diğer benzer sözleşmelerden ayırır.

Ortaklığın kararlarının, bütün ortakların oybirliğiyle alınacak olması, sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse, çoğunluğun ortak sayısına göre belirlenmesi (TBK m.624); ortakların, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamaması (TBK m.626), özen borcu (TBK m.628) gibi hükümler ortak amaç uğruna birlikte çabaya örnek gösterilebilir.

---

ticari işletme işletemeyeceğini; **Becker** (BernerKommntar Art. 530, N.1) gibi müellifler ise işletebileceğini ifade etmektedir.

[80] **Tahiroğlu, B.:** Roma Hukuku, 2009, s. 236.

5) Katılma Payı Koyma Yükümlülüğü

"*Adi ortaklık sözleşmesi*", iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir (TBK m.620/1). Her ortak para, alacak ya da başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir "*katılma payı*" koymakla yükümlüdür (TBK m.621/1). Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, "*ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte*" ve "*birbirlerine eşit olmak*" zorundadır (TBK m.621/2).

Bütün bu hükümlerden de anlaşıldığı üzere, bir kişi birliğine "*adi şirket*" niteliği verilebilmesi için, "*kişi unsuru*", "*sözleşme unsuru*", "*ortak amaç*" ve ortak amaca ulaşmak için "*birlikte çaba (affectio societatis)*" unsurlarının birarada bulunması gerekmektedir. Bir adi şirket sözleşmesi ile biraraya gelen ortakların, bu sözleşmeye göre bir katılma payı koyma yükümlülüğü de vardır. Katılma payının fiilen getirilmesi adi şirketin kuruluşu bakımından "*kurucu unsur*" değildir; adi şirket sözleşmesiyle ortakların üstlendikleri bir yükümlülüktür. Buna göre, henüz katılma payı ifa edilmeden, iki veya daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme ile adi şirket vücut bulur.

a) Katılma Payının Mahiyeti

Kanun koyucu katılma payını tarif etmemiş; TBK m.620/1'de "*mal ve emek*"ten bahsedilmiş; TBK m.621/1'de de, her ortağın, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir "*katılma payı*" getirmekle yükümlü olacağı hükme bağlanmıştır.

Katılma (katılım) payı, şirket sözleşmesinde öngörülen ve sözleşmeye katılanlar tarafından kabul edilen "*ortak amaca erişmek üzere, ortaklarca şirkete tahsis edilen değerlerdir*".

818 sayılı evvelki Borçlar Kanununda katılma payı, "*sermaye*" olarak nitelendirilmişti (Bkz. m. 521/1). Hâlbuki sermaye, şirketlerin amacını gerçekleştirmeye yarayacak malvarlığı değerlerinin toplamını (*Kapital*); katılma payı (*Beitrag*) ise her ortağın şirkete getirdiği değeri ifade eder; bu anlamda, malvarlığından da farklıdırlar. *Malvarlığı*, herhangi bir anda, şirketin parayla ölçülebilen hak ve borçlarının bütünüdür; şirketin faaliyeti sonucu oluştuğu için değişkendir. *Sermaye* ise, katılma paylarının bir araya gelmesiyle oluşan bir bütündür. *Katılma payı*, ortakların, ortak amaca ulaşmak için şirkete getirmeyi

yükümlendiği bir değerdir; sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmalıdır. Katılma payı, ortağın, şirkete karşı, sözleşmeden doğan bir borcudur.

Hangi değerlerin şirkete katılma payı olarak getirilebileceği, TBK m.621/1'de, para, alacak veya başka bir mal veya emek olarak belirtilmiş; ancak tahdit edilmemiş, "*ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte*" olması arzu edilmiştir.

Buna göre adi şirkete sermaye olarak para getirilebileceği gibi, bir kambiyo senedi de verilebilir. Ancak bu halde, kambiyo senedinin (poliçe, bono, çek) ifa yerine mi yoksa ifa uğruna mı verildiğinin belirlenmesi gerekir; aksinin taraflarca açıkça belirlenmemiş olduğu hallerde kambiyo senedinin *ifa uğruna* verilmiş sayılacağı kabul edildiğinden (TBK m.133/2) kambiyo senedinden doğan meblağ tahsil edilmedikçe, katılma payı borcu ifa edilmiş olmaz.

Adi şirkete katılma payı olarak bir malın mülkiyeti veya kullanma hakkı da getirilebilir.

Katılma payı olarak bir taşınmazın getirilmesi halinde, bu hukuki ilişkideki taahhüt ve tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı ele alınması gerekir. TMK'nun 706'ncı maddesinin birinci fıkrasına göre, "*Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmi şekilde düzenlenmiş olmalarına bağlıdır*". Buna göre, adi şirkete katılma payı olarak taşınmazın taahhüt edildiği hallerde, katılma payı borcunun ifa edilmiş sayılması için, devir sözleşmesinin *resmî şekilde* yapılması gerekir.

Taşınır bir malın katılma payı olarak getirilmesinde ise, taahhüt işlemi herhangi bir şekle bağlı değildir. Bununla birlikte katılma payı borcunun yerine getirilmiş sayılması tasarruf işlemine bağlıdır; taşınır malın mülkiyetinin nakli, zilyetliğin devri gerekir.

Adi şirkete katılma payı olarak mülkiyet hakkı getirilebileceği gibi, malın kullanma hakkı da katılma payı olarak getirilebilir. Kullanma hakkının katılma payı olarak getirilmesinde esas olan, bu kullanma hakkının şirketin gayesinin icap ettirdiği nitelikte olmasıdır (TBK m.621/2).

Adi şirkete katılma payı olarak kullanma hakkının getirilmesi bir özellik arz etmez; katılma payı olarak kullanma hakkının getirilmesi

halinde, diğer ortaklarla *kira sözleşmesine* benzer bir hukuki ilişki kurulmuş olur, şekle tâbi değildir (TBK m.299 vd.). Ancak bu halde "*ayıp*", "*hasar*" gibi konularda, farklılıklar ortaya çıkar. Mülkiyet hakkının katılma payı olarak getirilmesinde "*ayıp*", "*hasar*" gibi konularda satışa ilişkin hükümlerin uygulanması gerekirken; kullanma hakkında kiraya ilişkin hükümler tatbik edilecektir.

Şirket sözleşmesinden bir malın mülkiyet hakkının mı, kullanma hakkının mı katılma payı olarak taahhüt edildiği anlaşılamıyorsa; mülkiyet hakkının katılma payı olarak getirildiği kabul edilir[81].

TBK m.621/2'de *alacakların* da katılma payı olarak adi şirkete getirilebileceği öngörülmüştür. Alacakların katılma payı olarak getirilmesi, "*alacağın devri*" (TBK m.183 vd.) hükümlerine göre olur; yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır (TBK m. 184). Alacağın katılma payı olarak konulmasında, katılma payı borcunun yerine getirilmiş sayılması, alacağın tahsil edilmesine bağlıdır; alacak tahsil edilmedikçe katılma payı borcu ifa edilmiş sayılmaz.

Kanun koyucu, para ve alacaktan ayrı "*başka bir mal*"ın da katılma payı olarak getirilebileceğini öngörmüş; bununla fikri mülkiyete konu teşkil eden *marka, lisans, know-how* gibi değerlerin veya bir ticari işletmenin de katılma payı olarak konulabileceğini kabul etmiştir. Ancak bu halde, bu değerlerin devri bir şekle tâbi kılınmışsa, devir sözleşmesinin öngörülen şekilde yapılması, meselâ markalarda bu sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve noter tarafından onaylanması gerekir (Sınai Mülkiyet Kanunu m.148/4).

Bütün bu açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, adi şirket sözleşmesinde söze konu edilen "*ortak amacı*" gerçekleştirmeye elverişli, iktisadi değeri haiz her şey (TBK m.26-27 esasları doğrultusunda, kanuna, adaba, ahlâka ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla) adi şirkete katılma payı olarak getirilebilir. Bu "*iktisadi değeri haiz şey*"in içeriğini tespit etmek için de Türk Ticaret Kanununda "*sermaye koyma borcu*"nu düzenleyen 127'inci madde hükmünden istifade edilebilir.

Adi şirketlerde katılma payı olarak getirilebileceği ifade edilen *emek* özellik arz eder. Ortaklar, şirket sözleşmesinde, emeğin katılma payı olarak nasıl ifa edileceğini serbestçe kararlaştırabilirler. Şirket sözleşmesinde kararlaştırmamışlarsa; ortaklığın amacının gerektirdiği

---

[81] Yargıtay 13 HD.'nin, 3.2.1992 T, E. 10226, K. 810 sayılı kararı için bkz., **Şener**, s. 201.

şekil ve kapsamda bir belirleme yapılır. Emeğin katılma payı olarak getirilmesi, emeğin şirkete devamlı bir şekilde tahsis edilmesi şeklinde anlaşılmamalıdır; geçici veya dönemsel olarak da emek katılma payı olarak konulabilir. Hatta şirketin kuruluş aşamalarını düzenlemek, şirketin faaliyete geçmesini temin etmek maksadıyla yapılan çalışmalar da (fizibilite raporu hazırlamak gibi), emeğin katılma payı olarak getirilmesidir.

b) Katılma Payının İfası ve İfa Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi

"*Katılma payı koyma yükümlülüğü*", şirketin kuruluşuyla ilgili değildir; *katılma payını ifa*, ortakların şirket sözleşmesinden doğan borcudur.

Kanun koyucu katılma payından söz etmişse de, ortaklar için asgari bir "*katılma payı*" öngörmemiş; sadece "*ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte olması*" gerektiğini vurgulamıştır. Getirilecek sermayenin oranının veya miktarının da sözleşmeyle serbestçe belirlenebileceği kabul edilmiş; sözleşmeyle belirtilmemişse "*birbirine eşit olması*" gerektiği hükme bağlanmıştır.

aa) Katılma Payının İfası

Katılma payının ifası, ortakların şirket sözleşmesiyle borçlandığı edimin niteliğine göre bazen "*edim fiilinin yerine getirilmesi*" bazen de "*edim sonucunun yerine getirilmesi*" şeklindedir. Bu anlamda, emeğin katılma payı olarak getirilmesinde ifa, edim fiilinin; katılma payı para ise edim sonucunun yerine getirilmesidir.

Ortakların katılma payı borcunun *ifa yeri*, sözleşme hükümlerine göre belirlenir; sözleşmede belirlenmemişse, borçlanılan edimin niteliğine göre genel hükümlere göre tespit edilir (TBK m.89). Katılma payının "*emek*" olarak getirilebileceği sözleşme ile kabul edilmişse, bu katılma payının niteliği de sözleşmede gösterilir; sözleşmede hüküm yoksa emeğini katılma payı olarak getiren ortağın "*düzenleme ve talimatlara*" uyması gerekir (TBK m.399).

Katılma payı *ifa zamanı* taraflarca serbestçe kararlaştırılabilir. Şirket sözleşmesinde ifa zamanına ilişkin hüküm yoksa ve şirket sözleşmesinden aksi anlaşılmıyorsa, adi şirketin kurulması ile katılma payı muaccel olur (TBK m.90); ifası gerekir.

bb) Katılma Payının İfa Edilmemesi

Adi şirketin amacına ulaşabilmesi için katılma payı yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmamışsa veya şirket sözleşmesinin mahiyetinden farklı bir sonuç çıkmıyorsa her borç doğumu anında muaccel olduğundan (TBK m.90); adi şirket sözleşmesinin kurulmasıyla, ortaklar şirket sözleşmesiyle üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar.

Katılma payının ifası, sözleşmede kararlaştırılan zamanda, yerde ve sözleşmede öngörüldüğü şekilde yerine getirilmelidir. Sözleşmede öngörüldüğü şekilde veya sözleşmede düzenlenmediği hallerde de TBK m.83 vd. maddelerinde hükme bağlandığı tarzda ifada bulunmayan ortak, TBK m.112 vd. maddelerinde düzenlenen "*borçların ifa edilmemesinin sonuçları*"na katlanmak zorunda kalır.

Katılma payını ifa etmeyen ortağa karşı, diğer tüm ortaklar veya temsil hükümleri çerçevesinde ortaklar adına temsilci yahut ortaklardan biri, bir eda davası (*actio pro socio*) açarak, katılma payının aynen ifasını isteyebilir. Ancak bu son halde de davacı ortak, ifanın kendisine yapılmasını isteyemez; katılma payının kişi birliğine ifasını talep ve dava etmelidir.

Eğer katılma payının *emek* olarak getirileceği belirtilmişse; dava ile ortağın, şirketin amacına uygun şekilde çalışması talep edilir (İİK m.30/1). Katılma payı *para veya para alacağı ise* ve katılma payı borçlusu temerrüde düşerse, temerrüt faizi ödemekle yükümlü olur (TBK m.88, 117, 120). Alacaklı, temerrüt faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe, bu zararı da gidermekle yükümlüdür (TBK m.122). Temerrüde düşen katılma payı borçlusundan, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat etmedikçe, borcun geç ifasından doğan zararlar da istenebileceği (TBK m.118) gibi, sözleşmede hüküm varsa cezai şart dahi istenebilir.

Katılma payının ifa edilmemesi, diğer ortaklar bakımından *haklı sebep* sayılacağından, diğer ortaklar, şirketin sona erdirilmesini (TBK m.639/b.6-7) veya sona erdirme yerine mütemerrit ortağın şirketten çıkarılmasını isteyebilirler (TTK m.255'e kıyasen).

IV) ADİ ŞİRKET VE TÜZEL KİŞİLİK

A) GENEL OLARAK

İki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmeyle kurulan adi şirkete, "*kişilik*" tanınmamış; bağımsız hak süjesi olma vasfı verilmemiştir. Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Tüzel kişiliği olmadığı için de hak ehliyetine sahip değildir[82].

Adi şirketin tüzel kişiliği haiz olmamasının bir takım hukuki sonuçlarının olacağı şüphesizdir.

B) ADİ ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİNİN OLMAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI

1) Hukuki İşlemlerde Taraf Olma Ehliyeti

Tüzel kişiliği olmadığı için adi şirket, üçüncü kişilerle hukuki işlem yapamaz; bütün ortakların birlikte hareket etmesi veya işlemlerin ortakları temsil eden bir temsilci tarafından yapılması gerekir. Ortak, kendi adına ve şirket hesabına hareket ederse (*dolaylı temsil*), üçüncü kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur (TBK m.637/1); diğer ortakların yapılan işlemle bağlanmaları için alacağın devri (alacağın temliki) (TBK m.183 vd) veya borcun üstlenilmesi (TBK m.195 vd.) hakkındaki hükümlere uyulması gerekir.

Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa (*doğrudan temsil*), diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar (TBK m.637/2). Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil yetkisi var sayılır (TBK m.637/3).

2) Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İcra İflâs Kanununa Göre Taraf Ehliyeti

Hukukumuzda adi şirketin davada taraf ehliyeti olmadığı gibi, icra ve iflâs takibinde de adi şirket olarak yer alamazlar; ortaklar birlikte

---

[82] Mehaz İsviçre hukukunda da adi şirketin bağımsız bir hak süjesi olmadığı kabul edilmektedir (**Meier-Hayoz/Forstmoser**, §12, N.14). Alman hukukunda ise adi şirkete tüzel kişilik tanınmamış ve fakat adi şirketin hak ehliyetinden istifade edebileceği (Rechtsfähigkeit) ifade edilmiştir (Bkz. **Bilgili**, F., Türk Ortaklıklar Hukuklunda Gizli Ortaklık İlişkileri, 2003, s.197 vd).

dava açmak veya takipte bulunmak zorundadırlar (*mecburi dava arkadaşlığı*)[83]. Bununla birlikte Yargıtay, ortakların tamamının dava açmaması halinde davanın reddedilmemesini; ortaklardan birinin dava açması hâlinde, dava açan ortağa, diğer ortakları davaya katması için süre verilmesinin gerektiğini içtihat etmiştir[84].

Üçüncü kişilerce adi şirkete karşı açılacak dava, dava konusu bir ortak tarafından tek başına yerine getirilebilecek para borcu gibi bir edime ilişkin ise, müteselsil sorumluluk sebebiyle (TBK m.634), dava ortaklardan birine veya birkaçına ya da tümüne yöneltilebilir (*ihtiyari dava arkadaşlığı*)[85].

Adi şirketin yönetimi ortaklardan birisine bırakılmışsa, yönetim yetkisini haiz ortak, diğer ortakları temsilen tek başına dava açabileceği gibi, adi şirket hakkında açılacak davalarda da ortakları (şirketi değil) temsilen yönetici ortağa karşı dava açılabilir[86].

3) Şirket Malvarlığı Üzerindeki Hak Sahipliği

Adi şirketin tüzel kişiliği olmaması sebebiyle, şirkete tahsis edilen katılma payları ve şirketin faaliyetlerinden elde edilen değerler üzerinde şirketin kendisi değil, bütün ortaklar; el birliği halindeki (iştirak halindeki) mülkiyet (TMK m.701 vd.) esasına göre hak sahibi olurlar (TBK m.638/1).

Türk Borçlar Kanununun 638'inci maddesinin birinci fıkrasında ifadesini bulan, "*ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği halinde bütün ortaklara ait olur*" hükmü gereğince, mal varlığı üzerinde hak sahipliğinde, el birliği mülkiyetinin esas olduğu; ancak şirket sözleşmesiyle paylı (müşterek) mülkiyet esasının da kabul edilebileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, paylı mülkiyetin adi şirketlerin yapısına çok uygun olmadığını ifade etmek gerekir[87].

---

83 Yargıtay 13. HD'nin 15.12.1983 T., E. 7910, K. 8956 sayılı kararı için bkz., **Uygur**, T., Açıklamalı-İçtihatlı Borçlar Kanunu, C. 8, 3. Baskı, 2010, s.6907.

84 Yargıtay 13 HD'nin 22.2.1982 T., E.620, K.1145 sayılı sayılı kararı için bkz., **Uygur**, C.8, s.9607-9608.

85 Yargıtay 11 HD'nin, 17.2.1988 T., E.1988/3556, K. 1988/3052 sayılı kararı için bkz., **Şener**, s.163.

86 Yargıtay 1 HD'nin,10.04.1990 T., E.1990/14453, K. 1990/5204 sayılı kararı için bkz., **Şener**, s.167-168.

87 Bu hususta bkz. **Yongalık**, s.65-67.

4) Sorumluluk

Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, ortaklığın üçüncü kişilerle ilişkisi "*temsil*" hükümleri çerçevesinde yürütülür. "*Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur*" (TBK m.637). "*Dolaylı temsil*" olarak isimlendirilen bu halde, hukuki işlemin sonuçları, "alacağın devri" (alacağın temliki) ve "borcun üstlenilmesi" (borcun nakli) ile diğer ortaklara teşmil edilir.

"*Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı ve borçlusu olur*" (*doğrudan temsil*) (TBK m.637/2).

Bu hükümlere göre, dolaylı temsilde, sadece işlemi yapan ortak sorumluluk altına girecek; doğrudan temsilde ise, temsil hükümleri çerçevesinde bütün ortaklar *müteselsilen* sorumlu olacaklardır. Bu halde müteselsil sorumluluk, şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, yani hak süjesi olmayan adi şirkete başvurma imkânı olmadığından, birinci dereceden; sorumlulukları da sınırlandırılmadığından, sınırsız ve müteselsil sorumluluktur. Ancak müteselsil sorumluluğun söz konusu olabilmesi için, para veya tazminat borcu gibi, borcun tek başına bir ortak tarafından yerine getirilebilmesi mümkün bir borç olması gerekir. Ortakların elbirliği ile tasarruf edebilecekleri bir edime ilişkin borçlarda müteselsil sorumluluk olmaz; ortakların hepsine birden müracaat etmek gerekir.

Müteselsil sorumluluk hallerinde her ortak, borcun tamamından sorumlu olur; alacaklı, bütün borçlulara müracaat edebileceği gibi, müteselsil borçlu olan bir veya birkaç ortağa da başvurarak alacağını talep edebilir. Ödeyen ortağın diğer ortaklara başvuru hakkı, genel hükümlere göre olacaktır. Alacaklının, ortaklardan birini takip etmesi, diğer ortaklara karşı talebinden vazgeçtiği anlamına da gelmez[88].

5) Haksız Fiilden Sorumluluk

Haksız fiil sorumluluğu esas itibariyle gerçek kişilere aittir; tüzel kişilerin haksız fiil sorumluluğu Türk Medeni Kanununun 50'nci maddesinin ikinci fıkrasında, "*Organlar hukuki işlemleri ve diğer bütün*

---

[88] Bu hususta geniş bilgi için bkz., **Şener**, s.416-429.

fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar" şeklinde düzenlenmiştir. Maddedeki "*diğer bütün fiilleriyle*" ifadesi, tüzel kişinin "haksız fiil sorumluluğunu" ve bu sorumluluk yanında "hakkaniyet sorumluluğunu" ve "objektif sorumluluk" hallerini de içine alır.

Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından ve ortakların da "*organ*" sıfatı bulunmadığından dolayı, bir ortağın haksız fiilinden (TBK m.49 vd.) diğer ortakları sorumlu tutmak mümkün değildir. Haksız fiil faili ortak, doğrudan temsil hakkını haiz ortak olsa bile, sonuç değişmez. Zira temsil, hukuki işlemler için söz konusu olur; haksız fiiller temsil kapsamına girmez, haksız fiil ika eden, bu haksız fiilden bizzat sorumlu olacaktır.

6) Ticaret Unvanı

Adi şirket tüzel kişiliği haiz olmadığından, bir ticari işletmeyi işletmek amacıyla kurulsa dahi, ticari işletme adi şirket adına tescil ettirilemez; işletmenin bütün ortaklar adına ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Bundan dolayı, adi şirketin işlettiği ticari işletme için, ortaklarından ayrı bir ticaret unvanına sahip olması da mümkün değildir.

Buna göre, adi şirketin bir ticari işletme işletmek için kurulması halinde, ortakların ticari işletmeyi, her birinin ad ve soyadından oluşan bir ticaret unvanı alarak ticaret siciline kaydettirmeleri gerekir; ticari işletmenin özelliğini göstermek için de, TTK m.46'ya uygun olarak, kişi topluluğunu ifade edecek "*ihtiyari ek*" alabilir[89].

7) Defter Tutma

Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, ticari bir işletme işletmek için kurulan adi şirketlerde tacir sıfatı şirketin değildir; ticari işletmeyi işleten ortaklar tacir sıfatını iktisap eder (TTK m.12/1). Türk Ticaret Kanununa göre defter tutmak tacir olmanın hukuki sonucudur; tacirler

---

[89] Hâl böyle olmasına rağmen, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan, *"Ticaret Şirketlerinin Tüzel Kişiliği Bulunmayan Bir Ortaklık Yapısı İle İşlettikleri Ticari İşletmelerin Ticaret Siciline Tescili Hakkında Tebliğ"*de (2009/2 sayılı tebliğ) farklı bir düzenlemeye yer verilmiştir. 2009/2 sayılı tebliğin üçüncü maddesinin birinci fıkrasında, *"tüzel kişiliği haiz ticaret şirketlerinin müştereken belli bir amacı gerçekleştirmek ve kâr elde etmek için kurdukları ve müştereken yönettikleri tüzel kişiliği bulunmayan ortaklıklar aracılığıyla işletilen ticari işletmeler talep edilmesi halinde ticaret siciline tescil edilir"* denilmektedir.

ticari defter tutmakla yükümlüdür (TTK m.18/1; 64/1). Bu sebeple defter tutma yükümlülüğü olan adi şirket değil; tacir sıfatını haiz olan adi şirket ortaklarıdır (TTK m.18/1; 64/1).

Uygulamada da şirketin yasal defterleri, şirkete değil ortakların şahsına bağlı olarak tutulmaktadır. Bir diğer söyleyişle, yasal defterlerin tasdikinde, şirketin adi şirket olduğu ifade edilerek, defterlerde tüm ortakların adları belirtilmektedir. Ortaklardan birinin herhangi bir şekilde ortaklıktan ayrılması halinde, söz konusu tarih itibariyle kayıtların kapatılıp, dönem sonuçlarının belirlenmesinden sonra yeniden açılması gerekmektedir.

8) Vergi

Adi şirketler, vergi uygulamasında bağımsız bir birim ve muhatap olarak kabul edilmemiş; ortaklarının ortaklık faaliyetinden elde ettiği kazanç, Gelir Vergisine tâbi tutulmuştur. Buna göre, adi şirketlerde ortakların her birinin elde ettiği kazançlar (şirketin tüzel kişiliği olmadığı için), ortakların bizatihi kendilerinin ticarî kazancı sayılmakta; ortakların, TBK m.622 vd. hükümlerine göre paylarına düşen kazançlarını, ayrı ayrı ticari kazanç olarak beyan etmeleri gerekmektedir.

9) Yerleşim Yeri

Yerleşim yeri, Türk Medeni Kanununda gerçek kişiler (m.19) ve tüzel kişiler (m.51) açısından öngörülmüştür. Adi şirketlerin tüzel kişiliği olmaması nedeniyle bir "*yerleşim yeri*"nden de bahsedilemez. Bununla beraber, adi şirket ortakları, şirket sözleşmesinde iş merkezi olarak bir yer göstermişlerse, bu yere; adi şirket bir ticari işletme işletiyorsa, işletmenin merkezinin bulunduğu yere, "*yerleşim yeri*"nin doğurduğu hukuki sonuçlar tevcih edilebilir. Böyle bir sonuç, adi şirketlerin, tüzel kişiler gibi "*yerleşim yeri*"nin bulunduğu anlamına gelmez; sadece "*yerleşim yeri*"nin doğurduğu bazı neticeler, bu yerler için de uygulanabilir.

Adi şirket sözleşmesinde bir hüküm yoksa ve adi şirket de ticari işletme işletmiyorsa, ortakların tek tek "*yerleşim yeri*"nden bahsedilebilir[90].

---

[90] **Ansay**, s. 104-108.

10) Tâbiiyet

Tâbiiyet, esas itibariyle gerçek kişiler için söz konusudur. Gerçek kişilerden başka, tüzel kişilerin de bir tâbiiyeti olması gerektiği tartışılmış; gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin de bir tâbiiyetinin bulunması gerektiği ifade edilmiştir[91].

Adi şirketlerin tüzel kişiliği olmadığından, bir tâbiiyetinden de bahsedilemez. Ancak bilhassa uygulanacak hukuku tespit bakımından, adi şirketlerin de ayrıca değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Zira bir adi şirket ortaklarının çeşitli ülke vatandaşı olması, bu ülkelerin tâbiiyetinde bulunmaları, farklı ülkelerin yerleşim yeri olarak kabul edilmesi ve adi şirketin birden fazla ülkede faaliyet göstermesi mümkündür; bu halde adi şirketlerde uygulanacak hukukun tespiti güçlük arz edebilir.

Tüzel kişilerin tabiiyetini tespit etmek maksadıyla çeşitli görüşler ileri sürülmüş, kimileri "*kurucuların tâbiiyetini*", kimileri ise "*sermayenin bulunduğu yeri*" esas almış; bazıları da, "*kuruluş yeri*"nin, "*merkezin bulunduğu yer*"e üstün olduğunu kabul etmiştir.

Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından, tüzel kişilere ilişkin bu görüşlerin uygulanma imkânı bulunmaz; fakat uygulanacak hukuku tespit için bu görüşlerden yararlanılabilir.

Buna göre, adi şirket sözleşmesinde uygulanacak hukuku gösteren bir hüküm varsa; bu hükme göre hareket etmek gerekir. Adi şirket sözleşmesinde bir hüküm bulunmamasına karşın, adi şirket bir ticari işletme işletiyorsa ve işletmeyi tescil ettirmişse, tescil yeri hukukuna üstünlük tanınabilir. Bu dahi yoksa sözleşmenin yapıldığı yer hukukuna öncelik verilebilir.

V) UYGULAMADA ADİ ŞİRKET

Adi şirketin, kuruluşundaki basitlik, uygulama kolaylığı sağlaması, kısa süreli iktisadi gayelere elverişli olması vb. sebepler, iktisadi hayatın tüm alanlarında görülmesine imkân vermektedir.

Bu esastan olmak üzere, tarım alanında uygulanan "*yarıcılık*" (ortaklık), bir benzin istasyonunun birlikte işletilmesi, ihracat veya ithalatın birlikte yapılması, müştereken loto oynanması, piyango bileti satın

---

91 Tüzel kişilerin ve bu bağlamda şirketlerin tabiiyeti ile ilgili açıklamalar için bkz., **Doğan**, V., Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara, 1999, s. 204 vd.; **Aygül**, M., Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Temeli, Ankara 2007.

alınması, ileride kurulacak bir ticaret şirketi için bir araya gelmek, "*gizli ortaklık*" ilişkisi ve hatta adi şirket temeline dayanması kaydıyla, "*konsorsiyum*", "*joint venture*", "*kartel*" ve "*konzern*"ler de adi şirket hükümlerine tâbi olur. Bu bağlamda bunların bir kısmına temas etmekte fayda görüyoruz.

A) KURULUŞ ORTAKLIĞI

İki veya daha fazla kişinin bir ticaret şirketi kurmak amacıyla müşterek çaba göstermeleri halinde, ticaret şirketinin tüzel kişilik kazanmasına kadar, bir adi şirket ilişkisinden bahsedilir. Kuruluş ortaklığının konusunu teşkil eden ticaret şirketi, şahıs ticaret şirketi veya sermaye şirketi yahut kooperatif olabilir; bu ticaret şirketleri tüzel kişilik kazanıncaya kadar aralarında "*kuruluş ortaklığı*" (Gründungsgesellschaft) veya "*kurucular ortaklığı*" (Gründergesellschaft) diye nitelendirilen ilişki, adi şirket sayılır.

"*Kuruluş ortaklığı*", TTK'nin 335'inci maddesinin gerekçesinde ifadesini bulan "*ön şirket*"ten farklıdır. TTK m.335'e göre, anonim (ve limited) şirket, şirket esas sözleşmesinin kurucular tarafından imzalanması, imzaların da noterce onaylanmasıyla veya ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmasıyla kurulur. Ancak şirketin tüzel kişilik kazanması için şirketin ticaret siciline kaydedilmesi gerekir (TTK m.335/2; 355/1). İmzaların noter tarafından tasdiki veya sicil müdürü ya da yardımcısı huzurunda imzalanması ile şirketin ticaret siciline tescili anına kadar geçen sürece "*ön şirket*" denilmektedir.

"*Ön şirket*"in hukuki mahiyeti tartışmalı olmakla beraber, ön şirketin de bir adi şirket olarak nitelendirilmesi isabetli olur. Zira henüz tüzel kişilik kazanmamış bir anonim (veya limited) şirket kurulmuş ve ortaklar arasındaki ilişkilere (iç ilişki) artık bu ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerin hâkim olduğu; kabul edilmeli, şirket henüz tüzel kişilik kazanmadığından, üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde (dış ilişki) ise, şirketin mahiyetiyle uygun olduğu müddetçe, adi şirket hükümleri tatbik edilmelidir[92].

B) GİZLİ ŞİRKET

Bilhassa ticaret yapma yasağına tâbi olan kişiler, bir başkasının işlettiği ticari işletmeye ortak olmak isteyebilirler. Bu halde dış münase-

---

92 Bu hususta değerlendirmeler için bkz. **Barlas**, s.156-161.

bette (görünüşte) ticari işletme ve o işletmenin sahibi tek kişi olmasına karşın; iç münasebette bir ortaklık ilişkisi kurulmuş olur. Bu durumda ortak olan kişi, üçüncü kişilerden gizlenmekte; dışa karşı bir şirket görünümü verilmemektedir. Üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen bu ortağa "*gizli ortak*" (der stille Gesellschafter), bu şekilde kurulan şirkete de "*gizli şirket*" (die stille Gesellschaft) denir[93].

Hukukumuzda "*gizli şirket*" ile ilgili özel düzenlemeler mevcut değildir. Ancak hukuki ilişkinin mahiyeti nazara alındığında, gizli şirketin niteliğine uygun olduğu nispette, adi şirket hükümleri tatbik edilmelidir[94].

C) ADİ ŞİRKET TEMELİNE DAYALI SÖZLEŞME İLİŞKİLERİ

İktisadi hayatın süratle gelişmesi ve değişmesi ile beraber, iş hayatına ortak amaca müştereken ulaşabilmek maksadıyla yeni veya yenilenen kişi birlikleri dâhil olmuştur. Bunlar doktrinde[95], "*adi şirket temeline dayalı sözleşme ilişkileri*" olarak nitelendirilmektedir.

Adi şirket temeline dayalı sözleşme ilişkilerinin "*konsorsiyum*", "*joint venture*", "*kartel*" ve "*konzern*" olduğu, adi şirkete ilişkin kuralların, bu sözleşme ilişkilerine, bunlar adi şirket olarak nitelendirildikleri nispette uygulanması gerektiği ifade edilmektedir.

VI) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ

A) GENEL OLARAK

Bir şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri ile şirketle olan ilişkileri; ortakların veya şirketin üçüncü kişilerle olan ilişkilerinden ayrılır. Ortakların birbirleriyle olan ilişkileri ile şirketle olan ilişkilerine "*iç ilişki*"; ortakların veya şirketin üçüncü kişilerle olan ilişkilerine de "*dış ilişki*" adı verilmektedir.

Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığından, ortakların birbirleriyle olan ilişkileri ile diğer ortakların tamamıyla olan ilişkiler, "*iç ilişki*"; ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkileri de "*dış ilişki*" olarak değerlendirilir.

---

93 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Bilgili**, F., Türk Ortaklıklar Hukuklunda Gizli Ortaklık İlişkileri, 2003

94 Gizli şirket hakkındaki tartışmalar için bkz. **Barlas**, s.177-203.

95 Bkz. **Barlas**, s. 205-290.

1- Ortaklar Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti

Adi şirketlerde ortaklar arasındaki ilişkiler (*iç ilişki*), sözleşme serbestîsi ilkesi gereği, esas itibarıyla "*şirket sözleşmesi*" ile belirlenir. Bir diğer ifadeyle, adi şirketlerde ortaklar arasındaki ilişkilere öncelikle, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmayan sözleşme hükümleri uygulanır. Adi şirket sözleşmesinde ortaklar arası ilişkiyi düzenleyen bir hüküm yoksa Türk Borçlar Kanununun "*adi şirkete*" müteallik hükümleri (m. 620-645) tatbik edilir.

Adi şirket sözleşmesi de diğer borç doğuran sözleşmeler gibi, sözleşmeye katılanlar lehine bazı haklar veya aleyhine bazı yükümlülüklerin doğmasına sebebiyet verir. Ancak şirket sözleşmesi çok taraflı bir akit olduğundan, onunla ortaklardan herhangi biri, diğer ortağa karşı değil, diğer bütün ortaklara karşı yükümlülük altına girer. Buna göre ortaklardan birinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde; bu yükümlülüğün yerine getirilmesini, esas itibarıyla, diğer ortaklar müştereken talep edebilirler. Bununla birlikte şirket sözleşmesi ile şirket sözleşmesinden doğan yükümlülükler, aynı zamanda her ortağa karşı da taahhüt edilmiş olduğundan; bir ortağın yükümlülüğünü yerine getirmesi, diğer herhangi bir ortak tarafından istenebilir (*actio pro socio*). Ancak bu halde, yükümlülüğün yerine getirilmesini isteyen ortak, borçlu ortağın kendisine değil; diğer bütün ortaklara ifada bulunmasını talep edebilir.

2- Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü

Her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür (TBK m.628/1).

a) Özen Yükümünün Kapsamı

TBK m.630/1'e göre, *"Kanunun bu bölümünde veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tâbidir". "Yönetim, sözleşme veya bir kararla bir veya birden çok ortağa ya da ortak olmayan üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir"* (TBK m.625).

Kanun koyucu, TBK m.628'de, *"Her ortak ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür"* derken, ortaklık işlerinin görülmesindeki *"çaba ve özen"*den söz etmektedir.

Bu halde *çaba ve özenin* ölçüsünün tespitinde evvela TBK m.620-645 hükümleri ele alınmalı; burada veya sözleşmede aksine hüküm olmadıkça, *vekâlet* hükümlerine itibar edilmelidir.

TBK m.628'de, *çaba ve özenin* ölçüsü, "*her ortağın kendi işlerinde gösterdiği çaba ve özendir.* TBKm.506/2'de ise, "*Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı menfaatini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür*". "*Vekilin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır*" (TBK m.506/3).

Bütün bu hükümlerin bir arada değerlendirilmesinin sonucunda, her ortağın kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen gösterme yükümlülüğünü; "*ortakların haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmek*" ve "*benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken bir davranış*" olarak kabul edilmesi gerekir.

Buna göre, sadece "*ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortağın*" vekâlet hükümlerine tâbi tutulması, diğerlerinin "*kendi işlerinde gösterdiği çaba ve özenin*" esas alınması yerine; özen borcunun tespitinde, "*ortakların menfaatini gözeterek, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranışın*" esas alınması isabetli olur.

Kaldı ki, adi şirket ortakları, ortaklık ilişkisine dayalı olarak bir ticari işletme işletiyorlarsa; bu işletmeyi "*kısmen de olsa*" kendi adlarına işlettikleri için tacirdirler (TTK m.12/1). Bu halde de tacir olmanın sonuçlarına ve bilhassa özen borcunun tespitinde, "*Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir*" hükmü (TTK m. 18/2) ihmâl edilmemelidir.

b) Özen Yükümüne Aykırı Davranmanın Müeyyidesi

Şirket işlerinin görülmesinde özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranan ortak, diğer ortaklara karşı kendi kusuruyla verdiği zararları gidermekle yükümlüdür (TBK m.628/2). Bu yükümlülüğün esası, borçlar hukukuna hâkim olan, sözleşmeye aykırı hareketin diğer tarafın bu yüzden uğradığı zararın tazminini gerektireceğine ilişkin TBK m.112 hükmüdür. Buna göre ortağın özen borcuna aykırı davranması, "*sözleşmenin müspet ihlâli*" mahiyetindedir ve tazminat yükümlülüğünün doğumuna sebebiyet verir.

Bu kural TBK m.628/2'de, "*Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları... gidermekle yükümlüdür*" şeklinde ifade edilerek, tazminat yükümlülüğünün şartları teferruatlı bir surette tespit edilmiştir.

Buna göre, tazminat alacaklıları, özen borcuna aykırılıktan zarar gören diğer ortaklardır. Özen borcuna aykırı davranarak diğer ortaklara zarar veren ortağın, verdiği zararları, şirkete diğer işlerde sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı da yoktur (TBK m.628/2).

Özen borcuna aykırı olarak yapılan işe, diğer ortaklar önceden açık veya örtülü olarak muvafakat etmişler veya sonradan onay vermişlerse; "*Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir ya da tamamen kaldırabilir*" (TBK m.52/1).

3- Eşitlik İlkesi

Adi şirkette ortaklar arasındaki ilişkilerde kural olarak eşitlik ilkesi hâkimdir. Bu ilke gereğince, aksi kararlaştırılmadıkça ortaklar, haklardan eşit şekilde yararlanır ve borçları eşit şekilde paylaşırlar.

Bu esastan olmak üzere; sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın *eşittir* (TTK m.623/1). Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, *bütün ortaklar* ortaklığı yönetme hakkına sahiptir (TTK m.625). *Her ortak,* ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür (TTK m.628/1). Yönetim yetkisi olmasa bile, *her ortağın*, ortaklığın işleyişi hakkında bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme, bunlardan örnek alma ve mali durumu hakkında özet çıkarma hakkı vardır. *Aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür* (TTK m.631). Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, *yönetici olmayan ortaklar da dâhil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle* yapılır (TTK m.644/1).

4- Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri

Adi şirketlerde, ortaklar arasındaki ilişkilerden doğan hak ve borçlar, şahsa bağlı olduğundan; esas itibariyle devredilemez. Ortaklar arasındaki ilişkilerden doğan hak ve borçların devredilememesi kuralına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu bağlamda ortaklar ancak diğer or-

takların kabulüyle; şirketteki payını, bir başkasına devredebilmektedir. Ayrıca, ortaklar, yönetim, denetim ve oy hakları ile temsil yetkisini bir bütün hâlinde devredemeseler de; kimi hâllerde, haklarını temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu hakların devamlı olarak devredilmesi, sadece küçük ve kısıtlılar için söz konusu olabilir. Ortakların borçlarının devredilememesine ilişkin kuralın bir istisnası, katılma paylarında kendisini gösterir. Buna göre, ortakların katılma payını ifa borcu, katılma payının ifası, şahsa bağlı değilse; bir başkası tarafından yerine getirilebilir.

B) ADİ ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ

Adi şirketlerde iç ilişki, mali nitelikte ve şahsi nitelikteki ilişkiler olmak üzere iki ana başlık altında incelenmektedir.

1- Mali Nitelikteki İlişkiler

Adi şirkette ortakların mali nitelikteki ilişkileri, katılma payı, kazanç ve zarara katılma, tasfiye payı ile ücret, faiz ve masrafları talep etme haklarından oluşur.

a) Katılma Payı

Adi ortaklık sözleşmesi", iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek için birleştirmeyi üstlendikleri bir sözleşmedir (TBK m.620/1). Her ortak para, alacak ya da başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir "*katılma payı*" koymakla yükümlüdür (TBK m.621/1). Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, "*ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte*" ve "*birbirlerine eşit olmak*" zorundadır (TBK m.621/2).

Katılma (katılım) payı, şirket sözleşmesinde öngörülen ve sözleşmeye katılanlar tarafından kabul edilen "*ortak amaca erişmek üzere, ortaklarca şirkete tahsis edilen değerlerdir*[96]. Katılma payını şirkete getirmek, ortak açısından hem bir hak hem de bir borçtur.

b) Kazanç ve Zarara Katılma

Adi şirkette bahse konu edilen "*ortak amaç*", kazanç elde etme ve bu kazancı paylaşmaktır. Şirketin elde ettiği kazanca iştirak, ortakların

---

[96] Ayrıntılı bilgi için bkz. İkinci Bölüm, § 3, I, B başlığı

hakkı olduğu gibi, elde edilen kazançtan, diğer ortakların paylarını ayırarak onlara vermek her ortağın yükümlülüğüdür. "*Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdür*" (TBK m.622)[97].

aa) Kazanç ve Zarar Kavramı

Kazanç veya zarar[98], ortakların müşterek amaca erişmek için yaptıkları faaliyetlerin bir hesap dönemi sonunda şirket malvarlığında meydana getirdiği artma veya azalmadır. Hesap dönemi, esas itibariyle takvim yılıdır. Ancak, takvim yılı dönemi işletmenin çalışma ve işlemlerinin niteliğine uygun düşmüyorsa; özel hesap dönemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından on ikişer aylık olarak belirlenebilir. Yeniden işe başlama veya işi bırakma hâllerinde hesap dönemi içinde bir yıldan eksik faaliyet süreleri, bir hesap dönemi sayılır (VUK m. 174).

Kazanç veya zarar üzerinde uyuşmazlık halinde, kazanç veya zararın bilirkişi aracılığıyla tespit edilmesi gerekir[99].

bb) Yönetici Ortağın Hesapları Çıkarması

"*Ortaklar niteliği gereği ortaklığa ait bütün kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdür*" (TBK m.622). Kanun koyucu TBK m.622'de her ne kadar "*kazancın paylaştırılması*"ndan söz etmişse de (emeğini

---

97 Maddenin gerekçesinde, "818 sayılı Borçlar Kanununun 522'nci maddesini karşıladığı; 818 sayılı Borçlar Kanununun 522'nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "*II. Kâr ve zarar / 1. Kârın taksimi*" şeklindeki ibarenin, "*II. Kazanç ve zarar / 1. Kazancın paylaşılması*" şeklinde değiştirildiği; metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği olmadığı" ifade edilmiştir.

98 Türk Borçlar Kanununda kazanç ve zarar kavramlarının neyi ifade ettiği açıklanmamıştır. 818 sayılı Borçlar Kanununda kazanç kavramı yerine kullanılan ***kâr***, genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre, net satışlar ile diğer faaliyetlerden elde edilen gelir toplamından, satışların maliyeti, faaliyet giderleri, diğer faaliyetlerden doğan olağan giderler, finansman giderleri, olağandışı gider ve zararların toplamının düşülmesinden sonra kalan miktardır. "***Ticari kâr***" da denilen bu kârdan, ödenmesi gereken vergi düşüldükten sonra bulunan kâra da, "***dağıtımdan önceki kâr***" denilmektedir. Adi şirketlerin, şirket sıfatıyla vergi mükellefi olmadığı nazara alınacak olursa, dağıtılacak kazanç, ticari kâr olarak nitelendirdiğimiz miktar olmalıdır.

99 Yargıtay 13 HD., 1974/5005 E, 1975/416 K., 24.1.1974 T.'li kararı için bkz., **Yalman, M / Taylan**, E., Adi Ortaklık, Ankara 1976, s. 101.

katılma payı olarak koyan ortağın sözleşmeyle oluşturulabilecek istisnai durumu haricinde), zararın da aynı şekilde paylaştırılması gerekir.

Kazanç veya zararın belirlenmesi ile ortaklar arasında taksim edilmesi, yöneticilerin görevleri arasındadır. TBK m.630/3'e göre, "*Yönetici ortaklar yılda en az bir defa hesap vermek ve kazanç paylarını ortaklara ödemekle yükümlüdür*". "*Ortaklığı yönetenin ortaklardan birisi olmaması durumunda da aynı kural uygulanır*".

Adi şirket yöneticisi veya yöneticileri, ortaklara dağıtılacak sâfi (net) kazancı tespit ettikten sonra; kazanç ve zararın taksimi esaslarına göre ortaklar arasında dağıtmakla yükümlüdür. Yöneticinin bu dağıtım görevini yerine getirmedeki ihmâli veya dağıtım usulünün diğer ortaklar tarafından kabul edilmemesi halinde; ortaklardan her biri mahkemeye başvurarak, kazancın veya zararın tespitini ve sözleşme veya kanun hükümlerine göre paylaştırılmasını isteyebilir. Bu dava, şirketin tüzel kişiliği olmadığından, yöneticiler aleyhine açılır.

cc) Kazanç ve Zararın Paylaştırılması

TBK m.623'e göre, kazanç ve zararın nasıl paylaştırılacağı şirket sözleşmesinde gösterilebilir. "*Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın zarar ve kazançtaki payı, katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir*" (TBK m.623/1). "*Sözleşmede, ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse, bu belirleme, diğerindeki payı da ifade eder*" (TBK m.623/2).

TBK m.623'ün düzenlemesi nazara alındığında, adi şirketlerde kazanç ve zararın paylaştırılması esasları aşağıda bahsedileceği şekilde belirlenmiştir.

aaa) Kazanç ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara Göre Paylaştırılması

TBK m.623/1'e göre, sözleşme yapma serbestîsi gereği; ortaklar, adi şirket sözleşmesinde, kazanç ve zararın paylaştırılması esaslarını serbestçe belirleyebilirler. Ortaklar, kazanç ve zararların paylaştırılması esaslarını belirlerken; katılma paylarını esas alarak bir paylaştırma öngörebilecekleri gibi katılma paylarından bağımsız bir tarzda paylaştırmayı da kabul edebilirler.

Kanun koyucu, her ne kadar sadece, "*sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa*" demişse de; aynı sonuca ortakların alacağı bir kararla da varılabilir. Buna göre kazanç ve zararın paylaştırılmasında *sözleşmede*

bir hüküm olmadığı hallerde; ortaklar TBK m.624'e uygun olarak alacakları *bir kararla da*, kazanç ve zararın taksimini kararlaştırabilirler.

Gerek sözleşmeyle gerek kararla belirlensin; kazanç ve zararın paylaştırılmasında, kazanç ve zarara katılma oranları farklı olabilir. Bir diğer ifadeyle, kazanç payı oranının mutlaka zarar payı oranına eşit olması gerekmez; farklı oranlar kabul edilebilir. Ancak bazı ortakların sadece zarara katılacağı; kazanca katılmayacağı veya çok cüz'i oranda katılacağına ilişkin hükümler (*Aslan Payı Ortaklığı*)[100] esas itibariyle geçersizdir. Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak katılma payı olarak sadece emeğini koymuş ortak için, o da sadece *iç münasebette geçerlidir* (TBK m.623/3).

---

[100] Bu tür şirketlere "***aslan paylı şirket***" (*societasleonina*) denilmesi, eski MÖ VI. yüzyılda yaşadığı varsayılan Yunan masalcılarından *Ezop*'un (Aisopos) bir hikâyesine dayanmaktadır. Benzer bir hikâye *Mevlana*'nın *Mesnevî*'sinde de mevcuttur. *Mesnevî*'deki hikâyeye göre (1-3013):
Bir gün aslan, kurt ve tilki avlanmak için dağa çıkarlar. Avlanırken geniş arazide daha çok av yakalamak için birbirlerine yardım etme hususunda anlaşırlar; işleri rast gider. Bir yaban öküzü, bir dağ keçisi ve bir de tavşanı avlarlar. Avlarını kanlar içinde sürükleyerek, ağaçlık bir subaşına getirirler. İyice yorulmuş ve acıkmışlardır. Özellikle kurt ve tilkinin ağzının suyu akmakta; paylarını bir an önce alma hevesindedirler.
Aslan "*Ey tecrübeli ve ihtiyar kurt! Avladığımız hayvanları aramızda adaletli bir şekilde paylaştır. İyi bir adalet koy ortaya, vekilim sensin*" der.
Kurt, "*Padişahım! Sizin büyüklüğünüze, iri ve büyük olan bu yaban öküzü yakışır; çevikliğinize ve semizliğinize uygun düşer. Keçi, orta boyda ve irilikte, o da bana uygun olur. En küçüğümüz tilki olduğuna göre, avımızın en küçük parçası olan tavşan da onun hakkıdır*" diye cevap verir.
Aslan, bu paylaştırma karşısında kızıp kükrer, "*Ey kurt! Nasıl paylaştırdığını anlayamadım; yaklaş karşıma bir daha söyle*" der ve yanına yaklaşınca da, bir pençe vurarak kurdu parçalar.
Aslan tilkiye dönerek: "*Ey tilki! Şimdi bu avları adaletli bir şekilde sen paylaştır bakalım*" diyerek, paylaştırmayı tilkinin yapmasını ister.
Tilki önce aslanın önünde saygıyla eğilir; yer öper. Sonra, "*Bu semiz yaban öküzü, efendimizin kuşluk yemeğidir; güne bunu yiyerek başlarsınız. Bu keçi de aziz padişahımıza, öğle yemeği için güzel bir yahni olur. Lütuf ve kerem sahibi sultanımızın akşam yemeğindeki çerezi de tavşan olsun*" diyerek, paylaştırmanın nasıl olması gerektiğini söyler.
Aslan, "*Ey tilki, adaletin ışığını sen yaktın; tam hakça paylaştırdın. Söyle bakayım, bu taksimi kimden öğrendin?*". Tilki, kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırıp, kurnazca gülerek; "*Kurdun başına gelenlerden efendim, kurdun başına gelenlerden*" diye cevap verir.

Şirket sözleşmesinde kazanç ve zararın paylaştırılmasında sadece kazancın veya zararın nasıl paylaştırılacağı hükme bağlanmış; meselâ kazancın nasıl paylaştırılacağı belirtilmişken, zararın nasıl taksim edileceği belirtilmemiş olabilir. "*Sözleşmede ortakların kazanç ve zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu belirleme diğerindeki payı da ifade eder*" (TBK m.623/2). Bu halde örneğimizde olduğu gibi, kazancın nasıl paylaştırılacağı belirtilmiş, zararın nasıl taksim edileceği hükme bağlanmamışsa; kazanç nasıl paylaştırılıyorsa zarar da ona göre paylaştırılacaktır.

bbb) Kanun Gereğince Paylaşma

Kazancın ve zararın ne surette paylaştırılacağı şirket sözleşmesinde gösterilmemişse; her ortağın kazanç ve zarardaki payı, katılım payının niteliğine ve değerine bakmaksızın kanunen eşittir (TBK m.623/1). Buna göre aksine bir sözleşme veya karar yoksa; her ortağın kazanç veya zarardan hissesi, katılma payının kıymeti ve mahiyeti ne olursa olsun *eşittir.*

Bu bağlamda, şirketin amacına ulaşmak için emeğini katılma payı olarak koyan ortak da bu hükümden istifade edecek; ayrıca emeği için bir ücret isteyemeyecektir. Ancak, yükümlü olmadığı halde ortaklık işleri için emek sarf etmiş bir ortak, bu emeği katılma payı da değilse; hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir (TBK m.627/3).

c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı

Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflası, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir (TBK m.633). Adi şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın payının tasfiye edilmesi gerekir.

Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçer. Bu durumda diğer ortakların payı, *ipso iure* iktisap ettikleri pay oranında artar. Böylelikle ortaya çıkan infisah sebebi, ortaklığın aynen devam etmesi sağlanarak bertaraf edilmiştir.

Adi şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın ayrılma payı, ortak olma sıfatının sona erdiği tarihte şirket sona ermiş ve tasfiye edilmiş olsaydı ortağın alacağı tasfiye payına göre belirlenir. Bu esastan olmak üzere, diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlüdür. Ayrılan ortak, ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtarılır. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilirler. Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, mali işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu kişi, hâkim tarafından atanır (TBK m.634).

d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı

Ortakların şirket işlerini görmesi, şirket sözleşmesinin mahiyeti gereğidir. Faaliyetin karşılığında şirket kazanç temin edecek, ortak da bu kazançtan payını alacak; emeği için de (kural olarak) bir tazminat talep edemeyecektir.

Bununla birlikte, bütün ortaklara faydası olacak böyle bir faaliyetin mameleki külfetlerine, sadece işi yapan ortağın katlanmasını beklememek gerekir. Bu nedenle kanun koyucu, "*Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar gidermek zorundadır*" diyerek, diğer ortakların katılımını temin etmiştir.

Bu hükme göre ortak, şirket işleri için yaptığı giderlere diğer ortakların katılmasını isteyebileceği gibi, üstlendiği borçlardan dolayı da; diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar.

Ayrıca ortak, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya veya ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda bir zarara uğrarsa, diğer ortaklar bu zararı da tazmin etmek zorundadır.

TBK m.627 hükmü sadece yönetici ortaklar hakkında uygulanmaz; muayyen bir işin yapılması hakkında kendisine yetki verilmiş bulunan ve hatta böyle bir yetkisi olmaksızın hareket eden ortaklar hakkında da geçerlidir. Ancak bu son halde, yetkisi olmadan muamelede bulunan

ortak, ancak şirket bu suretle zenginleşmiş olduğu takdirde ve bu oranda dava hakkını haiz olmalıdır.

TBK m.627/2'ye göre de, "*ortaklığa avans olarak para veren ortak*", verdiği avansın kendisine ödenmesini isteyebileceği gibi, "*verdiği günden başlamak üzere*", verdiği avans için "*faiz*" de isteyebilir; istenecek faiz, sözleşmede aksine hüküm yoksa kanuni anapara faizidir.

Şirket işlerini görmek, yönetici ortak için hem hak hem de vazifedir. Şirket sözleşmesinde ayrıca öngörülmedikçe veya daha sonra alınacak bir kararla belirlenmemişse, şirket işlerini gören yönetici ortağa, emeğinin karşılığının verilmesi gerekmez; şirketin kazancına katılır. Bununla birlikte, yönetici olmayan, yükümlü olmadığı halde ortaklık işleri için emek sarf etmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir (TBK m.627/3).

2- Şahsi Nitelikteki İlişkiler

Adi şirketlerde ortakların şahsi nitelikteki ilişkileri; yönetim hakkı, inceleme hakkı ve rekabet yasağına tâbi olmaları şeklinde belirtilebilir.

a) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkı

Şirketin yönetimi, şirketin amacının elde edilmesi maksadıyla tüm iş ve işlemlerin yapılmasıdır. Adi şirkette ortak amaç, ortakların müşterek gayret ve vasıtaları ile gerçekleşeceğinden, şirketin yönetimi ortakların hem hakları hem de görevleridir.

aa) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti

Yukarıda kısmen dahi olsa belirtildiği gibi, TBK m.630/1'e göre *Kanunun bu bölümünde (m.620-645) veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesi hükümlerine tâbidir*".

"*Ortaklığı yönetme yetkisi olmayan bir ortağın, ortaklığın işlerini görmesi veya bu yetkiye sahip ortağın yetkisini aşması hallerinde, vekâletsiz iş görmeye ilişkin hükümler uygulanır*" (TBK m.630/2).

Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur (TBK m.628/3).

Kanun koyucu gerek TBK m.630'da gerek TBK m.628/3'de "*yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkileri*" düzenlemiş; vekâlet sözleşmesi hükümlerine tâbi tutmuştur. Yönetim yetkisinin, ortaklardan

birine veya birkaçına değil de üçüncü bir kişiye verildiği halde de (TBK m.625/1).aynı hükümlerin cari olması gerekir

bb) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı

TBK m.625'e göre yönetim yetkisi, şirketin amacının elde edilebilmesi için gerekli *olağan iş ve işlemleri ile sınırlıdır*. Olağan iş ve işlemler dışındaki iş ve işlemlerin yapılabilmesi (gecikmesinde sakınca olanlar hariç), bütün ortakların oy birliğine bağlıdır.

Bu hükme nazaran, adi şirketlerin yönetimi, ortak amaca erişmek için ortaklar arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, şirketin olağan ve olağanüstü işlerinin yürütülmesidir. Adi şirketlerde, sözleşme serbestîsi gereği, yönetim işleri hakkında bir düzenleme yapılmışsa, yönetim bu hükümlere göre; yönetim işleri hakkında bir düzenleme yapılmamışsa yönetim, olağan ve olağanüstü işler ayrımına göre yapılır.

aaa) Olağan İşlerde Yönetim Yetkisi

Adi şirketlerde *olağan işler*, olağanüstü işler dışında kalan ve şirketin amacına uygun olarak faaliyette bulunabilmesini sağlayacak, ortak gayenin elde edilebilmesi için zaruri olan iş ve işlemlerdir.

Adi şirketlerde olağan işlerin yönetimi, şirket sözleşmesi veya "*ortaklığın kararı*" (TBK m.624) ile yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklara aittir (TBK m.625/1). Bu halde ferdi yönetim esastır; *sözleşmede* ya da *kararda* aksi belirtilmediği müddetçe, her ortağın diğer ortakların katılımı olmaksızın, şirketin olağan işlerini yapma hakkı vardır. Ancak, şirketi yönetmeye yetkili her ortak, tamamlanmasından önce bu işleme itiraz etmek suretiyle (veto hakkı), bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.

bbb) Olağanüstü İşlerde Yönetim Yetkisi

Kanun koyucu, adi şirketlerde olağanüstü işlerden bahsetmiş, ancak olağanüstü işlerin ne olduğunu belirtmemiş, sadece "*ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlemlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oy birliği gereklidir*" (TBK m.625/3) şeklinde bir ifade kullanmıştır.

TBK m.630/1 gereğince, "*Kanunun bu bölümünde (m.620-645) veya ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesi hükümlerine tâbi*" oldukları için, olağan ve olağan üstü işlerin tayininde,

vekâlete ilişkin TBK'nin "*vekâletin kapsamı*"nı düzenleyen 504'üncü maddesi esas alınabilir.

TBK m.504'e göre, "*Vekâletin kapsamı sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir*" (TBK m.504/1). "*Vekâlet, özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar*" (TBK m.504/2). "*Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflâsın ertelenmesini ve konkordato talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz*" (TBK m.504/3).

TBK m.630'un yaptığı yollama sebebiyle TBK m.504'ün uygulanması halinde, adi şirketlerde olağan işleri belirlemedeki kıstas, "*görülecek işin niteliği*"dir. Yönetici ortak, üstlendiği işin görülmesi için gerekli olan hukuki işlemleri, olağan işlerden sayıldığı için, yapabilecektir.

Buna karşılık yönetici ortağın özel yetki alması gereken (olağanüstü) işler de vardır. Bu haller, TBK m.630'un yaptığı atıf dolayısıyla TBK m.504/3 gereğince belirlenmiş; yönetici ortağın "*özel olarak yetkili kılınmadıkça dava açamayacağı, sulh olamayacağı, hakeme başvuramayacağı, iflâs, iflâsın ertelenmesi ve konkordato talep edemeyeceği, kambiyo taahhüdünde bulunamayacağı, kefil olamayacağı, taşınmazı devredemeyeceği ve bir hak ile sınırlandıramayacağı*" kabul edilmiştir.

Bu şekilde bir kabulün, adi şirketin mahiyeti ile bağdaşmadığı, bu sebeple TBK m.630'un yaptığı atıf nedeniyle TBK m.504/3'ün uygulanması yerine, TTK'nin kollektif şirkete ilişkin 223'üncü maddesinin uygulanmasının daha isabetli olacağı da savunulmaktadır. Bu görüşü savunan müellifler bilhassa, kambiyo taahhüdünde bulunulmasının (poliçe, bono, çek) adi şirketlerin her zaman yapmak zorunda bulunduğu işlerden olduğu, bir kambiyo taahhüdünde bulunmak için her zaman karar alınması gerekliliğinin savunulmasının doğru olmadığını ifade etmektedirler.

Kanaatimizce, olağanüstü işleri tespitte, TBK m.630'un yaptığı yollama nedeniyle, TBK m.504'ün uygulanması daha isabetli olur. Zira kanun koyucu TBK m.504'e yollama yaparken, TTK m.223'e herhangi bir atıfta bulunmamıştır. Kanunun atıf yaptığı bir müessese varken, atıf yapmadığı bir hususta, müessese benzerliğinden istifade ederek, atıf yapılmayan bir müessese hükmünden ne kadar istifade edilebilir?

Kaldı ki, adi şirketlerde temsil müessesesi ile vekâlet sözleşmesi hükümleri nazara alındığında böyle bir zorlamaya da gerek olmadığını düşünüyoruz. Zira "*vekil özel yetki gerektiren işi yetki olmadan yapmış ise müvekkilin sonradan vereceği icazet ile bu yetki eksikliğinin giderilmesi mümkündür*"[101].

Bunun yanında, adi şirket yöneticisi temsil yetkisini, TBK m.637'ye göre ya doğrudan ya da dolaylı temsil suretiyle kullanır. Yönetici, özel yetki gerektiren işi yetkisi olmadan yapmış ise, yetkisiz temsil söz konusu olacağından bu ilişkide yetkisiz temsile ilişkin hükümler uygulama alanı bulur (TBK m.46).

Adi şirkette, *olağanüstü işleri* yönetici ortak veya ortaklar yapamaz; *bütün ortakların oy birliği gerekir*. Sözleşmede kararların oy çokluğu ile alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir (TBK m.624).

Hal böyle olmasına karşın, *gecikmesinde sakınca olan olağanüstü işleri* yönetici ortaklardan her biri yapabilir. Ancak kanaatimizce, diğer ortakların katılımı olmadan yapılan bu işlemlerde dahi, yetki eksikliğinin giderilmesi için *diğer ortakların icazetinin alınması* gerekir.

cc) Yönetim Hakkının Kazanılması

Yönetim, sözleşme ya da kararla yalnız bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça; bütün ortaklar, "*ortaklığı*" yönetme hakkına sahiptir (TBK m.625/1). Hükümden de anlaşılacağı üzere yönetim hakkı; sözleşme, ortaklar kararı yahut kanun gereğince kazanılmaktadır.

Bu halde asıl olan ferdi yönetimdir; şirket, ortakların tümü veya bir kaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir. Ancak şirketi yönetmeye yetkili her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle bu işlemin yapılmasını engelleyebilir (TBK m.625/2).

Bunun yanında, şirket sözleşmesinde veya sonradan, ortakların tamamının müştereken hareket etmeleri de kararlaştırılmış olabilir. Bu halde şirketin yönetimi için karar alınması gerekir. "Ortaklığın kararları bütün ortakların oy birliğiyle alınır" (TBK m.624/1). Ancak şirket sözleşmesinde kararların oy çokluğu ile alınacağı kararlaştırılabilir.

---

[101] **Becker, H.,** Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch Bd. V. Obligationenrecht, 2. Abteilung, Bern, 1934, Art. 396, N.7.

"*Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir*" (TBK m.624/2). Bu halde katılma payı miktarına bakılmaz; katılma payı ne olursa olsun, her ortağın bir oyu vardır.

Ancak ortaklar, şirket sözleşmesiyle veya daha sonra alacakları bir kararla, şirketin yönetimini ortaklardan birine, birkaçına veya üçüncü bir kişiye bırakabilirler (TBK m.625/1). Şirketin yönetiminin birden fazla ortağa veya birden fazla üçüncü kişiye bırakılması halinde de esas olan "*ferdi yönetim*"dir; yönetici ortaklardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir. Ancak yönetim yetkisine sahip olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir; bu halde işlemin yapılması için ortakların karar alması şarttır (TBK m.625/2, 624).

Adi şirketlerin yönetiminde ferdi idare esas olmakla birlikte, birden ziyade ortağın birlikte hareket etmesi de öngörülebilir; bu hâlde birlikte yönetim söz konusu olur. Birlikte yönetimde, şirket ortaklarının yapılan muameleyle bağlı olmaları, muameleyi diğer ortakları temsilen birlikte yapmalarına bağlıdır.

Adi şirkete, gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de ortak ve bu bağlamda yönetici olabilirler. Bu halde adi şirketin ortağı tüzel kişi, yönetim yetkisini, kendi organları vasıtasıyla kullanır.

dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması

Adi şirketlerde yönetim, ortaklar için hem hak hem de yükümlülüktür. Bu hususu nazara alan kanun koyucu, "*yönetim yetkisinin kaldırılması ve sınırlandırılması*"nı muayyen esaslara tâbi tutmuştur.

aaa) Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması

TBK m.629/1'e göre, "*Ortaklık sözleşmesiyle ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi, haklı bir sebep olmadıkça diğer ortaklarca kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz*". Bu hükme nazaran, şirket sözleşmesi ile ortaklardan birine verilen yönetim yetkisi ancak haklı bir sebebe dayanarak kaldırılabilir ve sınırlandırılabilir.

Haklı sebepler TBK m.629/3'de örnek olarak gösterilmiştir. "*Haklı sebepler, özellikle yönetici ortağın görevini aşırı ölçüde ihmal etmesi veya iyi yönetim için gerekli olan yeteneği kaybetmesi durumlarında vardır*" (TBK m.629/3).

"*Ortaklık sözleşmesiyle yetkinin kaldırılmayacağına ilişkin bir hüküm bulunsa bile, haklı sebep varsa, diğer ortaklardan her biri yönetim yetkisini kaldırabilir*" (TBK m.629/3). Buna göre yönetici ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özeni göstermiyorsa (TBK m.628/1), şirket sözleşmesinde yetkinin kaldırılamayacağına dair bir hüküm bulunsa bile; her ortak tek taraflı bir irade beyanıyla, yönetim yetkisini kaldırabilir veya sınırlandırabilir (TBK m.629/2). Yönetim yetkisinin kaldırılmasına veya sınırlandırılmasına ilişkin hak, bozucu yenilik doğuran bir haktır.

bbb) Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması

Yönetim hakkının geri alınması, TBK'de açık şekilde düzenlenmemiştir. Zira Kanunda sadece yönetim hakkının adi şirket sözleşmesi ile verilmesi hali ile ilgili olarak yasal bir düzenleme yapılmış; buna karşılık yönetim hakkının bir karar ile verilmesi durumunda, bunun kaldırılması veya sınırlandırılmasına dair açık bir düzenleme sevk edilmemiştir.

Bununla birlikte yönetim hakkının bir kararla verilmesi durumunda bu yetkinin kaldırılması veya sınırlandırılması hususunda adi şirket sözleşmesinde çeşitli düzenlemeler kararlaştırılabilir. Yönetim hakkının verilmesi ve kaldırılması ile sınırlandırılması konularında Kanunda bu hususta emredici mahiyette düzenleme bulunmadığından, şirket sözleşmesinde ayrıca bir düzenleme olmadığı müddetçe verildiği şekilde geri alınması uygun olur.

ccc) Kanun Hükmü Gereğince Kazanılan Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması

Yönetim hakkının kanun gereği kazanıldığı hallerde yönetim hakkının diğer ortaklar tarafından kaldırılması veya sınırlandırılması mümkün olmalıdır. Bu hususta sözleşmede ayrıca bir hüküm yoksa yönetim hakkının kaldırılmasına ilişkin kararların, oybirliğiyle alınması gerekir. Bununla birlikte sözleşmede kararların oyçokluğuyla alınacağı belirlenmişse, yönetim yetkisi oyçokluğuyla alınır, ancak bu halde çoğunluğun ortak sayısına göre belirlenmesi gerekir (TBK m.624/2). Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde haklı bir sebep varsa bu sebebe istinaden yönetim yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması istenebilir.

ee) Adi Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması

aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü

Yönetim yetkisi, şirketin olağan işlemlerini kapsar. Şirketin olağan işlemleriyle kastedilen, şirketin işletme konusunu gerçekleştirmek amacıyla sürekli şekilde icra ettiği gündelik iş ve işlemleridir. Şirketin olağan işlemlerinin yerine getirilmesinde yönetici ortaklardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir. Diğer bir anlatımla yönetim hakkı, her bir ortağa münferiden tanınmıştır.

Bununla birlikte yönetim yetkisinin iki halde sınırlandırılmış olduğu görülmektedir: Bunlardan ilki *olağan dışı işlemler*; diğeri *itiraz hakkıdır*.

Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların *oybirliği* gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkili kılınmıştır (TBK m.625).

Yönetici ortağın işlemlerine itiraz edilmesi halinde de bu ortak, münferiden kendisine tanınmış olan yönetim hakkını kullanamayacaktır.

bbb) İtiraz

Adi şirket, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak *şirketi yönetmeye yetkili olan her ortak*, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir (TBK m.625/2). Yönetici olmayan ortağa ise itiraz hakkı tanınmamıştır.

Kanun koyucu, yönetim yetkisine sahip ortağın, yapılacak işleme itiraz etmesine, işlemin dış ilişkide icrasının önlenmesi hukuki sonucunu bağlamıştır Yapılacak itiraz, dış ilişkide işlemin icrasını durdurduğu için, itiraza rağmen yapılan işlem, *yetkisiz temsil hükümlerinin* uygulanmasını gerektirecektir[102].

İtirazın haksız olması dahi, işlemin icrasına engel oluşturur. Bu halde işlemine itiraz edilen yönetici ortağın nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususunda Kanunda açık bir hüküm sevk edilmemiştir. Bununla

---

[102] **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 40.

birlikte *ratio legis* yönetici ortağın, konuyu ortakların tümüne götürmesine imkân tanımaktadır[103].

b) Adi Şirketlerde İnceleme Hakkı

Adi şirket, iki ya da daha fazla kişinin "*ortak amaca erişmek üzere*" oluşturdukları bir kişi birliği olduğu içindir ki; *ortak amaca erişmek*" bütün ortakları yakından ilgilendirir. Şirketin ortak amacının gerçekleşmesi bütün ortakları yakından ilgilendirdiği için, şirket işlerinin bu amacın elde edilmesini temin edecek surette, sözleşme ve kanun hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini incelemek; yönetici olsun olmasın her ortağın hakkıdır (TBK m.631/1). Bu husus, ortak amaca erişmek için birleşmenin üstlenildiği şirket sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri olduğundan; "*aksine sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür*" (TBK m.631/2).

Şirket işlerini *inceleme hakkı*, şirketin işleyişi hakkında *bilgi alma, defter ve kayıtlarını inceleme*, bunlardan *örnek alma* ve *mali durumu hakkında özet çıkarma* hakkını kapsar.

İnceleme hakkını ortadan kaldıran veya sınırlandıran sözleşmeler kesin olarak hükümsüzse de, bu hakkın nasıl kullanılacağı kararlaştırılabilir; inceleme hakkını sınırlandırılması mahiyetinde olmadığı sürece, inceleme hakkının kullanılmasına ilişkin bu şekildeki bir sözleşme hükmü geçerlidir.

İnceleme hakkı, ortak tarafından *bizzat kullanılması gereken* bir haktır; bu hususta yardımcı eleman kullanılamaz. Bununla birlikte, şayet incelemenin mahiyeti özel uzmanlık gerektiriyorsa, mesleği gereği sır saklamakla yükümlü bulunan bir mali müşavirden, bir avukattan yardım alınabilmelidir[104].

Şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın inceleme hakkı yoktur. Ancak bu ortaklar, henüz ortak oldukları dönemde başlanmış ve tamamlanmamış işler hakkında bilgi alma hakkına; somut olayın özelliklerine göre de, sadece bu işlerle sınırlı olarak inceleme hakkına sahiptir[105].

Mirasçıların inceleme hakkını, şirket sözleşmesindeki hükme göre değerlendirmek gerekir. Şirket sözleşmesinde, şirketin mirasçılarla devamına ilişkin hüküm varsa; mirasçıların inceleme hakkını kabul etmek

---

[103] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 89.
[104] **Handschin / Vonzun**, Art. 541, N. 15-17.
[105] **Handschin / Vonzun**, Art. 541, N.4.

gerekir. Şayet şirketin mirasçılarla devamına ilişkin bir hüküm yoksa ve şirketin kalan ortaklarla devam edeceği kararlaştırılmışsa; mirasçıların TBK m.631 anlamında doğrudan inceleme hakkının olmadığı düşünülmelidir[106]. Bu halde mirasçılar, tasfiye payını alacaklarından, yalnızca tasfiye payının hesaplanmasını dava edebilirler.

İnceleme hakkı sınırlandırılan veya kullandırılmayan ortak, hakkının kullanılmasını temin maksadıyla mahkemeye müracaat edebilmelidir. Eda davası niteliğinde olan bu dava sonucunda ortağa inceleme hakkı tanınabilir.

c) Adi Şirketlerde Rekabet Yasağı

Şirketlerde esas olan, ortak amaca ulaşmak olduğu için, ortaklardan herhangi birinin bu amacı tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmesi, sözleşmeye aykırılık teşkil eder; ortakların, kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici ve zarar verici işleri yapması yasaklanmıştır (TBK m.626).

aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti

Rekabet yasağı, sadakat yükümlülüğü ve *affectio societatis* gereğidir. Adi şirket ortaklarının tamamını kapsayan bir yasaktır.

Bu yasak, iç ilişkiyi ilgilendirdiği için *emredici nitelik taşımaz*. Ortakların rekabet yasağına aykırı davranışlara rıza göstermesi ile veya şirketin sona ermesi ile bu yükümlülük de ortadan kalkar[107].

bb) Rekabet Yasağının Kapsamı

Rekabet yasağı, "*sadakat*" borcunun (TBK m.506/2) bir sonucudur. Sadakat borcu, ortak amaca ulaşmak için bir araya gelenlerin gerek sözleşmenin devamı esnasında gerek şirketten ayrıldıktan sonra, kendisine karşı duyulan güvene uygun olarak şirket menfaatini, şirket sözleşmesi ile güdülen amaç çerçevesinde koruması ve kendi menfaatini şirketin menfaatine tâbi kılması yükümlülüğüdür. Başka bir ifadeyle, ortaklar sadakat borcu gereği olarak, şirketin yararına olacak davranışlarda bulunmak ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

Sadakat borcu, ortaklık ilişkisinin nasıl yerine getirileceği konusunda sözleşmede açık bir hüküm bulunmasa ve diğer ortakların

---

[106] **Handschin / Vonzun**, Art. 541, N.6.
[107] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 95a.

herhangi bir talimatı bulunmasa da yine zorunlu olarak ortaya çıkar. Bununla beraber, sadakat borcunun bir sonucu olarak ortaya çıkan "*rekabet yasağı*" emredici mahiyette bir yasak değildir. Ortaklar şirket sözleşmesiyle yahut daha sonra alacakları açık ya da örtülü bir kararla bu yasağı kaldırabilirler; kapsamını ve mahiyetini belirleyebilir, yasağın kapsamını daraltabilecekleri gibi genişletebilirler. Ancak rekabet yasağının genişletilmesi, TMK'nin "*kişiliğin korunması*" hükmü (m.23) gereğince, "*özgürlüklerinden vazgeçme veya onları hukuka ya da ahlaka aykırı olarak sınırlama*" mahiyetinde olmamalıdır; böyle bir sınırlama TMK m.2'ye aykırılık teşkil eder, hukuk düzeni bu tür bir sınırlamayı korumaz.

cc) Rekabet Yasağının Yaptırımı

Kanun koyucu, TBK m.626'da "*rekabet*" yasağını hükme bağlamasına karşın, bu yasağa aykırı davranışın müeyyidesini öngörmemiştir. Kanaatimizce bu halde TTK'de düzenlenen kollektif şirket ortaklarının rekabet yasağına ilişkin 231'inci maddedeki düzenlemeden istifade edilebilir. Gerçekten de diğer ortakların haklı sebeplere binaen şirketin feshini talep etmeleri (TBK m.639/b.7) yerine, TTK m.231'de olduğu gibi, rekabet yasağına aykırı davranan ortaktan *tazminat istenmesi* veya *tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işlerin şirket adına yapılmış sayılması*; *bu işler üçüncü kişilerin hesabına yapılmışsa, işlerden doğan menfaatin şirkete bırakılması*, şirket ve ortakların menfaatine daha uygun olur.

dd) Zamanaşımı

Rekabet yasağına aykırılık halinde kollektif şirketler (TTK m.231) ve anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için (TTK m.396) daha kısa zamanaşımı sürelerine (3 ay-1 yıl) tâbi tutulmasına karşın adi şirketlerde rekabet yasağına aykırı davranılması halinde açılabilecek davalarla ilgili olarak kanun koyucu suskun kalmıştır. Bu durumda TBK m.147/b.4'te düzenlenen bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacakların beş yıllık zamanaşımına tâbi olacağına ilişkin hükmün rekabet yasağı için de uygulanabileceği akla gelirse de; rekabet yasağının mahiyeti nazara alındığında uzun süre suskun kalan ortağın

bu zamanaşımı süresinden yararlandırılması TMK m.2 ve kanun koyucunun genel politikasına uygun olmaz.

C) ADİ ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ

1) Adi Şirketlerde Temsil

Adi şirketlerde tüzel kişilik bulunmadığı için, ticaret şirketlerinden farklı olarak organsal temsilden söz edilemez. Dolayısıyla adi şirketlerde ortaklar, TBK hükümleri gereğince temsil edilir. Bununla birlikte TBK m.637 hükmü, adi şirketlerde temsili ayrıca ve açıkça düzenlediğinden, bu hükümde düzenlenmeyen hususlarda TBK m.40 vd. hükümlerine başvurulur.

"Kendi adına ve ortaklık hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi alacaklı ve borçlu olur" (TBK m.637/1).

Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar (TBK m.637/2). Bu halde doğrudan temsil hükümleri uygulanır. Adi şirketlerde temsil konusunda TBK m.40/2, c.2 hükmüne benzer bir düzenlemeye yer verilmediğinden, temsil yetkisini kullanan ortağın, diğer ortaklar adına işlem yaptığını üçüncü kişiye bildirmemesi halinde, sadece işlemi yapan ortağın sorumlu olacağı; diğer tüm ortakların sorumlu tutulamayacağı kabul edilir[108]. Diğer ortakların sorumluluğu, ancak işleme icazet vermeleri halinde söz konusu olabilir.

Bununla birlikte kanun koyucu TBK m.637/3 hükmünde bir karine öngörmüş; *"Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi var sayılır"* diyerek iyi niyetli üçüncü kişileri korumak amacıyla bir hüküm sevk etmiştir. Bununla birlikte temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine ilişkin yetkinin, bütün ortakların *oybirliğiyle* verilmiş olması ve yetki belgesinde bu hususun açıkça belirtilmiş olması şarttır.

---

[108] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 99a.

a) Adi Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması

Adi şirketlerde temsilci sıfatı, Kanun gereği (TBK m.637/3), adi ortaklık sözleşmesi ile veya şirketin alacağı bir karar ile olmak üzere üç şekilde kazanılabilir.

Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi kanunen var sayılır. Dolayısıyla temsilci sıfatının Kanun gereği kazanıldığı hallerde diğer ortaklar bu durumun aksini ispat ederek sorumluluktan kurtulamazlar[109].

Temsil yetkisi, kararda temsil yetkisinin verildiği açıkça belirtilerek veya zımnen de verilebilir. Hatta adi şirkette ortaklar, kendi adlarına yapılan işleme icazet vererek de temsil yetkisi bahşedebilirler.

b) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

Adi şirketlerde temsil yetkisi, bir sürenin öngörüldüğü hallerde sürenin sona ermesi ile veya adi şirket sözleşmesi veya karar ile verildiği hallerde bu işlemlerin değiştirilmesi veya kaldırılması ile ya da Kanunla kazanılan hallerde haklı sebeple idare hakkının kaldırılması yoluyla sona erebilir. Nihayet adi şirketin sona ermesi de temsil yetkisinin sona ermesi neticesini doğurur.

Adi şirketlerde temsil yetkisi, TBK m.43 hükmü gereğince, aksi kararlaştırılmadıkça veya işin özelliğinden anlaşılmadıkça, temsil olunanın veya temsilcinin ölümü, gaipliğine karar verilmesi, fiil ehliyetini kaybetmesi veya iflas etmesi durumlarında da sona erer.

c) Adi Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı

Adi şirketlerde temsil yetkisinin kapsamı, temsil yetkisinin hukuki işlemle (adi şirket sözleşmesi veya karar ile) verildiği hallerde bu işlemin kapsamına göre belirlenir. Temsilin haksız fillerde uygulanmadığına ilişkin genel kural, adi şirketlerde de geçerlidir.

Temsil yetkisinin Kanun gereği kazanıldığı hallerde ise yönetim yetkisinin kapsamına uygun olarak temsil yetkisinin kapsamı, olağan işlemler ile sınırlı şekilde belirlenir.

---

[109] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 99c.

Temsil yetkisinin, olağan işlemlere kıyasla daha dar şekilde verildiği hallerde ise bu husus, üçüncü kişilere karşı ancak bildikleri takdirde (*müspet vukuf*) ileri sürülebilir[110].

Temsil yetkisinin kapsamı aşılarak veya yetkisiz şekilde diğer ortaklar adına işlem yapılan hallerde TBK m.46 vd.'daki yetkisiz temsil düzenlemeleri uygulanır.

d) Temsilin Sonuçları

Ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen şeyler, alacaklar ve ayni haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde bütün ortaklara ait olur (TBK m.638/1). Alacaklılar bu malvarlığına doğrudan müdahale edemezler. Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın şahsi alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilir (TBK m.638/2).

2) Adi Şirketin ve Ortakların Borç ve Taahhütlerden Sorumluluğu

a) Adi Şirketin Sorumluluğu

Adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığından, ortakların borç ve taahhütlerinden herhangi bir sorumluluğu söz konusu değildir; bu sebeple adi şirket aleyhine dava ve takip yürütülemez. Adi şirketle ilgili davalarda ve takiplerde ortaklar adına veya aleyhine dava ve takip işlemleri yürütülür. Nihayet adi şirket iflas ettirilemez. Şartları varsa adi şirket ortaklarının iflası istenebilir.

b) Ortakların Sorumluluğu

Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi çerçevesinde üstlendikleri borçlardan ve taahhütlerden, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu olurlar (TBK m.638/3). Ortakların sorumluluğu, birinci dereceden ve sınırsızdır.

Adi şirket ortakları, bir ortağın veya yönetici/temsilci sıfatını haiz kişinin haksız fiillerinden sorumlu değildir[111]. Bununla birlikte birden çok kişi birlikte bir zarara sebebiyet verdikleri veya aynı zarardan çeşitli sebeplerden dolayı sorumlu oldukları takdirde, haklarında müteselsil sorumluluğa ilişkin hükümler uygulanır (TBK m.61).

---

110 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 99f.

111 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 100a.

Adi şirkete yeni giren bir ortak, girdiği tarihe kadar doğan borçlardan, diğer ortaklarla birlikte veya onu temsilen borç altına girilmiş olmadığından, sorumlu değildir. Benzer bir gerekçeyle şirketten ayrılan ortak da ayrılma anından sonra doğan borçlardan sorumlu olmaz.

VII) ADİ ŞİRKETLERDE OY HAKKI VE KARAR

Adi şirketlerde her ortağın bir adet oy hakkı bulunur. Bu esasa aykırı düzenlemelerin kararlaştırılıp kararlaştırılamayacağı konusunda Kanunda açık bir düzenleme sevk edilmemiştir. "*Adi şirket kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir*" (TTK m.624). Bu hüküm nazara alındığında, her ortağın bir oy hakkının bulunmasına ilişkin düzenlemenin aksine, örneğin şirkete getirilen sermaye oranında oy hakkına sahip olunacağına ilişkin sözleşme düzenlemelerinin kararlaştırılamayacağı sonucuna varabiliriz.

VIII) ADİ ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK

Kanun koyucu, 818 sayılı Borçlar Kanununda, mehaz İsviçre Borçlar Kanununda (Art. 542) olduğu gibi, ortaklar arasındaki değişikliklere yeterince temas etmemiş; sadece 532'nci maddede "*Yeni şerik kabulü ve şirkete iştirak*" başlığı altında, adi şirkete yeni ortak alınması ile ortaklık payının devrini düzenlemiş; adi şirketten çıkma ve çıkarılma konuları ile yeni bir ortağın şirkete girmesi, çıkma ve çıkarılmanın sonuçlarını hükme bağlamamıştı.

Bu eksiklikleri gidermek maksadıyla olacak ki, Alman Medeni Kanunu BGB §§ 736-740'dan mülhem olarak, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa dört yeni madde ilâve edilmiş; "*ortaklıktan çıkma ve çıkarılma*" özel olarak hükme bağlanmıştır.

Bu haliyle 818 sayılı Borçlar Kanununun 532'nci maddesinin kenar başlığında kullanılan "*VII. Yeni şerik kabulü ve şirkete iştirak*" şeklindeki ibare, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 632'nci maddesinde "*1. Yeni ortak alımı ve alt katılım*" şeklinde ifade edilmiş; ancak Kanunda ortaklık yapısındaki değişiklikler kapsamında olmak üzere, çıkma ve çıkarılma gibi başkaca konuların düzenlenmesi söz konusu olduğu için "*VII. Ortaklar Arasındaki ve Ortaklık Yapısındaki Değişiklikler*" şeklinde bir üst başlık oluşturulmuştur.

Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler, şirkete *yeni ortak alımı* ile *ortaklıktan çıkma* ve *çıkarılmayı* ifade etmek maksadıyla kullanılmıştır.

D) ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI VE PAYIN DEVRİ

Türk Borçlar Kanununun 632'nci maddesinde iki konu ele alınmış; birinci fıkrada "Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır" (**yeni ortak alımı**) diyen kanun koyucu ikinci fıkrada, "Ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz" (**alt katılım**) şeklinde bir düzenleme getirmiştir.

Şirkete yeni ortak alınması, payını devretmek isteyen ortak ile payı devralmak isteyen üçüncü kişi arasında yapılan devir sözleşmesine, diğer ortakların onay vermesine bağlıdır. Yukarıda izaha çalıştığımız şekilde "*ortakların onayı*" olmadan payı devralan, adi şirkete ortak olamaz (TBK m.632/2).

1) Şirkete Yeni Ortak Alınması

Adi şirket, ortakların şahsına dayalı bir kişi birliği olduğu için, Türk Borçlar Kanununun 632'nci maddesinin birinci fıkrasında; *"Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına"* bağlı tutulmuştur. Bu hüküm Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesinde yer alan "*Ortaklığın kararları*" hükmüyle uyumludur. Türk Borçlar Kanununun bahse konu hükmüne göre, "*Ortakların kararları, bütün ortakların oybirliği ile alınır*".

Buna göre, şekil bakımından şirkete yeni bir ortak alınması, ya önceki şirket sözleşmesinin feshi ile yerine yeni bir şirket sözleşmesinin yapılması veya bütün ortakların onayının alınması suretiyle olur.

Kanun koyucu, Türk Borçlar Kanununun sistemi içinde, yeni bir ortağın şirkete alınması hâlinde, yeni bir şirketin kurulmadığını, mevcut şirketin yeni ortaklarla devam edeceği ilkesini kabul etmiştir; ancak bunun aksi kararlaştırılabilir. Bir diğer ifadeyle, evvelce kurulmuş şirket feshedilerek, aralarında yeni bir şirket kurabilirler.

2) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınması

Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler, yeni bir ortağın şirkete kabulü şeklinde olabileceği gibi; ortaklardan birinin tek

taraflı olarak bir üçüncü kişiye ortaklıktaki payını kısmen veya tamamen devretmesi suretiyle de gerçekleşebilir. Ortaklık payının kısmen devredilmesinde, devreden ortağın ortaklık sıfatı devam ederken; ortaklık payının tamamen devredilmesinde, devreden ortağın ortaklık sıfatı sona erer.

a) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Şirkete Yeni Ortak Alınmasının Şartları

Ortaklık payının ister kısmen ister tamamen devrinde, bu devrin geçerli olması; devralanın ortak sıfatını kazanabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bunlar:

aa) Ortaklık payını devreden ile devralan arasında, ortaklık payının kısmen veya tamamen devredilmesine ilişkin bir "devir sözleşmesinin" yapılması

Adi şirketlerde ortaklık payının devri; ortaklık sıfatına bağlı birtakım hak ve borçların devrini kapsar. Ortaklık sıfatına bağlı birtakım hak ve borçların aktif ve pasifleriyle devri; TBK m.202'de hükme bağlanan "*malvarlığının devri*" mahiyetindedir.

Bir malvarlığını (ortaklık payını) aktif ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki (ortaklık payındaki) borçlardan sorumlu olur. Bununla birlikte, *iki yıl süreyle* önceki borçlu (devreden) da devralanla birlikte müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır[112].

Bu hâliyle, ortaklık payının kısmen veya tamamen devredilmesine ilişkin "*devir sözleşmesi*" herhangi bir şekil şartına bağlı da değildir.

bb) Ortaklık payının kısmen veya tamamen devri suretiyle şirkete yeni ortak alınmasında oybirliğinin aranması

Türk Borçlar Kanununun 632'nci maddesinin birinci fıkrasında, *"Ortaklığa, yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına"* bağlı tutulduğu gibi; *ortaklık payının kısmen veya tamamen devri* de bütün ortakların rızasına bağlanmıştır. Ortaklardan birinin, bütün ortakların

---

[112] Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar. Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden doğan sonuçlarla özdeştir. Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe, iki yıllık süre işlemeye başlamaz (TBK m.202).

rızası olmaksızın tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak etmesi veya payını devretmesi hâlinde bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz (TBK m.632/2). Bu hüküm yukarıda da izah edildiği gibi, Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesinde yer alan "*Ortaklığın kararları*" hükmüyle uyumludur.

Burada üzerinde durulması gereken konu, Türk Borçlar Kanununun "*kararlar*" ile ilgili kuralına istisna getiren ikinci fıkra hükmünün "*payın devri suretiyle yeni ortak alınmasında*" da uygulanıp uygulanamayacağı meselesidir.

Bilindiği gibi, Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, "*sözleşmede kararların oy çokluğu*" ile de alınabileceği hükme bağlanmış; bu hâlde "*oy çokluğunun*" ortak sayısına göre belirlenmesi gerektiği, emredici olarak düzenlenmiştir.

Buna göre, sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, oy çokluğu ile payın devri suretiyle şirkete yeni ortak alınması mümkün olabilecek midir?

Kanaatimizce bu soruya olumlu cevap verilmesi; bir diğer ifadeyle, sözleşmede hüküm bulunması hâlinde, tüm ortakların oy çokluğu ile şirkete, payın devri suretiyle yeni ortak alınabileceğinin kabulü gerekir[113].

Adi şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle "*oy çokluğu*" ile yeni ortak alınması mümkün olabileceği gibi; şirket sözleşmesine konulacak bir hükümle, ortağın payının serbestçe devre konu oluşturabileceğinin de kabulü gerekir.

Bu ihtimalde, sözleşmede ortaklık payının "*muayyen bir şahsa*" devredilmesi öngörülmüşse; diğer ortaklar buna itiraz edememeli, şirket, sözleşmede öngörülen ortakla devam etmelidir. Buna mukabil, sözleşmede muayyen bir şahıs öngörülmemiş, sadece "*devir serbestîsi*" tanınmış ve ortak bu sözleşme hükmüne istinaden, ortaklık payını sözleşmede öngörülmeyen bir üçüncü şahsa devretmişse; ortakların onayı olmadan yapılan bu devir geçerli olacak mıdır? Kanaatimizce bu halde de devrin geçerli olduğu kabul edilmeli; ancak diğer ortaklar, "*haklı sebeple*" Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesine göre şirketin feshini isteyebilmelidir.

---

[113] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 96a. İsviçre Hukuku'ndaki değerlendirme için bkz. **Handschin / Vonzun**, Art. 542, N.6 vd.

b) Ortaklık Payının Devri Suretiyle Yeni Ortağın Şirkete Girmesinin Usulü

Şirket sözleşmesinin birleşme sözleşmelerinden olduğu kabul edildiğinde, şirkete ortaklık payını devralmak suretiyle girmek isteyen kişinin, diğer ortakların daha evvel kendi aralarında akdettiği *adi şirket sözleşmesine* katılması gerekir. Bir diğer ifadeyle, ortaklık payını devretmek isteyenle ortaklık payını devralmak isteyen arasında yapılan *devir sözleşmesi*, ortak sıfatının kazanılmasında yeterli değildir; ortaklık payını devralmak isteyenin ayrıca daha evvel yapılan adi şirket sözleşmesine katılması gerekir. *Payı devralmak isteyen kişinin sözleşmeye katılması özel bir şekle tâbi değildir;* diğer ortakların onayı yeterlidir. Onayın bir karar şeklinde ittihaz edilmesi gerekir; bu karar sözleşmede aksi belirtilmemişse oybirliği ile alınır (TBK m.624).

Bununla birlikte, ortak olmak isteyen kişi, devri şekle tâbi bir katılma payı getirmek suretiyle şirkete girmek istiyorsa, katılma payı taahhüdünün şekle uygun bir tarzda yapılması da gerekecektir. Ancak yukarıda da izah ettiğimiz gibi, bu hâlde dahi diğer ortakların onayı ile devri şekle tâbi bir katılma payı getirmek suretiyle ortak olmak isteyen kişi, kanaatimizce ortakların onayı ile ortak sıfatını kazanır; ayrıca taahhüdünü yerine getirmesi istenir.

3) Alt Katılım

Kanun koyucu Türk Borçlar Kanununun 632'nci maddesinin ikinci fıkrasında, *"ortaklardan biri tek taraflı olarak (ortakların rızasını almadan) bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz"* demek suretiyle alt katılımı hükme bağlamıştır.

Kanun koyucu bu düzenlemeyle, *alt katılımın mümkün olduğunu*; ancak diğer ortakların rızası olmaksızın yapılan ortaklık payının devrinin şirkete (diğer ortaklara) karşı ileri sürülemeyeceğini, ortaklık payını kısmen veya tamamen devralan kişinin, adi şirkette ortak sıfatını kazanamayacağını hükme bağlamış; bu devir sözleşmesinin sadece devredenle devralan arasında geçerli olduğunu kabul etmiştir (TBK m.632/2).

Bu şekliyle alt katılım, adi şirkete ortak olma hakkını vermemekte; ortaklık payını diğer ortakların rızası olmadan devralan, sadece devredenin ortağı olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, ortaklık payını diğer

ortakların rızası olmaksızın devralan kişi, adi şirketin ortağı olamamakta; sadece devredenin ortağı olmaktadır. Bu hâliyle "*alt katılım*", payını kısmen veya tamamen devreden ortağın, adi şirketteki ortaklık haklarını birlikte kullanma hakkı veren bir adi şirket sözleşmesi mahiyetindedir. Devralan haklarını ancak kendisiyle sözleşme yapan kişiye karşı ileri sürebilir; diğer ortakların onayı olmadan payı devralan üçüncü kişi adi şirkete ortak olmadığı için, adi şirkete karşı bir talepte bulunamaz; adi şirket ortakları veya alacaklıları da doğrudan kendisine müracaat edemez. Alt katılan, şirketin değil; payını devreden ortağın ortağıdır.

E) ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Adi şirketlerde "*Ortaklıktan Çıkma ve Çıkarılma*", 818 sayılı Borçlar Kanunumuzda yer almamakla birlikte; adi şirketten çıkma ve çıkarılmanın mümkün olduğu kabul edilmekteydi. Kanun koyucu bu eksikliği gidermek maksadıyla, önemli yeni bir düzenlemeyi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa dâhil etmiştir.

1. Genel Olarak

TBK'de adi şirketten çıkma ve çıkarılma aynı maddede düzenlenmiş; "*Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir*" denilmiştir (TBK m.633).

2. Çıkma

Çıkma, adi şirket ortağının, şirketten *kendi iradesiyle* ayrılmasını; ortaklık bağının sona erdirilmesini ifade eder. Çıkma hakkı sözleşmeyle tanınabileceği gibi; sözleşmeyle öngörülmeyen hallerde kanundan doğan sebeplerle de çıkma hakkı kullanılabilir.

a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkma

Sözleşme serbestîsi ilkesi gereğince ortaklara şirketten çıkma hakkı, başlangıçta ortaklık sözleşmesinde öngörülebileceği gibi; sözleşme değişikliği ile de tanınabilir. Bu durumda, sözleşmede öngörülen hâller-

den birinin gerçekleşmesiyle; sözleşmede öngörülen şekle riayet etmek suretiyle şirketten çıkmak mümkündür. Ancak şirketten çıkmak için sözleşmede öngörülen sebeplere dayanılması ve sözleşmede öngörülen şekilde çıkma hakkının kullanılması; çıkma beyanının, ortaklıktan ayrılma iradesini açıkça ortaya koymasına bağlıdır.

b) Kanundan doğan çıkma hâlleri

aa) Diğer ortakların rızasıyla çıkma

Sözleşmede çıkma ile ilgili bir düzenleme olmasa da; diğer ortaklar, şirketten ayrılmak isteyen ortağın ortaklıktan çıkmasına muvafakat edebilirler. Bir ortağın ortaklıktan çıkması, sözleşme değişikliği mahiyetini taşıdığından; aksine hüküm yoksa bütün ortakların rızasına bağlıdır.

bb) Kanun gereğince çıkma

Türk Borçlar Kanununun yukarıda metnini verdiğimiz 633'üncü maddesine göre, sözleşmede *ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm bulunması* koşuluyla, aşağıdaki durumlardan biri gerçekleştiği takdirde ilgili ortağın veya temsilcisinin ya da ölen ortağın mirasçısının ortaklıktan çıkabileceği kabul edilmektedir.

aaa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması

Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması suretiyle ortaklık ilişkisinin sona erdirilmesi; TBK m.639/b.7 ve 640 hükümlerine göre mümkündür. Bu hükümlere nazaran; ***i)*** şirket sözleşmesiyle ortağa tek taraflı olarak şirketi feshi ihbar yoluyla sona erdirme hakkı tanınmışsa veya ***ii)*** haklı bir sebep varsa (TBK m.639/b. 7) yahut ***iii)*** şirket belirsiz süreli olarak kurulmuş ya da ***iv)*** ortaklardan birinin veya birkaçının hayatı boyunca geçerli olmak üzere kurulmuşsa, bir ortak fesih bildiriminde bulunmak suretiyle şirketi sona erdirebilir. İşte bu hallerde ortağın fesih bildiriminde bulunmak suretiyle şirketi sona erdirmesi yerine, ortağın çıkma hakkını kullanabilmesi kabul edilmiştir (TBK m.633).

bbb) Kısıtlanması

Gerçek kişilerde fiil ehliyetinin olumsuz şartı, kişinin "kısıtlı olmaması"; bir diğer söyleyişle, "kişinin fiil ehliyetinin TMK'nın 405 vd. hükümlerinde öngörülen sebeplerden birine dayanılarak mahkeme kararıyla kısıtlanmamış olmasıdır". Kısıtlanmış olan kişinin, kendi

fiilleriyle kendi lehine hak ve aleyhine borç yaratabilme ehliyeti, mahkeme kararıyla kaldırılmış olur. Kısıtlıya, kendisi adına hukuki işlemler yapmak, yani onu üçüncü kişilere karşı temsil etmek üzere bir yasal temsilci atanır.

Bir ortağın kısıtlanması, adi şirketin sona erme sebeplerindendir (TBK m.639/b. 3). Bir ortağın kısıtlanması hâlinde; şirketi sona erdirmek yerine, kısıtlanan ortağın şirketten çıkarılabilmesi de mümkün olabilmektedir. Şirket sözleşmesinde ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm varsa; kısıtlanan ortak, yasal temsilcisi vasıtasıyla TBK m.633'e istinaden çıkma hakkını kullanabilir.

ccc) İflâsı

Adi şirket ortağı, ortaklık faaliyetlerinden dolayı, şartları varsa iflâs edebileceği gibi; ortaklık dışı faaliyetler nedeniyle de iflâs edebilir. Ortağın iflâsı adi şirketin sona erme sebeplerindendir (TBK m.639/b.3). Ortağın bilhassa ortaklık dışı faaliyetlerinden dolayı iflâsı hâlinde, şayet şirket sözleşmesinde ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm varsa; diğer ortaklar iflâs eden ortağın çıkarılmasına karar verebilirler. Bu durumda iflâs eden ortak da, çıkma hakkını kullanabilir. Bu hâlde çıkan ortağın tasfiye payı, iflâs masasına geçer.

ddd) Tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi

Adi şirket ortağının tasfiyedeki payının, cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi de şirketin sona erme nedenlerindendir (TBK m.639/b. 3). Bu hâlde şirket sözleşmesinde ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm varsa, ortak şirketten çıkarılabileceği gibi; tasfiyedeki payı, cebri icra yoluyla paraya çevrilen ortak da, çıkma hakkını kullanabilir. Belirtmek gerekir ki, tasfiyedeki payına cebri icra tatbik edilmesi, çıkma veya çıkarılma için yeterli değildir; tasfiyedeki payının, cebri icra yoluyla *paraya çevrilmesi* gereklidir.

eee) Ortağın ölmesi

Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa; ortaklardan birinin ölmesi, şirketin sona erme sebebidir (TBK m.639/b. 2). Buna mukabil, şirket sözleşmesinde ortaklığın diğer

ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm varsa; ölen ortağın mirasçıları ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir (TBK m.633).

3. Çıkarılma

Adi şirket ortağının ortaklık sıfatının *iradesi dışında* elinden alınmasına *çıkarılma* denir. Çıkarılma, sözleşme serbestîsi ilkesi gereği; sözleşmede öngörülebileceği gibi, kanunda belirtilen sebeplerle de olabilir.

a) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılma

Adi şirket sözleşmesinde şirketten çıkarılma ile ilgili özel bir hüküm varsa; bu düzenlemeye dayanılarak ve sözleşmedeki esaslara uygun bir şekilde, ortağın çıkarılması mümkündür. Ortak çıkarıldıktan sonra, şirket, diğer ortaklar arasında devam eder.

Sözleşme hükümlerine istinaden şirketten çıkarılan ortağın, çıkarılma kararına karşı dava açma hakkının olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak, kanunda bir hüküm olmadığı için, bu hakkın nasıl kullanılacağı tartışmalıdır. Kanaatimizce, hükümlerin illeti aynı olduğu için, kollektif şirketlerde ortağın çıkması ve çıkarılmasının hüküm ve sonuçlarının düzenlendiği hükümlerin, adi şirketlerde de menfaatler dengesine ve *bu şirketin niteliğine uygun olduğu nispette* tatbiki mümkündür[114].

Ancak, kollektif şirketlerde çıkarılan ortağın, bu kararın tebliğinden itibaren üç aylık *hak düşürücü süre* içinde, çıkarılmanın iptali davası açması ile ilgili hükmün (TTK m. 255/2), adi şirketlerde tatbik edilmemesi gerekir. Malûm olduğu üzere *hak düşürücü süre*, hakkın kanunda öngörülen süre içinde kullanılmaması hâlinde, hakkın ileri sürülmesi imkânını ortadan kaldırır; hak düşer. Hak düşürücü süreler, kanunlarda istisnai olarak yer alır; kanunda öngörülmeyen bir hak düşürücü süre kabul edilmemelidir. Adi şirketlere, kanunda öngörülmeyen, kollektif şirketlere ilişkin hak düşürücü sürenin, yorum yoluyla uygulanması da doğru olmaz. Bununla birlikte, adi şirketlerde çıkarılma kararına karşı açılacak iptal davasının makul bir sürede açılması gerekir. İptal davası makul sürede açılmazsa, hâkim, uzun süre sessiz kalan davacı aleyhine, *sessiz kalmak suretiyle hak kaybına* uğradığına hükmedebilir. Makul

---

[114] **Şener**, s. 391; **Yongalık**, s. 103.

süre, somut olayın özellikleri nazara alınarak, hâkim tarafından belirlenir[115].

b) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılma

aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması

Bir ortak, ister sözleşmede öngörülen sebeplerle ister haklı sebebe veya TBK m.639'da sayılan diğer sona erme sebeplerine istinaden şirketin feshini talep ederse; diğer ortaklar tarafından *yazılı* olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir (TBK m.633).

Ortak, şirketin haklı sebeple feshini Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 7'nci bendine göre istemiş ve diğer ortaklar, fesih isteyen ortağın m. 633'e göre çıkarılmasına karar vermişse; hâkim şirketin feshine karar veremez.

bb) Ortağın kısıtlanması

Adi şirkette ortakların şahsı önemli olduğu için, bir ortağın fiil ehliyetinin, TMK'nin m.405 vd. hükümlerinde öngörülen sebeplerden birine dayanılarak mahkeme kararıyla kısıtlanması, şirketin son erme sebeplerinden biri olarak kabul edilmiş; kanun koyucu diğer ortakları, kısıtlanan ortak yerine yasal temsilciyle ortaklık ilişkisini devam ettirme mecburiyetinde bırakmaktan kaçınmıştır.

Bu hâlde şirketin sona ermesini istemeyen diğer ortaklar, şirket sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla, yazılı olarak yapacakları bir bildirimle, kısıtlanan ortağı şirketten çıkarabilirler (TBK m.633).

---

[115] Bunun gibi, kollektif şirketlerde çıkarılma kararının tebliğinin "*noter*" vasıtasıyla yapılması hükmünün de adi şirketlere mutlak surette tatbiki uygun değildir; çıkarılma kararının bildirilmesi yeterli olmalıdır. Bununla birlikte, adi şirket ticari işletme işletiyorsa, adi şirket ortakları, "*ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işlettiği*" için tacir sıfatını kazandıklarından, TTK m. 18/3 gereği, "*tacirler arasında,.....sözleşmeyi feshe ilişkin ihbar ve ihtarların noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla .....*" yapılması hükmünün burada da geçerli olup olmadığı hususu gündeme gelebilir. Kanaatimizce, TTK m.18/3 hükmü burada geçerli olmamalıdır. Zira kanun koyucunun TTK m. 18/3 hükümdeki muradı, diğer tacirlerle yapılan mübadele sözleşmesidir; birleşme sözleşmesi mahiyetinde olan adi şirketlerdeki ortaklar arasındaki ilişkiler bu kapsama girmez. Kaldı ki, 6102 sayılı TTK düzenlemesinde m.18/3 hükmü geçerlilik değil; ispat şeklidir. Hâlbuki kollektif şirketlerde bahsi geçen noter aracılığıyla bildirim, geçerlilik bildirimidir; adi şirketlere tatbiki uygun olmaz. Ancak, ispat sorunu yaratabileceğinden, bu bildirimin yazılı yapılması isabetli olur.

cc) Ortaklardan birinin iflâsı

TBK m.639/b. 3'e göre, adi şirket ortaklarından birinin iflâsı, şirketin sona erme sebeplerindendir. Adi şirket ortaklarından birinin iflâsının şirketi sona erdirebilmesi için, iflâs talebinde bulunulması yeterli değildir; *iflâsına karar verilmesi gerekir.*

Şayet ortaklardan biri iflâs ederse, şirketi devam ettirmek isteyen diğer ortaklar, sözleşmede şirketin diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm bulunmak kaydıyla, yazılı olarak yapacakları bir bildirimle, iflâs eden ortağı şirketten çıkarabilirler (TBK m.633).

dd) Bir ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi

Kanun koyucu, adi şirket ortaklarından birinin tasfiyedeki payının, yani şirketin feshi sonucunda ortağa düşecek payın, cebri icra yoluyla paraya çevrilmesini, şirketin sona erme sebeplerinden biri olarak kabul etmiştir (TBK m.639/b. 3). Bu hâlde şirketi devam ettirmek isteyen diğer ortaklar, sözleşmede şirketin diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin hüküm bulunmak kaydıyla; yazılı olarak yapacakları bir bildirimle, tasfiyedeki payı cebrî icra yoluyla paraya çevrilen ortağı şirketten çıkarabilirler (TBK m.633). Ancak burada dikkat edilmesi gerekir ki, tasfiyedeki pay üzerine cebri icra vukuu (*haciz konulması*), şirketin sona ermesi ve şirketin sona ermesini önlemek için ortağın şirketten çıkarılması için yeterli değildir*; tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi gerekir.*

ee) Ortaklardan birinin ölümü

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin ikinci bendinde, "*Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölmesiyle*" adi şirketin sona ereceği hükme bağlanmıştır. Kanunda açık bir düzenleme olmamakla birlikte, "*ölüm karinesi*" (TMK m.31) ve "*gaiplik kararı*" da (TMK m.32 vd.) aynı sonucu doğurmalıdır.

Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa ortaklardan birinin ölmesiyle şirket sona ererse de, ortaklardan birinin ölmesi hâlinde "*sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa*", diğer ortaklar tarafın-

dan yapılacak bir bildirimle, ölen ortağın tasfiye payı mirasçılara verilmek (çıkarılmak) suretiyle, şirketin devamı temin edilebilir (TBK m.633).

4. Çıkma ve Çıkarılma Sebebiyle Ortaklık Sıfatının Sona Erdiği An

Kanun koyucu, çıkma ve çıkarılma sebebiyle ortaklık sıfatının sona erdiği tarihi, çıkan ve çıkarılan ortağın hak ve borçları açısından önemsemiş; ancak çıkma ve çıkarılma sebebiyle ortaklık sıfatının hangi anda gerçekleşeceğini hükme bağlamamıştır.

a) Çıkmanın hüküm ifade ettiği an

Çıkma hakkı, yukarıda da ifade edildiği üzere, sözleşmede öngörülen sebeplere dayanılarak kullanılabileceği gibi, kanunda belirtilen sebeplere istinaden de kullanılabilir.

aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an

Çıkma hakkı sözleşmede öngörülen sebeplere istinaden kullanılmışsa, *iç ilişkide çıkma*; sözleşmede öngörülen şartlara uygun olarak yapılan bir beyanla gerçekleşir. Çıkma hakkını kullanmak isteyen ortak, sözleşmede belirtilen şekilde ve açıkça çıkma iradesini belirtmek suretiyle şirketten çıkabilir. Bu hâlde iç ilişkide çıkma beyanı, yönetim yetkisi verilen ortağa; yönetim yetkisi bir ortağa bırakılmamışsa, tüm ortaklara ulaşmakla ortak çıkmış olur.

Ortağın çıkması, sözleşmede belirlenen bazı şartlara bağlanmışsa, çıkmak isteyen ortağın bu şartları da yerine getirmesi gerekir; aksi takdirde şirketten çıkamaz.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, diğer ortaklar, sözleşmede öngörülen sebeplerin gerçekleşmediği veya sözleşmede belirtilen usule uyulmadığı gerekçesiyle, çıkmak isteyen ortağın talebini reddedebilir; çıkma talebi reddedilmemişse, çıkma, çıkma beyanının yönetim yetkisi verilen ortağa, yönetim yetkisi bir ortağa bırakılmamışsa tüm ortaklara ulaşmakla gerçekleşmiş olur. Çıkma talebinin kabul edilmemesi hâlinde, çıkma talebinde bulunan ortağın, sözleşmede çıkma için aranan şartların gerçekleştiğinin tespitini mahkemeden istemesi mümkündür.

Dış ilişkide çıkma, adi şirketle işlem yapan üçüncü kişilere duyurulmasıyla gerçekleşir. Üçüncü kişilere duyurma TBK m.202'deki şekil şartlarına bağlıdır. Ayrıca ticari işletme işleten adi şirketlerde ayrılan

ortak temsil yetkisini haizse, temsil yetkisinin sona erdiğinin tescil ve ilânı gerekir.

bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkmanın hüküm ifade ettiği an

Kanun koyucu, kanunda öngörülen hâllerden birinin gerçekleşmesiyle ortağın çıkabileceğini hükme bağlamasına karşın, burada kendiliğinden çıkma, bir diğer ifadeyle, öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesiyle, başka bir işleme gerek olmadan çıkma söz konusu değildir; çıkmanın diğer ortaklar tarafından kabulü gerekir.

Gerçekten de, sözleşmede çıkma ile ilgili bir düzenleme olmamasına rağmen, (diğer ortakların bir ortağın ortaklıktan çıkmasına "*muvafakat etmeleriyle çıkmada*" olduğu gibi) bir ortağın şirketten çıkması, sözleşme değişikliği mahiyetini taşıdığından, aksine hüküm yoksa bütün ortakların rızasına bağlıdır; iç ilişkide çıkma, bu kabul beyanı ile tamam olur.

Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa ve bu durumlardan biri gerçekleşmişse, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısının ortaklıktan *çıkma talebinde bulunması* ve bu talebin *diğer ortaklar tarafından kabul edilmesi* gerekir. Zira bu sebepler aynı zamanda şirketin sona erme sebepleri olduğu için, diğer ortaklar, sözleşmede şirketi devam ettirme ile ilgili hüküm bulunmasına rağmen, şirketi devam ettirmek yerine, şirketi sona erdirebilirler. Şirketi devam ettirmek isterlerse; iç ilişkide çıkma anı, çıkma beyanının kabulü anıdır.

b) Çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an

Çıkarılma, yukarıda da ifade edildiği üzere, sözleşmede öngörülen sebeplere dayanılarak kullanılabileceği gibi, kanunda belirtilen sebeplere istinaden de kullanılabilir.

aa) Sözleşmede öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an

Bilindiği gibi, adi şirket bir sözleşmeyle kurulur. Her sözleşme taraflar arasında bir hukuki ilişki meydana getirir; bu ilişkiye sözleşme ilişkisi (akdi ilişki) denir. Sözleşme ilişkisini sona erdiren sebepler, "*ifa*", "*bozma sözleşmesi*", "*fesih*", "*dönme*", "*geri alma*" ve "*iptal*"dir.

Ancak, yukarıda da izahına çalışıldığı üzere, *şirket sözleşmesinde* edimler "*mübadele*" edilmemekte; sadece birleştirilmektedir. Gerçi ortakların edimleri arasında bir görevsel bağ vardır ama gerçek anlamda bir "*karşılıklılık ilişkisi*" yoktur; bu sözleşmede "*sinallagma*" nitelikleri eksiktir. Bunun yanında şirket sözleşmesi aynı zamanda sürekli sözleşme ilişkisi kuran sözleşmelerdendir.

Şirket sözleşmesinin bu özellikleri sebebiyle, karşılıklı sözleşmelere ilişkin kuralların, birleşme sözleşmesine uygulanması konusunda çekimser davranılmaktadır.

Bir sürekli sözleşme ilişkisi, bir kere ifa sürecine girdiğinde, artık bu ilişki, sözleşme öncesi durumun yeniden kurulması amacına yönelik bir çözülme ilişkisine dönüştürülemez. İfa sürecine girilmiş olan sözleşme ilişkisinin "*iptal*", "*geri alma*" ya da "*dönme*" eliyle çözülmesi hem adalete, hem hukuksal güvenliğe hem de yerindeliğe aykırı olur[116]. Sürekli edimin ifası safhasına geçilmiş sürekli sözleşme ilişkilerinde sözleşme ilişkisi, ancak "*fesih*" yoluyla sona erdirilebilir.

Buna göre, adi şirket sözleşmesinde şirketten çıkarılma ile ilgili özel bir hüküm varsa, bu düzenlemeye dayanılarak ve düzenlemedeki esaslara uygun bir şekilde, ortağın çıkarılması mümkündür. Çıkarılma kararı, sözleşme ilişkisini ileriye doğru (*ex nunc*) sona erdiren bir olumsuz (*bozucu*) yenilik doğuran hak veya işlemdir ve ilke olarak hak sahibinin diğer tarafa varması gerekli tek taraflı irade beyanıyla kullanılır. Çıkarılan ortak çıkarılma kararına itiraz etmezse; çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an, çıkarılma kararının çıkarılan ortağa ulaştığı andır.

Çıkarılan ortak, çıkarılma kararına karşı, çıkarılma kararının hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yargı yoluna başvurursa; çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an, yine çıkarılma kararının çıkarılan ortağa ulaştığı andır. Ancak mahkeme çıkarılma kararını iptal ederse, kollektif şirketlerden mülhem olarak (TTK m. 255/2), çıkarılma kararı geçmişe etkili olarak iptal edilmiş olur ve ortak hiç çıkarılmamış gibi şirketteki hak ve borçlarına sahip olmaya devam eder.

bb) Kanunda öngörülen sebeplerle çıkarılmanın hüküm ifade ettiği an

Türk Borçlar Kanununun 633'üncü maddesine göre, *"Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, iflâsı, tasfiyedeki payının*

---

[116] **Serozan**, s. 167.

cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu durumlardan biri gerçekleştiğinde, ...diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir".

Hükümden de anlaşıldığı gibi, "*ortaklıktan çıkarılma*", kanunda belirlenen hâllerin gerçekleşmesi üzerine, diğer ortakların çıkartma konusundaki kararının, çıkarılacak ortağa *yazılı bir şekilde yapılacak bildirilme* şartına bağlanmıştır. Çıkarılma kararının, çıkarılacak ortağa *yazılı bir şekilde* bildirildiği an, çıkarılma kararının hüküm ifade ettiği andır.

5) Çıkan Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun Adi Ortaklık Sözleşmesini düzenleyen on sekizinci bölümünde "VIII. Ortaklar arasındaki ve ortaklık yapısındaki değişiklikler" üst başlığı altında 632'nci maddede "1. Yeni ortak alımı ve alt katılım", hemen sonra da "2. Ortaklıktan çıkma ve çıkarılma" üst başlığı altında 633'üncü maddede çıkma ve çıkarılma "**a.** Genel olarak" ele alınmış; 634'üncü maddede "**b.** ortaklık payının tasfiyesi", 635'inci maddede "**c.** malvarlığının yetersizliği" ve 636'ncı maddede "**d.** tamamlanmamış işler" hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen hükümler, çıkan veya çıkarılan ortağın sorumluluğu hakkında da düzenlemeler getirmektedir.

a) Çıkma veya çıkarılmanın sorumluluk üzerine genel etkileri

Çıkan veya çıkarılan ortağın, çıkma veya çıkarılma anından sonraki işlemlerden dolayı sorumluluğu söz konusu olmaz. Bir diğer ifadeyle, hukuki görünüşe bağlı olarak, ayrılmanın hüküm ifade ettiği andan sonra şirket alacaklılarına karşı yeni bir sorumluluğun doğması mümkün değildir (Kurulmuş olan sürekli borç ilişkilerinden kaynaklanan borçlarda, somut olayın özelliklerine göre durum farklı olabilir).

Buna karşın, ayrılmadan önceki işlemlerden üçüncü kişilere karşı doğan sınırsız ve müteselsil sorumluluk ile diğer ortakların rücu hakları, ortak şirketten ayrılsa bile ortadan kalkmaz. Zira müteselsil borçlular arasında yapılan işlemlerden, alacaklının hukuki durumu etkilenmez.

Ayrılan ortak, müteselsil sorumluluk nedeniyle, şirket ilişkisinden doğan borçları üçüncü kişiye öderse, ödediği miktar bakımından diğer ortaklara rücu edebilir[117].

b) Çıkma ve çıkarılmada özel hâller

aa) Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketin muaccel olan ve olmayan borçlarından sorumluluğu

Çıkan veya çıkarılan ortağın, çıkma veya çıkarılma tarihinden sonraki şirket borçlarından sorumluluğu söz konusu olmaz. Buna mukabil, çıkan veya çıkarılan ortağın, çıkma veya çıkarılma tarihinden evvelki şirket muamelelerinden doğan borçlarından müteselsil sorumluluğu devam eder.

bb) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması veya güvence verilmesi

Çıkan veya çıkarılan ortak, şirket ortağı olduğu dönemde yapılan muamelelerden dolayı diğer ortaklarla birlikte müteselsil sorumludur. Çıkan veya çıkarılan ortağın muaccel olan veya olmayan şirket borçlarından dolayı *iç ilişkide* müteselsil sorumluluktan kurtulması, diğer ortakların ayrılan ortağı *borçtan kurtarmasına* bağlıdır. Şirketin henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilirler.

aaa) Çıkan veya çıkarılan ortağın borçtan kurtarılması

Yukarıda da izahına çalıştığımız gibi, çıkan veya çıkarılan ortağın, çıkma veya çıkarılma tarihinden sonraki şirket borçlarından sorumluluğunun söz konusu olmayacağı; buna mukabil, çıkan veya çıkarılan ortağın, çıkma veya çıkarılma tarihinden evvelki şirket muamelelerinden doğan borçlarından müteselsil sorumluluğunun devam edeceği *kuralı* geçerlidir.

Kural bu olmakla birlikte, çıkan veya çıkarılan ortağın müteselsil sorumluluktan *kurtarılabileceği* öngörülmüş; diğer ortakların, çıkan veya çıkarılan ortağı muaccel olan ve olmayan borçlardan dolayı "*müteselsil sorumluluktan kurtarabilecekleri*" hükme bağlanmıştır. TBK m.634/2'ye göre diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı "*ortaklığın muaccel olan ve olmayan borçlarından kurtararak, ortak sıfatının sona*

---

[117] **Şener**, s. 392.

erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını ödemekle yükümlü" tutulmuşlardır.

Kanun koyucu TBK m.634/2'de, muaccel olmayan borçlarda, muaccel borçlardan farklı olarak, diğer ortaklara seçimlik hak tanımış; ortaklığın henüz *muaccel olmayan borçları için* diğer ortakların, çıkarılan ortağı borçtan *kurtarabileceğini* veya borçtan kurtarma yerine kendisine bir *güvence* verilebileceğini hükme bağlamıştır. Buna göre, şirkette kalan diğer ortaklar, çıkarılan ortağı borçtan *kurtarabilir* veya borçtan kurtarma yerine kendisine bir *güvence* verebilirler.

Bununla birlikte önemle belirtilmelidir ki, çıkan veya çıkarılan ortağı muaccel olan ve olmayan borçlardan dolayı "*müteselsil sorumluluktan kurtarabilecekleri*" ne ilişkin hüküm, sadece *ortaklar arasındaki ilişkilerde (iç ilişkide) geçerlidir*. Zira "*Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçer*" hükmünden de anlaşılacağı üzere; ortakların çıkma veya çıkarılması, çıkan veya çıkarılan ortağın şirketteki "*malvarlığının devri*" (TBK m.202) mahiyetindedir. Bu nedenle, çıkma veya çıkarılmanın alacaklılara bildirildiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilânla duyurulduğu tarihten başlayarak, iki yıl süreyle çıkan veya çıkartılan ortak da devralanla (şirkette kalan ortaklarla) birlikte, alacaklılara karşı müteselsil borçlu olarak sorumlu kalmaya devam edecektir.

bbb) Çıkan veya çıkarılan ortağa güvence verilmesi

Türk Borçlar Kanununun 634'üncü maddesi mucibince, "*Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine, kendisine bir güvence verebilirler*" (TBK m.634/2). Kanun koyucunun ifadesinden, güvencenin, sadece muaccel olmayan borçlar için verilebileceği gibi bir sonuç çıkıyorsa da; hükmün genel amacı[118], şirketin sona ermesinin önüne geçilmesi olmasına karşın, ayrılan ortağın durumunun, tasfiyedeki duruma mümkün olduğunca yaklaştırmak olduğundan, ayrılan ortağa muaccel borçlar için de güvence verilebileceği kanaatindeyiz.

---

[118] **Ulmer, P / Schäfer, C.:** Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, BGB Bond 7: Schuldrecht Besonderer Teil IV, 7. Aufl, 2017, § 738, N. 1.

Kanun koyucu çıkan veya çıkarılan ortağa, ortaklığın borçları için diğer ortaklar tarafından *"güvence"* verilebileceğinden bahsetmişse de, verilecek *güvencenin* mahiyetine temas edilmemiştir. Kanaatimizce verilecek güvencenin mahiyetinde bir sınırlama yapmamak gerekir. Buna göre, ayrılan ortağın ayrılma payı hesaplandıktan sonra, muaccel olmayan şirket borçlarından doğabilecek sorumluluğunu karşılayabilecek mahiyette bir güvence verilmesi yeterlidir. Bu güvence, *ayrılan ortağın fiilini üstlenerek* yahut *kefalet* ya da *rehin* yahut sair surette verilebilir.

Verilen güvencenin, ayrılan ortağın sorumlu tutulacağı miktarı karşılamaya yetip yetmemesi de önemli değildir. Zira yukarıda da bahsedildiği gibi, ayrılana tasfiye payının verilmesi ile şirkette kalan ortaklar, zaten ayrılan ortağın borcunu üstlenmiş olmaktadır. Verilen güvence, muaccel olmayan borçlardan doğan sorumluluğu karşılamaya yetmezse; ayrılan ortak borcun iç üstlenilmesi hükümlerinę göre diğer ortaklara müracaat edebilmelidir.

6) Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları

Adi şirketlerde bir ortağın çıkması ve çıkarılması hâlinde ayrılan ve kalan ortaklara ilişkin sonuçlar; Türk Borçlar Kanununun 634-636'ncı maddeleri arasında, *"malvarlığının tasfiyesi"*, *"malvarlığının yetersizliği"* ve *"tamamlanmamış işler"* başlıkları altında hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerin temel yaklaşımı, şirketin sona ermesinin engellenmesi olmasına karşın, ayrılan ortağın durumunu, tasfiye olsaydı (TBK m.634/2) tasfiyedeki durumuna mümkün olduğunca yaklaştırmak; şirketin sona ermesi yerine devam etmesinden kaynaklanan malvarlığına dayalı olumsuzlukları, ayrılana yansıtmamaktır.

Türk Borçlar Kanununun bu düzenlemeleri yanında, ayrıca ele alınmamış olsa da, çıkma ve çıkarılmanın şirketin idare ve temsil üzerine etkileri de vardır.

a) Çıkma ve çıkarılmanın yönetim ve temsil yetkisi üzerine etkileri

Çıkma veya çıkarılma suretiyle ortaklık sıfatının sona ermesi; kural olarak, ortaklık hak ve yükümlülüklerini de sona erdirir. Buna göre çıkan veya çıkarılan ortağın, yönetim ve temsil yetkisi de ayrılma tarihi itibariyle sona erer.

İç ilişkide yönetim ve temsil yetkisinin sona ermesi; çıkma veya çıkarılma anıdır. Dış ilişkide ise, temsil yetkisine sahip ortağın çıkması-

nın veya çıkarılmasının adi şirketle işlem yapan üçüncü kişilere duyurulmasıyla gerçekleşir. Ticari işletme işletmeyen adi şirketlerde üçüncü kişilere duyurulması icap eder. Zira TBK m.634 gereği, çıkma veya çıkarılma durumunda, çıkan veya çıkarılan ortağın payı kendiliğinden diğer ortaklara geçeceğinden, TBK m.202 gereği bu durumun alacaklılara duyurulması gerekir. Ticari işletme işleten adi şirketlerde ise çıkan veya çıkarılan ortak temsil yetkisini haiz ise, ayrıca ticaret siciline tescil ve ilân gerekir.

b) Çıkma veya çıkarılma hâlinde ortaklık payının tasfiyesi

Çıkan veya çıkarılan ortak, şirket malvarlığındaki haklarını kaybeder ve *"bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçer"* (TBK m.634/1).

aa) Ayrılan ortağın ortaklık payının diğer ortaklara geçmesi

Türk Borçlar Kanununun 634'üncü maddesinin birinci fıkrasında, *"bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçer"* denilmesine karşın; bu hükmün uygulanabilmesi, çıkan veya çıkarılan ortağın payını bir başkasına devretmemesi; sadece tasfiye payını alması şartına bağlıdır. Ayrılan ortak payını geçerli bir şekilde bir başkasına devrederse, payı diğer ortaklara değil, devrettiği kişiye geçer.

Bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payının, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçmesi (çoğalma) ilkesi, tarafların iradesi ile kaldırılabilecek nitelikte değildir. Buna mukabil, sözleşmeye konulacak bir hükümle veya daha sonra alınacak bir kararla payların geçişiyle ilgili düzenlemeler yapılabilir; payın geçiş esasları belirlenebilir. Sözleşmeye böyle bir hüküm konulmamış veya bir karar alınmamışsa, ayrılan ortağın payı, diğer ortaklara *payları oranında* kendiliğinden geçer; çıkan veya çıkarılan ortağın, şirketteki malvarlığı, şirkette kalan ortaklar tarafından devralınmış olur.

Kanun koyucu, bir ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payının, diğer ortaklara payları oranında kendiliğinden geçeceğini ifade ederken; malvarlığının devrinde olduğu gibi, çıkma veya çıkarılmanın alacaklılara duyurulmasıyla birlikte, malvarlığına

dâhil unsurların, başkaca bir devir işlemine gerek olmadan devredilmiş sayılacağını ifade etmek istemektedir.

bb) Tasfiye payının tespiti ve ödenmesi

Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtararak, ortak sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye payını ödemekle yükümlüdürler (TBK m.634/2). Bu hâlde ödenecek olan gerçek tasfiye payı olmadığı için; ödenecek olan bu paya *"ayrılma akçesi"* (Abfindungsanspruch) de denilmektedir[119].

Adi şirketlerde *tasfiyeye ilişkin hükümler*, iç ilişkiyi ilgilendirmesi ve ortakların üçüncü kişilere karşı müteselsil, sınırsız ve birinci dereceden sorumlu olması nedeniyle, niteliği gereği *tamamlayıcı hükümlerdir*. Buna göre ortaklar, özellikle tasfiye payının (ayrılma akçesinin) muacceliyeti ve miktarı ile ilgili düzenleme yapabilir; tasfiye payı da bu esaslara göre tespit edilir ve ödenir.

Şirket sözleşmesinde tasfiyeye ilişkin bir hüküm yoksa ve ortaklar tasfiyeye ilişkin bir karar da almamışsa; tasfiye bakiyesi, getirilen sermayenin nev'i, mahiyeti veya miktarı nazara alınmadan ortaklar arasında eşit olarak paylaştırılır. Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği tarih itibarıyla, mali işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi üzerinde anlaşamamaları durumunda bu kişi, hâkim tarafından atanır (TBK m.634/3).

Tasfiye payını (ayrılma akçesini) çıkan veya çıkarılan ortağa ödeyecek olan, diğer (kalan) ortaklardır. Tasfiye payının ifası bakımından diğer (kalan) ortaklar, ayrılan ortağa karşı şahsen sorumludur. Diğer alacaklılarına karşı müteselsil sorumlu olan adi şirket ortakları, tasfiye payının ödenmesinde de ayrılan ortağa karşı, şahsen ve müteselsilen sorumludur.

Bütün bunların yanında TBK m.634/2'de özel bir düzenleme getirilmiş, *"şirkete katılma payı olarak bir şeyin kullanımı konulmuşsa*, diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü tutulmuştur" (TBK m.634/2).

---

[119] **Ulmer/Schäfer**, Münchener Kommentar zum BGB, § 738, N. 2.

c) Malvarlığının yetersizliği

Adi şirketlerde çıkma ve çıkarılma sebepleri; yukarıda da izah edildiği gibi, aynı zamanda şirketin sona erme sebepleridir. Kanun koyucu, şirketin sona ermesi yerine, şirketin sona ermesine sebep olan ortağın çıkabileceğini veya çıkarılabileceğini hükme bağlamıştır.

Tasfiye payının (ayrılma akçesinin) hükme bağlanması da aynı sebebe yöneliktir. Böylece, şayet şirket tasfiye olsaydı; ödenmesi gereken tasfiye payı, ayrılan ortağa ödenmektedir. Ayrılan ortağa ayrılma akçesinin (tasfiye payının) ödenmesi, dağıtılacak bir tasfiye bakiyesinin varlığına bağlıdır. Bir diğer söyleyişle, şirket tasfiyeye girmemekle birlikte, sanki tasfiyeye girmiş gibi hesaplama yapılır; adi şirketin alacakları tahsil edilip borçları ödendikten sonra hâlâ bir şey kalmışsa, ayrılan ortağa bu miktar tasfiye payı olarak ödenir.

Bu şekilde yapılan sanal tasfiye sonucunda, ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, *ortaklığın malvarlığının, borçlarını karşılamaya yetmediği anlaşılırsa;* çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür (TBK m.635). Ancak önemle belirtelim ki, ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, *ortaklığın malvarlığının, borçlarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması* üzerine çıkan veya çıkarılan ortağın, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlü olması; sadece ayrılma akçesini almak suretiyle ayrılanlar için geçerlidir; payını bir başkasına devreden ortağın bu tür bir sorumluluğu yoktur[120].

d) Tamamlanmamış işler

Kanun koyucu, *çıkan veya çıkarılan ortağın, ortak olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılacağını,* Türk Borçlar Kanununun 636'ncı maddesinin birinci fıkrasında hükme bağlamıştır. Bu hükmün uygulaması (malvarlığının yetersizliğinde olduğu gibi), sadece ayrılma akçesini (tasfiye payını) almak suretiyle ayrılanlar için söz konusudur; payını bir başkasına devreden ortağın bu tür bir hakkı yoktur[121]. Kaldı ki, "*ortaklık payının tasfiyesi*" (TBK m.634) esnasında, *tamamlanmamış işler ile ilgili olarak bir mutabakat*

---

120 **Ulmer/Schäfer**, Münchener Kommentar zum BGB, § 739, N.1.

121 **Ulmer/Schäfer**, Münchener Kommentar zum BGB, § 740, N.1.

temin edilmişse, bir diğer ifadeyle, ayrılan ortak ile kalan ortaklar arasında tamamlanmamış işlerin akıbeti hakkında karara varılmışsa ve ayrılma akçesi tamamlanmamış işleri de içeriyorsa, ayrılan ortak TBK m.636 mucibince kâr payı isteyemez; kendisine de zarar için iç ilişkide başvurulamaz.

Ayrılan ortak, şartların varlığı hâlinde, tamamlanmamış işlerle ilgili olarak kâr payını isteyebileceği gibi, tamamlanmamış işler hakkında *bilgi de isteyebilir* (TBK m.636/2).

IX) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Adi şirketin sona ermesi, şirket sözleşmesiyle ortaklar arasında kurulan hukuki bağın çözülmesi; sona ermesi demektir. Şirket sözleşmesi, yukarıda da izah edildiği gibi, diğer borç sözleşmelerinden farklı özellikleri haizdir. Birlikte mülkiyet esasına dayanan şirket malvarlığı, özel bir rejime tâbi şirket borçları vb. gibi devamlı bazı münasebetlerin doğmasına sebebiyet verir. Bu yüzden adi şirketin sona ermesi, diğer borç münasebetleri gibi, basit bir muamele ile ve bir anda değil; ihtiva ettiği birçok devamlı münasebetlerin çözülerek sona ermesi sonucunu doğuran bir süreçtir. Bu süreç "*sona erme*" sebeplerinin gerçekleşmesiyle başlar, "*tasfiye*" işlemleri ile tamamlanır.

A) SONA ERME SEBEPLERİ

Şirketin normal faaliyetine son vererek, şirketi *tasfiye sürecine* sokan sebeplere "*sona erme sebepleri*" adı verilir. Adi şirketin sona erme sebepleri Türk Borçlar Kanununun 639 ve 640'ıncı maddelerinde hükme bağlandığı üzere *kanundan* doğabileceği gibi, *şirket sözleşmesinde* de sona erme sebepleri kabul edilebilir. Kanundan doğan veya sözleşmede kabul edilen bu sona erme sebepleri incelendiğinde, bazılarının *iradi* bazılarının ise *irade dışı* olduğu gözlenmektedir.

Adi şirket sözleşmesi ile ortaklar arasında kurulan hukuki bağın, *iradi* olarak sona erdirilmesine *"fesih"* (dağıtma) adı verilmektedir. Adi şirketin sona ermesi sonucunu doğuran bu irade, *kanundan* veya *sözleşmeden* doğan bir hakkın kullanılması şeklinde, ortakların iradesi veya yargısal irade (mahkeme kararı) olarak ortaya çıkabilir. Ortaklara kanunda tanınan veya sözleşmeyle ortaklara verilen fesih hakkı (fesih bildiriminde bulunulması), bozucu yenilik doğuran bir hakkın kullanılmasıdır; kural olarak kabule ihtiyaç göstermeden, yöneltildikleri

muhataba ulaşmakla hukuki sonuçlarını meydana getirir. Bununla birlikte sözleşme ile tanınan fesih hakkı bazı şartlara, meselâ bir *önele* bağlı tutulabilir. Ortakların veya mahkemenin fesih kararı da yenilik doğuran bir karar niteliği taşır.

Adi şirket sözleşmesi ile ortaklar arasında kurulan hukuki bağın, *irade dışı* sona ermesine ise *"infisah"* (dağılma) denilmektedir. İnfisah sebeplerinin gerçekleşmesi ile şirket kendiliğinden, başka bir işleme gerek kalmadan sona erer. Kanunda öngörülen infisah sebeplerinin yanında sözleşmede de infisah sebepleri öngörülebilir.

1) İnfisah (Dağılma) Sebepleri

İnfisah sebepleri kanunda veya sözleşmede öngörülmüş olabilir. Bunları "*kanunda öngörülen infisah sebepleri*" ve "*sözleşmede öngörülen infisah sebepleri*" başlığı altında inceleyeceğiz.

a) Kanunda öngörülen infisah sebepleri

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinde sayılan ve şirketin kendiliğinden (*ipso iure*) sona ermesini gerektiren sebeplerin gerçekleşmesi halinde, ilgililerden herhangi biri, şirketin sona erdiğinin tespitini isteyebileceği gibi; sona ermenin tespitiyle birlikte, sona erme neticelerini de (idare ve temsil yetkisinin sona ermesi ve tasfiye) talep edebilir. Kanunda öngörülen kendiliğinden sona erme (infisah) nedenleri şunlardır:

aa) Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi

Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını *ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşme* olduğu için, şirketin gayesinin elde edilmesi ile artık onun devamı için bir sebep kalmaz.

Adi şirketlerde ortak amaç, ortakların şirket sözleşmesiyle kabul ettikleri, şirket olarak ulaşmak istedikleri nihai amaçtır; iktisadi olması, yani gelir elde etmeye yönelik olması gerekir. Amacın geçici veya sürekli olması, adi şirketin vasfını etkilemez. Ancak şirket, muayyen olan tek bir amacı elde etmek maksadıyla, meselâ sadece bir baraj yapımı için kurulmuşsa, bu barajın yapılmasıyla birlikte ortak amaca erişildiği için şirket kendiliğinden sona erer.

Ortaklık sözleşmesinde öngörülen *amacın gerçekleşmesinin imkânsız* duruma gelmesi de aynı neticeyi doğurur. İmkânsızlığın adi şirket sözleşmesinin yapılmasından sonra ortaya çıkması gerekir. Zira Türk Borçlar Kanununun 27'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, içeriği imkânsız veya hukuka ya da ahlâka aykırı sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür; hükümsüz olan şirket sözleşmesinde şirketin sona ermesinden bahsedilemez, kesin hükümsüzlüğün (butlanın) tespiti istenir.

Şirket sözleşmesinin yapılmasını müteakip, şirketin faaliyete geçmesinden sonra ortaya çıkan imkânsızlık hâlinde de, ortakların şirket çatısı altında birleşmesini gerektiren sebepler ortadan kalkmış ve artık kişi birliğinin devamına da lüzum kalmamıştır. Ancak bu neticeyi doğurabilmesi için *imkânsızlığın devamlı ve objektif bir mahiyet arz etmesi* lâzımdır; nispeten kısa bir zaman için gayretlerin neticesiz kalması veya kâr elde edilememesi, ortakların şahsından kaynaklanan sebeplerden dolayı başarısızlık, bu anlamda imkânsızlık olarak kabul edilemez.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki, ortaklık sözleşmesinde öngörülen *amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız* hâle gelmesi durumunda ortaklar, gerçekleşen veya gerçekleşmesi imkânsız hâle gelen *amacı değiştirerek* veya faaliyetlerine devam ederek şirketin sona ermesini engelleyebilirler[122]. Şirketin amacının değiştirilmesi, ortakların Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesine uygun bir şekilde alacakları kararla açık bir şekilde veya faaliyetlerine amaç değiştirerek devam etmek suretiyle *örtülü* bir tarzda da olabilir.

bb) Ortaklardan birinin ölmesi ve sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması

Bir ortağın ölmesi hâlinde, sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm *varsa;* yukarıda *çıkma ve çıkarılma* bahsinde izah edildiği gibi, ölen ortağın mirasçısı ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabilir (TBK m.639/1,b.2); şirket diğer ortaklarla devam eder.

Buna karşılık, sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm *yoksa*; ortaklardan birinin ölmesi, şirketin infisah

---

122 **Handschin/Vonzun**, (Art 545, Abs.1. Ziff.1), N.32-33.

sebebidir. Mirasçılarla şirketin devamı hususunda bir hüküm bulunmamasına karşın; acaba mirasçılarla kalan ortaklar arasında şirketin devamı hususunda bir anlaşma yapılabilir mi? Kanaatimizce yapılacak böyle bir anlaşma, yeni bir şirket mahiyetindedir; ortağı ölen şirket sona erer. Bu durumda kalan ortaklar, TBK m.632'de öngörüldüğü şekilde mirasçıları yeni ortak olarak da alamaz; şirket sona ermiştir. Bundan sonra yapılacak sözleşme ile mirasçıların adi ortaklığa alınması veya mirasçılar olmadan kalan ortaklarla devama karar verilmesi, yeni bir şirketin kuruluşuna vücut verir[123].

Ortaklardan birinin gaipliğine hükmolunması veya ölüm karinesi, infisah bakımından onun ölümüne eşdeğer hüküm ve neticeler doğurur (TMK m.45).

cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm bulunmaması halinde bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 3'üncü bendinde, üç ayrı infisah sebebi kabul edilmiştir.

aaa) Ortağın kısıtlanması

Bir ortağın TMK m.405-408 hükümlerine istinaden kısıtlanması durumunda, sözleşmede ortaklığın *diğer ortaklarla devam edeceğine* ilişkin bir hüküm varsa, kısıtlanan ortağın temsilcisi ortaklıktan çıkmayı isteyebileceği gibi, diğer ortaklar da yazılı olarak yapacakları bir bildirimle kısıtlanan ortağı ortaklıktan çıkarabilir (TBK m.633); şirket diğer ortaklarla devam eder.

Buna karşılık, sözleşmede, bir ortağın kısıtlanması durumunda, ortaklığın *diğer ortaklarla devam edeceğine* ilişkin bir hüküm *bulunmuyorsa*; bir ortağın kısıtlanması, şirketin sona erme sebebi olarak kabul edilmiştir (TBK m.639/1,b.3). Bu hâlde diğer ortaklar, şirketin kendi aralarında devamına karar veremezler; diğer ortakların şirketin devamı tarzındaki kararı, yeni bir şirket mahiyetindedir.

Kısıtlama kararının hangi anda hüküm ifade ettiğinin tespiti; şirketin infisah anını belirlemede önemlidir. Bilindiği gibi Kanundaki

---

[123] Adi ortaklık sözleşmesinde, ortaklığın ölüme bağlı olarak sona ermeyeceğine ilişkin bir hüküm olmasa dahi sağ kalan ortakların, ortaklığı aralarında veya mirasçılarla devam ettirebileceği yönündeki görüş için bkz. **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,** s. 76, N. 107a.

istisnalar hariç olmak üzere, "*temyiz, kararın icrasını durdurmaz*" (HMK m.367/1). HMK'da gösterilen bu istisnalardan birisi de kişiler hukukuna ilişkindir. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 367'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, "*Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez*". Bir diğer söyleyişle aile ve şahsın hukukuna dair hükümlerin temyizi, icrayı kendiliğinden durdurur. Bunun için teminat gösterilmesine ve Yargıtay'dan icranın geri bırakılması kararı alınmasına gerek yoktur. Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur. Kısıtlama, iyi niyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez (TMK m.410).

bbb) Ortağın iflâsı

İflâs yolu ile takip, ancak Türk Ticaret Kanunu gereğince, tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tâbi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflâsa tâbi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır (İİK m.43).

Adi şirket ortağı, ortaklık dışı iktisadî faaliyetlerinde ticari işletme işletebileceği ve bu faaliyetleri dolayısıyla tacir sıfatını kazanabileceği gibi; adi şirket ticari bir işletme işletebileceğinden (adi şirketin tüzel kişiliği bulunmadığı için), bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten adi şirket ortakları tacir sıfatını kazanır (TTK m.12/1) ve bu sıfatla iflâsa tâbi olur (TTK m.18/1).

İflâsın açılması ile birlikte, müflisin haczedilebilen bütün mal ve hakları ve tabiidir ki adi şirketteki ortaklık payı kendiliğinden iflâs masasına intikal edeceğinden ve müflis tacir artık bu özel mamelek (iflâs masasına giren mallar) üzerinde tasarrufta bulunamayacağından, iflâsın açılma anının belirlenmesi gerekir.

İcra ve İflâs Kanununun 165'inci maddesine göre, "*İflâs hükümle açılır* ve *bu hükümde açılma anı gösterilir*". Bu hükme nazaran, Ticaret Mahkemesinin iflâsa karar verdiği anda, borçlu (müflis) hakkında iflâs açılmış olur ve iflâs kararında iflâsın açılma anı (zamanı) gün, saat olarak gösterilir (İİK m.165; TSY m.137). İflâs kararı bütün hüküm ve sonuçlarını, iflâs kararında gösterilmiş olan iflâsın açılma anından itibaren meydana getirir; kararın kesinleşmesi beklenmez (İİK m. 164/2-3; 166/2).

Adi şirket sözleşmesinde ortaklığın *diğer ortaklarla devam edeceğine* ilişkin bir hüküm varsa, iflâs eden ortak *çıkabilir* veya *çıkarılabilir* (TBK m.633); bu hâlde şirket diğer ortaklarla devam eder.

Buna karşılık, sözleşmede, bir ortağın iflâsı halinde, ortaklığın *diğer ortaklarla devam edeceğine* ilişkin bir hüküm *bulunmuyorsa*; bir ortağın iflâsı, şirketin sona erme sebebi olarak kabul edilmiştir (TBK m.639/1,b.3). Bu durumda diğer ortaklar iflâs eden ortağı çıkartmak suretiyle şirketin kendi aralarında devamını sağlayamazlar. Kalan ortakların kendi aralarında yapacakları bu sözleşme, şirketin devamını sağlamaz; yeni bir şirket kurulmuş olur.

ccc) Ortağın tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi

Türk Borçlar Kanununun 638'inci maddesinin ikinci fıkrasına göre,"Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler". Bu yüzden ortakların alacaklılarının haklarını elde etmelerine imkân vermek üzere, Türk Borçlar Kanununda ortaklardan birinin tasfiyedeki payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi ile şirketin sona ereceği kabul edilmiştir. Ancak şirketin infisahı için ortağın tasfiyedeki payının haczi ve paraya çevrilmesi talebinde bulunulması veya ona kıymet takdiri yeterli değildir; cebri icranın gerçekleşmiş yani tasfiye hissesinin paraya çevrilmesi de lâzımdır. Zira bu ana kadar borçlunun borcunu ödemesi veya diğer ortakların onun borcunu ödemeleri vs. suretiyle icra takibini durdurmak ve böylece şirketin infisahını önlemek daima mümkündür.

dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi

Adi şirket sözleşmesinin bir süreye bağlı olarak yapılması gerekmez; belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulabileceği gibi, şirket sözleşmesi belirli bir süreye de bağlanabilir. Şirket sözleşmesinin belirli bir süreye bağlanması hâlinde adi şirket, sözleşmede belirlenen sürenin geçmesiyle birlikte kendiliğinden sona erer (TBK m.639/1,b.5).

Sözleşmede belirlenen süre, muayyen bir tarih olarak gösterilebileceği gibi, kuruluş tarihi esas alınarak meselâ beş yıl, on yıl gibi kuruluştan itibaren belirli bir süre öngörülebilir.

Kanun koyucu, sözleşmede belirlenen sürenin geçmesiyle birlikte şirketin kendiliğinden sona ereceğini hükme bağlamışsa da, sözleşmede

belirlenen sürenin sona ermesine rağmen şirket faaliyetlerine devam ediyorsa ve *bütün ortaklar* buna muvafakat ediyorsa, muvafakatin açık veya örtülü olmasına bakılmaksızın, şirket *belirsiz süreli şirkete dönüşür* (TBK m.640/3).

Sözleşmede belirlenen sürenin bitmesinden sonra şirket faaliyetlerine ortakların açık bir beyanı ile devam edilebilir; bu halde TBK m.624'e uygun bir şekilde karar alınmalıdır. Bunun yanında TBK m.640/3'te açıkça ifade edildiği üzere, "*Sözleşmede öngörülmüş olan sürenin bitiminden sonra ortaklık, ortakların örtülü iradesiyle sürdürülürse, belirsiz süreli ortaklığa dönüşür*".

b) Sözleşmede öngörülen infisah sebepleri

Türk Borçlar Kanununun 26'ncı maddesinde taraflara, sözleşmenin içeriğini kanunda öngörülen sınırlar içinde diledikleri gibi özgürce belirleme, düzenleme yetkisi verilmiştir.

Sözleşme özgürlüğü uyarınca taraflar, bir yandan sözleşmenin tipini, diğer yandan da sözleşmenin içeriğini, yani edimlerin miktarını, konusunu, süresini ve bu bağlamda sözleşmeyi sona erdiren sebepleri, kanunda öngörülen sınırlar içinde özgürce belirleyebilir.

Bilindiği üzere, geçerli olarak yapılmış bir sözleşmenin sonuçlarının ortadan kalkması, gelecekteki belirsiz bir olayın gerçekleşmesine bağlanmış ise, bozucu şarta bağlı bir sözleşme söz konusu olur (TBK m.173/1). Bu anlamda, şirket sözleşmesinde öngörülen infisah sebeplerini, bozucu şart olarak nitelendirerek, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde sözleşmeye konulabileceğini kabul etmek gerekir. Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmayan her şart, (meselâ şirketin devamı için hayati ehemmiyeti haiz bir patent hakkının iptali), sözleşmeyle infisah sebebi olarak nitelendirilebilir (TBK m.26-27).

2) Fesih Sebepleri

Adi şirket sözleşmesi ile ortaklar arasında kurulan hukuki bağın, *iradi* olarak sona erdirilmesi olarak nitelendirdiğimiz *"fesih"* (dağıtma) sebepleri, kanunda veya sözleşmede öngörülmüş olabilir. Bunları "*kanunda öngörülen fesih sebepleri*" ve "*sözleşmede öngörülen fesih sebepleri*" başlığı altında inceleyeceğiz.

a) Kanunda öngörülen fesih hâlleri

Kanun koyucu Türk Borçlar Kanununun 639 ve 640'ıncı maddelerinde fesih sebeplerini saymıştır.

aa) Ortakların alacağı kararla fesih

Diğer borç sözleşmeleri gibi, şirket sözleşmesi de onu vücuda getiren tarafların karşılıklı ve birbirine uygun iradeleri ile herhangi bir anda ortadan kaldırılabilir.

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 4'üncü bendinin açık hükmü karşısında; sona erme kararının *oybirliği* ile alınması gerekir. Bununla birlikte, şirket sözleşmesinde sona ermeyle ilgili kararın *oy çokluğu* ile alınabileceği açıkça belirtilerek oy birliği şartından vazgeçilebilir[124]; bu hâlde oy çokluğu, ortak sayısına göre belirlenecektir (TBK m.624/2).

bb) Kanunda tanınan feshi ihbar hakkının kullanılmasıyla şirketin sona erdirilmesi

Feshi ihbar suretiyle adi şirketin sona erdirilebilmesi için, ortakların ya sözleşme ya da kanun hükmü gereği feshi ihbar hakkının bulunması ve bu hakkın usulüne uygun şekilde kullanılması gerekir. Bu başlık altında, kanun hükmü gereği feshi ihbar hakkının kullanılmasıyla şirketin sona erdirilmesi ele alınacaktır.

aaa) Kanundan doğan feshi ihbar hakları

Sözleşmeyle fesih hakkı verilmemiş olsa bile ortaklar, *kanunda* belirtilen iki hâlde feshi ihbarda bulunmak suretiyle şirketi sona erdirebilirler.

(1) Şirketin belirsiz süreli olması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı

Adi şirket sözleşmesi, belirli bir süre öngörülerek veya öngörülmeden kurulabilir (TBK m.640/1). Belirli süre ya muayyen bir tarih (31.12.2020 gibi) olarak öngörülür ya da kuruluştan itibaren belirli bir süre (şirketin süresi on yıldır gibi) olarak da gösterilebilir. Belirsiz süreli şirketlerde sürenin belirsiz olduğunu ifade etmek gerekmez;

---

[124] **Handschin/Vonzun**, Art. 545, Ziff.4 und 5, N. 110.

herhangi bir sürenin belirtilmemiş olması, şirketi belirsiz süreli şirket hâline getirir.

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 6'ncı bendinde "*...ortaklık **belirsiz bir süre için kurulmuşsa**, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla*" şirketin sona ereceği hükme bağlanmış; bu feshin, ortaklardan her biri tarafından (önel verilerek) altı ay önceden kullanılması gerektiği (TBK m.640/1) kabul edilmiştir. Ortaklara tanınmış bulunan fesih hakkı, emredici mahiyettedir, şirket sözleşmesiyle ortakların elinden alınamaz; ancak bu hakkın nasıl kullanılacağına dair hükümler geçerli olmalıdır.

(2) Şirketin ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulması hâlinde ortaklara tanınan feshi ihbar hakkı

Şirketin sözleşmesinin, ortaklardan birinin ömrü boyunca geçerli olmak üzere kurulması, şirketin belirsiz süreli şirket olarak kurulmasının sonuçlarına tâbi tutulmuş; bu durumda belirsiz süreli şirketlerde olduğu gibi, ortakların feshi ihbar hakkının bulunduğu kanun koyucu tarafından belirtilmiş (TBK m.639/1,6); bu feshin, altı ay evvel bildirilmesi gerektiği ifade edilmiştir (TBK m.640/1).

bbb) Kanundan doğan feshi ihbar hakkının kullanılması

Fesih, sürekli bir sözleşme ilişkisini ileriye doğru sona erdiren, varması gereken, bozucu yenilik doğuran hak olduğundan, ihbar edilme (bildirilme) gereği vardır.

Kanun koyucu, feshin ihbarını herhangi bir *şekil şartına tâbi tutmamış*; fesih iradesinin açıkça ifade edilmesini yeterli görmüştür. Bu husus, adi şirketin bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulması hâlinde de geçerli olmalıdır. Adi şirket ortakları, TTK m.12/1 gereği tacir sayılacaklarından, feshi ihbarın, TTK m.18/3'de hükme bağlandığı gibi, "*noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi*" ile yapılması gerekeceği sonucuna varılmamalıdır; kişi birliği olan adi şirketlerin sona erdirilmesini amaçlayan ihbarlar bu kapsamda değerlendirilmemelidir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki TTK m.18/3'de öngörülen bu şekil zaten, *geçerlilik değil sadece ispat şartıdır.*

Kanun koyucu ortakların feshi ihbar hakkının ne zaman ve nasıl kullanılabileceğini Türk Borçlar Kanununun 640'ıncı maddesinde düzenlemiştir. Buna göre, "*Ortaklık, belirsiz süre için veya ortaklardan*

birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulmuşsa, ortaklardan her biri, *altı ay önceden fesih bildiriminde bulunabilir"*(TBK m.640/1); *"**fesih bildirimi, ancak hesap yılı sonunda hüküm ifade eder**"*(TBK m.640/2).

Fesih bildiriminin TBK m.640/1'de belirtilen süreye riayet edilmeden yapılması, ihbarı geçersiz kılmaz; sadece hüküm ifade edeceği tarihi değiştirir. Bir diğer ifadeyle, feshi ihbar bildirimi süresinde yapılırsa, hesap yılı sonunda hüküm ifade edecekken, süresinde yapılmazsa feshi ihbar yine geçerli olacak; ancak hükmünü, ilk hesap yılı sonunda değil, bir sonraki hesap yılında gösterecektir.

"Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda yapılamaz" (TBK m.640/2). Fesih bildirimi, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda yapılırsa, fesih yine geçerlidir; ancak fesih bildirimini dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan zamanda yapan ortak, diğer ortakların bu sebeple uğradığı zararı tazmin ile yükümlü olabilir.

b) Şirket sözleşmesinde öngörülen fesih hakkı

Sözleşme özgürlüğü çerçevesinde, Kanunda hükme bağlanan fesih sebeplerinden başka, sözleşmede açıkça tanımlanmak kaydıyla, şirket sözleşmesiyle ortaklara fesih hakkı tanınabilir. Bu husus, Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 6'ncı bendine göre, *"Ortaklık sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuş...(ise), bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla"* şirket sona erer şeklinde ifade edilmiştir. Hükümden de anlaşıldığı üzere, hem belirli hem de belirsiz süreli şirketlerde, şirket sözleşmesiyle ortaklara veya ortaklardan birine şirketi sona erdirme; feshi bildirme (ihbar) hakkı tanınabilmektedir.

Bozucu yenilik doğuran bir hak olan fesih hakkı, fesih bildiriminin karşı tarafa ulaşmasıyla hüküm ifade eder[125]. Bununla birlikte, fesih

[125] Bilindiği üzere *fesih*, sürekli bir sözleşme ilişkisini ileriye doğru sona erdiren *bozucu yenilik doğuran bir haktır*. Türk hukuk geleneğinde süresiz (bildirimsiz/derhal) feshe *"fesih"*, süreli (bildirimli) feshe ise *"feshi ihbar"* denilmektedir. Bu bağlamda TBK m.639/1, b.6'da da *"fesihi bildirime hakkı saklı tutulmuş"* bulunulmasından bahsedildiği için, *süreli (bildirimli) feshin* kastedildiği sonucu algılanıyorsa da, kanun koyucunun amacının fesih için bir süre (önel) vermek değil; sadece feshi bildirmek (bildirimsiz/önel vermeden fesih) olduğu

hakkının kullanılması sözleşmeyle özel olarak düzenlenmişse ve bu bağlamda, feshin geçerli olması bir süreye bağlanmışsa; fesih hakkı sözleşmede belirlenen şekilde kullanılmalıdır.

Bu hâlde kendisine fesih hakkı verilen ortak veya ortaklar, sözleşmede öngörülen fesih sebeplerinin gerçekleştiği iddiasıyla sözleşmede belirtilen şekilde şirket sözleşmesini feshedebilir. Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması hâlinde, *sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa*, feshi ihbarda bulunan ortak, şirketin feshi yerine şirketten çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle şirketten çıkarılabilir (TBK m.633).

Sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa ve ortak, kendisine tanınan fesih hakkını kullanarak şirketin feshini talep etmişse, diğer ortaklar şirketin devamına karar veremez; ortakların alacağı karar, yeni bir şirketin kurulmasına yönelik olabilir. Mevcut şirket feshi ihbarla sona ereceğinden tasfiye sürecinin başlatılması gerekir.

c) Mahkeme kararıyla (haklı sebeplerle) fesih

Türk Borçlar Kanununda öngörülen fesih sebeplerinden biri de haklı sebeplerin bulunması hâlinde ortaklara tanınan, mahkemeden şirketin feshini talep hakkıdır.

Türk Borçlar Kanununun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının yedinci bendinde, "*Haklı sebeplerin bulunması hâlinde, her zaman başkaca koşul aranmaksızın, fesih istemi üzerine mahkeme kararıyla*" şirketin sona erdirilebileceği hükme bağlanmıştır.

Haklı sebeplere dayalı olarak kullanılacak fesih hakkı, dava yoluyla ileri sürülebilen, sözleşmeyle veya daha sonra alınacak bir kararla ortadan kaldırılamayan; *bozucu yenilik doğurucu bir haktır* ve tüm ortaklara tanınmıştır. Ortaklardan biri haklı sebebe istinaden şirketin feshini talep ettiğinde diğer ortakların, TBK m.633 gereğince, feshi ihbarda bulunan ortağı şirketten çıkarma imkânı vardır. Fesih davası

---

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda fesih, bildirim (önel verme) şartına bağlanmamışsa; TBK m.639/1, b.6'ya göre, kendisine şirketi feshetme yetkisi tanınan ortağın, fesih hakkını kullanmasıyla şirket sona erer.

açılmasından sonra fesih bildiriminde bulunan ortağın diğer ortaklar tarafından TBK m.633'e göre çıkarılması hâlinde, ortağın ortaklık sıfatı sona ereceğinden fesih davası düşer[126].

Davanın haklı sebeplere istinaden açılması gerekmesine karşın, Kanunumuzda *haklı sebep tanımlanmamış*; açık bir norm olarak bırakılmıştır. Bu sebeple TMK m.4'de öngörüldüğü üzere, Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda *hâkim*, hukuka ve hakkaniyete göre karar vermelidir. Bununla birlikte hâkimin, kişileri bir araya getiren ve şirket sözleşmesinin kurulmasına sebebiyet veren önemli koşulların ortadan kalkmasını haklı sebep olarak nitelendirmesi yanlış olmaz. Ortakların müşterek amaca ulaşmak için çalışma yerine veya onun yanında, kendi menfaatini şirket menfaatinden üstün tutması da haklı sebep olarak kabul edilebilir. Haklı sebep kavramı, kollektif şirketler açısından TTK m. 255'te örnekleme suretiyle açıklanmıştır. Söz konusu hüküm, adi şirketler bakımından da mahiyetine uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanabilir.

Mahkemenin haklı sebebe istinaden verdiği sona erme kararı, bozucu yenilik doğuran bir karardır; mahkeme kararının kesinleşmesiyle ileriye doğru hüküm doğurur. *Mahkeme kararı ile hükmün kesinleşmesi tarihleri arasında* adi şirket ilişkisi süreceğinden, haklı sebebe istinaden fesih talebinde bulunan ortağın ortaklık hakları devam edecektir. Bu durumun mahzurlarını ortadan kaldırmak maksadıyla; hâkim, adi şirketle ilgili olarak gerekli tedbirleri almalıdır

B) ADİ ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

Daha evvelce de özellikle belirttiğimiz üzere, gerek fesih gerek infisah sebeplerinin gerçekleşmesi, şirketi hemen sona erdirmez; fesih veya infisah sebeplerinin gerçekleştiği an, şirketin sona ereceği sürecin başlangıcını teşkil eder.

Sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle şirket tasfiye sürecine girer ve bu sürecin tamamlanmasına kadar başlangıçtakinden farklı bir gaye, yani *tasfiye gayesi ile şirket devam eder*. Bununla birlikte sona ermenin hüküm ve sonuçları, sona erme sebeplerinin ortaya çıkması anından itibaren geçerlidir. Bu bakımdan adi şirketin sona erme

---

[126] Bu durum, farklı sebeplerle fesih bildiriminde bulunan ortak açısından da geçerlidir.

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi durumunda, iki sonuç ortaya çıkar; bunlardan birisi, yöneticilerin görevinin sona ermesi, diğeri ise tasfiyedir.

1) Sona ermenin şirketin yönetimine etkisi

Sona ermenin ortaklık yönetimine etkisini hükme bağlayan Türk Borçlar Kanununun 641'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, "Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona ererse, bir ortağın ortaklık işlerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi öğrendiği veya durumun gerektirdiği özeni gösterseydi öğrenebileceği zamana kadar, kendisi hakkında devam eder".

Hükümden de anlaşıldığı üzere, bir ortaktan şirket faaliyetlerini tatil etmesi, ancak onun şirketin sona ermesini *öğrendiği* veya *öğrenmesi lâzım geldiği* andan itibaren talep olunabileceğinden; bu ana kadar onun şirket işlerini idare ve iyi niyetli üçüncü şahıslara karşı temsil etme yetkisinin devam ettiğinin kabul edilmesi gerekir. Şirketin fesih bildirimi ile sona erdirilmesinde, kendisine bildirimde bulunulmuş olan ortak, feshi öğrenmediğini ileri süremeyeceğinden; yönetim ve temsil yetkisinin devamı söz konusu olmaz. Bütün ortakların oybirliği ile şirketin sona ermesine karar verilmesi hâlinde de durum aynıdır; kararla birlikte, ortakların yönetim ve temsil yetkisi sona erer.

Şirket, ortaklardan birinin ölümü sebebiyle infisah etmişse; diğer ortakların sona erme sebebine muttali olmayarak şirket işlerine devam etmelerini önlemek üzere, ölen ortağın mirasçılarının diğer ortakları derhal haberdar etmeleri lâzımdır. Diğer yandan, ortaklardan birinin ölümü ile onun evvelce idare etmekte olduğu işlerin birdenbire durması yüzünden şirketin zarara uğramasına mani olmak üzere; ölen ortağın mirasçıları, lüzumlu tedbirler alınıncaya kadar, dürüstlük kuralları çerçevesinde bu işlerin idaresine devam etmeye de mecbur tutulmuşlardır (TBK m.641/2).

Aynı sebepten, yani şirketin sona ermesini takiben şirket içerisindeki faaliyetlerini birdenbire sadece tasfiye muamelelerine tahsis ederek, daha evvel başlamış olan şirket işlerine alâka göstermemek suretiyle, şirketin zarara uğramasına meydan vermemeleri için; *diğer ortaklar dahi*, geçici olarak şirket işlerini aynı surette idareye devam etmekle mükellef kılınmışlardır (TBK m.641/2).

2) Adi Şirketin Tasfiyesi

a) Tasfiye kavramı

Şirketin sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle şirket hemen sona ermez; şirketin amacı değişir ve şirket tasfiye sürecine girerek *tasfiye hâlinde şirket* sıfatını alır. Tasfiyenin amacı, şirketin tamamen sona ermesi sonucunu doğuracak işlemlerin yapılmasıdır.

Bu şekliyle tasfiye, şirket sözleşmesiyle ortaklar arasında kurulan hukuki bağın çözülmesi neticesinde, müşterek gaye etrafında toplanmış bulunan unsurların, tekrar ortakların bireysel çevresine iadesini ifade ederken (geniş anlamda tasfiye); diğer anlamda ise, alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi, şirketin üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinin tamamen kesilmesi, şirketin malvarlığının nakde çevrilmesi ve kalanın dağıtılmasıdır (dar anlamda tasfiye).

Sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle birlikte her ortak, şirketin tasfiyesini talep edebilir; ortakların tasfiyeyi talep hakkı, sözleşmeyle ortadan kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz.

Tasfiye, tasfiyeye ihtiyaç gösteren muamelelerinin tamamını kapsayan, birbirine bağlı ve uyumlu işlemler bütünü olduğundan, hiçbir ortak, münferit bazı münasebetlerin ayrıca tasfiyesini isteyemeyeceği gibi, bundan mütevellit özel bazı haklar da ileri süremez.

b) Tasfiye hâlinin şirkette meydana getirdiği değişiklikler

Tasfiye hâline giren şirket sona ermez; tasfiye kapanıncaya kadar kişi birliği devam eder; ancak tasfiyenin sona ermesi yani tasfiyenin kapanması ile birlikte, kişi birliği de sona erer.

Şirket tasfiye haline girmekle sona ermediği için, tasfiye hâlindeki şirket, tasfiyeden önceki şirkettir; şirketin mahiyetinde bir değişiklik olmadığı için, malvarlığının devri ve bundan kaynaklanan vergi mükellefiyetleri de söz konusu değildir. Bu itibarla tasfiye hâlindeki şirketin, tasfiyeye girmeden evvel üçüncü şahıslarla yaptığı sözleşmeler ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri de değişmeden devam eder.

Tasfiye hâline giren şirketin sadece *gayesi değişir*; şirketin kazanç sağlamak ve bunu paylaşmak olan gayesi, tasfiye gayesine dönüşür ve esas itibariyle bundan böyle sadece tasfiye gayesine yönelik muameleler yapılabilir.

c) Tasfiye hâline uygulanacak hükümler

Adi şirketlerde tasfiyenin nasıl yapılacağı, *tasfiye usulü* başlığı altında Türk Borçlar Kanununun 644'üncü maddesinde hükme bağlanmış; hükmün tetkikinden de anlaşılacağı üzere, adi şirketlerin tasfiyesinde ortakların iradesine üstünlük tanınarak, tasfiyenin nasıl yapılacağının sözleşmede ya da daha sonra alınacak bir kararla belirlenebileceği kabul edilmiştir.

Buna göre tasfiye, şirket sözleşmesinde öngörülen usulde veya ortakların alacağı bir kararla; şirket sözleşmesinde tasfiyeye ilişkin hüküm bulunmaması veya bir karar alınamaması hâlinde, tasfiye Türk Borçlar Kanununda öngörüldüğü tarzda yapılacaktır. Bu anlamda *Türk Borçlar Kanunundaki tasfiyeye ilişkin hükümler tamamlayıcı mahiyettedir.*

d) Tasfiye görevlileri

Tasfiye, tasfiye görevlileri tarafından gerçekleştirilir. Tasfiye görevlileri, tasfiye sürecini kanun ve sözleşme hükümleri ile genel kurul kararları doğrultusunda yürütecek kişi veya kişilerdir.

Sözleşmeyle yahut daha sonra alınacak bir kararla tasfiyenin hangi esaslara bağlı olarak yapılacağı kararlaştırılabileceği gibi, tasfiye usulünün haricinde, bilhassa tasfiyeyi yapacak olan tasfiye görevlilerinin atanması da şirket sözleşmesiyle yapılabilir veya daha sonra ortakların alacağı bir kararla tasfiye görevlisi atanabilir.

aa) Tasfiye görevlilerinin atanması

aaa) Tasfiye görevlilerinin şirket sözleşmesi uyarınca atanması

Şirket sözleşmesiyle, şirketin kuruluşu esnasında tasfiye usulü serbestçe belirlenebileceği gibi, daha sonra sözleşmenin değiştirilmesi suretiyle de *tasfiyenin usulü* ve tasfiyenin kimler tarafından yapılacağı kararlaştırılabilir. Bu bağlamda şirket sözleşmesiyle, ortaklardan bir veya birkaçının yahut tüm ortakların *tasfiye görevlisi* olarak belirlenmesi mümkündür. Üçüncü bir kişinin tasfiye görevlisi olarak atanması hâlinde bu kişinin *belirlenmiş* veya "*tasfiye şirket mali müşaviri tarafından yapılacaktır*" gibi *belirlenebilir olması* yeterlidir.

Sözleşmeyle atanan tasfiye görevlisinin, görevi reddetme hakkı her zaman mevcuttur. Görevin reddi hâlinde, sözleşmede başka bir çözüm tarzı öngörülmemiş ve ortaklar oybirliği ile yeni bir tasfiye görevlisi

atamamışlarsa; tasfiye Türk Borçlar Kanunu m.644/1 hükmüne göre "*bütün ortakların elbirliğiyle*" yapılır. Şirket sözleşmesiyle birden ziyade tasfiye görevlisi atanmış ve bunların birlikte hareket edecekleri öngörülmüş olmasına karşın, içlerinden biri görevi reddederse; sözleşmede başka bir çözüm tarzı getirilmemiş ve ortaklar oybirliği ile yeni bir tasfiye görevlisi atamamışlarsa; tasfiye yine Türk Borçlar Kanunu m.644/1 hükmüne göre "*bütün ortakların elbirliğiyle*" yapılacaktır.

bbb) Tasfiye görevlisinin ortakların kararıyla atanması

Şirket sözleşmesinde tasfiyenin usulü ve tasfiyenin kimler tarafından yapılacağı belirlenmemiş olsa da, ortaklar daha sonra alacakları bir kararla tasfiye usulünü ve tasfiyenin kim yahut kimler tarafından yapılacağını kararlaştırabilirler. Ortaklığın kararları, bütün *ortakların oybirliğiyle* alınır. Sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısına göre belirlenir (TBK m.624).

ccc) Tasfiye görevlisinin kanun gereği atanması

Şirket sözleşmesinde bir tasfiye usulü öngörülmemiş ve daha sonra ortaklar tarafından da tasfiyenin nasıl yapılacağına ilişkin bir karar alınmamışsa, tasfiyenin kanunda belirtildiği usulde yapılması gerekir. *Tasfiye usulünü* hükme bağlayan Türk Borçlar Kanununun 644'üncü maddesine göre, "*Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici olmayan ortaklar da dâhil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır*".

Buna göre sona erme anında ortak sıfatını haiz olanlar, kendiliğinden *tasfiye görevlisi* sıfatıyla tasfiye işlerini üstlenmiş olurlar ve tasfiyenin kapanışına kadar da bu sıfatla görevlerini sürdürürler. Ortaklardan biri veya birkaçı tasfiye görevini kabul etmezse; diğer ortaklar tasfiyeye devam edemez. Bu durumda ortaklardan her biri tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması isteminde bulunabilir (TBK m.644/2).

ddd) Tasfiye görevlisinin hâkim tarafından atanması

Şirket sözleşmesinde bir tasfiye usulü öngörülmemiş ve daha sonra ortaklar tasfiyenin nasıl yapılacağına ilişkin *bir karar alamamışsa* ve bir araya gelip *tasfiyeyi elbirliği ile de yapamıyorlarsa*, ortaklardan her

biri tasfiye görevlisinin *hâkim tarafından* atanması[127] isteminde bulunabilir (TBK m.644/2). Bu hâlde tasfiye, hâkim tarafından atanan tasfiye görevlisi veya görevlileri tarafından yapılacaktır.

Hâkim tarafından atama yapılabilmesi için, ortaklardan birinin dava yoluyla talepte bulunması gerekir; hâkim kendiliğinden harekete geçemez. Bu davada ortak, şirketin sona erdiğini, sözleşmede tasfiyeye ilişkin bir düzenleme olmadığını, kendi aralarında anlaşamadıklarını ve bu nedenle ortaklığın tasfiyesinin, mahkeme tarafından atanacak tasfiye görevlisi marifetiyle yapılmasını talep eder. Dava ortaklardan biri tarafından diğer tüm ortaklara karşı, sulh hukuk mahkemesinde açılmalıdır (HMK m. 4/1.c). Ancak adi şirket ticari işletme işletiyorsa davanın, işletme merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde görülmesi gerekir.

bb) Tasfiye görevlilerine ilişkin şartlar

Adi şirketlerde tasfiye işlerinin tasfiye görevlisi tarafından yapılacağı ve tasfiye görevlilerinin nasıl atanacağı Türk Borçlar Kanununun 644'üncü maddesinde hükme bağlanmış; tasfiye görevlilerine ilişkin şartlardan söz edilmemiştir.

Kanundaki düzenlemeye nazaran, tasfiye görevlileri ortaklar arasından atanabileceği gibi; ortak olmayanlar arasından da atanabilir. Kanaatimizce tasfiye görevlisinin gerçek kişi olması zorunlu değildir; tüzel kişilerin ve bilhassa bağımsız denetim yapmak üzere ruhsat almış tüzel kişilerin tasfiye görevlisi olması mümkündür[128].

---

127 TBK m.644/2'de, her ne kadar "*hâkim tarafından atanma*"dan söz edilse de; burada kastedilenin hukuk mahkemesi olduğunda şüphe yoktur.

128 Bkz., Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu §265/2; Tasfiye görevlisi olarak atanacak kişilerin uyrukluğu hakkında Türk Borçlar Kanununda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bilindiği gibi 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi ile 11.6.1932 tarih ve 2007 sayılı Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış; 2007 sayılı Kanunda yer alan mesleklerin yabancılar tarafından icra edilebilmesi mümkün hâle gelmiştir. Ancak 2007 sayılı Kanunun dışında da yabancıların çalışma hayatına sınırlamalar getiren ve hâlen yürürlükte olan kanunlar bulunmaktadır. Nitekim 4817 sayılı Kanunun13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında konuya açıklık getirilerek "*diğer kanunlarda yer alan, yabancıların çalışamayacağı iş ve mesleklere dair hükümler saklıdır*" hükmüne yer verilmiştir. Bu itibarla süreli, süresiz ve bağımsız çalışma izni verilenler ile muafiyet kapsamındaki yabancıların 2007 sayılı Kanun haricindeki Kanunlarda yer alan ve sırf Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan iş ve mesleklerde çalışmaları mümkün

cc) Tasfiye görevlilerinin hukuki durumu

Tasfiye görevliliği sıfatı hangi usulle kazanılmış olursa olsun, ortaklarla tasfiye görevlisi arasında bir hukuki ilişkinin bulunduğu kabul edilmelidir.

Bu hukuki ilişkiyi tavsif eden, tasfiye görevlisinin görev ve yetkileridir. Bilindiği üzere tasfiye görevlisi; şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, ortaklar ad ve hesabına, şirketin tasfiyeye giren iş ve işlemlerini yapan kişidir. Hukukumuzda bir kimsenin, hüküm ve sonuçları başka bir kişinin hukuk alanında doğmak üzere o kişinin ad ve hesabına hukuki işlem yapma yetkisine *temsil* denir (TBK m.40). Temsil yetkisi, tasfiye görevlisinin sözleşmeyle veya daha sonra alacakları bir karara dayanarak seçilmesinde olduğu gibi, temsil olunanın iradesine dayanıyorsa *iradi temsil*; temsil, bütün ortakların tasfiye görevlisi sıfatıyla hareket etmesinde olduğu gibi kanun icabı doğuyorsa, buna da *kanuni temsil* adı verilir. Kanuni temsil, bazı hallerde yine kaynağını bir kanun hükmünde bulmakla birlikte, temsil ilişkisi, resmi bir makamın, özellikle bir mahkemenin kararı ile doğabilir.

Tasfiye görevlisinin tasfiye işlerine başlayabilmesi için, tasfiye işlerini yapmak üzere tasfiye görevlisine *ortakları temsil yetkisinin verilmesi gerekir*. Ortakların tasfiye görevlisine, tasfiye işlerini kendileri adına yapmak üzere, tek taraflı, varması gerekli bir irade beyanı ile verdiği yetki ile iç ilişkide tasfiye işleri başlamış olur. Tasfiye görevlisinin tasfiye işlerinde ortakları temsil yetkisi, ortakların tasfiye işlerini yapmak üzere tasfiye görevlisi olarak atandığının bildirildiği anda doğar ve bundan böyle tasfiye görevlisi tarafından yapılan hukuki işlemin hüküm ve sonuçları ortakların hukuki alanında meydana gelir.

Ancak tasfiye görevlisi aynı zamanda üçüncü kişilerle de ilişki içine girmek; tasfiyeyi gerçekleştirmek maksadıyla alacakları tahsil, borçları ifa etmek, tasfiyenin amacına uygun sair işlemleri ortaklar ad ve hesabına yapmak zorundadır. Tasfiye görevlisine verilen bu görevlerin yerine getirilebilmesi, yetkilerin kullanılması için, tasfiye görevlisine üçüncü şahıslarla işlem yapması hususunda yetki verilmesi gerekir.

Tasfiye görevlisine bu dış temsil yetkisinin verilmesi herhangi bir şekle tâbi değildir; iç temsil yetkisinde olduğu gibi, tasfiye görevlisi

---

bulunmamaktadır. Yabancılara yasaklanan işler arasında tasfiye görevliliği yer almamaktadır. Bu itibarla Türk vatandaşı olmayan kişilerin de tasfiye görevlisi olabileceğinin kabulü gerekir.

olarak atanmış olmak, dış temsil yetkisi için de yeterlidir. Bununla beraber, tasfiye görevlisi olarak atanan kişinin, tasfiyeye ilişkin muameleleri yapabilmesi için, tasfiye ile görevlendirildiğinin üçüncü kişilere duyurulması gerekir. Adi şirketlerde bu duyuru herhangi bir şekle tâbi değildir; sözlü veya yazılı olabileceği gibi, bir gazetede ilân da edilebilir.

Hangi surette atanırsa atansın, adi şirket ticari işletme işletiyorsa, atanan tasfiye memurunun ticaret siciline tescil edilmesi ve TTK m. 35'de sözü edilen gazete ile ilân edilmesi gerekir. Bu hâlde tescilin fonksiyonu bildiricidir; tasfiye görevlisi olmanın şartı değildir. Tasfiye görevlisi olarak atanan kişi, tescil işleminden evvel, atama işlemiyle birlikte tasfiye görevliliği sıfatını kazanmıştır.

dd) Tasfiye görevlilerinin hak ve yetkileri

aaa) Tasfiye görevlilerinin hakları

Tasfiye görevlilerinin haklarının başında, ücret hakkı gelir. Türk Borçlar Kanunu m.644/3 uyarınca, "Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirliğiyle verilmiş bir karar yoksa tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önünde tutularak hâkim tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, ortaklardan müteselsilen karşılanır".

Hükümden de anlaşılacağı üzere, her ne şekilde kazanılırsa kazanılsın, tasfiye görevlisi sıfatını kazanan herkes, *ücret isteme* hakkını haizdir. Bu esastan olmak üzere, tasfiye işleri bütün ortakların elbirliği ile yapıldığında dahi tasfiye görevlisi sıfatını taşıyan ortakların tamamı ücrete hak kazanır.

Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, *sözleşmede* hükme bağlanabilir; sözleşmede hükme bağlanmamışsa, *ortaklarca* kararlaştırılabilir. Ortakların tasfiye görevlisine ödenecek ücret konusunda alacağı kararda oybirliği esastır. Bununla birlikte kanaatimizce Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesinin ikinci fıkrası mucibince, sözleşmede kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse, tasfiye görevlisine ödenecek ücret çoğunluk kararıyla da belirlenebilir; bu durumda çoğunluk, ortak sayısına göre hesap edilir.

Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede hükme bağlanmamış ve ortaklarca da kararlaştırılmamışsa, *hâkim* tarafından belirlenir.

Hâkim, tasfiye görevlisine ödenecek ücreti belirlerken, tasfiyenin gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığını ve gelirini göz önünde tutacaktır. Tasfiye görevlilerine ödenecek ücretin öncelikle ortaklık malvarlığından ödenmesi; buna imkân bulunmazsa, ortakların müteselsilen ödemesi gerekir.

Tasfiye görevlisinin ücret hakkının yanında, yapısına uygun düştüğü ölçüde, yönetici ortağa sağlanan haklardan da istifade edebileceğinin kabulü gerekir. Bu bağlamdan olmak üzere, tesislerden faydalanma hakkı gibi haklarından bahsedilebilir.

bbb) Tasfiye görevlilerinin yetkileri

Tasfiye görevlileri, tasfiye hâlindeki şirketi özel yetkilerle idare eder. Tasfiye görevlilerinin bu yetkileri onların aynı zamanda yükümlülükleridir; yerine getirilmemesi sorumluluklarını gerektirir.

Tasfiye görevlilerinin sahip olduğu yetkilerin genel sınırını, tasfiyenin yapılabilmesi için zorunlu olan ve mahiyeti icabı tasfiye görevlisi tarafından yapılması gereken işler oluşturur.

Tasfiye görevlileri bu yetkileri bizzat kullanmak zorundadır; bir tasfiye görevlisi görevini, diğer bir tasfiye görevlisine veya üçüncü kişilere devredemez. Ancak, bazı belirli iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için tasfiye görevlileri, içlerinden birini veya bazılarını ya da üçüncü kişiyi vekil edebilir (TTK m.279); yardımcı kullanabilir.

Birden fazla tasfiye görevlisi tayin edilmişse, şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla tasfiye işlerini yalnız başına görmeye yetkili kılınmamış olan tasfiye görevlileri birlikte hareket ederler (TTK m.278/1). Birlikte hareket edilmesi, aynı anda hareket edilmesi veya aynı anda imza atılması anlamına gelmez; birinin yaptığı işleme diğerinin katılması veya icazet vermesi yeterlidir.

ee) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesi

Tasfiye görevlisi sıfatı azil, istifa, ölüm veya fiil ehliyetinin kaybedilmesi gibi çeşitli nedenlerle sona erebilir.

aaa) Tasfiye görevlisi sıfatının sona erme sebepleri

(1) Azil

Şirket sözleşmesiyle veya ortakların kararıyla atanmış olan tasfiye görevlileri, ortakların Türk Borçlar Kanununun 624'üncü maddesine

uygun şekilde alacağı bir kararla her zaman azledilebilir. Mahkemenin atadığı tasfiye görevlisinin ortakların alacağı kararla azli mümkün değildir; ortaklar, mahkeme kararıyla atanan tasfiye görevlisinin azlini mahkemeden isteyebilirler. Ortakların tasfiye görevlisinin azli hususunda anlaşamamaları hâlinde de ortaklardan herhangi biri, tasfiye görevlisinin haklı sebeple azlini mahkemeden talep edebilir.

(2) İstifa

Tasfiye memuru, atama şekli ne olursa olsun, her zaman istifa edebilir. Tasfiye memuru istifa ederken herhangi bir gerekçe göstermek mecburiyetinde de değildir. Bununla birlikte uygun olmayan bir zamanda istifa, bir zarara sebebiyet verirse, ortakların tazminat talep hakları doğar.

(3) Diğer sona erme sebepleri

Tasfiye görevlisinin tasfiye işlemlerini tamamlayıp tasfiyeyi kapatması, süreli olarak atanmışsa kararlaştırılan sürenin sona ermesi; tasfiye görevlisi bir gerçek kişi ise ölümü, fiil ehliyetini kaybetmesi, tasfiye görevlisi sıfatının diğer sona erme sebepleri olarak gösterilebilir.

bbb) Tasfiye görevlisi sıfatının sona ermesinin duyurulması

Tasfiye görevlisi sıfatının sona erdiğinin iç ilişkide tasfiye görevlisine ihbar edilmesi gerekir. İç ilişkide tasfiye görevlisinin atanması herhangi bir şekle tâbi olmadığı gibi, sona ermenin meselâ azlin bildirilmesi de bir şekle tâbi değildir. Buna karşılık dış ilişkide temsil yetkisinin sona erdiğinin üçüncü kişilere duyurulması gerekir. Bu duyurma esas itibariyle herhangi bir şekle tâbi değildir. Ancak adi şirket bir ticari işletme işletiyorsa, ticaret siciline tescil ve ilân edilmelidir.

e) Tasfiye işlemleri

Tasfiyeyi düzenleyen hükümlerden de anlaşıldığı üzere, tasfiyenin yapılabilmesi için öncelikle şirket aktiflerinin paraya çevrilmesi ve şirket borçlarının ödenmesi (*dış tasfiye*); şirket borçları ödendikten sonra geriye bir şey kalırsa, bu kalanın belirli esaslar dâhilinde ortaklara dağıtılması (*iç tasfiye*) gerekir[129]. Ancak Türk Borçlar Kanununda açıkça

[129] Yargıtay 13. HD, 03.02.2011 tarih, E 2010/5661 K 2010/1578 kararında, tasfiyenin hangi sıraya göre yapılması gerektiğini şöyle tespit etmektedir: "*Ortaklık sözleşmesinde hüküm bulunduğu takdirde tasfiyenin sözleşmedeki hükümlere*

ifade edilmesine karşın, tasfiye işlemlerine geçmeden evvel tasfiye görevlisinin belirli tedbirleri alması bazı işlemleri yapması gerekecektir.

aa) Tasfiyeye başlanmadan evvel alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler

Tasfiye görevlisi, ortakların haklı menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle gereken tedbirleri almalı (TBK m.506/2); bu esastan olmak üzere meselâ, gerekiyorsa işletme faaliyetlerini durdurmalı, ortaklık mallarını sigortalatmak gibi *koruyucu tedbirler* almalı, bunun yanında, tasfiyenin sıhhatli bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan defterleri de tutmalı (Bkz., TTK m.286, 288), şirketin tasfiyeye girdiğini vergi daireleri ile diğer tahsil dairelerine bildirmelidir (VUK m.162, 168; AATUHK m.33).

Türk Borçlar Kanununda hükme bağlanmamakla birlikte, kollektif şirketlerde olduğu gibi, tasfiye görevlileri, önceden seçilmişlerse şirketin sona ermesini hemen izleyen günlerde ve şirketin sona ermesinden sonra ortaklarca seçilmiş veya mahkemece atanmışlarsa seçimlerinden ve atanmalarından hemen sonra şirket işlerini gören kişileri çağırarak onlarla birlikte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına, şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenlemelidirler (TTK m.287). Tasfiye görevlileri gerek görürlerse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurabilmeli; düzenlenen envanter ile bilanço,

---

göre yapılması asıldır. Böyle bir hükmün bulunmaması halinde ise tasfiyenin bu defa BK'nın 539 (TBK m.643). maddesindeki sıra takip edilerek yapılması gereklidir. Dava konusu olayda sözleşmede tasfiye ile ilgili özel bir hüküm bulunmadığından tasfiyenin BK'nın 539 (TBK m.643) ve devamı maddelerine göre yapılması zorunlu olup, bunun için mahkemece öncelikle yönetici ortak olan davalıdan, kurulduğu tarihten itibaren ortaklığın tüm muhasebesi ile ilgili hesap listesi istenmeli, ortakların gerek tasfiye şekli gerekse hesap listesi üzerinde uyuştukları ve uyuşmadıkları noktalar saptanmalı, uyuşamadıkları noktalarda tarafların delil ve karşı delileri sorulup toplanmalı, yönetici ortağın hesap listesi vermemesi durumunda hesap vermekten kaçındığı kabul edilmeli, bu durumda mevcut delillere göre hüküm kurulmalı, ortaklığa ait tüm gelir gider hesabı çıkarıldıktan, ortaklığın tüm aktif ve pasifi kesin olarak belirlendikten sonra ortaklığın varsa üçüncü kişilere veya kurumlara olan borçları ortaklığın aktifinden mahsup edilmeli, ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslarla, ortaklık için yapmış oldukları masraflar ve vermiş oldukları sermaye iade edilmeli, bundan sonra varsa kalan miktar ortaklar arasında paylaştırılmalı, tasfiye bu şekilde tamamlanmalıdır" (Yargıtay Kararları Dergisi, Ağustos 2011, s. 80).

tasfiye memurlarının önünde şirket işlerini yönetenler tarafından da imzalanmalıdır.

bb) Dış tasfiye

Türk Borçlar Kanununun 643'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre, *"Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır"*. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere dış tasfiye, şirket malvarlığının ortaklar arasında dağıtılması sürecine girilmesine kadar geçen ve şirket aktiflerinin paraya çevrilmesi ve şirket borçlarının ödenmesi işlemlerinin yapılmasını kapsayan bir tasfiye aşamasıdır.

Tasfiye görevlisi ilk envanter ve bilançoyu hazırladıktan sonra, şirketin envanterinde bulunan bütün malları ile defter ve belgelerine el koyar; alacaklı oldukları şirket defterlerinden ve diğer belgelerden anlaşılan alacaklıları toplantıya çağırarak alacaklarını bildirmelerini ister. Alacaklıların toplantıya çağırılması, dış tasfiyenin bir gereğidir; herhangi bir şekle tâbi de değildir. Çağrının, tasfiyenin bir gereği olarak ortakların haklı menfaati gözetilerek gecikmeden yapılması gerekir.

Tasfiye görevlisi şirketin tüm alacaklarını tahsil etmeli; tasfiye gayesine ve ortakların haklı menfaatine uygun olması koşuluyla, alacakları satabilmeli (faktoring), temlik edebilmeli, uzlaşabilmeli ve hatta feragat edebilmelidir.

Tasfiyenin gerçekleştirilebilmesi için şirket aktiflerinin paraya çevrilmesi gerekir. Aktiflerin paraya çevrilmesinde, atama esnasında aksi ifade edilmemişse, tasfiye görevlileri, şirketin aktiflerini *pazarlık usulü ile veya ortakların alacağı bir kararla toptan da satabilir.*

Alacakların tahsil edilmesi ve aktiflerin paraya çevrilmesi sonucunda, şirket malvarlığı yeterliyse borçların ödenmesi; şirket mevcudunun şirket borçlarını ödemeye yetmeyeceğinin anlaşılması hâlinde ise, payına düşen borç tutarının, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ortaklardan istenmesi gerekir (TBK m.635).

cc) İç Tasfiye

Şirketin aktifleri paraya çevrilip borçları ödendikten sonra geriye bir şey kalırsa, tasfiyede iç tasfiye sürecine geçilir. Kanun koyucu, ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı

geri verildikten sonra bir şey artarsa, bunun kazanç olduğunu ve ortaklar arasında kazancın taksimi esaslarına göre paylaşılması gerektiğini hükme bağlamıştır (TBK m.643/1).

Kanun koyucu, tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları ödendikten sonra kalan artığın, bir diğer ifadeyle tasfiye bakiyesinin dağıtılacağını hükme bağlamaktan başka, tasfiye işlemlerinin sırasını da belirlemiştir. Buna göre, ortaklığın borçları ödendikten sonra ilk olarak ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler geri verilecek; daha sonra koymuş oldukları katılım payları iade edilecektir.

Katılım paylarının iadesinde, katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan ortağa, ortaklığın sona ermesi üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şey olduğu gibi geri verilmez; koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değer verilir (TBK m.642/1). Buna karşılık, katılım payı olarak bir şeyin kullanımını şirkete bırakan ortağa, ortaklığın sona ermesi üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şey iade edilir (TBK m.634/2).

dd) Kapanış hesabının hazırlanması

Tasfiye görevlisi, tasfiye sonunda bir kapanış hesabı hazırlayarak, ortakların tasvibine sunar. Kapanış hesabını görüşmek üzere toplanacak ortakları toplantıya çağrı, tasfiye görevlileri tarafından yapılır. Bu toplantıda tasfiye görevlileri kapanış hesabından (son bilanço) başka tasfiye işlemleri hakkında da bir rapor hazırlayarak ortaklara sunar. Ortaklar bu rapora itiraz etmezlerse, tasfiye kesinleşir (TTK m.289/1). Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen payları almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye görevlileri, bu payları her ortağın ayrı ayrı adlarına tevdi mahalli göstererek ve bilhassa TTK m.296'da gösterilen bankalardan birine yatırabilir (TTK m.289/2).

Tasfiye görevlilerinin hazırladığı raporun ortaklar tarafından kabul edilmesi, tasfiye esnasında yapılan bütün işlerden tasfiye görevlilerinin *ibraları* sonucunu doğurur.

f) Tasfiyenin Kapanışı

Ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir şey artarsa bu kazanç, ortaklar

arasında kazancın paylaşılması esaslarına göre dağıtılır. Zarar söz konusu ise, zararın paylaşılması esası geçerlidir. Bu işlemlerle birlikte tasfiye işlemleri tamamlanmış olur (TBK m.643).

Hükümden de anlaşılacağı üzere, tasfiyenin tamamlanabilmesi için, ortaklığın borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir. Borçların ödenebilmesi için taraflar arasında bir ihtilâfın bulunmaması, ihtilâf varsa bunun giderilmiş olması gerekir. Bu bağlamda, üçüncü bir şahıs, şirketten alacağını tahsil etmek maksadıyla yargı yoluna başvurmuş ve dava henüz sonuçlanmamışsa, tasfiye kapatılabilecek midir? Yargıtay'ın kollektif şirketlere ilişkin olarak verdiği ve adi şirketlere de tatbik edilebileceğini düşündüğümüz bir kararına göre, açılmış davalar sonuçlandırılmadan, tasfiyenin kapatılması söz konusu olamamalı[130]; ihtilaflı borçların mevcudiyeti halinde, bunlar açıklığa kavuşuncaya kadar tasfiye devam etmelidir.

Buna karşılık, şirket malvarlığının alacaklıları tatmin etmeye yetmemesi, tasfiyenin kapanmasını engellememeli; *"ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, borçlarını karşılamaya yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle yükümlüdür"* (TBK m.635) hükmünden mülhem olarak, tasfiye görevlisinin, yetmeyen kısmı, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ortaklardan alabileceğinin kabulü gerekir.

Bu şekilde tasfiye işlemleri tamamlandıktan, ortaklar tasfiyeyi kabul ettikten sonra tasfiyenin kapatıldığı, tasfiye görevlileri tarafından vergi dairesine ve ticaret siciline kayıtlı işletmelerde, işletmenin sicil kayıtlarının terkini için sicil müdürlüğüne bildirilir.

Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanması gerekir. Tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterlerin saklanması hakkında TTK'nın 82'nci maddesi hükmünün kıyasen adi şirketlere de tatbik edilmesi uygun olur (TTK m.290).

3) Şirketin Tasfiyesinin Üçüncü Kişilere Karşı Etkisi

Tasfiyenin tamamlanması ile şirket ortakları arasındaki ortaklık ilişkisi sona erse de; *"Ortaklığın sona ermesi, üçüncü kişilere karşı olan yükümlülükleri değiştirmez"*(TBK m.645). Bir diğer ifadeyle, adi şirket

---

[130] Yargıtay 10. HD., 12.10.1973 T., E.573, K.744 (**Eriş**, C.I, s.722).

adına yapılan işlemlerden doğan yükümlülükler, ortaklık tasfiye edilmiş olsa da ortaklardan müteselsil sorumluluk hükümlerine göre, zamanaşımı süreleri içinde istenebilir[131].

X) ZAMANAŞIMI

Türk Borçlar Kanununda, 620-645'inci maddeleri arasında adi şirketlere ilişkin olarak özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş; Türk Borçlar Kanununda düzenlenen diğer borç ve borç ilişkilerinde olduğu gibi, adi şirketlerin de Türk Borçlar Kanununun birinci kısmının üçüncü bölümündeki hükümlere tâbi olacağı öngörülmüştür.

Bilindiği gibi, Türk Borçlar Kanununun birinci kısmının üçüncü bölümünün başlığı, "*Borç ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, Zamanaşımı*"dır. Üçüncü bölüm iki "*ayırım*" altında incelenmiş, birinci ayırımda Borçların ve Borç İlişkilerinin "Sona Erme Hâlleri"; ikinci ayırımda ise "Zamanaşımı" ele alınmıştır. Kanun koyucunun bu sistematiği, *zamanaşımı* ile *borçların ve borç ilişkilerinin sona ermesini* birbirinden ayırması bakımından isabetli olmuştur. Zira zamanaşımı, borcu ve borç ilişkisini sona erdirmez; sadece borçlu, zamanaşımı def'ini ileri sürmek suretiyle dava edilen edimi yerine getirmekten kaçınma hakkını elde eder.

Kanun koyucunun kabulüne nazaran adi şirketlerde zamanaşımı, *adi şirketle üçüncü kişi arasındaki ilişkilerde zamanaşımı ve adi şirketlerde ortaklar arasındaki ilişki bakımından zamanaşımı* başlıkları altında incelenecektir.

A) ADİ ŞİRKETLE ÜÇÜNCÜ KİŞİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ZAMANAŞIMI

Adi şirketle, daha doğru bir ifadeyle adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için adi şirket ortaklarıyla üçüncü kişi arasındaki hukuki ilişkilerde zamanaşımı, bu hukuki ilişkinin bağlı olduğu zamanaşımı hükümlerine tâbidir.

B) ADİ ŞİRKETTE ORTAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE ZAMANAŞIMI

Adi şirketlerde ortaklar arasındaki zamanaşımı süresi kadar, zamanaşımı süresinin başlangıç anının tespiti de önemlidir.

---

[131] Yargıtay 13.HD., 25.5.1981 T., E.3345, K.3908 (**Şener**, 640-642).

1) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresi

Kanun koyucu Türk Borçlar Kanununun 146'ncı maddesinde "*Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir*"hükmünü takiben 147'nci maddede beş yıllık zamanaşımı sürelerini ayrıca düzenlemiştir. Türk Borçlar Kanununun 147'nci maddesinin dördüncü bendinde şirketlerle ilgili olarak, "*Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar*"ın da ***beş yıllık*** zamanaşımı sürelerine tâbi olacağı öngörülmüştür.

Bu hükme nazaran, ortağın kâr payı ile tasfiyeden doğan alacakları beş yılda zamanaşımına uğrayacağı gibi, rekabet yasağına aykırılıktan doğan sorumluluk davaları (TBK m.626)[132], ortakların yapmış olduğu giderlerden ve işlerden doğan alacaklar (TBK m.627), özen borcuna aykırılıktan doğan borçlar (TBK m.628) da beş yılda zamanaşımına uğrar.

2) Adi Şirkette Ortaklar Arasındaki İlişkilerde Zamanaşımı Süresinin Başlaması

Zamanaşımının başlangıcını düzenleyen Türk Borçlar Kanununun 149'uncu maddesi mucibince, *"Zamanaşımı, alacağın muaccel olmasıyla işlemeye başlar. Alacağın muaccel olmasının bir bildirime bağlı olduğu hâllerde zamanaşımı, bu bildirimin yapılabileceği günden işlemeye başlar".*

Buna göre kâr payı alacağı TBK m.630 gereğince, o yılın sonunda ödenmesi gerekeceğinden, zamanaşımının da o tarihten başlatılması gerekecektir[133]. Tasfiye alacağının muacceliyet anını Yargıtay, şirketin

---

[132] Yargıtay'ımız çeşitli tarihlerde verdiği kararlarda (Kararlar için bkz., Yalman/Taylan, s.272-275), "*ortaklıktan doğan davalar beş yıllık zamanaşımına tâbi*" olduğu hükme bağlanmış olmasına karşın **Şener** (bkz., s.353) kollektif şirketlerden (TTK m.231) mülhem olarak, "*rekabet yasağına aykırı bir işlemin yapıldığının öğrenildiği tarihten başlayarak üç ay ve her hâlde işlemin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar*" sonucuna varmıştır. Kanaatimizce rekabet yasağına aykırı davranma sebebiyle açılacak davaların da beş yıllık zamanaşımı süresine tâbi olması gerekir. Ancak, rekabet yasağına ilişkin hüküm esas itibariyle emredici olmadığından, öğrenme tarihinden itibaren uzun süre dava açılmaması, bu eyleme onay verildiği anlamına gelir; açılan davanın da bu sebeple reddedilmesi uygun olur.

[133] Bkz., **Şener,** s.645 ve orada zikredilen Yargıtay kararı.

sona erme anı olarak kabul etmiş; şirketin sona erme anını ise, sona erme sebebinin gerçekleştiği an olarak belirlemiştir[134].

Ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar (TBK m.627/1). Giderleri yapan veya borçları üstlenen ortağın diğer ortaklara müracaat hakkı, giderin yapıldığı veya borcun üstlenildiği tarihten itibaren beş yılda zamanaşımına uğrayacaktır. Bunun gibi, bu ortağın, yönetim işleri yüzünden doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklardan talep hakkı da zararın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarf etmiş olan bir ortak, hakkaniyetin gerektirdiği bir karşılık ödenmesini, emeği sarf ettiği tarihten itibaren beş yılda talep edebilir.

Türk Borçlar Kanununun 628'inci maddesi gereğince, ortaklardan her biri şirket işlerini yönetirken kendi işlerinde olduğu ölçüde çaba ve özen göstermek zorundadır. Gerekli özenin gösterilmemesi durumunda ortak kusurlu sayılmalı; bu eylem ve işleminden doğan zarardan diğer ortaklara karşı sorumlu olmalıdır. Diğer ortaklara karşı olan bu sorumlulukta da zamanaşımı, eylem ve işlem tarihinden itibaren beş yıldır.

---

134 Yargıtay'ın kararında "*Davacılar miras bırakanın 31.7.1969 gününde öldüğü bellidir. Ayrıca davacılar, kendileri ile davalı arasında ortaklığın sürdürülmesine ilişkin bir anlaşmanın varlığını da ispat edebilmiş değillerdir. Bu durumda ortaklık, ortaklardan M'nin 31.7.1969 gününde ölümü ile sona ermiş ve dava da aradan beş yıldan fazla süre geçtikten sonra açılmış olmakla zamanaşımına uğramıştır*" denilmektedir (Yargıtay 13.HD., 19.11.1984 T., E.1984/6479, K.1984/7303). (Karar ve bu konudaki görüşleri için bkz., **Şener,** s. 646-647).

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§4- TİCARET ŞİRKETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

LİTERATÜR

Tekinalp, Ü., Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, 4. Baskı, İstanbul 2015, *Çağlar, H., "Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın "Cartesio" Kararı"*, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C.I, Ankara 2010, s. 623- 638; *Poroy, R./ Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.*, Ortaklıklar Hukuku I, 13. Baskı, İstanbul 2014; *Pulaşlı,H.*, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 5. Baskı, Ankara 2017; *Bozkurt, T.*, Şirketler Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019.

GİRİŞ

Türk Hukukunda şirketler, Türk Borçlar Kanununun Özel Borç İlişkilerini düzenleyen ikinci kısmının 18. bölümünde (m.620-645) "*Adi Ortaklık Sözleşmesi*" ve Türk Ticaret Kanunu'nun ikinci kitabında "*Ticaret Şirketleri*" başlığı altında (m.124-644) düzenlenmiş; TTK m.124/1 gereği ticaret şirketi olarak kabul edilen kooperatifler ise 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda ele alınmıştır.

I) TİCARET ŞİRKETİ KAVRAMI

Kanun koyucu ticaret şirketlerini tanımlamamış; TTK m.124/1'de, *"Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır"* demekle yetinmiş ve TTK m.125/1'de de, ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olduğunu hükme bağlamıştır.

Ticaret şirketi olarak kabul edilen şirketlerin ortak özellikleri ve bu şirketlere bağlanan hukuki sonuçlar esas alındığında, ticaret şirketlerini; "*kişi veya kişilerin, yazılı bir şirket sözleşmesine bağlı olarak; bir iktisadi amaca ulaşmak maksadıyla, kanunda belirlenmiş şirket türlerinden birini tercih ederek oluşturdukları bir tüzel kişilik*" şeklinde tanımlamak mümkündür.

Benimsediğimiz bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, bir ticaret şirketinden söz edilebilmesi için; *kişi veya kişilerin, yazılı şekilde bir şirket sözleşmesi* yaparak şirket sözleşmesinde belirlenen *iktisadi amacı* gerçekleştirmek maksadıyla, kanunda belirlenen ticaret şirketlerinden birini tercih etmeleri gerekmektedir. Hukukumuzda, sözleşme ve iktisadi amaç olmadan ticaret şirketi kurulamaz.

Şirket sözleşmesini oluşturanlar, şirket sözleşmesinde belirledikleri iktisadi amacı gerçekleştirmek için, kanun koyucu tarafından belirlenmiş bir ticaret şirketi tipi altında faaliyet göstermek; bu ticaret şirketine *tüzel kişilik* kazandırarak, tüzel kişiliği olan bu ticaret şirketi tipinin özelliklerine uygun davranmak yükümlülüğü altına da girmektedir. Ticaret şirketleri, ticaret siciline tescille tüzel kişilik kazanır; tüzel kişiliğin kazanılmasında, tescil kurucudur.

Bütün bu değerlendirmelere göre, bir ticaret şirketinden söz edilebilmesi ve bu ticaret şirketinin tüzel kişilik kazanması için, şirket sözleşmesinin *yazılı* olarak yapılması, şirket sözleşmesindeki *imzaların noterce tasdik edilmesi* veya *ticaret sicili yetkilisi huzurunda imzalanması* ve *sicile tescil edilmesi* gerekmektedir. Bu ortak hususlardan başka, her ticaret şirketi tipi için ek şartlar da aranabilmektedir.

II) TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜRLERİ

Kanun koyucu TTK m.124'te, "*Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir*" demek suretiyle, ticaret şirket türlerini sınırlandırmış (*numerus clausus*); bahsi geçen türler haricinde ticaret şirketi olmadığını kabul etmiştir. Kanun koyucu, şirket türlerini belirlemekten başka, "*Bu Kanunda, kollektif ile (adi) komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır*" hükmünü kabul ederek, ticaret şirketlerini kendi içinde tasnife tâbi tutmuş; ticaret şirketlerinden sayılan kooperatifleri ise, tasnife dâhil etmemiştir.

Kanun koyucunun kabulüne bağlı olarak, ticaret şirketlerinin; "*şahıs şirketleri*", "*sermaye şirketleri*" ve "*kooperatif şirketler*" olarak tasnif edilmesi gerekmektedir.

A) ŞAHIS ŞİRKETLERİ

TTK m.124/2'de, *kollektif* ve *(adi) komandit* şirketlerin müşterek özellikleri nazara alınarak; bu şirketler, şahıs şirketleri olarak nitelendirilmiştir.

Şahıs şirketleri olarak kabul edilen kollektif ve (adi) komandit şirketlere ilişkin düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere; şahıs şirketlerinde, *şirket ortaklarının kişiliği* ön plâna çıkmaktadır. Gerçekten de, şahıs şirketinin kurulmasında, sözleşmeye katılanların şahsiyeti, mesleki ve sosyal durumu önem kazanmakta; birbirine güvenen kişilerin, şahıs şirketi kurması tavsiye edilmektedir. Bu nedenle şahıs şirketi kurmak maksadıyla yapılan sözleşmelerin, *intiutu personae* (karşı tarafın kişiliği göz önüne alınarak işlem yapılması) karakterli olduğu ifade edilmektedir.

Şahıs şirketi kurulurken, sözleşmeye katılanların şahsiyeti, mesleki ve sosyal durumunun ön plâna çıkması, birbirine güvenen kişilerin şahıs şirketine ortak olması; bilhassa, şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların, getirilen sermayenin nev'i ve mahiyeti nazara alınmadan oybirliği ile verilmesinde görülür (TTK m.226/2; m. 308/1). Bunun gibi, şirkete girme, şirketten çıkma, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi mahiyetinde olduğu için kural olarak oybirliği şarttır (TTK m.253 vd.; m. 328).

Şahıs şirketleri esas itibariyle, bir ortağın ölümü, iflâs etmesi, hacir altına alınması ile sona erer (TTK m.243 vd.; m. 328). Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin (sınırlı sorumlu ortak) ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi neticesini doğurmaz (TTK m.328). Şahıs şirketleri, kural olarak gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarının hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış olan şirkettir (TTK m.211). Sadece komandit şirketlerde, tüzel kişiler de *komanditer* ortak olabilir; komanditerler sorumluluğu sınırlandırılmış ortaklardır (TTK m.304).

B) SERMAYE ŞİRKETLERİ

TTK m.124/2'ye göre sermaye şirketleri, *anonim*, *limited* ve *sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerinden* ibarettir.

Sermaye şirketlerinin müşterek özelliklerinin başında, idare ve temsil yetkilerinin organlar vasıtasıyla kullanılması gelir (TMK m. 47;

TTK m.359 vd.). Sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkiler (adi) komandit şirketlerdeki hükümlere tâbidir; bununla beraber, anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümleri, yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerlidir (TTK m.565/1; m. 570).

Ortakların şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu kural olarak bulunmamakta; pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumluluk altına girmektedirler (TTK m.329; m. 573). Sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde komandite ortak, kollektif şirket ortağı gibi, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumludur (TTK m.564).

Sermaye şirketlerinde sözleşme değişikliği esas itibariyle, oy çokluğuna bağlanmış (TTK m.421; m. 589; m. 565/2); ortaklık sıfatındaki değişiklikler kolaylaştırılmış, sadece sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, komandite ortakların şirketten ayrılmaları, komandit şirket hükümlerine tâbi tutulmuştur (TTK m.565/1).

C) KOOPERATİF ŞİRKET

İsviçre Borçlar Kanununun 29'uncu faslındaki kooperatife ilişkin hükümleri (828-926) esas alınarak hazırlanan 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu; 6762 sayılı TTK'nin, kooperatifleri düzenleyen 485 ilâ 502'nci maddelerini ilga etmiş ve yeni bir yapıya ve ilkelere dayanan bir kooperatif yapısı oluşturmuş; kooperatifin, değişir ortaklı, değişir sermayeli bir ticaret şirketi olduğu kabul edilmiştir (TTK m.124).

1163 sayılı Kanundaki kabule göre, kooperatifler de bir kişi birliğidir ve amacı da iktisadidir. Ancak, diğer ticaret şirketlerinde kâr elde etmek ve bu kârı paylaşmak olarak görülen bu iktisadi amaç; kooperatiflerde, *bireyin ekonomisini geliştirmek* şeklinde ifade edilmiştir. "*Ekonominin geliştirilmesi*" birey çapındadır; bireyin, günlük yaşamı için yiyeceğini ve giyeceğini iyi fiyatla sağlayabilmesi; rahat ve sağlık şartlarına uygun bir eve sahip olabilmesi; mesleği ile ilgili araçları kolaylıkla elde edip kullanabilmesi; bu yolla kazancını artırması kooperatif vasıtasıyla gerçekleştirilebilirse, birey temelinde ekonomisi gelişmiş olur.

Kooperatiflerde çalışma konuları bakımından; kooperatifin ortakları ile yaptığı işlemler ve kooperatifin ortak olmayan kişilerle yaptığı işlemler olmak üzere iki tür işlem söz konusudur. Kooperatifler, yaptığı

bu işlemler neticesinde bir gelir elde ederse; ana sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, ortaklarla yapılan muamelelerden bir yıllık faaliyet sonunda elde edilen hasılanın tamamı *gelir gider farkı* olarak kooperatifin yedek akçelerine eklenir. Buna karşın, ana sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla; gelir gider farkı, ortaklar arasında bölüşülebilir; bu bölüşmenin ortakların muameleleri oranında yapılması gerekir (KoopK m. 38).

Kooperatiflerin bu özelliğini nazara alan kanun koyucu kooperatifi, *"Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir"* şeklinde tanımlamıştır (KoopK m. 1).

III) TÜZEL KİŞİLİK

Hukukumuzda, haklara ve borçlara sahip olabilen varlıklar olarak nitelendirilen kişinin, sadece gerçek kişilerden ibaret olmadığı; toplum hayatındaki gelişmeler ve ihtiyaçlar, gerçek kişilerin yanı sıra, belli amaçları gerçekleştirmeye yönelik olarak, bazı kişi ve mal topluluklarına da haklara ve borçlara sahip olma iktidarının verildiği ve ihtiyaçlar sebebiyle ihdas edilen bu hukuk süjelerine "*tüzel kişi*" denildiği bilinmektedir.

TTK m.125'te, "*Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir*" denilmek suretiyle, ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğe sahip olduğu ve bu hususta kanuni istisnalar saklı kalmak kaydıyla, ticaret şirketlerinin, Türk Medenî Kanununun 48'inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabileceği ve borçları üstlenebileceği kabul edilmiştir.

Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olduğu ve bu hususta TMK hükümlerine atıf yapılmasına karşın, tüzel kişilik Kanunlarımızda tanımlanmamış; tüzel kişinin hükme bağlandığı TMK m. 47'de, "*Başlıbaşına bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar*" denilmekle yetinilmiştir.

A) TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI

Ticaret şirketleri, ortak iktisadi bir amacın sürekli olarak gerçekleşmesini sağlayacak örgütlenmeye sahip; kendisini oluşturan kişi veya kişilerden bağımsız bir tüzel kişiliktir. Ticaret şirketleri, *ticaret siciline tescil* ile tüzel kişilik kazanır (TTK m.232; m.317; m.355; m.588; KoopK m.7); ticaret siciline tescil, tüzel kişiliğin kazanılmasında kurucu unsurdur.

B) TÜZEL KİŞİLİK KAZANMANIN SONUÇLARI

Ticaret şirketlerinin, ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanacağını hükme bağlayan kanun koyucu; tüzel kişiliğe bağlı bazı sonuçlar öngörmüştür.

1) Bağımsız Malvarlığı

Ticaret şirketlerinin tüzel kişiliği haiz olması nedeniyle; kendisini oluşturan kişi veya kişilerden bağımsız bir malvarlığı vardır; ticaret şirketi, bu malvarlığı üzerinde *ferdi mülkiyet* esaslarına göre hak sahibidir. Bir diğer söyleyişle, ticaret şirketine tahsis edilen katılma payları ve şirketin faaliyetlerinden elde edilen değerler üzerinde şirket tüzel kişiliği; *ferdi mülkiyet* esasına göre hak sahibi olur.

2) Ticaret Unvanı

Ticaret şirketlerinin ticaret unvanının şekli; TTK'nin 42 ve 43'üncü maddelerinde hükme bağlanmıştır. Buna göre, *kollektif şirketin ticaret unvanının* bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermesi gerekirken (TTK m.42/1; TSY m.43/5); *adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı,* komandite, yani sınırsız sorumlu ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösterecek bir ibareden oluşur (TTK m.42/2; TSY m.43/6).

Buna karşın, *anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanının* çekirdek kısmında, şirketin işletme *konusunun*, şirket türünün gösterilmesi gerekir (TTK m.43; TSY m.43/7). *Kooperatiflerin ticaret unvanının* çekirdek kısmında da, kooperatifin işletme konusunun ve "*kooperatif*" kelimelerinin bulunması zorunludur (TTK m.43/1, 2; TSY m.43/7).

Ticaret unvanlarının çekirdek kısmına Türk Ticaret Kanunu'nun 46'ncı maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde *ek* alınabilir.

3) Yerleşim Yeri (Merkez)

Genel yetkili mahkemenin, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi olduğu nazara alındığında; ticaret şirketlerinin yerleşim yerinin tespiti önem kazanmaktadır. HMK m. 6/2'ye göre, "*yerleşim yeri, Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir*".

TMK'nin 51'inci maddesinde, tüzel kişilerin yerleşim yeri, "*kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça işlerinin yönetildiği yerdir*" şeklinde hükme bağlanmıştır. Ticaret şirketlerini oluşturan kuruluş belgesinde (sözleşme, esas sözleşme veya ana sözleşme) merkezin gösterilmesi zorunluluğu [TTK m.213/1(c); m.339/2(a); m.576/1(a); KoopK m. 3/1(b.3)] nazara alındığında; ticaret şirketlerinin merkezinin, *kuruluş belgelerinde gösterilen yer* olduğu kabul edilmelidir.

4) Tabiiyet

Tâbiiyet, gerçek kişiler için söz konusu olmasına karşın; gerçek kişilerden başka, tüzel kişilerin de bir tâbiiyeti olması gerektiği tartışılmış ve gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin de bir tâbiiyetin bulunması gerektiği ifade edilmiştir[135]. Gerçek kişiler yanında tüzel kişilerin de bir tâbiiyetinin bulunması gerektiğini ifade edenler, tüzel kişilerin tabiiyetini tespit etmek maksadıyla çeşitli görüşler ileri sürmüş; kimileri "*kurucuların tâbiiyetini*", kimileri ise "*sermayenin bulunduğu yeri*" esas almış; bazıları da, "*kuruluş yeri*"nin, "*merkezin bulunduğu yer*"e üstün olduğunu kabul etmiştir.

6326 sayılı Petrol Kanunu'nda olduğu gibi, Kanunlarımızda Türk şirketi ve yabancı şirket kavramlarına yer verildiği nazara alındığında; ticaret şirketlerinin tâbiiyetinin tespiti, bilhassa uygulanacak hukuku belirlemek bakımından, önem arz etmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nda, ticaret şirketlerinin tâbiiyeti ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu nedenle, ticaret şirketlerinin tâbiiyetinin, diğer düzenlemelerin yardımıyla tespit edilmesi söz konusudur. Türk hukukunda, şirket ortaklarının veya kurucuların tâbiiyetine göre

---

[135] Tüzel kişilerin ve bu bağlamda şirketlerin tabiiyeti ile ilgili açıklamalar için bkz., **Doğan, V.**, Türk Vatandaşlık Hukuku, Ankara 1999, s.204 vd.; **Algül, M.**, Milletlerarası Özel Hukukta Şirketlere Uygulanacak Hukukun Tespiti, Ankara 2007, s. 57 vd.

bir değerlendirme yapılmadığı; ticaret şirketlerinin tâbiiyetinin tespitinde, Türk kanunlarına göre kurulması ve merkezinin Türkiye'de bulunmasının esas alındığı gözlemlenmektedir[136]. Bu kuralın bir istisnasına, TTK m.940/4'te, bir geminin *Türk gemisi* sayılması münasebetiyle yer verilmiş; *"Türk kanunları uyarınca kurulup da; Türk ticaret şirketlerine ait olan gemiler, şirketi yönetmeye yetkili olanların çoğunluğunun Türk vatandaşı olmaları ve şirket sözleşmesine göre oy çoğunluğunun Türk ortaklarda bulunması, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde ayrıca payların çoğunluğunun nama yazılı ve bir yabancıya devrinin şirket yönetim kurulunun iznine bağlı bulunması, şartıyla Türk gemisi sayılırlar"* denilmiştir.

5) Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti

TTK m.125'te, *"Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanunu'nun 48'inci maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler"* denilmek suretiyle; ticaret şirketlerinin ehliyeti ve ehliyetinin sınırları hükme bağlanmıştır.

Bilindiği üzere kişilerin ehliyeti; hak ve fiil ehliyeti olarak iki başlık altında incelenmektedir.

Tüzel kişilerin hak ehliyeti, TMK m. 48'de *"tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler"* şeklinde hükme bağlanmıştır. Bu değerlendirmeye göre tüzel kişiler, yapıları gereği bazı haklara; bu bağlamda, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olan haklara ehil değildir.

Tüzel kişilerin hak ehliyeti, TMK m. 48'deki bu genel sınırlama haricinde, esas itibariyle sınırlandırılamaz. Tüzel kişinin hak ehliyetinin sınırlandırılabilmesi için, 6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanunu'nun 137'nci maddesinde olduğu gibi, *"ticaret şirketlerinin ehliyetinin, şirket mukavelesinde yazılı işletme mevzuu ile sınırlı olduğu"* şeklinde bir hükmün bulunması gerekir.

6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanunu'nun 137'nci maddesinde; *"Ticaret şirketleri hükmi şahsiyeti haiz olup şirket mukavelesinde yazılı*

---

[136] Avrupa Birliği'nde benimsenen şirketlerin yerleşme serbesti için ayrıca bkz. ***Çağlar, H.***, *"Avrupa Birliği Hukukuna Göre Şirketlerin Yerleşme Serbestisi ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı'nın "Cartesio" Kararı"*, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C.I, Ankara 2010, s. 624.

işletme mevzuunun çevresi içinde kalmak şartıyla bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilirler" denilmekteydi. Kanun koyucu bu düzenlemeyle, ticaret şirketini öne çıkartan en önemli unsurun, ticaret şirketinin amacı olduğunu; ticaret şirketlerinin bu amaca uygun olarak faaliyet göstermesi gerektiğini, amaç dışı yapılan işlerin ehliyet dışı (ultra vires) olması sebebiyle ticaret şirketini bağlamayacağını kabul etmişti.

6102 sayılı yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 125'inci maddesine, 6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanunu'nun 137'nci maddesindeki hüküm alınmamış[137]; ticaret şirketlerinin ehliyetinin sınırının, TMK m.48 ile belirlendiği kabul edilmiştir.

Fiil ehliyeti, bir kişinin kendi eylemleriyle, lehine haklar ve aleyhine borçlar ihdas edebilme yeteneğidir. TTK'de, ticaret şirketlerinin ehliyeti hakkında özel bir düzenlemeye gidilmemiş; TMK'deki hükümlerin bu konuda da geçerli olduğu esası benimsenmiştir.

Ticaret şirketleri de, diğer tüzel kişilerde olduğu gibi; *"kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar"* (TMK m.49). Tüzel kişinin iradesini açıklayarak, onun işlemlerini yapma ve işlemlerini yürütme görevi organlara aittir. Bu görevi üstlenen organlar, bir kurul şeklinde ya da tek kişiden oluşabilir. Ticaret şirketleri fiil ehliyetini, hak ehliyeti sınırları dâhilinde, organları vasıtasıyla kullanır; organlar, hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle ticaret şirketini borç altına sokar.

Ticaret şirketleri, hukuki işlem ehliyeti ve hukuka aykırı fiillerinden sorumlu olma ehliyetine bağlı olarak, davada taraf ehliyetine sahiptir; organların işlem ve fiillerinden dolayı, tüzel kişi davacı ve davalı olabilir. Bunun gibi, icra ve iflâs takibinin de, kural olarak tüzel kişiye karşı yapılması gerekir.

---

[137] Bu husus gerekçede, *"6762 sayılı Kanunun 137'nci maddesinde öngörülmüş bulunan ve tüm ticaret şirketleri için geçerli olan ultra vires ilkesini, AET'nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin Birinci Yönergesinin ilgili hükmünü dikkate alarak kaldırmıştır (Genel Gerekçenin 100 numaralı paragrafına bakılmalıdır). Ticaret şirketleri Türk Medenî Kanununun 48'inci maddesi çerçevesinde haklardan yararlanabilecek, borçlar üstlenebileceklerdir. 371'inci maddenin ikinci fıkrasında olduğu gibi Tasarının bazı hükümlerinde, işletme konusu dışında yapılan işlemlerin hukukî sonuçları özel olarak düzenlenmiştir"* şeklinde ifade edilmiştir.

6) Hukuka Aykırı Füllerinden Sorumluluk

TMK m.50/2'de, organların hukuki işlemlerden başka, diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokacağı kabul edilerek; organların haksız fiilinden, ticaret şirketi tüzel kişiliğinin sorumlu olacağı belirtilmiş; organların haksız fiilinden doğrudan doğruya tüzel kişinin sorumlu olacağı kabul edilmiştir. Organlar, kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumludurlar (TMK m. 50/3).

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER

TTK m.1/2'de, "*Mahkeme, hakkında bir ticari hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir*" (TTK m.1/2) denilerek, ticari işlerden doğan ihtilâflarla ilgili hükümlerin uygulama sırasını gösterilmiş; ticaret şirketleriyle ilgili olarak TTK m.126'da özel bir hükme yer verilmiştir. Buna göre her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri hakkında da uygulanacaktır.

Bu iki hüküm ve şirketler hukukuna hâkim olan irade serbestisi ilkesi nazara alındığında, ticaret şirketlerine uygulanacak hükümleri;

(1) Emredici hükümlere aykırı olmayan *sözleşme hükümleri*,

(2) Ticari hükümler;

(a) Şirket türüne özgü hükümler,

(b) Ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler (TTK m.124-210),

(3) Şirket türünün mahiyetine uygun olduğu nispette;

(a) TMK m.47 vd.'nda hükme bağlanan tüzel kişilerle ilgili hükümler,

(b) TBK m.620 vd.'nda hükme bağlanan adi şirketlere ilişkin hükümler,

(4) TTK m.1/2 gereği;

(a) Şirket türüne özgü hükümler ile ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler haricindeki *ticari hükümler,*

(b) Ticari örf ve âdet,

(c) Genel hükümler;
olarak sıralamamız mümkündür.

V) TİCARET ŞİRKETLERİNDE SERMAYE

Bir şirkete, "*ticaret şirketi*" niteliği verilebilmesi için, "*kişi unsuru*", "*sözleşme unsuru*", "*ortak amaç*" ve "*tüzel kişilik*" unsurunun yanında; "*katılma payı*" taahhüdünün de bulunması gerekir. Buna göre, ticaret şirketi kurucularının veya ticaret şirketinin türüne göre, şirkete daha sonra katılanların; şirket sözleşmesinde yazılı amaca ulaşabilmesi için, bir katılma payı taahhüdünde bulunması zorunludur. Bu husus, TTK m.128'de, "*her ortak, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettiği sermayeden dolayı şirkete karşı borçludur*" şeklinde ifade edilmiş; ticaret şirketlerinde katılma payı, sermaye olarak nitelendirilmiştir.

A) SERMAYE KOYMA BORCU

Ticaret şirketlerinde her ortağın şirkete getirmeyi taahhüt ederek şirkete karşı borçlandığı değer *katılma payı* (*Beitrag*) olarak adlandırılırken; katılma paylarının bir araya getirilmesiyle oluşan değer, *sermaye* olarak nitelendirilir. Ticaret şirketlerinin sermayesi, her ortağın şirkete getirmeyi taahhüt ederek şirkete karşı borçlandığı değerlerin toplamından oluşur.

Ticaret şirketlerinin türüne göre farklılık göstermekle birlikte, ticaret şirketlerine konulabilecek değerler, bunlarla sınırlı olmamak üzere TTK m.127'de belirtilmiş; devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerin ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebileceği ifade edilmiştir.

1) Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilebilecek Değerler

Kanun koyucu, devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değerin, ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebileceğini kabul ederken; Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak; (1) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait payların, (2) Fikrî mülkiyet haklarının, (3) Taşınırlar ve her çeşit taşınmazın, (4) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma haklarının, (5) Kişisel emeğin, (6) Ticari itibarın, (7) Ticari işletmelerin, (8) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar,

alanlar, adlar ve işaretler gibi değerlerin, (9) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer hakların, getirilebileceğini hükme bağlamıştır.

Hükmün tetkikinden de anlaşılacağı üzere, kanuna, ahlâka ve kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla, devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen ve şirket amacını elde etmeye elverişli her türlü değerin, ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebileceği kabul edilmiş; bu hususta, TTK m.307/2 ile TTK m.342/1 ve TTK m.581/1 hükümlerinin saklı olduğu hükme bağlanarak, devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen mahiyette olsa dahi, bu hükümlerde bahsedilen değerlerin ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilemeyeceği ifade edilmiştir.

Saklı tutulan bu hükümler gereği, komandit şirketlerde, bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamayacaktır (TTK m.307/2). Anonim ve limited şirketlerde de, *üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz* (TTK m.342/1; m.581/1).

2) Katılma Payı Taahhüdünde Uygulanacak Hükümler

TTK m.127'de, Kanunda aksine hüküm olmadıkça, ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebilecek değerlerden bahsedildikten sonra; TTK m.128'de, bu değerlerin şirkete katılma payı olarak getirilmesinin esasları ayrı ayrı hükme bağlanmıştır.

a) Taşınmazlara İlişkin Hükümler

Taşınmazların mülkiyetinin veya taşınmaz üzerindeki bir ayni hakkın, katılma payı olarak şirkete getirilebilmesi için; şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle, tapuya şerh verilmesi gerekir (TTK m.128/2).

Taşınmaz üzerindeki bir hakkın, ticaret şirketine ayni sermaye olarak getirilebilmesi için, tapuya şerh verilmesi gerekirse de, taşınmaz mülkiyetinin ayni sermaye olarak şirkete getirilmesini amaçlayan şirket sözleşmesinin, TMK m. 706'da öngörülen resmi şekilde yapılması gerekmez (TTK m.128/3); esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle şirket sözleşmesine yazılması yeterlidir. Bir diğer söyleyişle, taşınmaz mülkiyetinin şirkete ayni sermaye olarak getirilmesi

taahhüdünün geçerli olması için, şirket sözleşmesinin Kanunda öngörüldüğü şekilde yapılması yeterlidir; şirket sözleşmesinin şekline ilişkin hükümler, resmi şeklin yerine geçer.

Hâl böyle olmakla birlikte, şirkete ayni sermaye olarak getirilecek değerlerle ilgili olarak, taahhüt ve tasarruf işlemi ayrımı yapılmıştır. Taşınmazın ayni sermaye olarak getirilmesi için, usulüne uygun olarak yapılmış bir şirket sözleşmesinin, taahhüt işlemi için yeterli olduğu kabul edilirken; taşınmaz mülkiyetinin veya diğer ayni bir hakkın sermaye olarak konulması hâlinde, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil edilmesinin gerekli olduğu hükme bağlanmıştır (TTK m.128/5).

Kanun koyucu, taşınmazların şirkete katılma payı olarak taahhüt edilebileceğini, katılma payı olarak taahhüt edilen taşınmaz üzerinde tasarruf edilebilmesi için tapu siciline tescil edilmesinin gerekli olduğunu hükme bağlarken; bu iki işlem arasında, kurulacak şirketin menfaatlerinin korunmasını temin etmek amacıyla, kurucuların, taşınmaz taahhüdünde bulunan ortaklar aleyhine, ihtiyati tedbir isteyebileceğini kabul etmiştir (TTK m.128/8).

İhtiyati tedbir, HMK m. 397 hükmüne tâbidir. Ancak bu hâlde, tedbir üzerine açılacak davalar için Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen iki haftalık süre, şirketin tescil ve ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır (TTK m.128/8).

Mülkiyet ve diğer ayni hakların tapu siciline tescili istemi, ticaret sicili müdürü tarafından, ilgili sicile re'sen ve hemen yapılır. Şirketin tek taraflı istemde bulunabilme hakkı saklıdır (TTK m.128/6).

b) Taşınırlara İlişkin Hükümler

Taşınırların ve taşınırlar üzerindeki faydalanma ve kullanma haklarının, şirkete katılma payı olarak getirilebilmesi için, şirket sözleşmesine veya esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınırların, *güvenilir bir kişiye tevdi* edilmeleri gerekir (TTK m.128/2).

TTK m.127/1, a'da, *kıymetli evrakın* da, ticaret şirketine katılma payı olarak getirilebileceği öngörülmüştür. TTK m.645 vd. hükümlerinde düzenlenen kıymetli evrakın, senet vasfı esas alınarak, taşınır sayıldığı kabul edilmektedir. Bu nedenle, taşınırlara ilişkin hükümlerin kıymetli evrak için de geçerli olması ve güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi gerekmektedir. Kıymetli evrakın mahiyeti itibariyle, güvenilir bir

kişiye tevdi edilmesi, sermaye koyma borcunun ifa edilmiş sayılması sonucunu doğurmaz; bu senetlerin tahsil de edilmesi gerekir.

Kanun koyucu, taşınırların, *güvenilir bir kişiye tevdi* edilmeleri gereğinden söz etmesine karşın; *güvenilir kişiye* ilişkin bir açıklamada bulunmamıştır. Hukuk sistemimizde HMK m. 391/1 ile kabul gören *"yediemin"* müessesesinden istifade edilebilir.

Şirkete katılma payı olarak bir taşınırın sermaye olarak konulmasının borçlanılması hâlinde şirket, tüzel kişilik kazandığı andan itibaren bunlar üzerinde malik sıfatıyla doğrudan tasarruf edebilir (TTK m.128/4).

c) Fikrî Mülkiyet Haklarına İlişkin Hükümler

Fikri mülkiyet hakları ya da diğer bir ifadeyle "fikri ve sınaî mülkiyet hakları"; insan düşüncesinin ürünü olan gayri maddi mallar üzerindeki mutlak hâkimiyet haklarını ifade eder ve *"patentleri"*, *"faydalı modelleri"*, *"tasarımları"*, *"coğrafi işaretleri"*, *"ticaret unvanı ve işletme adlarını"*, *"markaları"*, *"sembol ve logoları"*, *"telif haklarını"*, *"internet alan adlarını"*, *"yarı iletken ürünlerin topografyalarını (microchip)"* ve *"ıslahçı haklarını"* kapsar.

Kanun koyucu tarafından, fikri mülkiyet haklarının ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebileceği kabul edilmesine karşın, fikri mülkiyet haklarından olan, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları; lisans ve devir benzeri hukuki işlemlere konu olamayacağından, bunların ticaret şirketlerine katılım payı olarak getirilmesi mümkün değildir.

Özel sicilleri bulunan fikri mülkiyet hakları üzerindeki hukuki işlemler yazılı şekle tâbidir. Devir sözleşmelerinin geçerliliği, ancak noter tarafından onaylanmış şekilde yapılmış olmalarına bağlıdır (SMK m. 148/4). Sınai Mülkiyet Kanununa göre durum böyle olmasına karşın; fikri mülkiyet haklarının ayni sermaye olarak şirkete getirilmesini amaçlayan şirket sözleşmesinin, SMK m. 148/4'te öngörülen resmi şekilde yapılması gerekmez; esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle şirket sözleşmesine yazılması yeterlidir.

Bir diğer söyleyişle, fikri mülkiyet hakkının şirkete ayni sermaye olarak getirilmesi taahhüdünün geçerli olması için, şirket sözleşmesinin Kanunda öngörüldüğü şekilde yapılması yeterlidir; şirket sözleşmesinin şekline ilişkin hükümler, resmi şeklin yerine geçer. Bununla birlikte, şirket sözleşmesi ile taahhüt edilen borcun (fikri mülkiyet hakkının sermaye olarak getirilmesinin) yerine getirilmiş sayılabilmesi için, özel

sicillerine kaydedilmeleri gerekir (TTK m.128/2). Fikri mülkiyet hakkının sermaye olarak konulması hâlinde, şirketin bunlar üzerinde tasarruf edebilmesi için özel sicillerine tescil edilmeleri lâzımdır.

d) Kişisel Emek ve Ticari İtibarla İlgili Hükümler

Kanun koyucu, kişisel emek ile ticari itibarın, ticaret şirketlerine katılma payı olarak getirilebileceğini hükme bağlamasına karşın (TTK m.127/1, e, f); anonim ve limited şirketlerde, hizmet edimleri ile kişisel emek ve ticari itibarın sermaye olamayacağını özel olarak ifade etmiştir (TTK m.342; m.581/1).

Buna göre, kişisel emek ve ticari itibar sadece, kollektif şirketlerde ve komandit şirketler için ise, komandite ortak bakımından mümkün olabilir. Katılma payı olarak *emek* taahhüt edilmişse; ortaklar, şirket sözleşmesinde, emeğin katılma payı olarak nasıl ifa edileceğini serbestçe kararlaştırabilirler. Şirket sözleşmesinde kararlaştırmamışlarsa; şirketin amacının gerektirdiği şekil ve kapsamda bir belirleme yapılır. Emeğin katılma payı olarak getirilmesi, emeğin şirkete devamlı bir şekilde tahsis edilmesi şeklinde anlaşılmamalıdır; geçici veya dönemsel olarak da emek katılma payı olarak konulabilir. Hatta şirketin kuruluş aşamalarını düzenlemek, şirketin faaliyete geçmesini temin etmek maksadıyla yapılan çalışmalar da, emeğin katılma payı olarak getirilmesidir.

Kooperatiflerin, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını *işgücü* ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ticaret şirketleri olduğu nazara alındığında; emeğin, kooperatiflere sermaye olarak getirilebileceğinin kabulü gerekir. Emeğini katılma payı olarak getirmeyi taahhüt eden ortağa, kooperatif ana sözleşmesinde belirlendiği şekilde ortaklık payı verilmesi gerekir.

e) Ticari İşletmenin Katılma Payı Olarak Taahhüt Edilmesiyle İlgili Hükümler

Ticari işletmenin, ticaret şirketine katılma payı olarak konabileceği (TTK m.127/1, g) kabul edilmiş; ticari işletmenin katılma payı olarak nasıl getirilebileceğine ilişkin bir düzenlemeye TTK m.128'de yer verilmemiştir. Bu durumda, ticari işletmenin devrine ilişkin TTK m.11/3

hükmünün burada da geçerli olduğu kabul edilmeli; katılma payı borcunun ifa edilmiş sayılabilmesi için, zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın, devir sözleşmesinin yazılı olarak yapılması ve ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi gerekir.

Ancak kanaatimizce, ticari işletmenin ticaret şirketine sermaye olarak getirilebilmesi için, ticari işletmenin sermaye olarak şirkete getirilmesini amaçlayan şirket sözleşmesinin, usulüne uygun olarak hazırlanması ve imzaların tasdik edilmesi/ticaret sicili yetkilisi huzurunda imzalanması ve esas sözleşmede bilirkişi tarafından belirlenen değerleriyle şirket sözleşmesine yazılması yeterlidir. Bir diğer söyleyişle, ticari işletmenin şirkete sermaye olarak getirilmesi için, şirket sözleşmesinin Kanunda öngörüldüğü şekilde yapılması yeterlidir; şirket sözleşmesinin şekline ilişkin hükümler, ticari işletmenin devri şekli yerine geçer.

f) Para ve Alacaklarla İlgili Hükümler

Para ve alacağın, şirkete katılma payı olarak getirilebileceği, TTK m.127 hükmünde kabul edilmiştir.

aa) Paranın Sermaye Olarak Konulması

Ticaret şirketlerine katılma payı olarak bir miktar paranın getirileceği taahhüt edilmiş ve ifa zamanı taraflarca kararlaştırılmamış veya hukuki ilişkinin özelliğinden anlaşılmıyorsa, "*her borç doğumu anında muaccel olur*" (TBK m.90) ilkesi gereği; katılma payının, kurulacak şirket hesabına derhal ödenmesi gerekir.

Şirkete sermaye olarak getirilecek para, memleket parası olabileceği gibi, serbestçe memleket parasına dönüşebilecek bir para birimi olması şartıyla yabancı para da olabilir; ancak yabancı para, alacak şeklinde olmadığı müddetçe nakit sermaye olarak değerlendirilmeli; nakit paranın şirkete sermaye olarak getirilmesindeki usul uygulanmalıdır[138].

bb) Alacak

TTK m.127 hükmünde kabul edildiği üzere, alacak da sermaye olarak getirilebilmektedir. Alacağın sermaye olarak getirilmesi, Ticaret

---

[138] **Thalmann, P./Benninger**, N., "Bares ist Wahres Zur Liberierung in Fremdwährungen nach schweizerischem Aktienrecht", Reprax, 4/2003, s. 19 vd. Sermaye payı olarak döviz konulması durumunda, esas sözleşmede döviz karşılığının TL cinsinden gösterilmesi gerektiği yönünde bkz. **Pulaşlı,** H.: Şirketler Hukuku Genel Esaslar, 5. Baskı, Ankara 2017, s. 571, N. 10.

Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün Ticaret Sicili Müdürlüklerine gönderdiği, 27 Eylül 2013 tarihli Genelgede; pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak şirkete koyması ile bu şekilde yapılacak sermaye artırımlarının sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasının temini bakımından;

i) Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerektiği,

ii) Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanunun 343 üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği, ifade edilmiştir.

Alacağın sermaye olarak getirilmesinin mahiyeti ve Bakanlığın Genelgesi nazara alındığında, alacağın sermaye olarak getirilmesi, ayni sermaye taahhüdü olarak kabul edilmelidir[139].

Taahhüt edilen sermaye, bir alacak hakkının devrine ilişkin ise; devir işleminin yazılı olarak yapılması gerekir (TBK m.184). Bununla birlikte, alacağın devredildiğine ilişkin olarak yazılı yapılmış şirket sözleşmesindeki imzaların onaylanması/ticaret sicili yetkilisi huzurunda atılması, TBK m.184'teki yazılı şekil yerine geçer. Yazılı olarak yapılmış şirket sözleşmesindeki imzaların onaylanmasıyla/ticaret sicili yetkilisi huzurunda atılmasıyla alacak şirkete katılma payı olarak getirilebilirse de; alacak tahsil edilmeden, sermaye koyma borcu ifa edilmiş sayılmaz (TTK m.130/1).

Ticaret şirketlerine, alacağın sermaye olarak getirilebilmesi esas olmakla birlikte; TTK m.342 gereği, vadesi gelmemiş alacaklar ve bu

---

[139] Bkz. **Çonkar, M. H.,** Anonim Ortaklıkta Ayni Sermaye, İstanbul 2016, s. 164 vd.; ***Arıcı, M. F.,*** *"Sermaye Şirketleri Hukukunda Vadeli Alacağın Sermaye Olarak Konulması Yasağı"*, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXXIII, S. 1, s. 319 vd.

bağlamda, vadesi gelmemiş kıymetli evrak, anonim ve limited şirketlerde sermaye olarak konulamaz (TTK m.578/1; m.581/1).

3) Katılma Payı Borcunun Yerine Getirilmesini İsteme Hakkı

TTK m.128/7'ye göre, *"Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi için ihtar şarttır. Şahıs şirketlerinde bu davayı ortaklar da açabilir".*

Hükmün düzenlenmesinden de anlaşıldığı üzere, sermaye şirketlerinde şirket; şahıs şirketlerinde şirket veya ortaklar, *her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebilir* ve *sermaye koyma borcunun yerine getirilmesini dava edebilir.* Belirtmek gerekir ki, sermaye koyma borcunun yerine getirilmesinin istenmesi veya sermaye koyma borcunun yerine getirilmesini sağlamak maksadıyla dava açılması; şirketin, *gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini* istemeye engel değildir. Sermaye şirketlerinde şirket, şahıs şirketlerinde şirket veya ortaklar, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isterken; sermaye koyma borcunu yerine getirmede gecikme sebebiyle, şirketin uğradığı zararın tazminini de isteyebilir. Şahıs şirketlerinde, ortakların açacağı zararın tazmini davasında hükmolunacak tazminat şirkete ödenir.

4) Temerrüt Faizi

Temerrüt faizi, katılma payı olarak sadece para, alacak ve kıymetli evrak taahhüdünde söz konusu olur; para, alacak ve kıymetli evrak haricindeki katılma paylarının yerine getirilmesinde gecikme hâlinde, temerrüt faizi değil, şirketin uğradığı zararın tazmini istenebilir.

Buna göre, alacağın veya kıymetli evrakın vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça vade gününden; muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir (TTK m.130/2). Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla; ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de öder (TTK m.130/3). Alacak kısmen tahsil edilmişse; gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin

temerrüt faizini sadece tahsil edilmemiş olan kısım için öder (TTK m.130/4).

5) Faiz ve Ücret Alma Hakkı

Şirket türleriyle ilgili düzenlemelerde, [anonim ve limited şirketlerde (TTK m.509/1; 609) olduğu gibi] aksine hüküm yoksa, şirket sözleşmesiyle ortakların, koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri sebebiyle kendilerine ücret verilmesi kabul olunabilir. Anonim ve limited şirketlerde sermaye için faiz ödenemez (TTK m.509/1; m.609).

B) SERMAYE KOYMA BORCUNDA KABUL GÖREN KARİNELER

Kanun koyucu, sermaye koyma borcu hakkında TTK m.131'de bazı karineler getirmiş; bazı kabullerde bulunmuştur. Bu karinelerin başında, "*sermaye olarak konulan aynılara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, ilgililerce kabul edilmiş sayılacağına*" (TTK m.131/1) ilişkin olan karine gelmektedir.

TTK m.131/2'de kabul edilen karineye göre de, "*şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa; sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur*".

Bir diğer karine, TTK m.131/3'te hükme bağlanmış, "*hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez*" denilmiştir.

VI) ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI

Ticaret şirketinin ortaklarının (şirket dışı işlemlerinden dolayı) şahsi alacaklısı, alacağını tahsil etmek maksadıyla, ortağın şirket dışındaki mallarına başvurabileceği gibi; ortakların ticaret şirketindeki hisse ve alacaklarına müracaat ederek alacağını tahsil cihetine gidebilir. TTK m.133'te, ortakların şahsi alacaklılarının, ortakların ticaret şirketindeki hisse ve alacaklarına hangi şartlarla müracaat edebilecekleri; şahıs ve sermaye şirketlerinde ortakların kişisel alacaklıları yönünden temas edilmiştir. Tekrar olmak üzere belirtmek gerekir ki, alacaklıların, ortakların ticaret şirketindeki hisse ve alacaklarına başvurması; borçlu

ortakların şirket dışındaki mallarına müracaat etmesine engel değildir (TTK m.133/4).

A) ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI

Bir şahıs şirketi devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı, bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir (TTK m.133/1). Bunun dışında, alacaklılar alacaklarını, ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir (TTK m.133/3).

B) SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARI

Sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya bağlanmamış payların, İcra ve İflas Kanununun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir (TTK m.133/2). Bunun dışında, alacaklılar alacaklarını, şahıs şirketlerinde olduğu gibi, ortağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir (TTK m.133/3).

VII) ZAMANAŞIMI

Ticaret şirketi tüzel kişiliği ile üçüncü kişi arasındaki hukuki ilişkilerde zamanaşımının, bu hukuki ilişkinin bağlı olduğu zamanaşımı hükümlerine tâbi olacağı tartışmasızdır. Buna karşın, ticaret şirketlerinin ortaklarıyla ilişkisi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nda, özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiş; Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenen diğer borç ve borç ilişkilerinde olduğu gibi, Türk Borçlar Kanunu'nun birinci kısmının üçüncü bölümündeki hükümlere tâbi olacağı kabul edilmiştir.

Kanun koyucu Türk Borçlar Kanunu'nun 146'ncı maddesinde "*Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, her alacak on yıllık zamanaşımına tâbidir*" hükmünü takiben 147'nci maddede *beş yıllık* zamanaşımı

sürelerini ayrıca düzenlemiştir. Türk Borçlar Kanunu'nun 147'nci maddesinin dördüncü bendinde şirketlerle ilgili olarak, "*Bir ortaklıkta, ortaklık sözleşmesinden doğan ve ortakların birbirleri veya kendileri ile ortaklık arasındaki; bir ortaklığın müdürleri, temsilcileri, denetçileri ile ortaklık veya ortaklar arasındaki alacaklar*"ın da ***beş yıllık*** zamanaşımı sürelerine tâbi olacağı öngörülmüştür.

Ticaret şirketleri bakımından her ne kadar TBK m.147 hükmü uygulama alanı bulacak olmakla birlikte, Türk Ticaret Kanunu'nun bazı maddelerinde özel zamanaşımı süreleri öngörüldüğünün ilave edilmesi gerekir. Örneğin hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılmasından kaynaklı olarak pay sahiplerinin hâkim teşebbüse karşı açacağı davalar (TTK m.202/2), kollektif şirketlerde ortakların rekabet yasağına aykırı hareket etmesinden doğan şirket talepleri (TTK m.231/2) ve tasfiye memurlarına karşı açılacak sorumluluk davaları (TTK m.285/3), anonim şirketlerde yönetim kurulu üyelerinin rekabet yasağına aykırı hareket etmesi halinde şirketin sahip olduğu talepler (TTK m.396/3), denetçinin sır saklamadan dolayı sorumluluğu bakımından açılacak davalar (TTK m.404/5), kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları hakkında açılacak sorumluluk davaları (TTK m.560), limited şirketlerde haksız yere kâr almış olan ortak ve müdürlere karşı ileri sürülecek iade talepleri (TTK m.611/3) hakkında öngörülen zamanaşımı süreleri burada zikredilebilir.

§5-TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME VE DENETLEME YETKİSİ

Türk Ticaret Kanununun 210'uncu maddesinde, *"Gümrük ve Ticaret Bakanlığı*[140] *bu Kanunun (TTK) ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili* ***tebliğler yayımlamaya*** *yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyarlar. Ticaret şirketlerinin işlemleri, ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek Sanayi ve Ticaret Bakanlığı* ***denetim elemanları tarafından denetlenir.***

Diğer bakanlık, kurum, kurul ve kuruluşlar, ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tâbi olarak, şirketlere ilişkin düzenlemeler yapabilirler. Bu düzenlemeler bu Kanunun (TTK) ilkelerine ve sistemine aykırı olamaz. Söz konusu düzenlemelerin bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerini ilgilendirmeleri hâlinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığının yazılı uygun görüşü alınır. Bakanlık düzenlemeyi kanuna uygunluk yönünden inceleyerek görüşünü en geç otuz gün içinde yazılı olarak ilgili bakanlık, kurum, kurul veya kuruluşa bildirir; süresi içinde bildirilmemişse görüş olumlu kabul edilir.

Kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren ***bir yıl içinde fesih davası açılabilir****"* denilmiştir.

TTK m.210/1-2'de Ticaret Bakanlığının iki yetkisinden, *düzenleme* ve *denetleme* yetkisinden bahsedilmiş; kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu yönde *hazırlıklarda* ya da *muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu* belirlenen ticaret şirketleri hakkında da Bakanlık tarafından *fesih davası* açılabileceği ifade edilmiştir.

---

[140] Her ne kadar TTK m.210/1 hükmünde "*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı*" olarak ifade edilse de Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede, 703 sayılı *Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname* ile yapılan değişiklik ile Bakanlığın adı "*Ticaret Bakanlığı*" şeklinde değiştirilmiştir.

I) TİCARET BAKANLIĞININ DÜZENLEME YAPMA YETKİSİ

Düzenleme ya da kural koyma yetkisi sadece yasama organının tekelinde değildir; Devletin diğer organ ve birimlerinin de Anayasa ve kanunlardan aldığı yetkiyle *kural koymaları* mümkündür. Ancak yürütmenin sahip olduğu düzenleme yetkisi, asli bir yetki değildir; kanundan kaynaklanan ikincil nitelikli, türevsel bir yetkidir. Bir diğer söyleyişle, yürütme organının işlemleri ister sübjektif ister düzenleyici işlemler olsun; daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir kanuna dayanmak zorundadır. Bu anlamda yürütme organının işlemleri, kanunu izleyen, kanundan kaynaklanan işlemlerdir. Buna göre, yasama organı kanunlarla genel ilkeler koyarak, bir çerçeve çizmekte, sınırları belirlemekte; bu ilkeler doğrultusunda ayrıntıyı düzenlemek suretiyle yasama fonksiyonunu tamamlamak üzere yürütme organı ya da idare, *düzenleyici işlem (kural işlem)* tesis etmektedir[141].

İdari işlemlerin diğer türleri bir yana, *düzenleyici idarî işlemler*, genel ve kişilik dışı idarî işlemlerdir. Anayasada öngörülmüş idarenin düzenleyici işlemleri, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik olarak belirlenmiştir. Ancak uygulamada, yürütme organının bunların dışında, "*kararname*", "*karar*", "*sirküler*", "*genelge*", "*ilke kararı*", "*esaslar*", "*yönerge*", "*talimat*", "*statü*", "*genel emir*", "*ilân*", "*duyuru*", "*plân*", "*tarife*", "*izahname*", "*açıklama*" gibi değişik isimler taşıyan *genel, soyut, objektif hukuk kuralları* koyduğu görülmektedir.

İdarenin kanuna aykırı olmamak (*intra legem*) kaydıyla, tüzük ve yönetmelik dışında da, istediği isim altında istediği şekilde düzenleyici işlem tesis edebileceği kabul edilmektedir[142]. Bu esastan olmak üzere, idarenin tesis edebileceği düzenleyici işlemlerden birisi de "***tebliğ***"dir.

Sözcük anlamıyla "*duyurma, bildirme, haber verme*" anlamına gelen "*tebliğ*", idare hukukunda, idarenin genel ve kişilik dışı idarî işlemlerinden olan tüzük ve yönetmelik gibi bir düzenleyici işlemidir.

Kanun koyucu, TTK'nin 210'uncu maddesinde, SPK ve BDDK gibi özerk kuruluşlara tanınan kural koyma yetkisini Ticaret Bakanlığına da

---

141 **Akyılmaz, B./Sezginer, M./Kaya, C.**, Türk İdare Hukuku, 7. Baskı, Ankara 2016, s. 39.

142 **Gözler, K./Kaplan, G.**, İdare Hukuku Dersleri, 12. Baskı, Bursa 2012, s. 443.

tanımış; Ticaret Bakanlığının, Türk Ticaret Kanunu'nun "*ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili tebliğler yayınlamaya yetkili olduğunu*" kabul etmiştir.

Ticaret Bakanlığının düzenleyici işlem mahiyetindeki bu yetkisi, *münhasır bir yetkidir*; diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlar, TTK'nin ilkelerine ve sistemine aykırı olmamak kaydıyla ve ancak kendilerine kanunla tanınan yetkinin sınırları içinde kalmak şartıyla ve öngörülen amaç, konu ve şekle tâbi olarak ticaret şirketlerine ilişkin düzenlemeler yapabilir (TTK m.210/2).

Ticaret sicili müdürlükleri ve ticaret şirketleri, Ticaret Bakanlığı tarafından çıkartılan bu tebliğlere uymak zorundadır (TTK m.210/1).

II) TİCARET BAKANLIĞININ DENETLEME YETKİSİ

Sözlükteki anlamıyla "*denetleme*", denetlemek işidir; bu işi yapana "*denetçi*" denir. Denetlemek ise, bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek anlamlarına gelmektedir[143]. Kanunun lâfzı ve düzenleme amacı nazara alınırsa, farklı anlamlar taşımalarına karşın, TTK m.210'da hükme bağlanan "*denetim yetkisi*", murakabe, teftiş ve kontrolü içine alan geniş bir yetkidir.

Maddenin gerekçesinde, sadece üçüncü fıkranın *(fesih davası);* 6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanununun 274'üncü maddesinden esinlenerek kaleme alındığı ifade edilmişse de, denetim de aynı maddeden esinlenildiği anlaşılmaktadır.

6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanununun 274'üncü maddesinde *"Anonim şirketlerinin muameleleri, bir tüzük ile tayin olunacak şekilde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ticaret müfettişleri tarafından denetlenir.*

---

[143] Denetimle ilgili düzenlemelerde "denetim" yerine, "murakabe", teftiş", "kontrol" kelimelerinin de "eş anlamlı" olarak kullanıldığını görülmektedir. "***Murakabe***", bakmak gözetmek, gözaltında tutmak anlamındadır (Bankalar Yeminli Murakıplarında olduğu gibi). "***Teftiş***", bir işin yolunda gidip gitmediğini anlamak için sorup araştırma anlamındadır; teftiş yapana müfettiş denir (Banka müfettişleri gibi). "**Kontrol**", Latince "contra ratulare (iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek) kelimesinden türetilerek batı dillerine, oradan da Türkçeye geçmiş; kulanım yerine göre farklı anlamlar yüklenebilen ve fakat esas itibariyle, bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi anlamında kullanılan bir kelimedir; kontrolü yapana "kontrolör" denilmektedir (Gümrük kontrolör gibi).

Denetim, bilançonun açıklık ve doğruluk esasları çerçevesinde yapılacak incelemeyi de kapsar" denilmekteydi ve bu denetimin nasıl yapılacağı "Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzük[144]"te gösterilmişti.

Benzer düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bütün ticaret şirketleri için hükme bağlanmış ve bu denetimin usul ve esasları da "*Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik*[145]"te gösterilmiştir.

A) TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN DENETİMİN AMACI

Bakanlıkça yapılacak **denetimin amacı**; ticaret şirketlerinin Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Bakanlıkça ticaret şirketlerinin kuruluşundan sona ermesine kadar gerçekleşen tüm işlemlerinin Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğu denetlenir, uygunsuzlukların giderilmesi için rehberlik edilir, cezai sorumluluğu tespit edilenler yetkili makamlara, hukuki sorumluluğu tespit edilenler de genel kurul gündemine alınıp görüşülmek üzere şirketin yönetim organına bildirilir ve uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesine yönelik tedbirler alınır (Yönetmelik m.4).

B) DENETİM İLKELERİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak denetimin ilkeleri Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde hükme bağlanmış ve *"Ticaret şirketlerinin işlemleri; tarafsızlık, eşitlik, dürüstlük, gizlilik ve mesleki özen ilkeleri başta olmak üzere aşağıdaki esaslara göre denetlenir"* denilmiştir. Buna göre, denetim esnasında:

a) Denetim kanıtlarının toplanmasında, önyargısız ve tarafsız davranılır.

b) Toplanan kanıtlar, adil ve nesnel şekilde değerlendirilir.

c) Ulaşılan sonuçlar, yeterli ve uygun kanıtlara dayandırılır ve bu konuda azami mesleki özen ve dikkat gösterilir.

ç) Gerektiğinde denetlenenlerin incelenen işlemler hakkındaki görüşleri alınır.

---

144 07.08.1972 Tarih ve 14269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

145 28.08.2012 Tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

d) Denetim faaliyetleri yerine getirilirken kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket edilir.

e) Denetim çalışmaları dürüstlük ve sorumluluk duygusu içinde yürütülür.

f) Denetim faaliyetlerinin yürütülmesi ve raporlanması aşamalarında gizliliğe riayet edilir.

C) DENETİME KONU İŞLEMLER

Ticaret şirketlerinin işlemlerinin denetlenmesi esas olmakla birlikte, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla; hangi konuların denetleneceği Yönetmeliğin 5'inci maddesinde ifadesini bulmuştur. Buna göre; ticaret şirketlerinin, Bakanlığın denetimine konu işlemleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Kuruluş işlemleri,

b) Ticaret siciline tescil ve ilan işlemleri,

c) Ticaret unvanına ve işletme adına ilişkin işlemler,

ç) Ticari defterlere ilişkin işlemler,

d) Birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemleri,

e) Şirketler topluluğuna, bağlılığa ve hâkimiyete ilişkin işlemler,

f) Genel kurulun çağrılmasına, toplanmasına, karar almasına, görevlerine ve yetkilerine ilişkin işlemler,

g) Yönetim organının oluşumuna, toplanmasına, karar almasına, sorumluluğuna, görev ve yetkilerine yönelik işlemler,

ğ) Denetçinin seçilmesine ilişkin işlemler,

h) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin işlemler,

ı) Paya ve sermaye koyma borcuna ilişkin işlemler,

i) Menkul kıymet işlemleri,

j) Sermayenin artırılması, azaltılması ve tamamlanması işlemleri,

k) Finansal tablolara, yıllık faaliyet raporlarına ve yedek akçelere yönelik işlemler,

l) Kâr, kazanç ve tasfiye payına ilişkin işlemler,

m) Elektronik ve bilgi toplumu hizmetlerine ilişkin işlemler,

n) Sona erme ve tasfiyeye yönelik işlemler,

o) Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere konu işlemler.

Bu işlemlerin denetiminin, her bir ticaret şirketinin türüne göre ve bu türe bağlı özellikler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır.

Kuruluşları ve faaliyetleri diğer kanunlarla düzenlenen ticaret şirketlerinin denetiminde, bu ticaret şirketlerinin denetiminden sorumlu olan yetkili bakanlığın; denetim kapsamı dışındaki işlemler de Ticaret Bakanlığının denetimine tâbidir.

D) DENETİM USULÜ

Ticaret şirketlerinin işlemleri, Bakanlık denetim elemanlarınca denetlenir. Bakanlık, ticaret şirketlerinin denetimine *re'sen* veya ortakların yahut üçüncü kişilerin *istem, ihbar ve şikâyetleri* üzerine karar verebilir.

Ticaret şirketlerinin işlemleri, şirketin merkezinde ve gerektiğinde şubelerinde veya ticari işletmesinde denetlenir. Ancak, denetimin belirtilen yerlerde yürütülmesine ilişkin koşulların yeterli ve uygun olmaması halinde denetim çalışmaları, denetim elemanının belirleyeceği yerde sürdürülür.

Denetim çalışmaları, ticaret şirketine ait teknolojik alt yapının yeterli ve güvenli olması, denetim elemanınca şirket merkezinde denetim yapılmasına gerek görülmemesi ve Başkanlığın da uygun görüşü üzerine kayıt ve belgelere elektronik ortamda erişim sağlanması suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Denetim elemanları, denetledikleri ticaret şirketiyle iştirak, hâkim yahut bağlı şirket ilişkisi içinde olan ve bu Yönetmelik kapsamına giren ticaret şirketlerinin de denetime dâhil edilmesini gerekli görürlerse, durumu gerekçesiyle birlikte Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirirler ve bu konuda izin isterler.

E) DENETİM RAPORLARI

Bakanlık denetim elemanları, yapılan denetimler sonucunda, denetimin mahiyetine göre "*rapor*" düzenlerler.

1) Düzenlenecek Raporlar

Denetim elemanları tarafından düzenlenecek ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına sunulmak üzere hazırlanacak olan raporlar, denetimin amacıyla ilgili olarak Yönetmeliğin 9'uncu maddesinde hükme bağlanmıştır.

a) Teftiş Raporu

Ticaret şirketlerinin belli bir döneme ait işlemlerinin, örnekleme ve amaca uygun diğer denetim teknikleri kullanılarak, Kanuna ve Kanuna dayanılarak çıkarılan düzenleyici işlemlere uygunluğunun incelenmesi sonucunda düzenlenen rapordur.

b) Soruşturma Raporu

Denetim sırasında, kamu adına soruşturmayı ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğinin öğrenilmesi durumunda yetkili makamlara bildirilmek üzere düzenlenen rapordur.

c) İnceleme Raporu

Teftiş ve soruşturma raporlarına konu olmayan hususlarda düzenlenen rapordur.

Denetim elemanlarınca hazırlanan bu raporlar, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Rapor Değerlendirme Komisyonlarınca değerlendirilmek üzere Başkanlığa sunulur.

2) Fesih Davası

Ticaret şirketlerinin, kamu düzenine veya *işletme konusuna aykırı işlemlerde* veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğunun *Bakanlık denetim elemanlarınca tespit edilmesi halinde*, Bakanlıkça fesih davası açılabilmesi için *inceleme raporu* düzenlenir (Yönetmelik m.9/3).

Bakanlık denetim elemanlarınca, *"kamu düzenine veya* ***işletme konusuna aykırı*** *işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren* ***bir yıl içinde*** *fesih davası açılabilir"* (TTK m.210/3). Davanın, şirketin merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinde açılması gerekir.

Ancak burada açıklanması gereken önemli bir husus vardır. Kanunun gerekçesinde açıkça ifade edildiği ve bizim de yukarıda ifade ettiğimiz gibi, 6762 sayılı Kanunun 137'nci maddesinde öngörülmüş bulunan ve tüm ticaret şirketleri için geçerli olan *ultra vires* ilkesi,

AET'nin 68/151 sayılı şirketlere ilişkin Birinci Yönergesinin ilgili hükmü dikkate alınarak kaldırılmıştır.

Kanunun genel gerekçesinde bu husus, *"6762 sayılı Kanun, ticaret şirketlerinin, şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusunun çerçevesi içinde kalmak şartıyla, hak iktisap edebilecekleri ve borç yüklenebilecekleri ilkesel hükmünü içeriyordu. Bu hüküm uyarınca, işletme konusu dışında ticaret şirketleri hak ehliyetini haiz değildi; işletme konusu dışında yapılan işlemler ultra vires olduğu için yok sayılıyordu. Türk hukukuna 6762 sayılı Kanun ile giren, ticaret şirketleri hukukuna hâkim olan bu temel kural, Türk ticaret ve medeni hukuk öğretilerinde eleştiriliyordu. Hatta bazıları ultra vires'i geçmiş yıllarda kalan merkezî planlama anlayışı ile bağlantılı görüyordu. AET 1968 tarihli ve 68/54 sayılı, şirketlere ilişkin birinci yönergesinde, AET'ye üye ülkelerin ultra vires kuralını kanunlarından çıkarmalarını öngörüyordu. Yönerge, bu hükmü ile üçüncü kişileri korumayı amaçlıyordu. Temsile yetkili kişilerin, şirket adına yaptıkları işlemlerin şirketi bağlayacağına üçüncü kişilerin güvenmelerinin sağlanması, işlem ve pazar güvenliği için şarttı. Bir taraftan hep gündemde bulunan eleştiriler, diğer taraftan AET'nin yönergesi dikkate alınarak ultra vires hükmüne Tasarıda yer verilmemiştir. İlkenin kaldırılması sebebiyle, şirketin işletme konusu dışında yapacağı işlemlerin sonuçları, Tasarıda üçüncü kişinin iyi niyeti çerçevesinde düzenlenmiştir"* şeklinde açıklanmıştır.

Yargı kararlarının nasıl oluşacağı bilinmemekle beraber, Kanunun gerekçesi nazara alındığında, Bakanlığın fesih davası açmasının, işletme konusuna her aykırılık halinde söz konusu olamayacağının; *işletme konusuna aykırılık iyi niyet kuralları ile bağdaşmıyorsa fesih davası açılabileceğinin* kabulü gerekir.

Denetleme sonucuna göre, şirketin feshini gerektirecek nitelikte olmayan hukuka aykırılıklarla ilgili olarak, Kanuna ve Kanuna dayalı olarak çıkartılan düzenleyici işlemlere aykırı davrandığı belirlenenler hakkında, cezai sorumluluğu tespit edilenler yetkili makamlara; hukuki sorumluluğu tespit edilenler de genel kurul gündemine alınıp görüşülmek üzere, şirketin yönetim organına bildirilir (Yönetmelik m.4). Ayrıca diğer bakanlık, kurul, kurum ve kuruluşların görev alanına giren ve bunlar tarafından tedbir alınmasını veya denetim yapılmasını gerektiren durumların yetkili birimlere bildirilmesi de gerekir (Yönetmelik m.9).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

§6- KOLLEKTİF ŞİRKET

LİTERATÜR

İmregün, O., *Kollektif, Komandit ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklıklar*, İstanbul 1989; Arslanlı, H., *Kollektif ve Komandit Şirketler,* İstanbul 1960; Çamoğlu, E., *Kollektif Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi ve Ortağın Haklı Sebeple Çıkarılması*, İstanbul 2008; Güman, N., *Elbirliği Mülkiyeti ile Kollektif ve Komandit Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya Çevrilmesi*, İstanbul 2010

I) KOLLEKTİF ŞİRKET KAVRAMI

TTK m. 211'de, *"ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirket"* olarak tanımlanmaya çalışılan kollektif şirkete ilişkin hükümlerin (m. 211-303) kaynağı; esas itibarıyla[146] 6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanunudur[147].

---

[146] Bazı katkı ve değişiklikler için bkz., TTK m. 216, 224, 226, 235, 243, 245, 255, 264.

[147] Kollektif şirketlerle ilgili hükümlerin kaynağını oluşturan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun gerekçesinde, kollektif şirketlere müteallik hükümlerin, teferruat ve kanun tekniği bakımından İsviçre ve Türk hukukunda birbirinden farklı olduğu; bu nedenle 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kollektif şirketlerle ilgili hükümlerinin tanziminde, 865 sayılı Ticaret Kanunu'ndaki kollektif şirket hükümlerinin esas alındığı ifade edilmiştir. Kanun koyucuyu bu düşünceye sevk eden sebep gerekçede, İsviçre Borçlar Kanunu'nda kollektif şirketlere tüzel kişilik tanınmadığı ve 865 sayılı Ticaret Kanununda kollektif şirketler (105) maddede düzenlenirken, İsviçre Borçlar Kanunu'nda çok muhtasar bir şekilde (42) maddede tedvin edildiği; bu bakımdan yürürlükteki 865 sayılı Ticaret Kanunu, memleketimizin özel şartlarına İsviçre Kanunundan daha uygun görüldüğü şeklinde açıklanmıştır. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kolektif ortaklıklar hakkındaki (153-242)'nci maddeleri 865 sayılı Ticaret Kanunu'nun (146-250)'nci maddelerine tekabül etmiş; hükümlerin tertibi bakımından çok karışık bir manzara arz eden tasfiye kısmı hariç olmak üzere 6762 sayılı Kanunun tertip

TTK m.124/2'de şahıs şirketlerinden olduğu ifade edilen kollektif şirket, şahıs şirketlerinin ayırıcı tüm özelliklerini taşır ve mahiyeti itibarıyla, gerçek kişiler tarafından kurulmuş adi şirketlerin tüzel kişilik kazanmış türü olarak görülür. Bu bağlamdan olmak üzere, kollektif şirketlerin *intiutu personae* (karşı tarafın kişiliği göz önüne alınarak işlem yapılması) karakterini taşıdığı; esas itibarıyla birbirini tanıyan ve birbirine güvenen az sayıda ortak tarafından kurulduğu söylenebilir. Gerçekten de, şirkete girmenin ve çıkmanın sözleşme değişikliğini ve dolayısıyla oybirliğini gerektirdiği (TTK m. 226/2); şirket sözleşmesi veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine veya birkaçına yahut tümüne verilmemişse ortakların her birinin ayrı ayrı şirketi yönetme hakkına sahip olduğu (TTK m. 218/1); ortakların arasında rekabet yasağının bulunduğu (TTK m. 230); bir ortağın ölümünün, iflasının, hacir altına alınmasının şirketin geleceğini etkilediği (TTK m. 243) nazara alındığında, kollektif şirketin *intiutu personae* karakteri taşıyan bir şahıs şirketi sayılmasında bir tereddüt bulunmamalıdır.

Kollektif şirketlerin iktisadi önemi; hukuki mahiyeti itibarıyla, ortaklarının emek ve sermayelerini bir araya getirebilme ve yönetimde gösterilen esneklik özelliğine dayanır. Bu bağlamdan olmak üzere, kollektif şirket ortaklarına sermaye olarak getirilebilecek değerler hususunda geniş bir serbesti tanınmış; TTK m. 127'de zikredilen değerlerin kollektif şirketlere sermaye olarak getirilebileceği kabul edilmiştir. Bunun yanında, yönetim işleri ile ilgili olarak da, TTK m. 218 çerçevesinde, ortakların her birinin ayrı ayrı şirketi yönetme hakkına sahip olduğu hükme bağlanarak, ticari bir işletmeyi tek başına işleten kişilerin (tacirin) sahip olduğu, piyasa şartlarına süratle uyum sağlayabilme imkânı da sağlanmıştır.

Kollektif şirketlerle ilgili olarak; kurulması ve faaliyetiyle ilgili bu faydaların yanında, bazı mahzurlarının bulunduğu da burada zikredilmelidir. Bilhassa, şirketin borçlarından dolayı kollektif şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlandırılmamış olması; kişilerin, kollektif şirket kurma hususundaki iradelerine tesir etmektedir. Bunun gibi,

---

şekli ve sırası esas itibarıyla olduğu gibi bırakılmıştır. 6102 sayılı Kanun döneminde de, kollektif şirketlerle ilgili hükümler mufassal bir şekilde (93 maddede) hükme bağlanmıştır. İsviçre Borçlar Kanunundaki kollektif şirketlere ilişkin hükümler ise, (42) maddeden müteşekkildir.

ortaklardan birinin ölmesi, ortaklardan birinin kollektif şirketteki tasfiye payının cebri icra yoluyla paraya çevrilmesi hâlinde şirketi sona ermesi söz konusu olabilmektedir. Bu ve benzeri sakıncalar, kişileri kollektif şirket kurma hususunda tereddüde sevk etmekte; ülkemizde kollektif şirket kurma yönündeki iradenin zayıfladığı gözlemlenmektedir[148].

II) KOLLEKTİF ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

TTK m. 211'de *"tanım"* başlığı altında, *"kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış olan şirkettir"* şeklindeki nitelendirmeden anlaşılacağı üzere; kanun koyucu sözü geçen hükümde, kollektif şirketi tanımlamak yerine, kollektif şirketin bazı özelliklerine temas etmiştir. Belirtmek gerekir ki, kollektif şirketlerin özelliklerinin, TTK m.211'de ifade edilenlerle sınırlı olmadığı; bu bağlamdan olmak üzere, tüzel kişiliğin de, kollektif şirketin özelliklerinden olduğu kabul edilmelidir.

TTK m.211 ve diğer düzenlemelerden hareketle; bir şirketin, kollektif şirket sayılabilmesi için, aşağıda belirteceğimiz özellikleri taşıması gerektiği ifade edilebilir.

A) TİCARİ İŞLETME İŞLETMEK AMACIYLA KURULMASI

Kanun koyucu, ticaret şirketleri arasında sayılan anonim ve limited şirketlerin kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabileceğini (TTK m.331, 573/3) kabul ederken; kollektif (ve komandit) şirketlerin ancak bir ticari işletme işletmek amacıyla kurulabileceğini hükme bağlamıştır (TTK m.211, 304/1).

Kollektif şirketin henüz faaliyete geçmemiş olduğu kuruluş döneminde, esnaf işletmesi faaliyetleri için öngörülen sınırı aşıp aşamayacağı belli olmadığından; kollektif şirket sözleşmesinde gösterilen işletmenin hacim ve ehemmiyetinden ziyade, ortakların maksadına bakılmalıdır. Ortakların müşterek iradesi, ticari işletmenin işletilmesine yönelik ise; şirket, kollektif şirket olarak kabul edilmelidir.

---

[148] Bu kapsamda 31.12.2016 tarihi itibariyle ülkemizde tescilli kollektif şirket sayısı 12.744 iken, 31.12.2018 itibari ile bu sayı 10.730'a düşmüştür.

B) TİCARİ İŞLETMENİN TİCARET UNVANI ALTINDA İŞLETİLMESİ

Kollektif şirketten bahsedilebilmesi için, ticari işletmenin bir ticaret unvanı altında işletilmesi gerekmektedir. Bu husus hem TTK m.211'de; hem zorunlu sözleşme kayıtlarının hükme bağlandığı TTK m.213'de belirtilmiştir.

Ticaret unvanı, kazanç paylaşma amaçlı kişi birliği olan kollektif şirketi, üçüncü kişilere tanıtan adıdır; kollektif şirket ortaklarının, bu unvanla muamele yapmayı kabul ettiklerini gösterir.

Kollektif şirketlerin tüzel kişi tacir (TTK m.16) olduğu ve tacir sıfatıyla kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmekle (TTK m.18/1) yükümlü bulunduğu nazara alındığında; ticari işletme işletmek amacıyla kurulması gereken kollektif şirketlerin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorunda bulunması (TTK m.39/1) zaten kaçınılmazdır.

TTK m.42/1 gereğince, kollektif şirketin ticaret unvanının *"çekirdek"* kısmı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir ve bu unvana TTK m.46 uyarınca, *"ek"* alınabilir.

C) ORTAKLARININ GERÇEK KİŞİ OLMASI

Tek kişi ile kollektif şirket kurulabileceğine ilişkin istisna öngörülmediğinden; bir sözleşme olması itibarıyla, kollektif şirket sözleşmesine en az iki ortağın iştiraki şarttır. Kanunda, ortak sayısının yukarıya doğru bir sınırlaması yapılmamıştır. Ancak, ortakların şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu olduğu ve yönetim ile temsil hükümleri nazara alındığında; çok ortaklı bir yapının kollektif şirkete uygun olmadığı söylenebilir.

Kollektif şirketin müşterek ve ferdi faaliyete dayanan bir şahıs şirketi olduğu esasından hareket eden kanun koyucu; kollektif şirket ortaklarının *gerçek kişi* olması gerektiğini hükme bağlamıştır (TTK m.211).

Buna göre, kollektif şirket ortaklarının akit ile borçlanmaya ehil olan gerçek kişiler olduğu söylenebilir. Türk Ticaret Kanununda, küçük ve kısıtlıların kollektif şirkete ortak olmaları hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. TMK hükümleri çerçevesinde (TMK m.15; 453, 462/7,

463/3), bunların da kollektif şirkete ortak olmalarının mümkün olduğu kabul edilmelidir.

D) ORTAKLARIN ŞİRKET BORÇLARINDAN DOLAYI SINIRSIZ VE MÜTESELSİL SORUMLU OLMASI

Kollektif şirketin borç ve yükümlülükleri, şirketi temsile yetkili kişilerin, yetkileri çerçevesinde, hukuki muamele ile tüzel kişi adına iltizam ettikleri taahhütlerle, sebepsiz zenginleşme ile organların haksız fiilleri gibi Kanundan doğan ve tüzel kişiliğe izafe edilen borçlardan oluşur. Bu esastan olmak üzere, vergi gibi, kamu hukukundan doğan borçlara da öncelikle kollektif şirket tüzel kişiliği muhataptır.

Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı; şirket tüzel kişiliği şirket malvarlığı ile birinci dereceden sorumludur (TTK m.237/1). Şirketin borç ve taahhütleri bakımından şirket tüzel kişiliğinin birinci dereceden sorumlu olduğunu kabul eden kanun koyucu; Türk Ticaret Kanununun 236 ve 211'inci maddelerinde, ortakların da şirket borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumlu olduğunu hükme bağlamıştır.

Ortaklarının sorumluluklarının sınırlandırılması sadece ortaklar arasındaki *ilişkide (iç ilişki) geçerlidir; ortakların sorumluluğunun,* şirket alacaklılarına karşı (dış ilişkide) sınırlandırılması mümkün değildir (TTK m.211). Ortakların, müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumlu olması, sadece kuruluşa iştirak eden ortaklara ilişkin de değildir; şirkete yeni giren bir ortak, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte, müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur (TTK m.236/2).

E) TÜZEL KİŞİLİK

Kanun koyucu kollektif şirketin, ticaret şirketi olarak (TTK m.124/2) tüzel kişiliği haiz olduğunu (TTK m.125/1) hükme bağlamış; kollektif şirketi, tüzel kişi tacir (TTK m.16/1) olarak nitelendirilmiştir.

Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek zorundadır[149] (TTK m.215). "*Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile*

[149] Şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanması hâlinde de sureti ticaret sicili müdürlüğü tarafından saklanarak tescil ve ilân

tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir" (TTK m. 232). Ticaret siciline tescil kurucu niteliktedir; TTK m. 215'de ilândan bahsedilmişse de, ilânın açıklayıcı etkiyi haiz olduğu kabul edilmelidir.

III) KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞU

Kollektif şirketin kurulması için bir şirket sözleşmesinin akdedilmesi ve kollektif şirketin ticaret siciline tescili gerekir.

A) ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

Kollektif şirket, şirket olması nedeniyle; bir şirket sözleşmesine istinaden kurulur. Bir diğer söyleyişle, kollektif şirketten bahsedebilmek için, sözleşmeye katılanların, katılma paylarını *ortak bir amaca erişmek üzere* birleştirmeyi üstlenmeleri; şirket sözleşmesinin de, kollektif şirket için aranan diğer özellikleri taşıması gerekir. Şirket sözleşmesi olmadan ve bu bağlamda sözleşmeye katılanların şirket kurma iradesi bulunmadan kollektif şirket kurulamaz (TTK m.216/2).

Kollektif şirketten söz edebilmek için bir şirket sözleşmesinin bulunması gerekliliğine temas eden kanun koyucu; şirket sözleşmesinin şekle tâbi olduğunu da hükme bağlamıştır. TTK m.212/1 gereğince, "*Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tâbidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır*".

1) Şirket Sözleşmesinin Şekli

TTK m.212/1'de, "*kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tâbidir*" denildikten başka, TTK m.213/1'de, kollektif şirket sözleşmesinde bazı kayıtların bulunmasının zorunlu olduğu ifade edilerek; bu yazılı şeklin, "*nitelikli yazılı şekil*" olduğu kabul edilmiştir.

Kollektif şirket sözleşmesinin *nitelikli yazılı şekle* tâbi olduğunu hükme bağlayan kanun koyucu, şirket sözleşmesinin Kanunda öngörüldüğü şekliyle yazılı olarak yapılmaması veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan birinin veya bazılarının eksik yahut geçersiz olması hâline hukuki sonuç bağlamış; bu şirketin, adi şirket hükmünde olduğunu kabul etmiştir (TTK m.214/1).

---

sağlanır (TTK m. 215'e, 15.07.2016 tarihli 6728 sayılı Kanunun 67'nci maddesi ile eklenen cümle).

2) Şirket Sözleşmesinin İçeriği

Kollektif şirket sözleşmesine, TTK m.213/1'de zikredilen hususların yazılması zorunludur; ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabilirler (TTK m.213/2).

a) Şirket sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu kayıtlar

Kollektif şirket sözleşmesine aşağıdaki kayıtların yazılması zorunludur:

(1) Ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıkları

Kollektif şirket ortaklarının, şirket borçlarından dolayı, sınırsız ve müteselsil sorumlu olduğundan hareket eden kanun koyucu; kollektif şirket sözleşmesi yapılırken, ortakların şahsen belirlenmesi gerektiğini kabul ederek, ortakların ad ve soyadlarıyla yerleşim yerleri ve vatandaşlıklarının şirket sözleşmesinde yer alması gerektiğini hükme bağlamıştır.

Kollektif şirket ortaklarının ad ve soyadlarıyla, yerleşim yerleri ve vatandaşlıklarının şirket sözleşmesinde yer alması zorunlu olmasına karşın; kollektif şirket ortaklarının Türkiye'de bir yerleşim yerlerinin bulunması ve ortakların Türk vatandaşı olması gerekmez.

(2) Şirketin kollektif olduğu

Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradelerinin nazara alınması (TBK m.19/1) esas olmakla birlikte; kanun koyucu, ortakların sınırsız sorumlu oluğunu belirtmek maksadıyla olacak ki, kollektif şirket sözleşmesinde, sözleşmeye katılanların kollektif şirket kurma iradelerinin şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

(3) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi

Kollektif şirketlerin ticaret unvanı, hem TTK m.211'deki tanımda; hem zorunlu sözleşme kayıtlarının hükme bağlandığı TTK m.213'de belirtilmiş; TTK m.216/2'de ise "*ortak unvan*" kavramı tercih edilmiştir.

Ticaret unvanı, kişi birliği olan kollektif şirketi üçüncü kişilere tanıtan adıdır; kollektif şirket ortaklarının, bu unvanla muamele yapmayı kabul ettiklerini gösterir. Kollektif şirket, ticari işletmesine ilişkin işlemlerini ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır (TTK m.39/1).

Kollektif şirket muamelelerinin ticaret unvanı altında yapılması hâlinde, yapılan muamelelerden dolayı bütün ortaklar, şirketle birlikte sınırsız ve müteselsil sorumlu olur; bu sorumluluk şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılamaz. Kollektif şirket muamelelerinin ticaret unvanı altında yapılması zorunlu olmasına karşın; bir kollektif şirket sözleşmesi yapılmaksızın, şirketin türünü gösterir bir kaydı içermese bile, ortak bir unvan altında, üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız bir fiil işlenmesi hâlinde de, ortakların müteselsil sorumluluğu söz konusu olur (TTK m.216/2).

Yukarıda da ifade edildiği üzere, TTK m.42/1 gereğince, kollektif şirketin ticaret unvanının "*çekirdek*" kısmı, *bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir* ve bu unvana TTK m. 46 uyarınca, "*ek*" alınabilir.

Şirket sözleşmesinde, şirketin merkezinin de gösterilmesi gerekir; şirket sözleşmesinde merkezin gösterilmemiş olması, şirketin adi şirket hükümlerine tâbi olması sonucunu doğurur (TTK m.214/1). Şirketin merkezi, şirketin adresi olarak nitelendirilmemeli; şirket faaliyet ve münasebetlerinin yoğunlaştığı mülki birlik olarak anlaşılmalıdır. Şirket merkezinin değişikliği, şirket sözleşmesinin değişikliğini gerektirirken; adres değişikliği, şirket sözleşmesinin değişikliğini gerektirmez.

(4) Şirketin işletme konusu

Türk hukukunda anonim ve limited şirketler kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilirken (TTK m.331, 573/3); TTK m.211'de ifadesini bulan tanıma göre, kollektif şirket sadece *ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla* kurulabilir.

Şirketin konusu, ticari işletmede olduğu gibi, iktisadi faaliyet dallarından herhangi biri olabilir. Şirket sözleşmesinde işletme konusunun sınırlarının açıkça gösterilmiş olması gerekir (TTK m.213/1, d).

(5) Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği katılma payının belirtilmesi

TTK m.213/1-e'ye göre, "*Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değeri*"nin şirket sözleşmesinde gösterilmesi gerekir.

Kollektif şirketlerde ortakların şirkete getirmeyi taahhüt ettiği katılma payı, TTK m.127'de ifadesini bulan iktisadi değerlerden birisi olabilir.

Şirket sözleşmesinde, her ortağın şirkete getirmeyi taahhüt ettiği katılma payı belirlenmemişse; kollektif şirket adi şirket hükmündedir. Adi şirketlerde de, TBK m.621 gereğince her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır.

(6) Şirketi temsile yetkili kimselerin belirtilmesi

Kanun koyucu, TTK m.213/1-f'de, şirketi temsile yetkili kimselerin belirlenmesini; bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduklarının şirket sözleşmesinde düzenlenmesi gereğinden söz ederken; TTK m.218'de, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına bırakılmamışsa, ortaklardan her birinin, ayrı ayrı şirketi yönetme hak ve görevinden bahsedilmiştir. Buna göre, şirket sözleşmesinde TTK m.213/1-f'de belirlenen temsile ilişkin kayıt yoksa; kanunen her ortak münferiden idare hakkını ve TTK m.233 gereğince de temsil yetkisini haiz sayılır. Hâl böyle iken, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadlarının, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduklarının şirket sözleşmesinde gösterilmemesi durumunda kollektif şirketin, adi şirket sayılacağının kabulü, tartışmaya açıktır.

b) Şirket sözleşmesine ihtiyari olarak konulabilecek kayıtlar

Kanun koyucu, kollektif şirket sözleşmesine bazı kayıtların yazılmasının zorunlu olduğunu TTK m.213/1'de hükme bağladıktan sonra;

TTK m.213/2'de ortakların, *emredici hükümlere aykırı olmamak şartıyla, şirket sözleşmesine diledikleri kayıtları koyabileceğini* kabul etmiştir.

3) Şirket Sözleşmesinin İmzalanması

Kollektif şirket sözleşmesinin, TTK m.213'de öngörülen şartlarla yazılı olarak hazırlanmasından sonra; kurucular tarafından imzalanması da gerekir. Şirket sözleşmesinin kurucular tarafından imzalanması gereği, TTK m.212'de, "*Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tâbidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır*" şeklindeki ifadeden anlaşılmaktadır.

Ayrıca şirket sözleşmesinin tanzim tarihinin belirtilmemesi, iç münasebette şirket akdinin oluşumunu tespitte önemli değildir. Zira sözleşmedeki imzalar noter tarafından onaylandığında veya şirket sözleşmesi ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalandığında bir tarih konulması gerekecektir. Kaldı ki üçüncü şahıslar, şirketin iç ilişkide kurulduğunu her türlü delille ispat edebilirler.

B) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRÜ YAHUT YARDIMCISI HUZURUNDA İMZALANMASI VEYA SÖZLEŞMEDEKİ İMZALARIN NOTERCE ONAYLANMASI

TTK m.212'de, *"kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir" denildikten sonra; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır"* düzenlemesine yer verilmiştir.

Buna göre, şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması; şirket sözleşmesi ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmamışsa, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması gerekmektedir.

Şirket kuruluş sözleşmesinin ticaret sicili müdürlüklerinde imzalanması, Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılmalıdır[150]. Şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması; imzaların kuruculara veya temsilcilere ait olduğunun tasdiki mahiyetindedir; ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı, bu aşamada içerik

---

150 *"Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ"* için bkz., 6.12.2016 Tarih ve 29910 sayılı Resmi Gazete.

denetimi yapamaz. Ticaret sicili müdürlüğünün içerik denetimi, tescil talebi ile doğar.

Kollektif şirket sözleşmesindeki imzaların noterce onaylanması hâlinde de, noter, sadece imzaların kuruculara veya temsilcilerine ait olduğunu tasdik eder; şirket sözleşmesinin içeriği ile ilgili bir değerlendirme yapamaz.

Kollektif şirket sözleşmesindeki imzaların **noterce onaylanması** hâlinde; kurucuların, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini, onay tarihinden itibaren *on beş gün içinde* şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemesi gerekir (TTK m.215). Noter, sadece imzaların kuruculara veya temsilcilerine ait olduğunu tasdik eder; şirket sözleşmesinin içeriği ile ilgili bir değerlendirme yapamaz.

C) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN

TTK m.215 gereğince, *"kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay tarihinden itibaren on beş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline vererek şirketin tescilini istemek zorundadır"*.

1) Tescil

Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine (TTK m.27/1) gerçekleşir; tescil istemi, merkezin bulunduğu yer ticaret siciline yazılı şekilde dilekçe ile (TTK m.29/1) veya elektronik ortamda yapılabilir. Dilekçede istem açıkça belirtilir ve tescil edilecek olgular gösterilir. Dilekçeye doğrulayıcı belgelerin asılları ya da onaylı örnekleri eklenir. Belgeler, hukuki gereklere uygun şekilde onaylanarak imzalanır. Onaylı örnekler elektronik ortamda da hazırlanabilir. Başvurunun elektronik ortamda yapılması halinde dilekçe ve belgeler güvenli elektronik imza ile imzalanır. Dilekçe, tescil isteminde bulunmaya yetkili kişi veya kişilerce imzalanır (TSY m.23).

a) Tescil Başvurusuna Yetkili Kişiler

Kanun koyucu TTK m.215'de, *kollektif şirketi kuranların, şirketin tescilini istemek zorunda* olduğunu ve TTK m.29/1'de de tescil isteminin dilekçe ile yapılacağını hükme bağlamıştır. TSY m.22/2-ç'de, *"kollektif şirketin kuruluşunda, kurucuların tamamının"* tescil başvurusunda bulunmaları gereğinden söz edilmişse de; kurucuların temsilci-

lerinin de tescil başvurusunda bulunabileceği kabul edilmelidir. Buna göre, *kollektif şirketi kuranların* veya *temsilcilerinin*, ticaret siciline hitaben yazılacak tescil başvurusunu birlikte imzalaması gerekmektedir.

Kollektif şirket sözleşmesi, kanuna uygun olarak yapıldıktan sonra kurucuların veya temsilcilerinin tescil talebinde bulunması gerekir. Ortaklar tescil başvurusunda bulunmazlarsa; ticaret sicili müdürü, kurucuları tescile davet eder (TTK m.33/1).

Kuruculardan bazılarının tescil talebinden kaçınması hâlinde; ortaklardan herhangi biri, şirketin feshini isteyebilir veya tescil için öngörülen sürenin sona ermesiyle birlikte, kollektif şirketin dava yoluyla tescilini talep edebilir.

b) Tescili Talep Süresi

Kollektif şirket sözleşmesindeki imzaların **noterce onaylanmasında**, kurucuların, onay tarihinden itibaren *on beş gün içinde* ticaret siciline tescilini istemek zorunda (TTK m.215) olduğu hükme bağlanmışken; Tebliğ'in 11'inci maddesinde, bu süre *üç ay* olarak öngörülmüştür. Buna göre, ticaret sicil müdürlüğünde imzalanan sözleşmenin, imzaların onay tarihinden itibaren *üç ay içinde* tescili için başvuruda bulunulması; onay tarihinden itibaren üç ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerektiği belirtilmiştir (Tebliğ m.11).

2) İlân

Kollektif şirketin ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanacağını hükme bağlayan kanun koyucu; sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlar ile kanunun emreylediği diğer hususların, sicile tescil edilmesi yanında; ilân olunması gereğinden de söz etmiştir (TTK m.215). Tescil edilen olgular, Kanunda veya sicil yönetmeliğinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ilân olunur. İlân, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilânına özgü Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanır.

3) Tescilin ve İlânın Hükmü

"*Kollektif şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Aksine sözleşme üçüncü kişilere karşı geçersizdir*" (TTK m.232). Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiği; ilânın tamamı aynı

nüshada yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurduğundan (TTK m.36/1); üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez (TTK m.36/3). Bu anlamda tescil kurucu; ilân ise açıklayıcı mahiyettedir.

Tescil yükümlülüğü yerine getirilmeksizin şirket adına işlere başlanmışsa, kollektif şirketten bahsedilemez; sadece, ortaklar giriştikleri islerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olur (TTK m.216/1).

IV)KOLLEKTİF ŞİRKETİN KURULUŞUNDA EKSİKLİK VEYA SAKATLIK

Şirket sözleşmesi de diğer sözleşmeler gibi, sözleşmeye katılanların uygun irade beyanları ile kurulur. Bu iradeler, akdin kurulması esnasında; ehliyetsizlik, yanıltma, aldatma gibi sebeplerle sakatlanabileceği gibi, yapılan sözleşme TTK m.212'de hükme bağlanan yazılı şekle riayetsizlik nedeniyle veya işletme konusu bakımından geçersiz olabilir.

Geçersiz olan şirket sözleşmeleri bakımından şirketin adi veya kollektif şirket olması arasında fark yoktur. TTK m.214'te, *"Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adi şirket hükmünde olup, hakkında 216'ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, Türk Borçlar Kanunu'nun adi şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır"* denilmesine karşın; geçersiz olan şirket sözleşmeleri bakımından bu hükmün tatbiki mümkün değildir.

Geçersiz olan şirket sözleşmeleri ile ilgili olarak söylenebilecekler bir yana; şirket sözleşmesindeki bazı eksiklikler ile şirketin tescil edilmemiş olması (tüzel kişilik kazanamaması) hâllerinin ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Zira şirket sözleşmesinin şekil şartlarına uygun olarak yapılmamasının hukuki sonuçlarının düzenlendiği TTK m.214'te, "*Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adi şirket hükmünde* sayılırken; TTK m.214'te saklı tutulan m.216 hükmünde "*tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden*" söz edilmektedir.

A) TESCİL YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMİŞ OLMASI

Tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tüzel kişiliğin kazanılmasını engeller; tüzel kişilik olmadığı için, tüzel kişilik adına hukuki muamele yapılamaz. Bu hâlde, tüzel kişilik adına hukuki muamele yapılması kural olmakla beraber; "*tescil yükümlülüğü yerine getirilmeksizin şirket adına işlere başlanmışsa, ortaklar giriştikleri işlerden dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu*" olurlar (TTK m.216).

Kanun koyucu bu kabulüyle, tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, şirketi yine adi şirket hükmünde saymış; ancak, sorumluluk hukuku yönünden adi şirket hükümlerinin tatbik edilmeyeceğini hükme bağlamıştır. Bu durumda *ortaklar, giriştikleri işlerden dolayı* üçüncü *kişilere karşı müteselsilen; tüzel kişilik de olmadığından birinci dereceden sorumlu olacaklardır.*

B) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN KANUNİ ŞEKİLDE YAPILMAMASI VEYA SÖZLEŞMEYE KONMASI ZORUNLU OLAN KAYITLARDAN BİRİNİN VEYA BAZILARININ EKSİK YAHUT GEÇERSİZ OLMASI

Şirket sözleşmesinin şekil şartlarına uygun olarak yapılmamasının hukuki sonuçları, TTK m.214'te, "*Noksanlıklar*" başlığı altında hükme bağlanmış; "*Sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirket, adi şirket hükmünde*" sayılmıştır.

Kanun koyucu, sözleşmesi kanuni şekilde yapılmamış veya sözleşmeye konması zorunlu olan kayıtlardan biri veya bazıları eksik yahut geçersiz olan bir kollektif şirketi adi şirket hükmünde sayarken; TTK m.12 hükmünü saklı tutmuştur. Bilindiği üzere, TTK m.12'de gerçek kişi tacir hükme bağlanmış; tacir sayılanlar ile tacir gibi sorumlu olanlardan bahsedilmiştir. Buna göre, kollektif şirket ticari işletmeyi işletmek amacıyla kurulduğundan; *adi şirket hükmünde* sayılan kollektif şirket ortakları tacir sayılacaktır.

V) KOLLEKTİF ŞİRKETİN EHLİYETİ

Ticaret şirketlerinin ehliyeti ile ilgili olarak, *ultra vires ilkesi* kaldırılmış ve ticaret şirketlerinin ehliyeti TMK m.48'e tâbi tutulmuş olmasına karşın (TTK m.125/2); TTK m. 213/1-d'de, *esaslı noktaları*

belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun belirtilmesi zorunluluğu muhafaza edilmiştir. Bilindiği üzere, kanun koyucunun kabulüyle, ticaret şirketlerinin hak ehliyetinin sınırı, TMK m.48'de belirlenmiştir. Şirketlerin, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehil olduğu kabul edilmiştir. Ancak TTK m.213/1-d'de, kollektif şirket için ehliyetin, konu ile sınırlı olduğu izlenimi yaratılmıştır.

Konu ile sınırlı ehliyet izlenimi sadece TTK m.213/1-d hükmü ile sınırlı olarak değerlendirilmemeli; TTK m.233'deki, *"Şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir"* hükmünün de konu ile sınırlı ehliyet izlenimi verdiği kabul edilmelidir.

Konu ile sınırlı ehliyetin kabulü, ortaklar arasında bir güvenlik sağlarsa da, TTK m.125 hükmü karşısında, kollektif şirketlerde, konu ile sınırlı ehliyet kabul edilmemeli; hak ehliyetiyle ilgili olarak TMK m.48'in geçerli olduğu kabul edilmelidir. Kaldı ki, konuyla ilgili sınırlı ehliyet olduğu kabul edildiğinde bile; ortakların sorumluluğu ile ilgili olarak fazla bir değişiklik gözlemlenmemektedir. Zira TTK m.12/2'de tescil ve ilân edilen kollektif şirket, üçüncü kişiler nazarında kollektif şirket sayılır; tescil ve ilân edilen kollektif şirket, faaliyeti esnasında, amacı dışında bir muamelede bulunsa dahi, ortakları TTK m.12/2'ye göre tacir sayıldığından, yapılan muameleden ortaklar sorumlu olur. Kaldı ki, yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, işletme konusu, şirketin hak ehliyeti ile ilgili değildir; sorumluluk hukuku bakımından önemlidir.

VI) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLARIN BİRBİRLERİYLE VE ŞİRKETİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ

Kollektif şirketlerde ilişkiler; şirketin ortaklarla ve ortakların diğer ortaklarla olan ilişkileri (iç ilişkiler) ile şirketin ve şirket ortaklarının üçüncü kişilerle olan münasebetleri (dış ilişki) iki ayrı başlık altında incelenmektedir.

A) GENEL OLARAK

Kollektif şirketlerde ortaklar arasındaki iç ve dış ilişkilerin incelemesine geçmeden evvel; bu ilişkilerin genel özelliklerini ele almanın uygun olacağını düşünüyoruz.

1) Ortaklar Arasındaki İlişkilerin Mahiyeti

Kollektif şirkette, şirketin ortaklarla ve ortakların diğer ortaklarla olan ilişkilerini (iç ilişkileri) düzenleyen hükümler, esas itibarıyla *düzenleyici*; şirketin ve şirket ortaklarının üçüncü kişilerle olan münasebetlerini (dış ilişki) düzenleyen hükümleri ise *emredici* mahiyettedir.

Bu değerlendirmeye göre, ortaklar arasındaki ilişkilerin, şirket sözleşmesi hükümlerine göre tanzim edileceği kabul edilir (TTK m.217). Buna karşın dış ilişkilere, Türk Ticaret Kanununun emredici hükümleri uygulanır. Ortaklar arasındaki ilişkilere (iç ilişkiler) sözleşme hükümlerinin uygulanması asıl olmasına karşın; iç münasebette kabul edilen, sınırsız ve müteselsil sorumluluğa aykırı olan şartlar, üçüncü şahıslara karşı hüküm ifade etmez (TTK m.236). Bunun gibi, temsil yetkisinin iç münasebette TTK m.233'e aykırı olarak sınırlandırılmış olması; iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

Üçüncü kişiler bakımından sevk edilmiş bulunan bu emredici hükümler haricinde; ortaklar arasındaki münasebetleri düzenleyen iç ilişkiler konusunda, ortaklara geniş bir serbesti tanınmış ve bu sahaya istisnaen müdahale ihtiyacı duyulmuştur. Bu istisnalardan birisi, TTK m.225'de hükme bağlanmış; ortakların denetim hakkının, şirket sözleşmesiyle ortadan kaldırılamayacağı ifade edilmiştir. Bunun gibi, TTK m.228 gereği ortağa tanınmış olan hakları kaldırma veya daraltma sonucunu doğuran sözleşme şartlarının geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır (TTK m.228/2).

2) Ortakların Sadakat ve Özen Yükümü

Kollektif şirketin, şahıs şirketi olduğu ve dış münasebette sınırsız ve müteselsil mesuliyetin bulunduğu nazara alındığında; ortakların sermaye koyma borcunu ifa etmeleriyle, sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin sona erdiği kabul edilmemelidir. Bu anlamda, sermaye koyma borcu yerine getirildikten sonra da ortakların, şirkete ve birbirlerine karşı sadakat ve iyi niyetle hareket etmek ve şirket menfaatlerini korumak borcu devam eder; ortaklardan hiçbiri şirket amacına aykırı ve

zararlı işleri yapamaz (TBK m.626). Kollektif şirketlerin bu özelliği dikkate alınarak; ortakların gerek ortaklarla gerek şirketle olan ilişkilerinde, ortakların sadakat ve özen borcuna uygun hareket etmesi gerekmektedir.

Kollektif şirket sözleşmesi yapılırken, ortakların şahsi niteliklerinin, diğer ortaklar tarafından bilindiği varsayıldığı için; diğer ortaklar, ortağın kendisinden beklenemeyecek bir özeni göstermesini, ortaktan isteyemezler. Bu nedenle ortakların, şirkete ve diğer ortaklara karşı haiz olduğu hak ve borçlarda göstereceği özenin ölçüsünde; ortağın kendi işlerinde gösterdiği olağan dikkat ve basiretin esas alınması gerekir.

3) Eşitlik İlkesi

Kollektif şirkette, şirket ve ortaklar arasındaki ilişkilerde, eşitlik ilkesi esastır. Bir diğer söyleyişle, kollektif şirket ortaklarının şirkete koymayı taahhüt ettiği katılma payları birbirinden farklı olsa da; her ortak aynı şartlar altında, aynı haklara sahip ve aynı borçlara tâbi olmalıdır. Bu ilke, TBK m.621'de zımnen ifadesini bulmuştur. Türk Ticaret Kanununun 218, 233 ve 226'ncı maddeleri de eşitlik ilkesinin bir görünümüdür.

Eşitlik ilkesi, ortakların, aynı şartlar altında, aynı haklara sahip ve aynı borçlara tâbi olması olarak anlaşılmalıdır. Ancak, sözleşmede hükme bağlanmak şartıyla; iç münasebette, özel durumları nedeniyle bazı ortaklara ilâve haklar tanınarak, eşitlik ilkesinden sapılabilir. Belirtmek gerekir ki aksine sözleşmede hüküm veya karar bulunmadıkça ortakların, aynı şartlar altında, aynı haklara sahip ve aynı borçlara tâbi olmaları asıldır.

4) Ortaklık Hak ve Borçlarının Devri

Kollektif şirketlerde, ortaklar arasındaki ilişkilerden doğan hak ve borçlar, şahsa bağlı olduğundan; esas itibarıyla devredilemez. Ortaklar arasındaki ilişkilerden doğan hak ve borçların devredilememesi kuralına bazı istisnalar getirilmiştir. Bu bağlamda ortaklar ancak diğer ortakların kabulüyle şirketteki payını, bir başkasına devredebilmektedir. Ayrıca ortaklar, yönetim, denetim ve oy hakları ile temsil yetkisini bir bütün hâlinde devredemeseler de kimi hâllerde, haklarını temsilci vasıtasıyla kullanabilirler. Bu hakların devamlı olarak devredilmesi, sadece küçük ve kısıtlılar için söz konusu olabilir. Ortakların borçlarının

devredilememesine ilişkin kuralın bir istisnası, katılma paylarında kendisini gösterir. Buna göre, ortakların katılma payını ifası, şahsa bağlı değilse bir başkası tarafından yerine getirilebilir.

B) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE İÇ İLİŞKİ

Kollektif şirketlerde iç ilişki, ortakların şirketle ve birbirleriyle olan ilişkileri anlamında kullanılmaktadır. TTK m.217 gereğince, "*Ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesinde sözleşme serbestisi geçerlidir*". Kollektif şirketlerde iç ilişkide, *sözleşme serbestisi geçerli* olmasına karşın; yukarıda belirttiğimiz üzere, bu kurala kanun koyucu tarafından bazı istisnalar getirilmiştir (bkz. TTK m.225, 228). İç ilişkilerin tasnifinde, mali ve şahsi ilişkiler ayrımına yer verilmektedir.

1) Mali Nitelikteki İlişkiler

Mali nitelikteki ilişkiler; sermaye koyma borcu, kâr ve zarara katılma, tasfiye veya ayrılma payı ile ücret-faiz ve masraf talebi başlıkları altında incelenmektedir.

a) Sermaye Koyma Borcu

TTK'de kollektif şirketlerin kurulabilmesi için asgari bir sermaye miktarı öngörülmediği gibi, ortakların asgari bir sermaye getirmesi gereğinden de bahsedilmemiştir. Bununla birlikte, kollektif şirketin bir ticari işletmeyi işletmek amacıyla kurulabileceği nazara alınarak kollektif şirketin sermayesinin, ticari işletmeyi işletme kapasitesine sahip olması gereğinden bahsedilebilir. Bunun gibi, ortakların getirmeyi taahhüt ettikleri sermayenin de amaca ulaşmaya elverişli olması gerekir.

TTK m.213 gereğince, *"her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı; para niteliğinde olmayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş olduğu; sermaye olarak kişisel emek konulmuşsa bu emeğin niteliği, kapsamı ve değerinin"* şirket sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur. Bu kapsamda, TTK m.127'de hükme bağlanmış ve şirket gayesini elde etmeye elverişli; nakden değerlendirilebilen ve devredilebilen mahiyette aynî nitelikteki katılma payları ile emek ve ticari itibar gibi şahsi nitelikteki katılma paylarının, kollektif şirketlere sermaye olarak getirilmesi mümkündür.

Kollektif şirketin sermayesi, ortaklarının taahhütlerinden oluşur. Bir şirketten bahsedebilmek için, her ortağın; şirket amacını gerçekleştirmeye elverişli bir katılma payı ile şirkete iştirak etmesi gerekir. Şirket

sözleşmesi ile kararlaştırılan katılma payı taahhütleri, ortakların sermaye borçlarını oluşturur. Kanuni şekilde yapılan şirket sözleşmesinin ticaret siciline tesciliyle birlikte ortak, şirket tüzel kişiliğine karşı borçlanmış olur. Şirket sözleşmesinde aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur (TTK m.131).

b) Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma

Kâr payı hakkı ve zarara katılma TTK m.227-229 arasında düzenlenmiş; kâr payı TTK m.228'de, "*ortakların istemleri*" başlığı altında hükme bağlanırken, "*zarar payı*" TTK m.229'da ele alınmıştır.

aa) Finansal Tablolarının Çıkartılması

TTK m.228/1 gereğince, *"her ortak, şirketten faaliyet dönemi sonunda gerçekleşen kârdan kendisine düşen payı, şirkete ödünç olarak verdiği paranın ve kararlaştırılmışsa koyduğu sermayenin faizlerini, şirket sözleşmesi gereğince hak ettiği ücreti; kanuna veya şirket sözleşmesine göre yılsonu bilançosu çıkarılmamışsa çıkarılmasını, bilançoda kâr payı saptanmamışsa saptanmasını ve alacaklarını istemek hakkına sahiptir".*

Ortağın bu hakkı kullanabilmesi için *yönetici ortakların, şirketin faaliyet dönemi sonunda, ticari defterlere ilişkin hükümleri uyarınca (TTK m. 64-88) uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalaması ve ortaklar kurulunun onayına sunması* gerekmektedir; finansal tablolar ortakların çoğunluğunun onayı ile kesinleşir (TTK m.227/1).

bb) Kâr ve Zararın Paylaştırılması

Kanun koyucu, zarar payı ile ilgili olarak özel bir hüküm getirmiş; "*ortaklar oybirliği ile karar almadıkça hiçbir ortak, sermayesinden eksilen kısmı tamamlamaya zorlanamaz*" denilmiştir. Bu hâlde sermayenin zararla eksilen kısmı, aksine karar yoksa, gerçekleşecek kâr ile kapatılacaktır (TTK m.229).

Zararla ilgili bu hüküm saklı kalmak kaydıyla ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler.

aaa) Kâr ve Zararın Sözleşme Hükümlerine veya Karara Göre Paylaştırılması

Kollektif şirket sözleşmesinde, kâr ve zarara katılma hususunda bir düzenleme varsa ortakların kâr ve zarara katılması bu hükümler uyarınca yapılır. Sözleşmede sadece kâr payı belirlenmişse zarar payı, kâr payına; sadece zarar payı belirlenmişse kâr payı, zarar payına göre belirlenir. Sözleşmede kâr ve zarara katılma hususunda bir düzenleme yoksa ortaklar, sonradan alacakları bir kararla da kâr ve zarardan kendilerine düşen payı belirleyebilirler.

bbb) Kâr ve Zararın Paylaştırıcı Tarafından Paylaştırılması

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla belirleyebileceği gibi; kâr ve zarardan kendilerine düşen payı belirlemesi için içlerinden birini veya bir üçüncü kişiyi sözleşmeyle veya sonradan alacakları bir kararla tayin edebilirler.

ccc) Kanun Gereğince Paylaşma

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesi hakkında şirket sözleşmesinde bir hüküm yoksa ve sonradan bir karar alamamış ve bir paylaştırıcı da seçememişse; TTK m.227/3'den hareketle, getirilen sermayenin türü, niteliği ve miktarı nazara alınmadan, kâr ve zarar ortaklar arasında eşit olarak taksim edilir.

cc) Kâr ve Zararın Paylaştırılmasına İtiraz

Finansal tabloların onaylandığı toplantıda *kârın dağıtımı* da karara bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması halinde, kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler (TTK m.227/1).

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakmışlarsa; bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Kararın hakkaniyete aykırı olduğunu iddia eden ortak; söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde dava açmalıdır. Üç ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer.

c) Tasfiye Payı/Ayrılma Payı

Şirket sona ermekle, (tasfiyesiz sona erme hâlleri hariç) tasfiye sürecine girer. Bu süreçte öncelikle dış tasfiye yapılacak; borçlar ödenecek; alacaklar tahsil edilecek ve iç tasfiyeye geçilecektir. Bu süreç, tasfiye sonucu ortaya çıkacak net varlığı tespite yöneliktir. Tasfiye sonucunda belirlenen şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılacaktır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde, dağıtma para olarak yapılır (TTK m.300). Kollektif şirket ortaklarının, dağıtılacak bu net varlığına iştirak hakkı vardır. Belirtmek gerekir ki tasfiye payına iştirak hakkı şarta bağlı bir mali talep hakkıdır; şirketin tasfiyesi tamamlanmadan istenemez.

Şirketin tasfiye sürecine girmediği, faaliyetine devam ettiği hâllerde, ortaklardan biri şirketten çıkabilir veya çıkarılabilir. Bu durumda, çıkan veya çıkarılan ortağa tasfiye payı yerine ayrılma payının verilmesi gerekir. Ayrılma payı, ayrılma tarihine en yakın olan bir tarihte belirlenecek bilançoya dayanarak, sanal olarak yapılacak tasfiyeye göre belirlenir. Ayrılma payı da şarta bağlı bir mali talep hakkıdır; ortak şirketten çıkmadığı veya çıkarılmadığı müddetçe istenemez.

Tasfiye payının tespiti, şirket sözleşmesine göre yapılır; şirketin, tasfiyeye göre net varlığı tespit edildikten sonra tasfiye payı talep edilebilir. Tasfiye payında öncelikle, ortakların koymuş oldukları sermaye payı kendilerine verilir. Ortak sermaye payı olarak bir malın kullanma hakkını devretmişse kullanma hakkını devrettiği mal iade edilir ve fakat kural olarak kullanma hakkı karşılığı olarak bir şey verilmez. Sermaye payları iade edildikten sonra hâlâ bir şey kalmışsa bu kâr olarak nitelendirilir ve kârın paylaştırılması hükümlerine göre dağıtılır.

d) Ücret-Faiz İsteme ve Masrafı Talep Hakkı

Ortaklar, şahsi emeklerinden dolayı, şirketten ayrıca tazminat veya ücret talep edemezler; şahsi emeklerinden dolayı ücret isteyebilmeleri için, şirket sözleşmesinde hüküm bulunması gerekir (TTK m.132, 228/1). Bununla birlikte, ortağın ifa ettiği hizmet, şirket sözleşmesinde ortaklara tahmil edilen görevlerden değilse; ispat edilmek kaydıyla, hizmet, vekalet veya istisna akdi hükümlerine göre, üçüncü bir şahıs gibi ücret istenebilir. Şirketin iflası hâlinde ortaklar, hak ettiği ücretler için herhangi bir alacaklı gibi masaya girebilirler (TTK m.241).

Kollektif şirketlerde, ortaklar tarafından getirilen sermayeye faiz verilmesi, sözleşme ile kararlaştırılabilir (TTK m.132). Bu hâlde faizin istenebilmesi, şirketin kâr etmesine bağlı da değildir. Gerek ücret gerek faiz talep hakkı, TTK m.228 uyarınca emredici mahiyettedir.

Şirketin yönetimi için yapılan harcamalar, şirket tarafından ödenir. Şirket yöneticileri, ve hatta yönetici olmamasına karşın şirketin işlerini yapan ortak, şirketin işlerini görürken, kendi şahsi malvarlığından harcama yapmışsa TBK m.627'ye kıyasen, bu masrafların da şirket tarafından ödenmesi gerekir.

Ortak, şirketin faaliyeti esnasında, şirkete ödünç olarak bir miktar para vermişse şirkete ödünç olarak verdiği parayı ve kararlaştırılmışsa faizini de isteyebilir (TTK m.228).

2) Şahsi Nitelikteki İlişkiler

Şahsi nitelikteki ilişkiler, şirketin yönetimi, denetim ve rekabet yasağı başlıkları altında incelenecektir.

a) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkı

Kollektif şirketin, işletme amacını gerçekleştirmesi; ortakların şirket adına hareket etmesine bağlıdır. Kollektif şirketin üçüncü şahıslarla olan ilişkisi, kollektif şirketin kanuni temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirilir. Ancak, temsilcilerin üçüncü şahıslarla yapacakları muameleler öncesi; kollektif şirket tüzel kişiliği bünyesi içinde, yani ortaklar arasında, şirket amacının gerçekleştirilmesine yönelik bazı faaliyetlerin icrası gerekir. Temsilcilerin yaptıkları her hukuki muamele bir karara dayanmalıdır; bu karar, iç ilişkide yönetim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan, Türk Ticaret Kanununun "*şirketin yönetimi*" (TTK m.218-223), hukuken ve mahiyet itibarıyla temsilden (TTK m.233) ve genel olarak idaresinden farklıdır.

aa) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Hukuki Mahiyeti

TTK m.218/1'de, "*Ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir*" (TTK m.218/1) denilmek suretiyle; şirket yönetimi ile ilgili esaslar tespit edilmiştir. Buna göre şirket yönetiminde, ferdi yönetim esastır ve şirketin yönetimi, kollektif şirket ortakları için hem hak hem görevdir.

Şirket yönetiminin, kollektif şirket ortakları için hem hak hem görev olduğu hükme bağlanmasına karşın; TTK'de yönetici ortaklar ile şirket

ve diğer ortaklar arasındaki ilişkilerin hukuki mahiyetine temas edilmemiştir. Bilindiği üzere adi şirketlerde, adi şirketlere ilişkin düzenlemelerde veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, yönetici ortaklar ile diğer ortaklar arasındaki ilişkiler, vekâlet sözleşmesine ilişkin hükümlere tâbi tutulmuştur (TBK m.630).

Kollektif şirketlerde yönetim hakkının, konu itibarıyla; vekâlete nispetle daha geniş olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, kollektif şirket yöneticilerinin, şirketin amacını ve konusunu elde etmek için yapılması gereken olağan işlem ve işleri, *organ sıfatıyla* yaptığının; vekalette olduğu gibi, müvekkilinden talimat almasının gerekmediğinin kabulü gerekir. Hâl böyle olmakla birlikte, kollektif şirketin mahiyetine aykırı olmadığı müddetçe; vekâletle ilgili hükümlerin, yöneticiler ile kollektif şirket arasındaki ilişkiler için de geçerli olduğu ifade edilebilir.

Yönetim yetkisini haiz ortak, diğer ortakların itirazına maruz kalmadıkça; olağan işleri kendi görüşüne göre ve aksi belirtilmediği sürece, diğer yönetici ortakların katılımı olmaksızın bağımsız olarak yapar. Şirket sözleşmesinde ayrıca hüküm varsa, usulünce alınan kararla, yönetici ortağa talimat verilebileceği kabul edilmelidir. Bununla birlikte, yönetim hakkı sözleşme ile bir ortağa verilmişse; diğer ortakların itiraz hakkının bulunmadığı da unutulmamalıdır (TTK m.222).

bb) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kapsamı

TTK m.223'de yönetim hakkının kapsamının belirlenmesinde, olağan ve olağanüstü işler ayrımı yapılmış; yönetim hakkının olağan işlerle sınırlı olduğu ifade edilmiştir. Buna göre, yönetim hakkının kapsamı, şirketin amacını ve konusunu elde etmek için yapılması gereken olağan işlem ve işlerdir. Şirketi yönetenler, şirket menfaatine uygun gördükleri işlerde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak şartıyla, sulh, feragat ve kabul ile tahkime de yetkilidirler.

Kanun koyucu, olağan işler dışındaki işleri, olağanüstü iş olarak kabul ederek; sınırlı sayıda olmamak üzere olağanüstü işlerin neler olabileceğine ilişkin bazı örnekler vermiştir. Kanun koyucunun kabulüne göre; bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticari mümessil tayin etmek ve şirket konusuna girmiyorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticari işletme rehni kurmak olağanüstü işlerden sayılmıştır. Olağan iş ve işlemler dışında kalan hususlarda ortakların oybirliği şarttır.

cc) Yönetim Hakkının Kazanılması

TTK m.218 gereğince, *"ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir"*.

Hükümden de anlaşılacağı üzere, yönetici sıfatının kazanılmasında üç usul öngörülmüştür. Bunlardan birincisi, *ortaklardan her birinin, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haiz* olduğuna ilişkin; yöneticilik sıfatının *kanun gereği* kazanılmasıdır. Bu hâlde her ortak, diğerinin katılımı olmaksızın şirketi yönetmeye yetkilidir; bir diğer söyleyişle, ferdi yönetim esastır.

Yönetici sıfatının kazanılmasının ikinci hali, yöneticilik sıfatının *sözleşme gereği* kazanılmasıdır. Ortaklar sözleşmeyle, şirketin yönetim hakkını, ortaklardan birine veya birkaçına bırakabilir; ortak olmayanlar yönetici olamaz. Ortak olmayanlara yönetim hakkı, ticari temsilci veya ticari vekil sıfatıyla verilebilir; ancak, ticari temsilci veya ticari vekil, TTK m.218 anlamında yönetici sıfatını kazanamaz.

Yönetici sıfatının kazanılması, ortakların kararı ile de olabilir; buna yöneticilik sıfatının *kararla* kazanılması denilmektedir. Ortakların kararıyla yönetici tayini için, TTK m.226 uyarınca bir karar alınması gerekir.

Şirket islerinin yönetiminin, ortakların tümüne veya birden ziyade kişiye verilmesi hâlinde, bunların her biri yalnız başına yönetim hak ve görevini haizdir. Ancak şirketi yönetmekle yükümlü olan ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ileri sürebilir. Bu durumda, işin yapılması yönetim hak ve görevini haiz diğer ortakların çoğunluğunun kararına bağlıdır (TTK m.221/1).

dd) Yönetim Hakkının Kaybedilmesi ve Sınırlandırılması

Ortağa verilen yöneticilik hakkı, kural olarak şirketin sona ermesine kadar devam eder (TTK m.251). Kural böyle olmakla birlikte, yöneticilik sıfatı, yöneticinin ölümü, iflâsı veya ehliyetin kaybı gibi nedenlerle *kendiliğinden sona* erer. Yönetim hakkının kendiliğinden sona ermesi dışında; ortağın yönetimdeki ihmali ve yetersizliği gibi sebeplerle, şirket sona ermeden, yöneticilik sıfatı, iradi olarak da geri alınabilir veya sınırlandırılabilir yahut yönetici istifa da edebilir. Yöneticilik sıfatının ölüm, iflâs veya ehliyetin kaybı gibi sebeplerle *kendiliğinden sona* ereceği unutulmadan; yönetim hakkının diğer ortaklar tarafından

geri alınması ve sınırlandırılmasının, yönetici sıfatının kazanılmasına bağlı olarak ayrı ayrı incelenmesi gerekir.

aaa) Sözleşmeyle Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması

Şirketi yönetme hakkı, *sözleşmeyle* verilmişse, yönetim hakkının geri alınması veya sınırlandırılması sözleşme değişikliği mahiyetinde olduğu için; TTK m.226/2 gereği oybirliği ile karar alınmalıdır. Oylamaya görevden alınacak ortağın da dâhil olduğu düşünülecek olursa; oybirliği sağlanamadığı durumlarda, *haklı sebeplere* istinaden mahkemeye gidilebilir. Haklı sebeplerin varlığı hâlinde, ortaklardan birinin talebi üzerine mahkeme kararıyla yönetim hakkı sınırlandırılabilir yahut geri alınabilir.

Yönetim hakkının geri alınması veya sınırlandırılması ile ilgili olarak haklı sebep kavramına yer vermeyen kanun koyucu; haklı sebebe, kollektif şirketin sona ermesi münasebetiyle temas etmiştir. TTK m.245'te ***haklı sebep***, *"şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasıdır"* şeklinde ifade edilmiştir. Hükmün, yöneticinin azli bakımından değerlendirilmesinde; yönetici ortağın *"şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması"*, *"kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi"*, *"kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması"*, *"uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi"* gibi hâller haklı sebep olarak nitelendirilebilir.

Yönetim hakkının geri alınması veya sınırlandırılması ile ilgili mahkeme kararı, inşai mahiyettedir; yönetim hakkı, mahkeme kararıyla geri alınmış veya sınırlandırılmış olur.

bbb) Kararla Verilen Yönetim Hakkının Geri Alınması veya Sınırlandırılması

Yönetici kararla tayin edilmişse tayin için aranan çoğunluk kararıyla, yönetici azledilebilir veya yetkileri sınırlandırılabilir. Ortaklar kanun gereği yönetici sıfatını kazanmışsa yönetim yetkisinin çoğunluk kararıyla geri alınması mümkündür. Çoğunluk sağlanamadığında, ortaklardan biri, haklı sebebe dayanarak yönetim hakkının sınırlandırılması yahut geri alınması için mahkemeye başvurabilir.

ee) Kollektif Şirketlerde Yönetim Hakkının Kullanılması

aaa) Yönetim Hakkının Kullanılması Usulü

"Şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, bunların her biri yalnız başına yönetim hak ve görevini haizdir" (TTK m.221/1) hükmünden de anlaşılacağı üzere, kollektif şirketlerde yönetim hakkının diğer ortakların katılımı olmaksızın kullanılması; diğer bir söyleyişle ferdi yönetim esası benimsenmiştir.

Şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, bunların her biri yalnız basına yönetim hak ve görevini haiz olmasına karşın; şirketi yönetmekle yükümlü olan ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ileri sürerlerse, yönetim hak ve görevini haiz diğer ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler (TTK m.221/1).

Kollektif şirkette, ferdi yönetim esas olmakla birlikte; şirket sözleşmesinde şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş ortakların birlikte hareket etmeleri kabul edilebilir. Bu hâlde, birlikte hareket etmesi kararlaştırılan yönetici ortaklar, gecikmesinde tehlike görülen hâller istisna olmak üzere, her işte anlaşmalı; birlikte hareket etmelidir. Anlaşamadıkları takdirde durum ortaklar kuruluna götürülür ve bu kurulca verilecek karara göre hareket edilir (TTK m.221/2) .

bbb) İtiraz

Şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, bunların her biri *olağan işlerde*, yalnız başına yönetim hak ve görevini haizdir. Bununla beraber, *şirketi yönetmekle yükümlü olan ortaklardan bazısı*, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ileri sürerlerse, yönetim hak ve görevini haiz diğer ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler (TTK m.221/1).

Yönetici olmayan ortakların, olağan işlerde itiraz hakkı bulunmamaktadır. Buna karşın, olağanüstü işlerde kural olarak bütün ortaklar yönetim hakkını haiz olduğu için; olağan işler bakımından yönetim hakkı bulunmayan ortağın, olağanüstü işler bakımından itiraz hakkının bulunduğu kabul edilmelidir.

Yönetim şirket sözleşmesiyle sadece bir ortağa verilmişse, diğer ortakların yönetim hakkı bulunmadığından; bu ortak, diğer ortaklar itiraz etseler ve karşı çıksalar bile, hileye dayalı olmamak şartıyla, şirketin

yönetimi için gereken işlemleri yapabilir (TTK m.222) . Kanun koyucunun kabulüyle, yönetim şirket sözleşmesiyle sadece bir ortağa verilmişse diğer ortaklar, hileye dayandığı gerekçesiyle, yapılacak işlere itiraz edebilir.

TTK'de itiraz herhangi bir şekle tâbi kılınmamış; varması gerekli bir beyan olarak nitelendirilmiş ve muamelenin icrasına kadar yapılabileceği, muamelenin icrasından sonra itiraz hakkının düşeceği kabul edilmiştir. Belirtmek gerekir ki itiraz, sadece iç ilişkide hüküm ifade eder. Yönetim hakkını haiz ortak, itiraza veya çoğunluğun kararına rağmen muameleyi icra ederse; temsil yetkisi sınırları içinde icra ettiği bu muamele şirketi bağlar.

b) Kollektif Şirketlerde Denetim ve Bilgi Edinme Hakkı

Kollektif şirket ortaklarının sorumluluğunun şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmadığını nazara alan kanun koyucu; ortakların denetleme ve bilgi edinme hakkını kollektif şirketlerde geniş tutmuş ve bu hakkın sınırlandırılmasının geçersiz olduğunu hükme bağlamıştır (TTK m.225).

Kollektif şirkette bir ortak yönetim hakkını ve görevini haiz olmasa da şirket işlerinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi için şirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek hakkını haizdir.

TTK m.225'de, denetleme ve bilgi edinme hakkı, kollektif şirketin bütün ortaklarına tanınmış; yönetim hakkını ve görevini haiz olmasa da her ortağın, denetleme ve bilgi edinme hakkını kullanabileceği kabul edilmiştir. Denetleme ve bilgi edinme hakkının kollektif şirket ortağı tarafından, kural olarak şahsen kullanılması gerekir. Ortaklık sıfatına bağlı olarak yönetici ortağa, şirket tasfiye hâlindeyse tasfiye memuruna (TTK m. 301) yöneltilerek kullanılabilecek bu hak; diğer ortakların muvafakati olmadan üçüncü bir şahsa devredilemez. Bununla birlikte, denetim hakkının kullanılması özel uzmanlığı gerektiriyorsa; bilhassa görevi gereği sır saklamakla yükümlü olan avukat, mali müşavir veya bir denetim kuruluşundan yardım almasının mümkün olduğu kabul edilmelidir.

Denetim hakkı, *ortaklık sıfatına bağlı bir haktır*; bu sıfatın ortadan kalkmasıyla sona erer. Bu nedenle, kollektif şirket ortağının mirasçıları denetleme hakkını kullanamaz. Ortağın mirasçıları, ayrılma payının

doğru hesaplanmadığı iddiasıyla kollektif şirketin defterlerinin delil olarak kullanılmasını isteyebilirler.

Bilgi edinme hakkı da ortaklık sıfatına bağlıdır. Ancak kanun koyucu, ortaklık sıfatı sona ermesine karşın; çıkarılan veya çıkan ortağın, her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içinde bitirilen işlerin hesaplarını ve devam etmekte olan işlemlerin o tarihteki durumu hakkında bilgi verilmesinin istenebileceğini kabul etmiştir (TTK m.263/2).

c) Kollektif Şirketlerde Rekabet Yasağı

Kollektif şirket sözleşmesi, ortakların müşterek bir amaç etrafında birleşmesine ve bu amacın müşterek gayret ve faaliyetle gerçekleşmesine yöneliktir. Bu nedenle ortakların, şirketin amacının gerçekleşmesini engelleyecek davranışlardan kaçınması; sadakat yükümüne uygun davranması gerekir.

Bu esastan hareket eden kanun koyucu, ortakların, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi, diğer ortakların izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak giremeyeceğini hükme bağlamıştır (TTK m.230/1).

aa) Rekabet Yasağının Hukuki Mahiyeti

TTK m.231/1'deki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, rekabet yasağı *emredici mahiyette değildir*. Ortakların, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi, kendi veya başkası hesabına yapmasına veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak girmesine diğer ortaklar izin verebilir.

Diğer ortakların vereceği bu izin, bir karara müstenit olabileceği gibi; örtülü (zımni) de olabilir. Bu bağlamda, yeni kurulan bir şirkete giren ortağın, daha önce kurulmuş diğer bir şirketin de sorumluluğu sınırlandırılmamış ortaklarından olduğunu diğer ortaklar bildikleri hâlde önceki şirketten ilişiğinin kesilmesini aralarında açıkça kararlaştırmamışlarsa, bu durumu kabul ettikleri varsayılır (TTK m.230/2). Bunun gibi, ortağın rekabet yasağına aykırı davrandığı diğer ortaklar tarafından bilinmesine karşın; sessiz kalınmışsa, izin verilmiş sayılır.

bb) Rekabet Yasağının Kapsamı

Kollektif şirketlerde rekabet yasağı, adi şirketler için kabul edilen rekabet yasağından farklı olarak hükme bağlanmıştır. Adi şirketlerde

rekabet yasağı, *ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işler* olarak belirlenmişken; kollektif şirketlerde rekabet yasağı, *ortakların, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işlerle* sınırlandırılmıştır. Bir diğer ifadeyle, adi şirketlerde rekabet yasağından söz edebilmek için, muamelenin *ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici* olduğunun ispatı istenirken; kollektif şirketlerde, *ortakların, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işleri* yapması yeterli görülerek, yapılan bu işlerin *ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici* olduğunun ispat edilmesi şartı aranmamıştır.

TTK m.230'da, rekabet yasağı kapsamına giren işlerin, kendi veya başkası hesabına yapılmasının yasak olduğu hükme bağlandıktan sonra; ortakların, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak girmesinin de yasak kapsamında olduğu ifade edilmiştir. Kanaatimizce *ortakların, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak olarak girmesinin yasaklanması* dar yorumlanmamalı; yönetimdeki etki derecesi nazara alınarak, kollektif şirket ortağının mesela limited şirkette müdür de olamayacağı kabul edilmelidir.

cc) Rekabet Yasağının Yaptırımı

Rekabet yasağına aykırı davranışın yaptırımları, TTK m.231'de hükme bağlanmış; şirkete birini veya diğerini seçme hususunda serbesti tanınmıştır.

Buna göre, bir ortak rekabet yasağına aykırı hareket ederse; şirket, bu ortaktan tazminat istemekte veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış saymakta, üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını istemekte serbesttir (TTK m.231/1). Bu seçeneklerden birine, diğer ortaklar çoğunlukla karar verir (TTK m.231/2).

Diğer ortaklar, tazminat veya tazminat yerine bu ortağın kendi adına yaptığı işleri şirket adına yapılmış sayılmasını, üçüncü kişilerin hesabına yapmış olduğu işlerden doğan menfaatlerin şirkete bırakılmasını isteme yanında; bu istemleri saklı kalmak üzere, şirketin feshini veya haklı sebeple ortağın şirketten çıkarılmasını da talep edebilirler (TTK m.231/3).

dd) Zamanaşımı

Kanun koyucu TTK m.231'de düzenlenen hakların kullanımı için gayet kısa zamanaşımı süreleri öngörmüş; TTK m.231'deki bu hakların, rekabet yasağına aykırı işlemin yapıldığının veya ortağın diğer bir şirkete girdiğinin öğrenildiği tarihten başlayarak *üç ay* ve her hâlde işlemin yapıldığı tarihten itibaren *bir yıl* sonra zamanaşımına uğrayacağını kabul etmiştir (TTK m.231/2).

C) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE DIŞ İLİŞKİ

Kollektif şirketlerde dış ilişki başlığı altında, şirketin ve şirket ortaklarının üçüncü şahıslarla ilişkileri; bir diğer ifadeyle *kollektif şirketlerde temsil* ve *kollektif şirketin ve ortaklarının şirket borç ve taahhütlerinden sorumluluğuna* temas edilecektir.

1) Kollektif Şirketlerin Temsili

Kollektif şirket, diğer ticaret şirketleri gibi, tüzel kişiliği haizdir (TTK m.125/1) ve cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildir (TTK m.125/2). Kollektif şirketler kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini kazanırlar (TMK m.49) ve iradesini, organları aracılığıyla açıklarlar (TMK m.50).

Kollektif şirketlerde temsilden bahsedebilmek için, şirketin ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Tescil ile tüzel kişilik kazanan kollektif şirket; *temsilcileri vasıtasıyla* yapılan hukukî işlemler ve diğer bütün fiillerle borç altına girer.

Kollektif şirketin temsilcileri, temsil yetkisini kanun veya sözleme hükümlerine göre kazanan şirket ortaklarıdır; temsil yetkisi, ortaklar için hem hak hem görev niteliğindedir. Kollektif şirketin ticari işletmeyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında yapmak maksadıyla yetki verdiği ticari temsilcinin (TBK m. 547) aksine; temsil yetkisini kanun veya sözleme hükümlerine göre kazanan ortaklar, kollektif şirketin organı vasfındadır.

a) Kollektif Şirketlerde Temsilci Sıfatının Kazanılması

6762 sayılı evvelki Türk Ticaret Kanununun *"Şirketi ortaklara ve üçüncü şahıslara karşı temsil salahiyet ve vazifesi, tescil ve ilân edilen mukavelede aksine hüküm olmadıkça, 160'ncı madde gereğince şirket*

işlerini idare hak ve vazifesini haiz olanlara aittir" şeklindeki 175'inci maddesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa alınmamıştır[151].

6762 sayılı TTK m.175'in, 6102 sayılı TTK'ye alınmaması, gerekçesi ile birlikte değerlendirildiğinde, kollektif şirketlerde idarecilik sıfatının kazanılmasında, *sözleşme serbestisinin geçerli olduğu*; temsilcilik sıfatının kanun gereği kazanılmasının söz konusu olamayacağı kabul edilmelidir.

TTK m.232/1'de, *şirketi temsil yetkisini haiz olan kimselerden* söz edilmiş; bu kimselerin kollektif şirket ortağı olması gereğinden bahsedilmemiştir. Bu nedenle, kollektif şirketin temsilcisinin, *ortak olmayan bir üçüncü kişi* olması da mümkündür. Kollektif şirkete temsilci olarak bir üçüncü kişinin getirilmesi hâlinde; bu üçüncü kişi, ticari temsilci veya ticari vekil değil; kollektif şirketin temsilcisi, diğer bir ifadeyle organı sıfatındadır.

TTK m.213'de, şirket sözleşmesinde bulunması şart olan asgari kayıtlar öngörülürken; *"şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili olduklarının"* (TTK m. 213/1-f) bulunması gereğinden bahsedildiği için; kollektif şirketin ilk temsilcilerinin, kollektif şirket kuruluş sözleşmesinde gösterilmesi gerekir.

b) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kaldırılması

Kollektif şirket sözleşmesiyle kendisine temsil yetkisi verilen kişinin, şirketin devamı süresince temsilci sıfatını haiz olduğundan hareket eden kanun koyucu, TTK m.235'de, "*Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu üzerine, mahkemece kaldırılabilir*" demek suretiyle, kollektif şirketlerde temsil yetkisinin sadece haklı sebeplere istinaden mahkeme kararıyla kaldırılabileceğini ifade etmiş; ortakların iradesiyle temsil yetkisinin kaldırılıp kaldırılamayacağı hususuna değinmemiştir.

---

[151] Gerekçede bu husus, *"Tasarının bu maddesi, 6762 sayılı Kanunun 176 nci maddesinin tekrarıdır. Buna karşılık 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi Tasarıya alınmamıştır. Çünkü, 6762 sayılı Kanunun 175 inci maddesi, aynı Kanunun 160 ncı maddesine gönderme yaparak hem 6762 sayılı Kanunun 155 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi hükmü ile çelişiyor, hem de temsil kurumuna uymuyordu"* şeklinde ifade edilmiştir.

Kollektif şirketlerde temsil yetkisinin ortakların iradesiyle kaldırılmasını engelleyen bir hüküm TTK'de yer almamakla birlikte; temsil yetkisinin ortakların iradesiyle kaldırılması ihtimaline yer verilmemesi gerekir. Zira temsilcinin şirket sözleşmesinde belirlenmesi, şirket sözleşmesinin asgari unsurudur ve *şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların oybirliğiyle alınması* (TTK m.226/2) gerekmektedir. Temsil yetkisinin kaldırılabilmesi için sözleşme değişikliğine gidilmesi ve sözleşme değişikliğinde bütün ortakların birlikte hareket etmesi gereği karşısında; temsil yetkisi kaldırılacak ortağın, temsil yetkisinin kaldırılmasına muvafakat etmesi gerekmektedir.

Temsil yetkisi kaldırılacak ortağın, buna muvafakat etmemesi durumunda, ortaklardan her biri; *haklı sebeplere* istinaden mahkemeye başvurarak, temsil yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılmasını isteyebilecektir (TTK m.235).

Temsil yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılmasını gerektirici *haklı sebeplere* ilişkin bir düzenleme, TTK'de bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kollektif şirketin sona ermesinde hükme bağlanan haklı sebeplerin (TTK m.245), temsil yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılmasını gerektirici *haklı sebepler* olarak kabul edilmesi mümkündür. Buna göre, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere; yönetici ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması, kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi, gibi hâller haklı sebep olarak kabul edilmelidir.

Temsil yetkisinin mahkemece haklı sebeplere istinaden kaldırılması hâlinde, mahkeme ortakların yerine geçerek temsilci atayamaz; sadece, gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde temsil yetkisini ihtiyati tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir (TTK m.235/1).

Temsil yetkisinin mahkemece kaldırılması hâlinde, şirket ortaklarının sözleşme değişikliğine gitmesi; temsil yetkisi kaldırılan ortağın yerine yeni temsilci belirlemesi gerekecektir. *Şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların oybirliği ile alınması* gereği nazara alındığında; oybirliğinin sağlanmasının mümkün olamadığı durumlarda, temsil yetkisi kaldırılan ortağın haricindeki diğer ortakların kararının, temsilci tayini için yeterli olacağının kabulü

uygun olur. Aksi takdirde, şirket organsız kalabileceğinden, şirketin feshi gündeme gelebilir.

c) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Geri Alınması

Kollektif şirketlerde temsil yetkisinin geri alınmasına ilişkin bir düzenleme TTK'de bulunmamaktadır.

Temsilcinin şirket sözleşmesinde belirlenmesinin, şirket sözleşmesinin asgari unsuru olduğu ve *şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların oybirliğiyle alınması* (TTK m. 226/2) gerektiği nazara alındığında, temsil yetkisinin geri alınması için bütün ortakların birlikte hareket etmesi ve sözleşme değişikliğine gidilmesi gerekir. Temsil yetkisi kaldırılacak olan ortağın bu karara katılması ihtimali göz ardı edildiğinde; temsil yetkisinin ortakların kararıyla kaldırılmasının söz konusu olamayacağı ifade edilebilir. Bu durumda diğer ortakların, temsil yetkisinin haklı sebeplere istinaden mahkeme kararıyla kaldırılması için mahkemeye başvurmaları gerekir.

d) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Kapsamı

Kollektif şirketlerin ehliyeti kısmında da ifade edildiği üzere, ticaret şirketlerinin ehliyeti ile ilgili olarak, *ultra vires* bir diğer söyleyişle "*amaçla sınırlı ehliyet*" ilkesi kaldırılmış ve ticaret şirketlerinin ehliyeti TMK m.48'e tâbi tutulmuştur. Kanun koyucunun bu kabulüne göre, kollektif şirketlerin hak ehliyetinin sınırı; sadece cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı olanlara ilişkindir; bu sınırlama haricinde şirket, bütün haklara ve borçlara ehildir. Kollektif şirketler, hak ehliyeti dâhilindeki tüm haklarını, temsilcileri (organları) vasıtasıyla kullanabilir; organlar, hukukî işlem ve diğer bütün fiilleriyle kollektif şirketi borç altına sokarlar (TMK m.50/2).

Buna göre, kollektif şirket temsilcilerinin, bu ehliyet sınırları içinde kollektif şirketi temsil edebilecekleri kabul edilmekte; amaç dışı işlerin kollektif şirketi bağlamayacağından söz edilemeyeceği ifade edilmektedir. Kollektif şirketlerin temsil yetkisinin kapsamı TTK m.233/1'de belirlenmiş ve şirketi temsile yetkili olanların, şirketin ehliyet sınırları dâhilinde her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapabileceği ve şirketin unvanını kullanabileceği hükme bağlanarak; bu yetkiyi sınırlayan her şartın, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyeceği kabul edilmiştir.

Hâl böyle olmasına karşın; TTK m.213/1-d'de, esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun belirtilmesi zorunluluğu ve *"şirketi temsile yetkili olan kimse, şirketin işletme konusuna giren her türlü işi ve hukuki işlemleri şirket adına yapmak ve şirketin unvanını kullanmak yetkisine sahiptir"* (TTK m.233) hükmü muhafaza edilmiş; kollektif şirket tüzel kişiliğinin ehliyetinin, konu ile sınırlı olduğu izlenimi yaratılmıştır.

Ancak kanaatimizce bahsi geçen hükümler, şirketin hak ehliyeti ve buna bağlı olarak fiil ehliyeti ile değil; temsilcilerin konu dışı işlemlerinden dolayı, gerek şirkete gerek ortaklarına karşı sorumluluğunun tespiti bakımından, diğer bir anlatımla, sorumluluk hukukuyla ilgilidir.

e) Kollektif Şirketlerde Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

Kollektif şirketin, TMK m.48 çerçevesindeki ehliyet sınırları içinde temsilciler tarafından temsil edileceği kabul edilmiştir. Temsilcilerin temsil yetkisinin sınırlandırılması ve bu bağlamda temsil yetkisinin sadece şube işlerine hasredilmesi de mümkün görülmemiştir.

Temsilcilerin temsil yetkisinin dış münasebette konu, miktar veya yer olarak sınırlandırılması mümkün olmamakla beraber; temsil yetkisinin *kişi olarak sınırlandırılması*, şirket sözleşmesinde birlikte temsil yetkisinin kabul edilmesiyle mümkündür. Bu husus TTK m.231/1-f'de, *"Şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, bunların yalnız başına mı, yoksa birlikte mi imza koymaya yetkili oldukları"* kaydının şirket sözleşmesinde zorunlu olarak yer alması hakkındaki düzenlemeden başka; TTK m.233/2'deki, *"şirket sözleşmesinin tescil ve ilanı gerekli hükümlerine göre şirketin bağlanabilmesi için birlikte imza şart kılınmışsa, bu şart, üçüncü kişilere karşı da geçerlidir"* hükümlerinden anlaşılmaktadır.

Şirket sözleşmesinde birden fazla temsilci olduğu belirtilmiş ve bunların birlikte hareket etmeleri hükme bağlanarak *tescil ve ilân edilmişse*; temsilcilerin tek başına yaptığı işlemler tüzel kişiliği bağlamaz. Birlikte temsilde, tüzel kişiliğin yapılan işlemle bağlı olabilmesi için yapılan işin, birlikte yapılması gerekir.

f) Temsil Yetkisinin Hükümleri

"Şirketi temsil yetkisini haiz olan kimseler tarafından, açık veya zımni olarak şirket adına yapılmış olan işlemlerden dolayı, şirket alacaklı ve borçlu olur. Bir ortağın şirkete ait görevlerini yerine getirirken işlediği haksız fiillerden şirket de doğrudan doğruya sorumludur" (TTK m.234).

2) Kollektif Şirketin ve Ortaklarının Şirketin Borç ve Taahhütlerinden Dolayı Sorumluluğu

Kollektif şirketin "*borç ve taahhütleri*" (TTK m.236) şirketi temsile yetkili kimselerin, ehliyet sınırları içinde hukuki bir muamele ile tüzel kişiyi bağladıkları taahhütlerle; sebepsiz zenginleşme, başkası hesabına tasarruf, haksız fiiller gibi kanundan doğan ve tüzel kişiye izafe edilebilen borçlar ve kanunların tüzel kişilere yüklediği borçlar olarak nitelendirilmektedir.

a) Kollektif Şirket Tüzel Kişiliğinin Sorumluluğu

Kollektif şirketin bu *borç ve taahhütlerinin* muhatabı, kollektif şirket tüzel kişiliğidir. *Kollektif şirket tüzel kişiliği, bu borç ve taahhütler nedeniyle, sermayesiyle değil, bütün malvarlığı ile birinci dereceden sorumludur.* Şirket alacaklıları borcun ifasını şirketten talep ve ifa edilmemesi hâlinde şirket mallarına başvurabilir.

Kollektif şirketin bu borç ve taahhütlerine, *ortakların kişisel borçları dâhil değildir.* Kollektif şirket devam ettiği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu gereğince o ortağa düşen kâr payından ve şirket fesholunmuşsa tasfiye payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı, bilançonun düzenlenmesi sonucunda borçluya düşecek kâr ve tasfiye payı üzerine haciz koydurabilir (TTK m.133/1; m.249).

b) Ortakların Sorumluluğu

Kollektif şirketlerde şirket tüzel kişiliği yanında ortaklar da şirketin borç ve taahhütlerinden sorumlu tutulmuş; ortakların, şirket borç ve taahhütlerinden dolayı *müteselsilen ve bütün malları ile sorumlu olduğu kabul edilmiştir* (TTK m.211; m.236).

aa) Ortakların Sorumluluğunun Esasları

Kollektif şirket ortaklarının sorumluluğu, TTK m.236/1'de ifade edildiği üzere, esas itibarıyla *malvarlığı ile* sorumluluktur. *Ortaklar, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur.* Ortakların sorumluluğu, tüzel kişiye ait borcu malvarlığı ile ödemekten ibarettir. Bu bağlamdan olmak üzere, şirkete yeni giren ortağın da girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumlu olduğu unutulmamalıdır (TTK m.236/2). Bunun gibi, şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın, bu durumun tescil ve ilan edildiği tarihe kadar yapılan şirket işlemlerinden üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğu da ihmal edilmemelidir (TTK m.259/4).

Kollektif şirket ortaklarının sorumluluğu, esas itibarıyla *malvarlığı ile* sorumluluk olmasına karşın; bu sorumluluğun, aynı zamanda *şahsi sorumluluk* olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu sonuca, Türk Ticaret Kanununun 237'nci maddesinde, "*şirket borç ve taahhütlerinden dolayı birinci derecede şirket mesuldür*" denildikten sonra; "*ancak, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış ve şirket her hangi bir sebeple sona ermişse yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir*" düzenlemesinden ulaşılabilmektedir. Gerçekten de dava ikamesi ve icra takibi borcun ifasını dava veya takip yoluyla talebi de ihtiva ettiğinden, bu hüküm delaletiyle ifanın ortaklardan da istenebileceği, ortakların şirket borçlarından şahsen mesul oldukları neticesine varılabilir.

Türk Ticaret Kanununun 237'nci maddesinin birinci fıkrasında, alacaklıya ortakla birlikte şirket aleyhine dava hakkı da tanımış; gerek şirket gerek ortak aleyhine dava ikamesinin ancak şirketçe taahhüt edilen borcun ortak tarafından ifası istenebildiği takdirde mümkün olduğu kabul edilmiştir. TTK m.238 gereğince, yalnız şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı, şirket hakkındaki takip semeresiz kalmadıkça veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş olmadıkça ortaklar hakkında icra edilemez.

bb) Ortakların İkinci ve Birinci Dereceden Sorumluluğu

Türk Ticaret Kanununda kabul edilen sisteme göre, şirket borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu, *ikinci derecedendir.* Şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı *birinci derecede şirket sorumludur* (TTK m.237/1).

Ancak, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, sadece ortak veya ortakla birlikte şirket aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir (TTK m.237/1). Aynı şekilde, "*şirketin iflası, ortakların iflasını gerektirmez. Ancak, depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı, depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına karar verilmesini mahkemeden isteyebilir. Bu hakkını kullanmamış olan alacaklının, şirket masasından alacağını tamamen alamaması hâlinde ortakları iflas yoluyla da ayrıca takip hakkı saklıdır*" (TTK m.240/1).

Şirket alacaklısının icra veya iflâs yoluyla ortağa müracaat edebilmesi için; TTK'nin 237 ve 240'ıncı maddelerinde hükme bağlanmış hususların gerçekleşmiş olması gerekir. Bu hâllerin gerçekleşmesi durumunda, ortakların birinci dereceden sorumluluğundan bahsedilir.

Ortakların birinci dereceden sorumluluğunun doğması; "*şirkete karşı icra takibinin semeresiz kalması*", "*şirketin sona ermesi*", "*şirketin iflâsı*" hâlleri ile sınırlandırılmıştır. Ortaklar, birinci dereceden sorumluluğun şartlarının oluşmadığını def'i yoluyla ileri sürebilirler; hâkim, birinci dereceden sorumluluğun şartlarının oluşmadığını kendiliğinden nazara alamaz.

aaa) Şirkete Karşı İcra Takibinin Semeresiz Kalması

TTK m.237/1'de, *şirkete karşı icra takibinin kısmen dahi olsa semeresiz kalması,* ortağın birinci dereceden sorumluluğunun doğması için yeterli kabul edilmiş; bunun için, şirkete karşı icra takibinin semeresiz kaldığı hususunda bir aciz vesikası alınması gerektiğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

bbb) Şirketin Sona Ermesi

Kollektif şirket herhangi bir sebeple sona ermişse, ortaklara müracaat hakkı doğar. Müracaat hakkının doğması, yani ortaklara karşı dava ve talep engelinin kalkması, fesih veya infisahın tescil ve ilânına veya tasfiyenin sona ermesine bağlı değildir; şirketin hukuken feshedilmiş veya infisah etmiş sayılması kâfidir.

ccc) Şirketin İflâsı

Kural olarak, *şirketin iflâsı, ortakların iflâsını gerektirmez*. Ancak, depo kararına rağmen para yatırılmadığı takdirde alacaklı, depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına da tebliğini ve gereğini yerine getirmedikleri takdirde şirketle birlikte iflaslarına karar verilmesini mahkemeden isteyebilir (TTK m.240/1).

Buna göre, kollektif şirket iflas etmişse, alacaklı iki imkândan istifade edebilir. İsterse ortaklar aleyhine TTK m.237 gereğince dava açar ve icra takibinde bulunur; isterse iflâs masasının tasfiyesini bekler ve bu masadan alacağını tamamen alamadığı takdirde ortaklar aleyhine iflâs yoluyla takibe geçer (TTK m.240/1, c.3). Bu ihtimalde, alacaklı iflâs masasının sonucunu beklemeye mecburdur. Ortakların iflâs yoluyla takip edilebilmesi, şirketin iflâsına ve alacağın iflâs masasından tamamen alınamamış olması şartına bağlı tutulmuştur.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere kanun koyucu, üç halde alacaklılara ortakların da iflâsını isteme hakkı tanımıştır. Bunlardan birincisi, şirketin iflâs etmiş ve alacaklının alacağını iflâs masasından alamamış olmasıdır. İkinci hâl, iflas davası açılmış olup, şirket aleyhine depo kararı verilmiş ve bu karara rağmen ortaklar para yatırmamışsa, alacaklı; iflas davasında taraf olmamasına karşın, şirket aleyhine alınan depo kararının ortaklara veya içlerinden bazılarına tebliğini ve gereğinin yerine getirilmesini ve getirilmediği takdirde şirketle birlikte, ortakların iflâslarına hükmedilmesini isteyebilmesidir. Üçüncü hâl, şirket aleyhine alınmış olan mahkeme kararı üzerine çıkarılan icra emrinin şirket tarafından yerine getirilmemiş olmasıdır. Bu durumda alacaklı, evvelce takibe hacet kalmaksızın, şirketle birlikte ortakların veya bazılarının doğrudan doğruya iflâsını isteyebilir (İİK m.177/4).

VII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KARAR

Kollektif şirket ortakları, şirket işleri ve birbirleriyle olan ilişkilerinde iradelerini, karar oluşturmak amacıyla oy vermek suretiyle açıklarlar. Oy, ortakların bir teklifin leh veya aleyhinde karar oluşturmak veya bir kararın alınmasına engel olmak amacıyla yapılan bir irade açıklamasıdır. Kollektif şirketlerde karar, oy verme işlemine bağlıdır.

A) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE OY HAKKI

TTK m.226/1'de göre, *"her ortağın bir oy hakkını haiz"* olduğu ve bu esasa aykırı sözleşme hükümlerinin geçersiz kabul edildiği hükme bağlanmıştır.

Kollektif şirketlerde ortakların oy hakkı, mahiyeti itibarıyla bir hak görünümündedir; bir yükümlülük değildir. Bununla birlikte, TTK m.221/2'de hükme bağlandığı gibi bir yükümlülük hâlinde de ortaya çıkabilir.

Kollektif şirketlerde ortaklık sıfatı ortağın şahsına bağlı olduğundan oy hakkı da ortak tarafından kullanılır. Oy hakkının ortak tarafından kullanılması kuralına, TTK m.268/2'de bir istisna getirilmiş; tasfiye memurlarının atanmaları ve görevden alınmaları veya onlara verilecek talimatla ilgili kararlara katılma hakkı, bir ortağın iflasında iflas idaresine, ölümünde mirasçılara ve kısıtlanması durumunda kanuni temsilcisine bırakılmıştır.

Oy hakkı, ortağa ortaklık sıfatına bağlı olarak tanınan, vazgeçilemez veya sınırlandırılamaz bir hak olmasına karşın; kanun koyucu ortağı bazı hâllerde *oy hakkından yoksun* bırakmıştır. Bu hâlin hükme bağlandığı TTK m.221/1'de, *"şirket işlerinin yönetimi, ortakların tümüne veya birkaçına verilmiş ise, bunların her biri yalnız başına yönetim hak ve görevini haiz olmakla beraber; şirketi yönetmekle yükümlü olan ortaklardan bazısı, yapılacak bir işin, şirketin menfaatlerine uygun olmadığını ileri sürerlerse, yönetim hak ve görevini haiz diğer ortaklar, çoğunluk kararıyla o işi yapabilirler"* denilmiştir.

Yapılan işte ortağın kişisel menfaati olduğu zaman ortağın oy hakkından yoksun bırakılıp bırakılmayacağına ilişkin bir düzenleme kollektif şirkete ilişkin düzenlemelerde yer almamaktadır. Bu hâlde, anonim şirketler için kabul olunan TTK m.436 veya TMK m.82 hükmünün kıyas yoluyla uygulanması akla gelebilir.

Kollektif şirketlerde her ortak oyunu, diğer bütün ortaklara hitaben açıklar. Ortaklar, karar alınıncaya kadar, herhangi bir sebep göstermeden oyunu değiştirebileceği gibi, iradeyi bozan sebeplere dayanarak, verdiği oyun iptalini de isteyebilir.

B) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE KARAR

Karar, toplantı yetersayısının bulunduğu bir toplulukta; hukuken gerekli sayıda oyların aynı yönde toplanması ile doğan çok taraflı hukuki

bir işlemdir. TTK'de, kollektif şirketlerde kararın nasıl oluşacağına ve şekline ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. TTK m.64 vd. hükümleri ile *Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ*[152] hükümleri esas alındığında; alınan kararların, kararı alanlar tarafından imza edilmesi yeterli görülmelidir.

1) Karar Yetersayısı

Karar yetersayısı, TTK m. 226'da hükme bağlanmış; şirket sözleşmesinin değiştirilmesi haricinde, karar yetersayısının sözleşmeyle de düzenlenebileceği kabul edilmiştir.

a) Kanunda Öngörülen Karar Yetersayıları

TTK m.226/2'de, *şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların oybirliğiyle; diğer kararların ise, kanunda veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, ortakların çoğunluğunun oylarıyla verileceği* kabul edilmiştir. Bu hükümde, *"oybirliği"* şirketteki ortakların tümünü; *"çoğunluk"* ise, şirketteki ortakların salt çoğunluğunu ifade etmek üzere kullanılmıştır (TTK m.226/3).

b) Şirket Sözleşmesinde Öngörülen Karar Yetersayıları

TTK m.226/2'deki karar yetersayılarından az olmamak kaydıyla şirket sözleşmesine hüküm konulabilir; bu esastan olmak üzere, *diğer kararların* alınmasında da oybirliği aranacağı kabul edilebilir.

2) Kararların İptali

Kollektif şirket kararlarının çeşitli sebeplerle iptalinin istenmesi mümkündür. Bu esastan olmak üzere; toplantıya çağrılmadığını, toplantıya katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, toplantıya katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ileri süren ortakların, kollektif şirket kararlarının iptalini isteyebileceği kabul edilmelidir.

Ortakların usulü nitelikteki bu sebeplere istinaden iptal davası açabileceği kabul edildiğinde, iptal davasını hangi sürede açacakları sorunu ile karşılaşılır. Usul hükümleri ortakları korumak ve ticari hayata olan güveni temin etmek maksadıyla sevk edilmiştir. Ortak bu korumadan açık veya örtülü olarak feragat edebileceğinden kararın

---

[152] 19.12.2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

alınmasından sonra sergilediği hareket tarzı, meselâ sessiz kalması, kararın alınmasına itiraz etmemesi, feragat anlamına gelebilir.

İptal istemi kararın içeriğine ilişkin de olabilir. Alınan kararların kanun veya sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olmaması gerekir; aykırılık hâlinde, ortağın iptal davası açma hakkı olduğu kabul edilmelidir.

Bu hususta özel bir düzenleme, kâr payı ile ilgili olarak TTK m.227/2'de yer almaktadır. TTK m. 227/2'ye göre, *"ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer"*.

VIII) KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK

Kollektif şirketlerde ortaklar arasında değişiklik başlığı altında; şirkete yeni ortak alınması, ortaklık payının devri, çıkma ve çıkarılma konularına temas edilecektir.

A) ŞİRKETE YENİ ORTAK ALINMASI

Türk Ticaret Kanunu'nda, kollektif şirketlerde bir ortağın çıkması, çıkarılması, ortağın ölümü hâlleri ile ilgili hüküm sevk edilmiş olmasına karşın; üçüncü bir şahsın, kollektif şirkete ortak alınmasına dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Kollektif şirketlere ilişkin düzenlemelerde hüküm bulunmayan hâllerde, Türk Medenî Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümlerinin (TMK m. 47-55); genel hükümlerde bir düzenleme bulunmayan hususlarda ise, kollektif şirketin niteliğine uygun olduğu nispette, Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümlerinin kollektif şirketler hakkında da geçerli olduğu kanun koyucunun kabulündedir (TTK m. 126). Bu düzenlemelerden hareketle, üçüncü bir şahsın, kollektif şirkete yeni ortak alınmasında; TBK m. 632 hükmünün esas alınması gerekecektir.

Şirkete yeni ortak alımı hususunda, adi şirket kısmında yaptığımız açıklamalar saklı kalmak kaydıyla; TBK m. 632'ye göre, kollektif şirkete yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır. Kollektif şirkete yeni bir ortak alınması, kollektif şirket sözleşmesinin değiştirilmesini gerektirdiği ve şirket sözleşmesinin her ne şekilde olursa olsun değiştirilmesine ilişkin kararların oybirliğiyle alınmasının şart olduğu (TTK m. 226/2) nazara alındığında; kararın oy çokluğu esasına göre alınması söz konusu olamamalıdır.

Şirkete yeni giren ortak, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile, şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumludur (TTK m. 236/2).

B) PAYIN DEVRİ

Türk Ticaret Kanunu'nda, üçüncü bir şahsın, kollektif şirkete ortak alınmasında olduğu gibi; kollektif şirket ortaklarının payının devri hususunda da bir düzenleme yoktur. Bu durumda, yukarıda da izah edildiği üzere, TBK m. 632'nin uygulanması gerekir. TBK m. 632'ye göre, "*ortaklardan biri tek taraflı olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona devrederse, bu üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz*".

TBK m. 632 hükmünden de anlaşılacağı üzere, kollektif şirkette ortaklık payının tamamen veya kısmen devredilmesi mümkündür. Ortaklık payı ister kısmen ister tamamen devredilsin; ortaklık payının devri, sözleşme değişikliği anlamında olduğundan; ortaklık payının devrine bütün ortakların muvafakat etmesi gerekmektedir (TTK m. 226/2).

Bununla birlikte, ortaklık payının devrinin, iki ayrı muameleden oluştuğu da unutulmamalıdır. Bu muamelelerden ilki, payını devretmek isteyen ortakla, payı devralmak isteyen kişi arasında bir pay devir sözleşmesi yapılması; ikincisi ise, ortakların bu devir işlemine onay vermesidir. Ortakların devir işlemine onay vermesi, payın devri sözleşmesinden önce veya sonra olabileceği gibi; payın serbestçe devredilebileceği hususundaki sözleşme hükmü de, ortakların önceden verdiği onay sayılabilir. Ortakların devir işlemine onay vermediği pay devirleri, şirkete ve ortaklara karşı geçersizdir; devreden ve devralan arasındaki sözleşme, şirkete ve ortaklara karşı ileri sürülemez.

IX) ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Türk Ticaret Kanununun kollektif şirketler kısmındaki bazı maddelerinde (m. 254, 255, 256, 257) ortağın şirketten çıkarılmasından bahsedilmiş ve *bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılması hâlinde, diğer ortakların çıkma ve çıkarılmayı tescil ve ilan ettirmekle yükümlü* olduğu (TTK m. 259/1); *bir ortağın şirketten çıkması veya çıkarılmasının üçüncü kişilere karşı ancak tescil ve ilan tarihinden itibaren geçerli olacağı* (TTK m. 259/3) hükme bağlanmıştır.

Çıkma ve çıkarılma, birbirinden farklı kavramlardır. Kollektif şirketlerde *çıkma*, ortağın serbestçe veya bazı şartların gerçekleşmesiyle kendi rızasıyla şirket ortaklığından ayrılmasını; *çıkarılma* ise, ortağın rızası olmaksızın mahkeme veya diğer ortakların kararıyla, ortağın şirket ortaklığı ilişkisinin sona erdirilmesini ifade etmektedir. Bu izahtan da anlaşılacağı üzere, çıkma ve çıkarılma, kimi durumda iradenin açıklanması kimi zaman da mahkeme kararı ile gerçekleşmektedir. Bu nedenle çıkma ve çıkarılma konusunu, irade beyanına dayalı çıkma ve çıkarılma ile mahkeme kararına istinaden çıkma ve çıkarılma başlıkları altında incelemeyi uygun bulduk.

A) ORTAĞIN İRADE BEYANINA BAĞLI OLARAK ŞİRKETTEN ÇIKMASI VE ÇIKARILMASI

Bu kısımda, mahkeme kararı olmaksızın çıkma ve çıkarılma hâllerine temas edilecektir.

1) Ortağın Şirketten Çıkması

Bir ortağın şirketten çıkması, şirket sözleşmesinde hüküm bulunup bulunmadığına göre ayrı başlıklar altında incelenecektir.

a) Sözleşme Hükümlerine Göre Çıkma

Şirket sözleşmesine çıkmayla ilgili hükümlerin konulması mümkündür. Bu hâlde çıkma, sözleşmede belirlenen şartların gerçekleşmesiyle *kendiliğinden* yahut çıkma beyanıyla *rızaî çıkma* şeklinde gerçekleşebilir.

aa) Rızaî Çıkma

Kollektif şirket sözleşmesiyle ortağa şirketten çıkma hakkı tanınabilir. Ortağa çıkma hakkı sözleşme ile herhangi bir şarta bağlı olmadan verilmişse; ortak, bir sınırlamaya tâbi olmaksızın sözleşmeden doğan

çıkma hakkını kullanabilir. Bu hâlde ortağın çıkma beyanının şirkete ulaşmasıyla, iç ilişkide, çıkma gerçekleşir. Çıkmanın üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi; tescil ve ilân şartına bağlıdır (TTK m. 259/1).

bb) Kendiliğinden Çıkma

Kollektif şirket sözleşmesine, bazı şartların gerçekleşmesine veya belirli bir zamana bağlı olarak şirketten çıkılabileceğine ve bu bağlamda meselâ yaş haddine ilişkin hükümler konulması da mümkündür. Bu durumda ortak, bir beyana gerek olmaksızın şirketten çıkabilir ve ayrılma payını isteyebilir. Şirket sözleşmesinde öngörülen çıkma şartlarının gerçekleşmesi hâlinde, çıkmanın diğer ortaklarca kabul edilmesi söz konusu olmaz; iç ilişkide, şartın tahakkuku ile çıkma gerçekleşmiş olur, şirket diğer ortaklar arasında devam eder. Çıkmanın üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi; tescil ve ilân şartına bağlıdır (TTK m. 259/1).

b) Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Hâllerde Çıkma

Şirket sözleşmesinde ortağa çıkma hakkı tanınmamışsa ortak; diğer ortakların kabulüne bağlı olarak şirketten çıkabilir. Bu hâlde, ortağın çıkması sözleşme değişikliğini gerektirdiği için; çıkma kararının oybirliği ile alınması gerekir. Çıkma, iç münasebette kararın alınmasıyla gerçekleşirse de; üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmesi, tescil ve ilân şartına bağlıdır.

2) Ortağın Şirketten Çıkarılması

Türk Ticaret Kanunu'nun 254, 255, 256 ve 257'nci maddelerinde bir ortağın, rızası hilâfına şirketten çıkarılabileceği hükme bağlanmış; çıkmada olduğu gibi çıkarılma hâlinde de, şirketin diğer ortaklarla devam edeceği kabul edilmiştir.

Bir ortağın çıkarılma sebepleri kanun koyucu tarafından hükme bağlanmış; sözleşmede çıkarılma sebeplerinin öngörülemeyeceğine ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

a) Sözleşmede Öngörülen Sebeplerle Çıkarılma

Sözleşmede öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi hâlinde diğer ortaklar; ortağın şirketten çıkarılmasına oybirliği ile karar verir. Çıkarılan ortak bu karara katılamazsa da; bu kararın noter aracılığıyla tebliğinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde şirkete karşı çıkarılmanın iptali davasını açabilir (TTK m. 255/2).

b) Kanunda Öngörülen Çıkarılma Sebepleri

Kanun koyucu, TTK'de bazı çıkarılma hâlleri öngörmüştür. Bunlar:

aa) Ortağın İflâsı Hâlinde Çıkarılma

Ortaklardan birinin iflâsını şirketin sona erme sebebi olarak nitelendiren kanun koyucu; şirketin sona ermesini engellemek maksadıyla, *ortaklardan birinin iflası hâlinde, müflis ortağın şirketten çıkarılabileceğini, müflisin payının iflâs masasına ödenmesi suretiyle şirketin diğer ortaklar arasında devam edeceğini* kabul etmiştir (TTK m. 254).

Ortağın iflâsı, ortaklık sıfatının kendiliğinden sona erme sebebi değildir; ortağın iflâsından başka, diğer ortakların, iflâs eden ortağın çıkarılmasına dair bir karar alması gerekir. Kaldı ki, iflâs eden ortağın çıkarılmasına ilişkin olarak diğer ortaklara tanınan bu hakkın sözleşme ile kaldırılması da mümkündür.

bb) Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine Çıkarılma

Bir ortağın kişisel alacaklısının, aşağıda belirtilen iki hâlde şirketin feshini talep edebileceği ve fesih talebi üzerine, borçlu ortağın çıkarılabileceği kabul edilmiştir. Şirketin feshini isteyen alacaklının talebi üzerine borçlu ortağın çıkarılabilmesi için; diğer ortakların oybirliği ile karar alması gerekir. Çıkarılan ortak; bu kararın noter aracılığıyla tebliğinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde şirkete karşı çıkarılmanın iptali davasını açabilir (TTK m. 255/2).

aaa) Alacağını Tahsil Edemeyen Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirketin Feshini İstemesi Üzerine Borçlu Ortağın Çıkarılması

Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve şirketteki kâr payından alacağını alamazsa (TTK m. 133), tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve altı ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm ifade etmek üzere, şirketin feshini istemeye yetkilidir. Alacaklının fesih hakkını kullanabilmesi için, ortağın şahsi mallarına ve şirketteki kâr payına başvurması ve alacağını tahsil edememiş olması gerekir.

Şartların gerçekleşmesiyle şirketin feshini isteyen alacaklının talebi üzerine, mahkemece feshe karar verilmeden önce, şirket veya diğer ortaklar borcu öder (TTK m. 249/2) veya feshi engellemek için, borçlu

ortağı şirketten çıkartıp şirketin aralarında devamına karar verirse (TTK m 256/2); fesih davası düşer.

bbb) Ortağın Şahsi Alacaklısının Şirket Süresinin Uzatılmasına İtirazı Hâlinde Borçlu Ortağın Çıkarılması

Ortaklarca alınan şirketin süresinin uzatılmasına ilişkin karara, ortaklardan herhangi birinin kişisel alacaklısı itiraz edebilir (TTK m. 248/1). Bu durumda diğer ortaklar şirketin sona ermesini engellemek için; borçlu ortağı şirketten çıkarıp şirketin kendi aralarında devam etmesine karar verebilirler (TTK m. 256/2).

cc) Süresiz Şirketlerde Şirketin Feshini Talep Eden Ortağın Çıkarılması

Süresiz şirketlerde ortaklardan biri şirketin feshi ihbarında bulunduğu takdirde, diğer ortaklar feshi kabul etmeyerek, o ortağı şirketten çıkarıp şirketin kendi aralarında devam etmesine karar verebilirler (TTK m. 256/1). TTK m. 256/1 hükmünün, şirketin bir veya birkaç ortağının hayatı müddetince akdedilmiş olan şirket sözleşmeleri için de geçerli olduğu kabul edilmelidir (TBK m. 636; TTK m. 247).

dd) Ortağın Haklı Sebeplerle Çıkarılması

Kanun koyucu; kollektif şirketlerde *haklı sebep* kavramına öncelikle TTK m. 245'te yer vermiş; şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasını *haklı sebep olarak kabul etmiş* ve haklı sebebi, şirketin sona erme nedenleri arasında nitelendirmiştir.

TTK m. 245'de ayrıca, bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması, kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneğini ve ehliyetini kaybetmesi *gibi hâller* haklı sebep olarak kabul edilmiştir.

TTK m. 255/1'de de, şirketin sona ermesi sonucunu doğuran haklı sebeplerin, bir ortağın durumundan da kaynaklanabileceği nazara alınarak; bir ortağın kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin istenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümünün, o ortağın şirketten çıkarılmasına ve şirketin devamına karar verebilecekleri kabul

edilmiştir. Şirket sözleşmesinde bu kararın çoğunlukla alınması öngörülebilir.

c) Çıkarılma Kararına İtiraz

Ortağın çıkarılmasını gerektiren sebeplerin ortaya çıkması üzerine, diğer ortakların kararıyla ortağın çıkarılmasında, çıkartılan ortağın itiraz hakkına, "*haklı sebeplerle çıkarılma*" münasebetiyle yer verilmiş; çıkarılan ortağın, bu *kararın noter aracılığıyla tebliğinden itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde şirkete karşı* çıkarılmanın iptali istemiyle dava açabileceği kabul edilmiştir (TTK m. 255/2).

Haklı sebeplerle ortağın çıkarılmasına ilişkin olarak ortağa tanınan bu *çıkarılma kararlarının iptali davası* açma hakkının; diğer çıkarılma sebeplerinde de uygulanacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, menfaatler durumu esas alındığında; diğer çıkarılma sebeplerine göre çıkartılan ortağın da, *çıkarılma kararının iptali davası* açma hakkının bulunduğu kabul edilmelidir.

B) ORTAĞIN MAHKEME KARARIYLA ÇIKARILMASI

Türk Ticaret Kanunu'nda, mahkeme kararıyla çıkarılmaya, sadece iki kişilik şirket (TTK m. 257-258) ve haklı sebeple çıkarılma için öngörülmüş olan kararın alınamaması (TTK m. 255/3) münasebetiyle yer verilmiştir.

1) Haklı Sebeple Çıkarılma Kararı Alınamaması Hâlinde Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması

Kanun koyucu TTK m. 255/1'de, bir ortağın, diğer ortakların alacağı kararla haklı sebebe istinaden çıkartılabileceğini hükme bağladıktan sonra; çıkarma kararı alınamadığı takdirde, *her ortağın*, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortağın şirketten çıkarılmasını isteyebileceğini kabul etmiştir (TTK m. 255/3). Kanaatimizce, diğer çıkarılma hâllerinde de; çıkarma kararı alınamadığı takdirde, her ortak, söz konusu ortağın şirketten çıkarılmasını isteyebilmelidir.

2) İki Ortaklı Kollektif Şirkette Ortağın Mahkeme Kararıyla Çıkarılması

Yalnız iki kişiden oluşan bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin şirketten çıkarılmasını gerektiren haklı sebepler varsa, diğer ortağın istemi üzerine mahkeme fesih ve tasfiyeye karar vermeksizin şirketin

bütün iş ve işlemleri, varlıkları, alacak ve borçlarıyla davacı ortağa bırakılmasına ve diğer ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebilir (TTK m. 257).

Kanun koyucu, iki kişiden oluşan bir kollektif şirkette, ortaklardan birinin şirketten çıkarılmasını sadece haklı sebeplere bağlamamış; iki kişiden oluşan bir şirkette, ortaklardan birinin kişisel alacaklısının fesih istemesi (TTK m. 249, 256) ile şirket süresinin uzatılması kararına itiraz etmesi (TTK m. 248) hâllerinde de, mahkeme kararıyla ortağın çıkartılabileceğini kabul etmiştir (TTK m. 258).

Kanun koyucu mahkemenin, *fesih ve tasfiyeye karar vermeksizin ortağın şirketten çıkarılmasına karar verebileceğini* hükme bağlamış; tek kişi ile kollektif şirket tüzel kişiliğinin devam edebileceği gibi bir izlenim vermiştir. Kanaatimizce, tek kişi ile kollektif şirket olarak devam etmek mümkün değildir; inşai mahiyette olan mahkeme kararıyla birlikte, kollektif şirket bir ticari işletmeye dönüşür (TTK m. 194/3); ticari işletme, bu kişi adına ticaret siciline tescil ve ilân edilmelidir.

C) ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN HÜKÜMLERİ

Bir ortağın çıkması veya çıkarılması, kollektif şirketin hak ve borçlarında bir değişiklik meydana getirmezse de; çıkma ve çıkarılmanın üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade etmesi için tescil ve ilân şarttır (TTK m. 259/1). Bir ortağın kollektif şirketten çıkması veya çıkarılması üçüncü kişilere karşı ancak tescil ve ilân tarihinden itibaren geçerli olur (TTK m. 259/3).

1) Çıkma ve Çıkarılmanın Ticaret Unvanına Etkisi

Kollektif şirketin ticaret unvanında, çıkan veya çıkarılan ortağın ad ve soyadı yer alması hâlinde, unvanın değiştirilmeden kalabilmesi için; çıkan veya çıkarılan ortağın ticaret unvanın devamına muvafakat etmesi gerekir. Çıkan veya çıkarılan ortak, ticaret unvanının devam etmesine muvafakat etmezse; unvanın değiştirilmesi gerekir. Ancak, unvanın değişmesi, tüzel kişiliğin ayniyeti üzerinde herhangi bir etki yaratmaz.

2) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi

Çıkma ve çıkarılmanın üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade etmesi için tescil ve ilân şart olmasına karşın; ortaklar arasındaki ilişkilere etkisi, tescilden önce başlar.

a) Çıkma ve Çıkarılmanın Ortaklık Sıfatını Sona Erdirmesi

Ortağın çıkması veya çıkarılması, iç münasebette tescilden önce hüküm ifade eder ve çıkan veya çıkarılan ortağın, diğer ortaklara karşı ortaklık sıfatına bağlı hak ve yükümlülükleri sona erer. Bu esastan olmak üzere, yönetim, toplantılara katılmak, toplantılarda oy kullanmak ve şirket işlerini incelemek haklarını kaybeder. Çıkan veya çıkarılan ortağın ortaklık sıfatı sona erdiği için; ortak sıfatına bağlı olan, rekabet yasağı hükümleri, çıkan veya çıkarılan ortak hakkında uygulanmaz.

Çıkan veya çıkartılan ortağın ortaklık sıfatı iç ilişkide çıkma veya çıkarılma, dış ilişkide tescil ve ilân tarihinde sona ermesine karşın; *çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin doğrudan doğruya sonuçları olan hak ve borçlara katılmaya devam* eder. Bu bağlamdan olmak üzere, şirket işlerini inceleme yetkisi olmamakla birlikte, yöneticilerden tamamlanmamış işlerle ilgili olarak bilgi isteyebilir; kazanç payı talep edebilir.

b) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Tasfiye Payını Talep Hakkı

Çıkan veya çıkarılan ortağın şirketle ilişkisi kesildiğinden; çıkan veya çıkarılan ortak, fesih ve tasfiyeye bağlı olan tasfiye (ayrılma) payını isteyebilir. Şirketten çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye (ayrılma) payı, şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa, çıkmanın istendiği veya ortağın çıkarıldığı, uyuşmazlık hâlinde karar tarihine en yakın tarihteki şirket varlığı esas alınarak hesaplanır (TTK m. 260) ve çıkan veya çıkarılan ortağa nakden ödenir (TTK m. 261).

Çıkan veya çıkarılan ortağın hesaplanacak ayrılma payı, şirket sözleşmesinde gösterilen tarihte ve şirket sözleşmesinde hüküm yoksa ayrılmadan sonra çıkarılacak ilk bilanço tarihinde ödenirse de (TTK m. 262/1); çıkarılan veya çıkan ortağın, ayrılma tarihinden önce girişilen işler tasfiye edilmedikçe şirketteki sermaye payını alamayacağı unutulmamalıdır (TTK m. 262/2).

Ortağın tasfiye (ayrılma) payı, ortaklık dışı şahsi bir alacak hakkı doğurur. Bu nedenle çıkan veya çıkarılan ortak, tasfiye (ayrılma) payının şirket tarafından ödenmemesi hâlinde; alacağını, şirkette kalan ortaklardan talep edebilir.

3) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğu

a) Çıkan veya Çıkarılan Ortağın Sorumluluğunun Esasları

Çıkma ve çıkarılmanın üçüncü kişiler bakımından hüküm ifade etmesi tescil ve ilân şartına bağlı olduğu için; ortağın üçüncü kişilere karşı sorumluluğu, çıkma veya çıkarılmanın tescil ve ilân tarihine kadar devam eder (TTK m.259/4).

Bununla birlikte, tescilin fonksiyonları nazara alındığında, TTK m. 259/4 hükmünün hukuki işlemler için geçerli olduğu; haksız fiil sorumluluğu hakkında etkili olmadığı kabul edilmelidir. Buna göre, ortak şirketten çıktıktan veya çıkarıldıktan ve fakat çıkma veya çıkarılmanın henüz tescil ve ilân edilmediği zaman diliminde, şirket yöneticileri bir haksız fiil ika ederse; çıkan veya çıkarılan ortağın sorumluluğuna gidilemez. Çıkan veya çıkarılan ortağın sorumluluğu, çıkma veya çıkarılmanın tescil ve ilân tarihine kadar yapılmış olan hukuki muamelelerle sınırlıdır; hukuki muameleden doğan borcun muaccel veya müeccel olması, sorumluluğa etkili değildir. Çıkan veya çıkarılan ortak, tescil ve ilân tarihine kadar yapılmış olan hukuki muamelelerden dolayı, diğer ortaklar gibi; bütün malvarlığıyla sınırsız ve müteselsil sorumludur.

b) Tamamlanmamış İşler

Çıkan veya çıkarılan ortağın ortaklık sıfatı iç münasebette, çıkma veya çıkarılma, dış münasebette tescil ve ilân ile sona ererse de; çıkma veya çıkarılmadan evvel başlanmasına mukabil, çıkma veya çıkarılma tarihinde henüz tamamlanmamış işlerle ilgili olarak *hak ve borçları devam eder*. Bu husus, TTK m. 263/1'de, "*çıkarılan veya çıkan ortak, ayrılmadan önce başlamış olan işlerin doğrudan doğruya sonuçları olan hak ve borçlara katılır*" şeklinde ifade edilmiştir.

Çıkarılan veya çıkan ortak, evvelce başlanmış işlerin kalan ortaklar tarafından faydalı sayılacak şekilde tamamlanmasına ve bir sonuca bağlanmasına engel olamaz. Ancak, söz konusu işlerin hemen tasfiyesi mümkün olamadığı takdirde çıkan veya çıkarılan ortak, her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içinde bitirilen işlerin hesaplarını ve devam etmekte olan işlemlerin o tarihteki durumu hakkında bilgi verilmesini isteyebilir (TTK m.263/2).

X) ORTAĞIN ÖLÜMÜ

Kollektif şirket ortaklarından birinin ölümünün hukuki sonuçları, TTK m. 253'de, şirket sözleşmesinde şirketin, ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine ilişkin düzenleme olup olmadığına göre ayrı ayrı hükme bağlanmıştır.

A) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE ŞİRKETİN ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARIYLA DEVAM EDECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMAMASI

Şirket sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine ilişkin *düzenleme yoksa*, mirasçılarla diğer ortakların oybirliği ile verecekleri karar üzerine şirket bunların arasında devam edebilir.

Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı olmazlarsa, diğer ortaklar, ölen ortağın razı olmayan mirasçılarına düşen paylarını ödeyerek onları şirketten çıkarır ve aralarında şirkete devam edebilirler. Bu durumda sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına onay vermemesi sebebiyle oybirliği sağlanamadığı takdirde şirket sona erer (TTK m. 253/1).

B) ŞİRKET SÖZLEŞMESİNDE ŞİRKETİN ÖLEN ORTAĞIN MİRASÇILARIYLA DEVAM EDECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME BULUNMASI

Şirketin, ölen ortağın mirasçılarıyla diğer ortaklar arasında kollektif şirket olarak devam edeceği hakkında şirket sözleşmesinde *hüküm varsa*, mirasçılar kollektif sıfatıyla şirkete devam edip etmemekte serbesttirler.

Mirasçılar şirketin kollektif şirket olarak devam etmesini isterlerse; diğer ortaklar bu isteği kabul etmek zorundadır. Ancak, kollektif sıfatıyla şirkette kalmak istemeyen mirasçı varsa; ölen ortağın payından kendisine düşen tutar ile komanditer olarak şirkete kabul edilmesini önerebilir. Ancak diğer ortaklar bu öneriyi kabul etmek zorunda değildir.

Mirasçılar şirkete kollektif ortak veya komanditer olarak girip girmeyeceklerini ortağın ölüm tarihinden itibaren *üç ay içinde* şirkete ihbar etmelidir. Durumun şirkete ihbarına kadar, mirasçılar şirkette komanditer olarak kalmış sayılırlar. Bu süre içinde ihbarda bulunmamış olan mirasçılar, sürenin sona ermesinden itibaren kollektif ortak sıfatını alırlar (TTK m. 253/2).

XI) KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

Ticari bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulacağı ifade edilen kollektif şirket sona ermekle; sona erme tarihine kadar geçerli olan *kazanç paylaşma gayesi*, *tasfiye gayesine* dönüşür. Tasfiye hâline giren şirket, ortaklarla ilişkilerinde de (TTK m. 293 hükmü saklı kalmak kaydıyla), ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sınırlı olarak *tüzel kişiliğini korur* ve ticaret unvanını buna "*tasfiye hâlinde*" ibaresini ekleyerek kullanmaya devam eder (TTK m. 269).

TTK m. 269'daki bu ifadeden de anlaşılacağı üzere, şirketin sona ermesi, şirket tüzel kişiliğinin sona ermesi sonucunu doğurmasa da; şirketin ehliyeti ile şirket ortaklarının hak ve borçlarında önemli değişikliklere sebep olmaktadır.

A) KOLLEKTİF ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Kanun koyucu, kollektif şirketin sona erme sebepleri hakkında, TBK'nin 639 ve 640'ıncı maddelerine atıf yapmış; kollektif şirketlere ilişkin sona erme sebeplerini de TTK'nin. 243'üncü maddesinde tanzim etmekle yetinmiştir. Bununla birlikte sona erme sebeplerini sadece Kanunda belirlenen bu hâllerle sınırlı tutmamak; sözleşme ile de sona erme nedenlerinin öngörülebileceğini kabul etmek gerekir. Ancak, Kanunda öngörülen sona erme nedenlerinin bazılarının, şirketin hukuki mahiyeti; bazılarının ise, ortakların veya üçüncü kişilerin menfaati gereği emredici olduğu da unutulmamalıdır. Bu husus TTK m. 244'te, "*şirket sözleşmesinde belirli bir veya birkaç sebep göstermeksizin hükümde infisah sebeplerinden herhangi birinin varlığı hâlinde şirketin sona ermeyeceğinin ifade edildiği genel nitelikteki hüküm geçerli olmaz. Ancak, kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, bazı belirli fesih sebeplerinin şirketin sona ermesi sonucu doğurmayacağı şirket sözleşmesinde kabul olunabilir*" şeklinde ifade edilmiştir.

Kanunda veya sözleşmede hükme bağlanan sona erme sebeplerinden bazıları, sebebin gerçekleşmesiyle kollektif şirketin kendiliğinden (*ipso iure*) sona ermesi sonucunu doğurur (*infisah*). Bu sebeplerin dışında, şirketin ortakların iradesine bağlı olarak (*fesih*) veya *mahkeme kararıyla* sona ermesi de söz konusu olabilir. Bu nedenle şirketin sona ermesini, *infisah*, *fesih* ve *mahkeme kararıyla son erme* başlıkları altında inceleyeceğiz.

1) Kollektif Şirketlerin İnfisahı (Kendiliğinden Sona Ermesi)

Kanunda veya sözleşmede belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi üzerine, başka bir işlem yapılmasına ihtiyaç olmadan; şirketin kendiliğinden sona ermesine, *infisah* (*kendiliğinden sona erme*) denilmektedir. İnfisah hâllerinin bir kısmı, TTK m. 243'de yapılan atıfla TBK'de; diğerleri ise TTK m.243'de hükme bağlanmıştır. Kanunun emredici hükümleri saklı kalmak kaydıyla; şirket sözleşmesine de infisah sebepleri koymak mümkündür.

a) Kanunda Öngörülen İnfisah Sebepleri

Yapılan atıf gereğince, Türk Borçlar Kanunu'nun 639'uncu maddesinde ve ayrıca TTK m. 243'de sayılan sebeplerden birinin gerçekleşmesi halinde; şirket kendiliğinden (*ipso iure*) sona erer. Şirketin kendiliğinden sona ermesi üzerine ilgililerden herhangi biri, şirketin sona erdiğinin tespitini isteyebileceği gibi; sona ermenin tespitiyle birlikte, sona erme neticelerini de (idare ve temsil yetkisinin sona ermesi ve tasfiye) talep edebilir. Kanunda öngörülen kendiliğinden sona erme (infisah) nedenleri şunlardır:

aa) Şirket sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle gelmesi

Bu hususta, adi şirketle ilgili olarak yaptığımız açıklamalar saklı kalmak kaydıyla, şirket sözleşmesinin yapılmasını müteakip, şirketin faaliyete geçmesinden sonra ortaya çıkan imkânsızlığın, kollektif şirketi sona erdireceği kabul edilmektedir (TBK m. 639/1). Ancak sonradan ortaya çıkan bu imkânsızlığın, *devamlı ve objektif bir mahiyette* olması gerekir; nispeten kısa bir zaman için gayretlerin neticesiz kalması veya herhangi bir sebeple kâr elde edilememesi, ortakların şahsından kaynaklanan durumlardan dolayı başarısızlık, bu anlamda imkânsızlık olarak kabul edilmemelidir.

Bu noktada önemle belirtmek gerekir ki, ortaklık sözleşmesinde öngörülen *amacın gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız* hâle gelmesi durumunda ortaklar; gerçekleşen veya gerçekleşmesi imkânsız hâle gelen *amacı değiştirerek* veya faaliyetlerine devam ederek şirketin sona ermesini engelleyebilirler. Şirketin amacının değiştirilmesi, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 226'ncı maddesine uygun bir şekilde alacakları kararla *açık* bir şekilde veya faaliyetlerine amaç değiştirerek devam etmek suretiyle *örtülü* bir tarzda da olabilir.

bb) Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm olmaması hâlinde ortaklardan birinin ölmesi

Şirket sözleşmesinde şirketin ölen ortağın mirasçılarıyla devam edeceğine ilişkin düzenleme yoksa; mirasçılarla diğer ortakların oybirliği ile verecekleri karar üzerine şirket bunların arasında devam edebilir. Mirasçılar veya içlerinden biri şirkette kalmaya razı olmazlarsa; diğer ortaklar, ölen ortağın razı olmayan mirasçılarına düşen payları ödeyerek onları şirketten çıkarır ve aralarında şirkete devam edebilirler. Bu durumda sağ kalan ortaklardan birinin şirketin devamına onay vermemesi sebebiyle oybirliği sağlanamadığı takdirde şirket sona erer (TTK m. 253/1).

cc) Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi

TTK m. 243/1'de atıf yapılan Türk Borçlar Kanunu'nun 639'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının 3'üncü bendinde, "*sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle*" şirketin sona ereceği kabul edilmiştir. Ancak, bu hâllerden birinin gerçekleşmesi durumunda, diğer ortaklar, kısıtlanan, iflâs eden veya tasfiyedeki payı cebrî icra yoluyla paraya çevrilen ortağı çıkarmak suretiyle, sona ermeyi engelleyebilirler.

dd) Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin sona ermesi

Kollektif şirket sözleşmesinin bir süreye bağlı olarak yapılması gerekmez. Kollektif şirket, belirsiz süre için veya ortaklardan birinin ömrü boyunca sürmek üzere kurulabileceği gibi, belirli bir süreye de bağlanabilir. Şirket sözleşmesinin belirli bir süreye bağlanması hâlinde kollektif şirket, sözleşmede belirlenen sürenin geçmesiyle birlikte kendiliğinden sona erer (TBK m.639/1.b.5).

Kanun koyucu, sözleşmede belirlenen sürenin geçmesiyle birlikte şirketin kendiliğinden sona ereceğini hükme bağlamışsa da; sözleşmede belirlenen sürenin sona ermesine rağmen şirket faaliyetlerine devam ediyorsa ve *bütün ortakların* buna muvafakati varsa, ortakların şahsi alacaklıları da sürenin uzatılmasına itiraz etmemişse; muvafakatin açık veya örtülü olmasına bakılmaksızın, şirket *belirsiz süreli şirkete dönüşür* (TBK m. 640/3).

ee) Şirketin iflâsı

TTK m. 243/1'de, *konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflâsı,* kendiliğinden sona erme sebebi sayılmıştır.

ff) Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybı

Kollektif şirket, sermayenin tamamını veya üçte ikisini kaybettiğinde; sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar verilmezse infisah eder (TTK m. 243/1. b)[153].

Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybedilmesi, tasfiyede olduğu gibi, şirketin bütün alacak ve hakları esas alınarak değerlendirilmeli ve infisah anı olarak; sermayenin tamamının veya üçte ikisini kaybedildiğine ilişkin bilançonun görüşülmesi sonucunda ortakların sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye karar vermemesi anı olarak belirlenmesi uygun olur. Sermayenin tamamlanmasına veya geri kalan sermaye ile yetinmeye ilişkin bu karar, sözleşmenin değiştirilmesi mahiyetinde olduğu için; kararın oybirliği ile alınması gerekir.

gg) Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi

Kollektif şirketin diğer bir şirketle birleşmesi, TTK m. 243/1.c'de infisah sebebi olarak nitelendirilmiştir. Bilindiği üzere, kollektif şirketler, bir şahıs şirketiyle ve devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketiyle kooperatiflerle birleşebilirler (TTK m. 137/2). Birleşmeyle, devralan şirketin, devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralındığı, devrolunan şirketin sona erdiği ve ticaret sicilinden silindiği (TTK m. 137/4) nazara alındığında; kollektif şirket, *devralan sıfatıyla birleşmeye katılırsa, şirket sona ermez.* Buna karşın, birleşme yeni kuruluş şeklinde gerçekleşirse veya kollektif şirket devrolunan şirket durumundaysa; kollektif şirket kendiliğinden sona erer.

b) Sözleşmede Öngörülen İnfisah Sebepleri

Sözleşme özgürlüğü uyarınca taraflar, bir yandan sözleşmenin tipini, diğer yandan da sözleşmenin içeriğini, yani edimlerin miktarını, konusunu, süresini ve bu bağlamda sözleşmeyi sona erdiren sebepleri, kanunda öngörülen sınırlar içinde serbestçe belirleyebilir (TBK m. 26).

---

153 Ortaklarının şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu sınırlandırılmamış, sermaye unsurundan ziyade ortakların ön plânda olduğu kollektif şirkette; sermayenin kaybının, kendiliğinden sona erme sebebi sayılması anlaşılamamaktadır.

Bilindiği üzere, geçerli olarak yapılmış bir sözleşmenin sonuçlarının ortadan kalkması, gelecekteki belirsiz bir olayın gerçekleşmesine bağlanmış ise, bozucu şarta bağlı bir sözleşme söz konusu olur (TBK m.173/1). Bu anlamda, şirket sözleşmesinde öngörülen infisah sebeplerini, bozucu şart olarak nitelendirerek, sözleşme özgürlüğü çerçevesinde sözleşmeye konulabileceğini kabul etmek gerekir. Kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olmayan her şart, (meselâ şirketin devamı için hayati ehemmiyeti haiz bir patent hakkının iptali), sözleşmeyle infisah sebebi olarak nitelendirilebilir.

2) Kollektif Şirketlerin Feshi

Fesih, ortakların veya ortakların şahsi alacaklılarının iradeleriyle kollektif şirketin sona erdirilmesi anlamında kullanılmaktadır. Fesih hakkı, Kanunda veya sözleşmede düzenlenmiş olabilir.

a) Kanunda Öngörülen Fesih Sebepleri

Kanun koyucu, şirketin infisah sebepleri yanında, ortakların iradesine bağlı olarak şirketin feshedilebileceğini kabul etmiştir.

aa) Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması

TTK m. 243/1'de yapılan atıf gereği, Türk Borçlar Kanunu'nun 639'uncu maddesinin 6'ncı bendine göre, şirket sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmuşsa, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla şirket sona erer.

Şirketin ortaklardan birinin beyanı ile sona erebilmesi için; fesih hakkının sözleşme ile verilmiş olması şarttır. Sözleşme ile tanınan fesih hakkı, mücerret bir hak olarak tanınabileceği gibi; şarta da bağlanabilir. Fesih hakkı şirket sözleşmesinde herhangi bir şarta bağlı tutulmamışsa; ortağın fesih beyanı, şirketin sona ermesi için yeterlidir. Feshi ihbar hakkı bazı şartlara veya belirli süreye bağlı tutulmuşsa; bu şartların gerçekleşmesi üzerine veya gerçekleşmesi şartıyla fesih beyanında bulunulabilir.

İnşai mahiyette olan fesih ihbar hakkı, bir şarta bağlı değilse, hakkın kullanılması ve ihbarın diğer ortaklara varması ile sonuç doğurur. Fesih ihbarının tüm ortaklara yapılması gerekir; beyanın son ortağa ulaşmasıyla şirket sona erer.

Fesih ihbarının şekli ile ilgili bir düzenleme olmamakla birlikte; kollektif şirket sözleşmesinin yazılı şekle tâbi olduğu noktasından hareketle; sözleşmeyi sona erdirecek olan fesih ihbarının da yazılı olması gerektiği söylenebilir.

Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması hâlinde, şirket sona erse de; sözleşmede şirketin diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, fesih bildiriminde bulunan ortağın, ortaklıktan çıkabileceği veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabileceği de unutulmamalıdır (TBK m. 633).

bb) Belirsiz süreli kollektif şirketlerde ortakların fesih hakkı

Kollektif şirket sözleşmesinde feshi bildirme hakkı saklı tutulmamış olsa dahi; şirket *belirsiz bir süre için* ya da *ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulmuşsa*, bir ortak fesih bildiriminde bulunmak suretiyle şirketi sona erdirebilir (TBK m. 639/1. b. 6).

Belirsiz bir süre için ya da ortaklardan birinin ömrü boyunca kurulan kollektif şirketlerde ortaklara tanınan fesih hakkı kanundan doğan ve emredici mahiyette olan bir haktır. Emredici mahiyette olmakla birlikte, bu hakkın nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler; hakkın özünü ihlâl etmediği müddetçe geçerli olmalıdır.

Belirsiz süreli kollektif şirketlerin, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasıyla sona erdirilmesinde de, bir ortağın fesih bildiriminde bulunmasında olduğu gibi, sözleşmede şirketin diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa; fesih bildiriminde bulunan ortağın, ortaklıktan çıkabileceği veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle ortaklıktan çıkarılabileceği kabul edilmelidir.

cc) Ortakların kararıyla fesih

Ortakların alacağı bir kararla şirketin sona ermesi; TTK m. 243'de yapılan atıfla, TBK m. 639/1.b.4'te hükme bağlanmıştır. TBK m. 639/1.b.4'te, bütün ortakların oybirliğiyle karar vermesiyle şirketin sona ereceği hükme bağlanmışsa da; şirket sözleşmesinde, bu kararın oy çokluğu ile alınabileceğine ilişin açık bir hüküm varsa, fesih kararı oy çokluğu ile alınabilmelidir. Sözleşmede kararın oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayısının salt çoğunluğuna göre belirlenir (TTK m. 226/3).

Kollektif şirket ortaklarının kararı ile şirketin sona erdirilmesi, şirket sözleşmesiyle bir şarta bağlı tutulmuş olsa bile; bu şart geçersizdir. Şirket, ortakların kararıyla her zaman sona erdirilebilir.

Şirketin feshi hakkındaki karara, yönetim yetkisini haiz olsun olmasın tüm ortaklar iştirak ederler. Ortakların şirketin feshine ilişkin bu kararı, inşai mahiyettedir; iç münasebette etkisini derhal gösterir. Dış münasebette şirketin sona ermesi; tescil ve ilân şartına bağlıdır.

Ortakların alacağı bir kararla şirketin sona erdirilebilmesi için; kollektif şirket sözleşmesinin yazılı olduğu nazara alınarak, bu sözleşmeyi sona erdiren kararın da yazılı olması ve ortaklar tarafından imzalanması gerektiği düşünülmektedir. Ortakların aldığı kararın dış münasebette geçerli olabilmesi için, ayrıca tescil edilmesi; tescil edilebilmesi için de, yazılı kararın sicil müdürlüğüne verilmesi gerektiği hatırlandığında, sona erme kararının yazılı olması gerektiği kanaatimiz güçlenmektedir.

b) Sözleşmede Öngörülen Fesih Sebepleri

İnfisahta olduğu gibi, sözleşme özgürlüğü sınırları içinde, fesih sebeplerinin de şirket sözleşmesine konulması mümkündür. Sözleşmede öngörülen bu fesih hakkının kullanılması; sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde kullanılır.

3) Kollektif Şirketlerin Mahkeme Kararıyla Sona Ermesi

Kollektif şirketin mahkeme kararıyla feshi; haklı sebeplerle fesih ile şirketin tescil edilmemesi üzerine fesih ve ortağın şahsi alacaklısının talebi üzerine fesih başlıkları altında incelenecektir.

a) Kollektif Şirketlerin Haklı Sebeple Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi

Yönetim hakkının geri alınması veya sınırlandırılması, temsil yetkisinin kaldırılması ve ortağın çıkarılması münasebetiyle söze konu ettiğimiz *haklı sebep*; TTK m. 243'te yapılan atıfla, TBK m. 639/1.b.7'de, kollektif şirketin sona erme nedeni olarak kabul edilmiştir.

Haklı sebep Türk Borçlar Kanunu'nda tanımlanmamış; ancak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, TTK m. 245'de, "haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olmasıdır" şeklinde ifade edilmiştir.

Kanun koyucu bu ifadeyle yetinmeyerek, "*bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş olması, kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi, kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye kullanması, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi gibi hâlleri*" haklı sebebe örnek olarak vermiştir.

TTK m. 255/1'de de, şirketin sona ermesi sonucunu doğuran haklı sebeplerin, bir ortağın durumundan da kaynaklanabileceği nazara alınarak; bir ortağın kendisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı şirketin feshinin istenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümünün, o ortağın şirketten çıkarılmasına ve şirketin devamına karar verebileceği kabul edilmiştir. Şirket sözleşmesinde bu kararın çoğunlukla alınması öngörülebilir.

Haklı sebeple fesih, dava yoluyla istenebilir. Ortaklardan birinin haklı sebebe dayanarak dava açabilmesi için; her şeyden önce, TTK m. 245'de ifadesini bulan haklı bir sebebin bulunması gerekir; davacının fesih davası açabilmesi için önceden bir ihbarda bulunmasına ihtiyaç yoktur.

aa) Dava süresi

Kanun koyucu haklı sebeple fesih davası açılması hakkında bir süre öngörmemiştir. Bu nedenle, haklı sebep devam ettiği müddetçe; haklı sebeple şirketin feshi istenebilir. Ancak, haklı sebebin ortaya çıktığı ve devam ettiği süre içinde, ortakların dava açma hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanacak hareketlerde bulunulması veya haklı sebep bir ortağın şahsından kaynaklanıyorsa, bu ortağın affedilmesi durumlarında dava açılamaz; dava açılmışsa kabul edilmemesi gerekir. Bunun gibi, haklı nedenin ortaya çıkmasından sonra uzunca bir müddet geçmiş, dava hakkını haiz olanlar suskun kalmışsa; haklı sebebe istinaden dava açılamayacağının kabulü gerekir.

bb) Fesih Kararı

Fesih kararı, inşai mahiyettedir; mahkemenin verdiği fesih kararının kesinleşmesiyle, şirket sona erer. Şirketin sona ermesi için, mahkemenin verdiği fesih kararının ayrıca infazına gerek yoktur.

b) Kollektif Şirketlerin Kuruluşundaki *Tescil ve İlân* Merasimine Aykırılık Nedeniyle Mahkeme Kararıyla Fesih

Türk Ticaret Kanunun 215'inci maddesinde gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapılmamışsa, *aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun*; ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine ve bu ortağın noter aracılığıyla diğer ortaklara uygun bir süreyi içeren ihtar göndermiş olması şartıyla mahkemece kollektif şirketin feshine karar verilir (TTK m. 243/1.d).

Bu hâlde fesih hakkı ortaklardan herhangi biri tarafından kullanılabilir. Kanun koyucu, "gösterilen süre içinde veya sonra tescil ve ilân yapılmamışsa, *aradan ne kadar süre geçmiş olursa olsun*" dava açılabileceğini öngörmüştür.

c) Kollektif Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Talebi Üzerine Mahkeme Kararıyla Fesih

Bir ortağın kişisel alacaklısı, borçlunun kişisel mallarından ve TTK m. 133 gereğince şirketteki kâr payından alacağını alamazsa; tasfiye sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurmaya ve *altı ay önce ihbarda bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm ifade etmek üzere*, şirketin feshini istemeye yetkilidir (TTK m. 249/1).

Ortağın kişisel alacaklısının fesih talebinin mahkeme tarafından hükme bağlanabilmesi için; borcun hesap yılı sonuna kadar ödenmemiş olması gerekir. Mahkeme feshe karar vermeden önce borç; borçlu veya şirket yahut diğer ortaklar tarafından ödenirse, fesih davası düşer. Borç, borçlu veya şirket yahut diğer ortaklar tarafından ödenmezse; mahkeme feshe karar verir.

Borcun, mahkemenin fesih kararından sonra ödenmesi hâlinde; ortaklar arasında şirket malvarlığının dağıtımına başlanmamışsa, ortaklar mahkemeye müracaatla tasfiye kararının kaldırılmasını isteyebilmelidir.

B) KOLLEKTİF ŞİRKETİN TASFİYESİ

Kollektif şirketin sona erme sebeplerinden biri gerçekleştiğinde; tasfiyesiz sona erme hâlleri haricinde, şirket kural olarak tasfiye aşamasına girer. Tasfiye aşamasında şirketin tüzel kişiliği devam eder (TTK m. 269). Ancak, tasfiye aşamasına giren şirketin amacı değişir; bundan

böyle amaç, gerek şirketle üçüncü kişiler gerek ortakların kendi aralarındaki ilişkinin sona erdirilmesidir.

Bundan dolayıdır ki, tasfiye aşamasında öncelikle şirketin malvarlığı paraya çevrilir ve borçları ödenir; ödemeler yapıldıktan sonra, arta kalan paranın bulunup bulunmamasına göre ortakların kendi aralarındaki hukuki ilişkiye son verilir. Bu işlemlerin ve tasfiyenin tamamlanmasıyla birlikte durum ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik sona erdirilir.

Tasfiye sırasında uygulanacak hükümler bakımından öncelikle şirket sözleşmesine bakılması gerekmektedir. Şirket sözleşmesinde bu konuda özel hüküm varsa bunlar uygulanır. Sözleşmede hüküm bulunmaması hâlinde ise; Ticaret Kanununun 267 ve devamı maddelerinde düzenlenen hükümlerin uygulanması gerekir (TTK m.267). Ayrıca, tasfiye ile görevli memurlar, ortaklar tarafından tasfiye zamanında oybirliği ile verilen kararlar doğrultusunda hareket etmek durumundadırlar (TTK m. 268/1).

1) Tasfiyenin Şirket İlişkileri Üzerindeki Etkileri

Kollektif şirketin tasfiye sürecine girmesiyle birlikte; kazanç amacı, tüzel kişiliğin sona erdirilmesi amacına dönüşür. Şirketin amacındaki bu değişiklik; şirketin işleyişini, yöneticilerini de etkiler. Bu nedenle, tasfiye sürecinin etkilerinin kısaca izahında fayda olduğunu düşünüyoruz.

a) Tüzel Kişiliğin Ehliyeti

Kollektif şirketin sona ermesi, tüzel kişiliği sona erdirmez; tasfiye hâline giren kollektif şirket tüzel kişiliğini gerek dış gerek iç münasebette tasfiyenin sonuna kadar muhafaza eder. Bu husus TTK m. 269'da, *"Tasfiye hâline giren şirket, ortaklarla ilişkilerinde de, 293'üncü madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sınırlı olarak tüzel kişiliğini korur"* şeklinde ifade edilmiştir.

TTK m. 291'e göre tasfiye amacı, *"şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya, şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye, şirketin alacaklarını toplamaya, gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye, net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemler"* olarak ifade edilmiş ve tasfiye hâline giren kollektif şirketin haklardan istifade ehliyeti, tasfiye amacıyla

sınırlandırılmıştır. Ancak, hükmün düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, tasfiye işleri maddede yazılanlarla sınırlı değildir; hükümde sadece tasfiye amacına yönelik olarak yapılacak işlere örnek verilmiştir.

Bu hükme nazaran, tasfiye hâlinde kollektif şirket tüzel kişiliği sıfatı ile istifade edebileceği haklar ve üstlenebileceği borçlar; tasfiye amacıyla sınırlandırılmış olduğundan, şirketin tasfiye sürecine girdiği tescil ve ilân edilmişse, tasfiye amacı dışında yapılan bir muamele şirketi bağlamaz. Bu bakımdan üçüncü kişinin iyiniyeti de yapılan işlem üzerinde etkili olmaz.

Tasfiye hâlinde kollektif şirket tüzel kişiliğinin ehliyeti, tasfiye amacıyla sınırlandırılmasına karşın, TTK m. 293'te sınırlı ehliyete bir istisna getirilerek, tasfiye *memurlarının, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemleri yapabileceği; bunun için ortakların oybirliğiyle karar vermesi gerektiği hükme bağlanmıştır.* Feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda, ortaklar oybirliğini sağlayamazlarsa; *şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemler* mahkemenin onay kararıyla yapılabilir.

b) Ticaret Unvanı

Kollektif şirketin sona ermesi ve tasfiye sürecine girmesi ile amacı değişirse de, tüzel kişilik ticaret şirketi sıfatını korur; ticaret unvanını buna "*tasfiye hâlinde*" ibaresini ekleyerek kullanmakta devam eder (TTK m. 269).

c) Defter Tutma

Tasfiye hâlinde kollektif şirketin tacir sıfatı devam ettiği için; defter tutma yükümlülüğü sona ermez. Defterlerin tasfiye gayesi ile sınırlı olarak tutulması gerekir.

2) Tasfiyenin Ortaklar Arasındaki İlişkilere Etkisi

TTK m. 269'da, sadece şirketin ehliyeti sınırlandırılmış olmakla beraber, 293'üncü maddeye yapılan atıftan; kollektif şirketin tasfiye sürecinin, iç münasebette ortakların hak ve borçlarını etkilediği ve bunların da tasfiye gayesiyle sınırlandırıldığı anlaşılmaktadır. Belirtmek gerekir ki, ortaklar arasındaki münasebetlerde, şirket sözleşmesiyle Kanunun tasfiyeye ilişkin hükümleri dışındaki hükümleri; ancak tasfiye amacına uygun olduğu ölçüde tatbik edilebilir.

a) Ortakların Hak ve Borçları

Ortakların hak ve borçları tasfiye amacına göre belirlenir ve bu bağlamda, şirketin mevcudu borçların ifasına yetiyorsa, bakiye sermaye borçlarının ifası istenemez; rekabet yasağı kalkar.

b) Yönetim ve Temsil Yetkisi

Tasfiye sürecine girilmesi hâlinde, ortakların yönetim temsil yetkileri sona erer; sona ermiş şirket adına ve hesabına işlem yapamazlar (TTK m. 251); şirketi temsil ve yönetme yetkisi, tasfiye işleri ile sınırlı olmak kaydıyla, tasfiye memurlarına aittir. Aksi hâlde, bu işlemleri yapanlar; işlemlerden müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

c) Denetleme Hakkı

Şirketin faal olduğu döneme ait olarak TTK m. 225'te düzenlenen denetleme hakkı; tasfiye sürecinde genişletilmiştir. TTK m. 225'de *denetleme hakkı*, şirket işlerinin gidişi hakkında bizzat bilgi edinmek, şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek, bunlara göre kendisi için şirketin finansal durumunu gösterecek bir hesap tablosu düzenlemek olarak belirtilmişken; tasfiye sürecinde denetleme hakkı iki ayrı maddede (TTK m. 301-302) ele alınmıştır.

TTK m. 301'e göre, ortaklar tasfiye memurlarından, tasfiye işlerinin durumu hakkında, bilgi isteyebilmekte ve bu bilginin imzalı bir belgeye dönüştürülmesini talep edebilmektedir. Tasfiye memurları, istem üzerine şirkete ve tasfiyeye ilişkin bütün defterleri ve belgeleri tasfiye işleminin yapıldığı yerde ortaklara göstermekle de yükümlüdürler. Ortakların bu defter ve belgelerden suret almalarına tasfiye memurları engel olamazlar (TTK m. 302).

3) Tasfiye Memurları

Kollektif şirketin tasfiyesi, iflâs dışındaki sona erme hâllerinde tasfiye memurlarına aittir (TTK m. 272).

a) Tasfiye Memurlarının Seçimi/Atanması ve Görevden Alınması

Tasfiye memurlarının atanmalarına, değiştirilmelerine, görevden alınmalarına ve yetkilerine ilişkin şirket sözleşmesinin hükümleri ile ortaklar veya mahkeme tarafından verilen tasfiyeye ilişkin kararların tescil ve ilânı şarttır (TTK m. 283).

aa) Tasfiye Memurlarının Seçimi veya Atanması

Kanun koyucu, tasfiye memurlarının seçiminde ortaklara serbesti tanımıştır. Bu hususun hükme bağlandığı TTK m. 273/1'de, *"Tasfiye memurlarının şirket sözleşmesiyle, şirketin devamı sırasında veya sona ermesinden sonra ortakların oybirliğiyle seçileceğini"*; ortakların tasfiye memuru seçememesi durumunda, tüm ortakların veya bunların kanuni temsilcilerinin tasfiyeye memur sayılacağını kabul etmiştir (TTK m. 273/2).

Kural böyle olmakla beraber, ortaklardan birinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesi tarafından, tasfiye hâlindeki şirket için bir veya birkaç tasfiye memuru atanması da mümkündür. Tasfiye memuru atayan mahkeme gerek görürse; tasfiye memuru atanmasına ilişkin dilekçeyi tebliğ ederek, diğer ortakları dinleyebilir (TTK m. 273/2). Gerek ortakların seçecekleri gerek mahkemenin atayacağı tasfiye memurları ortaklardan veya üçüncü kişilerden olabilir (TTK m. 273/3).

bb) Tasfiye Memurlarının Görevden Alınması

Kanun koyucu, tasfiye memurlarının görevden alınmasını; tasfiye memurunun ortak olup olmamasına ve mahkeme kararıyla atanmasına göre ayrıma tâbi tutmuştur.

aaa) Ortak olan tasfiye memurunun görevden alınması

Tasfiye memurları, *şirket sözleşmesiyle* veya şirketin sona ermesinden önce bir *ortaklar kararıyla*, ortaklar arasından seçilmişlerse, diğer ortakların *oybirliğiyle* verebilecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, *haklı sebepler varsa,* mahkemece görevden alınabilirler. Görevden alma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir (TTK m. 274).

Şirketin sona ermesinden sonra, ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, diğer ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece görevden alınabilirler (TTK m. 274).

bbb) Ortak olmayan tasfiye memurunun görevden alınması

Ortak olmayan tasfiye memurları, şirket sözleşmesi veya sonradan verilen bir kararla ya da şirketin sona ermesinden sonra seçilmiş olsalar bile, ancak ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece görevden alınabilirler. Görevden alınma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir (TTK m. 276).

ccc) Mahkeme kararıyla atanan tasfiye memurunun görevden alınması

TTK m. 277'de yapılan atıf gereğince, mahkeme kararıyla atanan tasfiye memuru, ortakların oybirliğiyle verecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine haklı sebeplerden dolayı mahkemece görevden alınabilirler.

b) Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisi

Tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve dışarıda tasfiye memurları temsil eder. Tasfiye memurları şirket için yararlı gördükleri takdirde, olağan işlem ve işlerle sınırlı olmak koşuluyla, sulhe, feragate, kabule, tahkime ve özellikle hakem seçmeye de yetkilidirler; gereklilik hâlinde yeni işlemler de yapabilirler. Tasfiye hâlinde bulunan kollektif şirket adına düzenlenen bütün belgeler ve senetlerin "*tasfiye hâlinde bulunan filan şirketin tasfiye memurları*" ibaresi eklenerek tasfiye memurları tarafından imzalanması şarttır. Bir tasfiye memurunun görevini yaparken işlediği haksız fiillerden şirket de sorumludur (TTK m. 280).

Birden fazla tasfiye memuru varsa; bunların birlikte hareket etmesi gerekir. Bununla birlikte, şirketin menfaatleri için tehlike umulan durumlarda özellikle kanun yollarına başvurulmasında tasfiye memurları tek başlarına hareket edebilirler ve üçüncü kişiler tarafından yapılacak teklif, icap, ihbar, ihtar ve tebliğ gibi beyanların tasfiye memurlarından yalnız birine karşı yapılması yeterlidir (TTK m. 281).

Tasfiye memurlarının kanunen haiz oldukları bu yetkiler, ortaklar tarafından oybirliğiyle veya haklı sebeplerin bulunması durumunda mahkeme kararı ile daraltılıp genişletilebilir. Tescil ve ilan olunmadıkça yetkilerin daraltılması, iyiniyetli üçüncü kişilere ileri sürülemez (TTK m. 282).

c) Tasfiye Memurlarının Yükümlülükleri

Türk Ticaret Kanunu'nun 286-290'ıncı maddeleri arasında "*tasfiye işleri*" başlığı altında, tasfiye memurlarının yükümlülüklerine temas edilmiştir. Buna göre tasfiye memurları, tasfiye hâlinde bulunan *şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla* ve *tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlüdür* (TTK m. 286). Bu esastan olmak üzere:

aa) Koruma tedbirleri almak

Göreve başlayan tasfiye memurları, şirketin mal ve haklarının korunmasını temin maksadıyla; gerekli tüm önlemleri yükümlüdür (TTK m. 286). Bu yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla da öncelikle bir başlangıç envanteri ve bilançosu hazırlarlar.

TTK m. 287'ye göre tasfiye memurları, "*önceden seçilmişlerse* şirketin sona ermesini hemen izleyen günlerde ve şirketin sona ermesinden sonra *ortaklarca seçilmiş veya mahkemece atanmışlarsa* seçimlerinden ve atanmalarından hemen sonra şirket işlerini gören kişileri çağırarak onlarla birlikte, gelmedikleri takdirde yalnız başlarına, şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenlerler. Tasfiye memurları gerek görürlerse şirket mallarına değer biçmek için uzmanlara başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye memurlarının önünde şirket işlerini yönetenler tarafından imzalanır. Envanter ve bilançonun imzasından sonra, tasfiye memurları sona ermiş bulunan şirketin envanterde yazılı bütün malları ile belgelerine ve defterlerine el koyarlar".

bb) Defter Tutmak

Tasfiye memurları tasfiye işlemlerinin güvenliğini sağlamak için gereken defterleri tutmakla (TTK m. 288) ve tasfiyenin sonunda belgelerin ve defterleri saklamakla (TTK m. 290) yükümlüdür.

cc) Son bilançoyu çıkarmak

Tasfiye sonunda, tasfiye memurları şirket sözleşmesi veya kanun hükümlerine göre ortakların sermaye ile kâr ve zarardaki paylarını ve diğer haklarını gösteren bir bilanço düzenleyerek ortaklara tebliğ ile yükümlüdürler. Ortaklar bir ay içinde mahkemeye başvurarak itiraz etmezlerse, bilanço kesinleşir (TTK m. 289/1).

Bundan sonra ortaklar, kendilerine düşen payları almaktan kaçındıkları takdirde tasfiye memurları, bu payları her ortağın ayrı ayrı adlarına mahkemece belirlenecek bir bankaya yatırırlar (TTK m. 289/2).

d) Tasfiye Memurlarının Hakları

Ortaklar arasından seçilen tasfiye memurları, sözleşmede veya sonradan verilmiş bir kararda belirtilmediği takdirde ücret alamazlar. Buna karşın, ortak olmayanlardan atanan tasfiye memurları, ücret kararlaştırılmasa bile, hâlin gereğine göre takdir edilecek uygun bir ücret isteyebilirler; anlaşmazlık durumunda taraflar yargı yoluna başvurabilir (TTK m. 286).

4) Tasfiye İşlemleri ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

"Tasfiye işleri" Türk Ticaret Kanunu'nun 286-290'ıncı maddeleri arasında hükme bağlanmış; tasfiye memurlarının, tasfiye hâlinde bulunan *şirketin bütün mal ve haklarının korunması için basiretli bir iş adamı gibi gerekli önlemleri almakla* ve *tasfiyeyi olabildiğince en kısa zamanda bitirmekle yükümlü* (TTK m. 286) olduğu ifade edilmiştir.

Buna göre, tasfiye işlerinin başlangıcında, tasfiye hâlinde bulunan *şirketin bütün mal ve haklarının korunması için* gerekli tüm tedbirlerin alınması ve bu bağlamda şirketin finansal durumunu gösteren bir envanter ile bilanço düzenlenmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle şirket veya ortaklar zarara uğrarsa; yükümlülüğünü yerine getirmeyen tasfiye memuru sorumlu olur.

Koruma tedbirlerinden sonra tasfiye sürecine geçilir. Tasfiyede esas olan öncelikle dış tasfiyenin yapılması; şirketin alacaklarının tahsil edilmesi ve borçlarının ödenmesi gerekir.

Tasfiye memurları bu aşamada, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, ancak, ortakların oybirliğiyle; feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda, ortaklar oybirliğini sağlayamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler (TTK m. 293); bu istisnanın haricinde, tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir işlem yapamazlar. Aksi takdirde, bu tür işlemlerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen sorumlu olurlar (TTK m. 292).

Tasfiye memurları şirketin sona ermesi durumunda şirkete ait taşınırları, durumun gereklerine göre ya artırma yoluyla veya pazarlıkla

satabilirler. Oybirliğiyle verilen bir kararla ortaklar başka bir satış şeklini belirlemedikleri takdirde, taşınmazlar ancak İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca açık artırma yoluyla satılabilir (TTK m. 294). Ortaklar oybirliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak, oybirliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir (TTK m. 295).

Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş, olan borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar (TTK m. 297). Kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar (TTK m. 298).

Bütün bu işlemler yapıldıktan sonra şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır (TTK m. 300).

Tasfiyenin sona ermesi üzerine, *şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi ve bunun tescil ve ilânı için* durum, tasfiye memurları tarafından ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir (TTK m. 303).

BEŞİNCİ BÖLÜM

§7- ADİ KOMANDİT ŞİRKET

Komandit şirketler, birbirinden mahiyetleri itibariyle farklı olan iki ayrı türe sahiptir: Şahıs şirketi özelliklerini taşıyan adi komandit şirketler ve sermaye şirketi özellikleri ağır basan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler (TTK m.124/2).

I. KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ

Adi komandit şirketler, biri komandite (sınırsız sorumlu) ve diğeri komanditer (sınırlı sorumlu) ortak olmak üzere en az iki ortağın, bir adi komandit şirket kurmak amacıyla Kanunda öngörülen içerikte bir şirket sözleşmesi akdetmeleri suretiyle ve şirketin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesiyle kurulur.

A) KAVRAM

Adi komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirkettir (TTK m.304/1).

Adi komandit şirket veya komandit şirket, Türk Ticaret Kanununda açıkça ticaret şirketi ve şahıs şirketi olarak kabul edilmektedir (TTK m. 124). Bu nedenle adi komandit şirket, ortaklarından bağımsız bir tüzel kişiliğe ve dolayısıyla hak ve fiil ehliyetine sahip olan (TTK m. 125), kurulduğu andan itibaren tacir sıfatı bulunan (TTK m. 16) kendi borçlarından dolayı sınırsız şekilde sorumlu olan şirkettir.

B) ÖZELLİKLER

Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelerden adi komandit şirketlerin temel birtakım özellikleri şu şekilde tespit edilebilir:

1. Kişi (Şahıs)

Adi komandit şirketler, biri *komandite* ve diğeri *komanditer* ortak olmak üzere en az iki ortak ile kurulabilir. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite ortak; sorumluluğu sınırlı olanlara ise komanditer ortak adı verilir. Bununla birlikte Kanunda ortak sayısına bir üst sınır getirilmemiştir. Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler (TTK m.304/3).

2. Ticari İşletme

Adi komandit şirketler de kollektif şirketler gibi ancak ticari bir işletme işletmek amacıyla kurulabilir. Dolayısıyla komandit şirketlerin, esnaf faaliyeti sınırlarını aşacak düzeyde gelir getiren bir işletmeyi işletmek amacıyla kurulması gerekir.

3. Ortakların Sorumluluğu

Adi komandit şirketlerde ortaklardan en az birisi (komandite ortak), şirket alacaklılarına karşı ikinci dereceden, sınırsız ve müteselsilen sorumlu iken; en az bir ortak (komanditer ortak), şirkete getirdiği sermaye payı ile sorumluluk altına girer. Komandit şirketi kollektif şirketten ayıran özellik, sermaye ile sınırlı sorumlu olan komanditer ortağın bulunmasıdır.

4. Ticaret Unvanı

Adi komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları bulunamaz (TTK m.42/2). Adı şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu sayılır (TTK m.320).

5. Tüzel Kişilik

Her ticaret şirketi gibi adi komandit şirket de ticaret siciline tescil edilmekle tüzel kişilik kazanır (TTK m.317, m.232). Bu andan itibaren dış ilişkide hakların ve borçların sahibi olur.

I. KURULUŞ

Adi komandit şirketin kuruluşunda kollektif şirkete ilişkin hükümlere atıf yapılmıştır (TTK m.305/1). Komandit şirket, Kanuna uygun olarak ortaklarca hazırlanan sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesiyle kurulur.

Komandit şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir; ayrıca, sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır (TTK m.305/1, m.212). Bununla birlikte kollektif şirket sözleşmesinden farklı olarak adi komandit şirket sözleşmesinde yazılması gereken birtakım farklı hususlara da temas edilmesi gerekmektedir.

Kollektif şirket sözleşmesinden farklı olarak komandit şirket sözleşmesinde sorumluluk açısından farklı şekilde düzenlenmiş iki ayrı ortak bulunur (TTK m.304). Şirketin ticaret unvanında sadece komandite ortakların ad ve soyadlarına yer verilir ve şirketin adi komandit şirket olduğu belirtilir. Her ortağın sermaye olarak koymayı taahhüt ettiği miktar sözleşmede belirtilirken bir komanditer ortağın, kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamayacağı göz önünde bulundurulur (TTK m.213, m.307/2). Ayrıca şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir (TTK m.305/2).

II. İŞLEYİŞ

Adi komandit şirketlerin işleyişi de kollektif şirketlere paralel olarak ortaklar arasındaki ilişkileri kapsayan iç işleyiş ve üçüncü kişilerle ilişkileri konu alan dış işleyiş şeklinde iki başlık altında incelenebilir.

A. İÇ İŞLEYİŞ

Komandit şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda, TTK m.308 vd. hükümleri saklı kalmak şartıyla kollektif şirketlere ilişkin 217 ilâ 231'inci maddeler uygulanır.

1. Mali İlişkiler

a. Sermaye Koyma Borcu

Bir komandit şirket sözleşmesi, komanditerlerin adları/unvanları ile her birinin koydukları veya koymayı taahhüt ettikleri sermayenin cins ve miktarları yazılarak tescil ve ilan ettirilir. Bir komanditer kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz. Komandit şirketlerde, sermaye şirketlerinden farklı olarak ayni sermaye olarak konulabilecek malvarlığı unsurlarına ilişkin sınırlayıcı bir düzenleme öngörülmediği için kollektif şirketlerde sermaye koyma borcuna ilişkin hükümler, adi komandit şirket hakkında da geçerli olur.

b. Kâr ve Zarara Katılma

Adi komandit şirketlerde ortakların kâr ve zarara katılması hakkında esas itibarıyla kollektif şirkete ilişkin hükümler uygulanmakla birlikte komanditer ortağın sorumluluğu hakkında özel düzenlemeler sevk edilmiştir.

Komanditer ortağın sorumluluğu, koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz (TTK m.319). Dolayısıyla komanditer ortak zarara, sermaye miktarıyla sınırlı olarak katlanır. Bununla birlikte komanditer, şirkete koymayı taahhüt ettiği sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzerine aldığını yazı ile bildirmiş veya ilan etmişse üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı bu tutar kadar sorumlu olur (TTK m.322/3).

c. Tasfiye Payı

Komanditer, koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunun henüz ödemediği tutarına kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Bu suretle kendisine başvurulan komanditer ortak, şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Şirket alacaklıları, şirket sona ermiş olmadıkça veya şirket aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmadıkça, komanditere başvuramazlar (TTK m.322/1).

Şirketten alacağı olan bir kişinin, sermaye borcunu henüz yerine getirmemiş veya koyduğu sermayeyi geri almış bir komanditere borcu varsa, bu kişi şirketteki alacağını komanditere olan borcu ile takas edebilir (TTK m.327).

2. Şahsi İlişkiler

a. Yönetim Yetkisi

İster komandite ister komanditer olsun her ortağın bir oy hakkı vardır. Bu kurala aykırı düzenlemeler geçersizdir. Şirket, komanditeler tarafından yönetilir. Komanditerler, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak, olağanüstü iş ve işlemlerde, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme, birleşme ve bölünme gibi yapısal değişikliklerde; şirkete ortak alınması, çıkarılması ve payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de oy hakkını haizdirler (TTK m.309).

b. İtiraz Hakkı

Komandite ortak, kollektif şirket ortağı gibi yönetim yetkisinin kullanılması kapsamındaki iş ve işlemlere itiraz edebilir. Buna karşılık komanditerler, şirket işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıklarından, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler (TTK m.309/3).

c. Denetim Yetkisi

Komandite ortağın demetim hakkı, kollektif şirket ortağı gibidir. Komanditer ortak ise, iş yılı sonunda ve iş saatleri içinde, şirketin envanterleriyle bilançosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, bunların doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye yetkili kılınmıştır. Komanditer ortak, bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi bir uzmana da yaptırabilir (TTK m.310). Bu esasa aykırı şirket sözleşmesi hükümleri geçersizdir.

d. Rekabet Yasağı

Komandit şirkette ortakların birbirleriyle olan ilişkileri şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirket sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlarda, kollektif şirketlere ilişkin 217 ilâ 231'inci maddeler uygulanır. Buna karşılık kollektif ortakların, şirket konusunu oluşturan işlemlerin aynını yapamayacaklarına ilişkin 230'uncu madde komanditerler hakkında uygulanmaz. Ancak komanditer, şirketin işletme konusunun kapsamına giren işlerle uğraşacak bir ticari işletme açar veya böyle bir işletme açan bir kişiyle ortak olur ya da bu nitelikte bir şirkete

girerse, komandit şirketin belgelerini ve defterlerini incelemek hakkını kaybeder (TTK m.311).

B. DIŞ İŞLEYİŞ

Şirket ve ortakların üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, komandit şirket hakkındaki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete ilişkin 232 ilâ 242'nci maddeler uygulanır.

1. Ortaklığın Temsili

Komandit şirketler, kural olarak komandite ortaklar tarafından temsil edilir. Kollektif şirketin temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümleri komandit şirkete de uygulanır.

Komanditer ortaklar, ortak sıfatıyla şirketi temsile yetkili değildirler. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmamak şartıyla, komanditer ortak da ticari temsilci, ticari vekil veya seyyar tüccar memuru (*pazarlamacı*) olarak atanabilir. Bu halde komanditer ortak temsilci sıfatıyla hareket ettiğini açıkça bildirmeksizin, şirket adına işlemlerde bulunursa, bu işlemler nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur (TTK m.321/1).

Şirketin ticaret siciline tescilinden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından bilindiğini ispat etmediği takdirde, komandite ortak gibi sorumlu tutulur (TTK m.321/2).

2. Şirket Borçlarından Sorumluluk

Şirket borçlarından birinci derecede şirket sorumlu iken; komandite ve komanditer ortakların sorumluluğu, Kanunda öngörülen durumların gerçekleşmesi şartıyla ikinci derecedendir. TTK m.317 hükmünün kollektif şirketlere yapmış olduğu yollama nedeniyle TTK m.237/1 hükmü gereğince, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, ortaklara veya ortaklarla birlikte şirkete başvurulabilir.

Komandite ortak, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün malvarlığı ile sorumlu iken; komanditer ortağın, şirkete getirmeyi taahhüt etmiş olduğu sermaye miktarı kadar belirli hallerde alacaklılara karşı sorumlu olduğu kabul edilir. Bununla birlikte komanditer ortağın adı/unvanı şirket unvanında yer alıyorsa (TTK m.320) ya

da komanditer ortak şirket adına işlemlerde bulunurken temsilci sıfatıyla hareket ettiğini bildirmiyorsa ve üçüncü kişiler de sorumluluğun sınırlı olduğunu bilmiyorsa (TTK m.321/2) komanditer ortağın sorumluluğu, komandite ortak gibi sınırsız hale gelir.

Alacaklı, komanditerin koyduğu sermayeye biçilen değerin, bu sermayenin konulduğu andaki değerinin altında olduğunu ispat ederse, aradaki fark tutarınca komanditer sorumlu olur. Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin şirkete girmesinden önce doğan borçlardan da sorumlu kılınmıştır (TTK m.321). Bunlara ilave olarak komanditer ortak, şirkete koymayı taahhüt ettiği sermayeyi aşan bir tutar ile sorumluluğu üzerine aldığını yazı ile bildirmiş veya ilan etmişse üçüncü kişilere veya bildirimin muhatabına karşı bu tutar kadar sorumlu olur (TTK m.322/3).

Komanditerin, şirket yönetimine karışması sonucunu doğurmayacak şekilde öğüt vermesi, görüş açıklaması, olağanüstü iş ve işlemler ile şirketin iş ve işlemleri üzerinde haiz olduğu denetleme haklarını kullanması, kanunda yazılı hâllerde yönetim işlerini gören kimselerin atanmalarına, görevden alınmalarına katılması, şirket içinde ikinci derecedeki hizmetlerde ve görevlerde çalıştırılması, komanditer sıfatıyla sorumluluğunu etkilemez (TTK m.321/5).

C. ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİKLER

Adi komandit şirketlerde ortaklar arasındaki ilişkiler esas itibarıyla kollektif şirket hükümlerine tâbidir. Bununla birlikte komanditer ortaklar hakkında, ortakların sorumlulukları için öngörülen düzenlemelerden kaynaklı birtakım farklılıklar ortaya çıkar.

Komanditer, şirketteki payını başkasına devredebilir. Ancak, devre diğer ortaklar onay vermemişlerse bu kişi ortak sıfatını kazanamaz (TBK m.632, m.315). Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz (TTK m.328). Komanditer ortağın ölmesi halinde yerine mirasçıları geçer (TTK m.316).

Komandit şirketlerde ortakların şirketten çıkma ve çıkarılmasına ilişkin olarak kollektif şirket hükümleri uygulanır (TTK m.328, m.243-303).

III. SONA ERME VE TASFİYE

Adi komandit şirketin sona ermesi ve tasfiyesi konularında kollektif şirketlerin sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin hükümler kıyasen uygulanır (TTK m.328).

ALTINCI BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR VE ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

§8- ANONİM ŞİRKETLERLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

LİTERATÜR

Akdağ Güney, N.: *Anonim Şirketlerde Kuruluş*, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014; Anaral, H.: *Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye*, Ankara 1982; Bahtiyar, M.: *Anonim Ortaklıkta Kayıtlı Sermaye Sistemi ve Sermaye Artırımı*, İstanbul 1996; Çevik, K.: *Fransız ve Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirket/Sınırlı Sorumlu Ticari İşletme*, Bozer'e Armağan, İstanbul 1998, s. 37-55; Erdem, E.; *Türk ve İsviçre Hukuklarında Eşit İşlem İlkesi*, İsviçre Borçlar Kanunu'nun İktibasının 80. Yılında İsviçre Borçlar Hukukunun Türk Ticaret Hukukuna Etkileri, İstanbul 2009, 393, 407; Eroğlu, M.: *Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirketler*, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 1253; Forstmoser, P./Meier-Hayoz, A./Nobel, P.: Schweizerisches Aktienrecht, 2. Auflage, Bern 1996; Hızır, S. *Anonim Şirkette Borçlanma Yasağını Düzenleyen TTK'nın 358. Maddesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler*, Batider C. XXIX, S. 2, s. 227-289; Huguenin Jacobs, Claire: *Das Gleichbehandlungsprinzip im Aktienrecht*, Zürich 1994; Karasu, Rauf: *Anonim Şirketlerde Emredici Hükümler İlkesi*, Yetkin Yayınevi, 2. Baskı Ankara 2015; *Kaşak*, F. E.: *Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık*, İstanbul 2019; Kendigelen, Abuzer: *Anonim Ortaklıkta Yönetime Katılma Haklarında İmtiyaz*, İstanbul 1999; Kervankıran, E.: *"Ön Şirket ve Hukuki Niteliği"*, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken, Sempozyum 10-12 Mayıs 2012, MÜHF-HAD 2012, C. 18, S. 2 (Özel Sayı), s. 349- 370; Manavgat, Ç.: *Halka Açık Anonim Ortaklıklar ve Halka Arz,* Ankara 2016; Nomer, F.: *"Anonim Ortaklıkta Eşit Davranma (Eşit İşlem) İlkesi"*, Prof. Dr. Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998. s. 469-490; Omağ, M. K.: *Anonim Şirketler Hukukunda Eşit İşlem İlkesinin (Hukuki) Sonuçları*, 1986, Cilt 1, s. 1-8; Şehirali Çelik, F. H.: *Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler*, Batider 2007, C. XXIV, s. 163 vd.; Tamer, A.: *Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Bir Yenilik: "Pay Sahiplerinin*

(Ortakların) Şirkete Borçlanma Yasağı" (TTK m. 358), TBB Dergisi 2012 (102), s. 93-114; Tekinalp, Ü.: *"Esas Sözleşmesel Müktesep Hak",* İkt. Mal. 1983, C. XXX, S. 1, s. 21-31; Tekinalp, Ü.: *Sermayenin Korunması İlkesi,* Prof. Dr. Rona Serozan'a Armağan, İstanbul 2010; Tekinalp, Ü.: *Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı ve Türk Hukukunun Bu Konudaki Açılımı,* Ülgen'e Armağan, 2007, s. 579-610; Yıldız, Şükrü: *Anonim Ortaklıkta Pay Sahipleri Açısından Eşit İşlem İlkesi,* Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004.

I) KAVRAM (TANIM)

Anonim şirket, bir veya daha çok sayıda kişinin bir sözleşme ile kurdukları, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip şirkettir (TTK m.329). TTK m.124 hükmünde açıkça bir ticaret şirketi olduğu belirtilen anonim şirket, TTK m.16 gereğince tüzel kişi tacir sıfatına sahiptir.

Anonim şirket her türlü iktisadi faaliyette bulunmak amacıyla kurulabilir. Şirketin kuruluş amacı kazanç elde etmek ve bunu ortaklarına dağıtmaktır. Söz konusu amaca ulaşmak için belirli bir sermayeye ve organizasyona ihtiyaç vardır. Şirketin kuruluşu, işleyişi ve sona ermesi hakkında gerekli düzenlemeler TTK'de ve bunlara bağlı olarak çıkarılmış ikincil düzenlemelerde ayrıntılı olarak tespit edilmiştir. Ayrıca bazı özel tür anonim şirketler için çıkarılmış düzenlemeleri ve hakkında özel kanun çıkarılmış anonim şirketlerin tâbi olduğu düzenlemeleri de zikretmek gerekir. Anılan yasal düzenlemeler yanında kanunların elverdiği ölçüde şirket sözleşmesine konulacak hükümlerle de birçok husus önceden kurala bağlanabilir.

Anonim şirketler ülkemiz uygulamasında sayıca limited şirketler kadar çok olmasa da kurumsal yapıyı hedefleyen girişimcilerin en çok tercih ettiği şirket türüdür. Bu tercihin en önemli sebebi, ortakların tek borç ilkesi gereği taahhüt edilen sermayenin ödenmesi dışında bir sorumluluk taşımamalarıdır.

II) ANONİM ŞİRKETİN ORTAYA ÇIKIŞI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

Anonim şirketlerin ilk örneklerine 15. yüzyılın başlarında Cenova'da rastlanmakla birlikte modern anlamda anonim şirketlerin ise

17. yüzyıldan itibaren görülmeye başlandığını söylemek mümkündür. Anonim şirketin düzenlendiği ilk yazılı örneklerden olan 1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu 1850 tarihli Kanunname-i Ticaret adıyla Osmanlının ilk Ticaret Kanununa kaynaklık etmiştir. Bu yıllarda Fransa dışında, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde de kanuni düzenlemelere gidildiği görülmektedir[154]. Gerek ülkemiz düzenlemelerinde gerekse kaynak ülke düzenlemelerinde zaman içerisinde birçok kez kapsamlı değişikliklerin yapılmasına rağmen reform çalışmaları ülkeler düzeyinde ve AB düzeyinde hâlen devam etmektedir. Buna örnek olarak İsviçre'de 2007 yılında başlayan reform çalışmaları gösterilebilir.

Türk Hukuku açısından anonim şirketlerin de içerisinde düzenlendiği ilk Ticaret Kanunu mahiyetindeki 1850 tarihli Kanunname-i Ticareti 1926 tarihli ve 865 sayılı Türk Ticaret Kanunu takip etmiş; 1956 yılında 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu yürürlüğe girmiş ve en son olarak 2012 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uygulanmaya başlanmıştır[155]. 6102 sayılı TTK da, geride kalan çok kısa sürede sayısız değişikliğe uğramasına rağmen birçok açıdan ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır.

III) ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

A) TİCARET UNVANI

Hukukumuzda anonim şirketlerin de diğer bütün tacirler gibi bir ticaret unvanı altında faaliyet göstermesi zorunludur (TTK m.18/1)[156]. Ticaret unvanlarının nasıl oluşturulacağı ise TTK m.43 ve TSY m.42/1, 43/7'de açıkça ortaya konmuştur. Buna göre unvan; şirketin işletme konusu ile anonim şirket ibarelerinden ve gerekliyse veya isteniyorsa alınacak eklerden oluşturulur. Ticaret unvanında bir gerçek kişinin adının bulunması halinde ise şirketi ve türünü gösteren ibareler kısaltılmadan yazılmalıdır (TTK m.43/2).

---

[154] **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** I, N 442 vd.

[155] Türkiye'de anonim şirketler hukukunun gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** I, N.459 vd.

[156] Her ne kadar anonim şirketi tanımlayan TTK m.329 hükmünde ticaret unvanı açıkça bir unsur olarak belirtilmemişse de tacire ve ticaret unvanına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde anonim şirketin de ancak kendisine ait bir unvan altında faaliyet yürütmesi gerektiği açıktır, bkz. **Ayhan, R./Çağlar, H.**: Ticari İşletme Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2018, s. 299.

B. SERMAYE

Anonim şirketin kurulabilmesi için tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş en az 50.000TL sermayeye ihtiyaç vardır. Sermayenin nakit olarak ifade edilmesi zorunludur. Bu rakam, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan anonim şirketlerde 100.000TL'den az olamaz. Bazı özel alanlarda faaliyet gösterecek anonim şirketler için (bankacılık gibi) daha yüksek asgari sermaye miktarları belirlenmiştir (ör. Bankalar için 30.000.000TL).

C. TÜZEL KİŞİLİK

Anonim şirket, TTK m.124/1 gereğince tüzel kişiliğe sahip bir ticaret şirketidir[157]. Tüzel kişilik ise ticaret siciline tescil ile kazanılır. Tescil, aynı zamanda anonim şirketin hak ehliyetini elde etmesinin de koşuludur. Anonim şirket hak ve fiil ehliyetini organları eliyle kullanır. Şirketin tüzel kişiliği, şirket ticaret sicilinden terkin edilinceye kadar devam eder.

D. AMAÇ VE KONU

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir ve faaliyet gösterebilirler. Ultra vires ilkesinin[158] kalkması ile artık anonim şirketler açısından da şirket esas sözleşmesinde yazılı konularla sınırlı olarak faaliyette bulunma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Ancak şirketin esas sözleşmesinde yine de faaliyet konularının yazılması gereklidir. Zira bu hususu düzenleyen TTK m.339/2-b hükmünde "*esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun esas sözleşmeye yazılması*" şart koşulmuştur.

E. ORTAKLARIN SINIRLI SORUMLULUĞU

Sermaye şirketlerinin tipik örneği olan anonim şirketleri diğer ticaret şirketlerinden ayıran en temel özelliklerden biri, ortakların sorumlu-

---

157 Tüzel kişilik hakkında geniş bilgi için bkz. Birinci Bölüm, § 2, B başlığı.

158 Ultra vires: Gerçek veya tüzel kişinin ya da mahkemenin hukuk tarafından veya anayasa tarafından tanınan yetkileri aşmalarıdır (**Yılmaz,** s. 712-713). Şirketler hukuku açısından, şirketlerin sözleşmelerinde yazılı ehliyetinin aşılmasıdır, bkz. **Yıldız**, B., "*TTK Tasarısı'nda Şirketlerin Ehliyeti Ve Bu Bağlamda TTK m. 137 Hükmündeki "Ultra Vires" Sınırlamasının Yerindeliğinin Değerlendirilmesi*", AÜHFD, 2006, C. 55, S. 1-2, s. 321 vd.

luğunun şirkete getirmeyi taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı olmasıdır. Şayet ortak, taahhüt ettiği sermayeyi şirkete getirmişse artık şirkete karşı veya şirket alacaklılarına karşı bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Bu sebeple alacaklılar ancak şirket malvarlığından alacaklarının karşılanması için talepte bulunabileceklerdir. Pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile sınırlı olarak şirkete karşı sorumlu olacakları hususu TTK m.329/2 hükmünde açıkça ortaya konmuştur.

IV) ANONİM ŞİRKET TÜRLERİ

A) ORTAK SAYISI AÇISINDAN

Ortak sayısı açısından anonim şirketler, tek ortaklı anonim şirket ve çok ortaklı anonim şirket olarak ikiye ayrılabilir. Birden çok ortaklı anonim şirket, tipik anonim şirket olarak da ifade edilmektedir. Tek ortaklı anonim şirket ise ya başta tek kişi tarafından kurulmuş ya da kuruluştan sonra ortak sayısı bire inmiş anonim şirket olarak karşımıza çıkar. Anonim şirketin tek kişilik anonim şirket olması halinde kural olarak, TTK hükümlerinden bazılarının uygulanması mümkün olmaz (genel kurul toplantı daveti vs.).

B) TÂBİ OLDUKLARI HÜKÜMLER AÇISINDAN

Tâbi oldukları hükümler açısından anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'na tâbi anonim şirketler ve özel kanun hükümlerine tâbi anonim şirketler veya hakkında özel kanun çıkarılmış anonim şirketler olarak tasnif edilebilirler. Özel kanun hükmü olarak Sermaye Piyasası Kanunu yanında Bankacılık Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu gibi kanunlar sayılabilir. Anılan kanunlara tâbi olacak anonim şirketler hakkında öncelikle bu kanunlar uygulanır; hüküm bulunmayan hallerde ise TTK'nın anonim şirketlere ilişkin hükümleri uygulanır. Hakkında özel kanun çıkarılmış anonim şirketlere örnek olarak T.C. Merkez Bankası A.Ş., İller Bankası A.Ş. gösterilebilir. Bu şirketlerin kuruluşu ve işleyişi ise özel olarak çıkarılan kendi kanunlarında düzenlenmiştir.

C) HALKA AÇIK OLUP OLMAMA AÇISINDAN

Halka açık olup olmama açısından anonim şirketler kapalı anonim şirket ve halka açık anonim şirket olarak ikiye ayrılabilirler. Halka açık

anonim şirketler, payları borsada işlem gören şirketler ile kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan şirketler hariç olmak üzere, pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim şirketler şeklinde kendi içerisinde tekrar ikiye ayrılabilir. HAAŞ esas itibarıyla Sermaye Piyasası Kanununda (SPK) düzenlenmiştir. SPK'da hüküm bulunmayan hususlarda ise TTK hükümleri uygulanacaktır (SPK m.2/2).

D) ÖLÇEKLERİ AÇISINDAN

Ölçeklerine göre anonim şirketler Türk Ticaret Kanunu'nda küçük, orta ölçekli anonim şirketler ve büyük ölçekli anonim şirketler şeklinde ayrıma tâbi tutulmaktadır (TTK m.1522, 1523). Ölçütlerin ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir[159].

E) BAĞIMSIZ DENETİME TÂBİ OLUP OLMAMALARI AÇISINDAN

Anonim ortaklıkların denetimine ilişkin TTK m.397/4 hükmünde, 398. madde kapsamında denetime tâbi olacak şirketlerin Bakanlar Kurulunca (Cumhurbaşkanınca) belirleneceği ifade edilmiştir. Bakanlar Kurulu da bağımsız denetime tâbi olacak şirketlerin belirlenmesine dair kararı kabul ederek resmî gazetede yayımlamıştır[160]. Bunun yanında bağımsız denetime tâbi olan anonim şirketler dışında kalan şirketlerin denetimi konusunda da bir yönetmelik çıkarılmasına ilişkin TTK m.397 hükmüne fıkra eklenmiş, ancak anılan yönetmelik, hazırlıkları tamamlandığı halde halen yayınlanmamıştır. Dolayısıyla bağımsız denetime tâbi anonim şirketlerin dışında kalan anonim şirketler açısından denetim söz konusu değildir. Bağımsız dış denetim konusu ise ileride ayrıntılı olarak ele alınacağından burada daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir[161].

---

159 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan yönetmelik birden çok kez değişikliğe uğramıştır. Buna göre küçük ve orta boy işletmeler yıllık çalışan sayısı 250'nin altında olan ve yıllık satış hâsılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve anılan yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükte işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder (m.4/I-b).

160 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı karar için bkz. 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete.

161 Bkz. aşağıda Dokuzuncu Bölüm, § 12, III başlığı.

V) ANONİM ŞİRKETLERE HÂKİM OLAN İLKELER

A) ÇOĞUNLUK İLKESİ

Anonim şirketlerde gerek yönetim kurulunda gerekse genel kurulda alınacak kararlar daha ziyade oy çokluğu ilkesine dayalıdır. Şirketin merkezinin yurt dışına taşınması ve bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararların alınması gibi çok önemli kararlar için öngörülen oy birliği ile esas sözleşme değişiklikleri için aranan ağırlaştırılmış nisaplar dışında kalan hallerde toplantı ve karar nisabı açısından oy çokluğu yeterli görülmüştür. Ayrıca söz konusu özel haller dışında toplantı ve karar yetersayıları oldukça düşük tutulmuştur. Zaten doğası gereği ortak sayısı çok fazla olan HAAO'larda oy birliğini sağlamak neredeyse imkânsızdır.

Çoğunluğun tespiti açısından kanun koyucu genel olarak sermaye payını esas almakla birlikte (esas sözleşme değişikliklerinde) bazı hallerde oy çoğunluğunu (genel kurul toplantılarında), bazı hallerde ise kişi sayısını (yönetim kurulu toplantı ve kararlarında) esas almıştır. Kanunda çoğunluğun belirlenmesinde açıkça üye sayısının veya sermaye payının esas alınmadığı hallerde çoğunluk, oy sayısı esasına göre hesaplanmalıdır.

Çoğunluk ilkesinin uygulanmasının yol açabileceği bazı sakıncaları giderebilmek için kanun koyucu bazı başka tedbirler de öngörmüştür. Özellikle azınlığın korunması amacıyla tanınan bazı haklar (genel kurul kararlarının iptali, bilanço görüşmelerinin ertelenmesi gibi) ile eşit işlem ilkesi (TTK m. 357) gibi ilkelerle çoğunluğun azınlığa zarar vermesinin de önüne geçilmek istenmiştir. Bu gibi hallerde anonim şirketlerde yüzde on azınlığa ve HAAO'larda ise yüzde beş azınlığa koruyucu haklar tanınmıştır.

B) HAKLARDAN SERMAYEYE KATILMA ORANINDA YARARLANMA İLKESİ

Sermaye şirketi olarak anonim şirketlerde ortağın kişiliği değil getirdiği/getirmeyi taahhüt ettiği sermaye payı önem taşır. Her bir ortak şirket sermayesine katıldığı ölçüde şirketle ilgili konularda hak sahibi olur. Özellikle kâr payı, tasfiye payı, hazırlık devresi faizi ve yeni pay alma gibi mali haklarla, şirkete yönetici seçme gibi oy hakkının kullanılmasında sermayeye katılma oranı belirleyici rol oynar. Bazı hallerde ise haklardan sermayeye katılma oranında yararlanma ilkesi sınırlandırılmış

veya tamamen ortadan kaldırılmış olabilir. Esas sözleşmeye konulacak hükümle bazı paylara imtiyaz tanımak suretiyle bir kısım haklar açısından sermayeye katılma oranından ayrılmak mümkündür. Buna karşılık genel kurulun alacağı bir kararla bazı pay sahiplerinin genel kurula katılması, konuşması veya öneride bulunması engellenemez; iptal davası açma hakkı kaldırılamaz, pay sahiplerinin şirketin tesislerinden yararlanması yasaklanamaz[162]. Söz konusu hallerde küçük bir payın sahibi ile payların çoğunluğuna sahip olan kişi arasında bir fark bulunmamaktadır.

C) DEVLETİN İLGİLENMESİ İLKESİ

Anonim şirketlerin anonimlik özelliği sebebiyle birbirini tanımayan sermaye sahiplerinin bir araya geliyor olmaları bazı tehlikeleri de beraberinde getirebilir. Özellikle çok sayıda küçük pay sahibinin bir araya geldiği ancak şirket yönetiminde etkin olmadıkları hallerde şirket iyi örgütlenmiş bir azınlık grubun eline geçebilir ve şirketin içinin boşaltılması gibi bazı riskler ortaya çıkabilir. Yine faaliyet konusu kamu hizmeti olan bir anonim şirketin faaliyetlerini sorunsuz sürdürmesinde bütün kamunun menfaati olduğu için devlet bunlarla ilgilenme ihtiyacı hissedebilir. Devlet bu ilgisini bazı şirketlerin kuruluşunda Ticaret Bakanlığının iznini aramak suretiyle (m.333), genel kurulda temsilci bulundurmak suretiyle (m.407/3), şirketin yönetim kuruluna temsilci atamak suretiyle (m.334) veya bazı şirketleri dışarıdan denetlemek suretiyle (m.210) gösterir. Devletin ilgisi bazı hallerde şirketin feshini talep edebilecek kadar yoğundur (TTK m.210/3). HAAO bakımından ise Sermaye Piyasası Kurulunun çok geniş denetleme ve gözetleme yetkisi bulunmaktadır.

D) EMREDİCİ HÜKÜMLER İLKESİ

Anonim şirketler hukukuna 6102 sayılı TTK ile giren bu ilke gereğince artık anonim şirket esas sözleşmesi TTK hükümlerinden ancak bu Kanunda izin verilen hallerde sapabilecektir (m.340). Esas sözleşmede TTK'den sapmak ancak "*esas sözleşme ile kararlaştırılabilir veya öngörülebilir*" yahut "*esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, aksi öngörülmemişse*" şeklinde açıkça izin verilmesine bağlıdır[163]. Kanun hükmünden, TTK'nın anonim şirketlerle ilgili hükümlerinin tama-

---

[162] **Pulaşlı**, C. I, §15 N. 8.
[163] **Pulaşlı**, C. I, §15 N. 22.

mının emredici olduğu sonucu çıkmaktaysa da bu yanlışlığın temelinde mehaz APOK § 23/5 hükmünün eksik olarak alınması yatmaktadır. Oysa anılan mehaz düzenlemede sadece kanunun emredici hükümleri açısından esas sözleşmede bir sapmaya yasak getirildiği, tamamlayıcı hükümler açısından böyle bir yasağın getirilmediği görülmektedir[164].

Emredici hükümlere ilişkin düzenlemeye aykırılık halinde uygulanacak yaptırım belirtilmemiştir. Doktrinde emredici hangi hükme aykırılık varsa o hükme aykırılığa ilişkin yaptırımın uygulanması gerektiği görüşü dile getirilmiştir[165]. Örneğin şirketin temel yapısı ile ilgili hükümlere aykırı bir esas sözleşme hükmünün (sermayenin 50.000 TL'nin altına indirilebilmesine ilişkin hükmün) batıl olması gerektiği, pay sahibi olmayan kişilerin genel kurula katılabilmesine ilişkin esas sözleşme hükmünün ise iptal edilebilir olması gerektiği haklı olarak ifade edilmiştir[166].

E) EŞİT İŞLEM İLKESİ

Anonim şirketler hukukunda eşit işlem ilkesinin yansıması, işlemlerin türü ve işlemin taraflarına göre farklı şekillerde ortaya çıkabilmektedir. Bu anlamda eşit işlem ilkesinin kaynağını teşkil eden eşitlik, anonim şirketler hukukunda daha ziyade sayı olarak (mutlak) eşitlik veya orantılı (nisbî) eşitlik olarak karşımıza çıkar[167].

Sayı olarak eşitlik, kuralın uygulanacağı kişilerin durumlarını ve farklılıkları göz önüne almadan her bir kişi veya durum için aynı kuralın uygulanmasını ifade eder. Bu ilkenin şirketler hukukunda kısmen geçerli olduğunu, örneğin pay sahipliği haklarının uygulanmasında, imtiyazlı olsun olmasın her bir payın en az bir oy hakkı verecek olmasında, tek bir pay sahibinin de genel kurul kararlarının iptalini isteyebilmesinde, her bir pay sahibinin bilgi alma hakkının olmasında, her bir pay sahibinin sorumluluk davası açabilecek olmasında görüldüğü gibi[168]. Bu ilkenin uygulanması birçok halde haksızlığa yol açabilir ise de bazı

---

164 **Karasu**, s. 67 vd.; **Kaşak, F. E.:** Sözleşme Özgürlüğünün Sınırı Olarak Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılık, İstanbul 2019, s. 293 vd.

165 **Karasu,** s.70; **Pulaşlı**, C. I, §15 N. 34, 36.

166 **Pulaşlı**, C. I, §15 N. 34, 36.

167 Bunların yanında bir de biçimsel eşitlik ilkesinden söz edilmekteyse de bu ilkenin anonim şirketler hukukunda uygulanması söz konusu olmamaktadır. Ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. **Yıldız,** s. 32.

168 **Meier-Hayoz/Forstmoser**, § 16, N. 147.

hallerde uygulanmaması da haksızlık yaratabilir. Doktrinde bu ilkenin şirket ortağına tanınan koruyucu haklar açısından uygulanmasının; yararlanma, elde etme ve menfaat sağlama hakları açısından ise uygulanmamasının daha adaletli olacağı görüşü haklı olarak ifade edilmiştir[169].

Orantılı eşitlikte ise esas olan işlemin eşit olması değil sonucun eşit olmasıdır. Anonim şirket ortaklarının haklardan yararlanmada, örneğin kârdan veya tasfiye bakiyesinden pay almada sermayeye katılma oranlarının esas alınması neticesinde pay sahipliği oranına göre sonuca varılması aslında her bir pay açısından sayısal eşitlik ilkesinin de bir neticesini doğurur. Ancak bazı hallerde orantısal eşitlik ilkesi çoğunluğun dilediğini yaptırabilmesi, azınlığın haklarının zarar görmesine yol açabilir. Bu sebeple, bazı hususlarda kanun koyucunun sayı olarak eşitlik ilkesini özellikle gözettiğini ve sayısal eşitlik ilkesinin uygulanmasını düzenleyen kuralların emredici mahiyette olduklarını söyleyebiliriz[170].

Türk hukukunda daha önce ayrı bir düzenlemenin konusu olmayan, daha ziyade Yargıtay kararları ile kabul edilen eşit işlem ilkesi TTK gerekçesinde bir üst kural[171] olarak açıkça ifade edilmiş ve m.357 hükmünde pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tâbi tutulacakları şeklinde kaleme alınmıştır. Düzenleme bu haliyle 2012/30/EU no.lu AB yönergesinin 46. maddesinde yer alan eşit işlem ilkesi ile de benzerdir. Ancak "*pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işlem ilkesine tâbi tutulacakları*" şeklindeki ifade çok açık olmamıştır. Hâlbuki bunun yerine AB yönergesindeki hükme benzer "*aynı durumda bulunan pay sahiplerine eşit davranılması gerektiği*" şeklinde kaleme alınması daha isabetli olurdu[172].

Türk Ticaret Kanunu'nda eşit işlem ilkesinin bir yansıması olarak, yönetim kurulu kararlarının butlanını düzenleyen m.391/1-a hükmünde eşit işlem ilkesine aykırı yönetim kurulu kararlarının butlanının tespitine imkân tanınmıştır[173]. Anılan hükmün gerekçesinde açıkça İsviçre

---

169 **Huguenin, J. C.,** Das Gleichbehandlungsprin zip im Aktienrecht, Zürich 1994, s. 37; **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** I, N. 1859; **Kendigelen**, s. 42, **Yıldız**, s. 34.

170 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** I, N. 879; **Yıldız**, s. 36.

171 TTK m.357 gerekçesi.

172 Art. 46, 2012/30/EU "*Für die Anwendung dieser Richtlinie müssen die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die Gleichbehandlung der Aktionäre sicherstellen, die sich in denselben Verhältnissen befinden.*".

173 TTK m.391/1-a hükmünde butlan sebebi olarak yer alan bu husus mehaz İsviçre hukukunda bir iptal sebebi olarak Art. 706, 2, b. 3 OR hükmünde yer almaktadır.

uygulamasına ve eSPK m.12 hükmüne atıf yapılarak, sayma yoluyla butlan sebepleri belirlenmiş ve düzenlemenin amacının pay sahiplerinin daha güçlendirilmesi olduğuna işaret edilmiştir. Eşit işlem ilkesine aykırılığın da bir butlan sebebi olarak ele alınmış olması, ilkenin yerleşmesine önemli katkıda bulunacaktır.

F) BORÇLANMA YASAĞI

Anonim şirkete borçlanma yasağı hem pay sahiplerinin şirkete borçlanma yasağını hem de yöneticilerin veya yakınlarının şirkete borçlanma yasağını kapsamaktadır. Bu sebeple konu TTK'de iki ayrı maddede ele alınmıştır.

1. Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanma Yasağı

Anonim şirkete borçlanma yasağına ilişkin düzenlemelerden ilki TTK m.358 hükmüdür. Buna göre pay sahipleri, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını ifa etmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte kârı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamaz. Bu koşullara uyulması kaydıyla pay sahipleri diledikleri kadar, diledikleri zaman ve diledikleri şekilde şirkete borçlanabilirler.

Yasak kapsamına girenler pay sahipleri ile intifa hakkı sahipleridir. Buna karşılık intifa senedi sahipleri, rehin ve hapis hakkı sahipleri ile pay sahibinin vekili, velisi, vasisi veya temsilcisi gibi kişiler yasak kapsamında değildirler.

Alman hukukunda APOK § 57 Abs. 3 gereğince ortaklara sadece bilanço kârı dağıtılabilir. Pay sahipleri şirkete piyasa koşullarına aykırı şekilde borçlanamazlar (APOK §57 Abs. 1, S. 3). Aksi halde sermayenin iadesi yasağına ilişkin hükümler devreye girer.

İsviçre hukukunda konu özellikle vergi hukuku yönünden ele alınmış ve faizsiz olarak borç verilmesi örtülü kazanç aktarımı olarak nitelendirilmiştir (BGE 138 II 57, 30.01.2012). Ayrıca ciddi bir ödeme planının varlığı da aranmıştır.

Pay sahibinin TTK m.358'e aykırı şekilde şirkete borçlanması halinde, pay sahibine söz konusu borcu verenler (yönetim kurulu üyeleri) 300 günden az olmamak üzere adli para cezası ile cezalandırılırlar (TTK m.562/5-b). Bunun yanında koşulları var ise şirkete borçlanan pay sahiplerinin TCK m.155 çerçevesinde cezalandırılması da söz konusu olabilir.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yakınlarının Şirkete Borçlanma Yasağı

Anonim şirkete borçlanma yasağının ikinci kısmı pay sahibi olmayan anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin ve yakınlarının şirkete borçlanma yasağına ilişkindir. Buna göre; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü maddede sayılan yakınları (alt ve üstsoydan biri, eş ile üçüncü derece dâhil kan ve kayın hısımları) şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi halde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

TTK m.395/2 birinci veya ikinci cümlesi hükümlerini ihlal edenler *üç yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla* cezalandırılır (TTK m.562/5-c).

G) MALVARLIĞININ KORUNMASI İLKESİ

Anonim şirket, alacaklılara karşı yalnız malvarlığı ile sınırlı şekilde sorumlu olduğundan, şirket malvarlığının korunması şahıs şirketlerine kıyasla çok daha fazla önem taşır. Kanun koyucu anonim şirket malvarlığının korunabilmesi için şirketin kuruluşu aşamasından itibaren uyulması gerekli katı kurallar öngörmüştür. Bunlar arasında;

-sermayenin tamamının kurucular tarafından taahhüt edilmesi,

-itibari değerinin altında pay çıkarılamaması,

-ayni sermayeye bağımsız bilirkişilerce değer biçilmesi,

-nakit sermaye koyma borcunun en az dörtte birinin peşin ifası,

-kâr payının sadece safi kârdan ödenebilmesi,

-sermaye için faiz ödenmesinin yasak olması,

-sermayenin belirli oranların üstünde azalması halinde gerekli tedbirlerin alınması zorunluluğu,

-şirketin kendi paylarını iktisap edebilmesinin koşullara bağlı olması,

-kanuni yedek akçe ayrılması zorunluluğu

yer almaktadır.

§9- ANONİM ŞİRKETİN KURULUŞU

LİTERATÜR

Akdağ Güney, N.: *Anonim Şirketlerde Kuruluş*, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014; Akın, M. Y.: *İsviçre Hukuku Örneğinde Türk Medeni Kanunu Madde 47/11 ile Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Madde 353 Üzerine Düşünceler,* Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, 26(1), 175-227; Arıcı, F.: Alacak Hakkının Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taahhüdü, İstanbul 2003; Bahtiyar, M.: *Anonim Ortaklık Anasözleşmesi,* İstanbul 2001; Çağlar, H.: *Anonim Şirketlerde Ayni Sermaye Değer Biçilmesi,* BATİDER, C. XXIV, S. 2, s. 35 vd.; Kendigelen, A.: *İsviçre Hukukunda Oy Hakkında İmtiyazlı Paylar (*Stimmrechtsaktie), Oğuz İmregün'e Armağan, İstanbul 1998, s. 335 vd.; Paslı, A.: *Yeni Türk Ticaret Kanunu, Anonim Ortaklık Hükümlerinin Tanıtılması (II) YTK Kitap 2. Kısım 4. Bölüm "Kuruluşa İlişkin Sisteme Yönelik Temel Değişiklikler ve Kuruluş İşlemleri*, BATİDER, C. XXVIII, 2012, S. 1 s. 141-198; Pulaşlı, H.: *Alman Federal Mahkemesinin Ön Şirkete İlişkin 23.10.2006 tarihli Kararı ve Türk Ticaret Kanununu Tasarısı Bakımından Değerlendirilmesi*, Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007, S. 467 vd.

I) KURULUŞ İŞLEMLERİ

Anonim şirket basit kuruluş veya nitelikli kuruluş şeklinde kurulabilir. Basit kuruluşta sadece nakit sermaye ile kuruluş söz konusudur. Nitelikli kuruluşta ise nakit yerine başka bir malvarlığı unsuru (ayın) sermaye olarak şirkete konulmaktadır. Aralarındaki fark taahhüt edilen sermayenin niteliği ve sermaye koyma borcunun yerine getirilmesi zamanı ile ilgilidir. Bu sebeple farklılıklara yeri geldiğince değinilecek ancak konu tek bir başlık altında anlatılacaktır.

A) ESAS SÖZLEŞMENİN HAZIRLANMASI

Anonim şirket kurmak isteyen kişi veya kişiler, öncelikle kurmak istedikleri anonim şirketin anayasası mahiyetinde olan ve şirketin işleyişinde temel alınacak esas sözleşmeyi hazırlamalıdır. Esas sözleşmeyi hazırlayanlar kurulacak müstakbel şirketin kurucusu konumundadır.

Kurucu veya kurucular gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Yeni TTK'da asgari kurucu ve ortak sayısı belirtilmediğinden, artık anonim şirket tek bir kişi tarafından da kurulabilir.

Hazırlanacak esas sözleşmenin içeriği TTK m.339 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır[174].

Esas sözleşmenin anonim şirketlere ilişkin TTK hükümlerinden sapabilmesi Kanunda buna açıkça izin verilmiş olması koşuluna bağlı olduğundan, esas sözleşmenin hazırlanması sırasında bu hususa dikkat edilmesi gerekir (TTK m.340). Uygulamada ticaret odaları tarafından hazırlanmış örnek sözleşmelerin kullanıldığı görülmektedir.

Esas sözleşmede yer alması zorunlu olan unsurları ve ihtiyari unsurları ayrı ayrı ele almak uygun olacaktır.

1) Esas Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Unsurlar

a) Kurucu/Kurucular

Anonim şirkette kurucular gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Buna karşın gerçek veya tüzel kişiliği olmayanlar, kurucu olamayacakları gibi ortak da olamazlar. Bu çerçevede adi şirket veya donatma iştiraki gibi tüzel kişiliği olmayan yapılar kurucu veya ortak olamazlar. Buna karşın kurucu veya ortak olmak için fiil ehliyetinin bulunması gerekmez; hak ehliyetine sahip olunması yeterlidir.

b) Ticaret Unvanı

Anonim şirketin ticaret unvanına ilişkin olarak TTK m.329 vd. hükümlerinde bir düzenleme bulunmasa da tacirin ticaret unvanının düzenlendiği kısımda açıkça anonim şirketin ticaret unvanının nasıl oluşturulacağı düzenlenmiş bulunduğundan yeni Kanun döneminde de anonim şirketin bir ticaret unvanı alması zorunluluğunun devam ettiği kabul edilmelidir.

---

[174] Limited şirketler açısından 18.02.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile imzanın ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda atılması şarttır.

c) Şirket Merkezinin Bulunacağı Yer

Anonim şirketin merkezi Türkiye'nin herhangi bir yerinde bulunabilir. Merkez olarak ticari faaliyetlerin yoğunlaştığı yerin seçilmesi zorunlu değildir. Şirketin merkezinin neresi olduğu hem şirketin tescil edileceği ticaret sicilinin belirlenmesinde hem de şirketle ilgili veya şirkete karşı açılacak davaların görüleceği yetkili mahkemenin belirlenmesinde önem taşır. Merkezin belirlenmiş olması özellikle şirketin şubelerinin ve başkaca amaçla kurulmuş birimlerinin bulunması halinde bunlardan hangisinin şirket merkezi olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda belirsizliğe yol açabileceğinden önceden tespit edilerek sözleşmeye yazılmalıdır. Şirketin tek bir merkezinin bulunması gerekir. Şirket sözleşmesinde yer alan merkezin değiştirilebilmesi için esas sözleşmede değişiklik yapılması gerekir; merkez yurt dışına taşınacaksa, buna ilişkin genel kurul kararının tüm pay sahiplerinin oybirliğiyle alınması gerekir.

d) Şirketin İşletme Konusu

TTK m.339/2-b bendinde "*esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış işletme konusu*" nun esas sözleşmede yer alması gerektiği açıkça ifade edilmiştir. Bu halde şirketin ekonomik amacını gerçekleştirmek için faaliyet konularının belirlenmiş olması zorunludur. Uygulamada şirketin faaliyet konularının çok geniş tutulduğu görülmektedir. Böylece yeni bir faaliyet alanına girilmesi halinde, her seferinde esas sözleşme değişikliği yapılması zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.

e) Şirketin Sermayesi ile Her Payın İtibarî Değeri, Bunların Ödenmesinin Şekil ve Şartları

TTK m.339/2-c bendine göre, şirketin sermayesinin, her payın itibari değerinin ve bunların ödenme şekil ve şartlarının yazılması gerekir. Anonim şirketin esas sermayesi asgari 50.000TL'dir. Sermaye nakit olarak ödenecek ise şirketin kuruluşundan önce en az yüzde yirmi beşinin ödenmesi gerekir. Kalan miktarın da tescilden itibaren en geç yirmi dört ay içerisinde ödenmesi şarttır.

Şirketin sermayesinin bölüneceği pay sayısının ve her bir payın itibari (nominal) değerinin de esas sözleşmede belirlenmiş olması zorunludur.

Pay karşılığı olan sermaye taahhüdü nakit dışında unsurlarla karşılanacak ise bunların şirketin kuruluşundan önce şirkete getirilmesi gerekir. Bu amaçla ayın sermayeye mahkemelerce atanmış bağımsız bilirkişilerce değer biçilmesi, gayrimenkullerin veya sicile kayıtlı malvarlığı unsurlarının ilgili sicile şerh verilmek suretiyle şirkete tahsis edilmesi, menkul varlıkların ise güvenilir bir kişiye tevdi edilmesi gereklidir.

f) Pay Senetlerinin Türü

Anonim şirket pay senetleri nama veya hamiline yazılı olabilir (TTK m.484/1). Şirket esas sözleşmesinde pay senetlerinin hamiline mi yoksa nama yazılı mı olacağı hususu belirtilmelidir. Hamiline yazılı payların bastırılabilmesi için bedellerinin tamamen ödenmiş olması gerekir (TTK m.484/2).

g) Devir Sınırlamaları

Anonim şirketin temel özelliklerinden biri payların kolayca el değiştirebilmesidir. Buna karşılık nama yazılı payların devri sınırlandırılabilir. Kanuni sınırlandırmaların esas sözleşmede yer alması gerekli değilken devir iradi olarak sınırlandırılmak isteniyorsa bu hususun esas sözleşmeye konulması gerekir. İşte esas sözleşmeye konulacak hükümle nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği şeklinde bir devir sınırlandırması öngörülebilir ve bu sınırlandırmalar "*bağlam*" olarak nitelendirilir. (TTK m.492). Bu halde çıkarılacak paylara da "*bağlı nama yazılı pay*" adı verilir.

h) Paradan Başka Sermaye Olarak Konan Haklar ve Ayınlarla İlgili Bilgiler

Anonim şirkete sermaye olarak para dışında hangi unsurların getirilebileceği TTK m.342 hükmünde yer almaktadır. Sermaye olarak konacak unsurların ne şekilde şirket sözleşmesinde yer alacağı hususu ise TTK m.339/2-e hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre sermaye olarak konan haklar ve ayınlar ile bunların değerleri, bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir ayın veya işletmenin devralınması halinde bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleri ve şirketin kurulması sırasında hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarının da esas sözleşmede gösterilmesi gerekir.

ı) Kurucularla Yönetim Kurulu Üyelerine ve Diğer Kimselere Şirket Kârından Sağlanacak Menfaatler

Anonim şirketin kurucularına, yönetim kurulu üyelerine ve diğer başka kişilere şirket kârından menfaat sağlanması söz konusu olacaksa bunların da şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur.

i) Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Bunlardan İmzaya Yetkili Olanlar ve İlk Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim kurulu üye sayısı bir veya daha fazla olabilir. Üyelerin tamamı imzaya yetkili olabileceği gibi bunların sadece birine veya bir kısmına imza yetkisi verilebilir. Hem üye sayısının hem imzaya yetkili olan üyelerin hem de ilk yönetim kurulu üyelerinin kimler olduğu hususları esas sözleşmede yer alması gereken konulardandır.

j) Genel Kurulların Toplantıya Nasıl Çağırılacakları, Oy Hakları

Anonim şirket genel kurul toplantılarına çağrının ne şekilde yapılması gerektiği, TTK m.414 hükmünde ifade edilmiştir. Buna göre çağrının, şirketin internet sitesinde (internet sitesi açma zorunluluğu bulunan şirketler açısından), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket sözleşmesinde yer alan şekilde yapılması zorunludur. İşte şirket anılan hükümde yer alan şekillerin dışında bir çağrı usulü benimsemişse, bunun da esas sözleşmede yer alması gerekir.

Anonim şirketlerde paylara oyda imtiyazların tanınması veya oy hakları bakımından sınırlamaları söz konusu olabilir. İşte bunların da sözleşmeye derç edilmesi gerekir.

k) Şirkete Ait İlânların Nasıl Yapılacağı,

Anonim şirkete ait ilanların hangi yöntemle ve ne şekilde yapılacağı hususunun da şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur.

l) Pay Sahiplerinin Taahhüt Ettiği Sermaye Paylarının Türleri ve Miktarları

Pay sahiplerinin her birinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ile miktarlarının da şirket esas sözleşmesinde yer alması gerekir. Ayrıca şirketin kuruluşunda nakit dışı sermaye taahhüt edilmesi söz konusu ise bunların türleri, değerleri ve bunların karşılığında verilecek payların

miktarı, bir işletme veya aynın devralınması söz konusu olduğunda bunların bedeli de esas sözleşmede yer almalıdır.

m) Şirketin Hesap Dönemi

Her ne kadar finansal tabloların yıllık olması zorunluluğu, hesap döneminin de vergi düzeni sebebiyle yıllık olması gerekliliği karşısında şirketin hesap dönemi belirlemesi mümkün olmasa da Kanun gereği şirketin hesap döneminin yıllık olduğu ve bunun da 1 Ocak - 31 Aralık olarak şirket sözleşmesinde yer alması zorunludur. Zorunlu bir unsurun şirket sözleşmesinde yer almaması halinde ise sicil müdürü tescilden imtina edebilecektir.

2) Esas Sözleşmede Yer Alabilecek İhtiyari Unsurlar

Anonim şirket esas sözleşmesinde birçok konuda ihtiyari olarak düzenleme yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte önemli olanlarını aşağıda ayrı başlıklar halinde ele almak uygun olacaktır.

a) Varsa Şirketin Süresi

Anonim şirket bir süreye bağlı olarak faaliyet göstermek üzere kurulmaktaysa bu sürenin de şirket esas sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. Uygulamada şirketlerin bir süreye bağlı olarak kurulmadıkları görülmektedir.

b) Şartlı Sermaye Artırma Yöntemi veya Kayıtlı Sermaye Sistemi Kabul Edilmişse Buna İlişkin Hususlar

Anonim şirketlerde esas sermaye sistemi yanında kayıtlı sermaye sistemi de benimsenebilir. Ayrıca sermaye artırımı türü olarak 6102 sayılı TTK ile sistemimize giren şartlı sermaye artırma yöntemi de benimsenmek istenebilir. İşte gerek kayıtlı sermaye sisteminin benimsenmesi gerekse şartlı sermaye artırım yönteminin kabulü halinde bunlara ilişkin hususların da şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi gerekir.

c) Tanınan İmtiyazlar

TTK m.478 uyarınca anonim şirkette bazı paylara imtiyaz tanınmak isteniyorsa bunların şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi gerekir. Unutulmamalıdır ki imtiyazlar paylara tanınabilir ancak istisnaen belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine de tanınabilir (TTK m.360). Bu halde

farklı pay grupları oluşturulması ve farklı imtiyazlar tanınması uygun olacaktır.

B) ANONİM ŞİRKETİN KURULMASI

Türk Ticaret Kanununda belirtilen asgari içeriğe sahip esas sözleşmenin kurucu veya kurucular tarafından hazırlanması veya hazırlatılması işlemini müteakip sözleşmenin anılan kişilerce imzalanması ve imzaların noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması şarttır.

Esas sözleşmenin kurucular tarafından imzalanması, şirketin bu kişiler arasında kurulmuş sayılması için yeterlidir. Zira ortak olmak isteyen kişiler iradelerini yazılı olarak ortaya koymuşlar ve imzaların kendilerine ait olduğu hususu da noter tarafından onaylanmış veya imzalar ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda atılmıştır. "*Ön anonim şirket/ön şirket*" olarak da adlandırılan bu aşamanın etkisi ve sonuçlarının Kanunda düzenlenmemiş olması haklı olarak eleştirilmiştir[175]. Bununla birlikte doktrinde genel kabul, esas sözleşmenin kurucular tarafından imzalanmasıyla ortaklar arasında ön anonim şirketin kurulduğunun kabul edilmesi gerektiği yönündedir[176].

C) SERMAYENİN KISMEN VEYA TAMAMEN ÖDENMESİ

Ticaret şirketlerine sermaye olarak nelerin getirilebileceği genel olarak TTK m.127 hükmünde sayılmıştır. Bununla birlikte anılan hükümde sayılan unsurlardan bazılarının anonim şirkete sermaye olarak konulmasına izin verilmemiştir. TTK m.342/1 hükmünde "*Üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz.*" denilmek suretiyle sermaye olarak konulacak unsurların nitelikleri belirlenmiş ve bazı unsurların da hiçbir surette sermaye olarak konulamayacağına vurgu yapılmıştır. Buna göre bir aynın sermaye olarak anonim şirkete getirilebilmesi için;

1- üzerinde sınırlı ayni hak, haciz ve (veya) tedbir bulunmaması,

2- nakden değerlendirilebilir olması,

---

175 **Pulaşlı**, Şerh C. I, §24, N. 9 vd.

176 **Pulaşlı,** Şerh C I, §24, N. 9 vd.

3- devrolunabilir olması,

gerekir.

Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar ise anonim şirkete sermaye olarak konulamaz. Hizmet edimleri ile vadesi gelmemiş alacaklar açısından bütünüyle yasaklamanın isabetli olmadığı açıktır. Özellikle banka garantili bir çek, henüz vadesi gelmediği için sermaye olarak konulamazken, değeri her zaman değişebilecek bir hisse senedinin sermaye olarak getirilebilmesi düşündürücüdür. Aynı şekilde belirli bir süre için ve önceden kapsamı belirlenmiş bir hizmet edimini şirket dışından daha pahalıya temin etmek yerine şirket kurucularının aynı hizmet edimini benzer koşullarda ve hatta daha ucuza şirkete sermaye olarak taahhüt etmesine izin vermek daha yerinde olabilir.

Esas sözleşmenin hazırlanması ve imzaların noter tarafından onaylanmasını veya ticaret sicili müdürü veya yardımcısı huzurunda imzaların atılmasını müteakip, yapılması gereken işlemlerden ilki nakit olarak taahhüt edilen sermayenin en az yüzde yirmi beşinin ödenmesidir. Geri kalan kısmın ise ortaklığın ticaret siciline tescilinden itibaren yirmi dört ay içerisinde ödenmesi zorunludur. Paylar primli ise çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. Ödemeler kurulmakta olan şirket adına bir bankada açılacak özel bir hesaba yatırılır. Bankaya yapılan ödeme, banka tarafından ticaret sicili müdürlüğüne hitaben yazılacak bir banka mektubu ile ispatlanır. Şirketin tüzel kişilik kazandığının Ticaret Sicili Müdürlüğünce bildirilmesiyle hesap üzerinde şirketçe tasarrufta bulunulabilir.

Şirket, esas sözleşmedeki imzaların noter tarafından onayladığı veya şirket sözleşmesinin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalandığı tarihten itibaren üç aylık süre içerisinde tüzel kişilik kazanamaz ise bu hususu doğrulayan ticaret sicili müdürlüğü yazısı üzerine ödenmiş olan bedeller banka tarafından sahiplerine geri verilir (TTK m.345/2).

Sermaye olarak taahhüt edilen unsur bir taşınmaz ise bilirkişi tarafından belirlenen değeri üzerinden tapuya şerh verilmesi gerekir. Sermaye taahhüdünün konusu fikri mülkiyet hakkı veya başkaca değerler ise varsa özel sicillerine kaydedildikleri ve taşınırlar güvenilir bir kişiye tevdi edildikleri takdirde ayni sermaye kabul olunur.

Şirketin kuruluşunda sermaye olarak taşınmaz mülkiyeti veya taşınmaz üzerinde var olan veya kurulacak olan ayni bir hakkın konulması borcunu içeren şirket sözleşmesi hükümleri açısından resmi şekil aranmayacağı Kanunun 128. maddesinde açıkça ifade edilmiştir.

Anonim şirkete taahhüt edilen sermaye unsurunun nakit dışı bir değer olması halinde, şirketin tüzel kişilik kazanmasını müteakip bunlar üzerindeki mülkiyet hakkını şirket malik sıfatıyla doğrudan kullanmaya başlayabilir. Bununla birlikte sermaye olarak taahhüt edilen değer taşınmaz mülkiyeti veya diğer ayni bir hak ise şirketin tasarruf edebilmesi için tapu siciline tescil gerekir. Tescil işlemi ise şirketin tüzel kişilik kazanması üzerine ticaret sicili müdürü tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirim ile gerçekleştirilir. Ticaret sicili müdürünün re'sen ve hemen bildirimde bulunması zorunluluğu yanında şirketin tek taraflı istemde bulunma hakkı da saklı tutulmuştur (TTK m.128).

Şirkete sermaye olarak bir alacağın taahhüt edilmiş olduğu halde alacak şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcu yerine getirilmiş olmaz. Anılan alacağın şirket esas sözleşme tarihinden itibaren[177] bir ay içinde tahsili gerçekleştirilmelidir. Bu süre içerisinde tahsil edilemediği hallerde şirketin tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla bir aylık sürenin bitiminden itibaren temerrüt faizi istenebilir.

Anonim şirketin paylarının kuruluştan sonra halka arz edilecek olması halinde ise pay bedellerinin ödenmesine dair TTK m.344 hükmü yerine TTK m.346'da yer alan istisna uygulanacaktır.

D) GEREKİYORSA BAKANLIK İZNİ

Türk Ticaret Kanunu m.333 hükmünde, Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğle, faaliyet alanları belirlenip ilân edilen anonim ortaklıkların Bakanlığın izni ile kurulabileceği ifade edilmiştir. 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "*Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tâbi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ*" m.5 hükmüne göre;

---

[177] Her ne kadar TTK m.130/2 hükmünde, vadesi gelmiş alacakların esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edileceği öngörülmüş ise de, "*esas sözleşmenin tarihinden itibaren*" ibaresinin "*şirketin tescil tarihinden itibaren*" şeklinde anlaşılması uygun olur.

Bankalar,

- ❖ Finansal kiralama şirketleri,
- ❖ Faktoring şirketleri,
- ❖ Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri,
- ❖ Varlık yönetim şirketleri,
- ❖ Sigorta şirketleri,
- ❖ Anonim şirket şeklinde kurulan holdingler,
- ❖ Döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler,
- ❖ Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri,
- ❖ Ürün ihtisas borsası şirketleri,
- ❖ Bağımsız denetim şirketleri,
- ❖ Gözetim şirketleri,
- ❖ Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri,
- ❖ Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile
- ❖ Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin

kuruluşları ve esas sözleşme değişiklikleri Bakanlığın iznine tâbidir. Ancak, kayıtlı sermaye sistemine kabul edilen, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi halka açık anonim şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı içinde yapacakları sermaye artışlarında Bakanlık izni aranmaz.

E) TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE İLÂN

Anonim şirket, merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanacağından, şirket esas sözleşmesinin diğer belgeler ile birlikte sicil müdürlüğüne verilmesi ve tescilin yaptırılması gerekir. Şirketin ticaret siciline tescili için kuruculara tanınan süre, bakanlığın iznine tâbi şirketler açısından iznin alınmasından itibaren, diğer anonim şirketler açısından şirket esas sözleşmesinde yer alan imzaların noterce onaylanması işleminden veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması tarihinden itibaren otuz gündür. Bu süreye uyulmamasının yaptırımı Kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak, TTK m.345 hükmünde, noter onay tarihinden veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması tarihinden (ve izne tâbi şirketlerde izin tarihinden) itibaren üç ay içerisinde tüzel kişiliğin kazanılamaması halinde, bu hususu doğrulayan bir sicil müdürlüğü yazısının sunulması üzerine, ödenmiş olan sermaye bedellerinin sahiplerine geri verileceği ifade

edilmiştir. Dolayısıyla üç aylık süre içerisinde şirketin ticaret siciline tescil ettirilmemesi üzerine bazı kurucular sermaye bedellerini geri isteme imkânına kavuşacağından şirketin kurulmasından vazgeçilmesi de gündeme gelebilecektir. Bunun yanında, şirketin ticaret siciline süresinde tescil ettirilmemesinde, gecikmeye sebep olanlar hakkında, diğer koşulların da varlığı halinde, sorumluluk davası açılması söz konusu olabilir.

Ticaret siciline yapılacak tescil ile şirket tüzel kişilik kazanmış olur. Tescil kurucu etkiye sahiptir. Ticaret siciline tescil edilen ortaklığın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilmesi gerekir. Yapılacak ilân açıklayıcı niteliktedir.

II) KURULUŞTAN SONRA PAYLARIN HALKA ARZEDİLMESİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6762 sayılı Kanun zamanında, kanunda yer almasına rağmen uygulaması olmayan tedrici kuruluş sisteminden vazgeçerek, şirketin kuruluşunu müteakip paylarının halka arzı imkânını getirmiştir (m.346). Bunun için şirketin esas sözleşmesinde hüküm bulunmalı, taahhüt ve garanti edilmiş nakit karşılığı payların sahiplerince, şirketin tüzel kişilik kazanmasını müteakip iki aylık süre içerisinde halka arzı geçekleştirilmelidir. Satış süresinin sonunda, payların itibari değerlerinin, varsa çıkarma priminin karşılığı şirkete, giderler düşüldükten sonra kalan tutar ise, pay senetlerini halka arz eden pay sahiplerine ödenir. Pay senetleri Sermaye Piyasası mevzuatına göre halka arz edilir. Halka arz edilip de satılmayan payların bedellerinin tamamı, süresinde halka arz edilmeyen payların bedellerinin ise yüzde yirmi beşi şirketin tescilinden sonraki iki aylık süreyi izleyen üç gün içinde taahhüt edenlerce şirkete ödenir. Sermaye taahhüdünün geriye kalan kısmı da kuruluşu takip eden iki yıllık süre içerisinde yerine getirilmelidir.

III) KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİK VE AYKIRILIKLARIN YAPTIRIMI

Anonim şirketin tüzel kişilik kazanmasından sonra, kuruluş işlemlerinde bir eksiklik veya hukuka aykırılık ortaya çıkarsa artık şirketin yokluğu veya butlanı ileri sürülemez (TTK m.353). Anılan işlemler sebebiyle sadece şirketin feshi davası açılabilir. Fesih davasının açılabil-

mesi için şirketin kuruluşu sırasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay sahiplerinin veya kamunun menfaatlerinin önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş ve ihlal edilmiş olması gerekir. Anılan sebeplerle şirketin feshi davasını açma hakkı yönetim kuruluna, Ticaret Bakanlığına, ilgili alacaklıya ve pay sahiplerine tanınmıştır.

Dava şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde, şirketin tüzel kişilik kazanmasından itibaren üç aylık (hak düşürücü) süre içerisinde açılmalıdır. Mahkeme, davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. Gerçekten de iddia edildiği gibi hukuka aykırılıkların veya eksikliklerin bulunduğu tespit edilirse ortaklığın feshine karar verilir ve durum derhal ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. Fesih kararı ileriye etkili sonuçlar doğurur. Şirketin tüzel kişilik kazanmış olmasına güvenerek ortaklıkla işlem yapmış olan kişilerin hakları da böylece korunmuş olur.

IV) KURULUŞ SIRASINDA YAPILAN İŞLEMLERDEN ORTAKLIĞIN SORUMLULUĞU

Anonim şirketin kuruluş işlemleri sırasında ve tüzel kişilik henüz ortaya çıkmadan önce kurucular tarafından şirket adına işlem yapılmış olması halinde bu işlemlerden doğacak sorumluluk TTK m.355/2 hükmünde özel olarak düzenlenmiştir. Buna göre tescilden önce şirket adına işlem yapanlar veya taahhütte bulunanlar bu işlem veya taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumlu olmakla birlikte, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içerisinde bu işlem ve taahhütler şirket tarafından kabul edilmişse yalnız şirket sorumlu olur.

Kuruluş sırasında yapılan giderler şirketçe kabul olunmadığı takdirde bunlara kurucuların katlanması gerekir. Kanunda bu giderlerin diğer pay sahiplerine rücu edilmesi de yasaklanmıştır (TTK m.355/3).

V) KANUNA KARŞI HİLE

Şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz (m.356/1). Bu halde genel kurulun

toplantı ve karar nisabı sermayenin ¾'ü olarak önceki kanuna göre ağırlaştırılmıştır[178]. Düzenlemenin amacı şirketin kuruluşunda getirilmek istenen ayın sermayeye mahkeme marifetiyle değer biçilmesinden kaçınılması ve şirketin kuruluşundan hemen sonra söz konusu aynın değerinden yüksek bedelle şirkete alınmasının önüne geçilmesidir[179].

---

178 6762 s. TTK m.311'e göre toplantı nisabı sermayenin yarısı, karar nisabı ise mevcut reylerin ekseriyeti şeklinde idi.

179 Tek kişilik anonim şirkette ise şirket genel kurulunda karar alınması sorunu çözmeyecek, sonradan şirkete ortak olanların veya şirket alacaklılarının dikkatli olması gerekecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

§10- ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU

LİTERATÜR

Aydın, A.: *"Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üye Sayısının Belirlenmesi"*, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan, İÜHFM, C. XXXI, S. 2, İstanbul 2013, s. 21 vd.; Ayhan, R.: *Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr ve Kazanç Paylarının İadesi*/Ulusoy, Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, s. 97-138; Bozer, A.: *"Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Üyelerinin Kazanç Payları"*, Batider C. IV, S. 4, s. 675 vd; Chapuis, C.: *Schweizerisches Obligationenrecht, OR Kommentar, OFK-Orell Füssli Kommentar,* Hrsg: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankha-user, 3. Aufl. 2016; Çamoğlu, E.: *"Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Ortaklıkla İşlem Yapma Yasağı"*, İkt. Mal., C. XVII, S. 2 (Mayıs 1970), s. 78 vd.; Çamoğlu, E.: *"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Bakış"*, Yargı Dünyası, S. 212, Ağustos 2013, s. 11 vd.; Çamoğlu, E.: *"Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyesi Sıfatının Kazanılması ve Kaybedilmesi"*, Yargı Dünyası, S. 190 Ekim 2011, s. 11 vd; Çamoğlu, E.: *Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu*, İstanbul 1972; Kalender, E.: *Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.392),* Ankara 2017; Mimaroğlu, S. K.: *Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti*, Ankara 1967; Odman Boztosun, A.: *Hukuksal Açıdan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği*, Ankara 2013; Öçal, A.: *"Huzur Hakkı"*, Batider C. IV, S. 4, s. 616 vd.; Özdamar, M., *"6552 Sayılı Kanun İle TTK'da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili"* Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, S. 3-4, s. 153 vd.; Özdamar, M.: *Banka Yöneticilerinin Mali Hakları*, Yetkin Yayınları, Ankara 2016; Pekcanıtez, H./Sungurtekin Özkan, M./Özekes, M./Atalay, O.: *İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı*, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2018; Plüss, A./Facincani-Kunz, D.: *Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung, Art. 530-771 OR – VegüV, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Hrsg. Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb Schulthess Juristische Medien* AG, 3. Aufl. 2016; Tandoğan, H.: *"Hükmî Şahısların Anonim Şirket İdare Meclisinde Temsili"*, Batider C. I, S. 1, s. 7 vd.; Tekinalp, Ü.: *"Anonim Ortaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel kişilerin Temsili"*, Ankara 1965; *Kaşak*, E., Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018; Teoman, Ö.: *"Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçim ve Azillerinin, Gündeme Bağlılık İlkesi ile İlişkisi"*, İkt. Mal. 1981, S. 1, s. 20 vd; Türk, A.: *Anonim Ortaklıkta Sermaye*

Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, (TTK m. 324), Ankara 1999; Türk, H. S.: *"Anonim Ortaklık Genel Kurulu Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Azil ve Seçimi"*, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu I, Ankara 1984, s. 175-205; Ulusoy, E.: *Anonim Şirketlerde Şirketle İşlem Yapma Yasağı ve Çifte Temsil*, Ankara 2005; Yıldız, B.: *"Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği"*, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111-134; Yüce, A. A.: *Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı*, İstanbul 2013; *Can*, M. Ç.: *"Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi"*, GÜHFD, C. XX, Y. 2016, Sa. 1, s. 27 vd.

I) KURUL-ORGAN OLARAK YÖNETİM KURULU

Tüzel kişiler hak ehliyetini organları eliyle kullanırlar. Söz konusu organlar tüzel kişinin türüne ve amacına göre farklı isimlerle anılır. Anonim şirketlerde bunlar yönetim kurulu ve genel kurul olarak adlandırılmıştır. Genel kurul ve yönetim kurulu anonim şirketin zorunlu organlarıdır. Genel kurul kural olarak anonim şirketin karar organı iken yönetim kurulu icra ile görevli organıdır. Şirketin yönetim ve temsili konusunda yetkili bu organın yokluğu da diğer zorunlu organ olan genel kurulun yokluğu gibi şirketin sona ermesine yol açabilir. Yönetim kurulu kural olarak yetkilerini bizzat kullanmak zorunda ise de bazı hallerde yönetim ve temsil yetkisinin delege edilmesi mümkündür. Ancak bu halde de gözetim ve denetim görevi ve dolayısıyla sorumluluğu da devam eder.

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm yoksa yönetim kurulu bir ya da daha çok sayıda üyeden oluşur. Üye sayısının şirket esas sözleşmesinde gösterilmesi gerekir (TTK m.339/2-g). Bununla birlikte bazı özellikli alanlarda faaliyet gösteren anonim şirket yönetim kurulları için farklı zorunlu asgari sayılar belirlenmiştir. Mesela Halka Açık Anonim Şirketlerde (SPK m.17) ve Bankalarda (5411 s. BanK. m.23) yönetim kurulu üye sayısı en az beş kişi olarak belirlenmiştir.

Yönetim kurulu, genel kurulun aksine, sürekli bir organ niteliği taşır.

II) YÖNETİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

A. GENEL OLARAK

6102 sayılı TTK'nin anonim şirket yönetim kuruluna ilişkin olarak getirdiği önemli yeniliklerden biri yönetim kurulunda gerçek kişilerin yanında tüzel kişilerin de görev alabilmesine imkân tanımasıdır. Böylece şirket ortağı olsun olmasın tüzel kişinin yönetim kurulunda doğrudan görev alması mümkün olabilecek; eskiden olduğu gibi bir gerçek kişiyi önerip seçtirmek zorunda kalmayacaktır. Pratikte bunun faydası ise yeni bir genel kurul kararına ihtiyaç olmaksızın yönetime seçilmiş olan tüzel kişinin temsilcisi gerçek kişiyi dilediği zaman değiştirmesidir.

Anonim şirket yönetim kurulu üyeliği görevine seçilmek veya atanmak ve göreve başlamak için pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmamaktadır.

B. ÜYELİĞE SEÇİLME/ATANMA KOŞULLARI

1. Vatandaşlık

Anonim şirket yönetim kuruluna seçilmek veya atanmak için gerçek kişiler açısından Türk vatandaşı olma veya tüzel kişiler açısından merkezinin Türkiye'de bulunması zorunluluğu kural olarak aranmamaktadır.

2. Yerleşim Yeri

Anonim şirket yönetim kuruluna seçilmek veya atanmak için gerçek kişiler açısından Türkiye'de yerleşim yeri sahibi olma zorunluluğu da kural olarak bulunmamaktadır. Bununla birlikte merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin Türkiye'deki şubeleri için, yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanması gerekir (TTK m.40/4). Aynı esastan olmak üzere merkezi yurtdışında bulunan anonim şirketlerin Türkiye'deki şubeleri için de yerleşim yeri Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atanması icap eder.

3. Ehliyet

Anonim şirket yönetim kuruluna seçilecek veya atanacak gerçek kişilerin tam ehliyetli olması gereklidir (TTK m.359/3). 6762 sayılı TTK

dönemindeki ehliyetle ilgili tartışmaların sona erdirilebilmesi için yeni Kanunda açık bir düzenlemeye gidilmiştir. Tam ehliyetli olma koşulu, yönetim kuruluna tüzel kişinin seçilmesi halinde onun adına sicile tescil olunacak gerçek kişi açısından da aranır.

Yönetim kurulu üyeliğine bir tüzel kişinin seçilebilmesi için bu tüzel kişinin Türk Hukukuna göre geçerli bir tüzel kişi olması gerekir[180]. Bu çerçevede dernek, vakıf gibi medeni hukuk kaynaklı tüzel kişiler yanında ticaret şirketleri ve kamu kurum/kuruluşları da anonim şirket yönetim kuruluna seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kuruluna seçimi sonrasında bu tüzel kişi ile birlikte onu temsilen yönetim kurulu toplantılarına katılacak olan sadece bir gerçek kişinin de ticaret siciline tescili gerekir (TTK m.359/2). Tescil edilen gerçek kişi, tüzel kişi tarafından belirlenen temsilcidir.

Tüzel kişi adına temsilci olarak tescil edilen kişi dışında başkaca gerçek kişinin yönetim kurulunda yer alması isteniyorsa diğer gerçek kişilerin genel kurul tarafından ayrıca seçilmesi gerekir. Yönetim kuruluna tüzel kişinin seçilmesi ve onunla birlikte tescil edilecek gerçek kişi her zaman yönetim kurulu üyesi tüzel kişi tarafından değiştirilebilir. Oysa tüzel kişinin önerisiyle genel kurul tarafından seçilen gerçek kişi ancak genel kurul tarafından görevden alınabilir.

TTK m.359/2 gereğince tüzel kişiyi temsilen sadece bir kişinin temsilci olarak atanabilmesinden doğan kısıtlama devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde uygulanmaz. Bu şirketlerde anılan tüzel kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilirler. Yönetim kurulunun ikiden fazla kişiden oluştuğu anonim şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna seçilebilir (TTK m.359/5).

4. Seçilme Engellerinin Bulunmaması

Anonim şirket yönetim kuruluna seçilmek veya atanmak için seçilme engellerinin bulunmaması da gerekir. TTK m.359/4 hükmünde üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engel kabul edilmiştir. Üyeliği

---

[180] **Can, M. Ç.:** *"Banka Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Tüzel Kişi"*, GÜHFD, C. XX, Y. 2016, Sa. 1, s. 27 vd.

sona erdiren sebepler ise Kanundan doğabileceği gibi esas sözleşmeden de doğabilir.

Kanundan doğan yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi sebepleri, TTK m.363/2 hükmünde iflas, ehliyetin kısıtlanması ve üyelik için gerekli diğer kanuni şartlar olarak belirlenmiştir. TTK yanında Türk Ceza Kanunu'nda da güvenlik tedbirleri başlığı altında m.53/1-d hükmünde **kasıtlı bir suçtan** dolayı **hapis cezasıyla cezalandırılmış** bir kişinin **hükmün infazı bitinceye kadar** şirket yöneticisi olma hakkından yoksun olacağı ifade edilmiştir.

Esas sözleşmeye konulacak hükümle gerçek kişi yönetim kurulu üyeleri açısından yaşa ilişkin (70 yaşını aşmamış olmak), toplam üyelik süresine ilişkin (en çok 12 yıl), eğitime ilişkin (hukuk fakültesi mezunu olmak), tekrar seçilmeye ilişkin (en çok 3 kez) koşullar öngörülebilir (TTK m.363/2). Esas sözleşmede öngörülen niteliklerin kaybı üyeliğin de kendiliğinden sona ermesine yol açar.

C. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ

Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri her bir atama veya seçilmede en çok üç yıl için görevlendirilirler. Bununla birlikte görev süresi dolan üyelerin tekrar seçilmesine engel bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin seçilme veya atanma süreleri için şirket esas sözleşmesi ile üç yıldan daha kısa bir süre öngörülebilirse de daha uzun bir süre öngörülemez. Genel kurulun seçim kararında bir süre belirtilmemişse seçilen yönetim kurulu üyelerinin bir faaliyet yılı için, yani sonraki yılın genel kurul tarihine kadar görev yapacaklarının kabul edilmesi uygun olur[181].

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi birbirinden farklı olabileceği gibi belirli periyotta yenilenmesi için her yıl belirli sayıda üyelik için seçim yapılabilir.

D. TESCİL VE İLÂN

Anonim şirketin ilk yönetim kurulu üyelerinin şirket esas sözleşmesinde yer alması zorunluluğu sebebiyle sözleşmenin tescil ve ilânı ile ilk yönetim kurulu üyelerinin isim veya unvanları da ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiş olacaktır (m.354/1-g). Sonradan meydana gelecek değişikliklerin de sicile tescil ve ilânı gerekir. Ticaret sicilinde tescil ve ilân yanında, anonim şirketin

---

[181] Aynı görüşte **Çamoğlu, (Tekinalp/Poroy),** I, N. 544.

internet sitesi açma zorunluluğu bulunduğu hallerde (TTK m.397 gereğince bağımsız denetime tabi anonim şirketler) yönetim kurulu üyelerinin ticaret siciline tescil ve ilânın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde şirketin internet sitesinde de yayınlanması kanun gereğidir (m.1524/1).

III. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞTURULMASI

A. ESAS SÖZLEŞMEYLE ATANMA

Anonim şirketin kuruluşunda ilk yönetim kurulu üyeleri şirket sözleşmesinde yer almalıdır (TTK m.339). Dolayısıyla ilk yönetim kurulu üyeleri kurucular tarafından atanacaklardır. Şirketin tescil ile tüzel kişilik kazanması üzerine yönetim kurulu da yetkilerini kullanmaya ve görevlerini ifa etmeye başlar. Yönetim kurulunda sonradan yapılacak değişiklikler, yani yeni üyelerin seçilmesinin bir şirket sözleşmesi değişikliği olarak esas sözleşmeye işlenmesi gerekmez.

B. GENEL KURUL TARAFINDAN SEÇİLME

Anonim şirketin kuruluşundan sonra seçilecek tüm yönetim kurulu üyeleri Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde genel kurul tarafından seçilir.

Genel kurul tarafından yapılacak seçimler için TTK'de özel bir toplantı ve karar nisabı öngörülmemiştir. Dolayısıyla TTK m.418 hükmünde yer alan adi nisap uygulanır. Yani TTK'de veya şirket esas sözleşmesinde aksine daha ağır nisaplar bulunmamak kaydıyla sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Genel kurul toplantılarında, esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, birikimli oy sisteminin uygulanması ve azınlığın da belirli sayıda yönetim kurulu üyesini seçebilmesine imkân tanınabilir. Birikimli oy, genel kurula katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin kullanmaya yetkili olduğu oy sayısının, seçimi yapılacak yönetim kurulu üye sayısı ile çarpılması suretiyle hesaplanır[182].

---

[182] Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, m.4 (29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete).

Birikimli oy, şirket içerisinde azınlıkta olan pay sahiplerine yönetim kuruluna üye seçme imkânı sağlayan bir sistemdir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurulun yetkisi devredilemez yetkilerden olup, bu yetki yönetim kuruluna veya başka bir kişiye devredilemez, vazgeçilemez.

Esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kuruluna yedek üye seçilmesi de mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde belirli pay gruplarına esas sözleşme ile yetki verilmesi de mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde her bir üye için ayrı oylama yapılması gerekir. Anonim şirketin kuruluşundan sonra yapılan yönetim kurulu üyeliklerine seçim ve atamanın ticaret siciline kaydolunması, ilânı ve internet sitesinde yayınlanması gerekir.

C. KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİLİ

Kamu tüzel kişileri pay sahibi olmasalar bile, şirket esas sözleşmesinde hüküm bulunmak kaydıyla, işletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirket yönetim kurulunda temsilci bulundurabilirler (m.334). Söz konusu kamu tüzel kişileri devlet, il özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerinden biri olabilir. Hükmün amacı, kamu hizmeti gören anonim şirketlerde, kamu tüzel kişilerinin yönetime katılmasının sağlanmasıdır (merkezi kayıt kuruluşunda SPK temsilcisi bulunması gibi). Bu halde yönetim kurulu üyesinin genel kurul tarafından seçilmesi söz konusu olmayıp, doğrudan ilgili kamu tüzel kişisinin temsilci görevlendirmesi gündeme gelecektir. Aynı hak bu tür şirketlerde pay sahibi olan kamu tüzel kişilerine de tanınmıştır.

TTK m.334 hükmü özel hüküm mahiyetinde olduğundan m.359/2 hükmündeki sınırlandırmaya tabi olmaksızın, sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla kamu tüzel kişisine yönetim kurulunda birden çok temsilci bulundurma hakkı verilebileceği gibi, birden çok kamu tüzel kişisine de bu hak verilebilmelidir[183].

---

[183] Aynı yönde **Kırca/Şehirali Çelik/Manavgat**, C. I. S. 419; aksi görüşte, **Tekinalp**, Ü., Anonim Otaklıkların Yönetim Kurullarında Tüzel Kişilerin Temsili, Ankara 1965, s. 82.

D. YÖNETİM KURULU TARAFINDAN SEÇİLME

Kooptasyon adı da verilen bu yönteme göre yönetim kurulunun ikiden fazla kişiden oluşması ve yönetim kurulu üyeliklerinden birinin boşalması durumunda, geride kalan yönetim kurulu üyeleri toplanarak boşalan üyeliğe seçim yapabilmektedir. Bu şekilde seçilen üye, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul toplantısında bu kişinin yönetim kurulu üyeliği onaylanabileceği gibi başka bir kişi de üyeliğe seçilebilir. Kooptasyon yöntemiyle seçilen kişi genel kurul tarafından onaylanırsa, selefinin süresini tamamlayacak süre kadar görev yapar.

E. SERMAYE PİYASASI KURULUNCA ATAMA

Sermaye Piyasası Kanunu m.128/1-k hükmüne göre Sermaye Piyasası Kurulu, bazı hallerde halka açık anonim şirketlere yönetim kurulu üyesi atama yetkisine sahiptir. Sonradan Kanuna eklenen bu hüküm ile halka açık anonim şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin sürelerinin dolması veya başka sebeplerle boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması veya 30 gün içerisinde yönetim kurulu seçimi için genel kurulun toplanamaması veya yeter sayıda yönetim kurulu üyesinin seçilememesi halinde yönetim kurulu toplantı sayısını sağlayacak asgari sayıda üyeyi Sermaye Piyasası Kurulu re'sen atar. Geriye kalan üyeleri ise pay sahiplerinin önerecekleri üç katı aday arasından atar.

F. BELİRLİ GRUPLARIN YÖNETİM KURULUNDA TEMSİL EDİLMESİ

Anonim şirket yönetim kurulunda belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa temsil edilebilme hakkı verilebilir. Bunun için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekir. Bahse konu gruplar tarafından önerilen adayın genel kurul tarafından seçilmesi ancak haklı bir sebebin varlığına bağlı olarak reddedilebilir. Esasen belirli pay gruplarına tanınan bu imtiyaz sebebiyle yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin genel kurulun devredilemez ve vazgeçilemez yetkisi kısıtlanmış olmakta, sadece haklı sebep varsa genel kurul belirli pay gruplarının önerdiği adayları yönetim kuruluna seçmekten kaçınabilmektedir.

TTK m.360 hükmüne göre yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan paylar imtiyazlı pay olarak kabul edilmiştir (m.360/2).

Halka açık anonim şirketlerde, bu şekilde imtiyaz tanınarak seçilebilecek yönetim kurulu üye sayısı yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz.

IV. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ŞİRKET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Yönetim kurulu üyesinin genel kurul tarafından seçilmesi ve seçilen kişinin bunu kabul etmesi ile şirket ve ilgili üye arasında bir sözleşme ilişkisi kurulur[184]. Anonim şirket ile yönetim kurulu üyeleri arasındaki bu ilişkinin hukuki niteliği konusu, doktrin ve yargı kararlarında çok kez ele alınmış ancak üzerinde görüş birliği sağlanamamış konulardandır.

Üyeler ile şirket arasındaki ilişki bir iş görme ilişkisi olarak kabul edilmekte ve buna bağlı olarak da duruma göre *vekâlet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi* veya *sui generis* bir sözleşme olarak nitelendirilmektedir[185]. Yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzel kişiliği arasındaki ilişki esasen vekalet sözleşmesine yakın olmakla beraber her somut olayda üyelerin yetki ve görevleri dikkate alındığında farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle söz konusu ilişkiye *sui generis* nitelikte bir sözleşme olarak nitelendirebilirse de her somut olayın şartlarına bakılarak karar verilmesi ve tek bir sözleşme tipinin kesin olarak kabul edilmemesi uygulamadaki sorunların çözümü bakımından da kolaylık arz etmektedir. Bununla birlikte özellikle yargı kararlarında, söz konusu sözleşme ilişkisinin vekalet sözleşmesine daha yakın olduğu kabul edilmektedir.

Bir iş görme sözleşmesi olan vekâlet sözleşmesi, TBK'nin 502. maddesinde *"vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir"* şeklinde tanımlanmıştır. İş/hizmet sözleşmesinin temel karakteristik unsuru olan bağlılık, bu sözleşmenin vekâlet sözleşmesinden ayrılmasına imkân verir. Uygulamada, üyeler ile şirket arasındaki hukuki ilişkinin mahiyetinin tespitinde, bağlılık ilişkisi içerisinde bulunup bulunmadığı, emir ve talimat ile çalışıp çalışmadığı, sigorta primlerinin hangi esaslara göre yatırıldığı gibi noktalara bakılmaktadır.

Çoğu zaman üyeler ile şirket tüzel kişiliği arasındaki ilişkinin tespiti hem görevli mahkemenin hem de görevinden alınan yönetim kurulu

---

184 **Pulaşlı**, C. II, § 36 N 143.

185 Tartışmalar için bkz., **Özdamar,** Mali Haklar, s. 124 vd.

üyesinin haklarının belirlenmesi açısından önem arz etmektedir. Yargıtay da üyeler ile şirket arasındaki ilişkinin vekalet sözleşmesi olduğu yönünde kararlar vermiştir. Buna göre; "*Anonim şirket ile yönetim kurulu üyesi arasındaki ilişkinin hukuki niteliği karşılaştırmalı hukukta tartışmalı olmakla beraber, Alman hukukunda sözleşme şartlarına göre, vekalet veya hizmet akdi olarak nitelendirilmekle birlikte, daha çok, hizmet akdi olduğu yönündedir. Fransız hukukunda da bu ilişkinin bir vekalet akdi olduğu kabul edilmiştir. İsviçre hukukunda ise, vekalet hakkındaki hükümlerin uygulanacağı kabul edilmektedir*[186]*. Türk öğretisinde de bu ilişkinin vekalet akdi olduğu görüşü hakimdir*[187].

Yargıtay, yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir hizmet akdi bulunmadığını, en azından şirket genel müdürü iken, yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişinin hizmet akdi ilişkisinin sona erdiğini kabul etmiştir (H.G.K.'nun 5.2.2003 gün ve 2003/9-82 E.-65 K. sayılı ilamı)

....Şirket yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında bir vekalet akdi ilişkisi bulunduğundan, üyelerin şirkete karşı vekil gibi sorumlu olmaları doğaldır. (H.G.K.'nun 7.11.2001 gün ve 2001/13-1026 E.-765 K. sayılı ilamı)[188].

V. YÖNETİM KURULUNUN YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİ

A) YÖNETİM YETKİSİ

1) Genel Olarak

Yönetim kurulunun temel görevi, şirketin yönetimidir. Yönetim yetkisi eğer delege edilmemiş ise[189] tüm yönetim kurulu üyelerine aittir (TTK m.367/2). Yönetim yetkisi, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler olarak nitelendiri-

---

186 **Mimaroğlu, S. K.:** *Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Hukuki Mesuliyeti*, Ankara 1967, s. 100

187 **Çamoğlu, E.**: *Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu*, İstanbul 1972, s. 102-104; **Mimaroğlu**, s. 101-102.

188 **YHGK.** 2010/9-328 E., 2010/370 K, 07.07.2010 T.; **Y. 22. HD**. E: 2013/20241 K: 2013/18527 T: 10.09.2013 sayılı kararı da aynı yöndedir.

189 Delegasyon imkânı ve şartları hakkında bkz. aşağıda Yedinci Bölüm, § 10, V, C başlığı.

lebilir. Yönetim alanında tek yetkili organ yönetim kurulu değildir. Genel kurul da örneğin kâr payının nasıl kullanılacağına karar vermek suretiyle yönetim alanındaki yetkileri kullanır.

Genel kurul ve yönetim kurulunun yetkileri arasındaki sınır, TTK m.374/1 hükmüyle çizilmiştir. Buna göre, yönetim kurulu, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Bu hüküm ile yönetim alanında yönetim kurulu lehine "*yetki karinesi*" öngörülmüştür.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerek yönetim kurulu lehine öngördüğü yetki karinesi, gerek aşağıda görüleceği üzere yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerini saymak suretiyle, bu organın konumunu güçlendirmiştir. Özellikle yönetim kurulunun devri mümkün olmayan yetkilerinin aynı zamanda vazgeçilemez olduğu vurgusu yapılarak, genel kurulun bu alanda yönetim kuruluna emir ve talimat vermesi yasaklanmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, organlar arasında eşitlik esasına dayalı bir sistemi benimsemiştir[190].

2) Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkiler

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri, TTK m.375'te bir liste halinde sayılmıştır. Bu yetkilerin TTK m.367 uyarınca murahhaslara delege edilmesi mümkün olmadığı gibi genel kurula bırakılması da mümkün değildir. Genel kurulun da yönetim kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine müdahale etmesine izin verilmemiştir. Zira TTK m.375'te sayılan yetkilerin delegasyonu yasak olduğu gibi, yönetim kurulunun bu yetkilerden mahrum bırakılmasına da izin verilmemiştir.

---

190 **Kaşak**, E., Anonim Şirketlerde Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Arasındaki Yetki Dağılımına İlişkin Temel Esaslar, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2018, s. 54 vd; TTK m. 375 hükmünün gerekçesinde, "*Yönetim kurulunun devredilemez yetkilerini gösteren 375 inci madde yenidir. Bu hüküm ile, Ticaret Kanununda, organlar arasında işlev ayrımı yapılmış, organlar arasında işlev bağlamında güç yönünden denklik kabul edilmiş, buna karşılık genel kurulun herşeye kadir olduğuna ve bütün kararları alabilme yetkisi ile donatıldığına ilişkin salt yetki teorisi reddedilmiştir. Genel kurulun bir üst organ olduğu anlayışı Ticaret Kanununa yabancıdır*" denilmiştir.

Yönetim kurulu sayılan yetkileri bizzat kendisi kurul olarak kullanır ve sorumluluğu da kendisi taşır. Delegasyon yasağının kapsamına yalnızca karar yetkileri girer. Yoksa sayılan yetkilerin kullanılması amacına matuf hazırlık çalışmalarında TTK m.366/2 uyarınca kurulacak komite ve komisyonlardan istifade edilebilir. Ayrıca bu alana giren meseleler hakkında genel kurulda istişari/danışmasal oylama yapılması da mümkündür. İstişari oylama sonucu, yönetim kurulu bakımından hukuken bağlayıcı değildir.

Yönetim kurulunun, devri mümkün olmayan yetkileri yalnızca TTK m.375'te sayılanlarla sınırlı olmayıp, Kanun'un diğer maddelerinde yer almakla birlikte yine devredilemez nitelikte olduğu kabul edilen başkaca yetkiler de bulunmaktadır. Aşağıda öncelikle TTK m.375'te sayılan yetkiler kısaca açıklandıktan sonra, Kanunun diğer maddelerinde yer almakla birlikte devredilemez nitelikteki yetkiler örnek kabilinden zikredilmiştir.

a) TTK m.375'te Sayılanlar

aa) Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi

TTK m.375 hükmünde sayılan ilk yetki "*şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi*"dir. Madde metninde şirketin "*üst düzeyde yönetimi*" denilmekle yönetim kuruluna şirketin günlük işlemlerini delege etme imkânı sağlanmıştır[191]. Üst düzeyde yönetim kavramı ile esas itibarıyla, şirketin stratejik amaçlarının oluşturulması, bu amaçlara ulaşmak için gerekli araçların tespiti, şirket yönetim organlarının tespit edilen amacı takip edip etmediklerinin kontrolü kastedilmektedir[192]. TTK m.375'te sayılan görevlerin birçoğu, üst yönetim görevinin somutlaştırılmasından ibaret olup; üst düzeyde yönetim kavramı sayılan bu yetkilerin kısa bir ifadesi olarak görülmektedir[193].

Yönetim kurulu şirket stratejilerini esas sözleşmede yer alan işletme konusu sınırları içerisinde belirler. Yönetim kurulu tarafından belirlenen stratejiler ile ilgili talimatların verilmesi de devredilemez görevler arasında zikredilmiştir. Yönetim kurulu bu amaçla yöneticilere talimat vermelidir. Talimatların verilmesi herhangi bir şekle tâbi tutulmamıştır;

---

191 **Meier-Hayoz/Forstmoser,** 2012, §16 N 414.
192 Botschaft (Gerekçe) 1983, 921.
193 Botschaft (Gerekçe) 1983, 921.

bu sebeple talimatların yönerge, yönetim kurulu karar defteri içinde yer alması veya sözlü olarak verilmesi de mümkündür[194].

bb) Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi

Yönetim kurulunun devredilemez olarak nitelendirilmiş ikinci yetkisi "*şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi*"dir. Bununla yönetim kurulunun şirket yönetiminin amaca uygun bir şekilde tesisinden sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Şirketin yönetim organizasyonun belirlenmesi bakımından yönetim kurulunun oldukça geniş yetkilere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Örneğin esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla yönetim kurulu, çıkaracağı iç yönergeye göre devri mümkün yetkileri delege ederek, kendisi yalnızca devredilemez yetkileri üstlenebilir.

Organizasyonun tespiti yetkisinin kapsamına yönetim kurulu toplantı sayıları ve zamanları, kimin hangi işi yapacağı, raporlama yükümlülükleri, komite ve komisyonların görev ve sorumlulukları, görev dağılımı, sekretaryanın kurulması gibi hususların belirlenmesi girer. Yetkinin devredilemez mahiyette olan kısmı, yönetim kuruluna doğrudan tâbi olan en üst yönetimin tanımlanması, hiyerarşinin ve rapor verme düzeninin belirlenmesi ve görev alanlarının, sorumlulukların belirlenmesidir; buna karşılık daha alt kademede yer alan şirket çalışanlarının organizasyonu devredilebilir[195].

Yönetimin organizasyonu konusunda büyük ölçüde serbesti bulunmasına karşın örneğin bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekilinin seçilmesi zorunludur (TTK m.366). Yönetim organizasyonunu belirleme yükümlülüğünün yanı sıra, düzenli kontrollerin yapılması ve gerektiğinde bir kez seçilen

---

194 **OFK- Chapuis, C.:** Schweizerisches Obligationenrecht, OR Kommentar, OFK-Orell Füssli Kommentar, Hrsg: Jolanta Kren Kostkiewicz, Stephan Wolf, Marc Amstutz, Roland Fankhauser, 3. Aufl. 2016, Art. 716a OR, N 4.

195 Bkz. ve karş. **CHK- Plüss, A./Facincani-Kunz, D.:** Personengesellschaften und Aktiengesellschaft – Vergütungsverordnung, Art. 530-771 OR – VegüV, CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Hrsg. Vito Roberto, Hans Rudolf Trüeb Schulthess Juristische Medien AG, 3. Aufl. 2016, Art. 716a OR N 4; **BSK OR II-Watter, R./Roth Pellanda, K.**: Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Verlag, Art. 716a N 11.

organizasyonun değişen koşullara uyarlanması da yönetim kurulunun devredilemez yetkisine dâhildir[196].

cc) Muhasebe, Finans Denetimi ve Finansal Planlamaya İlişkin Görevleri

Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması görevi yönetim kurulunun bir başka devredilemez yetkisidir (TTK m.375/1-c). Yönetim kurulunun yükümlülüğü, esas itibarıyla gerekli organizasyonun kurulmasını, talimatların verilmesini ve gerekli kontrollerin yapılmasını kapsar.

Muhasebe için gerekli düzenin kurulması kapsamına, "kanuna ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre muhasebe örgütünün (bölümünün), konsolide hesap sisteminin, defter ve kayıtların tutulma kurallarının tespiti, hesap planlarının yapılması" girer; burada esasen, muhasebe bölümünün örgütlenmesi söz konusudur[197]. Yönetim kurulu, muhasebe düzenin kurulmasından sorumludur; muhasebenin tutulması devredilebilir[198].

dd) Personelin Atanması veya Görevden Alınmasına İlişkin Görev ve Yetkileri

Kanunun lafzına göre "*müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları*" yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasındadır (TTK m.375/1-d). Bu madde kapsamında yönetim kurulu sadece en üst hiyerarşik kısmı kendisi atamak zorundadır; bunların altında kalan kişilerin atanmasına ilişkin yetki devredebilir[199]. Hatta İsviçre öğretisinde hâkim öğreti, imza yetkililerinin atanması bakımından da aynı esasın geçerli olduğu yönündedir[200].

Madde metninde müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları yanında bu kişilerin görevden alınmaları da yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında zikredilmiştir.

---

196 Bkz. ve karş. **BSK OR II-Watter/Roth Pellanda**, Art. 716a N 14.

197 TTK m.375 gerekçesi.

198 TTK m.375 gerekçesi.

199 **CHK-Plüss/Facincani-Kunz,** Art. 716a OR N 6; **Krneta**, N. 1262.

200 **CHK-Plüss/Facincani-Kunz,** Art. 716a OR N 6.

ee) Yönetimle Görevli Kişilerin Üst Gözetimine İlişkin Görev ve Yetkileri

Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi de yönetim kurulunun devredilemez yetkilerindendir. Kanun metninde yönetim kurulu üyelerinin bu yükümlülüğünün yalnızca normatif, bir başka anlatımla, kanunlara, esas sözleşme ve alt düzenlemelere uygunluğun gözetimi yönüne değinilmiştir. Hal böyle olmakla birlikte, üst gözetim yükümlülüğünün kapsamına, yönetimle görevli kişilerin fiil ve işlemlerinin amaca uygunluğunun denetlenmesinin de dâhil olduğunu ifade etmek gerekir[201]. Yönetim kurulu gözetim yükümlüğünü yerine getirmek için, raporlama ve iç kontrol sistemlerini kurmak zorundadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, iç kontrol sistemlerinin kurulmasını önemsemiş ve bu bağlamda risklerin erken saptanması ve yönetimi amacıyla gerektiğinde komite kurulmasını da zorunlu hale getirmiştir. Komitenin kurulmasının amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesinin teminidir. Komitenin kurulması bakımından TTK m.378/1'de pay senetleri borsada işlem gören şirketler ile diğer şirketler şeklinde ikili bir ayrım yapılmıştır. Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde ise, bu komitenin denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulması gerekir.

Komiteye ayrıca raporlama yükümlülüğü getirilmiş olup, bunun ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda vermesi gerekir. Ayrıca her iki ayda bir, yönetim kuruluna durum değerlendirmesini içeren ve varsa tehlikelere işaret eden raporun verilmesi öngörülmüştür. Raporun ayrıca denetçiye de yollanacağı hükme bağlanmıştır (TTK m.378/2).

ff) Defter ve Kayıtların Tutulması ve Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Görevleri

Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun hazırlanması yönetim

---

201 **CHK-Plüss/Facincani-Kunz,** Art. 716a OR N 7.

kurulunun devri mümkün olmayan yetkileri arasındadır (TTK m.375/1-f). Bunun yanı sıra 6102 sayılı TTK'de genel bir hukuk politikası olarak kurumsal yönetim alanında yapılan çalışmalara önem verilmiş olup; bu hususta kanunda pozitif düzenlemelere yer verilmiştir. Örneğin yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar bakımından sigorta yapılmışsa, bu hususun kurumsal yönetim ilkelerine uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır. Benzer şekilde kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması da yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında zikredilmiştir.

Genel kurul, prensip itibarıyla icrai yetkileri olmayan ve gerek toplanması gerek toplantıda alınan kararlarının uygulanması bakımından yönetim kuruluna ihtiyacı olan bir organdır. Bu sebeple kanunda genel kurulun toplanmasına ilişkin hazırlıklarının yapılması görevi yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında zikredilmiştir. Toplantı hazırlıklarına örnek olarak finansal tabloların, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun hazırlanması, gündem, toplantı yeri ve zamanı gibi hususları belirleyerek usulüne uygun olarak genel kurul toplantı çağrısının yapılması gösterilebilir.

Şirketin temsili, bir başka anlatımla şirketin içerisinde alınan kararların dış ilişkide icra edilmesi prensip olarak yönetim kurulunun yetkisindedir. Yönetim kurulu, genel kuruldan çıkan kararları da icra ile yükümlüdür ve bu devredilemez yetkiler arasında zikredilmiştir (TTK m.375/1-f). Bu yükümlülüğün genel kuruldan çıkan her kararın icra edilmek zorunda olduğu şeklinde anlaşılmaması gerekir. Aksine, yönetim kurulu genel kuruldan çıkan kararları kanuna uygunluk bakımından incelemeli, eğer kararın yok, batıl veya iptal edilebilir olduğu kanaatine ulaşırsa, kararın butlanının veya yokluğunun tespitini veya duruma göre kararın iptalini mahkemeden talep etmesi gerekir (bkz. TTK m.446/1-c, 447). Aksi halde kanuna aykırı genel kurul kararının icrasından dolayı şartları bulunması halinde kendilerine TTK m.553 vd. hükümleri uyarınca sorumluluk davası açılabilir.

Defterlerin tutulması, genel kurul toplantılarının yapılması veya genel kurul kararlarının icrası görevi, yönetim kurulunun devredilemez yetkileri arasında zikredilmişse de, örneğin defterlerin bizzat yönetim kurulu tarafından tutulması zorunlu değildir; yönetim kurulunun sorumluluğu defterlerin tutulmasının sağlanması, bununla ilgili talimatların verilmesi ve gerekli kontrollerin yapılması bakımından söz konusu

olur. Bir başka anlatımla yönetim kurulu bu noktada kendisine TTK m.366/2'de tanınan imkândan istifade edebilir. TTK m.366/2'de, yönetim kurulunun, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceği hükme bağlanmıştır.

b) Diğer Görev ve Yetkileri

Doktrinde diğer maddelerde sayılmakla birlikte yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez olarak nitelendirilen görevler vardır. Dolayısıyla TTK m.375'te sayılan yetkiler tahdidi değildir. Bunlara *örnek olarak* birleşme, bölünme, tür değiştirme planının ve raporlarının hazırlanması (TTK m.145, 169, 185, 186), sermaye kaybı ve borca batıklık halinde gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin yükümlülükler (TTK m.376/1, 2) riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin kurulması (TTK m.378) genel kurul kararları aleyhine iptal davası açılmasına (m.446/1-c) ilişkin yetkiler zikredilebilir[202].

B) TEMSİL YETKİSİ

1) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Temsil, şirket içerisinde alınan kararların dış ilişkide icra edilmesidir. Şirketi temsile, yönetim kurulu yetkili kılınmıştır (TTK m.370) Temsile yetkili kişiler, şirketin amacına ve işletme konusuna giren her tür işleri ve hukuki işlemleri, şirket adına yapabilir ve bunun için şirket unvanını kullanabilirler.

Daha evvel ticaret şirketlerinin ehliyeti kısmında işaret edildiği üzere, ticaret şirketlerinin şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu çevresi içinde kalmak şartıyla hak iktisap ve borç iltizam edebilecekelerine ilişkin *ultra vires ilkesi*[203] 6102 sayılı TTK ile terk edilmiştir. Bununla birlikte, "*şirketin işletme konusu*" kavramı tamamen işlevini kaybetmiş değildir. TTK m.339/2-b hükmünde esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusunun esas

---

202 (Bkz. **Kırca/(Şehirali Çelik/Manavgat)**, C. I, s. 591).

203 **Burçak Y.:** "*Ultra Vires İlkesinin Kaldırılmasının Ardından İşletme Konusu Unsuru ve Ticaret Şirketlerinin İşletme Konusu Dışındaki İşlemlerinin Hukukî Niteliği*", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi 2011, C. XXVII, S. 3, s. 111-134 .

sözleşmede öngörüleceği hükme bağlanmıştır. İşletme konusunun şirketin ticaret unvanında gösterilmesi gerekir (TTK m.43)[204]. Benzer şekilde şirketin işletme konusu, şirketi temsile yetkili olanların temsil yetkisinin sınırı olarak kanunda varlığını korumaktadır.

Kanunda temsile yetkili olanların, üçüncü kişilerle, işletme konusu dışında yaptığı işlemlerin de şirketi bağlayacağı öngörülmüştür. Ancak üçüncü kişinin, işlemin işletme konusu dışında bulunduğunu bildiği veya durumun gereğinden, bilebilecek durumda bulunduğunun ispat edilmesi halinde artık yapılan işlem şirketi bağlamayacaktır.

Şirketle işlem yapan üçüncü kişinin kötüniyetinin ispatı bakımında Kanunda bir sınırlama yapılmıştır. Buna göre şirket esas sözleşmesinin ilan edilmiş olması, üçüncü kişinin işlemin işletme konusu dışında olduğunu bildiğinin ispatı açısından, tek başına yeterli delil değildir.

2) Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması

Ticari faaliyetlerde güven ve süratin sağlanması bakımından anonim şirket temsilcilerinin temsil yetkilerinin kapsamı son derece geniş belirlenmiştir. Bununla birlikte istisnai iki halde temsil yetkisinin sınırlandırılmasına ve bu sınırlandırmaların ticaret siciline tesciline izin verilmiştir. Bunlar temsil yetkisinin *merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına* ilişkin sınırlandırmalardır (TTK m.371/3).

Temsil yetkisinin merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin sınırlandırmalar ticaret siciline tescil ve ilân edilmekle ticaret sicilinin olumlu etkisinden istifade edilebilir. Bu suretle üçüncü kişilerin, bu sicil kayıtlarını bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez (TTK m.36/3). Bu durum temsil yetkisi bakımından başka hiçbir sınırlandırma yapılamayacağı şeklinde anlaşılmamalıdır.

Temsil yetkisi hakkında, konu, miktar gibi tescili caiz olmayan sınırlandırmalar yapılabilir; fakat Kanun bu tür sınırlandırmaların iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmeyeceği prensibini amirdir (TTK m.371/3). Dolayısıyla eğer temsile yetkili kişilerin temsil yetkisi miktar veya konu bakımından sınırlandırılmış ve şirketle işlem yapan üçüncü kişi sınırlandırmayı biliyorsa yapılan işlem şirketi bağlamaz. Tescili caiz olmayan sınırlandırmaların sicile tescili mümkün

[204] Örneklerin artırılması mümkündür: bkz. TTK m.210/3, 356/5, 374, 380.

olmayıp, her nasılsa tescil edilmişse de sicilin olumlu etkisinden istifade edilmesi söz konusu olmayacaktır[205].

Temsile yetkili kişiler tarafından yapılan işlemin esas sözleşmeye veya genel kurul kararına aykırı olması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilerin o işlemden dolayı şirkete başvurmalarına engel değildir (TTK m.371/4). Ancak bazı hallerde yapılan işlemin hüküm ve sonuçlarını doğurabilmesi için genel kurulun onayının gerekli olduğu Kanunda açıkça hükme bağlanmıştır. Örneğin şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz (TTK m.356/1). Dolayısıyla bu gibi durumlarda TTK m.371/4'te yer alan hükme dayanılarak işlemin şirketi bağladığı kabul edilemez.

Temsile veya yönetime yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden şirket sorumludur. Söz konusu hüküm esas itibarıyla "*organlar hukukî işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar*" şeklindeki TMK m.50/2 hükmünün kısmen tekrarı mahiyetindedir.

Şirketin temsili bakımından tek kişilik anonim şirketler için özel bir düzenleme öngörülmüş olup, buna göre sözleşmenin yapılması sırasında, tek pay sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin geçerli olması, sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmelerde uygulanmayacaktır. Belirtmek gerekir ki yasağın uygulanması için şirketin tek pay sahibi tarafından temsil ediliyor olması şart değildir (TTK m.371/6)[206].

---

205 Ticaret sicilinin olumlu etkisi hakkında **Ayhan/Çağlar,** 2018, s. 263 vd.

206 Anonim şirketlerde, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların "*sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak*" atanmasına ilişkin bazı esaslar TTK m.371/7'de öngörülmüştür. Bu şekilde atanan tacir yardımcılarının 367'nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenmesi ve iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Bu şekilde yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir (Bkz. **Ayhan/Çağlar,** 2018, s. 463 vd.; **Özdamar, M.:** "*6552 Sayılı Kanun İle TTK'da Yapılan Değişiklikler Çerçevesinde Anonim Şirketin Temsili*" Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVIII, Y. 2014, S. 3-4, s. 153 vd.).

3) İmza Yetkisinin Verilmesine İlişkin Esaslar

Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler, şirketin unvanı altında imza atarlar. Yönetim kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noterce onaylanmış suretini, tescil ve ilan edilmek üzere ticaret siciline verir.

Temsil yetkisinin ticaret sicilinde tescilinden sonra, ilgili kişilerin seçimine veya atanmalarına ilişkin herhangi bir hukuki sakatlık, şirket tarafından üçüncü kişilere, ancak sakatlığın bunlar tarafından bilindiğinin ispat edilmesi şartıyla ileri sürülebilir (TTK m.373/2). Dolayısıyla eğer üçüncü kişi, kendisi ile işlem yaptığı şirket temsilcisinin hukuken sakat bir işlem sonucu o konumda bulunduğunu bilmiyorsa, sakatlığa rağmen temsilci konumundaki kişinin yaptığı işlem şirketi bağlayacaktır. Hukukî sakatlığın mahiyeti bakımından -örneğin yok, batıl, iptal edilebilir şeklinde- herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Hükmün konulmasındaki amaç, "*üçüncü kişiye izleyemeyeceği, belirleyemeyeceği ve yargılayamayacağı bir yükümlülük yüklenmesini engellemek ve işlem güvenliği ile adaleti sağlamak*"tır[207].

4) Çift İmza Kuralı

Anonim şirketlerde kural olarak çift imza kuralı geçerlidir; şirket adına düzenlenecek evraklarda en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması gerekir. Ancak eğer yönetim kurulu tek kişiden oluşuyorsa çift imza kuralı uygulanmayacaktır (TTK m.370/1).

Çift imza kuralının aksinin esas sözleşmede kararlaştırılması mümkündür. Bu bağlamda esas sözleşmede tek imza kuralı kararlaştırılabileceği gibi, şirket adına düzenlenen belgelerde tüm yönetim kurulu üyelerinin imzalarının bulunması da şart koşulabilir.

C) YÖNETİM VE TEMSİL YETKİSİNİN DELEGASYONU

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir. Aynı şekilde yönetim kurulu üyelerinin her biri şirketi temsile yetkili olup, bunlardan ikisinin imzalayacağı belgeler şirketi bağlar. Ancak Kanunla öngörülen bu düzenin değiştirilmesi, şirketin büyüklüğü, faaliyet alanı ve ihtiyaçlarına göre uygun bir düzenin kurulması mümkündür.

---

[207] TTK m.373/2 gerekçesi.

Aşağıda görüleceği üzere, bazı şartlara riayet edilmesi kaydıyla, yönetim ve temsil yetkilerinin yönetim kurulu üyelerine veya yönetim kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devredilmesi mümkündür.

1. Yönetim Yetkisinin Delegasyonu

Kanunda yönetim yetkisinin delegasyonuna izin verilmiş ancak, delegasyon hakkında bazı şartlar öngörülmüştür. Aşağıda bu hususlar üzerinde durulmuştur.

a) Delegasyon İmkânı ve Anlamı

Anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri prensip itibarıyla şirketin yönetiminden sorumlu olmakla birlikte, bu görevin kısmen delegasyonuna izin verilmiştir. Delegasyon halinde dahi yönetim kurulunun devredilemez yetki ve görevlerden dolayı sorumluluğu devam eder.

Delegasyon, yönetim kurulu üyeleri bakımından TTK m.553 vd.'da öngörülen sorumluluğun belirli şartlar altında sınırlandırılmasına olanak sağlar. TTK m.553/2'de öngörüldüğü üzere, Kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

b) Delegasyonun Şartları

aa) Şekli Şartlar

Yönetim kurulunun delegasyon imkânından istifade etmesi bazı şekli şartların bulunmasına bağlıdır. Bu kapsamda ilk şart "*esas sözleşmede yönetim kurulunun yönetimi kısmen veya tamamen devretmeye yetkili kılınmasıdır*". Esas sözleşmede değişiklik yapmaya genel kurul yetkili olduğundan, yönetim görevlerini delege etmek isteyen bir yönetim kurulunun genel kurulun koordinasyonuna ihtiyacı bulunmaktadır.

Esas sözleşmeye konulacak yetki hükmüne ilave olarak ayrıca yönetim kurulu tarafından bir iç yönerge hazırlanması gereklidir. İç yönerge şirketin yönetimini düzenler ve bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler.

TTK m.367 uyarınca düzenlenen iç yönergenin prensip olarak[208] tescil ve ilanı gerekli değildir. Ancak yönetim kurulu istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.

bb) Maddi Şartlar

Delegasyonun maddi şartları, delege edilecek yetkilerin mahiyeti ile alakalıdır. Buna göre geçerli bir delegasyondan bahsedilebilmesi için, delegasyona konu yetkilerin devri mümkün olmalıdır. Dolayısıyla TTK m.375'te sayılan yetkilerin delege edilmesi mümkün değildir.

2) Temsil Yetkisinin Delegasyonu

TTK m.371/2'ye göre, yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

VI. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HAKLARI

A) MALİ HAKLARI

1) Mali Hak Türleri

Yönetim kurulu üyelerine, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir (TTK m.394)[209]. Ücret, üyelere belirli dönemler halinde ödenen mali haktır[210]. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerine toplantıda hazır bulunmaları münasebetiyle ödenir[211]. Bunun yanısıra yöneticilere şirket kazancından kazanç payı altında ödeme yapılabileceği gibi, başarılı hizmetleri için ikramiye[212] veya prim ödemesi

---

208 İç yönergenin tescil ve ilan edilmemesi kuralının istisnası TTK m. 371/7'de yer almaktadır. Buna göre eğer TTK m. 371/7 hükmü uyarınca tacir yardımcısı atanmış ise, atanan kişilerin görev ve yetkilerinin TTK m. 367 uyarınca hazırlanan iç yönergede belirtilmesi ve iç yönergenin de tescil ve ilan edilmesi gerekir.

209 Yönetim kurulunun mali hakları hakkında geniş bilgi için bkz. **Özdamar**, Mali Haklar, s. 199 vd.

210 Ücret hakkında bkz. ve karş. **Özer**, I., Türk ve Yabancı Hukuk Sistemlerinde Anonim Şirket Yöneticilerinin Mali Hakları, Ankara 2013, s. 147.

211 **Tekil**, F., Anonim Şirketler Hukuku, İstanbul 1998, s. 190.

212 İkramiye hakkında açıklamalar için bkz. **Poroy (Çamoğlu/Tekinalp)**, I, N 562.

yapılabilir. Yönetim kurulu üyelerine belirtilen ödemelerin yapılması için kanunda bazı şartlar aranmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi yetkisi genel kurulun devredilemez yetkileri arasında zikredilmiştir (TTK m.408/2-b). Ancak TTK m.339/2-f hükmünde yönetim kurulu üyelerine şirket kârından sağlanacak menfaatlerin esas sözleşmede yer alması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hüküm sebebiyle kazanç payının ödenebilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması gerekir.

Esas sözleşmede hüküm bulunması zorunluluğu yalnızca ödemenin yapılıp yapılamayacağına ilişkindir. Yoksa yapılacak ödemenin tutarının esas sözleşme ile belirlenmesi şart değildir. Eğer tutar esas sözleşmede belirlenmemiş ise, bu husus TTK m.394 uyarınca genel kurul tarafından karara bağlanabilir. Üyelere ücret ve huzur hakkı ödenmesi için ise esas sözleşmede hüküm bulunması mümkün ancak gerekli değildir.

Kazanç payı ödemesi yapılabilmesi hakkında esas sözleşmede hüküm bulunması dışında kanunda başkaca ilave şartlar da öngörülmüştür. Buna göre kazanç payları, sadece net kârdan ve ancak kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir (TTK m.511, 519/2-c).

2) Haksız Yere ve Kötüniyetle Alınan Kazanç Paylarının İadesi

Kanunda haksız yere ve kötüniyetle kazanç payı alan yönetim kurulu üyelerinin, bunları geri vermekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir[213]. Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şirketin iflası hâlinde ise farklı esaslar benimsenmiştir. Buna göre şirketin iflası halinde, yönetim kurulu üyeleri şirket alacaklılarına karşı, iflasın açılmasından önceki son üç yıl içinde kazanç payı veya başka bir ad altında hizmetlerine karşılık olarak aldıkları ve fakat uygun ücreti aşan ve bilanço uygun bir ücret miktarına göre tedbirli bir tarzda düzenlenmiş olsaydı ödenmemesi gereken paraları geri vermekle yükümlüdürler.

---

213 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Ayhan, R.**: *Anonim Şirketlerde Haksız ve Kötüniyetle Alınan Kâr ve Kazanç Paylarının İadesi,* Ulusoy, s. 97 vd.

Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümler gereğince alınması mümkün olmayan paraların geri verilmesi yükümlülüğü yoktur. Mahkeme, hâlin bütün gereklerini göz önünde bulundurarak takdir hakkını kullanır.

B) BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1) Genel Olarak

Yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu toplantısına katılması, oy hakkını kullanması gibi haklardan etkin bir şekilde istifade etmesi, bu haklarını bilgiye dayalı olarak kullanılmasına bağlıdır[214]. Ayrıca bu durum özenli bir yönetimin de en önemli şartıdır. Bu sebeple yönetim kurulu üyelerine bilgi alma ve inceleme hakkı tanınmıştır. Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir (TTK m.392/1).

Yönetim kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas sözleşmenin üyelerin bilgi alma hakkını kısıtlayan veya kaldıran hükümleri, kesin hükümsüzdür. Buna karşılık esas sözleşme, yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. Her bir üyenin yönetim kurulunu toplantıya çağırabilmesi son derece önemli bir imkân olup, Kanunda her bir üyenin başkandan yazılı olarak talep etmeleri şartıyla toplantı yapılmasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır (TTK m.392/7).

Kanun koyucu, üyelerin bilgi alma hakkını toplantı sırasında ve toplantı dışında olmak üzere ikili bir ayrıma tâbi tutmuştur. Aşağıda bilgi alma hakkı bakımından öncelikle toplantı sırasında daha sonra toplantı dışında kabul edilen ilke ve kurallara değinilmiştir.

2) Toplantı Sırasında

Her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınması reddedilemez (TTK m.392/1). Eğer reddedilirse, bu

---

214 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Kalender, E.**: Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma Hakkı (TTK m.392), Ankara 2017, s. 9 vd.

durumda, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alma talebinin reddi halinde takip edilecek usule uygun hareket edilir.

Yönetim kurulu toplantılarında, yönetim kurulunun bütün üyeleri gibi, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki isteminin reddedilmesi veya sorularının cevapsız bırakılması mümkün değildir.

3) Toplantı Dışında

Her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir.

Başkan bir üyenin, söz konusu bilgi alma, soru sorma ve inceleme yapma istemini reddederse, konu iki gün içinde yönetim kuruluna getirilir. Kurulun toplanmaması veya bu istemi reddetmesi hâlinde üye, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Mahkeme istemi dosya üzerinden inceleyip karara bağlayabilir, mahkemenin kararı kesindir.

Yönetim kurulu başkanı, kurulun izni olmaksızın, yönetim kurulu toplantıları dışında bilgi alamaz, şirket defter ve dosyalarını inceleyemez. Yönetim kurulu başkanının bu isteminin reddedilmesi hâlinde başkan da aynı şekilde kurulun diğer üyeleri gibi mahkemeye başvurabilir.

VII. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. ÖZEN VE SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. Yönetim hakkı TTK 367. maddeye göre kendisine devredilen üçüncü kişiler de özen ve sadakat yükümlülüğüne tâbidir. Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişilerin özen ölçüsünün belirlenmesinde, benzer işletmelerdeki yöneticilerden beklenebilen işin gerektirdiği özen esas alınır.

Sadakat yükümlülüğü, özen yükümlülüğü ile yakından ilgili olup bununla, yönetim kurulu üyelerinin kişisel menfaatini, hâkim pay sahibinin, pay sahiplerinin veya üçüncü kişilerin menfaatini, şirketin menfaatinin önüne geçirmeme yükümlülüğü kastedilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri, menfaat çatışması bulunan örneğin üyelerin şirketle işlem yapması gibi durumlarda şirket menfaatlerinin korunması bakımından gerekli önlemleri almak zorundadır. Şirket menfaatlerinin korunması zorunluluğu topluluk oluşturan şirketlerde bağlı şirket bakımından sakınca doğurabilir. Bu sebeple TTK m.369/2 hükmünde, 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklı tutulmuştur.

B. EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk Ticaret Kanunu m.57'de, "*pay sahipleri eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulur*" denilmekle, özellikle azınlık pay sahipleri bakımından eşit muamele görme ilkesi kanunla hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm sebebiyle şirket genel kurulu ve yönetim kurulu, karar ve uygulamalarında eşit şartlarda olan pay sahiplerine eşit muamelede bulunmalıdır.

C. MENFAAT ÇATIŞMASI

Yönetim kurulu, anonim şirketin zorunlu organlarından biri olup, şirketin yönetim ve temsili hak ve yetkisi –delegasyon imkânı ile birlikte- yönetim kurulu üyelerine aittir. Anonim şirketlerde pay sahiplerinin, bu sıfatları dolayısıyla yönetim ve temsil yetki ve görevleri bulunmamaktadır[215]. Şirketin yönetimi yetkisi "*yönetim kurulu*"ndadır. Eğer pay sahipleri şirketin yönetiminde yer almak istiyorlarsa, genel kurul tarafından seçim yoluyla bu göreve getirilmelidir. Hemen belirtmek gerekir ki pay sahiplerine TTK m.367 ile yönetim yetkilerinin delege edilmesi de mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri pay sahiplerinden oluşabileceği gibi, pay sahibi sıfatı taşımayan üçüncü kişilerin de yönetim kurulu üyesi olması mümkündür[216]. Dolayısıyla her bir pay sahibinin yönetim kurulunda

---

[215] Buna karşılık örneğin kollektif şirketlerde, "*ortaklardan her biri, ayrı ayrı şirketi yönetme hakkını ve görevini haizdir. Ancak, şirket sözleşmesiyle veya ortakların çoğunluğunun kararıyla yönetim işleri ortaklardan birine, birkaçına veya tümüne verilebilir*" (TTK m. 258).

[216] 6762 sayılı TTK m. 312'de, yönetim kurulunun pay sahiplerinden oluşacağı hükme bağlanmış; ancak pay sahibi olmayan kişilerin üye seçilmesi halinde, bu

yer almaması veya yönetim kurulunun tamamen üçüncü kişilerden teşekkül ettiği hallerde, şirkete sermaye koyan kişiler ile (pay sahipleri), şirketi yönetenler (yönetim kurulu, yöneticiler) birbirinden ayrılmaktadır. Dolayısıyla bu halde şirket yöneticileri, başkalarının menfaatlerini korumakla yükümlü olan kişiler konumuna geçmektedir. Yönetim kurulu üyeleri ile şirketin menfaatlerinin çatışması halinde, üyelerin kendi menfaatlerine üstünlük tanıma tehlikesi bulunduğu için kanunda bu türlü tehlikeleri önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alınmıştır. Üyeler, kanunda öngörülen usul ve şartlara riayet etmezlerse, bundan doğan şirket zararlarını tazminle yükümlü olurlar.

Menfaat çatışmalarının sakıncalarını ortadan kaldırmak amacıyla öngörülen en genel yükümlülük özen ve sadakat yükümlülüğüdür (TTK m.369). Buna ilave olarak Kanun koyucu bazı iş ve işlemler bakımından maddi ve usulü bir takım önlemler alarak menfaat çatışmalarından kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri bertaraf etmeye çalışmıştır. Örneğin yönetim kurulu üyesinin, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapması halinde bunun genel kurulun onayına tâbi tutulması, aksi halde şirketin, yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilmesine imkân tanıyan TTK m.395/1 bu kapsamda zikredilebilir. Benzer şekilde yönetim kurulu üyesinin, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya kanunda belirtilen yakınlarının kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaması, aksi halde bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlü tutulmaları da menfaat çatışmalarının giderilmesine ilişkin hükümlere örnek olarak verilebilir.

D. SERMAYE KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK HALİNDE GÖREVLERİ

Anonim şirketler, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumludur. Pay sahiplerinin şirket borçlarından dolayı, şirket alacaklılarına karşı herhangi bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu sebeple şirketin sermayesinin ve malvarlığının korunması amacıyla kanunda çok sayıda önlem alınmıştır. Bu önemlerden biri de ayrıntıları aşağıda açıklanmış olan TTK m.376 vd. hükümlerinde düzenlenmiş "*sermayenin kaybı, borca batık olma durumu*"nda alınacak önlemlerdir.

---

kişilerin pay sahibi sıfatını kazandıktan sonra işe başlayabilecekleri öngörülmüştü.

1. Sermaye Kaybı

Şirketin son yıllık bilançosundan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulunun hemen genel kurulu toplantıya çağırması ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunması gerekir (TTK m.376/1).

Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yine genel kurulun derhâl toplantıya çağrılması gerekir. Bu toplantıda genel kurul ya sermayenin üçte biri ile yetinilmesi veya sermayenin tamamlanmasına karar verir. Eğer bu iki karardan biri verilmezse şirket kendiliğinden sona erer (TTK m.376/2).

2. Borca Batıklık

Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.

Borca batıklık halinde, şirketin iflasının engellenmesi için şöyle bir imkân tanınmıştır: Mahkemece iflas kararının verilmesinden önce, "*şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olursa*" yönetim kurulunun şirketin iflasını istemesi gerekmez. Ancak kanunda aranan şartlar, bilirkişilerce doğrulanmamış olursa, mahkemeye bilirkişi incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur (TTK m.376/3).

Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı, TTK m.376/3 uyarınca yapacağı iflâs talebiyle birlikte veya bu kapsamda yapılan iflâs yargılaması sırasında 2004 sayılı Kanunun 285 inci ve devamı maddeleri uyarınca konkordato da talep edebilir. Konkordato, borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlunun, vade verilmek veya tenzilat yapılmak

suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için başvurabileceği hukuki imkândır[217].

E. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Şirketin kendi paylarını iktisabı ve rehin olarak kabul edilmesi belirli istisnalar dışında mülga 6762 sayılı Kanun döneminde mümkün değildi[218]. 6102 sayılı Kanun ile birlikte, belirli şartlar altında şirketin kendi paylarını iktisap etmesine sınırlı şekilde izin verilmiş; şirketin kendi paylarını iktisabından doğacak sakıncaların bertaraf edilmesi amacıyla bazı önlemler getirilmiştir.

1. Genel Olarak

6102 sayılı TTK sisteminde anonim şirketlere, kanunda öngörülen şartlara uymak kaydıyla, sermayesinin yüzde onuna kadar kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edebilme imkânı verilmiştir (TTK m.379/1). Kanunda sayılan şartlara uyulmak kaydıyla, her anonim şirket, sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile, kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edebileceği için, yasağın sermayenin yüzde doksanını oluşturan paylar için geçerli olduğu söylenebilir[219]. Yasak, ivazlı iktisaplar bakımından geçerlidir. Yoksa bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, şirket kendi paylarını ivazsız iktisap edebilir; ancak ivazsız olarak iktisap edilen paylar bakımından da elden çıkarma zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirketin sermayesinin yüzde onunu aşmamak kaydıyla kendi paylarını iktisap ve rehin olarak kabul edilebilmesi için gerekli şartlardan ilki yönetim kurulunun bu konuda genel kurul tarafından yetkilendirmesidir. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilecek yetkinin süresi en çok beş yıl olabilir. Sürenin dolması halinde, yeniden yetki verilmesi

---

217 Konkordato hakkında ayrıntılı bilgiler için bkz. **Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes,** s. 441 vd.

218 Anonim şirketlerin paylarını iktisap etmelerinin mutlak bir şekilde yasaklanması şeklindeki yaklaşımın miadını doldurduğu, şirketin kendi paylarını iktisap etmelerine belirli şartlar altında izin verilmesi gerektiği yönünde 6762 sayılı Kanun döneminde yapılan öneri ve eleştiriler için bkz. **Özdamar**, İktisap, s. 93 vd.

219 TTK m. 379 gerekçesi.

mümkündür[220]. Verilen yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayıları belirtilerek toplam itibarî değerleriyle söz konusu edilecek paylara ödenebilecek bedelin alt ve üst sınırı gösterilir (TTK m.379/2). Genel kurul tarafından yetkilendirme yapıldığı zaman, şirket sermayesinin yüzde onuna kadar (*serbest yüzde*) ivazlı iktisap ve rehin yasağı artık uygulanmamaktadır[221].

Genel kurul tarafından yönetim kurulunun yetkilendirilmesine ilave olarak iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, kalan şirket net aktifinin, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olması gerekir. Ayrıca iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların bedellerinin tümünün ödenmiş olması gerekir. Kanunda öngörülen bu sınırlar, ana şirketin paylarının yavru şirket tarafından iktisabı hâlinde de uygulanır (TTK m.379/3, 4, 5).

Anonim şirketlerin kendi paylarının iktisabı amacıyla üçüncü kişilere finansal destek verilmesi de yasaklanmış, bu amacı taşıyan konusu avans, ödünç veya teminat verilmesi olan hukuki işlemler batıl sayılmıştır. Kanun koyucu, üçüncü kişilere finansal destek sağlanmasını, şirketin kendi paylarını *dolaylı* olarak kendisinin alması şeklinde kabul etmiş ve TTK m.379 ile öngörülen düzenin etkisiz kalmasını ve dolanılmasını engellemeyi amaçlamaktadır[222].

2. Yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi

Şirketin kendi paylarını iktisabına yukarıda görüldüğü gibi, şirket sermayesinin yüzde onuna kadar yalnızca belirli şartlar altında izin verilmiş olmasına rağmen, yakın ve ciddi bir kaybın bulunması halinde şirket paylarının iktisabından doğacak kayıp daha önemsiz görülerek, bu hallere özgü ayrıksı bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre bir şirketin, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak için gerekli olduğu takdirde, kendi paylarını, genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan da iktisap etmesi mümkündür (TTK m.381/1). Paylar eğer bu şekilde iktisap edilmiş ise, yönetim kurulu ilk genel kurula, iktisabın sebep ve amacı, iktisap edilen payların sayıları, itibarî değerlerinin toplamı ve

---

220 TTK m. 379 gerekçesi.
221 TTK m. 379 gerekçesi.
222 TTK m. 379 gerekçesi.

sermayenin ne kadarını temsil ettiği, bedeli ve ödeme şartları hakkında yazılı bilgi verir.

Madde metninde geçen, "yakın" sözcüğünün, hem doğrudan hem de sonuçlarını hemen doğurabilecek kaybı ifade ettiği; "kayıp" sözcüğünün de zararı kapsayan geniş bir kavram olduğu ifade edilmiştir[223]. Yakın ve ciddi tehlikeye örnek olarak hükmün gerekçesinde, "*şirketin, kendi paylarını iktisap edememesi durumunda borca batık bir kişiden alacağın tahsil edilememesi, hisse senetlerinin borsada anî düşmesi veya düşebilecek durumda bulunması, şirket hakimiyetinin başka bir grubun eline geçmesi veya geçecek olması*" durumları gösterilmiştir.

3. İstisnalar

Kanun koyucu, 6762 sayılı kanunda olduğu gibi, iktisap ve rehin yasağı bakımından bazı istisnalar da öngörmüştür. Buna göre bir şirket, TTK m.379 hükümleri ile bağlı olmaksızın; esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin TTK m.473 ilâ 475 inci madde hükümlerini uyguluyorsa, küllî halefiyet kuralının gereğiyse, bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa, bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının tahsili amacına yönelikse, kendi paylarını iktisap edebilir. Aynı esas, şirketin menkul kıymetler şirketi olması halinde de geçerlidir.

4. İktisap Edilen Payların Elden Çıkarılması

Paylar, TTK'nin 382. maddesinde öngörüldüğü üzere küllî halefiyet kuralı gereği veya bir kanuni satın alma yükümünden kaynaklı olarak veyahut cebrî icradan alınmış ise, iktisap edilen paylar, şirket için herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her hâlde iktisaplarından itibaren *üç yıl* içinde elden çıkarılırlar. Aynı prensip ivazsız olarak iktisap edilen paylar bakımından da geçerlidir. Ancak şirketin sahibi olduğu bu payların toplamı şirketin sermayesinin yüzde onunu aşmadığı müddetçe elden çıkarma zorunluluğu bulunmamaktadır (TTK m.384).

Şirketin kendi paylarını iktisabı ile ilgili olarak TTK m.379'da öngörülen genel esaslara veya yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesine ilişkin TTK m.381 hükmüne aykırı bir şekilde iktisap edilen veya rehin olarak alınan paylar, iktisapları veya rehin olarak kabulleri tarihinden

---

223 TTK m. 379 gerekçesi.

itibaren *en geç altı ay* içinde elden çıkarılır ya da üzerlerindeki rehin kaldırılır.

Elden çıkarılamayan payların, sermayenin azaltılması yoluyla hemen yok edilmesi gerekir.

5. Kendi paylarını taahhüt yasağı

Şirket sermayesinin korunmasının bir gereği olarak, şirketin kendi paylarını taahhüt etmesi de yasaklanmıştır. Ayrıca yasağın dolanılmasının engellenmesi amacıyla, üçüncü kişinin veya bir yavru şirketin kendi adına fakat şirket hesabına şirketin payını taahhüt etmesinin de, şirketin kendi payını taahhüt etmesi sayılacağı öngörülmüştür (TTK m.388/2). Taahhüt yasağına aykırılık halinde, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bu kişiler pay bedellerinden sorumlu olurlar. Ancak kanuna aykırı taahhütte herhangi bir kusurları bulunmadığını ispat eden kurucular ve sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri sorumluluktan kurtulurlar.

Taahhüt yasağı, ana şirketin paylarını taahhüt eden yavru şirketlere kıyas yoluyla uygulanır. Söz konusu paylar yavru şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından taahhüt edilmiş kabul olunur ve üyeler pay bedellerinden sorumludur.

6. Hakların kullanılması

Şirketin kanuna uygun veya aykırı bir şekilde iktisap ettiği paylar şirkete prensip olarak pay sahipliği hakkı vermez. Bedelsiz payların iktisabı bundan müstesnadır. Şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin payları, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaz. Ayrıca yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar.

VIII. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TÂBİ OLDUKLARI YASAKLAR

A. ŞİRKETLE İŞLEM YAPMA YASAĞI

Yönetim kurulu üyelerinin kendi menfaatlerini takip etmeleri tehlikesi bulunduğu için şirketle işlem yapmaları yasaklanmıştır. Buna göre, yönetim kurulu üyesinin, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi

bir işlem yapması mümkün değildir. Hükmün kenar başlığı her ne kadar şirketle işlem yapma yasağı şeklinde kaleme alınmışsa da, bu yasak mutlak değildir. Çünkü yönetim kurulu üyelerinin genel kuruldan izin almaları kaydıyla şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapması mümkündür. Eğer izin alınmadan işlem yapılmış ise, şirketin yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürmesi mümkün iken, diğer tarafın böyle bir iddiada bulunamayacağı hükme bağlanmıştır (TTK m.395/1).

B. ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI

Pay sahiplerinin şirkete borçlanmalarına ilişkin ilke ve esaslar, TTK m.358'de hükme bağlanmıştır. Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları (alt ve üst soyundan biri ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri) şirkete nakit olarak borçlanamayacağı ise TTK m.395/2'de hükme bağlanmıştır. Belirtilen kişiler için, şirketin kefalet, garanti ve teminat vermesi yasak olduğu gibi, sorumluluk yüklenmesi ve bu kişilerin borçlarını devralması da engellenmiştir[224].

C. ŞİRKETLE REKABET ETME YASAĞI

Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında rekabet yasağı öngörülmüştür. Bunun sebebi, şirket yöneticilerinin edindiği bilgi ve şirket sırlarını başka şirketler için kullanmasının önüne geçmektir. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinden birinin, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi mümkün değildir. Bununla birlikte yönetim kurulu üyelerinin şirketle rekabet oluşturabilecek faaliyetlerde bulunmasına genel kurul tarafından izin verilebilir (TTK m.396/1); bir başka anlatımla yasak emredici mahiyette değildir.

Rekabet yasağına aykırı bir davranışın bulunup bulunmadığı incelenirken, şirketin işletme konusunun dar yorumlanmak suretiyle

---

224 Ayrıntılı bilgi için bkz. Altıncı Bölüm, § 8, V, F, başlığı. Ayrıca bkz. **Özdamar M. / Doğan, İ.:** *"Banka Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin Borçlanma Yasağı"* Bankacılar Dergisi, Eylül 2013 s. 3 vd.

"*şirketin fiilen uğraştığı işler*" şeklinde yorumlanması gerekir[225]. Nitekim 865 sayılı TTK m.324'te "*şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlem*" ifadesi yerine, isabetli bir şekilde "***şirketin icra eylediği muamele-i ticariye nevinden bir muamele***" ifadesi kullanılmıştır.

Rekabet yasağına aykırı hareket edilirse, şirket bundan doğan zararını, yasağa aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerine tazmin ettirebilir. Şirketin tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış sayması ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmesi de mümkündür. Kanunda tanınan seçimlik haklardan hangisinin kullanılacağına, yasağı ihlal eden üye dışındaki yönetim kurulu üyeleri karar verir.

Rekabet yasağından doğan şirket talepleri hakkında kanunda kısa zamanaşımı süreleri öngörülmüştür. Buna göre, şirketin sahip olduğu seçimlik haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve her hâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar.

IX. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR ALINMASI

A. TOPLANTININ ORGANİZASYONU

Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere, en az bir başkan vekili seçer. Yönetim kurulunu toplantıya kural olarak başkan davet eder. Ancak her yönetim kurulu üyesi başkandan, yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir. Yönetim kurulunun yılda kaç defa toplanacağına, üyeler kendileri karar verir.

Yönetim kurulu toplantılarına katılmak üyeler bakımından hem bir yetki hem de bir görevdir. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

---

[225] **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 569.

B. KARAR ALINMASI

1. Toplantı ve Karar Nisapları

Yönetim kurulu, kurulun üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Bununla birlikte kanunda öngörülen nisaplar hakkında esas sözleşmede *ağırlaştırıcı* yönde düzenleme yapılabilir.

Alınan kararların geçerli olması için, yazılıp imzalanmaları gerekir. Türk Ticaret Kanunu sistemi içinde anonim şirket yönetim kurulu başkanına üstün oy hakkı tanınmamıştır. Eğer oylar eşit olursa, o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

2. Sirküler Karar Ve Elektronik Yönetim Kurulu

Yönetim kurulunun, toplanmasına gerek olmaksızın bir önerinin imzalanması yolu ile veya elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılarak karar alması mümkündür. Buna göre, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle yönetim kurulu kararı alınabilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Bu şekilde alınan karara "*sirküler karar*" denilir. Ayrıca sirküler karar alınabilmesi için üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmamış olması gerekir.

Esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, anonim şirketlerde, yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir[226]. Bu hâllerde Kanunda veya esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

---

[226] Bu hususta bkz. "*Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ*", 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete.

C. KARARLARIN GEÇERSİZLİĞİ

Yönetim kurulu kararlarının kural olarak iptalinin istenmesi mümkün değildir. Ancak bazı istisnai durumlarda yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılabilmesine izin verilmiştir. Yönetim kurulu kararlarına karşı butlanın tespiti davası açılabileceği, 6762 sayılı Kanun döneminde gerek Yargıtay içtihatlarında gerek öğretide kabul edilmekteydi. TTK m.391'de, mevcut kabul doğrultusunda yönetim kurulu kararlarının butlanı düzenlenmiştir.

1. Yokluk

Yokluk bir işlemin kurucu unsurlarının bulunmamasıdır[227]. Yönetim kurulu kararları bakımından, gerekli toplantı veya karar yetersayılarına uyulmaksızın alınan kararlar yokluk ile maluldür[228]. Yokluk ile malul olan bir yönetim kurulu kararı aleyhine menfaati olan herkes tespit davası açabilir.

2. Butlan

Yönetim kurulu kararlarının butlanla malul olmasına yol açan sebepler, TTK m. 391'de sayılmış olmakla birlikte, yapılan bu sayım tahdidi değil; örnekleyicidir[229]. Tespit davası meşrû menfaati bulunan herkes tarafından, herhangi bir süreye bağlı olmaksızın açılabilir.

Kanunda yönetim kurulunun kararlarının butlanına yol açacağı belirtilen ilk durum, kararın eşit işlem ilkesine aykırı olmasıdır. Bunun dışında, anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen yönetim kurulu kararları da batıldır. Bu anlamda yönetim kurulunun pay sahiplerine, ödedikleri sermayenin iade edileceğine ilişkin kararları batıldır[230].

Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren veya diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin kararlar batıldır.

---

227 **Kaşak, F. E.,** s. 460.

228 **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp),** I, N 534.

229 TTK m.391 gerekçesi; **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp),** I, N 534; TBK m. 27 çerçevesinde ortaya çıkabilecek butlan sebepleri için bkz. **Kaşak**, F. E., s. 366 vd.

230 Batıl yönetim kurulu kararları hakkında bkz. **KUKO- Sunaric, P.:** Kurzkommentar OR, Art. 1-1186 OR, Hrsg: Honsell, Heinrich, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2014, Art. 714, N 3 vd.

3. İptal

Genel kurul kararlarının iptali mümkün olmakla birlikte, yönetim kurulu kararlarının iptali hakkında genel bir hüküm öngörülmemiştir. Ancak kanun koyucu, bazı istisnai hallerde yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılmasına izin vermiştir.

Bilindiği üzere yapısal değişlik kararları genel kurulun onayına tâbidir. Ancak bazı hallerde kanunda genel kurulun onayı aranmamış, yapısal değişiklikler bakımından yalnızca yönetim kurulu kararı ile iktifa edilmesine izin verilmiştir. Örneğin aralarında belirli oranda iştirak ilişkisi bulunan şirketlerin birleşmesinde, birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulmasından imtina edilebilir. Bunun gibi, kararın yönetim kurulu tarafından verilmesi hâlinde, yönetim kurulu kararına karşı iptal davası açılabilir. Söz konusu davanın, birleşme, kararına olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye katılan şirketlerin ortakları tarafından açılması gerekir. Davanın açılması hak düşürücü süreye tâbi tutulmuş olup, dava ancak kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren iki ay içinde açılabilir. İlanın gerekmediği hâllerde süre tescil tarihinden başlar.

Yönetim kurulu kararları aleyhine iptal davası açılabilecek bir başka hal, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden anonim şirketler bakımından söz konusu olur. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden şirketlerde, yönetim kurulu esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olmak kaydıyla, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarılmasına ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırılmasına karar verebilir. Bu durumda yönetim kurulu kararları aleyhine, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin olarak TTK m.445'te öngörülen sebeplerin varlığı hâlinde kararın ilanı tarihinden itibaren *bir ay* içinde iptal davası açabilirler. Bu davada, genel kurul kararlarının iptali hakkında uygulanan - ilan, teminat ve kanun yolu, kararın yürütülmesinin geri bırakılması, kararların etkisi ve kötüniyetle iptal ve butlan davası açanların sorumluluğuna ilişkin 448 ilâ 451 inci maddeler kıyas yoluyla uygulanır.

Kayıtlı sermaye sitemini kabul eden halka açık anonim şirketler bakımından, SPK m.18/5'te, yönetim kurulunun, esas sözleşme ile yetkilendirilmesi kaydıyla, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını

sınırlandırması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alabilmesi mümkündür. Yönetim kurulunun aldığı bu kararlar aleyhine, 6102 sayılı Kanunun genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler (SPK m.18/6).

X. YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

A. GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa aynı kişilerin yeniden seçilmesi mümkündür. Yönetim kurulu üyelerinin tamamının görev süresi sona ermiş ve yerine yenileri seçilmemiş ise, hukuki durumun ne olacağı konusunda Kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Yalnızca görev süresi sona erse dahi yönetim kurulunun, genel kurulu toplantıya çağırabileceği hükme bağlanmıştır (TTK m.410/1).

B. İSTİFA

Yönetim kurulu üyeleri, her zaman istifa edebilirler. İstifa hakkından baştan vazgeçilmesi mümkün değildir.

C. AZİL

Yönetim kurulu üyelerinin azline genel kurul yetkilidir ve bu genel kurulun devredilemez yetkilerindendir (TTK m.408/2-b). Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Görevden alınan üyeler, şartları varsa tazminat talep edebilirler.

D. DİĞER SEBEPLER

Yönetim kurulu üyelerinden birinin iflasına karar verilmesi, ehliyetinin kısıtlanması ya da üyelik için gerekli kanuni şartları yahut esas sözleşmede öngörülen nitelikleri kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

§11- ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

LİTERATÜR

Akad, G.: *6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketlerde İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu*, İstanbul 2013; Arseven, H.: *"Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul Kararlarına Karşı Kötüniyetle Açılan İptal Davasının Müeyyideleri"*, Arslanlı'ya Armağan, İstanbul 1978, s. 277-287; Coştan, H.: *Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kararları*, Ankara, Temmuz 2012, s. 76 vd.; Çamoğlu, E.: *Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar*, Yaklaşım, Y. 21, S. 241; s. 244 vd.; Çamoğlu, E.: *"Anonim Ortaklık Genel Kurulu İç Yönergesi Hakkında Düşünceler"*, Yaklaşım, Y. 21, S. 247, s. 246 vd; Çamoğlu, E.: *"Anonim Ortaklık Genel Kurulunu Toplantıya Kimler Çağırır?"* Yargı Dünyası, S. 204, Aralık 2012; Erdem, N.: *"6102 Sayılı Yeni TTK'ya göre Anonim Ortaklık Pay Sahiplerinin Müktesep (Kazanılmış) Hakları"*, REGESTA 2012, C. II, S. 1, s. 29-44; İmregün, O.: *"Anonim Şirketlerde Münferit Pay Sahibinin Umumi Heyet Kararları Aleyhine Dava Açma Hakkı"*, Batider, C. I, S: 2, s. 149 vd.; İmregün, O.: *Anonim Şirketlerde Pay Sahipleri Arasında Umumi Heyet Kararlarından Doğan Menfaat İhtilafları ve Bunları Telif Çareleri*, Ankara 1962; Kalpsüz, T.: *"Bilanço ve Oy Kullanma Esaslarına Aykırılık Sebebiyle Genel Kurul Kararlarının İptali"*, Batider, C. X, S. 1, s. 23-65; Korkut, Ö.: *6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Butlanı*, Adana 2012; Kuru, B.: *"Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının İptali Davasında Teminat Gösterme Dava Şartı mıdır?"* Batider, C. X, S. 9, s. 951 vd.; Moroğlu, E.: *Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya Daveti Genel Kurul Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları*, Sempozyum VII; Ankara 1990, s. 37 vd.; Moroğlu, E.: *Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri*, İstanbul 2007; Moroğlu, E.: *Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü*, İstanbul 2017; Nomer, H. N.: *Kişi Birliklerinde Genel Kurul Kararlarının Geçersizliğine İlişkin Esaslar,*

İstanbul 2008; Pulaşlı, H.: *"Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi"*, Prof. Dr. Ersin Çamoğlu'na Armağan, İÜHF, C. XXI, S. 2, İstanbul 2013, s. 335 vd.; Saka, Z.: *Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul*, İstanbul 2004; Teoman, Ö.: *"Anonim Ortaklıkta İptal Edilebilir Genel Kurul Kararlarının Doğrulanması"*, İkt. Mal. C. XVII, S. 12, Mart 1971, s. 545 vd.; Teoman, Ö.: *"Çağrısız Genel Kurul Gündemine Oybirliği ile Madde Eklenmesi"*, Batider, C. XXVII, S. 3 (Eylül 2011), s. 5 vd.; Tekinalp, Ü.: *"Olumlu veya Çekimser Oy Kullanan Pay Sahibi İptal Davası Açabilir mi?"* İkt. Mal. C. XXIX, s. 278 vd.; Tekinalp, Ü.: *"Genel Kurul Kararlarının Butlanında Anonim Ortaklığa Özgü Sebeplerin Kabulü İhtiyacı"*, Batider 2009, C. XXV, s. 4 vd.; Teoman, Ö.: *"Yürürlükteki Hukukumuzca ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Ortaklık Genel Kurul Toplantılarına Katılmak Zorunda Olanlar"*, Prof. Dr. Reha Poroy'un Anısına Armağan, Batider, C. XXV, S: 5, Aralık 2009, s. 19 vd.; Von Bühren, R./Stoffel, W.A./Weber, R.H.: Grundriss des Aktienrechts Mit Berücksichtigung der laufende Revision, 3.Aufl., 2011.

GİRİŞ

Anonim şirketlerde genel kurul, oy hakkına sahip tüm pay sahiplerinin oluşturduğu ve sürekli olmayan bir organdır. Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar.

Genel kurul üçüncü kişilerle doğrudan bir etkileşim içinde olmadığından, yönetim kurulunun aksine, bir iç organ olarak da nitelendirilebilir[231].

Kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul olağan veya olağanüstü toplanarak çalışır. Bu toplantılara pay sahipleri veya yetkili temsilcileri katılırlar.

Genel kurul, ortaklığın en yüksek karar organıdır. Genel kurul, kararları ile ortaklık iradesini açıklar. Bu kararlar bütün pay sahipleri hakkında geçerlidir. Yeter ki, toplantı ve karar alma usullerine uyulsun. Şirket ortaklarının toplantıda hazır bulunup bulunmamasının, çekimser veya muhalif oy verip vermemesinin önemi yoktur.

Genel kurul kararları pay sahiplerini olduğu kadar, şirketin diğer organlarını da bağlar.

---

[231] **Von Büren/Stoffel/Weber,** N. 467.

I) GENEL KURULUN YETKİLERİ

A. GENEL OLARAK

Genel kurul yetkileri esas itibariyle TTK'nin değişik maddelerinde düzenlenmiştir. Bu yetkilerin bir kısmı açıkça devredilemez görev ve yetkiler başlığı altında m.408 hükmünde yer alırken, bir kısım görev ve yetkileri ise Kanunun çeşitli maddelerinde dağınık şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca bazı konularda şirket sözleşmesi ile de genel kurula yetki tanınması söz konusu olabilir.

B. GENEL KURULUN DEVREDEMEYECEĞİ YETKİLER

Genel kurulun başka bir kişiye veya organa devredemeyeceği yetkiler TTK m.408/2 hükmünde sayılmış ve diğer hükümlerde yer alan devredilemez görevler ve yetkiler de saklı tutulmuştur. Kanunda açıkça devri yasaklanan görev ve yetkiler nitelikleri gereği sadece genel kurul tarafından kullanılır. Esas sözleşmeyle dahi başka bir organa devredilemez. Söz konusu bu yetkileri ayrıntılı olarak ele almak uygun olacaktır.

1. Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi

Anonim şirket esas sözleşmesi, kurucular tarafından hazırlanıp tescil ettirildikten sonra değiştirilebilmesi ancak genel kurul tarafından gerekli asgari çoğunluk sağlanmak kaydıyla mümkün olabilir (TTK m.408/2, a). Bu çerçevede sermayenin artırılması, azaltılması, şirket merkezinin değiştirilmesi gibi konularda sözleşmenin değiştirilebilmesi ancak genel kurulun belirli nitelikte çoğunlukla karar alınmasını gerektirir.

2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Süreleri, Ücretleri Gibi Konularda Karar Almak

Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim hakkı gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları (TTK m.408/2, b) genel kurulun devredilemez yetkileri arasındadır.

Esas sözleşmeyle veya yönetim kurulu tarafından atanmış veya genel kurulca seçilmiş olsalar da yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yerine yenilerinin atanması yetkisi genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerindendir.

Aynı şekilde yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının belirlenmesi ve ibra edilmeleri de genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasındadır.

3. Denetçinin Seçimi

Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması (TTK m.408/2, c) da genel kurulun devredilemez yetkileri arasında sayılmışsa da denetçinin görevden alınması konusunda genel kurulun yetkisi bulunmamaktadır. Gerekli hallerde bu yetki ancak mahkemeler tarafından kullanılabilir. Nitekim bu konuyu düzenleyen TTK m.399/4 hükmünde açıkça denetçinin görevden alınması ve yerine yenisinin atanması yetki ve görevi şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine tanınmıştır.

4. Finansal Tablolar, Yıllık Rapor ve Kâr Dağıtımına İlişkin Karar Alınması

Genel kurulun devredemeyeceği yetkilerinden bir diğeri de finansal konularla ilgilidir. Kanun koyucu, TTK m.408/2-d hükmünde finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınmasını da devredilemeyecek yetkiler arasında saymıştır.

5. Şirketin Feshi

Anonim şirketin sona erme sebeplerinden biri de genel kurulda fesih kararı alınmasıdır. İşte genel kurulun fesih kararı alma yetkisi de devredilemeyecek yetkilerdendir (TTK m.408/2-e). Söz konusu yetki şirket genel kurulunda sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyları ile kullanılabilir (m.529/1-d; 421/3).

6. Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı

Genel kurulun devredemeyeceği yetkilerinden bir diğeri de şirketin önemli miktarda varlığının toptan satışıdır (TTK m.408/2, f). Bu surette şirket alacaklılarının ve pay sahiplerinin yegane teminatını oluşturan şirket malvarlığının ve dolayısıyla şirket sermayesinin korunması amaçlanmıştır. Genel kurulun onayı olmadan önemli miktarda varlığın toptan satışı yapılamayacaktır.

C. GENEL KURULUN DİĞER YETKİLERİ

Yukarıda sayılan devredilemez görev ve yetkileri yanında genel kurulun başkaca görev ve yetkileri de Kanunun çeşitli hükümlerinde yer almaktadır. Buna göre birleşme, bölünme, tür değiştirme, tasfiye memuru atanması, intifa senedi çıkarılması, her türlü borçlanma senetleri alma ve değiştirme hakkı içeren menkul kıymetler çıkarılması gibi yetkiler genel kurul tarafından kullanılır.

Bunun yanında şirket esas sözleşmesi ile de genel kurula bazı görev ve yetkiler verilebilir. Bu kapsamda örneğin esas sözleşmede öngörülmek kaydıyla şirket yönetim kurulu başkanı veya başkan vekilinin veya bunlardan birinin genel kurul tarafından seçilmesi öngörülebilir (TTK m.366/1).

D. GENEL KURULUN YETKİLERİNİN SINIRI

1. Üçüncü Kişilerin Hakları

Genel kurul kararları, kural olarak üçüncü kişilerin hakları üzerinde doğrudan etkili değildir. Meselâ şirket genel kurul kararıyla, üçüncü kişi ile şirket arasındaki bir sözleşmenin tek taraflı olarak değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi münfesih de sayılması da mümkün değildir. Buna karşılık bazı hallerde yönetim kurulunun genel kurulun onayını almadan üçüncü kişiler ile yaptığı sözleşmelerin şirketi bağlamayacağı hükme bağlanmıştır. Örneğin şirketin tescilinden itibaren iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü tasarruf geçersizdir (TTK m.356).

2. Diğer Organların Münhasır Yetkileri

Esas sözleşmeye hüküm koymakla genel kurulun yetkileri genişletilebilir. Bununla beraber, Kanunun münhasıran diğer organlara verdiği yetkiler, sözleşmeye hüküm konarak genel kurula devredilemez. Meselâ;

- Temsil yetkisi yönetim kurulunundur, genel kurul bunu üzerine alamaz.

- Genel kurulun yürütme yetkisi olmadığından, yürütme ile ilgili görevleri de üzerine alamaz.

- Yönetim kuruluna verilecek toplantı başına ücret (huzur hakkı) esas mukavele ile tayin edilmemişse genel kurulca tayin olunur.

- Genel kurul denetleme yetkileriyle donatılamaz. Ortaklığın denetimi denetçilerin görevidir.

3. Bireysel Haklar, Müktesep Haklar ve Azınlık Hakları

Genel kurul, yetkilerini Kanunun ve esas sözleşmenin öngördüğü çoğunlukla alacağı kararlarla kullanır. Ancak bu kararlar, kanunda öngörülen hallerde, azınlığın haklarını ve hatta pay sahiplerinin bireysel haklarını ihlal edemez. Genel kurul müktesep haklara muhalif karar alamaz.

Bireysel Haklar

Ortaklık sıfatından doğan;

- Genel kurul kararları aleyhine iptal davası açma,
- Yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açma,
- Genel kurula katılma,
- Genel kurulda oy kullanma,
- Bilgi alma,
- Kâr payı talebi,
- Tasfiye payına katılma hakları gibi haklar bireysel hakların başlıcalarıdır.

Bunların kullanılmaları azınlık veya çoğunluğun sağlanması şartına bağlanmamıştır. Bireysel haklara sahip olabilmek için bir tek paya sahip olmak yeterlidir.

Müktesep Haklar

Bireysel hakların bir kısmını, ortağın rızası olmaksızın elinden alınamayan müktesep haklar teşkil eder. Kanun müktesep hakları, evvelki Kanundan farklı olarak tanımlamamış ve bu hususta örnek de vermemiştir. Doktrinde de bir tanım verilmemiş, hatta bir tanım vermeye imkân olmadığı savunulmuştur. Bununla birlikte bir hakkın müktesep olup olmadığını tespitte hak sahibinin rızasıyla hakka müdahale edilip edilemeyeceğinin belirleyici olduğu kabul edilir.

Müktesep haklar, pay sahibinin rızası olmadan elinden alınamayan haklardır. Meselâ, ortaklığın merkezinin yurtdışına taşınması veya bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararların alınabilmesi için oybirliği aranmaktadır. Bu iki konu haricinde kalan hususlar üzerinde, niteliğine göre değişen ağırlaştırılmış toplantı ve karar nisaplarına uyulmak koşuluyla, çoğunluk tarafından tasarruf edilebilmektedir.

Görülüyor ki, müktesep haklar, çoğunluğun üzerinde hiç tasarruf edemeyeceği haklar değildir. İsviçre doktrininde ortağın rızası hilafına üzerinde tasarruf olunabilen bu grup haklar, öğretide nispi müktesep haklar olarak nitelendirilmektedir[232]. Müktesep haklardan yalnızca mutlak müktesep haklar anlaşılmamalıdır. Zira; müktesep haklara örnek gösterilen kâr payı almak, tasfiye sonucuna katılmak gibi haklar üzerinde genel kurulun tasarruf edebileceği kanunun çeşitli hükümlerinde öngörülmüştür. Meselâ, TTK m. 478'e göre, bazı paylara kâra ya da tasfiye bakiyesine katılmada imtiyaz hakkı tanınması da, bu hakların bir daraltılma şeklidir.

Demek ki, bazı müktesep hakların sınırlandırılması mümkündür. Ancak bunun sınırı objektif iyiniyet kurallarıdır. Böyle olunca, genel kurulun müktesep hakları ihlal eden kararları TTK m. 445 uyarınca iptali mümkün kararlardır[233].

Müktesep haklar, esas sözleşme ile de tanınabilir. Bu tür haklar açısından esas sözleşme değiştirilemezlik özelliği taşır. Bundan esas sözleşme değişikliğinin imkânsızlığı değil, değiştirilebilmesi için pay sahibinin rızasının şart olduğu anlaşılır.

Azınlık Hakları

Azınlık hakları, çoğunluğun azınlığa tahakküm etmesi tehlikesine karşı tanınmış haklardır. Azınlığın meşru menfaatlerini korumak ve çoğunluğun tahakkümüne engel olmak amacıyla sermayenin belirli oranına sahip ortaklara bazı haklar tanınmıştır.

---

232 **Von Bühren, R./Stoffel, W.A./Weber, R.H.**: Grundriss des Aktienrechtsi Mit Berücksichtigung der laufende Revision, 3.Aufl., 2011, N. 867 vd.

233 Genel kurul kararlarının hükümsüzlüğü hakkında bkz. aşağıda Sekizinci Bölüm, § 11, VI başlığı.

Türk hukukunda azınlık hakları, ortaklık sermayesinin onda birini temsil eden ortaklara tanınmış haklardır. Burada ortak sayısı değil, sermayenin 1/10'unu temsil eden ortak veya ortaklar azınlık haklarından yararlanabilir. Halka açık anonim ortaklıklarda bu oran 1/20 olarak belirlenmiştir.

TTK m.411 hükmüne göre genel kurulu toplantıya davet veya gündeme madde koydurma hakkı esas sözleşme ile daha düşük bir miktar paya sahip olan ortak veya ortaklara tanınabilir.

4. İmtiyazlı Paylar

TTK m.478 hükmüne göre esas sözleşme ile veya sözleşme değişikliği ile sonradan bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyazlar kâr payında, tasfiye bakiyesinde, rüçhan hakkında ve oyda imtiyaz şeklinde tanınabilir. İmtiyazlı pay olarak adlandırılan bu payların sahiplerinin onayı olmadan genel kurulda alınacak bir karar ile bu imtiyazlar hakkında değişiklik söz konusu olamayacağından genel kurulun yetkilerinin diğer bir sınırını da işte bu imtiyazlı paylar oluşturur.

II) GENEL KURUL TOPLANTI TÜRLERİ

A. OLAĞAN – OLAĞANÜSTÜ OLMASINA GÖRE

1. Olağan Genel Kurul Toplantısı (Adi Toplantı)

Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az bir defa yapılır. Toplantının bu süre içerisinde yapılmamasının bir yaptırımı bulunmamaktadır. Yılda birkaç kez kâr dağıtan anonim şirketlerde, her dağıtım için genel kurulu toplantıya çağırmak gerekir.

Olağan genel kurul toplantısı, öngörülen günde toplantı nisabı elde edilemediği için (TTK m.418) veya azınlığın talebi ile (TTK m.420) bir veya daha fazla kez ertelenmişse, ertelenen toplantılar da olağan genel kurul toplantısı sayılır.

2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Olağanüstü genel kurul toplantıları, belirsiz zamanlarda, *gereği halinde* kurulun toplantıya çağrılması ile yapılır. Bu türden toplantının yapılması azınlığın talebi üzerine gündeme gelebileceği gibi, sermayenin kaybı gibi hallerde Kanun gereği de gündeme gelebilir. Ne zaman

yapılacağı ve yapılıp yapılmayacağı önceden belirli olmayan bu toplantılara olağanüstü genel kurul toplantıları denilmektedir.

Genel kurul toplantısının olağanüstü olmasının usul ve şekil kuralları açısından olağan genel kurul toplantılarıyla bir farklılık yaratmadığını belirtmek gerekir.

B. ÇAĞRILI –ÇAĞRISIZ OLMASINA GÖRE

1. Çağrılı Genel Kurul Toplantısı

Genel kurul, pay sahiplerine toplantı daveti ve gündem gönderilmek ve ticaret sicili gazetesinde en az 15 gün önceden ilân edilmek suretiyle yapılacaksa, bu toplantıya çağrılı genel kurul toplantısı denir (TTK m.410 vd.).

2. Çağrısız Genel Kurul Toplantısı

Genel kurul toplantısı tüm pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması kaydıyla ve içlerinden herhangi birinin itiraz etmemesi halinde yapılacaksa buna da çağrısız genel kurul toplantısı denir. Bu toplantının gündemi pay sahiplerinin oybirliği ile alacakları karara bağlı olarak toplantı öncesinde belirlenebilir. Alınan kararların geçerli olabilmesi için toplantı sonuna kadar tüm pay sahiplerinin hazır bulunması gerekir (TTK m.416).

C. ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURUL

Genel kurul toplantısı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin fiziken bir araya gelmeleri suretiyle veya elektronik ortamda yapılabilir. TTK m.1527 hükmü ile getirilen bu son yönteme göre ortakların tamamı elektronik ortamda yapılan toplantıya katılabilecekleri gibi, sadece bir kısmının fiziken bir kısmının elektronik ortamda katılması ile de toplantının yapılması da mümkündür. Konuya ilişkin ayrıntılar Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir[234]. Buna göre anonim şirketler, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak kaydıyla isteğe bağlı olarak genel kurullarını elektronik ortamda yapabilirler veya genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaya izin verebilirler. Bunun için yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan esas sözleşme

---

[234] Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete.

hükmü örneğinin değiştirilmeden aynen sözleşmeye alınması gerekir. Ayrıca mezkur yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelmiştir (TTK m.1527/5).

Elektronik genel kurulun yapılabilmesi için gerekli hazırlıklar şirket yönetimi tarafından yerine getirilir.

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılması, toplantıya katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme hususlarında fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

Elektronik genel kurul sistemini kabul eden anonim şirketler toplantı davetini elektronik ortamda yapmanın yanında toplantı öncesi pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken belgeleri de elektronik sistemde erişime hazır bulundurmalıdır.

Anonim şirket ortaklarının veya temsilcilerinin elektronik genel kurul toplantısına katılabilmesi için güvenli elektronik imza ile sisteme girmeleri gerekir. Toplantı, toplantıya katılanların listesinin çıkarılmasıyla başlar. Toplantıya bakanlık temsilcisinin de katılması zorunludur[235].

D. TEK ORTAKLI ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL

Anonim şirketlerin tek ortakla kurulabilmesi veya sonradan tek ortaklı hale gelmesi mümkündür. Genel kurulu tek ortaktan oluşan anonim şirketlerde birden çok ortaklı anonim şirket genel kurul toplantılarından farklı olarak toplantıya çağrı merasimine gerek yoktur. Bununla birlikte payların tek bir sahibi olmasına rağmen payların tamamı bu kişi tarafından temsil edilmiyorsa (ör. payların bir kısmı üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse) çağrı merasimine de uymak gerekir. Bunun dışında tek ortaklı anonim şirket genel kurul toplantısında alınan kararların gerekli onayın ardından, -tescil ve ilanı gerekli hususların- tescil ve ilân ettirilmesi gerekir.

---

[235] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik m.32/1-b.

E. İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU

Anonim şirkette imtiyazlı paylar öngörülmüşse ve genel kurulda esas sözleşmenin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararlarıyla yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteyse, bu karar imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda ayrıca onaylanmadıkça uygulanamaz.

Özel kurul, anonim şirketin yönetim kurulunca genel kurul kararının ilanından itibaren bir ay içinde toplantıya çağrılır. Yönetim kurulunun anılan süre içerisinde çağrıda bulunmaması halinde her bir imtiyazlı pay sahibi bu süreyi takip eden on beş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden toplantıya çağrıyı talep edebilir (m.454/2).

Anonim şirket özel kurulunun toplantısı için imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının hazır bulunması ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alınması gerekir (m.454/3). Ancak genel kurul toplantısında imtiyazlı pay sahipleri söz konusu toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz. Bunun yanında çağrıya rağmen özel kurul süresi içinde toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.

İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısında, genel kurul kararının onaylanmaması halinde, karar gerekçeli olarak tutanağa bağlanır ve on gün içerisinde yönetim kuruluna teslim edilir. Özel kurulun onaylamama kararı aleyhine ise yönetim kurulu tarafından, karar tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu kararın iptali ve genel kurul kararının tescili davası açılabilir. Davada genel kurul kararının imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal etmediği ispat edilmelidir. İptal davasının davalıları ise, özel kurulda genel kurul kararının onaylanmasına olumsuz oy veren pay sahipleridir.

III) GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI

A. GENEL KURULU TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYA YETKİLİ KİŞİ VE ORGANLAR

Genel Kurulu toplantıya çağırmaya yetkili olanlar:

1- Yönetim Kurulu,

2- Azınlık ve bazı hallerde herhangi bir pay sahibi,

3- Tasfiye memurları'dır.

1. Yönetim Kurulu

Organ olarak genel kurul, toplantısını kural olarak yönetim kurulunun çağrısı üzerine yapar. Yönetim kurulu, gerektiği zaman genel kurulu olağanüstü toplantıya da çağırabilir.

İster olağan isterse olağanüstü olsun, yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmak için kurul halinde karar almak zorundadır (TTK m.410). 6102 sayılı TTK m.410/1 hükmü ile süresi dolmuş olsa bile yönetim kurulunun toplantıya çağrı hakkı bulunduğu kabul edilmiştir.

2. Pay Sahipleri

Azınlık da (ortaklık sermayesinin en az 1/10'una sahip olan ortak veya ortaklar, HAAO'larda 1/20), gerektirici sebepleri gösteren yazılı talepleri ile yönetim kurulundan genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını isteyebilirler.

Yönetim kurulu azınlığın bu talebini kabul ederse en geç 45 gün içerisinde toplanacak şekilde daveti yapar; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Azınlığın talebinin yönetim kurulu tarafından reddedilmesi veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde istem sahipleri mahkemeye başvurarak asliye ticaret mahkemesinden karar almak suretiyle toplantıyı yapabilir.

TTK m.410/2 hükmüne göre yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması hallerinde mahkemenin izniyle tek bir pay sahibi de genel kurulu toplantıya çağırabilir. Bu halde mahkemenin kararı kesindir.

3. Tasfiye Memurları

Tasfiye halindeki bir anonim şirkette, tasfiye işlerinin gereği olan hususlarda genel kurul tasfiye memurları tarafından toplantıya davet edilir (TTK m.410/1). Tasfiye işleri dışındaki konularda genel kurulu toplantıya çağırma yetkisi yine yönetim kurulundadır.

B. TOPLANTIYA ÇAĞRI MERASİMİ

Toplantıya çağrı, Kanun ve esas sözleşmede gösterilen şekil ve surette ve herhalde ticaret sicil gazetesinde ilân suretiyle yapılır.

Nama yazılı hisse senetleri sahiplerinin adresleri ortaklıkça bilindiğinden, toplantı onlara ayrıca iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Buna karşılık hamile yazılı pay senetleri sahipleri bilinmediğinden veya borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören hisse senetleri sahiplerini mektupla davete gerek yoktur. Ancak, bunlardan hisse senedi ile adresini bu amaçla ortaklığa bırakanlar varsa, kendilerine de toplantı daveti iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Söz konusu ilanın, ilân günü ve toplantı günü hariç olmak üzere en az 2 hafta önceden yapılması gerekir (TTK m.414/1). Kanun mektuplar için herhangi bir süre koymamış olmakla beraber, bunların da aynı süreye tâbi olması gerekir. İlan ve mektuplara toplantının gündemi eklenmek zorunda olduğu gibi ilân ve mektuplarda toplantı yer ve tarihi de belirtilmelidir.

Çağrı merasiminde, kanunda öngörülen hususlar kısmen ve eksik olarak yerine getirilmişse, yani toplantıya çağrı mevcut olmakla beraber, bu usulü dairesinde yapılmamış veya gündem gereği gibi ilân ve tebliğ edilmemiş ise toplantıda alınan kararlara karşı, toplantıya katılmayan pay sahiplerinin iptal davası açma hakkı vardır.

Toplantıya çağrı merasimine hiç uyulmamış, toplantı gün, gündem ve yeri hiç ilân edilmemiş, ilgili pay sahiplerine tebligat yapılmamış, gündemde bulunmayan hususlar hakkında karar alınmış ise alınan kararlar yoklukla maluldür.

Çağrıdan başka pay sahibinin gereken incelemeleri yapabilmesi için; kâr - zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor, kârın dağıtılması teklifi ve denetçi raporları toplantıdan en az 15 gün önce ortaklığın merkez veya şubelerinde incelemeye hazır tutulmalıdır. Bu hususların da, çağrıyla birlikte ilanı ve adresi bilinenlere tebliği gerekir.

C. GENEL KURULUN TOPLANMASI

1. Toplantı Yeri

Genel kurulun toplantı yeri, ortaklık merkezinin bulunduğu yerdir. Esas sözleşmede bunun aksi de kararlaştırılabilir. Toplantıya davette bu yer adresinin belirtilmesi gerekir.

2. Genel Kurula Katılmaya Yetkili Olanlar

Anonim şirketlerde her pay, sahibine en az bir oy hakkı verir. Bu nedenle tek bir payın sahibi dahi genel kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir. Paylar üzerinde intifa hakkı tesis edilmişse toplantıya katılma hakkı da intifa hakkı sahibine aittir.

Genel kurula katılacak ortak, nama yazılı pay sahibi ise, ismi pay defterinde yazılı olacağından, hüviyetini ispatla toplantıya katılır. Anonim şirkette SPK hükümleri uyarınca kayden izlenen paylar söz konusu ise yönetim kurulu pay sahipleri listesini merkezi kayıt kuruluşundan temin eder.

Hamiline yazılı pay senedi sahipleri ise, toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu giriş kartlarını ibraz ederek toplantıya katılabilirler (TTK m.415/3).

Hısımlık veya oylanan işe katılmış olma gibi sebeplerle oydan mahrum olmak, genel kurula katılmaya engel teşkil etmez.

Pay sahibi, genel kurul toplantısına bizzat katılabileceği gibi, toplantıya pay sahibi olan veya olmayan temsilci de gönderebilir. Ancak temsilcinin pay sahibi olmasını öngören esas sözleşme hükmü geçersizdir (TTK m.425). Temsil yetkisi, şartları genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin ilgili yönetmeliğin 18 ve 21. maddelerinde öngörülen usule göre verilir.

Üzerinde rehin hakkı bulunan veya tevdi edilmiş (emaneten verilmiş) veya herhangi bir nedenle ariyet verilmiş senetlerde (hamiline yazılı olanlar dâhil) genel kurula katılma ve oy hakkı pay sahibinindir.

Bir hisse senedinin birden fazla sahibi bulunursa (yani pay iştirak halinde veya müşterek mülkiyete konu teşkil ediyorsa), bu senet ortaklığa karşı bölünemeyeceğine göre, bunlar haklarını müşterek bir temsilci vasıtasıyla kullanabilirler, genel kurula da o katılır.

Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kişiler, karara katılmışlarsa ve bu şekilde genel kurul kararının alınmasında etkili olmuşlarsa, bunun müeyyidesi kararın iptal edilmesidir (TTK m.446/1-b).

3. Genel Kurul Toplantısına Katılması Zorunlu Olanlar

Anonim şirket genel kurul toplantısına varsa murahhas üyelerle yönetim kurulu üyelerinden en az birisinin ve denetime tâbi şirketlerde

denetçinin katılması zorunludur. Bunlar görüş açıklayabilirler. Katılma zorunluluğu hem olağan hem de olağanüstü toplantılar açısından geçerlidir. Çağrısız genel kurullarda da aynı kuralın geçerli olması gerekir.

Kuruluşunda Ticaret Bakanlığının izni gereken şirketlerin genel kurullarında bakanlık temsilcisinin de hazır bulunması gerekir.

4. Toplantı Nisabı

Anonim şirket genel kurul toplantısının yapılabilmesi bazı hallerde belirlenmiş yeter sayılara uygun davranılmasını gerektirir. Söz konusu toplantılar için aranan genel toplantı nisabı yanında özellikle esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul toplantıları ile şirketle ilgili bazı önemli kararların alınması amacıyla toplanan genel kurullarda ağırlaştırılmış nisaplar aranmaktadır. Bunun yanında yapısal değişiklikler ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda ve pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerin genel kurullarında farklı toplantı nisapları söz konusu olmaktadır.

a. Kural

Toplantı yeter sayıları, esas sermayeye göre tespit olunmuştur. Özel nisap aranmayan olağan işlerde toplantı nisabı, ilk toplantıda esas sermayenin %25'ine sahip ortakların hazır bulunmasıyla oluşur. İlk toplantıya %25'i temsil eden bir pay sahibi dahi gelse toplantı nisabı oluşmuştur. Anonim şirket genel kurulunda bulunması gereken toplantı nisabının toplantı sona erinceye dek muhafaza edilmesi zorunludur (TTK m.418/1).

Toplantıda anılan nisap bulunmazsa, genel kurul yeniden toplantıya çağrılır. Bu çağrı ilk çağrı usulünce yapılır. Uygulamada genellikle ikinci toplantının yer ve zamanı da ilk toplantı daveti ile pay sahiplerine duyurulmaktadır. İkinci toplantıda ise, temsil edilen sermayenin miktarı ne olursa olsun, toplantı nisabı var sayılır. Bu toplantıda herhangi bir yeter sayı aranmadığından, tek bir payın sahibinin katılımıyla dahi genel kurul teşkil edebilir.

b. Özel (Ağırlaştırılmış) Toplantı Nisapları

Kanun bazı işlerle ilgili genel kurul toplantı nisaplarını özel yeter sayılara bağlamıştır. Bunlar daha ziyade esas sözleşmede yer alan konular olup esas sözleşme değişikliğini gerektiren konulardır.

aa. Sermayenin Tümünü Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Hazır Bulunması Gereken Esas Sözleşme Değişiklikleri

Anonim şirket genel kurulunda bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirketin merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararların alınabilmesi için sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması gerekir. Konuyu düzenleyen TTK m.421/2 hükmünde toplantı nisabından açıkça söz edilmiş olmasa da karar nisabı oybirliği olarak tespit edilmiş olduğundan toplantı nisabının da asgari bu nisaba uygun olması gerekir.

İlk toplantıda bu nisaba ulaşılamazsa yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır (TTK m.421/4).

bb. Sermayenin Yüzde Yetmişbeş Çoğunluğunu Gerektiren Esas Sözleşme Değişiklikleri

Toplantı nisabının ayrıca düzenlenmediği ancak asgari karar nisabından ulaşılan bir diğer ağırlaştırılmış toplantı nisabı da sermayenin en az yüzde yetmişbeşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu aranan hallerdir. Söz konusu çoğunluk dört ayrı konuda esas sözleşme değişikliği için aranmaktadır. Bunlar;

-Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi,

-İmtiyazlı pay oluşturulması,

-Esas sermayenin azaltılması ve

-Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasıdır.

İlk toplantıda bu nisaba ulaşılamazsa yapılacak ikinci toplantıda da aynı nisap aranır (TTK m.421/4).

cc. Diğer Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yukarıda belirtilen sermayenin tümünü veya yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasını gerektirenler dışındaki esas sözleşme değişiklikleri için kanun koyucu daha düşük sermaye oranları ile yetinmiştir. TTK m.421/1 hükmüne göre Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. Dikkat edilirse Kanun koyucu genel mahiyetteki esas sözleşme değişiklikleri için yapılacak genel kurulun ilk toplantısında

şirket sermayesinin yarısını temsil eden pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunmasını yeterli görmüştür. İlk toplantı için bu çoğunluk sağlanamazsa en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda aranacak toplantı nisabı ise şirket sermayesinin üçte biridir. TTK m.421/1 hükmünde öngörülen bu nisapların indirilmesi veya nispi çoğunluğun öngörülmesi ise aynı fıkranın son cümlesinde yasaklanmıştır.

dd. Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Toplantı Nisapları

Anonim şirketlerin bir başka ticaret şirketiyle birleşmesi, başka bir ticaret şirketine dönüşmesi veya bölünmesi halinde anılan işlem için gerekli genel kurul kararı için aranacak toplantı nisapları ayrı ayrı düzenlenmiştir[236]. Buna göre bir anonim şirketin birleşmesine ilişkin genel kurulda esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması gerekir (TTK m.151/1-a). Bir anonim şirketin bölünmesinde de toplantı nisabı açısından aynı hükme atıf yapılmıştır (TTK m.173/2). Tür değiştirme açısından ise anonim şirketin hangi türe dönüşeceğine bağlı olarak birbirinden farklı toplantı nisapları aranacaktır. Anonim şirket bir başka sermaye şirketine dönüşecekse toplantıda esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisi; bir kooperatife dönüşecekse tüm ortakların hazır bulunması gerekir (TTK m.189/1-a, b).

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerde, birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin kararların alınacağı genel kurul toplantılarında TTK m.418 hükmündeki toplantı nisabı uygulanır (TTK m.421/5). Yani ilk toplantı için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı aranırken, toplantı nisabı sağlanamadığı için en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz.

ee. İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulunda Toplantı Nisapları

Anonim şirketlerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunda aranan toplantı nisabı imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışı olarak belirlenmiştir.

ff. Pay Senetleri Menkul Kıymet Borsalarında İşlem Gören Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantı Nisapları

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerin alelade genel kurul toplantılarında herhangi bir toplantı nisabı

---

[236] Yapısal değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. On beşinci Bölüm, § 23, 24, 25

aranmamıştır. Bununla birlikte sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine dair esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kararların alınacağı genel kurul toplantılarında TTK m. 418 hükmündeki toplantı nisabı uygulanmalıdır (TTK m. 421/5). Yani ilk toplantı için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığı aranırken, toplantı nisabı sağlanamadığı için en geç bir ay içinde yapılacak ikinci toplantıda nisap aranmaz.

D. GENEL KURULUN ÇALIŞMASI

Anonim şirketlerin genel kurullarının çalışma usul ve esasları ticaret bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenmiştir. Yönetmeliğin 40vd. maddelerinde bir iç yönergenin hazırlanması, asgari içeriği ve uygulanmasına dair kurallar yer almaktadır. Hazırlanacak iç yönergeye göre toplantının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün olacaktır.

Anonim şirket genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesinin imzalanmasını müteakip toplantı başkanının seçilmesiyle çalışmalarına başlar. Toplantı başkanının pay sahibi olması şart değildir. Başkan esas sözleşmeyle belirlenmiş olabilir. Belirlenmemişse genel kurulca seçilir. Bu seçimde genel kurula başkanlığı, toplantının yürümesi için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olan yönetim kurulu başkanı yapar.

Yönetim kurulu, kararlar, seçimler ve beyanların geçirilmesi için zabıt tutulmasını da sağlamakla yükümlüdür. Başkan, hazır bulunanların adı, soyadı, ikametgâhı ve pay miktarını gösteren bir listeyi imza ederek ilk oyların toplanmasından önce hazır olanların görebilecekleri bir yere asar.

1. Gündeme Bağlılık İlkesi

Genel kurulda ancak gündemde bulunan hususlar hakkında görüşme açılabilir ve karar verilebilir. Genel kurul gündeminde yer alması gereken hususlar yönetmeliğin[237] 13'üncü maddesinde sayılmıştır. Buna göre;

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3- Denetçi raporlarının okunması,

---

[237] Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete.

4- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrası,

6- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,

8- Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması,

9- Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti,

10- Denetçinin seçimi,

hususları olağan genel kurul gündeminde muhakkak bulunmalıdır.

Ancak bunlardan başka diğer hususlar da gündeme konabilir. Ayrıca çağrı üzerine yapılan genel kurul toplantısında gündem maddeleri görüşülmeye başlanmadan önce bütün pay sahiplerinin oybirliği ile alacakları karara istinaden yeni gündeme yeni maddeler eklenebilir.

Olağanüstü genel kurulunun ise belli bir gündemi yoktur. Toplantıda, toplanmayı gerektiren konular ele alınacağından, bu konular usulü uyarınca önceden gündem maddesi haline getirilir ve gündeme bağlılık ilkesi uygulanır.

Genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesi sırasını toplantıya katılan oyların çoğunluğu ile değiştirmek mümkündür.

Gündemde yer alan bir konuda karar alınmış ise toplantıda hazır bulunanların oybirliği ile karar almaları halinde aynı konu tekrar görüşülüp karara bağlanabilir.

2. Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları

Gündeme bağlılık ilkesinin zorunlu bazı istisnaları vardır. Bunlar;

1- Pay sahiplerinin tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir,

2- Kanunun 438'inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır,

3- Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili

sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir,

4- Gündemde madde bulunmasa bile, yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

5- TTK m.437/2 uyarınca bir pay sahibine yönetim kurulu tarafından genel kurul dışında belirli bir konuda bilgi verilmişse, diğer ortaklardan birinin talebi üzerine gündemde olmasa bile söz konusu bilgi, talep eden pay sahibine de verilmelidir. Bu taleple ilgili olarak şirket sırrı gerekçesine sığınılamaz.

3. Karar Nisapları

Her pay, sahibine kural olarak bir oy hakkı verir. Birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy hakkı esas sözleşmeyle sınırlandırılabilir. Bunun yanında bir paya en çok on beş oy hakkı verilebilir. Oy hakkına tanınan imtiyazların genel kurulda kullanılmasının yasaklandığı veya oydan yoksunluğun söz konusu olmadığı hallerde pay sahipleri oy haklarını sermayelerinin itibari değerleri ile orantılı olarak kullanabilirler.

Karar nisabı veya karar alabilmek için gerekli çoğunluk, özel düzenlemeye tâbi olmayan hallerde toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğudur (TTK m.418/2). Ağırlaştırılmış karar nisabının arandığı haller şunlardır:

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar ile şirketin merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar sermayenin tümünü oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin oybirliği ile alınabilir.

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, esas sermayenin azaltılması ve nama yazılı payların devrinin sınırlandırılmasına yönelik esas sözleşme değişikliği kararları sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu ile alınır.

4. Oy Hakkından Yoksunluk

Anonim şirketlerde pay sahipleri, bazı konulara ilişkin oylamalarda oy hakkından yoksun bırakılmışlardır. Buna göre pay sahibi kendisi,

eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile pay sahibi oldukları anonim şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamazlar. Düzenleme ile pay sahibi ve pay sahibinin anılan yakınları ile şirket arasında ortaya çıkabilecek menfaat çatışmalarında şirketin haklarının korunması amaçlanmıştır.

Oy hakkından yoksunluğun söz konusu olacağı diğer hal de şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişilerin, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmalarında karşımıza çıkar. Kanun koyucu böylece pay sahibi olan yönetim kurulu üyelerinin ibra oylamasında birbirleri lehinde oy kullanarak ibra müessesesini etkisiz kılmalarını önlemek istemiştir.

Oy hakkından yoksun olan kişi, pay sahibi sıfatı ile oy kullanamaz; bu kişi sahibi bulunduğu paylardaki oy hakkını bir temsilci aracılığı ile de kullanamaz. Ancak oy hakkından yoksun olan pay sahibinin, başka pay sahiplerinin temsilcisi sıfatı ile oy kullanıp kullanamayacağı hususu tartışmalıdır[238]. Bazı yazarlar[239] oy hakkından yoksunluğun, temsilen oy kullanılmasını kapsamadığı görüşündeyken[240] bazı yazarlar da yönetim kurulu üyelerinin aslen sahip oldukları paylardan doğan oy hakkından yoksunluğun, temsilen kullanılmak istenen oylar açısından da geçerli olması gerektiği görüşündedirler[241]. Yargıtay da 6762 sayılı TTK döneminde verdiği kararlarda oy hakkından yoksun olan kişilerin ibra oylamasında temsilen oy kullanabileceklerine hükmetmiştir[242]. Kanaatimizce oy hakkından yoksun olan yönetim kurulu üyeleri, 6102 sayılı TTK m. 436/2 hükmünde açıkça ve sadece "*...kendilerine ait*

---

238 Konuyla ilgili ayrıntılı bir değerlendirme için birçokları yerine bkz. **Kırca, İsmail;** Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesinin İbra Oylamasında Temsilci Sıfatıyla Oy Kullanıp Kullanamayacağı Sorunu, AÜHF Dergisi, C. 53, Sa. 1, 2004, s. 65vd.

239 **Kalpsüz, T.;** "*Bilanço ve Oy Kullanma Esaslarına Aykırılık Sebebiyle Genel Kurul Kararının İptali*", BATIDER, 1979, C. X, S.1, s. 41; **Teoman**, s. 171.

240 **Arslanlı** ise ibra oylaması hariç olmak üzere oydan yoksunluğun temsilen oy kullanılmasını kapsamadığı görüşündedir (A.Ş. II-III, s. 55).

241 **Arslanlı**, s. 555; **Aytaç**, Z.; Anonim Ortaklıklarda İbra, Ankara 1982, s. 121 dpn. 45'de anılan yazarlar.

242 **Kalpsüz**, s., 45, 46 ve 56'da verilen kararlar.

paylardan doğan oy haklarını kullanamaz" denildiğine göre oy hakkını sınırlandıran bu istisnai hükmün dar yorumlanması suretiyle yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerini temsilen kendisinin veya diğer yönetim kurulu üyelerinin ibralarına ilişkin oylamada oy hakkını kullanabilmelidir[243]. Doktrinde *Çamoğlu*, yönetim kurulu üyelerinin, ibra oylamasında bir üçüncü kişinin temsilcisi olarak oy kullanmalarının hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığı görüşündedir[244]. Bu yöndeki Yargıtay kararına[245] da şiddetle karşı çıkmaktadır[246]. Ancak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan *Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik*[247] m. 19/4 hükmünde yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyesi olmayan diğer pay sahiplerinin oy haklarını temsilen kullanabilecekleri kabul edilmiştir.

İsviçre Hukukunda konuyla ilgili olarak baskın görüş, oy hakkından yoksun olan kişinin başkasını temsilen de oy hakkını kullanamayacağı yönündedir[248]. Aynı husus, oy hakkından yoksun olan kişinin, oy hakkını başkasına temsil yetkisi vererek kullandırması açısından da söz konusudur[249].

Alman hukukunda konu § 136 Abs. 1, AktG hükmünde Türk ve İsviçre Hukukundaki düzenlemelerin aksine çok net olarak düzenlenmiştir. Buna göre "*hiç kimse şirkete karşı yükümlülüklerinden kurtulacağı, ibra olunacağı veya kendisine karşı şirketin bir haktan vazgeçeceği bir*

---

243 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Çağlar**, İbra, s. 40.

244 **Çamoğlu(Poroy/Tekinalp)** Ortaklıklar I, N. 614a.

245 Yargıtay 11. HD. 27.01.2006 tarih, 2006/134 E., 2006/615 K. sayılı karar, **Eriş, G.**; Açıklamalı İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu, 3. Cilt, 2. Baskı, Ankara 2010, s. 2613, N. 17.

246 **Çamoğlu(Poroy/Tekinalp)** Ortaklıklar I, N. 614a.

247 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

248 **Forstmoser, P.:** Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1987, N. 425; **Gautschi**, G., Das Depotstimmrecht der Banken, in Probleme der Aktienrechtsrevision, Berner Tage für die juristische Praxis, Bern 1972, s. 139; aksi görüşte **Tillmann**, E., Das Depotstimmrecht der Banken, Zürich 1985, s. 106.

249 **Bürgi, W.F.:** Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, 5. Teil, Die Aktiengesellschaft, b/2: Art. 698-738 OR, Schulthess&CO AG, Zürich 1969, Art. 698, N. 94; **Forstmoser**, Verantwortlichkeit, N. 422 ve orada anılan eserler.

kararın alınacağı oylamada kendisi için veya bir başkası için oy hakkını kullanamaz." Böylece yönetim kurulu üyesinin ibra oylamasında başka bir pay sahibini temsilen oy kullanması tamamen yasaklanmıştır[250].

Oy hakkından yoksunluğu dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir (TTK m.433/1). Bu halde pay sahibinin inançlı bir işlemle geçici olarak paylarını üçüncü bir kişiye devretmesi ve bu kişi aracılığıyla paylarından doğan oy haklarını kullanması mümkün değildir. Buna rağmen genel kurula yetkisiz katılma söz konusu ise her pay sahibi, toplantı başkanlığına itirazda bulunabilir, itirazını ve yönetim kuruluna da itirazda bulunmuş olduğunu tutanağa geçirtebilir (TTK m.433/2).

Oy hakkından yoksunluğa ilişkin hükümlere uymamanın müeyyidesi iptal davasıdır.

5. Oy Anlaşmaları

Genel kurul toplantısında oy kullanacak pay sahipleri, oylarını şu veya bu yönde kullanmak üzere anlaşabilirler.

Bu anlaşmalar pay sahipleri arasında olabileceği gibi pay sahipleriyle anonim şirket veya organları veya anonim şirketin denetimi altında bir kuruluşla yapılabilir.

Ancak anlaşmaların gayesi kanun veya esas sözleşmenin emredici hükümlerini dolanmak veya etkisiz kılmak olursa ya da anlaşmanın konusu ahlak ve adaba aykırı bulunursa, hukuken geçerli sayılmaz.

6. Çeşitli Yönde Oy Kullanma

Toplantıda hazır bulunan pay sahipleri, birden çok oy kullanma durumunda iseler, belirli bir teklif hakkında oyların bir kısmını olumlu, bir kısmını ise olumsuz olarak kullanabilir mi? Konu tartışılabilir.

Bir görüş olarak birden fazla paya sahip ortağın oylarının şahsileştiği, bu sebeple pay sahibinin bütün oylarının aynı yönde kullanılması gerektiği, aksi halde bir icaba hem evet hem hayır demek gibi bir duruma düşüleceği ileri sürülebilir. Buna karşılık oy hakkının, Türk hukukunda pay sahibine değil, paya bağlanmış olduğu ve pay sahibinin

---

250 **Hüffer/Koch**, § 136 AktG, N. 19.

değişik yönde oy kullanmada haklı bir menfaati bulunabileceği de savunulabilir. Meselâ, beş oya sahip bir ortak, bunların sadece üçünü belli bir yönde kullanacağına dair anlaşma yapmış bulunabilir.

Bazı paylar üzerinde intifa hakkına sahip olan ortak, bu paylara ilişkin oy hakkını payın sahibinin menfaatini koruyacak şekilde kullanmak zorunda olabilir; buna karşılık kendi paylarına bağlı oy hakkını dilediği yönde kullanabilir.

7. Genel Kurulda Temsil

Pay sahibi genel kurul toplantısına şahsen katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak tayin edebilir. Bu noktada iki tür bireysel temsilci üzerinde durmakta fayda vardır; olağan temsilci ve tevdi eden temsilcisi. Toplu temsille ilgili hükümler yakın tarihte kanundan çıkarılmıştır[251].

a) Olağan Temsilci

Olağan temsilci, anonim şirket pay sahibinin TBK hükümlerine göre atadığı gerçek kişidir (TTK m.426). Temsilci yazılı temsil belgesi ile genel kurul toplantılarına katılabilir. Temsil belgesinin noter onaylı olması gerekmez. Temsilci olarak birden fazla kişi atanmışsa, bunlardan hangisinin oy hakkını kullanmaya yetkili olduğunun temsil belgesinde gösterilmesi gerekir. Bunun yanında ortağın kanuni temsilcisi varsa bunlar da ortağı temsilen genel kurul toplantılarına katılabilir. Aynı şekilde tüzel kişinin temsilcilerinin de tüzel kişi adına toplantıya katılmaları mümkündür.

Temsilcinin hangi tarihte yapılacak toplantıda pay sahibini temsil edeceğinin temsil belgesinde gösterilmesi zorunludur. Temsil belgesi geçerli olduğu toplantının devamı niteliğindeki toplantılarda da geçerlidir. Genel bir temsil belgesi ile herhangi bir genel kurul toplantısına katılmak mümkün değildir. Ayrıca temsil olunan temsilcinin yetkisini genel kurul gündem maddelerinin bir kısmı ile sınırlandırabilir.

Temsilci her ne kadar temsil olunanın talimatlarına uygun hareket etmek zorunda ise de aksine bir davranışı da ortağı bağlar. Bu halde temsilci aleyhine sorumluluk davası açılabilir.

---

[251] 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı Kanun m. 23 ile değişiklik yapılmıştır. Bu Kanun, 30356 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

b) Tevdi eden temsilcisi

Anonim şirketlerde pay veya pay senetlerinin herhangi bir kişi ya da kuruma tevdi edilmesi halinde, bu pay veya pay senetlerinden doğan genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı gibi hakların tevdi eden adına kullanılması mümkündür. Tevdi eden, pay veya pay senetlerini rehin, saklama, kullanım ödüncü gibi bir sözleşme uyarınca tevdi ettiği veya inançlı bir işlemle kendisine devrettiği pay senetlerinden doğan haklarını bir temsilci vasıtasıyla kullanmak istiyorsa bu kişiyle bir anlaşma yapabilir. Anlaşmanın yazılı olması gerekir.

Tevdi eden temsilcisi genel kurulda nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için genel kurul toplantısından önce tevdi edene başvurmalıdır.

Tevdi olunan kişilerin bağlı olacakları usul ve esaslar ve temsil belgesinin içeriği Ticaret bakanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle düzenlenmiştir[252].

c) Bakanlık Temsilcisi

Anonim şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisinin hangi hallerde katılması gerektiği hususu ticaret bakanlığı tarafından çıkarılan anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak ticaret bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin 32. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

-kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Ticaret Bakanlığı'nın iznine tâbi anonim şirketler,

-gündemlerinde sermaye artırımı, azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ya da bu sistemden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının artırılması, faaliyet konusunun değiştirilmesi ya da gündeminde birleşme, bölünme, tür değiştirme konuları bulunan genel kurul toplantılarında,

-elektronik katılım sistemi uygulanan genel kurul toplantılarında,

-yurtdışında yapılacak genel kurul ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantılarında bakanlık temsilcisi hazır bulunmalıdır.

---

252 Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 44 vd. maddeleri (28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete.).

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu genel kurul toplantılarında bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçersizdir.

8. Tutanak

Buraya kadar anlattığımız esaslar uyarınca alınan kararın geçerli olabilmesi için bazı usulü işlemlerin yerine getirilmiş olması da gerekir. Öncelikle toplantının başından itibaren yapılan işlemlerin, alınan kararların ve tespit edilen hususların toplantı başkanı tarafından tutanağa bağlanması ve imzalanması şarttır. Toplantıya bakanlık temsilcisi katılmışsa tutanağı onun da imzalaması gerekir. Tutanağın toplantı yerinde ve toplantı sırasında düzenlenmesi, varsa muhalefet şerhi koyanların muhalefetlerinin de tutanağa yazılması ve onların da tutanakta imzalarının bulunması şarttır.

Yönetim kurulu, toplantı sonrasında tutanağı, notere onaylattıktan sonra bir örneğini tescil ve ilân edilmesi için ticaret sicili müdürlüğüne verir. Anonim şirket genel kurulunda alınan kararların şirket dışında etki doğurabilmesi için tescil ve ilân edilmesi gerekir.

IV. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMLERİ

Genel kurul kararları, toplantıda bulunmayan veya bulunup da olumsuz oy kullanan ortaklar açısından da bağlayıcıdır (TTK m.423). Genel kurulda alınan kararları icra organı olarak yönetim kurulu yerine getirir. Genel kurulda alınan kararların bir kısmının tescil ve ilanı zorunludur. Söz konusu kararların derhal ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. Yönetim kurulu, genel kurul kararlarını yerine getirirken özen ve sadakat yükümlülüğüne uygun davranmalı, genel kurulun talimatlarına uymalıdır. Bununla birlikte genel kurulda alınan kararlar diğer organların devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerine tecavüz etmemelidir. Alınan kararların Kanuna veya esas sözleşmeye aykırı olması halinde ya da dürüstlük kuralına aykırı olması halinde yönetim kurulu, kararın iptali için mahkemeye başvurabilir.

Anonim şirketin genel kurulunda alınan bazı kararların geçerli olabilmesi ek koşullara bağlanmış olabilir. Örneğin imtiyazlı payların bulunması halinde, esas sözleşmenin değiştirilmesi kararı bunların haklarını ihlal edecek nitelikte ise, kararın geçerli olabilmesi için, söz konusu ortakların özel olarak toplanmaları ve genel kurul kararını onaylamaları gereklidir.

V. GENEL KURUL KARARLARININ GEÇERSİZLİĞİ

Genel kurul kararları toplantıda bulunanlar yanında toplantıda bulunmayan veya bulunup da olumsuz oy veren pay sahiplerini de bağladığından, alınan kararlar kanuna, esas sözleşmeye veya dürüstlük kuralına aykırı oldukları takdirde, ilgililerin (pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri veya diğer menfaat sahiplerinin) korunmalarını sağlayacak hukuk yollarının da bulunması gerekir.

Türk Ticaret Kanunu'nda genel kurul kararlarının iptali ve butlanı düzenlenmiş; yokluğuna ilişkin hususlar ise genel hükümlere bırakılmıştır. İstisnai olarak alınan kararın askıda hükümsüz sayılması da söz konusu olabilir.

A) YOKLUK

Bir genel kurul kararından söz edilebilmesi için iki unsur gerekir.

1- Genel kurul niteliğinde bir kurul,

2- Bu kurulu oluşturan pay sahiplerinin bir kararı

- Toplananlar pay sahipleri değilse,
- Pay sahipleri TTK'nin emrettiği şekil ve usulde toplanmamışlarsa, bir genel kurul kararından bahsedilemez.

Örnek:

- Yetkililerce bir davet yapılmamış,
- Bazı pay sahipleri kendiliğinden toplanmış,
- Ticaret Bakanlığı temsilcisi toplantıda hazır bulunması gerekirken toplantıya katılmamış veya tutanağı imzalamamış,
- Çeşitli kararlar için toplantı ve karar nisaplarına uyulmamış ise alınan kararlar yoklukla maluldür.

Genel bir ölçü vermek istersek, şekil ve usul açısından emredici hükümlere aykırılık YOKLUK halini doğurur[253].

B) BUTLAN

6102 sayılı TTK genel kurul kararlarının butlanı konusunda açık bir düzenleme içermektedir. Konuyu düzenleyen m.447 hükmüne göre genel kurulun almış olduğu bazı kararların batıl olduğu kabul edilmiştir. Kanun koyucu batıl kararları sayarken "özellikle" sözcüğünü kullanarak burada sayılanlar dışında da batıl kararlara kapı aralamıştır.

---

[253] **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 722a.

Kanunda açıkça ifade edilen batıl kararlar üç tanedir. Bunlardan ilki pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlardır. İkincisi pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran kararlardır. Üçüncü ve son sırada ise anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararların batıl olduğu ifade edilmiştir.

Batıl bir genel kurul kararının geçersizliğini pay sahipleri yanında diğer menfaat sahipleri de ileri sürebilir. Ayrıca kararın batıl olduğunu ileri sürme hakkı bir süreyle de sınırlandırılmamıştır. Batıl bir genel kurul kararı baştan itibaren geçersizdir. Bu yönüyle "yoklukla malul bir genel kurul kararı" ile aynı akıbeti paylaşır. Dikkat edilirse batıl bir karar da "yokluk" halinde olduğu gibi kanunun emredici mahiyetteki kurallarına aykırıdır. Ancak "yokluk" halinde olduğu gibi şekil ve usul açısından emredici kurallara aykırılık değil; esas açısından emredici hükümlere aykırılık söz konusudur.

C) İPTAL EDİLEBİLİRLİK

Anonim şirket genel kurul kararının iptali, mahkeme tarafından kararın geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasını ifade eder. Genel kurul kararları yanında imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararlarının iptali de bazı hallerde söz konusu olabilir.

Kesin hükümsüzlük yani yokluk ve butlan halleri dışında kalan geçersizliklerde genel kurul kararının iptal edilmesi istenebilir[254].

Hukuki işlem güvenliği bakımından yokluk ve butlan hallerinin olabildiğince sınırlı tutulması ve tereddüt yaratan hallerde iptal edilebilirliğin kabul edilmesi gerekir[255]. Diğer bir ifadeyle yokluk ve butlan derecesinde olmayan sakatlıklar içeren genel kurul kararları iptal edilebilirler. İptal edilebilir kararlar ile yokluk veya butlan yaptırımına tâbi kararlar arasında önemli farklar bulunmaktadır.

Yoklukta hukuki işlem görünüşte bile yoktur.

Batıl işlemlerde ise görünüşte bir karar alınmakta ancak buna hukuk düzeni sonuç bağlamamaktadır.

---

[254] **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 723.
[255] **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 723.

İptal kabiliyeti olan karar ise daha farklıdır. Karar baştan itibaren hüküm ve sonuç doğurmaya başlar ve üç aylık hak düşürücü süre içerisinde iptali istenmezse artık daha sonra iptali de istenemez. Kararın iptaline ilişkin hüküm ise kararı en baştan itibaren geçersiz kılar.

1. İptal Sebepleri

Anonim şirket genel kurul kararlarının iptal sebepleri TTK m.445 hükmünde üç ayrı gruba ayrılmıştır. Bunlar, genel kurul kararının kanuna, esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olmasıdır.

a) Kanuna Aykırılık

Yokluk ve butlan sonucunu doğuracak ağırlıkta olmayan kanuna aykırılık hallerinde, genel kurul kararı aleyhine iptal davası açılması mümkündür.

Kanuna aykırılık, sadece anonim şirketleri düzenleyen hükümlere veya TTK hükümlerine değil, yürürlükteki bütün kanunların hükümlerine aykırılık olarak anlaşılmalıdır.

Söz konusu kanunun usule veya esasa ilişkin olması da fark etmez. Ancak TTK m.446/1-b hükmünde yer alan "*etki kuralı*" vurgusu sebebiyle orada sayılan aykırılıkların kararın alınmasına etkisinin olduğunun ispatı gerekir.

b) Esas Sözleşmeye Aykırılık

Esas sözleşmeye aykırılık, esas sözleşmede yer alan ve emredici hükümler ilkesine aykırı olmayan hükümlere aykırılık olarak kabul edilmelidir. Zira TTK m.340 hükmüne rağmen bir şekilde şirket esas sözleşmesine yazılmış bir kural zaten geçersiz olacağından, genel kurul kararının geçersiz bir sözleşme hükmüne aykırılığının ileri sürülmesi de mümkün olamayacaktır.

c) Dürüstlük Kurallarına Aykırılık

Dürüstlük kuralı TMK m.2 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

Bir genel kurul kararı, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olsa dahi, dürüstlük kurallarına aykırı düştüğü takdirde iptal edilebilecektir.

Çoğunluğun, ortaklık menfaati gerektirmediği halde, yetkilerini kötüye kullanarak aldığı, azlığın veya münferit ortakların meşru menfaatlerini zedeleyen kararlar, dürüstlük kurallarına aykırı sayılmaktadır. Bu çerçevede ihtiyaç olduğu belgelendirilemediği halde birden çok kez ve kısa bir zaman aralığında esas sermaye artırma kararı alınması ve böylece azınlığın ya da küçük pay sahiplerinin şirket içindeki haklarının onlara rağmen kısıtlanması veya ellerinden alınması, dürüstlük kuralına aykırı kabul edilebilir[256].

2. İptal Davasında Taraflar

a. Davacı

İptal davası, belirli şartlar altında pay sahipleri, yönetim kurulu veya yönetim kurulu üyelerinin her biri tarafından açılabilir.

aa) Pay Sahipleri

Pay sahipleri, iptal davası açabilmeleri bakımından genel kurul toplantısında hazır bulunup bulunmadıklarına göre değişik hükümlere tâbi olurlar.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin iptal davası açabilmeleri için karara olumsuz oy vermiş olmaları ve bu muhalefetlerini toplantı tutanağına geçirtmiş olmaları gerekir.

Bunun yanında pay sahipleri toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun yada olmasın, çağrının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilân edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri genel kurul kararının iptalini talep edebilirler (TTK m.446/2).

Oy hakkından yoksun bulunan pay sahiplerinin de muhalefetlerini tutanağa geçirtmek şartıyla iptal davası açabilecekleri kabul edilmelidir.

---

[256] Yargıtay 11. HD. 11.12.1995 tarih 8154/9165 sayılı kararı (**Moroğlu**, Hükümsüzlük, s. 239, dpn. 417).

bb) Yönetim Kurulu

Yönetim kurulu da genel kurul kararlarının iptali talebiyle kurul olarak dava açabilir. Dava açma kararını, yönetim kurulu çoğunlukla alır.

Yönetim kurulunun, kurul olarak dava açma hakkı, pay sahiplerinin dava hakkından bağımsız olarak üyelerinin bazılarının veya hepsinin toplantıda hazır bulunmuş olmalarına, karar aleyhinde oy kullanmalarına veya muhalefetlerini tutağa şerh ettirmelerine bağlı değildir.

Bu dava, ortaklığın çıkarlarının korunması için yürütme organına verilmiş bir görevdir ve yerine getirilmemesi sorumluluk doğurur. Bu sebeple, aynı zamanda pay sahibi sıfatını da haiz olan üyeler, genel kurulda alınan karara olumlu oy vermiş olsalar da, kararın şirket menfaatlerine aykırı olması halinde daha sonradan karar aleyhine iptal davası açma kararının alınması mümkündür[257].

cc. Yönetim Kurulu Üyeleri

Anonim şirket genel kurul kararlarının yerine getirilmesi, kişisel sorumluluklarına yol açacaksa, kararlar aleyhine yönetim kurulu üyelerinin her biri de iptal davası açabilir.

Burada amaç ortaklığın çıkarını koruma görevinin yerine getirilmesi değil, kendi sorumluluklarını bertaraf etmek olduğundan, dava masrafları anonim şirkete yüklenemez.

b. Davalı

Davalı anonim şirket tüzel kişiliğidir. Pay sahiplerinin veya yönetim kurulu üyelerinin açmış oldukları davalarda şirketi yönetim kurulu temsil eder. Dava yönetim kurulu tarafından açılmışsa bu halde şirkete TMK m. 426 uyarınca kayyum atanması gerekir. Şirketin tasfiyesi aşamasında açılan iptal davalarında, dava yönetim kurulunca açılmışsa, şirketi tasfiye memurları-iflas idaresi, buna karşılık dava tasfiye memurları tarafından açılmışsa, şirket yönetim kurulu tarafından temsil edilir[258].

---

257 **Moroğlu**, Hükümsüzlük, s. 298.

258 **Moroğlu**, Hükümsüzlük, s. 297; şirketin tasfiyesi halinde iptal davalarının yönetim kurulu tarafından açılacağı yönünde bkz. **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 741f.

3. Dava Açma Süresi

İptal davası üç aylık hak düşürücü bir süreye bağlanmıştır. Emredici hüküm mahiyetinde olduğundan, esas sözleşmeye süreyi değiştiren hüküm konamaz.

Bu süre hâkim tarafından resen nazara alınır. Sürenin başlangıcı kararın alındığı tarihtir (TTK m.445). Buna karşılık sürenin toplantıya katılmayan pay sahipleri açısından karar tarihinden değil, kararın tescil ve ilân edildiği tarihten itibaren başlatılmasının daha adil olacağı haklı olarak ifade edilmiştir[259].

4. İptal Davasında Usul

İptal davası anonim şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde açılır. Dava kim tarafından açılmış olursa olsun, dava şirkete bildirildikten sonra iptal davasının açıldığı ve duruşma günü, yönetim kurulu tarafından usulüne uygun olarak ilân edilir. Birden fazla iptal davası açılmışsa, bunlar birleştirilir. Bu sebeple, iptal davasına ilişkin duruşmaya, üç aylık hak düşürücü sürenin geçmesinden önce başlanamaz. İptal davalarında basit yargılama usulü uygulanır (TTK m.1521).

Mahkeme, şirketin talebi üzerine, davacının ortaklığın muhtemel zararlarına karşı teminat göstermesine karar verebilir. Teminatın niteliği ve miktarı mahkemece takdir olunur. Teminat, pay sahibinin iptal davası açma hakkını kullanmasını engelleyecek tutarda olamaz.

Bir genel kurul kararı aleyhine iptal davası açılmış olması kararın geçerliliğini etkilemez. Buna karşın mahkemece, yönetim kurulu üyelerinin de görüşü alınarak dava konusu kararın yürütülmesinin geri bırakılmasına karar verilebilir (TTK m.449). Bu halde genel kurul kararının derhal uygulanmasının telafisi imkânsız zararlara yol açabileceğinin davacılarca ispat edilmiş olması gerekir.

İptal edebilir kararlar, hakkında henüz iptal kararı verilmeden genel kurul tarafından yeni bir kararla düzeltilebilir.

5. İptal Kararının Hukuki Etkileri

Genel kurul kararının iptaline dair mahkeme kararı kesinleşince, bütün pay sahipleri hakkında ve geçmişe etkili olarak hüküm ifade eder

---

[259] **Çamoğlu (Poroy/Tekinalp)**, I, N. 743.

(TTK m.450). Zira bu karar bozucu yenilik doğuran bir karardır. Ancak iptal kararı verilmeden önce, iyiniyetli üçüncü kişilerin genel kurul kararına dayanarak kazandıkları haklar kural olarak saklı kalır ve üçüncü kişilerle yapılan işlemler geçerlidir.

Yönetim kurulu iptal kararının bir örneğini derhal ticaret siciline bildirerek tescili sağlamalı ve varsa şirketin internet sitesine koymalıdır.

D) ASKIDA HÜKÜMSÜZLÜK

Anonim şirket genel kurul kararları, toplantının yapılması ve karar alınması sürecinde bir eksiklik veya hukuka aykırılık sebebiyle geçersiz olmadıkları halde çeşitli sebeplerle hemen hüküm ve sonuç doğurmaya başlayamayabilirler. Bu sebepler kanundan kaynaklanabileceği gibi şirket esas sözleşmesinden de kaynaklanabilir[260]. Başlıca askıda hükümsüzlük halleri genel kurul kararlarının bir kısım pay sahiplerinin muvafakatine bağlı olması, birden çok pay kategorisinin mevcudiyeti halinde bu pay kategorilerinin alacağı kararlara bağlı olması ve alınan kararların ticaret siciline tescili olarak ifade edilebilir.

Türk hukukunda genel kurul kararlarının askıda hükümsüzlüğü konusuna hem Türk Ticaret Kanunu'nda hem de diğer bazı kanunlarda rastlanmaktadır. Konumuzla ilgili olarak anonim şirketin esas sözleşmesinin değiştirilmesi hususunu düzenleyen TTK m.454 hükmünde esas sözleşmede yapılacak değişikliğin imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edebilecek nitelikte olması halinde, genel kurulun esas sözleşme değişikliğine ilişkin kararının imtiyazlı pay sahipleri tarafından yapılacak özel bir toplantı ile onanması gerektiği ifade edilmiştir.

Şirket sermayesinde yapılacak değişiklikler aynı zamanda esas sözleşme değişikliği gerektirdiğinden, özellikle TTK m.452 hükmüne uygun şekilde, çeşitli imtiyazları haiz hisse senetlerinin bulunması halinde, değişikliğin her bir tür hisse senedi sahipleri kurulunca özel bir toplantıda karara bağlanması gerekir.

Türk hukukunda geçerli olan ve inceleme konumuzla ilgili bir başka askıda hükümsüzlük hali de TTK m.455 hükmünde düzenlenen, genel kurul kararlarının ticaret siciline tescil öncesindeki durumuna ilişkindir. Esas sözleşme değişikliğinin hüküm ve sonuç doğurabilmesi bu kararın yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tesciline bağlıdır. Bu süre içerisinde söz konusu genel kurul kararı aleyhine iptal davası açılması,

---

260 **Moroğlu**, Hükümsüzlük, s. 40.

yönetim kurulunun sözleşme değişikliğine bağlı olarak yapması gereken işlemleri yapması mümkün veya zorunlu olmakla birlikte, kararın üçüncü kişilere karşı etkisi ancak tescil ile doğar[261].

Askıda hükümsüzlük hali TTK dışında bazı özel kanunlarda düzenlenen veya TTK dışında kalan kanun hükümlerine tâbi tutulan anonim şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri ve dolayısıyla sermaye azaltma amacına matuf esas sözleşme değişikliklerine yönelik olarak yapılan genel kurullarda alınan kararlarla ilgili olarak da gündeme gelebilmektedir.

VI. GENEL KURULUN SORUMSUZLUĞU

Genel kurul, bir karar organı olması, yürütme yetkisi bulunmaması nedeni ile bir kurul olarak sorumlu değildir.

Sorumluluk, genel kurul kararlarını uygulayan yönetim kuruluna ve üyelerine aittir.

Bunlar sorumluluktan kurtulmak isterlerse, kararın iptalini usulü dairesinde talep etmelidirler (TTK. m.445 vd.).

Genel kurulun yürütme yetkisi olmadığından, yürütme ile ilgili görevleri de üzerine alamaz. Bu sebepten kural olarak haksız fiil de işleyemez, bu nedenle de sorumlu olmaz.

---

[261] **Moroğlu**, Hükümsüzlük, s. 37.

DOKUZUNCU BÖLÜM

§ 12- ANONİM ŞİRKETLERDE DENETİM

LİTERATÜR

Arı, Z.: Anonim Şirketlerde Denetçi Sorumluluğunun Sınırlanması, Ankara 2012; Arkan, S.: *Halka Açık Anonim Ortaklıkların Özellikleri ve Dış Denetimleri,* Ankara 1976; Çelik, A.: *"Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketin Denetimi",* Prof. Dr. Tuğrul Ansay'a Armağan, Ankara 2006, s. 545-594; Günay, G. E.: *Anonim Ortaklıklar Hukukunda Özel Denetim,* İstanbul 2018; Gürbüz Usluel, A. E.: *"Yeni Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Anonim Ortaklıklarda Kamu Denetiminin Değerlendirilmesi,* Batider, C. XXVIII, S. 1, s. 157-190; Köksal, A.: "Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 397 ila 406. Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu", Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C. I, Ankara 2010, s. 1387 vd.; Köksal, A: *Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Bankacılık Mevzuatı Açısından ve Karşılaştırmalı Olarak Bağımsız Denetim Sözleşmesi,* İstanbul 2009; Memiş, T.: *"Şirketler Hukukunda Denetim",* EÜHFD, C. XVI, S. 3–4 (2012), s. 152 vd.; Özdamar, M.: *"Anonim Şirketlerde Özel Denetim", Anonim Şirketlerde Azınlık Hakları,* İstanbul 2014, s. 45 vd.; Özkorkut, K.: *"Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Denetiminde Yeni Dönem: Bağımsız Denetleme Kuruluşları, Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler",* Batider, C. XXIII, s. 29-69; Özkorkut, K.: *6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim,* Ankara 2013; Uçar Bulut, G. C.: *Anonim Şirketlerde Özel Denetim,* Ankara 2018; Tekinalp, Ü.: *"Türk Ticaret Kanununu Tasarısının Merkez Kurumu, Bağımsız Denetim, Denetçi, Denetimin Konusu ve Yöntemi Yönünden Analizi"* Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu – X, Kıbrıs 2007, s. 24-30; Urkan, E.: *Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk,* Ankara 2016.

GİRİŞ

Denetim başlığı altında, 6102 sayılı TTK'de denetime ilişkine getirilen sistem üzerinden anonim şirketin hem içeriden hem de dışarıdan denetlenmesi meselesi üzerinde durulacaktır.

I. KAVRAM OLARAK DENETİM

Denetim, inceleme konusu iş ve işlemlerin önceden belirlenmiş mevzuata uygun şekilde yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesine ilişkin faaliyetlerin tamamı şeklinde tarif edilebilir. Böylece denetlenen icra makamı, gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin kurallara uygun şekilde yapılması konusunda ilave bir özen gösterir. Aksi halde yapılan denetim sonucunda ortaya çıkan eksiklik ve aykırılıklar, işlemleri gerçekleştiren icra makamının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektirir.

Şirketler hukukunda denetimin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Gerçekten anonim şirket pay sahiplerinin her zaman yönetimde etkin olamamaları sebebiyle şirketin işleyişi ile ilgili bilgileri denetim sayesinde elde etmeleri mümkündür. Pay sahiplerinin yanı sıra anonim şirket üzerindeki diğer menfaat gruplarından olan şirketin alacaklıları, çalışanları ve vergi tahsil etme ihtimali olan devlet dahi şirket hakkındaki gelişmelerden denetim vesilesiyle haberdar olabilirler. Bu nedenle denetim, anonim şirket tüzel kişiliği de olmak üzere anonim şirketin tüm ilgilileri bakımından büyük önem taşımaktadır.

II. DENETİM TÜRLERİ

Denetim çeşitli açılardan türlere ayrılabilir. Konunun daha iyi anlaşılması için burada bazı denetim türlerini aktarmakta fayda mülahaza etmekteyiz. Zira denetim türlerinin ortaya konulması suretiyle anonim ve dolayısıyla limited şirketlerdeki denetimin izah edilmesi daha kolay hale gelecektir.

A. DENETİME ESAS OLAN İRADE BAKIMINDAN DENETİM

Denetime esas olan iradenin şirketin içinden ya da dışından kaynaklanmasına göre denetimi *iç ve dış denetim* olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

1. İç Denetim

İç denetim, şirketin işleyişi konusunda pay sahiplerine bilgi ve hesap verilmesi olarak kısaca tanımlanabilir. İç denetim sayesinde, pay

sahipleri şirketin içinde bulunduğu ekonomik ve idari durumu tespit edebilmekte ve gerektiği halde yöneticilere hesap sorabilmektedir.

Özellikle 6762 sayılı TTK'de (m.347-359), aynı zamanda şirketin organı olarak kabul edilen ve iç denetimi ayrıntılı bir şekilde gerçekleştirmesi görevi yüklenen ve oldukça geniş yetkilerle donatılan denetçiden, her yıl genel kurula sunduğu denetim raporu ile ortaklara şirketin içinde bulunduğu durum ile ilgili bilgiler sunması beklenmekteydi. Kendisine tanınan geniş yetkilere rağmen özel bir uzmanlık aranmaması ve seçilmesi konusundaki özensiz düzenleme sebebiyle bahse konu denetçiden beklenen sonuçlar hemen hemen hiç elde edilememiştir. Bu nedenle öğretide sık sık eleştirilen organ niteliğine sahip denetçinin bağımsız ve tarafsız şekilde görev yapabilmesi çoğu zaman mümkün olmamıştır. Bilhassa yönetim kurulunu ve denetçileri genel kuruldaki aynı hâkim grubun seçmesi sebebiyle denetçiler, kural olarak, objektif olarak denetim görevini ifa edememişler, tarafsız kalamamışlardır.

6102 sayılı TTK ise kendisinden yeterince verim alınamayan organ niteliğindeki denetçiliği kaldırmıştır[262]. Bunun yerine denetimin, şirketin dışında, konusunda uzman denetçi ve/veya denetim kuruluşları eliyle yapılması esnasını getirmiştir (m.397 vd.). Böylece günümüzde, iç denetimin organ niteliğine sahip denetçiler eliyle yapılması zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunun yerine şirket ile organik bağı bulunmayan denetçiler eliyle aynı denetim ikâme edilmeye çalışılmıştır. Tabi bu durumda, evvelki Kanundaki gibi şirketin içerisinde yer almayan ve organ sıfatına sahip olmayan denetçilerin/denetim kuruluşlarının gerçekleştirdiği denetimi artık iç denetim olarak nitelendirmek mümkün olamamaktadır. Bu tür denetçiler eliyle yapılan denetim artık dış denetim olarak kabul edilmektedir. Buna karşılık arzu eden şirketlerin, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan ihtiyari nitelikte, denetim komite veya komisyonu kurması mümkündür (TTK m.366/2). Ayrıca özel konularda faaliyet gösteren bazı anonim şirketlerde, bağımsız dış denetimin yanı

---

[262] Kanunun gerekçesinde denetçinin organ olma özelliğinin kaldırıldığına ilişkin birbiri ile çelişen ifadeler yer almaktadır. Bununla birlikte denetçinin sahip olduğu yetkiler ve üstlendiği görevler dikkate alındığında denetçinin organ olma özelliğinin kaldırıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Konuya ilgili tartışmalar ve ayrıntılı bilgi için bkz. **Köksal, A.:** *"Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 397 ila 406. Maddeleri Arasında Düzenlenen Denetçinin Anonim Ortaklığın Bir Organı Olup Olmadığı Sorunu"*, Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan, C. 1, Ankara 2010, s. 1387 vd.

sıra iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi gibi bazı birimlerin bulunduğunu da belirtmek gerekir[263].

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun düzenlemesi karşısında, sürekli bir şekilde anonim şirketin iç denetimini gerçekleştiren bir organ ya da birimin bulunmadığı açıktır. Bu nedenle artık iç denetimin sadece her bir pay sahibinin ve belirli şartlar altında azınlık sıfatına sahip ortakların talep edebildiği özel denetim çerçevesinde gerçekleştiğini kabul etmek gerekir[264].

2. Dış Denetim

Dış denetim, şirketin dışındaki yetkili kurum ve kuruluşlar eliyle şirketin denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Dış denetim günümüzde, bir taraftan Devlet eliyle yapılan denetim (TTK m.210) diğer taraftan bağımsız denetçi ve bağımsız denetim kuruluşları (TTK m.397 vd.) tarafından yapılan denetim olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Dış denetim daha önce bahsedildiği üzere sadece pay sahiplerinin değil, şirket çalışanlarının, alacaklılarının ve kamunun menfaatine olacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, şirketin içinde bulunduğu ekonomik ve idari durumun tespit edilmesi; tüm menfaat gruplarının konumunu ona göre ayarlaması mümkün olabilecektir.

B. DEVLET DENETİMİ

Gerek özel konularla iştigal etsin gerek alelade şekilde faaliyet göstersin tüm anonim şirketlerin denetiminde toplumun hemen hemen tamamının menfaatinin olduğu daha önce izah edilmişti. Bu nedenle evvelki Kanun zamanında, sermaye şirketlerinin kurulabilmesi için Devletin izni ile şirket esas sözleşmelerinin asliye ticaret mahkemelerince onaylanması gerekiyordu. Meydana getirdiği büyük iş yükü sebebiyle,

---

263 Bankalar, sigorta şirketleri, halka açık anonim şirketler gibi nitelikli şirketlerde, kendilerine özgü yasal düzenlemeleri sebebiyle, kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu ve bağımsız çalışması için gerekli önlemlerin alındığı iç denetim, iç kontrol ve risk yönetimi gibi birimlerin kurulması zorunludur. Böylece dışarıdan yapılan denetimin yanı sıra bu tür şirketlerin içeriden de etkin bir şekilde denetlenmesi ve gözetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca bkz. **Özdamar, M.:** *"Bankaların İç Denetiminde Yeni Bir Organ, Denetim Komitesi"*, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen'e Armağan, İstanbul 2007, s. 1493 vd.

264 **Özkorkut, K.:** *6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Bağımsız Denetim*, Ankara 2013, s. 28.

her şirketin kuruluşunda, önce mahkemelerin inceleme aşaması daha sonra da Bakanlıktan izin alınması şartı kaldırılmıştır. Bunlara ilaveten 6762 sayılı Kanun döneminde anonim şirketlerin tamamının genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisi (Hükumet Komiseri) katılmaktaydı (m.274, 297, 378). Sürecin sağlıklı şekilde işlemediğinden bahisle mevcut TTK ile Bakanlık Temsilcilerinin sınırlı hallerde genel kurul toplantılarına katılması esası getirilmiştir (TTK m.407/3).

Devlet eliyle yapılan denetim ile esas itibarıyla alelade anonim şirketlerin *ilgili Bakanlık*[265] tarafından yapılan denetimi kastedilmektedir. Bakanlık denetimi, TTK m.210'da yer alan hüküm çerçevesinde tarif edilmiştir. Bakanlık, Kanundaki düzenlemeye göre hem şirketleri denetleme hem de Kanunun şirketlerle ilgili hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ikincil düzenleme yapabilme yetkisine sahiptir. Bakanlığın yapacağı denetimin usul ve esasları ile denetime tâbi şirketler Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelikle düzenlenmiştir. Bu bağlamda, "*Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik*" çıkarılmıştır[266]. Günümüzde Bakanlık eliyle yapılan denetim, Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir[267].

Devlet eliyle yapılan denetimden esasen Bakanlık denetimi anlaşılmakla beraber özel bazı şirketlerin yine Devlete ait kuruluşlar tarafından denetlenmesi de söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, bankaların BDDK, halka açık şirketlerin ve diğer sermaye piyasası şirketlerinin SPK, enerji şirketlerinin EPDK gibi üst kuruluşlar tarafından denetlendiği belirtilmelidir. Her bir üst kuruluş özel kanunla kurulmuştur ve bu kuruluş kanunlarında ilgili alanda faaliyet gösteren şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin usul ve esaslar da yer almaktadır.

C. BAĞIMSIZ DENETİM

Dış denetimin ikinci ayağını oluşturan *bağımsız denetim* ise TTK m.397 vd. maddelerinde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Esasen bağımsız denetim ülkemizde 6102 sayılı TTK'den önce de uygulanmaktaydı.

---

265 Kitabın yayına hazırlandığı esnada ilgili Bakanlık, Ticaret Bakanlığı'dır.

266 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete.

267 Bakanlık denetimi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 5, II başlığı.

Evvelki TTK'nin denetime ilişkin hükümlerinin yetersiz kalması sebebiyle, faaliyetleri tüm toplum bakımından önem arz eden özel bazı şirketler bakımından bağımsız denetim uzun süreden beri ülkemizde görülmektedir. Bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları gibi alanlarda bilhassa Devletin ilgili kurum ve kuruluşunun izni ya da ruhsatı (imtiyaz) ile faaliyet gösteren şirketlerin bağımsız uzman denetçiler eliyle denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim zorunlu kılınmaya başlanmıştır[268]. Daha sonra bu uygulama diğer tüm sermaye şirketlerini kapsayacak şekilde 6102 sayılı TTK'ye alınmıştır.

D. ZORUNLU VE İHTİYARİ DENETİM

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, yürürlüğe girmeden önceki ilk halinde bağımsız denetim tüm sermaye şirketleri bakımından zorunlu kılınmıştı (TTK m.397/1). Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik çerçevesinde, denetime tâbi olan anonim ve limited şirketlerin Bakanlar Kurulu (*Cumhurbaşkanı*) kararı ile tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla günümüzde tüm anonim ve limited şirketler zorunlu bağımsız dış denetim kapsamında değildir.

Gelinen bu noktada bağımsız denetim açısından yapılabilecek bu ayrıma göre, anonim ve limited şirketlerin bir kısmı bakımından denetim zorunludur. Bu durumda karşımıza *zorunlu denetim* çıkar. Buna karşılık, zorunlu denetime tâbi olmamakla beraber şirketin kendi isteği ile bağımsız denetime tâbi olmayı seçmesi halinde *ihtiyari denetimden* bahsedilecektir. Özellikle şirketlerin kredi yapılandırmaları, birleşme ve bölünme gibi işlemlerden önce bağımsız denetim raporu almaları muhatapları tarafından istenmektedir.

E. GENEL VE ÖZEL DENETİM

Anonim ve limited şirketlerin tüm faaliyetlerinin belirli kıstaslara göre incelendiği süreç, genel nitelikli denetimdir. Bu bağlamda bağımsız denetim genel nitelikli denetim olarak kabul edilir. Şirketlerin faaliyet dönemi içindeki tüm iş ve işlemlerinin özeti niteliğinde hazırlanan finansal tablolar ve yıllık faaliyet raporları, genel denetimin ko-

---

[268] Konuyla ilgili olarak bkz. 06.12.2012 tarihli 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.14; 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.15; 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu m.18.

nularını oluşturur. Buna karşılık genel nitelikli bağımsız denetimde, şirketin faaliyet dönemi içerisindeki hiçbir somut iş ve işlemi tek başına inceleme konusu yapılmaz. Şirketleri ilgilendiren somut olaylar, resmin bütünü içerisinde genel olarak denetime tâbi tutulurlar.

Şirketlerdeki genel denetime mukabil, pay sahiplerinin incelenmesini istedikleri konularda ayrıca «*özel denetim*» yapılması mümkündür. Özel denetim, pay sahiplerinin bilgi alma haklarıyla bağlantılı olarak somut bir konuda uzman eliyle denetim yapılmasıdır (TTK m.438 vd.). Böylece genel denetim esnasında gözden kaçan veya bağımsız denetime tâbi olmayan şirketlerde veyahut pay sahiplerinin yeterince bilgi edinemedikleri konularda özel bir inceleme yapılması ve sonuçlarının rapora bağlanarak genel kurulun bilgisine sunulması imkânı ortaya çıkmaktadır.

III) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERİN DENETİMİ

Anonim şirketlerin ve dolaylı olarak limited şirketlerin denetimi, esas itibarıyla TTK m.397 vd. hükümlerine tâbidir. 6102 sayılı TTK'de esas olarak bağımsız denetim benimsenmiş olmakla birlikte, m.397/5'e sonradan eklenen düzenleme ile bağımsız denetimin kapsamı dışında kalan sermaye şirketleri ile kooperatiflerin denetiminin usul ve esaslarının ayrıca çıkarılacak bir yönetmelik ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır[269].

A. GENEL OLARAK

Türkiye'de bazı özel anonim şirketler için uzun süreden beri uygulanan bağımsız denetim müessesesi, mevcut Türk Ticaret Kanunu 13.01.2011'de kabul edilirken anonim ve limited şirketlerin tamamı için zorunlu hale getirilmişti. Kanunun yürürlüğe girişinin yaklaşık on sekiz ay sonrası olan 01.07.2012 tarihine bırakılmasının sebebi, tamamlanması ve çıkarılması gereken çok sayıdaki ikincil düzenlenmenin hazırlanması için zaman tanıma olarak belirtilmişti.

---

269 Bağımsız denetim kapsamı dışında kalan şirketlerin denetimine ilişkin Bakanlık tarafından hazırlanan taslak yönetmelik kamuoyu ile paylaşılmış ve görüşler toplanmıştır. Ancak kitap yayına hazırladığı dönemde, söz konusu yönetmelik henüz kabul edilip yürürlüğe girmemiştir.

6102 sayılı TTK'nin getirdiği sert kuralların şirketleri oldukça sıkacağı fark edilince, bu Kanun, henüz yürürlüğe girmesinden bir gün önce yayınlanan 6335 sayılı Kanun ile büyük değişikliğe uğramıştır. Söz konusu değişikliklerden birisi de Kanunun 398'inci maddesindeki tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tâbi olması kuralının kaldırılarak denetime tâbi şirketlerin Bakanlar Kurulu (Cumhurbaşkanı) kararıyla belirlenmesidir (6335 sK. m.18).

Kanunun kendisine yetki verdiği Bakanlar Kurulu, ilk kez 19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Kararı[270] ile denetim kapsamına giren sermaye şirketlerinin belirlenmesi için gerekli koşulları açıklamıştır. Açıklanan koşullar çerçevesinde sermaye şirketlerinin büyük çoğunluğu denetim kapsamı dışında kalmıştır. Bağımsız denetimin bu kadar yaygın olarak ilk kez hayata geçirilmesi sebebiyle aşamalı bir şekilde tabana yayılması ilkesi benimsenmiş ve zamanla kapsamın genişletilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Bakanlar Kurulu'nun 2014/5973 sayılı[271], 2014/7149 sayılı[272], 2016/8549 sayılı[273] ve nihayet 2018/11597 sayılı[274] kararları ile ilk kararda değişiklik yapılarak bağımsız denetimin kapsamı genişletilmiştir. Günümüzde geçerli olan koşullar ile bağımsız denetimin kapsamı, ilk karara nazaran genişlemiştir.

6102 sayılı TTK'nin yürürlüğe girmesinden önce yapılan önemli değişikliklerden birisi de anonim ve limited şirketlerin kuruluşundan itibaren önemli birçok aşamada görüşünün alınması zorunlu kılınan ve uzman kişilerden seçilebilen *işlem denetçiliğinin* tamamen kaldırılmasıdır (6335 sayılı Kanun m.40-41). Böylece önemli bir kurum olan ve şirketin pay sahipleri bakımından önem arz eden konulardaki işlemlerinde (*esas sermaye artırımı, esas sermaye azaltılması, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı gibi*) raporunun alınması gereken işlem denetçiliği ve işlem denetçisi raporu bütünüyle Kanundan çıkarılmıştır.

---

270 23.01.2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete.
271 14.03.2014 tarih ve 28941 sayılı Resmi Gazete.
272 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete.
273 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete.
274 26.05.2018 tarih ve 30432 sayılı Resmi Gazete.

B. BAĞIMSIZ DENETİM

Anonim ve limited şirketlerin denetiminde esas olan bağımsız denetim müessesesi tüm özellikleri ile birlikte bu başlık altında incelenmiştir.

1. Tanımı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.397/1 hükmü esas alınarak şu şekilde bir tanım yapılabilir: Bağımsız denetim, şirketin bir faaliyet dönemindeki finansal tablolarının kanuna, esas sözleşmeye, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının; ayrıca finansal tablolar ile yönetim kurulu faaliyet raporunun uyumunun incelenmesi ve rapora bağlanmasıdır.

2. Özellikleri

Bağımsız denetim, daha önce izah edildiği üzere şirketin *dışından ve belirli zamanlarda* uzman kişiler eliyle gerçekleştirilir. Evvelki Kanundaki anonim şirketlerin iç denetiminden farklı olarak şirketin tüm işlerinin, sözleşmelerinin, faturalarının, ödemelerinin, banka hesaplarının, kasasının kontrol edildiği bir denetim olmayıp, şirket yönetimini sürekli bir şekilde denetim ve gözetim altında da tutmamaktadır. Bağımsız denetim esasen, önceden belirlenmiş standartlara göre hazırlanmış şirketin yıllık finansal tabloları ile yönetim kurulu/müdürün hazırladığı yıllık faaliyet raporunun tek tek ve birlikte incelenmesi temeline dayalıdır. Denetim esnasında bir taraftan hazırlanan tabloların mevzuata uygun olup olmadığı diğer taraftan yönetim kurulunun faaliyet raporundaki veriler ile uyumu incelenmektedir.

Bağımsız denetim yukarıda ifade edildiği üzere, *genel nitelikli denetim* özelliği gösterir. Şirketin yıllık faaliyetleri bir bütün olarak incelenerek elde edilen hukuki ve mali sonuçlar rapora bağlanır. Mali idare bakımından bağlayıcı olmamakla beraber, şirketlerin yıllık vergi matrahlarının belirlenmesinde de bahse konu denetim raporları da dikkate alınır. Böylece genel nitelikli denetimden hem şirketin kendisi hem pay sahipleri hem de kamu maliyesi faydalanır.

Bağımsız denetim, sahip olduğu öneme binaen, *kamu idaresi tarafından ayrıca denetlenmektedir*. Konuyla ilgili olarak 660 Sayılı KHK ile 02.11.2011 tarihinde kurulan Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim

Standartları Kurumu (KGK) tarafından, tüm bağımsız denetçiler denetime tâbi tutulurlar.

Bağımsız denetim yaptırma zorunluluğu kural olarak *kanundan kaynaklanmaktadır.* Yukarıda da bahsedildiği üzere anonim ve limited şirketler ile özel bazı konular ile iştigal eden şirketlerin denetimi kanuni düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Anonim ve limited şirketlere ilişkin zorunluluk TTK m.397 vd. hükümlerinden, diğer özel şirketlere ilişkin zorunluluk ise Bankacılık, Sigortacılık Kanunları ile Sermaye Piyasası Kanunu gibi düzenlemelerden kaynaklanmaktadır.

Bağımsız denetim yaptırmak kanunen zorunlu kılınmış olsa da şirketin hangi denetçi veya denetim kuruluşu ile çalışacağı kendi serbest iradesine bırakılmıştır. Bu bağlamda bağımsız denetim, *sözleşmeye dayanan bir denetim yöntemidir.* Bağımsız denetçi ile denetlenecek olan şirket arasındaki ilişki, kanuni sınırlandırmalara uyulmak kaydıyla her zaman serbest iradeler ile yapılan *bağımsız denetim sözleşmesine* dayanmaktadır.

3. Denetimin Kapsamı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun kabul edildiği ilk halinde, istisnasız tüm anonim ve limited şirketlerin bağımsız denetime tâbi kılındığı; daha sonra Kanun yürürlüğe girmeden hemen önce çıkarılan 6335 sayılı Kanun ile denetime tâbi olacak şirketlerin tespitinin Bakanlar Kuruluna (Cumhurbaşkanı) bırakıldığı yukarıda ifade edilmişti. Kitabın yayına hazırlandığı esnada yürürlükte olan 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre[275], denetime tâbi olan şirketlerin kapsamı genişletilmiş ve önceki döneme nazaran daha fazla şirketin zorunlu bağımsız denetimin kapsamına girmesi sağlanmıştır.

Halihazırda geçerli olan Bakanlar Kurulu kararında, evvelki düzenlemelerde olduğu gibi bağımsız denetime tâbi şirketler ile kesin olarak bağımsız denetim kapsamı dışında kalan şirketler belirtilmiştir. Bağımsız denetime tâbi şirketlere ilişkin ise kriterler öngörülmüştür.

a. Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketler

Bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin üç alt başlık altında incelenmesi mümkündür.

---

[275] Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı, önceki kararlardan farklı olarak, 19.12.2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararını yürürlükten kaldırmıştır.

aa) Doğrudan Bağımsız Denetime Tâbi Olan Şirketler

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu kararında (m.3/1-a), önceki kararlarda olduğu gibi, bazı şirketlerin faaliyet konularının taşıdığı önemden dolayı herhangi bir kriter aranmaksızın bağımsız denetim kapsamına alındığı görülmektedir. Karara ekli 1 Sayılı Listede yer alan, özellikle *Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tâbi bazı şirketler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tâbi olan bazı şirketler, Sigortacılık Kanunu ile Bireysel emeklilik ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, Borsa İstanbul piyasaların faaliyet göstermesine müsaade edilen şirketler, umumi mağazalar ile çeşitli lisanslara sahip olan medya hizmet sağlayıcısı olan şirketlerin,* bağımsız denetim kapsamına alınması bakımından herhangi başka bir kriter aranmamıştır.

bb) Özel Kriterlere Tâbi Olan Şirketler

2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında (m.3/1-b) özel kriter öngörülen iki ayrı şirketler grubu bulunmaktadır. Aşağıda sayılan üç kriterden herhangi ikisini eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde, şirketler müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tâbi olacaktır (Karar m.5).

Öncelikle *sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak 6362 Sayılı SPK kapsamında halka açık şirketler* için eşik değerler şu şekilde belirlenmiştir:

i) Aktif toplamı 15 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 20 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 50 kişi.

İkinci olarak, özel kriterlere tâbi tutulan diğer grup şirketler ise Karara ekli 2 numaralı listede yer alan şirketlerdir[276]. Bunlar için belirlenen eşik değerler şu şekildedir:

---

[276] Bakanlar Kurulu kararına ekli 2 Numaralı Liste şu şekildedir:
1) Sermayesinin en az %25'i kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, sendikalara, derneklere, vakıflara, kooperatiflere ve bunların üst kuruluşlarına doğrudan veya dolaylı olarak ait olan şirketler.
2) Yurt çapında günlük olarak gazete yayımlayan şirketler.
3) Çağrı merkezi şirketleri hariç olmak üzere, 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 6102 sayılı

i) Aktif toplamı 30 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 40 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 125 kişi.

cc) Genel Kriterler

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere, Bakanlar Kurulu kararında belirlenen özel kriterler dışında kalan tüm sermaye şirketleri için geçerli olmak üzere belirlenen genel eşik değerler şu şekildedir:

i) Aktif toplamı 35 milyon Türk Lirası.

ii) Yıllık net satış hasılatı 70 milyon Türk Lirası.

iii) Çalışan sayısı 175 kişi.

b. Bağımsız Denetime Tâbi Olmayan Şirketler

Bakanlar Kurulu kararında belirlenmiş olan kriterlerin dışında kaldıkları için denetime tâbi olmayan şirketlerin yanı sıra, Kararın 4'üncü maddesinde doğrudan kapsam dışı kalan şirketler ayrıca belirlenmiştir. Buna göre,

i) Ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tâbi şirketler.

ii) Ekli (I) sayılı listede belirtilenler ile ekli (II) sayılı listenin 5(b) sırasında belirtilen şirketler hariç olmak üzere sermayesinin en az yüzde 50'si devlete, il özel idarelerine, kanunla kurulmuş vakıflara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler.

Kanunun 1525 inci maddesi kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenleme ve denetimine tâbi olan şirketler.

4) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan lisans, sertifika veya yetki belgesi alıp bu Kurum düzenlemelerine tâbi olarak faaliyet gösteren şirketler.

5) (I) sayılı liste kapsamında olanlar hariç olmak üzere;

a) Gayri faal olan veya faaliyetleri geçici olarak durdurulan veya iptal edilmiş olan (gerekli ana sözleşme değişiklikleri ve benzeri prosedür işlemleri henüz gerçekleştirilmemiş olanlar dahil) iştirak ve şirketler hariç olmak üzere, Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonunun (TMSF) iştirakleri ile mülga 4389 sayılı Bankalar Kanunu ve 5411 sayılı Kanun kapsamında TMSF tarafından denetimi ve yönetimi devralınan şirketler.

b) 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin en az %50'si belediyelere ait olan şirketler.

c. Uygulama Esasları

Yukarıda belirlenen kriterlerin ne şekilde uygulanacağına, bağımsız denetim kapsamına giren şirketlerin ne şekilde belirleneceğine ilişkin esaslar, Kararın 5'inci maddesinde izah edilmiştir. Buna göre,

(1) Eşik değerlere tâbi şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin eşik değerini art arda iki hesap döneminde aştığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tâbi olur.

(2) Eşik değerleri aştığı için bağımsız denetime tâbi şirket, art arda iki hesap döneminde üç ölçütten en az ikisine ait eşik değerlerin altında kaldığı ya da bir hesap döneminde bu ölçütlerden en az ikisine ait eşik değerlerin yüzde 20 veya daha fazla oranda altında kaldığı takdirde müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkar.

(3) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından şirketin tâbi olduğu mevzuat uyarınca hazırlanmış olan son iki yıla ait finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise son iki yıla ait ortalama çalışan sayısı esas alınır.

(4) Eşik değerlerin aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde şirketler bağlı ortaklık ve iştirakleriyle birlikte dikkate alınır. Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketlerde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklık ve bağlı ortaklığın son iki yıla ait ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır; iştirakler açısından, iştirake ait söz konusu kalemler şirketin iştirakteki hissesi oranında dikkate alınır.

4. Denetçi

Bağımsız denetim, denetim konusunda uzmanlaşmış ve gerekli nitelikleri taşıyanlar arasından Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yetkilendirilmiş[277] ve bağımsız denetçi siciline[278] kayıtlı olan *bağımsız*

---

[277] Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, bağımsız denetçilerin ve bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine ilişkin olarak 25.01.2013 tarihli "*Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği*" çıkarılmıştır.

[278] Kamu Gözetimi Kurumu tarafından, bağımsız denetçilerin kaydedilmeleri amacıyla tutulan resmi sicile ilişkin olarak 25.01.2013 tarihli "*Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği*" çıkarılmıştır.

denetçiler veya bunların ortak olduğu sermaye şirketi niteliğindeki *bağımsız denetim kuruluşları* eliyle yürütülür (TTK m.400/1). Hangi şirketlerin bağımsız denetçi hangilerinin bağımsız denetim kuruluşları eliyle denetleneceği KGK tarafından belirlenir[279].

a. Denetçilerin Özellikleri

Bağımsız denetçilerin taşımaları gereken temel özellikler KGK tarafından belirlenmekte ve kontrol edilmektedir. Buna karşılık özel bazı alanlarda denetim yapabilmek için ilave özellikler aranabilmekte ve bu alanlardaki ilgili kamu kuruluşlarının ilgili listelerine kayıt (akredite) olunması aranabilmektedir. Bu bağlamda enerji piyasalarında denetim yapabilmek için EPDK'nin; bankacılık alanında denetim yapabilmek için BDDK'nin, sermaye piyasalarında ise SPK'nin denetime ilişkin özel düzenlemelerine tâbi olmak gerekmektedir.

Bağımsız denetçilerin denetlemeye konu şirketlerle olan münasebetlerinin düzenlenmesi ve denetçinin bağımsız kalabilmesi için kanun koyucu tarafından birtakım kurallar konulmuştur. Bilhassa, denetçi ve şirket arasında daha önceye dayalı menfaat ilişkisinin bulunması halinde denetçilik yapılmasının engellenmesi amacıyla özel kurallar öngörülmüştür (TTK m.400). Bunun yanı sıra bağımsız denetim kuruluşlarının bağımsızlıklarına ilişkin kuralların belirlenmesi görevi, 660 sayılı KHK uyarınca Kamu Gözetimi Kurumuna bırakılmıştır. Kurum da çıkardığı *Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği*[280] ile bahse konu kuruluşların bağımsızlığına ilişkin kuralları öngörmüştür.

b. Denetçinin Seçimi ve Göreve Başlaması

Bağımsız denetçinin kontrol edeceği organ şirketin yönetimidir. Başta yönetim kurulu olmak diğer icrai yetkiler kullanan yöneticiler bir

---

279 660 sayılı KHK'nın 23/1 maddesi uyarınca *kamu yararını ilgilendiren kuruluşların* denetimi bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılabilir. Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlar, *Halka açık şirketler, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, faktöring şirketleri, finansman şirketleri, finansal kiralama şirketleri, varlık yönetim şirketleri, emeklilik fonları, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları ile faaliyet alanları, işlem hacimleri, istihdam ettikleri çalışan sayısı ve benzeri ölçütlere göre önemli ölçüde kamuoyunu ilgilendirdiği için Kurum tarafından bu kapsamda değerlendirilen kuruluşlardır* (660 sayılı KHK m.2/1-ğ).

280 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete.

bütün olarak denetlenir. Dolayısıyla bağımsız denetçinin seçilmesi konusundaki yetkinin yöneticilere verilmemesi doğal bir zorunluluktur. Kanun koyucu da bağımsız denetçinin seçilmesi yetkisini, kural olarak, *şirketin genel kuruluna* vermiştir (TTK m.399/1).

Denetçiyi belirleme yetkisi, *genel kurulun devredilemez yetkileri* arasında sayılmıştır (TTK m.408/2-c). Dolayısıyla Kanunda yer alan istisnalar dışında bağımsız denetçi şirket genel kurulu tarafından seçilir. Yönetim kurulu da seçilen bağımsız denetçiyle sözleşme imzalayarak, seçilen denetçiyi gecikmeksizin ticaret siciline tescil ve ilân ettirir (TTK m.399/1). Denetçinin seçilmesi, olağanüstü bir karar niteliği taşımadığından, genel kurulun olağan işler için gerekli olan toplantı ve karar nisabına uyarak denetçiyi seçmesi gereklidir (TTK m.418).

Genel kurulun denetçiyi seçemeyeceği iki halde, denetimde boşluk doğmaması adına kanun koyucu *iki istisnaya* yer vermiştir.

İlk olarak, belli şartlar altında denetçinin *mahkeme* tarafından görevlendirilmesi mümkündür. Kanun koyucu denetçinin mahkeme tarafından görevlendirilmesini birkaç farklı durum için öngörmüştür. TTK m.397/4 hükmüne göre, yönetim kurulunun ve 5'inci fıkradaki şartları taşıyan azınlık pay sahiplerinin denetçinin seçiminin TTSG'de yayınlanmasından itibaren 3 hafta içinde talebi üzerine, seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı sebebin varlığı ve özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde kuşkuların bulunması halinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi tarafından başka bir denetçi atanabilir. Aynı şekilde Kanunun m.399/6'daki düzenlemesine göre, faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, yönetim kurulu üyelerinin veya herhangi bir pay sahibinin talebi üzerine, aynı mahkeme tarafından görevlendirilir. Mahkemenin görevlendirme süreci, denetçinin seçimine ilişkin kararın geçersizliği veya denetçinin sözleşmeyi feshetmesi veya denetçilik görevini ifa edememesi hallerinde de uygulanır. Mahkemenin bağımsız denetçiyi görevlendirme kararı kesindir (TTK m.399/6).

İkinci olarak denetçinin kendisine tanınan yetki çerçevesinde denetim sözleşmesini feshetmesi halinde, faaliyet döneminin kalan kısmında denetim görevini ifa etmesi için istisnai olarak yönetim kurulu tarafından hemen geçici bir denetçi seçilir. Yönetim kurulu denetim sözleşmesinin feshedilmesini genel kurulun bilgisine, seçtiği denetçiyi de aynı kurulun onayına sunar (TTK m.399/9). Genel kurul geçici olarak

seçilen denetçiyi onaylayabileceği gibi yerine başka bir denetçi de seçebilir[281]. Madde gerekçesinde yönetim kuruluna istisnaen de olsa bu yetkinin verilmesi sebebi, geçici de olsa şirketin denetiminde herhangi bir boşluğun doğmaması olarak verilmiştir.

c) Denetim Sözleşmesi

Şirket genel kurulu tarafından seçilen, ticaret siciline tescil ve ilân edilen bağımsız denetçinin görevini bir denetim sözleşmesine göre yerine getirmesi esastır. Kanunda açıkça ismi zikredilmemiş olsa da sözleşmenin tarafları (m.400/1), tarafların karşılıklı yükümlülükleri (m.402-404; 397/7 ve 401), denetim sözleşmesinin sona ermesi (m.399/2,4 ve 8. fıkraları) hakkında çeşitli hükümler serdedilmiştir.

Denetim sözleşmelerinin şekline ilişkin TTK'de açık bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Bağımsız Denetim Yönetmeliği'nin[282] 29'uncu maddesinde denetim sözleşmesinin *yazılı* olarak yapılması[283] öngörülmüş; ayrıca içermesi gereken asgari unsurlar sayılmıştır. Şirket genel kurulunun aldığı karar doğrultusunda veya Kanunda sayılan hallerde mahkeme kararı uyarınca, şirketin sözleşme yapma iradesinin bağımsız denetçi tarafından kabul edilmesi sonucunda sözleşme kurulmuş olur[284]. Ancak gerek ticaret siciline gerek Kamu Gözetimi Kurumuna sunulacak denetim sözleşmesinin asgari şartlarını içeren ve tarafların iradelerini gösteren yazılı bir metin olması gereklidir. Denetim ücret karşılığında yapıldığından, denetçiye ödenecek ücretin de mutlaka sözleşmede yer alması gerekir (KGK Bağımsız Denetim Yönetmeliği m.32)[285].

Denetim sözleşmesinin her iki tarafa karşılıklı borç yükleyen, iş görme edimi temeline dayanan, kendine özgü (*sui generis*) sözleşme

---

281 **Özkorkut,** s. 282.

282 29.12.2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete.

283 Kanunda yazılı şekil şartı öngörülmemesine rağmen, ilgili Yönetmelik sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasını aramıştır. Bu durumda söz konusu şekil kuralının, geçerlilik şartı olmayıp ispat şartı olarak değerlendirilmesini söylemek gerekir.

284 bkz. **Urkan, E.,** Sermaye Piyasalarında Bağımsız Denetim Sözleşmeleri ve Sorumluluk, Ankara 2016, s. 114 vd.

285 Bağımsız denetçinin ücret hakkı ile ilgili açıklamalar için bkz. **Urkan,** s. 239 vd.

niteliğinde olduğu ifade edilebilir[286]. Bağımsız denetçinin denetime konu şirket ya da topluluk ile başka bir hizmet vermesi yasaklandığından (TTK m.400/1), denetim sözleşmesinde başka bir hizmet ediminin yer alması mümkün değildir. Denetim hizmeti yıllık olarak verildiğinden, her faaliyet yılı için ayrı ayrı denetim sözleşmesi yapılması gerekmektedir.

d) Denetçilik Görevinin İfası

Denetçinin sözleşme ile yükümlendiği asıl edimi, bağımsız denetim faaliyetlerini standartlara uygun bir şekilde yürütmek ve tamamlamaktır. Denetçi özellikle, şirketin veya şirketler topluluğunun finansal tablolarının ve yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun, denetim esnasında elde edilen bilgilerle uyum içerisinde olup olmadığını açıklayacak şekilde yapılmalıdır (TTK m. 398/2).

Denetçi, denetim görevini ifası esnasında ihtiyaç duyduğu defterleri, yazışmaları, sözleşmeleri, diğer her türlü bilgi ve belgeyi yönetim kurulundan talep eder. Yönetim kurulu, kendisinden talep edilen bilgi ve belgelerin incelenmesini sağlamak adına denetçiye gerekli olan imkânı sunmakla yükümlüdür (TTK m.401/1). Özenli bir denetim için gerekli olduğu takdirde denetçi, incelemesini ana ve yavru şirketleri içine alacak şekilde genişleterek onlara ilişkin bilgi ve belgeleri de talep edebilir.

Bağımsız denetçinin denetim görevini kural olarak şahsen ifa etmesi gerekir. Ancak özellikle bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme imzalanmış olması halinde, bu kuruluşun yetkili denetçilerinin şirketi denetlemesi gerekli ve yeterli sayılmalıdır.

Bağımsız denetçilerin görevlerinin ifası esnasında verebilecekleri zararların tazmin edilebilmesi amacıyla *mesleki sorumluluk sigortası* yaptırmaları zorunlu kılınmıştır. Gerçekten Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 33'üncü maddesine göre, denetim kuruluşlarının ve denetim faaliyeti üstlenen bağımsız denetçilerin, üstlendikleri ilk denetim işiyle birlikte başlamak üzere, tüm denetimlerini kapsayacak şekilde mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaları şarttır.

---

[286] Bağımsız denetim sözleşmelerinin hukuki niteliği ile ilgili ayrıntılı bilgi ve tartışmalar için bkz. **Urkan,** s. 88 vd.; **Özkorkut,** bağımsız denetim, s. 276; **Köksal,** s. 92 vd.

5. Denetim Raporu

Denetçinin denetim süreci sonucunda elde ettiği bilgiler doğrultusunda, Kanunda yer alan hususları kapsayacak şekilde denetim raporu hazırlaması ve imzalayarak şirket yönetim kuruluna sunması beklenir. Gerçekten denetçi, yapılan denetimin türü, kapsamı, niteliği ve sonuçları hakkında, gereken açıklıkta, anlaşılır, basit bir dille yazılmış ve geçmiş yılla karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve finansal tabloları konu alan rapor hazırlamalıdır (TTK m.402/1). Denetçi bu raporun yanı sıra, ayrı bir rapor halinde, yönetim kurulunun şirketin veya topluluğun durumu hakkındaki yıllık faaliyet raporunda yer alan irdelemeleri, finansal tablolar ile tutarlılığı ve gerçeğe uygunluğu açısından değerlendirir (TTK m.402/2).

Denetim raporunun esas bölümünde;

- Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olup olmadığı,
- Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği, hususlarının açıkça yer alması gerekmektedir (TTK m.402/4).

Raporda ayrıca finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin;

- Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı,
- Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde yansıtıp yansıtmadığı, belirtilmelidir (TTK m.402/5).

6. Görüş Yazıları

Denetçi, yaptığı denetimin ardından hazırladığı denetim raporunda, şirket ya da şirketler topluluğu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerini içeren yazısını hazırlayarak açıklamak durumundadır. Bu bağlamda denetçi, denetim sonunda, KGK'nin belirlediği esaslar doğrultusunda, denetimin konusu, türü, niteliği ve kapsamı yanında denetçinin değerlendirmelerini de içerecek şekilde hazırlanır (TTK m.403/1). Denetçinin yaptığı denetim sonunda dört farklı şekilde görüş verme imkânı bulunmaktadır.

Olumlu görüş, denetçinin verebileceği ve şirket yönetimi açısından en uygun görüş türüdür. Şirketin finansal tablolarının ve yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun mevzuata uygun olması halinde, denetçi olumlu görüş verir (TTK m.403/1, 2). Şirketin denetimi sonunda verilen olumlu görüş yazısı, yönetim kurulunun ibrasına önemli bir dayanak teşkil eder. Ancak olumlu görüş yazısına rağmen yönetim kurulunun ibra edilmemesi ve hakkında sorumluluk davası açılması mümkündür[287].

Sınırlı olumlu görüş, denetçinin yaptığı denetimin ardından şirketin işleyişiyle alakalı genel itibariyle olumlu olmasına karşın birtakım çekincelerinin bulunması halinde söz konusu olur (TTK m.403/3). Finansal tablolarda şirketin yetkili kurullarınca düzeltilebilecek bazı eksikliklerin bulunduğu, bunların tablolarda açıklanmış sonuçlara etkilerinin kapsamlı ve büyük olmadığı durumlarda sınırlı olumlu görüş yazısı verilir. Böylece denetçi şirketin genel görünümünün iyi olduğunu ancak küçük birtakım sıkıntıların giderilmesi halinde daha iyi olabileceğini vurgulamış olmaktadır.

Olumsuz görüş, şirketin durumunun iyi olmadığı, finansal tabloların ve yıllık faaliyet raporunun gerçeği yansıtmadığı hallerde verilir (TTK m.403/3). Denetçinin raporunun olumsuz olması halinde ağır sonuçları bulunmaktadır. Öncelikle yönetim kurulu, dört iş günü içerisinde genel kurulu toplantıya çağırır. Genel kurul, çağrı üzerine yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında yeni bir yönetim kurulu seçer. Esas sözleşmede aksine düzenleme olmaması halinde, eski yönetim kurulu üyeleri yeniden göreve seçilebilir. Yeni yönetim kurulu altı ay içerisinde kanuna, esas sözleşmeye ve standartlara uygun finansal tablolar hazırlatır ve bunları denetleme raporu ile birlikte genel kurula sunar (TTK m.403/5). Şirketin iç işleyişindeki bu etkilerin dışında, olumsuz görüş yazısı, şirketin dışarıdaki ticari itibarına, güvenilirliğine de büyük zarar verir. Bu nedenle uygulamada çok sık karşılaşılmayan bir rapor türüdür.

Görüş bildirmekten kaçınma, denetçinin, şirketle ilgili gerekli olan bilgi ve belgelere erişememesi ve şirketle ilgili sonuca varılmasına engel olacak derecede belirsizliğin bulunması halinde, gerekçeleri açıklanmak suretiyle verdiği görüştür (TTK m.403/4). Denetçi, görüş vermekten kaçınmasına sebep olan hususları maddi vakıalar ile ispatlama imkanından yoksun olsa da bu yolu tercih edebilir. Görüş vermekten

---

[287] **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 265.

kaçınma hali, olumsuz görüşünün hüküm ve sonuçlarını doğurur (TTK m.403/4).

7. Denetim İlişkisinin Sona Ermesi

Bağımsız denetim sözleşmesinin sona ermesi sınırlı durumlarda mümkündür. Öncelikle belirtmek gerekir ki bir faaliyet yılı için yapılan sözleşme, bu sürenin dolması ve görevin ifa edilmesi ile birlikte kendiliğinden sona erer. Taraflar sınırlamalara uymak kaydıyla sonraki yıl için aynı şekilde yeni bir sözleşme yapabilirler.

Anonim şirket genel kurulu, *bağımsız denetçi ile yapılan sözleşmeyi tek taraflı feshetme yetkisini haiz değildir.* Gerçekten TTK m.399/2 hükmüne göre, haklı nedenlerin bulunması halinde, şirket denetçiyi azledememekte sadece ilgili mahkemeden görevden alınmasını talep edebilmektedir. Kanunun bu düzenlemesi genel kurulun yetkilerini düzenleyen TTK m.408/2-c hükmü ile uyumsuzdur. Zira genel kurulun yetkileri arasında, denetçiyi seçmek ve gerektiğinde azletmek sayılmıştır. Ancak TTK m.399'da şirketin denetçinin görevden alınmasını mahkemeden isteyebilmesi sebebiyle azil yetkisinin kullanılamayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır[288].

Denetçinin görevden alınmasına ilişkin dava, genel kurulda en az üç aydan beri pay sahipliği sıfatı taşıyan, denetçinin seçiminde olumsuz oy kullanmış ve bunu zapta geçirtmiş olan azınlık tarafından, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılabilir (TTK m.399/5). Davanın denetçinin seçimine ilişkin kararın TTSG'de yayımlanmasından itibaren üç hafta içerisinde açılması gerekmektedir. Mahkeme ileri sürülen sebepleri haklı olarak nitelendirirse, denetçinin görevden alınmasına ve yerine yenisinin seçilmesine karar verebilir.

6102 sayılı TTK, *bağımsız denetçiye, tek başına alacağı karar ile denetim sözleşmesini feshetme yetkisi* tanımıştır (m.399/8). Denetçi haklı bir sebebin bulunması veya kendisine karşı görevden alma davasının açılması halinde denetim sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilir. Fesih beyanında denetçi, sözleşmenin neden sona erdirildiğini de

---

[288] Öğretide, genel kurulun TTK m. 408/2-c'de zikredilen denetçiyi görevden alma yetkisi, sınırlı da olsa, TTK m. 399/9 hükmünde, yönetim kurulunun seçtiği denetçinin genel kurul tarafından onaylanmayıp yerine yenisinin seçilmesi halinde kullanılabildiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgili açıklamalar için bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 17-34.

şirkete açıklamalıdır. Denetçi fesih anına kadar elde ettiği sonuçları, yine de şirket genel kuruluna sunmak zorundadır. (TTK m.399/8).

8. Denetçinin Sır Saklama Yükümlülüğü

Denetim sözleşmesi ile denetçinin yükümlendiği en önemli görev denetim faaliyetinin yerine getirilmesi olup, buna ilişkin usul ve esaslar kanun koyucu tarafından açıklanmıştır. Denetim sözleşmesi kapsamında denetçiye yüklenen ve kanun koyucu tarafından kendisine özel bir önem atfedilen bir başka yükümlülük «*sır saklama*»dır. Görevin niteliği gereği inceleme konusu şirketin hemen hemen tüm ticari bilgilerine ve birtakım sırlarına vakıf olan denetçinin bu sırları, denetçilik ilişkisi sona erse de saklaması gerektiği açıktır.

TTK m. 404 hükmüne göre denetçi, özel denetçi ve bunların yardımcıları ile denetleme yapmasına yardımcı olan temsilcileri, denetimi dürüst, tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla yükümlüdür. Faaliyetleri esnasında öğrendikleri, denetleme ile ilgili iş ve işletme sırlarını izinsiz olarak kullanamazlar. Kasten ya da ihmal ile yükümlülüklerini ihlal edenler şirkete verdikleri zararlardan dolayı tek başlarına veya müteselsilen sorumludurlar. Denetimi bağımsız denetim kuruluşu yapmış ise sır saklama yükümlülüğü bunların yönetim kurulu üyelerini ve çalışanlarını da kapsar (TTK m.404/3).

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesinde ihmali bulunan kişiler hakkında, verdikleri zarar sebebiyle her bir denetim için yüzbin TL, pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde ise üçyüzbin TL'ye kadar tazminata hükmedilebilir. Söz konusu tazminat sınırlaması, denetime birden çok kişinin katılması ve zarar verici birden çok eylemin bulunması halinde ve katılanların bazılarının kasıtlı hareket etmeleri halinde de uygulanır (TTK m.404/2).

Denetçilerin sır saklama yükümlülüğünün sözleşme ile ortadan kaldırılamayacağı veya sınırlandırılamayacağı da ayrıca hükme bağlanmıştır (TTK m.404/4).

Denetçinin bu tür sorumluluğuna ilişkin talepler, rapor tarihinden başlayarak beş yılda zamanaşımına uğrar. Ancak fiil suç oluşturup da Türk Ceza Kanunu'na göre süresi daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat hakkına da aynı zamanaşımı süresi uygulanır (TTK m.404/5).

C. ÖZEL DENETİM

Pay sahiplerinin şirketin işleyişi hakkında genel bilgilerin dışında, özel bazı konularla ilgili özel inceleme yapılmasını isteme hakkı bulunmaktadır. Organ niteliği taşıyan iç denetimin 6102 sayılı TTK ile kaldırılmış olmasından sonra, pay sahipleri, belirli konuların incelenmesini ancak özel denetçi sayesinde sağlayabilmektedir. Bu nedenle özel denetim, hem evvelki Kanundaki sisteme nazaran daha ayrıntılı şekilde düzenlenmesi hem de pay sahiplerinin içeriden özel bilgi almalarının tek yolu olarak Kanunda kalması sebebiyle ayrı bir önemi haiz duruma gelmiştir.

1. Özel Denetimin Amacı ve Kapsamı

Anonim şirketlerin denetiminin artık bağımsız denetçiler eliyle ve şirketin dışından yapılmakta olduğu yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edildi. Bağımsız denetçiler tarafından hazırlanan denetim raporu ve ekleriyle birlikte yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, her yıl olağan genel kurul toplantısından on beş gün öncesinden itibaren şirket merkezinin bulunduğu yerde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur (TTK m.437/1). Bu sayede pay sahipleri, genel kurul toplantısından önce, toplantıdaki müzakere konuları hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bunun dışında internet sitesi kurma zorunluluğu bulunan şirketler ile halka açık şirketlerde, pay sahiplerinin ayrıca bilgilendirilmeleri söz konusudur. Belirtilen bu imkanlar dışında pay sahiplerinin doğal yollardan şirketin işleyişi ile bilgi alma imkânları sınırlıdır. İşte bu nedenle pay sahiplerine bilgi alma ve inceleme hakkı ile özel denetçi isteme hakkı tanınmıştır.

Yukarıda ayrıntılı olarak izah edildiği üzere[289] pay sahiplerinin özel konularda bilgi alma hakları TTK m.437'de düzenlenmiştir. Buna göre pay sahipleri, genel kurul toplantısında yönetim kurulundan şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir (TTK m.437/2). Pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkını daha önce kullanmış olmasına karşın yeterli sonuç elde edemediği hallerde kendisine ayrıca özel denetçi isteme imkânı tanınmıştır (TTK

[289] Bkz. Onbirinci Bölüm, § 14, II, C, 3, gg, ccc başlığı.

m.438 vd.). Böylece pay sahipleri, şirketin menfaatini ilgilendiren konularda yönetimin ne şekilde hareket ettiğini en azından takip etme imkânına kavuşmuş olmaktadır.

2. Özel Denetçinin Atanması

Evvelki Kanunda azınlığa tanınan bir hak olan özel denetim isteme hakkı, 6102 sayılı TTK'de her pay sahibinin kullanımına sunulmuştur. TTK m.438/1 hükmüne göre, anonim şirketin her bir pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olması halinde, bilgi alma veya inceleme hakkını daha önce kullanmış olmak kaydıyla, belirli olayların özel bir denetimle açığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa dahi genel kuruldan isteyebilir. Böylece evvelki Kanun döneminde yaşanan gündemde hüküm bulunmaması halinde, azınlığın özel denetim isteme hakkını nasıl kullanacağı sorusu cevaplanmış olmaktadır. Gündemde yer almasa bile her pay sahibi genel kuruldan bu yönde bir istemde bulunabilmektedir.

Pay sahibinin isteminin genel kurul tarafından kabul edilmesi halinde, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içerisinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını isteyebilir (TTK m.438/2).

Genel kurulun özel denetçi atanma talebini reddetmesi halinde mahkemeden özel denetçi istenmesi ise kanunda özel bir şarta bağlanmıştır. TTK m.439 hükmüne göre, genel kurulun talebi reddetmesi üzerine sermayenin en az onda biri halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değerinin toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri, üç ay içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını talep edebilirler[290]. Görüldüğü üzere özel denetçi atanmasını genel kuruldan istemek her pay sahibine tanınmışken talebin reddedilmesi halinde dava açılması özel bir azınlık hakkı olarak düzenlenmiştir.

Mahkeme, önüne gelen özel denetçi talebini şeklen inceledikten sonra, dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını ikna edici bir şekilde ortaya koyup koymadıklarına bakar

---

[290] Sadece özel denetim isteme hakkı kullanılırken payların itibari değeri de dikkate alınmıştır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. **Özdamar,** Özel Denetim, s. 56-57.

(TTK m.439/2). Mesele ikna edici şekilde sunulmuşsa mahkeme, şirketi ve istem sahiplerini de dinledikten sonra özel denetçi atamasını yapar (TTK m.440).

3. Özel Denetim Raporu

Ataması yapılan özel denetçi veya gerekmesi halinde denetçiler, şirketin işlerini aksatmadan gerekli inceleme ve araştırmayı yapar. Yönetim kurulunun yanı sıra, şirketin diğer çalışanlarından da bilgi ve belge isteme imkânı özel denetçiye verilmiştir. Şirket ile bilgi ve belgelerin verilmesi konusunda anlaşmazlık yaşanması halinde sorunu mahkemenin çözmesi gerektiği ifade edilmiştir (TTK m.441/3).

Denetçinin çalışma süresi ile ilgili kanun koyucu kesin bir süre vermekten kaçınarak «*amaca yararlı bir süre*» ifadesini kullanmıştır (TTK m.441/1). Özel denetçi, çalışmasının sonucunda elde ettiği verileri içeren ve aynı zamanda şirketin sırlarını koruyan bir rapor hazırlar. Hazırlanan ve mahkemeye sunulan rapor şirkete tebliğ edilir (TTK m.442).

Yönetim kurulu, raporu ve buna ilişkin değerlendirmeleri, ilk genel kurula sunar (TTK m. 443/1). Her pay sahibi, genel kurul toplantısını izleyen bir yıllık süre içerisinde şirketten raporun ve yönetim kurulunun görüşünün bir suretinin verilmesini isteyebilir (TTK m.443/2).

Özel denetçinin, çalışması esnasında şirketin ticari işleyişine ilişkin bilgilere sahip olacağı aşikârdır. Bu nedenle bağımsız denetçi de olduğu gibi özel denetçi bakımından da kanun koyucu, özel olarak *sır saklama yükümlülüğünün* bulunduğunu hükme bağlamıştır (TTK m.441/5). Gerçekten özel denetçinin görevi sebebiyle elde ettiği özel bilgileri hem başka yerlerde hem de özel denetim raporunu hazırlarken dikkatli bir şekilde kullanması gereklidir. Aksi halde bundan dolayı şirkete verdiği zarar sebebiyle sorumlu olur.

Özel denetçinin sorumluluğuna ilişkin TTK m.438-444 arasında ayrı bir düzenleme bulunmamaktadır. Buna karşılık denetçinin sorumluluğu başlığı altında yapılan düzenlemede (TTK m.554) bağımsız denetçinin yanı sıra özel denetçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara yer verilmiştir[291].

---

[291] Özel denetçinin sorumluğunun özellikleri için bkz. **Özdamar,** Özel Denetim, s. 66-67.

ONUNCU BÖLÜM

§ 13- ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

LİTERATÜR

ANARAL, H.: *Anonim Ortaklıklarda Kayıtlı Sermaye Sistemi*, Ankara 1982; ARSLAN, İ.: *"Kayıtlı Sermayeli Anonim Şirketlerde Sermayenin Artırılması"*, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. 3 S. 1, 241-267; Bahtiyar, M.: *Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi*, İstanbul 2001; Çağlar, H.: *Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması, 2010*; Çağlar, H.: *Sınırlı Esnek Sermaye Sistemi (Kapitalband),, İsviçre Anonim Şirketler Hukukunda Yeni Bir Müessese*, GÜHFD, C. 17, S. 1-2, s. 353-370; Demir, K.: *Şarta Bağlı Sermaye Artırımında Tahvil Benzeri Borçlanma Araçları Kavramı*, BATİDER, C. XXXI, S. 3, s. 59-74; Gericke, D.: *Das Kapitalband*, GesKR Sondernummer 2008, s. 38-44; Günay Akdağ, N.: *6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirket Esas Sözleşmesinin ve Sözleşme Değişikliğinin Tescili ve Tescilin Etkileri*, Regesta 2011, S. 1, s. 39-58; Kägi, U: *Revision des Kapitalherabsetzungsrechts*, GesKR Sondernummer 2008, s. 1-30; Kaya, M. İ.: *Şartlı Sermaye Artırımı*, Ankara 2009; Keskin, H.: *"Sermaye Azaltımının Esnekleştirilmesi: 'Kayıtlı Sermaye Azaltımı' İçin Bir Öneri"*, BATİDER 2009, C. XXV, S. 2, s. 405-424; Moroğlu, E.: *Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı*, İstanbul 1972; Natterer, J.: *Materielle Kontrolle von Kapitalherabsetzungsbeschlüssen? Die Sachsenmilch-Rechtsprechung*, AG 2001; Öcal, Ş.: *"Anonim Şirketlerde Ana Sözleşme Değişiklikleri"*, İstanbul Barosu Dergisi, S. 81 Y.2007; Saraç, T.: *"Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artırımı"*, Ankara 2009; Müller; *Der Schutz der Aktiengesellschaft vor unzulässigen Kapitalentnahmen*, Bern 1997; Schluep, W. R.: *Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht*, Zürich 1955; Tanrıverdi, A.: *"Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Güncel Sorunlar"*, TBB Dergisi 2015, S. 116, s. 305-314; Türk, A.: *Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Sermaye İndirimi*, Batider, 1998 S. 4, s. 145-174; Ünal, M.: *Anonim Şirketlerde Esas Sermaye*

Azaltımı, Prof. Dr. Tuğrul Ansay'a Armağan, Ankara 2006, s. 601-643; Von Ah, J.: *Die Kapitalherabsetzung von Publikumsgesellschaften*, Zurich 2001; Yılmaz, S.S.: *"TTK'da Anonim Şirketlerde Sermaye Artırımına İlişkin Genel Hükümler ve Kayıtlı Sermaye Sisteminde Dış Kaynaklardan Sermaye Artırımı"*, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD) 2013, C. 8, S. 1, s. 187- 233.

I) GENEL DEĞİŞİKLİKLER

Anonim şirket esas sözleşmesi genel kurul tarafından Kanunda öngörülen şartlara uyulmak kaydıyla her zaman değiştirilebilir. Değişiklik, müktesep ve vazgeçilmez haklar dışında kalan bütün konulara ilişkin olabilir (TTK m.452).

Değişikliğin yapılabilmesi için Ticaret bakanlığının izni gereken hallerde öncelikle izin almak gerekir. Bunun yanında değişikliğin konusuna göre farklı ağırlaştırılmış nisaplara bağlı olarak karar almak gerekir (TTK m.421/2, 3; m.473/3). Ağırlaştırılmış özel bir nisap yoksa, esas sözleşme değişikliklerinde TTK m.421/1 hükmünde yer alan toplantı ve karar nisapları ile değişiklik kararı alınabilir.

Genel kurul kararlarının geçerli olabilmesi bazı hallerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına bağlı olabilir. Bu halde ise özel kurulun onay kararı da bulunmalıdır.

Anonim şirket genel kurulunda esas sözleşme değişikliği kararının alınmasının ardından yönetim kurulu bu kararı şirket merkezinin ve şubelerinin bulunduğu yerlerin ticaret siciline tescil ettirilir. İlanı gerekli hususlar ise ayrıca ilân edilir. Şirketin internet sitesi açması zorunlu ise değişiklik kararı şirketin internet sitesine de konulur.

Esas sözleşme değişikliğine ilişkin genel kurul kararları üçüncü kişilere karşı tescilden önce hüküm ifade etmez (TTK m.455). Buna karşılık iç ilişkide bazı değişiklikler derhal hüküm ve sonuç doğurmaya başlar.

II. ÖZEL DEĞİŞİKLİKLER

Anonim şirketlerde gerek sermayenin artırılması gerekse azaltılması sermaye miktarında değişiklik yapılmasını gerektirir. Sermaye miktarının değiştirilmesi ise kural olarak esas sözleşme değişikliği ile mümkündür. 6102 sayılı TTK ile artık kapalı tip anonim şirketlerde de

uygulanmaya başlanan kayıtlı sermaye sisteminde ve yeni Kanunla hukuk sistemimize ilk kez giren şartlı sermaye artımı yönteminde ise bir kez yönetim kuruluna yetki verdikten sonra verilen süre boyunca genel kurul kararına gerek kalmaksızın esas sermaye değişikliği mümkün olabilmektedir. Bu sebeplerle aşağıda önce esas sermayenin doğrudan genel kurul kararıyla artırılması, kayıtlı sermaye sisteminde sermayenin artırılması ve şartlı sermaye artımı yoluyla sermayenin artırılması ayrı başlıklar halinde ele alınacaktır.

A. SERMAYENİN ARTIRILMASI

1. Sermaye Artırımının Nedenleri

Anonim şirketlerde sermayenin artırılması çeşitli sebeplerle gündeme gelebilir. Bunların başında şirketin finansman ihtiyacının karşılanması gelir. Şirket, finansman ihtiyacını kredi almak yoluyla karşılayabilirse de, bazı hallerde borçlanma maliyetlerinin yüksekliği, borca karşılık teminat vermenin güçlüğü gibi sebeplerle daha az maliyetli ve riskli olan sermaye artırımı yolunu tercih edebilir. Bu durumda şirketin finansman ihtiyacı pay sahipleri veya yeni ortak olacak sermaye sahipleri tarafından karşılanır.

Anonim şirket, sermaye miktarını, yedek akçelerini, dağıtılabilir kârını ve diğer şirket aktiflerini sermayeye dönüştürerek artırabilir. Böylece şirket sermaye yapısı, güçleneceğinden yeni yatırımların ve yeni kaynak temininin önü açılmış olur.

Kanunda bazı hallerde sermaye artırımı yapılması zorunlu olarak öngörülmüştür. Şirketin son yıllık bilançosundan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, yönetim kurulu genel kurulu derhâl toplantıya çağırır. Genel kurul, bu toplantıda sermayenin üçte biri ile yetinmeye veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. Buradaki sermayenin tamamlanması ile kastedilen sermayenin azaltmayla eş zamanlı olarak artırılmasıdır. Bunun dışında ayrıca, birleşme veya tür değiştirmeye bağlı olarak sermayenin artırılması zorunluluğu ortaya çıkabilir.

Her ne kadar esas sermayenin artırılması da bir esas sözleşme değişikliği mahiyetindeyse de konunun önemi sebebiyle Kanunda özel düzenlemeler yapılması yoluna gidilmiştir. Zira sermayenin artırılması, ortakların ortaklık payını ve tüm haklarını etkileyecek türden bir esas

sözleşme değişikliğidir. Özellikle sermayenin arttırılan kısmının doğrudan dış kaynaklardan sağlanması halinde bu işlem mevcut ortakların haklarında olumsuz etki yapacağından bunlara rüçhan hakkı tanınması yoluna gidilmiştir. Sermaye artırımı anonim şirket açısından her zaman gerçekleştirilmesi gerekebilecek bir iştir. Dolayısıyla ortaklardan bir kısmının bu işleme karşı çıkmasının önemi yoktur. Önemli olan kanunda bu iş için öngörülen asgari koşullara uyulmasıdır.

2. Sermaye Artırımının Başlıca Türleri

Sermaye artırımı çeşitli biçimlerde gerçekleştirilmesi mümkün olup, aşağıda bunların en yaygın olanlarına işaret edilmiştir.

a) Esas Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı

Anonim şirket sermaye artırımını iç kaynaklardan yapabileceği gibi dış kaynaklardan da yapabilir. Örneğin sermaye artırımı yeni hisse senedi çıkarılmak suretiyle gerçekleştirilecekse sermayenin tamamının ödenmiş olması gerekir. Diğer hallerde ise bu zorunlu değildir.

Toplantı ve karar nisabı için TTK m.421/1 gereğince sermayenin yarısını temsil eden pay sahipleri, bu sağlanamazsa en geç bir ay içinde 1/3 pay sahiplerinin veya temsilcilerinin hazır bulunması ve toplantıya katılan pay sahiplerinin çoğunluğunun kararı ile sermaye artırımına yönelik esas sözleşme değişikliği gerçekleştirilir. Gerekli çoğunluk sağlanamazsa karar alınamaz.

Esas sermaye sisteminde, şirketin sermayesi iki değişik şekilde artırılabilir:

1- Yeni sermaye taahhüt etmek suretiyle (dış kaynaklardan sermaye artırımı),

2- Şirket varlıklarının ve yedek akçelerinin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle (iç kaynaklardan sermaye artırımı).

Ayrıca kayıtlı sermaye sistemini benimseyen anonim şirketlerde ve şartlı sermaye artımını benimseyen anonim şirketlerde yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yoluna gidilebilir.

b) Kayıtlı Sermaye Sisteminde Sermaye Artırımı

Kayıtlı sermaye sisteminde daha evvelde izah edildiği üzere, sermayeyi artırma yetkisi kayıtlı sermaye tavanına kadar yönetim kurulunun yetkisindedir. Esas sözleşmede belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırma yetkisi, yönetim kuruluna tanındığı takdirde, bu

kurul, sermaye artırımını, TTK'deki hükümler çerçevesinde ve esas sözleşmede öngörülen yetki sınırları içinde gerçekleştirebilir. Esas sözleşmedeki yetki en çok beş yıl için tanınabilir (TTK m.460/1).

Sermayenin artırılabilmesi için, yönetim kurulu, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin hükümlerinin, TTK 333'üncü madde uyarınca gerekli olması hâlinde, ilgili Bakanlıktan izni alınmış şekillerini, sermayenin artırılmasına ilişkin kararını, imtiyazlı paylara ve rüçhan haklarına ilişkin sınırlamaları, prime dair kayıtları ve bunun uygulanması hakkındaki kuralları, esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde ilân eder ve internet sitesinde yayımlar (TTK m.460/2). Yönetim kurulu, bu kararında; artırılan sermayenin tutarını, çıkarılacak yeni payların itibarî değerlerini, sayılarını, cinslerini, primli ve imtiyazlı olup olmadıklarını, rüçhan hakkının sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını, kullanılma şartları ile süresini belirtir. Ayrıca bu hususlarla kamuyu aydınlatma ilkesi uyarınca gerekli olan diğer konularda bilgi verir (TTK m.460/2).

Çıkarılacak yeni payların taahhüdü, ödenmesi gereken en az nakdî tutar, ayni sermaye konulması ve diğer konular hakkında TTK 459 uncu madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanır (TTK m.460/3).

Kayıtlı sermaye sisteminde, yönetim kuruluna başkaca bazı yetkilerin tanınması mümkündür. Buna göre yönetim kurulu esas sözleşmede hüküm bulunmak kaydıyla, imtiyazlı veya itibarî değerinin üzerinde pay çıkarılmasına ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasına karar verebilir (TTK m.460/5).

Sermaye artırımının gerçekleştirilmesinden sonra, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermaye maddesinin yeni şekli, yönetim kurulunca tescil ettirilir (TTK m. 460/6).

c. Şarta Bağlı Sermaye Artırımı

Şarta bağlı sermaye artırımı 6102 sayılı Kanunla Türk hukukuna kazandırılmış bir müessesedir.

3. Artırıma İlişkin Genel Esaslar

Şarta bağlı sermaye artırımı, yeni çıkarılacak tahvillerin ve benzeri borçlanma araçlarının alacaklılarının şirketin pay sahiplerine dönüşmelerini amaçlayan bir sermaye artırım sistemidir[292]. Bu yolun tercih

---

292 TTK m.463 gerekçesi.

edilmesi halinde sermaye, üçüncü kişilerin değiştirme ve alım hakları sahipleri tarafından kullanıldıkça kısım kısım artar[293].

Şarta bağlı sermaye artırımı için kanunda bazı şartlar öngörülmüştür. Bunların başında esas sözleşmede hüküm bulunması gerekliliği bulunmaktadır. Buna göre, esas sözleşmede, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, şirketten alacaklı olanlara veya çalışanlara, değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek hakkı sağlanmasına ilişkin hüküm bulunmalıdır (TTK m.463/1).

Genel kurulun esas sözleşmede yapacağı bu değişiklik ile şirket sermayesi artmış olmaz[294]. Sermaye, değiştirme veya alım hakkı kullanıldığı ve sermaye borcu takas veya ödeme yoluyla yerine getirildiği anda ve ölçüde kendiliğinden artar (TTK m.463/2). Dolayısıyla artırımın yapılması üçüncü kişilerin kararı «şartına» bağlı olarak gerçekleşmektir[295].

Şarta bağlı olarak sermaye artırımı yapılması, bazı yönlerden sınırlandırılmıştır. Buna göre, şartlı olarak artırılan sermayenin toplam itibarî değeri, sermayenin yarısını aşamayacaktır (TTK m. 464/1). Ayrıca yapılan ödeme, en az, nominal değere eşit olmalıdır (TTK m.464/2).

4. Esas Sözleşmedeki Dayanağın İçeriği

Şarta bağlı sermaye artırımı yapılabilmesi için yukarıda izah edildiği üzere, esas sözleşmede hüküm bulunması gerekir. Hatta şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme hükmünün tescilinden önce tanınmış bulunan değiştirme ve alım hakları batıldır.

Esas sözleşmenin ilgili hükmünün;

- Şarta bağlı sermaye artırımının itibarî değerini,
- Payların sayılarını, itibarî değerlerini, türlerini,
- Değiştirme veya alım hakkından yararlanabilecek grupları,
- Mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının kaldırılmış bulunduğunu ve bunun miktarını,
- Belli pay gruplarına tanınacak imtiyazları,
- Yeni nama yazılı payların devrine ilişkin sınırlamaları,

içermesi gerekir.

---

293 TTK m.463 gerekçesi.
294 TTK m.463 gerekçesi.
295 TTK m.463 gerekçesi.

Tahviller ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı değiştirme ve alım hakları içeren tahviller veya benzeri borçlanma araçları, öncelikle pay sahiplerine önerilmiyorsa, esas sözleşmede ayrıca; değiştirme veya alım haklarının kullanılma şartlarının ve ihraç bedelinin hesaplanmasına ilişkin esasların da açıklanması icap eder.

5. Pay Sahiplerinin Korunması

Kanunda pay sahiplerinin haklarının korunması bakımından bazı önlemler de alınmıştır. Buna göre, şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bunların önce, mevcut payları oranında, pay sahiplerine önerilmesi gerekir. Ancak bu şekilde düzenlenen önerilmeye muhatap olma hakkı, *haklı sebeplerin* varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir. Bununla birlikte, bu şekilde hiç kimse haklı görülmeyecek bir şekilde yararlandırılamaz veya kayba uğratılamaz.

6. Değiştirme veya Alım Hakkını Haiz Bulunan Kişilerin Korunması

Pay sahiplerinin yanısıra değiştirme ve alım hakkını haiz olan kişilerin menfaatlerinin korunması ihtiyacı da dikkate alınarak, kanun koyucu tarafından bazı düzenlemeler öngörülmüştür. İlk olarak kendilerine nama yazılı payları iktisap etme hakkı tanınmış bulunan değiştirme veya alım hakkını haiz alacaklılar veya çalışanların, bu tür payların devirlerinin sınırlandırılmış olduğu gerekçesiyle, söz konusu hakları kullanmaktan engellenemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ancak bu husus, esas sözleşmede ve izahnamede saklı tutulmuş olursa, devir sınırlandırmaların bu kişilere karşı ileri sürülmesi mümkündür.

Değiştirme fiyatı indirilmiş veya hak sahiplerine uygun bir denkleştirme sağlanmış ya da aynı şekilde, pay sahiplerinin hakları da kayba uğratılmış olmadıkça, değiştirme veya alım hakları, sermaye artırımı yapılması, yeni değiştirme veya alım hakları tanınması veya başka bir yolla kayba uğratılamaz.

7. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesi

Değiştirme ve alım hakları, esas sözleşmenin şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmüne gönderme yapan yazılı bir beyan ile kullanılır. Taahhüdün ifası, para yatırılması veya takas yoluyla bir mevduat veya katılım bankası aracılığıyla gerçekleştirilir (TTK m.468/1,2). Pay

sahipliği haklarının doğması, sermaye taahhüdünün ifasına bağlıdır (TTK m.468/3).

Şarta bağlı sermaye artırımında yönetim kurulunun esas sözleşmeyi, uygun duruma getirmesi gerekir. Buna göre yönetim kurulu, sermaye artırımı beyannamesinde, yeni çıkarılan payların sayısını, itibarî değerini, türlerini, belirli gruplara tanınan imtiyazları veya hesap döneminin sonundaki sermayenin durumunu belirler ve esas sözleşmeyi mevcut duruma uyarlar. Esas sözleşme değişikliğinin yine yönetim kurulu tarafından, hesap döneminin kapanmasından itibaren en geç üç ay içinde, ticaret siciline tescil ettirilmesi gerekir (TTK m.471). Değiştirme ve alım haklarının sona ermesi üzerine yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin hükmü esas sözleşmeden çıkarır. Hükmün sicilde de silinmesi gerekir (TTK m.472).

B. SERMAYENİN AZALTILMASI

1. Genel Olarak

Anonim şirketlerde sermayenin azaltılması çok çeşitli sebeplerle gündeme gelebilir. Bunların başında sermayenin gerçek ihtiyacın üzerinde olması, bilanço açığının kapatılmak istenmesi gibi temel sebepler yanında sermayenin itfası, pay sahiplerinin şirketten çıkması veya çıkarılması, şirketin kendi hisse senetlerini iktisap etmesi ve belirli bir süre elden çıkaramaması halinde bunları imha etmek zorunda olması ve imha ettiği paylar karşılığı olan sermayenin azaltılması gibi sebeplerle de sermayenin azaltılması gündeme gelebilir[296]. Ayrıca şirketin bölünmesi sebebiyle yeni kurulan şirkete aktarılan oranda sermayenin azaltılması veya vergi ödemeden pay sahiplerine kâr aktarımı yapabilmek için sermayenin pay sahiplerine iadesi amacıyla şirket esas sermayesinin azaltılması söz konusu olabilir.

Anonim şirketin sermayesinin azaltılması ile karıştırılan bazı işlemlere de rastlanabilir. Özellikle şirketin kendi paylarını iktisap etmesi, sermaye koyma borcunu süresinde yerine getirmeyen ortağın iskat edilmesi, yedek akçelerin çözülmesi, katılma intifa senedi karşılığı sermayenin esas sermayeye dönüştürülmesi, intifa senetlerinin ortadan kaldırılması veya sayısının azaltılması ve hisse senetlerinin iptal edilmesi işlemleri doğrudan sermayenin azaltılması olarak nitelendirilemez.

---

[296] **Çağlar, H.**: Anonim Şirketlerde Sermayenin Azaltılması, Ankara 2010, s. 18 vd.

Sermayenin azaltılması olağan sermaye azaltımı şeklinde ortaya çıkabileceği gibi, basitleştirilmiş sermaye azaltımı, sermayenin azaltılması ve eş zamanlı artırılması veya sınırlı esnek sermaye sisteminde azaltma şeklinde de karşımıza çıkabilir. Bunları aşağıda ayrıntılı olarak ele alacağız.

2. Sermayenin Azaltılması Türleri

a) Olağan Sermaye Azaltımı

Olağan sermaye azaltımından anonim şirketin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan sermayesinin Kanunda belirlenmiş olan şartlara bağlı olarak azaltılması anlaşılmalıdır. Bu tür sermaye azaltmanın belirleyici özelliği, anonim şirketin sermayeyi azaltarak ortaya çıkan miktarı ortaklara iade etmesidir. Ortaklara yapılacak sermaye iadesi doğrudan olabileceği gibi dolaylı olarak da gerçekleşebilir. Azaltılan sermayenin doğrudan iadesi ile anlatılmak istenen, sermaye azaltma suretiyle açığa çıkan miktarın ortaklara sermaye payları oranında paylaştırılmasıdır. Dolaylı olarak iadede ise sermaye azaltmak suretiyle açığa çıkan meblağın şirketin serbestçe tasarruf edebileceği özel bir yedek akçe olarak ayrılması[297] veya ortaklardan alınan borç haline dönüştürülmesi[298] söz konusudur. Azaltılan sermayenin doğrudan iade edilmeyerek ortaklar lehine borç olarak kaydedilmesi halinde, yapılan sermaye azaltımı şirketin yeniden finansmanı amacıyla sermaye azaltımı olarak da adlandırılmaktadır[299]. Zira bu halde şirketin bilançosunda bir azalma söz konusu olmamaktadır. Şirketin bilançosunda pasifler hanesinde yazılı bulunan sermaye kısmı azalmakta ise de yine pasifler kısmında yer alan borçlar artmakta ve sonuçta bilançonun pasif kısmında bir değişiklik söz konusu olmamaktadır.

Bu sermaye azaltma türü TTK m.473-475 hükümlerinde sermaye azaltmanın esas türü olarak kabul edilmiş ve diğerlerine göre çok daha ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Olağan sermaye azaltımı veya kurucu sermaye azaltımı olarak isimlendirilen bu türde her zaman mevcut ve ödenmiş sermayenin azaltıl-

---

297 **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, § 53, N 36; **Heinzmann**, N 18.

298 **Von Ah**, s. 9.

299 **Von Ah**, s. 9; **Müller**, s. 36.

ması söz konusu olmayabilir. Taahhüt edilmiş ancak kısmen ödenmemiş sermaye katılım payları için de azaltma yoluna başvurulabilir[300].

b) Basitleştirilmiş Sermaye Azaltımı

Basitleştirilmiş esas sermaye azaltımı veya *açıklayıcı esas sermaye azaltımı*[301] olarak adlandırılan ikinci sermaye azaltma türü istisnai olarak uygulama alanı bulmaktadır. Bu azaltma türünde amaç şirket bilançosunda yer alan açığı bertaraf etmektir[302]. Dolayısıyla sermayenin azaltılması aslında sadece muhasebe kayıtlarında yapılan bir değişiklik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu azaltma türünde olağan veya kurucu sermaye azaltma türündekinin tam aksine şirket ortaklarına herhangi bir sermaye iadesi söz konusu olmamaktadır. Yapılacak sermaye azaltma işlemi neticesinde ortaklar sermaye olarak şirkete getirdiklerinin bir kısmından da feragat etmiş olmaktadırlar. Amaç sermaye kaybı niteliğindeki bilanço açığının giderilmesi olduğundan,[303] anonim şirket alacaklılarının korunması için ayrı bir tedbire ihtiyaç duyulmaz. Adından da anlaşılacağı üzere basitleştirilmiş bir usul çerçevesinde şirketin sermayesini azaltması söz konusudur.

C) SERMAYENİN AZALTILMASI VE EŞZAMANLI OLARAK SERMAYENİN ARTIRILMASI

Yukarıda ele alınan iki önemli sermaye azaltma türünün yanında, sermayenin azaltılmasını müteakip yeniden sermayenin artırılması suretiyle uygulanan ve her iki işlemin aynı anda gerçekleştirildiği diğer tür ise sermayeyi eşzamanlı olarak artırmak amacıyla azaltmak olarak ifade edilebilir. Bu azaltma türü anonim şirketin ekonomik açıdan zor durumda olduğu hallerde gündeme gelir ve şirketin fiilen azalmış olan sermayesi önce hukuken de azaltılır ve aynı işlemle birlikte sermaye

---

300 **Von Ah**, s. 9; **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, § 53, N 15, 34; yazarlar ayrıca esas sermaye azaltma işleminin şirketin tasfiyesi aşamasında bile gerçekleştirilebileceğini belirtmişlerdir. Ancak bu halde özellikle alacaklıların korunmasına yönelik işlemlerin çok sağlıklı olarak yerine getirilemeyeceği de açıktır, § 53, N 19.

301 Türk ve İsviçre hukuklarında ise kanunda açıkça bu kavram kullanılmamışsa da doktrinde ve uygulamada bu kavram veya aynı anlama gelen başkaca kavramlar kullanılmaktadır, bkz. **Tekinalp/Poroy/Çamoğlu**, II, N 1419; **Heinzmann**, N 18, 349 vd.; **Von Ah**, s. 10; **Müller**, s. 33; **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, § 53, N 16, 258 vd.; **Kägi**, s. 3.

302 **Heinzmann**, N 18.

303 **Von Ah**, s. 10.

artışına gidilerek şirkete yeni kaynak sağlanmak suretiyle şirketin bozulan mali yapısı sağlıklı hale getirilmeye çalışılır[304].

Basitleştirilmiş sermaye azaltma türü ile karşılaştırıldığında, sermaye kaybı yaşayan şirketin hukuken de fiili duruma uygun hale getirilmesi amacı taşıyor olması sebebiyle benzerlik taşıdığı ancak bunu müteakip yeni sermaye getirilmesi suretiyle, şirketin bozulan yapısının gerçek anlamda sağlıklı hale getirilmesini sağlaması yönüyle farklı olduğu görülmektedir. Sermayenin tekrar artırılmak üzere azaltılması işleminin münferit olarak sicile tescili veya şirket esas sözleşmesinde tek başına bir değişiklik yapmayı zorunlu kılmaması sebebiyle aslında tipik bir sermaye azaltma türü olarak kabul edilemeyeceği görüşü de savunulmakla birlikte[305] bu işlemi sermaye azaltmanın bir özel türü olarak nitelendirenler de bulunmaktadır[306].

D) SINIRLI ESNEK SERMAYE SİSTEMİNDE SERMAYENİN AZALTILMASI

Kayıtlı sermaye sistemine benzer bu sistemde anonim şirket, genel kurulunda alacağı kararla yönetim kurulunu yetkilendirmek suretiyle ticaret sicilinde tescilli esas sermayesini belirli bir orana kadar artırabilmekte veya azaltabilmektedir. Kayıtlı sermaye sisteminden en önemli farkı esas sermayenin hem artırılabilmesi hem de azaltılabilmesidir. İsviçre hukukunda 21 Aralık 2007 tarihinde kamuoyuna açıklanan Borçlar Kanunu Değişikliği Tasarısında yer alan bu sistem doktrinden de büyük destek görmüştür[307]. İşte söz konusu bu sistemde esas sermayenin yönetim kurulu kararıyla ve olağan sermaye azaltımı usulündeki şartlara bağlı olmadan çok daha hızlı ve masrafsız olarak azaltılması söz konusu olmaktadır.

E) ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI YÖNTEMLERİ

a) Payların İtibarî Değerinin Düşürülmesi

Türk hukukunda anonim şirketlerde her payın itibari değerinin bulunması zorunludur[308]. Bu husus Türk hukukunda düzenlenirken payla-

---

304 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Çağlar**, Sermayenin Azaltılması, s. 122 vd.

305 **Heinzmann**, N 18.

306 **Böckli**, (2009), § 2, N 381.

307 **Böckli**, (2009), § 2, N 334; **Gericke**, s. 38 vd.; **Kägi**, s. 11 vd.

308 Başta ABD olmak üzere Belçika, Lüksemburg, Lichtenstein gibi bazı ülkelerde payın itibari değerinin bulunması zorunlu değildir. Almanya gibi bazı ülkelerde

rın itibari değerinin 1 Krş' tan daha az olamayacağı da açıkça ifade edilmiş ve bunun 1 Krş' un katları olarak artırılabileceği hükme bağlanmıştır (TTK m.476/1). Ayrıca anılan maddenin 3'üncü fıkrası gereğince zora giren şirketin finansal durumunun düzeltilmesi amacıyla payın itibari değerinin 1 Krş' a kadar indirilebileceği hükmüne yer verilmiştir.

Anonim şirket sermayesinin azaltılması sürecinde başvurulacak yöntemlerden bir tanesi payların itibari değerinin düşürülmesidir. Bu halde pay sahiplerinin pay sahipliğinden doğan hakları varlığını aynen sürdürmeye devam eder[309]. Zira payların değeri eşit bir şekilde azaltılmaktadır[310]. Ancak farklı kategorilerde yer alan paylar için yapılacak indirimin de orantılı olarak uygulanması gereklidir[311]. Anonim şirket paylarının itibari değerinin indirilmesi neticesinde payların yeni itibari değerinin ve pay sayısının anonim şirketin azaltmadan sonra ortaya çıkan sermaye miktarı ile uyumlu olması şarttır[312].

Payların itibari değerinin azaltılması yönteminde sadece payların itibari değeri azaltılabileceği gibi payların itibari değerinin yanı sıra payların sayısının azaltılması yoluna birlikte başvurulmasına da bir engel bulunmamaktadır[313].

b) Pay Sayısının Azaltılması

aa) Payların Birleştirilmesi

Anonim şirketin sermaye azaltmak istemesi halinde her zaman payların itibari değerinin düşürülmesi yoluna başvurması mümkün olmayabilir. Bu durum özellikle şirketin paylarının itibari değerinin Kanunda önceden belirlenen limitin altına indirilemeyecek olması halinde

---

ise anonim şirketlerin itibari değerli payları veya itibari değerden yoksun payları tercih etmesine müsaade edilmiştir.

309 **Natterer, J.:** *Materielle Kontrolle von Kapitalherabsetzungsbeschlüssen? Die Sachsenmilch-Rechtsprechung*, AG 2001, s. 632.

310 Payların itibari değeri eşit şekilde azaltılmıyorsa pay sahiplerinin buna itiraz hakları vardır, bkz. **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, § 53, N 68.

311 **Heinzmann**, N 536; **Schluep, W. R.:** *Die wohlerworbenen Rechte des Aktionärs und ihr Schutz nach schweizerischem Recht,* Zürich 1955, s. 207.

312 **Spindler/Stilz/Vatter** § 8, N 25.

313 BSK OR II- **Küng**, vor Art. 732-735 N 9; **Heinzmann**, N 393.

söz konusu olabilir[314]. Örneğin 100 bin TL sermayeye sahip olan ve her biri 1 Krş itibari değere sahip 10 milyon pay söz konusu olduğunda ve şirketin sermayesi yarı yarıya azaltılmak istendiğinde, payların itibari değerinin azaltılması yoluna gidilemeyecektir. Zira Kanun (TTK m.476/1) açıkça itibari değerin 1 Krş' tan az olamayacağını belirttiğinden, zorunlu olarak payların birleştirilmesi yoluna gidilmelidir. Bu halde en azından her iki payın bir pay olarak birleştirilmesi ve birleşen bu payların itibari değerinin 1 Krş' a indirilmesi suretiyle sermayenin de 50 bin TL'ye indirilmesi mümkün olabilir.

Anonim şirket ortakları sermaye azaltma sırasında payların itibari değerinde bir değişiklik yapmak yerine payların sayısını azaltmak isteyebilirler. Bu durumda tamamen ortakların hür iradesiyle payların birleştirilmesi suretiyle sayılarının azaltılması yöntemi tercih edilebilir.

Hem Kanundan doğan zorunluluk hem de ortakların bir tercihi olarak payların birleştirilmesi yöntemine başvurulduğunda, birleştirme oranı ile birlikte bazı pay sahiplerinin paylarının sayı itibariyle birleşmeye uygun olmaması halinde ortaya sorun çıkar. Özellikle birleştirme oranının katları dışında pay sahibi olanların paylarının birleştirilmesi halinde kesirli sayılar ortaya çıkabilir. Ancak payın bölünemez olması sebebiyle söz konusu kesirli payların şirketçe diğer ortaklara ait kesirli paylarla birleştirilerek bunlar adına satılması söz konusu olabilir. Kesirli payları satılan ortakların da, istekli olmaları halinde, bu birleştirilen kesirli payları satın almaları mümkündür. Ayrıca bir diğer olanak da henüz birleştirme öncesi ortakların kendi aralarında tam birleşmeyi sağlayacak miktarda pay alışverişi yapmalarıdır.

Payların birleştirilmesi yöntemine başvurulabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunmuyorsa önce esas sözleşmenin değiştirilmesi gerekir. Bunun yanında birleştirme işleminin geçerli olabilmesi, pay sahiplerinin hepsinin bu işleme muvafakat etmeleri şartına bağlıdır[315] (TTK m.477/2). Zira anonim şirket ortaklarının şirkete karşı tek yükümlülüğü taahhüt edilen sermaye payını ödemekten ibarettir. Pay

---

[314] İtibari değerli paylar söz konusu olduğunda, bunların değerinin Türk hukukunda 1 Krş, İsviçre hukukunda 1 Rappen ve Alman hukukunda ise 1 Euro' nun altında olamayacağı ilgili düzenlemelerde açıkça ifade edilmiştir.

[315] **Poroy, R./Tekinalp, Ü./Çamoğlu, E.**, Ortaklıklar Hukuku II, 13. Baskı, İstanbul 2017, N 1447a; **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, § 53, N 78.

sahiplerine bunun dışında doğrudan veya dolaylı olarak bir borç yüklenemez (TTK m.480/1). Oysa ortakların rızası olmaksızın yapılacak bir pay birleştirmesi işlemi ortakları, ellerinde birleştirmeye uygun sayıda payın bulunmaması halinde, paylarını veya paylarının bir kısmını kaybetme veya şirketçe birleştirilmek suretiyle oluşturulan paylardan satın almak için yeni sermaye getirme yükümlülüğü ile karşı karşıya bırakabilir.

Payların birleştirilmesi işleminin tamamlanabilmesi için bu payları temsil eden belgelerin şirkete teslim edilmesi gerekir. Aksi halde bu payları temsil eden belgelerin geçersiz kılınması ve yenilerinin çıkarılması gerekir.

bb) Payların İtfa Edilmesi

Anonim şirketin sermayesinin azaltılması amacıyla pay sayısında indirim işlemi, şirketin paylarından bir kısmının yok edilmesi suretiyle de gerçekleştirilebilir. Bu işlemin, payların itibari değerinin azaltılması suretiyle sermaye azaltılmasından temel farkı bu paylardan kaynaklı ortaklık haklarının da bir daha canlanmamak üzere sona erecek olmasıdır. Payların birleştirilmesi suretiyle yapılan sermaye azaltılmasından farkı ise birleşen pay sahiplerinin ortaklık sıfatı devam ederken yok edilen pay sahiplerinin bu sıfatının sona erecek olmasıdır.

Payların yok edilebilmesi için öncelikle bu payların şirket tarafından elde edilmesi gerekir. Bu paylar zaten şirketin kendi mülkiyetinde ise bunların itfa edilmesi diğer pay sahiplerinin durumunda bir değişikliğe yol açmayacaktır. İtfa edilecek payların şirketin kendi paylarını iktisap etmesi ile ilgili kurallar çerçevesinde elde edilmesi gerekir. Bunun yanında şirketin bu işlemleri yapabilmesi için konu ile ilgili olarak genel kurulda karar alınması gerekir. İtfa edilecek paylarla ilgili olarak alınacak karar, anonim şirketlerde geçerli eşit işlem ilkesi çerçevesinde gerçekleşmeyebilir. Bu sebeple itfa edilecek payların sahibinin buna rıza göstermesi şarttır. Bu mümkün olmuyorsa eşit işlem ilkesi çerçevesinde payların itfa edilmesi uygun olur. Ancak eşit işlem ilkesinin uygulanmasında sayısal olarak eşitlik değil oransal olarak eşitlik esas alınmalıdır[316]. Sayı olarak eşitlik uygulanacak olursa itfa edilecek pay sayısı itibariyle bazı pay sahiplerinin ortak sıfatını yitirmesi gündeme gelirken bazı pay sahiplerinin ise itfa sonrası şirketteki payları azalmış

[316] **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N 1448.

ancak konumları aynı kalmış[317] hatta bazı pay sahiplerinin şirketteki durumu daha da güçlenmiş olabilir.

c) Esas Sermayenin Azaltılması İşlemleri

Kıta Avrupası hukuk sisteminde geçerli olan sermayenin ve dolayısıyla şirket alacaklılarının korunması ilkesi gereğince özellikle kurucu veya olağan sermaye azaltımı söz konusu olduğunda çok katı kurallar gündeme gelmektedir. Bu çerçevede öncelikle şirketin durumunu ve alacaklıların haklarına halel gelmeyeceğini gösteren bir rapora ihtiyaç duyulmaktadır. Bu husus TTK m.473, 2 hükmünde açıkça düzenlenmiştir.

Anonim şirket sermayesinin sabit ve önceden esas sözleşmede belirlenmiş olması sebebiyle sermayenin azaltılması söz konusu olduğunda da esas sözleşmede belirtilmesi zorunlu olan sermaye miktarının değiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkar. Bunu gerçekleştirmek amacıyla yapılacak genel kurul toplantısı da aslında bir esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle buna ilişkin özel hükümlerle birlikte ele alınmalıdır. Sermaye azaltma kararının alınacağı genel kurulda TTK m.421/3 hükmünde yer alan sermayenin yüzde yetmişbeşinin olumlu oylarıyla karar alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Bazı hallerde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararına da ihtiyaç duyulabilir.

Sermayenin azaltılabilmesi için alacaklılara bir hafta arayla üç kez çağrı yapılması gerektiğine ilişkin TTK m.474 hükmü de Kanunun emredici hükümlerindendir. Çağrı üzerine başvuran alacaklıların alacakları ödenmeli veya teminat altına alınmalıdır.

Sonraki işlem ise sermaye azaltma kararının yerine getirilmesidir. İşlemin tamamlanması için sermaye azaltma işleminin ticaret siciline de tescil ettirilmesi ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde meydana gelen değişikliği de ilân ettirmek gerekir.

---

[317] **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu)**, II, N. 1448.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

§ 14- ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SAHİPLİĞİ

LİTERATÜR

Bilgeç, H., Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2017; *Aytuğar, B.*, Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara 2018; *Bozkurt*, T., Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) –Die Vinkulierung-, İstanbul 2016; *Tekinalp, Ü.*, Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları (Pay Defteri Hukuku ile), İstanbul 2012; *Ulusoy, E.*, Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları, Ankara 2016.

I. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY

Anonim şirketler TTK'nin 329'uncu maddesinde, "*sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirket*" şeklinde tanımlanmış; pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları *sermaye payları* ile şirkete karşı sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Diğer taraftan TTK'nin dördüncü kısmının altıncı bölümünde "*Pay ve Sermaye Koyma Borcu*"; yedinci bölümünde ise "*Menkul Kıymetler*" başlıkları altında pay ve pay senetleri düzenlenmiş; sekizinci bölümde "*Kâr, Kazanç ve Tasfiye Payı*" na ilişkin hükümler sevk edilmiştir. Kanunda anonim şirketlerde "*pay*" kavramına merkezi bir önem atfedilmiş olduğundan, anonim şirket yapısının iyi şekilde kavranması için payın anlam ve işlevinin doğru şekilde öğrenilmesi büyük değer kazanır.

A. PAY KAVRAMI

Anonim şirketlerde pay (*Aktie*), payın asgari itibari değere sahip olması gereği; oransallık ilkesinin uygulanmasında temel ölçüt olması ve kural olarak devir serbestliği kuralına tâbi olması yönlerinden adi şirketlerdeki ya da kollektif şirketlerdeki katılma payı (*Anteil*) kavramın-

dan ayrılır[318]. Limited şirketlerde esas sermaye payı ise, konulan sermayeyi gösteren ve bazı hesabi işlemlere temel oluşturan, diğer paylarla eşit olması zorunlu bulunmayan esas sermayenin bir parçasıdır. Anonim şirkette sermaye paylara bölünmüşken; limited şirkette esas sermaye payı, bazı hakların belirlenebilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla hesabi olarak bölünür. Payın hesaben bölünmesi, payın verdiği oy hakkının hesaplanmasına ve temettünün belirlenmesine, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin uygulanmasına hizmet eder[319].

Anonim şirketlerde pay, kuruluşta şirketin, sermaye artırımında artırım kararının tescil edilmesiyle doğan, pay sahipliği haklarının ve borçlarının kaynağı olan, sermayenin kural olarak serbestçe devredilebilen itibari değeri haiz bağımsız birimidir. Anonim şirketlerde pay, şahıs şirketlerinden farklı olarak, kural olarak diğer ortakların rızasına gerek olmaksızın serbestçe devredilebilir (TTK m.490 vd.). Pay, şirkete karşı bölünemez. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler (TTK m.477). Anonim şirketlerde pay, hamiline ya da nama yazılı pay senedine bağlanabileceği gibi (TTK m.484), kural olarak senede bağlanmaksızın (*çıplak pay*[320]) da hukuki işlemlere konu olabilir[321]. Payın senede bağlanması, paya bağlı hak ve borçlarda bir

---

318 **Pulaşlı**, Hasan, Şirketler Hukuku Genel Esaslar, B. 5, Ankara 2017, s. 567, N. 1, (Genel Esaslar).

319 Gerekçe TTK m. 583.

320 "*Çıplak pay*" kavramı kanuni bir terim olmayıp senede bağlanmamış payları nitelemek amacıyla Yargıtay kararlarında ve öğretide yer edinmiştir. Bu yönde bkz. **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 764; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 274. *"...Davalı anonim şirketin pay senetleri nama yazılıdır. Ancak, şirket payları henüz senede bağlanmadığı gibi, bunlara ilişkin ilmühaber dahi çıkartılmış olmayıp, çıplak pay durumundadır. Senede bağlanmamış payların devri ise, BK'nin 163 ve devamı maddelerinde yer alan alacağın temliki hükümlerine tabidir. Alacağın temliki, temliki tasarrufi bir işlem olduğu için, temlik ile çıplak pay devralana geçer. Bunun için alacağın temlikinde öngörüldüğü gibi, yazılı şekil şarttır. Tarafların da çıplak payın devrini, taahhüt sözleşmesindeki edimlerin yerine getirilmesini mülteakip devir ve ferağ beyannamesine bağlamış bulunmaları, yukarıda değinilen zorunlu hukuki gereksinimin doğal bir sonucudur."* (Y. 11. HD., T. 13.12.2001, E. 2001/765, K. 2001/1011 sayılı kararı için bkz. https://www.corpus.com.tr, (E.T. 01.02.2019)).

321 Hamiline yazılı paylarda yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır (TTK m.486/2). Nama yazılı paylarda ise azlık pay sahipleri talep ederse pay senedi

değişikliğe yol açmazken sadece payın tedavül yeteneğini kolaylaştırır ve bununla bağlı olarak paya ilişkin işlemlerin şekli yönünden bazı farklılıklara neden olur (TTK m.489-490). Pay senetleri bu özelliği ile pay sahipliği haklarının kazanılması ve borçlarının doğumu bakımından kurucu değil; *açıklayıcı* bir niteliği haizdir[322].

B. PAYIN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI

Anonim şirketlerde payın, esas sermayenin bir parçası olması, pay sahipliği mevkiini göstermesi ve pay sahipliği haklarını ve borçlarını içeren belge olması açılarından üç farklı anlam ihtiva ettiği kabul edilmektedir.

Esas sermayenin bir parçası olarak pay, şirket sermayesinin birim değere bölünmüş her bir parçasıdır. 100.000 TL değerdeki bir sermaye 10.000 adet eşit parçaya bölünmüşse her 10 TL bir payı oluşturacaktır. Bu durumda sermaye, eşit ve 10 TL itibari (*nominal*) değerdeki (*Nominalbetrag/Nennwert*) paylara bölünmüş olmakta; payların itibari değeri ile sayısının çarpımı esas sermaye tutarını vermektedir. Anonim şirketlerde paylar zaman içerisinde itibari değerinin üstünde piyasa değerine ulaşabileceğinden, itibari değer ile payın gerçek ya da piyasa değeri her zaman aynı olmayabilir. Bununla birlikte bir anonim şirkette farklı itibari değerde paylar çıkarılmasına hukuken bir engel olmadığı[323] ve hatta bunun gerekli olabileceği ifade edilmelidir[324].

Pay sahipliği mevkii olarak pay, anonim şirketin sermaye şirketi olmasının bir sonucu olarak, şirkete ortak olan kişilerin özelliklerinden bağımsız bir mevkii olarak pay sahipliğinin ve bundan doğan hak ve borçların, paya bağlı olmasıdır. Diğer bir anlatımla pay sahibinin, sahip olduğu pay adedi kadar pay sahipliğinden doğan hakları iktisap etmesi

---

bastırılıp dağıtılır (TTK m.486/3). 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu m.12/3 hükmünde, "*Sermaye piyasası araçlarının satış esnasında alıcıya teslimi şarttır*" denilerek halka açık şirketlerde senet bastırma ve satış esnasında alıcıya teslim etme zorunluluğu öngörülmüştür.

322 **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 570, N. 8. Bu kabulden hareketle senedin ziyaı ile değil itfası ile payın yok olacağı yönünde bkz. **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, I**, N. 765.

323 Buna karşılık oy hakkında imtiyaz tanınması için paylar eşit itibari değerde olmalıdır (TTK m.479/1).

324 Bkz. **Türk**, H. S., "*Anonim Ortaklık Pay Senetlerinde İtibari Değer Farkları*", Prof. Dr. Mahmut Koloğlu'ya 70'inci Yaş Armağanı, Ankara 1975, s. 566 vd.; **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, I**, N. 758.

ve borçları üstlenmesidir. Pay sahipliğinden doğan hak ve borçlar "*pay*"a bağlı olduğu içindir ki pay sahibi değişse de sermaye değiştirilmediği müddetçe pay sahipliği mevkii sabit kalır; ilgili payı devralan, pay sahipliği mevkiini kazanır. Paylara bölünmüş olan pay sahipliğinden doğan hak ve borçlardır[325].

Pay sahipliği haklarını ve borçlarını içeren belge olması açısından pay, şirkete sermaye taahhüt ederek ortak olan pay sahiplerinin haklarının ve borçlarının kaynağı olan pay için pay sahipliğini gösteren bir belge (*hisse senedi*) çıkarılmasıdır. Payın senede bağlanması, hamiline yazılı paylar hariç zorunlu olmadığı gibi, senetlerin çıkarılması, pay sahipliği haklarının kazanılması bakımından kurucu nitelik de arz etmezler[326]. Buna karşılık anonim şirketlerde pay senetleri en erken, şirketin kuruluşunda şirketin tescilinden; sermaye artırımında ise artırım kararının tescilinden sonra çıkarılabilir (TTK m.486/1). Tescilden önce pay senedi çıkaran kimse, bundan doğan zararlardan sorumludur (TTK m.486/4).

C. PAY TÜRLERİ

Paylar, bahşettikleri haklar, pay karşılığında şirkete taahhüt edilen sermaye türü veya payın itibari değeri açılardan tasnif edilebilir.

1. Nakit Karşılığı Pay-Ayın Karşılığı Pay

Nakit karşılığı pay ya da nakdi pay, şirkete nakit taahhüt edilerek ve nakit ödeme yapılarak iktisap edilen paydır. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir (TTK m.344/1). Halka arz edilecek paylar, sadece nakdi pay olabilir[327] (TTK m.346/1; SPK m.12/1).

Ayın karşılığı pay, şirkete sermaye olarak getirilebilecek nakit dışı sermaye karşılığında iktisap edilen paydır. Anonim şirketlere nakit sermayenin yanı sıra, üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz ve tedbir

---

325 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 759.

326 *"Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı esastır"* (SPK m.13/1).

327 Bu zorunluluk, Türkiye'de kurulacak bankalar için 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.7/b hükmünde; yatırım ortaklıkları için ise SPK m.49/1,c bendinde öngörülmüştür.

bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak getirilebilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar ise sermaye olamaz (TTK m.342). Konulan ayni sermayeye, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce değer biçilir (TTK m.343/1).

2. Oy Hakkı Olan Pay-Oy Hakkından Yoksun Pay

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 14/A maddesinde anonim ortaklıkların, esas sözleşmelerinde hüküm bulunmak şartıyla, kâr payı imtiyazı sağlayarak, oy hakkından yoksun paylar ihraç edebileceği kabul edilmişti. Ancak bu düzenleme, mer'i 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa alınmamıştır. Türk Ticaret Kanununda da her pay sahibinin sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haiz olacağı öngörüldüğünden, oy hakkı her bir paya emredici şekilde bağlanmıştır. Diğer bir anlatımla Türk Ticaret Kanunu sisteminde oy hakkı bulunmayan ya da oydan yoksun pay kabul edilmemiştir. Her ne kadar şirketlerin yapısal değişikliklerinde (TTK m.140/3; m.146/1,c; m.167/1,d; m.183/1) *oydan yoksun paylar* karşılığında verilecek hak ve paylardan bahsedilse de Kanunun 140'ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının gerekçesinde, Türk hukukunda oydan yoksun payın, evvelki SerPK m. 14/A dolayısıyla söz konusu olabileceği belirtildiğinden, hükümlerde geçen oydan yoksun pay ile mülga SerPK'ye dayanılarak çıkarılan payların kastedildiği kabul edilmelidir.

Oydan yoksun pay, şirketlere sermaye girdisi sağlarken oy dağılımını ve böylece şirkette kurulan hâkimiyet ilişkisini bozmamak amacıyla genellikle malvarlığı haklarında tanınacak imtiyazlarla birlikte ihraç edilen ve ayrı bir pay grubu oluşturan paylardır[328]. Oydan yoksun paylar, oy hakkı ve buna bağlı hakları, payın ilk ihraç edildiği andan itibaren bahşetmez. Oydan yoksunluk durumu paya bağlıdır ve süreklilik arz eder. Bu yönüyle oy hakkının donduğu hallerden (TTK m.201,389), belirli konularda alınacak kararlarda oy hakkının kullanılamadığı hallerden (TTK m.436/1,2) ve borsaya kote edilmiş nama

---

328 **Tekinalp**, Ü., "*Katılma İntifa Senetleri (Partizipationsschein)*", BATİDER, C. VI, 1971, s. 298-299; **Nomer**, N. F., Anonim Ortaklıkta Oydan Yoksun Paylar, İstanbul 1994, s. 7.

yazılı payları devralan kişinin şirket tarafından tanınmamış olması halinde ortaya çıkan oy hakkından yoksunluk durumlarından (TTK m.497/3) ayrılır. Nihayet birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısının esas sözleşmeyle sınırlandırılması durumunda (TTK m.434/2) öngörülen sınırı aşan pay sahiplerinin oy haklarını kullanamayacak olmaları da oydan yoksun paylardan söz etmeye imkân vermemektedir. Zira öngörülen sınırı aşmayan veya şirkette daha önce herhangi bir paya sahip olmayan kişiye söz konusu oy hakkı kullanılamayan bu payların devri, oy hakkının tamamen veya kısmen canlanmasına neden olacaktır.

3. Adi Pay-İmtiyazlı Pay

İmtiyaz hakkı, diğer paylara tanınmayan veya diğer paylara (*adi paylara*) kıyasla kapsam itibarıyla daha iyi şekilde tanınan ya da zamansal olarak öncelikle yararlanma hakkı veren ve bu suretle farklı bir pay grubu oluşturan pay sahipliği hakkıdır[329]. Anonim şirketlerde haklardan yararlanmada, sermayeye katılım ölçüsü (*orantılılık ilkesi*) esas alınmakta; imtiyaz hakkı ise, sermayeye katılımın ölçüsünü aşacak düzeyde hak sağlamak suretiyle bu ilkeden ayrılmaktadır.

İmtiyaz hakkı tanınan payların karşısında yer alan, imtiyazlı payların bahşettiği haklara kıyasla herhangi bir ayrıcalık ya da üstünlük özelliği içermeyen paylar ise adi pay (*Stammaktien*) olarak isimlendirilir. İmtiyaz hakkı, paya kanunen bahşedilmiş asgari pay sahipliği haklarına kıyasla değil; şirketin daha önce ihraç etmiş olduğu payların bahşettiği haklara kıyasla daha fazla veya öncelikle hak bahşedilmesi durumunda karşımıza çıkar. Örneğin, bir şirkette sadece dört oy hakkı veren paylar mevcutsa bu paylar, sadece kanunen asgari bir oy hakkının (TTK m.434/2) üstünde oy verdiği için imtiyazlı kabul edilmemelidir[330]. Bu paylar, ancak şirketin bir, iki veya üç oy hakkı veren yeni payları ihraç etmesi durumunda imtiyazlı pay niteliğine sahip olacaktır[331].

---

329 **Kägi**, A., Die Prioritätsaktien nach schweizerischem und deutschem Recht, Zürich 1918, s. 4.

330 İmtiyazların belirlenmesinde karşılaştırmaya konu payların Kanunda asgari pay sahipliği hakları ile donatılmış paylar olduğu yönündeki görüş için bkz. **Tekinalp**, Sermaye Ortaklıkları 2013, s. 75-76, N. 9-09.

331 Kanunda öngörülen asgari bir oy hakkından fazla oy hakkı veren bu payların "*geciktirici şarta bağlı imtiyazlı hak*" bahşettiği ve şart gerçekleşmedikçe askı

İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır (TTK m.478/2). İmtiyaz hakkı, şirket sözleşmesinde konu ve kapsamı açıkça belirtilmek suretiyle tanınmalı; payın bahşettiği pay sahipliği haklarına ilişkin olmalıdır. Bu bağlamda paya bağlı olmayan (*kişiye tanınan*) üstün haklar (*genel kurul başkanının üstün oy hakkı gibi*), payların itibari değer farklılıkları ya da pay için yapılan ödemelerdeki farklılıklar imtiyaz hakkı niteliği göstermez[332].

İmtiyaz, paya tanınan üstün bir haktır[333]. Bununla birlikte imtiyazlı payları düzenleyen TTK m.478/3 hükmünde, TTK m.360 hükmü saklı tutulmuştur[334]. TTK m.360 hükmünde, *özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine* ve *azlığa* yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabileceği ve kendisine bu hak tanınan payların imtiyazlı sayılacağı kabul edilmiştir. Böylelikle imtiyazın, esas sözleşme ile farklı ölçütlere göre oluşturulan pay sahiplerinden oluşan gruplara da tanınabileceği (*grup imtiyazı*) kabul edilmiştir[335].

İmtiyaz hakkı tanınacak pay sahipliği hakları sınırlı sayıda belirtilmemiştir. Kanunda açıkça belirtilmeyen bir hak, örneğin şirkete ait tesis veya plajlardan yararlanma hakkının belirli bir pay grubuna açıkça esas sözleşme ile tanınması da imtiyaz hakkı kapsamında ele alınır. Bununla birlikte imtiyaz hakkının, hakkın mahiyeti bakımından *i) malvarlığı*

---

durumunun devam ettiği; bu süre içinde imtiyazdan söz edilemeyeceği yönünde bkz. **Pulaşlı**, Şerh C. 2, s. 1750, N. 141.

332 **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 578, N. 33.

333 Gerekçe TTK m.478/2.

334 ***Kendigelen,*** TTK m.360 hükmünde düzenlenen yönetim kurulunda temsil edilme hakkının, ön tasarıda açıkça imtiyaz olarak düzenlenmemesi nedeniyle imtiyazlı paylara ilişkin maddeye, m.360 hükmünü saklı tutan bir fıkra eklendiğini; ancak kabul edilen Kanun metninde bu hak, açıkça imtiyaz olarak düzenlenmesine rağmen, m.478/3 hükmünün madde metninden çıkarılmadığını ve zaman içerisinde yapılan tercihe paralel olarak saklı tutulan bu fıkranın, imtiyazın paya tanınması ilkesinin bir istisnasını vurgulamak amacıyla korunduğu şeklinde anlaşılması gerektiğini ileri sürmüştür, (bkz. İlk Tespitler, s. 383).

335 Hâkim görüş, kural olarak imtiyazın paya tanındığını; ancak TTK m.360 hükmüyle söz konusu kurala bir istisna getirildiğini ve imtiyazın pay sahipliğine de bağlanabildiğini savunmuştur. Bu yönde bkz. **Kendigelen,** Değerlendirme, s. 170; **Kırca/Şehirali Çelik./Manavgat,** , Ankara 2013, s. 427.

haklarında veya *ii) yönetime katılma haklarında* olmak üzere esas itibariyle iki temel konuda tanınabileceği söylenebilir. Malvarlığı hakkında tanınacak imtiyaz hakkı, özellikle kâr payında[336], tasfiye payında ve rüçhan hakkında tanınabilir (TTK m.507/2, m.543/1). Yönetime katılma hakkında imtiyaz kapsamında ise, oy hakkında (TTK m.479) ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında tanınan imtiyazlar zikredilebilir (TTK m.360). Kanun koyucu, önemine ve tercih edilme eğilimine binaen oy hakkında ve yönetim kurulunda temsil edilme hakkında imtiyaz konularını ayrıca düzenlemiştir.

Oy hakkında imtiyaz, imtiyazın bir türü olarak belirli paylara, sermayeye katılma ölçüsünü aşarak, diğer paylara (*adi paylara*) kıyasla oy hakkının kapsam itibariyle daha fazla sayıda ya da daha güçlü şekilde tanınmasıdır. Anonim şirketlerde oyda imtiyaz, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir (TTK m.479/1; karş. TTK m.618/2). Bu hüküm yasaklamamış olmakla birlikte, bir anonim şirkette farklı itibari değerde payların bulunması halinde oyda imtiyazlı pay yaratılmasını zorlaştırmıştır[337]. Bununla birlikte farklı itibari değerdeki paylara eşit oy hakkı sağlayarak imtiyaz tanınması tamamen yasaklanmıştır.

Oy hakkında imtiyazın kötüye kullanılması tehlikesini bertaraf etmek amacıyla kanun koyucu, imtiyazın bu türüne birtakım sınırlandırmalar getirmiştir[338]. Bunlardan ilki, bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabileceğine ilişkin nispî sınırlama hükmüdür. Bununla birlikte, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi,

---

336 Kâr payında tanınacak imtiyaz, itibari değerin ya da dağıtılabilir kazancın sabit bir tutarı yahut belirli bir yüzdesine ilişkin olabilir. Kâr payında imtiyaz, kârdan daha fazla pay almak veya sözleşmede öngörülen meblağın ödenememesi durumunda gelecek yılda kümülatif (*birikimli*) olarak imtiyazlı pay sahiplerine ödeme yapılması şeklinde öngörülebilir. Bu yönde bkz. **Jung**, §8, s. 397. Halka açık olmayan anonim şirketlerde kâr payından öncelikle yararlanmak şeklinde imtiyaz tanınabileceği yönünde bkz. **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 583, N. 47.

337 Gerekçe TTK m.479/2. Farklı itibari değerdeki paylara farklı oy hakkı tanıyarak oyda imtiyazın tesis edilemeyeceği yönündeki görüş için bkz. **Bilgeç**, H., Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Ankara 2017, s. 138; **Aytuğar**, B., Anonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyaz, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara 2018, s. 226, dpn. 914.

338 Bu hususta ayrıca bkz. **Aytuğar**, s. 244 vd.

kurumlaşma projesini veya haklı sebebi inceleyerek, sınırlamadan istisna edilme kararı verebilir (TTK m.479/2). Diğer bir sınırlandırma hükmü, oy hakkında imtiyazın belirli konularda alınacak genel kurul kararlarında uygulanamayacağına ilişkin mutlak sınırlama düzenlemesidir. Buna göre oy hakkında imtiyaz, esas sözleşme değişikliği kararları ile ibra[339] ve sorumluluk davası açılması[340] hakkında alınacak kararlarda kullanılamaz (TTK m.479/3).

Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir ve kendisine yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan bu paylar imtiyazlı sayılır (TTK m.360). Yönetim kurulu üyeleri, belirlenmiş bir grup içerisinden seçilebileceği gibi, bu gruba aday önerme hakkının (*Vorschlagsrecht*) tanınması da mümkündür. Bununla birlikte esas sözleşme ile doğrudan yönetim kuruluna üye gönderme hakkının tanınması, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerine müdahale anlamı taşıyacağından, önerilen adayın ve/veya gruba mensup adayın mutlaka genel kurul kararı ile seçilmesi gereklidir[341]. Kanun koyucu, haklı bir sebep bulunmadığı takdirde genel kurulun bu kişileri seçme konusunda takdir hakkına sahip olmadığını hükme bağlamakla pay ve pay sahibi grupları ile azınlık pay sahiplerine, bağlayıcı öneride bulunma hakkı bahşetmiştir. Bu şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu üye sayısının yarısını aşamaz.

Genel kurulun esas sözleşme değişikliği ve yönetim kuruluna sermaye artırım yetkisi verilmesi kararları ile yönetim kurulunun sermaye

---

339 Oyda imtiyaz yasağının, örtülü ibrada geçerli olmayacağına yönelik bkz. **Tekinalp**, Sermaye Ortaklıkları, s.86, N. 9-09i; **Çağlar**, İbra, s. 45.

340 İbra etmeme kararının sorumluluk davası açılması için yeterli olduğu; ayrıca genel kurulda sorumluluk davası açılması kararının alınmasının gerekli olmadığı; evvelki Kanunun 341. maddesi hükmüne 6102 sayılı Kanunda yer vermeyen kanun koyucunun bilinçli bir tercihte bulunduğu yönünde bkz. **Çağlar**, İbra, s.72-73. TTK m.479/3,(c) bendinde geçen genel kurulun alacağı sorumluluk davası açılması kararının, dava şartı olmadığı yönünde bkz. **Akdağ Güney**, N.; Anonim Şirkette Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul 2016, s. 332.

341 **Aytuğar, B.**, "*Oy Hakkında İmtiyazlı Pay Sahibi Grubunun Yönetim Kurulunda Temsil Edilme Hakkı*", Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019, C. XXIII, S. 1, s. 93 vd.

artırım kararlarının[342], imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte ise, anılan pay sahiplerinin yapacakları özel bir toplantıda alacakları bir kararla onanmadıkça uygulanamaz olduğu kabul edilmiştir (TTK m.454/1). Özel kurul imtiyazlı payları temsil eden sermayenin yüzde altmışının çoğunluğuyla toplanır ve toplantıda temsil edilen payların çoğunluğuyla karar alır (TTK m.454/3). Bununla birlikte genel kurulda, imtiyazlı payların sahip veya temsilcileri, esas sözleşmenin değiştirilmesine, özel kurulda aranan toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy vermişlerse ayrıca özel toplantı yapılmaz (TTK m.454/4). Çağrıya rağmen, süresi içinde özel kurul toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır (TTK m.454/5).

4. Bedelli Pay-Bedelsiz (Gratis) Pay

İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında artırım kararının tescili ile pay sahiplerinin, mevcut paylarının sermayeye oranına göre bedelsiz payları kendiliğinden iktisap edeceği öngörülmüştür (TTK m.462/3). Bu payların karşılıkları özvarlıktan karşılandığı için, bu paylar sahiplerine bilâ-bedel verilirler[343]. Bedelsiz paylar üzerindeki hak kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz; bu haktan vazgeçilemez.

Buna karşılık dış kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında yeni payları iktisap edecek kişiler, payların karşılığını şirkete getirmek zorunda olduklarından bu paylar, bedelli pay olarak anılmaktadır[344] (TTK m.456/1).

5. İtibari Değeri Olan Pay-İtibari Değeri Olmayan Pay

İtibari değer, pay sahipliği haklarının kullanılmasında esas alınan temel ölçüdür. Zira pay sahipleri sermayeye, paylarının itibari değerleri nispetinde iştirak ederler; net dönem kârına ve tasfiye sonucunda kalan

---

[342] Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna imtiyazlı pay ihraç etme yetkisi esas sözleşme ile verilebilir (TTK m.460/4; SerPK m.18/5). Halka açık şirketlerde kayıtlı sermaye tavanı dâhilindeki sermaye artırımlarında, bu karar imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikte olsa da özel kurul kararı gerekli görülmemişken (SPK m.18/4); halka açık olmayan anonim şirketlerde kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştirilecek sermaye artırımları, imtiyazlı pay sahiplerinin hakları ihlal edilecek nitelikte ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurul onayı aranacaktır (TTK m.454/1). Düzenlemenin eleştirisi hakkında bkz. **Kendigelen,** İlk Tespitler, s. 353; **Moroğlu,** Değerlendirme, s. 273.

[343] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 808.

[344] **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 280.

tutara payları oranında katılma hakkını haizdirler (TTK m.507/1); oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanırlar (TTK m.434/1). Kanun koyucu, itibari değerin taşıdığı önemi göz önüne alarak payın itibari değerinin en az bir kuruş olması gerektiğini; ancak birer kuruş ve katları olarak yükseltilebileceğini ve buna aykırı çıkarılan payların geçersiz olacağını hükme bağlamıştır. Geçersiz olan söz konusu payları ihraç edenler, zarar verdikleri kişilere karşı müteselsilen sorumlu tutulmuşlardır. Zora giren şirketin finansal durumunun iyileştirilmesi amacıyla da olsa payın itibari değerinin en az bir kuruşa kadar indirilebileceği kabul edilmiştir. Görüldüğü üzere kanun koyucu, itibari değerden yoksun pay ihracına kural olarak izin vermemiştir[345].

Bununla birlikte halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun, payların piyasa fiyatı veya defter değerinin nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine izin verebileceği kabul edildiği gibi (SerPK m.12/2), kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş halka açık anonim şirketlerde esas sözleşme ile yetkili kılınması durumunda yönetim kurulunun, nominal değerinin altında pay çıkarabilmesine de müsaade edilmiştir (SerPK m.18/5). Bu istisnai yetkiler dışında, itibari değerinden aşağı bedelle pay çıkarılamaz. Payların itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılabilmeleri için esas sözleşmede hüküm veya genel kurul kararı bulunmalıdır (TTK m.347/1). İtibari değerin üzerindeki fark değer "*agio*" veya "*prim*" adını alır ve bu paylara "*agiolu/primli pay*" denilir. Agio, kanuni yedek akçeye eklenir (TTK m.519/2,a).

II. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY SAHİPLİĞİ

Pay sahibi, çıplak payın veya pay senedinin maliki olan gerçek veya tüzel kişidir. Bir pay sahibi, birden çok payın sahibi olabileceği gibi, bir paya birden çok kişinin sahip olması da mümkündür. Ancak ikinci durumda, pay sahipleri şirkete karşı haklarını ancak ortak bir temsilci aracılığıyla kullanabilirler (TTK m.477/1).

---

345 "*Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının itibari değeri bulunmaz*" (SerPK m.50/2). Mehaz Alman Hukukunda "*Stückaktien*" olarak belirtilen ve Türkçe'ye "*parça pay*" olarak çevrilebilecek olan payların itibari değeri yoktur. Bu paylar şirket sermayesine eşit kapsamda katılırlar ve münferiden paya düşen sermaye miktarı 1 Euro'dan az olamaz (§8, Abs.3 AktG).

Bir paya sahip olmak için kanun koyucu kural olarak TMK'de düzenlenen ehliyet kuralları haricinde özel bir ehliyet şartı aramamıştır (İstisna için bkz. TTK m.940). Bununla birlikte pay sahibinin gerçek veya tüzel kişi olması gerekli olup adi ortaklığın veya miras ortaklığının tüzel kişiliği bulunmadığından, bunların pay sahipliğinde TTK m.477 hükmü gereğince bir payın birden fazla malikinin bulunmasına ilişkin düzenleme uygulama alanı bulur[346].

A. PAY SAHİPLİĞİNİN KAZANILMASI

Pay sahipliği aslen veya devren kazanılabilir. Aslen kazanma; bir kişinin, önceden başkasına ait olmayan bir şey üzerinde hukuki bir olay veya kişinin iradi fiili ile hak elde etmesidir. Devren kazanmada ise, başkasına ait olan bir şey üzerindeki hak, hukuki bir olay veya hukuki işlem yoluyla bir başkasına intikal eder.

Pay sahipliğinin aslen kazanılması; kuruluşta veya sermaye artırımında sermaye taahhüdünde bulunulması; birleşme ve tür değiştirme sonucu çıkarılan payların kazanılması yolları ile gerçekleşir. Devren kazanma ise, çıplak payın veya pay senedinin satış sözleşmesi veya bağışlama gibi bir hukuki işlemle veya miras, cebri icra, eşler arasındaki mal rejimleri gereğince intikal etmesi ile gerçekleşir.

Anonim şirketlerde pay, senede bağlanmış olsun olmasın, şahıs şirketlerinden farklı şekilde, kural olarak diğer ortakların rızasına gerek olmaksızın serbestçe devredilebilse de bu kuralın da birtakım istisnaları bulunmaktadır.

1. Kanundan Doğan Sınırlandırmalar

Payın serbestçe devredilebilmesine ilişkin ilkenin kanuni istisnalarından ilki, şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin sınırlama hükmüdür. Buna göre bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. Bedellerinin tümü ödenmiş bulunan payların, sermayenin %10'unu aşmayacak şekilde iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, finansal durumu bu işlemi gerçekleştirmek için uygun olan şirketin genel kurulunun, yönetim kurulunu en çok beş yıl için yetkilendirmesi şarttır (TTK m.379). Bu düzenlemenin amacı, şirket sermaye-

[346] **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 812.

sinin iade edilmemesi ve böylece hem alacaklıların hem pay sahiplerinin menfaatlerini hem de anonim şirketin kurumsal yapısını korumaktır[347]. Kanun koyucu TTK m.380 hükmünde kanuna karşı hile kurumunu düzenleyerek şirketin kendi paylarını kanunu dolanmak suretiyle iktisap veya rehin olarak kabul etmesine engel olmak istemiştir[348].

Bu sınırlandırma hali ile bağlantılı şekilde anonim şirketin kendi paylarını taahhüt edemeyeceği düzenlenmiştir (TTK m.388/1). Bu esasa aykırı hareket edilmesi durumunda, söz konusu payları, kuruluşta kurucular, sermaye artırımlarında yönetim kurulu üyeleri taahhüt etmiş sayılır ve bunlar pay bedellerinden sorumlu olurlar. Diğer bir ifadeyle kendi payını taahhüt yasağının ihlal edilmesi halinde tasarruf işlemlerinin geçerli olacağı kabul edilmiştir[349].

Pay taahhüdünün, şirketin tescilinden önce devri, şirkete karşı geçersizdir (TTK m.352/1). Şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce çıkarılan paylar (*pay senetleri*) geçersizdir[350] (TTK m.486/1).

Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe nama yazılı paylar herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmadan devredilebilirler. Buna karşılık bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, kural olarak ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Şirket, sadece, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir (TTK m.491).

2. İradî Sınırlandırmalar

Esas sözleşme ile nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla devredilebileceği (*bağlam düzenlemesi*) öngörülebilir (TTK m.492/1). Pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hâllerde, esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan edimleri *(ikincil yükümlülükler)* yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir (TTK m.480/4).

---

347 **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 285; **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, I,** N. 836.

348 Altıncı Bölüm, § 9, V başlığı

349 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, I,** N. 837b.

350 Her ne kadar Kanunda "pay" denilmiş olsa da konunun düzenlendiği yer ve kenar başlığı pay senetleri olarak düzenlendiğinden pay kavramı, pay senedi olarak anlaşılmalıdır.

Payın serbestçe devredilmesine ilişkin bir diğer iradi sınırlama, pay sahiplerinin kendi aralarında veya üçüncü kişilerle yapmış oldukları alım, önalım ve geri alım hakkının tanınmasını konu alan sözleşmeler yoluyla sağlanabilmektedir. Esas itibariyle borçlar hukuku hükümlerine tâbi olan ve sadece taraflar arasında hüküm ve sonuç doğuran bu sözleşmelere, TTK m.340 hükmünde düzenlenen emredici hükümler ilkesi gereği şirket sözleşmesinde yer verilemeyeceği söylenebilir. Hatta TTK'de düzenlenen bağlam hükümleri dahi bu sözleşmelere ortaksal nitelik kazandıramaz.

Bununla birlikte borsaya kote edilmemiş nama yazılı paylarda şirketin, devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle, kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebileceğine ilişkin yasal düzenlemenin (TTK m.493/1) kanuni bir önalım hakkı mahiyeti taşıdığı kabul edilmektedir[351]. Diğer yandan şarta bağlı sermaye artırımında pay sahiplerine önerilmeye muhatap olma hakkı tanınmış (TTK m.466/1); böylece pay sahiplerine bir tür rüçhan hakkı bahşedilerek korunması amaçlanmıştır[352]. Bu yasal düzenlemeler ışığında, anonim şirket esas sözleşmelerinde satılacak payın öncelikle diğer pay sahiplerine önerilmesine ilişkin düzenlemelerin kararlaştırılabileceği; bir pay sahibinin, payını satmadan önce diğer pay sahiplerine önermesinin esas sözleşme ile öngörülmesinin, kanun koyucunun amacına uygun düşeceği de kabul edilmektedir[353].

B. PAY SAHİPLİĞİNİN KAYBEDİLMESİ

Anonim şirketlerde pay sahipliğinin kaybedilmesinin olağan yolu payın devredilmesidir. Bununla birlikte şirket birleşmelerinde birleşme sözleşmesinde seçimlik veya zorunlu şekilde ayrılma akçesi öngörülerek (TTK m.141); şirketin ticaret sicili kaydının silinmesi ile tüzel kişiliğini kaybetmesi suretiyle; pay sahibinin rızasıyla payın itfası yoluyla; sermaye koyma borcunun yerine getirilmemesi nedeniyle ortağın

---

351 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 852. *"Ayni hak benzeri (quasi-dinglich)"* olduğu yönünde bkz. **Böckli**, §6, N. 210.

352 **Tekinalp**, Ü., Anonim Ortaklıkta Yeni Bağlam Sisteminin Esasları, Pay Defteri Hukuku İle, İstanbul 2012, N. 9-09, (Bağlam).

353 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, I, N. 860 ve N. 863; **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 289.

ıskat edilmesiyle (TTK m.482); pay sahiplerinin paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına mahkeme kararıyla hükmedilmesiyle (TTK m.202); hâkim şirketin azlığın paylarını satın almasıyla (TTK m.208) veya haklı sebeple fesih davasında mahkeme kararı ile azınlık pay sahiplerinin şirketten çıkarılmaları (TTK m.531) yollarıyla da pay sahipliği sıfatı kaybedilebilir.

Anonim şirketlerde geçerli emredici hükümler ilkesi gereği (TTK m.340), esas sözleşme ile Kanunda düzenlenmeyen yeni bir çıkma ya da çıkarılma sebebi öngörülemez. Bir pay sahibine esas sözleşme ile payını satma yükümlülüğünün getirilmesi, aynı zamanda tek borç ilkesine aykırılık yaratır (TTK m.480).

Pay sahipliği sıfatının kaybedilmesi ile alacak hakkına dönüşen talepler hariç, payın sağladığı tüm haklar kaybedilir. Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, nama yazılı payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden istenemez; ancak, şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış ise sermaye koyma borcunun ifası payı devredenden istenebilir (TTK m.501/2).

C. PAY SAHİBİNİN HAKLARI

Pay sahipliği haklarının pek çok açıdan tasnifi yapılmakla birlikte esas itibariyle üç temel konuda gerçekleştirilen ayrım dikkate alınmaktadır[354]: *i)* Pay sahipliği haklarının korunma gücü açısından vazgeçilemez (*unverzichtbar*) ve müktesep (*unentziehbar-wohlerworben*) haklar *ii)* Hak sahiplerinin çevresi açısından bireysel (*Einzelrecht*), azınlık (*Minderheitenrecht*) ve grup (*Gruppenrecht*) hakları, *iii)* Hakların içeriği yönünden mali-malvarlıksal (*vermögensmässig*) ve malvarlıksal olmayan idari-katılma hakları (*nicht vermögensmässig*).

1. Pay Sahipliği Haklarının Korunma Gücü Açısından

6762 sayılı TTK m.385 hükmünde örnek vermek suretiyle tanımlanan müktesep pay sahipliği hakları, 6102 sayılı TTK metninde vaz-

---

[354] **Kunz**, P. V., Der Minderheitenschutz im schweizerischen Aktienrecht, Bern 2001, §1, s. 71, N. 201.

geçilmez haklar ile birlikte sadece ismen zikredilmiştir. Buna göre genel kurul, aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde, müktesep ve vazgeçilmez haklar saklı kalmak kaydıyla esas sözleşmenin bütün hükümlerini değiştirebilir (TTK m.452).

a. Vazgeçilemez Haklar

Vazgeçilmez haklar, pay sahibinin iradesiyle dahi vazgeçemeyeceği haklardır. Bu haklarda sadece pay sahibinin bireysel menfaati değil; anonim şirketin hukuki menfaati de bulunduğundan, söze konu haklar pay sahibinin tasarrufuna terk edilmemiştir. Bu haklara; asgari olarak her bir paya bağlanan bir oy hakkını, dava hakkını, genel kurula katılma hakkını örnek olarak verebiliriz[355] (TTK m.447/1,a).

b. Müktesep Haklar

6762 sayılı TTK m.385 hükmünde müktesep haklar; *"kanun veya esas mukavele hükümlerine göre umumi heyet ve idare meclisi kararlarına tabi olmayan yahut umumi heyetin toplantılarına iştirak hakkından doğan, hususiyle azalık, rey kullanmak, iptal davası açmak, kar payı almak ve tasfiye neticesine iştirak etmek gibi haklardır"* şeklinde tanımlanmıştı. Bu tanımın yetersiz olduğu ve yanlış anlamalara yol açtığı için 6102 sayılı TTK metnine alınmadığı hükmün gerekçesinde ifade edilmiştir. Hakikaten 6762 sayılı Kanundaki bu liste müktesep hakların tümünü içermediği gibi, vazgeçilmez hak niteliğindeki haklara ilişkin ayrımı da tamamen ortadan kaldırmaktaydı. Mehaz İsviçre Borçlar Kanununun aksine kavramın muhafaza edilmesinin sebebi, kanunun bu tür haklara çeşitli hükümlerinde yer vermesi ve esas sözleşme ile de bu nitelikte hak oluşturabilmesi olarak belirtilmiştir[356].

Müktesep hak, en yalın ifadesiyle pay sahibinin rızası olmaksızın elinden alınamayan pay sahipliği hakkıdır. Bu hakların tipik özelliği, pay sahiplerinin bu haklardan vazgeçebilmeleri; ancak rızaları hilafına ellerinden alınamaz olmasıdır. Oybirliğini gerektiren genel kurul kararları ile (TTK m.421/2) payların birleştirilebilmesi hakkı (TTK m.477/2) müktesep haklara örnek verilebilir.

---

[355] **Kunz**, §1, s. 73, N. 207.
[356] Gerekçe TTK m.452.

2. Hak Sahiplerinin Çevresi Açısından

Hak sahiplerinin çevresi açısından pay sahipliği hakları; bireysel pay sahipliği hakları, azınlık hakları ve grup hakları olarak tasnif edilebilir.

a. Bireysel Pay Sahipliği Hakkı

Belirli bir sermaye iştirakinden veya belirli bir itibari değerin temsil edilmesinden bağımsız şekilde, münferiden pay sahibine düşen tüm pay sahipliği hakları bireysel pay sahipliği hakkı kapsamında ele alınabilir[357]. Bireysel pay sahipliği hakları müktesep veya vazgeçilmez hak karakteri gösterebilir. Pay sahibinin oy hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı, dava hakkı gibi hakları, pay sahibinin bireysel haklarıdır.

b. Azınlık Hakkı

Azınlık hakkı, bir pay sahibine, yalnızca ortak sıfatı nedeniyle bahşedilmeyen; hakkı kullanması için tek başına veya diğer pay sahipleriyle birlikte şirket sermayesinin asgari belirli bir miktarına iştirak etmesi gerekli görülen pay sahipliği hakkıdır[358].

Anonim şirketlerde geçerli olan çoğunluk ilkesinin katı bir şekilde uygulanması, azınlık pay sahiplerinin menfaatlerinin sürekli korumasız kalmasına yol açabilecektir. Kanun koyucu bu hususu gözeterek azınlığa, çoğunluğun aldığı kararlara etki edebilme imkânı bahşetmiştir. Etki imkânı, kimi zaman çoğunluğun karar almasına engel olma şeklinde gerçekleşirken (*olumsuz azınlık hakkı*); kimi zaman da çoğunluğun kararlarına rağmen bazı işlemleri gerçekleştirme yetkisini bahşeder (*olumlu azınlık hakkı*).

aa) Olumsuz Azınlık Hakları

Olumsuz azınlık hakkı esas itibariyle *sulh ve ibraya engel olma* ve *ağırlaştırılmış yeter sayıların öngörüldüğü hallerde* karşımıza çıkar. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun

---

357 **Kunz**, §1, s. 78, N. 219.
358 **Kunz**, §1, s. 79, N. 222.

onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz (TTK m.559). Genel kurul toplantıları için ağırlaştırılmış yeter sayının arandığı hallerde de azınlık, yeter sayının oluşmasına, böylece kararların alınmasına engel olabilmektedir[359].

bb) Olumlu Azınlık Hakları

Olumlu azınlık haklarını; *yönetim kurulunda temsil hakkı, genel kurulu toplantıya davet etme, finansal tabloların görüşmelerini erteletme, özel denetçi atanmasını talep etme, pay senedi basılmasını isteme ve şirketin haklı nedenle feshini isteme* başlıkları altında sıralayabiliriz.

Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile azınlık pay sahiplerine yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu halde genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı azlığa mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınan *azınlık payları* imtiyazlı sayılır (TTK m.360).

Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri (*azınlık pay sahipleri*), yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda paya sahip pay sahiplerine tanınabilir (TTK m.411).

Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır (TTK m.420).

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan

[359] **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 310.

pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir (TTK m.439).

Azlık istemde bulunursa nama yazılı pay senedi bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır (TTK m.486/3). Böylece kapalı anonim şirketlerde, özellikle aile şirketlerinde pay senedinin bastırılmaması ve dağıtılmaması yoluyla baskı yapılması, pay sahiplerinin bu sıfatlarını ispattan yoksun bırakılmaları, devir olanaklarının sınırlandırılması gibi hukuka aykırı yöntemlerin önüne geçilmiştir. Nama yazılı pay senetlerinin basılmaması ve pay sahiplerine dağıtılmaması, pay defteri bulunmayan, düzensiz olan ve güncel durumu yansıtmayan şirketlerde daha büyük sakıncalar doğurmaktadır. Hükme aykırılık halinde yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna gidilebilecektir.

Anonim şirketlerde haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri (*azınlık pay sahipleri*) şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler (TTK m.531).

Azınlık haklarının kullanılması için gerekli görülen sermaye iştiraki oranı, Kanunda ya "*asgari-en az*" şeklinde belirtilmiş ya da iştirak oranına işaret edilmeksizin sadece azınlık hakkı tanındığından söz edilmiştir. Hükümlerin azınlık pay sahiplerini koruma amacından hareketle esas sözleşme ile azınlık için öngörülen iştirak oranlarının hafifletilebileceği; ancak azınlık aleyhine bir durum oluşturacağından ağırlaştırılamayacağı ifade edilebilir.

c. Grup Hakkı

Grup hakkı, özel hukuki duruma sahip pay sahiplerinin oluşturduğu özel bir gruba bağlanan haklardır[360]. Grup hakkı, imtiyazlı payların oluşturduğu pay grubuna esas sözleşme ile yönetim kurulunda temsil edilme imtiyazının tanınması halinde karşımıza çıkar (TTK m.360). Bu halde, kendisine aday önerme hakkı tanınan pay grubunun yönetim kuruluna önereceği adayı, ayrı bir toplantı yapmak suretiyle belirlemesi gerekli olacak; aday, grubun çoğunluğunun olumlu oyu ile belirlenecektir.

---

[360] **Kunz**, §1, s. 81, N. 225.

3. Hakların İçeriği Açısından

Pay sahipliği haklarının içeriği veya niteliği açısından yapılan ayrımda pay sahiplerinin malvarlığı hakları ile saf malvarlığı hakkı bahşetmeyen katılma haklarından söz edilir.

a. Mali (Malvarlıksal) Hakları

Pay sahibinin mali hakları; kâr payı (*temettü*) hakkı, hazırlık devresi faizi hakkı, tasfiye payı hakkı, rüçhan hakkı (*yeni pay alma hakkı*), önerilmeye muhatap olma hakkı ve bedelsiz payı edinme hakkı olarak sayılabilir.

aa) Kâr Payı Hakkı

Kâr payı (*temettü*) hakkı, payın sağladığı en önemli mali haklardandır. Kâr payı, Kanunda veya esas sözleşmede öngörülen şartlar ile dağıtılabildiğinden, şarta bağlı bir talep hakkı verdiği kabul edilmektedir[361]. Kâr payı hakkı, şirkete getirilen sermayenin semeresidir[362]. Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir (TTK m.507/1).

Anonim şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç için kurulabilir. Bu bağlamda şirketin kâr elde etme ve bunu paylaştırma amacını terk edemeyeceği ifade edilebilir. Bu esastan hareketle kâr payı hakkı pay sahibi için vazgeçilmez hak niteliği gösterir. Diğer yandan, elde edilen kârın tamamı dağıtılmayıp kanuni ve ihtiyari yedek akçelere ayrıldığından ve Kanunda, şirket sözleşmesinde veya genel kurul kararında öngörülen şartlarla dağıtıma konu edildiğinden pay sahibinin kâr payı hakkının, belirli şartlara tâbi kılınmış nispî müktesep hak niteliği gösterdiği de ifade edilebilir[363].

Kâr payının dağıtılabilmesi için kanun koyucu birtakım şartlar öngörmüştür[364]. Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez. Yedek akçe, şirket malvarlığının sermayeyi aşan kısmıdır ve aktiflerin

---

361 **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 615, N. 4.

362 **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 295.

363 Kâr payının müktesep ve vazgeçilmez hak niteliği taşımadığı yönünde bkz. **Gürbüz Usluel**, A.E., Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Kâr Payı Alma Hakkı, Ankara 2016, s. 101-105.

364 Halka açık anonim şirketler hakkında bkz. SerPK m.19.

zararlar nedeniyle eksildiği hallerde güvence bahşeder[365]. Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır (TTK m.519/1). Yedek akçeye yıllık kârın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında esas sözleşmeye hüküm konabilir (TTK m.521). Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir (TTK m.519/2,c). Kanun koyucu bu yasa hükmü ile asgari bir kâr dağıtım zorunluluğu öngörmüştür. Genel kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir (TTK m.519/3). Şirket, iktisap ettiği kendi payları için de iktisap değerlerini karşılayan tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda çözülebilirler (TTK m.520/1).

Kanunen ayrılan yedek akçenin yanında genel kurul da belirli hallerde Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe ayrılmasına karar verebilir. Bu haller; aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gereklilik bulunması ve bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı görülmesi olarak belirtilmiştir (TTK m.523/2). Ayrıca esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir (TTK m.523/3).

Yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerindendir (TTK m.408/2,d). Genel kurul, Kanunla kendisine verilen bu yetkiyi kullanarak kârın bir defada veya birkaç taksitte ödenmesine karar verebilir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm

---

[365] **Gürbüz Usluel**, s. 17.

yoksa kâr ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.

Pay sahibinin kâr payı alacağının şartsız ve talep edilebilir bir alacak haline gelmesi, genel kurulun oluşan kârın dağıtılması hususunda karar almasına bağlıdır[366]. Genel kurul kâr dağıtım kararını, olağan toplantı ve karar yeter sayılarına riayet ederek alabilir. Kâr payı alacağı, muaccel olduğu tarihten itibaren beş yıl içerisinde şirketten talep edilmezse alacak zamanaşımına uğrar (TBK m.147/1, b.4). Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı alan pay sahipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar (TTK m.512).

Kar payı avansı, Sermaye Piyasası Kanununa tâbi olmayan şirketlerde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Ticaret Bakanlığının) bir tebliği ile düzenlenir (TTK m.509/3). Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'in[367] 4'üncü maddesine göre kâr payı avansı, kâr payından mahsup edilmek üzere ara dönem finansal tablolara göre oluşan kârlar üzerinden Tebliğ hükümlerine göre hesaplanan tutarı ifade eder. Tebliğin 5'inci maddesi hükmüne göre, şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir (m.5/1). 05.01.2019 tarihinde hükme eklenen ikinci fıkra gereğince, "*Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından 7'nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.*"

bb) Hazırlık Devresi Faizi Hakkı

Anonim şirketlerde sermayenin taşıdığı önemi gözeten kanun koyucu, sermaye için faiz ödenemeyeceğini açıkça hükme bağlamıştır (TTK m.509/1). Bununla birlikte işletmenin tam bir şekilde faaliyete

366 **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 617, N. 13; **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 296.
367 09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete.

başlamasına kadar geçecek hazırlık dönemi için pay sahiplerine, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olmak koşuluyla, özellikli varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir faiz ödenmesi *esas sözleşmede* öngörülebilir ve bu dönemle sınırlı olmak üzere, faiz ödemelerinin en geç ne zamana kadar süreceği belirtilir (TTK m.510/1). Böylece şirkete yatırım yapmayı düşünen kişilerin, belirli süre ve belirli oranda faiz yoluyla teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

İşletme yeni paylar çıkarılarak genişletilecek olursa, sermayenin artırılmasına dair olan kararda, yeni pay sahiplerine, özellikli varlık niteliğindeki yatırımların maliyetine yüklenmek üzere, belirli bir süreyle en geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenmesi kabul olunabilir (TTK m.510/2). Kanun koyucu sermaye artırımlarından sadece yeni pay ihraç edilerek yapılacak sermaye artırımları için ve en geç yeni yatırımın işletmeye alındığı güne kadar faiz ödenebileceğini hükme bağlamıştır.

cc) Tasfiye Payı Hakkı

Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara (*tasfiye artığına*) payı oranında katılır (TTK m.507/1). Şirketin önce dış sonra iç tasfiyesi tamamlandıktan sonra kalan malvarlığı (*tasfiye artığı-tasfiye payı*) pay sahipleri arasında payları veya bu hususta imtiyaz hakkı tanınmış ise imtiyazlar ölçüsünde dağıtılır. Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, dağıtma para olarak yapılır (TTK m.543/3).

Tasfiye payı hakkı, şirketin sona erme sebebinin gerçekleşmesini müteakip tasfiye işlemlerinin tamamlanmasından sonra alacak hakkı niteliğini kazanacağından, *geciktirici şarta bağlı bir haktır*. Diğer yandan pay sahibinin tasfiye payı hakkı, belirli hallerde sınırlandırılabileceğinden *nispî müktesep hak niteliği* taşıdığı da ifade edilebilir. Bu bağlamda tasfiye payı hakkı, imtiyaz hakkı tanınmasıyla ya da intifa senedi sahiplerine tasfiye sonucunda kalan tutara katılma hakkı tanınarak (TTK m.503) sınırlandırılabilir.

dd) Rüçhan Hakkı (Yeni Pay Alma Hakkı)

Pay sahibinin rüçhan hakkı, sermaye artırım kararı kapsamında yeni çıkarılan paylardan, mevcut paylarının sermayeye oranına göre öncelikle alma hakkıdır (TTK m.461/1). Bu hak, şirkette bulunan pay sahiplerinin mali ve idari haklarının sermaye artırım kararından olumsuz etkilenmemesi için öngörülmüştür. Zira rüçhan hakkının tanınmaması veya sınırlandırılması, pay sahibinin toplam sermaye içerisindeki pay sahipliği oranını ve paya bağlı haklarını kaybetmesine veya önceki kapsamıyla kullanamamasına neden olacaktır.

Rüçhan hakkı, sadece yeni pay çıkarılması sonucunu doğuran sermaye artırımlarında gündeme gelebilir. Bu bağlamda iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında ve yeni pay çıkarılması sonucunu doğurmayan dış kaynaklardan sermaye artırımlarında (*payların itibari değeri yükseltilerek*) pay sahibinin rüçhan hakkı gündeme gelmez.

Genel kurulun, sermayenin artırımına ilişkin kararı ile pay sahibinin rüçhan hakkı, ancak haklı sebepler bulunduğu takdirde ve en az esas sermayenin yüzde altmışının olumlu oyu ile sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Özellikle halka arz, işletmelerin, işletme kısımlarının, iştiraklerin devralınması ve işçilerin şirkete katılmaları haklı sebep kabul edilmiştir (TTK m.461/2). Kayıtlı sermaye sistemini benimsemiş halka açık olan ve halka açık olmayan anonim şirketlerde yönetim kurulunun pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlandırabilmesi için esas sözleşmeyle yetkilendirilmiş olması gerekli görülmüştür (TTK m.460/4; SerPK m.18/5). Yönetim kurulunun rüçhan hakkını sınırlandıran kararları aleyhine TTK m.445'te öngörülen sebeplerin varlığı halinde iptal davası açılabilir (TTK m.460/5; SerPK m.18/6).

ee) Önerilmeye Muhatap Olma Hakkı

Şarta bağlı sermaye artırımında pay sahibine tanınmış olan önerilmeye muhatap olma hakkı, rüçhan hakkı yerine ikame edilmiş bir haktır. Şarta bağlı sermaye artırımında, tahvillere ve benzeri borçlanma araçlarına bağlı olarak değiştirme ve alım hakları içeren senetler ihraç edildiği takdirde, bunlar önce, mevcut payları oranında, pay sahiplerine önerilir (TTK m.466/1). Sermaye artırımının bu türünde de pay sahipleri, rüçhan hakları kaldırıldığından zarara uğrarlar. Pay sahipleri yeni payları alamadıkları için şirketteki katılma oranları düşer; teknik terimle sulanır. Bu kayıp, önerilme hakkı ile dengelenir. Önerilme hakkı,

şarta bağlı sermaye artırımında değiştirme veya satım hakkı içeren tahvillerin veya benzeri borçlanma senetlerinin önce pay sahiplerine önerilmesi zorunluğuna ilişkin yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Bu pay sahipliği hakkı, şirketin önerme, yani öneride bulunma zorunluğundan doğar. Önerilme hakkı aracılığı ile pay sahibi yeni pay alma hakkını dolaylı bir şekilde korumuş olur.

Rüçhan hakkında olduğu gibi, önerilmeye muhatap olma hakkı da haklı sebeplerin varlığında kaldırılabilir veya sınırlandırılabilir (TTK m.466/2). Haklı sebep, şirketin menfaati yönünden değerlendirilmeli; eşit işlem ve hakların sakınılarak kullanılması ilkesine uyulmalıdır. Piyasa şartları haklı sebep olarak kabul olunabilir.

ff) Bedelsiz Payı Edinme Hakkı

Bedelsiz pay, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımında artırım kararının tescili yoluyla kesinleştiği anda doğan paydır. Bu paylara "*bedelsiz*" denmesinin sebebi, payın karşılığının şirket özvarlığından ödenmesidir. Tescil ile eski pay bedelsiz pay ile birlikte kendiliğinden doğar; diğer bir anlatımla şirketin ayrıca bedelsiz payın kazanılması hususunda bir karar almasına gerek yoktur. Bedelsiz paya ilişkin hak bir rüçhan hakkı değildir. Bu sebeple ne sınırlandırılabilir ne kaldırılabilir ne de bundan vazgeçilebilir (TTK m.462/3).

gg) İdari (Katılma) Hakları

Pay sahibinin idari hakları, şirket yönetimine katılma ve denetleme haklarını kapsar. Bu bağlamda genel kurul toplantılarına katılma hakkı, oy hakkı, bilgi alma ve inceleme hakkı, özel denetim isteme hakkı ile dava hakkı sayılabilir.

aaa) Genel Kurul Toplantılarına Katılma Hakkı

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula yollayabilir (TTK m.425/1). Genel kurula katılma hakkı, pay sahibinin sermaye payının büyüklüğünden bağımsız olup genel kurul toplantısına çağrılma ve toplantıda söz alarak öneride bulunma haklarını da kapsar. Pay sahibinin genel kurula katılma hakkı, sadece pay sahibinin değil; şirket iradesinin genel kurulda oluşması yönündeki şirkete ait menfaati de ihtiva ettiğinden Kanunda

vazgeçilemez nitelikteki haklar arasında sayılmıştır[368]. Bu kabulden hareketle genel kurulun, pay sahibinin genel kurula katılma hakkını sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlarının batıl olduğu ifade edilmiştir (TTK m.447/1-a). Buna karşılık genel kurul toplantısının kurallara uygun şekilde yürütülmesi için gerekli ise toplantı başkanı tarafından bu hakkın sınırlandırılabileceği kabul edilmektedir[369].

Genel kurula katılma hakkı, esas itibarıyla oy hakkı kavramından daha geniş bir mahiyet taşır. Zira oy hakkı, genel kurula katılma hakkı olmadan düşünülemezken; genel kurula katılma hakkı, oy hakkından bağımsız kullanılabilir[370] (TTK m.436, SerPK m.17/3 ve m.29/6).

bbb) Oy Hakkı

Oy hakkı, pay sahibinin şirket yönetimine katılımını sağlayan en önemli idari haklarından birisidir. Oy hakkı, yöneldiği hukuki sonuçlar açısından genel kurul kararlarından bağımsız, tek taraflı ve yenilik doğurucu bir hukuki işlemdir[371].

Her pay sahibi, sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haiz olması gerektiğinden asgari bir oy hakkının vazgeçilmez hak niteliğinde düzenlendiği söylenebilir. Bununla birlikte kanun koyucu, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısının esas sözleşmeyle sınırlandırılabilmesine müsaade etmiştir (TTK m.434/2). Diğer yandan, oy hakkı kural olarak payın itibari değeriyle orantılı şekilde kullanılacak olsa da Kanunda esas sözleşme ile belirli payların ya da pay gruplarının, itibari değerlerine oranla daha fazla sayıda oy hakkı verebileceği hususunda düzenleme yapılabileceği kabul edilmiştir (TTK m.478, m.479). Oy hakkının, Kanunda belirtilen şartlara riayet ederek esas sözleşme ile sınırlandırılmasını kabul eden kanun koyucu, asgari bir oy hakkı hariç oy hakkını, nispî müktesep hak niteliğinde düzenlemiştir. Pay sahibinin belirli sayıda paya sahip olması şartıyla oy hakkını kullanabileceğine ilişkin düzenlemeler, anonim şirketin temel yapısına ve

---

368 Mutlak müktesep hak nitelemesi için bkz. **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 624, N. 42.

369 **Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel**, s. 218, N. 104; **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 624, N. 43; **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 303.

370 **Von Salis**, U., Die Gestaltung des Stimm- und des Vertretungsrechts im schweizerischen Aktienrecht, Zürich 1996, §6, s. 41-42.

371 **Paslı**, A., *"Anonim Ortaklık Genel Kurulunda Kullanılan "Oy"un Hukuki Niteliği"*, İÜHFM, 2009, C. LXVII, S. 1-2, s. 167 vd.

asgari bir oy hakkının vazgeçilmez hak niteliğine aykırı olacağından batıl kabul edilecektir (TTK m.447/1-a).

Pay sahibinin oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar (TTK m.435/1). Bu halde nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce ödendiği takdirde oy hakkı doğacaktır[372] (TTK m.344/1).

Kanun koyucu bazı durumlarda oy hakkının kullanılmasına izin vermemiş; bu halleri *oydan yoksunluk* ve *oy hakkının donduğu haller* başlıkları altında düzenlemiştir.

Oy hakkından yoksunluğun ortaya çıkacağı durumlar TTK m.436 hükmünde düzenlenmiştir[373].

Oy hakkının donduğu hallerden ilki, şirketin iktisap ettiği kendi payları ile yavru şirket tarafından iktisap edilen ana şirketin paylarının, ana şirketin genel kurulunun toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmadığı haldir (TTK m.389/1). Dolayısıyla şirketin devraldığı kendi payları hiçbir pay sahipliği hakkını ve bu bağlamda oy hakkını bahşetmez. Yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar da donar.

Oy hakkının donduğu bir diğer durum, TTK m.434/2 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre, birden fazla paya sahip olanlara tanınacak oy sayısı esas sözleşmeyle sınırlandırıldığı takdirde, esas sözleşmede öngörülen sınırı aşan pay sahiplerinin sınırı aştığı oranda paylardan doğan oy haklarını kullanamayacakları; diğer bir ifadeyle oy hakkının donacağı söylenebilir. Bu halde, şirkette daha önce pay sahipliği sıfatını

---

372 Nakit pay bedeli tamamen ödenmiş paylar ile eşit itibari değerde fakat bu kez pay bedeli tamamen ödenmemiş olan paylar aynı sayıda oy hakkı bahşettiğinde, ilk grup payların daha az ödeme yaparak daha çok oy hakkı bahşettiği ve bu suretle ilk grup paylar lehine gerçek olmayan imtiyaz tesis edildiği düşünülebilir. Oy hakkı, payın itibari değeriyle orantılı şekilde kullanılacağından, bu halde de paylar için farklı miktarlarda ödeme yapılsa da itibari değerleri eşit olan payların eşit oy hakkı vermesi gerekir. Payın itibari değeri ve payın bedeli farklı kavramlardır. Pay için şirketin tescili anına kadar farklı oranda ödeme yapılmasına izin verilse de pay sahibinin taahhüt ettiği pay bedeli oranında ekonomik rizikoyu taşıdığı ve şirketin her zaman bu bedelin ödenmesini talep edebileceği unutulmamalıdır. Oy hakkında imtiyaz ise, payın itibari değeri ile oy hakkı arasında kurulan oransal ilişkiyi ortadan kaldıran bir hukuki imkân olup, pay için yapılan ödemelerden hareketle imtiyaz tesis edildiği kabul edilmemelidir.

373 Ayrıntılı bilgi için bkz. Sekizinci Bölüm § 11, III, D, 4.

iktisap etmemiş olan ya da sözleşmede öngörülen sınırı aşmayan pay sahiplerine, oy hakkı donmuş olan bu paylar devredildiği takdirde oy hakkı yeniden canlanacaktır.

Bu durumlara ilave olarak, borsaya kote edilmiş nama yazılı paylar için esas sözleşmede, iktisap edilebilecek paylar ile ilgili olarak iktisap edenin pay sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngörülmüş ve bu üst sınır aşılmışsa, bu paylardan doğan oy hakkı ve oy hakkına bağlı diğer haklar kullanılamaz (TTK m.495, m.497).

ccc) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahibinin, paydan doğan idari ve mali nitelikteki haklarını etkin şekilde kullanması, şirket iş ve işlemlerinden haberdar olmasına bağlıdır. Bu önemi gözeten kanun koyucu, pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkını TTK m.437 hükmünde ayrıca düzenlemiştir.

Bu kapsamda düzenlenen ilk husus, genel kurulun kanuna ve esas sözleşmeye uygun şekilde çağrılmasında, pay sahibinin menfaatlerinin dikkate alınması ve genel kurul toplantısının yapılmasından önce bazı bilgi ve belgelerin pay sahiplerinin incelemesine sunulmasıdır. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az on beş gün önce, şirketin merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri şirkete ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir (TTK m.437/1).

Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, şirketin işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır. Pay sahiplerinden herhangi birine bu sıfatı dolayısıyla genel kurul dışında bir konuda bilgi verilmişse, diğer bir pay sahibinin istemde bulunması üzerine, aynı bilgi, gündemle ilgili olmasa da aynı kapsam ve ayrıntıda verilir. Bilgi verilmesi, sadece, istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir (TTK m.437/2).

Şirketin ticari defterleriyle yazışmalarının, pay sahibinin sorusunu ilgilendiren kısımlarının incelenebilmesi için, genel kurulun açık izni veya yönetim kurulunun bu hususta kararı gerekir. İzin alındığı takdirde inceleme bir uzman aracılığıyla da yapılabilir (TTK m.437/4).

Bilgi alma veya inceleme istemleri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra anlamında bilgi alamayan pay sahibi, reddi izleyen on gün içinde, diğer hâllerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine başvurabilir. Pay sahibi dava talebini, bilgi alma ve inceleme hakkını somutlaştıracak şekilde yapmalıdır. Diğer bir ifadeyle dava yoluyla genel olarak bilgi alma ve inceleme talebinde bulunulamamalıdır. Bu bağlamda pay sahibinin genel kurulda bilgi alma ve inceleme talebinde bulunması, *dava şartı* olarak kabul edilebilir[374]. Başvuru basit yargılama usulüne göre incelenir. Mahkeme kararı, bilginin genel kurul dışında verilmesi talimatını ve bunun şeklini de içerebilir. Mahkeme kararı kesindir (TTK m.437/5).

Bilgi alma ve inceleme hakkı, esas sözleşmeyle ve şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz (TTK m.437/6). Her ne kadar emredici nitelikte düzenlenmiş olsa da pay sahibinin bilgi alma ve inceleme yükümlülüğünün olmadığı vurgulanmalıdır. Bu hak, vazgeçilmez nitelikte bireysel pay sahipliği hakkı niteliği taşır.

ddd) Özel Denetim İsteme Hakkı

Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir (TTK m.438).

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, *sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir*

---

374 **Weber, R. H.:** Basler Kommentar: Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR (Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH), Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, 2016, 5. Auflage, Helbing & Lichtenhahn Verlag, Art. 697, N. 21.

milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir. Dilekçe sahiplerinin, kurucuların veya şirket organlarının, kanunu veya esas sözleşmeyi ihlal ederek, şirketi veya pay sahiplerini zarara uğrattıklarını ikna edici bir şekilde ortaya koymaları hâlinde özel denetçi atanır (TTK m.439). Kanun koyucu, özel denetim talebinin reddedilmesi halinde mahkemeye başvurma hakkını, açıkça her bir pay sahibine değil; azınlık oluşturan pay sahiplerine (olumlu azınlık hakkı) veya itibari değeri belirli bir kanuni sınırı aşan payların sahiplerine tanımıştır.

D. PAY SAHİBİNİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Pay sahibinin asli borcu olarak da nitelendirilebilen sermaye koyma borcunun yanında, esas sözleşme ile öngörülebilen ikincil yükümlülükleri, belirli hallerde sadakat yükümlülüğü ile sır saklamadan doğan yükümlülükleri bulunmaktadır.

1) Sermaye Koyma Borcu (Tek Borç İlkesi)

Anonim şirketlerde pay sahibinin asli borcu, taahhüt ettiği sermayeyi şirkete getirme borcudur. Bu borç pay bedeli kadar ve şirkete karşıdır. Bu husus TTK m.480/1 hükmünde, "*Kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle pay sahibine, pay bedelini veya payın itibari değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez*" şeklinde ifade edilmiştir[375]. Bu hüküm, pay sahipleri sözleşmeleriyle oluşturulabilecek düzenin, esas sözleşme düzenini ortadan kaldırmasına sınırsız bir şekilde izin vermemeyi amaçlamaktadır. Pay sahibine, rızası olmadıkça asli yükümlülüğü olan taahhüt ettiği pay bedeli ile bu bedeli aşan primi şirkete ifa etme borcu dışında esas sözleşme ile başkaca bir yükümlülük yüklenememesi kuralına, "*tek borç ilkesi*" adı verilmektedir[376].

---

375 "*İlke yönünden 6762 sayılı Kanunun 405 inci maddesinin birinci fıkrasının ifadesinde değişiklik yapılmıştır. Mevcut metin "fazla bir şey ödemeye esas mukavele ile dahi mecbur tutulamaz" diyerek ödeme sözcüğünü vurgulamıştı. Bu da, Türk öğretisinde, hükmün sermaye ve prim borcu dışındaki diğer para borçlarını kapsamadığı görüşünün ileri sürülmesine sebep olmuştu. Onun için 480 inci maddede "borç yükletilemez" ifadesi bilinerek kullanılmıştır. Hükümdeki borç sözcüğü geniş anlam taşımaktadır*" (Bkz. Gerekçe TTK m.480).

376 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, II, N. 1019.

Kanunun lafzından hareketle Kanunda öngörülen istisnai durumlarda, esas sözleşmeyle pay sahibine tek borç ilkesine aykırı yükümlülükler yüklenebileceği söylenebilir. Esas sözleşmede hüküm bulunması veya genel kurul ya da kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna verilen yetki gereğince yönetim kurulu kararı ile payların itibari değerinden yüksek bir bedelle çıkarılması mümkündür. İtibari değeri aşan primin sermaye borcu kapsamında bulunması nedeniyle prim ödeme borcu, tek borç ilkesinin bir istisnasını teşkil etmez. Benzer bir sonuç, Borçlar Hukuku sözleşmeleri (*pay sahipleri sözleşmeleri*) ile pay sahibi için getirilen yükümlülükler için de geçerlidir; zira bu sözleşmeler, ortaksal yükümlülük getirmemekte; sadece sözleşenler arasında hüküm ve sonuç doğurmaktadır.

Buna karşılık esas sözleşme ile pay sahiplerine yüklenebilen ikincil yükümlülükler, istisna kapsamında zikredilebilir (TTK m.480/4). Ayrıca sermaye kaybı ve borca batık olma durumunda sermayenin korunması ilkesi gereği düzenlenen TTK m.376 hükmü de tek borç ilkesinin kanuni bir istisnası olarak zikredilebilir. Hükme göre, son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhal toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya *sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde* şirket kendiliğinden sona erer. Bu halde sermayenin tamamlanmasına karar verecek olan şirketin bilanço zararlarının kapatılması için esas sözleşme ile yükümlülük koyması gerekecek ve bu, oybirliği ile alınacak esas sözleşme değişikliği kararına ihtiyaç gösterecektir (TTK m.421/2-a).

Pay bedelinin ödenmemiş olduğu durumlarda borçlu sıfatı pay sahibine ait olacaktır. Birden fazla kişinin bir payı birlikte iktisap etmesi halinde, pay bedelinden müteselsilen sorumluluk doğacaktır. Buna ilave olarak nama yazılı payların devrinde kanuni bir sınırlama olarak pay bedelinin tamamen ödenmemesi hali zikredilebilir. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, devrin miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleştiği durumlar hariç, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Bu halde borcun *(pay bedelinin)* dış üstlenilmesi söz konusu olacağından (TTK m.196) kanun koyucu alacaklı sıfatını haiz şirketin devre onay vermesini gerekli görmüştür. Şirket, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir.

Bedeli tamamen ödenmemiş bulunan nama yazılı bir payı iktisap eden kimse, pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı geri kalan pay bedelini ödemekle yükümlü olur. Şirketin kurulması veya esas sermayenin artırılması sırasında iştirak taahhüdünde bulunan kimse, payını başkasına devrettiği takdirde, bedelin henüz ödenmemiş olan kısmı kendisinden istenemez; iktisap edenin pay defterine kaydedilmesiyle borçlarından kurtulmuş olur. Buna karşılık şirketin kuruluşu veya esas sermayenin artırılması tarihinden itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmiş ve payı iktisap eden kimse paydan doğan haklardan yoksun bırakılmış ise, pay bedelinin ödenmemiş olan kısmı, payı devredenden istenebilir (TTK m.501/2).

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı tescilden önce ödenir (TTK m.344/1). Bakiye sermaye borcunun yerine getirilmesi, yönetim kurulu tarafından, esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilan yoluyla istenir. İlanda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir (TTK m.481/1). Pay bedelinin ödenmesi hususunda esas sözleşme ile genel kurula yetki verilebileceği gibi, ödemeye çağrı, tasfiye halinde tasfiye memurlarınca veya iflasta iflas idaresince de yapılabilir.

Şirket, her ortağın sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebileceği ve dava edebileceği gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle uğradığı zararın tazminini de isteyebilir (TTK m.128/7). Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine getirmeyen pay sahibi, *ihtara gerek olmaksızın,* temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, yönetim kurulu, temerrüde düşen (*mütemerrit*) pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı kısmi ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye yetkilidir (*iskat*). Esas sözleşmeyle, pay sahipleri, temerrüt halinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu tutulabilirler. Şirket, pay bedelini ifada temerrüde düşen ortaktan tazminat isteyebilir (TTK m.482). Tazminat istemi için ihtar şarttır (TTK m.128/7).

Pay sahibinin pay bedelini ifada temerrüde düşmesi neticesinde iskat edilebilmesi için, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile esas sözleşmenin öngördüğü

şekilde ilan yoluyla şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, mütemerrit pay sahibinin temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi halde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının isteneceği belirtilir. Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilan yerine, iadeli taahhütlü mektupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, mektubun alındığı tarihten başlar. Mütemerrit pay sahibi, yeni pay sahibinin ödemelerinden açık kalan tutar için şirkete karşı sorumludur (TTK m.483).

2. İkincil Yükümlülükler

Pay devirlerinin şirketin onayına bağlı olduğu hallerde, esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye taahhüdünden doğan borçtan başka, *belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para olmayan edimleri* yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir. Bu yükümlülüklere "*ikincil yükümlülük*" adı verilir (TTK m.480/4).

İkincil yükümlülüklerin ayırıcı özelliği, belirli zamanlarda tekrarlanan nitelik taşıması ve konusunun para olmamasıdır. Örneğin un ve unlu mamul üretimi ile uğraşan bir şirkette pay sahiplerinden, altı ayda bir şirkete üç ton buğday getirmelerinin istenilmesi, ikincil yükümlülüktür. İkincil yükümlülüklerin esas sözleşmede öngörülmesi şarttır ve Kanunda oybirliği ile alınması gereken kararlar arasında belirtilmiştir (TTK m.421/2, a). İkincil yükümlülüklerin yerine getirilmesi için de esas sözleşmede, sözleşme cezası öngörülebilir (TTK m.481/2).

3) Sadakat Yükümlülüğü

Anonim şirketlerde pay sahibinin, ortaklığın menfaatlerini kendi menfaatlerinin üzerinde tutma ve diğer ortakların menfaatlerine uygun hareket etme şeklinde şahıs şirketlerinde kabul edilen sadakat yükümlülüğünün bulunup bulunmadığına ilişkin olarak doktrinde görüş birliğinin bulunmadığı görülmektedir[377]. Kanunda pay sahibinin tek borç

---

[377] Bir konzernde büyük pay sahibinin, iradenin oluşumuna fiili organ olarak müdahale edebildiği durumlarda bu pay sahibinin sadakat yükümlülüğü bulunduğu yönündeki görüş için bkz. **Baudenbacher, C.:** Basler Kommentar Obligationenrecht II, Art. 530-964 OR, Art. 1-6 SchlT AG, Art. 1-11 ÜBest GmbH, Helbing Lichtenhahn Verlag, 5. Auflage, Hrsg: Heinrich Honsell, Nedim Peter Vogt, Rolf Watter, Basel 2016, Art. 530-964 OR, Art. 620 OR, N. 35. Esas itibarıyla pay sahibinin sadakat yükümlülüğünün bulunmadığını kabul eden görüş için bkz.

ilkesi emredici şekilde öngörüldüğünden ve pay sahibinin dürüstlük kuralına uygun davranmasının da bu tür bir yükümlülüğün yaratılmasına yeterli gerekçe oluşturmayacağından hareketle pay sahibinin anonim şirketlerde esas itibarıyla ayrıca sadakat yükümlülüğüne tâbi olmadığı söylenebilir.

4) Sır Saklama Yükümlülüğü

Pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkını kullanarak elde ettiği bilgilerden ortaklık sırrı niteliğindeki bilgileri saklaması gerektiği kabul edilir. Şirket sırrı kavramı Kanunda tanımlanmamıştır. Şirket sırrında, rakip bir şirketin bilmediği, öğrenmemesi gereken, şirketin zararına kullanabileceği, elde etmek için çalıştığı, bilgi esas alınmaktadır.

Pay sahibine bilgi verilmesi, sadece istenilen bilgi verildiği takdirde şirket sırlarının açıklanacağı veya korunması gereken diğer şirket menfaatlerinin tehlikeye girebileceği gerekçesi ile reddedilebilir (TTK m.437/3). Kanun koyucu hükümde, şirket sırlarının ve korunması gereken şirket menfaatlerinin bilgi vermenin sınırını oluşturduğunu ifade etmiştir.

Bilgi alma ve inceleme hakkını kullanan pay sahiplerinin gerçek amacı çok çeşitli olabilir. Bu amaçların bir kısmı bilgi alma hakkının amacı ile bağdaşmayabilir, hatta ona ters düşebilir. Eşit işlem ilkesi uyarınca her pay sahibine bu hak tanındığı için menfaatler dengesi gereği söz konusu hakka sınır konulmak istenilmiştir. Genel kabul gören sınır, şirket sırrı bağlamında şirket menfaati olarak belirlenmiştir[378].

Buna ilave olarak görevi dolayısıyla incelemesine sunulan defter ve belgeleri inceleyenlerin, elde ettikleri veya verilen bilgilerden öğrendikleri iş ve işletme sırlarını açıklamaları yasaklanmıştır. Bu yasağa aykırı hareket halinde, şirketin uğradığı maddi ve manevi zarar tazmin edilmelidir (TTK m.527).

III) ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER

Menkul kıymetler 2499 sayılı evvelki Sermaye Piyasası Kanununda, ortaklık veya alacaklılık hakkı sağlayan, belirli bir meblağı temsil

---

BGE 91 II 298, 305; **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, II, N. 1091; **Pulaşlı**, Genel Esaslar, s. 642.

[378] Gerekçe TTK m.437.

eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte ve seri halde çıkarılan, ibareleri aynı olan kıymetli evrak olarak tanımlanmıştı (m.3/b). Menkul kıymetler 6362 sayılı mer'i SerPK m.3/1, (o) bendinde, "*Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını, borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını*" şeklinde ifade edilmiş; ancak açık bir tanım yapılmamıştır. Kanunda menkul kıymetler başlığını taşıyan yedinci bölüm içerisinde, pay senetleri, intifa senetleri, borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler düzenlenmiştir (TTK m.484 vd.).

A. PAY SENETLERİ

1) Pay Senedi Kavramı

Anonim şirketlerde pay senetleri, payı temsil eden ve paya tedavül olanağı kazandıran menkul kıymetlerdir.

Pay senetleri, TTK m.484/1 hükmü gereğince hamiline veya nama yazılı olur. Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz; buna aykırı olarak çıkarılanlar geçersizdir. Bununla birlikte payın türü değiştirilebilir. Dönüştürme esas sözleşmenin değiştirilmesiyle yapılır. Nama yazılı pay senetlerinin hamiline yazılı pay senetlerine dönüştürülebilmesi için payların bedellerinin tamamen ödenmiş olması şarttır (TTK m.485/2).

Hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılması zorunlu iken; nama yazılı pay senedi bastırılması, azlık pay sahiplerinin istemde bulunması şartına bağlanmıştır (TTK m.486/2, 3). Payın senede bağlanması, yukarıda da ifade edildiği üzere payın sağladığı hak ve borçlarda bir değişiklik yaratmamakta; sadece paya tedavül yeteneği kazandırılmakta ve hamiline yazılı senetlerde senet zilyetliğinin devri suretiyle temsil ya da inançlı devir olanaklarından faydalanılması mümkün olmaktadır.

2) Pay Senedi Türleri

Pay senetleri, hamiline veya nama yazılı olabilir (TTK m.484/1).

a. Hamiline Yazılı Pay Senetleri

Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır (TTK m.658/1). Hamiline yazılı pay senetlerinin devri, şirket ve üçüncü kişiler hakkında, ancak zilyetliğin geçirilmesiyle hüküm ifade eder (TTK m.489). Zilyet, iradesi dışında elinden çıkmış olsa bile, hamile yazılı senetleri iyi niyetle edinmiş olan kimseye karşı taşınır davası açamaz (TTK m.990).

Hamiline yazılı pay senetlerini devralan, şirkete ve üçüncü kişilere karşı pay sahibi sıfatını kazanır. Pay sahibinin haklarını kullanması için, kural olarak senedin ibrazı gereklidir. Bu husus, "*Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula katılabilirler*" şeklinde belirtilmiştir (TTK m.415/3).

b. Nama Yazılı Pay Senetleri

Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır (TTK m.654). Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler. Hukuki işlemle devir, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir (TTK m.490). Şirket, nama yazılı pay senedi sahiplerini, ad, soyadı, unvan ve adresleriyle, pay defterine kaydeder. Şirketle ilişkilerde, sadece pay defterinde kayıtlı bulunan kimse pay sahibi olarak kabul edilir (TTK m.499/4). Buna karşılık pay defterindeki kayıtlar açıklayıcı niteliktedir. Pay defterindeki kayda rağmen gerçek hak sahipliği ispatlanarak paydan doğan haklar kullanılabilir[379].

Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı ile devrolunabilir. Devir, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşirse, şirket onayı şartı aranmaz (TTK m.491/1). Bununla birlikte devralanın ödeme

---

[379] **Narbay**, Ş., Anonim Ortaklıkta Pay Defteri, Ankara 2003, s. 146-147.

yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse şirket devralan kişiyi pay sahibi olarak kabul etmeyebilir (TTK m.491/2).

c. Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri

Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe, nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler (TTK m.490/1). Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylara ilişkin kanuni sınırlama düzenlemesinin yanı sıra, esas sözleşme ile de nama yazılı payların devri, şirket onayına bağlanabilir. Kanun koyucu, pay sahipleri kompozisyonunu korumak için esas sözleşme ile pay devrine sınırlamalar getirilebileceğini düzenlemiştir. Bu şekilde nama yazılı payların devrini sınırlayan esas sözleşme hükümlerine "*sözleşmesel bağlam*"; hakkında bağlam hükmü öngörülen nama yazılı paylara/pay senetlerine de "bağlı *nama yazılı pay/pay senetleri*" adı verilir.

Sözleşmesel bağlam, şirket sözleşmesi yerine, pay senedi veya pay defteri üzerinde belirtilerek tesis edilemez. Bağlam hükmü, sadece nama yazılı paylar veya pay senetleri için öngörülebilir. Bağlam hükümleri, anonim şirketin nama yazılı paylarının borsaya kote edilip edilmediğine bağlı olarak iki alt başlıkta incelenmektedir.

aa) Borsaya Kote Edilmemiş Nama Yazılı Paylar

Şirket, borsaya kote edilmemiş nama yazılı payların devrinde devralan kişiyi pay sahibi olarak tanımayı üç halde reddedebilir ve bu şartlar esas sözleşme ile ağırlaştırılamaz (TTK m.493/7).

Bunlardan ilki; esas sözleşmede öngörülmüş önemli bir sebebi ileri sürerek devrin şirket tarafından reddedilmesidir. Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin esas sözleşme hükümlerinin, şirketin işletme konusu veya işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden onayın reddini haklı göstermesi önemli sebep nitelemesi için yeterli görülmüştür (TTK m.493/2). Pay sahipleri çevresinin bileşimine ilişkin şirket sözleşmesi hükmü ile kastedilen, şirkete ancak belirli özellik ve niteliğe sahip pay sahiplerinin ortak olmasına imkân veren sözleşme düzenlemeleridir. Sözleşme ile belirlenen pay sahiplerinin özellik ve nitelikleri, şirketin işletme konusunun[380] yerine getirilmesine hizmet edecekse

---

[380] Şirketin işletme konusunun, şirketin kâğıt üzerindeki değil, gerçek iştigal konusu şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmektedir. Bu yönde bkz. **Bozkurt**, T., Anonim Şirketlerde Pay Devrinin Sınırlandırılması (Bağlam) –Die Vinkulierung- İstanbul 2016, s. 77.

veya şirketin rakip işletmelerin ellerine geçmesini önleyici bir işlev görecekse, ancak bu hallerde önemli sebebin oluştuğu; payı devralan kişinin reddedilebileceği ifade edilebilir.

İkinci olarak, şirket devredene, paylarını, başvurma anındaki gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek, onay istemini reddedebilir (TTK m.493/1). Kanun koyucu bu düzenleme ile şirkete *kanuni bir önalım hakkı* tanımıştır[381].

Nihayet devralan, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket, devrin pay defterine kaydını reddedebilir (TTK m.493). Böylece esas sözleşmede öngörülen önemli sebep engeline takılmamak için nama yazılı payların kendi hesabına alınmasını sağlayan kişilerin şirkete sızmasına engel olunmak istenilmiştir[382]. Payı iktisap eden yanlış beyanda bulunmuşsa şirket, pay defterine yapılan kaydı, ilgililerin görüşlerini alarak silebilir (TTK m.500/1).

Paylar; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmişlerse, şirket, payları edinen kişiye, sadece paylarını gerçek değeri ile devralmayı önerdiği takdirde onay vermeyi reddedebilir (TTK m.493/4).

Devir için gerekli olan onay verilmediği sürece, payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm haklar devredende kalır. Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra gereği iktisap edilmeleri halinde, bunların *mülkiyeti* ve bunlardan kaynaklanan *malvarlığına ilişkin haklar derhal*; *genel kurula katılma haklarıyla oy hakları ise ancak şirketin onayı ile birlikte* devralana geçer. Şirket, onaylamaya ilişkin istemi, aldığı tarihten itibaren *en geç üç ay içinde reddetmemişse veya ret haksızsa*, onay verilmiş sayılır (TTK m.494).

bb) Borsaya Kote Edilmiş Nama Yazılı Paylar

Borsaya kote edilmiş nama yazılı paylarda bağlam düzenlemesi, payları borsaya kote edilmemiş olan şirketlere kıyasla amaca daha az hizmet edecek olsa da kanun koyucu bu şirketlere de yabancılaşma tehlikesine önlem olarak esas sözleşme ile bağlam hükmünü kararlaştırma imkânı vermiştir. Buna göre şirket, borsada kote edilmiş nama yazılı payları borsadan iktisap eden bir kimseyi, pay sahibi olarak tanımayı, ancak esas sözleşme, iktisap edilebilecek nama yazılı paylar ile ilgili

381 **Tekinalp**, Bağlam, N. 6-22.
382 **Tekinalp**, Bağlam, N. 6-23.

olarak iktisap edenin pay sahibi olarak tanınacağı, sermayeyi esas alan ve yüzde ile ifade edilen bir iktisap üst sınırı öngörmüş ve bu üst sınır aşılmışsa reddedebilir (TTK m.495/1). Böylece şirketin, bir veya birkaç kişinin hâkimiyeti altına girmesi engellenmeye ve sermayenin yayılması sağlanmaya çalışılır. Örneğin, bir pay sahibinin borsadan iktisap edebileceği payların itibari değerinin, sermayenin yüzde yirmisini geçmesi halinde, devre şirket tarafından onay verilmeyeceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir. Bu hallerde yönetim kurulunun pay defterine kayıttan kaçınması bir yükümlülük olarak öngörülebileceği gibi, yönetim kuruluna takdir hakkı da verilebilir[383].

Kanun koyucu, bu hükmün de dolanılmasına engel olmak amacıyla istemde bulunmasına rağmen devralanın, payları kendi ad ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi halinde, şirketin, payların pay defterine kaydını reddedebileceğini öngörmüştür (TTK m.495/2). Payı iktisap eden yanlış beyanda bulunmuşsa şirket, pay defterine yapılan kaydı, ilgililerin görüşlerini alarak silebilir (TTK m.500/1).

Borsaya kote nama yazılı paylar *borsadan iktisap edildikleri takdirde*, paylardan kaynaklanan haklar, payların devri ile birlikte devralana geçer. Borsaya kote nama yazılı payların, *borsa dışından iktisap edilmeleri halinde*, söz konusu haklar, pay sahipliği sıfatının şirket tarafından tanınması için, devralanın şirkete başvuruda bulunmasıyla devralana geçer (TTK m.497/1). Diğer bir ifadeyle ilk durumdan farklı olarak, borsaya kote edilmiş nama yazılı payların borsa dışından iktisap edilmesi durumunda, mülkiyet hakkı derhal; pay sahipliğinden doğan haklar ise şirkete başvuruda bulunulmasıyla geçer.

Devralan, payları ister borsadan isterse borsa dışından iktisap etsin, şirket tarafından tanınıncaya kadar, paylardan doğan, genel kurula katılma ve oy hakkını ve oy hakkına bağlı diğer hakları kullanamaz. Buna karşılık tüm diğer pay sahipliği haklarını, özellikle rüçhan hakkını kullanabilir (TTK m.497/2). Şirket tarafından henüz tanınmamış bulunan devralanlar, hakların geçmesinden sonra, oy hakkından yoksun pay sahibi olarak pay defterine yazılır. Söz konusu paylar genel kurulda temsil edilemez (TTK m.497/3).

Şirketin vereceği ret kararı hukuka aykırı ise şirket, hukuka aykırılığı tespit eden mahkeme kararının kesinleşme tarihinden itibaren, oy

---

383 **Tekinalp**, Bağlam, N. 7-13.

hakkını ve buna bağlı hakları tanır. Şirket, kusursuz olduğunu ispat edemezse, devralanın ret nedeniyle uğradığı zararı gidermekle yükümlü kılınmıştır (TTK m.497/4). Şirket, devralanın, pay sahibi olarak tanınması istemini, istemi aldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde reddetmemişse devralan, pay sahibi olarak tanınmış sayılır (TTK m.498/1).

B. İLMÜHABERLER

Yönetim kurulu kararı gereğince, pay senedi bastırılıncaya kadar pay senetlerinin yerine geçici olarak çıkarılan menkul kıymete "*ilmühaber*" adı verilir. Hamiline yazılı pay senetlerinin yerine geçici olarak çıkarılan ilmühaberlere kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır (TTK m.486/2). Hükmün, nama yazılı pay senetleri yerine çıkarılabilecek ilmühaberlere de uygulanabileceği kabul edilebilir[384].

C. İNTİFA SENETLERİ

Pay sahipliği hakkı vermeyen intifa senetleri, net kâra, tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları bahşeden bildirici (*ihbarî*) nitelikte menkul kıymetlerdir (TTK m.503).

Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına karar verebilir. Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir (TTK m.502).

D. BORÇLANMA SENETLERİYLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLER

Her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler, aksi kanunlarda öngörülmedikçe, *ancak genel kurul kararı ile* çıkarılabilirler. Genel kurul bu kararı, kanunlarda ve esas sözleşmede farklı bir düzenleme yoksa sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alır (TTK m.504/1).

---

[384] **Kendigelen**, İlk Tespitler, s. 394.

Borçlanma senetleri arasında yer alan tahviller, anonim şirketlerin işletme konularını gerçekleştirmek için ihtiyaçları olan yabancı sermayeyi tesis edebilmek amacıyla çıkarabilecekleri menkul kıymetlerdendir. 6762 sayılı TTK m.420 hükmünde "*Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları borç senetlerine (tahvil) denir*" şeklinde açıkça tanımlanmıştı. Tahvil sahipleri, tahvil için ödediği miktar kadar anonim şirkete borç vermiş olmaktadır. Bu yönüyle borç senedi özelliğinin yanında para alacağı senedi özelliği gösterdiği de söylenebilir[385]. Pay senetleri ortaklık hakkı sağlarken ve kâr payı hakkı bahşederken; tahvil, alacak hakkını içerir ve faiz hakkı bahşeder. Tahvil sahibinin alacak hakkı ödendikten sonra, tahvilin yok edilmesi gerekir. Buna ilave olarak tahvil sahibi olan kişinin alacak hakkı üzerinde şirket tek yanlı tasarrufta bulunamaz[386].

Pay senediyle değiştirilebilir tahviller ise, tahvil sahibine, değiştirme hakkının kullanılmasıyla pay sahipliği sıfatını bahşeden ya da doğrudan yeni pay alma hakkını veren sabit getirili menkul kıymetlerdir. Tek taraflı ve yenilik doğurucu hak niteliğindeki değiştirme hakkının kullanılması ile alacaklı sıfatı yerini, pay sahipliği sıfatına bırakmaktadır[387].

Borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler, hamiline veya emre yazılı ve itibari değerli olabilir. İtibari değer, genel kurul ve yetkilendirilmiş olması halinde yönetim kurulunca belirlenir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin *nakit* olması ve teslimi anında *tamamen ödenmesi şarttır* (TTK m.504/1).

Aksi kanunda öngörülmemişse, genel kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptamak yetkisini, en çok on beş ay için yönetim kuruluna bırakabilir. Yetkilendirme kararının verilmesi için de sermayenin en az yüzde yetmiş beşini oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oy vermesi gereklidir (TTK m.505).

---

385 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu**, II, N. 1273.
386 **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 342.
387 **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 343.

ONİKİNCİ BÖLÜM

§ 15- ANONİM ŞİRKETLERDE SONA ERME, TASFİYE VE HUKUKİ SORUMLULUK

LİTERATÜR

Çamoğlu, E., Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 3. Bası, İstanbul 2010; *Akdağ Güney, N.,* Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Baskı, İstanbul 2010; *Arı, Z.,* Anonim Şirketlerde Denetçi Sorumluluğunun Sınırlanması, Ankara 2012; *Şahin, A.;* Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi, İstanbul 2013; *Erdem, N.,* Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi; *Soykan, İ. C.,* Anonim Ortaklıklarda Organ Yokluğu, İstanbul 2012; *Al Kılıç, Ş.,* Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara 2017; *Çelik, A.,* Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu, Ankara 2005; *Helvacı, M.,* Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyesinin Hukuki Sorumluluğu, 2. Bası, İstanbul 2001; *Çetin, M.,* Anonim Şirketlerde Kurucuların Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2017; *Korkmaz, E.,* Anonim Şirketlerde Sınırlı Yetkili Temsilci Tayini ve Sorumluluk, Ankara 2018; *Ekecik, N.,* Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2018; *Aytulun, M./ Toroslu, Mahmut V.,* İçtihatlı ve Uygulamalı Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014; *Bilge, M. E., "Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi"*, EÜHFD, 2012, C. XVI, S. 3–4, s. 261-293*; Karaman Coşgun, Ö.*, Anonim Şirketin Tasfiyesi, Adalet Yayınları, Ankara 2015; *Kaderoğlu, M.*, Anonim Şirketlerin İnfisahı (Dağılması), Oniki Levha Yayıncılık, 2017; *Kervankıran, E.*, Anonim Şirketlerin Tasfiyesi, Seçkin Yayınları, Ankara 2015; *Şener, O. H.*, Anonim Ortaklıkta Ek Tasfiye (İhya), Adalet Yayınevi, Ankara 2015; *Çağlar H./,Kaşak E., Anonim Şirkete Ait Taşınmazların Satımında Temsil ve Ehliyet Soruları*, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010, C.1, s. 61-85; *Çağlar, H./Kaşak, E., "Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshine İlişkin TTK'm 531 Hükmünün Zaman Bakımından Uygulanması"*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 65, S.3, s. 659-686; *Yılmaz, A., "Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim ve Limited Şirketlerde Ek Tasfiye"*, Banka ve

Ticaret Hukuku Dergisi, 2016, C. 32, S. 2, s. 149- 173; *Yördem, Y.*, Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğunda Farklılaştırılmış Teselsül İlkesi, Ankara 2017; *Akdağ Güney, N.;* Anonim Şirket Yönetim Kurulu, 2. Baskı, İstanbul 2016.

I- ANONİM ŞİRKETLERİN SONA ERMESİ VE TASFİYE

A) ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Tüzel kişiliğe sahip olan anonim şirketin sona erme sebepleri, Kanunda infisah (kendiliğinden sona erme) ve fesih (bir iradeye bağlı olarak sona erme) şeklinde ikiye ayrılarak sayılmıştır.

1. İnfisah Sebepleri

Kanunda veya esas sözleşmede öngörülen sebeplerin gerçekleşmesi sonucunda başka bir karar alınmasına gerek olmaksızın şirketin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebepler aşağıda açıklanmıştır.

a) Sürenin Sona Ermesi

Anonim şirketler belirli süreli veya sözleşmede herhangi bir süre öngörülmeyerek belirsiz süreli olarak kurulabilir (TTK m.339/2-ı). Bunun yanında esas sözleşmesinde belirli bir süre öngörülen anonim şirket, sürenin sona ermesine rağmen faaliyetlerine devam etmek suretiyle belirsiz süreli şirkete tahvil edilebilir (TTK m.529/1-a)[388].

Şirketin belirli bir süre için kurulması halinde sürenin dolmasıyla şirket sona ermiş sayılır. Ancak Kanundaki düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, yalnızca şirketin faaliyetlerine devam etmemesi halinde bu sona erme sebebi gerçekleşir ve şirket tasfiye aşamasına girer. Özellikle gayri faal şirketler bakımından gerçekleşecek bu sona erme sebebi, çalışmalarına devam eden ve sürenin dolduğunu fark etmeyen şirketler bakımından bir önem arz etmeyecektir. Eski Kanunda sürenin dolmasına rağmen ticari faaliyetlerini sürdüren şirketlere ilişkin özel bir hüküm olmadığından, bu şirketlerin akıbetleri belirsiz durumdaydı[389].

---

[388] Sürenin dolmasına rağmen faaliyetlere devam edilmesi şirketin belirsiz süreli hale geldiğinin kabulü için yeterli olup; ayrıca esas sözleşmesinin değiştirilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu hususta bkz. **Kendigelen,** İlk Tespitler, s. 375.

[389] **Pulaşlı,** C. III, s. 2388-2390; § 60- 12-20.

Buna karşılık yeni TTK ile söz konusu belirsizlik giderilmiş ve bu şirketlerin belirsiz süreli şirket haline gelecekleri kabul edilmiştir (m.529/1-a).

Şirketin süresinin dolması ve faaliyetlerine devam edilmemesi halinde şirket infisah etmiş olur; ama hala ticaret sicilinde aktif bir şirket olarak görünmeye devam eder. Bu durumda ortakların, şirketin infisah ettiğinin tespiti için dava açması gerekir. Mahkeme, şirketin süresinin dolmasına karşın faaliyetlerine devam etmediğini belirlemek suretiyle infisahın varlığını tespit ederek şirketin sicilden terkinini sağlar.

b) İşletme Konusunun Gerçekleşmesi veya Gerçekleşmesinin İmkânsız Hale Gelmesiyle

Anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde işletme konularının yazılması kuralı varlığını muhafaza etmiştir (TTK m.339/2-b). Hak ve fiil ehliyetinin sözleşmede yazılı konularla sınırlı olduğuna ilişkin *ultra vires* kuralı yeni TTK'ya alınmamış olmasına karşın, esas sözleşmede şirketin faaliyet konusunun yazılı olması aranmıştır. İşletme konuları, anonim şirketin yönetim kurulunun temsil yetkisinin olağan sınırlarının çizilmesinde dikkate alınmaktadır (TTK m.371/1, 2).

6762 sayılı Kanundaki (m.434/1, b.2) sona erme sebebi olan ortaklığın maksadının (amacının) gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkânsız hale gelmesi şeklindeki düzenleme aynen yeni Kanuna alınmamıştır. Mevcut TTK'da, anonim şirketin *amacını* değil *işletme konusunu* elde etmesi sona erme sebebi olarak kabul edilmiştir. Madde gerekçesinden, ortaklığın kazanç elde etmek ve paylaşmak olarak tarif edilen amacına ulaşması veya ulaşmasının imkânsız hale gelmesinin nesnel olarak belirlenemeyeceği varsayımından hareketle konu kavramının tercih edildiği anlaşılmaktadır. Ancak işletme konusu, anonim şirketin faaliyet gösterdiği ticari alanlardır. Turizm, otelcilik, madencilik, taşımacılık gibi sayılabilen söz konusu işletme konularının elde edilmesi, pratik hayatta gerçekleşmeyecek niteliktedir. Şirketin sadece somut bir konu için kurulması halinde, onun elde edilmesi veya elde edilmesinin imkânsız hale gelmesi durumunda söz konusu sona erme sebebi hayata geçebilir. Mesela, İstanbul Yavuz Sultan Selim köprüsünü (3. Köprü) inşa etmek ve işletmek için kurulan anonim şirket, inşaat tamamlanmasına rağmen köprü ve çevre yollarını işletmeye devam ettiği için faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak köprünün işletme süresi bitip devlete devredilmesinden sonra söz konusu anonim şirket

işletme konusunu elde ettiği için başkaca bir faaliyette bulunmayacaksa sona erecektir.

İşletme konusunun elde edilmesinin imkânsız hale gelmesi, ancak söz konusu faaliyet konusunda çalışılmasının artık mümkün olmaması durumunda ortaya çıkar. Faaliyetin doğal olarak yapılamaması veya devlet ya da yargı kararıyla yasaklanması halinde bu durum gerçekleşir. Şirketin işletme konusu tek olmadığı sürece, bir tane işletme konusu imkânsız hale gelse de diğer konular üzerinden şirket faaliyetlerini sürdürmeye devam eder. Bu bağlamda şirketin tüm ticari işletmesini devretmesinin şirketi sona erdireceği kabul edilmektedir[390].

c) Esas Sözleşmede Sayılan İnfisah Sebebinin Gerçekleşmesi

Anonim şirket esas sözleşmesine infisah sebeplerinin yazılması uygulamada pek karşılaşılmayan bir durumdur. Ancak arzu edilmesi halinde sözleşmeye yazılacak kayıtların gerçekleşmesi ile şirketin kendiliğinden sona ereceği kararlaştırılabilir (TTK m.529/1-c). Şirketin faaliyet konusu ile ilgili bazı olayların gerçekleşmesi, mesela şirketin maden ruhsatının iptal edilmesi, elektrik üretim lisansının süresinin dolması, şirketin uzun süre zarar etmesi gibi kayıtlar infisah sebebi olarak öngörülebilir[391].

d) Şirket Sermayesinin 2/3'ünün Karşılıksız Kalması

6102 sayılı TTK'de sona erme sebepleri arasında özel olarak gösterilmemekle birlikte m.529/1-f bendinde, *kanunlarda öngörülen diğer hallerde* denilmek suretiyle, anonim şirketin sermayesinin (en az) 2/3'ünün karşılıksız kalması ve kanunda sayılan önlemlerin alınmaması hali de infisah sebebi olarak bu kapsamda değerlendirilir.

TTK m.376/2 hükmünde, sermayenin ve yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kalması halinde yönetim kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırır. Genel kurul sermayenin üçte biri ile yetinme (sermayenin azaltılması) ya da sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirketin kendiliğinden sona ereceği belirtilmiştir[392].

---

390 **Pulaşlı,** C. III, s. 2392, § 60-23, 24.

391 **Pulaşlı,** C. III, s. 2393, § 60-27-28; **Bahtiyar,** M.: Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesi, İstanbul 2001 s. 207.

392 Bkz. 15.05.2018 Tarih ve 30536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticaret Bakanlığının 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği m. 11.

e) Anonim Şirketin İflası

Mahkemece anonim şirketin iflasına karar verilmesi halinde, şirket infisah eder. Mahkemeye şirket yönetim kurulu, sermayenin karşılıksız kalması sebebiyle başvurabileceği gibi, şirket alacaklılarının alacaklarını takip için de başvurmaları mümkündür. Her iki halde, şirketin gerekli önlemleri almaması, depo kararının gereğini yerine getirmemesi halinde mahkeme iflas kararı verebilir.

2. Fesih Sebepleri

Fesih, Kanunda ya da esas sözleşmede öngörülen sebeplerin gerçekleşmesi sonucunda mahkemenin veya genel kurulun iradesi ile şirketin sona erdirilmesidir. İnfisah halinden farkı, şirketin ayrı bir irade beyanıyla sona erdirilmesidir.

3. Genel Kurul Kararıyla Fesih

Anonim şirketin karar organı olan genel kurul, özel bir sebep gözetmeksizin, şirketin feshedilmesine yönelik kararı, TTK m.421/3 ve 4. fıkralardaki yetersayılara uygun şekilde alabilir (TTK m.529/1-d). Buna göre genel kurulda fesih kararları, sermayenin yüzde yetmiş beşini oluşturan pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda söz konusu yetersayıya ulaşılamaması halinde izleyen toplantılarda da aynı yetersayı aranır. Dolayısıyla fesih kararı alınabilmesi için, esas sözleşmede önemli değişikliklerin yapılabilmesi bakımından gerekli olan yetersayının tesis edilmesi gereklidir.

Bunun dışında anonim şirketin başka bir şirketle birleşmesi (TTK m.136) veya tam bölünme suretiyle sona ermesine (TTK m.159/1) yönelik kararlar da yine genel kurul tarafından Kanunda öngörülen gerekli yetersayılara uyularak verilir.

4. Mahkeme Kararıyla Fesih

Kendisine yetki verilmiş olan kişi ya da makamların başvurması üzerine, yetkili ve görevli mahkeme gerekli incelemeleri yaptıktan sonra şirketin sona ermesine ilişkin fesih kararı verebilir. Ancak şirketin feshedilmesinden ziyade yaşatılması önem taşıdığından, mahkeme fesih kararı almadan önce gerekli uyarılarını yaparak önlemlerin alınmasını ister. En son çare olarak fesih kararını alarak şirketin sona ermesini sağlar.

Aşağıda Ticaret Kanununda yer alan fesih halleri incelenmiştir:

a) Şirketin Zorunlu Organlarının Mevcut Olmaması

Anonim şirketlerde zorunlu organ olarak genel kurul ve yönetim kurulunun bulunduğu daha önce izah edilmişti. Bu bağlamda şirketin zorunlu organlarının bulunmaması veya genel kurulun uzun süre toplanamaması, şirketin sona erme sebepleri olarak düzenlenmiştir (TTK m.530). Zorunlu organların bulunmaması halinde pay sahipleri, şirket alacaklıları ve Ticaret Bakanlığı şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurarak şirketin sona erdirilmesini isteyebilir. Mahkeme kendisine yapılan başvuru üzerine şirket yönetim kurulunu dinleyerek şirketin durumunun kanuna uygun hale getirilmesi için bir süre verir. Bu süre içinde durum düzeltilmezse mahkeme şirketin feshine karar verir (TTK m.530/1).

Şirketin genel kurulunun uzun süreden beri toplanmaması ve yönetim kurulunun bulunması halinde mahkemenin süre vermesi ve eksikliğin giderilmesi yönündeki uyarısının bir anlamı olabilir. Buna karşılık yönetim kurulu üyelerinin süresinin dolması, ölmesi, istifa etmesi ve yerine yenisinin seçilmemiş olması halinde şirketin fiilen bir yönetim kurulu bulunmayacaktır. Buna ilaveten yönetim kurulunun uzun süreden beri toplanamaması hali de organ yokluğuna delalet edebilir. Bu durumda mahkeme, özellikle davayı açan tarafın isteği üzerine, şirkete bir yönetim kayyımı atayarak genel kurulu toplantıya çağırması ve genel kurulun yeni üye/üyeler seçerek yönetim kurulunu yeniden faaliyete geçirmesini sağlamaya çalışabilir (TTK m.530/2). Verilen süreye rağmen gerekli kararlar alınamazsa veya genel kurul toplanamazsa mahkeme şirketi fesheder[393].

b) Kamu Düzenine ve İşletme Konusuna Aykırı Faaliyetlerde Bulunmak

Kanun koyucu, anonim şirketlerin sürekli şekilde kamu düzenine ve işletme konusuna aykırı harekette bulunmaları halinde, Ticaret Bakanlığına şirketin feshi için dava açma hakkı tanımıştır (TTK m.210/3). Bakanlığın şirketler üzerindeki denetim yetkisini düzenleyen ilgili hükümde, şirketlerin kamu düzenine ve işletme konusuna aykırı faaliyet-

[393] Ayrıntılı bilgi için bkz. **Soykan,** s. 255 vd.

lerinin yanı sıra bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında fesih davası açılabileceği belirtilmiştir. Bakanlığın fesih davası açma yetkisi, bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıllık süreye bağlanmıştır (TTK m.210/3)[394].

c) Şirket Esas Sözleşmesinde Öngörülen Fesih Sebeplerinin Gerçekleşmesi

Anonim şirket esas sözleşmesinde şirketin feshi için bazı sebepler öngörülebilir (TTK m.529/1-c). Uygulamada çok sık karşılaşılmamakla beraber, şirketin faaliyetlerinin durması, pay sahibinin ölmesi, belirli bir süre kâr elde edememesi gibi sebepler öngörülerek özellikle şirket pay sahiplerine fesih davası açma imkânı verilebilir.

d) Anonim Şirketin Haklı Sebeple Feshi

Anonim şirketlerde uzun süreden beri, ortakların şirketten ayrılabilmeleri için paylarını devretmeleri imkânı bulunmaktadır. Ancak ortağın payını devredememesi veya devrin çeşitli bağlam hükümleri ile sınırlandırılmış olması ya da devrin yönetim kurulu tarafından farklı gerekçeler ileri sürülerek pay defterine kaydedilmesinden kaçınılması hallerinde şirketten çıkma imkânı neredeyse ortadan kalkmaktadır. Bu durumda ortakların istemedikleri bir şirkette ortak olarak kalmaya zorlanmaları söz konusu olmaktadır.

Evvelki Kanunda alternatif bir çözüm yolu olmamasına karşın mevcut Kanunda, oldukça önemli bir yenilik yapılarak *anonim şirketin haklı sebeple feshi* imkânı öngörülmüştür (TTK m.531)[395].

aa) Kanundaki Düzenleniş Şekli

Anonim şirketlerin haklı sebeple feshini düzenleyen TTK m.531, fesih davasını azınlık pay sahiplerinin açabileceğini, mahkemenin fesih yerine başka bir çözüm yolu bularak bunu uygulayabileceğini hükme bağlamıştır.

---

394 Ayrıntılı bilgi için bkz. Üçüncü Bölüm, § 5, II, E, 2.

395 Haklı sebeple fesih ve özellikle zaman açısından uygulanması için bkz. **Çağlar, H./Kaşak, E.**, *"Anonim Şirketin Haklı Nedenle Feshine İlişkin TTK m 531 Hükmünün Zaman Bakımından Uygulanması"*, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 65, S.3, s. 659 vd.

Kanundaki düzenlemeye göre haklı sebeplerin varlığı halinde, sermayenin en az onda biri (%10) ve halka açık anonim şirketlerde yirmide birini (%5) temsil eden pay sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme kendisine yapılan müracaat üzerine fesih yerine, davacı pay sahiplerine paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerinin ödenip şirketten çıkarılmalarına veya durumun niteliğine uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

bb) Haklı Sebep Kavramı

Kanun koyucu, anonim şirketlerin feshi bakımından *haklı sebep* kavramını izah etmemiştir. Haklı sebep, ortakların şirketten umdukları faydayı elde edememeleri, süreklilik arz eden şirket ilişkisine devam etmeyi çekilmez hale getirdiği kabul edilen maddi ve hukuki olaylar şeklinde geniş olarak tanımlanabilir[396]. Mahkeme, önüne gelen davada ileri sürülen sebeplerin fesih için haklı olup olmadığına takdir hakkı çerçevesinde kendisi karar verecektir.

Haklı sebeple ilgili olarak kollektif şirketler bakımından TTK m.245'te özel bir düzenleme yer almaktadır[397]. Söz konusu hükümde genel olarak haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili ve kişisel sebeplerin, şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkânsız kılacak veya güçleştirecek şekilde ortadan kalkmış olması, şeklinde tarif edilmiştir. Bunun yanı sıra aynı maddede, dört bent halinde örnek babından haklı sebepler sayılmıştır. Maddede sayılan haklı sebeplerin, anonim şirketlerin niteliğine uygun düştüğü ölçüde burada da uygulanabileceğini söylemek gerekir.

Anonim şirketlerde haklı sebepler daha çok, çoğunluğun sahip olduğu idare ve temsil gücünü iyiniyet kurallarına aykırı şekilde kullanarak azınlığa zarar vermesi şeklinde karşımıza çıkar. Bununla birlikte istisnaen de olsa azınlık pay sahiplerinin kanunen kendilerine tanınan haklarını kötüye kullanmaları halinde de haklı sebep hali ortaya çıkabilir. Bu bağlamda, şirketin kâr etmesine rağmen uzun süre kâr payı dağıtmaması, şirketin sahip olduğu tek ticari işletmesinin kiraya verilmesi, eşit işlem ilkesine aykırı hareket edilmesi, şirket yöneticilerinin

---

396 Farklı tanımlar için bkz. **Erdem,** 100 vd.; **Şahin,** s. 106 vd.

397 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yukarıda ???

yüksek miktarda mali haklar alması, genel kurul kararlarının uygulanmaması, şirketin kötü yönetilmesi gibi sebepler, fesih için haklı sebeplere örnek olarak verilebilir[398].

cc) Haklı Sebeple Fesih Davasında Usul

Haklı sebeple fesih davasının usulüne ilişkin özel kurallar TTK m.531'deki düzenlemede yer almamıştır. Sadece fesih davasına bakacak olan mahkemenin şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi olduğu ve davacı sıfatının anonim şirketin azınlık pay sahiplerine ait olduğu belirtilmiştir.

Davanın açılabileceği süreye ilişkin kanun koyucunun özel bir tercihi bulunmamaktadır. Kanunda herhangi bir zamanaşımı veya iptal davası olmasa da haklı sebeplerin ortaya çıkmasından çok uzun bir süre sonra açılacak fesih davasının TMK m.2'ye aykırı olduğu iddiası gündeme gelebilir. Bu arada haklı sebebin ortadan kalkması halinde dava açma hakkı düşebilir. Bu nedenle, haklı sebebin kesintisiz bir şekilde devam etmesi halinde münasip bir zaman içerisinde davanın açılması doğru olur.

Haklı sebeple fesih davasında ortaya çıkan bir diğer usul meselesi, davanın açılması esnasında şirketin feshi istenmesine rağmen daha sonra hâkimin farklı bir çözüm yoluna karar vermesi meselesidir. Yargılamaya hâkim olan ilkeler arasında sayılan taleple bağlılık ilkesine göre, hâkim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır (HMK m.26). Ancak TTK m.531'de açıkça hâkimin durumun gereklerine uygun düşen bir diğer çözüm yolunu kabul edebileceği belirtildiği için, bunun HMK m.26'ya istisna getiren özel hüküm niteliğinde olduğu kabul edilerek yargılamanın yapılması mümkün sayılmalıdır.

dd) Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Hâkimin Verebileceği Kararlar

Anonim şirketin haklı sebeple feshi davasına bakan mahkemenin, fesih yerine iki farklı şekilde karar verebileceği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir (TTK m.531).

Mahkeme ilk olarak, davacı pay sahiplerinin paylarının bedeli ödenerek şirketten çıkarılmalarına karar verebilir. Şirketin feshi halinde

---

[398] Örnekler için bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 14-12; **Erdem,** s. 111 vd.; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 384; **Şahin,** s. 137 vd.; **İlbasmış Hızlısoy,** s. 83 vd.

ticari faaliyetlerinin sona ermesi, çalışanların işsiz kalması gibi birçok sakıncalar, davacı ortakların paylarının alınarak şirketten çıkarılmaları halinde ortaya çıkmayacaktır.

Mahkeme, ortakların çıkarılmaları için payların karar tarihine en yakın tarihteki değerini bilirkişiler tarafından tespit ettirir. Daha sonra vereceği karar ile bu bedelin ödenerek ortakların şirketten çıkarılmalarına hükmeder. Bu durumda payların bedeli şirket tarafından ödenerek alınan paylar diğer pay sahiplerine ya da üçüncü kişilere devredilebilir. Payların bedelinin, yeterince bulunması halinde şirketin serbest yedeklerinden ödenmesi söz konusu olabilir. Serbest yedeklerden ödenmesi halinde herhangi bir sıkıntı olmamakla birlikte sermaye kaleminden ödeme yapılabilmesi ancak sermayenin azaltılması yolu ile mümkün olacaktır[399].

Kanun koyucu hâkime, duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilmesi konusunda takdir yetkisi vermiştir. Davanın durumuna göre, fesih ya da ortakların çıkarılmaları yerine başka bir çözüm yolu bulunabilir. Bu bağlamda öğretide kabul edilen ancak uygulamada hâkimlerin fazla başvurmadığı çözüm önerileri şu şekilde sıralanabilir[400]:

Davacıların haklı sebep olarak ileriye sürdüğü sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik önlemler alınabilir. Bu bağlamda, şirketin kâr payı dağıtması, ortakların bilgi alma haklarının kullanmalarının sağlanması, azınlık pay sahiplerinin yönetimde temsiline imkân tanınması gibi esas sözleşme değişiklikleri yapılarak kalıcı hale gelen önlemler akla gelebilir.

Hâkim anonim şirketin faaliyetlerinin müsait olması durumunda şirketin *bölünmesine* karar vererek her pay sahibi grubunun faaliyetlerine ayrı ayrı devam etmelerini sağlayabilir. Şirketin yönetim kurulunun değiştirilmesi veya seçilen bağımsız denetçilerin yerine yenilerinin seçilmesi gibi ihtimaller de önerilebilir.

II) ANONİM ŞİRKETİN TASFİYESİ

İnfisah ya da fesih sonrasında ticaret sicilinden terkin edilene kadar geçen süreçte anonim şirket tasfiye aşamasında bulunur. Şirketin tüzel

---

399 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 14-13; **Erdem,** s. 279-280; **Şahin,** 438-440; **Çağlar**, Sermayenin Azaltılması, s. 23 vd.

400 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 14-13b; **Erdem,** s. 241 vd.

kişiliği devam etse de faaliyetleri eskisine nazaran kısıtlanır ve sadece tasfiyeye yönelik işlemler yapılabilir. Ayrıca şirketin organları varlığını devam ettirse de yetkileri konusunda kanuni bazı kısıtlamalar söz konusu olur.

Tasfiye dönemi, şirketin tüzel kişiliğinin devam ettiği, üçüncü kişilerle ve kamu ile olan tüm borç-alacak ilişkilerinin sona erdirildiği, kalan bakiyenin ortaklara tasfiye payı olarak dağıtıldığı, akabinde şirketin sicil kaydının silinerek tüzel kişiliğin sona erdirildiği zaman aralığı olarak karşımıza çıkar.

A. TASFİYE HALİNDEKİ ANONİM ŞİRKETİN ÖZELLİKLERİ

Anonim şirket hakkında sona erme sebeplerinden birisi gerçekleştikten sonra borç-alacak ilişkilerinin bitirilmesine yönelik olarak şirketin tasfiye aşamasına geçilir. Bu aşamaya geçiş için ayrı bir karar alınması veya işlem yapılmasına gerek yoktur. Sona erme sebebi gerçekleşince şirket kendiliğinden tasfiye aşamasına geçer (TTK m.533/1).

Sona erme hali, mahkeme kararı veya iflas dışındaki bir sebepten dolayı ortaya çıkmışsa, şirket yönetim kurulu durumu ticaret siciline tescil ve ilân ettirir (TTK m.532). Buna karşılık feshe ya da iflasa karar veren mahkeme, durumu kendiliğinden ticaret siciline bildirerek tescil ve ilân işlemlerinin yapılmasını sağlar.

1) Şirketin Tüzel Kişiliği Varlığını Sürdürür

Şirket sona ermesine rağmen tasfiye işlemlerinin sonuna kadar tüzel kişiliği devam eder. Tüzel kişilik, tüm tasfiye işlemleri bittikten sonra, şirket yöneticilerinin ticaret siciline başvurarak şirketin sicil kaydını terkin ettirdiği zaman ortadan kalkar (TTK m.533/2).

2) Şirketin Amacı Değişir

Tüzel kişiliğin amacı, kendiliğinden tasfiye amacına dönüşür. Bundan sonra şirket kural olarak sadece tasfiyeye yönelik işlemler yapabilir; bu yönde hak elde eder ve borç altına girebilir (TTK m.533/2-son). Dolayısıyla şirketin hak ve fiil ehliyeti de aynı şekilde tasfiye işlemleriyle kısıtlanmış ve değişmiş olur. Bu bağlamda şirket organlarının da yetkileri sınırlanır ve şirket organları sadece tasfiyeye yönelik işlemler yapabilir. Bu aşamada şirketin tasfiyeden çıkmadan yeni bir ihaleye girmesi, yeni yatırım yapması vs. kural olarak mümkün değildir. Söz konusu işlemler, yapan kişinin yetkisiz temsilci hükümleri

çerçevesinde kendi sorumluluğunu meydana getirir. Sadece tasfiyeye yardımcı olmak, mevcut işi tamamlamak amacıyla kısa süreli iş alınabilir.

3) Şirketin Ticaret Unvanı Zorunlu Ek Alır

Ticaret unvanına kural olarak ek alınması ihtiyaridir (TTK m.46). Buna karşılık belirli hallerde kanun koyucu üçüncü kişilerin yanılmalarını önlemek amacıyla, ticaret unvanına ek alınmasını zorunlu kılmış olabilir. Ek alınmasının zorunlu olduğu hallerden birisi de şirketin tasfiye aşamasına girmesidir. TTK m.533/2 hükmüne göre, tasfiye aşamasına giren anonim şirketin ticaret siciline tescil edilmesi ile birlikte unvanına "*tasfiye halindedir*" ibaresinin eklenmesi zorunludur. Böylece şirketle iş yapan üçüncü kişilerin, şirketin tasfiye halinde olduğunu başkaca bir gayret sarf etmeden öğrenmeleri sağlanmış olur.

4. Şirketin Organları Varlığını Sürdürür

Anonim şirketin zorunlu iki organı olan genel kurul ve yönetim kurulu tasfiye aşamasında da görevlerini sürdürür.

Esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru seçilmemişse *yönetim kurulu*, tasfiye memuru sıfatıyla da işlemleri yürütür (TTK m.536/1). Şirketin tasfiye işlemlerini yürütmeleri için şirkete ayrı tasfiye memuru seçilebilir. Bu durumda yönetim kurulu, tasfiye memurları tarafından yapılmayan işlemlerle sınırlı olarak faaliyetlerini sürdürür. Yönetim kurulu daha çok tasfiye işlemlerine nezaret etmek, tasfiye memurlarının gözetimini sağlamak şeklindeki bir yapıya bürünür.

Genel kurulun, tasfiye sürecinin uzun sürmesi halinde toplanıp karar alması gerekebilir. Aynı şekilde tasfiye işlemlerinin gerektirmesi halinde esas sözleşmenin değiştirilmesi, tasfiye aşamasında şirketin önemli miktarda malvarlığının satışının sağlanması, zorunlu olması halinde sermayenin azaltılması, süresi biten yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının görev sürelerinin uzatılması veya yerlerine yenisinin seçilmesi, yönetim kurulu ve tasfiye memurlarının ibra edilmesi gibi konularda genel kurulun toplanıp karar alması gereklidir.

B) TASFİYE MEMURLARI

Anonim şirketin tasfiye aşamasındaki işlemleri bir ya da daha fazla kişi olabilen tasfiye memurları tarafından yerine getirilir. Daha önce

ifade edildiği üzere, ayrı bir tasfiye memuru belirlenmemişse, şirketin idare ve temsil organı yönetim kurulu, tasfiye memuru sıfatıyla gerekli işlemleri yapabilir. Dolayısıyla anonim şirketlerde, tasfiye memurunun atanmaması sebebiyle şirket yönetiminin kilitlenmesi ihtimali oldukça düşüktür. Her hâlükârda şirket yönetim kurulu tasfiye memuru sıfatıyla işlemleri yerine getireceğinden mahkemeye başvurarak tasfiye memurunun atanmasının istenmesi sadece yönetim kurulu üyelerinin bulunmaması veya yönetim kurulu üyeleri arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle yönetim kurulunda karar alınamaması halinde söz konusu olur.

C) ATANMALARI VE GÖREVDEN ALINMALARI

Tasfiye memurları esas sözleşme ile tayin edilebilir (TTK m.536/1). Tasfiye memurları ismen gösterilebileceği gibi yalnızca sayı ve özellikleri (örneğin bir avukat veya muhasebeci yahut bir kurumun başkanı gibi) tasfiye memurunun belirlenmesine ilişkin ilkeler de konulabilir. Esas sözleşmede bu yönde bir düzenleme bulunmadığı takdirde genel kurulun tasfiye aşamasına girmiş olan şirkete tasfiye memuru ataması gerekir. Genel kurul, kendi takdirine göre, şirketin işlerini yürütebilecek nitelikte, mevcut ortaklar arasından veya yönetim kurulu üyelerinden ya da üçüncü kişiler arasından seçeceği kişi/kişileri tasfiye memuru olarak tayin edebilir (TTK m.536/1).

Tasfiye memurunun olağan atanma hali olan esas sözleşme ya da genel kurul kararı dışında istisnai iki durumda mahkeme kararı ile tasfiye memurlarının atandığına tanık olunabilir. İlk olarak şirketin feshine mahkemenin karar vermesi halinde, tasfiye memuru da mahkeme tarafından tayin edilebilir (TTK m.536/3). İkinci olarak, tasfiye halindeki anonim şirketin pay sahiplerinin haklı talebi üzerine ve sebeplerin varlığı halinde, mahkeme tasfiye memurlarını görevinden alabilir yerlerine yenilerini atayabilir. Bu şekilde atanan tasfiye memurları, mahkeme kararına dayanılarak tescil ve ilân olunurlar (TTK m.537/2).

Tasfiye memuru atanması için esas sözleşmede aksine bir düzenleme yoksa özel bir şart aranmaz. Sadece tasfiyeye yetkili memurların en az birisinin Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gereklidir (TTK m.536/4).

Yukarıda izah edilen üç şekilde tayin edilen tasfiye memurları, yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilân edilirler. Ayrıca tasfiye memuru seçilmemesi sebebiyle yönetim kurulunun bu sıfatla görev yapacağı hallerde de bu defa yönetim kurulunun tasfiye memuru

sıfatıyla sicile tescil ve ilân edilmesi gerekir (TTK m.536/2). Aksi halde, yani tasfiye memurlarının hiçbirinin Türk vatandaşı olmaması ve Türkiye'de ikamet etmemeleri halinde, pay sahiplerinin, alacaklıların ve Bakanlığın başvurusu üzerine mahkeme, bu özelliklere sahip birini tasfiye memuru olarak atar (TTK m.537/3). Bu durumda diğer tasfiye memurlarını görevden almayıp, onların yanına yeni birisini atayarak kanuni şartı sağlayabilir.

Tasfiye memurları esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla atansalar bile veya bu görevi yönetim kurulu üyeleri yerine getiriyorsa, her zaman genel kurul kararı ile azledilebilirler (TTK m.537/1). Sadece mahkeme kararı ile tayin edilen tasfiye memurlarının görevden alınmaları yine mahkeme kararına tâbi olmalıdır. Bunun dışında esas sözleşme veya genel kurul kararıyla atanmış olan tasfiye memurlarının haklı sebeple azledilmeleri yine talep üzerine mahkeme kararına bağlıdır (TTK m.537/2).

Tasfiye memurları esas olarak, tasfiye halindeki anonim şirketin tüm idare ve temsil yetkisine sahiptir. Bu bağlamda şirketin devam eden işlerini bitirmek, ortaklardan veya üçüncü kişilerden alacakların tahsili için dava açmak ve icra takibi yapmak veya bunun için vekalet vermek, ara bilanço çıkararak şirketin içinde bulunduğu aktif-pasif durumunu tespit etmek gibi tasfiyeye yönelik işlemler tasfiye memurları tarafından yerine getirilir.

Tasfiye memurları idare ve temsil yetkisine sahip olsalar da özellikle genel kurulun yetkilerini kullanamaz. Bu bağlamda esas sözleşmenin değiştirilmesi, yönetim kurulu üyelerinin ve tasfiye memurlarının atanması, önemli miktarda aktiflerin toptan satılması, kâr dağıtımı kararı alınması gibi konularda sadece genel kurul tarafından karar alınabilir. Bununla birlikte genel kurul kararıyla aksi kararlaştırılmamışsa, tasfiye memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla satabilirler (TTK m.538/1).

Kanunen sadece tasfiye işlemleri ile yetkilendirilen tasfiye memurları, bunların dışında kalan işlemleri yapamazlar. Tasfiye memurları kendilerine verilen görevleri kural olarak bizzat yerine getirmek zorundadır. Bununla birlikte, belirli uygulama işlemlerinin yapılabilmesi için tasfiye memurlarından biri diğerine veya üçüncü kişilere temsil yetkisi verebilir. Mesela davaların takibi için şirket adına avukata vekâlet verme tasfiye memuru tarafından yapılır.

Tasfiye memurlarının temsil yetkisinin sınırları, yönetim kurulunun temsil yetkisine benzer şekilde çizilmiştir. Buna göre, tasfiye memurlarının üçüncü kişilerle tasfiye dışında yaptıkları işler şirketi bağlar. Üçüncü kişilerin, yapılan işlemin tasfiye amacının dışında olduğunu bildiği veya hâlin gereğinden bilmemesinin mümkün olamayacağı hallerde işlem şirket açısından bağlayıcı olmaz. Bu bağlamda, tasfiyenin sadece tescil ve ilân edilmiş olmasının bu hususun ispatı bakımından yeterli olmayacağı kabul edilmiştir (TTK m.539/2)[401]. Şirketin tasfiye aşamasına girmesi halinde ticaret unvanına "tasfiye halindedir" ibaresinin ekleneceği ve şirketle işlem yapan herkesin bunu göreceği dikkatten kaçırılmamalıdır. Bu bakımdan, tek başına ticaret siciline tescilin üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırmayacağı açıkça hükme bağlanmakla beraber şirketin unvanını gören kişilerin iyiniyetinin ortadan kalkacağı kabul edilmelidir.

Yönetim kurulunun şirketi temsil etmesindeki usulde olduğu gibi, sayıca birden fazla olan tasfiye memurlarının şirketi bağlayıcı hukuki işlem yapabilmeleri için en az iki tasfiye memurunun şirketin ticaret unvanı altında imza atması gerekmektedir. Bunun aksi esas sözleşmede veya genel kurul kararında öngörülebilir ve tek bir tasfiye memurunun imza atması mümkün olabilir (TTK m.539/3).

Tasfiye memurlarının görevlerini ifa etmeleri esnasında işledikleri haksız fiilden, şirket tüzel kişiliği de sorumlu tutulur (TTK m.539/4).

Tasfiye işlemleri esnasında şirketin tüm faaliyetlerinin yürütülmesi, nakit akışının kontrol edilmesi, malvarlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması, tasfiye işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve güvenliği için gerekli defterlerin tutulması, pay sahiplerine talep etmeleri halinde tasfiye hakkında bilgi verilmesi, şirket borçlarının şirket varlıklarından fazla olması halinde durumu şirket merkezindeki asliye ticaret mahkemesine bildirerek iflası talep etmesi gibi konular tasfiye memurlarının kanunla gösterilen görevleri arasında sayılmıştır (TTK m.542).

D) TASFİYE İŞLEMLERİ

Tasfiye işlemleri, esasen tasfiye memurları tarafından ve aynı zamanda onların görevi olarak kabul edilen iş ve işlemleri ifade eder.

---

401 Yönetim kurulunun temsil yetkisinin sınırlarının çizilmesinde benzer şekilde düzenlenmiş bulunan TTK m. 371/2 hakkındaki tartışma ve açıklamalar hakkında bkz. Yedinci Bölüm, § 10, V, B, 2.

1. Envanter ve Bilanço Hazırlanması

Tasfiye memurlarının göreve başladıktan sonra yapmaları gereken ilk işleri, şirketin içinde bulunduğu mali durumu tespit edebilmek amacıyla, envanter ve bilanço hazırlayarak bunu genel kurulun onayına sunmaktır. (TTK m.540). Gerekirse malvarlığı unsurlarının değerini belirleyebilmek için uzmanlara başvurarak şirketin gerçek mali durumunu ortaya çıkarmalıdırlar. Hazırlanan evraklar, anonim şirketin tasfiye aşamasının ilk envanter ve bilançosudur. Buna ilaveten tasfiyenin uzun sürmesi halinde her yılın sonunda ayrıca bilanço hazırlanarak genel kurula sunulur (TTK m.542/1-d).

Tasfiye memurları ilk envanter ve bilançonun çıkarılmasını müteakiben, şirketin envanterinde kayıtlı tüm malları ile defter ve belgelerine el koyarlar. Böylece şirketin kâğıt üzerindeki değil gerçek anlamda mali durumunu görerek tasfiye işlemlerini yönetirler veya gerekiyorsa şirketin iflasını mahkemeden isterler.

2. Alacaklılara Davet

Tasfiye aşamasındaki önemli işlerden birisi de şirketin alacaklılarına ulaşarak alacakların ödenmesidir. Bunun için tasfiye memurları, öncelikle şirketin kayıtlarından alacaklı olduğu anlaşılan ve adresleri bilinen kişilere taahhütlü mektup ile bunun yanında ticaret sicil gazetesi ve şirketin internet sitesinden birer hafta arayla yapılacak üç ilânla şirketin sona ermiş olduğu ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağırırlar (TTK m.541/1).

Alacaklarını bildiren veya alacaklı olduğunu gösterir belgeleri (mesela kambiyo senedi) sunan alacaklıların alacakları ödenir. Alacaklarını bildirmeyen fakat şirket kayıtlarında yer alanların tutarı Bakanlık tarafından belirlenen bir bankaya depo edilir (TTK m.541/2).

Ayrıca şirketin henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan alacaklar, yeterli bir teminata bağlanmadıkça veya şirket varlığının pay sahipleri arasındaki paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olmadıkça, bunları karşılayacak tutardaki para notere depo edilir (TTK m.542/3)[402]. Henüz vadesi gelmemiş borçlar TC. Merkez

[402] Konuya ilişkin olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/3857 Esas, 2017/2499 Karar sayılı ve 27.04.2017 tarihli kararında notere yeterli paranın tevdi edilmemesinden dolayı tasfiye memurlarının sorumlu oldukları şu şekilde hükme bağlanmıştır: "... *Davacı vekili, davacının ... Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçisi*

Bankasının kısa vadeli krediler için uyguladığı oran üzerinden iskonto edilerek ödenir. Alacaklılar iskonto edilmiş bu ödemeyi kabul etmek zorundadır (TTK m.542/1-h).

Tasfiye memurları yukarıda açıklanan düzenlemelere aykırı olacak şekilde hareket edip haksız olarak ödeme yapmaları durumunda, bundan dolayı şirkete karşı sorumlu olurlar (TTK m.541/4).

3. Diğer Tasfiye İşleri

Tasfiye memurları yukarıda sayılan hususlar dışında, sona ermeden önce başlamış işlerin bitirilmesi, aktiflerin paraya çevrilmesi işlemlerini tamamlar. Aktiflerin satışı esnasında, genel kurulun aksine bir kararının bulunmaması halinde, tasfiye memurları ihale yerine pazarlık usulünü kullanabilirler (TTK m.538/1).

---

olarak çalıştığını, işçilik alacakları ödenmediğinden adı geçen şirket aleyhine açtığı alacak davasında kabul kararı verildiğini, hükmedilen işçilik alacaklarının tahsili için ilamlı icra takibi başlatıldığını, şirketin fiilen kapanmış olması nedeniyle alacak tahsilinin mümkün olmadığını, şirketin 05.11.2010 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında tasfiye sürecine girdiğini, şirkete tasfiye memuru olarak davalı ...'un tayin edildiğini, şirketin yönetim kurulu üyesi ve tasfiye memuru olan davalıların şirket sermayesini ve öz kaynaklarını ekonomik kullanmadıklarını, şirket personelini ve şirket özvarlıklarını kendi özel ihtiyaçları için kullandıklarını, şirket kayıtlarının usule uygun tutulmadığını, tasfiyenin yasaya ve usule uygun yapılmadığını, şirket alacaklılarından mal kaçırmak için şirketin içinin boşaltıldığını, davalıların kusurları nedeniyle borçtan şahsen sorumlu olduklarını ileri sürerek, alacağın 02.10.2012 takip tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesini talep ve dava etmiştir....

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre; davacının dava dışı ... Kimya A.Ş'den alacağının iş mahkemesince verilen kesinleşmiş ilamı ile sabit olduğu, davalıların dava dışı ... Kimya A.Ş'nin yönetim kurulu üyesi oldukları, davalı ...'un aynı zamanda 13.10.2010 tarihinde tasfiye memuru olarak atandığı, ***adı geçen tasfiye memurunun ihtilaflı durumdaki bu şirket borcu tutarını noterе tevdi etmesi gerektiği, ancak bu görevi yerine getirdiğine dair herhangi bir somut belge bulunmadığı, diğer yönetim kurulu üyelerine atfedilecek bir kusur tespit edilemediği gerekçesiyle,*** fazlaya dair haklar saklı kalmak kaydı ile alacağın 02/10/2012 tarihinden itibaren ticari temerrüt faizi ile birlikte davalılardan ...dan tahsiline, diğer davalılar aleyhine açılan davanın reddine karar verilmiştir...

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Taraf vekillerinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA...

Aktifler paraya çevrildikten, tüm borçlar ödendikten sonra geriye bir tasfiye bakiyesi kalmışsa, esas sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmaması halinde, bu bakiye pay sahipleri arasında ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın bulunması halinde, esas sözleşmedeki düzenleme uygulanır (TTK m.543/1).

Tasfiye bakiyesinin ortaklara dağıtılabilmesi için, alacalılara üçüncü kez çağrı tarihinden itibaren en az altı ay geçmiş olması gerekir. Şirketin içinde bulunduğu duruma göre, alacaklılar için bir tehlikenin olmadığı anlaşıldığı takdirde, mahkeme kararına bağlı olarak altı aylık süre geçmeden de dağıtıma müsaade edilebilir (TTK m.543/2). Esas sözleşme ve genel kurul kararlarında aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, tasfiye bakiyesi para olarak dağıtılır (TTK m.543/3).

Şirketin sona ermeden önceki ticari defterleri ile birlikte tasfiye esnasında tutulan ticari defterler, TTK m.82 uyarınca son kayıt tarihinden itibaren on yıl boyunca tasfiye memurlarının talebiyle sulh hukuk mahkemesi tarafından saklanır (TTK m.544). Böylece eskiye dayalı taleplerin ortaya çıkması halinde, defterlerin delil olma özelliği uzun süre devam edecektir.

E) TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN

Tasfiye işlemlerinin bütünüyle tamamlanmasının ardından, tasfiye memurları şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesini talep ederler. Ticaret sicil müdürlüğü, tasfiye işlemlerinin eksiksiz yapılıp yapılmadığını kontrol ettikten sonra, şirketi ve ticaret unvanını ticaret sicilinden terkin eder (TTK m.545).

F) EK TASFİYE VE TASFİYEDEN DÖNME

Kanun koyucu, önceki Kanunda yer almayan ancak öğreti ve yargı kararları ile kabul edilen iki yeni müesseseyi yeni Kanuna almıştır[403]. Bu bağlamda ek tasfiye (TTK m.547) ve tasfiyeden dönülmesi (TTK m.548) ilk kez kanuni düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tasfiye işlemleri tamamlanmış görünmesine rağmen ilave bazı işlerin ortaya çıkması halinde *ek tasfiye* söz konusu olur (TTK m.547).

---

[403] Ayrıntılı bilgi için bkz. **Al Kılıç, Ş.,** Anonim Şirketlerde Tasfiyeden Dönme, Ankara 2017, s. 7 vd.; **Bilge, M.E.,** "Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi", EÜHFD, C. XVI, S. 3-4, s. 288 vd

Özellikle tasfiye esnasında gözden kaçan bazı malvarlığı unsurlarının sonradan fark edilmesi gibi önemli hususların varlığı halinde, son tasfiye memurları, yönetim kurulu üyeleri, pay sahipleri ve alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bu ek işlemler sonuçlandırılıncaya kadar şirketin yeniden tescilini (ihyasını) isteyebilirler (TTK m.547/1).

Mahkeme yapılan ek tasfiye talebinin uygun olduğuna kanaat getirirse ek tasfiye için şirketin yeniden tesciline karar verir. İlave işlemlerin yapılması için son tasfiye memurlarını ya da bir ya da birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir (TTK m.547/2). Mesela, şirketin kayıtlarında yer almayan ancak şirket adına tapuda tescilli bir taşınmazın tasfiye esnasında gözden kaçması ve sonradan durumun öğrenilmesi halinde tapuda malik hanesinde yazılı olan tüzel kişilik artık hukuk âleminde bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemeye müracaat edilerek şirketin yeniden tescili ve söz konusu taşınmazın tasfiyesi ile birlikte şirketin yeniden terkin edilmesi gerekir.

Anonim şirketin süresinin dolması veya genel kurul kararı ile sona erdiği hallerde, malvarlığı dağıtımına henüz başlanmamışsa *tasfiyeden dönülmesi* söz konusu olabilir (TTK m.548). Bu durumda genel kurul, esas sözleşmede daha ağır bir oran öngörülmemişse, sermayenin en az yüzde altmışının olumlu oyu ile şirketin devamına karar verebilir. Genel kurulda bu şekilde alınan karar, tasfiye memurları tarafından tescil ve ilân ettirilir (TTK m.548/1). Böylece ortaya çıkan yeni gelişmeler çerçevesinde, pay sahiplerine tasfiyeden vazgeçilerek şirketin yeniden faaliyetlerine başlaması imkânı sunulmaktadır.

İflas nedeniyle sona erme halinde, iflas kaldırılmış veya iflas konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse (İİK m.309/5) şirket devam eder. Tasfiye memuru iflasın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil talebine, pay bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtımına başlanmadığına ilişkin belge de eklenir (TTK m.548/2, 3).

§ 16- ANONİM ŞİRKETLERDE HUKUKİ SORUMLULUK

Hukuki sorumluluk başlığı altında, *kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin, denetçilerin* ve *tasfiye memurlarının* sorumluluğu ele alınacaktır. Sorumluluk süjeleri arasında sayılan *yöneticiler*, yönetim kurulu üyesi olmamakla beraber anonim şirket adına karar alan, yönetim kurulunun aldığı kararları icra eden, genellikle kendilerine devredilmiş bulunan temsil yetkisine sahip olan farklı sıfatlara sahip genel müdür, genel müdür yardımcıları, direktör ve müdürleri ifade etmektedir[404].

Kanun koyucu evvelki TTK'den farklı olarak her bir sorumluluk süjesi için ayrı ayrı hüküm koymak yerine hepsi için ortak bir sorumluluk sistemi öngörerek on birinci bölümde ayrıntılı bir düzenleme getirmiştir (TTK m.549-561).

I) SORUMLULUĞUN ŞARTLARI

İnceleme konusu sorumluluğun temelinde, sorumluluk süjelerinin kendilerine kanunla yüklenen görevlerini kusurlarıyla ihlal etmeleri sebebiyle ortaya çıkan zararın tazmin edilmesi yatmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, borçlar hukukundaki zararın tazmini müessesesi ile paralellik arz etmektedir. Ancak şirketler hukukunda söz konusu sorumluluk, farklı şartlara tâbi kılınmıştır. Bu bağlamda, evvelki TTK'den farklı olarak mevcut 6102 sayılı TTK'de sorumluluğun şartları ve özellikleri değiştirilmiş ve değişik bir sistem benimsenmiştir.

A. ZARAR

Özel hukuk alanında sorumluluğun ortaya çıkabilmesinin temel şartı, maddi ya da manevi bir zararın meydana gelmesidir. Diğer bir deyişle, zarar olmayan yerde hukuki sorumluluk doğmaz. Bu bağlamda anonim şirket yönetici ve denetçilerinin faaliyetlerinden dolayı malvarlığında haksız bir azalma yaşayan veya muhtemel bir artıştan mahrum olan başta şirket tüzel kişiliği olmak üzere pay sahibi ve alacaklılar zarar görmüş sayılır. Böylece zarar gören kimseler, zararlarının tazmin edilmesi için doğrudan sorumlu olanlara karşı dava açabilirler.

---

[404] **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-58.

Anonim şirketin kurucularının, yöneticilerinin ve denetçilerinin kusurlu davranışlarından dolayı şirket tüzel kişiliği, ortaklar ve şirket alacaklıları zarar görebilir. Bu tür zarara *doğrudan zarar* adı verilir. Mesela yönetim kurulunun eşit statüdeki ortaklar arasında ayrım yapması ve eşit davranma ilkesini ihlal etmesi halinde pay sahibi doğrudan zarar görmektedir. Aynı şekilde şirket alacaklılarından bir kısmına vadesi gelmiş alacakları için ödeme yapılmazken diğer bir kısmına henüz vadesi gelmemiş alacaklarının ödenmesi de alacaklıların doğrudan zarar görmesine örnek olarak verilebilir. Doğrudan zararın varlığı halinde zarar gören kişiler, sorumlulara karşı doğrudan dava açarak uğradıkları zararın tazminini talep edebilirler (TTK m.553)[405].

Buna karşılık söz konusu kusurlu davranışlardan anonim şirketin zarar görmesi halinde, pay sahipleri ve şirket alacaklıları şirketle olan menfaat ilişkileri sebebiyle *dolaylı zarara* uğrayabilirler. Öncelikle belirtmek gerekir ki, borçlar hukuku ilkelerine göre dolaylı zarara uğrayan kişilerin kural olarak sorumluluk davası açma hakları bulunmamaktadır. Buna karşılık aşağıda izah edildiği gibi kanun koyucu anonim şirketler hukukunda istisnai bir düzenleme yaparak dolaylı zarar gören kişilere de dava açma hakkı tanımıştır.

Kanun koyucu hukuki sorumluluk bahsinde, açıkça *doğrudan-dolaylı zarar* ayrımı yapmamıştır[406]. Böyle bir ayrım olmamakla beraber, TTK m.553'de doğrudan zarar gören kişilerden, TTK m.555'de ise şirketin yanında zarar gören pay sahiplerinin dava hakkından bahsedilmesi karşısında, dolaylı zarar görenlerin de dikkate alındığı anlaşılmaktadır[407]. Kaldı ki hem TTK m.553 hem m.555 hükümlerinin gerekçelerinde, doğrudan ve dolaylı zarar ayrımı yapılmış, şirketin zarara uğraması halinde, tazminat şirkete ödenmek üzere pay sahiplerinin de sorumluluk davası açabilecekleri açıkça belirtilmiştir.

---

405 Pay sahiplerinin veya alacaklıların doğrudan zararlarıyla ilgili açacakları davalara ilişkin olarak ayrıca bkz. **Can, M. Ç.**, *"Pay Sahiplerinin Veya Alacaklıların Doğrudan Zararlarının Tazmini Amacıyla İkame Edilen Sorumluluk Davalarında TTK m. 1534'ün Etkisi"*, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2017, C. XXI, S. 4, s. 9 vd.,

406 Oysa eski TTK'da kurucuların sorumluluğunu düzenleyen m. 309'da açıkça dolaylı zarardan bahsedilmiş; yönetim kurulunun sorumluluğuna ilişkin m. 340'da ise m. 309'a atıf yaparak dolaylı zarar açık bir şekilde kabul edilmişti.

407 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-85-87.

Şirketin zarara uğradığı hallerde, *pay sahiplerine* doğrudan dava açma hakkı tanınmıştır (TTK m.555). Söz konusu dava hakkı, yargılama sonunda hükmedilecek tazminatın şirkete ödenmesi şartına bağlanmıştır. Böylece, şirket zarara uğramasına rağmen yöneticilerin sorumluluk davası açmaktan kaçınması halinde, yönetimde olmayan pay sahiplerinin dava açarak şirketin haklarının muhafazasına imkân tanınmak istenmiştir. Ayrıca pay sahiplerinin uğradığı dolaylı zararın tazmin edilmesi sağlanmıştır.

Şirketin zarar görmesi sebebiyle dolaylı olarak zarara uğrayan *şirket alacaklılarına* tanınan dava açma hakkı şarta bağlanmıştır. Gerçekten TTK m.556 hükmüne göre, şirketin iflas etmesi halinde ve tazminat talebi önce iflas idaresi tarafından ileriye sürülüp dava açılmaması halinde, pay sahiplerinin yanı sıra şirket alacaklılarının da dava açma hakkının olduğu belirtilmiştir. Bu dava sonucunda elde edilen tazminatın, öncelikle davayı açan alacaklıların alacaklarının ödenmesine tahsis olunacağı yine Kanunda zikredilmiştir (TTK m.556/2).

B. KANUNA VEYA ESAS SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK

Anonim şirket kurucuları, yöneticileri ve denetçilerinin sorumluluğunun kaynağı, kanun veya esas sözleşme ile belirlenmiş olan yükümlülüklerin ihlalidir. Evvelki Kanunda (m.335/5), yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun kaynağı genel olarak "*Gerek kanunun gerek esas mukavelelerinin kendilerine yüklediği sair vazifelerin kasden veya ihmal neticesi olarak yapılmaması*" şeklinde kaleme alınmıştı. Buna karşılık, sorumluluğa sebebiyet veren husus TTK m.553'de küçük değişikliklerle, "*... kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde,...*" şeklinde düzenlenmiştir. Mevcut sistemde, kanun ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlalinden bahsedilmektedir. Aslında her iki düzenleme de birbirine oldukça yakın olup, düzenlemelerin ifade tarzında bazı değişiklikler bulunmaktadır[408].

Kanun koyucu hukuki sorumluluk bahsinde, sorumluluk süjelerinin sorumluluğuna sebebiyet veren genel kaynağın yukarıda ifade edildiği

---

[408] *Tekinalp*, TTK m.553'deki düzenleme ile birlikte sorumluluğun hukuki dayanağının değiştiğini, vazifelerin yerine getirilmemesi ile yükümlülüklerin ihlalinin birbirinden farklı hususlar olduğunu ileri sürmüştür (Tek Kişi Ortaklık, N. 16-11).

gibi kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali olduğunu belirttikten sonra, "sorumluluk halleri" başlığı altında somut sorumluluk sebeplerini saymıştır.

Aşağıdaki başlıklar altında özellikle anonim şirketin sermaye ve malvarlığının korunmasına yönelik alınan önlemler kapsamında yer alan sorumluluk halleri incelenmiştir.

1. Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması

Türk Ticaret Kanununun 549'uncu maddesine göre, şirketin kuruluşu, sermayenin artırılması ve azaltılması ile birleşme, bölünme, tür değiştirme ve menkul kıymet çıkarma gibi işlemlerle ilgili belgelerin, izahnamelerin, taahhütlerin, beyanların ve garantilerin yanlış, hileli, sahte, gerçeğe aykırı olmasından, gerçeğin saklanmış bulunmasından ve diğer kanuna aykırılıklardan doğan zararlardan belgeleri düzenleyenler veya beyanları yapanlar ile kusurlarının varlığı halinde bunlara katılanlar sorumludur.

Görüldüğü üzere, anonim şirketin önemli işlemlerinin hemen hemen tamamında kullanılan belgelerin, karar alıcıların iradesini sakatlayacak derecede gerçeğe aykırı veya gerçeği göstermeyecek şekilde düzenlenmesinden dolayı *sorumluluk hali meydana gelmektedir.* Burada önemli olan husus, özellikle genel kurulda karar alınması esnasında sunulan belgelerde sıkıntının olmasıdır. Mesela, pay sahipleri sunulan belgelere bakarak ilgililerin ibrasına karar vermektedir. Dolayısıyla belgelere ve beyanlara bakarak gerçek durumun fark edilememesi halinde, kanunda aranan sorumluluk şartı gerçekleşmiş olur.

Sorumluluğu doğuran olayın hukuki niteliği, failin bulunduğu konuma göre farklı şekilde ortaya çıkabilir. Şirket bünyesindeki kurucu, yönetici ve çalışanların gerçekleştirdiği gerçeğe aykırı belge ve beyanlardan dolayı *akdi bir sorumluluk hali* söz konusu olur. Buna karşılık şirket dışındaki üçüncü kişilerin sorumluluğunu doğuran fiilin gerçekleşmesi halinde, sorumluluk *haksız fiil nitelikli* olacaktır[409].

Kanun koyucu, belgeleri düzenleyenler ve beyanları sunanların kusurlu olmasını aramamıştır. Diğer bir ifadeyle, belgeleri düzenleyen ve beyanları yapanlar kusursuz olsalar dahi sorumlu tutulabilecektir. Buna karşılık, bunlara katılan kişilerin doğan zarardan sorumlu olabilmeleri için kusurlu olmaları aranmıştır (TTK m.549/1-son cümle).

---

[409] **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-22.

Belge ve beyanlardaki usulsüzlük aynı zamanda cezai yaptırıma bağlanmıştır. TTK m.562/8'e göre, 549'uncu maddede belirtilen belgeleri sahte olarak düzenleyenler ile ticari defterlere kasıtlı olarak gerçeğe aykırı kayıt yapanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi

Sermaye tamamıyla taahhüt olunmamış veya karşılığı kanun veya esas sözleşme hükümleri gereği ödenmemişken, taahhüt edilmiş veya ödenmiş gibi gösterenler ile kusurlu olmaları şartıyla, şirket yetkilileri, bu payları üstlenmiş kabul edilirler ve payların karşılıkları ile zararı faiziyle birlikte müteselsilen öderler (TTK m.550). Kanun koyucunun, şirket yetkilisi kavramını tercih ederek bunun kapsamını geniş tutmak istediği, sermaye işlemlerini yöneten yönetim kurulu üyeleri, mali danışmanlar, yeminli mali müşavirler ve denetçilerin bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğini belirttiği madde gerekçesinden anlaşılmaktadır.

TTK m.550'de, sermaye taahhüdüyle ilgili usulsüzlük yapılması ile ilgili şirket yetkililerinin kusurlu olması aranmıştır. Buna karşılık sermaye işlemlerini yürüten kişilerin sorumluluğunun doğabilmesi için kusur aranmamıştır. Özellikle sermayenin ödenmemesi veya ödenmiş gibi gösterilmesi aşamasında sürece dâhil olan muhasebeci, yeminli mali müşavir gibi şirket yetkililerinin sorumluluğu için kusur aranmamıştır.

Sermaye taahhüdünde ve ödenmesinde usulsüzlük yapanlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılırlar (TTK m.562/10).

3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk

Anonim şirketin kuruluşunda veya daha sonrasında sermaye artırımı esnasında şirkete getirilmek istenen ayni sermayenin veya devralınacak işletme ile ayni unsurların değerinin biçilmesinde usulsüzlük yapılarak emsallerine oranla yüksek fiyat biçenler, işletme ve ayın niteliğini veya durumunu farklı gösterenler ya da başka bir şekilde yolsuzluk yapanlar bundan doğan zarardan sorumlu tutulmuşlardır (TTK m.551). Madde metninde açıkça kusur şartından bahsedilmemekle beraber, gerekçede hükmün kusur esasına dayandığı belirtilmiştir.

Uygulamada sıklıkla karşılaşılan bu durumda, şirkete ayni sermaye olarak getirilen unsurların veya devralınmak istenen işletme ve unsurların değerinin tespit edilmesi esnasında genellikle uzman raporu alınır. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının yanı sıra şirkete getirilen veya devralınan unsurun niteliğine göre yine bir uzmandan değer tespiti istenir. İşte bu aşamada gerek değer tespiti yapan uzmanların gerek şirket yöneticilerinin veya ortakların yaptıkları usulsüzlük sonucunda bahse konu sermaye unsuruna, emsallerine oranla daha yüksek değer biçilerek şirket zarara uğratılabilir. Mesela, piyasada on milyon TL olarak değer biçilen taşınmazın şirket tarafından yirmi milyon TL üzerinden devralınması veya sermaye olarak kabul edilmesi bu konuya örnek olarak verilebilir.

TTK m.562/10 hükmünde, ayni sermayeye değer biçilmesinde yolsuzluk yapanlara üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilebileceği belirtilmiştir.

4. Halktan Para Toplamak

Eski Kanunda karşılığı bulunmayan söz konusu düzenleme, ülkemizde karşılaşılan ve herhangi bir kamu izni almadan halktan yatırım yapılacağı veya yüksek gelir verileceği vaadiyle para toplama girişimlerine engel olabilmek amacıyla yeni Kanuna alınmıştır. TTK m.552 hükmüne göre, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunarak para toplanması yasaklanmıştır.

Para toplama yetkisinin sadece devletten lisans almış bulunan bankalar ve finans kuruluşlarına ait olduğu ve şirket hisse satışlarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde halka açık anonim şirketler bakımından mümkün kılındığı gerçeği karşısında, bunların dışında halkı bir anlamda kandırarak para toplamanın önüne geçilmek istenmiştir.

Usulsüz şekilde halktan para toplanmasının cezai müeyyidesi ise altı aydan iki yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir (TTK m.562/11).

C. İLLİYET BAĞI

Türk hukukunda tazminat sorumluluğunun ortaya çıkabilmesinin temel şartlarından birisi, kusurlu davranış ile zararlı sonuç arasında uygun illiyet bağının bulunmasıdır[410]. Şirketin kurucularının, yöneticilerinin, denetçilerinin ve tasfiye memurlarının kanundan veya esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ihlali ile ortaya çıkan zararlı sonuç arasında uygun bir sebep sonuç ilişkisinin bulunması gereklidir.

Anonim şirketlerde hukuki sorumluluğun sınırları çizilirken dolaylı zararın kabul edilmiş olması, illiyet bağının çerçevesini genişletmektedir. Pay sahipleri ve şirket alacaklıları, kendileri doğrudan zarar görmemiş olsalar dahi şirket tüzel kişiliğinin uğradığı zarardan dolayı sorumluluk davası açabilmektedir. Bununla birlikte yine de şirketin uğradığı zarar ile sorumluların kusurlu davranışları arasında uygun illiyet bağının bulunması gereklidir.

D) KUSUR

Anonim şirkette sorumluluk süjelerinin kanundan veya esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini, kusurlarıyla ihlal etmeleri halinde sorumluluk ortaya çıkmaktadır (TTK m.553/1). Diğer bir deyişle anonim şirketlerdeki hukuki sorumluluk *kusur temellidir*. Kast ya da ihmal şeklinde gerçekleşen *kusur*, hukuk düzeni tarafından kınanan bir davranışın yapılması şeklinde tanımlanabilir. Kusurun derecesi ile ilgili kanun koyucu açıklama yapmamış ve özel bir derece aramamıştır. Bahse konu yükümlülüklerin ihlalinde kast ya da ihmallerinin bulunması, gerek kurucuların gerek yöneticilerin sorumluluklarının doğması için yeterli kabul edilecektir[411].

Evvelki Türk Ticaret Kanununda yer alan, yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler için öngörülen ve davacılar bakımından önemli bir kolaylık getiren *kusur karinesi*, mevcut Kanuna alınmamıştır. Diğer bir deyişle şirketin zarar görmesi halinde yönetim kurulunun ve denetçilerin kusurunun bulunduğu yönündeki evvelki TTK m.336 ve 339'daki

---

410 **Eren, F.,** Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975, s. 5 vd.

411 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-78, 79.

düzenleme yeni Kanunun 553 ve 554'üncü[412] maddelerinde yer almamıştır. Dolayısıyla günümüzde, sorumluluk davası açmak isteyen muhtemel davacılar, kanun ve esas sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ihlalini, zararı ve sorumluluk süjelerinin kusurunu ispat etmek durumundadır. Böylece önemli bir kolaylık olan kusur karinesinden günümüzdeki davacılar yararlanamamaktadır[413].

Kusurun ispatı noktasında gerek yönetim kurulu üyelerine gerek denetçilere kanun ile birtakım yükümlülükler getirildiği açıktır. Söz konusu yükümlülüklerin ihlalinde de kural olarak ilgililerin kusurlu olmaları muhtemeldir. Dolayısıyla davacıların, yükümlülüklerin ihlal edildiğini ve zararlı sonucun ortaya çıktığını ispatlamaları halinde sorumluların kusurlu olduklarının ispatlanması çok daha kolay hale gelir. Hatta bu tür durumlarda, sorumlu olan kişiler zararlı sonucun meydana gelmemesi için gerekli özeni gösterdiklerini ortaya koymak zorunda kalabilirler. Özellikle yönetim kurulu üyelerinin özen yükümlülüğünü belirlemek için öngörülen *tedbirli yönetici (iş insanı kararı)*[414] kavramının kabulü sonrasında (TTK m.369), zararlı sonucun doğmaması için alınan önlemler açıklanmak durumunda kalınır. Mesela yeni yapılan maden yatırımının zararla sonuçlanması halinde, yönetim kurulu üyeleri ve diğer yöneticiler, konuyla ilgili gerekli araştırmaları yaptıklarını, uzmanlardan rapor aldıklarını ve buna rağmen yatırımın zarar ettiğini ortaya koymak durumunda kalabilirler.

---

412 Kurucuların, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğunu düzenleyen TTK m. 554'üncü madde metninin ilk halinde, kusur karinesini devam ettirir şekilde "*kusurlarının bulunmadığını ispatlamadıkça*" hükmü yer almakta; buna karşılık denetçilerin sorumluluğunu düzenleyen TTK m. 554'de ise bu yönde bir ifade bulunmamaktaydı. Oldukça eleştirilen bu farklılık, 6335 sayılı Kanun ile giderilmiş ve m. 553'deki yukarıdaki ifade çıkarılarak "*yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal ettikleri takdirde*" şekline dönüştürülmüştür. Böylece genel sorumluluk düzenlemesinde, kusur karinesi bütünüyle kaldırılmış olmaktadır. Söz konusu değişikliğin Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarına uygun olması için yapıldığı ve kendisinin buna karşı çıktığı yönünde bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-76.

413 TTK m. 553'de yapılan değişikliğe rağmen özellikle yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve tasfiye memurları hakkında kusur karinesinin var olduğu, bu kimselerin sorumluluktan kurtulabilmeleri için kusursuz olduklarını ispat etmelerinin gerekli olduğu yönünde bkz. **Kendigelen,** İlk Tespitler, s. 458-460.

414 Yönetim kurulunun özen yükümlülüğü için bkz. Yedinci Bölüm, § 10, V, A.

TTK m.553'deki genel sorumluluk halinin yanı sıra m.549 ve 550'deki özel sorumluluk hallerinde, kanun koyucu bazen açıkça kusuru aramıştır. Dolayısıyla burada sayılan özel durumlarda, sorumluluk süjeleri bakımından kusurun arandığı hallerde, kast ya da ihmalin bulunması gereklidir. Buna karşılık anılan hallerde bazı sorumluluk süjeleri bakımından kusur aranmaması, zararlı sonucun ortaya çıkması halinde bu kimseler hakkında *kusur karinesi* getirildiği, zira ilgili maddelerde bahsedilen fiillerin kusur hatta kast olmadan yapılamayacağı gerçeğinden hareket edildiği söylenebilir.

Mesela, TTK m.549'daki gerçeğe aykırı veya gerçeğin saklandığı belge ve beyanları hazırlayıp ilgili yerlere sunan kimselerin kusurundan bahsedilmemiştir. Zira gerçeğe aykırı belge hazırlamak veya beyanda bulunmak zaten kusur olmadan gerçekleştirilemez. Buna karşılık sorumlu kimselere katılanların sorumlu tutulabilmeleri için kanun koyucu kusurlu olmalarını aramıştır. Dolayısıyla muhtemel bir yargılamada, her bir sorumluluk süjesinin kusur durumu ayrı ayrı incelenerek bir sonuca varılması gerekir. Aynı şekilde TTK m.550'deki sermayenin taahhüdünde veya ödenmesindeki usulsüzlüğü yapanlar bakımından kusur aranmamışken, şirket yetkililerinin sorumlu olabilmeleri için kusurlu olmaları aranmıştır.

II) HUKUKİ SORUMLULUĞA HÂKİM OLAN İLKELER

Anonim şirketlerde hukuki sorumluluğun şartlarını izah ettikten sonra, buna hâkim olan ve sorumluluğun sınırları belirlenirken dikkate alınan ilkeleri açıklamak gereklidir. Somut olayda sorumluluğun şartları gerçekleştikten sonra, yapılacak yargılama esnasında söz konusu ilkeler önem arz etmektedir.

A. SORUMLULUĞUN AKDİ OLMASI

Anonim şirket yönetici ve denetçilerin sorumluluğunun hukuki niteliği konusunda bir tespitte bulunmak gereklidir. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin, tasfiye memurlarının ve denetçilerin sorumluluğunun hukuki niteliği konusunda tam bir netlik bulunmamaktadır. Bu bağlamda haksız fiil, kanundan doğan borç ve akdi sorumluluk halleri akla gelmektedir. Eski Kanun döneminde bu konu üzerinde yaşanan tartışma, günümüzde de canlılığını korumaktadır.

Kurucuların anonim şirket ile aralarındaki bağlantı, bir sözleşmeden ziyade kanuni bir borç ilişkisine dayanmaktadır. Bağımsız denetçi ve diğer yöneticiler ile şirket arasında bir sözleşme ilişkisinin olduğu oldukça açıktır. Sadece yönetim kurulu üyeleri ve tasfiye memurları ile şirket arasında organ olmaktan kaynaklanan kanuni borç ilişkisi mi yoksa akdi bir ilişki mi olduğu hususu tartışmalıdır[415]. Öğretide genel olarak kabul olunduğu üzere, yönetim kurulu üyeleri ile anonim şirket arasındaki ilişki temelde sözleşmeye dayanmaktadır[416]. Bu sözleşmenin niteliğinin de hizmet, vekalet sözleşmesi veya *sui generis* bir sözleşme olduğu konusunda da bir tartışma bulunmaktadır[417]. Hangi sözleşme olduğu kabul edilirse edilsin genel hüküm olarak vekalet sözleşmesi hükümleri uygulanacağından (TBK m.502/2), sorumluluğun tespitinde de vekalet sözleşmesinden yararlanılabilir.

Sonuç olarak yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticiler, denetçiler ve tasfiye memurları ile şirket arasındaki sözleşme ilişkisinden dolayı sorumluluk bahsinde de sözleşme ilkeleri uygulanır.

Taraflar arasındaki sözleşme ilişkisinde yazılı şekilde açıkça belirtilmemiş olsa da yukarıda sayılan sorumluluk süjeleri ile şirket arasındaki sözleşmeden kaynaklanan özen ve sadakat yükümlülüğünün ihlali, sorumluluğu ortaya çıkaran temel sebeptir. TTK m.553/1'de de belirtildiği gibi kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülük ihlali sorumluluğu doğuran hususdur. İşte uygulamada ihlali ile en çok karşılaşılan yükümlülük, özen ve sadakat yükümlülüğüdür. Bunun ihlali halinde akdi sorumluluk çerçevesinde gerekli inceleme ve tespitler yapılır.

B. SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI

Anonim şirketin zarara uğramasına sebep olan sorumluluk süjelerinin, kural olarak, hem eski hem de yeni Kanunda zarar görene karşı müteselsilen sorumlu oldukları kabul edilmiştir. Ancak her iki kanunun düzenlemesinde sorumluluk sistemini temelden değiştiren önemli bir

---

415 Yönetim kurulu ile şirket arasındaki ilişkinin organik bir bağ olduğu; buna karşılık yönetim kurulu üyeleri ile şirket tüzel kişiliği arasında akdi bir ilişki olduğu konusundaki açıklamalar için bkz. **Özdamar,** Mali Haklar, s. 124-125. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. Yedinci Bölüm, § 10, IV.

416 **Tekinalp,** Tek Kişi Ortaklık, N. 112; **Akdağ Güney,** Yönetim Kurulu, s. 276 vd.; **Kırca (Şehirali Çelik/ Manavgat),** s. 453.

417 **Akdağ Güney,** Yönetim Kurulu, 276 vd.; **İzmirli,** s. 35-37.

farklılık göze çarpmaktadır. Eski Kanundaki *mutlak teselsül* sistemine karşı yeni Kanunda *farklılaştırılmış teselsül* kabul edilmiştir.

1. Mutlak Teselsül

Evvelki Türk Ticaret Kanununda, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin, sorumluluğa sebebiyet veren zarardan dolayı müteselsilen sorumlu oldukları açıkça belirlenmişti (m.336 vd.). Sorumluluk süjelerinin kusurlarının ağırlığına bakılmaksızın zarardan birlikte sorumlu oldukları kabul edilmekte ve alacaklılar herhangi bir borçludan tazminatın tamamını talep edebilmekteydi. Bu durumda tazminatın tamamını ödemek zorunda kalan kişi, kusurları oranında diğer kimselere başvurup ödediği tazminatın bir bölümünü rücû edebilmekteydi.

Esasen alacaklılar bakımından büyük kolaylık sağlayan söz konusu mutlak teselsül hali, özellikle az kusurlu ve fakat ödeme kabiliyeti bulunan kişiler açısından adil olmayan sonuçlar ortaya çıkarmaktaydı. Zira bu kimseler, sorumluluk davası esnasında kendilerinin az kusurlu olduklarını ileri süremeyip tazminatın tamamını ödemek zorunda kalabilmektedirler. Diğer sorumluluk süjelerine kusurları oranında rücû etmek istemelerine rağmen bundan sonuç alamadıkları takdirde, bütün zararı tek başlarına tazmin etmek durumunda kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu tür müteselsil sorumlulukta, sorumluluk süjelerinin kusurlarının ağırlığı sadece iç ilişkideki rücû esnasında dikkate alınmaktadır.

2. Farklılaştırılmış Teselsül

Mevcut Türk Ticaret Kanununda ise sorumluluk süjelerinin ortaya çıkan zarardan sorumluluklarına ilişkin *farklılaştırılmış teselsül* sistemi öngörülmüştür. Mehaz İsviçre sistemine daha yakın olan bu sorumluluk sisteminde, herkesin kusurları oranında sorumlu tutulmalarına dair bir düzenleme yapılmıştır.

a) Özellikleri

Farklılaştırılmış teselsül sisteminde, ortaya çıkan zararı tazmin etmekle yükümlü olan kişiler, zararın doğmasındaki kusurları oranında diğer sorumluluk süjeleri ile birlikte sorumluluk altına girmektedirler. Tazminat alacaklısı bakımından mutlak teselsüle nazaran daha zor bir sistem olan farklılaştırılmış teselsül, borçlular bakımından ise daha adil bir çözüm yolu sunmaktadır. Zira bu sistemde, sorumluluk süjelerinin tamamı, zararın meydana gelmesindeki kusurlarının hesaplanmasını ve

ödemede dikkate alınmasını isteyebilmektedir. Diğer bir deyişle kusurun ağırlığı, sadece içerideki rücû ilişkisinde değil, asıl yargılama esnasında da dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.

Anonim şirketlere ilişkin hukuki sorumluluk bahsinde farklılaştırılmış teselsül sistemi TTK m.557'de düzenlenmiştir. Hüküm, esasen sorumluluğun dış ilişkideki görünümünü ele almakta, sorumluların kendi aralarındaki iç ilişkiye ilişkin ise somut bir çözüm tarzı içermemektedir[418]. TTK m.557/1 hükmüne göre, birden çok kişinin aynı zararı tazminle yükümlü olmaları halinde, bunlardan her biri, kusuruna ve durumun gereklerine göre, zarar şahsen kendisine yüklenilebildiği ölçüde, bu zarardan diğerleriyle birlikte müteselsilen sorumlu olur.

Bahse konu düzenlemede göze çarpan iki önemli özellik bulunmaktadır. İlk olarak belirtmek gerekir ki, kişinin bireysel davranışından bir zararlı sonucun meydana gelmesi halinde, bundan dolayı doğrudan ve sadece ilgili kişi sorumlu olur. Mesela, şirketle rekabet etmeme yasağının ihlalinden kaynaklanan sorumluluğun sadece yasağı ihlal eden kişiye ait olduğunu söylemek gerekir. İkinci olarak, sorumluluğa ilişkin yargılama esnasında bütün sorumluluk süjelerinin ayrı ayrı değerlendirilerek *aynı zararın* ortaya çıkmasındaki kusurları ve katkıları tespit edilerek buna göre bir sorumluluk miktarının belirlenmesi söz konusu olur. Başka bir deyişle, TTK m.557/1'de bahsedilen aynı zarardan dolayı her bir kimsenin sorumluklarının çerçevesi çizilir.

b. Zarar Görenin Dava Açma Hakkı

Farklılaştırılmış teselsül uygulamasının, ortaya çıkan zarardan etkilenen kişilerin dava açma hakkını zorlaştırdığı akla gelebilir. Gerçekten davacının, her bir sorumluluk süjesine kusuru oranında ayrı ayrı dava açmasını zorunlu kılmak, davacıyı çok ağır bir yük altına sokar. Zira bu durum, davacıyı her bir sorumluluk süjesinin zarara katkısını hesaplayıp ona göre tazminat davası açmak zorunda bırakacaktır. Bunu dikkate alan kanun koyucu, davacının birden çok sorumlu kişiyi aynı anda dava ederek bunların sorumlu oldukları tazminat miktarının ayrı ayrı hesabını mahkemeden talep edebileceklerini hükme bağlamıştır (TTK

---

418 **Göktürk, K./Can, M.Ç.**: *"Farklılaştırılmış Teselsülün-Özellikle-Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu ile Karşılaştırılması"*. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2016, C. 2, s. 254.

m.557/2). Davalılara birlikte dava açabilme imkânı, farklılaştırılmış teselsülün alacaklılar bakımından ortaya çıkardığı dezavantajlı durumu bir nebze olsun rahatlatmaktadır. Davacı, sorumluluk süjelerinin tamamına karşı birlikte dava açabileceği gibi içlerinden bazılarına karşı dava açması da mümkündür. Özellikle bazı yöneticilerin kusursuz oldukları-nın düşünülmesi veya bunlarla ayrı bir münasebetinin bulunması davanın herkese yöneltilmemesine yol açabilir.

c) Tazminat Miktarının Hesaplanması

Hâkim kendi önüne gelen davada hem toplam tazminat miktarını hem de bu miktardan sorumluluk süjelerinin ayrı ayrı sorumlu oldukları kısımları tespit etmek durumundadır. Bu arada zararın belirli bir kısmı, ilgililerin bireysel kusurlu davranışlarından kaynaklanmışsa, mahkeme tazminatın bu bölümünden ilgili kişiyi bireysel olarak sorumlu tutar. Zararın tamamı hesap edildikten sonra bunun bir kısmından ilgililerin şahsen, bir kısmından ise diğerleri ile birlikte müteselsilen sorumlu oldukları kısımlar mahkeme tarafından belirlenir.

Zarardan sorumlu olan her bir sorumluluk süjesinin dış ilişkide ödemesi gereken tazminat tutarı, o kişinin bireysel müteselsil sorumluluk tavanını ifade eder. Mahkeme yaptığı hesaplama ile her bir kişinin alacaklıya karşı sorumlu olduğu azami miktarı tespit etmekte; söz konusu miktar sorumluluk süjesinin gerçekte ödemesi gereken miktar olmamaktadır. Nihai miktarın hesabı, indirim sebepleri vs. dikkate alınarak iç ilişkideki rücû davasında yapılmaktadır. Dolayısıyla sorumlu kişinin dış ilişkide sorumluluk tavanı, davacının tazminat miktarına eşit olabilmekteyken, iç ilişkide diğer sorumluların durumu da dikkate alınarak daha düşük kalabilmektedir.

Mesela, zararlı sonucu doğuran sözleşmeyi imzalayan murahhas yönetim kurulu üyesi meydana gelen 90.000TL tutarındaki zararın tamamından davacılara karşı sorumlu olmakla birlikte, iç ilişkide sözleşmeyi inceleyen ve hesaplamaları yapan hukuk müşaviri ile finans müdürünün de sorumlu olmaları sebebiyle miktar 60.000TL'ye düşebilir. Bu durumda tazminatın tamamını ödeyen yönetim kurulu üyesi, iç ilişkide fazladan ödediği 30.000TL'yi diğer sorumlu olan hukuk müşavirine, finans müdürüne kusurları nispetinde rücû edebilir. Finans müdürünün hesaplama hatası yapmasından dolayı daha fazla kusuru olduğu ortaya çıkarsa, söz konusu miktarın 20.000TL'sini kendisi, 10.000TL'lik kısmını ise hukuk müşaviri ödemek durumunda kalabilir.

d) İç İlişkide Rücû Davası

Müteselsil sorumluların kendi aralarındaki iç ilişkiye dair düzenleme ise TTK m.557/3 hükmünde ele alınmıştır. Evvelki Kanun döneminde bulunmayan rücû davası, mevcut Kanun ile somut olarak düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye göre, "*Birden çok sorumlu arasındaki başvuru, durumun bütün gerekleri dikkate alınarak hâkim tarafından belirlenir*".

Tazminatı dış ilişkide ödemek durumunda kalan kişi ya da kişiler, haklarında sorumluluk davası açılmış olsun ya da olmasın diğer tüm sorumluluk süjelerine karşı rücû davası açabilecektir[419]. Aksi düşünce, sorumluluk davası açılırken bazı yönetici veya denetçilerin kayırılmasına, davacıların sorumlular arasında tercihte bulunabilmelerine ve hakkaniyete uygun olmayan sonuçlara yol açabilecektir. Tüm sorumluluk süjelerine rücu davasının açılması, bahse konu sakıncaları ortadan kaldıracak niteliktedir.

Hâkime geniş bir takdir yetkisi veren TTK m.557/3 hükmü, alacaklının dış ilişkide hükmolunan tazminatını kısmen veya tamamen aldıktan sonra sorumluların kendi aralarındaki rücû ilişkisini düzenlemektedir. Burada hâkim, dış ilişkide tazminat tavanı ile sınırlı olmak kaydıyla her bir sorumluluk süjesinin kusurunun ağırlığına ve indirim sebeplerine göre belirleyeceği tazminat miktarlarının rücû edilmesini sağlar. Rücû davasında artık müteselsil sorumluluk olmadığından, fazladan tazminat ödeyen kişi, diğer sorumlulara ayrı ayrı payları oranında rücû eder. Sorumluların kusur oranları dış ilişkideki tazminat davasında belirlenmişse, hâkim bu oranlar üzerinden iç ilişkideki sorumluluk miktarlarını tespit eder. Kusur oranları tespit edilmemişse rücû davasında hâkim, bilirkişi marifetiyle her bir sorumluluk süjesinin kusur oranını belirleyerek rücû miktarlarını hesaplar.

e) Farklılaştırılmış Teselsül Uygulamasına Örnek

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 557'nci maddesinin gerekçesinde, farklılaştırılmış teselsül uygulamasının daha rahat anlaşılabilmesi için şu şekilde bir örneklendirme yapılmıştır:

Yatırım için arsa arayan bir anonim şirkete, yönetim kurulu üyesi A kardeşine ait bir arsayı aldırmayı planlamaktadır. Bu amaçla, kimseye

---

[419] Kanundaki birden çok sorumlu ifadesinin, tüm sorumluluk süjelerini kapsadığı yönünde ayrıca bkz. **Yördem,** s. 274.

haber vermeden avukata da bir satış vaadi sözleşmesi hazırlatmış ve ona 1000 TL ödemiştir. Sözleşme (geçersiz olmasına rağmen) A ile kardeşi arasında imzalanmıştır. Planını yönetim kurulu üyesi B'ye açan A, ondan yardım istemiş ve kardeşinin B'ye bir miktar para vereceği vaadinde de bulunmuştur. B, bazı emsaller göstererek söz konusu arsanın fiyatını savunacaktır. Yönetim kurulu A, B, C, D ve E'den oluşmaktadır. Konunun karara bağlanacağı gün D ve E, A'nın, Tasarının 393 üncü maddesine göre toplantıya katılamayacağı itirazında bulunmuşlarsa da bu itiraz A, B ve C'nin oyları ile reddedilmiştir. D ve E ayrıca, arsanın emsalleri ile fiyatını karşılaştıran ve imar durumunu gösteren bir uzman raporunun kurula sunulabilmesi için toplantının ertelenmesini önermişlerdir. Bu öneri de A, B ve C'nin oylarıyla reddedilmiştir. Toplantıda B, emsaller hakkında yanıltıcı bilgiler vermiştir. Sonuçta B'nin yaptığı karşılaştırmaların ciddi olduğuna inanan C'nin de katılması ile arsa A, B ve C'nin oyları ile alınmış ve para ödenmiştir. Bir yıl sonra kurul tamamen değişmiştir. Bu arada arsanın imar durumu olmadığı da anlaşılmıştır. Yeni (yönetim) kurul, avukata ödenen 1000 TL de dahil olmak üzere 5000 TL zarar için A, B, C, D, E'ye karşı sorumluluk davası açıp bu tutarı davalılardan müteselsilen talep etmiştir. Mahkeme D ve E bakımından davayı reddetmiş, birlikte verilen bir zarar olmadığı gerekçesiyle avukata ödenen 1000 TL'den tek başına A'yı sorumlu tutmuş, 4000 TL için de A, B, C'yi müteselsilen sorumlu bulmuştur. Mahkeme A ve B'nin yaptıkları anlaşma dolayısıyla olayda kasıtları bulunmasına karşı, C'nin Tasarının 393. maddesini ihlâl eden davranışını kusur olarak nitelendirip ona BK m.43 ile 44'ü uygulayıp müteselsil sorumluluktaki payını yüzde doksan olarak belirlemiştir. Buna göre 1000 TL A tarafından ödenecektir. A, B, C müteselsil sorumludur. Ancak A ile B'nin sorumluluk tavanları 4000 TL iken C'nin sorumluluk tavanı 3600 TL'dir. Bir an için B'nin ödeme gücünün bulunmadığını düşünelim. Şirket 4000TL'nin tamamını A'dan alabilecektir. Bu tavan C için 3600 TL'dir. A ve B'nin ikisinin de varlıksız C'nin zengin bir kişi olduğunu varsayarsak 3600 C'den istenebilecektir. Olayda A ve B'nin ödeme güçleri bulunmadığı için şirket 1400 TL kayıptadır. Ancak bu farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk anlayışının ürünü değildir. Çünkü 1000TL'lik kayıp, birlikte verilen zarardan kaynaklanmamaktadır. Uygun nedensellik kurallarına göre bunu C'den istemek, bunun için müteselsil sorumluluk kavramını kullanmak hem yanlış olurdu, hem de adalete aykırı düşerdi. 400 TL'lik kayıp ise genel hükümlerin ve

hâkimin takdirinin doğal sonucudur. Yeni anlayış davacıyı (adalet temelinde) kayba uğratmamış, onun zararını kanuna aykırı olarak başkalarına yüklemesine engel olmuştur.

III) SORUMLULUK DAVASI

Anonim şirketin kurucuları, yöneticileri, denetçileri ve tasfiye memurlarının sorumluluğuna ilişkin olarak açılacak davanın özellikleri bu başlık altında incelenecektir. Uygulamada sorumluluk davasının HMK m.107 hükmü çerçevesinde belirsiz alacak davası olarak açıldığını söylemek gerekir. Davacıların toplam zararı ve sorumluluk miktarını baştan tespit etmelerinin oldukça zor olduğu gerçeği karşısında, davaların genellikle belirsiz alacak davası şeklinde ikame edilmesi söz konusu olur. Buna karşılık zarar miktarının önceden bilinmesi halinde belirsiz alacak davasına başvurulmamalıdır.

A. DAVACILAR

Kanun koyucu sorumluluk davasında üç tür davacı belirlemiştir. Kusurlu davranışlardan dolayı asıl zarar gören şirket tüzel kişiliği olduğundan, ilk davacı şirket tüzel kişiliğidir. Bunun yanı sıra kanun koyucu pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına da dava açma hakkı tanıyarak, sorumlulara karşı dava açılmasını güvence altına almak istemiştir.

1) Anonim Şirket

Öncelikle sorumluluk davasının asıl davacısı *şirket tüzel kişiliği*dir. Zira ortaya çıkan zarardan ilk olarak şirket etkilenir. Şirketin, yetkili organları vasıtasıyla karar alıp ilgililere karşı sorumluluk davası açması gerekir. Bu konuda yetkili organın hangisi olduğu kanuni düzenlemede açık değildir. Zira organların münhasır yetkilerini belirleyen TTK m.374 ve 408'inci maddelerde sorumluluk davası açılmasına hangi organın karar vereceği açıkça düzenlenmemiştir. Bununla birlikte yönetim kurulunun genel yetkisini düzenleyen TTK m.374 hükmü uyarınca, genel kurula açıkça bırakılan alanların dışında kalan ve şirketin işletme konusunun gerçekleşmesi için gerekli olan her iş ve işlemler yönetim kurulunun yetkisine bırakılmıştır. Bu nedenle sorumluluk davasının

açılmasına karar verilmesi ve bunun icra edilmesi yönetim kurulunun yetki ve görevi olarak kabul edilmelidir[420].

Şirketin uğradığı zarara, yönetim kurulu üyelerinin tamamının yol açması halinde, bu kişilerin kendi aleyhlerine dava açma kararı almaları pek mümkün görünmemektedir. Genel kurulun yönetim kurulunu ibra etmemesi üzerine bu kişiler hakkında sorumluluk davası açılması söz konusu olur. İşte yönetim kurulu üyelerinin tamamı aleyhine sorumluluk davasının açıldığı durumlarda, şirkete dava için bir kayyım atanarak davayı bunun açması ve takip etmesi gerekir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu ibra edilmiş ise, dava bunların alacağı bir karar ile açılabilir. Yönetim kurulu değişmiş ise, yine bunların alacağı bir karar ile önceki sorumlu yöneticiler aleyhine dava açılabilir[421].

2) Pay Sahipleri

Anonim şirket sorumluluk davasını açmasına imkân tanınan ikinci grup davacı *pay sahipleridir*. Pay sahiplerinin dava açma hakkı doğrudan ve dolaylı zarar halinde iki farklı şekilde ortaya çıkar. Doğrudan zarar gören pay sahiplerinin, tazminatı kendileri almak üzere her daim sorumluluk davası açmaları mümkündür[422].

Dolaylı zarar halinde, özellikle sorumlu olan kişilerin şirkette hâkim durumda bulunmaları, yönetim kurulunu kontrol etmeleri sebebiyle sorumluluk davası açılmaması ihtimali düşünülerek pay sahiplerine de

---

420 Sorumluluk davasının açılmasında Genel Kurul kararının alınmasının gerektiği yönünde bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.07.2017 tarih, 2016/8829 Esas, 2017/4095 sayılı kararı, www.kazanci.com,

421 **Çağlar,** İbra, s., s. 74.

422 Konuya ilişkin olarak verilen Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/14194 Esas ve 2018/6167 Karar sayılı ve 10.10.2018 tarihli kararında, anonim şirket ortaklarının doğrudan dava açabilmek için doğrudan gördükleri zararı mutlaka ispat etmeleri gerektiği şu şekilde hükme bağlamıştır: "... ***anonim şirket ortaklarının doğrudan yönetim kuruluna karşı dava açabilmesi için doğrudan zararlarının olması gerektiği,*** *bilirkişi raporuna göre şirketin herhangi bir zararının olmadığı, şirketin mali durumunun iyi olduğunun belirtildiği,* ***zararın davacı tarafça ispatı gerektiği****, organ yokluğu söz konusu olmadığından ve bu durumda haklı sebep sayılamayacağından anonim şirket ortaklarının kanunda yazılı prosedüre göre genel kurulu toplayıp, yönetim kurulunu seçmesi gerektiği gerekçesiyle davacı tarafın anonim şirketin feshine yönelik davasının reddine,* ***alınan bilirkişi raporuna göre de şirketin yönetimi nedeniyle maddi zararın olmadığı*** *göz önünde bulundurularak açılan tazminat davasının reddine karar verilmiştir..*", www.kararama.yargitay.gov.tr.

dava açma imkânı tanınmıştır. Açılan davada hükmolunacak tazminatın şirkete ödenmesi zorunludur. Böylece şirketin uğradığı zararın tazmini, yöneticiler eliyle olmasa da pay sahipleri aracılığıyla sağlanmış olur.

Şirketin zarara uğramasına rağmen tazminat talep edilmemesi halinde, herhangi bir asgari pay sahipliği sınırı aranmaksızın tüm pay sahiplerine dava açma hakkı tanınmıştır (TTK m.555/1). Bu durum, evvelki Kanunda azınlığa tanınan dava açma hakkının (m.341) yeni Kanunda yer almasını da gereksiz hale getirmiştir.

Pay sahibinin açtığı davayı hukuki ve maddi sebepler haklı gösterdiği takdirde, mahkeme, dava giderleriyle vekalet ücretini, bu giderler davalıya yükletilemediği hallerde davacı pay sahibi ile şirket arasında hakkaniyete göre paylaştırır (TTK m.555/2). Şirketin tazminata hak kazanması halinde, davalıya yükletilemeyen masraf kalemlerinin şirket tarafından karşılanmasının hakkaniyete daha uygun bir çözüm yöntemi olacağı kuşkusuzdur.

3) Şirket Alacaklıları

Sorumluluk davasındaki sonuncu davacı grup ise *şirket alacaklılarıdır*. Şirketin yönetici ve denetçilerinin yaptıkları kusurlu davranışlar ile şirket alacaklılarına doğrudan zarar vermeleri mümkündür. Mesela, şirketin bir malvarlığını devralmak isteyen veya şirkete mal satan kişilerin doğan alacaklarının ödenmesi yönetim kurulunun yetkisindedir. Ödemenin geciktirilmesi veya şirketin içinde bulunduğu durumun bağımsız denetim raporunda gösterilmemesi gibi hallerde şirket alacaklıları doğrudan zarar görebilirler. Bu durumda alacaklılara, uğradıkları zararın tazmini için ilgililere karşı doğrudan sorumluluk davası açma imkânı verilmiştir (TTK m.553/1). Açılan davadan elde edilen tazminat, şirket alacaklısının uğradığı zararın tazmini için kullanılır.

Şirket alacaklılarının dolaylı zarar halinde dava açabilmeleri şirketin iflas etmesi şartına bağlanmıştır. TTK m.556 hükmüne göre, şirketin iflası halinde sorumluluk davasının iflas idaresi tarafından açılmaması halinde, her pay sahibi ve şirket alacaklısı, tazminatın şirkete tahsis edilmesi şartıyla, sorumluluk davası açabilir.

B. DAVALILAR

Sorumluluk davasında davalılar geniş bir yelpaze olarak ortaya konulmuştur. Bir taraftan TTK m.553'deki genel sorumluluk düzenlemesinde, diğer taraftan m.549 ilâ 552'de yer alan dört farklı sorumluluk

halinde, çeşitli ihtimallere göre farklı davalılar öngörülmüştür. Burada sadece genel sorumluluk düzenlemesinde ismen sayılmış olan davalılar ele alınmıştır.

1. Kurucular

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tedrici kuruluşun kaldırılmış olması sebebiyle sadece ani kuruluş bulunmaktadır. Ani kuruluş esnasında yapılan işlemlerle ilgili olarak kurucuların hukuki (TTK m.553, 549) ve cezai (TTK m.562, 563) sorumluluğuna ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Anonim şirkette *kurucular*, pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerdir (TTK m.337). Bu işlemlerin üçüncü kişiler hesabına yapılması halinde, bu kişiler de kuruluştan doğan sorumluluk bakımından kurucu sayılmaktadır (TTK m.337/2).

Sorumluluğun kaynağına göre sadece kuruculara dava açılabileceği gibi diğer ilgililerin de kusurunun bulunması halinde kurucularla birlikte kusurlu davranışa katılan diğer sorumluluk süjelerine de dava açılabilir.

2. Yönetim Kurulu Üyeleri

Esas sözleşme veya genel kurul kararı ile tayin edilmiş ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan yönetim kurulu üyeleri aleyhine sorumluluk davası açılabilir. Bu kişilerin zararın oluşmasındaki kusurlarından sorumlu olacağı aşikardır.

İşletme konusu kamu hizmeti olan anonim şirketlerin esas sözleşmesine konulacak bir hükümle, şirkette pay sahibi olmasalar dahi kamu tüzel kişilerine, yönetim kurulunda temsilci bulundurma imkânı sunulabilir (TTK m.334). Bu durumda temsilcilerin yönetim kurulunda yaptıkları kusurlu davranışlardan dolayı kamu tüzel kişiliği sorumlu tutulur. Tüzel kişinin temsilcisine karşı rücû hakkı saklıdır (TTK m.334/3).

Anonim şirketin yönetim kurulu üyeliğine, gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişiler de seçilebilir. Üyeliğe tüzel kişinin seçilmesi halinde, tüzel kişi adına yönetim kuruluna katılacak bir gerçek kişi, tüzel kişi tarafından belirlenir ve sicile tescil ve ilan edilir (TTK m.359/2). Tüzel kişi adına sadece bu kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Temsilcinin yönetim kurulunda yansıttığı irade, tüzel kişi üyeye ait olduğundan ve kullanılan oy tüzel kişinin oyu sayıldığından herhangi bir sorumluluk halinde davanın doğrudan tüzel kişi üyeye karşı açılması gerekir. Bununla birlikte gerçek kişi temsilci kendisine verilen talimata aykırı

hareket etmişse, tüzel kişi üyenin iç ilişkide temsilciye rücû etmesi mümkün sayılmalıdır.

3. Diğer Yöneticiler

Anonim şirketin ticari faaliyetlerinin boyutuna göre farklı konumlardaki yöneticiler istihdam edilebilir. Çeşitli isimler altında çalışan bu yöneticilerin bir kısmı temsil yetkisine sahip olup şirketle ilgili iş ve işlemlerde faaliyet gösterirler. Genel müdür, genel müdür yardımcısı, müdür, direktör şeklinde isimlendirilen yöneticiler, hukuki açıdan kural olarak ticari temsilci veya ticari vekil olarak nitelendirilebilirler.

Diğer yöneticiler ile anonim şirket arasında temsil yetkisi içeren yöneticilik ilişkisinin yanı sıra genellikle işçi-işveren ilişkisi de bulunmaktadır. Diğer bir deyişle söz konusu yöneticiler, genellikle anonim şirketin temsil yetkisine sahip yöneticisi olmakla beraber hukuki statüleri işçi konumundadır. Bununla birlikte temsil yetkisini kullanarak anonim şirket için yaptıkları hukuki işlemlerden dolayı bir zarar meydana gelirse bundan dolayı TTK m.553 vd. hükümlerine göre sorumlu olurlar[423].

Şirketin ticari nitelikteki tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesinde aktif görev alan söz konusu yöneticiler, zararlı sonuç doğuran işlemlerin icrasında da katkıda bulunmuş olabilirler. Yöneticilerin kusurlu davranış-

---

[423] Diğer yöneticilerin sorumluluk rejimine ilişkin verilen bir Yargıtay kararında da bu yöneticilerin TTK m.553 vd. hükümlerine göre sorumlu olmaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/8320 Esas, 2018/1396 Karar sayılı ve 26.02.2018 tarihli kararı şu şekildedir: "... *Davacı taraf dilekçesinde davalı ...'nin üst düzey yönetici ve müdür olarak görev yaptığını belirtmiş, buna ilişkin olarak da 05.08.2009 tarihli vekaletnameyi ibraz etmiştir. Vekaletnamede davalı ...'nin şirket müdürlerinden olduğu ve müşterek imza ile nakliye işleri ile ilgili olarak 2.000 TL'ye kadar çek tanzim etmeye yetkisinin bulunduğu yazılıdır. Anonim şirketlerde bir kişinin 6102 sayılı TTK'nın 367. maddesi uyarınca* ***icracı müdür olarak görevlendirilmesi halinde bu kişinin şirket ile aynı zamanda işçi işveren ilişkisinin bulunması onun şirketin zarar verici eyleminden kaynaklanan sorumluluğunun aynı yasanın 553. maddesi uyarınca değerlendirilmesi gereğini ortadan kaldırmayacağından*** *mahkemece tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda davalının TTK'nın 367. maddesi uyarınca icracı müdür olarak görev yapıp yapmadığı belirlenip sonucuna göre görev hususunun değerlendirilmesi gerekirken, yetersiz araştırma ve gerekçeyle yazılı şekilde görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün* ***BOZULMASINA...***, www.kararara ma.yargitay.gov.tr,

ları, hem özel sorumluluk hallerinde hem de genel sorumluluk durumunda ortaya çıkabilir. Yöneticilerin bireysel olarak katkılarının bulunması halinde, diğer sorumluluk süjelerinin yanı sıra bunların aleyhine de sorumluluk davası açılabilir.

4. Denetçiler

Anonim şirketlerin zorunlu organı olmaktan çıkan denetçiler artık şirketlerin bünyesinde istihdam edilmemektedir. Buna karşılık şirketlerin denetimi, artık dışarıdan *bağımsız denetçiler* eliyle yerine getirilmektedir (TTK m.397 vd.)[424].

Bağımsız denetçilerin yanı sıra, anonim şirketteki azınlığın bilgiye ulaşmasını sağlamak ve yöneticilerin yaptıkları bazı iş ve işlemlerin incelenmesi amacıyla *özel denetçi* tayini öngörülmüştür (TTK m.438 vd.)[425].

Anonim şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket etmeleri halinde hem şirkete hem pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludurlar (TTK m.554).

Denetçilerin kusurlarının ispatlanması yukarıda izah edildiği üzere diğer sorumluluk süjeleri ile aynı şekilde gerçekleşmektedir. Zarar verenlerin birden fazla olması halinde diğer sorumluluk süjeleri ile birlikte aleyhlerine dava açılır ve farklılaştırılmış teselsül ilkesi doğrultusunda kusurları oranında sorumlu olurlar.

5. Tasfiye Memurları

Şirketin sona ermesinin arkasından tasfiye aşamasındaki işlemler, tasfiye memurları eliyle yürütülür. Tasfiye memurlarının ayrıca atanmaması halinde, yönetim kurulu bu sıfatla tasfiye işlemlerini gerçekleştirir. Şirkete ayrıca atanan tasfiye memurlarının yaptıkları işlemlerde kusurlu hareket etmeleri halinde, tasfiye memurları sorumlu olurlar ve aleyhlerine dava açılır[426] (TTK m.553/1).

---

[424] Bağımsız denetim ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Dokuzuncu Bölüm, § 12, III, B.

[425] Özel denetçi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda Dokuzuncu Bölüm, § 12, II, E.

[426] **İzmirli**, s. 175 vd.

C. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Sorumluluk davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılacaktır (TTK m.561). 06.12.2018 tarihli 7155 sayılı Kanununun 20'inci maddesi ile Ticaret Kanununa eklenen 5/A maddesi ile ticari davalarda zorunlu arabuluculuk müessesesi getirilmiştir. Bu nedenle, alacak ve tazminat talepli olan sorumluluk davasının açılmasından önce zorunlu olarak arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ancak oldukça ayrıntılı bir yargılama gerektiren ve her bir sorumluluk süjesinin farklılaştırılmış teselsül ilkesine göre kusur oranlarının tespit edilmesi gereken sorumluluk davasından önce gidilecek arabulucuda anlaşmanın sağlanması ihtimali oldukça düşüktür. Ancak yine de dava açılmadan önce arabuluculuk sürecinin tüketilmesi gerekir.

IV) SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER

Anonim şirkette hukuki sorumluluğu sona erdiren veya ortadan kaldıran bazı haller bulunmaktadır. Aşağıda sorumluluk süjelerini kısmen ya da tamamen sorumluluktan kurtaran haller açıklanmıştır.

A. KUSURSUZLUĞUN İSPATI (YETKİ DEVRİ HALİ)

Anonim şirkette hukuki sorumluluğun, kusur sorumluluğu olduğu hususu yukarıda ayrıntılı bir şekilde izah edilmiştir. TTK m.553 hükmünde, ilgililerin kusursuzluklarını ispat etmeleri yönünde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla evvelki TTK'den farklı olarak mevcut Kanunda sorumlular bakımından bir kusur karinesi kabul edilmemiştir. Sorumluluk davasında davacılar, davalıların kusurlu olduklarını iddia ve ispat etmek durumundadırlar[427].

Yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin ve diğer yöneticilerin zararlı sonuç doğuran işlemle ilgili kusurlarının bulunmaması halinde sorumlu olmayacakları açıktır. Yapılan işlemle ilgili gerekli her türlü özenin gösterilmesi, araştırmanın yapılması, uzman raporlarının alınmış olması halinde yine de zararlı sonuç meydana gelirse, artık bu kişilerin kusurlu oldukları ve dolayısıyla sorumluluklarının meydana geldiği ileri sürülemez. Bu bağlamda evvelki Kanunda zikredilen ve fakat yeni

---

[427] Kendigelen sorumlular ile şirket arasındaki ilişkinin sözleşme olduğu (BK 112) gerekçesiyle sorumluluktan kurtulmak isteyen kişinin kusursuzluğunu ispat etmesi gerektiğini savunmaktadır.

Kanunda sayılmasına gerek duyulmayan yönetim kurulu toplantısına mazereti sebebiyle katılamayan veya alınan kararın aleyhine oy kullanıp gerekçesini zapta geçirten yönetim kurulu üyesinin, alınan karardan dolayı sorumlu olmayacağını söylemek gerekir[428].

Şirketin zorunlu organı olan, idare ve temsil yetkisine sahip yönetim kurulunun, kendisine bağlı olarak çalışan ve diğer yöneticiler olarak nitelendirebileceğimiz kişilerin kusurlu davranışlarından sorumluluğunun ne olacağı hususu kanunda açık değildir. Aslında TTK m.553/2 hükmü, *kanundan veya esas sözleşmeden doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hali hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar*, şeklindedir. Görüldüğü üzere, yönetim kurulunun sahip olduğu yetkiyi kanunun kendisine izin verdiği şekilde ve usulüne uygun olarak devretmesi; yetki devri yapılan kişilerin seçiminde gerekli özenin gösterilmesi halinde, artık yönetim kurulunun sorumluluğundan bahsedilemeyecektir.

Varılan bu sonucu TTK m.553/3'de yer alan hiç kimse kontrolü dışında kalan, kanuna veya esas sözleşmeye aykırılıklar veya yolsuzluklar sebebiyle sorumlu tutulamaz; bu sorumlu olmama durumu gözetim ve özen yükümü gerekçe gösterilerek geçersiz kılınamaz, şeklindeki hüküm de desteklemektedir. Yönetim kurulunun idare ve temsil dışında gözetim görevinin bulunduğu açık olmakla birlikte, bu görevin ileriye sürülerek sorumluluk doğacağı kabul edilmemektedir. Diğer bir deyişle, kanun koyucu tarafından usulüne uygun yetki devri ile birlikte özellikle yönetim kurulunun ve diğer üst düzey yöneticilerin sorumluluktan kurtulabilecekleri öngörülmüştür.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, yönetim kurulu TTK m.375'de sayılan devredilemez yetki ve görevleri ile ilgili olarak bir başkasından yardım alsalar dahi sorumluluk doğrudan yönetim kurulu üyelerine ait olacaktır. Yani bu tür görevlerle ilgili yetki devri yapılamayacağı gibi yardımcı kişilerin davranışları üzerinde yönetim kurulunun gözetim görevi devam ettiğinden bu kişilerin kusurlu davranışlarından yönetim kurulu da sorumlu olur. Aynı şekilde devrin mümkün olduğu hallerde, işinin ehli, iyi eğitimli ve tecrübeli kişilere yapılan yetki devri halinde de gözetim

---

[428] Konuyla ilgili olarak bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-83.

yükümlülüğü devam edeceğinden yönetim kurulu, bu kişilerin kusurlu davranışlarından da sorumlu olur[429].

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 549 vd. maddelerinde öngörülen bu sorumluluk sistemi, denetçilerin sorumluluğuna ilişkin 554'üncü maddede 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten[430] sonra kendi içerisinde yeknesak bir hale getirilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu, yürürlüğe girmesinden sonra irili ufaklı çok sayıda değişikliğe konu olmuştur. Söz konusu değişikliklerden birisi de 6552 sayılı Kanun[431] ile 371'inci maddeye eklenen 7'nci fıkra hükmüdür[432]. Anonim ve limited şirketlerde sınırlı yetkili yönetim kurulu üyesi ihtiyacından dolayı yapılan söz konusu değişiklik ile sınırlı yetkili ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının atanması imkânı getirilmiştir. Anılan çerçevede tayin edilen tacir yardımcılarının kusurlu davranışlarından dolayı sorumluluğuna ilişkin değişik bir sistem öngörülmüştür. Gerçekten TTK m.371/7 hükmüne TBMM'de eklenen son cümle sebebiyle, yetki devri sonucunda ortaya çıkan yukarıdaki sorumluluk sistemi değiştirilmiştir. Söz konusu hüküm, *"Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur"* şeklindedir. Görüldüğü gibi usulüne uygun şekilde yapılan yetki devri, yönetim kurulunun sorumluluktan kurtulabilmesine imkân tanıyan TTK m.553 hükmünden farklıdır. TTK m.371/7'deki hükmün istisnai nitelikte dar bir düzenleme olduğu, sadece bu kapsamda iç yönerge hazırlanarak yetki devri yapılan ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları bakımından müteselsil sorumluluğun söz konusu olduğu kabul edilmelidir. Burada zikredilen müteselsil sorumluluğun, TTK m.557'de ifade edilen farklılaştırılmış teselsül olup

---

429 Aksi görüş için bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 16-69-16-72.

430 Daha önce de ifade edildiği gibi, 554'üncü maddenin ilk halindeki *denetçilerin kusurlu olmadıklarını ispat etmedikçe sorumlu olacaklarını* öngören hükmün 6335 sayılı Kanun ile değiştirilerek, *kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdirde* şekline çevrilmesi sonucunda maddeler arasındaki uyumsuzluk ortadan kalkmıştır.

431 11.09.2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

432 Ayrıntılı bilgi için bkz. **Özdamar,** 6552 sayılı Kanun, s. 137 vd.

olmadığı tartışmaya yol açmıştır[433]. Bunun dışında kalan yetki devirleri hakkında yine TTK m.553 vd. hükümleri uygulanmalıdır[434].

B. İBRA

Kelime anlamı itibariyle aklamak, borçtan kurtarmak anlamlarına gelen *ibra*, şirketler hukukunda, şirketin yönetimi ve denetimi ile görevli kişilerin, ilgili dönem itibariyle şirkete karşı sorumlu olmadıklarının genel kurul kararıyla tespit edilmesidir[435]. Hukuki anlamda ise menfi borç ikrarı olarak kabul edilen ibra, inceleme konusu yapılan zaman aralığında, gerçekleştirilen işlemlerin kanuna ve esas sözleşmeye uygun olduğunun genel kurul tarafından beyan edilmesidir.

1. İbra Kararının Alınması

Anonim şirket genel kurulunun, ilgililer hakkında ibra kararını, toplantı ve karar yetersayılarına uymak kaydıyla, iki şekilde alabileceği kabul edilmiştir.

a) Açık İbra

Açık ibra denilen ilk halde, genel kurulun toplantı gündeminde yer alan ibra konusu, gerekli prosedür tamamlandıktan sonra toplantıya katılan pay sahipleri tarafından müzakere edilir ve oya sunulur. Yapılan oylamada gerekli yetersayının sağlanması halinde, yönetici ve denetçilerin, ilgili dönem için şirkete karşı sorumlu olmadıkları bizzat şirketin asıl karar organı tarafından beyan edilmiş olur.

TTK m.409/1'de, anonim şirketlerde her hesap yılının bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gereken olağan genel kurulun zorunlu gündem maddeleri arasında yönetim kurulunun ibrası da konulmuştur. Böylece, her yıl yapılması gereken olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulunun ve gerekli olduğu hallerde diğer ilgililerin ibrası müzakere edilerek karara bağlanacaktır. Her hesap yılı ayrı ayrı alınan ibra kararı ile yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları iş ve işlemlerden

---

[433] Madde metninde öngörülen sorumluluğun tam teselsül olduğuna ilişkin bkz. **Akdağ Güney, N.:** "*6552 Sayılı Torba Kanun ile TTK md. 371'e Eklenen Yedinci Fıkraya İlişkin Değerlendirmeler*", Halil Arslanlı Bilim Arşivi, http://arslanlibilimarsivi.com, son erişim tarihi: 20/02/2019. s.22; sorumluluğun farklılaştırılmış teselsül olduğu yönünde bkz. **Özdamar,** 6552 Sayılı Kanun, s. 161.

[434] **Özdamar,** 6552 Sayılı Kanun, s. 161-162.

[435] Ayrıntılı bilgi için bkz. **Çağlar,** İbra, s. 29 vd.

genel kurulun bilgisine sunulanlarla sınırlı şekilde şirket tarafından aklanmış olmaktadır.

Genel kurulun ibra kararı alabilmesi için gerekli olan toplantı ve karar yetersayısı basit yetersayıya tabidir. TTK m.418'de olağan nitelikteki kararların alınabilmesi için öngörülen ilk toplantıda sermayenin dörtte birinin hazır bulunması, aksi halde ikinci toplantıda herhangi bir yetersayı aranmayacağı hükme bağlanmıştır. Kararlar, toplantıda hazır bulunanların oyçokluğu ile verilir (TTK m.418/2).

Genel kurulda ibra kararının alınması esnasında *oy hakkından yoksunluğu* öngören kanuni düzenlemeleri dikkate almak gerekir. Gerçekten konuya ilişkin olarak TTK m.436/2 hükmüne göre, şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamazlar. Dolayısıyla hem pay sahibi hem de yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkisine sahip yönetici konumunda olan kişiler, kendilerinin ibra edilmesine ilişkin genel kurul toplantısına katılabilseler de oy kullanamazlar. Burada önemli olan husus, şirketin faaliyetlerini yöneten kişilerin aynı zamanda oy hakkına sahip olmasından dolayı sübjektif hareket edip hukuki sıkıntıların üzerinin kapatılmasının önlenmek istenmesidir. Aynı şekilde tüzel kişi yönetim kurulu üyelerini temsil etmesi için yönetim kuruluna bildirilen gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişi yönetim kurulu üyesinin ibrasında oy kullanmaması gerekir.

Üzerinde durulması gereken ve ibra oylamasında oy hakkından yoksunluğa ilişkin bir diğer konu ise yönetim kurulu üyesi ile diğer temsilcilerin pay sahibi olan eşi, alt ve üst soyunun oy hakkının ibra oylamasındaki akıbetidir. Gerçekten TTK m.436/1, "*Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz*", hükmünü amirdir. Bununla birlikte ibraya özel olarak konulan ikinci fıkra hükmünde ise eş, alt ve üst soyun oy hakkına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Yargıtay'ın ve öğretinin yerleşik kararları doğrultusunda, yönetim kurulu üyelerinin ve temsilcilerin ibra kararında eş, alt ve üst soyu olan pay sahiplerinin oy kullanmalarının mümkün olduğu kabul edilmelidir. Bununla birlikte oy hakkının kullanılmasına ilişkin

sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersiz olacağından (TTK m.433) yönetim kurulu üyesi veya yönetici ortakların oydan yoksunluğu dolanmak üzere her tür pay devri yasaklanmıştır.

Kanunda yer alan oy hakkının kullanılmamasına dair düzenlemeye aykırı hareket edilmesi halinde, ibra kararı hukuken sakatlanacağından, bu karar TTK m.445 vd. maddeleri çerçevesinde süresi içinde açılacak iptal davasına konu olabilir[436]. Bu noktada vurgulanması gereken husus, genel kurul toplantısında alınan kararlar hakkında başkaca bir hukuka aykırılık iddiası yok ise, iptal sadece ibraya ilişkin alınan karara münhasır olmalıdır.

İbra kararı ile bağlantılı olan sorumluluk davası açılmasına ilişkin genel kurul kararında da aynı şekilde oy hakkından yoksunluk halinin ortaya çıkıp çıkmayacağı TTK düzenlemesinde açık değildir. Zira TTK m.436/2 düzenlemesinde sadece ibraya ilişkin kararlarda oy hakkından yoksunluk hali düzenlenmiştir. Bununla birlikte yönetim kurulu üyesi hakkında sorumluluk davası açılmasına ilişkin genel kurul kararında da ibra kararı ile bağlantılı olduğu ve aynı amaca hizmet ettiği için oy hakkından yoksunluğun olması gerektiği Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından yeni tarihli bir kararında kabul edilmiştir[437].

---

436 Yetkisiz kişilerin oy kullanması halinde genel kurul kararlarının akıbeti hakkında bkz. **Kırca, (Şehirali Çelik/Manavgat);** C. II, s. 146 vd.

437 Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/12403 Esas, 2018/4469 Karar sayılı ve 18.06.2018 tarihli kararında sorumluluk davasında oy hakkından yoksunluğa ilişkin şu şekilde bir karar verilmiştir: "... *Oysa, yönetim kurulu üyeleri için TTK'nın 436/2 maddesinde öngörülen oydan yoksunluk halinin, sorumluluğa ilişkin davanın açılması hakkındaki kararın oylanması halinde de uygulanması gerekir.* ***Söyle ki, TTK'nın 436/2 maddesi gereğince yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanamayacaklarına göre, ibra edilmemenin tamamlayıcısı niteliğinde olan ve ibraya oranla daha ağır bir durumu ifade eden sorumluluk davasının oylamasında da bu hakka sahip olamazlar.*** *Somut olayda, genel kurul gündeminin (6). maddesinde yer alan, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi zarar verici işlem yapan yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılması hususu görüşülerek yönetim kurulu üyelerinin kullandıkları oylar neticesinde sorumluluk davası açılması talebi reddedilmiştir. Bu durumda, mahkemece, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi zarar verici işlem yapan yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılması hususunda da TTK'nın 436/2 maddesinde öngörülen oydan yoksunluk halinin aranması gerektiği ve* ***somut olayda yönetim kurulu üyelerinin oy kullanmasının sonuca etkili olduğu gözetilerek*** *genel kurulda alınan (6) numaralı kararın*

b) Örtülü (Zımni) İbra

İbra kararının genel kurulda açıkça müzakere edilip oylanmadan da verilebileceği kanun koyucu tarafından belirtilmiştir. *Örtülü, zımni ibra* olarak adlandırılan bu durumda, genel kurulda bilançonun onaylanmasının, ibra ile ilgili aksine ve açık bir karar alınmadıkça, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibrası sonucunu doğuracağı belirtilmiştir (TTK m.424). Böylece açıkça ibra kararı alınmadan sadece bilançonun onaylanmasına, kanun koyucu bu şekilde bir hukuki sonuç bağlamıştır.

Pay sahipleri bazen zımni ibra anlamına geldiğini düşünmeden ya da bilmeden, kendilerine sunulan bilanço ve eklerine bakarak kâğıt üzerinde her şeyin kuralına uygun yapıldığını düşünerek bilançoyu onaylarlar. Zira bilindiği üzere, şirketin defter ve belgeleri genel kuruldan en az on beş gün önce, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulur (TTK m.437/1). Bununla birlikte pay sahiplerinin bu imkândan çok fazla yararlanmadıkları ve genellikle kendilerine sunulan özet bilanço ve kar-zarar hesabı raporuyla yetindikleri bilinmektedir. Bu nedenle, kanun koyucu, bazı hallerde bilançonun onaylanmasının ibra sonucunu doğurmayacağını hükme bağlamıştır. Gerçekten TTK m.424/1'in ikinci cümlesinde, bilançoda bazı konular hiç ya da gereği gibi belirtilmemişse veya bilanço şirketin gerçek durumunun görülmesine engel olacak bazı hususları içeriyorsa ve bu hususta bilinçli hareket edilmişse, bilançonun onaylanmasının ibra etkisi doğurmayacağı açıkça belirtilmiştir. Görüldüğü üzere, pay sahiplerinin sadece bilanço ve kar-zarar hesabına ve bunun özeti niteliğindeki raporlara baktığını bilen yönetici ve denetçilerin hazırladıkları ve kâğıt üzerinde her şeyin güzel göründüğü raporlara bakılarak verilen onama kararının ibra anlamına gelmeyeceği takdir edilmiştir.

Zımni ibra, bilançoda yer alması gereken ve usulüne uygun şekilde bilançoya konulmuş maddi olaylara ilişkin sonuç doğurur. Buna karşılık, bu durumun bilançoda yer alması gerekmeyen ancak hukuki sorumluluk doğurabilecek nitelikteki olaylarla ilgili ibra anlamına gelmeyeceği belirtilmelidir. Bu bağlamda, yapılmak istenen yeni yatırım ile ilgili yeterli araştırma yapılmaması, ihaleye girip istenilen fiyattan ihalenin kazanılmasına rağmen daha sonra zarar edileceği anlaşılarak ihaleden çekilme ve teminat mektubunun yanması gibi hallerde, zımni ibra

---

iptaline karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeye dayalı olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir".

olduğu ileri sürülerek sorumluluk davasından kaçınılması mümkün değildir.

Pay sahiplerini korumaya yönelik bu düzenleme, bilanço ve eklerini hazırlayanların usulsüzlük yapılması esnasında *kasıtlı davranışlarını* aramaktadır. Dolayısıyla yöneticilerin ve denetçilerin kasıtlı fiillerinin bulunmaması halinde bilançonun onaylanmasının ibra sonucunu doğuracağı açıktır.

Yukarıda belirtildiği üzere, TTK m.409/1 hükmü ile ibra konusunun olağan genel kurul toplantılarının zorunlu gündemi haline getirilmesinden sonra, sadece bilançonun onaylanarak zımni ibra kararı alınmasının istisnai niteliğe bürüneceği açıktır.

2. İbranın Etkisi

Açık ya da zımni şekilde alınmış ibra kararının öncelikle şirket tüzel kişiliğinin, ibranın kapsadığı açıklanan maddi olaylara dair yönetici ve denetçilerle ilgili olarak menfi borç ikrarı anlamına geldiğini ve sorumluluk davası açma hakkını ortadan kaldırdığını belirtmek gerekir. Ayrıca genel kurul toplantısında, ibra kararı lehine oy kullanan ve oylamadan sonra ibra kararını bilerek payı iktisap etmiş olan pay sahipleri bakımından da aynı etki ortaya çıkar (TTK m.558/2). Dolayısıyla ibra kararının alınması ile birlikte, şirket ve karara olumlu oy veren ve ibra kararını bilerek payı devralan pay sahipleri, ibra edilmiş bulunan yönetici ve denetçilere karşı sorumluluk davası açamazlar.

İbra kararına muhalif kalan veya ibra kararını bilmeden payları devralan pay sahiplerinin sorumluluk davası açma hakları devam eder. Ancak kanun koyucu sorumluluk davasını, zamanaşımı süresinden başka ayrıca bir hak düşürücü süreye bağlamıştır. Gerçekten TTK m.558/2-son cümlede, diğer pay sahiplerinin dava haklarının, ibra tarihinden itibaren *altı ay geçmekle düşeceği* hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla ibra kararına rağmen sorumluluk davası açılmak istenmesi halinde, bunun altı ay içerisinde hayata geçirilmesi gerekmektedir.

İbra kararının alınmasında şirket alacaklılarının herhangi bir katkısı veya etkisi olmadığından, yönetici ve denetçilere karşı dava açma hakları saklı kalmaktadır. Bir diğer ifadeyle ibra kararı alınmış olmasına rağmen şirket alacaklıları, diğer şartların sağlanması halinde, sorumluluk davasını ikame edebilirler.

3. İbranın Kaldırılamaması

6762 sayılı Kanun döneminde öğreti ve uygulamayı meşgul eden konulardan birisi de genel kurulda alınmış olan ibra kararının daha sonra alınacak yeni bir genel kurul kararı ile kaldırılmasıdır. Özellikle şirketin hâkim paylarının devredilmesi veya diğer usullerle el değiştirmesinden sonra, yeni hâkim grubun yeni bir genel kurul yaparak eski dönemde alınan ibra kararını ortadan kaldırması ve eski yönetici ve denetçilere sorumluluk davası ikame edilmesi gibi durumlarla karşılaşılmaktaydı. Payların devredilmesi ve şirketten çıkılmasından sonra açılan bu tür davalar eski yöneticiler bakımından işlem güvenliğini de zedelemekteydi.

Üzerinde uzun tartışmaların yapıldığı bu konu, Yargıtay'ın yerleşik içtihatları çerçevesinde, ibra kararının yeni bir genel kurul kararı ile kaldırılamayacağı şeklinde kanuna açık hüküm konularak çözümlenmiştir (TTK m.558/1). İbra kararı yeni bir genel kurul kararı ile kaldırılamayacak olmasına rağmen, alınan ibra kararının iptal davasına konu edilmesine engel bulunmamaktadır. TTK m.558/1'de, iptal davasına ilişkin 445'inci madde hükmü saklı tutularak bu husus açıkça vurgulanmıştır.

4. Kuruluş ve Sermaye Artırımında İbra

Anonim şirkette ibra kararı alınarak sorumluluğun ortadan kaldırılması bazı kişi ve olaylarla ilgili olarak özel hükümlere tâbi kılınmıştır. Bu çerçevede kanun koyucu 559'uncu maddede ibranın belirli bir süre için alınmayacağını hükme bağlamıştır. Buna göre, kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ya da ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra yapılacak sulh ya da ibra genel kurulun onayı ile geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ya da ibra kararına muhalif kalırlarsa, sulh ya da ibra genel kurulda onaylanamaz. Alınan karar geçerli olmaz ve ticaret siciline tescil ve ilan edilemez.

Azınlık hakkı niteliğinde olan sulh ya da ibra kararını engelleme, kanunda açıkça azınlığa tanınmış bir olumsuz (menfi) azınlık hakkıdır. Şirketin kuruluşunun üzerinden dört yıllık zaman geçtikten sonra çoğunluk istese de maddede sayılan sorumluluk süjelerini ibra edeme-

mekte veya bunlarla yapılmış olan sulh sözleşmesini genel kurulda onaylatamamaktadır. Çoğunluğun şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımında yapılan usulsüzlüklerin üzerini örtmesini engellemek için getirilen söz konusu olumsuz azınlık hakkının, iyiniyet kuralları çerçevesinde kullanılması gerektiğini bir kez daha ifade etmek gerekir.

Genel kurulda sulh sözleşmesinin onaylanması veya ibra kararı alınması için şirketin kuruluşunu gösteren sicile tescilinden itibaren dört yıllık bir süre öngörülmüştür. Kanunda geçen dört yıllık süreyi, esas sermaye artırımları için ilgili genel kurul kararının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren başlatmak gerekir.

TTK m.559'da sorumluluk süjeleri arasında denetçilerin de sayılmış olmasının, mevcut düzenleme bakımından gereksiz hale geldiği düşünülebilir. Zira işlem denetçiliğinin kaldırılmasından sonra, şirketin kuruluş işlemlerini denetleyen bir mekanizma kalmamıştır. Bu nedenle kuruluş işlemlerindeki usulsüzlükleri inceleyecek bir denetçi bulunmamaktadır. Sermaye artırımları esnasında, şirketin niteliğine göre çalışmak zorunda olduğu bağımsız denetçi tarafından incelenmesi gerektiği düşünüldüğünde, dört yıllık sulh ve ibra yasağının bağımsız denetçi ile ilgili olduğu kabul edilebilir.

C. ZAMANAŞIMI

Anonim şirkette sorumluluk süjelerinin sorumluluklarını ortadan kaldıran bir diğer durum ise zamanaşımıdır. TTK m.560 hükmüne göre, sorumlu olanlara karşı tazminat isteme hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği andan itibaren *iki* ve her halde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren *beş yıl* geçmekle zamanaşımına uğrar. Eski Kanundaki iki ve beş yıllık zamanaşımı süreleri aynı şekilde yeni Kanuna da alınmıştır.

Sorumluluğu doğuran fiilin aynı zamanda cezayı gerektirmesi ve Türk Ceza Kanununda daha uzun bir zamanaşımı süresine tabi olması halinde, tazminat davasına da bu zamanaşımı süresi uygulanır (TTK m.560/1-ikinci cümle).

V) KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK

Anonim şirket ortakları için geçerli olan tek borç ilkesi (sermaye koyma borcu) sebebiyle, ortakların şirketin borçlarından sorumlu olmadıkları daha önce izah edilmişti. Buna karşılık şirketin kamu borçların-

dan dolayı (vergi borcu, SGK prim borcu gibi) şirket tüzel kişiliğinin yanı sıra yönetim kurulu üyelerinin de sorumlu oldukları Türk Ticaret Kanununun dışında Vergi Usul Kanununda (VUK) kararlaştırılmıştır. Gerçekten VUK m.10 hükmüne göre, şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen *vergi borçları*, şirketin kanuni temsilcileri olan yönetim kurulu üyelerinden tahsil edilir. Benzer bir düzenleme de Amme Alacaklarının Tahsili ve Usulü Hakkındaki 6183 sayılı Kanunun 35'inci maddesinde diğer kamu alacakları için öngörülmüştür. Böylece tüm kamu alacakları bu kapsamda değerlendirilir ve şirketten tahsil edilemedikleri takdirde yönetim kurulu üyelerine başvurulur.

Şirketin vergi borçlarının ödenmesi, pay sahiplerinin değil kanuni temsilcilerinin görevi ve yetkisinin kapsamındadır. Bu nedenle borçların ödenmemesinden dolayı anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri, limited şirketlerde ise müdürler ve ortaklar şahsi malvarlıkları ile sorumlu tutulmuşlardır[438]. Görüldüğü üzere anonim şirket ortaklarından farklı olarak limited şirket ortaklarının şirketin kamu borçlarından da sorumlu olması esası benimsenmiştir. Bu bağlamda, anonim şirket ortaklarının ilave bir kefalet, aval veya garanti vermemeleri halinde, şirket borçlarından dolayı sorumlulukları sınırlıdır.

VI) CEZAİ SORUMLULUK

Yukarıdaki paragrafta "hukuki sorumluluk" başlığı yer almış olsa da 6102 sayılı TTK'nin karakteristik özelliklerinden birisi olan cezai hükümlerden kısaca da olsa bahsetmek gerekir. Öncelikle Kanunun ilk halinde oldukça geniş kapsamlı ve etkili cezalar öngörülmüş olmakla beraber, Kanunun yürürlüğe girmesinden önce geniş kapsamlı değişiklik yapan 6335 sayılı Kanun ile cezaların hem kapsamı daraltılmış hem de cezalar hafifletilmiştir.

Bununla birlikte yine de TTK m.562'de uzun ve ayrıntılı şekilde cezai sorumluluk gerektiren fiiller ve bunlara uygulanacak cezalar hükme bağlanmıştır. Sadece anonim şirketlerdeki sorumluluğu düzenleyen

---

438 Konuyla ilgili olarak bkz. **Çamoğlu, E.,** *"Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Dolayı Sorumluluğu"*, Prof. Dr. Gülören Tekinalp'e Armağan, 2003, s. 139 vd.; **Yıldız, Ş.,** *"Anonim Ortaklıkta Yönetim Kurulu Üyelerinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu"*, Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu'na Armağan'a 65. Yaşgünü Armağanı, İstanbul 2001, s. 771 vd.

özel hükümler olan 549, 550, 551 ve 552'nci maddelerde yer alan fiilleri işleyenler hakkında hapis cezası öngörülmüştür. Bunun dışındaki sorumluluk gerektiren ve Kanunun ilk halinde hapis cezası öngörülen fiiller adli para cezasına, adli para cezasına tabi olan fiiller de idari para cezasına çevrilmiştir. Görüldüğü üzere cezaların ağırlığı düşürülmüştür.

TTK m.562'de belirtilen fiillerin takibi şikâyete bağlı suç kapsamında oldukları ve ilgililerin şikâyeti üzerine soruşturma başlayacağını da belirtmek gerekir. Zira bu suçların takibinin re'sen yapılacağına ilişkin TTK m.563 hükmü de 6335 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bu nedenle artık bu maddede sayılan suçların takibinin şikâyete bağlı olduğu kabul edilmektedir.

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

§ 17- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, TTK m.564 vd. hükümlerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, uygulamada çok tercih edilen bir şirket türü değildir. Kanunda da çok ayrıntılı bir şekilde düzenlenmemiş; genellikle anonim şirketlere ve komandit şirketlere atıf yapılmakla yetinilmiştir. Aşağıda bu türe ilişkin esaslar izah edilmiştir.

I. KAVRAM VE ÖZELLİKLER

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde[439], şirketin sermayesi paylara bölünmüştür. Bu açıdan anonim şirket ile benzerlik gösterir[440]. Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, kanun koyucu tarafından sermaye şirketleri arasına konulmuştur (TTK m. 124/2).

Bu şirketlerde, «*komanditer*» ve «*komandite*» olmak üzere iki ayrı ortak bulunur. Komandite ortak, şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, komanditer ortak, anonim şirket pay sahibi gibi sorumludur. Bu sebeple bu şirket türüne ilişkin esaslarda kanun koyucu bir taraftan komandit şirketlere, diğer taraftan anonim şirketlere atıf yapmıştır. Komandite ortak, şirket alacaklılarına karşı, tüm malvarlığı ile ikinci dereceden sorumludur. Komanditer ortak ise, anonim şirket pay sahipleri gibi sorumlu olup; bunların sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye payı ile sınırlıdır.

Komandite ortakların birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten ayrılmaları, komandit şirketlerdeki hükümlere tâbidir (TTK m.565/1). Bu hususların dışında, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkete anonim şirket hükümleri uygulanır (TTK m.565/2).

Şirket sermayesi, paylara bölünmeksizin sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara

---

439 Paylı komandit şirket şeklinde anıldığı da görülmektedir (**Tekinalp (Poroy/Çamoğlu)**, II, N. 1609).

440 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu)**, II, N. 1609.

ayrılmış bulunuyorsa, bu halde komandit şirket hükümleri uygulama alanı bulur (TTK m. 564).

II. ŞİRKETİN KURULUŞU

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin kuruluşuna, bu şirket türüne özgü olarak belirlenmiş hükümler saklı kalmak kaydıyla anonim şirketlerin kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır. Aşağıda kuruluş aşamaları hakkında bilgi verilmiştir.

A) ESAS SÖZLEŞME

Sermayesi paylara bölünmüş şirketin kuruluşu bakımından da şirket esas sözleşmesinin düzenlenmesi, diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi şekle tâbi tutulmuştur. Buna göre esas sözleşmenin yazılı şekilde düzenlenmesi, kurucularla komandite ortakların tümü tarafından imzalanması; imzaların noterce onaylanması veya esas sözleşmenin ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanması gerekir (TTK m.566/1). Bununla birlikte kuruluşu izne bağlı anonim şirketler hakkındaki TTK m.333 hükmünün, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere uygulanmayacağı açıkça belirtilmiştir (TTK m. 566/2).

Esas sözleşmenin içeriği bakımından anonim şirket esas sözleşmelerinin içeriği hakkındaki TTK m.339 hükmü uygulama alanı bulur. Esas sözleşmede, kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak menfaatler dışında TTK m.339'da sayılan tüm hususların bulunması zorunludur. Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde kurucularla, yöneticilere veya üçüncü kişilere şirket kârından menfaat sağlanmasına izin verilmemiştir.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, şirketin işletme konusu bakımından Kanunda herhangi bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu sebeple bu tür şirketlerin kollektif şirketlerde olduğu gibi ticari işletme işletmek amacıyla kurulmaları şart değildir; anonim şirketlerde olduğu gibi ekonomik amaçlarla kurulması mümkündür[441].

B) KURUCULAR

Esas sözleşmeyi imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır. Kurucu sayısı bakımından, anonim

---

[441] **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N 1615; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 411.

şirketlerin tek pay sahibi ile kurulmasına olanak sağlanmasına rağmen, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, kurucu sayısının *beşten az olamayacağı* hükme bağlanmıştır. Ayrıca kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının esas sözleşmeye yazılması gerekir.

C) TESCİL VE İLAN

Şirketin ticaret siciline tescili bakımından anonim şirketler bakımından geçerli olan esaslar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler hakkında da geçerlidir.

III. ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin organsal yapısı hakkında, anonim şirketler ile benzer esaslar kabul edilmiştir. Bu şirketlerde de genel kurul ve yönetim kurulu zorunlu organdır; ancak denetim konusunda anonim şirketlere atıf yapıldığı için bağımsız denetçinin organ olmadığına ilişki tespit bu şirketler hakkında da cari olacaktır[442].

A) YÖNETİM KURULU

1. Yönetim ve Temsil

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, yönetim, komanditeler eliyle gerçekleştirilir. Anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümler, yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerli olur. Komandite ortaklar, şirketin yönetimine ve kural olarak temsiline kanundan dolayı yetkilidir. Bu açıdan "*özden organ*" ilkesi geçerlidir[443].

Şirketi yönetmek ve temsil etmekle görevli olan komandite ortaklar, kollektif şirketin yönetimine ve temsiline görevli ortaklar için kanunda belirlenen hâllerde ve öngörülen şartlar uyarınca görevden alınabilirler. Görevden alma kararının tescili ile görevden alınan ortağın şirketin bu tarihten sonra doğacak borçlarından dolayı kişisel sorumlulukları sona erer.

---

442 **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, **s.** 412.

443 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N. 1623.

2. Rekabet Yasağı

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette, komandite ortaklar bakımından rekabet yasağı öngörülmüştür. Buna göre, komandite ortak diğer komanditelerin ve genel kurulun izni olmaksızın şirketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz. Bu madde hükmüne aykırı hareket eden komandite ortak hakkında kollektif şirkete ilişkin hükümler uygulanır.

B) GENEL KURUL

Genel kurul, komandite ve komanditer ortaklardan oluşan organdır. Anonim şirket genel kuruluna benzemekle birlikte, iki şirket genel kurulu arasında bazı farklılıklar bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır. Örneğin, anonim şirket genel kurulundan farklı olarak, bu şirketlerde genel kurulun yöneticileri seçme yetkisi yoktur[444].

C) DENETİM

Denetim hakkında, TTK m.565/2 hükmünde yapılan atıf sebebiyle anonim şirketlerin denetimine ilişkin esaslar, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler bakımından da geçerlidir[445].

IV. SONA ERME VE TASFİYE

Şirketin sona ermesi ve tasfiyesi hakkında, TTK m.565/2 hükmünde yapılan atıf sebebiyle anonim şirketlerin tasfiye ve sona ermesine ilişkin ilkeler uygulama alanı bulur[446].

---

444 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N 1625.
445 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N 1634.
446 **Tekinalp (Poroy/Çamoğlu),** II, N 1634a.

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

§ 18- LİMİTED ŞİRKETLER

LİTERATÜR

Yıldız, Ş,; Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Şirketler Hukuku, İstanbul 2007; *Şener, O. H.;* Yargıtay Kararları Işığında Limited Ortaklıklar Hukuku, Ankara 2017; *Şener, O. H.;* Yeni TTK Döneminde Anonim ve Limited Ortaklıklara İlişkin Verilen Yargıtay Emsal Kararlarının Değerlendirilmesi, İstanbul 2019; *Yasan, M.;* Limited Şirkette Ortakların Genişletilmiş Hukuki Sorumluluğu, Ankara 2018, *Can, O.;* 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara 2015; *Yıldırım, A. H.;* 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Ortaklığın Haklı sebeple Feshi, Bursa 2013; *Altaş, S..;* Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler, 8. Baskı, Ankara 2017; *Gürbüz Usluel, A., Limited Şirketlerde Ortağın Ek Ödeme Yükümlülüğü,* Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019, *Yalçın Sırakaya, E.;* Limited Şirketin Sona Erme Nedenleri, Ankara 2018.

I) LİMİTED ŞİRKETLE İLGİLİ GENEL ESASLAR

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLER

Ülkemizde sayı itibarıyla en fazla kullanılan şirket türü olan limited şirketler, şahıs şirketlerine ilişkin özellikler taşımakla birlikte daha çok sermaye şirketlerinin temel özelliklerini yansıtmaktadır (TTK m.124/2). Bununla birlikte anonim şirkette olduğu gibi limited şirketin saf bir sermaye şirketi olduğunu söylemek zordur. Zira Kanundaki düzenlemede, şahıs şirketlerine ilişkin birtakım özelliklerin limited şirketler bakımından da halâ geçerli olduğu görülmektedir. Bilhassa ortakların az sayıda olup birbirlerini tanıdıkları ve birbirlerine güven duydukları ortama sahip olan limited şirketlerde ortakların şirket borçlarından sınırlı sorumlu olması (tek borç ilkesi), uygulamada bu şirketlerin diğer şirket türlerine nazaran daha fazla tercih edilmelerine yol açmıştır.

Limited şirket ortaklarının sayısının daha ziyade az olması, ortakların birbirlerinin şahsına güvenerek şirkete ortak olmaları, şirkette pay devrinin zorlaştırılmış olması (TTK m.595), şirketten çıkma ve çıkarılmaya imkân sağlanması (TTK m.638, 640), bazı genel kurul kararlarının alınabilmesi için sermaye ve payların nitelikli çoğunluğunun birlikte aranması (TTK m.621) gibi hususlardan dolayı limited şirket hala şahıs şirketlerine benzemektedir.

Şahıs şirketlerine benzemekle beraber limited şirketin ortaklarının şirket borçlarından sınırlı şekilde sorumlu olması, şirket denetiminin anonim şirketlerdeki bağımsız denetim sistemine tâbi kılınması, genel kurul ve müdürlerin yetki ve görevlerinin ayrıştırılması, genel kurulun nitelikli çoğunluk ile alacağı kararla müdürlerin görevden alınabilmesi, idare ve temsil yetkisinin sınırlandırılması (TTK m.630/1), tek ortaklı şirkete müsaade edilmiş olması (TTK m.573/1), anonim şirketlere ilişkin birçok hükme atıf yapılmış olması (bkz. TTK m.578, 592, 610, 622, 629 vd.) limited şirketlerin sermaye şirketi özelliğini ön plana çıkarmaktadır.

Limited şirketin Türk Ticaret Kanununun 573'üncü maddesindeki tanımı ve diğer özelliklerinden yola çıkılarak yapılan tanımı ve yine kanundaki düzenlemelerdeki özellikleri aşağıda yer almaktadır.

1) Kavram

Limited şirket, en az bir en fazla elli gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından kanunen yasaklanmamış bir amaç ve konuda faaliyet göstermek üzere kurulan, ortakların şirket borçlarından dolayı sınırlı sorumlu oldukları, esas sermayesi belli ve payların itibari değerlerinin toplamından oluşan bir sermaye şirketidir.

Limited şirket, Türk Ticaret Kanununda açıkça ticaret şirketi ve sermaye şirketi olarak kabul edilmektedir (TTK m.124). Bu nedenle limited şirket, ortaklarından bağımsız bir tüzel kişiliğe ve dolayısıyla hak ve fiil ehliyetine sahip olan (TTK m.125), kurulduğu andan itibaren tacir sıfatı bulunan (TTK m.16) kendi borçlarından dolayı sınırsız şekilde sorumlu olan şirkettir.

2) Özellikler

Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelerden limited şirketlerin temel birtakım unsurları şu şekilde tespit edilebilir:

a. Kişi (Şahıs)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden birisi olan ortak sayısının bir kişi olarak belirlenebilmesi ilkesi, limited şirketler bakımından da geçerlidir. TTK m.574 hükmüne göre, limited şirketlerde ortak sayısı en az bir en fazla elli olmalıdır.

Limited şirketin ortaklarının paylarını geri alması, TTK m.612'deki esaslar çerçevesinde sınırlı bir şekilde mümkün kılınmıştır. Buna karşılık, limited şirketin ortaksız kalmasına yol açacak şekilde tüm paylarını iktisap etmesi kabul edilmemiştir. Gerçekten TTK m.574/3 hükmüne göre, şirket tek ortağının kendisinin olacağı şirkete dönüşeceği sonucunu doğuracak şekilde esas sermaye payını iktisap edemez. Dolayısıyla kanun koyucu ortaksız limited şirket yapısını yasaklamış ve buna yol açabilecek şekilde pay devirlerini geçersiz saymıştır.

Şirketin ortak sayısının bir kişiye düşmesi halinde durumun üçüncü kişilere duyurulabilmesi için kanun koyucu birtakım önlemler almıştır. TTK m.574/2 hükmüne göre, şirketin kurulduktan sonra pay devirleri sonucunda tek ortaklı hale gelmesi halinde durum yedi gün içerisinde şirket müdürüne yazılı olarak bildirilir. Şirket müdürü bildirimi aldıktan sonraki ikinci yedi günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını ticaret siciline tescil ettirir. Şirketin baştan tek ortaklı kurulması halinde, aynı bilgilerin yine ticaret siciline tescil edilmesi gerekmektedir. Böylece şirketin baştan veya sonradan tek ortaklı hale gelmesi durumunun, üçüncü kişiler tarafından ticaret sicili sayesinde öğrenilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Limited şirketlerde ortak sayısının üst sınır olan elli kişiyi aşması halinde hukuki akıbetin ne olacağına ilişkin kanunda açık bir düzenleme yer almamaktadır. Türk Ticaret Kanununun 574'üncü maddesinin gerekçesinde, elli ortak sınırının aşılmamasına hem müdürlerin hem de genel kurulun dikkat etmesi; bu hususta özen göstermeleri, sınırı aşan tescillere onay vermemeleri konusunda belki ilgililerin hukuki sorumluluğunu doğuracak ama somut meseleyi çözümsüz bırakacak bir açıklama yer almaktadır[447]. Bu durumda, kanunun emredici nitelikteki

---

[447] *"Birinci fıkrada tek kişilik limited şirkete olanak veren değişiklik yapılırken, en çok elli ortak sınırlaması korunmuştur. Elli ortak sınırının aşılmamasına hem müdürler hem de genel kurul dikkat etmeli; bu hususta özen göstermeli, sınırı aşan tescillere onay vermemelidir"* (Gerekçe TTK m.574).

bu hükmüne aykırı olarak yapılan devir işleminin geçersiz olduğu düşünülmelidir. Sayının artması miras gibi bir hukuki müesseseden kaynaklanmışsa, pay devri yoluyla şirket ortağı olacak mirasçıların sayısının azaltılması veya payların bir kişide toplanması yahut şirketin anonim şirkete dönüşmesi yoluna gidilmelidir. Aksi halde, şirket yöneticisinin veya sicil müdürünün talebi üzerine mahkemenin verdiği uygun süre içinde ortak sayısının azaltılmaması halinde şirketin sona ermiş sayılması söz konusu olabilir[448].

b. Ticaret Unvanı

Limited şirketler ticaret şirketi kapsamında olduklarından TTK m.16 hükmü uyarınca tüzel kişi tacir sayılmaktadır. Bu bağlamda, her limited şirket, kanunun kendisine öngördüğü şekilde ticaret unvanı seçmek, seçtiği unvanı sicile tescil ettirmek ve ticari işlemlerinde bunu kullanmak zorundadır (TTK m.18, 573/1). Limited şirketler, *konu ticaret unvanı* belirlemek durumunda olduklarından, unvanlarında işletme konusu ile şirketi ve türünü gösteren ibarenin bulunması gerekli ve yeterlidir (TTK m.43). Mesela, (Uzay) Yazılım ve Bilgisayar Programcılığı Limited Şirketi.

c. Esas Sermaye ve Pay

Limited şirketlerin esas sermayesi, en az on bin TL olmalı ve şirketin esas sözleşmesinde miktarı ve ortaklar tarafından taahhüt edildiği belirtilmelidir (TTK m.580). Sözleşmede yazılı olan tutarın, esas sözleşmenin değiştirilmesi usulüne tâbi olarak sermayenin artırılması veya

---

448 Öğretide ortak sayısı elli kişiyi aşan limited şirketlerin akıbeti konusunda fikir birliği bulunmamaktadır. *Yıldız*, ortak sayısının elli kişiyi aşması halinde yapılan pay devrinin geçersiz olması veya tasarıda yer alan ve fakat 6335 sayılı Kanun ile kaldırılan TTK m. 628/2'deki ticaret sicil müdürünün şirket müdürleri ile ilgili durumun düzeltilmesi için süre vermesi ve aykırılık giderilmezse şirketin feshi için dava açması yoluna gidilmesini önermiştir (s. 70). Buna karşılık, *Bilgili/Demirkapı* ise, elli ortak sınırının aşılması halinde ortak sayısının aşağıya çekilmesi veya tür değiştirme yollarından birinin izlenmesi gerektiğini savunmaktadır (s.621-622). Öğretide *Çeker* ise, Fransız hukukunda konuya ilişkin getirilen çözüm tarzının Türk hukukuna da uygulanabileceğini ve buna göre, şirkete mahkemece uygun bir süre tanınması ve bu süre içinde gerekli tedbirleri almayan şirketin feshine karar verilmesi gerekeceğini ifade etmiştir, (**Çeker, M.**, "*Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması*", TFM, 2015, C.1, S.1, s. 61-62).

istisnai hallerde azaltılması mümkündür. Şirket sermayesi, nakdi veya ayni (kanunda sayılan sermaye unsurları) şekilde belirlenebilir.

Limited şirketin sermayesi, ortaklarının sermaye payları toplamından oluşmaktadır. Şirket sözleşmesinde her bir payın itibari değerini en az yirmi beş TL ve katları şeklinde belirleyip göstermek gereklidir (TTK m.583/1). Şirketin mali durumunun iyileştirilmesi amacıyla söz konusu rakamın altında bir bedel üzerinden itibari değer tespit edilebilir. Ortakların her birinin esas sermaye payları yirmi beş TL ve katları şeklinde olmak kaydıyla farklı farklı belirlenebilir (TTK m.583/2).

Limited şirketlerde ortakların paylarının, yirmi beş TL ve katları şeklindeki itibari değer üzerinden belirlenmesine rağmen, burada anonim şirketlerde olduğu gibi, gerçek anlamda sermayenin paylara bölünmesinden bahsedilmemektedir[449]. Ortakların oy hakkının, payların itibari değerine göre hesaplanmasının, esas sermayenin paylara bölünmesi anlamına gelmediği hükme bağlanmıştır (TTK m.618/2). Dolayısıyla anonim şirketlerde olduğu gibi ortakların haklarının belirlenmesinde esas alınan sermaye payı ile limited şirketteki esas sermaye payı bire bir aynı değildir[450].

---

449 TTK m. 583'ün gerekçesinde, şu ifadeler yer almaktadır: "*Limited şirkette, "itibarî değer", anonim şirketteki itibarî değerden hem teorik hem de doğmatik düzen yönünden farklıdır. Anonim şirkette itibarî değer, gerçek anlamda paylara bölünmüşlüğün gereği olarak sermayenin serbestçe devredilebilen, hak kaynağı işlevini haiz, bağımsız bir birimini oluştururken; limited şirkette pay bir taraftan konulan sermayeyi gösteren ve bazı hesabi işlemlere temel oluşturan diğer paylarla eşit olması zorunlu bulunmayan esas sermayenin bir parçasını oluşturur. Anonim şirkette sermaye paylara bölünmüştür, limited şirkette ise esas sermaye payı, bazı hakların belirlenebilmesi ve kullanılabilmesi amacıyla hesabi olarak bölünür. Payın hesaben bölünmesi, payın verdiği oy hakkının hesaplanmasına ve temettünün belirlenmesine, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin uygulanmasına hizmet eder. Diğer yandan, "bir ortak=bir pay" kuralının belirli bir yararı bulunmamakta, aksine, payın kısmî devrinde bölünme gibi güçlüklere yol açmaktadır*".

450 Öğretide ***Tekinalp***, limited şirketlerde sermayenin paylara bölünmemiş olduğunu, bir sermaye payının verdiği oy sayısını belirlemek amacıyla itibari değer üzerinden bölünmesinin gerçek anlamda olmayıp hesaben bölünme olduğunu, söz konusu iki bölünmeyi birbirinden ayırt etmeyi sağlamak üzere kanunda sıra dışı bir şekilde ve ikaz etmek amacıyla, TTK m. 583/2-c.3 hükmünün ihdas edildiğini ifade etmektedir (Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, N. 18-20). Ayrıca bkz. **Pulaşlı,** Şerh, C. 3, s. 2724, §67 N. 72-74.

d. İşletme Konusu

Limited şirketlerin kanunen yasak olmayan her türlü ticari amaç için kurulabileceği kanunda açıkça hükme bağlanmıştır (TTK m.573/3). Bununla birlikte birtakım ticari faaliyetlerin özel olarak anonim şirket eliyle yapılması kararlaştırılmıştır.

e. Tüzel Kişilik

Limited şirket, diğer ticaret şirketlerinde olduğu gibi tescil edildiği andan itibaren tüzel kişiliğe sahiptir (TTK m.125/1, 588). 6102 sayılı TTK ile *Ultra Vires* ilkesi kaldırıldığı için, limited şirket amacı ve konusu dâhilinde hakları kullanabilir, borç altına girebilir (TTK m.125; TMK m.48)[451].

f. Ortakların Sınırlı Sorumluluğu

Sermaye şirketlerine rengini veren özellik olan ortakların şirket borçlarından sınırlı sorumlu olması (tek borç ilkesi), kural olarak limited şirketler bakımından da geçerlidir (TTK m.573/2). Anonim şirketlerden farklı olarak limited şirket ortakları, sözleşmede yer alması halinde, sermaye borcuna ilaveten ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalabilirler. Bunun dışında, ortağın borcu limited şirket tüzel kişiliğinedir. Ödenmemiş olan sermaye borcundan dolayı şirket alacaklılarının, ortağı doğrudan takip etme yetkisinin bulunmadığı kabul edilmelidir[452].

6183 sayılı AATUHK'nin istisnai nitelikteki 35'nci maddesi hükmü uyarınca, ortakların, limited şirketin kamu borçlarından dolayı sınırsız ve müteselsilen sorumlu olduklarını belirtmek gerekir. Limited şirket ortaklarına münhasıran uygulanan söz konusu düzenleme çerçevesinde,

---

Buna karşılık ***Bahtiyar***, TTK m. 583'ün gerekçesinin yanıltıcı olduğunu, sermayenin paylara bölünmesi ile esas sermaye payının bölünmesini birbirinden ayrı değerlendirmek gerektiğini, limited şirkette de payların birbirinden farklı da olsa itibari değerinin bulunmasının ve bunun esas sözleşmede gösterilmesinin esas sermayenin paylara bölündüğü anlamına geldiğini ve esas sermaye payının anonim şirket payına benzediğini ifade etmektedir (Ortaklıklar Hukuku, s. 420 vd.).

451 Ticaret Şirketlerinin Genel Hükümlerinde de ele alınan kısım atıf

452 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, s. 511-512, N. 18.03; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 418; **Pulaşlı**, Şerh, C. III, s. 2827, § 67-82.

ortakların sermaye koyma borcuna ilaveten ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin yanı sıra kamu borçlarından da sorumlu olmaları kanunen kabul edilmiştir.

II) KURULUŞ

Limited şirketler, kural olarak anonim şirketlere ilişkin hükümler kapsamında yeni şirket kuruluşu esasları çerçevesinde kurulurlar.

A. ŞİRKET SÖZLEŞMESİ

Limited şirketin kuruluşu için öncelikle kanunda belirtilen şartları içeren yazılı sözleşmenin[453] kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin[454] huzurunda imzalanması gerekir (TTK m.575).

Şirket sözleşmesinde yer alabilecek hususlarla ilgili olarak, anonim şirketler bakımından ayrıntılı şekilde incelenmiş bulunan emredici hükümler ilkesi[455] limited şirket için de geçerli kılınmıştır (TTK m.579). Gerçekten şirket sözleşmesinde, Kanunda öngörülen hükümlerden ancak yine Kanunda buna açıkça cevaz verilmişse sapılabilir. Kanunda müsaade edilmemişse, sözleşmeye konulan hükümlerin geçerli olmayacağını söylemek gerekir[456].

Kanun koyucu, limited şirket sözleşmesinin içeriğini, anonim şirketlere ilişkin TTK m.339'dan en azından şeklen ayrılarak, m. 576'da *zorunlu kayıtlar*, m. 577'de ise *şirket sözleşmesinde öngörülmeleri kaydıyla bağlayıcı olan kayıtlar* şeklinde ikiye ayırarak incelemiştir.

---

453 TTK m. 575'e 6728 sayılı Kanun ile yapılan eklemeyle limited şirketin kuruluşunda, *şirket sözleşmesini ihtiva eden kâğıtlardan değerli kağıt bedeli alınmayacağı* hükme bağlanmıştır.

454 Kanunun ilk halinde kurucuların imzalarının noterde onaylanacağı öngörülmüş olmakla birlikte daha sonra 15.07.2016 tarihli ve 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle onay yetkisi ticaret sicil müdürüne ve yardımcısına bırakılmıştır. Sicil müdürünün veya yardımcısının tüm kuruluş işlemlerine nezaret etmesi oldukça zor olduğundan 15.02.2018 tarih ve 7069 sayılı Kanun ile yapılan son değişiklikle bu yetkinin *sicil müdürlüğünün görevlendireceği personele* ait olacağı kararlaştırılmıştır.

455 Anonim şirketler için geçerli olan emredici hükümler ilkesi hakkında bkz. Altıncı Bölüm, § 8, V, D.

456 Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlere de sözleşme içeriğine getirilen sınırlamalarla çelik korse giydirildiği ifade edilmektedir. Bu konuda bkz. **Kendigelen,** İlk Tespitler, s. 484; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 424.

Böylece her iki başlık altında düzenlenen hususlar dışındaki bir konunun şirket sözleşmesine yazılabilmesi için yine Kanunun izin vermesi gereklidir.

1. Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Gereken Zorunlu Kayıtlar

TTK m.576'da şirket sözleşmesinde açıkça yer alması gereken kayıtlar şu şekilde sıralanmıştır:

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu.

c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları.

d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.

e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.

Şirket sözleşmesinde asgari olarak yer alması gereken hususlar bu şekilde sıralanmıştır. Sözleşme tescil için ticaret siciline götürüldüğünde, sicil müdürü veya yetkilendirdiği kişi tarafından bu hususların olup olmadığı re'sen incelenecektir.

2. Şirket Sözleşmesinde Yer Alması Halinde Bağlayıcı Olan Kayıtlar

Aslında iki taraf arasında sınırlı etkisi olan hükümlerin şirket sözleşmesine konulması halinde, şirketler hukuku bağlamında etkiye sahip olması ve şirkete ortak olan herkese karşı ileri sürülebilecek niteliğe bürünmesi söz konusu olur[457]. Söz konusu kayıtlar şu şekilde gösterilebilir (TTK m.577):

Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümlerdir:

a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler.

b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım hakları tanınması.

---

[457] Öğretide **Tekinalp,** TTK m. 577'de yer alan hususların sözleşme tescil ve ilan edilince TTK m. 36 hükmündeki sicilin olumlu etkisinden yararlanamayacağını, bu konuda TTK m. 557'nin m. 587'de olduğu gibi m. 36'ya gönderme yapmadığını, söz konusu hususların sadece şirketi ve ortakları bağlayacağını, üçüncü kişilere karşı ileriye sürülemeyeceğini ifade etmiştir, (Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, N. 19-13a).

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler.

f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.

g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.

h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.

ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.

i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.

j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.

k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.

l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.

B) SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

Yukarıda izah edilen unsurları içeren şirket sözleşmesinin, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünün yetkilendirdiği personel huzurunda imzalanması gereklidir. Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketler bakımından da kurucuların beyan verme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır (TTK m.349, 586/2).

C. TESCİL VE İLAN

Ön şirket müessesesi limited şirket bakımından da öngörülmüştür. TTK m.585/1'e göre şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi şartsız olarak taahhüt

ettikleri, ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur. Böylece ön şirket, şirket sözleşmesinin sicildeki yetkili kişiler önünde imzalandığı anda kurulur ve sözleşme usulüne uygun şekilde tescil edilip tüzel kişilik kazanılana kadar devam eder (TTK m.588).

Şirketin, kuruluşuna kadar geçen dönemde ön limited şirket olduğu ortaya çıkmaktadır[458]. Bu dönemde ortaklar arasında kural olarak şirket sözleşmesi hükümleri uygulanır. Ancak sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ve özellikle dış ilişki bakımından adi şirket hükümlerinin uygulanması düşünülebilir[459].

Usulüne uygun şekilde hazırlanmış bulunan şirket sözleşmesinin yetkili sicil personeli önünde imzalanmasını müteakiben otuz gün içerisinde sicile tescili gereklidir. Kurucuların gerekli diğer evrakları da önceden temin etmek suretiyle şirket sözleşmesinin imzalanmasını müteakip sicil müdürlüğünde tescil işlemlerini derhal yaptırabilmeleri mümkün olduğundan otuz günlük sürenin pratikte çok fazla önemi kalmamıştır. Zira şirket sözleşmesinin zaten sicil personeli huzurunda imzalanmasının ardından tescil aşamasına geçilebilecek olması otuz günlük sürenin önemini ortadan kaldırmıştır.

Limited şirket, sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesi ile tüzel kişilik kazanır (TTK m.588/1).

D. ŞİRKETİN KURULUŞUNDAN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLER VE MASRAFLAR

Şirketin kurulmasından önce yapılan işlemlerin ve masrafların akıbetine ilişkin olarak, anonim şirket hükümlerine paralel şekilde, TTK m.588'de özel bir düzenleme yer almıştır. Buna göre şirketin, tüzel kişilik kazanmasının akabinde, daha önce şirket adına ve hesabına yapılan masrafları kabul etmesi gerekir (TTK m.588/2). Şirket tarafından kabul

---

458 Öğretide ***Tekinalp***, ön şirket aşamasında hukuk âleminde bir adi şirketin olduğunu, ortaklar arasındaki ilişkiye de adi şirket hükümlerinin uygulanması gerektiğini savunmaktadır, (Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, N. 10-27, 19-18). Buna karşılık ***Pulaşlı***, kanunun ifadesinin açık olduğunu belirterek tescile kadar ortada ön limited şirket olduğunu belirtmektedir, (C. 3, s. 2731-2732). Konuyla ilgili tartışmalar için ayrıca bkz. **Yıldız,** s. 97-98.

459 Aynı yönde bkz. **Yıldız,** s. 98.

edilmeyen kuruluş giderleri ile diğer masraflardan (şirketin kuruluşundan sonraki faaliyetlerine yönelik olarak yapılan) kurucular sorumlu olur. Bunları şirket ortaklarına rücû etme hakları da bulunmamaktadır.

Şirket sözleşmesinin tescilinden önce şirket adına yapılan işlemlerden (şirket faaliyetleri için işyeri kiralanması, içinin tefriş edilmesi, araç kiralanması vb. hususlar için yapılan sözleşmeler), bu işlemleri yapanlar şahsen ve müteselsilen sorumludur (TTK m.588/3). Bununla birlikte, söz konusu işlem ve sözleşmelerin ileride kurulacak şirket adına yapıldıklarının açıkça bildirilmeleri ve şirketin ticaret siciline tescilini izleyen üç aylık süre içerisinde şirket tarafından kabul edilmeleri halinde, bunlardan sadece şirket sorumlu olur (TTK m.588/4).

E. ESAS SERMAYENİN ÖZELLİKLERİ VE ÖDENMESİ

Limited şirkete getirilebilecek olan sermayenin *ayni* ve/veya *nakdi* unsurlardan belirlenmesi gereklidir. Şahsi sermaye unsurlarının (kişisel emek, ticari itibar vb.) limited şirkete sermaye olarak getirilmesi mümkün değildir (TTK m.581/1).

Anonim şirketlerde olduğu gibi, üzerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, *fikrî mülkiyet hakları* ile *sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı unsurları ayni sermaye* olarak konulabilir (TTK m.581/1). Ayrıca ayni sermaye, ayınların veya işletmelerin devralınması ve özel menfaatler hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır (TTK m.578).

Nakdi sermaye olarak taahhüt edilen miktarın şirket sözleşmesinde açıkça yazılması ve sicile tescil edilmesi gereklidir. Söz konusu sermayenin ödenmesi konusunda limited şirket bakımından günümüze kadar farklı yöntemler tesis edilmiştir. Kanunun ilk halinde sermayenin tamamının peşin olarak ödenmesi zorunluluğu[460] öngörülmesine karşın daha sonra yapılan değişiklikle anonim şirketlerde olduğu gibi sermayenin 1/4'ünün peşin, kalan 3/4'lük kısmının tescilden itibaren 24 ay içerisinde ödenmesi şart kılınmıştır[461]. Nihayet 2018 yılında yapılan son

---

460 TTK m. 585'inci maddenin ilk halinde limited şirkete getirilmesi taahhüt edilen nakdi sermayenin tamamının hemen ve tamamen ödenmesi ile şirketin kurulabileceği hükme bağlanmıştı.

461 Ticaret Kanunu henüz yürürlüğe girmeden önemli değişiklikler getiren 26.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile limited şirketlerdeki nakdi sermayenin ödenmesine ilişkin kural anonim şirketlerde olduğu gibi değiştirilmiştir. Buna

değişiklikle[462], taahhüt edilen sermayenin 1/4'ünün peşin ödenme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Bu durumda limited şirkete getirilecek olan sermayenin tescilden itibaren 24 ay içinde tamamının ödenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

F. KURULUŞ İŞLEMLERİNDEKİ EKSİKLİKLER VE FESİH

Kuruluş işlemlerindeki eksikliklerden dolayı ortaya çıkabilecek hukuki durum ile ilgili olarak limited şirketler kısmında özel bir düzenleme bulunmamakta ve şirketin feshine yönelik TTK m.353 hükmüne yollama yapılmaktadır (TTK m.644/1-b).

göre nakdi sermayenin ¼'ü peşin kalan kısmı ise 24 ay içerisinde ödenmesi gerekliydi.

462 15.02.2018 tarih ve 7099 sayılı Kanun ile TTK m. 585'e 3'üncü cümle olarak, *"Ancak nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az yüzde yirmi beşinin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmaz"* hükmü eklenmiştir.

§ 19- LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ

Limited şirketlerde, genel kurul ve müdürler olmak üzere iki adet zorunlu organ bulunmaktadır. Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de denetçilerin organ olma vasfı ortadan kaldırılmıştır[463].

Genel kurulun yetkilerinin belirlenmesi, bunlar arasında devredilemeyecek nitelikte olanların tespit edilmesi ve aynı şekilde müdürlerin yetkilerinin sınırlarının çizilmesi, limited şirketleri daha çok anonim şirketlere yaklaştırmıştır.

I) GENEL KURUL

Limited şirketin önemli kararlarının alındığı organı genel kuruldur. Genel kurulda alınan kararların icrası müdürler tarafından yerine getirilir.

A) GENEL KURULUN YETKİLERİ

Organlar arasındaki yetki sınırlarının daha kolay çizilebilmesi için anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de genel kurulun yetkileri belirlenmiş ve bunların hangilerinin münhasır (devredilemez) yetki olduğu da tespit edilmiştir. Genel kurulun münhasır yetkileri şu şekilde sıralanabilir:

a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi.

b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları.

c) Topluluk denetçisi ile denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları.

d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması.

e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi.

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları.

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması.

---

463 6762 sayılı TTK'da limited şirketlerin ortak sayısının yirmi rakamını aşmaması halinde ayrı bir denetçi tayinine gerek duyulmamış ve tüm ortakların denetçi sayılması kabul edilmişti. Buna karşılık ortak sayısının yirmiyi geçmesi halinde en az bir denetçinin seçilmesi zorunu kılınmıştı (m.548).

h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması.

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir iktisabın onaylanması.

i) Şirketin feshi.

j) Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi.

Kanun koyucu genel kurulun münhasır yetkilerinin yanı sıra esas sözleşmede zikredilmesi halinde devredilemeyecek nitelikteki bazı yetkileri de 616'ncı maddenin ikinci fıkrasında sıralamıştır:

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin faaliyetlerinin onaylanması.

b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması hakkında karar verilmesi.

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi.

d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması.

e) Şirket sözleşmesinin 613'üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların onayını yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı için gereken iznin verilmesi.

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması.

Limited şirketin tek ortaktan oluşması halinde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine tek başına sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şart kılınmıştır (TTK m.616/3).

Yukarıda yapılan saymanın dışında genel kurulun yetkilerinin sınırını üçüncü kişilerin hakları ile ortakların bireysel çıkarları oluşturur. Genel kurulda karar alınırken bunlara dikkate edilmesi ve bunların ihlal edilmemeleri gereklidir (TTK m.622).

B) GENEL KURUL TOPLANTILARI

Limited şirketlerde iki tür genel kurul toplantısı bulunmaktadır. Olağan ve olağanüstü olarak isimlendirilen söz konusu toplantılara kural olarak anonim şirket hükümleri kıyasen uygulanır (TTK m.617/3).

Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren üç ay içerisinde yapılır. Söz konusu süre hak düşürücü olmamakla beraber, uyulmadığı takdirde müdürlerin sorumluluğunu ortaya çıkarabilecek niteliktedir (TTK m.617/1).

Olağanüstü genel kurul toplantısı ise şirket sözleşmesi uyarınca belirlenen hallerde ve gerektikçe yapılır (TTK m.617/1).

1. Çağrı Usulü ve Gündem

Limited şirket genel kurul toplantısına çağrı yetkisi kural olarak şirket müdürüne veya birden fazla müdürün bulunması halinde müdürler kuruluna aittir (TTK m.617/1)[464]. Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, genel kurul toplantı gününden en az on beş gün önce toplantıya çağrının gerçekleştirilmesi gerekir (TTK m.617/2). Şirket sözleşmesi ile bu sürenin on güne kadar kısaltılabileceği ancak uzatılamayacağı yine Kanunda hükme bağlanmıştır (TTK m.617/2).

Limited şirket genel kurulu, müdürlerin yanı sıra, *tasfiye memurları*, mahkemeden izin alan *tek pay sahibi*, mahkemenin atayacağı kayyum aracılığıyla *azınlık (%10) pay sahipleri* tarafından toplantıya çağrılabilir (TTK m.617/3'ün yollamasıyla m.410-412).

Anonim şirketlerin bazı genel kurul toplantılarına Bakanlık temsilcisinin çağrılması ve tutanağı imzalaması zorunlu olmasına karşın limited şirketler bakımından böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır (TTK m.617/3).

---

464 Şirkette iki müdür bulunması halinde müdürlerin bir tanesinin genel kurulu toplantıya çağırmasının usule uygun olmadığı hakkında bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2015/ 15527 Esas, 2017 / 2736 Karar sayılı, 09.05.2017 Tarihli kararı: "*...Somut olayda toplantıya çağrı hususunda müdürler kurulu tarafından herhangi bir karar alınmadığı hususu tartışmasızdır. Her ne kadar diğer müdür, davacı müdür ile toplanamadıklarını ve bu nedenle çağrının kendisi tarafından yapıldığını savunmuş ise de TTK'nın 410/2. maddesinde böyle bir durumda çağrının ne şekilde yapılabileceği düzenlenmiş olup bu prosedüre uyulmadığı da dosya kapsamıyla sabittir. Bu durumda çağrıya yetkili organın genel kurul toplantısı yapılmasına yönelik bir kararı olmadan yetkisi bulunmayan bir müdür tarafından yapılan çağrı ile toplantının yapıldığını, toplantı esnasında davacı ortak müdürün bu şekilde toplantı yapılamayacağına ilişkin itirazda bulunduğu, bu itirazını muhalefet şerhi olarak tutanağa dercettirdiği anlaşıldığından bu toplantıda alınan tüm kararlar batıl olup mahkemece bu nedenle alınan kararların butlanına karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir*".

Toplantı gündemi, genel kurulu toplantıya çağıran irade tarafından belirlenir. Önceden hazırlanan gündemin[465] ortaklara çağrı merasimi ile birlikte tebliğ ve ayrıca ilan edilmesi gereklidir.

Toplantıya çağrı zorunlu olmakla birlikte kanun koyucu çağrısız genel kurul yapılmasını mümkün kılmıştır (TTK m.617/3'ün yollamasıyla m.416). Ortak sayısının genellikle az olması sebebiyle çağrısız genel kurul limited şirketlerde çok sık kullanılan bir yöntemdir.

Limited şirketleri anonim şirketlerden ayıran önemli özelliklerden birisi de elden imza dolaştırmak suretiyle genel kurul kararı (*sirküler karar*) alınmasıdır. Ortaklardan herhangi birisinin toplantı yapılması konusunda isteği olmadığı takdirde, ortaklardan birisinin sunduğu gündem maddesine ilişkin metnin imzalanması suretiyle de karar alınabilir (TTK m.617/4). Önerinin tüm ortakların onayına sunulması geçerlilik şartı olarak kabul edilmiştir. Elden imza suretiyle karar alma usulünde aranılması gereken yetersayılar konusunda açıklık bulunmamaktadır. Kanun koyucu, ayrıca toplantı yapmaya gerek duyulmayan bu usulde hangi çoğunlukla karar alınabileceğini açıkça ifade etmemiştir[466].

2. Toplantı ve Karar Yetersayıları

Limited şirket genel kurulunda aranan yeter sayılar, toplantıda alınacak kararların niteliğine göre değişmektedir.

a) Alelade Kararlar (Basit Nisap)

Şirketin önemli konuları dışında kalan kararların alınması esnasında uygulanan basit çoğunluktur (TTK m.620). Buna göre kararlar, kanunda veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadığı takdirde, toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. Ayrıca toplantı yeter sayısı öngörülmediğinden toplantıya gelen ortakların temsil ettikleri oyların salt çoğunluğu, kararın alınabilmesi için yeterlidir. Oysa

---

[465] Öğretide *Tekinalp*, limited şirketlerde gündeme bağlılık ilkesinin bulunmadığını belirtmektedir (Sermaye Ortaklıklarının Yeni Hukuku, N. 22-47).

[466] Anonim şirket yönetim kurulunun toplantı yapmaksızın karar almasını düzenleyen TTK m.390/4 hükmündeki üye tam sayısının çoğunluğu ölçüsünün kıyasen burada da uygulanabileceği belirtilmektedir (**Kendigelen,** İlk Tespitler, s. 526-527). Bu ölçünün kullanılabileceğini belirtmekle beraber, ortak sayısının mı sermaye miktarının mı esas alınacağı hususunun belirli olmadığı konusunda bkz. **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 432).

anonim şirketlerde, bu tür kararlar için ilk toplantıda toplantı yeter sayısı aranmamış; ancak bunun sağlanamaması halinde ikinci toplantıda yeter sayı aranmamıştır.

b) Önemli Kararlar (Ağırlaştırılmış Nisap)

Kanun koyucu önemli olarak kabul ettiği bazı kararların alınabilmesi için şirkette temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada olmasını aramıştır (TTK m.621/1). Söz konusu kararlar:

aa) Şirket işletme konusunun değiştirilmesi.

bb) Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi.

cc) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması.

dd) Esas sermayenin artırılması.

ee) Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması.

ff) Şirket merkezinin değiştirilmesi.

gg) Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi.

hh) Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması.

ıı) Şirketin feshi.

Kanunun ağırlaştırılmış yetersayıyı aradığı hallerde, bu nisabı daha da ağırlaştıracak sözleşme hükümleri, ancak şirket sözleşmesinde öngörülecek çoğunlukla kabul edilir (TTK m.621/2). Bu halde şirket sözleşmesinde değişiklik yapılarak daha ağır bir nisabın getirilebilmesi, mevcut sözleşmedeki çoğunlukla değil, getirilmek istenen çoğunlukla alınacak kararla yapılabilir.

Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin olarak özel bir hususa kanun koyucu TTK m.621/3'de yer vermiştir. Buna göre, bir ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin sebeplerin sözleşmeye konulabilmesi, sermayeyi temsil eden tüm ortakların genel kurul toplantısında oy birliği ile karar almasıyla mümkündür.

c) Kanunda Öngörülen Diğer Özel Kararlar

Yukarıda sayılanlar dışında limited şirket genel kurulunun alacağı bazı kararlar için ayrıca özel nisaplar öngörülmüştür. Esas sözleşmenin değiştirilmesi başta olmak üzere, ortaklara ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü getiren kararlar ile birleşme ve bölünmeye ilişkin alınan kararlara dair yeter sayılar özel olarak belirlenmiştir.

Limited şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine dair genel hüküm TTK m.589'da yer almıştır. Buna göre şirket sözleşmesi, sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. TTK m.589, m.621'deki düzenlemeyi saklı tuttuğu için burada sayılmayan esas sözleşme değişiklikleri için genel hüküm niteliğinde olan ilgili yeter sayı uygulanır[467]. Aslında TTK m.621'de öngörülen önemli konuların büyük çoğunluğu da esas sözleşme değişiklikleri ile ilgilidir. Orada sayılmayan esas sözleşme değişiklikleri, nitelik itibariyle TTK m.589'daki düzenlemeye tâbi olacaktır.

Şirket sözleşmesinin değiştirilmesini gerektiren bir diğer özel durum ise, ortaklara ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü getirilmesidir. Bahse konu kararın ilgili tüm ortakların oybirliği ile alınabileceği hükme bağlanmıştır (TTK m.607).

Şirketler hukukunun genel hükümleri arasında yer alan tür değiştirme, birleşme ve bölünme kararı için, nitelikli çifte çoğunluk aranmıştır (TTK m.189/1-c, 151/1-c, 173). Buna göre, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip olmaları koşuluyla, ortakların sayı itibariyle dörtte üçünün olumlu oyu gerekmektedir.

3. Oy Hakkı ve Hesaplanması

TTK m.618'de genel kurulda ortakların oy hakkı ve bunun nasıl hesaplanacağı düzenlenmiştir. Buna göre, ortakların oy hakkı esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır (TTK m.618/1). Esas sözleşmede daha yüksek bir tutar öngörülmemişse, her yirmi beş TL bir oy hakkı verir. Böylece esas sermaye yirmi beş TL itibari değerli paylara

---

[467] Esas sözleşme değişikliği için öngörülen yeter sayının TTK m.621'deki düzenlemeden daha ağır olduğu ve her iki yeter sayının birbiri ile uyumsuz bulunduğu yönündeki eleştiriler için bkz. **Yıldız,** s. 114-115; **Kendigelen,** s. 534.

bölünmüşse, her bir pay bir oy hakkı; elli TL itibari değerli paylara bölünmüşse her bir pay iki oy hakkı verecektir[468]. Dolayısıyla bu kuralın aksine sözleşme hükmü bulunmadıkça, limited şirkette oy hakkı ve bunun hesaplanmasında sermaye paylarının itibari değeri esas alınacaktır.

Kanunda oyda imtiyaza ilişkin özel bir düzenleme TTK m.618/2'de yer almıştır. Buna göre şirket sözleşmesiyle ortakların oy hakkı, itibari değerden bağımsız olarak her esas sermaye payına bir oy hakkı düşecek şekilde düzenlenebilir. Böylece farklı itibari değere sahip olan payların hepsinin birbirine eşit şekilde bir oy hakkı vermesi halinde imtiyazlı pay meydana getirilmektedir. Zira daha düşük itibari değere sahip paylar diğerlerine nazaran imtiyazlı hale gelmektedir. Mesela, itibari değeri yirmi beş TL olan ile yüz TL olan payın bir oy hakkı vermesi halinde yirmi beş TL itibari değere sahip olan paylar imtiyazlı hale gelecektir. Kanun koyucu bunun kötüye kullanılmasını engelleyebilmek için, en küçük esas sermaye payının itibari değeri, diğer esas sermaye paylarının itibari değerleri toplamının onda birinden[469] az olamaz (TTK m.618/2)[470] düzenlemesine yer vermiştir. Dolayısıyla en az yirmi beş TL itibari değeri olan paya bir oy hakkı verilirken diğer taraftan geride kalan sermaye paylarının itibari değerinin toplamı en fazla iki yüz elli TL olabilecektir. Böylece iki tür itibari değerli payın bulunduğu limited şirkette, biri yirmi beş TL diğeri ise en fazla iki yüz elli TL olabilecek ve oranlama olarak yirmi beş TL'lik pay on oya sahip gibi değerlendirilebilecektir[471].

Kanun koyucu, şirket sözleşmesi ile meydana getirilebilecek olan oyda imtiyaz hallerinin[472] bazı durumlarda *kısıtlanması esasını* benim-

---

468 **Yıldız,** s. 222-223.

469 Söz konusu hesaplama yöntemi ile ilgili eleştiriler için bkz. **Kendigelen,** s. 529.

470 Anonim şirketlerde oyda imtiyaz limited şirketten daha farklı bir yöntem ile eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilerek meydana getirilebilmektedir (TTK m.479/1). Söz konusu oyda imtiyaz imkânı, her bir paya en fazla onbeş oy hakkı verilebilmesi şeklinde sınırlandırılmıştır (TTK m.479/2). Buna karşılık limited şirketlerde ise farklı itibari değerdeki paylara bir oy hakkı tanınması şeklinde ortaya çıkarılabilen imtiyaz, TTK m.618/2'deki sınırlama dışında başka bir hükme tâbi tutulmamıştır. Anonim ve limited şirketlerdeki oyda imtiyaz yöntemlerinin farklılığı konusundaki eleştiriler ve öneriler için bkz. **Kendigelen,** s. 529; **Yıldız,** s. 222-224.

471 Bkz. **Yıldız,** s. 223.

472 TTK m.618/3'de yer alan "*oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket sözleşmesi hükmü*" ibaresini sözleşme ile meydana getirilen oyda imtiyaz şeklinde anlamak gerekir.

semiştir (TTK m.618/3). Denetçilerin seçimi, şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi ve sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi konularında söz konusu imtiyazlar dikkate alınmayacaktır. Anonim şirketlerdeki düzenlemeden farklı olarak, limited şirketlerde şirket sözleşmesindeki değişikliklere ilişkin kararlar, oyda imtiyazın kaldırıldığı haller arasında sayılmamıştır (TTK m.479/3, m.618)[473].

4. Oy Hakkından Yoksunluk

Pay sahiplerinin belirli konulardaki oylamalarda oy hakkından mahrum kalacaklarına ilişkin düzenleme, TTK m.619'da yer almıştır. Eski TTK'dan farklı olarak daha ayrıntılı bir şekilde pay sahiplerinin hangi hallerde oy hakkından yoksun kalacakları düzenlenmiştir. Buna göre üç ayrı durumda oy hakkının geçici olarak ortadan kalkacağı kabul edilmiştir:

İlk olarak herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibrasına ilişkin oylamalarda oy kullanamazlar.

İkinci olarak şirketin kendi esas sermaye payının iktisabına ilişkin kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak, devre konu paylardan doğan oy hakkını kullanamaz.

Son olarak da ortağın bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz.

5. Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği

Limited şirketlere ilişkin olarak özel bir düzenleme yer almadığından, anonim şirket genel kurul kararlarının butlanına ve iptaline ilişkin hükümler kıyasen limited şirketler için de uygulanır (TTK m.622).

II) MÜDÜRLER

Limited şirketlerin idare ve temsil organı olarak müdür/müdürler bulunmaktadır (TTK m.623). Anonim şirketlerdeki yönetim kurulunun karşılığı olarak limited şirketlerde müdür/müdürler yer almaktadır. Limited şirkette müdür bir ya da birden fazla kişi olabilir (TTK m.623/1).

---

[473] Öğretide ***Moroğlu,*** TTK m. 618/3'deki kısıtlamaların arasına, sözleşme değişikliğinin de eklenmesi gerektiği savunmaktadır, (Değerlendirme, s. 387). Ayrıca bkz. **Kendigelen,** s. 531; **Yıldız,** s. 224.

Eski TTK'de (m. 540) yer alan ayrı bir müdür seçilmediği takdirde tüm ortakların müdür sıfatıyla şirketi yöneteceklerine ilişkin düzenleme, mevcut Kanuna alınmamış ve müdürlerin esas sözleşme veya genel kurul kararıyla mutlaka seçilmesi kabul edilmiştir. Böylece, şirketin idare ve temsili ortaklar bakımından bir hak olarak korunmuş ve fakat yükümlülük olmaktan çıkarılmıştır. Yapılan değişiklik sonucunda limited şirketin idare ve temsili daha ziyade anonim şirketlere benzemiştir[474].

A. MÜDÜRÜN SEÇİLMESİ

Limited şirkette müdürün seçilmesi, *esas sözleşme* veya *genel kurul kararıyla* olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir.

Şirketin ne şekilde idare ve temsil edileceğine ilişkin temel kurallar esas sözleşmede gösterilir (TTK m.623/1). Şirket sözleşmesi ile şirketin idare ve temsili müdür sıfatını taşıyan bir ya da daha fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. Görüldüğü gibi esas sözleşme ile idare ve temsilin ortaklar eliyle mi, yoksa üçüncü kişiler tarafından mı yürütüleceği tespit edilir. Ancak her halükarda şirketin idare hakkının ve temsil yetkisinin en az bir ortakta olması gerekir (TTK m.623/1-son cümle). Böylece TTK m.370/2-son cümledeki anonim şirket yönetim kurulu için getirilen düzenlemeye yaklaşılmıştır. Ancak orada sadece en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine sahip olması gerektiğinden bahsedilirken limited şirketler hakkında en az bir ortağın hem idare hakkına hem de temsil yetkisine sahip olması gerektiği hükme bağlanmıştır.

Müdürlerin belirlenmesine ilişkin ikinci yöntem ise genel kurul kararı ile atanmadır. TTK m.623'te açıkça öngörülmemiş olsa da, ilk müdürlerin esas sözleşmede belirlenmesine karşın daha sonra yapılacak seçimlerin genel kurul kararı ile olması muhtemeldir. Zira genel kurulun yetkilerini düzenleyen TTK m.616/1-b'de müdürlerin atanmaları ve görevden alınmalarına ilişkin yetki, münhasıran genel kurula bırakılmıştır. Müdürlerin atanması ve görevden alınması, önemli işler katego-

---

474 Ortakların yönetici olmasının hem bir hak hem de yükümlülük olarak sayıldığı özden organ ilkesinin terk edildiği ve bunun yerine seçim yoluyla gelen idarenin tercih edildiği yönündeki açıklamalar için bkz. **Yıldız,** s. 176; **Kendigelen,** s. 536; **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 18-01; **Pulaşlı,** C.3, s. 2846, §70 N. 49-50.

risinde yer almadığı ve esas sözleşmenin değiştirilmesini gerektirmediği için olağan kararlar için öngörülen yeter sayı ile karar alınabilecektir (TTK m.620).

Kanun koyucu, anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemeden (TTK m.362) farklı olarak müdürlerin seçilebileceği azami süreyi göstermemiştir. Bu durumda, müdürlerin seçimi esnasında görev süreleri gösterilebilir. Müdürün seçimi esnasında görev süresinin belirlenmesine ve bu durumun sicile tescil ve ilân edilmesine herhangi bir engel bulunmadığı kanaatindeyiz.

B. BİRDEN FAZLA MÜDÜRÜN BELİRLENMESİ

Şirkette birden fazla müdürün bulunması halinde, anonim şirket yönetim kurulu başkanının seçiminden farklı olarak limited şirketlerde, ortak olmalarına bakılmaksızın bunlardan birinin genel kurul tarafından başkan olarak atanması gereklidir (TTK m.624/1). Müdürler, çoğunluğun iradesi ile karar alabilirler. Oylamada eşitlik çıkması halinde müdürler kurulu başkanının oyu üstün sayılır[475]. Bununla birlikte şirket esas sözleşmesinde, müdürlerin karar alabilmelerine yönelik olarak farklı bir yöntem belirlenebilir (TTK m.624/3).

Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması halinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağrılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka bir yönde karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, şirketin ortağı olup olmaması önem arz etmeksizin, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya yetkilidir (TTK m.624/2).

C. MÜDÜRLERİN ÖZELLİKLERİ

Limited şirket müdürlerinin özellikleri ile ilgili olarak kanun koyucu ayrı bir tespitte bulunmamıştır[476]. Müdür ya da müdürler ortak olabileceği gibi profesyonellerin şirket yönetimine dâhil olabilmeleri için dışarıdan da seçilebilirler. Ancak her halükarda idare ve temsile yetkili bir ortağın olması zorunludur (TTK m.623).

---

[475] Anonim şirket yönetim kurulunda başkanın oyu üstün tutulmamasına karşın (TTK m. 390) limited şirketlerde idare organındaki muhtemel kilitlenmeyi çözebilecek bir araç olarak kabul edilerek müdürler kurulu başkanının oyuna üstünlük tanınmıştır.

[476] Müdürlerin tam ehliyetli olması veya iflas etmemiş olması gibi hususlar açıkça aranmamıştır. Bununla birlikte müdürlük sıfatını sona erdiren hususların müdürlerde baştan aranması gerektiği konusunda bkz. **Yıldız,** Ş., Limited, s. 251.

Müdürler gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişiler arasından da seçilebilir. Şirketin müdürlerinden birisi tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler ve şirkete bildirir (TTK m.623/2). Böylece müdür sıfatı tüzel kişiye ait olmakla beraber, tüzel kişi adına icraatı belirlenmiş olan gerçek kişi yerine getirir. Gerçek kişinin değiştirilmesi için ayrı bir genel kurul kararına gerek olmayıp tüzel kişi olan müdürün iradesi ile yeni bir temsilci seçilebilir.

D. MÜDÜRLERİN GÖREVLERİ

Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula yetki vermediği her konuda yetkili kılınmıştır (TTK m.625/1). Müdürler bakımından da, bazı görevlerin devredilemez ve vazgeçilemez nitelikte olduğu belirtilmiştir:

a) Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi.

b) Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi.

c) Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve finansal planlamanın oluşturulması.

d) Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin gözetimi.

e) Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin kurulması.

f) Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi.

g) Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.

h) Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi.

Şirket esas sözleşmesinde, müdür veya müdürlerin aldıkları belirli kararları ve münferit sorunları, genel kurulun onayına sunmaları öngörülebilir. Ancak genel kurulun onayının alınmış olmasının, müdürlerin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi sınırlandırmayacağı da belirtilmiştir (TTK m.625/1). Organlar arasındaki işlevler ayrılığının özel

bir istisnası niteliğinde olan söz konusu düzenleme, organların birbirinden bağımsız oldukları ilkesini limited şirketler açısından yumuşatmıştır[477]. Bu durumda, genel kurulda kararın lehine oy kullanan pay sahiplerinin, sonradan müdürler aleyhine sorumluluk davası açması, çelişkili davranış yasağı ile karşılaşır. Bu nedenle sorumluluk davasının karara muhalif kalan pay sahipleri ile alacaklılar tarafından açılabileceğinin kabulü dürüstlük kuralına da uygunluk arz eder.

E. MÜDÜRLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müdürler, limited şirketin idare ve temsil organı olmaları sebebiyle sahip oldukları hakların yanı sıra birtakım yükümlülükler altına girerler. Özellikle kanunen ve esas sözleşme ile kendilerine yüklenen görevleri ifa ederken aşağıda bahsedilecek olan yükümlülüklere riayet etmeleri kendilerinden beklenir.

1. Özen ve Sadakat Yükümlülüğü

Müdürler, kendilerine yüklenen görevlerin ifası esnasında tüm özeni göstermek ve şirketin menfaatini dürüstlük kuralı çerçevesinde gözetmekle yükümlüdür (TTK m.626/1). Bunun yanı sıra ortaklar için Kanunda öngörülen bağlılık yükümlülüğü, ortak olsun ya da olmasın bütün müdürler için de geçerlidir (TTK m.626/3).

Müdürler hakkında şirketler topluluğuna ilişkin TTK m.202-205 hükümleri saklı tutulmuştur. Şirketler topluluğunda tam hâkimiyet halinde, hâkim olan şirketin yönetiminin belirli şartlar altında bağlı şirketin yöneticilerine (müdürlerine) talimat verebilecekleri; yöneticilerin de söz konusu talimatlara uymakla yükümlü oldukları hükme bağlanmıştır (TTK m.203). Bu tür talimatlara uymaları sonucunda ortaya çıkan zararlardan dolayı bağlı şirketin yöneticileri, şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulmayacaklardır (TTK m.205).

2. Rekabet Yasağı

Limited şirketlerde rekabet yasağı kanun ile sadece müdür sıfatına sahip olan kişiler için öngörülmüştür. Yönetici olmayan ortakların kural

---

[477] Müdürlerin aldığı kararın genel kurulda onaylanmasının ardından uygulanması sonucunda bir zarar meydana gelirse, belirlenecek tazminat miktarından indirim yapılması gerektiği konusunda bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 22-05/06.

olarak bu şekilde bir yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak şirket sözleşmesi ile ortakların da bu tür faaliyetlerden kaçınmalarına ilişkin kurallar konulabilir (TTK m.613/2).

Limited şirket müdürleri, şirket sözleşmesinde açıkça müsaade edilmedikçe veya tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişlerse, şirketle rekabet oluşturabilecek nitelikteki ticari faaliyetlerden kaçınmak zorundadır (TTK m.626/2). Şirket sözleşmesi, ortakların onayı yerine genel kurul kararını öngörebilir. Bu durumda, rekabet yasağına aykırı faaliyetler için genel kurul kararı ile izin verilebilir. Söz konusu izin, önemli işlerden sayıldığından, TTK m.621/1'deki yeter sayıya uygun şekilde alınacak bir genel kurul kararı ile verilmelidir.

3. Eşit İşlem Yükümlülüğü

Limited şirket müdürlerinin, eşit şartlar altında bulunan ortaklara eşit işlem yapmaları zorunlu kılınmıştır (TTK m.627). Anonim şirket yönetim kurulunda olduğu gibi limited şirket müdürlerinin de ortaklar arasında ayrım yapmaması, aynı şartlarda bulunan ortaklara aynı şekilde davranması gerekir. Aksi halde eşit işlem ilkesine aykırı hareketten, müdürlerin kararlarının geçersizliği söz konusu olabilir.

Kanunda açıkça zikredilmemiş olsa da, ortaklar arasında eşit işlem yapma ilkesinin genel kurul için de geçerli olması gerektiği söylenebilir. Anonim şirketlerde temel ilke olarak kabul edilen[478] ve böylece hem yönetim kurulu hem de genel kurul için bağlayıcı olan söz konusu ilkenin, limited şirketlerde sadece müdürler için öngörülmesi bir eksiklik olarak değerlendirilebilir[479].

4. Müdürlerin Şirketin Mali Durumunun Bozulduğunu Bildirim Yükümlülüğü

Limited şirketin esas sermayesinin kaybı veya borca batık olması hallerinde, anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır[480]. Dolayısıyla anonim şirketlerdeki hükümlere paralel şekilde, şirketin sermaye kaybı veya borca batıklık durumunun ortaya çıkması halinde, müdürler durumu tespit ettikten sonra genel kurula bilgi vermeli ve gerekli önlemlerin alınması konusunda yönlendirme yapmalıdır.

---

478 Anonim şirketlerde eşit işlem ilkesi için bkz. yukarıda Altıncı Bölüm, § 8, E.

479 **Kendigelen,** s. 542; **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 21-04.

480 Konuyla ilgili olarak bkz. yukarıda Yedinci Bölüm, § 10, VII, D.

Limited şirkete ilişkin iflasın bildirilmesi ve konkordato talebine anonim şirket hükümleri uygulanır (TTK m.634).

5. Müdürlerin Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı

Anonim şirketlere ilişkin hangi hükümlerin limited şirketler hakkında uygulanacağını gösteren TTK m.644/2 hükmüne sonradan yapılan ekleme[481] ile yönetim kurulunun borçlanma yasağına ilişkin düzenleme olan 395'inci maddeye yollama yapılmıştır. Ancak yollama, müdürlerin yakınlarının borçlanmasına ilişkin 395'inci maddenin 2'nci fıkrasının 1'inci ve 2'nci cümlelerinin limited şirketlerde uygulanacağı şeklinde yapılmıştır. Yapılan bu sınırlı yollamanın bilinçli şekilde yapılmadığı, hükmün, yakınlarının yanı sıra müdürlerin de nakit borçlanma yasağına tâbi olması gerektiği şeklinde anlaşılması daha doğrudur[482].

F. MÜDÜRLERİN TEMSİL YETKİSİ

Müdürlerin temsil yetkilerinin kapsamına, yetkinin sınırlandırılmasına, imzaya yetkili olanların belirlenmesine, imza şekli ile bunların tescil ve ilanına bu Kanunun anonim şirketlere ilişkin hükümleri (TTK m.370-373) kıyasen uygulanır (TTK m.629/1).

1. Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları

Müdürlerin idare ve temsil yetkisinin sınırları, kanunun ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği bütün konular olarak çizilebilir (TTK m.623/3, 625/1). Bu bağlamda şirketin faaliyet konusu çerçevesinde müdürler şirketi hak sahibi yapan veya borç altına sokan hukuki işlemleri yapabilir.

Esasen şirketin hak ve fiil ehliyetini sözleşmesinde yazılı faaliyet konuları ile sınırlayan *ultra vires* ilkesi mevcut Türk Ticaret Kanununa alınmamıştır[483]. Bununla birlikte TTK m.629/1 hükmünün yapmış olduğu yollama sebebiyle anonim şirket yönetim kurulunun temsil yetkisinin kapsamı ve sınırlandırılmasına ilişkin TTK m.371 hükmü limited şirketlerde uygulama alanı bulur. Bu bağlamda TTK m.371/1 hükmünde, anonim şirketi temsile yetkili olan kişilerin şirketin amacına

---

[481] 30.06.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun.

[482] **Kendigelen,** s. 559.

[483] Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 4, III, B, 5.

ve işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapabileceği belirtilmiştir. Bir an için müdürlerin şirketin işletme konusuna girmeyen faaliyetlerde bulunamayacağı (*ultra vires)* düşünülse de aynı maddenin 2'nci fıkrasına göre, şirketin işletme konusuna girmeyen hususlarda müdürlerce tesis edilecek işlemlerin de şirketi bağlayacağı; ancak işlemin diğer tarafı olan üçüncü kişinin, meselenin işletme konusuna girmediğini bilmesi veya bilebilecek durumda bulunması halinde, şirketin sorumluluktan kurtulabileceği öngörülmüştür[484]. Ayrıca belirtmek gerekir ki, şirket sözleşmesinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesinin, sicilin olumlu etkisinden yola çıkarak üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldıracağı düşünülebilirse de ilgili konu bakımından tescil ve ilan tek başına yeterli kabul edilmemiştir (TTK m.371/2-son cümle). Bahse konu açıklamalar aynı şekilde limited şirket müdürleri ve diğer temsilcileri için de geçerlidir.

2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması veya Kaldırılması

Müdürlerin belirli bir süre için atanmış olması halinde, bu sürenin dolması ile görevinin sona ereceği açıktır. Bunun yanı sıra henüz görev süresi dolmadan genel kurul kararı ile müdür ya da müdürler görevden alınabileceği gibi idare ve temsil yetkisi de sınırlandırılabilir (TTK m.630/1). Genel kurulda karar alınabilmesi için kanunda haklı sebep aranmamış olmasına karşın, bu yetkinin kötüye kullanılmaması için genel kurul kararının bir dayanağı aranmalıdır[485]. Aksi halde kararın iptali için açılabilecek davada şirketin zor durumda kalması söz konusu olabilir. Genel kurulda alınan kararın icrası için müdür aleyhine dava açılabilmesi için bir kayyum atanması ve davanın bu kayyum eliyle bağımsız ve objektif şekilde yürütülmesi gerekir[486].

---

484 Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda, Üçüncü Bölüm, § 4, III, B, 5.

485 *Pulaşlı,* şirketle müdür arasındaki ilişkinin güvene dayalı olduğunu, güvenin sarsılması halinde genel kurulun haklı bir sebep olsun ya da olmasın müdürün yetkilerini sınırlayabileceği veya kaldırabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte müdürün tazminat hakkının da saklı olduğunu, hatta haksız bir isnada maruz kalırsa manevi tazminat davası dahi açabileceğini belirtmiştir, (C. 3, s. 2857, § 70 N. 82).

486 Konuya ilişkin Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2016/11604 Esas, 2018/3853 Karar sayılı ve 23.05.2018 Tarihli kararı şu şekildedir: "*Dava, davalı limited şirketin fesih ve tasfiyesi ile diğer davalının müdürlükten azli talebini içermektedir. Ancak, davacılar ve davalı ...'in davalı şirkette birlikte müdür sıfatını taşıdıkları, tasfiye davasının şirkete yöneltilmesi gerektiği, zorunlu hasım olarak gösterilmesi gereken şirketin davanın tarafı olan ve müdür sıfatı bulunan üç gerçek kişiden*

Genel kurul kararının dışında, limited şirketin her ortağı, haklı sebeplerin varlığı halinde mahkemeye başvurarak yöneticilerin idare haklarının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını talep edebilir (TTK m.630/2)[487]. Haklı sebeplerin neler olabileceğine ilişkin TTK m.630/3 hükmünde açıklamalar bulunmaktadır. Buna göre, yöneticinin özen ve bağlılık yükümü ile diğer kanunlardan ve şirket sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini ağır bir şekilde ihlal etmesi veya şirketin iyi yönetimi için gerekli yeteneği kaybetmesi haklı sebep olarak kabul edilmiştir[488].

Genel kurul kararı ile görevden alınan müdürün şirkete karşı tazminat hakkının saklı olduğu hüküm altına alınmıştır (TTK m.630/4). Bu durumda, yöneticilik görevinin süresinden önce sona erdirilmesi sebebiyle müdürün uğradığı zararın tazmini gündeme gelir. Bu gerekçeyle

---

ikisinin imzası ile temsil edilebileceği anlaşılmaktadır. Temsil yetkisi bulunan iki ortağın (müdürün) davacı, diğer ortağın (müdürün) ise davalı tarafta yer aldığı işbu davada şirketin temsili konusunda taraflar arasında menfaat çatışması bulunduğu, davalı müdürün azlinin de talep edildiği ve bu talebin reddi ile kararın kesinleştiği de göz önünde bulundurulduğunda işbu davada şirketin temsili bakımından şirkete temsil kayyımı tayini gerekirken bu eksiklik giderilmeden yanılgılı değerlendirme ile yargılamaya devam olunması doğru olmamış kararın bu nedenle re'sen bozulması gerekmiştir".

487 Benzer bir düzenleme de TTK m. 219'da kollektif şirket yöneticileri için getirilmiştir. Birlikte karar alınması mümkün olmadığı takdirde her ortağın mahkemeye giderek yetkilerin sınırlandırılmasını veya kaldırılmasını isteme hakkı kollektif şirket ortaklarına da tanınmıştır. Konuyla ilgili olarak bkz. Yukarıda, Dördüncü Bölüm, § 6, VI, C, 1, c.

488 Konuyla ilgili olarak Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin verdiği 2016/ 5809 Esas, 2018 / 67 Karar sayılı 08.01.2018 Tarihli kararı şu şekildedir: *"... Dava, limited şirket müdürünün azline ilişkindir. Mahkemece, azınlık pay sahibi davacının önce genel kurula başvurup genel kuruldan karar alındıktan sonra dava yoluyla mahkemeden talepte bulunabileceği, ayrıca davacının bildirdiği sebeplerin şirket müdürünün azli için yeterli neden sayılmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu'nun 630/2. maddesi uyarınca, her ortak, haklı sebeplerin varlığı durumunda yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılmasını veya sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. Bu durumda, mahkemece anılan kanun maddesi gereğince davacı tarafından ileri sürülen sebeplerin tek tek tartışılıp azil için haklı sebep sayılıp sayılmayacağı gerekçelendirilmeden yazılı gerekçe ile ileri sürülen sebeplerin azil için yeterli sebep sayılmadığından bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın davacı yararına bozulmasını gerektirmiştir*".

tazminat hakkının saklı olduğu hükmünü (TTK m.630/4), anılan maddenin birinci fıkrasında yer alan genel kurul tarafından yönetim hakkının ve temsil yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması halinde gündeme gelebilecek bir hak olarak değerlendirmek gereklidir.

G. TİCARİ MÜMESSİLLER (TEMSİLCİLER) VE TİCARİ VEKİLLER

Şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme bulunmadığı takdirde, ticari temsilciler ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilir; yetkileri sınırlandırılabilir (TTK m.631/1). Esasen anonim şirketlerde yönetim kuruluna ait olan söz konusu atama yetkisi ortak sayısı daha az olan limited şirketlerde, önemine binaen genel kurula bırakılmıştır[489]. Ancak esas sözleşmeye hüküm konulmak suretiyle bu yetkinin yine müdürler tarafından kullanılması mümkündür.

Müdür ya da müdürlerin çoğunluğu, TTK m.623'ün kapsamına girmeyen ticari mümessili veya ticari vekili her zaman görevden uzaklaştırabilir. Bu kişi genel kurul kararı ile atanmışsa, görevden alma ve yetkilerini sınırlandırmak için genel kurul gecikmeksizin toplantıya çağrılır (TTK m.631/2)[490].

Anonim şirket yönetim kurulunun yetkilerinin miktar ile sınırlanamaması sonucunda ortaya çıkan sorunu aşabilmek amacıyla TTK m.371/son fıkrası ile uygulamada TBK'de düzenlenen ticari vekiller dışında yeni bir ticari vekil türü oluşturulmuştur[491]. Şirketin yönetimine ilişkin düzenlenecek iç yönerge ile sınırlı yetkili ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının atanabileceği hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme, TTK m.629'un 3'üncü fıkrası uyarınca kıyasen limited şirketlere de uygulanacaktır.

Yapılan açıklamalar çerçevesinde, limited şirkete atanacak ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları da iki grup halinde değerlendirilmelidir. TTK m.631 uyarınca atanacak olan temsilciler TBK m.547 vd. hükümleri gereğince atanacak ticari mümessil ve ticari vekiller olup esas sözleşmede aksine hüküm yoksa genel kurul tarafından atanırlar. Buna

---

489 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 22-56.

490 Hükmün eleştirisi için bkz. **Yıldız,** s. 266-267; **Tekinalp,** sermaye Ortaklıkları, N. 22-57.

491 Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. yukarıda Yedinci Bölüm, § 10, V, C, 2.

karşılık TTK m.629/3 hükmünün atfı ile TTK m.367 ve m.371/7 hükümleri gereğince limited şirketin idaresine yönelik olarak hazırlanacak olan iç yönerge çerçevesinde, sınırlı yetkilere sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları ise müdürler tarafından atanabilirler. Aynı şekilde müdür ya da müdürlerin çoğunluğunun ikinci tür ticari vekili görevden alması mümkün sayılmalıdır.

H. MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

Limited şirket müdürlerinin sorumluluğuna ilişkin olarak ayrı bir düzenleme konulmamış ve anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna ilişkin hükümlere yollama yapılmıştır (TTK m.644/1-a).

Limited şirket tüzel kişiliği, idare ve temsil için yetkilendirilen kişilerin görevlerini ifa ederken meydana getirdikleri haksız fiilden dolayı sorumludur (TTK m.632). Dolayısıyla müdürlerin görevlerini yerine getirirken kusurlu davranışlarıyla üçüncü kişilere verdikleri zararlardan dolayı şirket sorumlu olur.

Bununla birlikte TTK m.631 hükmüne göre şirket sözleşmesine hüküm konulmak kaydıyla müdürler tarafından ticari mümessil ve ticari vekil atanmışsa veya m.629/3 hükmüne göre sınırlı yetkiye sahip ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanmışsa, bunların faaliyetlerinden dolayı atama yetkisine sahip olan *müdürler* müteselsilen sorumludur (TTK m.371/7, son cümle). Buna karşılık genel kurul tarafından atanan ticari mümessiller ve ticari vekillerin faaliyetlerinden dolayı, *şirket* sorumlu olmalıdır (TTK m.631/1).

III) DENETİM

Limited şirketin denetimine ilişkin kurallar anonim şirkete benzer bir şekilde düzenlenmiş ve 6762 sayılı TTK'de yer alan denetim organı, 6102 sayılı Kanuna alınmamıştır. TTK m.635'te, TTK m.397'nin beş ve altıncı fıkraları dışında kalan, anonim şirketin denetçiye (m.399), denetime (m.398, 400-406) ve özel denetime (m.438-444) ilişkin hükümlerinin limited şirketlere uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

6102 sayılı TTK'nin ilk halinde, şirketlerin büyüklüğüne göre sermaye şirketlerinin büyük çoğunluğu bağımsız denetim[492] kapsamına

[492] Bağımsız denetim hakkında bkz. Dokuzuncu Bölüm, § 12, III, B.

alınmasına karşın, Kanunda değişiklik yapan 6335 ve 6455 sayılı Kanunların yürürlüğe girmesiyle bağımsız denetimin kapsamının belirlenmesi Bakanlar Kurulu (*günümüzde Cumhurbaşkanı*) kararına bırakılmıştı. Alınan kararlar doğrultusunda, belirli büyüklüğe sahip sınırlı sayıda anonim şirketler zorunlu denetime tâbi tutulurken limited şirketler önceleri çok sınırlı bir şekilde denetim kapsamına alınmıştır. Bununla birlikte zamanla bağımsız denetimin kapsamı genişletilirken limited şirketler de yavaş yavaş bağımsız denetim sürecine dâhil olmaya başlamışlardır. Zira anonim şirketlerde denetim bahsinde ayrıntılı olarak izah edildiği üzere[493], son olarak 26.03.2018 tarih ve 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile denetimin kapsamı oldukça genişletilmiştir. Bağımsız denetime ilişkin yapılan bu değişiklik sonucunda, anonim şirketlerle beraber limited şirketler de kısmen bireysel denetçi veya bağımsız denetim kuruluşu eliyle denetime tâbi olmuşlardır[494].

Limited şirketlerden zorunlu bağımsız denetimin kapsamı dışında kalanlar bakımından, şirketin kendi isteği ile bağımsız denetçi ile anlaşarak denetim raporu almasının mümkün olduğunu da ifade etmek gerekir. Zira uygulamada, şirketlerin birleşmesi, paylarının devredilmesi veya yerli ya da yabancı bankalardan finansman sağlanacak olması halinde, bağımsız denetim raporu istendiğine ve bundan dolayı ihtiyari olarak bağımsız denetim raporu alındığına sıklıkla rastlanmaktadır.

493 Bkz. Yukarıda Dokuzuncu Bölüm, § 12, III, B, 1, a.
494 Bkz. yukarıda Dokuzuncu Bölüm, § 12, III, B, 1, a, cc.

§ 20- LİMİTED ŞİRKETLERDE ORTAKLIK SIFATI VE BUNA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR

Limited şirketlerin sermaye şirketi özelliği mevcut Kanun ile daha ön plana çıkarılmış ve limited şirket birçok yönden anonim şirkete yakınlaştırılmıştır. Dolayısıyla ortakların şirket içindeki durumu, hakları ve borçları da buna göre belirlenmektedir. Bununla birlikte yine de şahıs şirketlerine ait özelliklerin bir kısmı hala geçerliliğini korumaktadır[495].

I) ORTAK SIFATININ KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ

Limited şirkette ortak sıfatı, pay sahipliği ile kazanılmakta, payların elden çıkması sonucunda da kaybedilmektedir. Anonim şirketteki pay kavramından farklı şekilde düzenlenmiş bulunan limited şirket paylarını aslen ya da devren iktisap eden kişi, ortak sıfatını kazanır. Kural olarak payların usulüne uygun şekilde devredilmesi ile limited şirketteki ortak sıfatı sona erer.

A. PAY DEFTERİ

Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirkette de esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutulur. Ortakların adları ve adresleri ile her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri, itibari değerleri, grupları ve esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları *(ya da ticaret unvanları)* ve adresleri bu deftere kaydedilir (TTK m.594/1).

Limited şirket ortaklarına pay defterini inceleme hakkı tanınmıştır. Böylece ortakların, şirketin mevcut pay durumunu ve paylar üzerindeki değişik hakların varlığını ve bunların sahiplerini öğrenme imkânları olacaktır. Ortak sıfatına sahip olmayan üçüncü kişilerin (mesela, pay

---

[495] Yukarıda izah edildiği üzere, bazı genel kurul kararları için sermayenin yanı sıra ortak sayısının dikkate alınması, müdür sıfatına sahip ortakların görevden alınması için ağırlaştırılmış yeter sayı veya haklı sebebe dayanan mahkeme kararına ihtiyaç duyulması, ortaklık paylarının devrinin anonim şirkete nazaran daha zor olması gibi özellikler, limited şirketlerin şahıs şirketlerine benzediği hususlar olarak sayılabilir.

devralmak isteyen kişi) pay defterlerini inceleme imkânı bulunmamaktadır.

Aşağıda ayrıca bahse konu olmakla birlikte, ortak sıfatının kazanılması açısından pay defterine yapılan kaydın kurucu nitelikte olduğu görüşü eski önemini kaybetmiştir. Bununla birlikte özellikle limited şirketlerde gerçek anlamda pay senedi çıkarılamadığından veya böyle bir kültür olmadığından, şirketteki pay sahipliğini ispata yarayan en önemli delil, halen pay defteridir. Ayrıca pay defterine kayıt, şirket ortaklarının devre muvafakat ettiğini göstermesi bakımından da önemlidir.

B. PAY SENEDİ DÜZENLENMESİ VE ORTAK SIFATININ KAZANILMASINDAKİ ETKİSİ

Limited şirkette istendiği takdirde, pay senedi çıkarılabileceği hem 6762 sayılı TTK m.518 hem de 6102 sayılı TTK m.593/2'de düzenlenmiştir. 6762 sayılı TTK döneminde, çıkarılan pay senetlerinin kıymetli evrak niteliğini haiz olmadığı bizzat kanun koyucu tarafından belirtilmişken; 6102 sayılı TTK hükümlerinde açık bir ifade bulunmadığından çıkarılan nama yazılı pay senetlerinin kıymetli evrak niteliğine sahip olup olmadığı tartışmalıdır[496]. Öte taraftan TTK m.593/2 hükmüne göre, esas sermaye pay senetleri ispat aracı olacak şekilde de çıkarılabilir. Söze konu bu ikinci türde kıymetli evrak niteliğinin bulunmadığı söylenmelidir. Ancak aşağıda da izah edildiği üzere, bu şekilde bir ayrım yapmanın kanunun lafzı karşısında pratikte bir önemi bulunmamaktadır.

Yine TTK m.593 hükmünün gerekçesinde de ifade edildiği üzere, payın nama yazılı senede bağlanmış olmasının, paya devir ve dolaşım kolaylığı sağlamayacağı, bunları anonim şirket paylarına yaklaştırmayacağı veya dönüştürmeyeceği söylenmiştir[497].

---

496 Nama yazılı olarak düzenlenen limited şirket esas sermaye pay senetlerinin kıymetli evrak niteliğinde olduğuna ilişkin bkz. **Bahtiyar**, Ortaklıklar Hukuku, s. 452; *Tekinalp*, esas sermaye payının nama yazılı olarak düzenlenmesi halinde senedin basit kıymetli evrak kaydı denilen çift taraflı ibraz kaydına bağlanmış olacağının, senedi ibraz etmeyen kişiyi limited ortaklığın isterse pay defterine kaydetmeyebileceğini savunmaktadır (Sermaye Ortaklıkları, N. 21-11); *Pulaşlı* ise limited şirketlerin çıkardıkları nama yazılı pay senetlerinin kıymetli evrak niteliğinde olmadığı; bu senetlerin devri kolaylaştıran ispat belgesi olduğu görüşündedir (Kıymetli Evrak Hukukunun Esasları, 6. Baskı, Ankara 2018, s. 8).

497 Hükmün kıymetli evrak hukukuna ilişkin temel kuralları bozduğu, pay senedine kıymetli evrak niteliği verme amacının tam olarak anlaşılamadığı, nama yazılı

İster ispat aracı olarak ister nama yazılı şekilde çıkarılsın, pay devri yine TTK m.595'de öngörüldüğü üzere yazılı şekilde hazırlanan devir sözleşmesi ve imzaların noterde onaylanması suretiyle yapılmak zorundadır. Aynı şekilde pay senedinin kaybı veya ziyaı halinde, ortaklık haklarına herhangi bir halel gelmez.

TTK m.593/2 hükmünün ikinci cümlesinde, ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya bütün ortakları kapsayacak şekilde düzenlenmiş bulunan rekabet yasağının ve şirket sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının, bu senetlerde açıkça belirtilmesinin gerekli olduğu hükme bağlanmıştır[498].

C. ORTAK SIFATININ KAZANILMASI

Limited şirkette ortak sıfatının kazanılması, anonim şirketlerde olduğu gibi, şirket paylarına bağlı olarak aslen veya devren kazanma olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir.

1. Aslen Kazanma

Aslen kazanma, daha istisnai nitelikte olup şirketin kuruluşunda veya sermaye artırımı esnasında gerçekleşebilir (TTK m.588, 590).

2. Devren Kazanma

Esas sermaye payının devri, payın ortaklar veya üçüncü kişiler tarafından devralınması veya miras, eşler arasındaki mal rejimi ve cebri icra yoluyla kazanılması gibi birkaç şekilde gerçekleşebilir.

a. Payın Sözleşmeyle Devri

Esas sermaye payının devri ortaklara tanınan bir hak olmasına karşın belirli usuli işlemlere bağlanmıştır. Bununla birlikte eski TTK'den farklı olarak devir usulü kolaylaştırılmış ve bu sayede limited şirket şahıs şirketlerinden uzaklaşarak sermaye şirketlerine yakınlaşmıştır.

---

pay senedi çıkarılmasının gereksiz olduğu yönündeki eleştirileri için bkz. **Yıldız,** Ş., s. 132-134.

498 Söz konusu unsurların geçerlilik şartı olduğu ve bunları içermeyen senetlerin geçersiz olacağı yönünde bkz. **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 21-08.

aa) Devir Sözleşmesi

Esas sermaye payının devri ve devir borcu doğuran sözleşmeler *yazılı şekle tabidir ve tarafların imzalarının noterde onaylanması* gerekir (TTK m.595/1). Daha önce izah edildiği üzere, nama yazılı pay senedi çıkarılması, devir usulünü değiştirmez.

bb) Devrin Genel Kurulda Onaylanması

Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, esas sermaye payının devri için *genel kurulun onayı* gereklidir (TTK m.595/2). Yapılan pay devri, ancak genel kurulun onaylamasından sonra geçerlilik kazanır. Dolayısıyla onay işlemine kadar devir sözleşmesinin hükümleri askıdadır. Hatta genel kurulun, sözleşmede aksine bir düzenleme bulunmadığı takdirde, herhangi bir sebep belirtmeksizin pay devrini onaylamaması, reddetmesi mümkündür (TTK m.595/3). Böylece kanun koyucu genel kurula, oldukça geniş bir takdir yetkisi vermiştir. Özellikle arzu edilmeyen üçüncü kişilerin şirkete ortak olmasının engellenmesi amacıyla söz konusu *kanuni bağlamın* kabul edildiği söylenebilir.

Genel kurulun devrin onaylanmasına ilişkin kararının hangi nisapla alınacağı konusunda TTK m.595 hükmünde özel bir düzenleme bulunmadığı gibi mesele m. 621'deki genel kurulun önemli kararlarının arasında da sayılmamıştır. Bu nedenle, pay devirlerinin onaylanması, genel kurulun alelade işlere ilişkin kararları için gerekli olan toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğuna tabidir (TTK m.620). Böylece mevcut TTK'deki düzenleme, eski TTK m.520'deki genel kurulun ortakların dörtte üçünün sermaye paylarının dörtte üçüne sahip olması halinde onay kararı alabileceği hükmüne nazaran pay devirlerini önemli ölçüde kolaylaştırmıştır.

Şirket esas sözleşmesi ile pay devirlerine ilişkin kanuni düzenlemede değişiklik yapılabilir. Söz konusu değişiklik ile pay devirleri daha da kolaylaştırılabileceği gibi aksine zorlaştırılabilir ve hatta tamamen yasaklanabilir.

Esas sözleşme ile pay devir sözleşmesinin *genel kurul tarafından onaylanması şartı kaldırılabilir* (TTK m.595/2). Böyle bir değişiklik halinde limited şirket daha fazla anonim şirketlere benzemiş olur. Usulüne uygun şekilde yapılan devir sözleşmesinin şirkete bildirilmesi ve pay defterine kayıt ile pay devri tamamlanmış olur. Bu noktada, pay devrini inceleyen şirket müdürlerinin, pay defterine kayıttan kaçınması halinde durumun ne olacağı açık değildir. Esasen müdürlerin böyle bir

yetkisi olmamakla beraber, sözleşme ile genel kurul onayının kaldırılması sebebiyle, şirket için sakıncalı gördükleri bir pay devrini deftere kayıttan kaçınmaları ihtimali düşünülebilir. Ancak eski Kanundan farklı olarak payın devrinin şirkete karşı geçerli olması için pay defterine kayıt şartı ortadan kaldırıldığı için, payın devri tamamlanmış sayılacak ve devralan, şirkete karşı pay sahipliğini ileriye sürebilecektir. Ayrıca pay devrini kanuna aykırı bir şekilde pay defterine kaydetmeyen müdürlerin hukuki sorumluluğunun doğacağı açıktır[499].

Şirket sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri öngörüldüğü takdirde, devralanın ödeme gücü şüpheli görüldüğü için ondan istenen teminat verilmemişse, genel kurul, şirket sözleşmesinde hüküm bulunmasa bile, onayı reddedebilir (TTK m.595/6).

Pay devir sözleşmesinin imzalarının noterde onaylanmasından sonra şirkete onay için gönderilmesi gerekir. Şirkete devrin onaylanması için, yapılan başvurudan itibaren üç ay içerisinde genel kurulun toplanıp karar alması zorunludur. Aksi takdirde, yani üç ay içerisinde genel kurul reddetmediği takdirde onay vermiş sayılır (TTK m.595/6). Bu şekilde, kanun koyucu tarafından pay devrini sürüncemede bırakmanın önüne geçilmek istenmiştir.

cc) Pay Devrinin Yasaklanması

Esas sözleşme ile *pay devrinin tamamen yasaklanması* mümkündür (TTK m.595/3). Şirkete dışarıdan üçüncü kişilerin ortak olmasının istenmediği hallerde, sözleşmeye konulacak hükümle, pay devrinin tamamen yasaklanması mümkündür. Böylece, ortakların şirketten ayrılmak istemeleri halinde pay devri yolu kapanmış olmaktadır. Buna karşılık, pay devrinin yasaklanması veya genel kurulun sebepsiz yere devre onay vermemesi halinde ortağın şirketten çıkma hakkı saklı tutulmuştur (TTK m.595/5). Böyle bir durumla karşılaşan ortak, mahkemeye başvurarak şirketten çıkarılmasını talep edebilir.

dd) Devir İşlemlerinin Tamamlanması

Pay devrinin genel kurulda onaylanması veya genel kurul onayının gerekmediği hallerde, devralan ortak sıfatını kazanır. Diğer bir deyişle pay defterine kayıt mevcut kanunda, ortaklık sıfatının geçişi bakımından zorunlu olarak görülmemiştir. Bununla birlikte, genel kurulun

---

[499] **Yıldız, Ş.**, s. 141.

onayını veya onay gerekmediği hallerde devrin müdürlere bildirimine müteakiben tamamlanan esas sermaye pay devirlerinin müdürler tarafından pay defterine kaydedilmesi (TTK m.594) ve akabinde ticaret siciline tescil için başvurmaları gerekmektedir (TTK m.598/1). Ticaret siciline yapılan kaydın hukuki niteliği itibariyle *bildirici (açıklayıcı)* olduğunu söylemek gerekir.

Müdürlerin ticaret siciline tescil için gerekli olan başvuruyu otuz gün içinde yapmamaları halinde, ayrılan ortak, adının söz konusu paylarla ilgili olarak silinmesi için ticaret siciline başvurabilir. Bunun üzerine sicil müdürü, şirkete, iktisap edenin adının bildirilmesi için süre verir (TTK m.598/2). Böylece devrin pay defterine kaydından ve ticaret siciline başvurudan kaçınmaları halinde devreden ve devralanın hükmen tescil davası açmalarına gerek kalmamış; doğrudan sicile başvurarak devrin sicile tescilini sağlama imkânı tanınmıştır[500].

b. Payın Kanunen Devri

Kanun koyucu bazı hallerde payların devir sözleşmesine gerek kalmaksızın geçişini öngörmüştür. *Miras, eşler arasındaki mal rejimine ilişkin hükümler* veya *cebri icra* hallerinde paya bağlı tüm haklar ve borçlar, genel kurulun baştan onayı gerekmeksizin kendiliğinden hak sahibine intikal eder (TTK m.596/1).

Kendiliğinden pay devrinin her zaman uygun sonuçlar doğurmayacağından hareketle bazen şirkete kanuni işleme konu olan payı alma imkânı tanınmıştır. Buna göre, şirket, devri öğrendikten sonra üç ay içinde devrin gerçekleştiği kişiyi onaylamayı reddedebilir[501]. Ancak bunun için şirketin payları kendi veya ortağı ya da kendisi tarafından gösterilen üçüncü bir kişi hesabına, gerçek değeri üzerinden devralmayı, payın geçtiği kişiye önermesi zorunludur (TTK m.596/2). Böylece payın gerçek değerinden alınmasıyla, bir taraftan hak sahibinin zararı söz konusu olmayacak, diğer taraftan şirket istemediği bir üçüncü kişiyi ortak sıfatıyla içine almamış olacaktır.

---

500 **Tekinalp,** Sermaye Ortaklıkları, N. 21-21.

501 Kanunen sayılan işlemlerin gerçekleşmesi halinde payın kendiliğinden üçüncü kişiye geçeceği, artık şirketin onay vermesine gerek olan bir durumun bulunmadığı, sadece 3 aylık kanuni süre içinde şirket ortaklarının veya gösterdikleri başka bir kişinin hukuki işleme konu payı satın alma imkânının olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Konuyla ilgili bilgi için bkz. **Yıldız,** Ş., s. 145-147.

Gerçek değerin belirlenmesi konusunda öncelikle tarafların iradesi esas alınır. Ancak taraflar anlaşamamışlarsa bu değer, taraflardan birinin istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince belirlenir. Mahkemece tayin edilecek değer, şirketin hakkını kullanacağı tarihteki veya buna en yakın tarihteki değerdir. Mahkemelerin bizzat söz konusu değeri tespit etmesi mümkün olmadığında, limited şirketin faaliyet konusuna uygun olarak bilirkişi eliyle bu değeri belirlemesi gerekir. Mahkeme, yargılama ve değer belirleme giderlerini kendi takdirine göre paylaştırır. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir (TTK m.597/2).

Şirket genel kurulunun, devri onaylamaması halinde, buna ilişkin red kararı devrin gerçekleştiği günden itibaren geçerli olmak üzere geriye doğru etkilidir. Red, bu konudaki kararın verilmesine kadar geçen sürede alınan genel kurul kararlarının geçerliliğini etkilemez (TTK m.596/3).

Şirket, devrin kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içerisinde esas sermaye payının geçişini açıkça ve yazılı olarak reddetmemişse onayını vermiş sayılır (TTK m.596/4). Yapılan işlemin sürüncemede bırakılmasını önlemek için kanun koyucu devir sözleşmesinin onaylanmasında olduğu gibi (TTK m.595/7) onay için belirli bir süre öngörmüştür.

Limited şirket payının icra marifetiyle satılmasına ilişkin olarak, eski TTK'de yer alan uzun ve sıkıntılı süreç terkedilerek şirketin feshi istenmeksizin payın satışı ve icradan devralan kişinin şirkete ortak olmasının önü açılmış olmaktadır. Böylece borçlunun limited şirketteki payının, bir menkul malın haczi ve satışında olduğu gibi icra yoluyla satılması mümkün hale gelmiştir[502].

c. Paylar Üzerinde Rehin ve İntifa Hakkı Kurulması

Pay üzerinde devir dışındaki tüm hakları sahibine veren intifa hakkının kurulmasına, esas sermaye payının geçişine ilişkin hükümler uygulanır (TTK m.600/1). Dolayısıyla yazılı sözleşme ve imzaların noterde onaylanmasının yanı sıra sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, genel kurul onayı ile intifa hakkı kurulabilir. Daha sonra şirket

---

[502] Hükme ilişkin ayrıntılı açıklama için bkz. **Yıldız, Ş.**, s. 144 vd.

müdürleri tarafından bu hakkın pay defterine kaydedilmesi ve ardından ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi ile süreç tamamlanabilir[503].

Limited şirket payı üzerinde intifa hakkı kurulmasından sonra, pay intifa hakkı sahibi tarafından temsil edilir. Bu durumda intifa hakkını haiz kişi, esas sermaye payı sahibinin menfaatlerini, hakkaniyete uygun bir şekilde gözetmezse tazminat ile yükümlü olur (TTK m.600/3).

Pay üzerinde rehin hakkının kurulması genel kurulun onayına bağlanabilir. Bu durumda yine pay geçişine ilişkin hükümler uygulanır. Genel kurul, sadece haklı sebeplerin varlığı halinde, rehin hakkının kurulmasına onay vermekten kaçınabilir (TTK m.600/2). Haklı sebeplerin varlığı, açılacak bir iptal davasında mahkeme tarafından tetkik edilebilecektir. Bu nedenle, herkes tarafından makul görülebilecek ve objektif niteliklere sahip hususlar haklı sebep olarak kabul edilmelidir.

Şirket sözleşmesi ile payların devrinin tamamen yasaklanmış olması halinde, paylar üzerinde intifa ve rehin hakkının kurulamaması gerekir. Zira payın devrinin yasaklanmasına rağmen intifa ve rehin hakları ile bu yasağın dolanılması mümkün hale gelebilir[504].

d. Şirketin Kendi Paylarını İktisabı

Pay sahiplerinin paylarını üçüncü kişilerin yanı sıra şirket tüzel kişiliğine de devretmesi belirli şartlar altında mümkündür. Bunun için şirketin serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahip olması ve alacağı payların itibari değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu (%10) aşmaması gereklidir (TTK m.612/1). Bununla birlikte, şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla esas sermaye paylarının iktisabı halinde, yukarıdaki oran yüzde yirmi (%20) olarak uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermayenin azaltılması yoluyla itfa edilir (TTK m.612/2).

Şirketin kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırması gerekir. Kendi paylarını iktisap eden şirketin sermayesinde oluşan köpük kısmın zararını ortadan kaldırmak amacıyla getirilen bu hüküm sayesinde şirketin içi boşaltılmamış olacaktır.

---

503 Aynı yönde bkz. **Yıldız, Ş.,** s. 151.

504 **Yıldız, Ş.,** s. 151-152; **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 458-459.

Sermaye paylarının şirket tarafından iktisap edilmesi halinde, bu paylardan kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı olan diğer haklar, paylar şirket tüzel kişiliğinin elinde bulunduğu sürece donar (TTK m.612/4). Benzer şekilde, şirketin elinde bulunan esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, söz konusu paylar şirketin elinde bulunduğu sürece talep edilemez (TTK m.612/5). Dolayısıyla paylardan kaynaklanan haklar ve borçlar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece kullanılamaz ve talep edilemez[505].

Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas sermaye paylarının, şirketin çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı halinde de uygulanır (TTK m.612/6).

e. Pay Devrinin Tescili

Kanun koyucunun pay devrinde deftere kayıt ile ticaret siciline tescil ve ilanı bildirici nitelikte kabul ettiğini daha önce ifade etmiştik. Bu bağlamda sadece sözleşme ile devir değil, miras, mal rejimi ve cebri icra hallerinde de, ticaret siciline tescil ve ilan gereklidir (TTK m.598).

Şirket müdürlerinin, devrin kendilerine bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde sicile başvurmamaları halinde, devredenin doğrudan sicile başvurarak adının bu paylarla ilgili olarak silinmesini sağlaması mümkündür. Kanunda açıkça zikredilmemiş olsa da, devralan tarafın da benzer şekilde sicile başvurarak söz konusu payları adına tescil ettirebilmesi mümkün sayılmalıdır. Zira TTK m.598/2'de, sicilin şirkete payları iktisap edenin adını bildirmesi için süre vereceği hükme bağlanmıştır. Şirket tarafından devralanın adının bildirilmesi ile birlikte, devredenin adının silinerek devralanın tescil edilmesi gerekir.

6102 sayılı TTK'nin birinci kitabında düzenlenen ticaret siciline ilişkin hükümlerde, sicile güven ilkesinin olmadığı görülmektedir (TTK m.37). Buna karşılık TTK m.598/3 hükmünde, sicil kaydına güvenen iyiniyetli kişinin güveninin korunacağı belirtilmiştir. Böylece limited şirketler hukuku bakımından, sicile güven ilkesinin uygulanmayacağı kuralına istisna getirilmiş olmaktadır.

---

505 Öğretide *Pulaşlı*, temettü ve rüçhan hakkı gibi malvarlığı haklarının şirkete ait olmasının gerektiğini, aksi halde payların yeniden elden çıkarıldığında kar paylarının devralana verilmesinin gerekeceğini belirtmiştir, (C. 3, s. 2780; § 69-98).

D. ORTAK SIFATININ KAYBEDİLMESİ

Limited şirket ortağının bu sıfatını kaybetmesi, çıkma ve çıkarılma hallerinde söz konusu olur. Ortağın paylarının bir kısmını devretmesine karşılık bir kısmını elinde tutması halinde ortak sıfatı devam eder.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda ortağın şirketten çıkmasına imkân tanınması ve belirli koşullar altında şirketten çıkarılması ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Evvelki Kanundaki bazı eksiklikler giderilmiş ve ortaklara diledikleri zaman şirkete zarar vermeden çıkma imkânı tanınmıştır.

1. Çıkma

Ortağın kendi iradesi ile ortaklık payının tamamını ortaklardan birisine veya üçüncü bir kişiye devretmesi ile ortaklıktan çıkması söz konusu olur. Payın devredilmesi yolu ile çıkma meselesi yukarıda ayrıntılı bir şekilde ele alındığı için bu başlık altında pay devredilmeden çıkmanın özellikleri incelenecektir.

a. Şirket Sözleşmesi İle Ortaklara Çıkma Hakkı Tanınması

Şirket sözleşmesinde ortaklara şirketten çıkma hakkının tanınması mümkündür (TTK m.638/1). Çıkma hakkı, kuruluş aşamasında sözleşmeye konulabileceği gibi TTK m.589'daki nisaba uygun olarak sonradan yapılan sözleşme değişikliği ile de eklenebilir.

Çıkma hakkı, limited şirketin bütün ortaklarına tanınabileceği gibi bazı paylara imtiyaz niteliğinde de verilebilir. Çıkma hakkının kullanılması belirli şartlara bağlanabilir; hakkın doğrudan kullanılmasına da müsaade edilebilir.

Çıkma hakkını kullanmak isteyen ortak, durumu şirkete bildirerek işlemin gerçekleştirilmesini isteyebilir. Talebi alan şirket müdürü/müdürleri, esas sözleşmede gösterilen çıkma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyerek işlemi tamamlarlar. Şartların oluşmadığını düşünen müdürler çıkma bildiriminin iptalini dava edebilirler[506].

Çıkma hakkını kullanan ortağın ayrılma akçesi, serbest olan öz kaynaklardan ödenmelidir (TTK m.642). Bunun için öz kaynaklarda serbestçe kullanılabilir bir miktarın bulunması gereklidir.

---

[506] **Yıldız, Ş.,** s. 155.

Çıkma işleminin tamamlanmasından sonra müdürlerin, durumu pay defterine geçirmesi ve ticaret siciline tescil ettirmesi lazımdır. Müdürlerin söz konusu kayıt işlemlerini yapmamaları halinde, çıkan ortak ticaret siciline doğrudan başvurarak isminin sicilden silinmesini talep edebilir (TTK m.598/2).

b. Haklı Sebeplerin Varlığı Halinde Çıkma

Limited şirketin her ortağı, haklı sebeplerin varlığı halinde, esas sözleşmede hüküm bulunmasa da şirketten çıkarılmalarına izin verilmesini mahkemeden isteyebilir (TTK m.638/2). Kanunda yer alan bu hakkın esas sözleşme ile kaldırılmasının mümkün olmadığı ifade edilmelidir[507].

Haklı sebep, ortakların şirket çatısı altında faaliyetlerine devam etmelerini dürüstlük kuralı çerçevesinde imkânsız kılan veya güçleştiren sebepler[508] olarak ifade edilebilir[509]. Kanun koyucu limited şirketlere ilişkin düzenlemede haklı sebeplerin neler olduğundan bahsetmemiştir. Bu şekildeki çıkma hakkının kullanılması mahkeme kararına bağlı olduğundan, ortağın ileri sürdüğü sebeplerin haklı olup olmadığı mahkeme tarafından değerlendirilir (TTK m.638/2). Kanunda belirtilmemiş olsa da haklı sebebin varlığı halinde ortak, mahkemeye gitmek yerine öncelikle şirkete başvurarak çıkarılmasına karar verilmesini isteyebilir. Bu durumda, şirket genel kurulunun uygun görmesi halinde ortağın mahkemeye başvurmadan şirketten çıkması sağlanabilir.

Mahkeme talep üzerine, dava süresince, davacının şirketten kaynaklanan hak ve borçlarının bazılarının veya tümünün dondurulmasına karar verebilir veya davacı ortağın durumunun teminat altına alınması amacıyla başka önlemler alabilir (TTK m.638/2).

Haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme tarafından çıkmasına karar verilen ortağın ayrılma akçesi, TTK m.641 ve 642'nci maddeler çerçevesinde hesaplanıp ortağa ödenir.

---

507 **Yıldız,** s. 156.

508 Ortaklar arasındaki uzun süreden beri devam eden uyuşmazlıklar ve davalar, kanunun ve şirket sözleşmesinin sürekli şekilde ihlali, genel kurul kararlarının uygulanmaması, şirket yöneticilerinin ortaklar arasında eşit davranmaması, şirketin uzun süreden beri kâr elde edememesi veya kâr etmesine rağmen bunun ortaklara dağıtılmaması gibi sebepler, haklı sebepler arasında sayılabilir.

509 **Yıldız,** s. 156; **Pulaşlı,** C. III, s. 2784, § 118.

c. Çıkmaya Katılma

Ortaklar arasında eşit davranma ilkesinin bir yansıması olarak, şirketten çıkmak isteyen ortakların varlığı halinde, müdürün bu durumu diğer ortaklara bildirmesi ile isteyen ortağın kanunda sayılan şartlara uyarak çıkmaya katılması mümkündür (TTK m.639). Böylece şirketin içinde bulunduğu şartlar ve finansal durum yönünden uygun bir zamanda diğer ortaklar da ayrılma imkânından yararlanabilir. Çıkan ve çıkmaya katılmak isteyenlerin sermaye içerisindeki payı, yüzde ellinin üzerine çıktığında çıkma veya çıkmaya katılma yerine şirketin feshi de düşünülebilir.

Çıkma konusunda kendisine haber verilen her ortak, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde, şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerliyse kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek veya açacağı dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılmak haklarına sahiptir. Bu haklardan birini kullanarak aynı durumdaki ortaklar da çıkmadan yararlanabilirler.

2. Çıkarılma

Kanun koyucu limited şirket ortaklarının şirketten çıkarılmalarını iki şekilde düzenlemiştir. İlk olarak çıkarılmaya ilişkin şirket sözleşmesine hüküm konulması, ikinci olarak sözleşmede hüküm olmasa da haklı sebebin varlığı halinde şirketin mahkemeye başvurarak ortağın şirketten çıkarılmasını talep etmesi halidir.

Şirket esas sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabilmesine ilişkin sebepler öngörülebilir (TTK m.640/1). Söz konusu imkân sayesinde hem şirket önemli hallerde ilgili ortağı şirketten çıkarabilmekte hem de ortaklara hangi durumlarda şirketten çıkarılabilecekleri konusunda önceden bilgi verilmiş olmaktadır.

Ortağın şirketten çıkarılabilmesi için, genel kurulda temsil edilen oyların en az üçte ikisi ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu ile karar alınması gereklidir (TTK m.621/1-h). Görüldüğü gibi haklı sebeplerin varlığının incelenmesi ve bir ortak hakkında önemli bir karar verilmesi ağırlaştırılmış yeter sayıya tâbi tutulmuştur.

Genel kurulun çıkarma yetkisini kötüye kullanmasını engellemek için, şirketten çıkarılan ortağın, kararın kendisine tebliğ edilmesinden

itibaren üç ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde iptal davası açabilme imkânı bulunmaktadır (TTK m.640/2).

Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin ikinci durum, esas sözleşmede ayrı bir hüküm bulunmasa da şirketin talebi üzerine mahkeme kararıyla ortağın çıkarılmasıdır (TTK m.640/3). Bir ortağın şahsı üzerinde haklı sebeplerin (sadakat borcunun, rekabet yasağının ihlali gibi) meydana gelmesi ve bu durumun şirkete zarar veriyor olması halinde ortağın çıkarılması için mahkemeye başvurulabilir.

Haklı sebeplerin varlığı halinde ortağın çıkarılması amacıyla mahkemeye başvurulması için genel kurul kararı gereklidir. Genel kurul kararının TTK m.621/1-h'de yer alan nisapla alınması ve bu doğrultuda müdürlerin kararın icrası amacıyla ortağın çıkarılması için mahkemeye başvurması zorunludur. İki kişilik limited şirketlerde söz konusu nisabın sağlanması oldukça zor olduğundan, bir ortağın haklı sebepten dolayı diğer ortağın çıkarılması için mahkemeye müracaat edebilmesi kabul edilmektedir[510].

3. Ortaklık Sıfatını Kaybeden Ortağa Ayrılma Akçesi Ödenmesi

Ortaklık sıfatını genel kurul veya mahkeme kararıyla kaybeden ortağa esas sermaye payı ile orantılı olarak eşit işlem yapılması ve sermaye payının gerçek değerine uygun şekilde ayrılma akçesi ödenmesi gerekir (TTK m.641/1). Sermaye payının gerçek değerine göre ödenebilmesi için, bu bağlamda objektif bir hesaplama yapılması gerekir. Gerçek değer, ayrılma tarihine en yakın zamanda, şirketin piyasadaki objektif değerini ifade etmektedir.

Şirket sözleşmesinde ayrılma hakkının yer alması halinde, şirket sözleşmeleri ayrılma akçesini farklı bir şekilde düzenleyebilir (TTK m.641/2). Bu çerçevede ayrılma akçesinin, nakit ödemenin yanı sıra ayın ile ödeme, başka bir şirketin pay senedinin verilmesi gibi seçenekler şeklinde ödenmesi kararlaştırılabilir. Ancak ortaklara tanınan söz konusu seçenekler, genel hukuk ilkeleri ile sınırlı olup, hiçbir zaman keyfi, adalete ters ve müsadereye yakın bir düzenleme hakkı vermemelidir[511]. Ayrılan ortağın hakkının korunması, hakkaniyete uygun şekilde ayrılma akçesinin hesaplanması, oldukça büyük önem taşımaktadır.

---

[510] Konuyla ilgili tartışma ve açıklamalar için bkz. **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 464.

[511] TTK madde Gerekçesi, m. 641/2, s. 230.

Ayrılma akçesinin muaccel olması, kural olarak, ortağın şirketten kendi iradesi, genel kurul veya mahkeme kararı ile ayrılmasına bağlıdır. Ancak kanun koyucu muacceliyet için, bunların yanı sıra şirketin kullanılabilir bir öz sermayesinin bulunmasını, ayrılan ortağın sermaye payının devredilebilmesini ve esas sermayenin ilgili hükümlere göre azaltılmasını aramıştır (TTK m.642)[512].

TTK m.642/3 hükmüne göre, ayrılan ortağın ayrılma akçesinin ödenmeyen kısmı, şirkete karşı, bütün alacaklılardan sonra gelen bir alacak hakkı meydana getirir. Söz konusu alacak hakkı, yıllık raporda kullanılabilir özkaynak tutarının tespit edilmesi ile muaccel hale gelir.

4. Ayrılma İşlemlerinin Tamamlanması

Limited şirketten kendi rızası ile veya şirketin iradesi ile çıkan ya da çıkarılan ortağın durumunun pay defterine kaydedilmesi ve ticaret siciline tescil ve ilan ettirilmesi şirket müdürlerinin görevidir. Müdürlerin bu görevlerini ihmal etmeleri halinde, ayrılan ortağın doğrudan sicile başvurarak kendi adının şirketin paylarından çıkarılmasını talep edebileceği daha önce de ifade edilmişti. Burada ayrıca belirtmek gerekir ki, çıkma ve çıkarılma hali, iyiniyetli üçüncü kişiler bakımından sicile tescil ve ilan ile geçerlilik kazanacaktır (TTK m.598/3).

Çıkma ya da çıkarmaya mahkeme karar vermişse; kararın yerine getirilmesi için çıkan ya da çıkarılan ortak şirkete doğrudan başvurabileceği gibi ilamlı icra yoluyla da kararın yerine getirilmesini talep edebilir. Ticaret siciline bildirim, bildirici tescilin kurucu etkisi olarak nitelendirilmelidir. Diğer bir ifadeyle sicildeki tescil, üçüncü kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırması bakımından kurucu nitelikte kabul edilmektedir.

II) ORTAĞIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Limited şirkette pay sahipleri birtakım hakları haiz oldukları gibi yükümlülük altına da girerler. Bunun yanı sıra ortakların pay sahibi olmalarından kaynaklanan sorumlulukları da bulunmaktadır. Anonim şirketlerden farklı olarak limited şirketlerde, ortaklar bakımından tek

---

512 ***Tekinalp,*** TTK m. 642'de sayılan seçeneklere sırasıyla bakılacağını, burada sayılan koşulların gerçekleşmemesi halinde ayrılma akçesinin elde edilemeyeceğini belirtmiştir, (Sermaye Ortaklıkları, N. 21-53 vd.).

borç ilkesinden ayrılarak; ortakların sermaye koyma borcunun yanında şirkete karşı başka sorumlulukları da öngörülebilir.

A. ORTAKLARIN HAKLARI

Ortakların hakları, anonim şirketlerde olduğu gibi mali ve idari nitelikte olmak üzere iki grupta ele alınabilir.

1. Mali Haklar

Ortakların malvarlıklarına ilişkin hakları, çoğu zaman şirkete ortak olmanın ortaklar bakımından en önemli sonucudur.

a) Kâr Payı Hakkı

Ortakların mali olarak en önemli hakkı, şirketin elde ettiği kârdan pay almaktır. Şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, ortaklar, yıllık bilançoya göre elde edilmiş net kârdan pay alırlar (TTK m.608/1).

Şirket sözleşmesinde aksine hüküm bulunmadıkça, kâr payının hesaplanmasında esas sermaye payının itibari değerine olan oranı dikkate alınır (TTK m.608/2). Pay sahibinin ek ödeme yükümlülüğünün bulunması halinde, bunların yerine getirildiği miktar, kâr payının hesaplanmasında itibari değere eklenir. Dolayısıyla ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmiş olan ortağın alacağı kâr payı oranı da artış gösterir.

Kanun koyucu, ek ödeme yükümlülüğünü yerine getiren ortağın daha fazla kâr payı alacağını belirtmesine karşın, aynı hükmü sermaye borcunun yerine getirilmesi noktasında aramamıştır. Esasen TTK m.585'in ilk halinde limited şirket ortaklarının nakit sermayenin tamamını peşin olarak ödemeleri öngörüldüğünden, kâr payının hesaplanmasında bu hususun dikkate alınmaması makul görülebilirdi. Zira zaten tüm ortaklar sermaye borcunu peşin ödediklerinden, sermaye borcunun ifası oranında kârın hesaplanmasının dikkate alınması söz konusu değildi. Ancak son yapılan değişiklikle[513] ortakların sermayenin %25'ini dahi peşin ödemeleri zorunluluğu ortadan kaldırıldığından, kâr payının hesaplanmasında anonim şirket hükümlerine (TTK m.508) paralel şekilde, sermaye borcunun ödenmesinin de dikkate alınması gerekir[514].

---

513 15.02.2018 Tarihli 7099 Sayılı Kanun m. 25.

514 Aynı yöndeki açıklamalar için bkz. **Bahtiyar,** Ortaklıklar Hukuku, s. 468.

Kâr dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek akçeler ayrıldığı takdirde genel kurul tarafından karar verilebilir (TTK m.608/1).

Şirketin ortaklara hiç ya da kısmen kâr payı dağıtmamak için, hareket etmesini engelleyebilmek (kâr dağıtımını koruyabilmek) amacıyla kanunu koyucu TTK m.608/3'de önlem almıştır. Buna göre, şirket genel kurulu kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçe ayrılmalarına sadece iki halde müsaade etmiştir. Bunlar; zararların karşılanması için gerekliyse veya şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse daha yüksek oranda yedek akçe ayrılabilir.

Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de esas sermayeye ve ek ödemelere faiz ödenmez. Şirket sözleşmesiyle hazırlık dönemi faizi ödenmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda anonim şirketlere ilişkin hükümler kıyasen uygulama alanı bulur (TTK m.609).

Limited şirketin finansal tablolarına ve yedek akçelerine ilişkin olarak anonim şirket hükümleri uygulanır (TTK m.610).

b)Tasfiye Payı Hakkı

Şirketin tasfiyesine anonim şirket hükümleri uygulanır. Tasfiye sonucunda arta kalan malvarlığı, ortaklar arasında esas sermaye payları dikkate alınarak paylaştırılır (TTK m.643).

c) Yeni Pay Alma (Rüçhan) Hakkı

Şirket sözleşmesinde veya esas sermayenin artırılması kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payına uygun oranla yeni çıkarılan sermaye paylarından satın alma hakkına sahiptir (TTK m.591).

Rüçhan hakkı, ancak haklı sebeplerin varlığı ve TTK m.621/1-e bendinde öngörülen yeter sayı ile alınan genel kurul kararı ile sınırlandırılabilir veya ortadan kaldırılabilir (m.591/2).

Rüçhan hakkının kullanılması için ortaklara on beş günlük süre verilir (TTK m.591/3).

2. İdari Haklar

Ortakların daha ziyade şirket faaliyetlerine katılmalarına ilişkin olan haklar, mali haklarda olduğu gibi paya bağlıdır ve kural olarak ortağın rızası olmadan sınırlandırılamaz ve kaldırılamaz.

a. Genel Kurul Toplantısına Katılma ve Oy Kullanma

Limited şirkette her ortak, TTK m.617 vd. hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkına sahiptir. Bu bağlamda, ortakların artık doğal müdür olmaları ilkesi terk edildiğinden şirketin yönetimi için müdür ya da müdürlerin seçimine de katılmaları kendilerine tanınmış bir haktır.

Ortakların, genel kurulda alınan kararların hukuka aykırı olması halinde, kararların iptalini veya butlanının tespitini isteme hakkı bakımından, anonim şirket hükümleri kıyas yoluyla uygulanır (TTK m.622).

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Evvelki Kanundan farklı olarak mevcut düzenlemede, ortakların denetçi sıfatıyla şirketi denetleme imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle, ortakların şirketin işleyişi ve ticari faaliyetleri hakkında güncel bilgi alma imkânları sınırlıdır. Bu konuda sadece, ortakların şirketin gidişatı hakkında bilgi alma ve inceleme hakları bulunmaktadır (TTK m.614).

TTK m.614 hükmüne göre her ortak, müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve belirli konularda inceleme yapabilir[515]. Ortağın elde ettiği bilgileri şirketin zararına olacak şekilde kullanma tehlikesinin bulunması halinde, müdürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu üzerine genel kurul nihai kararı verir. Özellikle müdürlerin keyfi olarak bilgi alma ve inceleme hakkını sınırlamasının engellenmesi amacıyla genel kurul kararının alınması istenmiştir[516].

Genel kurulun ortağın bilgi alma ve inceleme hakkını keyfi olarak sınırlandırması halinde, ortağın mahkemeye başvurması gerekir. Mahkemenin her iki tarafın da iddialarını dikkate alıp, özellikle şirketin

---

[515] Konuyla ilgili olarak bkz. **Bilge, M.E.,** "Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma Hakkı", EÜHFD 2005, C. IX, S. 1-2, s. 429-449.

[516] Ayrıntılı bilgi için bkz. **Can, O.,** 6102 Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Limited Şirketlerde Ortakların Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Ankara 2015, s. 128 vd.

ticari sırlarının açığa çıkmasını engelleyerek ortakların bilgi alma hakkını kullanmalarını sağlaması önemlidir. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir (TTK m.614/3).

c. Çıkma ve Çıkmaya Katılma Hakkı

Yukarıda izah edildiği üzere, limited şirket ortakları belirli şartlar altında şirketten pay devri veya genel kurul ya da mahkeme kararı ile çıkabilirler (TTK m.638). Bunun yanında diğer ortaklar da şirketten ayrılmak isteyen bir ortak ile aynı şartları taşımaları halinde çıkmaya katılabilirler (TTK m.639).

d. Haklı Nedenlerle Şirketin Feshini İsteme Hakkı

Mevcut Türk Ticaret Kanununun sermaye şirketleri için getirdiği önemli yeniliklerden birisi de haklı sebeplerin varlığı halinde ortakların şirketin feshini talep edebilmeleridir (TTK m.636/3). Mahkeme şirketin feshi talebi yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine veya ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen kabul edilebilir başka bir çözüme hükmedebilir[517].

B. ORTAKLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Limited şirketlerde ortakların yükümlükleri anonim şirket ortaklarına nazaran daha kapsamlıdır. Kural olarak tek borç ilkesi, limited şirket ortakları bakımından her zaman geçerli olmaz. Aşağıda izah edildiği üzere, limited şirket ortakları, sermaye borcunun yanında başka şekilde borç ve sorumluluk altına girebilmektedir.

1. Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmesi Yükümlülüğü

Şirket ortaklarının temel borcu şirkete sermaye koymaktır. Daha da önce de ifade edildiği gibi, 6102 sayılı TTK m.585'in ilk halinde nakit sermaye borcunun tamamının kuruluştan önce peşin ödenmesi gerekirken günümüzde bu tür sermaye hiç ödenmeden de şirket kurulabilmektedir. Şirket kurmayı kolaylaştırmak için kanun koyucu, kuruluşta nakit sermaye taahhüdünü yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmıştır.

---

[517] Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için anonim şirketlerin haklı sebeple feshine ilişkin açıklamalara bakınız, yukarıda Onikinci Bölüm, § 15, I, 4, d.

Her ne kadar TTK m.585 hükmünde nakit sermaye koyma borcunun ne şekilde ve ne zaman ödeneceği açıkça düzenlenmiş olmasa da aynı hükümde anonim şirketlere yapılan yollama sebebiyle kuruluşta ve TTK m.590 hükmü sebebiyle sermaye artırımında anonim şirketlere ilişkin hükümlerin uygulanması gerekir. Anonim şirketler hakkında konuyu düzenleyen TTK m.344 hükmü gereğince, limited şirketlerde de nakit sermaye koyma borcunun şirket müdür ya da müdürler kurulu tarafından belirlenecek ödeme takvimine göre en geç yirmi dört ay içinde yerine getirilmesi şarttır.

Ayni sermaye taahhüdünde bulunan ortaklar ise, TTK m.581 uyarınca taahhüt ettikleri sermaye unsurlarını şirkete koymakla yükümlüdürler. Aksi halde kuruluştan sonra şirket yönetiminin sermaye unsurlarının şirkete devredilmesine zorlaması gerekebilir.

2. Bağlılık Yükümlülüğü

Genellikle az sayıdaki ortaklardan müteşekkil olan limited şirketlerde ortakların şirkete karşı bağlılık (sadakat) yükümlülüğü öngörülmüştür. Bu sayede limited şirketlerin ortaklık yapısına uygun bir düzenleme yapılmış olmaktadır.

Bağlılık yükümlülüğü çerçevesinde ilk olarak ortaklara şirket sırlarını koruma yükümlülüğü getirilmiştir (TTK m.613/1). Kanun koyucunun özel önem verdiği ve emredici şekilde düzenlediği söz konusu yükümlülüğün, şirket sözleşmesi veya genel kurul kararıyla kaldırılması mümkün değildir.

Şirket sırlarına vakıf olan müdür sıfatına sahip olan ya da olmayan ortakların, bunları saklamaları şirket bakımından büyük önem arz eder. Gerçi bu yükümlülüğün özel bir yaptırımı öngörülmemiş olsa da ihlal eden ortakların en azından şirketin zararını karşılamakla yükümlü olacağını söylemek mümkündür.

Ortakların ayrıca, şirkete zarar verici, şirketin çıkarlarını zedeleyici davranışlardan kaçınması bağlılık yükümlülüğü çerçevesinde hükme bağlanmıştır. TTK m.613/2 hükmünün ikinci cümlesinde, ortakların kendilerine özel menfaat sağlayan ve şirketin amacına zarar veren davranışlardan ve faaliyetlerden kaçınmalarının zorunlu olduğu açıkça belirtilmiştir.

Ortakların tamamının yazılı olarak onay vermesi veya esas sözleşmede yer almak kaydıyla genel kurul kararı ile bağlılık yükümlülüğüne aykırı düşen faaliyetlerin yapılması mümkündür (TTK m.613/4). Bu

durumda, mesela uzun yıllar müdürlük yapan ve şirketin birçok sırrını bilen ortağın şirketten ayrılarak daha büyük bir şirkete yönetici veya ortak olabilmesi, kalan ortakların iznine tâbidir.

3. Rekabet Yasağı

Ortakların şirkete bağlılık yükümlülüğünün bir diğer görünümü ise rekabet yasağıdır. Anonim şirketlerde sadece yönetim kurulu üyeleri için geçerli olan söz konusu yasak, limited şirketlerde de kural olarak müdürler için geçerlidir (TTK m.626). Buna karşılık esas sözleşmeye hüküm konulmak kaydıyla rekabet yasağının bütün ortaklar için öngörülmesi mümkündür (TTK m.613/2).

Ayrıca bağlılık yükümlülüğünde olduğu gibi rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde de geri kalan ortakların tümü yazılı olarak onay verirlerse; ortaklar, rekabet yasağına aykırı düşen faaliyetlerde bulunabilirler. Esas sözleşmede, ortakların yazılı onayı yerine ortaklar genel kurulunun kararı yeterli görülebilir (TTK m.613/4).

4. Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı

Limited şirket ortaklarına ilişkin olarak anonim şirket ortaklarının borçlanma yasağına dair TTK m.358'e yollama yapılmıştır (TTK m.644/1-b).

5. Ek Ödeme Yükümlülüğü

Limited şirketlerde, ortakların sermaye koymak şeklinde ifade edilebilen *tek borç ilkesinin* istisnası ek ödeme ve yan edim yükümlülükleridir.

a) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Genel Özellikleri

Kanun koyucu esas sözleşmeye konulacak hükümle, ortaklara sermaye koyma borcunun yanı sıra ek ödeme yükümlülüğü getirebilmenin önünü açmıştır (TTK m.603). Söz konusu düzenleme çerçevesinde, esas sözleşmede açıkça öngörülmesi ve Kanunda yer alan şartların gerçekleşmesi halinde, ortaklara şirkete nakdi ödemede bulunmaları borcu yüklenmektedir. Böylece finansal bakımdan zor duruma düşen şirkete, ortakların ilave ödemelerle destek olmaları ihtimali ortaya çıkar.

Ek ödeme yükümlülüğü, şirket sözleşmesinde ancak esas sermaye payını konu edinen belirli bir miktar olarak kararlaştırılabilir. Söz konusu miktar, esas sermaye payının itibari değerinin iki katını aşamaz

(TTK m.603/3). Böylece kanun koyucu, ortakların ağır bir yük altına girmelerini belirli bir miktar ile sınırlandırmıştır.

b) Ek Ödeme Yükümlülüğünün İstenebilmesi İçin Gerekli Şartlar

Ek ödeme yükümlülüğünün istenebilmesinin ön şartı, esas sözleşmede açık hüküm bulunmasıdır. Her ortak, sadece kendi esas sermaye payına düşen ek ödemeyi ödemekle yükümlüdür (TTK m.603/4).

Esas sözleşmede öngörülen ek ödemenin ortaklardan istenebilmesi için ayrıca TTK m.603/1'de yer alan diğer şartların da gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar, şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını karşılayamaması, şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması veya şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin gerçekleşmiş bulunmasıdır.

Kanunda sayılan bu şartlar gerçekleşmemiş olsa da, iflasın açılması ile ek ödeme yükümlülüğü muaccel hale gelir (TTK m.603/2).

c) Ek Ödeme Yükümlülüğünün Sona Ermesi

Ek ödeme yükümlülüğü belirli şartlar altında azaltılabilir veya tamamen kaldırılabilir (TTK m.603/6). Esas sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması mümkündür. Ek ödeme yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılması sürecine, esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümler kıyasen uygulanır.

Ortağın şirketten ayrılması ile paya bağlı diğer hak ve borçlar gibi ek ödeme yükümlülüğünün de sona erdiği söylenebilir. Ancak ortağın şirketten ayrılmasının sicile tescil edildiği tarihten itibaren iki yıl içinde şirket iflas etmişse, bu eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi istenir (TTK m.604/1).

Ayrıca ortağın payını devretmesi yoluyla şirketten çıkması halinde, payları devralan halefi ek ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemişse, devreden ortağın sorumluluğu, yükümlülüğün gerçekleştiği tarihte ortağa karşı ileri sürebileceği ölçüde devam eder (TTK m.604/2).

d) Ek Ödemenin İadesi

Yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin tutar, serbestçe kullanılabilir yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması halinde,

kısmen ya da tamamen ödeyen ortağa iade edilebilir. Böylece şirketin ihtiyacının ortadan kalkması halinde, geçici olarak verilen ek ödeme desteğinin de ortaklara iade edilmesi söz konusu olur.

6. Yan Edim Yükümlülüğü

Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir (TTK m.606/1). Ek ödeme yükümlülüğünden farklı olarak nakdi bir ödemeyi kapsamayan söz konusu yükümlülükler, şirketin faaliyetlerine yardımcı olmayı amaçlar. Ortakları yazılımcılardan oluşan şirketin önemli projeler alması halinde, ortakların bu projelerde çalışması gibi emek ya da benzeri yardımlar yan edim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilebilir. Yan edimler karşılıksız olmadığından bunlara karşı ödenecek ücretlerin tespiti yönteminin de esas sözleşmede belirlenmesi gerekir.

Esas sözleşme ile yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı, koşulları ve diğer önemli noktalar belirtilir. Ayrıntı gerektiren hususların genel kurulun iradesine bırakılması mümkündür (TTK m.606/2).

Şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmiş bir karşılığı veya uygun bir karşılığı bulunmayan ve özkaynak ihtiyacını karşılamaya hizmet eden nakdî ve ayni edim yükümlülükleri, ek ödeme yükümlülüğüne ilişkin hükümlere tâbidir (TTK m.606/3).

7. Haksız Alınan Kâr Paylarının İadesi Yükümlülüğü

Limited şirket ortak veya müdürü, haksız olarak alınan kâr paylarını iade etmekle yükümlüdür (TTK m.611). İyiniyetli olmaları halinde, ortak ya da müdürün haksız alınan kâr payını geri verme borcu, şirket alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan tutarı aşamaz (TTK m.611/2).

Şirketin haksız alınan kârı geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren beş yıl, iyiniyetin varlığında iki yıl sonra zamanaşımına uğrar (TTK m.611/3).

§ 21- LİMİTED ŞİRKETTE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Genel kurulun yetkili olduğu esas sözleşme değişiklikleri, kural olarak alelade genel kurul kararlarının alınması usulüne tâbidir. Sadece bu tür kararların alınabilmesi için, diğerlerinden farklı ağırlaştırılmış yeter sayılar öngörülmüştür.

I) ALELADE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Esas sözleşmesinin değiştirilebilmesi için bazı işlemlerin yapılması gereklidir.

Öncelikle genel kurulu toplantıya çağıran kişilerin (kural olarak müdürler), değişiklik metnini hazırlamaları zorunludur.

Ardından, usulüne uygun şekilde toplanan genel kurul toplantısında, esas sözleşmede daha yüksek bir yeter sayı öngörülmemişse, sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların veya temsilcilerinin olumlu oyuyla karar alınmalıdır (TTK m.589/1).

Son olarak, genel kurulda alınan değişiklik kararı, ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir (TTK m.589/2).

II) ÖZEL ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Özel değişiklikler Kanunda ayrıca belirtilmiş olan sermayenin artırılması ve azaltılmasıdır.

A. ESAS SERMAYE ARTIRIMI

Şirketin kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konulması ve bir işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye artırılabilir (TTK m.590).

Esas sermaye şirketin iç kaynaklarından artırıldığı takdirde, mevcut ortaklara, sermaye payları oranında yeni pay verilmesi veya mevcut itibari değerlerinin artırılması söz konusu olur. Buna karşılık dış kaynaklardan artırım yapıldığı takdirde, şirkete dışarıdan kaynak girmesi gereklidir. Bu çerçevede, mevcut ortakların çıkarılan yeni payları öncelikle alma (rüçhan) hakları bulunmaktadır (TTK m.591). Kanunda

belirtildiği üzere, sözleşmeyle veya sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararıyla kaldırılmadığı takdirde, her ortağın sermaye payı oranında artırıma katılma hakkı bulunmaktadır.

B. ESAS SERMAYENİN AZALTILMASI

Sermayenin azaltılmasına ilişkin olarak anonim şirket hükümleri uygulanır (TTK m.592). Sermayenin azaltılmasında şirketin asgari sermayesinin ve her payın zorunlu asgari itibari değerinin korunması ve bunun altına inilecek şekilde sermaye azaltılmasının yapılmaması gerekir.

Sermayenin, borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla azaltılabilmesi için, ancak şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi gerekir (TTK m.592/1-İkinci cümle). Aksi halde, borca batık bilançonun iyileştirilmesi için sermaye azaltımı yapılamaz.

§ 22- LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

I) SONA ERME

Limited şirketin sona erme sebepleri, TTK m.636'da düzenlenmiştir. Şirketin kendiliğinden sona erme sonucunu doğuran infisah ve fesih sebepleri şunlardır:

- Şirket sözleşmesindeki sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle.
- Genel kurul kararı ile.
- İflasın açılması ile.
- Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde, şirket sona erer.

Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler; buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin *feshine* karar verir.

Ayrıca TTK m.644'ün yollamasıyla uygulanacak m.353 hükmü uyarınca, şirketin kuruluşundaki eksiklik ve usulsüzlükler sebebiyle müdürlerin, Bakanlığın ve ilgili alacaklıların talebi üzerine mahkemece fesih kararı verilebilir.

II) TASFİYE

Şirketin sona ermesi üzerine durum ticaret siciline tescil ve ilan edilir (TTK m.637). Tasfiye memurlarının atanması ve azilleri ile tasfiyenin yapılması usulü hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır (TTK m.643).

ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER

LİTERATÜR

Coştan, H., Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme Kararları, Ankara 2012; *Al Kılıç, Ş.,* Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi, İstanbul 2009; *Develi, B.,* "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Ayrılma Akçesi", GÜHFD, C. XVII, Y. 2013, Sa. 1-2, s. 443 vd.

I) GENEL OLARAK

Ticaret şirketleri, değer maksimizasyonunu gerçekleştirmek için kimi zaman *faaliyet hacmini genişletmek*, kimi zaman ise *faaliyet hacmini daraltmak*; bazen de ***yapısal bir değişikliğe*** gitmek yolunu tercih eder. Faaliyet hacmini genişletmek yani büyümek isteyen ticaret şirketleri, işletmenin ekonomik faaliyetlerini artırarak, yeni ürünler geliştirerek pazar payını büyütebileceği gibi (*içsel büyüme*), diğer bir işletmeyi devir alarak veya bir başka şirketle ***birleşerek*** de (*dışsal büyüme*) büyüyebilir.

Ticaret şirketlerin büyümesi kimi zaman, verimliliğin azalmasına yönetim zafiyetlerine sebep olabilir. Bu zafiyetleri gidermek isteyen ticaret şirketleri, faaliyet alanlarını sınırlandırmak, *işletmelerini küçültmek*, birden fazla işletme olarak faaliyete devam etmek arzusunu da taşıyabilir. Bu amaca ulaşmak için faydalanılacak yollardan biri de *ticaret* ***şirketlerinin bölünmesidir*** (TTK m.159 vd.).

Ticaret şirketlerinin *birleşmesi* ve *bölünmesi* yanında; şirketin kurulduğu andaki *hukuki yapının değiştirilmesi*, meselâ limited şirket olarak kurulmuş bir şirketin anonim şirket şekline dönüştürülmesi de (***tür değiştirme***) gerekebilir (TTK m.180 vd.).

Kanun Koyucu, ticaret şirketlerinin bu kolaylıklardan istifade etmesini sağlamak maksadıyla, bizim "***ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler***" olarak nitelendirdiğimiz müesseseleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda "*Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme*" başlığı altında ele almıştır.

II) TİCARET ŞİRKETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİĞİN DÜZENLENMESİ

Ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler üst başlığı altında ele aldığımız *"birleşme", "bölünme"* ve *"tür değiştirme"* ile ilgili yasal düzenlemenin ana kaynağı, İsviçre'nin 2003 yılına ait *"Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun"*-dur[518].

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda, ticaret şirketlerinin *yapısal değişikliği,* mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunundan da farklı şekilde ele alınmış; münferit ticaret şirketlerine ilişkin kısımlarda, özel düzenlemeler yapmaktan kaçınılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 134-194'üncü maddeleri arasında düzenlenen ticaret şirketlerinin birleşmesi, bölünmesi ve tür değiştirmesi ile ilgili hükümler; münhasıran ticaret şirketlerine ilişkin olduğundan (TTK m.134/1), adi şirketlerin yapısal değişikliklerine uygulanmaz. Bununla birlikte TTK m.194 uyarınca (adi şirket tarafından işletilen) bir ticari işletmenin, ticaret şirketleriyle birleşmesi veya ticaret şirketine dönüşmesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanabileceği kabul edilmiştir.

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN ÜST NORM VE GENEL NORM NİTELİĞİ

Kanun Koyucunun düzenlemesine göre, ticaret şirketlerinin yapısal değişikliklerine ilişkin hükümler (TTK m.134-194) *genel norm ve üst norm olma* niteliğini haizdir.

Gerçekten de **"Diğer kanunların, bu kanunun 135 ilâ 194'üncü maddelerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır"** şeklinde kaleme alınan Türk Ticaret Kanununun 134'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükmüyle, bir taraftan diğer kanunlarla da yapısal değişikliğe ilişkin düzenlemelerin yapılabileceği, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelerin genel bir düzenleme olduğu kabul edilmiş; diğer taraftan, başkaca kanunlardaki düzenlemelerin Türk Ticaret Kanununun

---

518 *"Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung"* (FusG) (Çalışmamızda kısaca "İsviçre Birleşme Kanunu" olarak ifade edilecektir).

yapısal düzenleme ile ilgili hükümlerine (TTK m.134-194) aykırı olmayanların saklı olduğu vurgulanmak suretiyle, TTK m.134-194'te ele alınan düzenlemelere aykırı olan diğer düzenlemeler yerine Türk Ticaret Kanununun düzenlemelerinin uygulanacağına işaret edilerek, Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemelere üst norm kuvveti verilmiştir.

IV) KAVRAMLAR

Türk Ticaret Kanununun 135'inci maddesinde "*birleşme*", "*bölünme*" ve "*tür değiştirme*" ile ilgili hükümlerine uygulanmak üzere, "*kavramlar*" maddesine yer verilmiştir[519]. TTK m. 135'e göre, "*Türk Ticaret Kanununun 134 ilâ 194'üncü maddelerinin uygulanması bakımından*;

i) "Şirket", *ticaret şirketlerini* ifade etmektedir (TTK m.135/1). Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir (TTK m.124/1)[520].

---

519 Ticaret şirketlerinde yapısal değişikliğe ilişkin Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerinin ana kaynağını (mehazı) oluşturan İsviçre Birleşme Kanununda (FusG), Türk Ticaret Kanununun gerekçesinde de ifade edildiği gibi, *sadece ticaret şirketlerindeki yapısal değişiklikleri ele alınmamış*; ticaret şirketleri yanında vakıfların, tek kişi işletmelerinin, tüzel kişiliği olsun olmasın özel hukuk hükümleri çerçevesinde işletilmek üzere kurulan kurum ve kuruluşların yapısal değişikliğini de kanunun kapsamına dâhil edilmiştir. Bu nedenle mehaz İsviçre Birleşme Kanununun (FusG) ikinci maddesinde, kanunun uygulamasını kolaylaştırmak amacıyla "*kavramlar*" başlığı altında özel bir düzenlemeye gidilmiştir.
Türk Ticaret Kanununda, ticaret şirketlerinin yapısal değişiklileri düzenlenirken, vakıfların, tek kişi işletmelerinin, tüzel kişiliği olsun olmasın özel hukuk hükümleri çerçevesinde işletilmek üzere kurulan kurum ve kuruluşların yapısal değişikliği, kanunun kapsamına alınmamıştır. Mehaz kanundan farklı bir kapsam tercih edilmesine, fazlasıyla ihtiyaç olmamasına rağmen, muhtemel tereddütleri gidermek amacıyla Türk Ticaret Kanununda da "birleşme", "bölünme" ve "tür değiştirme" ile ilgili hükümlerine uygulanmak üzere, "*kavramlar*" maddesine yer verilmiştir.

520 Türk Ticaret Kanununun gerekçesinde her ne kadar şirket teriminin belirli bir ya da birkaç şirketi değil, bir anlamda İsviçre Birleşme Kanunundaki hukuk süjesi (Rechtsträger) kavramını karşıladığı yönünde açıklama yapılmış ise de, öğretide *Pulaşlı*'nın haklı olarak ifade ettiği gibi (Bkz., **Pulaşlı,** § 6, kn.7.), şirket terimi ile mehazda geçen hukuk süjesi terimleri birbirini karşılamamaktadır. Ticaret şirketleri haricindeki özel hukuk ve kamu hukuku organizasyonlarının da yapısal değişikliğini düzenleyen İsviçre Birleşme Kanununda zaten hukuk süjesi (Rechtsträger) ve şirket kavramları ayrı ayrı tanımlanmıştır (FusG Art.2).

ii) "Ortak", anonim şirketlerin pay sahiplerini, limited şirketler ile şahıs şirketlerinin ve kooperatiflerin ortaklarını (TTK m.135/1)[521],

iii) "Ortaklık Payı", şahıs şirketlerindeki ortaklık payını, anonim şirketteki payı, limited şirketteki esas sermaye payını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketteki ortaklık payını (TTK m.135/1)[522],

iv) "Genel Kurul", anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerle kooperatiflerdeki genel kurulu, şahıs şirketlerindeki ortaklar kurulunu ve gereğinde ortakların tümünü (TTK m.135/1),

v) "Yönetim Organı", anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi (TTK m.135/1),

vı) "Şirket Sözleşmesi", anonim şirketlerde esas sözleşmeyi, şahıs şirketleriyle limited şirketlerde şirket sözleşmesini ve kooperatifte ana sözleşmeyi ifade etmektedir (TTK m.135/1)[523].

Ticaret şirketlerinin farklı türleri nedeniyle kavramlar hakkında açıklık sağlayan Kanun Koyucu, yapı değişikliği bakımından küçük ve orta ölçekli şirketlerin ne surette belirleneceğine ilişkin olarak da düzenleme yapmış ve "*Küçük ve orta ölçekli şirketler belirlenirken, şahıs şirketleri için 1522, sermaye şirketleri hakkında ise 1523 üncü maddelerde öngörülen ölçütler uygulanır*" (TTK m.135/2) hükmünü getirmiştir.

---

521 TTK m.135/1'de, çeşitli ticaret şirketlerindeki farklı kavram tercihlerinden dolayı, ortağın neyi ifade ettiği hususunda yasal bir sayım yapılmıştır. Ancak yasada anonim şirket, limited şirket, şahıs şirketleri (kollektif ve komandit) ve kooperatif şirketlerden bahsedilmiş olmasına karşın, bir sermaye şirketi olan "*sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket*" (TTK m.124/2) ortakları sayım dışında bırakılmıştır. Ortaklık payının tanımlandığı TTK m.135/1 incelendiğinde, bu eksiklik açık şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ortaklarının sehven sayım dışı bırakıldığını ve ortak kavramıyla aynı zamanda bu şirket ortaklarının kastedildiğini kabul etmek gerekmektedir.

522 Ortaklık payına ilişkin sayımda ise kooperatif ortaklarının ihmal edildiği anlaşılmaktadır. Ortaklara ilişkin sayımda olduğu gibi, bu eksikliğin sehven gerçekleştiği kanaatini taşımaktayız.

523 Türk Ticaret Kanunda zikredilmemesine rağmen, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket bakımından kavramın esas sözleşmeyi ifade ettiğini kabul etmek gerekmektedir.

§ 23- BİRLEŞME

I) GENEL OLARAK

Ticaret şirketlerinde yapısal değişikliğin bir türü olan ***birleşme***, birden fazla ticaret şirketinin aralarında yaptığı *birleşme sözleşmesine* istinaden, birleşmeye katılan bir şirket veya yeni bir şirket bünyesinde bir araya gelmelerini; *yeni kurulan* veya *bünyesinde birleşilen şirket* dışında kalan şirket ya da şirketlerin *tasfiye edilmeksizin* sona ermesini amaçlayan bir hukuki müessesedir.

Yapılan açıklamadan da anlaşılacağı üzere *birleşme*, ya bir ticaret şirketinin diğer bir ticaret şirketini veya işletmeyi (TTK m. 194/1) devralması şeklinde (*devralma şeklinde birleşme*) *(absorbtion)* ya da mevcut ticaret şirketleri dışında kurulan yeni bir ticaret şirketi bünyesinde (*yeni kuruluş şeklinde birleşme) (kombination)* birleşme suretiyle gerçekleştirilir[524].

Türk Ticaret Kanunda düzenlenen birleşme, bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen *iradî* birleşmelerdir. Kamu yararı mülâhazasıyla kanunen veya kanunun yetki verdiği bir mercii kararıyla gerçekleştirilen *kanunî birleşmeler*; Türk Ticaret Kanununun kapsamına dâhil değildir[525].

II) BİRLEŞME KAVRAMI

Kelime olarak "*bir araya gelme*" anlamında olan "*birleşme*", Türk hukukunda, bu olguyu içinde barındıracak şekilde, çeşitli hukuki durumları izah için kullanılmıştır[526].

---

524 Anglo-Sakson hukuk çevrelerinde "*merger*", "*acquisition*", "*purchase*", "*consolidation*" ve "*combination*" kavramlarının işletmelerin birleşmesi için kullanıldığı ifade edilmektedir[524]. Kara Avrupası hukuk sistemlerinde ise "*birleşme*", Latince kökenli[524] ortak bir söyleyişle "*Fusion*" (Alm.), "*fusion*" (Fr.), "*fusione*" (İt.) vb. şeklinde ifade edilmektedir[524].Ülkemiz uygulamasında birleşme karşılığı olarak çeşitli kavramlar kullanılmışsa da[524] "*birleşme*" sözcüğü genel kabul görmüş ve yasal bir değer kazanmıştır.

525 Bu konuda bkz., 5411 sayılı BankK. m.107/5,a.

526 Bunlara Türk Borçlar Kanunu'nun "Borçların ve Borç İlişkilerinin Sona Ermesi"ni düzenleyen 131 vd. hükümlerindeki "*birleşme*"yi (TBK m.135); TBK m.203'deki, "*işletmenin birleşmesi ve şekil değiştirmesi*", hükmünü örnek verebiliriz. Ayrıca, madde metninde "birleşme" terimi geçmemesine karşın, müessese, "*devralma şeklinde birleşme*" kavramına benzer bir yapıyı ele aldığı için, Türk

Konumuz itibariyle *"birleşme"*, Türk Ticaret Kanununda *"Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme"* başlığı altında 136-158'inci maddeleri arasında; bankalar açısından 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 19'uncu maddesi; taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmeler için ise, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23'üncü maddesi ile 130'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28 Aralık 2012 tarihli tebliğde[527] (Tebliğ) hükme bağlanmıştır.

Birleşmeyi, *"en az bir ticaret şirketinin, ortaklarının [ticari işletmenin devralınmasında, ticari işletmeyi işletenlerin (TTK m. 194/1)] birleşilen şirkete alınmaları karşılığında, malvarlığı veya işletmesini aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak birleşilen şirkete devrederek tasfiyesiz dağılması (devralma yoluyla birleşme) veyahut en az iki ticaret şirketinin yeni kurulan bir şirket kurarak, malvarlıkları veya işletmelerini aktif ve pasifleriyle birer bütün olarak bu şirkete devrederek tasfiyesiz olarak sona ermesi (yeni şirket kurulması yoluyla birleşme) neticesinde iki veya daha çok ticaret şirketinin yahut ticari işletmenin tek bir ticaret şirketi altında bir araya gelmeleri"* şeklinde tanımlamak mümkündür[528].

III) BİRLEŞMENİN UNSURLARI

Birleşmenin yukarıda verilen *tanımından, birleşmeye hâkim olan ilkelerden* ve birleşmeye ilişkin diğer hükümlerden yola çıkarak, birleşmenin unsurlarını belirlemek mümkündür. Buna göre:

A) BİRLEŞMEDEN EVVEL EN AZ İKİ TİCARET ŞİRKETİNİN VEYA TİCARET ŞİRKETİ TARAFINDAN DEVRALINACAK EN AZ BİR TİCARİ İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ

TTK'deki birleşme ile ilgili hükümlerin asıl amacı, *ticaret şirketlerinin birleşmesine* yönelik olmasına karşın; bir ticari işletmenin, *ticaret şirketi tarafından devralınması da birleşme* olarak kabul edilmiş ve bu hâlde, Ticaret Kanununda öngörülen bazı hükümlerin kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir. Konuyu, aşağıda *ticaret şirketlerinin ticaret*

Borçlar Kanununun 202'nci maddesinde düzenlenen, *"Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devralmayı"* ve Türk Medeni Kanununda ise, *"karışma ve birleşme"* başlıklı 776'ncı maddesinde hükme bağlanan, taşınır malların birleşmesi hâlini de örnek olarak göstermek mümkündür.

527 "Birleşme ve Bölünme Tebliği", Seri:II, No: 23.2.

528 Tanım için bkz. **Türk, H. S.**, s.37-38.

şirketleriyle ve *ticaret şirketinin bir ticari işletmeyi devralması yoluyla* birleşme başlıkları altında ayrı ayrı inceleyeceğiz.

1) Ticaret Şirketinin Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri ile Birleşmesi

Birleşmeye ilişkin düzenlemelerden TTK m. 137'de, "***geçerli birleşmeler***" başlığı altında, hangi şirketlerin hangi şirketlerle birleşebileceği hükme bağlanarak, *birleşmenin serbest olamayacağı* esası benimsenmiştir.

a) Geçerli Birleşmeler

TTK m. 136'da, tüm ticaret şirketlerinin "*devralma*" veya "*yeni kuruluş*" şeklinde birleşebileceği kabul edildikten sonra, TTK m. 137'de "*geçerli birleşmeler*" başlığı altında, hangi şirketlerin hangi şirketle birleşebileceğini hükme bağlanarak; *birleşme serbestîsine sınır* getirilmiştir. *Geçerli birleşmeler* üç grup altında ele alınmıştır (TTK m.137). Buna göre;

aa) Sermaye şirketleri;

a) Sermaye şirketleriyle,
b) Kooperatiflerle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle,

bb) Şahıs şirketleri;

a) Şahıs şirketleriyle,
b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle,

cc) Kooperatifler;

a) Kooperatiflerle,
b) Sermaye şirketleriyle ve
c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebilirler.

Kanuni düzenlemeye göre *şahıs şirketleri*, şahıs şirketleriyle; *sermaye şirketleri ve kooperatifler*, sermaye şirketleriyle veya kooperatiflerle birleşebilmektedir.

Şahıs şirketlerinin, sermaye şirketleri veya kooperatiflerle birleşmesi ise koşula bağlıdır. Bu tür birleşmelerde şahıs şirketleri, *devrolunan şirket* olmaları; *sermaye şirketleri ve kooperatifler* ise *devralan* şirket olmaları kaydıyla birleşmeye katılabilirler. Düzenleme, kural olarak

sermaye ile sınırlı sorumluluğun olduğu şirketlerde, sermayenin alacaklılar açısından teminat oluşturmasını göz önünde bulundurulduğu; bu teminatın kaybolmasına sebebiyet verebilecek birleşmeye izin verilmediği kanaatini uyandırmaktadır[529].

Varlıkların alımı ile ortaklık haklarının alımı da birleşme olarak nitelendirilmesine karşın, bu tür birleşmeler, Türk Ticaret Kanunu anlamında bir birleşme değildir; Kanunun izin verdiği bu birleşme (geçerli birleşmeler) hallerinin dışında birleşme olanağı bulunmamaktadır. Malvarlıklarının birleşmesi veya hâkim şirket hâline gelinmesi, Türk Ticaret Kanunu anlamında birleşme değildir.

b) Ticaret Şirketinin *Başka Ticaret Şirketi veya Şirketleri* ile Birleşmesinde Özel Hâller

Yukarıda da ifade edildiği gibi, ilgili hükümlerin kıyasen uygulandığı haller bir tarafa bırakılacak olursa, *birleşmenin* ancak *ticaret şirketleri arasında* olabileceği kabul edilmiştir (TTK m.134). Bununla birlikte, "*tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması*" ile "*sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma*" hâlleri, özellikleri sebebiyle ayrıca hükme bağlanmıştır.

aa) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması

Tasfiye hâlindeki bir şirket, *malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa* ve *devrolunan şirket olması şartıyla*, birleşmeye katılabilir (TTK m.138/1)[530].

---

529 Ancak kanun gerekçesinde bu düzenlemenin sebebi, *"Şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu olan ortakların, şirket borçlarından sorumlu tutulmayan ortaklara dönüşmeleri uygun görülmüş, tersi reddedilmiştir. Çünkü şirket borçlarından ortakların kişisel olarak sorumlu oldukları bir şahıs şirketinin anonim şirkete iltihak etmesiyle, sermaye şirketinin ortaklarının şirket borçlarından sorumlu tutulmayacakları bir konuma gelmeleri, şahıs şirketinin alacaklılarının korunmasını gerektirir, fakat anonim şirket pay sahipler inin kolektif şirket ortağı sıfatıyla sınırsız sorumlu olmaları halinde alacaklıların korunmasına gerek yoktur"* ifadeleriyle açıklanmıştır. Mehaz İsviçre hukukundaki düzenlemenin gerekçesi hakkında Bkz. BBl 2000 4394 vd.

530 Taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmeleri hükme bağlayan Tebliğde de kural tekrar edilmiş, "*Tasfiye halindeki bir şirket malvarlığı dağıtılmaya başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması kaydıyla birleşmeye katılabilir*" denilmiştir (Tebliğ m.12/1).

Görüldüğü üzere, ticaret şirketi olması koşuluyla, tasfiye hâlindeki bir şirketin de birleşmeye katılması mümkündür. Ancak kanun koyucu tasfiye hâlindeki şirketin birleşmeye katılmasını iki şarta bağlı tutmuştur. Tasfiye hâlindeki ticaret şirketinin birleşmeye katılabilmesi için bu iki şartın bir arada bulunması gerekir.

Bu şartlardan birincisi, *malvarlığının dağıtılmasına başlanmamasıdır*. Tasfiye sürecinde malvarlığı dağıtılmaya başlanmışsa; tasfiye hâlindeki şirketin birleşmeye katılması mümkün değildir. Devrolunan şirket tasfiye halinde ise, malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtılmasına başlanmadığına ilişkin tasfiye memurlarınca hazırlanacak rapor ticaret sicil müdürlüğüne verilir (TSYm.126/5).

Tasfiye hâlindeki ticaret şirketinin birleşmeye katılabilmesi için *ikinci şart, devrolunan şirket olmasıdır*[531]; tasfiye hâlindeki ticaret şirketi birleşmeye devralan sıfatıyla katılamaz. Bu şartların bulunup bulunmadığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır (TTK m.138/2).

bb) Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma

Türk Ticaret Kanununda, tasfiye sürecine girmiş şirketlerin yanı sıra, *sermayesiyle kanuni yedek akçeleri toplamının yarısı zararla kaybolan ya da borca batık durumda bulunan* bir şirketin de birleşmeye katılabileceği kabul edilmiştir (TTK m. 139/1). Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısı bilanço zararlarıyla yitirilmişse, borca batıklık durumu söz konusu olur[532]. Borca batık şirketlerin birleşmesi, *iyileştirici birleşme* (*Sanierungsfusion*) olarak nitelendirilmekte ve şirketin mali durumunun düzeltilmesine hizmet eden bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

Borca batık şirketlerin birleşmesinde devralan şirketin (TTK m. 139), tasfiye sürecine girmiş şirketten farklı olarak; birleşmeye, *devralan* ya da *devrolunan* şirket olarak katılmaları mümkündür. TTK m. 139/2'de söze konu edilen, "*kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edi-*

---

531 Taraflarından en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde de benzeri bir düzenleme getirilmiş, "*Tasfiye halindeki bir şirket malvarlığı dağıtılmaya başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması kaydıyla birleşmeye katılabilir*" denilmiştir (Tebliğ m. 12/1).

532 Gerekçe s. 113.

lebilen özvarlığa sahip bulunduğunu ispatlayan belgelerin devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması" şartı; borca batık şirketin *devralınan şirket olması gerektiğini ifade etmez*. Bu belgelerin, devralan borca batık şirket ise, *borca batık şirketin*; borca batık şirket devralınıyorsa, *devralan ticaret şirketinin* merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması gerekir.

Ancak belirtmek gerekir ki, iyileştirici birleşme olarak kabul edilen bu birleşmeye katılan diğer şirket ya da şirketlerin, kaybolan sermayeyi ve gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe tasarruf edilebilen öz varlığa sahip olması gerekmektedir (TTK m. 139/1).

2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesi

TTK'de 136 ilâ 158'inci maddeleri arasında düzenlenen birleşme hükümleri; esas itibarıyla, *ticaret şirketlerinin birbirleriyle birleşmesine* yöneliktir. Bununla birlikte TTK m. 194/1'de, bir ticari işletmenin, *ticaret şirketi tarafından devralınması da birleşme olarak* kabul edilmiş ve bu hâlde, devralan ticaret şirketinin türüne göre 138 ilâ 140, 142 ilâ 158 ve ortak hükümlere ilişkin 191 ilâ 193 üncü madde hükümleri kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir.

a) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesinin Esasları

TTK m. 194/1'deki kabule göre, bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından *devralınmak suretiyle* birleşebilir. Hükümde, sadece *bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle* birleşebileceği kabul edilmekle birlikte; birden fazla ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesinin veya ticaret şirketleri birleşirken, bir veya daha fazla ticari işletmeyi devralarak birleşmelerinin de mümkün olduğu kabul edilmelidir.

b) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeyi Devralarak Birleşmesine Uygulanacak Hükümler

TTK m. 194/1'de, ticaret şirketlerinin birbiriyle birleşmesine ilişkin olarak getirilen bazı hükümlerin, bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine kıyas yoluyla uygulanacağı kabul edilmiştir. Bunlar;

aa) Tasfiye Hâlindeki Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeyi Devralması

Ticaret şirketlerinin birbiriyle birleşmesine ilişkin olarak getirilen bazı hükümlerin, bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine kıyas yoluyla uygulanacak hükümlerin başında, TTK m. 138 zikredilmiştir. Bahsi geçen hükümde, "*Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir*" denilmektedir. Buna göre, *tasfiye hâlindeki bir şirket*, henüz malvarlığının dağıtılmasına başlanmasa da; ancak devrolunan şirket olabileceğinden, *bir ticari işletmeyi devralarak birleşemeyecektir.*

bb) Borca Batık Ticaret Şirketinin Bir Ticari İşletmeyi Devralması

Ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesine kıyas yoluyla uygulanacak diğer bir hüküm, "*Sermayenin kaybı veya borca batıklık hâlinde birleşmeye katılma*" ile ilgili TTK m. 139'dur. Borca batık şirketin devralan şirket olabileceği kabul edildiğinde; borca batık bir şirketin, bir ticari işletmeyi devralarak birleşebilmesi için, devralınacak ticari işletmenin, kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunması şarttır.

cc) Devralınan Ticari İşletmenin Ortaklık Payının ve Haklarının Korunması

Ticari bir işletmenin, ticaret şirketi tarafından devralınarak birleşmesine, TTK m. 140'da hükme bağlanan *ortaklık payının ve haklarının korunmasına* ilişkin hükümlerin de, kıyas yoluyla tatbik edilmesi gerekmektedir.

Buna göre, devrolunan ticari işletme sahibinin, ticari işletme adi şirket olarak işletiliyorsa ortaklarının, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma haklarının bulunduğu kabul edilmeli ve bu istem hakkı, birleşmeye katılan ticari işletme ile devralan şirketin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

TTK m. 194/1'de, *ayrılma akçesine* atıf yapılmadığı için, devrolunan ticari işletme sahibine, ticari işletme adi şirket olarak işletiliyorsa ortaklarına *ayrılma akçesi verilmesi* suretiyle; devralan şirketteki haklarından mahrum edilemez.

dd) Ticari İşletmeyi Devralan Ticaret Şirketinin Sermaye Artırımı Yapması

Ticari işletmenin devralınması yoluyla birleşmede; devralan şirket, sermayesini, devralınan ticari işletmeyi işletenlerin haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde artırmak zorundadır.

ee) Ticari İşletmenin Bir Ticaret Şirketi Tarafından Devralınmasına Uygulanacak Diğer Hükümler

Ticaret şirketlerinin ticaret şirketleriyle birleşmesine ilişkin bazı hükümlerin ve bu bağlamda *yeni kuruluşa* ilişkin TTK m. 143'ün, ticari işletmenin ticaret şirketi tarafından devralınarak birleşmesine kıyas yoluyla uygulanabileceği belirtilmiş olmasına karşın; yeni kuruluş yoluyla ticari işletmeyle birleşme söz konusu olamayacağından, yeni kuruluşa ilişkin hüküm, ticaret şirketlerinin ticaret şirketleriyle birleşmesine uygulanamaz.

Buna karşın, *"birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu"* (TTK m. 145-148), *"inceleme hakkı ve malvarlığındaki değişiklikler"* (TTK m. 149-151), *"kesinleşmeye ilişkin hükümler"* (TTK m. 152-154), *"kolaylaştırılmış birleşme"* (TTK m. 155-156) ve *"alacaklıların ve çalışanların korunması"* (TTK m. 158) hükümleri, ticaret şirketlerinin ticari işletmeyle birleşmesine, kıyas yolu ile tatbik edilebilir.

Bu çerçevede, "*ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi*" (TTK m. 191) "*birleşmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları*" (TTK m. 192) ve "*sorumluluk*" hükümleri de, ticaret şirketlerinin ticari işletmeyle birleşmesine kıyas yoluyla uygulanabilir.

B) MALVARLIKLARININ BİRLEŞMESİ

Ticaret şirketlerinin birleşmesinden söz edebilmek için, katılan şirketin (devralınan işletmenin) malvarlığı ile devralan şirketin malvarlığının, *devralan şirkette*; yeni kuruluş söz konusu ise, birleşen şirketlerin malvarlığının, *yeni kurulan şirkette* birleşmesi gerekir.

Ticaret şirketlerinin birleşmesinde, en az bir ticaret şirketinin malvarlığı veya işletmesi bütün aktif ve pasifleriyle başka bir ticaret şirketine (devralma şeklinde birleşme) veyahut en az iki ticaret şirketinin malvarlıkları veya işletmeleri bütün aktif ve pasifleriyle yeni kurulan bir ticaret şirketine (yeni kuruluş şeklinde birleşme) devredilir.

C) BİRLEŞEN ŞİRKETLERİN ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATLARININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE DEVAM ETMESİ

"Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre ***devralan şirketin paylarının****, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir"* (TTK m.136/3; Tebliğ m. 11).

Kural bu olmakla beraber, birleşme sözleşmesinde TTK'nin 141'inci maddesinin 2'nci fıkrası anlamında ***ayrılma akçesi*** öngörülebilir[533]. Buna göre, birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı yerine; sadece şirket paylarının gerçek değerine denk gelen bir *ayrılma akçesinin* verilmesini öngörebilirler. Bu hâlde ortaklık sıfatının birleşilen şirkette devamı söz konusu olmaz.

Kanun Koyucunun atıf yapmamasına karşın, aynı ilkenin (ortaklık sıfatının devam etmemesine ilişkin istisnanın) TTK m.140'ta hükme bağlanan ***denkleştirmede*** de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz[534]. TTK m.140/2'ye göre, ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin *onda birini aşmaması şartıyla*, bir ***denkleştirme ödenmesi*** öngörülebilir. Bu durumda da kendisine denkleştirme ödemesi yapılan ortakların ortaklık sıfatı, denkleştirme oranında yeni şirkette devam etmez.

Denkleştirme ve *ayrılma akçesi* ile ilgili TTK m.140 ve 141 hükümlerinde getirilen istisnalar haricinde, birleşme nedeniyle dağılan şirket veya şirketlerin, birleşme esnasındaki ortaklarının, devralan veya yeni kurulan ticaret şirketinin ortağı sıfatını kazanmaları, meselâ dağılan

---

533 Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde, birleşme sözleşmesinde, TTK'nın 141 inci maddesi çerçevesinde *ayrılma akçesinin öngörülmesi durumunda*; ayrılma akçesinin Türk Lirası cinsinden nakit, menkul kıymet veya kısmen nakit kısmen menkul kıymet olarak belirlenmesi mümkündür. Ancak pay sahibinin talebi halinde ayrılma akçesinin nakden ödenmesi zorunludur (Tebliğ m.12/3).

534 Taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde, "*şirket paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin ortaklarına tahsis olunan şirket paylarının birleşme işlemine esas alınan değerlerinin onda birini aşmaması şartıyla, TTK'nın 140'ıncı maddesi çerçevesinde bir denkleştirme ödemesi öngörülebilir*" denilerek "denkleştirme" açık bir şekilde kabul edilmiştir(Bkz., Tebliğ m.11/2).

anonim şirket veya şirketlerinin pay sahiplerine, devralan veya yeni kurulan şirketin pay senetlerinden verilmesi gerekir[535].

D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ

Birleşmeyle, devralan (yeni kurulan veya iltihak edilen) ticaret şirketi, devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün hâlinde devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket veya şirketler sona erer ve ticaret sicilinden silinir (TTK m.136/4). Ticaret şirketlerinin birleşmesi hâlinde, *tasfiyesiz infisah* (dağılma) söz konusu olur.

E) KÜLLİ HALEFİYET

Birleşmek suretiyle tasfiyesiz olarak infisah eden ticaret şirket veya şirketlerinin malvarlıkları veya işletmeleri; aktif ve pasifiyle bir bütün hâlinde, yani külli halefiyet yoluyla devralan veya yeni kurulan şirkete, birleşmenin tescili ile birlikte kendiliğinden geçer. Bu şekliyle birleşen şirketlerin sürekliliği sağlanmıştır. Birleşmeyle dağılan şirketlerin tüm malvarlığı, yani tüm hakları ve yükümlülükleri hiçbir devir işlemine gerek kalmaksızın kendiliğinden devralan veya yeni kurulan şirkete geçmiş olur. Bir diğer söyleyişle, hak sahipliği süjesi değişikliğine karşın; malvarlığı haklarında süreklilik sağlanmış olur.

F) BİR ŞİRKET ÇATISI ALTINDA BİRLEŞMEK

İster devralma ister yeni kuruluş şeklinde birleşme söz konusu olsun, birleşmenin sonucunda; birleşen şirketler, tek bir ticaret şirketi durumuna gelir.

IV) BİRLEŞME TÜRLERİ

Ticaret şirketlerinin birleşmesi çeşitli açılardan tasnife tâbi tutulabilirse de[536] Kanun Koyucunun kabulüne göre ticaret şirketleri iki şekilde

---

[535] **Türk**, s.39.

[536] Bu düzenlemeyle, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda da aynen bulunan birleşmenin iki türü, 6102 sayılı kanunun 136'ncı maddesinin birinci fıkrasında, kooperatifler de dâhil olmak üzere tüm ticaret şirketlerini içerecek tarzda ifade edilmiştir. Kanunun gerekçesinde, devralma yolu ile birleşmelerin, *ana-yavru, ana-kardeş* şirketler arasında *düz ve ters birleşme* şeklinde olabileceği de ifade edilmiş; *ters birleşmenin,* yavru şirketin ana şirketi devralması şeklinde anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.

birleşebilir: "*devralma şeklinde birleşme*" ya da "*yeni kuruluş şeklinde birleşme*" (TTK m.136/1;Tebliğ m.4/1,e,r).

Devralma şeklinde birleşmede, birleşmeye katılan şirketlerden birinin bünyesinde, diğer şirket ya da şirketler bir araya gelmektedir[537].

Yeni kuruluş şeklinde birleşme ise, birleşmeye katılan tüm şirketlerin, yeni kurulan bir şirket bünyesinde bir araya gelmesidir. Yeni kurulan şirket, birleşme sözleşmesinin tescilinden önce tüzel kişilik kazanmışsa, yeni kuruluş şeklinde birleşme değil; devralma şeklinde birleşme söz konusu olacaktır (bkz. TSY m. 127).

Birleşme işleminin gerçekleşebilmesi için, (TTK m. 194/1'de hükme bağlanan, *"bir ticari işletmenin, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak suretiyle birleşmesi"* ile ilgili istisna haricinde) en az iki şirketin bulunması zorunludur. Ancak ikiden fazla sayıda şirketin de birleşme işlemini gerçekleştirmesi mümkündür.

Türk Ticaret Kanununun birleşmeye ilişkin 136-158'inci maddelerinde ve Tebliğin uygulamasında, kabul eden şirket "*devralan*"; katılan şirket "*devrolunan*" diye adlandırılmaktadır (TTK m.136/2)[538].

Ticaret şirketlerinin birleşmesi, *iktisadi* açıdan, yatay, dikey ve karma birleşmeler şeklinde üçlü bir tasnife tâbi tutulmuştur. *Yatay birleşme*, aynı faaliyet alanında ve coğrafi bölgede çalışan, üretim ve dağıtım zincirinin aynı seviyesinde bulunan şirketlerin birleşmesi olarak değerlendirilirken; *dikey birleşme*, bir mal veya hizmetin üretilmesinden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte yer alan işletmelerin birleşmesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Dikey birleşmede, birleşen işletmeler üretim ve dağıtım zincirinin farklı aşamalarında yer alan işletmelerdir. Karma birleşme ise, yatay ve dikey birleşme dışında kalan, farklı sektör ve/veya faaliyet alanlarında ve/veya coğrafi alanda çalışan işletmelerin birleşmesidir.

Muhasebe açısından yapılan ayrımda işletmelerin birleşmesi, varlık alımı ve ortaklık haklarının alımı şeklinde ayrıma tâbi tutulmaktadır. Ancak bu ayrımda söze konu edilen birleşmelerden varlık alımı, TTK anlamında birleşmelerden ziyade, TBK m.202'de hükme bağlanan "malvarlığının veya işletmenin devralınmasını ve TBK m.203'de düzenlenen "işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesini" hedef almaktadır. Ortaklık haklarının alımında ise, menkul kıymet yatırımları anlaşılmaktadır.

537 Tebliğde, Devralma şeklinde birleşme: *"En az bir şirketin, aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak başka bir şirkete devrederek tasfiyesiz sona ermesini ve devrolunan şirketin ortaklarına belirli bir değişim oranına göre hesaplanacak miktarda devralan şirketin paylarının verilmesini"* ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır (Tebliğ m.4/1.e).

538 TTK m.136/2'de bu husus, 136 ilâ 158 inci maddelerin uygulamasında, kabul eden şirket "devralan", katılan şirket "devrolunan" diye adlandırılır" *şeklinde ifade edilmiştir.*

Birleşmenin türüne göre (*devralma* veya *yeni kuruluş şeklinde birleşme)* yapılacak işlemler bazı farklılıklar içermekle birlikte; doğurdukları sonuçlar benzerlik arz eder.

Buna göre devrolunan şirket, birleşmeyle birlikte sona erer ve ticaret sicilinden silinir (TTK m. 136/4). Kanunun bu açık hükmü kapsamında, birleşmenin, devrolunan şirket açısından bir sona erme nedeni olduğunda tereddüt bulunmamaktadır. Buna rağmen bazı ticaret şirketi türleri bakımından birleşmenin bir sona erme nedeni olduğu, ilgili maddelerde özel olarak da belirtilmiştir[539].

V) ORTAKLIK PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI

Birleşme ilkelerinde kabul edildiği, birleşmenin unsurları kısmında bahsedildiği üzere, ticaret şirketlerinin birleşmesinden söz edilebilmesi için; birleşen şirketlerin ortaklarının ortaklık sıfatının, birleşilen şirkette devam etmesi gerekir. Ortaklık sıfatının, birleşilen şirkette devamının hangi esaslarla gerçekleşmesi gerektiği, TTK m. 140'ta, "*Ortaklık payının ve haklarının korunması*" başlığı altında özel olarak hükme bağlandıktan sonra; TTK m. 141 gereğince, birleşen şirketlerin ortaklarına "***ayrılma akçesi***" verilerek bu kuraldan sapılabileceği kabul edilmiştir. Kanun Koyucunun atıf yapmamasına karşın, aynı istisnanın TTK m.140'2a hükme bağlanan ***denkleştirmede*** de söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak dikkat edilmelidir ki, Kanun Koyucu TTK m. 140'ta sadece *ortaklık payından* değil; ortaklık payından başka, *ortaklık haklarını* da özellikle zikretmiştir.

A) ORTAKLIK SIFATININ BİRLEŞİLEN ŞİRKETTE DEVAMINDA, HAKLARIN DAĞILIMI

Birleşmeye katılan şirketlerde pay sahibi olanlar ile pay sahipliği haricinde diğer bazı haklara sahip olanların, birleşme sonrasındaki haklarının akıbetinin ne olacağı önemli bir sorundur. Türk Ticaret Kanununda, birleşmenin hak durumuna etkisi ile ilgili olarak bazı özel düzenlemelere yer verilmiştir.

---

[539] Kollektif ve komandit şirketleri için bkz. TTK m.243/1, m.328; Kooperatifler için bkz. KoopK m. 81/1,5.

1) Devrolunan Şirketin Pay Sahiplerine Tanınan Haklar

Birleşmenin temel ilkelerinden biri olan, *ortaklığın devamı ilkesinin* gereği olarak, ***devrolunan şirketin*** her bir *ortağı*, mevcut ortaklık paylarını ve bu ortaklık payları üzerindeki haklarını karşılayacak değerde, devralan şirketin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakkına sahiptir (TTK m.140/1; Tebliğ m.11/1).

Ancak dikkat edilmelidir ki, TTK m. 140/1 hükmü *yeni kuruluş* şeklinde birleşme açısından, birleşmeye katılan tüm şirketlerin ortaklarının; *devralma* şeklinde birleşme açısından ise, *sadece* devrolunan şirketin pay sahiplerinin menfaatine hizmet etmektedir. *Devralma* şeklinde birleşmede, devralan şirket pay sahipleri, pay sahipliği haklarının korunmasını TTK m. 140/1'e göre değil; TTK m. 192 ve 193 uyarınca dava yoluyla isteyebilecektir.

Devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketin payları üzerindeki istemde bulunma hakkı, *devralan şirkete karşı ileri sürülebilecek bir haktır*; devrolunan şirket ortakları bu hakkını, devrolunan şirketten isteyemezler.

a) Devrolunan Şirket Pay Sahiplerine Tanınan İstem Hakkının Kapsamı

Devrolunan şirket pay sahiplerine tanınan istem hakkının kapsamı (*değişim oranı*) belirlenirken, önem taşıyan tüm hususlar dikkate alınarak; *şirketlerin gerçek değerine göre* hesaplama yapılacaktır. Neyin birleşmede önem taşıyan hususlar kapsamında olduğu konusunda Kanun Koyucu, birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarının değeri ve oy haklarının dağılımını açıkça zikretmiştir (TTK m. 140/1;Tebliğ m11/1). Önem taşıyan hususlar kapsamında birleşmenin iyileştirici olup olmadığı, birleşmeye katılan şirketlerin işletme değerleri, payların itibari değerleri, primli pay çıkarılıp çıkarılmayacağı gibi hususlar dikkate alınacaktır[540]. Ancak önem taşıyan hususların sınırlı sayı ile belirlenmesi mümkün değildir; somut birleşme ve ilgililerin yönlendirmesi kapsamında değişim oranı belirlenecektir.

Devrolunan şirket pay sahiplerine tanınan istem hakkının kapsamı (*değişim oranı*) belirlenirken, bu kurala küçük bir *istisna* getirilerek; ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolunan şirketin

---

[540] Bkz Gerekçe s. 114

ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin *onda birini* aşmaması şartıyla, bir ***denkleştirme ödenmesi*** öngörülebilir (TTK m. 140/2; ayrıca bkz. Tebliğ m.11/2). Hükmün amacı, belirlenen değişim oranı yanında pay sahiplerine özel bir menfaat sağlamak ya da değişim oranının kısmen ve nakden ifasına olanak sağlamak değildir. Burada özellikle birleştirme oranı kapsamında ilgililerin sahip olacakları paylardaki *küsuratlar nedeniyle* ortaya çıkabilecek sorunun bertaraf edilmesi amaçlanmaktadır[541]. Denkleştirme ödenmesi yoluyla, söz konusu küsuratların nakden ifası suretiyle birleşmenin kolaylaştırılması hedeflenmiştir. Ancak suiistimale sebebiyet vermemesi açısından, ödeme yapılacak miktar, ortaklık paylarının gerçek değerinin 1/10'unu aşamayacaktır. Pay sahiplerine yapılacak denkleştirme ödemesi, devralan şirketin serbestçe tasarruf edebileceği özvarlıklardan karşılanacaktır[542].

Kanun Koyucu, devrolunan şirkette **imtiyazlı paylara** sahip olan ortakların durumunu ayrıca ele alarak; *"devrolunan şirkette mevcut bulunan paylara bağlı imtiyaz hakları karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya uygun bir karşılık verilir"* (TTK m. 140/4) hükmünü kabul etmiştir[543]. Kanunun gerekçesinde, maddede belirtilen imtiyaz kavramının, imtiyazlı paylara hasredilemeyeceği ve özel hakları kapsayacağı ifade edilmektedir[544].

Devrolunan şirketin *oydan yoksun paylarına* sahip ortaklarına aynı değerde, oydan yoksun veya oy hakkını haiz paylar verilir (TTK m. 140/3)[545].

---

541 Bkz. Gerekçe s. 115.

542 **Glanzman,** Art. 7, Rn. 24.

543 Taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde *"Devrolunan şirkette mevcut bulunan imtiyazlı paylar karşılığında, devralan şirkette eş değerde haklar veya **uzman kuruluş görüşü** dikkate alınarak belirlenen bir karşılık verilir. Şu kadar ki, farklı bir imtiyaz öngörülmesi veya farklı bir imtiyaz öngörülmesi ile aynı anda karşılık ödenmesi de mümkündür. Devralan halka açık ortaklık açısından yeni imtiyaz oluşturulması veya mevcut imtiyazların kapsam ve konusunun değiştirilmesine yol açan işlemlere ilişkin Kurulun ayrılma hakkına ilişkin düzenlemeleri saklıdır"* (Tebliğ m.11/3).

544 Gerekçe s. 115

545 SPK'nun Seri: I, No:36 sayılı Oydan Yoksun Paylara İlişkin Tebliğinin 4/1. (e) maddesinde **Oydan Yoksun Paylar** (OYP), *"Ortaklıkların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri, oy hakkı hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde bedelsiz pay alma hakkında imtiyaz dışındaki diğer hususlarda imtiyaz ve diğer ortaklık haklarını sağlayan, istendiğinde belirli bir vade veya vadelerde, sabit*

b) Değişim Oranını Tespit Tarihi

Değişim oranı, şirketlerin aynı tarih itibariyle değerlendirilmesi suretiyle bulunacaktır. Bu tarihin hangi gün olduğu konusunda TTK m. 140/5 hükmü hareket noktası olarak kabul edilebilecektir[546]. Anılan maddeye göre, *değişim oranı için, birleşme sözleşmesinin akdedildiği gün esas alınacaktır.* Keza TTK m.150 hükmünde de birleşme sözleşmesi tarihinden itibaren şirket malvarlığında önemli değişiklik meydana gelmesi halinde bildirim yükümlülüğüne yer verilmiş olması, bu tarihin esas alınması gerekliliğine işaret etmektedir[547].

2) Devrolunan Şirkette İntifa Hakkı Sahiplerine Tanınan Haklar

Kanun Koyucunun kabulüne göre, *"Devralan şirket, devrolunan şirketin **intifa senedi sahiplerine**, eş değerli haklar tanımak veya intifa senetlerini, birleşme sözleşmesinin yapıldığı tarihteki gerçek değeriyle satın almak zorundadır"* (TTK m. 140/5)[548].

---

veya değişken oranda ortaklığın oy hakkına sahip paylarını satın alma ve ortaklık payları ile değiştirme hakkı veren payları" ifade eder şeklinde tanımlanmış; 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Oydan Yoksun Paylara İlişkin Tebliği (Seri:I, No:36); 22 Haziran 2013 tarihli "Pay Tebliği" (VII-128.1) ile yürürlükten kaldırılmıştır.

546 Bkz.,Gerekçe s. 114.

547 Bu hususta bkz., **Glanzmann**, Lukas; in Fusionsgesetz, Hrsg. Baker&McKenzie, Bern 2003, Art.7, Rn.12.

548 Devrolunan şirket pay sahipleri açısından geçerli olan hususların, *şirketle ortaklık dışı ilişkisi* bulunan ve özellikle kâra iştirak hakkı tanınan kimseler için de kabul edilmesi gerekir. Fakat ilgililerin haklarının, "*ortaklık hakları ve payları*" başlığı altında hükme bağlandığı TTK'nın 140 ve 141'nci maddelerinde böyle genel bir düzenleme yapılmamış; sadece ortakların, oydan yoksun pay sahiplerinin, imtiyazlı pay sahiplerinin ve intifa senedi sahiplerinin istem hakları düzenlenmiştir. Özellikle kâra iştirak hakkı bulunan menkul kıymet sahipleri (örneğin kâr/zarar ortaklığı belgesi sahipleri) hakkında açık düzenleme yapılmaması ve bu kimselere haklarını koruyabilme imkânının Türk Ticaret Kanununun birleşmeye ilişkin hükümleri çerçevesinde[548] sağlanmaması karşısında, intifa haklarının himayesine ilişkin hükümlerin, bunlar hakkında kıyasen uygulanabileceğini kabul etmek gerekir. ***Zira alacaklıların haklarının himayesine ilişkin TTK m. 157 hükmü, meçhul ve faaliyet sonucuna bağlı alacağı himaye etmede yetersiz kalacaktır. TTK m. 191 ve 192'de tanınan haklar ise ortaklara hasredildiğinden, belirtilen maddelerdeki davaların açılması da mümkün değildir.***

B) AYRILMA AKÇESİ

Türk Ticaret Kanununun (ve Tebliğin) birleşme açısından kabul ettiği temel ilke, *ortaklığın devamı ilkesidir*. Yani, devrolunan şirket ortakları, belirli bir değişim oranı çerçevesinde, devralan şirkette ortaklıklarını devam ettirirler. Bu durum, aynı zamanda birleşme işlemini de karakterize eden bir özelliktir. Ancak TTK m.141'de "*ayrılma akçesi*" başlığı altında bu kuralın *istisnasına* yer verilmiştir[549].

TTK m.141'de getirilen istisna uyarınca, pay sahiplerinin, devralan şirkette sahip olacakları paylar yerine, bu payların gerçek değerine uygun bir ayrılma akçesi öngörülebileceği gibi (*zorunlu ayrılma akçesi*) (TTK m. 141/2); paylar ve ayrılma akçesinden birinin tercihi, pay sahiplerine de bırakılabilir (*seçimlik ayrılma akçesi*) (TTK m. 141/1).

Seçimlik ayrılma akçesinde, ortağın, birleşilen şirkette ortak sıfatının devam edip etmeyeceğine karar vermesi imkânı doğacağından, bu durum ortağın menfaatine olacak; bu surette birleşmeye katılmak istemeyen ortaklar, paylarının gerçek değerini alarak, birleşme sonrası ortaya çıkacak ortaklık ilişkilerine son verebileceklerdir. Belirtmek gerekir ki, bu ortaklar, mutlaka birleşme sözleşmesi aleyhine oy kullanmak zorunda değildir[550]. Kanunda bu konuda sınırlama yapılmadığından, birleşme lehine oy kullanan ortakların da ayrılma akçesi alabileceğini kabul etmek gerekir.

Zorunlu ayrılma akçesinde ise daha ziyade, çoğunluk tarafından istenilmeyen ortakların, ayrılma akçesi almak suretiyle şirketten çıkarılması söz konusudur.

Ayrılma akçesinin kullanılıp kullanılmayacağı, kullanılacak ise bunun ortaklar açısından seçimlik veya zorunlu olması, birleşme sözleşmesi ile tayin edilecektir. Ayrılma akçesinin birleşme sözleşmesinde yer alıp almayacağı, yer alacaksa hangi türünün söz konusu olabileceği konusunda *yasal sınırlama bulunmamaktadır*. Ancak seçimlik ayrılma akçesine ilişkin TTK m.141/1 gerekçesinde, ayrılma akçesinin nakden

---

549 TTK m. 155 uyarınca verilmesi önerilen nakdi karşılık da, ortaklığın devamlılığı ilkesinin istisnalarındandır.

550 "Birinci fıkrada yer alan hususların görüşüleceği genel kurul toplantısının gündeminde, bu kararlara muhalefet oyu kullanacak pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma hakkının bulunduğu hususu ile bu hakkın kullanılması durumunda payların ortaklık tarafından satın alınacağı bedel yer alır", (SPK m. 24/3). Ayrıca 24.12.2013 Tarih, Seri: II, No: 23.1 Tebliği m. 9/1.

ödendiği hallerde, bunun sermayenin iadesi şeklinde gerçekleşmemesi; ödemenin serbest yedeklerden yapılması gerektiğine işaret edilmektedir[551]. Dolayısıyla, nakdi ödeme için yeterli serbest yedeklerin bulunmaması, ayrılma akçesi öngörülmesi bakımından bir engel ya da sınır teşkil edecektir.

Ayrıca TTK m. 151/5 hükmünde, birleşme sözleşmesinin ayrılma akçesi öngörmesi halinde, sözleşmenin *devreden şirket genel kurulunda* %90'lık bir nisapla onaylanması gereği hükme bağlanmıştır. Belirtmek gerekir ki %90'lık nisap, İsviçre hukukunda *sadece "zorunlu"* ayrılma akçesi öngörülmesi halinde aranmaktadır (FusG Art. 18 Abs. 5)[552]. Ayrılma akçesinin seçimlik olarak öngörüldüğü hallerde ise, bu nisap aranmamaktadır. TTK m. 151/5'te ise böyle bir ayrım yapılmaksızın, şirket sözleşmesinde (zorunlu veya seçimlik) bir ayrılma akçesi öngörülmesi halinde %90'lık nisap aranmıştır. Ancak TTK m.151/5'te öngörülen nisabın, mehaza uygun olarak sadece zorunlu ayrılma akçesi öngörülen haller (TTK m. 141/2) için uygulanacağını kabul etmek gerekir[553].

VI) BİRLEŞME İŞLEMLERİ

Kanun Koyucunun kabulüne göre, ticaret şirketlerinin birleşmesi için evvelemirde taraflar arasında bir *birleşme sözleşmesinin* yapılması, daha sonra ise, birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarının, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir *rapor hazırlaması*, birleşmeye katılan şirketlerden her birinin, birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilançolarını, ortakların, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, menfaati bulunan kişilerin ve diğer *ilgililerin incelemesine sunması*, yönetim organının *karar organına birleşme sözleşmesini sunması*, karar organının *birleşme kararı alması*, birleşme kararı alınır alınmaz, yönetim organlarının, *birleşmenin tescili için ticaret siciline başvurulması* gerekir. Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil

---

551 Bkz. Gerekçe s. 115.

552 Anılan maddede "*Sieht der Fusionsvertrag **nur** eine Abfindung* vor..." ifadesi kullanılmak suretiyle, *sadece* (zorunlu) ayrılma akçesi öngörülen halde bu nisabın arandığı belirtilmiştir.

553 Kanundaki düzenleme tereddüt doğursa da, TTK m. 141 gerekçesinde, TTK m. 151/5 hükmünün nasıl anlaşılması gerektiğine işaret edilmektedir.

anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete geçer ve devrolunan şirketin ortakları, devralan şirketin ortağı olur.

A) BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Ticaret şirketlerinin birleşmesine ilişkin olarak yapılması gereken *birleşme sözleşmesi, yazılı geçerlilik şartına* tâbidir. Kanun koyucu sözleşmenin yazılı şekle tâbi olduğunu belirtmekten başka, yazılı sözleşmenin kapsamına ilişkin koşul da getirdiği için (bkz.TTK m.146)[554], bu yazılı şekle *nitelikli yazılı şekil* (qualifizierte Schriftlichkeit) diyebiliriz. Bu sebeple, sözleşmenin yazılı şekilde yapılması yeterli olmayıp, birleşme sözleşmesinin TTK m.146'da belirtilen unsurları da ihtiva etmesi gerekir.

Bu sözleşme, birleşmeye ilişkin temel esasları belirleyen bir sözleşmedir; birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organı[555] tarafından imzalanır (TTK m. 145/1).

TTK m.146 hükmüne göre, birleşme sözleşmesinin; (a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini, (b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları, (c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları, (d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini, (e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri, (f) Gereğinde 141'inci madde uyarınca ayrılma akçesini, (g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi, (h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları, (i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini, içermesi zorunludur.

---

554 Taraflarından en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde sözleşmenin içeriği için ayrıca bkz., (Tebliğ Ek 3).

555 Yönetim organı; anonim şirketler ve kooperatiflerde yönetim kurulunu, limited şirketlerde müdürü veya müdürleri, şahıs şirketleriyle sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticiyi ifade eder (TTK m.135/1).

Sözleşmede bulunması gereken asgari içerik, sözleşmenin geçerliliğini etkiler; bu unsurların bulunmaması, sözleşmenin birleşme sözleşmesi niteliğini ortadan kaldırır (TTK m.146). Taraflar, sözleşmenin mahiyetine göre, birleşme sözleşmesinin mahiyetine aykırı olmayan diğer hususları da sözleşmeye koyabilirler.

B) BİRLEŞME RAPORU

Birleşme sözleşmesi, sürecin başlaması için gerekli bir işlem olmakla birlikte, tek başına birleşmenin gerçekleşmesi (hükümlerini doğurması) sonucunu doğurmaz; birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarının, ayrı ayrı veya birlikte, birleşme hakkında bir *rapor hazırlaması* da gerekir (TTK m.147; Tebliğ m.9/2).

Birleşme raporunun içeriğini düzenleyen TTK m.147/2'de, raporda, gereğinde *ayrılma akçesinin* tutarının ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebeplerinin, değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin özelliklerin, gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarının belirtilmesi ve yeni kuruluş yoluyla birleşmede ise, birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesinin şart olduğu ifade edilmiştir[556].

Bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, birleşme raporunun hazırlanması ve hatta birleşme sözleşmesinin yapılmasından önce, birleşme için bazı işlemlerin de yapılması gerekmektedir.

Devralma yoluyla birleşmede devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının korunabilmesi için gerekli olan düzeyde artırmak zorundadır.

Yeni kuruluş şeklindeki birleşmede ise, şirketlerin bünyesinde birleşeceği yeni bir şirketin kurulması gerekir.

Birleşme raporunun hazırlanabilmesi için ayrıca bir bilançonun da hazırlanması gerekir (TTK m.144). Gerçekten de TTK m.144/1'de hükme bağlanan, "*Birleşme sözleşmesinin imzalandığı tarih ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarılmasından sonra, birleşmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmişse, birleşmeye katılan şirketler bir*

---

556 Taraflarından en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde, birleşme raporunda bulunması gereken asgari unsurlar hakkında bkz., (Tebliğ Ek 4).

ara bilanço çıkarmak zorundadır" şeklindeki bu düzenlemeden, birleşme raporunun hazırlanabilmesi için ayrıca bir bilançonun da hazırlanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Bahsi geçen bilanço, birleşme münasebetiyle hazırlanabileceği gibi, faaliyet dönemine ilişkin olarak çıkartılmış olabilir. Bununla birlikte şayet, yukarıda da belirtildiği üzere (TTK m.141/1), belirli hâllerde ayrıca birleşmeye katılan şirketlerin bir *ara bilanço* çıkarmak zorunluluğu da söz konusu olur.

Yeni kuruluş şeklinde birleşmede, henüz bir şirket olmadığı için; bilanço çıkarmak, birleşmeye katılanlar için öngörülmüş bir zorunluluktur.

Ara bilanço, TTK m. 140 uyarınca değişim oranının belirlenmesi ve mal varlıklarının değerlemesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden ara bilançonun güncel olması ve gerçek mal varlığı durumuna uygun olması gerekir; ara bilançonun güncel olması, ilgililerin menfaatleri icabıdır. Bu menfaat durumunu göz önünde bulunduran kanun koyucu, *iki halde ara bilanço çıkarılması zorunluluğuna* yer vermiştir.

Bunlardan birincisi, birleşme sözleşmesinin imzalanması ile bilanço günü arasında altı aydan fazla zaman geçmiş olmasıdır (TTK m. 144/1). Altı aylık süre, Avrupa Birliği'nin ilgili yönergesinde de öngörülmüştür. Belirtilen süre boyunca faaliyet, bilanço sonuçlarının olumlu ya da olumsuz yönde değişimini gerektirecek seviyededir[557].

Yeni bilanço hazırlanmasını gerektiren bir *diğer neden*, bilançonun çıkarılmasından sonra, *birleşmeye katılan şirketlerin mal varlıklarında önemli değişikliklerin meydana gelmiş olmasıdır*[558]. Bilanço gününden itibaren altı aylık süre geçmemiş olsa dahi, önemli değişiklikler nedeniyle bilanço çıkarılması gereklidir. Önemli değişikliklerin neler olduğu konusunda Kanunda bir ölçüte yer verilmemiş, gerekçede çeşitli örneklerden bahsedilmiştir[559].

Birleşme raporu, özellikle birleşmeye katılan şirketlerin *pay sahiplerini bilgilendirmeye hizmet eden* bir belgedir. TTK m.147 uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerden her birinin *yönetim organları* ayrı ayrı

---

[557] Gerekçe s. 117

[558] "Bilançonun çıkarılmasından sonra" ibaresini, "bilanço gününden sonra" şeklinde anlamak gerekir. Bkz. **Bommer**, Art. 11, Rn. 4.

[559] Bkz., Gerekçe TBMM, s.117.

veya beraberce *birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar*. Hazırlanan rapor, birleşmeye ilişkin genel kurul karar tarihinden önceki 30 gün boyunca[560] ilgililerin bilgisine sunulmak zorunda olduğundan (TTK m.149/1), yönetim organlarının genel kurul karar tarihinden 30 gün öncesinde raporu hazır etmiş olmaları gerekmektedir.

Birleşme raporunun sağladığı bilgiler bakımından hitap ettiği en önemli kesim, pay sahipleridir. Birleşme neticesinde ortaya çıkacak hukuki statülerinin, oy hakkı dağılımının, hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesinde pay sahiplerinin önemli menfaati bulunmaktadır. Ancak *küçük ve orta ölçekli şirketlerde,* ortakların tamamının onaylaması halinde birleşme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilecektir (TTK m. 147/4)[561].

Bu düzenlemeden de anlaşıldığı gibi, birleşme raporunun hazırlanmasından vazgeçmek için *ortakların tamamının*, raporun hazırlanmasından vazgeçilmesine onay vermesi gerekir; çekimser oy, oybirliğini engeller. Buna göre, her bir ortağın, raporun düzenlenmesinden vazgeçilmesini engelleme *(veto)* hakkı bulunmaktadır.

C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI

Başta pay sahipleri olmak üzere, ilgililerin birleşme hakkında bilgi edinebilmesi ve inceleme yapabilmesi için birleşmeyle ilgili önemli bazı belgelerin *genel kurul toplantısı öncesinde incelemeye açılması gereklidir*. Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde bu ihtiyacın giderilmesine yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Anılan düzenlemeye göre birleşmeye katılan şirketler birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu ve son üç yıla ait yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet

---

560 Bkz., aşağıda "ilgililerin inceleme hakkı" başlığı altında yer alan açıklamalar.

561 Taraflarından en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde de *"kolaylaştırılmış birleşme"* kabul edilmiş; *"Bir veya birden fazla sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının %95 veya daha fazlasına sahip bir halka açık ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesini gerektirmeyen durumlarda veya halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesi gereken ancak halka açık ortaklık paylarının nakit karşılığının devrolunan şirketlerin ortaklarına seçimlik hak olarak önerilmesi durumlarında, kolaylaştırılmış usulde birleşme uygulanabilir"* denilmiştir (Tebliğ m.13/1). Bu tür Kolaylaştırılmış usulde birleşmede bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmaz. Ayrıca birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunlu değildir (Tebliğ mi13/2).

raporlarını ve gereğinde ara bilançolarını incelemeye açmakla yükümlüdür.

Kanun Koyucu, inceleme hakkını haiz olanları; ortaklar, intifa senedi sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamilleri ile **menfaati bulunan kişiler** ve **diğer ilgililer** (TTK m. 149/1) olarak belirtmiş; menfaati bulunan kişiler ve diğer ilgililerin kim olabileceğine ise TTK m. 157 ve 158'inci maddede hükme bağlanan *"alacaklıların ve çalışanların"* korunması düzenlemesiyle işaret etmiştir. Bu hükümler nazara alındığında, birleşen şirketlerin *"alacaklıları"* ile *"çalışanlarının"*, menfaati bulunan kişiler ve diğer ilgililer olarak kabul edilmesi gerekir.

Birleşme raporunun hazırlanmasından vazgeçme imkânı tanınan *küçük ve orta ölçekli şirketler* bakımından, inceleme hakkı için de yasal bir istisnaya yer verilmiştir. Bu tür şirketlerde tüm ortakların onaylaması hâlinde, inceleme hakkından vazgeçilebilecektir (TTK m149/5)[562].

İnceleme hakkından vazgeçmek için ortakların tamamının, inceleme hakkından vazgeçilmesine onay vermesi gerekir; çekimser oy, burada da oybirliğini engeller. Buna göre, her bir ortağın, inceleme hakkından vazgeçilmesini engelleme *(veto)* hakkı bulunmaktadır[563].

D) BİRLEŞME KARARI

Birleşme sürecinin tamamlanması bakımından kanunun öngördüğü bir diğer işlem, imzalanan birleşme sözleşmesinin, birleşmeye katılan şirketlerin genel kurullarında onaylanmasıdır (TTK m. 145/1).

---

562 Ortakların kararıyla, ortak sıfatı bulunmayan ilgililerin inceleme hakkının kısıtlanmasının, ilgililere inceleme hakkı tanıyan TTK m. 149'un amacıyla bağdaşmadığı kanaatindeyiz.

563 Taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşmelerde, "Bir veya birden fazla sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının %95 veya daha fazlasına sahip bir halka açık ortaklık tarafından devralınması suretiyle birleşmede, halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesini gerektirmeyen durumlarda veya halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketlerin ortaklarına pay verilmesi gereken ancak halka açık ortaklık paylarının nakit karşılığının devrolunan şirketlerin ortaklarına seçimlik hak olarak önerilmesi durumlarında, kolaylaştırılmış usulde birleşme uygulanabilir" (Tebliğ m.13/1). "Kolaylaştırılmış usulde birleşmede bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü aranmaz. Ayrıca birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunlu değildir" (Tebliğ m.13/2).

Birleşme sözleşmesi, birleşmeye katılan her bir şirketin yönetim organı tarafından genel kurula sunulur ve onay, bir genel kurul kararı şeklinde ortaya çıkar.

Genel kurulun birleşme kararı verebilmesi için Türk Ticaret Kanunu özel *toplantı ve karar nisaplarına* yer vermiştir. Türk Ticaret Kanununun 151'incimaddesi hükmüne göre;

*(1)*Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. Birleşme sözleşmesi genel kurulda;

a) Bu Kanunun 421 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi saklı olmak üzere, *anonim* ve *sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu* temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan *oyların dörtte üçüyle,*

b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların *dörtte üçüyle,*

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, *tüm ortakların dörtte üçünün* oylarıyla,

d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla, onaylanmalıdır.

(2) Kollektif ve *komandit* şirketlerde birleşme sözleşmesinin *oybirliğiyle* onaylanması gerekir. Ancak, şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların dörtte üçünün kararıyla onaylanması öngörülebilir.

(3) Bir sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin, başka bir şirketi devralması halinde, birinci fıkranın (a) bendindeki nisaba ek olarak, *komanditelerin tamamının birleşmeyi yazılı olarak* onaylamaları gereklidir.

(4) Bir *limited şirket tarafından devralınan* anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette, devralma ile *ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa* veya bunlar mevcut olup da genişletiliyorsa, bütün ortakların *oybirliğine* gerek vardır.

(5) Birleşme sözleşmesi bir *ayrılma akçesini öngörüyorsa* bunun, devreden şirket şahıs şirketiyse oy hakkını haiz ortaklarının, sermaye

şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının *yüzde doksanının* olumlu oylarıyla onaylanması şarttır.

(6) Birleşme sözleşmesinde devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, birleşme sözleşmesinin ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli nisapla onaylanmış olması zorunludur.

		Nisaplar				
	Şirket türü	Toplantı nisabı	Karar nisabı	Özel nisap		
1	A.Ş.	Sermaye çoğunluğu	GK'da mevcut oyların ¾'ü			
2	PSMKBİGŞ[564]	1.Toplantı: Sermayenin ¼'ü	GK'da mevcut oyların çoğunluğu	Esas sözleşmede daha ağır toplantı nisabı öngörülebilir		
		2.Toplantı: Nisap yok				
3	Paylı komandit	Sermayeçoğunluğu	GK'damevcutoyların¾'ü			
5	Koop. tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde	Sermayeçoğunluğu	GK'damevcutoyların¾'ü			
6	Limited Şirketlerde	Sermayenin en az 3/4	GK'damevcutoyların¾'ü			
7	Kooperatiflerde					

E) BİRLEŞMENİN KESİNLEŞMESİ

Birleşme sözleşmesinin genel kurul tarafından onaylanmış olması, birleşme süreci bakımından gerekli bir işlem olmakla birlikte; birleşmenin hüküm doğurması için ayrıca birleşme kararının ticaret siciline tescili gereklidir. Bu açıdan tescil, *kurucu etkiye* sahiptir (TTK m. 153/1).

Birleşmeye birden fazla şirket katıldığından, tüm şirketlerin genel kurul kararlarının sicile tescili gereklidir. Bir şirketin birleşme kararını genel kurula onaylatıp, diğerlerinin onaylatmaması halinde, tescil için başvuru yapılamaz. Diğer şirketlerin genel kurul kararının alınmış olması beklenilmelidir[565].

---

564 Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketler.

565 Bkz. Gerekçe, s. 119.

Birleşmeye katılan tüm şirketlerin birleşmenin onanmasına yönelik genel kurul kararları tescil edilecek olmakla birlikte; hangi şirket genel kurul kararının tescili ile birleşmenin hüküm doğuracağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kanun metninde bu konuda sarahat olmamasına rağmen, *gerekçede* devrolunan şirketin genel kurul kararının ticaret siciline *tescili ile birleşmenin gerçekleşeceği,* bu *tescilin kurucu* olduğu, *mal varlığının geçişini* sağladığı ve devrolunan şirketin *ortaklarının kendiliğinden* devralan şirketin ortağı haline geldikleri; *devralan şirket genel kurul kararının tescilinin ise bildirici etkiye* sahip olduğu açıklanmaktadır[566].

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde de bu etki göz önünde bulundurularak, *devrolunan şirketin* birleşme kararını *öncelikle tescil* ettireceği, *bu tescil yapılmadan devralan şirket genel kurul kararının tescil edilemeyeceği* hükme bağlanmaktadır (TSY m. 127/1).

Devralan şirketin, birleşme dolayısıyla sermaye artırımı yapması gerekli olan hallerde, alınan sermaye artırım kararı ile birleşme kararı eş zamanlı olarak tescil edilir (TSY m. 127/5). Bu durum, devrolunan şirketin birleşme kararının tescilinin kurucu etkisini, yani devrolunan şirket ortaklarının, sermaye artırımının tescilinden önce, kararlaştırılan değişim oranı ölçüsünde devralan şirketin ortağı olduğu gerçeğini bertaraf etmez.

Yeni kuruluş şeklindeki birleşmede, birleşmeye katılan tüm şirketler devrolunan şirket statüsünde olup, yeni kurulacak şirketin kuruluşu ile birleşme kararı eş zamanlı olarak tescil edilecektir (TSY m.127/5). Tescile kadar devralan şirket (yeni kuruluş) hukuken var olmadığından, bahsi geçen birleşme kararının devrolunan tüm şirketlere ait birleşme kararları olarak anlaşılması gerekir. Devralan şirketle ilgili olarak yapılan tesciller, tescili yapan sicil müdürlüğü tarafından derhal devrolunan şirketin kayıtlı olduğu sicil müdürlüğüne bildirilir ve kendi birleşme kararının sicile tesciliyle sona eren devrolunan şirketin kaydı, bildirim üzerine re'sen silinir (TTK m. 152/3; TSY m. 127/5).

Birleşme kararının ilânı; hem üçüncü kişiler hem de Türk Ticaret Kanununun 158'inci maddesinde düzenlenen "*ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi*nin" uygulanması yönünden önem taşıdığından, "*Birleşme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur*" (TTK m. 154).

---

566 Bkz. Gerekçe, s. 120.

VII) SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE BİRLEŞMESİ

Birleşmenin karışık, nispeten uzun ve formalitelere tâbi bir süreç olması nedeniyle, belirli bazı durumlarda bu sürecin kısaltılmasına olanak vermek, menfaatler dengesine uygun bir çözüm olmaktadır. Bu nedenle Türk Ticaret Kanununda, birleşme sürecinin belirli formaliteleri yerine getirilmeden daha basit bir sürecin işletilmesine imkân sağlanmıştır.

Kolaylaştırma *(birleşme sözleşmesine konulacak bazı kayıtlardan sarfınazar edilmesi, birleşme raporunun düzenlenmemesi, inceleme hakkının bulunmaması veya inceleme sürecinin farklılaşması ve sözleşmenin genel kurul onayına sunulmaması şeklinde)* bazı formaliteleri bertaraf etme amacına yöneliktir.

Şirketler, kolaylaştırılmış birleşme usulüne göre birleşme imkânına sahip olsalar bile, bu usulü uygulayıp uygulamamak kendi takdirlerine bırakılmıştır (TTK m. 155).

Kolaylaştırılmış usulde birleşme, sadece sermaye şirketleri, yani anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin birleşmesi için *öngörülmüş* bir yöntemdir (TTK m. 155); şahıs şirketleri ve kooperatiflerin birleşmeye katılması halinde uygulanma olanağı yoktur[567].

Sermaye şirketlerinde bu usulün uygulanabilmesi için, birleşmeye katılanların sadece sermaye şirketi olması yeterli olmayıp; ayrıca birleşmeye katılan şirketler arasında, kanunda öngörülen düzeyde bir *hâkimiyet ilişkisinin* bulunması da gerekir.

Birleşmenin kolaylaştırılmasının temelinde, daha ziyade, hâkimiyet ilişkisi dolayısıyla pay sahiplerinin haklarının korunması ihtiyacının bulunmaması ya da daha düşük seviyede korunması ihtiyacının bulunması yatmaktadır[568]. Yani birleşme sürecinde gerçekleştirilecek bazı

---

567 Taraflardan en az birinin halka açık olduğu birleşmelerde "*kolaylaştırılmış usulde birleşme*" için bkz., (Tebliğ m.13).

568 Kanunun gerekçesinde, *"Birleşme, alacaklıların haklarının zarara uğraması olasılığı yoksa kolaylaşmaktadır. Bu sebeple şartları varsa Kanun koyucu, birleşme sözleşmesini yeterli bulmuş, birleşme raporuna, birleşmenin denetlenmesine, inceleme hakkı sağlanmasına, hatta bunun genel kurulun onayına sunulmasına gerek görmemiş, bu işlemlerin yapılıp yapılmamasını birleşen şirketlere bırakmıştır"* denilmektedir (Bkz. Gerekçe, s.120).

işlemler, pay sahiplerinin haklarının himayesi bakımından bir yarar sağlamayacaksa veya daha az önem taşıyıp pay sahiplerinin hakları yeterince teminat altına alınmışsa, söz konusu işlemlerin yapılmasından sarfınazar edilebilir veya bazı kolaylıklar sağlanabilir[569].

Türk Ticaret Kanununda, kolaylaştırılmış usulde birleşecek şirketler iki ana başlık halinde düzenlenmiştir:

A) OY HAKKI VEREN PAYLARIN TAMAMINA SAHİP OLUNMASI HALİNDE

Türk Ticaret Kanununun 155/1. maddesi hükmüne göre;

1- Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren bütün paylarına veya

2- Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına,

sahiplerse sermaye şirketleri kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler (TTK m.155/1).

Birinci grupta bahsi geçen ihtimalde, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkının tamamına sahip olan yine bir sermaye şirketidir *(Tochter-Mutter Fusion) (downstream mergers).* Bu ihtimalde birleşmenin yeni kuruluş şeklinde gerçekleşemeyeceğini kabul etmek gerekmektedir.

İkinci grupta bahsi geçen ihtimalde yine birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren paylarının tamamına hâkimiyet söz konusudur. Fakat oy hakkı veren paylara sahip olan, birleşmeye devralan olarak katılan sermaye şirketi değildir *(Schwesternfusion);* bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiptir. Dolayısıyla bu tür birleşmenin, ilk gruptan farklı olarak yeni kuruluş şeklinde de gerçekleşmesi mümkündür[570].

---

569 Mehaz İsviçre hukukunda düzenlemenin gerekçesi hakkında bkz., BBl.4422 ff: **Wolf, Mathias;** in Basler Kommentar, Fusionsgesetz, Hrsg. Watter, Rolf, Nedim Peter/Tschäni, Rudolf/Daeniker, Daniel, Basel 2015, Art.23, Rn.1.

570 Aynı yönde **Wolf**, Art. 23 Rn. 6 vd.

B) OY HAKKI VEREN PAYLARIN EN AZ %90'INA SAHİP OLUNMASI HÂLİNDE

Türk Ticaret Kanununun 155/2. maddesi hükmüne göre;

Devralan sermaye şirketi, devrolunan sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde doksanına sahipse, azınlıkta kalan pay sahipleri için;

1- Devralan şirkette bu payların denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, 141 inci maddeye göre, şirket paylarının gerçek değerinin tam dengi olan nakdi bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve

2- Birleşme dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut kişisel sorumluluğun doğmaması,

hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.

Devralan sermaye şirketinin, devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı veren paylarının en az %90'ına sahip olması durumunda, azınlıkta kalan pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ihtiyacı ortaya çıkar. Bu nedenle, böyle bir hâkimiyet ilişkisinin bulunması halinde, ancak belirli koşullar mevcutsa, birleşme kolaylaştırılmış usulde gerçekleşebilir.

Birleşmede, devralan sermaye şirketinin oy hakkına sahip olması koşulu arandığından, bu tür birleşme yeni kuruluş şeklinde gerçekleşemez.

Bu tür birleşmenin kolaylaştırılmış usulde gerçekleşmesi için kanunda aranan *iki şartın* bir arada bulunması gerekir. Her iki şart da esasen azınlıkta kalan pay sahiplerinin menfaatini korumaya hizmet etmektedir.

Bunlardan *ilki*, azınlıkta kalan pay sahiplerine, sahip oldukları payın, devralan şirketteki uygun karşılığı olan payın yanında bu payın gerçek değeri olan nakdi karşılığın önerilmiş olmasıdır. Yani azınlıkta kalan pay sahiplerine bir seçim hakkı önerilmiş olmalıdır.

İkinci olarak, birleşme dolayısıyla azınlıkta kalan pay sahiplerine ek ödeme yükümlülüğü, kişisel edim yükümlülüğü getirilmemiş olmalı ya da kişisel sorumluluğu doğmamalıdır.

Bu iki şart bir arada bulunmak şartıyla, birleşen şirketler kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemini benimseyebilirler.

VIII) BİRLEŞMENİN HÜKÜMLERİ

A) GENEL HÜKÜMLERİ

Türk Ticaret Kanununda birleşmenin kesinleşmesi, yani ticaret siciline tescilin sonuçları ile ilgili düzenlemelere yer verilmiş olmasına karşın; birleşmenin hükümleri bakımından bunlarla yetinmemek, birleşmenin tüm hükümlerini diğer düzenlemelerle birlikte değerlendirmek gerekir.

Bu kapsamda birleşmenin ilk sonucu, *devrolunan şirketlerin son bulmasıdır*. Devrolunan şirket birleşmenin ticaret siciline tescili ile infisah eder; bu infisah, tasfiyesiz infisahtır. Kendiliğinden sona erme sonucunda infisah eden şirketler tasfiye sürecine girmezler (TTK m. 152/3).

Ortaklığın devamlılığı ilkesi (TTK m. 136/3, m. 140, m. 153/2) uyarınca ise, kural olarak, devrolunan şirketin ortakları *ex lege* (kanundan dolayı) devralan şirketin ortağı olurlar (TTK m. 153/2). Ancak, kendi adına ve devralan ya da devrolunan şirketler hesabına hareket eden kişilerin elinde bulunan paylar için, bu sonuç kabul edilmez (TTK m. 153/2).

Birleşme sadece ortaklar bakımından değil, *malvarlığı bakımından da* hükümleri olan bir hukuki müessesedir. Birleşmenin tesciliyle birlikte, *devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifleri ex lege* devralan şirkete geçer (TTK m. 136/4, m. 153/1). Malvarlığının bir bütün olarak geçmesinin sonucu olarak, devralan şirket, devrolunanın mal ve haklarının sahibi olduğu gibi, borçlarından da sorumludur. Durumun devralan tarafından bilinip bilinmemesinin neticeye etkisi yoktur; intikal kanun gereği gerçekleştiğinden, münferit tasarruf işlemlerinin yapılması da gerekli değildir.

B) ALACAKLILAR, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI VE İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMLERİ

1) Alacaklılar Açısından Hükümleri

Birleşmede menfaatlerinin korunması gereken önemli bir grup da alacaklılardır. Türk Ticaret Kanununun birleşmeye ilişkin sistemi esas itibariyle *ortakların menfaatleri* esas alınmak suretiyle şekillenmiş olmakla birlikte; alacaklıların menfaatlerine hizmet eden özel düzenlemelere de yer verilmiştir.

6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununun alacaklılara birleşmeye itiraz imkânı tanıyan sistemi yerine, 6102 sayılı mer'i Türk Ticaret Kanununda *alacaklılara itiraz hakkı tanınmamış*; fakat alacaklarını teminat altına almaya yönelik bazı düzenlemelere yer verilmiştir.

Kanunda hükme bağlanan, alacaklıların menfaatine hizmet eden düzenlemelere değinmeden önce; *devralan şirketin külli halef olarak* alacaklılara karşı *sorumlu olduğunu* belirtmek gerekir. Birleşme, alacaklıların haklarını sona erdiren bir müessese değil; sadece borçlunun kanun gereği değiştiği bir hukuki müessesedir. Alacaklıların korunmasına yönelik düzenlemeler, bu hukuki sonuca ilâve bazı tedbirler içermektedir[571].

TTK m. 157/2 hükmüne göre, birleşmeye katılan şirketler, *alacaklılarına* hangi haklara sahip oldukları hususunda *yedişer* gün arayla Ticaret Sicili Gazetesinde *üç defa* yapacakları ilânla ve internet sitelerine koyacakları ilânla *bilgi verirler*. İlânların yapılacağı tarih hakkında açık bir düzenleme bulunmakla birlikte, birleşmenin kesinleşmesinden önce bunun yapılması gerekmektedir.

Birleşmenin kesinleşmesi tarihinden itibaren alacaklılar *üç ay içinde* istemde bulundukları takdirde, devralan şirket bu alacakları teminat altına almakla yükümlüdür (TTK m. 157/1). Teminat verme yükümlülüğü sadece devrolunan şirket alacaklıları için değil, aynı zamanda devralan şirket alacaklıları için de söz konusudur.

Teminat verme yükümlülüğü bulunan devralan şirket, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, *teminat vermek yerine bu borcu ödeyebilir* (TTK m. 157/4). Ödeme devralan şirketin takdirindedir. Ancak diğer alacaklıların zarara uğrama tehlikesi varsa; ödeme imkânı bulunmamaktadır. Kanun sisteminden anlaşıldığı üzere, kanun koyucu birleşmede, başvuran alacaklının menfaatlerini ön plânda tutan; durumdan fiilen haberdar olmayan ya da ilgisiz kalan alacaklıların menfaatlerini ikinci plana iten bir çözüme yer vermiştir.

2) Ortakların Sorumlulukları Açısından Hükümleri

Devrolunan şirketin borçlarından dolayı birleşmeden önce sorumlu olan ortakların durumu hakkında özel düzenlemelere yer verilmiş; devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların

---

[571] 6762 sayılı Kanuna nazaran, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanununda alacaklıların konumunun zayıflatıldığını düşünmekteyiz.

sorumluluklarının, birleşmeden sonra da devam edeceği kabul edilmiştir. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme kararının ilânından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır (TTK m. 158/1).

Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, birleşme kararının ilânı tarihinden itibaren *üç yıl* geçince *zamanaşımına* uğrar. Ancak, alacak ilân tarihinden sonra muaccel olursa; zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlayacaktır. Bu sınırlama, devralan şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz (TTK m. 158/2).

TTK m. 158/3 hükmüne göre, kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar devam eder; yeter ki izahnâme başka bir düzenleme içermesin[572].

3) İş İlişkileri Açısından Hükümleri

4857 sayılı İş Kanununda, *"İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer"* denilmişken; TTK m. 158/4 düzenlemesiyle, birleşmede "İş ilişkileri hakkında 178 inci madde hükmü uygulanır" şeklinde bir düzenlemeye ayrıca yer verilmiştir.

Devrolunan şirket çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, bu kişilerin hukuki durumlarıyla ilgili özel düzenlemelere yasada ayrıca yer verilmiştir. TTK m. 158/4 hükmü uyarınca birleşmede *iş ilişkileri hakkında*, bölünmede iş ilişkilerini düzenleyen TTK m. 178 hükmü uygulanacaktır.

TTK m. 158/4'ün atıf yaptığı TTK m. 178 uyarınca; işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, *işçi itiraz etmediği takdirde*, devir gününe kadar

---

572 Anılan madde gerekçesinde, İsviçre Birleşme Kanununun 26/3'üncü maddesinin hukukumuzda uygulama alanı olmadığı için; Türk Ticaret Kanununa alınmadığı belirtilmektedir. Ancak İsviçre Birleşme Kanunu'nun 26/3'üncü maddesi, Türk Ticaret Kanunu'na alınmadığı belirtilen TTK m. 158/3'e tekabül etmektedir. Kanun gerekçesi nazara alındığında, kamuya arz edilmiş tahvil ve diğer borç senetlerinden sorumluluğa ilişkin hüküm yasaya sehven alınmıştır ve uygulama kabiliyeti yoktur. Mehaz kanunun 26'ıncı maddesi üçüncü fıkrasından alınan hüküm, şirketin değil, ortakların borçlanma senetlerinden hukuki sorumluluğunu düzenlemektedir ve özellikle üç yıllık zamanaşımı süresinin, bu borçlar için uygulanmaması sonucuna hizmet etmektedir.

bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer. İşçiler muaccel olan ve itiraz etmemesi halinde muaccel olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler. Ancak *işçi itiraz ederse*, hizmet sözleşmesi, kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve işçi, o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür.

Devralan şirket, işçinin çalıştığı şirketin devralınmasından evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarından sorumludur.

Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşmesinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez.

Devrolunan şirketin birleşmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hizmet sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi normal olarak sona ermiş olsaydı muaccel hale gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler.

§ 24- BÖLÜNME

I) GENEL OLARAK

Ticaret şirketlerinin yapısal değişikliği usullerinden birleşme ve tür değişikliği müesseselerine ilişkin düzenlemeler, hukuk sistemlerinde evvelce mevzuatta yerini almışken; *bölünme*, gerek yabancı hukuk sistemlerinde gerek Türk Hukukunda, iktisadî, malî ve idarî ihtiyaçlar nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa dâhil edilmiştir[573].

---

[573] Bölünmenin Türkiye'de maddî hukuk yönünden ilk defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunuyla düzenlendiğini söylemek mümkünse de; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunundan önce, vergi hukuku ile ilgili kurallarda bazı düzenlemeler yapıldığı, Kurumlar Vergisi Kanununda 4684 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bölünmenin öngörüldüğü gözlemlenmektedir. Ancak Kurumlar Vergisi Kanunundaki bu düzenlemenin, bölünmenin maddî hukuk cephesini içermediği; bölünmenin maddî hukuk yönünden dogmatik düzeninin ülkemizde mevcut bulunmadığı da kabul ediliyordu.
4684 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer vergi mevzuatı dâhilindeki değişikliği müteakip, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ortaklaşa yayınladıkları "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmî Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" yürürlüğe girmiş; Kurumlar Vergisi Kanunundaki hükümlerine dayanılarak sadece kısmî bölünmenin maddî hukuk cephesi bu tebliğ ile düzenlenmeye çalışılmıştı.
Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ortaklaşa yayınladıkları "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmî Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ", tebliğ sınırları içinde kalan ve tebliğ hukukunun şartlarına özgülenen bu düzenlemeyle, uygulamada bölünmenin işlerliğini sağlamak amacını taşımaktaydı.
Ancak belirtmek gerekir ki, bölünmeyi ilk kez ele alan 4684 sayılı Kanunla vergi mevzuatında yapılan değişiklik, Maliye Bakanlığınca, Avrupa Birliğinin 1982 tarih ve 82/891 sayılı VI. Yönergesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun tasarısı incelenerek hazırlanmış olmasına ve bu Türk Ticaret Kanunun terimlerini kullanmasına rağmen, Türk Ticaret Kanununda öngörülen sistem, tebliğe tam olarak aktarılamamıştır.
4684 sayılı Kanunla vergi mevzuatında yapılan değişiklikle, öğretide iki basamaklı "demerger" diye anılan ve aynî sermaye konulmasına dayanan bir rejim kabul edilmiş; kısmî bölünme yolu ile ya bir yavru şirket kurulması ya da yavru şirketin paylarının, bölünen şirkette sermaye azaltılması yapılarak, payları itfa edilen ortaklara itfa bedeli olarak verilmesi yolu benimsenmişti. Oysa Türk Ticaret Kanununun bölünmeyle ilgili hükümleri, 82/891/AET Yönergesi ve İBirK ile bu Kanunun öntasarısı esas alınarak hazırlanmış; İsviçre BirK Alman Birleşme Kanunundan esinlendiği için de, Almanya'nın Birleşme Kanunundan da istifade

Bu hâliyle "*bölünme*", Türk Ticaret Kanununda "*Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme*" başlığı altında 159-179'uncu maddeleri arasında; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 17'inci maddesinde ve bu maddeye dayanılarak çıkartılan *Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte*[574] ve ayrıca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu bölünmeler için ise, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 23 üncü maddesi ile 130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan 28 Aralık 2012 tarihli Tebliğde hükme bağlanmıştır.

II) BÖLÜNME KAVRAMI

A) GENEL OLARAK

Bölünme, ***sermaye şirketlerinin*** ve ***kooperatiflerin*** malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden ayırarak, *tasfiyesiz olarak* ve *kısmî küllî halefiyet* yoluyla başka sermaye şirketlerine veya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan şirketlerde ortak konumunu *ipso iure* elde etmeleridir[575].

Bölünmede, bir şirket *(bölünen/devreden),* mal varlığının tamamını veya bir kısmını bir ya da daha fazla şirkete (*devralan)* devretmektedir. Devir tasfiyesiz olarak gerçekleşmekte; devralan açısından kısmî külli halefiyet sonucunu doğurmaktadır. Buna karşın devreden/bölünen şirket ortakları, kural olarak, devralan şirkette ortaklık hakkını kendiliğinden elde etmektedir[576]. Bölünme, mal varlığı devrinden farklıdır; mal varlığı devrinin, tüzel kişilik ve ortaklık düzeyinde etkileri bulunmamaktadır[577].

Birleşmeden farklı olarak bölünme, sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflerin yararlanabileceği bir müessesedir; sermaye şirketleri ve kooperatifler, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebilirler

---

edilmiş ve bu özel düzenlemelere uygun olarak, kısmî küllî halefiyete dayalı, aynî sermaye konulmasını ve sermaye azaltılmasını zorunlu kılmayan malvarlığı geçişi modeline göre şirketin ve ortak durumunun yeniden yapılandırılması yaklaşımını getirmiştir.

574 01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

575 Bkz. Gerekçe s. 123.

576 Bkz. Gerekçe s. 123.

577 Bkz. **Böckli**, SchweizerAktienrecht, § 3, Rn. 277a.

(TTK m. 160). Diğer şirketlerin bölünmesine, alacaklıların ancak tasfiye suretiyle korunabileceği gerekçesiyle, kanun koyucu tarafından izin verilmemiştir[578].

B) BÖLÜNMENİN TANIMI

Kanun koyucu, bölünmenin bir *tanımını yapmamış*, birleşmede olduğu gibi, *bölünme ilkelerini* hükme bağlamış (TTK m.159); "*bir şirket tam veya kısmî bölünebilir*" diyerek bölünmenin iki türünden ve bölünmenin diğer ilkelerinden bahsetmiştir (ayrıca bkz.Tebliğ m.2/1.ç).

Türk Ticaret Kanununda bir tanım olmamasına karşın, kanunun gerekçesi ve *"bölünmenin temel ilkeleri"* esas alınarak, **bölünmeyi**, *"sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin malvarlıklarını tamamen veya kısmen kendilerinden ayırarak, tasfiyesiz olarak ve kısmî küllî halefiyet yoluyla, başka sermaye şirketlerine veya kooperatiflere devretmeleri ve bunun karşılığında bölünen şirketin ortaklarının devralan şirketlerde ortak konumunu kanun gereği (ipso iure) elde etmeleridir"* şeklinde tanımlamak mümkündür[579].

III) BÖLÜNMENİN AMACI

Bölünmenin ana amacı; işletmelerin uygun değer (optimum) büyüklüğü bulma, ekonomik gelişimi sağlamak; yönetimde ortaya çıkan ihtilâfları gidermektir.

Bu bağlamda bölünme ile bilhassa, büyük ölçeli sermaye şirketleri ile kooperatiflerin, belirli bir ölçeğin üzerine çıkmaları sebebiyle ***azalan verimliliğinin önüne geçmek*** istenmektedir. Bölünmenin amacı, Kanununun gerekçesinde, "*bölünme, çok büyüyen ve çekirdek işletme konusundan uzaklaşan **şirketlerin ana konularına dönebilmelerine olanak sağlayan** bir yoldur*" şeklinde ifade edilmiş; ayrıca, *"Bölünme; aile ortaklıklarında, mirasın paylaşımında, iki veya üç gruplu şirketlerde **yönetim sorunlarını** (ihtilâflarını) çözmek amacıyla da kullanıla-*

---

578 Bkz. Gerekçe s. 125.

579 Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte "*Bölünme*": Bir bankanın tüzel kişiliği sona ermek kaydıyla tüm malvarlığının bölümlere ayrılmak suretiyle birden fazla banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki tam bölünmeyi veya bir bankanın malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün bankanın infisah etmesine neden olmayacak şekilde banka, finansal kuruluş veya diğer anonim şirketlere devredilmesi şeklindeki kısmi bölünmeyi ifade eder şeklinde tanımlanmıştır (m.4/1.c).

bilir. Nihayet bölünme, ***holding sistemine geçişte*** *de bir araç olarak kullanılabilir*" ifadelerine yer verilmiştir.

IV) BÖLÜNMENİN UNSURLARI

Bölünmenin yukarıda verilen tanımından ve birleşmeye hâkim olan ilkelerden yola çıkarak, bölünmenin unsurlarını tespit etmek mümkündür. Buna göre:

A) BÖLÜNMEDEN EVVEL BÖLÜNECEK BİR SERMAYE ŞİRKETİNİN VEYA KOOPERATİFİN MEVCUDİYETİ

Bölünmeye hâkim olan ilkelerin hükme bağlandığı TTK m. 159'da, bir şirketin, tam veya kısmi bölünme yoluyla bölünebileceği kabul edilmiştir. Ancak bu bölünme imkânının, *her ticaret şirketinin serbestçe bölünebileceği şeklinde değerlendirilmemesi* gerekir. Zira TTK m. 160'da, ***"geçerli bölünmeler"*** başlığı altında, hangi şirketlerin bölünebileceği hükme bağlanarak; bölünmenin tâbi olacağı esaslar belirlenmiştir.

1) Geçerli Bölünmeler

Türk Ticaret Kanununun 160'ıncı maddesinde, bölünmenin ancak *sermaye şirketleri* ile *kooperatiflerde* söz konusu olabileceği; *"Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünebileceği"* kabul edilmiştir.

Bu düzenlemeden de anlaşılacağı üzere, İBirK'nun 30'uncu maddesi esas alınarak hazırlanan TTK m.160'da, *bölünebilen şirketler sınırlayıcı bir tarzda belirlenmiş*; sadece *sermaye şirketleri* (TTK m.124/2) ile 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan *kooperatiflerin* bölünebileceği esası benimsenmiştir.

Ancak hükmün, her sermaye şirketinin veya kooperatifin kendi genel türü içinde bölüneceği şeklinde yorumlanmaması; bir anonim şirketin, bir limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yahut bir kooperatif şeklinde bölünebileceğinin kabulü gerekir. Bunun gibi, bir kooperatif şirketin de bir anonim şirket ve/veya limited şirket şeklinde bölünmesine de engel yoktur. Buna karşılık bir sermaye şirketi veya kooperatif; şahıs şirketleri şeklinde bölünemez ve tersi de mümkün değildir; anılan -*caiz olmayan*- bölünme türlerinde alacaklıların korunması ancak tasfiye hükümlerinin uygulanmasıyla mümkündür.

Bununla birlikte, bölünmesine izin verilen şirketler dışındaki şirketler açısından bölünme yasağı, tür değiştirme yoluyla aşılabilir[580].

b) Bölünmede Özel Hâller

Türk Ticaret Kanununun bölünmeye ilişkin hükümleri arasında, *tasfiye hâlinde* veya *borca batık durumda olan* şirket yahut kooperatifin bölünüp bölünemeyeceği hususunda bir düzenleme yoktur.

Bu durumda, tasfiyenin hukuki mahiyeti nazara alınarak; *tasfiyeden dönülmedikçe* (TTK m. 548; 565; 643; KoopK m.98), tasfiye hâlindeki bir şirketin bölünmesinden bahsedilmemesi gerekir.

Borca batıklık (TTK m. 376; 565; 643) hâlinde, *"genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden"* sona ereceğinden, tasfiye hâline gireceğinden ve tasfiyeden dönülemeyeceğinden (TTK m. 548), bu şirketlerin veya kooperatiflerin bölünmesinden de söz edilemez.

Ancak bilindiği üzere, TTK m. 376/3 gereğince, bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirmek ve *şirketin iflasını istemek* zorundadır. Şirketin iflasının istendiği hâllerde, TTK m. 376/3'de hükme bağlanan, mahkeme tarafından iflâs kararı verilmeden önce bazı şartların gerçekleştirilmesi üzerine; mahkeme iflâs kararı vermez. Bu durumda, iflâs isteminde bulunulmuş olmasına karşın, mahkeme iflâsa hükmetmemişse; borca batık olan şirketlerin bölünebileceği kabul edilmelidir.

KoopK m. 63'de ise, *"kooperatifin aczi hâlinde yapılacak işler"* başlığı altında, *"Malî durumun düzeltilmesinin mümkün görülmesi hâlinde yönetim kurulu veya alacaklılardan biri konkordato da talep edebilir. Bu takdirde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 285 inci ve devamı maddeleri uygulanır"* (KoopK m. 63/3) denilmiştir. Bu bağlamda, Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından tasdik edilen konkordato projesinde yer almıyorsa; konkordato talebi kabul edilen kooperatifin bölünememesi gerekir.

---

580 Gerekçe, s.125.

B) MALVARLIĞININ BÖLÜNMESİ

Bölünmede, sermaye şirketinin veya kooperatifin malvarlığının bölünmesi gerekir. Ancak, malvarlığının bölünmesi, bölünmenin türüne göre farlılık gösterir.

Tam bölünmede, sermaye şirketinin/kooperatifin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer sermaye şirketlerine veya kooperatiflere devrolunur, bölünen sermaye şirketi veya kooperatif sona ererek unvanı ticaret sicilinden silinirken; *kısmi bölünmede*, bir sermaye şirketinin/kooperatifin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer sermaye şirketlerine/kooperatiflere devrolunur; bölünen sermaye şirketi/kooperatif sona ermez.

C) BÖLÜNEN SERMAYE ŞİRKETİNİN/ KOOPERATİFİN ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATININ MALVARLIĞINI DEVRALAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE VEYA KOOPERATİFLERDE DEVAMI

Türk Ticaret Kanununa uyarınca bir bölünmeden söz edilebilmesi için, bölünen şirketin veya kooperatifin ortaklarının ortaklık sıfatının malvarlığını devralan şirketlerde veya kooperatiflerde devam etmesi gerekmektedir (TTK m. 159/1.b). Buna göre hem tam hem kısmi bölünmede esas olan, "*bölünen sermaye şirketinin/kooperatifin ortaklarının, devralan sermaye şirketlerinin/kooperatiflerin paylarını ve haklarını iktisap*" etmesidir.

Buna göre, ister tam ve isterse kısmi bölünme söz konusu olsun, ortaklık sıfatının devamı esastır; sermaye şirketi veya kooperatif paylarının ve haklarının birleşmede olduğu gibi (TTK m.140) korunması gerekir.

Kısmi bölünmede yavru şirket kurulması hâli hariç[581], ortaklık sıfatının devamlılığını sağlamak maksadıyla, bölünen sermaye şirketinin veya kooperatifin ortaklarına, mevcut ortaklık paylarını ve haklarını karşılayacak değerde, devralan sermaye şirketinin veya kooperatifin payları ve hakları üzerinde istemde bulunma hakkı verilmiştir. Bu istem hakkının, bölünmeye katılan şirketlerin veya kooperatiflerin malvarlıklarının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanması gerekir. Bununla birlikte, birleşmede olduğu gibi, ortaklık paylarının değişim oranları belirlenirken, devrolu-

---

[581] Yavru şirket hakkında bkz. Onaltıncı Bölüm, § 27, I.

nan şirketin veya kooperatifin ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin *onda birini* aşmaması şartıyla, bir *denkleştirme ödenmesi* öngörülebilir (TTK m.140/2); bu hâlde denkleştirme oranında ortaklık sıfatı sona erecektir[582].

D) TASFİYENİN ÖNLENMESİ

Tam bölünmede, bölünme sonucunda, devredilen sermaye şirketi veya kooperatif sona erer ve sicilden silinir (TTK m.159/1.a). Buradaki sona erme bir infisahtır. *İnfisah*, kanunda ve/veya esas sözleşmede öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi ile karar alınmasına veya ihbarda bulunulmasına ihtiyaç olmadan sermaye şirketinin veya kooperatifin kendiliğinden sona ermesidir (dağılma); infisah, sebebin gerçekleşmesiyle birlikte ileriye doğru (ex nunc) sonuç doğurur.

Ancak burada olağan dağılma nedenlerinden farklı olarak; bu dağılmayı (infisahı) bir tasfiye süreci takip etmez. Sermaye şirketlerinin veya kooperatiflerin bölünmesi hâlinde, *tasfiyesiz infisah* (dağılma) söz konusu olur.

Kısmî bölünmede ise, bölünme sonucunda malvarlığının bir kısmını devreden sermaye şirketinin veya kooperatifin sona ermesi bahis konusu değildir (TTK m.159/1.b); bölünme sonucunda malvarlığının bir kısmını devreden sermaye şirketi veya kooperatif faaliyetlerine devam eder. Bölünen sermaye şirketinin veya kooperatifin tüzel kişiliği sona ermeyeceğinden, bir tasfiyeden de bahsedilemez.

E) HALEFİYET

Bölünmede, sadece bölünme sonucunda malvarlığının bir kısmı devralan şirkete/kooperatife devredilmiş olmaz; bölünen şirketin/kooperatifin veya ortaklarının, devralan şirkette/kooperatifte ortaklık sıfatlarının devamı yanında, şirketin/kooperatifin *bölünen kısmı ile ilgili* bütün aktif ve pasifler de halefiyet yoluyla, bölünme sözleşmesi veya

---

582 Kanun koyucu, ortaklık sıfatının devamlılığına istisna getiren *denkleştirme ödemesinin* bölünmeye de uygulanabileceğini hükme bağlamasına (TTK m.161/1) karşın, birleşmede düzenlenen "***ayrılma akçesi***" ile ilgili bir yollamaya yer vermemiş; maddenin gerekçesinde ise, "*mutabakat varsa bölünen şirketten ayrılabilirler, ancak ihraç edilemezler*" denilmiştir. Kanunda atıf yapılmayan böyle bir sonuca, kanunun gerekçesiyle ulaşmak mümkün olmamakla beraber; sözleşme serbestîsinden hareketle seçimlik ayrılma akçesinin öngörülebileceği sonucu çıkartılabilir.

bölünme plânındaki esaslar doğrultusunda (ve esas itibariyle malvarlığının devri oranında), bir bütün hâlinde, bölünmenin tescili ile birlikte devralan sermaye şirketine veya kooperatife intikal eder.

Halefiyet, hem tam hem de kısmî bölünmede söz konusudur (TTK m.159). Ancak bu halefiyet, birleşmedeki gibi bir ***küllî halefiyet değildir***; sermaye şirketinin veya kooperatifin *bölünen kısmı ile ilgili* bütün aktif ve pasifler *halefiyet yoluyla*, bölünme sözleşmesi veya bölünme plânındaki esaslar doğrultusunda ve esas itibariyle *malvarlığının devri oranında,* bir bütün hâlinde, bölünmenin tescili ile birlikte devralan şirkete veya kooperatife intikal eder.

Bu husus **tam bölünmede**, "şirketin (kooperatifin) tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere (kooperatiflere) devrolunur" şeklinde ifade edilmiş (TTK m.159/1.a); düzenlemenin devamında ise, "bölünen şirketin (kooperatifin) ortakları, devralan şirketlerin (kooperatiflerin) paylarını ve haklarını iktisap ederler" denilerek, ortakların sahip olduğu haklar hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, bahsi geçen hükümde, devralan şirketlerin (kooperatiflerin), bölünen şirketin (kooperatifin) malvarlığını devralacakları ifade edilmiştir. Buradaki malvarlığı kavramından; bölünen sermaye şirketinin veya kooperatifin aktif ve pasifleri, alacak ve borçları ve hatta iş ilişkilerinin anlaşılması, müessesenin mahiyetine daha uygun olur. Bu sonuca, TTK'nin 167/1.b'deki ve 178'inci maddelerindeki düzenlemelerinden de ulaşmak mümkündür. Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânının içeriğini hükme bağlayan bu bentte, "aktif ve pasif malvarlığı" konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasından ve tahsisinden bahsedilirken; 178'inci maddede, iş ilişkilerinin geçmesiyle ilgili olarak "devir gününe kadar hizmet sözleşmesinden doğan hak ve borçlar devralana geçer" denilmiştir. Buna göre, bölünmenin tescili ile birlikte (TTK m.179), bölünme sözleşmesi veya bölünme plânı gereğince, haklara ve borçlara halefiyet söz konusu olacaktır.

Kısmî bölünmede de aynı kural geçerli olmakla birlikte, kısmî bölünmede bölünen yani malvarlığının bir kısmını devreden sermaye şirketinin veya kooperatifin sona ermediği; bu hâlde ise, bir kısım aktif ve pasif malvarlığı ile hukuki ilişkilerin bölünen sermaye şirketinde veya kooperatifte, bölünme sözleşmesi veya bölünme plânı gereğince kalacağı unutulmamalıdır.

Ancak özellikle tekrar edelim ki, bölünmedeki halefiyet, birleşmedeki gibi *küllî halefiyet değildir*; buradaki halefiyet, bölünme sözleşme-

si veya bölünme plânı gereğince söz konusu olan ***kısmî külli halefiyettir.***

Bölünmedeki halefiyetin bu özelliği sebebiyle Kanun Koyucu, alacaklıların haklarını korumak amacıyla, kendisine borç tahsis edilen şirket (kooperatif), alacaklıların alacağını ifa etmezse; bölünmeye katılan diğer şirketlerin (kooperatiflerin) de, ikinci dereceden müteselsil sorumlu olacağını hükme bağlamıştır (TTK m. 176).

F) BİRDEN FAZLA SERMAYE ŞİRKETİ VEYA KOOPERATİF HÂLİNE GELMEK

İster tam ister kısmî bölünme söz konusu olsun, bölünmenin ayırıcı özelliği, bölünme sonucunda birden fazla sermaye şirketinin veya kooperatifin oluşması mecburiyetidir. Bir diğer ifadeyle, tam bölünme hâlinde, tasfiye edilmeden sona eren sermaye şirketi veya kooperatifin yerine; en az iki *sermaye şirketi* veya *kooperatifin* oluşması; kısmî bölünmede ise, bölünen sermaye şirketi veya kooperatif faaliyetlerine devam ederken, bünyesinden en az bir sermaye şirketi veya kooperatifin çıkması gerekir. Aksi takdirde bölünmeden değil, belki de TBK m.202'de düzenlenen malvarlığının devrinden söz edilir.

V) BÖLÜNMENİN TÜRLERİ

TTK m. 159'da, kısmi ve tam bölünme ile ilgili olarak sadece *şirketlerden* söz edilmesine karşın; *kooperatiflerin* de, TTK m. 159 gereğince, şirketler gibi, *tam* veya *kısmî olarak bölünebileceği kabul* edilmelidir.

Buna göre, Türk Ticaret Kanunu sisteminde bölünmenin iki ana türü bulunmaktadır. Bunlar *tam bölünme* ve *kısmi bölünmedir* (TTK m. 159).

Tam bölünmede *(Aufspaltung-Yarılma)*, sermaye şirketinin veya kooperatifin tüm malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur (TTK m. 159/1,a). Bunun için *devralan konumunda* bulunan *en az iki sermaye şirketine* veya *kooperatife* ihtiyaç vardır. Bu sermaye şirketleri veya kooperatifler, mevcut sermaye şirketleri veya kooperatifler olabileceği gibi yeni kurulacak sermaye şirketleri veya kooperatifler de olabilir[583]. Süreç sonunda bölünerek, malvarlığı diğer sermaye

---

583 Bkz. BB1. 2000 4430, Gerekçe s. 124.

şirketlerine veya kooperatiflere devredilen sermaye şirketi veya kooperatif sona erer ve ticaret sicilinden silinir. Ortakları ise devralan sermaye şirketlerinin veya kooperatiflerin paylarını ve haklarını iktisap ederler (TTK m. 159/1,a)[584].

Kısmi bölünmede *(Abspaltung-Ayırma)* ise, bölünen şirketin veya kooperatifin mal varlığının tamamı değil; sadece bir kısmı başkaca şirket ya da şirketlere yahut kooperatife devrolunur. Tam bölünmeden farklı olarak, bölünerek malvarlığının bir kısmı devredilen şirket veya kooperatif, süreç sonunda sona ermez; hukuki varlığını sürdürür. Yine tam bölünmeden farklı olarak, devralan en az iki sermaye şirketinin veya kooperatifin bulunması zorunlu değildir[585]. Bölünen sermaye şirketinin veya kooperatifin malvarlığının bir kısmını devralan sermaye şirketi yahut kooperatif, mevcut bir sermaye şirketi yahut kooperatif olabileceği gibi; yeni kurulacak bir sermaye şirketi yahut kooperatif de olabilir[586].

Bölünen sermaye şirketinin/kooperatifin malvarlığının bir kısmını devralan sermaye şirketi veya kooperatif; sermaye şirketini veya kooperatifi değil, onun mal varlığının bir kısmını devraldığından, devralan açısından bir *birleşme hali söz konusu değildir.*

Kısmi bölünme iki şekilde gerçekleşir. Bunlardan birincisinde, tam bölünmede olduğu gibi, bölünen şirketin/kooperatifin ortakları, devralan şirketlerin/kooperatiflerin paylarını ve haklarını iktisap eder

---

584 Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinde "Tam bölünme: Bölünen şirketin malvarlığının tümünün mevcut veya yeni kurulacak en az iki şirkete geçmesini, bölünen şirketin sona ermesini ve ortaklarının devralan şirketlerin ortağı olmasını ifade eder" şeklinde tanımlanmıştır (Tebliğ m 4/1.ö).

585 TTK m.159/1,b hükmünde her ne kadar "şirketlere" ibaresi kullanılarak devralan en az iki şirketin/kooperatifin bulunması gerektiği kanaati uyandırılsa da, kısmi bölünmede devralan tek şirketin bulunması da yeterlidir. Aynı yönde bkz. Gerekçe s. 124.

586 Sermaye Piyasası Kurulunun Tebliğinde "Kısmî Bölünme: İştirak veya ortaklara pay devri şeklinde bölünmeyi ifade eder" (Tebliğ m. 4/1.k) denildikten sonra, "İştirak modeliyle kısmi bölünme": Bölünen şirketin, bölünmeye konu malvarlığının başka bir şirkete ayni sermaye olarak konulduğu ve devrin karşılığında bölünen şirketin devralan şirket sermayesinde pay sahibi olduğu kısmi bölünme" (Tebliğ m.4/1.ı); *"Ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme" ise bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümünün mevcut veya yeni kurulacak başka bir şirkete veya şirketlere devredildiği, bölünen şirket sona ermeksizin ortaklarının devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirket veya şirketlerin ortağı olduğu kısmi bölünme"* şeklinde tanımlanmıştır (Tebliğ m.4/1.n).

(ortaklara pay devri modeliyle kısmî bölünme). İkinci olarak ise bölünen şirketin, bölünmeye konu malvarlığı başka bir şirkete ayni sermaye olarak konulduğundan, bölünen şirketin malvarlığının bir kısmını devralan şirketin paylarını, devredilen şirket ortakları yerine; bölünme suretiyle malvarlığının bir kısmını devreden şirket tüzel kişiliği iktisap eder (Yavru Şirket Kurma/İştirak Modeliyle Kısmî Bölünme)[587]. Ancak bu ikinci halde devralan şirketin, devredenin yavru şirketi olması şarttır (TTK m. 159/1.b). Bölünme sonucunda yavru şirket ilişkisi kurulamıyorsa, bölünen şirkete değil; bölünen şirket ortaklarına pay verilmesi zorunludur. Kısmi bölünmenin bu ikinci türü olan yavru şirket kurulması, ortaklığın devamlılığı ilkesinin, yani devredilen şirket ortaklarının, devralan şirkette de ortaklığının devam etmesi kuralının önemli bir istisnasıdır[588].

İster tam bölünme ister kısmi bölünme şeklinde gerçekleşsin, bölünmenin devrolunan şirket veya kooperatif ortaklarına sunduğu haklar dikkate alındığında, ***oranın korunduğu*** *(symmetrisch)* ve ***korunmadığı*** *(asymmetrisch)* bölünme olarak ***iki türü daha*** bulunmaktadır.

Oranların korunduğu bölünmede, devredilen şirket ortaklarının devralan şirketteki paylarının dağılımı, devredilen şirketteki pay dağılımına göre belirlenir. Yani devredilen şirkette hangi oranda paya sahiplerse, devralan şirkette de aynı pay durumu korunur.

Oranın korunmadığı bölünmede ise, devredilen şirket ortaklarının bu şirkette sahip oldukları pay oranı dikkate alınmaksızın; devralan şirkette pay sahibi olması söz konusudur. Oranın korunmadığı bölünme, sermaye şirketlerinde yönetim zafiyetlerini gidermek maksadıyla kullanılan etkin bir yoldur.

---

587 Yukarıda da ifade edildiği üzere, Kooperatiflerde, "*Genel Kurulda her ortak yalnız bir oya sahiptir*" (KoopK m. 48/1) hükmü karşısında; şirketlerin/kooperatiflerin, kooperatif şeklinde *yavru şirket oluşturamayacağı* ve bu nedenle kısmi bölünmenin bahsedilen ikinci şeklinin kooperatiflerin yapısına uygun olmadığı düşünülmektedir.

588 Yavru şirket kurma şeklinde birleşme mehaz İsviçre Birleşme Kanununda düzenlenmemektedir. Madde gerekçesinde yavru şirket kurma şeklinde gerçekleşen ikinci tür kısmî bölünmenin, ilkinden farklı olarak aynî sermaye koyma şeklinde gerçekleştiği, yani devredenin, devralana aynî sermaye koyduğu ve küllî halefiyet ilkesinin bu tür birleşmede geçerli olmadığı vurgulanmaktadır.

Oranın korunduğu ve korunmadığı bölünmeler esas itibariyle aynı kurallara tâbidir. Fakat oranın korunmadığı bölünmede ortakların çıkarları daha büyük bir tehlike altında olduğundan; bölünme sözleşmesinin genel kurulda onaylanması bakımından daha farklı nisaplara yer verilmiştir (Bkz. TTK m. 173).

VI) BÖLÜNME İŞLEMLERİ

Bölünme de, birleşme gibi; *bölünme sözleşmesi* ya da *plânının* yapılması, *genel kurulun bu sözleşme ya da plânı onayı* ve *ticaret siciline tescil* süreçlerinin sonunda gerçekleşen bir işlemdir.

Türk Ticaret Kanununun bölünmeyle ilgili hükümlerine göre, sermaye şirketlerinin veya kooperatiflerin bölünebilmesi için bölünmeye katılanlar arasında bir *bölünme sözleşmesinin* veya *bölünme plânının* yapılması (TTK m.166), daha sonra ise, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organlarının, ayrı ayrı veya birlikte, bölünme hakkında bir *rapor hazırlaması* (TTK m.169/1), bölünmeye katılan şirketlerden her birinin, bölünme sözleşmesini, bölünme raporunu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını, varsa ara bilançolarını, bölünmeye katılan şirketlerin ortaklarının *incelemesine sunması*, yönetim organının *karar organına bölünme sözleşmesini sunması* (TTK m.173/1), karar organının *bölünme kararı alması* (TTK m.173/1), bölünme kararı alınır alınmaz, yönetim organlarının, *bölünmenin tescili için ticaret siciline başvurması* gerekir (TTK m.179).

A) BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Belirtmek gerekir ki, kanun koyucu tarafından öngörülmemesine karşın, bölünme de, *birleşmede olduğu gibi*, hemen gerçekleşmez; bölünme bir *müzakere* ile başlar.

Bu müzakereler, ileride gerçekleştirilecek bölünme sözleşmesinin esasını teşkil edecek; sözleşmenin esaslı unsurlarını belirleyecektir. Bu aşamada sözleşmenin oluşması için birtakım teklifler yapılacak (icap), bunların bir kısmı kabul edilecek veya karşı teklifler yapılacak; sözleşmenin esaslı noktalarında mutabakat temin edilmesinden sonra sözleşme yapılacaktır.

Bu konuda *daha evvel birleşmeyle ilgili olarak bilgi verildiği için,* birleşmeyle alâkalı olarak yaptığımız açıklamaların, bölünme sözleşmesinin hazırlanmasında da geçerli olacağını söylemek yeterli olacaktır.

Bu kısımda özellik taşıyan husus, bölünme plânıdır. Bir şirket, bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini yeni kurulacak şirketlere devredecekse, henüz kurulmuş bir şirket olmadığından; yönetim organı, yönetim sözleşmesi yerine, bir *bölünme planı* düzenler (TTK m. 166/2). Bölünme plânının da, mahiyeti gereği, bölünme sözleşmesinin içeriğini taşıması ve yazılı yapılması gerekir. Ancak burada henüz sözleşme yapılacak bir karşı taraf bulunmadığı için bu bölünme plânını; bölünen şirket yönetim kurulu hazırlayacaktır. Bölünen şirket yönetim kurulu tarafından hazırlanan bölünme plânı; bölünme iradesini açıklayan, tek taraflı bir hukukî işlem (*einseitige Rechtsgeschäft*) şeklinde olduğundan, buna da *tek yanlı bölünme beyanı* (*einseitige Aufspaltungserklärung*) denilebilir.

Ancak belirtmek gerekir ki, bölünmede, bölünme plânı da bölünme sözleşmesi de aynı hükümde (TTK m.166) ve farklılaştırılmadan düzenlenmiş; içeriği de, farlılaştırılmadan aynı hükme (TTK m.167) tâbi tutulmuştur. Bu hâlde, bölünme sözleşmesinin, sözleşme hükümlerine; bölünme plânının da tek taraflı hukukî işleme göre değerlendirilmesi, sözleşme görüşmelerinin de aynı esaslar dâhilinde yorumlanması gerekir.

Bir sermaye şirketi veya kooperatif bölünme yoluyla, mal varlığının bir kısmını mevcut bir ya da birkaç sermaye şirketine yahut kooperatife devredecekse, ***bölünme sözleşmesi*** *yapılması* zorunluluğu bulunmaktadır (TTK m. 166/1). Başka bir ifadeyle, mal varlığının bölünme suretiyle mevcut sermaye şirketlerine veya kooperatife devredilmesi, bu şirketler yahut kooperatifler arasında yapılacak sözleşmeyi; *çok taraflı bir hukuki işlemi*, gerekli kılmaktadır[589].

Bahse konu *bölünme sözleşmesini*, bölünmeye katılan şirketlerin veya kooperatiflerin yönetim organları akdedecektir. Birleşmede olduğu gibi, yönetim organının bu yetkisini devredemeyeceği kabul edilmelidir[590].

Bir *şirket veya kooperatif, bölünme sonucunda mal varlığını yeni kurulacak bir şirkete yahut kooperatife devredecekse*; henüz hukuki

---

589 Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelikte, Bankaların birleşme, devir, bölünme ve hisse değişimi işlemleri Kurulun iznine tâbi tutulmuştur (Bkz. Yönetmelik m.5).

590 İsviçre hukukundaki durum için bkz. BB1. 2000 4437; **Schenker, U;** in Fusionsgesetz, Hrsg., Baker& McKenzie, Art. 36, Rn. 6.

varlığı bulunmayan ve ancak bölünme neticesinde tüzel kişilik kazanacak bir şirket yahut kooperatif söz konusu olduğundan, bölünme sözleşmesi yapılması mümkün değildir. Bu durumda *bölünme sözleşmenin yerini, bölünme plânı alacaktır.* ***Bölünme plânı***, bölünen şirket veya kooperatif yönetim organı tarafından hazırlanan, *bölünme sözleşmesinin içerdiği kayıtlara benzer* içeriği havi *tek taraflı bir hukuki işlemdir.*

Eğer bir şirket veya kooperatif bölünme sonucunda hem mevcut hem de yeni kurulacak şirkete yahut kooperatife devredilecekse, sözleşmenin ayrı ayrı hazırlanması gerektiğini kabul etmek gerekmektedir[591].

Bölünme sözleşmesinin tarafları da, bölünen şirket/kooperatif ile bölünme sonucu malvarlığının bir kısmını devralacak şirket/kooperatif veya şirketlerdir/kooperatiflerdir.

Bir *şirket veya kooperatif, bölünme sonucunda mal varlığını* ***yeni kurulacak*** *bir sermaye şirketine yahut kooperatife devredecekse*; bu durumda henüz hukuki varlığı bulunmayan ve ancak bölünme neticesinde tüzel kişilik kazanacak bir şirket yahut kooperatif söz konusu olduğundan, bölünme sözleşmesi yerine, ***bölünme plânı*** yapılacaktır.

Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin bölünmesi için yapılması gereken *bölünme sözleşmesi/bölünme plânı*, ***yazılı geçerlilik şartına*** tâbidir. Kanun koyucu sözleşmenin/plânın yazılı şekle tâbi olduğunu belirtmekten başka; yazılı sözleşmenin/plânın kapsamına ilişkin koşul da getirmiştir (Bkz. TTK m.167; Tebliğ Ek-5). Bu hâliyle yazılı şekil, *nitelikli yazılı şekil* (qualifizierte Schriftlichkeit) olarak nitelendirilebilir. Bu sebeple, sözleşmenin/plânın yazılı şekilde yapılması yeterli olmayıp; bölünme sözleşmesinin/plânın, TTK m.167'de belirtilen unsurları da ihtiva etmesi gerekir.

Bu sözleşme/plân, bölünmeye ilişkin temel esasları belirler; bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organı tarafından imzalanır (TTK m. 145/1; Tebliğ m.15/1).

---

[591] TTK m. 169/1'de, "*Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında ayrı rapor hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir*" denilmesine karşın; bölünme sözleşmesinin yapılmasında "ortak sözleşme" yapılabileceğine ilişkin bir hükme tesadüf edilememiştir. *Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmeliğindeki, "Bankanın bölümlere ayrılmış malvarlığını devralacak her bir banka finansal kuruluş veya diğer anonim şirketler ile ayrı ayrı bölünme sözleşmesi imzalanır*" (m.16/1) bu yöndedir.

Bölünme sözleşmesinin/plânının içereceği kayıtlar hakkında TTK m. 167'de gösterilen içeriğe uygun hareket edilmelidir (ayrıca bkz. Tebliğ Ek-5 ve Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik m.16).

Kanun koyucu, bölünme sözleşmesinin asgari içeriğini belirlerken, "*özellikle*" ifadesini kullandığı için, bölünmenin mahiyetine uygun diğer kayıtlar da, bölünme sözleşmesinde yer alabilir.

Bölünmede, bilhassa devredilecek aktif ve pasif malvarlığının net bir şekilde bilinmesi gerekir. Bunun içindir ki kanun koyucu, "*aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve tahsisini; açık tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli evrakı ve maddi olmayan malvarlığını teker teker gösteren* ***listenin***" bölünme sözleşmesinde yer almasının gerekliliğine işaret etmiştir (TTK m.167/1.b).

Bölünme sözleşmesinin/plânının ayrıca, *payların değişim oranını* ve gereğinde ödenecek *denkleştirme tutarını* ve devreden şirketin/kooperatifin ortaklarının, devralan şirketteki/kooperatifteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamaları; devralan şirketin, intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine tahsis ettiği hakları ve şirket/kooperatif paylarının değişim tarzlarını da içermesi gerekir (TTK. m.167/1. c,d,e).

Bölünmede *"şirket (kooperatif) paylarının ve haklarının korunmasının"* düzenlendiği TTK'nun 161'inci maddesinde, tam veya kısmi bölünmede ortaklık payları ve haklarının korunması bakımından, birleşmeye ilişkin 140'ıncı maddeye atıf yapılmıştır. Anılan madde özetle, hakların dağılımı bakımından devamlılık esasını düzenlemektedir. Birleşme konusunda hakların dağılımı başlığı altında gerekli açıklamalar yapıldığından, bu açıklamalara atıf yapmakla yetiniyoruz (ayrıca bkz. Tebliğ m.18).

B) BÖLÜNME RAPORU

Bölünme raporu hazırlanabilmesi için; her şeyden önce bölünme sözleşmesi veya plânı yapılması zorunludur. Bölünme sözleşmesi/plânı, bölünme sürecinin başlaması için gerekli bir işlem olmakla birlikte, tek başına bölünmenin gerçekleşmesi sonucunu doğurmaz; bölünmeye katılan şirketlerin/kooperatiflerin *yönetim organlarının, ayrı ayrı* veya *birlikte*, bölünme hakkında bir *rapor hazırlaması* da gerekir

(TTK m.169/1; Tebliğ m.15). Hazırlanan raporun/raporların, birleşmeye ilişkin genel kurul karar tarihinden *iki ay önce ortakların bilgisine* sunulması da şarttır (TTK m. 171/1).

Bölünme raporunun/raporlarının içeriği nazara alındığında, rapora/raporlara esas olacak bazı bilgi ve belgelerin raporun/raporların hazırlanmasında önemli olduğu ve bu bilgi ve belgelerin bulunmaması hâlinde raporun/raporların hazırlanamayacağı anlaşılmaktadır[592].

Bu esastan olmak üzere, bölünme sözleşmesinde/plânında, *aktif ve pasif malvarlığının* devir amacıyla *bölümlere ayrılması ve tahsisi*; açık tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli evrakı ve maddi olmayan malvarlığını teker teker gösterilmesi, bunların *liste hâline getirilmesi*, *şirket/kooperatif paylarının değişim oranının gösterilmesi*, öngörülmüşse denkleştirme tutarının belirlenmesi; devrolunan şirketin/kooperatifin ortaklarının, devralan şirketteki/kooperatifteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamalara yer verilmesi gerekir (TTK m.167/1.b).

Kanun koyucu Türk Ticaret Kanununun 162 ilâ 165'inci maddeleri arasında, *bölünmenin uygulanmasına ilişkin hükümleri* düzenlemiş; bu düzenlemelerde, bölünme sebebiyle *devreden şirketin sermayesinin azaltılmasının* söz konusu olabileceğini, buna karşılık devralan şirketin sermayesini, devreden şirketin ortaklarının haklarını koruyacak miktarda *artırmak zorunda bulunduğunu* hükme bağlanmıştır. Bu esastan olmak üzere, bölünme çerçevesinde yeni bir şirketin kurulması hâlinde uygulanacak esaslar ile bilanço günüyle, bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihi arasında, altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun çıkarılmasından itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmiş olduğu takdirde, bir *ara bilanço çıkartılması* da hükme bağlanmıştır.

Bölünme sözleşmesi ve bölünme plânının, aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve tahsisini; açık tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli evrakı ve maddi olmayan malvarlığını teker teker gösteren listeyi ihtiva etmesi gerektiğinden, bölünme sözleşmesinin hazırlanması sırasında bir bilançonun çıkartılması şarttır.

---

[592] Tebliğ hükümleri uyarınca bölünme raporunda bulunması gereken asgari unsurlar için bkz., (Tebliğ Ek-7).

Türk Ticaret Kanununun 165'inci maddesinin başlığı "*ara bilanço*" olmasına karşın, maddede esas itibariyle bölünme sebebiyle bir bilanço tanziminden bahsedilmekte; "*bilanço günüyle, bölünme sözleşmesinin imzası veya bölünme planının düzenlenmesi tarihi arasında, altı aydan fazla bir zaman bulunduğu veya son bilançonun çıkarılmasından itibaren, bölünmeye katılan şirketlerin malvarlıklarında önemli değişiklikler meydana gelmiş olduğu takdirde, bir ara bilanço çıkartılması*" gereğine vurgu yapılmaktadır.

Yeni kuruluş şeklinde bölünmede, henüz bir şirket/kooperatif olmadığı için, bilanço çıkarmak zorunluluğu, bölünen şirket/kooperatif için öngörülmüş bir zorunluluktur.

Bilanço ve gereğinde çıkarılması gereken ara bilanço, TTK m. 167 uyarınca payların değişim oranını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını ve devreden şirketin/kooperatifin ortaklarının, devralan şirketteki/kooperatifteki ortaklık haklarına ilişkin açıklamaları, mal varlıklarının değerlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden bilançonun ve gereğinde çıkarılması gereken ara bilançonun güncel olması ve gerçek mal varlığı durumuna uygun olması gerekir; bilançonun güncel olması ilgililerin menfaatleri icabıdır.

Bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, bölünme hakkında ayrı rapor hazırlarlar; *ortak rapor da geçerlidir* (TTK m.169/1).

Bölünme raporunda; a) Bölünmenin amacının ve sonuçlarının, b) Bölünme sözleşmesinin veya bölünme planının, c) Payların değişim oranlarının ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarının, özellikle devreden şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin açıklamaların, d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özelliklerin, e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme yükümlülüklerinin, diğer kişisel edim yükümlülüklerinin ve sınırsız sorumluluğun, f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür sebebiyle söz konusu olan yükümlülüklerinin, g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğinin; varsa sosyal planın içeriğinin, h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini, hukuki ve ekonomik yönleri ile açıklanması ve gerekçelerinin gösterilmesi gerekir. Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme planına yeni şirketin sözleşmesinin de eklenmesi şarttır (TTK m. 169/3).

Bölünme raporu, pay sahiplerinin bölünme neticesinde ortaya çıkacak hukuki statülerini, oy hakkı dağılımlarını, hak ve yükümlülüklerini

belirlemekte; bu hak ve yükümlülüklerin öğrenilmesinde pay sahiplerinin önemli menfaati bulunmaktadır. Ancak *küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerinde, ortakların tamamının onaylaması hâlinde* bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilecektir (TTK m. 169/4).

Türk Ticaret Kanununun 169'uncu maddesinin dördüncü fıkrasındaki düzenlemeye nazaran, bölünme raporunun hazırlanmasından vazgeçmek için, bölünmeye katılan sermaye şirketlerinin, küçük ve orta ölçekli şirketlerden olması ve ortakların tamamının, raporun hazırlanmasından vazgeçilmesine onay vermesi gerekir; çekimser oy, oybirliğini engeller. Buna göre, bölünmeye katılan sermaye şirketlerinin her ortağının, raporun düzenlenmesinden vazgeçilmesini engelleme *(veto)* hakkı bulunmaktadır.

C) İLGİLİLERİN İNCELEME HAKKI

Bölünme hakkında bilgi edinilebilmesi ve inceleme yapılabilmesi için bölünmeyle ilgili önemli bazı belgelerin genel kurul toplantısı öncesinde incelemeye açılması gereklidir. Türk Ticaret Kanununun 171'inci maddesinde bu ihtiyacın giderilmesine yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Anılan düzenlemeye göre bölünmeye katılan şirketler/kooperatifler; bölünme sözleşmesini veya plânını, bölünme raporunu ve son üç yıla ait yılsonu finansal tablolarıyla yıllık faaliyet raporlarını ve gereğinde ara bilânçolarını incelemeye açmakla yükümlüdür. Birleşmeden farklı olarak *inceleme hakkı* ilgililere değil, *sadece pay sahiplerine tanınmıştır* (TTK m. 171/1).

İnceleme hakkıyla ilgili TTK m.171 hükmü, aynı ortaksal menfaatleri koruyan ve aynı bölünme kararının oylanmasında olduğu gibi, bilinçli oy kullanma amacına hizmet eden, vazgeçilmez bir hak niteliğindedir.

Hangi belgelerin incelemeye konu teşkil edeceği de TTK m.171/1'de üç bent hâlinde hükme altına alınmıştır. Buna göre, bölünmeye katılan şirketlerden/kooperatiflerden her biri; (1) bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını, (2) bölünme raporunu ve (3) son üç yılın yılsonu finansal tabloları ile faaliyet raporlarını ve varsa ara bilançolarını bölünmeye katılan şirketin/kooperatifin ortaklarının incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Bölünmeye katılan şirketlerden/kooperatiflerden her biri, Ticaret Sicili Gazetesinde, sermaye şirketleri ayrıca internet sitelerinde, inceleme haklarına işaret eden bir ilân yayımlarlar (TTK m. 171/4). İlânın

incelemeye imkân sağlayacak mahiyette ve inceleme süresinin başlamasından evvel yapılması uygun olur kanaatindeyiz.

Bölünmeye katılan şirketlerin/kooperatiflerin, inceleme hakkına konu belgeleri, *merkezlerinde* ve bölünmeye katılan şirket, halka açık anonim şirket ise, Sermaye Piyasası Kurulunun uygun gördüğü yerlerde, genel kurul kararından iki ay önce incelemeye açmakla yükümlüdürler hükmünün "*...genel kurul kararından önceki iki ay* ***boyunca.***. *.ortakların incelemesine sunmalıdır" şeklinde anlaşılması doğru olacaktır.*

Bölünme raporunun hazırlanmasından vazgeçme imkânı sadece *küçük ve orta ölçekli şirketler/kooperatifler* bakımından kabul edilmiştir. *Küçük ölçekli şirketlerde/kooperatiflerde* tüm ortakların onaylaması hâlinde, inceleme hakkından vazgeçilebilecektir (TTK m.171/2)[593].

İnceleme hakkından vazgeçmek için iki şartın bir arada bulunması gerekmektedir. Buna göre, bölünmeye katılan şirketlerin *küçük ve orta ölçekli şirket* olması ve ortakların tamamının, inceleme hakkından vazgeçilmesine onay vermesi gerekir. Kanunda açık şekilde genel kurul kararından bahsedilmediğinden, onayın bir genel kurul kararı şeklinde gerçekleşmesi de şart değildir; tüm ortakların onay iradesini içeren bir belgenin tanzimi gerekli ve yeterlidir.

D) BÖLÜNME KARARI

Bölünmeye katılan şirketler, 174'üncü maddede öngörülen *alacaklılara çağrı ilânlarının* yayımı tarihinden itibaren *üç ay içinde*, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar. Alacaklıların alacakları teminat altına alınmadan, bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının genel kurulun onayına sunulabilmesi mümkün değildir. Bu hususun hükme bağlandığı TTK m. 173/1'de, "Türk Ticaret Kanununun 175'inci maddesinde öngörülen *bu teminatların sağlanmasından sonra,* bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, *bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını genel kurula sunar*" denilerek; bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organlarının, *bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını genel kurula,* alacaklılara teminat sağlandıktan sonra sunabileceği kabul edilmiştir.

---

593 TTK m. 135/1'de, "134 ilâ 194 üncü maddelerin uygulanmasında; "şirketin", ticaret şirketlerini" ifade ettiği belirlenmiş; TTK m. 124'de de, "kooperatifler" ticaret şirketlerinden sayılmıştır. Ayrıca bkz. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik m. 4.

Hem TTK 173/1 hem de 175'inci maddenin emredici mahiyette olduğu nazara alındığında; alacaklıların alacakları teminat altına alınmadan bölünme sözleşmesinin veya bölünme plânının genel kurulun onayına sunulabilmesi mümkün değildir.

Hükümden de anlaşıldığı gibi, bölünme sözleşmesi veya plânının, bölünmeye katılan her bir şirketin yönetim organı tarafından genel kurula sunulan bölünme onayının bir *genel kurul kararı şeklinde ortaya çıkması gerekir.*

Kanun koyucu genel kurulun bölünme sözleşmesinin/plânının onama kararını, birleşme kararının onaylanmasına ilişkin olan *özel toplantı ve karar nisaplarına* (TTK m.151) *atıf yaparak düzenlemiş*; birleşmenin özelliğinden kaynaklanan hükümler haricindeki toplantı ve karar yetersayılarının bölünme için de geçerli olduğunu hükme bağlamış; *"Onama kararı 151 inci maddenin birinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen nisaplara uyularak alınır"*(TTK m.173/2) şeklinde bir düzenlemeye yer vermiştir.

Bu hükme göre, bölünme sözleşmesinin/plânının genel kurulda;

a) Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçüyle (TTK m.151/1.a),

b) Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların *dörtte üçüyle* (TTK m.151/1.b),

c) *Limited* şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip bulunmaları şartıyla, *tüm ortakların dörtte üçünün* oylarıyla (TTK m.151/1.c),

d) Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün kararıyla, *onaylanmalıdır* (TTK m.151/1.d).

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan *oyların dörtte üçüyle* onaylanmasının yanında, bu nisaba (TTK m.151/1.a'da öngörülen nisaba) ek olarak, *komanditelerin tamamının da bölünmeyi yazılı olarak* onaylamaları gereklidir.

Bir limited şirket, bölünme sonucunda bir malvarlığını devralıyorsa ve bu devralma ile limited şirkette *ek yükümlülük ve kişisel edim yükümlülükleri de öngörülüyorsa* veya bunlar mevcut olup da genişletiliyorsa, bölünme sözleşmesinin/plânının onaylanmasında bütün ortakların *oybirliğine* gerek vardır (TTK m.151/4).

Kanun koyucu "Birleşme sözleşmesinde devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse, birleşme sözleşmesinin ayrıca, şirket sözleşmesinin değiştirilmesi için gerekli *nisapla onaylanmış olması zorunludur*" (TTK m.151/6) dedikten sonra, bu hükmün "*bölünme*" hakkında da uygulanacağını hükme bağlamıştır (TTK m.173/2). Ancak, TTK m.151/6'daki "devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklik öngörülmüşse" düzenlemesinden de anlaşılacağı üzere, bu hükmün bölünmede uygulama imkânı bulunmamaktadır. Zira bölünmede bölünen bir malvarlığı devralınmakta, şirketin devralınması bahis konusu olmamaktadır. Bu hâlde "devrolunan şirketin işletme konusunda değişiklikten" söz de edilemeyeceğinden, TTK m. 151/6 hükmünün bölünmeye tatbik imkânı da bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 173'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "*Oranların korunmadığı bölünmede*" genel kurulun bölünmeyi onama kararı özel bir nisaba tâbi tutulmuş; karar nisabı ağırlaştırılmıştır. TTK m.173/3'e göre, "*Oranın korunmadığı bölünmede onama kararı, devreden şirkette oy hakkını haiz ortakların en az yüzde doksanıyla alınır*".

E) BÖLÜNMENİN KESİNLEŞMESİ

Bölünme genel kurul tarafından onaylanınca, yönetim organının bölünmenin tescilini istemesi gerekir (TTK m.179/1). Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, bölünme sözleşmesinin/plânının genel kurul tarafından onaylanmış olması, bölünme süreci bakımından gerekli bir işlem olmakla birlikte, bölünmenin hüküm doğurması için ayrıca bölünme hakkındaki genel kurul kararının ticaret siciline tescili de gerekmektedir. Bu açıdan tescil, *kurucu etkiye* sahiptir (TTK m. 179/1).

Bölünmeye birden fazla şirket katıldığı hâllerde, bölünmeye katılan tüm şirketlerin/kooperatiflerin genel kurul kararlarının sicile ayrı ayrı tescili gereklidir. Bir şirketin/kooperatifin bölünme kararını genel kurula onaylatıp, diğerlerinin onaylatmaması halinde, tescil için başvuru

yapılamaz. Diğer şirketlerin/kooperatiflerin genel kurul kararının alınmış olması beklenilmelidir[594].

Bölünmeye birden fazla şirketin/kooperatifin katıldığı hâllerde, bölünmeye katılan tüm şirketler/kooperatifler bölünmenin onaylanmasına yönelik genel kurul kararlarını tescil ettirmek zorundadır. Hâl böyle olmakla birlikte, hangi şirket/kooperatif genel kurul kararının tescili ile bölünmenin hüküm doğuracağı bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Kanun metninde bu konuda sarahat olmamasına rağmen, *gerekçeden* istifade ederek, *malvarlığı bölünerek devrolunan şirketin* genel kurul kararının ticaret siciline *tescili ile bölünmenin gerçekleşeceğini,* bu *tescilin kurucu* olduğunu, *mal varlığının geçişini* sağladığını ve bölünen şirketin *ortaklarının kendiliğinden* bölünme sonucu ortaya çıkan şirketin ortağı haline geldiklerini; malvarlığını *devralan şirket genel kurul kararının tescilinin ise bildirici etkiye* sahip olduğunu söyleyebiliriz[595].

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde de bu etki göz önünde bulundurularak, *devrolunan şirketin* birleşme kararını *öncelikle tescil* ettireceğini, *bu tescil yapılmadan devralan şirket genel kurul kararının tescil edilemeyeceğini* hükme bağlanmıştır (TSY m. 129/1).

Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 129'uncu maddesine göre, bölünmeye katılan şirketlerin tamamı, bölünme kararlarının tescili için ilgili müdürlük veya müdürlüklere başvurmadan tescil yapılamaz. Bölünen şirket/kooperatif, bölünme kararını tescil ettirmeden bölünmeye katılan diğer şirketler bölünmeye ilişkin olguları tescil ettiremez.

Bölünen şirketin malvarlığını devralan şirketler, bölünme dolayısıyla yapılacak sermaye artırımı ile bölünme kararını eş zamanlı olarak tescil ettirir. Bölünen şirketin malvarlığının yeni kurulacak şirket tarafından devralınması hâlinde ise bölünme kararı, kuruluşla birlikte eş zamanlı olarak tescil ettirilir. Tescili yapan müdürlük tam bölünme halinde, durumu bölünen şirketin kayıtlı olduğu müdürlüğe derhal bildirir. Tam bölünme nedeniyle infisah eden şirketin unvanı bu bildirim üzerine resen silinir (TSY m.129/6).

Bölünmeye katılan diğer şirketlerin kayıtlı olduğu sicil müdürlükleri; bölünen şirketin malvarlığına dâhil olan tapu, gemi ve fikri mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan ve müdürlüklerinde kayıtlı olan şirket tarafından devralınan mal ve hakların şirket

---

[594] Bkz. Gerekçe s. 119.
[595] Bkz. Gerekçe s. 120.

adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; yeni hak sahiplerini, *bölünme kararlarının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere derhal bildirmesi gerekir.*

Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer alan bütün aktifler ve pasifler devralan şirketlere geçer (TTK m.179/3).

Bölünme kararının ilânı; hem üçüncü kişiler hem de "*ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesinin*" uygulanması yönünden önem taşıdığından, bölünme kararının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olması gerekir.

VII) KOLAYLAŞTIRILMIŞ BÖLÜNME

Türk Ticaret Kanununda "*sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi*" hükme bağlanmış (TTK m.155-156) olmasına karşın, "***kolaylaştırılmış bölünme*" *düzenlenmemiş;*** *kolaylaştırılmış bölünmeden,* sadece Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinde bahsedilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğine göre, *"İştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde; bölünen halka açık ortaklığın, işlem sonucunda devralan tarafın oy hakkı veren paylarının en az %95'ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabilir"* (Tebliğ m.17).

Tebliğin bu hükmüne nazaran, kolaylaştırılmış bölünme sadece "*iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemlerinde*"[596] uygulanabilecek; "*devralma şeklindeki kısmî bölünme*"[597] işlemlerine uygulanamayacaktır.

Kolaylaştırılmış usulde bölünme, Türk Ticaret Kanununda açıkça düzenlenmemekle birlikte, *"tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ölçekli şirketler bölünme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler"* (TTK m.169/4) hükmü ile *"tüm ortakların onaylaması hâlinde*

---

596 ***İştirak modeliyle kısmi bölünme***: Bölünen şirketin, bölünmeye konu malvarlığının başka bir şirkete ayni sermaye olarak konulduğu ve devrin karşılığında bölünen *şirketin* devralan şirket sermayesinde pay sahibi olduğu kısmi bölünmeyi ifade eder (Tebliğ m.4/1.ı).

597 ***Devralma şeklinde birleşme***: En az bir şirketin, aktif ve pasif malvarlığı unsurlarını bir bütün olarak başka bir şirkete devrederek tasfiyesiz sona ermesini ve devrolunan şirketin ortaklarına belirli bir değişim oranına göre hesaplanacak miktarda devralan şirketin paylarının verilmesini ifade etmektedir (Tebliğ m.4/1.e).

küçük ölçekli şirketler ....inceleme hakkından vazgeçebilirler" (TTK m.171/2) düzenlemesi, bölünmede de bazı kolaylıkları öngörmüş; dolaylı da olsa kolaylaştırmadan bahsetmiştir.

VIII) BÖLÜNMENİN HÜKÜMLERİ

A) GENEL OLARAK

Türk Ticaret Kanununda bölünmenin kesinleşmesi, yani ticaret siciline tescilin sonuçları ile ilgili düzenlemelere yer verilmemiş olmasına karşın, "*korumaya ilişkin hükümler*" (TTK m.174-177) ve "*iş ilişkilerinin geçmesi*" (TTK m.178) hakkındaki düzenlemelerin, bölünmenin diğer hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi suretiyle, bölünmenin hüküm ve sonuçları tespit edilebilir.

Bu kapsamda bölünmenin ilk sonucu; *tam bölünmede, bölünen şirketin sona ermesidir*. Bölünme suretiyle malvarlığı devralan şirketlere devrolunan şirket, bölünmenin ticaret siciline tescili ile *infisah eder*; bu infisah, *tasfiyesiz infisahtır* (TTK m. 179). Kendiliğinden sona erme sonucunda infisah eden şirketler tasfiye sürecine girmezler.

Ortaklığın devamlılığı ilkesi (TTK m.159/1; m.161) uyarınca ise, bir bölünmeden bahsedilebilmesi için, kural olarak, devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketin veya şirketlerin ortağı olması gerekir (TTK m. 159/1; m.161)[598].

Bölünme sadece ortaklar bakımından değil, *mal varlığı bakımından da* hükümleri olan bir hukuki müessesedir. Bölünmenin tesciliyle birlikte, *kısmi bölünmede devrolunan şirketin malvarlığının bir kısmı, tam bölünmede bütün aktif ve pasifleri* devralan şirketlere geçer. Mal varlığının geçmesinin sonucu olarak, devralan şirketler, devrolunanın mal ve haklarının sahibi olduğu gibi, devraldığı malvarlığı sebebiyle kendisine tahsis edilen borçlarından da birinci dereceden sorumludur. Birinci dereceden sorumlu şirket, alacaklıların alacaklarını ifa etmezse; bölünmeye katılan diğer şirketler de, ikinci dereceden müteselsilen sorumlu olurlar. Durumun, malvarlığını devralan tarafından bilinip bilinmemesinin neticeye etkisi yoktur. İntikal, kanun gereği gerçekleştiğinden; münferit tasarruf işlemlerinin yapılması da gerekli değildir.

---

[598] Kuralın istisnası için bkz., "*denkleştirme ödenmesi*" yapılması ve "*yavru şirket*" kurulması.

B) BÖLÜNMENİN DIŞINDA KALAN MALVARLIĞI

Bölünme plânı ya da sözleşmesinde şirket/kooperatif aktiflerinde yer alan mal varlıklarının bazıları bölünmeye katılan şirketlerden/kooperatiflerden herhangi birine tahsis edilmemiş olabilir. Bu durum bilinçli ya da bilinçsiz şekilde gerçekleşebilir. Tahsisi yapılmayan bu mal varlıklarının akıbeti hakkında Türk Ticaret Kanununda iki ayrı duruma göre çözüme yer verilmiştir.

Eğer bölünme *kısmi bölünme* şeklinde gerçekleşiyorsa, yani mal varlığını devreden şirket/kooperatif, bölünme sonucunda hukuki varlığını koruyorsa; bu durumda, *tahsisin bilinçli olarak yapılmadığı farz edilir* ve tahsis yapılmayan (aktif ve pasif) mal varlığının devreden şirkette/kooperatifte kaldığı kabul edilir (TTK m. 168/1.b).

Eğer bölünme *tam bölünme* şeklinde gerçekleşiyorsa, yani mal varlığını devreden şirket, bölünme sonucunda hukuki varlığını kaybediyorsa; tahsis yapılmayan mal varlığının akıbeti hukuki bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. Bu halde Kanun Koyucu, devralan tüm şirketlerin söz konusu mal varlığı üzerinde *paylı mülkiyet* ilişkisi çerçevesinde mülkiyet hakkının bulunduğunu kabul etmektedir (TTK m. 168/1.a). Devralan şirketlerin paylı mülkiyet ilişkisi içinde pay oranları eşit olmayıp; bölünme sözleşmesi ya da bölünme planına göre kendilerine geçen net aktif mal varlığı[599] oranına göre belirlenecektir (TTK m. 168/1.a).

Alacak hakları ve maddi olmayan haklarda mülkiyet hakkı bulunmadığından, bu tür haklarda paylı mülkiyete ilişkin düzenleme kıyasen uygulanacaktır (TTK m. 168/2).

Bölünmeye katılan şirketlere, bölünme sözleşmesi veya plânıyla tahsis edilmeyen borçlardan dolayı sorumluluk konusu da; hakkında düzenleme yapılmasını gerektiren bir husustur. Kanunda, *kısmî bölünme* halinde borcun tahsis edilmemiş olması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda kısmi bölünme hâlinde, aktif mal varlığında olduğu gibi, tahsis edilmeyen borçtan bölünerek hukuki varlığını

---

599 Mehaz İsviçre Birleşme Kanununun tasarı hâlinde de, net aktif değeri (Nettoaktivvermögen) kavramı kullanılmasına rağmen, parlamento görüşmelerinde vergi hukuku kavramı olan "Reinvermögen" (vergilendirilebilen net değer) kavramı, bu kavramın yerine ikame edilmiştir (Bkz., **Watter, R./Rampini, C.:** Basler Kommentar, Fusionsgesetz (FusG), 2. (Hrsg: Watter, Rolf /Vogt, Nedim Peter/Tschäni, Rudolf /Daeniker, Daniel), 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015, Art. 38, Rn.3,9.

devam ettiren şirketin/kooperatifin sorumlu olduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Tam bölünme halinde tahsis edilmeyen borçlarla ilgili olarak, bölünme süreci sonunda, bölünen şirket/kooperatif hukuki varlığını kaybedeceğinden; tahsis edilmeyen borçlardan dolayı bölünen şirketin/kooperatifin sorumluluğundan bahsedilemez. Kanun koyucu, mal varlığını *devralan şirketlerin;* tahsis edilmeyen *bu borçlardan müteselsilen sorumlu olması* esasını kabul etmiştir (TTK m. 168/3). Borçlu şirketler arasındaki rücu ilişkisi Türk Ticaret Kanununda düzenlenmediğinden, genel hükümlere tâbidir. Ancak bu halde birleşme sözleşmesi veya plânı uyarınca devralınan net aktif değer oranının dikkate alınması kanaatindeyiz.

C) ALACAKLILARIN KORUNMASI, ORTAKLARIN SORUMLULUKLARI VE İŞ İLİŞKİLERİ AÇISINDAN HÜKÜMLERİ

1) Alacaklıların Korunması

Bölünmede ortakların yanında, menfaatleri korunması gereken önemli bir grup da alacaklılardır. Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğinin bölünmeye ilişkin sistemi, esas itibariyle *ortakların menfaatleri* esas alınmak suretiyle şekillenmiş olmakla birlikte, alacaklıların menfaatlerine hizmet eden özel düzenlemelere de yer verilmiştir.

Kanunun, alacaklıların menfaatine hizmet eden düzenlemelerine değinmeden önce, ***kısmî külli halef*** *olarak* kendilerine borç tahsis edilen *devralan şirketlerin* alacaklılara karşı *birinci dereceden sorumlu olduğunu*; birinci derecede sorumlu bulunan şirket, alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeye katılan diğer şirketlerin de *ikinci dereceden müteselsilen* sorumlu olduklarını belirtmek gerekir. Buna göre bölünme, alacaklıların haklarını sona erdirmemekte; sadece borçlu kanun gereği değişmekte; bölünmeye katılan diğer şirketlerin de, ikinci dereceden müteselsilen sorumlu oldukları kabul edilmektedir.

Alacaklıların korunmasına yönelik düzenlemeler, sadece bu hukuki sonuca ilâve bazı tedbirler içermektedir. TTK m. 174 hükmüne göre, "*Bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, tirajı ellibinin üstünde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan en az üç gazetede yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilanla,*

alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar". İlânların yapılacağı tarih hakkında açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, bölünme sözleşmesinin/plânının genel kurula sunulmasından evvel TTK m. 175'de hükme bağlandığı şekilde alacaklıların alacağının teminat altına alınması (TTK m. 173/1) gerektiğinden; bölünme sözleşmesinin/plânının genel kurula sunulmasından önce çağrının yapılması gerektiği söylenebilir.

Bölünmeye katılan şirketler/kooperatifler, bu *ilânlardan sonuncusunun yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde*, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak zorundadırlar (TTK m. 175/1).

Bölünmeye katılan şirketlerin/kooperatiflerin istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak esas olmasına rağmen, bölünme ile alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkmaktadır (TTK m.175/2). Ayrıca teminat verme yükümlülüğü bulunan şirketler/kooperatifler, diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarını ispat ederlerse, *teminat vermek yerine bu borcu ödeyebilir* (TTK m.175/3). Ödeme devralan şirketin/kooperatifin takdirindedir. Ancak diğer alacaklıların zarara uğrama tehlikesi varsa ödeme imkânı bulunmamaktadır. Kanun sisteminden anlaşıldığı üzere, kanun koyucu bölünmede, başvuran alacaklının menfaatlerini ön plânda tutan bir yaklaşımda bulunmuş; durumdan fiilen haberdar olmayan ya da ilgisiz kalan alacaklıların menfaatlerini ikinci plana iten bir çözüme yer vermiştir.

2) Sorumluluk İlişkileri

Kanun koyucu bölünmedeki sorumluluğu, "*bölünmeye katılan şirketlerin (kooperatiflerin) sorumluluğu*" ve "*ortakların kişisel sorumluluğu*" olarak iki ayrı başlık altında ele almıştır.

a) Bölünmeye Katılan Şirketlerin/Kooperatiflerin Sorumluluğu

Bölünme sözleşmesi veya bölünme plânıyla kendisine borç tahsis edilen şirket/kooperatif, kendisine tahsis edilen borç sebebiyle; bölünmenin tescili ile birlikte, bölünmenin tescili öncesinde doğmuş borçlardan *birinci dereceden* sorumlu olur. Bölünme sözleşmesi veya bölünme plânıyla kendisine borç tahsis edilen bu şirket/kooperatif, kendisine tahsis edilen borcu ifa etmezse; bölünmeye katılan diğer şirketler/kooperatifler; ödenmeyen, bölünmenin tescilinden önce doğmuş borçlardan

dolayı *ikinci dereceden* ve *müteselsilen* sorumlu olurlar (TTK m.176/1). Bölünmeye katılan diğer şirketler ile kooperatiflerin *ikinci dereceden* ve *müteselsilen* sorumluluğu, bir süre ile de sınırlandırılmamıştır (Bkz. TBK m.202).

Kanun koyucu, ikinci dereceden sorumlu olan şirketlerin/kooperatiflerin takip edilebilmelerini iki şartın bir arada olmasına bağlamıştır. Buna göre, *ikinci dereceden sorumlu olan şirketlerin takip edilebilmeleri için, **(1)** alacağın teminat altına alınmamış* olması ve ***(2)**birinci derecede sorumlu şirketin*; ***a)*** iflâs etmiş veya ***b)*** konkordato süresi almış veya ***c)*** aleyhinde yapılan bir icra takibinde kesin aciz vesikası alınmasının şartları doğmuş, ***d)*** merkezinin yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye'de takip edilemez duruma gelmiş olması veya ***e)*** yurt dışındaki merkezinin yeri değiştirilmiş ve bu sebeple *hukuken takibi önemli derecede güçleşmiş olması* gerekir (TTK m.176/2).

b) Ortakların Kişisel Sorumluluğu

Kanun koyucu, ortakların kişisel sorumlulukları hakkında, ticaret şirketlerinin birleşmesindeki sorumluluğa ilişkin Türk Ticaret Kanununun 158'inci maddesi hükmünün uygulanacağını belirtmiştir (TTK m.177). Ancak, ortakların kişisel sorumlulukları hakkında, ticaret şirketlerinin birleşmesindeki sorumluluğa ilişkin hükümlerinin uygulanması; bölünmenin mahiyetine uygun olduğu ölçüde söz konusu olabilir.

Zira bölünme, sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngörülmüş; sermaye şirketlerinden olan *anonim şirketlerde* ortakların, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu olacağı (TTK m. 329/2) kabul edilmiştir. Bu kabule göre, anonim şirketlerin bölünmesinde, alacaklıların ortakların sorumluluğuna gitmesi söz konusu olamaz.

Sermaye şirketlerinden olan *limited şirketlerde* de ortaklar, şirket borçlarından sorumlu değildir (TTK m.573/2). Bu kuralın istisnası, ek ödeme (TTK m. 603-605) ve yan edim (TTK m. 606) yükümlülükleri olarak kabul edilmiştir (TTK m.573/2). Ancak, gerek *ek ödeme* gerek *yan edim* yükümlülüğü, limited şirket alacaklılarına değil; şirkete karşı bir yükümlülüktür. Bu yükümün ifasını, limited şirket talep edebilir; limited şirket alacaklılarına karşı bir borç doğmaz. Bu nedenle, limited şirketlerin bölünmesinde, şirket alacaklıları, doğrudan şirket ortaklarına başvuramaz.

Kooperatiflerde ise, ortakların sorumluluğu, kural olarak sınırlıdır. Bununla birlikte, anasözleşmede, kooperatifin varlığı borçlarını karşılamaya yetmediği hallerde, ortakların da şahsen ve sınırsız olarak sorumlu tutulacakları hüküm altına alınabilir. Bu takdirde alacaklılar kooperatifin iflası veya diğer sebeplerle dağılması halinde, alacaklarını tamamen alacaklar; kooperatifin borçlarından dolayı, zincirleme ve bütün varlıklarıyla sorumlu olan kooperatif ortaklarına başvurabilecekleridir (KoopK m.29). Ayrıca, anasözleşmeye, kooperatif borçları için her ortağın kendi payından fazla olarak şahsen ve belirli bir miktara kadar kooperatiften sonra sorumlu olacakları hususunda bir hüküm de konabilir (KoopK m. 30). Sadece bu hâllerle sınırlı olarak, kooperatiflerin bölünmesinde, TTK m. 158 hükümleri tatbik edilerek, ortakların kişisel sorumluluğuna gidilebilir.

Yukarıda da izah edildiği üzere TTK m. 158'de, devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların sorumluluklarının; birleşmeden sonra da devam edeceği kabul edilmiştir. Şu şartla ki, bu borçlar *birleşme (bölünme) kararının ilânından* önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır (TTK m. 158/1). Bu düzenlemeden mülhem olarak, bölünme sözleşmesi veya bölünme plânıyla kendisine borç tahsis edilen şirket, kendisine tahsis edilen borç sebebiyle *birinci dereceden;* bölünme sözleşmesi veya bölünme plânıyla kendisine borç tahsis edilen bu şirket, kendisine tahsis edilen borcu ifa etmezse, bölünmeye katılan diğer şirketler, ödenmeyen bu borçtan dolayı *ikinci dereceden* ve *müteselsilen* sorumlu olacaktır (TTK m.176/1). Alacaklılar, alacaklarını birinci ve ikinci dereceden müteselsilen sorumlu olanlardan alamazlarsa; yukarıda belirttiğimiz esaslar çerçevesinde, ortaklara müracaat edebilirler.

Devrolunan şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, bölünme kararının ilânı tarihinden itibaren *üç yıl* geçince *zamanaşımına* uğrar. Alacak ilân tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlayacaktır. Bu sınırlama, *devralan şirketin* borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz (TTK m. 158/2).

TTK m. 158/3 hükmüne göre, kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar devam eder; yeter ki izahnâme başka bir düzenleme içermesin.

c) İş İlişkileri Açısından Hükümleri

Devrolunan şirket çalışanlarının hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla, bu kişilerin hukuki durumlarıyla ilgili özel düzenlemelere yasada ayrıca yer verilmiştir (TTK m.178). Bu açıdan *birleşme ve bölünmede de* aynı hükümler caridir[600].

Buna göre, tam veya kısmi bölünmede, işçilerle yapılan hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde, devir gününe kadar bu sözleşmeden doğan bütün hak ve borçlarla devralana geçer.

İşçi itiraz ederse, hizmet sözleşmesi kanuni işten çıkarma süresinin sonunda sona erer; devralan ve işçi o tarihe kadar sözleşmeyi yerine getirmekle yükümlüdür. Eski işveren ile devralan, işçinin bölünmeden evvel muaccel olmuş alacakları ile hizmet sözleşmesinin normal olarak sona ereceği veya işçinin itirazı sebebiyle sona erdiği tarihe kadar geçen sürede muaccel olacak alacaklarından müteselsilen sorumludur. Aksi kararlaştırılmadıkça veya hâlin gereğinden anlaşılmadıkça, işveren hizmet sözleşmesinden doğan hakları üçüncü bir kişiye devredemez. İşçiler muaccel olan ve birinci fıkrada öngörüldüğü şekilde muaccel olacak alacaklarının teminat altına alınmasını isteyebilirler.

Devreden şirketin bölünmeden önce şirket borçlarından dolayı sorumlu olan ortakları, hizmet sözleşmesinden doğan ve intikal gününe kadar muaccel olan borçlarla, hizmet sözleşmesi normal olarak sona ermiş olsaydı muaccel hâle gelecek olan veya işçinin itirazı sebebiyle hizmet sözleşmesinin sona erdiği ana kadar doğacak olan borçlardan müteselsilen sorumlu olmakta devam ederler.

---

[600] TTK m. 158/4 hükmü uyarınca; birleşmede *iş ilişkileri hakkında*, bölünmede iş ilişkilerini düzenleyen TTK m. 178 hükmü uygulanacaktır.

§ 25- TÜR DEĞİŞTİRME

I) TÜR DEĞİŞTİRME KAVRAMI

Ticaret şirketinin kuruluşunda, çeşitli *saiklerle* tercih edilen tür; ilerleyen dönemlerde, ticaret şirketinin ihtiyaçlarına cevap veremez hâle gele gelebilmektedir. Bu bağlamda, mevcut türleri daha kapsamlı girişimlere imkân vermeyen ticaret şirketleri; sermayelerinin etkinliğini arttırmak, kişisel sorumluluk sınırlarını daraltmak, kredi limitlerini yükseltmek, bazı vergilendirme ve teşvik tedbirlerinden yararlanmak, halka açılmak gibi nedenlerle ticaret şirketinin faaliyetlerini kesintiye uğratmaksızın, hukuki şekillerinde değişiklik yapmak isteyebilirler.

Tür değişikliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 180 ilâ 194'üncü maddelerinde, *İsviçre Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme ve Malvarlığı Devrine İlişkin Federal Kanun*'dan yararlanılarak, ayrıntılı bir şekilde hükme bağlanmıştır.

Türk Ticaret Kanununun birbirini tamamlayan 180 ve 181'inci maddeleri ile 194'üncü maddesinin 2 ve 3'üncü fıkrası birlikte değerlendirildiğinde ***tür değiştirme***; *"Kanunda belirtilen şartlara uygun olarak kurulan ticaret şirketi türlerinden birinin veya bir ticari işletmenin, tasfiye edilmeksizin, başka bir ticaret şirketi türüne veya bir ticari işletmeye dönüştürülmesi"* olarak tanımlanabilir.

II) TÜR DEĞİŞTİRMENİN UNSURLARI

Tür değiştirmenin yukarıda verilen *tanımından, tür değiştirmeye hâkim olan ilkelerden* ve tür değiştirmeye ilişkin diğer hükümlerden yola çıkarak, tür değiştirmenin unsurlarını belirlemek mümkündür. Buna göre:

A) TÜRÜ DEĞİŞECEK BİR TİCARET ŞİRKETİ VEYA TİCARİ İŞLETMENİN MEVCUDİYETİ

TTK'deki tür değiştirme ile ilgili hükümler incelendiğinde, hükümlerin asıl amacının, *ticaret şirketlerinin* tür değiştirmesine yönelik olduğu; *ticaret şirketinin ticari işletmeye* ve *ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesinin* de tür değişikliği içinde mütalaa edildiği, bir *ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi* hâlinde, 182 ilâ 193 üncü

maddelerin kıyas yoluyla uygulanabileceğinin kabul edildiği anlaşılmaktadır. Biz aşağıda, tüm bu hâlleri nazara alarak ayrı ayrı ele alacağız.

1) Ticaret Şirketlerinin Türünün Bir Başka Ticaret Şirketi Türüne Dönüşmesi

Tür değiştirmenin ilkelerinin hükme bağlandığı TTK m. 180'de ifade edildiği üzere, *tüm ticaret şirketleri* mevcut türünü değiştirebilme imkânına sahiptir; ancak bu imkân, genel bir tür değiştirme, bir diğer söyleyişle, *türden türe serbestçe geçiş* olarak nitelendirilmemelidir. Zira TTK m. 181'de, ***"geçerli tür değiştirmeler"*** başlığı altında, hangi şirketlerin hangi şirket türüne dönüşebileceği hükme bağlanarak, *türden türe serbest geçiş olamayacağı* esası benimsenmiştir.

Kanun koyucu, tür değiştirmenin *"genel hükümleri"* başlığı altında, ticaret şirketlerinin tür değiştirmelerinin ilkeleri ile geçerli tür değiştirmelerinden başka, kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin özel bir düzenleme getirmiş; TTK m. 194/3'te de, ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesini ele almıştır.

a) Geçerli Tür Değiştirmeler

TTK m. 180'de, tüm ticaret şirketlerinin mevcut türünü değiştirebilme imkânına sahip olduğu kabul edildikten sonra, TTK m. 181'de *"geçerli tür değiştirmeler"* başlığı altında, hangi şirketlerin hangi şirket türüne dönüşebileceği hükme bağlanmıştır.

TTK m. 181'deki kabule göre; ***sermaye şirketlerinin*** *ancak başka türde bir sermaye şirketine veya bir kooperatife;* ***kollektif şirketin*** *ise sadece, bir sermaye şirketine veya bir kooperatife yahut bir komandit şirkete dönüşebileceği kabul edilmiştir. Bunların yanında şahıs şirketlerinden olan* ***komandit şirketin****, bir sermaye şirketine veya bir kooperatife yahut bir kollektif şirkete dönüşebileceği; şahıs veya sermaye şirketi olarak nitelendirilmeyen* ***kooperatiflerin*** *ise yalnızca bir sermaye şirketine* dönüşebileceği esası benimsenmiştir.

Kanun koyucunu izin verdiği bu tür değişiklikleri (geçerli tür değişimleri) hâllerinin dışında, ticaret şirketlerinin başka bir ticaret şirketi türüne geçiş imkânı bulunmamaktadır.

b) Kollektif şirketin komandit şirkete ve komandit şirketin kollektif şirkete dönüşmesine ilişkin özel düzenleme

Ticaret şirketlerinin tür değiştirmesinde, hangi ticaret şirketlerin hangi ticaret şirketi türüne dönüşebileceği "*geçerli tür değiştirmeler*" başlığı altında TTK m.181'de hükme bağlandıktan sonra; 182'nci madde ile kollektif ve komandit şirketlerin tür değiştirmelerine ilişkin *emredici mahiyette olmamak üzere* özel bir düzenleme öngörülmüştür.

Bir *kollektif şirketin komandit şirkete* dönüşebilmesi için, kollektif şirkete bir komanditerin girmesi veya mevcut kollektif şirket ortaklarından birinin komanditer olması yöntemlerinden birinin seçilmesi öngörülmüştür (TTK m. 182/1). Bir *komandit şirketin kollektif şirkete* dönüşebilmesi için ise; mevcut tüm komanditer ortakların şirketten çıkması veya tüm komanditerlerin komandite ortağa dönüştürülmesi gerektiği (TTK m. 182/2) belirtilmiştir.

Kanun koyucunun kabulüne göre, bir kollektif veya komandit şirketin, komandit veya kollektif şirkete dönüşmesi halinde; Türk Ticaret Kanununun tür değiştirmeye ilişkin 180 ilâ 190'ıncı maddeleri uygulanmayacaktır (TTK m. 182/4).

2) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesi

TTK m. 181'de hükme bağlanan "*geçerli tür değiştirmeler*" esas olmakla birlikte; bir *ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi* de, TTK m. 194/3'te kabul edilmiştir (Ayrıca bkz., TSY m. 134).

a) Ticaret Şirketlerinin Ticari İşletmeye Dönüşmesinde Kabul Edilen İlke

TTK m. 194/3'te kabul edildiği üzere, *"Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi için, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilân edilmelidir".* TTK m. 194/3'te kabul edilen bu ilke, TSY m.134/1'de, *"Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi, tüzel kişinin şekil değiştirerek bir ticari işletme haline gelmesidir. Her ticaret şirketi, tâbi olduğu sorumluluk sistemi ne olursa olsun bir ticari işletmeye dönüşebilir"* şeklinde ifade edilmiştir.

TTK m. 194/3'te, ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesi, herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaksızın mümkün görülmesine karşın; TSY m. 134/4'te, *sermayesini kaybetmiş veya borca batık olan* (TTK m. 376, 633) anonim ve limited şirketlerle, *tasfiye halindeki ticaret şirketlerinin* ticari işletmeye dönüşemeyeceği kabul edilmiştir.

Tüm ticaret şirketleri için TTK m. 194/3'te kabul edilen "*bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülebilmesi*" ilkesine göre, sermayesini kaybetmiş veya borca batık olan anonim ve limited şirketlerle, tasfiye halindeki ticaret şirketleri hariç olmak üzere tüm ticaret şirketleri, şirket paylarının tümünün, ticari işletmeyi işletecek *kişi* veya *kişiler* tarafından devralınmasıyla, ticari işletmeye dönüşebilecektir. TTK m. 194/3'te, şirket paylarının birden fazla kişi tarafından devralınabileceği hükme bağlandığı için; tüm ticaret şirketlerinin *adi şirkete* (TBK m. 620 vd.) dönüşebilmesinin önü de açılmıştır.

b) Kollektif veya Komandit Şirketin Tek Kişi İşletmesine Dönüşmesine İlişkin Özel Düzenleme

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüştürülmesi, TTK m. 194/3'te hükme bağlanmasının yanında; TTK m. 182/3'te, "*Bir kollektif veya komandit şirketin tek kişi işletmesi olarak faaliyetine devam etmesine ilişkin 257'nci madde hükmü saklıdır*" denilerek, bir kollektif veya komandit şirketin *tek kişi işletmesine* dönüşmesi, istisnai olarak, sadece iki ortaklı *kollektif/komandit şirket* için ayrıca düzenlenmiştir. TTK m. 182/3'teki bu düzenleme, istisnai mahiyettedir ve sadece, *iki ortaklı kollektif/komandit* şirketin, *hâkim kararıyla tek kişi işletmesi* şeklinde faaliyetine devam edebileceğini öngörülmektedir.

3) Ticari İşletmelerin Ticaret Şirketine Dönüşmesi

TTK m. 194/2'de, bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi kabul edilmiş; bu hâlde 182 ilâ 193 üncü maddelerin kıyas yoluyla *uygulanabileceği* ifade edilmiştir.

a) Genel Olarak

Türk Ticaret Kanunundaki tür değiştirmeyle ilgili hükümler, ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi amacına yönelik olmasına karşın; *bir ticari işletmenin tür değiştirip ticaret şirketine dönüşebileceği*, TTK m. 194/2'de kabul edilmiştir. Kanun koyucunun kabulüne göre, *bir ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesi halinde tür değiştirmeye ilişkin*

182 ilâ 193'üncü maddeler kıyas yoluyla uygulanabilecektir (TTK m. 194/2).

Ticari işletme hukuk süjesi olmadığından, ticari işletme değil; ticari işletmeyi işleten gerçek veya tüzel kişi tacirin, Türk Ticaret Kanununun 184'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereği yeni türün kuruluşunda uygulanacak esaslara göre hareket ederek; bir ticaret şirketi kurması gerekecektir. Bu durumda; ticaret şirketlerinin kuruluşuna ilişkin hususlar ile şirketin taşıması gereken şartlara uyulması gerekmektedir.

b) Türk Borçlar Kanunundaki "Ticari İşletmelerin Kollektif veya Komandit Şirkete Dönüşmesi" ile İlgili Özel Düzenleme

Ticari işletmelerin kollektif veya komandit şirkete dönüşmesi ile ilgili düzenlemeye, TBK m. 203/2'de, "*borcun üstlenilmesi*" münasebetiyle, "*işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi*" müessesesinde yer verilmiştir.

TBK m. 203/1'de, "*Bir işletme, başka bir işletme ile aktif ve pasiflerin karşılıklı olarak devralınması ya da birinin diğerine katılması yoluyla birleştirilirse, her iki işletmenin alacaklıları, bir malvarlığının devralınmasından doğan haklara sahip olup, bütün alacaklarını yeni işletmeden alabilirler*" denildikten sonra; TBK m. 203/2'de, "Bir tek kişiye ait olup da, kollektif veya komandit ortaklık hâline dönüştürülen bir işletmenin borçları hakkında da" aynı hükmün uygulanacağı belirtilerek; tek kişiye ait olan bir ticari işletmenin, kollektif veya komandit şirkete dönüşebileceği kabul edilmiştir.

Ancak belirtmek gerekir ki, TBK m. 203/2'nin amacı, doğrudan doğruya ticari işletmelerin kollektif veya komandit şirkete dönüşmesini düzenlemek değil; ticari işletmelerin kollektif veya komandit şirkete dönüşmesi hâlinde, *işletmenin (işletmeyi işletenin) borçlarının* akıbetini hükme bağlamaktır. TBK m. 203/2'ye göre, kollektif veya komandit şirkete dönüşen *işletmenin alacaklıları,* bir malvarlığının devralınmasından doğan haklara sahip olacağından; *bütün alacaklarını kollektif veya komandit şirketten* alabileceklerdir.

B) YENİ TÜRÜN ESKİSİNİN DEVAMI OLMASI

Tür değiştirme ilkelerinde, "*yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır*" denilerek (TTK m. 180), yeni türe dönüştürülen şirket tüzel kişiliğinin, ticaret şirketine dönüşen ticari işletmenin veya türü değişen

şirketin devamı olduğu kabul edilmiş; buna karşın, ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesi durumunda ne olacağına temas edilmemiştir.

Ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesinde, yeni türe dönüştürülen bir şirketten bahsedilemeyeceğinden; "*yeni türün eski türün devamı olması*" kavramının ayrıca incelenmesi gerekir. Biz aşağıda, *ticaret şirketinin veya ticari işletmenin ticaret şirketine*; *ticaret şirketinin ticari işletmeye* dönüşmesini, bu hâlleri nazara alarak ayrı ayrı inceleyeceğiz.

1) Yeni Ticaret Şirketinin Eskisinin Devamı Olması

Tür değiştirmenin ilkeleri arasında sayılan, "*yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır*" ilkesiyle, yeni türe dönüştürülen *şirket tüzel kişiliğinin*, türü değiştirilen tüzel kişilik veya tüzel kişilik olarak yeniden yapılandırılan ticari işletmenin devamı sayılması amaçlanmış; *birleşme* ve *bölünmeden* farklı bir yaklaşım tarzı benimsenmiştir (TTK m.180/1. c. 2).

Kanun koyucu birleşmede, *külli halefiyet*, bölünmede *kısmi külli halefiyet* ilkesine yer verirken; tür değiştirmede, *yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı* olduğunu hükme bağlamıştır. Tür değiştirmede, (bir ticari işletmenin bir ticaret şirketine dönüşmesi hâli istisna edilecek olursa) sadece türü değişecek şirket vardır. Bu ticaret şirketi, TTK m. 181'de izin verilen diğer bir şirket türüne dönüşmekte, ticaret şirketinin *sadece türü değişmektedir* (süje tekliği); türü değişen şirketin sona ermesinden veya yeni türün külli halefiyetinden söz edilmemektedir.

TTK m. 180'de, "*yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır*" denilerek, yeni şirket, hem *eski ticaret şirketinin* hem *eski ticari işletmenin* devamı sayılmış; eski ticaret şirketinin veya eski ticari işletmenin gerek malvarlığında gerekse ekonomik durumunda süreklilik sağlanmıştır. Buna göre *yeni şirket*, hukuk süjesi olarak *türü değişen eski şirket* ile tür değiştirme sonucunda hukuk süjesi sıfatını kazanan *eski ticari işletmenin* devamı olarak kabul edilmiştir. Bu durumda, tür değiştirme neticesinde sorumluluk rejimi ile organsal yapıda değişiklikler meydana gelebilecekse de, bunların tür değiştirmenin doğal sonucu olarak nitelendirilmesi gerekir.

Tür değiştirmeye hâkim olan "*yeni ticaret şirketi tüzel kişiliğinin eskisinin devamı olması*" ilkesi; tür değiştirmede, külli ve kısmi külli halefiyet ilkesinin benimsendiği diğer yapısal değişikliklere nazaran, farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.

Külli halefiyetin ortaya çıkardığı farklılıklar bir yana, tür değiştirme sonucunda oluşan yeni ticaret şirketi tüzel kişiliğinin, eskisinin (eski ticaret şirketinin ve ticari işletmenin) devamı sayılması nedeniyle; birleşme ve bölünmede üzerinde hassasiyetle durulan bazı düzenlemelere, tür değiştirmede yer verilmemiştir.

Bunların başında, "*alacaklıların korunması*" gelmektedir. Birleşme ve bölünmede öngörüldüğünün aksine, tür değiştirmede, yeni şirket eskisinin devamı mahiyetinde olduğundan, alacaklıların korunmasına yönelik özel bir düzenlemeye gidilmemiş; sadece *ortakların kişisel sorumlulukları* hakkında 158'inci madde hükümlerinin tatbik edileceği ifade edilmiş; alacaklıların alacağının, teminat altına alınmasına gerek duyulmamıştır.

2) Ticaret Şirketinin Ticari İşletmeye Dönüştürülmesinde, Ticari İşletmenin Eski Ticaret Şirketinin Devamı Olması

"Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi" (TTK m. 194/3) hâlinde, yeni türe dönüştürülen şirketten bahsedilemeyeceğinden; TTK m.180'deki, *"yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır"* hükmünün, ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesi durumuna da tatbik edilip edilemeyeceği ayrıca incelenmelidir.

Kanun koyucu, ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüştürülmesinde, sadece, *"ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi, bir* ***kollektif*** *veya* ***komandit şirket ise*** *mezkûr ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264'üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olurlar"* demekle yetinmiştir.

Ticari işletmeye dönüşen diğer ticaret şirketleri bakımından TTK'de bir hüküm bulunmamakla birlikte, TSY m. 134/2'de, "*Dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır*" denildikten başka, "*Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde Kanunun 180'inci maddesi kıyasen uygulanır*" (TSY m. 134/5) ifadesine yer verilerek, *ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde de,* ticari işletmenin eski ticaret şirketinin devamı olduğu kabul edilmiştir.

Ancak ticari işletmenin hukuk süjesi olmadığı nazara alındığında; "*ticari işletme, dönüşen ticaret şirketinin devamıdır*" ifadesinin, ticari işletmeyi işleten tacirin, ticari işletmeye dönüşen ticaret şirket tüzel kişiliğinin *külli halefi* olduğu görüşü benimsenmelidir.

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde, ticari işletmeye ilişkin hususların tescili ile birlikte; tür değiştiren *ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği hususunun tescil edilmesi* gerekmektedir (TSY m. 135/3). Tescil, eski ticaret şirketinin sicil kaydı üzerinden yapılacak olsa da; tür değiştiren ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği gözden kaçırılmamalıdır.

Bu durumda, yukarıda da ifade edildiği üzere, ticari işletmenin ticaret şirketinin devamı olduğundan değil; ticari işletmeyi işletenlerin, ticaret şirketinin külli halefiyetinden bahsedilebilir.

Ticari işletmeyi işletenlerin, ticaret şirketinin külli halefi olduğu kabulünde ise, külli halefiyete ilişkin hükümlere yer verilmemiş olması, bazı sorunlara sebebiyet verebilecek; bu bağlamda, alacakların teminat altına alınmasıyla ilgili hükmün (TTK m. 157) uygulanıp uygulanamayacağı sorunuyla karşılaşılacaktır.

C) TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKET ORTAKLARININ ORTAKLIK SIFATLARININ TÜRÜ DEĞİŞEN ŞİRKETTE DEVAM ETMESİ

Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur. *Oydan yoksun paylar için* sahiplerine eşit değerde paylar veya oy hakkını haiz paylar verilir (TTK m. 183/1). TSY m. 134/5'te, "*Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde Kanunun 180 inci ve 182 ila 190 ıncı maddeleri kıyasen uygulanır*" denildiği için, bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesinde de ortaklık sıfatının korunması gerekir.

D) TASFİYENİN BULUNMAMASI

Bir ticaret şirketinin, yeni bir ticaret şirketi türüne dönüştürülmesinde, "*yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır*" ilkesi kabul edildiğinden, türü değişen ticaret şirketinin sona ermeyeceği; sona ermediği için de tasfiye edilmeyeceği ifade edilebilir.

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde, yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikler yapılır. *Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır* (TSY m. 135/2).

Bir ticaret şirketinin bir ticari işletmeye dönüşmesi halinde ise, ticari işletmeye ilişkin hususların tescili ile birlikte tür değiştiren ticaret şirketinin tüzel kişiliğinin sona erdiği hususu da tescil edilir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır (TSY m. 135/3).

E) ŞİRKET PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI

TTK m. 183/1'de, "*Tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur*" denilmek suretiyle, türü değişen şirketin ortaklarının, yeni türdeki şirketteki pay ve haklarının korunacağı hükme bağlanmıştır. Hüküm, ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesinde de uygulanacak mahiyette kaleme alınmıştır. Buna göre, ticari işletmeye dönüşen ticaret şirketinin ortaklarının *şirketteki paylarının ve haklarının,* ticari işletmede de korunması söz konusu olacaktır.

Yukarıda da ifade edildiği üzere, *"Tür değiştirmede ortakların şirket payları korunur"* kuralını hükme bağlayan kanun koyucu; *ayrılma akçesi* veya *denkleştirme ödemesi* yapılıp yapılamayacağı hususuna değinmemiştir. Bununla birlikte kanaatimizce TTK m. 191/1 ve 192/1'deki hükümlerden hareketle, tür değiştirmede de, ayrılma akçesi ve denkleştirme ödemesinin geçerli olduğu ifade edilebilir. Bu durumda, birleşme ve bölünme hükümlerinin esas alınması uygun olur.

Türü değişen şirket ortaklarının şirket paylarının yeni şirkette korunması, türü değişen şirketin ortaklarına, mevcut ortaklık paylarını karşılayacak değerde, yeni şirketin payları üzerinde istemde bulunma hakkı verilmek suretiyle sağlanabilir. Bu hak, türü değişen şirketin malvarlığının değeri, oy haklarının dağılımı ve önem taşıyan diğer hususlar dikkate alınarak hesaplanmalıdır. Aynı şekilde ticari işletmeye dönüşen ticaret şirketinin ortaklarının *şirketteki paylarının ve haklarının,* ticari işletmede de korunması söz konusu olacaktır.

III) TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİ

Kanun koyucunun kabulüne göre, ticaret şirketinin tür değiştirmesi veya ticari işletmeye dönüşmesi için evvelemirde, türü değişecek ticaret şirketinin *yönetim organı* tarafından *bir tür değiştirme planının yapılması*; daha sonra ise, tür değiştirme hakkında yazılı bir *rapor hazırlaması* ve *ortakların incelemesine sunulması* gerekmektedir. *Tür değiştirme planını yapan ve tür değiştirme raporunu hazırlayarak ortakların incelemesine sunan* yönetim organının, tür değiştirme plânı ile yeni türün şirket *sözleşmesini, türü değişecek şirket genel kuruluna sunması ve türü değişecek şirket genel kurulunun tür değiştirmeyi TTK m. 189'da hükme bağlanan nisaplarla onaylaması da gerekmektedir.* Türü değişen ticaret şirketinin yönetim organı; tür *değiştirme* kararı alınır alınmaz, *tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir.*

Tür değiştirme, tür değiştirmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescille birlikte, türü değişen ticaret şirketi eski ticaret şirketinin devamı sayılırken; ticari işletmeye dönüşmede, türü değişen şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden ticari işletmeyi işletenlere geçer ve türü değişen şirketin ortakları da ticari işletmenin ortağı olur.

Ticaret şirketlerinin tür değiştirmesi, bir sözleşmeye dayanmadığı için tür değiştirme sürecinde, sözleşme yapılmadan evvel tür değiştirmeye katılacak şirketlerden ve tür değiştirme öncesi taraflar arasındaki bir *müzakereden* bahsedilemez.

A) TÜR DEĞİŞTİRME PLÂNI

Tür değiştirme işlemlerinin başında, tür değiştirme plânının yapılması gelmektedir. *Tür değiştirme plânı*, türü değişen şirket yönetim organı tarafından hazırlanan, *kanun koyucunun belirlediği kayıtları* içeren, *tek taraflı bir hukuki işlemdir.*

Ancak yukarıda da izahına çalışıldığı üzere, TTK'deki tür değiştirme hükümleri, bir ticaret şirketinin hukuki şeklini değiştirerek, yeni ticaret şirketi türünde devam etmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bu bağlamda, tür değiştirme işlemleri ve buna bağlı olarak tür değiştirme plânının hazırlanmasında da aynı usul takip edilerek, ticaret şirketinin ticari işletmeye ve ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesi ile ilgili ayrı düzenlemelere yer verilmemiştir.

Tür değiştirme işlemlerine ilişkin hükümlerden anlaşıldığına göre, bir ticaret şirketinin hukuki şeklini değiştirerek, yeni ticaret şirketi türünde devam etmesi işlemleri ile ticaret şirketinin ticari işletmeye dönüşmesi işlemlerinde bazı farklılık gözlemlenmekle birlikte; yapılacak işlemlerin benzer olduğu görülmektedir. Buna karşın, ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesinde aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Tür değiştirme plânının da bu esaslar gözetilerek incelenmesi gerekmektedir.

B) TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU HAZIRLANMASI

Tür değiştirme plânı, tür değiştirme sürecinin başlaması için gerekli bir işlem olmakla birlikte, tek başına tür değiştirmenin gerçekleşmesi (hükümlerini doğurması) sonucunu doğurmaz; türü değişecek olan şirketin yönetim organının, tür değiştirme hakkında bir *rapor hazırlaması* da gerekir (TTK m. 186).

Tür değiştirme raporu, türü değişerek yeni ticaret şirketi türüne veya ticari işletmeye dönüşecek ticaret şirketinin yönetim organı tarafından hazırlanır. Ticari işletmenin ticaret şirketine dönüşmesinde, yönetim organından bahsedilemeyeceğinden, tür değiştirme raporundan da bahsedilememelidir.

Tür değiştirme raporunda belirtilmesi gereken hususlar nazara alındığında, rapora esas olacak bazı bilgi ve belgelerin raporun hazırlanmasında önemli olduğu ve bu bilgi ve belgelerin bulunmaması hâlinde raporun hazırlanamayacağı anlaşılmaktadır.

Tür değiştirme raporunun içeriğini düzenleyen TTK m.186/2'ye göre raporda; tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, yeni şirket sözleşmesi, tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. Bu düzenlemelerden anlaşıldığı üzere, tür değiştirme raporunun hazırlanması ve hatta tür değiştirme plânının yapılmasından önce, tür değiştirme için bazı işlemlerin de yapılması gerekmektedir.

Tür değiştirme raporunun hazırlanabilmesi için ayrıca bir bilançonun da hazırlanması gerekir. Bu husus TTK m. 184/2'de, *"bilanço günüyle tür değiştirme raporunun düzenlendiği tarih arasında altı aydan fazla zaman geçmişse veya son bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren şirketin malvarlığında önemli değişiklikler meydana gelmişse ara bilanço çıkarılır"* şeklinde hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, Kanun koyucu bir "bilanço" çıkarılmasını ve eğer gerekirse ara bilanço çıkarılmasını öngörmüştür.

Tür değiştirme raporu, türü değişen ticaret şirketinin ortaklarını bilgilendirmeye hizmet eden bir belgedir. TTK m.186 uyarınca *şirket yönetim organı* tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. Hazırlanan rapor, tür değiştirmeye ilişkin genel kurul karar tarihinden önceki 30 gün boyunca *ortakların bilgisine* sunulmak zorunda olduğundan, yönetim organının genel kurul karar tarihinden 30 gün öncesinde raporu hazır etmiş olması gerekmektedir.

Tür değiştirme raporunun içeriğinde nelerin yer alması gerektiği, TTK m. 186/2'de belirtilmiş olup buna göre; raporda; (1) tür değiştirmenin amacı ve sonuçları, (2) yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin

yerine getirilmiş bulunduğu, (3) yeni şirket sözleşmesi, (4) tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı, (5) varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, (6) ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri gösterilir. Buna ilave olarak TTK m. 186/2'de belirtilmemiş olmakla birlikte, öngörülmüşse denkleştirme akçesi, gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri; gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, *hukuki ve ekonomik* yönden açıklanmalı ve gerekçeleri de ihtiva etmelidir.

Tür değiştirme raporunun sağladığı bilgiler, pay sahiplerine yöneliktir. Tür değiştirme neticesinde ortaya çıkacak hukuki statülerinin, oy hakkı dağılımının, hak ve yükümlülüklerinin öğrenilmesinde ortakların önemli menfaati bulunmaktadır. Ancak *küçük ve orta ölçekli şirketlerde,* ortakların tamamının onaylaması halinde tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçilebilecektir (TTK m. 186/3).

Tür değiştirme hakkındaki raporun, yönetim organı tarafından *yazılı olarak* hazırlanması gerekir; yazılı şekil, raporun hazırlanmış sayılabilmesi için geçerlilik şartıdır. Bu yazılı şekil, muhtevasının asgari unsurları kanun koyucu tarafından belirlendiği için; nitelikli yazılı şekil olarak kabul edilmelidir.

C) ORTAKLARIN İNCELEME HAKKI

Kanun koyucu, ortakların tür değiştirme hakkında bilgi edinebilmesi ve inceleme yapabilmesi için tür değiştirmeyle ilgili önemli bazı belgelerin genel kurul toplantısı öncesinde incelemeye açılması gerektiğini hükme bağlamış; Türk Ticaret Kanunu'nun 188'inci maddesinde bu ihtiyacın giderilmesine yönelik bir düzenlemeye yer verilmiştir. Anılan düzenlemeye göre şirket, *i)* Tür değiştirme planını, *ii)* Tür değiştirme raporunu ve *iii)* Son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel kurulda karar alınmasından *otuz gün önce* merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde *ortakların incelemesine* sunmakla yükümlüdür.

Türk Ticaret Kanununun 188'inci maddesinde, ortakların inceleme hakkına sahip olduğu belgeleri tetkik edebilmelerini teminat altına almak maksadıyla ayrıntılı bir düzenlemeye yer verilmiştir. Hangi belgelerin incelemeye konu teşkil edeceği de TTK m.188/1'de üç bent

hâlinde hükme bağlanmıştır. Buna göre, birleşmeye katılan şirketlerden her biri; (1) tür değiştirme plânını, (2) tür değiştirme raporunu ve (3) son üç yılın finansal tablolarını, varsa ara bilançoyu, genel kurulda karar alınmasından *otuz gün önce* merkezinde ve halka açık anonim şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun istediği yerlerde ortakların incelemesine sunmakla yükümlüdür.

Madde metninde geçen "*30 gün önce*" ifadesinin, "*karar tarihinden önceki 30 gün boyunca*" şeklinde anlaşılması uygun olur. Aksi halde ortakların bilgi alma ve inceleme hakkının teminat altına alınması için yapılan düzenleme, bu hakların kısıtlanmasının bir aracı haline gelir.

Türü değişen şirketin, inceleme hakkına konu belgeleri nereye tevdi ettikleri ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını ortakları nasıl bilgilendireceklerine ilişkin doğrudan bir hüküm TTK m. 188'de öngörülmemesine karşın, "*Şirket, ortakları, uygun bir şekilde inceleme haklarının bulunduğu hususunda bilgilendirilir*" hükmünden hareketle; inceleme hakkı konusunda ortakların bilgilendirilmesi ve bu bağlamda, belgelerin tevdiinden evvel Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirket sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ilân edilmesi ve eğer türü değişen şirket internet sitesi açma yükümlülüğü olan bir şirket ise, ayrıca internet sitesinde ilân edilmesi uygun olur.

Kanun koyucu, "*merkez*" ifadesini kullandığı için, incelemeye sunulacak belgelerin sadece merkezde hazır bulundurulması gerekir; şubelerde incelemeye hazır tutulmasına ihtiyaç yoktur. TTK m. 188'de belirtilmemesine karşın; tür değiştiren şirket, internet sitesi açmak zorunda olan şirketlerden ise, ayrıca şirketin internet sitesinde de incelemeye konu belgeler yayınlanması gerekir.

Yukarıda bahsedilen düzenlemeler sayesinde ne surette bu belgeleri inceleyebileceklerini öğrenen ortaklar, herhangi bir bedel ödemeksizin incelemeye konu belgelerin suretlerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler (TTK m. 188/2).

Tüm ortakların onaylaması hâlinde *küçük ve orta ölçekli şirketlerde* tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebileceğini kabul eden kanun koyucu, inceleme hakkı için yasal bir istisnaya yer vermemiş; bu tür şirketlerde dahi tüm ortakların onaylaması hâlinde, inceleme hakkından vazgeçilebileceğine ilişkin bir düzenlemede bulunmamıştır.

D) TÜR DEĞİŞTİRME KARARI

Tür değiştirme sürecinin tamamlanması bakımından kanunun öngördüğü bir diğer işlem, tür değiştirme planı ile yeni türün şirket *sözleşmesinin genel kurul* tarafından onaylanmasıdır (TTK m. 189). Ancak, genel kurul onayının sadece ticaret şirketinin yeni bir ticaret şirketine ve ticaret şirketinin, ticari işletmeye dönüşmesinde aranacağı ihmal edilmemelidir. Ticari işletmenin, ticaret şirketine dönüşmesinde, ticari işletmenin genel kurulundan ve genel kurul onayından bahsetme imkânı yoktur.

Tür değiştirme kararı için Türk Ticaret Kanununda özel *toplantı ve karar nisaplarına* yer verilmiştir. TTK m. 189/1'e göre;

Yönetim organı tür değiştirme planı ile yeni türün şirket *sözleşmesini genel kurula sunar.* Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır:

a) Kanunun 421'inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklı olmak şartıyla *anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde*, esas veya çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların üçte ikisiyle; *limited şirkete dönüştürme hâlinde*, ek ödeme veya kişisel edim yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla;

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların onayıyla;

c) *Limited şirketlerde*, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, ortakların dörtte üçünün kararıyla;

d) *Kooperatiflerde;*

1. Ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla,

2. Ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla,

e) *Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme planı bütün ortakların oybirliğiyle* onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir.

E) TÜR DEĞİŞTİRMENİN GEÇERLİLİK KAZANMASI

Ticaret şirketinin yeni bir ticaret şirketine ve ticaret şirketinin, ticari işletmeye dönüşmesi hâllerinde *yönetim organı, tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirir.* Tür değiştirme *tescil ile hukuki geçerlilik kazanır* (TTK m. 189/2); bu bakımdan tescil, *kurucu etkiye* sahiptir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır (TSY m.131/2).

Bir ticari işletmenin bir ticaret şirket türüne dönüşmesi halinde, ticari işletmeyi işletenlerin, yeni türün tescili için zorunlu olan olguların tescili ile birlikte tür değişikliği nedeniyle ticari işletmeye ilişkin kayıtlarda gerekli değişiklikleri yapması gerekir. Tescil, eski türün sicil kaydı üzerinden yapılır (TSY m. 135/2).

Tür değiştirme kararının ilânı, hem üçüncü kişiler hem de Türk Ticaret Kanununun 190'ıncı maddesi gereği, "*ortakların kişisel sorumlulukları ve iş ilişkilerinin geçmesi*nin" uygulanması yönünden önem taşıdığından, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir (TTK m. 189/2); ilân bildiricidir.

IV) TİCARET ŞİRKETLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMIŞ ŞEKİLDE TÜR DEĞİŞTİRMESİ

Türk Ticaret Kanununda "*sermaye şirketlerinin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi*" hükme bağlanmış (TTK m.155-156); buna karşılık "*kolaylaştırılmış tür değiştirme*" düzenlenmemiştir.

Kolaylaştırılmış usulde tür değiştirme, Türk Ticaret Kanununda açıkça düzenlenmemekle birlikte, "*tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler*" (TTK m.186/3) hükmüyle, bir kolaylık öngörülmüş; dolaylı da olsa kolaylaştırmadan bahsetmiştir.

V) TÜR DEĞİŞTİRMENİN HÜKÜMLERİ

A) GENEL OLARAK

Türk Ticaret Kanunu m. 189/2 gereği, tür değiştirme *tescil ile hukuki geçerlilik kazanır.* Tür değiştirmenin *tescil ile hukuki geçerlilik kazanacağını* hükme bağlayan kanun koyucu; ticaret siciline tescilin sonuçları ile ilgili düzenlemelere ayrıca yer vermemiştir. Buna karşın; tür değiştirmenin tüm hükümlerinin diğer düzenlemelerle birlikte değerlendirilmesi suretiyle, tür değiştirmenin hükümleri belirlenebilir.

Bu kapsamda tür değiştirmenin ilk sonucu, yeni türe dönüştürülen şirketin *eskisinin devamı* olmasıdır. Tür değiştirmenin diğer bir sonucu *ortaklığın devamlılığı ilkesi* uyarınca ise, kural olarak, türü değişen şirketin ortaklarının *ex lege* (kanundan dolayı) yeni türdeki şirketin ortağı olmasıdır.

B) ALACAKLILARIN VE ÇALIŞANLARI KORUNMASI

TTK m. 190'da, *ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158'inci ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında 178'inci maddelerinin uygulanacağı* hükme bağlanmıştır.

1) Alacaklıların Korunması

TTK m. 190'ın başlığı, *"alacaklıların ve çalışanların korunması"* olmasına karşın; alacakların teminat altına alınmasına ilişkin bir yollamaya yer verilmemiş; sadece, ortakların kişisel sorumluluklarına ve iş sözleşmelerinden doğan borçlarına atıf yapılmasıyla yetinilmiştir. *"Yeni türe dönüştürülen şirket eskisinin devamıdır"* (TTK m. 180) hükmü nazara alındığında, bu durum bir eksiklik sayılmaz; alacaklılar alacaklarını, yeni türe dönüştürülen şirketten alabilirler.

Buna karşın, *ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesinde,* alacakların teminat altına alınmasına ilişkin bir yollamaya yer verilmemiş olması bir eksiklik olarak kabul edilir. Zira her ne kadar TSY m. 134/2'de, "*dönüşme sonucunda meydana gelen ticari işletme dönüşen ticaret şirketinin devamıdır*" ifadesine yer verilmişse de, Türk Hukukunda ticari işletmelere kişilik tanınmadığından, ticari işletme ticaret şirketinin devamı sayılamaz. Bu durumda şirket tüzel kişiliğinin hak ve yükümlülüğünün, ticari işletmeye dönüşen ticari işletmeye değil; ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletenlere külli halefiyet ilkeleri çerçevesinde intikal edeceği kabul edilmelidir. Külli halefiyet ilkesinin geçerli olduğu *ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesinde, alacakların teminat altına alınmasına* ilişkin bir yollamaya yer verilmemiş olması bir eksiklik görülmelidir.

2) Ortakların Sorumlulukları

TTK m. 190'da yapılan atıf gereği, ortakların kişisel sorumlulukları hakkında 158'inci madde hükmü uygulanacaktır.

TTK m. 158'in tür değiştirmeye tatbikinde, türü değişen şirketin veya tür değiştirerek ticaret şirketine dönüşen ticari işletmenin borçların-

dan, tür değiştirmeden önce sorumlu olan ortakların sorumluluklarının, tür değiştirmeden sonra da devam edeceği kabul edilmiştir. Şu şartla ki, bu borçlar tür değiştirme kararının ilânından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten önce oluşmuş bulunmalıdır (TTK m. 158/1).

Tür değiştiren şirketin borçlarından doğan, ortakların kişisel sorumluluğuna ilişkin istemler, tür değiştirme kararının ilânı tarihinden itibaren *üç yıl* geçince *zamanaşımına* uğrar. Alacak ilân tarihinden sonra muaccel olursa, zamanaşımı süresi muacceliyet tarihinden başlayacaktır. Bu sınırlama, türü değişen şirketin borçları dolayısıyla şahsen sorumlu olan ortakların sorumluluklarına uygulanmaz (TTK m. 158/2).

TTK m. 158/3 hükmüne göre, kamuya arz edilmiş olan tahvil ve diğer borç senetlerinde sorumluluk itfa tarihine kadar devam eder; yeter ki izahnâme başka bir düzenleme içermesin.

Ticaret şirketlerinin ticari işletmeye dönüşmesinde sorumluluğun; ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletenlerin sorumluluğu ve ticari işletmeye dönüşen ticaret şirketinin ortaklarının sorumluluğu açısından ayrı ayrı incelenmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Türk Hukukunda ticari işletmelere kişilik tanınmadığı için, şirket tüzel kişiliğinin hak ve yükümlülüğü, ticari işletmeye dönüşen ticari işletmeye değil; ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletenlere ait olacaktır (TTK m. 194/3, c. 2).

TTK'de, ticari işletmeye dönüşecek ticaret şirketinde, ortakların sorumluluğuyla ilgili genel bir düzenlemeye yer verilmemiş; sadece, ticari işletmeye dönüştürülen kollektif ve komandit şirketinin borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu hükme bağlanmıştır. Bu durumun hükme bağlandığı TTK m. 194/3, c. 2'deki hükme göre, *ticari işletmeye dönüştürülen kollektif veya komandit ticaret şirketinin borçlarından,*esas itibariyle ticari işletmeyi işletenler sorumlu olacak*;* ticari işletmeyi işletenler yanında, *ticaret şirketinin eski ortakları da TTK m. 264'üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olacaklardır.*

TTK'de ticari işletmeye dönüşecek ticaret şirketinde sorumlulukla ilgili genel bir düzenlemeye yer verilmemiş olmasına karşın; TSY m.134/3'te, *"(Ticari işletmeye) Dönüşen şirketin ortaklarının kişisel sorumlulukları ve iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında Kanunun 190 ıncı maddesi ile 194 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri*

uygulanır" ifadelerine yer verilerek; tüm ticaret şirketlerinde, ticari işletmeye dönüşen şirket ortaklarının, dönüşmeden evvelki sorumluluklarının aynen devam edeceği kabul edilmiştir.

Hâkim kararıyla ticari işletmeye dönüştürülen kollektif veya komandit şirketinin borçlarına ilişkin TTK m. 183/3'de hüküm bulunmamasına karşın; ticari işletmeyi işletecek kişi ile birlikte, ticaret şirketinin eski ortaklarının da, TTK m. 264 üncü maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu olacaklarının (TTK m. 194/3) kabul edilmesi gerekir.

3) İş İlişkileri

TTK m. 190'da yapılan atıf gereği, iş sözleşmelerinden doğan borçlar hakkında 178'inci madde madde hükmü uygulanacaktır[601].

[601] Bu hususta bkz. yukarıda Onbeşinci Bölüm, § 24, VIII, B, 3.

§ 26- YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Kanun koyucu, birleşme, bölünme ve tür değiştirme ile ilgili olarak *"ortak hükümler"* başlığı altında; *"ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının incelenmesi"* ve *"birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları"* hakkında iki ayrı düzenlemeye yer vermiştir. Bu hükümler, yapısal değişikliklerin mahiyetine uygun olduğu nispette, tüm yapısal değişiklik hâllerinde uygulama alanı bulur.

I) ORTAKLIK PAYLARININ VE ORTAKLIK HAKLARININ İNCELENMESİ İLE DENKLEŞTİRME AKÇESİNİN TESPİTİ

Yapısal değişikliklerde kural olarak[602], inceleme hakkının öngörüldüğü yukarıda ifade edilmişti. TTK m. 191'de ise, inceleme hakkının kullanılması sonucunda ortaya çıkması muhtemel haksızlıkların nasıl giderileceği hükme bağlanmıştır. Kanun koyucu, TTK m. 191 düzenlemesiyle, bu haksızlığı gidermeyi amaçlamış; ortağa inceleme hakkının verilmesini yeterli görmeyerek, genel kurulda çoğunluk karşısında hakkı ihlâl edilen ortağa, dava açma hakkını tanımıştır.

Ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmadığını veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmediğini iddia eden *ortak tarafından* açılacak bu davada; ortak, asliye ticaret mahkemesinden, uygun bir *denkleştirme akçesinin saptanmasını* isteyebilecektir.

Bir diğer söyleyişle, TTK m. 191'de hükme bağlanan bu davayla, yapısal değişiklik sonucunda, ortaklık paylarının ve ortaklık haklarının gereğince korunmadığını veya ayrılma karşılığının uygun belirlenmediğini iddia eden ortağın, sadece uygun bir denkleştirme akçesinin tespitini isteyebileceği kabul edilmiştir. Burada her nekadar denkleştirmenin tespiti denilmişse de açılan davada, Mahkeme, birleşme sözleşmesini ve bölünme ya da tür değiştirme sözleşmesini/planını inceleyerek *olması gereken karşılığın ödenmesini karara bağlayacağından* TTK

---

602 Bilindiği üzere, TTK m. 149/5 hükmü uyarınca birleşmede ve TTK m. 171/2 gereği bölünmede, *tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler inceleme hakkının kullanılmasından* vazgeçebilmektedir.

m. 191 gereğince açılacak davanın, bir eda davası olduğu sonucuna varılmakta; ortağın denkleştirme akçesi isteyebileceği kabul edilmektedir.

TTK m. 191'de nitelendirilen ve gerekçede inceleme yahut yeniden yapılandırma davası olarak adlandırılan bu davada, *davacı olma sıfatı*, yapısal değişiklik öncesinde şirkete ortak olanlara tanınmıştır.

Davanın, yapısal değişiklik işlemlerine katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde açılabileceği hükmünden hareketle, hem eski hem yapısal değişiklik sonucunda oluşan şirketlere karşı açılabileceği şeklinde bir sonuç ortaya çıkıyorsa da; davalının, yapısal değişiklik sonucunda oluşan şirket veya şirketler olacağının kabulü gerekir. Zira yapısal değişiklik sonucunda, kimi ihtimallerde, yapısal değişikliğe giden şirketlerin tüzel kişiliği sona ermektedir.

Yapısal değişiklik sonucunda, yapısal değişikliğe giden şirket veya şirketlerin tüzel kişiliği sona eriyorsa; *yetkili mahkeme*, yapısal değişiklik sonucu ortaya çıkan şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir. Kısmi bölünmede olduğu gibi, bölünen şirketin tüzel kişiliği sona ermiyorsa; yetkili mahkeme, bölünme işlemlerine katılan şirketlerden birinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Görevli mahkeme, TTK m. 191'deki açık ifadeye göre, asliye ticaret mahkemesidir.

Davanın birleşme, bölünme veya tür değiştirme kararının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilânından itibaren *iki ay içinde* açılması gerekir; bu iki aylık süre, hak düşürücü bir süredir.

TTK m. 191/2'de, *"davacı ile aynı hukuki durumda bulunmaları hâlinde, mahkeme kararı, birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin tüm ortakları hakkında da hüküm doğurur"* denilerek; mahkeme kararının aynı hukukî durumdaki ortaklara da uygulanacağı (class action) hükme bağlanmıştır. Buna göre, aynı hukukî durumdaki ortaklar, ayrıca dava açmadan, davacı ortakla ilgili karara dayanarak; denkleştirme akçesi isteyebileceklerdir.

II) BİRLEŞMENİN, BÖLÜNMENİN VE TÜR DEĞİŞTİRMENİN İPTALİ

TTK m. 192'de, *"Birleşmenin, bölünmenin, tür değiştirmenin iptali ve eksikliklerin sonuçları"* kenar başlığı altında; birleşme, bölünme ve

tür değiştirmeye ilişkin TTK m. 134 ilâ 190'ıncı maddelerin ihlâli hâlinde, *yapısal değişikliğin iptalinin* istenebileceği; 134 ilâ 190'ıncı maddelerin ihlâlinin iptali gerektirecek nitelikte olmaması hâlinde ise, *mahkemenin bunun giderilmesi için süre verebileceği,* özel olarak hükme bağlanmıştır.

Burada belirtmek gerekir ki, TTK m. 192/1'de yapısal değişiklik kararının iptaline ilişkin özel bir düzenlemeye yer verilmesi; yapısal değişiklik kararının, sakatlığın niteliğine göre, *yokluk* veya *butlanının*, genel hükümler çerçevesinde istenemeyeceği anlamına gelmez. Bu bağlamda mesela, yapısal değişiklik kararının yetkisiz bir organ tarafından verilmesi, birleşme veya bölünme sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmaması ve birleşme sözleşmesinde değişim oranının belirlenmemiş olması gibi hâllerde, sakatlığın mahiyetine göre; TTK m. 192/1'den bağımsız olarak, yapısal değişikliğin yokluğunun veya butlanının tespiti istenebilir.

Yapısal değişiklik süreçlerinin, kanunda belirtilen esaslara riayet edilerek gerçekleştirilmesinin, ortakların menfaatini korunması bakımından önemli olduğu noktasından hareket eden kanun koyucu; sermaye şirketlerinin yanı sıra kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarını da kanuna aykırı yapısal değişikliklerden korumak ve yapısal değişikliğe dair alınan kararın bir yönetim organı tarafından verildiği durumlarda bu organın kararına karşı iptal davası açılabilmesini sağlamak amacıyla hareket etmiştir.

Kanun koyucunun amacı, yapısal değişiklik kararına karşı ortakları korumaktır. Bu nedenle, TTK m. 192/1'de düzenlenen yapısal değişikliğin iptali davasının, çalışanların, alacaklının ya da iştirakçinin korunmasına dair olan kanun maddelerinin ihlal edildiği gerekçeleriyle açılamaması gerekir.

TTK m. 192/1'de düzenlenen ve sadece 134 ilâ 190'ıncı maddelerinin ihlâli sebebine dayanılarak açılan bu davada davacı, var olan bir hukuki durumun kaldırılmasını talep ettiğinden, "*yapısal değişikliğin iptali*" davası, "*inşai*" (yenilik doğuran) nitelikte bir dava; mahkemenin vereceği iptal kararı da, inşai mahiyette bir karardır. Yenilik doğuran (*inşai*) davalarda, davacının hukuki yararını ispat yükümlülüğü bulunmadığı için; davacının, sadece yapısal değişiklik esaslarına riayet edilmediğini ispat etmesi yeterlidir.

Ancak, inşai nitelikteki bu davada mahkemenin vereceği kararın mutlaka inşai bir hüküm olması gerekmez; aşağıda da ifade edileceği

üzere, birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde, giderilebilecek herhangi bir eksikliğin varlığı hâlinde, mahkeme iptale karar vermek yerine, taraflara bu eksikliklerin giderilmesi için süre verir (TTK m. 192/3). Taraflara, eksikliğin giderilmesi maksadıyla süre verilmesi ve verilen süre içinde eksikliklerin giderilmesi hâlinde, inşai dava reddedilmiş olur. Bu ret kararı inşai bir hüküm değil, bir tespit hükmüdür; eksikliklerin giderildiği, bu nedenle bir inşai hakkın kalmadığı tespit edilmiş olur.

Belirtmek gerekir ki, TTK m. 192/1'de düzenlenen *yapısal değişikliklerin iptali davası*, genel kurul kararlarının iptaline (TTK m. 445-446; 622) dair öngörülen genel iptal davasına nispetle *lex specialis (özel hüküm)* mahiyetindedir. Buna göre, yapısal değişikliğin iptalini talep eden ortağın, TTK'nın 134 ilâ 190'ıncı maddelerine aykırılığın varlığını ispat etmesi yeterli olacaktır. Ancak, TTK m. 192/1'de hükme bağlanan bu özel hüküm, anonim (TTK m. 445-446) ve limited şirketler (TTK m. 622) ile kooperatiflerde kabul edilen (KoopK m. 53) genel iptal davasının açılmasına engel değildir; ortak, TTK m. 192/1'e göre dava açabileceği gibi, dava şartlarının oluşması kaydıyla, genel iptal sebeplerine göre de davasını ikame edebilir.

Yapısal değişikliğin iptali davasının konusu, yapısal değişiklik ile ilgili münferit işlemlerin iptali değil; sadece *yapısal değişiklik kararının iptalidir. Bu bağlamda, yapısal değişiklik işlemlerinden, mesela, yapı*sal değişiklik raporunun iptali dava konusu yapılamaz; sadece yapısal değişiklik raporunun usulüne uygun hazırlanmadığı gerekçe gösterilerek, yapısal değişiklik kararının iptali istenebilir.

Yapısal değişikliğin iptali davasının konusu, *yapısal değişiklik kararının* iptali olduğu için, yapısal değişikliğin genel kurulda kabul edilmemesi üzerine, TTK m. 192/1'e göre dava açılamaz; şartları varsa ve kanun koyucu cevaz vermişse, genel iptal davası açılması gerekir.

Yapısal değişikliğin iptali davasının davacısı; birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına *olumlu oy vermemiş* ve *bunu tutanağa geçirmiş* bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür değiştirmeye katılan şirketlerin ortaklarıdır. TTK m. 192/1'de, TTK m. 446'da olduğu gibi "*olumsuz oy vermiş olma*" şeklinde bir ifadeye yer verilmemiş; sadece yapısal değişiklik kararına olumlu *oy vermemiş* ortaklardan bahsedilmiştir. Bu hâlde, çekimser oy kullanan ortak, çekimser oy kullandığını tutanağa geçirmişse; çekimser oy kullanan ortağın da dava açabileceği kabul edilmelidir.

Belirtmek gerekir ki, yapısal değişikliğin iptali davası, sadece genel kurulun yapısal değişiklik kararına karşı açılan bir dava değildir. Sermaye şirketleri arasında gerçekleşen kolaylaştırılmış birleşmede olduğu gibi (TTK m. 156) yapısal değişiklik kararı, yönetim organı tarafından verilmişse; yönetim organının kararının iptali de dava edilebilir (TTK m. 192/2).

Yapısal değişikliğin iptali davasının açılabilmesi için; ortağın, yapısal değişiklik kararının alındığı esnada, yapısal değişikliğe iştirak eden şirketin ortağı olması gerekir. Genel kurul kararının alınmasından sonra paylarını devreden bir pay sahibinin, ortak sıfatı ile iptal davası açması veya açtığı bir iptal davasına devam etmesi mümkün değildir[603].

Yapısal değişikliğin iptali davasında *davalı sıfatı*, yapısal değişiklik sonucunda ortaya çıkan yeni şirkettir. Tescil işlemi öncesinde TTK m. 192/1'e göre, "*geçerli bir yapısal değişiklik kararı*" bulunmadığı için, özel iptal usulünden faydalanılamaz; yapısal değişikliğin tescilden önceki aşamada, şartların varlığı hâlinde genel nitelikteki iptal davası açılabilir.

Yapısal değişikliğin iptali davasının, iptal kararının alındığı genel kurul toplantısında ortak sıfatını taşıyanlar tarafından, *yapısal değişiklik kararının alındığı tarihten değil*; kararın *Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilânından itibaren iki ay içerisinde* açılması gerekir. İlânın gerekmediği hâllerde, iki aylık süre, kararın tescil tarihinden itibaren işlemeye başlar (TTK m. 192/1, son cümle). TTK m. 192/1'de öngörülen bu iki aylık süre, hukuki mahiyeti itibariyle hak düşürücü süredir; hâkim tarafından re'sen dikkate alınır.

Yapısal değişikliğin iptali davasında, TTK m. 191'de düzenlenen "*Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi (denkleştirme)*" davasından farklı olarak, görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi olduğu belirtilmemiş olmasına karşın; birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin TTK'de düzenlendiği ve TTK m. 5/1 nazara alındığında, iptal davasında görevli mahkemenin "*asliye ticaret mahkemesi*" olacağı hususunda bir tereddüt olmamalıdır.

Yapısal değişikliğin iptali davasında, yetkili mahkeme hakkında, doğrudan bir sonuca varmak mümkün değildir. Zira yukarıda da ifade edildiği üzere, kimi yapısal değişiklik sonrası; yapısal değişikliğe katılan şirketlerin tüzel kişiliği sona ermekte; tüzel kişiliği sona eren bu

---

[603] Bu hususdaki tartışmalar için bkz., **Narbay, Ş. / Kesici, B.**, s.119.

şirketlere karşı dava açma imkânı bulunmamaktadır. Buna göre yetkili mahkemenin birleşmede, devralan veya yeni kurulan şirket merkezinin bulunduğu yer; tam bölünmede, devralan şirketin, kısmi bölünmede gerek devreden gerekse devralan şirketin merkezinin bulunduğu yer; tür değiştirmede ise, yeni tür şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olacağının kabulü gerekir.

III) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SORUMLULUK

TTK m.193/1'de, *"Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar"* denilmek suretiyle, yapısal değişikliklerle ilgili olarak hukuki sorumluluk esası belirlenmiştir.

Yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan *kişilerin* hukuki sorumluluğu için açılan davalar, sözleşmeye veya haksız fiile dayanan davalardan büyük bir farklılık göstermez; zarar ve buna bağlı olarak tazminat, Türk Borçlar Hukuku ilkelerine göre belirlenir. Hukuki sorumluluğun şartları ise, genel bir prensip olarak TBK m. 49'da hükme bağlanmış; haksız fiil sorumluluğuna ilişkin bu hükümlerin kıyas yoluyla sözleşmeye aykırılık hallerine de uygulanacağı kabul edilmiştir (TBK m. 114/2).

TTK m. 193'te, yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan *bütün kişilerin, kusurlarıyla verdikleri zararlardan* dolayı; yapısal değişikliğe katılan *şirketlere,* bu şirketlerin *ortaklarına ve alacaklılarına* karşı sorumlu olduğu kabul edilmiş ve fakat yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan *kişilerin* kim olduğuna ayrıca temas edilmemiştir.

Yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilerin sorumluluğu, bir *kusur sorumluluğudur.* Yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilerin TTK m.193'e istinaden hukuki sorumluluklarına hükmedilebilmesi için *zarar, kanuna aykırılık, kusur* ve *illiyet bağı* koşullarının gerçekleşmiş olması gerekir.

Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumlu olduğunu ayrıca

hükme bağlayan kanun koyucu; bu özel hükmün uygulanmasında bazı hâlleri saklı tutmuş, genel hükümlere atıf yapmıştır.

Saklı tutulan bu hükümlerin başında, kurucuların sorumlulukları vardır (TTK m. 193/1). Kanun koyucu bu düzenlemeyle, birleşme ve bölünme sonucunda yeni bir şirket kurulması durumunda; sorumluluk hükümleri bakımından, yeni şirketin kuruluşundaki sorumluluk hükümlerinin uygulanacağını kabul etmiştir.

Kanun koyucunun, yapısal değişiklik işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin sorumluluğunda saklı tuttuğu diğer bir hüküm; şirketler topluluğuna ilişkin olan 202 ilâ 208'inci maddeleridir. Buna göre, yapısal değişiklikler bir şirketler topluluğu içinde gerçekleşmişse; şirketler topluluğunda sorumluluk ilişkilerinin düzenlendiği hükümlerin öncelikle uygulanması gerekir.

TTK m. 193'te saklı tutulan diğer bir husus, anonim şirket kurucularının, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğunda, şirketin zararı ile ilgili olarak hükme bağlanan TTK'nin 555, 557 ve 560'ıncı madde hükümleridir. Buna göre, yapısal değişiklikler sebebiyle, yapısal değişikliği işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin, şirkete vermiş olduğu zararların tazmini, TTK m. 555 ve 557 çerçevesinde talep edilecek; sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve herhâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır (TTK m. 560).

Kanun koyucu ayrıca, bir sermaye şirketinin veya kooperatifin iflâsı hâlinde, 556 ve 570'inci maddeler ile Kooperatifler Kanunu'nun 98 inci maddesi kıyas yoluyla uygulanacağını kabul etmiştir.

A. SORUMLULUK DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Yapısal değişikliklerin TTK'de düzenlendiği nazara alındığında, yapısal değişikliği işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişilerin sorumluluğuna ilişkin davaların ticari dava (TTK m. 4/1); bu davalarda görevli mahkemenin de, asliye ticaret mahkemesi olduğu kabul edilmelidir (TTK m. 5).

Yapısal değişikliği işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan kişilerin sorumluluğu, bu kişilerin şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan dolayı sorumluk olduğu kabul

edildiğinde; hukuka aykırı fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesinin yetkili olduğu söylenebilir (HMK m. 16).

B. ZAMANAŞIMI

Tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır (TBK m. 72/1).

Kural böyle olmakla beraber, TTK m.193'de, TTK m. 560 hükmü saklı tutulduğu için, yapısal değişiklik nedeniyle ortaya çıkan anonim şirketlerde şirketin zararı ile ilgili olarak kurucular, yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler aleyhine açılacak sorumluluk davasında; zamanaşımının, davacının zararı ve sorumluyu öğrendiği tarihten itibaren iki ve herhâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacağı unutulmamalıdır. Şu kadar ki, bu fiil cezayı gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tâbi bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır.

IV) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERDE SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİ

Birleşme, bölünme ve tür değiştirme gibi yapı değişiklikler ile ayni sermaye konulması veya ticari işletmelerin devralınması sonucunda, tapu ve gemi sicili ile fikrî mülkiyete ilişkin sicillerde ve benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların sahipliklerinde meydana gelen değişikliklerin ilgili sicillere bildirilmesi ve sicil kayıtları ile belgelerindeki gerekli değişikliklerin yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksadıyla; Ticaret Bakanlığı tarafından, 31.10.2012 tarihli Resmi Gazetede, "*Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ*" (SAİT) çıkartılmıştır.

ONALTINCI BÖLÜM

§ 27- ŞİRKETLER TOPLULUĞU

LİTERATÜR

Yılmaz, A., Türk, İsviçre ve Alman Hukuklarında Şirketler Topluluğuna Güvenden Doğan Sorumluluk, Ankara 2010; *Göktürk, K.*, Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Esasları (Anonim Şirketlerden Oluşan Topluluklar Bakımından), Ankara 2015; *Akın, İ.*, Şirketler Topluluğu Sorumluluk Hukuku, İstanbul 2014; Karşılaştırmalı Şirketler Topluluğu Hukuku - 80. Yaş Gününde Prof. Dr. Ünal Tekinalp'e Saygı Konferansı; *Aytaç, Z.*, *"Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakimiyetinin Hukuka Aykırı Kullanılmasından Doğan Sorumluluğu"*, BATIDER, 2013, C. 29, S. 5, s. 5- 55.

I) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA İLİŞKİN DÜZENLEMENİN AMACI VE KAPSAMI

Hukuk düzeni, gerçek kişilerin haricinde, bazı kişi ve mal topluluklarına haklara ve borçlara sahip olma iktidarı, başka bir ifadeyle *"hak süjesi"* (kişi) olma niteliği tanımış; bunları tüzel kişi olarak adlandırmıştır (TMK m.47).

Tüzel kişiler, bir hak süjesi olarak, insana özgü niteliklere bağlı olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildir (TMK m.48); kanuna ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla, fiil ehliyetini kazanırlar (TMK m.49). Tüzel kişinin iradesi, organları aracılığıyla açıklanır (TMK m.50/1); organlar hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar (TMK m.50/2).

Kanun koyucu, ticaret şirketlerine de tüzel kişilik izafe etmiş (TTK m.125/1); organların hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle ticaret şirketlerini borç altına sokacağını kabul etmiştir (TTK m.125/2).

Ticaret şirketleri gibi kişi birliği grubuna dâhil olan tüzel kişiler, kendilerine vücut veren kişilerden ayrı bir kişiliğe sahip ise de; kendi hak ve menfaatlerini korumalarını sağlayacak somut görünümleri, çıkar

duyguları, çıkarlarını korumaya yönelik zihinsel ve fiziki unsurları bulunmamaktadır. Bu menfaatlerin korunması ve tüzel kişinin faaliyetlerinin yürütülmesi tüzel kişinin organlarına bırakılmıştır.

Tüzel kişinin faaliyetlerini organları vasıtasıyla yürütmesi, tüzel kişinin menfaatlerini korumaları bakımından yetersiz bulunmaları gerçeğini ortadan kaldırmamakta; organ üyeleri ile tüzel kişilik arasında *olası bir çıkar çatışmasında*, organların veya organ üyelerinin tüzel kişiliğin menfaatleri yerine, başkaca çıkarlara hizmet etmesi her zaman ihtimal dâhilinde bulunmaktadır.

Bu gerçekten hareket eden kanun koyucu, *tüzel kişinin organlarına*, tüzel kişinin menfaatlerini korumak bakımından *bazı yükümlülükler* tahmil etmiş; organın, tüzel kişi menfaatleri yerine, başkaca menfaatleri gözetmesini, çeşitli şekillerde yaptırım altına almıştır.

Ticaret şirketlerinin organlarının, sadece şirket menfaatini gözeterek faaliyette bulunması; şirket menfaatlerine aykırı olan işlem ve eylemlerden kaçınması yükümlülüğü, kendi menfaatini korumada yetersiz bulunan tüzel kişi bakımından önemli bir teminat olmakla birlikte, bazı ihtiyaçlara cevap vermekte yeterli olamamaktadır.

Gerçekten de, günümüzdeki iktisadi gelişmeler, şirketlerin birbiri ile olan bağlılık ilişkileri; ticaret şirketlerini, başka şirket veya teşebbüslerin etkisi altında faaliyetlerini yürütmek zorunda bırakmaktadır.

Bu halde, *üzerinde hâkimiyet kurulan ticaret şirketi* (bağlı şirket), hukuki olarak *tüzel kişiliğini yitirmemekle birlikte*; şirketin yönetim organı, şirket menfaatine olan karar ve işlemler yerine, kendisi üzerinde hâkimiyet kuran şirket veya teşebbüs tarafından verilen talimatları yerine getirmekte ya da onun yaptığı müdahalelere uygun şekilde hareket etmekte[604]; *organı olduğu şirketin menfaatleri yerine, hâkim şirket veya*

---

[604] Hâkim teşebbüs, her halükarda bağlı şirkete bir şekilde etkide bulunmaktadır. Kanunda, Alman hukukundaki ayrıma uygun olarak (AktG § 308, 311, 323), "*talimat vermek*" (m. 203 vd.) ve "*yöneltmek*" (m.202/1, a) kavramlarına yer verilmiştir. Aşağıda tam hâkimiyet kısmında da belirtildiği üzere ikisi arasındaki fark şu bakımdan ortaya çıkmaktadır: *Talimat* varsa bağlı şirket yönetim kurulu bunu yerine getirmek zorundadır, aykırı davranışı sorumluluğunu gündeme getirir; riayeti kendisini sorumluluktan kurtarır (TTK m.205). *Yöneltmede* ise bağlı şirket yönetim kurulunun bir takdiri vardır; uyup uymaması kendi takdirine kalmıştır, uyma zorunluluğu yoktur (TTK m.202). Kanun metninde "*yöneltmek*" fiili kullanılmasına rağmen (TTK m.202/1, a), yukarıda durumu daha iyi açıklayan

teşebbüsün menfaatlerini gözetmekte ve hatta hâkim şirket tarafından yürütülen işletme politikası gereği, bağlı şirketin zarar etmesine neden olabilecek işlemleri gerçekleştirebilmektedir[605].

Bu durumu nazara alan kanun koyucu, şirketlerin mali güçlerinin müşterek bir politika dâhilinde kullanılmasına imkân sağlanmasını, ekonomik birliğin yanında, topluluk üyelerinin müşterek politika çerçevesinde bağımsızlığını koruyup, kendi inisiyatifleri doğrultusunda hareket edebilmelerini, topluluğun pek çok şirketten oluşması nedeniyle, globalleşen piyasalarda, ülkenin koşullarına kolaylıkla adapte olabilmelerini ve daha birçok avantajın hukuki zeminini oluşturmak amacıyla, "*şirketler topluluğu*" düzenlemelerini hukukumuza dâhil etmiştir.

Ticaret şirketlerinde organların, bağımsız kişiliğe sahip ticaret şirketinin menfaatlerini gözetme yükümlülüğü yerine, bağlılık ilişkisi içinde bulundukları şirketin menfaatini hangi esaslar dâhilinde gözetebileceğini tayin etmek isteyen kanun koyucu; şirketler topluluğunu, şirketler topluluğunda bulunan *hâkim şirket ve bağlı şirketler arasındaki hukuki ilişkileri, karşılıklı hak ve yükümlülüklerini özel olarak düzenlemiştir.*

Bu esastan hareket eden kanun koyucu, Türk Ticaret Kanunu'nun *195-209*'uncu maddeleri arasında, *şirketler topluluğu* kavramını, oluşumunu, *bağlı ve hâkim şirketin hak ve yükümlülüklerini*, hâkimiyetin *hukuka aykırı kullanımından kaynaklanan sorumluluğu, özel denetimi ve güvenden doğan sorumluluğu* ayrı ayrı ele almıştır.

II) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI VE BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ

Genel olarak[606] hukuken birbirinden bağımsız olan ticaret şirketlerinin ortak bir çatı altında toplanmasına cevaz veren kanun koyucu,

---

"*müdahalede bulunmak*" kavramı tercih edilmiş; metin buna uygun şekilde kaleme alınmıştır.

605 Gerekçe, s.134.

606 "*Genel olarak*" ibaresi, aynı cümlede çoğul olarak geçen "*ticaret şirketlerinin*" ifadesi için kullanılmıştır. Zira şirketler topluluğu denildiğinde, m.195/4'te bağlı şirket için kullanılan çoğul ifade nedeniyle, genel olarak bağlı en az iki şirketin bulunması gerektiği düşüncesi hâsıl olmaktadır. Ancak şirketler topluluğunun oluşumu için bir hâkim ve bir bağlı şirketin bulunması yeterlidir. Bu bakımdan, TTK m.195'in lâfzında geçen çoğul ifade, yanıltıcı bir ifadedir. Kanunun diğer hükümleri (ör: m. 195/1,son; m. 203) bir hâkim ve bir bağlı şirketin varlığını,

şirketler topluluğunun doğrudan bir tanımını yapmamış; çeşitli kavramlardan hareket ederek şirketler topluluğuna işaret etmiştir.

A) ŞİRKETLER TOPLULUĞU KAVRAMI

1) Tanımı

"*Hâkim şirkete doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler yavru şirket konumundadır*" (TTK 195/4).

Görüldüğü gibi, kanun koyucu "*şirketler topluluğu*"nu tanımlamamış; sadece hangi hallerde şirketler topluluğunun olacağını hükme bağlamıştır.

Şirketler topluluğunun ele alınış tarzı ve müessesenin mahiyeti nazara alındığında, kanun koyucunun, şirketler topluluğunu oluşturan *doğrudan* veya *dolaylı bağlılık ilişkisini*, kontrol ve hâkimiyet ilişkisine ve kontrol ve hâkimiyet ilişkisinin olup olmadığının tespitini de bir takım *faraziye*[607] ve *karinelere* bağladığı anlaşılmaktadır (TTK m.195/1-2).

Buna göre meselâ, bir şirketin diğer bir şirkette *oy hakkının çoğunluğuna sahip olması* veya *yönetim organında karar alma çoğunluğunu oluşturan sayıda üyeyi seçme imkânına sahip olması* gibi, kanunda belirtilen haller; şirketler arasında hâkim veya bağlı şirket ilişkisinin kurulmasını sağlamakta ve tüm şirketler, bir şirketler topluluğunu oluşturmaktadır. Kanun koyucunun düzenlemesine nazaran, şirketler ara-

---

topluluk için yeterli görmektedir. Bir hâkim ve bir bağlı şirket bulunan hallerde topluluk oluşuyorsa, TTK m.195/5'de geçen teşebbüs kavramı, bu hâkim şirketin yerine ikame edildiğinde, topluluğun oluşumu için bir ticaret şirketinin varlığı yeterli olmaktadır. Neticede bir teşebbüs, sadece bir ticaret şirketine hâkimse, ortada birden fazla ticaret şirketi bulunmamasına rağmen, şirketler topluluğu doğmuş olur. Ticaret Sicil Yönetmeliğinde topluluk için bağlı en az iki ya da üç ticaret şirketinin aranması, kanuni düzenleme ile bağdaşmamaktadır (TSY m. 105). Netice olarak "şirketler topluluğu" kavramının bizatihi lâfzı birden fazla şirketin varlığını gerektirse, hem "şirketler" kavramı hem "topluluk" kavramı bu sonuca teyit etse de, mevcut hukuki yapı, tek bağlı şirket ve bir hâkim işletmeyi yeterli görmektedir. Bu açıdan kanun koyucunun "*şirketler topluluğu*" şeklindeki çoğul çağrışım yapan terim tercihi, kanaatimizce eleştiriye açıktır (195/4 hükmüne nazaran en küçük topluluk ilişkisinin bir hâkim iki bağlı şirketin bulunması halinde söz konusu olacağı yönündeki görüş için bkz. Tekinalp, 2015, N 23-15)

607 Bkz., TBMM Gerekçe, s.136; Faraziye, aksinin ispatı mümkün olmayan kanuni kabulü ifade etmektedir.

sındaki bu hâkimiyet ilişkisi ***fiili*** olarak veya ilgililer arasında yapılan bir ***sözleşme*** icabı da doğabilmektedir.

Bütün bu halleri nazara alan müellifler, şirketler topluluğunu çeşitli şekillerde tanımlamışlar; "*şirketler topluluğu, hukuken bağımsızlıklarını koruyan teşebbüslerin ortak bir yönetme gücü altında birleşerek oluşturdukları ekonomik bir bütündür*" demişlerdir[608].

Başkaca yapılan tanımlarda da benzer özellikler ifade edilmiş; "*şirketler topluluğu, hukuken bağımsız, birden fazla teşebbüsün tek bir malvarlıksal düzen temeli üzerinde tüm ekonomik faaliyetlerini kural olarak ortak bir iradeye ve ortak bir plâna göre sürdürmek durumunda olmaları ve böylece ekonomik bir birlik teşkil etmeleri*" şeklinde tanımlanmıştır[609].

2) Unsurları

Şirketler topluluğunun oluşumunu düzenleyen TTK m.195/4 ve ilgili diğer hükümler esas alındığında, bir şirketler topluluğundan bahsedebilmek için; *bağlı bir ticaret şirketinin mevcudiyeti* ile bu ticaret şirketinin *hâkim şirkete (teşebbüse) bağlı olması* unsurlarının bir arada bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

a) Bağlı Ticaret Şirketinin Mevcudiyeti

Şirketler topluluğunun söz konusu olabilmesi için, *bağlı birimin ticaret şirketi olması* gerekir. Bağlı bir ya da daha fazla ticaret şirketinin bulunduğu hallerde, şirketler topluluğunun varlığının kabulü gerekir[610].

Türk hukukunda şirketler topluluğundan bahsedebilmek için, kural olarak, *hâkimiyet ilişkisinin ticaret şirketleri arasında olması gerekir;*

---

608 **Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,** s. 1023.

609 **Naegeli,E.**,Die Doppelgesellschaft als rechtliche Organizationsform der Kartelle, Konzerne und anderen Unternehmerzusammenschlüsse nach deutschem und schweizerischem Recht, Bd.I., Zurich 1936 (Barlas, s. 229'dan naklen). Şirketler topluluğunun tanımında tek elden yönetimin bir unsur olarak kullanılması şart değildir, sadece bazı ülkelerde bir unsur olarak aranmaktadır.

610 Kanun koyucu, esas itibariyle mehazı oluşturan Alman hukukundan ayrılmış; Alman hukukunda, işletmeler arasındaki hâkimiyetin şirketler topluluğuna vücut verebileceği kabul edilirken, Türk hukukunda –kural olarak- *ticaret şirketleri arasındaki hâkimiyetin* şirketler topluluğunu oluşturacağı belirtilmiştir (TTK m.195/1).

ticaret şirketi (TTK m.124/1) niteliğini taşımayan kişi, şirket veya işletme birlikleri arasındaki hâkimiyet ilişkisi, onların "*şirketler topluluğu*" olarak nitelendirilmesine imkân vermez. Kanun koyucunun bu kabulüne göre, ticaret şirketi niteliği taşımayan kişi, şirket ya da işletmelerin mevcut şirketler topluluğuna dâhil edilmesi, *TTK m.195/5'de belirtilen istisna haricinde*, mümkün değildir[611].

TTK m.195/5 ile kabul edilen bu istisnayla; şirketler topluluğunun hâkiminin bir *teşebbüs* olabileceği de kabul edilmiş ve "*şirketler topluluğunun hâkimin bir teşebbüs olması halinde, şirketler topluluğuna ilişkin hükümler uygulama kabiliyeti bulacaktır*" (TTK m.195/5) denilmiştir[612]. Topluluk hâkimi bakımından getirilen bu istisnaî düzenlemede (TTK m.195/5), *hâkim birimin "teşebbüs"* olması hâli hükme bağlanmıştır[613].

---

611 Ticari alanda bağlılık ilişkisi ve bundan kaynaklanan sonuçlar tanzim edilirken, ticari sahada bazı aktörlerin kapsam dışında tutulması, yasanın uygulamaya geçmesi ile birlikte bazı sorunları da beraberinde getirecek ve sorunların çözümü bakımından muhtemelen yasada şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemelerin kıyasen uygulanması yolu tercih edilecektir. Bu sebeple ticaret sahasındaki bir kısım aktörler (ticaret şirketleri) arasındaki bağlılık ilişkisine dair düzenlemeler yapılıp, diğer bir kısmı hakkında boşluk bırakılması tenkide açıktır. İstisna hükmü (TTK m.195/5), sadece topluluk hâkimi bakımından istisna getirdiğinden, eleştirinin geçerliliğini koruduğunu kabul etmek gerekir.
Türk Ticaret Kanununun gerekçesinde de, şirketler topluluğunun sermaye şirketlerinden oluşmasının sebebi olarak, "*uygulama esas alınmış; uygulamada şirketler topluluğu bünyesi içinde, en çok karşılaşılan türün sermaye şirketleri olduğu, nadiren kolektif ve komandit şirketler de topluluk bünyesi içinde yer alsa da, gerçek kişi tarafından işletilen ticari işletmelere topluluk bünyesinde hemen hemen hiç rastlanılmamaktadır.*" denilmektedir (Bkz., TBMM Gerekçe, s.135).
9.11.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Tasarısı'nın 195'inci maddesinde "*ticaret şirketi*" yerine "*sermaye şirketi*" kavramı kullanılmış ve gerekçe sermaye şirketlerini esas alan düzenlemeye göre yazılmıştır. Ancak alt komisyon tarafından şirketler topluluğunun sermaye şirketlerine hasredilmesinin dar kapsamlı olması ve bu durumun şahıs şirketleri oluşturulmak suretiyle suiistimal edilmesinin engellenmesi amacıyla, maddenin kapsamı genişletilmiş ve değişiklik esas komisyon tarafından da kabul edilerek, yasa metni haline dönüşmüştür.

612 Bu halde topluluk merkezinin veya yerleşim yerinin Türkiye'de ya da yurt dışında bulunması sonucu değiştirmeyecektir (TTK m.195/5).

613 Bakanlar Kurulu Tasarısında, yasalaşan halinden farklı olarak 195'inci maddenin 5'inci fıkrası, "*Şirketler topluluğunun tepesinde, merkezi veya yerleşim yeri yurt içinde veya yurt dışında bulunan, sermaye şirketi olmayan, herhangi bir tüzel ya da gerçek kişinin veya işletmenin bulunması hâlinde, 195 ilâ 209'uncu madde*

Belirtmek gerekir ki, getirilen bu istisna, *sadece topluluk hâkimi* bakımından geçerlidir; topluluğa dâhil diğer birimler açısından, bağlı şirketin, ticaret şirketi olması kuralı geçerliliğini korumaktadır. Bu nedenle şirketler topluluğunun oluşumu için, hâkim birime bağlı en az *bir ticaret şirketinin varlığına* ihtiyaç bulunmaktadır.

TSY m. 105/1'de, "*bir şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret şirketinden meydana gelir*" denilmesine karşın; topluluk hâkimine bağlı sadece bir ticaret şirketinin bulunduğu hâllerde de, şirketler topluluğu ilişkisinin bulunduğu kabul edilmelidir (TTK m.195/1,5; m. 203; m. 195/5).

Kanun koyucu "*teşebbüs*"ü, "*girişim*" olarak ifade etmiş; ancak, teşebbüsün bir tanımını yapmamıştır. Kanunun gerekçesinden[614], teşebbüsün; gerçek ve tüzel kişiler ile işletmeleri kapsayacak bir içeriğe sahip olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu nedenle "*teşebbüs*" kavramının, gerçek kişi, kamu hukuku ya da özel hukuk tüzel kişisi; tüzel kişiliği bulunmayan kişi toplulukları ve ticari işletmeyi kapsayacak şekilde geniş yorumlanması gerekmektedir. Bu surette, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını bertaraf etme imkânı, en azından hâkim birimin niteliği bakımından ortadan kalkacaktır.

Hâkim teşebbüse bağlı tek bir ticaret şirketi bulunan hallerde de, şirketler topluluğunun oluşması mümkündür; yeter ki hâkim, teşebbüs niteliğini taşısın. Ancak bu durumu, bir ticaret şirketinde hâkimiyet sağlayan kişi ya da kişilerin, şirketiyle birlikte şirketler topluluğu oluştur-

---

hükümleri ile şirketler topluluğuna ilişkin diğer hükümlerde uygulanır. Tepedeki gerçek kişi tacir sayılır. Konsolide yılsonu tablolarına ilişkin hükümler saklıdır" şeklindeydi. Düzenleme metninden de anlaşılacağı üzere, "*işletme*" teriminin yerine "*teşebbüs*" kavramı kullanılmıştır.

614 Yasa tasarısının madde gerekçesinde "*işletme*" teriminin bilinçli olarak tercih edildiği ve bu kavramın "*teşebbüsü*" ve benzeri diğer kavramları kapsadığından şüphe duyulmaması gerektiği vurgulanmaktadır (Gerekçe TBMM s. 137). Buna karşın alt komisyonda, tasarıyla oluşturulan dar sistemin genişletilmesi amacıyla gerekli olan yerlerde değişiklik yapıldığı ve bu amaçla "*teşebbüs*" kavramına yer verildiği anlaşılmaktadır (Gerekçe TBMM s.478). Görüldüğü gibi kanun koyucunun ister teşebbüs ister işletme tabiri kullanılsın, neticede hükmün en geniş şekliyle uygulanmasını sağlamayı hedeflediği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla tasarı gerekçesinde, işletme kavramının "*teşebbüs*" ve benzeri kavramları kapsadığına ilişkin açıklamayı (Gerekçe TBMM s.137), teşebbüsün işletmeden daha dar kapsama sahip olduğu şeklinde değil, kanun koyucunun hükmün en geniş kapsamda uygulanmasını sağlamayı hedeflediği şeklinde anlamak gerekir.

duğu şeklinde *yorumlamamak* gerekir. Yasal düzenlemede kullanılan *teşebbüs* kavramı, en genel anlamıyla iktisadi bir faaliyette bulunmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla, başkaca iktisadi faaliyeti bulunmayıp, sadece bir şirketin hâkimi konumunda bulunan pay sahibi ya da sahiplerinin; şirketiyle birlikte topluluk oluşturmadığı kabul edilmelidir. Ancak iktisadi faaliyeti kapsamında, şirketteki hâkimiyetini, iktisadi faaliyetindeki menfaatleri için kullanma tehlikesi taşıyan hâkim ortağın, şirketiyle birlikte topluluk oluşturacağını kabul etmek gerekmektedir.

b) Hâkim Şirkete (Teşebbüse) Bağlı Olmak

Kanun koyucu, şirketler topluluğunun oluşmasında, hukuken bağımsızlıklarını koruyan ticaret şirketlerinin, hâkim şirkete (teşebbüse) bağlı olmasını esas almıştır.

aa) Genel Olarak

Bu hâlde "*bağlı olmak*" kavramının izah edilmesi gerekir. Bir şirketin başka bir şirket veya teşebbüs ile *herhangi bir surette irtibatlı olması*; meselâ diğer şirkette küçük bir pay iktisap etmiş olması, aynı işi beraberce üstlenmiş olmaları veya yönetim kurulu üyelerinden birinin veya birkaçının aynı şahıs olması hallerinde, teşebbüs ve/veya şirketler arasında bir şirketler topluluğu oluştuğu anlamına gelebilecek midir?

Önemle belirtmek gerekir ki, kanun koyucu şirketler topluluğunun oluşabilmesi için, birden fazla şirket ve/veya teşebbüs arasındaki *basit bir bağı yeterli görmemiş*; bir ticaret şirketi ya da teşebbüsün topluluğa dâhil olan ticaret şirketlerini *hâkimiyet altında tutacak bir bağın bulunmasını* aramıştır.

Ancak söz konusu *bağlılık ilişkisi,* şirketler hukukunun müdahale imkânları kapsamında değerlendirilmeli; şirketler hukukunun bahşettiği müdahale imkânları dışında kalan hallerin, örneğin bir şirketin başka bir şirkete olan borcu nedeniyle alacaklı şirketin yönlendirme ve müdahalelerine açık hale gelmesinin, şirketler topluluğu oluşumu için yeterli olan bir bağlılık ilişkisi olmadığı kabul edilmelidir[615].

---

[615] Bu konuda TTK m.195/1 (b) hükmü sorun doğurmaya müsait görünmektedir. Çünkü madde bir şirket bir şirketi "*başka bir yolla hâkimiyeti altında tutuyorsa*" şeklinde düzenlendikten başka; gerekçede de bunun geniş yoruma olanak sağladığından bahsedilmiştir. Kanuni düzenlemede bu açıdan sınır konulmamış olmasının (TTK m.195/1,b), her tür müdahale imkânının yasanın aradığı anlamda

Şirketler topluluğunun oluşumuna neden olacak bu ilişki çok çeşitli şekillerde ortaya çıkabilmekte ve farklı kavramlarla ifade edilmektedir. Ancak Avrupa Birliği ülkelerinde iki temel kavram yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlar "***kontrol***" ve "***hâkimiyet*** *ya da* ***bağlılık***[616]" kavramlarıdır.

Kontrol sistemi, bir ticaret şirketinin, diğer bir ticaret şirketi üzerinde *oy çoğunluğu* ya da *diğer hâkimiyet vasıtaları*[617] *ile bu şirketi kontrol etme* imkânı olarak nitelendirilmekte; bu hâlde söz konusu şirketlerin bir topluluk oluşturduğu kabul edilmektedir. Bir diğer söyleyişle, hâkim ticaret şirketi, diğer ticaret şirketi ya da şirketlerinin *karar* ve *işlemlerine*, kanunda bahsedilen diğer vasıtalarla *etki etmek imkânına sahipse*; şirketler topluluğunun varlığına sebebiyet veren hâkimiyet söz konusu olacaktır.

Hâkimiyet sistemi, bir şirketin, başka bir şirket üzerinde *belirleyici etkide bulunma iktidarına* sahip olması olarak değerlendirilmekte; bir şirketin, başka bir şirket üzerinde *belirleyici etkide bulunma iktidarına* sahip olduğu durumlarda, hâkimiyetin mevcut olduğu kabul edilmektedir[618].

Alman hukukunda *hâkimiyet sistemi* benimsenmiştir (AktG § 17 Abs. 1). Bu hukuk çevresinde bir şirket, başka bir şirket üzerinde, *belirleyici etkide bulunma iktidarını kullanmak suretiyle,* tek elden

---

bağlılık ilişkisinin kurulmasına yeterli olduğunu kabul etmeye değil; şirketler hukuku kapsamında gerçekleşebilecek müdahale olanaklarının sınırlı sayımının ya da mevzuat değişikliği suretiyle şirketler hukuku alanında ortaya çıkabilecek yeni müdahale imkânlarının kapsam dışında kalmasının sakıncalarını engellemeye matuf olduğu kanaatini taşımaktayız. Kanun gerekçesinde verilen örnekler de bu kanaati doğrular mahiyettedir.

616 Bkz., Forum Europaeum Kozernrecht, ZGR 4/1998, s.672-677 ve s.693.

617 *Forum Europaeum*'da (s. 694, dn. 113) bu hâkimiyet araçlarının neler olduğu konusunda 83/349/EWG sayılı *Avrupa Birliği Konsey Direktifi*'nin 1. maddesine atıf yapılmıştır. Direktifin anılan maddesinde hangi işletmelerin konsolide bilanço ve durum raporu düzenlemesi gerektiği belirtilmekte ve ana işletmenin bir işletmede oy çoğunluğuna sahip olması, diğer işletmenin yönetim ya da gözetim organını seçme ya da görevden alma hakkını haiz olması ve aynı zamanda bu işletmenin ortağı olması; aynı zamanda ortağı olduğu işletme ile yapılan bir sözleşme ya da o işletmenin esas sözleşmesi uyarınca hakimiyet etkisi kullanabilmesi gibi tek tek sayılan durumlarda, konsolide bilanço ve durum raporu düzenlenmesini gerektirmektedir.

618 Forum Europaeum, s. 694

yönetim için gerekli politikaları belirleyerek, hâkimiyet etkisini kullanıyor ve bütün şirketlerin bu politikayı izlemesini temin ediyorsa; başka bir ifadeyle, tek elden yönetimi sağlıyorsa, topluluk oluşmaktadır[619] (bkz. AktG § 18 Abs. 1).

Burada hâkimiyet sistemi ile tek elden yönetim kavramlarının birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir. Hâkimiyet sisteminden maksat, *oy çoğunluğu* ya da *pay çoğunluğu* gibi herhangi bir bağlılık vasıtası zikredilmeksizin, bir şirketin diğer bir şirket üzerinde belirleyici etkiye sahip olma gücünün varlığının, sistem olarak kabul edilmesidir. Bu sistem, şirketler arasındaki bağlılık ilişkisinin ne surette kurulacağını belirler. Tek elden yönetim ise, hâkimiyetin ötesinde, şirketler topluluğunun oluşması için aranılan şarttır[620].

Hâkimiyet sisteminde, kontrol sisteminden farklı olarak, hâkimiyeti sağlamak için gerekli *-pay ya da oy çoğunluğu gibi-* vasıtalara sahip olunması yeterli olmamakta; *hâkimiyetin etkisinin kullanılması* gerekmektedir[621]. Şüphesiz ki bu durumun ispat sahasında doğuracağı güçlükler bulunduğundan, *sorun karinelerle aşılmakta*; bu kapsamda pay veya oy çoğunluğuna sahip olunan hallerde, bu etkinin *kullanıldığı karine olarak* kabul edilmektedir[622]. Karinelerin etkisi sayesinde, hâkimiyet ve kontrol sistemleri birbiri ile örtüşmektedir[623]. Ancak bazı hallerde bu sistemlerden birinin diğerine nazaran daha kapsamlı olduğu

---

619 Tek elden yönetimin mevcudiyeti için, genel olarak topluluk hâkiminin finansman, üretim, pazarlama gibi stratejik yönetim faaliyetleri bakımından belirleyici olması ve bağlı şirketlerin belirlenen politikalar çerçevesinde hareket etmesi aranmaktadır.

620 Alman sisteminde, hâkimiyetin varlığı halinde tek elden yönetim, karine olarak kabul edilmiştir (AktG § 18 Abs. 1, S. 3)

621 Gerekçe TBMM, s. 135.

622 Forum Europaeum, s. 694; bkz. ayrıca AktG § 16-18; Türk Ticaret Kanunu gerekçesinde konu ile ilgili olarak "Hâkimiyet ve tek elden yönetim ölçüsüne dayalı sistemde ise hâkimiyet olanaklarının sadece varlığı, per se, hâkimiyetin de uygulandığı şeklinde yorumlanmaz, hâkimiyetin gerçekten uygulanıyor olması gerekli görülür; bunun (gereğinde) ispatı istenir" açıklamalarına yer verilmiştir. Açıklama içeriğinden, hâkimiyetin uygulandığının icabında ispatlanması gerektiği yönünde bir sonuç çıkmaktadır. Fakat gerekçenin aksine, söz konusu sistem oy ve pay çoğunluğu gibi hâkimiyet olanaklarının varlığı halinde, tek elden yönetim ve topluluk ilişkisinin varlığını karine olarak kabul ettiğinden, hâkimiyetin uygulandığının değil, aksinin ispatı gerekir. Bu açıdan gerekçedeki açıklama yanlış anlaşılmaya müsaittir. Bkz. Forum Europaeum, s. 694.

623 Forum Europaeum, s. 694

tespiti de yapılabilir. Meselâ bir şirketin, imtiyazlı pay bulunmayan başka bir şirkette %25 paya sahip olduğu ve şirket genel kurul toplantılarına sürekli olarak en fazla %40 pay sahibinin hazır olduğu durumlarda hâkimiyet mevcuttur; ancak kontrol sistemi uyarınca pay çoğunluğunun (%50+1) bulunmaması nedeniyle kontrol mevcut değildir. Bu bakımdan hâkimiyet sisteminin daha kapsamlı olduğu düşünülebilir. Bu sorunu aşmak için pek çok ülke; kontrol kavramını, fiili kontrole dönüştürerek, hâkimiyet sistemine yaklaştırmaktadır[624] (bkz. TTK m.195/1,b ve 195/2).

Türk hukukunda kanun koyucunun benimsediği sistem bakımından, kanun gerekçesi tartışmaya açıktır. Kanun gerekçesinde *kontrol sisteminin benimsendiği* vurgulandıktan hemen sonra; sadece TTK m.195/2 hükmünde bir karineye yer verildiğinden bahsedilmektedir[625]. Gerekçedeki açıklama, benimsenen sistem bakımından tereddüt doğurmaktadır. Zira kanunun kontrol sistemini benimsediği vurgulandıktan sonra, sadece TTK m.195/2 hükmünde bir karineye yer verildiğinden bahsedilmesi; karinenin kontrol sisteminin dışında olduğu gibi bir sonucu beraberinde getirmektedir.

Kanaatimizce *Türk hukukunun* benimsediği sistem bakımından, hâkimiyet, kontrol ve tek elden yönetim kavramlarının farklı amaçlara hizmet ettiği dikkate alınmalıdır. Tek elden yönetim, özellikle Alman hukukunda benimsenen ve şirketler topluluğunun oluşması için, bağlılık ilişkisinin yanında aranan ilâve bir unsurdur (AktG § 18 Abs. 1). Bu nedenle bu kavram, bağlılık ilişkisinin mevcut olup olmadığını değerlendirmede esas alınan kontrol ve hâkimiyet kavramları ile ilgili olmayıp, bir sonraki aşama olan topluluk oluşumu ile ilgilidir[626]. *Hâkimiyet sistemi*, bağlılık araçları zikredilmeksizin hâkimiyet etkisinin

---

624 Forum Europaeum, s. 694; Bkz. TBMM Gerekçe s. 136

625 Gerekçede bu konu ile ilgili olarak;
"...uygulamada ve öğretide genel kabul gören "kontrol" sistemidir. FE iki sistemin bir arada bulunabileceğini kabul etmektedir.
Tasarı, 195 inci maddenin birinci fıkrasından açıkça anlaşıldığı üzere "kontrol" sistemini temel almış, sadece ikinci fıkrasında bir karine kabul etmiştir" açıklamasına yer verilmiştir. Bkz. TBMM Gerekçe s. 135

626 Kanun gerekçesinde hâkimiyet ve tek elden yönetim kavramları birlikte kullanıldığından (bkz. TBMM Gerekçe s. 135), iki kavramın aynı müesseseyi ifade ettiği gibi bir sonuç da çıkmaktadır. Kontrol sisteminde topluluk oluşumu için ilâve bir özellik aranmamaktadır. Bu bakımdan kontrol ve tek elden yönetimin topluluğu

kullanılmasını, şirketler arasındaki bağlılık ilişkisi bakımından gerekli ve yeterli görürken; *kontrol sisteminde* bağlılık araçları zikredilmek suretiyle bağlılık ilişkisinin ne surette ortaya çıkması gerektiği aranmaktadır[627].

Bu açıklamalar çerçevesinde Türk hukukundaki düzenlemeler incelendiğinde; Türk hukukunda tek elden yönetim sisteminin benimsenmediği hususunda bir tereddüt yoktur. Mevcut düzenlemeler kapsamında kanun koyucunun, esas itibariyle *kontrol sistemini kabul ettiği* (TTK m.195/1.a); bununla birlikte, hâkimiyet sistemine de yer vererek (TTK m.195/1.b; 195/2) *karma bir sistemi benimsediği* sonucuna ulaşılabilir[628]. Hatta bu karma sistemde, hâkimiyet sistemini esas aldığı belirtilen TTK m.195/1.b ve 195/2 hükümleri dikkate alındığında, TTK m.195/1.(a) maddesinde zikredilen hallerin örnek kabilinden olduğunu

---

oluşturan özellik olması nedeniyle mukayese edilebilir olduğu düşünülebilir. Ancak kontrol sistemi ilâve bir özellik aramadığından, mukayeseye ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla birbiriyle mukayese edilebilir olan kavramlar, şirketler arasındaki ilişkiyi niteleyen hâkimiyet ve kontrol kavramlarıdır.

627 Kanaatimizce gerekçedeki vurgunun aksine, karinelerin ya da varsayımların, benimsenen sistemin türü bakımından etkisi yoktur.

628 TTK m.195/1,b hükmü uyarınca *"Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini... hâkimiyeti altında tutabiliyorsa"* hâkim ve bağlı şirket ilişkisi doğmaktadır. TTK m.195/2 hükmü uyarınca ise *"bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir."* Kanunun gerekçesinde, 195'inci maddenin birinci fıkrası esas alınarak açıkça kontrol sisteminin kabul edildiği belirtilirken, 195'inci maddenin ikinci fıkrası için hangi sistemin kabul edildiği açıklanmaksızın bir karineye yer verildiği belirtilmektedir. Bu konuyu ele alan **Pulaşlı,** kanunun açıkça kontrol sistemini benimsediğini belirterek; karineyi "hâkimiyet ilişkisinin nispî olduğu hâl" başlığı altında incelemektedir. Ancak kanun gerekçesi incelendiğinde, gerekçenin yazımında esas alındığı anlaşılan Forum Europaeu'da da, TTK m.195/2 kapsamında mütalaa edilen örneğin, hâkimiyet sistemi kapsamında olduğu ve kontrol sistemini benimseyen bazı devletlerde kontrolün, fiili kontrole dönüştürülmek suretiyle hâkimiyet sistemine yaklaştırıldığı vurgulanmaktadır (Bkz. Forum Europaeum, s.695). TTK m.195/1,b hükmünde ise kanunun açık lâfzı, hâkimiyet sisteminin benimsendiğini göstermektedir. Zira madde hükmü bir şirketin başka bir şirketi hâkimiyeti altında tutabilmesini, şirketler arasında olması gereken bağ bakımından yeterli görmektedir. Kanaatimizce 195/1,a'da kontrol, 195/1,b ve 195/2'de hâkimiyet sisteminin varlığını kabul etmek daha isabetli olacaktır. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, hakimiyet sistemini içeren bir kanunda, kontrol sisteminin araçlarının sayılması, bu araçların sadece örnek kabilinden olduğunu gösterir.

ve kanunun -*gerekçede belirtilenin aksine*- hâkimiyet sistemini esas aldığını, kontrol sisteminin kanunda yalnızca örnek olarak zikredilen haller bakımından benimsendiğini söylemek de mümkündür[629].

bb) Hâkimiyet Türleri

Kanun koyucunun düzenlemesine nazaran şirketler topluluğu; "*fiili*" bir durum sonucu ortaya çıkabileceği gibi, bir "*sözleşme*"ye de dayanabilir.

aaa) Fiili Şirketler Topluluğu

Fiili şirketler topluluğu, bir hâkimiyet sözleşmesine dayanmaksızın (TTK m.195/1.b), kanunda öngörülen koşulların[630] gerçekleşmesiyle doğan şirketler topluluğudur. Topluluğun oluşumuna hem kontrol hem de hâkimiyet sistemi etkili olabilmektedir.

(1) Kontrol sistemine dayalı fiili şirketler topluluğu

Türk Ticaret Kanunu'nun 195'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre, "*bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak;*

1. Oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya

2. Şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya

3. Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak tek başına veya diğer pay sahipleri ya da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa"

birinci şirket hâkim, diğeri bağlı şirkettir ve hâkimiyet ilişkisi kurulmuş olur.

Kanun gerekçesinde, kontrol sistemine dayanan ve sınırlı sayıda belirtilen bu üç hâlden birinin gerçekleşmesinin, hâkimiyetin varlığının

---

629 Kanuni düzenleme incelendiğinde, bahsedilen maddelerin (195/1,b;195/2) bir şekilde hâkimiyetin sağlanmasını, yani yönetime nüfuz edilmesini kastettiği açıktır. Diğer hükümler bunların yanında sadece örnek olarak kalmaktadır.

630 Kanun koyucunun böyle bir amacı bulunmamasına rağmen, bu koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğinin tespitini kolaylaştırmak ve kamunun aydınlatılmasını sağlamak bakımından, Kanunun 198'inci maddesinde belirli oranlardaki pay iktisapları ve aynı oranlardaki payların elden çıkarılması hakkında bildirim ve tescil yükümlülüklerine yer verildiğinin de kabulü gerekir.

kabulü için yeterli olduğu ve kanun koyucunun burada hâkimiyet ilişkisinin mevcudiyeti bakımından bir *faraziyeye* yer verdiği vurgulanmaktadır[631]. Bunun anlamı, ilgili kimselerin hâkimiyet ilişkisinin ya da hâkim şirket-bağlı şirket ilişkisinin bulunmadığını iddia ve ispat imkânının bulunmadığıdır.

Ancak, kanun gerekçesinde belirtilen bu sonuçlar, ciddi hukuki sorunları beraberinde getirecektir. *Bir kere* yasa maddesinde zikredilen hallerin bazılarının bir arada bulunması mümkündür. Mesela, 3 kişilik bir yönetim kurulu bulunan bağlı anonim şirkette pay ve oyların % 70'i (A) anonim şirketine, % 30'u (B) anonim şirketine ait ise; kanun koyucu (A) şirketini, oy çoğunluğuna sahip olduğu için hâkim şirket olarak görmektedir (TTK m.195/1,a,1).

Aynı ilişkide (B) şirketinin sahip olduğu azınlık payları nedeniyle yönetim kuruluna TTK m.360 uyarınca iki aday önerme hakkı var olduğunda (imtiyazlı pay), TTK m.195/1,a,2 uyarınca (B) de hâkimiyet kurmuş olacak; (A) sahip olduğu %70'lik oyla durumu sadece tasdik edecektir. (B)'nin TTK m.360/2 anlamında imtiyazlı paya sahip olması, kendisine oy imtiyazı vermemekte, oy çoğunluğu hâlen (A)'da bulunmaktadır. Hâkim şirket (B) olmasına rağmen, TTK m.195 sistemi ve kanun gerekçesi uyarınca oy çoğunluğuna sahip (A), hâkim şirket olmadığını iddia ve ispat etme hakkını haiz bulunmayıp, hâkim şirket olmanın sonuçlarına tâbi olacaktır. Bağlı şirket yönetim kurulu üye sayısının iki olduğu ve (B) şirketinin sadece bir aday önerme hakkının bulunduğu durumlarda, (A) ve (B) şirketlerinin hiçbiri, paylarına sahip

---

631 Bkz. Gerekçe s. 136; Kanun gerekçesinde maddenin (a) bendinde sayılan haller bakımından "hukuki faraziyeye" yer verildiğine dair açıklama, kanun yapım tekniği bakımından eleştiriye açıktır. Zira maddenin birinci fıkrası (a) ve (b) olarak isimlendirilen iki bentten; bahsi geçen her iki bent de tek bir cümleden oluşmaktadır. Bu bağlamda yasanın lâfzına dayalı olarak yapılacak yorumda, her iki bentte sayılan hâller bakımından da aynı hukuki sonucun kabul edilmesi, bir faraziye varsa bunun her iki bentte sayılan hâllerin tamamı için geçerli olması, tek cümlenin bentler için ortak yargıyı içermesinin doğal sonucudur. Bentler tek cümleden müteşekkil olmasına rağmen, yasa gerekçesinde (a) ve (b) bentleri bakımından doğacak hukuki sonuçlar birbirinden ayrılmış, (a) bendindeki haller bakımından hukuki faraziyeden bahsedilirken, (b) bendi bakımından bu sonuç kabul edilmemiştir. Oysa aynı cümle içerisinde yer alan, lâfzen ortak bir yargı ve yazgıya tâbi kılınan hâllerin, ortak hukuki sonuca tâbi olması hukuk güvenliği ve belirlilik ilkelerinin gereğidir.

olduğu şirkete tek başına nüfuz etme imkânına sahip olmamasına karşın; şirketler topluluğunun varlığı kabul edilecek ve oy çoğunluğu bulunan (A) hâkim şirket olarak kabul edilecektir. *Öte yandan* -son örnekten anlaşılacağı üzere- yasa maddesinde belirtilen kontrol araçlarından biri mevcut olmasına rağmen, hâkimiyet ilişkisinin bulunmaması ihtimal dâhilindedir.

Yine örneğin ticaret şirketleri olan (H) ve (I), (B) anonim şirketinde ortaktır. Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır ve (H)'nın %51, (I)'nın %49 payı vardır. Şirkete iki yönetim kurulu üyesi seçilecektir ve seçimde birikimli oy sistemi kullanılacaktır. Mevcut oy sistemi gereği her pay sahibinin yönetim kuruluna (1) üye seçtirmesi mümkündür. Buna rağmen TTK m.195/1,a,1 uyarınca (H), hâkim şirkettir ve aksini ispatlaması mümkün değildir. Benzer örneklerin çoğaltılması mümkündür.

Netice olarak kanun koyucu hâkimiyet ilişkisini olağan düzeni dikkate alarak tanzim etmekle birlikte, istisnai durumlarda ortaya çıkabilecek sorunları bertaraf etmeye yönelik mekanizmaları da kapatmıştır. Bilânço hukuku bakımından kabul edilebilecek bir varsayımın, hâkimiyet ilişkisi ve maddi şirketler topluluğunun varlığı için de kabul edilmiş olması; doğal olarak tereddütleri beraberinde getirmektedir. Kanaatimizce varsayıma dayalı olarak ortaya çıkan sonucun, hukuken himayesi mümkün değildir. Uygulamanın nasıl şekilleneceği belli olmamakla birlikte, hâkimiyet ilişkisinin yasal düzenlemeyle *karineye dayalı olarak kurulması,* menfaatler dengesi bakımından en makul çözüm olarak görülmektedir.

Kanun koyucunun kabulüne nazaran, hâkimiyet ilişkisinin tek bir şirket veya teşebbüs tarafından kullanılması şart değildir; hâkimiyet, birden fazla şirket veya teşebbüs tarafından beraberce tesis edilebilir.

Kontrol sistemi vasıtasıyla kurulan hâkimiyet ilişkisi, doğrudan veya dolaylı olarak gerçekleşebilir. *Doğrudan hâkimiyet*, bir teşebbüs veya ticaret şirketinin (herhangi bir aracı olmaksızın) diğer ticaret şirketi veya şirketlerine hâkim olmasıdır. *Dolaylı hâkimiyet* ise, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla, bir diğer ticaret şirketine hâkim olmayı ifade etmektedir (TTK m.195/3).

(2) Hâkimiyet sistemine dayalı fiili şirketler topluluğu

Hâkimiyet sistemine dayalı fiili şirketler topluluğunda topluluk, bir sözleşme ilişkisi çerçevesinde kurulmamakla birlikte; belirli şartların gerçekleşmesiyle hâkimiyetin varlığı kabul edilmektedir. Bu halde,

kontrol sisteminden farklı olarak, kanunda belirtilen koşulların varlığı halinde, *hâkimiyetin fiilen uygulanmadığının ispatı mümkündür.* Hâkimiyetin fiilen uygulanmadığı ispat edilmek suretiyle, şirketler topluluğunun oluşmadığı iddia edilebilir.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 195'inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, *"Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının çoğunluğuna sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse... birinci şirket hâkim diğeri bağlı şirkettir".*

TK m. 195/2'de ise, *"Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir"* denilmektedir.

Görüldüğü gibi, TTK m.195/2'de, TTK m.195/1'de belirtilen hâllerde hâkim ve bağlı şirketin oluşacağı kabul edildikten sonra; hâkim şirket hususunda birbirinden farklı *iki ihtimal* üzerinde durulmuştur.

Birinci ihtimalde, bir teşebbüs veya ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketinde pay çoğunluğuna sahiptir; bu çoğunluk doğrudan ya da dolaylı surette gerçekleşebilir.

Bu düzenlemeye nazaran, TTK m.195/1'de sözü edilen "*oy haklarının çoğunluğu*" yanında TTK m.195/2'de "*pay çoğunluğu*" esası da hâkim şirketi belirleyici bir ölçüt olarak kabul edilmiştir. Buna göre, *hâkimiyetin varlığı pay çoğunluğuna değil, oy çoğunluğuna bağlı* olmakla birlikte; TTK m.195/2'ye göre pay çoğunluğu da, hâkimiyetin varlığına bir karine teşkil etmektedir.

Pay çoğunluğu, hâkimiyetin varlığına sadece karine teşkil ettiği için, pay çoğunluğuna sahip bir şirket, hâkimiyet ilişkisinin mevcut olmadığını ispat etmek suretiyle, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasını bertaraf edebilir.

Diğer ihtimal, özellikle *pay sahiplerinin ilgisizliği* nedeniyle pay çoğunluğuna sahip olmamasına rağmen, şirket üzerinde hâkimiyet sağlanmasına yöneliktir. Bu tür şirketler genellikle pay senetleri geniş halk kitlelerine yayılmış olan anonim şirketlerdir. Bu tür şirketlerde pay sahipleri mali haklar dışında ortaklık haklarına ilgisizdir; bu ilgisizlik nedeniyle, payların %25-30'una ve hatta daha düşük oranına sahip olan

kimseler şirkette hâkimiyet sağlayabilir[632]. Bu nedenle kanunda, şirketi yönetebilecek kararları alabilecek oranda paya sahip olmak, hâkimiyet ilişkisinin kurulduğu yönünde bir *karine olarak* kabul edilmiştir.

TTK m.195/2'de düzenlenen bu ihtimalden başka, bir de TTK m.195/1.b'de de bir ihtimal nazara alınmış, "*Bir ticaret şirketi, diğer bir ticaret şirketini başka bir yolla hâkimiyet altında tutabiliyorsa*" denilerek "***başka bir yolla***" hâkimiyetin kurulabileceği ve şirketler topluluğunun oluşabileceği kabul edilmiştir.

Buna göre TTK m.195/1.b, TTK m.195/5 ile birlikte ele alındığında, bir ticaret şirketi ya da teşebbüs, başka bir ticaret şirketini herhangi bir yolla hâkimiyeti altında tutuyorsa, şirketler topluluğunun mevcudiyeti kabul edilecektir. Anılan düzenleme, yasanın hâkimiyet sistemine dayalı ikinci örneğini oluşturmaktadır. Başkaca yollarla hâkimiyet ilişkisinin kurulduğunu iddia eden, iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. *"Başka bir yolla"* hâkimiyetin kurulması, birleşme, bölünme ve pay alımları suretiyle gerçekleşebilir[633]. Ancak bu örnekler sınırlı sayıda değildir; herhangi bir surette hâkimiyetin sağlanması yeterlidir.

bbb) Sözleşmeye Dayalı Şirketler Topluluğu

Sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunda, topluluk ilişkisinin, topluluk birimleri arasında akdedilen bir sözleşmeye dayalı olarak ortaya çıkması söz konusudur[634]. Türk Ticaret Kanunu'nda bu sözleşmelerden; sadece hâkimiyet sözleşmesi, kavram olarak yer bulmuştur (TTK

---

632 Gerekçe TBMM, s.136.

633 Gerekçe TBMM, s. 136.

634 **Deilmann**, B., Die Entstehung des qualifizierten faktischen Konzerns, Berlin, 1990, s. 37; Alman hukukunda fiili ve sözleşmeye dayalı şirketler topluluğu ayrımında, hakimiyet aracının bir kriter olarak kullanılması durumunda, sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunda belirleyici özelliğinin hakimiyet vasıtası olduğu, bu bağlamda Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu 291 ve devamı paragrafında düzenlenen işletme sözleşmelerine dayalı olan toplulukların sözleşmeye dayalı şirketler topluluğu olduğu, ancak söz konusu sözleşmelerin farklı hukuki sonuçları doğurduğu, asıl ayrımın hakim şirketin yönetim gücü bakımından yapılabileceği, bu bakımdan ise hakim şirketin yönetim gücünün yasal olarak tanınmasının önem taşıdığı ve sadece hakimiyet sözleşmesi bakımından böyle bir özelliğin mevcut olduğu, dolayısıyla hakimiyet sözleşmesi bulunan hallerde sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunun mevcut olduğu görüşü de bulunmaktadır. Bkz. **Pahke, K.,** der vertragliche und faktische Konzern, 1986, s. 5.

m.198/3)[635]. Buna göre, bir ticaret şirketi veya teşebbüs, diğer bir ticaret şirketini, bir *sözleşme gereğince* hâkimiyeti altında tutuyorsa; sözleşmeye dayalı şirketler topluluğundan söz edilir (TTK m.195/1.b; 195/5).

Bu halde fiili hâkimiyet yerini, taraflar arasında yapılan bir *"sözleşmeye dayalı hâkimiyet"* ilişkisine bırakmaktadır. Bu sözleşme bir teşebbüs veya ticaret şirketi ile diğer ticaret şirketi arasında gerçekleştirilen bir borçlar hukuku sözleşmesidir.

Hâkimiyet sözleşmesine kanunda yer verilmesine, bu sözleşmenin mahiyeti ile ilgili bir düzenleme yapılmamış olmasına karşın; Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 106'ncı maddesinin birinci fıkrasında ***"Hâkimiyet Sözleşmesi"***, *"aralarında doğrudan veya dolaylı iştirak ilişkisi bulunmayan, bulunsa bile bu ilişkiden bağımsız ve soyutlanmış bir şekilde taraflardan birinin, sermaye şirketi olan diğerinin yönetim organına hiçbir şarta bağlı olmadan talimat verme yetkisini içeren sözleşmedir"* şeklinde tanımlanmıştır[636].

Mevcut tanım çerçevesinde *hâkimiyet sözleşmesinin amacının*, bir teşebbüs veya şirketin; diğer bir ticaret şirketi üzerinde talimat verme olanağını sağlayacak şekilde hâkimiyet kurması olduğu anlaşılmaktadır[637].

Hâkimiyet sözleşmesinin *geçerli olabilmesi* için bu sözleşmenin *ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekir* (TTK m.198/3; TSY

---

635 Türk Ticaret Kanununda sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunun kurulmasının mümkün olduğu yasal düzenlemeden anlaşılmakla birlikte (TTK m.195/1.b), kanunun esinlendiği Alman Paylı Ortaklıklar Kanunu'nun işletme sözleşmelerine ilişkin ayrıntılı hükümleri hukukumuza aktarılmamış, işletme sözleşmelerinden sadece hakimiyet sözleşmesi kavram olarak Türk Ticaret Kanununda yer bulmuştur (TTK m.198/3).

636 Alman hukukunda hakimiyet sözleşmesi, bir anonim şirket ya da sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin yönetimini, bir başka işletmeye tâbi kılması halinde ortaya çıkmakta (AktG § 291 I), bunu gerçekleştirmek için de hakim şirkete talimat yetkisi tanınmaktadır (AktG § 308 I). Talimat yetkisi, Alman hukukunda hakimiyet sözleşmesi yanında sadece bütünleşme (Eingliederung) halinde tanınmış olup, doğurduğu sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde, hakimiyet sözleşmesi de iktisadi açıdan pek çok yönüyle birleşmeye benzer bir etkiye sahiptir (Bkz. **Emmerich**, in **Emmerich, V./Habersack, M.:** Aktien- und GmbH-Konzernrecht, 7. Auflage, C.H. BECK 2013, § 291 Rn. 1,2).

637 Ticaret Sicili Yönetmeliği, hâkimiyet sözleşmesinin içeriği ile ilgili birtakım düzenlemeler öngörmüş olmakla birlikte, kanaatimizce kanun sistemini değiştiren düzenlemelerin yönetmelikle değil, kanunla yapılması gerekmektedir (Bkz. TSY m. 106).

m.106/2). Kanun koyucu tescil ve ilândan söz etmesine karşın, bu sözleşmenin *şekline* temas etmemiştir. Bununla beraber, tescil ve ilân edilmesi gereken bir sözleşme söz konusu olduğu için, yönetmelikte ve gerekçede de ifade edildiği gibi[638], bu sözleşmenin *yazılı şekilde* yapılması; yazılı olarak yapılmadığı hâlde ise tescil anında yazılı hale getirilmesi gerekir.

Yazılı şekil, *adi yazılı şekildir*; sözleşmenin taraflarının temsile yetkili organlarınca imzalanması gerekir. Ancak olması gereken hukuk bakımından hâkimiyet sözleşmesi, *yönetim organının yetkilerini aşan* ve kanaatimizce "*genel kurulun münhasır yetkilerine giren bir konudur*". Bu sebeple, şirketin türüne göre, ortaklar kurulunun veya genel kurulun "*hâkimiyet sözleşmesi*" konusunda karar alması ve bu karara dayalı olarak yönetim organının hâkimiyet sözleşmesini yapması gerekir (Bkz. Ticaret Sicili Yönetmeliği m. 106)[639].

"*Hâkimiyet sözleşmesinin geçerli olabilmesi için bu sözleşmenin ticaret siciline tescil ve ilânı şarttır*" (TTK m.198/3, 1.c; TSY m.106/2). Kanun koyucu bu düzenlemesiyle tescil ve ilânın, hâkimiyet sözleşmesi için geçerlilik koşulu olduğunu kabul etmiştir. Ancak, fıkranın ikinci cümlesinde "*Sözleşmenin geçersizliği bu kanun (Türk Ticaret Kanunu) ile diğer kanunlardaki şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel olmaz*" denilmek suretiyle; hâkimiyet sözleşmesi geçersiz olsa da Ticaret Kanunu ve diğer kanunlardaki *şirketler topluluğuna dair yükümlülüklere ve sorumluluklara ilişkin hükümlerin geçerli olacağına açıklık getirmiştir.*

Hâkimiyet sözleşmesi yapılmış olmasına rağmen tescil edilmemişse; tescil edilmemenin hukuki sonuçları bir yana, tescil edilmemiş bir sözleşmeye dayalı olarak hâkimiyet kurulmasını da, TTK m.195/1.b gereğince, "*başka bir yolla hâkimiyeti altında tutma*" şeklinde değerlendirerek, şirketler topluluğunun oluştuğunu kabul etmek gerekir.

cc. Hâkimiyetin Tespiti Esasları

Kanun koyucu, şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için ön koşul olarak, iki şirket arasında "*hâkimiyet*" ilişkisinin

---

638 Gerekçe TBMM, s. 138.

639 6762 sayılı kanun döneminde hâkimiyet sözleşmelerinin imzalanması için genel kurul kararının aranması gerektiği yönünde bkz. **Aker, H.:** "*Hâkim İşletme İle Bağımlı Şirket Arasındaki Hukukî İlişki ve Hâkim İşletmenin Sadakat Borcu*", BATİDER, 2003, C. XXII, S. 2, s. 163.

bulunmasını öngörmüştür. *Hâkimiyet, şirketler topluluğunu belirleyen merkez kavramdır.*

Kanunda "*hâkimiyet*" kavramı, bir yandan genel kurulda veya yönetim organında karar alabilecek çoğunluğa sahip olmak şeklinde, *matematiksel bir kıstasa* bağlanmış; *diğer yandan ise bir sözleşme ile veya başka herhangi bir yolla hâkimiyetin tesis edilebileceği öngörülmüş*; ayrıca *pay çoğunluğuna sahip olmanın hâkimiyetin varlığına "karine" teşkil edeceği kabul edilmiştir.*

Kanun koyucu "*hâkimiyet*"i merkez kavram olarak kabul etmesinin yanında; hâkimiyetin "*tek başına", "birlikte", "doğrudan", "dolaylı*" olabileceğini; başka bir ticaret şirketi veya teşebbüsün, bir sermaye şirketinin paylarının veya oy haklarının doğrudan veya dolaylı olarak *yüzde yüzüne sahip olması halinde* ise, bu hâkimiyetin "*tam hâkimiyet*" olduğunu ifade etmiştir.

Hâkimiyet, bir teşebbüs veya ticaret şirketi tarafından kullanılabiliyorsa, "*tek başına hâkimiyet*"; hâkimiyet tesis eden birden fazla şirket veya teşebbüs varsa ve hâkimiyeti beraberce tesis etmişlerse "*birlikte hâkimiyet*" söz konusu olur. Ayrıca hâkimiyet, başka bir şirket veya teşebbüsün katılımı olmadan kullanılabiliyorsa, buna "*doğrudan hâkimiyet*"; bir veya birkaç bağlı şirket vasıtasıyla sağlanıyorsa buna da "*dolaylı hâkimiyet*" denilmektedir.

aaa) Genel Olarak

Şirketler topluluğunun ve buna bağlı olarak hâkimiyetin tesis edilip edilmediğini tespit edilmesini temin maksadıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 198'inci maddesinde bazı *yükümlülükler* öngörülmüştür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi sayesinde; fiili veya sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunun oluştuğu yahut karşılıklı iştirakin mevcut bulunduğuna karar verilebilecektir.

(1) Bildirim yükümlülüğü

*"**Bir teşebbüs**, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde; teşebbüs, durumu söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on gün içinde, sermaye şirketine ve bu Kanun ile diğer kanunlarda gösterilen yetkili makamlara bildirir"* (TTK m.198/1).

Bildirim yükümlülüğü sadece *teşebbüse* özgülenmiş gibi görülüyorsa da, bir ticaret şirketinin de aynı şartlar altında bildirim yükümlülüğünün bulunduğunun kabul edilmesi gerekir. Yükümlülük teşebbüs için öngörüldüğünden, teşebbüs niteliği taşımayanların, söz gelimi, bir sermaye şirketinde sadece %50 pay iktisap eden, başkaca bir ticari faaliyeti bulunmayan bir memurun, bu hüküm dolayısıyla bildirim yükümlülüğü bulunmayacak; aşağıda belirtildiği üzere, oy hakkı dâhil diğer haklarının donması da söz konusu olmayacaktır.

TTK m.198'de sözü edilen bildirimin yapılacağı "*yetkili makam*", sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, SPK, BDDK, RK gibi özel kurumlar ile ticaret sicili gibi kuruluşlardır ve bildirimi alan her kurum ve kuruluş, kendi kanununa göre işlem yapacaktır[640].

Payların yukarıda belirtilen oranlarda kazanılması veya elden çıkarılması hâlinde, sermaye şirketine ve yetkili makamlara bildirilmesinden başka, yıllık faaliyet ve denetleme raporlarında da bu durum ayrı bir başlık altında açıklanır ve sermaye şirketinin internet sitesinde ilân edilir.

Bir teşebbüs, bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, *yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmibeşini, otuzüçünü, ellisini, altmışyedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına* sahip olmanın tespitinde, pay ve oy oranlarının tespiti maksadıyla sevk edilen TTK'nin 196'ncı maddesi uygulanacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 198'inci maddesinde hükme bağlanan *bildirim yükümlülüğü*, bildirim yükümlüsü *teşebbüs* ile teşebbüsün paylarını alarak iştirak ettiği sermaye şirketinin yönetim kurulu üyeleriyle yöneticilerinin, kendilerinin, eşlerinin, velayetleri altındaki çocuklarının ve bunların, sermayelerinin en az yüzde yirmisine sahip bulundukları ticaret şirketlerinin o sermaye şirketindeki payları ile ilgili olarak bildirimde bulunacakları şeklinde genişletilmiştir.

Burada bahse konu bildirim, sadece teşebbüsün ve teşebbüsün iştirak ettiği sermaye şirketinin bir bildirimi olarak kabul edilmemeli; şayet bir ticaret şirketi bir sermaye şirketinin paylarına TTK m.198 hükümleri çerçevesinde sahip oluyorsa, bu ticaret şirketinin yöneticilerinin aynı bildirim yükümlülüğüne tâbi olduğunun kabulü gerekmelidir.

---

640 Gerekçe TBMM, s. 138

(2) Bildirimin tescil ve ilânı

TTK m.198/1'de hükme bağlanan bu bildirimlerin; *yazılı şekilde* yapılması, ticaret siciline de *tescil ve ilân* olunması gerekir. Sözü edilen bildirimler, şirketler topluluğunun tespitinde pay ve oy oranlarının hesaplanmasında esas alınacağından, bu bildirim yapılmasa da şirketler topluluğu TTK m.196-198'inci maddelerde belirlenen hâllerde kurulmuş sayıldığından, bildirimin yazılı şekilde yapılması tescil şartı; ticaret siciline yapılan bu tescilin de bildirici etkiye sahip olduğu kabul edilmelidir.

(3) Bildirim ve tescil yükümlülüğünün yerine getirilmemesi

TTK m.198/1'de hükme bağlanan bildirimin "*on gün*" içinde yapılması gerekir. Ancak bu süre, zamanaşımı veya hak düşürücü bir süre değildir; sadece bildirimin bu süre içinde yapılmasını öngören bir *düzenleyici süredir.*

"Bildirim ile tescil ve ilân yükümlülüğü yerine getirilmediği sürece, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer haklar donar. Bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümler saklıdır" (TTK m.198/2).

Görüldüğü gibi kanun koyucu, bildirim ile tescil ve ilân yükümlülüğünün yerine getirilmemesinin sonucu olarak, ilgili paylara ait oy hakkı dâhil, diğer hakların donacağını hükme bağlamış; bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesine dair diğer hukuki sonuçlara ilişkin hükümleri de saklı tutmuştur.

Bu hâlde paylara ait olan hakların donması, TTK m.201'de sözü edilen "*donma*" hükümlerine tâbi olmadan; bir diğer ifadeyle, "*karşılıklı iştirak*" olup olmadığı araştırılmadan gerçekleşen bir donma olarak kabul edilmeli ve herhangi bir sınırlamaya bağlı tutulmadan, *bildirim, tescil ve ilânı gereken tüm haklar donmalı*; söz konusu paylar toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamalı, paydan doğan diğer haklar pay sahibine verilmemelidir.

Paylara ait olan hakların donmasına rağmen, söz konusu paylar, iştirak edilen sermaye şirketinin toplantı ve karar nisabının hesaplanmasında dikkate alınırsa ve meselâ bu paylar anonim şirket genel kurulunda temsil edilirse, TTK m.445 vd. hükümlerine göre, genel kurula katılma yetkisi olmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp

oy kullandıkları gerekçesiyle, genel kurul kararlarının iptali istenebileceği gibi, şartların oluşmasıyla ilgili sermaye şirketinin yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna da başvurulabilir.

TTK m.198'de hükme bağlanan bildirim ile tescil ve ilân, bu payları iktisap eden teşebbüs sahibi için bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini haber alan ticaret sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır. Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK m.33). Kaldı ki, Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 38'inci maddesi hükmüne göre, "*yükümlülüğü yerine getirmemiş olanları öğrenen noterler, odalar ve vergi daireleri gibi resmi makamlar durumu*" ticaret sicili müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

bbb) Pay ve pay oranlarına göre hâkimiyet esasları

Hâkimiyet ilişkisinin tespitinde, sermaye şirketlerindeki pay oranlarının hesaplanması, Türk Ticaret Kanunu'nun 196'ncı maddesinde *emredici* şekilde, pay ve oy oranları olarak ayrı ayrı hükme bağlanmıştır.

(1) Hâkimiyetin pay oranına göre tespiti esasları

Kanun koyucu, TTK m.195/2'de "bir *ticaret şirketinin başka ticaret şirketlerinin paylarının çoğunluğuna sahip olunmasını*" hâkimiyetin varlığına *karine* kabul ettikten sonra, pay çoğunluğundan ne anlaşılması gerektiğini ve pay çoğunluğunun nasıl hesaplanacağını TTK m.196'da hükme bağlamıştır.

TTK m.196'da kabul edilen kurala göre, pay oranlarının hesaplanmasında, bir ticaret şirketinin veya teşebbüsün, *"bir ticaret şirketindeki iştirakinin yüzdesi, o sermaye şirketindeki payının veya payların itibari değerleri toplamının, iştirak olunan şirketin sermayesine oranlamasıyla bulunur"* (TTK m.196/1, c.1).

İştirak oranının hesabında, kanun koyucunun kabul ettiği kıstas; *payın sayısı değil, itibari* değeridir. İştirak oranına esas olacak payların itibari değeri hesaplanırken, *pay bedellerinin ödenmiş olup olmaması herhangi bir önemi haiz değildir*[641]. Ayrıca payın itibari değerinden

[641] Gerekçe TBMM, s.137.

yüksek bir bedelle piyasaya çıkarılmasında da, aşan kısım iştirak oranının hesaplamasında değerlendirmeye esas alınmaz.

Kanun koyucunun kabulüne nazaran, bu iştirak oranının hesaplanmasında, *sermaye şirketinin doğrudan veya dolaylı olarak edindiği kendisine ait paylar dikkate alınmamaktadır* (TTK m.196/1., c.2). TTK m.196/1, c.2 ile getirilen bu istisna, paydan doğan hakların donduğu tüm durumlarda da uygulanmalıdır.

Bir teşebbüs ya da ticaret şirketinin bir sermaye şirketinde sahip olduğu paylar hesaplanırken, ona bağlı şirketlerin sahip oldukları veya onun hesabına alınmış olup üçüncü kişilerin elinde bulunan paylar da hesaba katılacaktır (TTK m.196/3)[642]. Hüküm dolaylı pay sahipliği bakımından uygulama kabiliyeti bulan oran hesabı ile ilgilidir; dolaylı pay sahipliği bakımından sadece bağlı şirketleri dikkate almaktadır. Kanaatimizce, hüküm, başkaca dolaylı oy oranlarının hesaplanmasına da uygulanabilecek niteliktedir. Zira belirtmek gerekir ki, dolaylı pay ya da oy sahipliğinin hesaplanmasında tek kıstas, bağlı şirket vasıtasıyla sahip olunan pay ve pay oranları değildir.

(2) Hâkimiyetin oy oranına göre tespiti esasları

Bir ticaret şirketi veya teşebbüsün, *"bir sermaye şirketinin oy hakkının yüzdesi, ticaret şirketinin sermaye şirketinde sahip bulunduğu paylardan doğan kullanılabilen oy haklarının toplamının, sermaye şirketindeki kullanılabilir tüm oy haklarının toplamına oranlamasıyla bulunur"* (TTK m.196/2, c.1).

Oy oranının hesaplanması bakımından kabul edilen ölçüt, sermaye şirketindeki kullanılabilir oy oranlarıdır. Bu nedenle *donma, oydan yoksunluk* ve sair herhangi bir sebeple kullanılabilir olma niteliği taşımayan oylar, hesaplamada dikkate alınmaz[643]. Buna göre pay oranının hesabında olduğu gibi; *"hesaplamada, sermaye şirketini hem kendi hem*

---

642 Türk Ticaret Kanunu'nun 196'ncı maddesi, gerek hükümet tasarısında gerekse Adalet Komisyonu raporu sonrasında oluşturulan yasa metninde iki fıkradan oluşurken, TBMM görüşmeleri esnasında verilen bir önergeyle, mehaz Alman Kanunu nazara alınarak, bağlı şirket dolayısıyla, "hesaba katma" hükmü üçüncü fıkra olarak maddeye ilâve edilmiştir (Bkz., TBMM Tutanak Dergisi, 23. Dönem, Cilt 90, Birleşim 51, s.52).

643 Gerekçe TBMM, s.137; TTK m.389'da, yavru şirketin iktisap ettiği ana şirkete ait paylarda, oy hakkı ve diğer hakların donacağı hükme bağlanırken, TTK

de onun hesabına alınmış olup da, üçüncü kişilerin elindeki paylardan doğan oy hakları düşülür." (TTK m.196/2, c.2).

B) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN BENZER KAVRAMLARLA İLİŞKİSİ

Şirketler topluluğunun benzer diğer kavramlarla karıştırılmaması için benzer kavramların kısaca izah edilmesi faydalı olacaktır.

Bu bağlamda şirketler topluluğu ile "*holding*" arasında bir yakınlık olduğu söylenebilir. Holding şirketler, hukukumuzda ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olmakla birlikte, TTK m.519/4'te bu tür şirketlerden bahsedilmektedir. TTK m.519/4'e göre "***holding***", *başlıca amacı başkaca işletmelere katılmaktan ibaret bulunan şirketlerdir.* Buna göre holding, bir *faaliyet türüdür*; asıl amacı başka işletmelere iştirak etmek suretiyle iktisadi faaliyette bulunan bir anonim şirkettir.

Şirketler topluluğu, *bir şirket türü değildir.* Şirketler topluluğundan bahsedebilmek için topluluk üyeleri arasında bağlı şirket-hâkim şirket ilişkisinin bulunması gerekir. Holdingin amacı başka işletmelere iştirak ederek iktisadi faaliyette bulunmak iken; şirketler topluluğunun hâkiminin amacı, hâkimiyet kurmaktır. Holdingin amacı, hâkimiyet kurmak değildir. Bununla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri nazara alındığında, amacı sebebiyle, diğer şirketlerde hâkim pay sahibi olan *holdingler, şirketler topluluğu hükümlerine tâbi olacaktır.*

Ticari faaliyetlerin yürütülmesi ve yaygınlaştırılmasında bir vasıta olarak kullanılan *merkez-şube* yapılanması şirketler topluluğu olarak kabul edilemez. Zira şirketler topluluğunda, topluluğa dâhil olan şirketlerin bağımsız bir hak süjesi olması karşısında; şubelerin hukuki anlamda böyle bir niteliği yoktur. Şubenin dış ilişkilerindeki bağımsızlığı ile organizasyona dayalı bağımsızlığı, hukuki şahsiyete sahip olmak bakımından önemli değildir[644].

---

m.197'de ise, karşılıklı iştirak hâlinde her iki şirketin birbirine hâkim olması durumunda, ikisinin de hem hâkim hem de bağlı şirket olacağı öngörülmüştür. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, karşılıklı iştirak hâlindeki bağlı (aynı zamanda hâkim) şirketlerin payları üzerindeki hakların donması söz konusu olacak ve bu durumda hâkimiyet ilişkisi ortadan kalkacaktır.

644 **von Büren, R./Stoffel, W.A./Schnyder, A.K./ChristenWestenberg, C.**: Aktienrecht, Schulthess, Zürich 2000, Rn.1236.

Şirketler topluluğu, *"kartel"*den de farklıdır. ***Kartel anlaşmaları,*** *birbiriyle rekabet halinde bulunan teşebbüsler arasında yapılan ve rekabetin engellenmesi, kaldırılması ya da bozulması amacını izleyen ya da böyle bir sonuç doğuran anlaşmalardır*[645]. Her iki müessese arasındaki temel fark iktisadi bağımsızlıktadır. Şirketler topluluğunda hukuki anlamda bağımsız şirketlere hâkim olmak suretiyle bunlar bir araya getirilir. Kartelde ise, iktisadi bağımsızlıklarını sadece kısmî hususlarda (mesela fiyat ve satış miktarı gibi) sınırlanmış olan hukuki ve iktisadi anlamda bağımsız işletmelerin koordinasyonunun sağlanması söz konusudur[646]. Şirketler topluluğu için her yönüyle şirketi hâkimiyet altına alma gerekli ise de, karteller de TTK'deki şirketler topluluğu hükümlerine tâbi tutulmuştur.

III) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNUN KURULMASININ SONUÇLARI

Yukarıda da izah edildiği üzere, şirketler topluluğu, *"fiili şirketler topluluğu"*, *"sözleşmeye dayalı şirketler topluluğu"* şeklinde oluşur. Buna göre, eğer şirketler topluluğuna dâhil unsurlar bir sözleşme yaparak bir araya geliyorsa, sözleşmeye dayalı şirketler topluluğu; bir sözleşme bulunmaksızın oy oranı veya diğer bir fiili ilişki sayesinde oluşuyorsa, fiili şirketler topluluğu söz konusudur.

Fiili şirketler topluluğu ilişkisinin temelinde, şirketler topluluğuna dâhil unsurlarca akdedilmiş bir sözleşme bağı bulunmamakta; hâkim teşebbüsün gücü de sözleşmeye değil, diğer şirketler üzerinde oy oranı başta olmak üzere çeşitli yollarla kurduğu hâkimiyete dayanmaktadır.

Fiili şirketler topluluğunda, topluluk unsurları arasında bir sözleşme bağı bulunmadığından, bu ilişkinin bir ortaklık sözleşmesi ilişkisi içerisinde nitelendirilmesi de mümkün değildir.

Sözleşmeye dayalı şirketler topluluğunda, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükler saklı olmak üzere, kanun koyucu gerek sözleşmeden doğan gerek fiili şirketler topluluğunda, ilgililerin karşılıklı bazı hak ve

---

645 **Özsunay E.,** *"Türk Kartel Hukukunda Teşebbüsler Arası Anlaşmalar ve Teşebbüs Birliklerinin* Kararı", Rekabet Kurulu Perşembe Konferansları 5, Ankara 2000, s. 57.

646 **Von Büren/Stoffel/Schnyder/Christen-Westenberg,** Rn.1235.

yükümlülüklerinin bulunduğunu hükme bağlamış; bilhassa *tam hâkimiyetin* gösterdiği özellikleri nazara alınarak ayrıca düzenlenmiştir[647]. Bu sebeple açıklamalarımızı, şirketler topluluğuna dâhil teşebbüslerin hak ve yükümlülüklerini "*genel olarak*" ele aldıktan sonra "*tam hâkimiyet*"-le ilgili olarak yapacağız.

A) GENEL OLARAK

1. Bağlı Şirketin "Bağlılık Raporu" Hazırlaması

"Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler" (TTK m.199/1, c.1); bu rapora ***"bağlılık raporu"*** denir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin ilk üç fıkrasında ele alınan "*bağlılık raporu*", kanun koyucunun düzenlemesinden anlaşıldığı üzere, bağlı şirket pay sahiplerinin, bağlı şirketin geçmiş faaliyet yılı içerisinde hâkim ve bağlı diğer şirketlerle olan ilişkilerinden haberdar olmaları amacıyla hazırlanır[648].

Bağlılık raporunu *hazırlama yükümlülüğü*, bağlı şirketin yönetim kurulundadır; kurul bu raporu *faaliyet yılını izleyen ilk üç ay* içinde düzenlemek zorundadır (TTK m.199/1). Faaliyet yılı içinde, sadece belirli bir dönemde bağlılık ilişkisi söz konusu olsa dahi, bağlılık raporu düzenleme yükümlülüğü vardır; ancak bu halde esas itibariyle, sadece bağlılığın söz konusu olduğu dönem bakımından "*bağlılık raporu*" düzenlenir. Kural bu olmakla beraber, bağlılığın *ön etkisinin* (Vorwirkungen der Abhängigkeit) veya *devam eden etkisinin* (Nachwirkungen der Abhängigkeit) söz konusu olduğu durumlarda, raporun süre itibarıyla kapsamının bu etkiye göre genişleyeceği kabul edilmelidir. Bir devralma sözleşmesinin rekabet hukuku çerçevesinde izne tâbi olması, bağlılıkta ön etkiye; devredilen çoğunluk payının geri

---

647 Mevcut sistemimiz aslında, hâkim şirketin yetki ve sorumluluklarını, "*tam hâkimiyet olan hâller*" ve "*olmayan hâller*" olarak ikiye ayırmıştır.

648 Alman hukukunda hâkim şirketin %100'lük hâkimiyeti durumunda, hukuki sonuçları bakımından birleşmeye benzeyen, ancak bağlı şirketin tüzel kişiliğini yitirmemesi nedeniyle birleşmeden farklı bir müessese olan *bütünleşme* (Eingliederung) yoluna gidilmesi mümkündür (AktG § 319 ff.) ve bu hâlde bağlılık raporunun düzenlenmesi gerekli değildir (AktG § 323 Abs. 1). Türk hukukunda tam hâkimiyetin bulunduğu hallerde bu raporun düzenlenmesinin gerekli olmadığı yönünde, özel bir hükme yer verilmemiştir. Mevcut düzenleme kapsamında, tam hâkimiyet durumunda da bağlılık raporu tanzimi gereklidir.

alma hakkıyla devredilmesi, bağlılıkta devam eden etkiye örnek gösterilebilir[649].

Bağlılık raporu, bağlı şirketin hâkim ve bağlı diğer şirketlerle olan ilişkileriyle, bu ilişkilerin bağlı şirketin yönetim kurulu tarafından değerlendirilen kayıp/yarar gibi sonuçları hakkındaki *bilgileri içerir*[650]. Buna göre rapor, ilişkilerin gösterildiği kısım ile sonucun yer aldığı kısım olmak üzere *iki ayrı bölümden oluşur* (TTK m.199/1-3).

Pay sahiplerinin bilgisine sunulan kısım, yıllık rapor vasıtasıyla açıklanan *sonuç kısmıdır* (TTK m.199/3). Yönetim kurulunun hazırladığı raporun *sonuç kısmı*, yıllık rapora alınarak olağan genel kurula sunulan, böylece pay sahiplerinin *aydınlatılmasında* önemli rolü olan kısımdır. Burada bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılında gerçekleştirdiği tüm hukuki işlemleri ve gerçekleştirilen ya da kaçınılan davranışları değerlendirerek, bunların şirkete sağladığı fayda ve kayıpları ortaya koyacaktır. Bağlı şirketin yönetim kurulu, söz konusu hukuki işlemler ve gerçekleştirilen ya da kaçınılan davranışlar söz konusu olduğunda, değerlendirmesini, kendisi tarafından bilinen hâl ve şartlar ışığında yapacaktır. *Maddenin gerekçesinde*, "*yönetim kurulunun sorumluluğu açısından kurulca* ***bilinmesi gereken*** *bazı hâl ve şartların da dikkate alınıp alınmayacağı, öğreti ve içtihat faaliyeti gerektirir*" denilmektedir.

Yönetim kurulu bağlılık raporunda, ilgili her hukuki işlem için karşı edimin uygunluğunu değerlendirmek; uygun bir karşı edim alınmamışsa bundan doğan kaybın nasıl denkleştirildiğini açıklamak zorundadır.

Bağlı şirketin yönetim kurulu raporunda, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesinden kaçınılan davranışlar için fayda/zarar analizini yapmak; o faaliyet yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesinin birinci fıkrasına göre açıklanması gereken bir hukuki işlem ve gerçekleştirilen veya kaçınılan bir davranışı bulunmuyorsa, bunu da raporuna yazmak zorundadır[651].

---

649 **Ziemons** in: Ziemons/Binnewies, §12 Rn.424 ff.

650 Gerekçe TBMM, s.138.

651 Bu sebeple raporun ilişkiler kısmında yer alan bilgilerin denetlenmesi önem taşır. Alman hukukunda bağlılık raporunun düzenlendiği AktG § 312'yi takip eden §§ 313-314'te bağlılık raporunun "*Gözetim Kurulu*" (Aufsichtsrat) ve orta ve büyük

Bağlılık raporunun *ilişkileri gösteren kısmında*, bağlı şirketin geçmiş faaliyet yılı içerisinde, hâkim şirketin yönlendirmesiyle veya hâkim veya başka bir bağlı şirket yararına yaptığı "*hukuki işlemler*", hâkim veya bağlı bir başka şirket yararına alınan ya da alınmasından kaçınılan davranışlar (*önlemler*) hakkında açıklamalara yer verilir; bu işlem ve şirket yararına alınan ya da alınmasından kaçınılan davranışların (önlemlerin) neler olduğu açıkça belirtilir. Kanunda bu husus, "*Hukuki işlemlerde edimler ve karşı edimler, önlemin* (şirket yararına alınan ya da alınmasından kaçınılan davranışların) *sebebi ve şirket yönünden yarar ve zararları belirtilir*" (TTK m.199/1, 3) şeklinde ifade edilmiştir.

Önlem (şirket yararına alınan ya da alınmasından kaçınılan davranışlar), hukuki işlemleri ve işletmeyle ilgili tüm icraî ve ihmalî işlem ve davranışları kapsar. Özellikle ihmalî davranışların ne zaman bağlılık raporunda yer alacağı bir sorun olarak akla gelse de; yönlendirme ya da yarar gözetilmediğinde, yönetim kurulunun yapması gereken bir iş yapılmamışsa veya yükümlülüklerine uygun hareket eden bir yönetim kurulunun yapması gereken bir iş söz konusuysa, söz konusu ihmalî davranışın raporda belirtilmesi gerekir[652].

Uğranılan bir ***zarar denkleştirilmişse*** "*bunun faaliyet yılı içinde nasıl gerçekleştiği veya şirketin sağladığı hangi menfaatlere ilişkin olarak bir istem hakkı tanındığı ayrıca bildirilir*" (TTK m.199/1,4). Bağlılık raporu sadece ilgililere fikir sağlama veya aydınlatmanın değil, yönetim kurulunun hesap vermesinin bir aracı olduğundan, *denetlemeye imkân sağlayacak açıklıkta olmalıdır* (TTK m.199/2)[653].

Bağlılık raporunun sonuç kısmında, ilişkiler kısmında yer alan bilgiler bağlamında, bir sonuç açıklaması yapılır. Bu kısımda yönetim kurulu tarafından, bilinen hâl ve şartlara göre, "*her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edimin sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin* (şirket yararına alınan ya da alınmasından

---

ölçekli anonim şirketlerde "*hesap denetçisi*" (Abschlussprüfer) tarafından denetlenmesi gereği belirtilmesine rağmen, Türk hukukunda bu hususta özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

652 **Ziemons,** Hilgard in: Handbuch der Aktiengesellschaft, Hrsg. Hildegard Ziemons/ Burkhard Binneweis, Köln 2011, §12, Rn. 440.

653 Bkz., Gerekçe TBMM, s. 140.

kaçınılan davranışların) *şirketi zarar uğratıp uğratmadığı* açıklanır. *Şirket zarara uğramışsa, yönetim kurulu ayrıca zararın denkleştirilip denkleştirilmediğini de belirtir*" (TTK m.199/3).

Yukarıda da belirtildiği üzere, bağlılık raporu, sınırlı olarak, *pay sahiplerini aydınlatma aracı* olarak kullanılabilecektir. Çünkü raporun tamamı değil, sadece sonuç kısmı yıllık raporda yer alabilecektir[654] (TTK m.199/3).

2) Hâkim Şirketin Bağlı Şirketten Bilgi Alma Hakkı

Şirketler topluluğunun kurulması ile birlikte bağlı şirket, kanunda öngörülen bazı bilgileri hâkim şirkete veya hâkim teşebbüse vermekle yükümlüdür. Bağlı şirketin bu yükümü, şirketler topluluğunun oluşmasıyla kendiliğinden yerine getirilmesi gereken bir yüküm değildir; hâkim şirket veya teşebbüsün bu yönde bir *talepte bulunması* gerekir (TTK m.199/4). Hâkim şirketin bağlı şirketten bilgi alma hakkı; hâkim şirket veya teşebbüs açısından bir hak, bağlı şirket bakımından da bir yükümlülüktür[655].

Bilgi alma hakkının ne zaman kullanılacağı hususunda kanunda herhangi bir sınırlama yoktur; hâkim şirketin bağlı şirketten her zaman bilgi alma hakkının bulunduğunun, bilgi alma hakkının hâkim şirketin uygun göreceği herhangi bir zamanda kullanabileceği bir denetim vasıtası olduğunun kabulü gerekir.

Bağlı şirketten kanunda öngörülen bilgileri isteme hakkı; hâkim şirketin yönetim kurulu başkanına aittir. Hâkim şirketin yönetim kurulu başkanı, *yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine veya böyle bir talep olmadan kendiliğinden,* bağlı şirketten kanunda öngörülen bilgileri isteyebilir; hâkim şirket yönetim kurulu üyelerinin bağlı şirketten

---

654 Sınırlı bir aydınlatma aracı olması nedeniyle, bu hak Alman hukukuna hâkim öğreti tarafından anonim şirket pay sahiplerinin AktG §131'de düzenlenen bilgi alma hakkı çerçevesinde kabul edilmektedir. **Ziemons** in: Ziemons/Binnewies, §12, Rn 467. Benzer durumun Türk Hukuku bakımından kabul edilmesi gerektiği gerekçede ifade edilmektedir. TTK'nin 199'uncu maddesinin birinci fıkrasının gerekçesinde, "*Hüküm, şirketler topluluğuna ilişkin sorumluluk hükümleri ve özellikle... 437 nci maddede öngörülen inceleme hakkı ile birlikte değerlendirildiğinde amacı daha iyi anlaşılır. Çünkü pay sahipleri bu rapora dayanarak sorumluluk davası açabilecekleri gibi bilgi alma haklarını daha bilinçli bir şekilde kullanabilirler*" denilmektedir (Gerekçe TBMM, s.138).

655 "*Bilgi Verme Yükümlülüğü*"ne aykırı hareket edenler adli para cezasıyla cezalandırılır (TTK m.562/3).

doğrudan bilgi isteme hakları yoktur. Yönetim kurulu üyeleri taleplerini hâkim şirketin yönetim kurulu başkanına yapar (TTK m.199/4).

Bilgi alma hakkı, yönetim kurulu başkanı, başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eden başkan vekili tarafından bizzat kullanılır.

Kanun koyucu, bilgi talep usulü bakımından, hâkim şirket yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin, hâkim şirket yönetim kurulu başkanından istemde bulunmasını aramakla birlikte; yönetim kurulu başkanının aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle herhangi bir yönetim kurulu üyesinin talebi olmadan re'sen bilgi isteyebileceğini kabul etmek gerekir.

Hâkim şirketin yönetim kurulu başkanının, bağlı şirketten aldığı bilgi; bilgiyi talep eden yönetim kurulu üyesine değil, *hâkim şirketin yönetim kuruluna* raporlanacaktır (TTK m.199/4). Hâkim şirketin yönetim kurulu başkanı ayrıca, hazırladığı raporun sonuç kısmını, bilgi talebinde bulunan yönetim kurulu üyesinin istemi kapsamında yıllık rapor ile denetleme raporuna da ekleyecektir (TTK m.199/4).

Hâkim şirket yönetim kurulu başkanının, bağlı şirketten *talep edebileceği bilgiler*, TTK m.199/4'te belirtilmiştir. TTK m.199/4 uyarınca yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerinden birinin talebi üzerine, bağlı şirketlerle ilgili olarak rapor hazırlayıp yönetim kuruluna sunmakla yükümlüdür. Rapor, "*bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri*" hakkında olabilecektir. Kanunda kapsamı belirtilen raporun hazırlanması için gerekli olanlar dışında, bağlı şirketin anılan madde uyarınca bilgi ve belge verme yükümlülüğü bulunmamaktadır (TTK m.199/4).

Bağlı şirketin bilgi verme yükümlülüğü, sadece hâkim şirket yönetim kurulunun, bağlı şirket hakkında fikir edinmesi ya da aydınlatılması amacını taşımaz; *denetlemeye imkân sağlayacak* sayısal ifadelerin, olgu ve sonuçların aktarılması da hedeflenmektedir. Bu suretle hâkim şirket, konsolide finansal durum hakkında bilgi edinme, denetim yapma ve önlemler alabilme imkânına sahip olacaktır[656]. Bu sebepten dolayı, bağlı

[656] Gerekçe TBMM, s. 139.

şirketin ilgili konularda aktaracağı bilgi ve belgelerin de *hesap verme ilkesine uygun şekilde olması gerekmektedir.*

Bağlı şirket, açık bir haklı sebebin bulunması halinde, istenilen bilgilerin verilmesinden imtina edebilir (TTK m.199/4). Haklı sebebin ne olduğunu ve bunun bilgilerin verilmesinden imtina için açık bir haklı sebep olmadığını, somut olayın koşulları belirleyecektir.

Bilgi verilmesinden kaçınılması için haklı sebebin bulunup bulunmadığında temel hareket noktası, *talep edilen bilgilerin amacı çerçevesinde kullanılıp kullanılmayacağıdır.* Bilgi almanın amacı, hâkim şirketin, bağlı şirketle ilgili bazı önemli hususlarda bilgi edinmesidir; bunun dışında kalan bir amaç için, meselâ bilginin bir haberde veya davada kullanılacak olması ya da rakibe, muhtemel rakibe veya yabancılara verilecek olması gibi haller, bilgi verilmesi talebinin reddi için haklı sebep teşkil edebilecektir[657]. Öte yandan, bilginin amaca uygun şekilde kullanılacak olması halinde dahi, açık haklı sebeplerin mevcudiyeti kabul edilmeli, bilgi verilmesinden imtina edilebilmelidir[658].

Bağlı şirketle ilgili olarak bilgi temin edilmesi isteminde bulunan yönetim kurulu üyesi, bunu üçüncü kişinin yararlanması amacıyla yapmışsa, bunun sonuçlarından hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacaktır (TTK m.199/4; 562/3).

3) Hâkim Şirket Pay Sahiplerinin Bilgi Alma Hakkı

"*Hâkim şirketin her pay sahibi*, ***genel kurulda***, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir" (TTK m.200).

Kanun koyucu TTK m.200'de yaptığı bu düzenlemeyle, hâkim şirket pay sahiplerine özel bilgi alma hakkı tanımış; pay sahibinin, pay sahibi olduğu hâkim şirketten bilgi alma hakkı, bağlı şirkete de teşmil edilmiştir[659].

---

657 Gerekçe TBMM, s. 139.
658 Gerekçe TBMM, s. 139.
659 Gerekçe TBMM, s. 139.

Kanunda açıkça belirtilmese de pay sahibinin bilgi alma hakkının muhatabı, yönetim kuruludur; *pay sahibi bu hakkını genel kurulda kullanır*. Yönetim kurulunun yükümlülüğünü yerine getirmesi, verilen bilgilerin denetlemeye elverişli olmasına bağlıdır; pay sahibinin soyut ve genel bir biçimde aydınlatılması yeterli değildir[660].

Bilgi alma hakkı çerçevesinde talep edilen bilgilerin verilmesine ilişkin TTK m.200 hükmüne riayet edilmemesinin *sonuçları Kanunda düzenlenmemiştir*. Ancak Kanunun gerekçesinden hareketle, pay sahibinin bilgi alma hakkını düzenleyen münferit hükümlerde yer alan esasların, bu hâle de uygulanabileceğini kabul etmek gerekir.

Hâkim şirket pay sahibinin bilgi alma hakkının usulü dairesinde yerine getirilebilmesi için, pay sahibine bilgi vermekle yükümlü olan hâkim şirket yönetim kurulunun, bağlı şirketten bilgi alma hakkına sahip olması gerekir. Dolayısıyla, pay sahibinin bilgi alma hakkının kapsamı; hâkim şirket yönetim kurulunun, bağlı şirketten bilgi alma hakkıyla sınırlıdır.

4) Hakların Donması

Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler topluluğuna ilişkin düzenlemeleri kapsamında, hakların donması ile ilgili bazı hükümlere yer verilmiştir. Bunlardan ilki yukarıda açıklanan *bildirim yükümlülüğünün ihlalinden* kaynaklanmaktadır. Diğer bir donma hali *karşılıklı iştirak* bakımından ortaya çıkmaktadır.

Sermaye şirketlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin paylarına sahip olması mümkündür[661]. Türk Ticaret Kanunu'nun 197'inci maddesinde, "***karşılıklı iştirak***" için, şirketlerin karşılıklı olarak birbirlerinin paylarına sahip olması esası kabul edilmiş; iştirak oranının belirli bir seviyeyi geçmesi halinde, bu şirketlerin *"karşılıklı iştirak"* durumunda olduğu kabul edilmiştir.

Bu kabule nazaran karşılıklı iştirak, teknik bir kavramdır; sermaye şirketlerinin birbirlerinden pay iktisap ettiği her hâl değil, sadece kanunda öngörülen limitin aşıldığı hâllerde karşılıklı iştirak vardır. Yasal düzenleme uyarınca, birbirlerinin paylarının *en az dörtte birine sahip olan sermaye şirketleri* karşılıklı iştirak konumundadır (TTK m.197/1).

---

660 Gerekçe TBMM, s. 139.

661 Gerekçe TBMM, s. 137.

Yasanın karşılıklı iştirake ilişkin sınırlandırıcı hükümlerinin uygulanması bakımından, karşılıklı iştirak halindeki şirketlerin; bir şirketler topluluğu bünyesinde bulunması şart değildir (TTK m.197/1, 201/1; *aksi yönde bkz.*, TSY m. 107/10).

Karşılıklı iştirak, sermaye şirketlerinde sermayenin sulandırılması ve kurumsal yönetim açısından içerdiği tehlike nedeniyle, kanun koyucuların üzerinde tedbir almasını gerektiren bir durumdur.

Bu kapsamda meselâ, (A) anonim şirketinin 100 birimlik sermayesi bulunduğu, (B) anonim şirketinin de 100 birimlik bir sermaye ile kurulmak istenildiği düşünüldüğünde, (A)'nın (B)'den iktisap edeceği 30 birimlik iştirak, başlangıçta bir sorun doğurmaz. Ancak (A)'nın 50 birimlik sermaye artırımına gitmesi ve (B)'nin bu artırımın tamamını karşılaması durumunda, (A) aslında iktisadi anlamda dolaylı olarak kendisine ait olan bir parayı, kendi sermayesini artırmak için kullanmış olmaktadır. Kanun koyucu bu sermaye iktisabının karşılıklı olarak %25'i aşması halinde (*basit karşılıklı iştirak*); bu durumu iktisadi düzen ve pay sahipleri açısından tehlike olarak kabul etmiş ve şirketlerin sürekli olarak aynı parayı kullanarak sermaye artırımına gitmesinin, mevcut sermayeyi sulandıracağını düşünmüştür. Öte yandan şirketlerin karşılıklı olarak birbirine hâkim olduğu karşılıklı iştirak halleri (*nitelikli karşılıklı iştirak*) şirket yönetimi bakımından bir sorunu beraberinde getirmektedir ki; artık pay sahiplerinin şirketlerdeki oy hakkının bir önemi kalmamakta, şirketler kendilerine ait oy haklarını yönetim kurulu vasıtasıyla kullanacağından, karşılıklı iştirak halindeki şirketlerin yönetim kurullarının, kendileri istemedikçe görevden alınamaması gibi bir tehlike gündeme gelecektir. İşte kanun koyucu bu tehlikeleri bertaraf etmek için, iştirak oranının karşılıklı olarak %25'i geçmesi durumunda (*basit karşılıklı iştirak*), bilerek karşılıklı iştirak konumuna geçen şirketin pay sahibi haklarının kullanımını büyük ölçüde sınırlandırmakta (TTK m.201/1), şirketlerden biri diğerine hâkim olmuşsa (*tek taraflı nitelikli karşılıklı iştirak*), yavru şirket ana şirkette oy haklarını kullanamamakta, her iki şirket birbirine hâkim olmuşsa (iki taraflı nitelikli karşılıklı iştirak), oy haklarının tamamı donmaktadır (TTK m.389, 612). Bu kapsamda aksine sonucu (oy haklarının tamamının kullanılacağını) öngören TTK m.201/2 hükmü, TTK m.201/1 hükmü ile açıkça çelişmekte olduğundan, çelişki bulunduğu ölçüde TTK m.201/1 hükmünün esas alınması gerekir.

Kanun koyucunun bu kabulüne göre, *karşılıklı iştirak geçersiz sayılmamakta*; fakat karşılıklı iştirakin hâkimiyet ve çoğu kez karşılıklı hâkimiyet ilişkisini kurarak, bu durumdaki şirketlerin hâkim ve bağlı şirketin yüküm ve sorumluluklarına tâbi olacağı açıkça hükme bağlanmakta ve bazı sınırlamaları (TTK m.201) da beraberinde getirmektedir.

Buna göre, karşılıklı olarak birbirlerinin paylarının *en az dörtte birine sahip* olan sermaye şirketlerinin arasında, karşılıklı iştirak söz konusudur (TTK m.197). Bu payların yüzdelerinin hesaplanmasında, "*pay ve pay oranlarının hesaplanması*" kıstaslarını düzenleyen TTK m.196 uygulanacaktır.

Karşılıklı iştirak halinde sermaye şirketlerinde biri diğerine hâkim olursa; aralarında hâkim şirket-bağlı şirket ilişkisi doğar (TTK m.197/1, c.3). Bu durumda TTK m.389 hükmü uyarınca yavru şirketin iktisap ettiği ana şirket paylarına ait oy hakları ile buna bağlı haklar donar. Ancak TTK m.389 hükmü, karşılıklı iştiraki esas almaksızın yavru şirketin oy haklarının donmasını öngördüğünden, yavru şirketin sahip olduğu hâkim şirket paylarının % 25'in üzerinde ya da altında olmasının önemi bulunmadığına dikkat edilmelidir; her halde yavru şirket oy hakları ve buna bağlı haklar bakımından donma söz konusudur. Söz konusu şirketlerden her biri diğerine hâkimse; ikisi de yavru ve hâkim şirket kabul olunacaktır (TTK m.197/1, c.4) ve her iki şirket bakımından oy hakları ve buna bağlı haklar donacaktır (TTK m.389).

5) Özel Denetim

Şirketler topluluğunun oluşumu sonrasında bağlılığın kötüye kullanıldığına ilişkin emarelerin mevcut olması halinde; kanun koyucu, bağlı şirket pay sahiplerinin haklarının korunması bakımından, *özel denetim* imkânına yer vermiştir. Bu esastan olmak üzere, "*denetçi, özel denetçi, riskin erken saptanması ve yönetim komitesi*; bağlı şirketin, hâkim şirketle veya diğer bağlı şirketle ilişkilerinde hilenin veya dolanın varlığını belirtir şekilde görüş bildirmişse, bağlı şirketin her pay sahibi, bu kanunun açıklığa kavuşturulması amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden *özel denetçi atanmasını*" isteyebilecektir (TTK m.207).

TTK m.207'de ve maddenin gerekçesinde herhangi bir açıklık olmamasına karşın, "*özel denetçi*" atanmasını isteme hakkı, TTK'nin 438 vd. maddelerinde hükme bağlanan, anonim şirket pay sahibinin "*özel denetim isteme hakkı*" çerçevesinde değerlendirilmelidir.

6) Payları Satın Alma Hakkı

Şirketler topluluğunda amaç, plânlanan şekilde tek elden yönetim sayesinde şirketler topluluğuna katılan teşebbüsler için ekonomik menfaat sağlamaktır. Bu sebeple, şirketler topluluğundaki bağlı şirketlerde küçük pay sahiplerinin bulunması, şirketler topluluğunun amacına uygun düşmeyebilir. Küçük pay sahipleri, topluluk yönetimine sorun çıkarırsa, azınlık pay sahibinin iradesine aykırı olarak şirketten ihraç edilmesi gündeme gelmektedir.

Bu mülahazadan hareket eden kanun koyucu, TTK m.208'de azınlığın paylarının *"satın alma hakkını"* hükme bağlamıştır. TTK m.208'e göre, "Hâkim şirket, doğrudan veya dolaylı olarak bir sermaye şirketinin paylarının veya oy haklarının *en az yüzde doksanına* sahipse, *azlık şirketin çalışmasını engelliyor, dürüstlük kuralına aykırı davranıyor, fark edilir sıkıntı yaratıyor* veya *pervasızca hareket ediyorsa*, hâkim şirket, azlığın paylarını varsa borsa değeri, yoksa 202'nci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen şekilde belirlenen değer ile satın alabilir".

Hâkim şirketin bağlı şirketteki azlık paylarını *"satın alma hakkı"* bazı koşulların bir arada bulunmasına bağlıdır. Bu kapsamda;

(1) Bağlı şirketin sermaye şirketi olması gerekir; diğer ticaret şirketlerinde, azınlık paylarını satın alma hakkı tanınmamıştır.

(2) Hâkim şirket, *doğrudan veya dolaylı olarak bağlı şirketin paylarının ve oy haklarının yüzde doksanına sahip olmalıdır*; yüzde doksan oranı hem paylar hem de oylar için şarttır, iki koşulun bir arada bulunması zorunludur.

(3) Azlığın bağlı şirketin çalışmasını engellemesi, dürüstlük kuralına aykırı davranması, fark edilir sıkıntı doğurması ya da pervasızca hareket etmesi gereklidir.

Bu şartların mevcudiyeti halinde hâkim şirket, azlık payını satın alabilecektir. Şartların mevcudiyeti, satın alma yönünde bir zorunluluk doğurmaz; sadece hâkim şirkete *"satın alma" yetkisi verir*[662].

TTK m.208'de, pay sahibinin şirketten *"çıkma hakkı"* düzenlenmemiştir; Hâkim şirkete, azlık paylarını *"satın alma hakkı"* tanınarak,

---

662 Hâkim şirketin yetkiyi hangi organ (yönetim kurulu veya genel kurul) vasıtasıyla kullanacağı hakkında bir sarahat yoktur. Buna göre meselâ, anonim şirketlerde genel kurulun bu yönde bir karar alması gerekecek midir? Yoksa TTK m.374 uyarınca bu hususun işletme konusunu gerçekleştirme kapsamında, yönetim kurulunun yetkisine mi girdiği belli değildir.

bağlı şirketin herhangi bir engelleme ile karşılaşmaksızın faaliyetlerini yürütebilmesi amaçlanmıştır.

Satın alma hakkının oluşması ile birlikte hâkim şirket, bağlı şirket paylarını, varsa borsa değerinden; borsa değeri yoksa TTK m.202/2'de öngörülen şekilde belirlenen değer ile satın alabilir. Satın alma hakkını düzenleyen TTK m.208'in atıf yaptığı 202'nci maddenin 2'nci fıkrasında, *payın gerçek değeri* ile ya da *genel kabul gören bir yöntemle* belirlenecek değerden bahsedilmektedir.

B) TAM HÂKİMİYET HALİNDE

Tam hâkimiyet; hâkim şirketin, bağlı sermaye şirketinin *paylarının ve oy haklarının yüzde yüzüne doğrudan veya dolaylı olarak sahip olmasını* ifade eder. Kanun koyucu tam hâkimiyetin doğurabileceği fiili sonuçları göz önüne alarak, tam hâkimiyete bazı özel sonuçlar bağlamıştır.

Kanunun gerekçesine göre tam hâkimiyet bağlı şirket yönetiminin fiilen etkisizleşmesi ve yönetimin de tam bağlı olması sonucunu doğurur. Bağlı şirket yöneticileri, hâkim şirketin talimatlarını yerine getirmezlerse, bu görevlerini kaybedeceklerini bilirler. Yerine gelenler de aynı akıbete tâbi olacağından bu durum süreklilik arz eder[663].

Kanun koyucu, bağlı şirket yöneticilerinin bu kaygılarını ortadan kaldırmak, tereddütlerini gidermek maksadıyla, *tam hâkimiyette, bağlı şirketin hâkim şirketin talimatlarına riayet etme zorunluluğunu kabul etmiştir.* TTK m.203'e göre, "Hâkim şirketin yönetim kurulu, *topluluğun belirlenmiş* ve *somut politikalarının gereği olmak şartıyla, kaybına sebep verebilecek nitelik taşısalar bile,* bağlı şirketin yönlendirmesine ve yönetimine ilişkin talimat verebilir. *Bağlı şirketin organları talimata uymak zorundadır*".

Tam hâkimiyette, hâkim şirketin kanundan kaynaklanan ve riayeti zorunlu olan bu talimat yetkisini kullanabilmesi, talimatın, şirketler topluluğunun belirlenmiş ve somut politikalarının gereği olmasına bağlıdır; *günlük talimatlar verilmesi* TTK m.203'ün kapsamı dışındadır[664].

Tam hâkimiyette, somut politikalar çerçevesinde hâkim şirket tarafından verilen talimatlara bağlı şirketin riayet etme yükümlülüğü bulunmakla birlikte; belirli bazı durumlarda, somut politikalar çerçevesinde

---

663 Gerekçe TBMM, s.142

664 Gerekçe TBMM, s.142.

olsa dahi, hâkim şirketin talimat verme yetkisi bulunmamaktadır. Gerçekten de TTK m.204'e göre, "*Bağlı şirketin ödeme gücünü açıkça aşan, varlığını tehlikeye düşürebilecek olan veya önemli varlıklarını kaybetmesine yol açabilecek nitelik taşıyan talimat verilemez*".

TTK m.204'te düzenlenen "***talimat verme yasağı***" iki yönlü bir etkiye sahiptir; bir taraftan hâkim şirketin bu konularda talimat vermesini yasaklamakta, diğer taraftan hâkim şirket bu yönde bir talimat verse bile, bağlı şirketin buna uymak zorunda olmadığını hükme bağlamaktadır.

Talimat verme yasağı, özü itibariyle, bağlı şirkete verilecek talimatın, bağlı şirketin mali dengesini ciddi bir şekilde bozacak nitelikteki talimatları ifade etmektedir. Tam hâkimiyet halinde, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin talimatlara riayet etmesi ve icabında bu suretle bağlı şirket menfaatlerini ikinci plana itebileceğine dair varsayıma, TTK m.204'te belirtilen hallerde itibar edilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bu hususa ilişkin olarak *kanunun gerekçesinde*, "bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri ve sorumlu tutulabilecek diğer ilgililer, TTK m.204'te *yasaklanan talimatı yerine getirirse*, TTK m.205'te öngörülen kanuni "*sorumsuzluk*" halinden istifade edemeyecekler; yasaklanan talimatı yerine getirmekten dolayı şirkete ve pay sahiplerine karşı hukuken sorumlu olacaklardır[665]" denilmiştir.

Ancak *gerekçede böyle denilmesine karşın, TTK m.205'te tam aksine bir sonuç hüküm altına alınmıştır.*

TTK m.205'te, bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin ve sorumlu tutulabilecek diğer ilgililerin, TTK m.204'te yasaklanan talimatı yerine getirmesi hâlinde dahi, şirkete ve pay sahiplerine karşı herhangi bir *sorumluluklarının bulunmadığı* hükme bağlanmıştır.

Herhangi bir ihtilâfta kanunun gerekçesi değil, metninin esas alınması temel yorum prensibi olduğundan, hukuk tekniği açısından, TTK m.205'in lâfzında yer alan esasın bağlayıcı olduğu kabul edilmeli; *bağlı şirket yönetim kurulu üyelerinin, yasak talimatı yerine getirmeleri halinde* ***sorumlu tutulmamaları*** *gerekir*. Ancak bu durum, Türk Ticaret Kanunun 204'üncü maddesinde yasaklanan talimata ilişkin düzenlemenin anlamsız kalması sonucunu doğurmaktadır. Neticede sorun, kanun

---

665 Gerekçe TBMM, s.143.

maddesi ve gerekçesi arasındaki sorun olmaktan öteye, iki kanun maddesi arasındaki çelişki olarak nitelendirilmelidir.

Kanaatimizce, bağlı şirketin iktisadi anlamda mahvına yol açacak talimatların, bağlı şirket yönetim kurulu tarafından yerine getirilmemesine ilişkin düzenleme; özellikle *bağlı şirket alacaklılarının menfaatlerinin himayesi bakımından, TTK m.205 düzenlemesine üstün tutulmalıdır.* Mevcut sistemde bağlı şirket alacaklılarının korunması bakımından, bağlı şirket yönetim kurulunun hâkim teşebbüsle olan ilişkilerde temel görevi, kaybın denkleştirilmesini sağlamak ve şirketin iktisadi anlamda mahvına yol açacak talimatları değerlendirerek, bunların yerine getirilmesinden kaçınmaktır. Netice itibarıyla kanun koyucu, TTK m.205 düzenlemesi metninde sehven bulunan 204'üncü maddeye ilişkin atfı maddeden çıkardığında, sorun hukuken sağlıklı şekilde çözümlenmiş olacaktır[666].

TTK m.205 uyarınca bağlı şirket yöneticileri ve diğer ilgililer, şirkete ve pay sahiplerine karşı sorumlu tutulamaz. TTK m.206'ya göre ise, "*Hâkim şirket ve yöneticilerinin, 203'üncü madde çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete*

---

[666] Alman hukukunda tam hâkimiyete benzeyen tek hâl, oy oranı bakımından %100 lük hâkimiyet arayan *bütünleşmedir* (Eingliederung) (bkz. **Pulaşlı**, C I, § 21, Rn. 16). Ancak tam hâkimiyet ve bütünleşmenin oy oranları dışında fazlaca benzer yanları bulunmamaktadır. Çünkü bütünleşme (Eingliederung), bağlı şirketin tüzel kişiliğini koruması dışında birleşmeye çok benzer bir mahiyet arz etmektedir. Bu durumda hâkim şirket, bağlı şirketin doğmuş ve doğacak bütün borçlarından bizzat sorumlu olmaktadır. Türk Ticaret Kanununda buna benzer bir düzenlemeye yer verilmemiş; sadece sene sonunda denkleştirme müessesesi getirilmiştir. Alman hukukunda bütünleşme (Eingliederung) hâlinde şirketin iktisadi anlamda mahvına yönelik talimatların verilip verilmeyeceği tartışmalıdır. Bu hususta esas itibariyle iki görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden "*verilebilir*" diyenlerin temel gerekçesi, hâkim şirketin doğmuş ve doğacak tüm borçlardan sorumlu olmasıdır. Bir diğer söyleyişle bu görüş taraftarları, "hâkim şirket doğmuş ve doğacak tüm borçlardan sorumlu olduğu için, bağlı şirketi bir işletme birimi gibi kullanabilir, icabında iktisadi anlamda mahvına yol açan talimat da verebilir" demektedirler. Bu görüş taraftarlarının esas aldığı nokta *sorumluluktur.* Eğer hâkim şirketin bu sorumluluğu olmasa, bu görüşü savunanların gerekçeleri kalmamaktadır. Türk Ticaret Kanununda ise zaten hâkim şirket sorumlu değildir; sadece kendi verdiği talimattan kaynaklanan kaybı gidermekle yükümlüdür. Onun için iktisadi anlamda mahva yol açacak bir talimat verememeli, vermişse de bunun yerine getirilmesini bağlı şirket yönetim kurulu engellemelidir.

denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan alacaklılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler".

IV) ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA SORUMLULUK ESASLARI

Şirketler topluluğunda hâkimiyet, kural olarak, hâkim şirkete bu gücü bağlı şirketlere karşı hukuka aykırı olarak kullanması hakkını vermez. TTK m.202'de, hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması hali sınırlı sayı (numerus clausus) olmadan hükme bağlanmış ve sonuçları düzenlenmiştir. TTK m.202'de öngörülen herhangi bir işlem, meselâ kefalet ve garanti verme, alacak veya borç devretme, birleşme, bölünme hukuka aykırı değildir; *hukuka aykırılık*, hâkimiyetin kullanılmasından ve uygulanmasından doğar. Hukuka aykırılık, işlemin, alınan kararın veya uygulanan ya da uygulanmasından kaçınılan önlemin, bağlı şirketin kaybına sebep olmasından ve şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına zarar vermesinden ve şirket yönünden haklı bir sebebi bulunmamasından kaynaklanmaktadır[667].

A) HÂKİMİYETİN HUKUKA AYKIRI KULLANILMASI

Kanun koyucu, bir şirket veya teşebbüsün bağlı şirketler üzerinde hâkimiyet uygulayabilecek vasıtalara sahip olması sebebiyle; hâkim şirket veya teşebbüsün bunu *kötüye kullanmasını* önlemek düşüncesinden hareket ederek, "*hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz*" demiştir (TTK m.202/1-a).

1. Kötüye Kullanma Halleri

Kanun koyucu, "Hâkim şirket, hâkimiyetini, bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanamaz" demek suretiyle genel kuralı hükme bağlamış; ancak hâkimiyetin hukuka aykırı kullanımını tanımlamamış, sadece kayba sebebiyet verebilecek bazı özel halleri zikretmiştir. Önemle belirtelim ki, TTK m.202/1-a'da söze konu edilen haller, örnek olarak belirtilmiştir; hâkimiyetin hukuka aykırı kullanım halleri burada belirtilenlerle sınırlı değildir.

TTK m.202/1-a'ya göre, "*Hakim şirket,....bağlı şirketi, iş, varlık, fon, personel, alacak ve borç devri gibi hukuki işlemler yapmaya; kârını*

---

667 Gerekçe TBMM, s.140.

azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını aynî veya kişisel nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini yenilememek, yatırımları kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez".

2. *Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Olarak Kullanılabilmesi İmkânı (Denkleştirme)*

Şirketler topluluğunun amacı, hukuken bağımsız birden fazla şirketin tüm ekonomik faaliyetlerini ortak bir iradeye ve ortak bir plana göre sürdürmek, bu amaçla ekonomik bir birlik oluşturmaktır. Bu ekonomik birliğin faaliyetlerinin elde edilmesini temin maksadıyla, kimi zaman, hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketleri kayba uğratacak şekilde kullanabilir.

Buna göre, "*hâkimiyetin hukuka aykırı*" bir şekilde kullanılması, hukuka aykırı olmasına rağmen; şirketler topluluğunun amacına uygun olarak, hâkim şirket, hâkimiyetini, bağlı şirketi kayba uğratacak şekilde kullanabilmektedir. Hâkim şirket, bağlı şirketi bu şekilde kayba uğratmışsa, bu kaybın tazmini gerekir. Ancak hâkim şirket, aynı faaliyet yılı içinde kaybı *denkleştirmişse* veya *denkleştirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda şirkete bir talep hakkı sağlamışsa,* bu kaybın tazmini gerekmez (TTK m.202/1.a).

Denkleştirme, bağlı şirkete yarar bir avantaj tanınması gibi kaybın giderilmesini sağlayacak bir karşılığa ilişkin olabilir. Meselâ verilen garanti veya kefaletin, karşı garanti ve kefalet ya da aval ile güvence altına alınması[668], herhangi bir lisans ve marka kullanma hakkı tanınması, herhangi bir ücret talep edilmeden araştırma ve geliştirme hizmeti verilmesi, know-how verilmesi, personele staj ve eğitim imkânları sağlanması, pazarlama ağından yararlandırılması, denk bir değerde taşınmazın devri, bağlı şirketin kayba uğramasının karşılığında yararlandırılmış

---

668 Kişisel güvence verilmesine ilişkin sözleşmeler ve aval hakkında bkz. **Can, M. Ç.:** "*Türk Borçlar Kanunu'nun 603. Maddesinin Kıymetli Evrak Hukukunda Uygulanabilirliği - Avalde Eşin Rızası Aranmalı Mı?*", GÜHFD, C. 21, S. 3, s. 35 vd.

olan diğer bir bağlı şirketin sermaye artırımında rüçhan hakkı tanınması, şartlı sermaye artırımında kayba uğrayan şirketin hak sahibi kılınması gibi şekillerde olabilir[669].

Denkleştirme, kayba sebebiyet verilen hesap yılı içinde fiilen gerçekleştirilebileceği gibi; o hesap yılı içinde, şirkete denkleştirmenin nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda bir talep hakkı kazandırılması ile de mümkündür.

Bağlı şirkete tanınan bu talep hakkı; hâkim şirketle bağlı şirket arasında yapılacak bir sözleşme ile sağlanabileceği gibi, hâkim şirketin taahhüdü ile de gerçekleşebilir[670].

3. Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasının Sonuçları

Hâkim şirket, aynı faaliyet yılı içinde kaybı denkleştirmemiş veya bu kaybın ne zaman ve nasıl denkleştirileceği hususunda bağlı şirkete bir talep hakkı da sağlamamışsa; hâkimiyetini hukuka aykırı kullanması sebebiyle *bağlı şirketin uğradığı zararını tazmin etmek zorundadır* (TTK m.202/1.b).

a) Kaybın Denkleştirilmemesi ve Zararın Tazmini

Kanun koyucu, bağlı şirketin kaybından bahsederken, "*kayıp*" kavramını, "*zarar*"dan farklı ve *zararı da kapsayacak şekilde kullanmıştır. Kayıp*, bir malvarlığı eksilmesi veya malvarlığının artmasının önlenmesi şeklinde ortaya çıkabileceği gibi; iş, fon ve personel devrinde olduğu üzere, şansın veya bir işi başarıyla yapabilme olanağının yitirilmesi tarzında da görülebilir[671]. Yasal düzenleme, hesap yılı sonuna kadar kaybın fiilen ya da hak sağlanmak suretiyle denkleştirilmesine olanak verdiğinden; bu süre tamamlanana kadar kaybın denkleştirilmesi için ilgililerin dava edilmesi mümkün değildir.

Süre dolduğunda ise, kayıp denkleştirilmemişse, artık denkleştirme değil; uğranılan zararın tazmini talep edilebilir. Bu nedenle şirketler topluluğunun belki de hukuki sorumluluk konusundaki en önemli avantajı; söz konusu hesap yılı sonuna kadar ilgililerden denkleştirmenin sağlanmasının istenememesi, bir anlamda sorumluluk imtiyazı sağlamasıdır.

---

669 Gerekçe TBMM, s. 141.
670 Gerekçe TBMM, s. 141.
671 Gerekçe TBMM, s. 140 vd.

aa) Tazminat Davası ve Diğer Koruma Vasıtaları

Kaybın hesap yılı sonuna kadar fiilen ya da bir talep hakkı sağlanmak suretiyle denkleştirilmemesi halinde; uğranılan zararın tazmini davası açılabilir. Bu dava; *bağlı şirket, bağlı şirket pay sahipleri* veya *bağlı şirket alacaklıları* tarafından, *hâkim şirkete* ve *kayba sebebiyet veren yönetim kurulu üyelerine*[672] karşı açılır (TTK m.202/1-b,c). Pay sahibi veya alacaklıların açacağı tazminat davasına, kıyas yoluyla 553, 555, 556, 557, 560 ve 561'inci maddeleri tatbik edilir.

Pay sahipleri tarafından açılan tazminat davasında, hükmolunacak *tazminatın, bağlı şirkete ödenmesi talep edilir.* Aynı şekilde alacaklılar da şirket iflâs etmemiş olsa bile, şirketin zararının şirkete ödenmesini isteyebilirler (TTK m.202/1-c).

Hâkim *istem üzerine* veya *re'sen* somut olayda hakkaniyete uygun düşecekse, *tazminat yerine*; TTK m.202/2 hükümlerine göre, *davacı pay sahiplerinin paylarının hâkim şirket tarafından satın alınmasına* veya duruma *uygun düşen ve kabul edilebilir başka bir çözüme* karar verebilir (TTK m.202/1-b).

bb) Tazminata Hükmedilememesi

Hâkimiyetin hukuka aykırı kullanılması halinde, *denkleştirme de yapılmamışa, zararın tazmini esas olmasına rağmen*; "kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında, şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınılabileceğinin ispatı halinde tazminata hükmedilmez" (TTK m.202/1-d).

b) Bağlı Şirketin Kararına Muhalif Olan Pay Sahiplerinin Hakları

Hâkimiyetin hukuka aykırı olarak kullanıldığı bazı hâllerde, *pay sahiplerine tanınan diğer bir hak,* TTK m.202/2'de hükme bağlanmış; bağlı şirket pay sahiplerinin, *zararın tazminini* isteyebileceği gibi, *kendi paylarının satın alınmasını* hâkim şirketten talep edebileceği kabul edilmiştir.

---

672 Kanun koyucu, yönetim kurulu üyelerine karşı dava açabileceğini hükme bağlamışsa da; davanın sorumluluğu bulunan yöneticilere karşı açılabileceğinin kabulü gerekir.

TTK m.202/2'ye göre, "Bağlı şirket bakımından açıkça anlaşılabilir haklı bir sebebi bulunmayan, birleşme, bölünme, tür değiştirme, fesih, menkul kıymet çıkarılması ve önemli esas sözleşme değişikliği gibi işlemlerde, *genel kurul kararına red oyu verip tutanağa geçirten veya yönetim kurulunun bu ve benzeri kararlarına yazılı olarak itiraz eden pay sahipleri*; hâkim teşebbüsten, zararlarının tazminini veya paylarının varsa en az *borsa değeri* ile böyle bir değer bulunmuyorsa veya borsa değeri hakkaniyete uygun düşmüyorsa, *gerçek değerle* veya *genel kabul gören bir yönteme* göre belirlenecek bir değerle *satın alınmasını mahkemeden isteyebilir*".

Değer belirlenirken mahkeme kararına en yakın tarihteki veriler esas alınır. *Tazminat veya payların satın alınmasını istem davası*, genel kurul kararının verildiği veya yönetim kurulu kararının ilân edildiği tarihten başlayarak *iki yılda zamanaşımına* uğrar.

Pay sahipleri tarafından, tazminat veya payların satın alınması davası açılınca, davacıların muhtemel zararlarını veya payların satın alma değerini karşılayan tutardaki paranın teminat olarak, mahkemece belirlenecek bir bankaya yatırılmasına karar verilir. Teminat yatırılmadığı sürece genel kurul veya yönetim kurulu kararına ilişkin hiçbir işlem yapılamaz.

Davanın kötü niyetle açılması halinde davalı, uğradığı zararın müteselsilen tazmin edilmesini ve mahkemeye teminat yatırılmasını davacılardan isteyebilir (TTK m.202/3).

B) TAM HÂKİMİYET HALİNDE SORUMLULUK

Tam hâkimiyet halinde, hâkim şirket, yönetim kurulu tarafından, topluluk politikaları çerçevesinde verilen yönlendirici ve yönetime ilişkin talimatlar, bağlı şirketin kaybına sebebiyet verecek nitelikte olsa bile; bağlı şirket, hâkim şirketin yönetim kurulu tarafından, topluluk politikaları çerçevesinde verilen yönlendirici ve yönetime ilişkin talimatlarına riayet etmek zorundadır (TTK m.203).

Hâkim şirketin talimatı sebebiyle, bağlı şirketin bir kaybı söz konusu olursa; bu kaybın hâkim şirket tarafından, kanunda öngörüldüğü şekilde giderilmesi (denkleştirilmesi) gerekir. Kaybın hâkim şirket tarafından giderilmemesi halinde; hâkim şirket ve bu kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyeleri aleyhine tazminat davası açılması mümkündür. Bu husus TTK m.206/1'de, "*hâkim şirket ve yöneticilerinin, 203'üncü*

madde çerçevesinde verdikleri talimatlar dolayısıyla bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde denkleştirilmediği veya zamanı ve şekli de belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayacak ***alacaklılar*** *hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı tazminat davası açabilirler*" şeklinde ifade edilmiştir.

TTK m.206/1'de, bağlı şirket "*alacaklıları*"nın dava hakkı düzenlenmektedir; bağlı şirketin ve bağlı şirket pay sahiplerinin, tam hâkimiyet sebebiyle dava hakkı bulunmamaktadır.

Bağlı şirket alacaklılarının dava açabilmesi için aynı hesap yılı içinde bağlı şirketin kaybının giderilmemesi veya bağlı şirkete somutlaştırılmış bir istem hakkının tanınmamış olması gerekir.

Bağlı şirketin alacaklılarının açacağı davada, hâkim şirket veya bağlı şirket yönetim kurulu üyeleri, "kayba sebebiyet veren işlemin, aynı veya benzer koşullar altında şirket menfaatlerini dürüstlük kuralına uygun olarak gözeten ve tedbirli bir yöneticinin özeniyle hareket eden, bağımsız bir şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından da yapılabileceği veya yapılmasından kaçınabileceğinin ispatı halinde tazminata hükmedilmez" (TTK m.202/1-d) hükmünden yararlanabilirler.

Davalı hâkim şirket ve/veya hâkim şirket yönetim kurulu üyeleri, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya istem hakkının tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler (TTK m.206/3).

Bağlı şirket alacaklarının açacağı davaya, kıyas yoluyla TTK m.553'te hükme bağlanan, "*kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin ve tasfiye memurlarının sorumluluğu*" kuralları uygulanır.

C) GÜVENDEN DOĞAN SORUMLULUK

Şirketler topluluğu ilişkisinin doğmasıyla hâkim şirket veya teşebbüs ile bağlı şirketler arasında hususi bir münasebet doğar. Bu ilişkinin bağlı şirket üzerinde doğurduğu etkiler sebebiyle kanun koyucu, bazı hallerde hâkim şirket ve hâkim şirket yetkililerinin hukuki sorumluluğunu kabul etmiştir. Hâkimiyetin uygulanması çerçevesinde gerçekleşen bu sonuç, daha ziyade fiili duruma, hukuki sonuç bağlanması olarak görülür.

Kanun koyucu hâkimiyet ilişkisi çerçevesinde istisnai bir sorumluluk hâli olarak "***güvenden doğan***" sorumluluğa da yer vermiştir. "*Güvenden doğan sorumluluk*", topluluk itibarının topluma veya tüketiciye güven veren bir düzeye ulaştığı hallerde, bu itibarın kullanılmasının uyandırdığı güvenden, hâkim şirketin sorumlu olmasını ifade eder (TTK m.209).

TTK m.209'da belirtilen sorumluluk hâli şirketler topluluğunun oluşmasıyla kendiliğinden doğan bir sorumluluk hâli değildir; sorumluluğun doğabilmesi için her şeyden önce, topluluk itibarının topluma ve tüketiciye güven veren bir seviyeye ulaşması ve ayrıca itibarın bağlı şirketler tarafından kullanılması gerekir[673].

Bağlı şirket, şirketler topluluğunun güven uyandıran itibarını rekabet vasıtası olarak kullanıyor ve bu surette iktisadi menfaat temin ediyor, hâkim şirket bu itibarın kullanılmasına müsaade ediyorsa, kanun koyucu yaratılan bu güvenden doğan zararlardan, hâkim şirketin de sorumlu olacağını kabul etmiştir. Sorumlu olmak istemeyen hâkim şirket, şirketler topluluğunun güven veren itibarının; bağlı şirket tarafından kullanılmasına müsaade etmemelidir.

---

673 Kullanılan topluluk adına güvenerek halkın veya daha dar anlamda tüketicinin bağlı şirkete yönelmesinin ve bağlı şirketin pazar payının yükseltilmesinin temelinde, o topluluğun üyesi olan şirketin, dürüst hareket edeceği, verdiği bilgilerin ve kamuya açılan tablo ve belgelerinin gerçeği yansıttığı, teknolojinin üstün, kalitenin iyi ve her şeyin gereği gibi olduğu inanç ve güveni vardır. İtibarın kullanılması ise, somut olaya göre belirlenir. Kullanma için adın zikredilmesi, topluluk logosunun kullanılması şart değildir. Tablo, bilgi, kalite vs. güvene uymuyorsa, adın kullanılmasına sesini çıkartmayan hâkim şirket, sonuçtan sorumlu olmalıdır. Bu sebeple sorumluluğun merkez şartı, "*itibarın kullanılması*"dır; kullanma yoksa sadece topluluğa "*mensubiyet*", sorumluluğu doğurmaz (Gerekçe TBMM, s. 143 vd.).

KAVRAM FİHRİSTİ

A

Actio Pro Socio, 85, 94
Adi pay, 414
Agio, 419
Ağırlaştırılmış nisap, 523
Aslen kazanma, 540
Asliye Ticaret Mahkemesi, 32, 192, 294, 603
Ayni sermaye, 181, 283, 654
Ayrılma akçesi, 550, 563
Azınlık, 297, 340, 341, 345, 346, 369, 409, 425-427, 499

B

Bağımsız denetim, 369, 372, 378-382, 384, 385, 451
Bağlam, 409, 422, 445-447
Bakanlık temsilcisi, 359
Basit karşılıklı iştirak, 688
Bilançonun iyileştirilmesi, 561
Birikimli oy, 302
Borçlanma yasağı, 271, 281, 282, 532, 557
Borsaya kote edilmiş nama yazılı pay, 446

Ç, D

Çağrı, 57, 347, 379, 407, 521
Çelişkili davranış yasağı, 530
Denetim hakkı, 210, 221, 506, 536
Denkleştirme, 575, 580, 695, 696
Devren kazanma, 540
Doğrudan hâkimiyet 669, 674
Doğrudan zarar, 471
Dolaylı hâkimiyet, 674,669

E

Ek tasfiye (ihya), 451
Ek yükümlülük, 589, 619
Elbirliği ile mülkiyet, 11, 12, 39
Elektronik genel kurul, 344
Esas sözleşme değişikliği, 291
Esas sözleşme, 272, 284, 288, 291, 337, 350, 363, 393, 398, 454, 457
Eşit işlem, 271, 531

F, G

Farklılaştırılmış teselsül, 452, 480, 481, 483
Fesih davası, 192
Grup imtiyazı, 415
Güvenden doğan sorumluluk, 655

H

Hâkim şirket, 662, 684, 686
Hâkimiyet, 663-669, 672-674, 677
Haklı sebeple fesih, 459
Halka açık anonim şirket, 298
Holding, 679
Huzur hakkı, 297

İ

Iskat 35, 400, 423, 440
İç kontrol, 311, 372,
İç yönerge, 335
İflas, 184, 262, 297, 469, 481
İkincil yükümlülük, 441
İmtiyaz, 271, 409, 414-416

İnfisah, 138, 247, 249, 452, 454, 455, 460, 605
İşletme konusu, 285, 298, 313, 453, 456, 512
İtibari değer, 411, 418

K

Kamu borçları, 501
Kanuna karşı hile, 294, 421
Kâr payı, 213, 428, 430, 552
Kartel, 680
Kayıtlı sermaye, 271, 288, 393, 396
Know-How, 83, 695
Komanditer ortak, 26, 43, 46, 47, 50, 167, 264-269, 503, 506, 631
Konkordato, 324, 325
Kooptasyon, 304
Kurucular, 284, 448, 488
Kuruluş giderleri, 517
Kuruluş işlemleri, 283

M, N

Menkul kıymet, 351, 409
Murahhas müdür, 55
Murahhas üye, 318, 348
Müdürlerin atanmaları, 519, 527
Müdürlerin görevden alınabilmesi, 508
Nakdi sermaye, 34, 35, 517, 518
Nama yazılı pay senedi, 44, 410, 427, 443, 444, 541

Ö

Ön limited şirket, 9, 516
Ön şirket, 271, 283
Özel denetçi, 391

P, R

Pay defteri, 409, 422, 444
Paylı mülkiyet, 10, 11, 40, 87, 623
Pazarlık usulü, 159, 467
Rekabet yasağı, 111, 112, 222, 223, 267, 506, 530, 557
Rüçhan hakkı, 432

S, Ş

Serbest yedekler, 460, 583
Sermaye borcu, 50, 266, 398, 439, 440, 512, 552, 555
Sermayenin artırılması, 190, 337, 345, 352, 393-397, 402, 423, 431, 440, 473, 510, 523, 553, 560
Sermayenin azaltılması, 393, 400-403, 407, 460
Sermayenin iadesi yasağı, 281
Sınırlı sorumluluk, 46, 167, 263, 264, 274, 507, 508, 512, 570
Sınırsız sorumluluk, 46, 589, 618,
Sirküler karar, 331
Sorumluluk davası, 653
Sulh, 105, 217, 259, 425, 426, 499
Şarta bağlı sermaye artırımı, 393, 397
Şirket merkezi, 285

T

Tasfiye memurunun atanması, 463
Tasfiye memurunun görevden alınması, 258, 259
Tasfiye payı, 101, 215, 243, 266, 409, 431, 553
Tasfiye, 101, 135, 136, 150-160, 163, 215, 243, 246, 254-262, 266, 340, 346, 409, 431, 451,

461, 463-469, 490, 553, 562, 570, 571, 573
Tasfiyeden dönme, 451, 468
Tek borç ilkesi, 438
Terkin, 161, 274, 453, 460, 461, 468, 469
Tescil ve ilân, 206,
Ticaret sicil müdürü, 510, 677
Ticari itibar, 179

U, V

Ultra vires, 274, 298, 313, 512
Vadesi gelmemiş alacak, 176, 181, 289, 290, 413, 471

Y

Yan edim yükümlülükleri, 46, 410, 511-513, 515, 520, 540, 542, 557, 559,
Yavru şirket, 609
Yedek akçe, 36, 169, 190, 281, 282, 319, 324, 326, 338, 395, 396, 400, 401, 419, 428, 429, 439, 454, 545, 553, 558, 571
Yetkisiz temsil, 106, 109, 115, 461
Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 355, 357, 495
Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu, 427, 472, 536
Yönetim yetkisinin devri, 52

Z

Zamanaşımı, 112, 162, 163, 224, 654
Zımni ibra, 497, 498